

금융분쟁조정 사례집(제2권)

은행 · 중소기업금융 · 금융투자

2017년 12월



금융감독원

총 목 차

제1편 | 금융권역별 주요 조정사례 (은행 및 중소서민금융)

1. 대출거래	3
(1) 대출금 명의대여자 등의 변제책임	3
(2) 채무명의 변경 등에 따른 권리·의무관계	12
(3) 수수료의 환급 등	30
(4) 시설대여(리스)	48
(5) 기타	54
2. 담보책임	94
(1) 포괄근저당의 피담보채무 범위	94
(2) 한정근저당의 피담보채무 범위	107
(3) 제3자담보 제공	125
(4) 기타	138
3. 보증책임	157
(1) 보증인에 대한 보증의사 미확인	157
(2) 담보제공자 겸 연대보증인의 보증책임	178
(3) 퇴직임원의 보증책임	186
(4) 기타	194
4. 예금 등 수신거래	211
(1) 계좌개설 및 입금	211
(2) 금리 적용	225

(3) 예금 지급 및 해지	234
(4) 예금 지급정지, 상계 및 착오송금	277
(5) 수표대금 지급	307
(6) 기타	315
5. 신용카드 등	326
(1) 신용카드의 제3자 부정사용	326
(2) 신용카드의 도용 및 위·변조 사용	339
(3) 기타	351
6. 금융투자상품 판매	356
(1) 펀드의 불완전판매	356
(2) 기타	379

제2편 | 금융권역별 주요 조정사례 (금융투자)

1. 설명의무 위반 및 부당권유	405
(1) ELS 및 ELF	405
(2) 주식형·채권형·혼합형 펀드	432
(3) 부동산펀드	445
(4) 선물·옵션	459
(5) 펀드 환매 등 기타	473
2. 매매주문 부당처리	548
(1) 매매주문 착오	548
(2) 반대매매 관련	562
3. 임의매매	596

(1) 임의매매 인정 사례	596
(2) 임의매매 불인정 사례	615
4. 과당 일임매매	633
5. 전산장애, 사무처리 오류 등	676
(1) 전산장애	676
(2) 사무처리 오류	695
(3) 횡령 및 배임	709
(4) 기타	734

부 록

1. 금융분쟁조정 관련 법규	743
(1) 금융위원회의 설치 등에 관한 법률(발체)	745
(2) 금융위원회의 설치 등에 관한 법률 시행령(발체)	748
(3) 금융분쟁조정세칙	751
2. 색인	763
(1) 법원 판례 목록	765
(2) 수록 안건 색인	775

사례 목차

제1편 | 은행 및 중소기업금융 (제1권)

제1장 대출 거래

제1절 대출금 명의대여자 등의 변제책임	3
1. 어음거래약정 명의대여자의 어음할인채무 변제책임 유무(2000)	3
2. 금융기관이 규제회피를 위해 타인명의로 대출한 경우 명의대여자 책임(2011)	6
3. 명의도용 대출의 변제책임 유무(2011)	9
제2절 채무명의 변경 등에 따른 권리·의무관계	12
4. 면책적 채무인수에 대하여 채권자인 은행의 승낙이 있었는지 여부(2001)	12
5. 계약인수로 채무자 명의가 변경된 경우 잔여채무 변제책임의 유무(2002)	14
6. 조건이 성취되지 않은 정지조건부 채권양도의 대물변제 효력 여부(2004)	17
7. 금융기관이 신청인의 채무인수 합의에 승낙해야 할 의무가 있는지 여부(2006)	20
8. 중첩적 계약인수와 관련한 대출채무 존재 여부(2009)	22
9. 이해관계 있는 제3자의 변제 해당여부(2010)	27
제3절 수수료의 환급 등	30
10. 건설사에 대한 PF대출 확인서 발급과 관련한 수수료의 반환 요청(2008)	30
11. 대출금 임의변제와 관련한 중도상환 수수료 반환 청구(2008)	33
12. 과도하게 수취한 PF대출 취급수수료의 환급(2008)	36
13. 대출연장 합의 성립 여부와 중도상환수수료 등 반환청구(2010)	41
14. 타행대환대출금 중도상환과 관련한 수수료 징수 특약의 적용 여부(2011)	44
제4절 시설대여(리스)	48

15. 리스기간 만료시 리스이용자의 리스물건 인수 의무(2001)	48
16. 리스사가 받은 선수금의 이자수익이 부당이득에 해당하는지 여부(2010)	51

제5절 기 타 54

17. 경매배당금의 변제충당순서(2001)	54
18. 신용회복지원 조정결정에 기한 부당이득 반환청구(2005)	56
19. 대출계약조건 번복으로 인한 금융기관의 손해배상책임 유무(2005)	60
20. 외화대출의 원화대출 전환에 따른 금융기관의 손해배상책임 유무(2007)	63
21. 대물변제를 통한 PF대출 원리금 상환의 적정성 및 정산비용의 범위(2010)	65
22. 연체이자 과다징수 여부(2010)	71
23. 대출금 분할상환 약정시 연체이자 감면의 합의가 있었는지 여부(2014)	74
24. 고객보호의무 위반 등에 따른 대출사기에 대한 손해배상책임(2014)	81
25. 은행 직원의 대출이자 손실보전약정 등에 따른 은행의 책임인정 여부(2016) ...	89

제2장 담보 책임

제1절 포괄근저당의 피담보채무 범위 94

1. 잔존채무가 존재하는 경우 근저당권 설정등기 말소청구의 타당성(2001)	94
2. 은행내규에서 금지하고 있는 포괄근저당권 설정의 피담보채무 범위(2002)	96
3. 담보말소 협의사실을 근저당권의 결산기 지정으로 볼 수 있는지 여부(2002) ..	100
4. 포괄근저당 피담보채무에 타기관 보증부대출이 포함되는지 여부(2011)	103

제2절 한정근저당의 피담보채무 범위 107

5. 한정근저당의 피담보채무 범위가 본건 대출금에 한정되는지 여부(2000)	107
6. 한정근저당권 설정계약서 문언의 성격(2005)	110
7. 한정근저당권의 피담보채무 범위가 특정되지 않은 경우(2009)	113
8. 한정근저당 피담보채무 범위의 일부를 금융회사가 보충한 경우(2010)	117

9. 한정근저당권의 피담보채무를 증서대출로 기재한 경우(2013)	121
제3절 제3자담보 제공	125
10. 제3자담보인 경우 피담보채무 범위에 차주의 보증채무가 포함되는지(1999) ...	125
11. 근저당권 전용(유용) 허락을 받지 않은 제3자 포괄근저당의 담보 효력(2011) ...	128
12. 제3자담보인 경우 근저당권 설정 이전의 기존채무까지 포함하는지 여부(2011) ...	132
제4절 기 타	138
13. 담보제공자의 담보물처분 요청권과 처분지체에 따른 담보권자의 책임(1999)	138
14. 폐업한 차주사의 근질권 설정계약의 유효 여부(2003)	143
15. 부동산담보신탁에 있어 제2순위 우선수익자의 최우선수익권 인정 여부(2008)	147
16. 소유권 변경으로 인한 근저당권의 효력 변경 여부(2009)	151
17. 아파트사업부지에 설정한 근저당의 효력이 상가부지에도 미치는지 여부(2011) ...	154
 제3장 보증 책임	
제1절 보증인에 대한 보증의사 미확인	157
1. 금융기관이 직접 보증의사를 확인하지 아니한 경우의 보증책임 유무(2000)	157
2. 보증관련 서류가 도용된 경우의 보증계약의 효력(2005)	161
3. 이사 명의의 근보증서를 대표이사가 대필한 경우 표현대리의 성립 여부(2010) ...	163
4. 남편 명의의 근보증서를 부인이 대필한 경우 보증계약의 효력(2010)	171
5. 위조된 근보증서에 따라 전화확인만을 거친 경우 보증계약의 효력(2013)	173
제2절 담보제공자 겸 연대보증인의 보증책임	178
6. 근보증서 제출이 의례적·형식적인 절차에 불과한 것인지 여부(2009)	178
7. 담보가액이 충분함에도 물적담보책임외에 보증책임을 지운 경우(2010)	183
제3절 퇴직임원의 보증책임	186

8. 퇴직 고용임원의 보증책임 범위(1999)	186
9. 기존 대표의 보증 해지 및 신규 대표 입보가 보증인 교체에 해당하는지(1999) ...	190

제4절 기타 194

10. 금융기관 직원에게 단순히 명의만 제공한 형식상 보증인의 보증책임(1999) ...	194
11. 후취담보로 인한 포괄근보증 효력의 소멸 여부(2004)	197
12. 채무자의 채무관련 신용정보 제공절차 불이행과 보증계약 효력과의 관계(2009) ...	201
13. 대출 관련 목적물이 특정된 경우의 보증채무 부존재 확인(2010)	206

제4장 예금 등 수신거래

제1절 계좌개설 및 입금 211

1. 위조신분증에 의한 예금계좌 부당개설에 따른 책임 여부(2005)	211
2. 실명확인 없는 예금계좌 개설 및 인출에 따른 손해배상책임 유무(2006)	213
3. 조합명의 예금통장의 재발급시 은행의 주의의무 위반 여부(2006)	217
4. 폐지된 「주택청약예금 자동적금통장」 교부에 따른 손해배상 책임(2011)	220

제2절 금리 적용 225

5. 자유적립예금 적용이율의 해석 및 이에 따른 손해배상청구(2002)	225
6. 근로자우대저축에 대한 확정금리 지급 여부(2003)	229

제3절 예금 지급 및 해지 234

7. 일부 상속자의 동의만으로 상속예금을 지급한 경우의 정당성 여부(1999)	234
8. 예금주의 해외체류중 배우자 요청에 의한 예금계좌 해지의 정당성 여부(1999) ...	236
9. 정당한 권리자가 아닌 자의 예금 청구에 의해 발생한 손해의 배상책임(2000) ...	240
10. 예금통장 이월시에 인감을 날인하지 않아 발생한 손해에 대한 배상책임(2005) ...	243
11. 이월발급한 통장을 제3자에게 교부하여 발생한 손해에 대한 배상책임(2006) ...	248
12. 은행 전산입력 하자로 종중예금이 특정인에 의해 인출된 경우 배상책임(2007) ...	252

13. 예금인출자가 본인이 아닌 것으로 사후에 밝혀진 경우 은행의 배상책임(2011) ···	257
14. 정당한 권리자 아닌 자에 대한 정기예금 지급의 책임 여부(2015) ·······	264
15. 정당한 권리자 아닌 자에 대한 예금지급의 효력 여부(2016) ·······	271
제4절 예금 지급정지, 상계 및 착오송금 ·······	277
16. 유치원 명의 예금의 지급정지 가능 여부(1999) ·······	277
17. 예금주 결정 및 상계처리 적정 여부(2004) ·······	280
18. 압류결정 송달일 이후 입금된 예금채권의 압류대상 해당 여부(2007) ·······	283
19. 금융기관이 착오송금임을 알면서도 추심권을 행사한 경우의 반환 의무(2010) ···	285
20. 착오송금 반환요청 전에 상계효력이 발생하지 않은 경우의 반환 의무(2013) ···	290
21. 착오송금 자금반환 업무처리 부적정에 따른 손해배상 책임 여부(2016) ·······	295
22. 은행의 선관주의의무 위반 여부(2016) ·······	300
제5절 수표대금 지급 ·······	307
23. 자기앞수표의 사고신고 전산등록 지연처리로 인한 손해배상책임 유무(2002) ···	307
24. 자기앞수표 소지인의 이득상환청구권 인정 여부(2008) ·······	310
제6절 기 타 ·······	315
25. 예금보장범위 설명 오류와 관련한 은행의 손해배상책임 유무(1999) ·······	315
26. 예금계좌 비밀번호 임의변경에 따른 손해배상책임 유무(2006) ·······	318
27. 계좌비밀번호 유출 등에 따른 텔레뱅킹 계좌이체금 반환청구(2010) ·······	322
 제5장 신용카드 등	
제1절 신용카드의 제3자 부당사용 ·······	326
1. 카드 분실 후 카드 부정사용 대금에 대한 회원의 책임(2000) ·······	326
2. 신용카드의 제3자 보관으로 인한 카드 부정사용의 해당 범위(2006) ·······	329
3. 임의 발급된 가족카드 부정사용에 따른 책임 유무(2008) ·······	331

4. 음주후 분실한 겸용카드의 부정사용에 대한 회원의 책임(2009)	335
제2절 신용카드의 도용 및 위·변조 사용	339
5. 제3자가 카드번호를 도용하여 전자상거래에 이용한 경우 회원의 책임(2005) ...	339
6. 위조카드에 의한 예금의 부당인출과 비밀번호 누설 책임(2006)	342
7. 위조 직불카드의 부정사용에 따른 책임 유무(2008)	345
8. 복제카드 부정사용 및 카드 비밀번호 누설에 따른 회원의 책임(2011)	348
제3절 기타	351
9. 카드대금 할부전환에 따른 할부항변권 인정여부(2015)	351
 제6장 금융투자상품 판매	
제1절 펀드의 불완전판매	356
1. 특정금전신탁 가입시 고객보호의무 위반 여부(2004)	356
2. 관련 투자경험이 부족한 고객에 대한 파생상품의 불완전판매(2008)	360
3. 파워인컴 펀드의 불완전판매에 따른 손해배상책임(2008)	364
4. 고령자에게 충분한 설명 없이 고위험펀드 판매에 따른 손해배상책임(2010) ...	369
5. 선박펀드의 불완전판매에 따른 손해배상책임(2010)	373
제2절 기타	379
6. 변경된 신탁약관의 임의적용에 따른 손실보상 요청의 건(2008)	379
7. 당사자간 계약체결 사실이 입증되지 않은 통화옵션계약의 성립 여부(2008) ...	382
8. 투자신탁 판매회사가 고유재산에 의한 환매의무를 부담하는 지 여부(2008) ...	385
9. 이미 성립된 투자 환매금의 지급채권이 환매연기로 실효되는지 여부(2009) ...	390
10. 저축은행 후순위채의 불완전판매 여부(2011)	395

제2편 | 금융투자(제1권)

제1장 설명의무 위반 및 부당권유

제1절 ELS 및 ELF	405
1. 청약서 작성시 펀드명칭이 미확정되어 추후 담당자가 이를 보충한 경우(2007) ...	405
2. 가입자와 협의후 증권사 직원이 가입처리 한 펀드의 임의가입 해당 여부(2008) ...	408
3. 펀드 부당권유 및 부당한 반대매매로 인한 손해배상책임 여부(2009)	412
4. ELF 만기손익구조의 설명 불충분과 관련한 손해배상책임 여부(2009)	418
5. 고위험상품의 특성을 이해하기 어려운 고객에 대한 적정성 의무 위반(2010) ...	422
6. ELS 부당권유로 인한 손해배상책임 여부(2010)	427
제2절 주식형·채권형·혼합형 펀드	432
7. 주식형 수익증권의 부당권유 및 임의가입 여부(2001)	432
8. 신탁재산 감소에 따라 동일종목 투자한도를 초과하게 된 경우의 책임(2001) ...	434
9. 혼합펀드에 대한 위험설명 부족 등 부당권유로 인한 손해배상책임 여부(2008) ...	437
10. 인사이트 펀드의 판매시 설명의무 위반 및 사후관리의무 위반 여부(2009) ...	441
제3절 부동산펀드	445
11. 다년간 펀드투자 경력이 있는 고객에 대한 설명의무 위반 여부(2008)	445
12. 부동산펀드의 부당 권유 등으로 인한 손해배상책임 여부(2008)	448
13. 고령자에게 위험성 높은 펀드의 특성에 대한 설명 없이 가입시킨 경우(2010) ...	453
제4절 선물·옵션	459
14. 선물·옵션의 위험성을 숨기고 장점만 부각한 경우 부당권유 인정 여부(2004) ...	459
15. 선물·옵션, ELW에 대한 부당권유 및 매매주문 불이행 여부(2008)	463
16. 투자경험이 없는 자에게 선물·옵션을 부당 권유한 데 따른 손해배상책임(2011) ...	468

제5절 펀드 환매 등 기타	473
17. 투자신탁의 환매거부의 적정성 및 임의가입 여부(2000)	473
18. 투자재산의 매각 지연으로 인한 수익증권 환매유예의 적법성 여부(2002)	475
19. 대량환매사태로 인한 환매유예조치의 적법성 여부(2003)	479
20. 투자경험이 풍부한 자에 대한 주식 부당권유 손해배상책임 성립 여부(2008)	484
21. 파생결합증권 중도상환에 대한 설명의무 위반 여부(2008)	488
22. 원금보장 약속 등을 통한 환매보류 권유로 인한 손해배상책임 여부(2009)	492
23. 환매보류의 적정성 및 사후관리 소홀로 인한 손해배상책임 여부(2009)	495
24. 간투법상 반대주주가 주식매수청구권 행사시 환매연기규정 적용 여부(2009)	497
25. 채권 매입시 거래세에 대한 설명의무 위반 여부(2010)	503
26. [주]△△ 회사채 불완전판매 등에 따른 손해배상책임(2014)	506
27. 파생결합증권(DLS) 불완전판매 등에 따른 손해배상책임(2016)	526
28. 원유선물 ETF 분할매수 랩(Wrap)상품 불완전판매로 인한 손해배상책임(2016)	535
29. 해외 원유선물 ETN 불완전판매에 따른 손해배상책임 성립여부(2017)	541

제2장 매매주문 관련

제1절 매매주문 착오	548
1. 직원이 신용매수주문을 현금매수로 잘못 처리한 경우 손해배상책임 여부(1999)	548
2. 직원이 공매도주문을 수탁거부한 경우 손해배상책임 여부(1999)	550
3. 주식매수청구권 행사를 약속한 후 이행하지 않은 경우의 손해배상책임(2000)	553
4. 직원이 매수주문과 다른 종목을 매수한 경우 손해배상책임 여부(2000)	555
5. 계좌주의 동의 없는 매도주문 처리로 인한 손해배상책임 여부(2009)	558
제2절 반대매매 관련	562
6. 미수금 규모에 비하여 과도한 옵션 반대매도로 인한 손해배상책임(2000)	562

7. 추가증거금 납부통지 없이 한 옵션 반대매매로 인한 손해배상책임(1)(2002)	565
8. 추가증거금 납부통지 없이 한 옵션 반대매매로 인한 손해배상책임(2)(2002)	572
9. 반대매매시 비상장주식의 담보가치를 인정하지 않은 것의 적법성 여부(2007)	575
10. 담보부족 관련 부정확한 반대매매 기준 안내에 따른 손해배상책임 유무(2007) ...	578
11. 주식담보대출 반대매매 절차에 있어 유선 통지의무가 있는지 여부(2010)	582
12. 증권사에 고객손실 최소화를 위한 적정시점 반대매매의무가 있는지 여부(2010) ..	585
13. 투자일임업자의 선관주의의무 위반에 따른 배상책임 인정여부(2016)	588

제3장 임의매매

제1절 임의매매 인정 사례 596

1. 임의매매 손해금에 대해 약속어음을 교부한 경우 손해배상액 산정기준(1999)	596
2. 주식매매과정에서 직원의 선관주의의무 위반 여부(2000)	598
3. 형사재판에서 주식의 임의매매로 인정된 경우의 민사상 배상책임 여부(2003)	602
4. 고객의 손실이 확대되는 과정에서 선관주의의무를 위배하였다고 본 사례(2008) ..	606
5. 임의매매 여부 및 손해배상청구권의 소멸시효 완성 여부(2009)	610

제2절 임의매매 불인정 사례 615

6. 고객 지인의 지시로 매매한 경우 임의매매 해당 여부(2001)	615
7. 임의매매와 협의매매와의 구별(2003)	618
8. 신청인이 거래내역을 인지하고 수차례 협의한 경우 임의매매 성립 여부(2005) ...	621
9. 타인명의 금융투자상품 거래가 무권대리로서 무효인지 여부(2011)	624
10. 포괄적 일임을 받은 증권사 직원이 퇴사한 이후 다른 직원을 통해 주식매매 주문을 한 경우 임의매매에 해당하는지 여부(2017)	628

제4장 과당 일임매매

1. 매매거래를 일임하였으나 과도한 매매거래로 손해를 본 경우(1999)	635
--	-----

2. 증권투자경험이 전혀 없는 고객에 대한 과다 일임매매 손해배상책임(2000) ...	637
3. 매매회전율은 다소 과다하나 고객이 거래내용을 충분히 인지한 경우(2001) ...	640
4. 과다 일임매매 인정 여부 및 손해배상금액 산정기준(2001)	643
5. 과당매매와 관련해 주식매매 반복이 전문가의 합리적 선택이었는지 여부(2002)	646
6. 수수료 수입을 위한 선물·옵션의 과당매매에 따른 손해배상책임 여부(2002)	650
7. 일임약정이 있었으나 무리한 과다회전매매로 인한 손해배상책임 여부(2005) ...	655
8. 주식의 과당 일임매매와 손해배상청구권의 시효 완성 여부(2005)	659
9. 임의매매에는 해당하지 않으나 과당일임매매로 인한 손해배상책임 발생(2005) ...	664
10. 단기매매에 주력하는 등 과당매매로 인한 손해배상책임 유무(2007)	669
11. 고령자에 대한 부당 매매권유, 과당매매 등으로 인한 손해배상책임 유무(2008) ...	672

제5장 전산장애, 사무처리 오류 등

제1절 전산장애	678
1. 전산장애로 예수금을 초과하여 매수한 경우 손해배상액 산정기준(1999)	678
2. 전산장애로 주문이 체결되지 아니한 경우 손해배상액 산정기준(2003)	680
3. HTS 오류로 주문이 실행되지 아니한 경우 손해배상책임 여부(2008)	685
4. 전산장애와 관련하여 주장하는 특별손해의 상당 인과관계 유무(2008)	688
5. 전산장애로 주식계좌대체 서비스가 중단된 경우 손해배상액 산정기준(2011) ...	692
제2절 사무처리 오류	697
6. 협회의 잘못된 부도공시로 투자자들이 주식을 매도하여 손해를 본 경우(1999) ...	697
7. 전산입력 오류와 주식매수청구권 불행사와의 인과관계 여부(2000)	700
8. ELS 최초기준지수 결정일 임의변경의 적정성 여부(2010)	703
9. ELS 가격변동추이 미통지로 인한 손해배상책임 유무(2010)	707
제3절 횡령 및 배임	711

10. 직원이 고객에게 타인명의 유상청약을 유도하고 그 자금을 횡령한 경우(1999) ...	711
11. 장외매매 명목으로 금원을 편취시 증권회사의 손해배상책임 여부(2003)	713
12. 직원의 고객예탁금 횡령에 대한 사용자배상책임 여부(2005)	717
13. 고객 차명계좌 거래금액을 횡령한 경우 사용자배상책임 인정 여부(2007)	720
14. 원금보장약속을 통한 투자권유 및 투자금 유용 관련 사용자책임 인정여부(2010) ...	722
15. 고객예탁금 횡령에 따른 손해배상책임(2015)	727
16. 증권회사 직원의 고객예탁금 편취에 따른 손해배상책임(2016)	731
제4절 기 타	736
15. 투자자문계약 해지 청구의 건(2005)	736
16. 증권저축약관 교부의무 위반 등으로 인한 손해배상책임 유무(2005)	739



제 1 편

금융권역별 주요 조정사례 (은행 및 중소서민금융)

- 제 1 장 대출거래
- 제 2 장 담보책임
- 제 3 장 보증책임
- 제 4 장 예금 등 수신거래
- 제 5 장 신용카드
- 제 6 장 금융투자상품 판매

제1장

대출 거래

제1절 대출금 명의대여자 등의 변제책임

1-1

어음거래 약정 명의대여자의 어음할인채무 변제책임 유무

[인용] 상호신용금고가 어음거래약정서상의 한도금액과 거래기간을 임의기입하였으므로 이를 한도거래약정으로 볼 수 없고, 약정서상의 신고된 인감과는 상이한 목도장으로 어음이 할인취급되었을 뿐만 아니라 어음할인 대전을 신청인이 전혀 사용하지 않았음이 명백하므로, 대법원의 판례취지 등을 감안할 때 본건 어음거래약정서 및 어음할인 거래는 통정허위표시에 해당되어 무효인 법률행위이며 어음할인은 명의도용에 의하여 이루어진 것으로 신청인에게 채무가 존재하지 아니한다고 판단됨.(2000.11.28. 조정번호 제2000-51호)

가. 사실관계

1997.6.12. 신청인이 A씨와 함께 상호신용금고(이하 “피신청인”이라 함)를 방문하여 장사인 (주)○○산업 발행어음 2매(만기일 1997.11.18.) 849백만원을 할인 요청함. 당시 어음거래약정서상에는 신청인이 자서·날인하였으며 한도액과 거래기간은 공란으로 하였으나, 피신청인이 법정관리 중인 (주)○○산업을 대한 채권신고시 한도액과 거래기간을 임의로 기입함. 위 어음은 만기이후 2차례에 걸쳐 A씨가 혼자 와서 920백만원으로 증액 대환처리후 상환함.

1998.9.10. A씨가 신청인의 목도장을 가지고 방문하여 본건 관련 (주)○○산업 발행어음 3매 1,390백만원을 할인한 후, 할인대전 중 350백만원은 B씨의 친척 예금계좌에, 250백만원은 피신청인의 출자자 직원 예금계좌에, 400백만원은 (주)○○산업 예금계좌에 각각 입금처리되고, 나머지는 A씨가 가져감.

1999.8.31. 위 어음들이 지급은행에서 부도처리되자 대출금 중 400백만원은 (주)○○산업 예금과 상계하고 현재 대출잔액은 990백만원임.

(주)○○산업 부도후 피신청인은 명의차주인 신청인에게는 채무변제책임을 묻지 않고 A씨에게만 변제독촉을 하였으며, 피신청인의 경영관리 개시 후 신청인 앞으로 채권채무 조회서를 발송함. 2000.8.14. 재차 통고서를 발송하면서 신청인에 대하여 불량거래등록을 하였고 이후 신청인의 항의로 해제를 함.

나. 당사자의 주장

(1) 신청인의 주장

상호신용금고 영업구역외 거래자인 A씨가 1997.6.12. 피신청인으로부터 400백만원을 할인받고자 신청인에게 차명을 요구하여 인감도장 등을 피신청인에게 전달한 후 당일 오후에 찾아왔음.

1998.9.10. 할인된 어음 3매(할인액 1,390백만원, 현재 잔액 990백만원)와 관련하여 신청인은 피신청인 영업장을 방문한 적도, 관련서류에 서명·날인한 사실도 없으며 날인된 인감은 어음거래약정서상의 것이 아니고, 피신청인도 이를 인정하고 있음.

(2) 피신청인의 주장

어음거래약정을 체결할 때 신청인이 직접 자필서명 및 날인을 하는 등 어음거래와 관련하여 발생할 수 있는 일련의 채무에 대해 신청인이 책임질 수 있는 상황을 충분히 인식할 수 있었는데도, 현재 문제가 되고 있는 어음들의 할인신청시 본인의 인감이나 자필서명이 없었음을 이유로 관련 채무에 대한 본인의 책임을 회피하려는 의도임.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 어음거래약정서 또는 어음할인신청서상 명의인인 신청인이 대출금 채무자로서의 상환책임이 있는지 여부라 할 것임.

(1) 본건 관련 일반적인 해석기준

금융기관이 대출을 취급할 때 대출계약서상의 차주가 실제 차주인 제3자를 위하여 단지 명의만을 대여한 사실을 알고 있으면서 실제 차주를 위하여 대출을 취급한 것으로 볼 수 있는 경우에 금융기관은 명의차주에게 대출금 변제 책임을 물을 수 없다는 것이 그간의 금융분쟁조정 결정¹⁾의 방향이며, 대법원도 금융기관이 동일인에 대한 대출한도를 회피하기 위하여 실질적인 채무자가 제3자를 형식상의 채무자로 내세우고, 금융기관도 이를 양해하여 제3자에 대하여는 채무자로서의 책임을 지우지 않을 의도하에 제3자 명의로 대출관계서류를 작성받은 경우에는 제3자는 형식상의 명의만을 빌려준 자에 불과하고 그 대출계약의 실질적인 당사자는 금융기관과 실질적 채무자이므로 제3자 명의로 되어 있는 대출약정은 금융기관의 양해하에 그에 따른 채무부담의 의사없이 형식적으로 이루어진 것에 불과하여 통정허위표시에 해당하는 무효의 법률행위라고 판시²⁾하고 있음.

(2) 본건 대출에 대한 신청인의 책임

금융분쟁조정위원회의 조정례, 대법원의 판례취지를 감안할 때 본건의 어음거래약정서 및 어음할인 거래는 통정허위표시에 해당되어 무효인 법률행위이고, 아래와 같은 점을 감안할 때 신청인의 대출채무는 존재하지 아니하는 것으로 판단됨.

① 1997.6.12. 어음거래약정서는 한도금액과 거래기간이 공란으로 작성되어 (주)○○산업의 채권신고시 피신청인이 임의기입한 것을 피신청인 직원들이 자인하고 있어 이를 한도거래약정으로 볼 수 없는 점.

② 1998.9.10.에 이루어진 어음할인 거래는 개별한도거래로 피신청인이 주장하는 한도액 1,000백만원을 초과하여 할인취급된 것이 이를 입증하고 있는 점.

③ 또한 대표이사의 지시에 의하여, 신고된 인감과는 상이한 목도장으로 어음이 할인 취급되었으므로 이는 명의대여가 아니라 사실상 명의도용으로 보아야 한다는 점.

④ 어음할인의 대전을 신청인이 전혀 사용하지 않았음이 명백하므로 본건은 실 채무자인 A씨와 피신청인 사이에 이루어진 금전소비대차로 볼 수 있다는 점.

1) 금융분쟁조정위원회 조정번호 제1998-11호, 제1999-47호 등 참조.

2) 대법원 1992.6.12. 선고 92다10722, 1999.3.12. 선고 98다48989 판결 참조.

라. 결론

본건은 그 간의 조정례, 대법원의 판례취지 등을 감안할 때 어음거래약정서 및 어음할인 거래는 통정허위표시에 해당되어 무효인 법률행위이며 어음할인은 명의도용에 의하여 이루어진 것으로 신청인에게 채무가 존재하지 아니한다.

1-2 금융기관이 규제회피를 위해 타인명의로 대출한 경우 명의대여자의 책임

[인용] 본건 대출은 피신청인이 동일인대출한도 규제를 회피하기 위해 사업자등록증이 있는 다른 사람의 채무자 명의를 요구함에 따라 실제차주가 신청인에게 부탁하여 사업자등록증을 만들게 한 후 신청인 명의로 대출을 신청한 것으로, 실제차주도 이를 인정하고 있고 금융감독원 검사결과에서도 이러한 내용이 밝혀진 점 등에 비추어 피신청인의 신청인에 대한 본건 대출은 존재하지 아니한다 할 것임.(2011.5.17. 조정번호 제2011-31호)

가. 사실관계

상호저축은행(이하 “피신청인”이라 함)은 2004.1.29. 신청인을 채무자 명의로 하여 9억원의 대출을 실행하는 것을 비롯해 2006.5.2.까지 총 16억원의 신청인 명의 대출을 취급하였으며, 동 대출금은 신청인 명의 예금계좌에 입금된 직후 보증인(B문화원 대표 A씨)에게 지급됨. 한편, 2008.8.25~10.10., 2009.3.23.~5.14. 기간중 피신청인에 대하여 실시한 금융감독원 검사에서 본건 대출은 동일인에 대한 여신한도 초과상황을 회피하기 위하여 실제차주(A씨)에게 타인 명의를 이용하여 대출³⁾이 이루어진 것으로 지적을 받음.

나. 당사자 주장

(1) 신청인 주장

신청인은 B문화원 대표 A씨의 부탁을 받고 명의만 빌려준 것이고 대출금을 사용한

3) 신청인은 당시 실제차주 A씨의 이중사촌으로 A씨가 운영하던 B문화원의 종업원으로 근무하고 있었고, 피신청인인 상호저축은행은 A씨에게 본건 포함 타인 명의를 이용하여 총48억원의 대출을 취급하였음.

사실이 없음. 본건 대출은 피신청인이 동일인대출한도 초과를 회피하기 위해 단순히 신청인의 명의를 이용한 것일 뿐 신청인에게 상환책임을 물을 의도로 대출을 취급한 것이 아니며, 실제차주인 A씨에게 상환책임을 물을 의도로 대출을 취급한 것임.

(2) 피신청인 주장

신청인이 본건 대출서류에 자의로 자서날인 하였고 대출금이 신청인의 예금통장에 입금된 후 인출되어 사용된 점 등을 감안하면 신청인과 A씨간에 사적금전대차가 존재하는 것으로 파악됨.

다. 위원회 판단

◆ 본건의 쟁점은 본건 대출관련 신청인의 대출채무가 유효하게 존재하는지 여부라 할 것임.

(1) 관련판례 및 조정례

명의대여의 경우, 대출계약에 따른 경제적 효과 뿐만 아니라 그 법률상 효과까지도 타인에게 귀속시키려는 의사였는지 여부는 구체적 사안에 있어서 실제 차주와 명의대여자의 이해관계의 일치 여부, 대출금의 실제 지급 여부 및 직접 수령자, 대출서류 작성과정에 있어서 명의대여자의 관여 정도, 대출의 실행이 명의대여자의 신용에 근거하여 이루어진 것인지 혹은 실제 차주의 담보제공이 있었는지 여부, 명의대여자에 대한 신용조사의 실시 여부 및 조사의 정도, 대출원리금의 연체에 따라 명의대여자에게 채무이행의 독촉이 있었는지 여부 및 그 독촉 시점 기타 명의대여의 경위와 명의대여자의 직업, 신분 등의 모든 사정을 종합하여 고려하여 판단할 것임.⁴⁾

또한 금융기관이 동일인에 대한 대출액 한도 제한을 회피하기 위하여 실질적인 주채무자가 실제 대출받고자 하는 채무액에 대하여 제3자를 형식상의 주채무자로 내세우고, 금융기관도 이를 양해하여 제3자에 대하여는 채무자로서 책임을 지우지 않을 의도 아래 제3자 명의로 대출관계서류를 작성받은 경우, 제3자는 형식상의 명의만을 빌려 준 자에

4) 대법원 2008.6.12. 선고 2008다7772 판결 등 참조.

불과하고 그 대출계약의 실질적인 당사자는 금융기관과 실질적 주채무자이므로, 제3자 명의로 되어 있는 대출약정은 금융기관의 양해 아래 그에 따른 채무부담의 의사 없이 형식적으로 이루어진 것에 불과하여 통정허위표시에 해당하는 무효의 법률행위에 해당한다 할 것임.⁵⁾

(2) 본건 대출채무의 유효성 여부

본건 관련 신청인의 대출책임 여부를 살펴보면, 위 조정사례 등에 비추어 볼 때 아래와 같은 이유로 피신청인이 신청인에게 본건 대출의 책임을 묻는 것은 부당하다고 판단됨.

① 피신청인에 대한 금융감독원 검사결과 신청인 명의의 본건 대출은 동일인 여신한도 초과를 회피하기 위하여 실제차주인 A씨에게 신청인 명의를 이용하여 대출을 한 것으로 밝혀진 점.

② 저축은행의 『표준대출규정』 제27조에 의하면 채무자의 재산, 신용 및 사업실태를 조사하도록 되어 있는데, 피신청인은 본건 대출취급시 신청인에 대한 형식적인 신용조사만 하였을 뿐이며 사실상 변제자력이 없는 신청인에게 본건과 같은 거액의 대출을 한다는 것은 쉽게 생각하기 어려운 점.

③ 신청인에 대한 본건 대출시 피신청인이 실제차주인 A씨와 그 가족을 보증인으로 입보시키고 있는 바, 사실상 변제자력이 없는 신청인에게 거액의 본건 대출을 취급하면서 A씨와 그 가족을 보증인으로 입보시킨 것은 A씨에게 상환책임을 묻고 변제자력이 없는 신청인에게는 상환책임을 부담시킬 의도가 없었다고 보여지는 점.

④ 본건 대출의 실제차주인 A씨 또한 본건 대출은 피신청인이 동일인 대출한도를 회피하기 위해 사업자등록증이 있는 다른 사람의 채무자 명의를 요구함에 따라 신청인에게 이를 부탁하여 사업자등록증을 만들게 한 후⁶⁾ 신청인 명의로 대출을 신청한 것이라면서 본건 대출의 실제차주는 본인이라고 인정하고 있는 점.

5) 대법원 1999.3.12. 선고 98다48989 판결, 2001.5.29. 선고 2001다11765 판결, 금융분쟁조정결정 조정번호 제2000-51호, 제2001-35호 등 참조.

6) A씨는 본건 대출 직전인 2004.1.20. B웨딩홀내에 “B스튜디오”라는 상호로 사업자등록을 한 바 있음.

라. 결 론

신청인의 피신청인에 대한 본건 대출채무는 존재하지 아니한다는 신청인의 주장은 이유 있으므로 이를 인용함.

1-3 명의도용 대출의 변제책임 유무

[인용] 제3자가 신청인의 명의를 도용하고 관련서류를 위조하여 피신청인과 대출계약을 체결한 경우 대출계약의 당사자는 대출계약에 표시된 신청인이라 할 것이나 제3자가 아무런 권한 없이 임의로 신청인 명의로 대출계약을 체결한 것이므로 대출계약이 유효하게 체결되었다고 보기 어렵다 할 것임.(2011.5.17. 조정번호 제2011-30호)

가. 사실관계

신청인은 대학 휴학생으로 2010.6.6. 친구인 A씨로부터 동인이 렌트하여 이용중인 차량(BMW)을 빌리면서 A씨에게 주민등록증을 교부하였음.

2010.6.7. A씨는 신청인의 주민등록증을 제시하며 신청인 행세를 하고, 동사무소에서 신청인의 주민등록등본 등·초본을 교부받은 후 ○○은행 모지점에서 ‘예금·신탁거래신청서’ 및 ‘전자금융거래신청서’를 작성하여 신청인 명의 예금계좌를 개설하고 ‘공인인증서’를 발급받았으며, 인터넷 대행사 사이트에 신청인의 주민등록번호와 이름을 입력하여 신청인 명의 휴학증명서를 발급받았음.

2010.6.9. A씨는 학자금대출을 중개해 주는 인터넷 대출모집수탁업체 (주)△△⁷⁾에 신청인의 주민등록등본, 휴학증명서, 주민등록증 사본, 은행 통장사본 등 본인관련 서류를 송부하였으며, 동 업체로부터 ○○상호저축은행(이하 “피신청인”이라 함)을 소개받은 후, 피신청인 홈페이지에 접속, 신청인 정보를 입력하고 은행에서 발급받은 공인인증서를 이용하여 피신청인으로부터 410만원을 대출⁸⁾받아 인출하였음.

7) (주)△△는 피신청인과 업무위탁계약을 체결하고 대출신청인의 신상정보 등 관련자료 제공, 대출신청서류 전달 등 업무를 수행하는 대출모집업체임.

피신청인은 대출당시 신청인에게 휴대폰으로 통화를 하여 본인확인을 하였다고 주장하나 이는 A씨가 신청인 행세를 하며 통화를 한 것이고, 신청인은 A씨가 휴대폰 배터리가 떨어졌다고 하여 신청인의 휴대폰을 A씨에게 잠시 빌려준 적이 있을 뿐이라고 주장하고 있음.

한편, 2011.2.8. A씨는 ○○지방법원에서 사문서위조, 사기죄 등으로 징역 2년 6월 및 벌금 2백만원을 선고받음

나. 당사자 주장

(1) 신청인 주장

본건 대출은 A씨가 신청인의 명의를 도용하여 이루어진 것이므로 신청인에게 대출채임을 묻는 것은 부당함.

(2) 피신청인 주장

대출 당시 신청인의 주민등록등본, 통장사본, 재학증명서 등 대출관련 서류를 제출받고 공인인증서로 본인임을 확인하고 본건 대출이 이루어진 것이므로 신청인 주장을 수용하기 어려움.

다. 위원회 판단

◆ 본건의 쟁점은 본건 대출에 대하여 신청인과 피신청인간 대출계약이 유효하게 성립되었는지 여부라 할 것임

신청인과 피신청인간 본건 대출계약이 유효하게 성립되었는지 여부를 살펴보면, 우선 계약을 체결하는 행위자가 타인의 이름으로 법률행위를 한 경우에 행위자 또는 명의인 가운데 누구를 계약의 당사자로 볼 것인가에 관하여는, 행위자와 상대방의 의사가 일치한 경우에는 그 일치한 의사대로 행위자 또는 명의인을 계약의 당사자로 확정해야 하고,

8) 피신청인 대출신청절차 : ① 피신청인 홈페이지에 접속하여 신청인 기본정보 입력 및 약관동의 → ② 대출신청서 작성 및 본인인증 → ③ 대출신청완료

행위자와 상대방의 의사가 일치하지 않는 경우에는 그 계약의 성질·내용·목적·체결 경위 등 그 계약 체결 전후의 구체적인 제반 사정을 토대로 상대방이 합리적인 사람이라면 행위자와 명의자 중 누구를 계약 당사자로 이해할 것인가에 의하여 당사자를 결정하여야 할 것임.⁹⁾

그런데 본건의 경우, A씨가 신청인의 명의를 임의로 모용하고 관련서류를 위조하여 피신청인과 본건 대출계약을 체결한 것이므로 본건 대출계약의 당사자는 대출계약에 표시된 신청인이라 할 것이고, 이는 A씨가 아무런 권한 없이 임의로 신청인 명의로 대출계약을 체결한 것이므로 신청인과 피신청인간 대출계약이 유효하게 체결되었다고 보기 어렵다 할 것임.

나아가, 피신청인은 본건 대출계약 체결시 대출관련 서류 및 공인인증서를 통하여 본인 여부를 확인하는 등 A씨를 본인인 것으로 믿었고 그 믿은 데에 정당한 이유가 있다는 취지의 주장을 하고 있으나, 민법상 표현대리는 대리인이 본인을 위한다는 의사를 명시 혹은 묵시적으로 표시하거나 대리의사를 가지고 권한 외의 행위를 하는 경우에 성립하고, 사술을 써서 위와 같은 대리행위의 표시를 하지 아니하고 단지 본인의 성명을 모용하여 자기가 마치 본인인 것처럼 기망하여 본인 명의로 직접 법률행위를 한 경우에는 특별한 사정이 없는 한 표현대리는 성립될 수 없다 할 것이고,¹⁰⁾ 본건의 경우도 A씨가 아무런 권한 없이 자신이 신청인인 것처럼 가장하여 대출계약을 체결한 경우이므로 신청인의 표현대리 책임도 인정되기 어렵다 할 것임.

라. 결 론

위에서 본 바와 같이 본건 대출채무가 부존재 한다는 신청인의 청구는 이유 있다 할 것임.

9) 대법원 2011.2.10. 선고 2010다83199 판결 참조.

10) 대법원 2002.6.28. 선고 2001다49814 판결 참조.

제2절 채무명의 변경 등에 따른 권리의무관계

1-4 면책적 채무인수에 대하여 채권자인 은행의 승낙이 있었는지 여부

[인용] 근저당권이 설정된 부동산 매매 당사자들이 은행을 방문하여 본건 대출금채무에 대한 인수의 승낙을 요청한 사실과 이를 은행이 수용키로 결정한 사실이 관련 자료에 의하여 확인되는 바, 신청인의 대출금 채무가 피신청인의 명시적 혹은 묵시적인 방법에 의한 승낙에 의하여 제3자에게 면책적으로 인수되었다고 볼 수 있으므로 신청인과 피신청인사이의 본건 대출금 채무는 존재하지 아니한 것으로 판단됨.(2001.1.30. 조정번호 제2001-4호)

가. 사실관계

1994.7.16. 신청인은 ○○은행(이하 “피신청인”이라 함)으로부터 금 15백만원을 대출(변제기 1995.7.18.)받으면서 소유부동산에 근저당권을 설정하였으며, 1995.5.24. 담보부동산의 소유권이 신청외 A씨에게 이전됨.

1997.10.14. 지방법원에서 위 부동산에 대한 임의경매 개시가 결정되었고, 1998.7.7. 피신청인은 경매배당금으로 11,931,984원을 수령(잔여채권 11,658,508원)하였으며, 1998.9.30. 피신청인은 자산관리공사에 동 채권을 매각함.

나. 당사자의 주장

(1) 신청인의 주장

담보부동산을 A씨에게 양도할 당시 대출금채무를 A씨가 인수한다는 조건이었으며 신청인의 처가 피신청인 직원에게 관련서류 일체를 제출하면서 피신청인 직원이 제시하는 서류에 인감날인 하는 절차를 밟았으므로 피신청인도 채무인수를 승낙하였다고 볼 수 있음. 위 A씨로부터 채권회수를 못하게 되자 당시의 사정과는 달리 신청인을 채무자로 확정시키려는 피신청인의 조치는 부당함.

(2) 피신청인의 주장

담보부동산 소유권이전사실 확인후 양 당사자(신청인 및 A씨)에게 대출금상환독촉을 하였으나 관련서류에 신청인 본인이 자서날인을 하지 아니하여 대출 양·수도 절차를 이행하지 아니하였음. 본건 대출과 관련하여 A씨에게 상환독촉한 것은 내부적으로 대출 관리를 위하여 A씨의 대출과 함께 관리한 것임.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 면책적 채무인수와 관련하여 채권자의 승낙이 있었는지 여부라 할 것임.

민법 제454조는 “제3자가 채무자와의 계약으로 채무를 인수한 경우에는 채권자의 승낙에 의하여 그 효력이 생긴다.”라고 규정하고 있으며, 대법원은 채무인수의 효력이 생기기 위하여 채권자의 승낙을 요하는 것은 면책적 채무인수의 경우에 한하고, 채무인수가 면책적인가 중첩적인가 하는 것은 채무인수계약에 나타난 당사자 의사의 해석에 관한 문제라고 판시하고 있음.¹¹⁾

신청인으로부터 근저당권이 설정된 부동산을 신청외 A씨가 매수하면서 본건 대출금 채무를 인수하기로 약정하였음은 양당사자간에 다툼이 없음. 그렇다면 면책적 채무인수와 관련하여 채권자인 피신청인의 승낙이 있었는지의 여부만이 문제된다고 할 것임.

피신청인은 면책적채무인수의 요건을 결하였다고 주장하나, ① 근저당권이 설정된 부동산 매매 양당사자가 은행을 방문하여 본건 대출금채무에 대한 인수의 승낙을 요청한 사실과 이를 은행이 수용키로 결정한 사실이 문답서 및 은행직원 작성의 경위서에 의하여 확인되는 점. ② 당시 신청인의 처가 은행직원이 요구하는 서류(인감증명서, 등기관리증, 주민등록등본 등)를 제출하였고 이러한 사실을 은행직원도 확인하고 있으며, 다만 채무자변경 관련서류상 신청인 본인의 자서날인 여부에 대하여만 다툼이 있으나, 피신청인의 내부업무처리기준상 채권관련서류의 작성시 본인이 자서날인을 하도록 규정되어 있다는 사실만으로는 대리인 혹은 사자(使者)에 의한 행위의 법적효력을 부인할 수 없는 점. ③ 문답서 및 피신청인 작성의 채권사후관리부의 기재내용을 살펴보면, A씨 대

11) 대법원 1998.11.24. 선고 98다33765 판결 참조.

출현황에 신청인 명의의 대출금이 포함된 사실 및 “보증인 입보후 대환요청 → 보증세울 사람이 없다고 함”의 기재취지와 A씨에게 수 차례에 걸쳐 변제독촉한 사실에 비추어 피신청인이 양당사자간 채무인수계약 직후 위 A씨를 채무자로 관리하였다고 추정하기에 충분한 점 등의 사정을 종합할 때, 채권자인 피신청인의 승낙이 있었으므로 본건 대출금 채무가 신청외 A씨에게 면책적으로 인수되었다고 판단됨.

대법원도 채무자와 인수인 사이의 계약에 의한 채무인수에 대하여 채권자는 명시적인 방법뿐만 아니라 묵시적인 방법으로도 승낙을 할 수 있는 것인데, 채권자가 직접 채무인수인에 대하여 인수채무금의 지급을 청구하였다면 그 지급청구로써 묵시적으로 채무인수를 승낙한 것으로 보아야 한다고 판시한 바 있음.¹²⁾

라. 결 론

신청인의 대출금채무가 피신청인의 명시적 혹은 묵시적인 방법에 의한 승낙에 의하여 신청외 A씨에게 면책적으로 인수되었다고 볼 수 있으므로 신청인과 피신청인 사이의 본건 대출금 채무는 존재하지 아니한 것으로 판단됨.

1-5 계약인수로 채무자 명의가 변경된 경우 잔여채무 변제책임의 유무

[인용] 채무자 명의가 계약인수에 의해 신청인에서 제3자로 변경되었고, 담보부동산의 근저당권이 ‘계약인수’를 등기원인으로 변경등기가 경료된 점, 근저당권변경계약서상에 구채무자가 신청인으로 신채무자가 제3자로 표시되어 있어 계약인수후 신청인의 채무자 지위가 탈퇴되었다고 볼 수 있는 점 등을 감안시, 신청인이 본 건 대출의 채무자 지위를 제3자에게 면책적으로 계약인수시키고 채무자 지위를 탈퇴한 것으로 판단되므로 본건 대출의 잔여채무를 변제할 책임이 없다고 봄이 타당함.(2002.8.6. 조정번호 제2002-34호)

가. 사실관계

12) 대법원 1989.11.14. 선고 88다카29962 판결 참조.

신청인은 1997.2.28. 구○○상호신용금고(이하 “구 금고”라 함)로부터 A개발(대표: B씨) 소유의 부동산(이하 “부동산”이라 함)을 담보로 제공하고 12억원(연대보증인:A개발과 B씨)을 대출(이하 “본건 대출”이라 함)받았음.

신청인, A개발 및 구○○상호신용금고는 1998.3.31. “계약인수로 인한 근저당권 변경계약서”를 작성하고 부동산에 설정된 본건 대출 관련 근저당권의 채무자 명의인을 신청인에서 A개발로 변경 등기하였음.

구○○상호신용금고는 본건 대출이 부실화되자 1999.10.28. 부동산을 임의경매로 처분하여 대출원금만을 회수(1999.10.28. 현재 미회수 연체이자: 1.9억원)하였고, 1999.7.13. 신청인에 대해 신용불량정보를 등록하였다가 동년 11.4. 해제하여 주었음. 한편 동 상호신용금고는 2000.6.15. 관련 법률에 의거 부실금융기관으로 지정되어 영업정지를 당한 후 2000.11.11. 피신청인에게 계약이전 됨.

나. 당사자 주장

(1) 신청인 주장

본 건 대출은 1998.3.31. A개발에 계약인수 되어 대출의 채무자 명의인이 신청인에서 A개발로 변경되었으므로 신청인은 동 대출의 잔여채무를 변제할 책임이 없음.

(2) 피신청인 주장

신청인, A개발 및 구 금고간에는 본건 대출에 대한 신청인의 채무자 지위를 탈퇴시키고 A개발이 본건 대출을 면책적으로 계약인수 하는 별도의 계약인수약정을 체결한 사실이 없음.

따라서 신청인은 본건 대출에 대한 채무자 지위를 그대로 유지하면서 동 대출을 A개발에 중첩적으로 계약인수 하였거나 또는 A개발이 본건 대출에 단순히 연대보증 하었다고 볼 수 있으므로 신청인은 본건 대출의 차주로서 미상환된 연체이자를 변제할 책임이 있음.

다. 위원회 판단

◆ 본건의 쟁점은 신청인 명의의 대출이 1998.3.31. 동 대출의 채무자 명의인이 신청인에서 A개발로 변경될 시 면책적 계약인수가 되었는지 여부라 할 것임.

신청인 명의의 대출이 1998.3.31. A개발에 계약인수 되어 동 대출의 채무자 명의인이 신청인에서 A개발로 변경될 시 면책적 계약인수가 되었는지 여부에 대해 살펴보면, 대출계약 인수는 종래의 대출계약 당사자 일방이 가지고 있던 권리·의무가 모두 그대로 계약인수인에게 이전되는 것을 말하며, 금융실무상 계약인수인이 종래 대출계약상의 채무자 지위를 전부 인수하여 기존 채무자가 채무자 지위에서 탈퇴되는 경우를 ‘면책적 계약인수’라 하고, 계약인수인이 종래 대출계약상의 채무자 지위를 중첩적으로 인수하여 기존 채무자와 함께 채무자로 추가되는 경우를 ‘중첩적 계약인수’라 함.

대법원의 「근저당권에 관한 등기사무처리지침」(이하 “등기사무지침”이라 함) 3-가에 의하면 근저당권 변경등기시 제3자가 기본계약을 전부 인수하는 경우에는 “계약인수”, 제3자가 수 개의 기본계약 중 그 일부를 인수하는 경우에는 “계약의 일부 인수”, 제3자가 기본계약상의 채무자 지위를 중첩적으로 인수하는 경우에는 “중첩적 계약인수”를 등기원인으로 각각 표시함. 등기사무지침 6-나-1-가)~다)에 의하면 등기원인이 ‘계약인수’인 경우 “변경전의 채무자 표시를 주말(朱抹)한다”고 규정되어 있음.

구 금고가 1998.3.31. 지방법원에 제출한 본건 대출관련 부동산의 ‘근저당권 변경등기 신청서’ 및 ‘근저당권 변경계약서’에 의하면 등기원인이 ‘계약인수’로, 구 채무자가 신청인으로, 신 채무자가 A개발로 각각 기재되어 있음. 부동산의 부동산등기부등본 을구를 살펴보면 제8번란에 ‘채무자 을(신청인)’이 실선¹³⁾으로 그어져 있고, 제8-1번란에는 ‘제8번 근저당권변경, 1998.3.31. 계약인수, 채무자 A개발’이 기재되어 있음.

아래와 같은 점에 비추어 볼 때 본건 대출의 채무자 명의인은 1998.3.31. 계약인수에 의해 신청인에서 A개발로 변경되었고 신청인은 본건 대출의 채무자 지위를 탈퇴한 것으로 보아야 할 것임.

13) 말소사항을 표시할 때 사용하며 등기사무지침상의 朱抹표시에 해당됨.

① 부동산의 근저당권이 제3자(B개발)가 기본계약(본건 대출계약)을 전부 인수하는 ‘계약인수’를 등기원인으로 하여 변경등기 된 점.

② 부동산의 부동산등기부등본 을구란에 신청인의 채무자 지위가 주말되어 있는 점.

③ 근저당권변경계약서상에 구 채무자가 신청인으로, 신 채무자가 A개발(주)로 표시되어 있어 계약인수후 신청인의 채무자 지위가 탈퇴된다고 볼 수 있는 점.

④ 피신청인은 A개발이 본건 대출을 중첩적으로 계약인수 하였거나 단순히 연대보증 하였다고 볼 수 있다고 주장하나 이를 입증할 수 있는 여타 증거를 발견할 수 없는 점.

라. 결 론

신청인은 1998.3.31. 본건 대출의 채무자 지위를 A개발 앞으로 면책적으로 계약인수 시키고 채무자 지위를 탈퇴한 것으로 판단되므로 본건 대출의 잔여채무를 변제할 책임이 없다고 봄이 타당함.

1-6 조건이 성취되지 않은 정지조건부 채권양도의 대물변제 효력 여부

[기각] 본건은 채권양도계약에 따른 구채권의 소멸여부가 쟁점인 바, 본건 채권양도계약은 대물변제 그 자체가 아니라 ‘대물변제의 예약’으로서, 환송판결의 내용이 그대로 확정되어야 비로소 변제의 효과가 발생하는 ‘정지조건부 채권양도’라고 판단되며 정지조건이 불성취되었으므로 결국 채권양도로 인한 대물변제의 효력은 인정되지 않는다고 할 것임.(2004.10.19. 조정번호 제2004-38호)

가. 사실관계

신청인 A씨 외 2인은 형제지간으로 양돈업에 종사하던 자인 바, 1991년경부터 ○○농협(이하 “피신청인”이라 함)으로부터 수차례에 걸쳐 4억4천여만원을 대출받았으나, 한국도로공사의 고속도로 확장공사로 인해 발생한 소음과 진동으로 신청인들이 사육하는 돼지들이 스트레스를 받아 몰사하자(1996.5월 양돈장 폐업) 대출금 변제가 곤란해짐.

신청인들은 1997.4.3. 한국도로공사를 상대로 손해배상청구소송을 제기하여 1998.6.18. 제1심판결후 가집행으로 8억7천여원을 배상받음.

신청인들의 변제가 지연되자, 피신청인은 2001.8.16. 신청인들을 채무자로, 한국도로공사를 제3채무자로 하여 채무자가 제3채무자에 대하여 가지는 손해배상채권중 일부에 대해 압류 및 추심명령을 받음.

신청인들은 2001.9.11. 위 손해배상소송의 파기환송심에서 17억여원의 일부승소판결을 받게 되자 피신청인에게 제안하여, 2001.9.17. 기존채권에 갈음하여 위 인용금액 중 7억3천만원¹⁴⁾의 손해배상채권을 피신청인에게 양도하는 계약¹⁵⁾을 체결하고, 대신 피신청인은 위 채권압류신청을 취하함.

2004.5.13. 선고된 제2차 파기환송판결로 인하여 위 한국도로공사의 신청인에 대한 전체 손해배상금은 8억7천여만원으로 확정되었는 바, 이는 제1심판결후 이미 가집행받은 인용금액정도에 불과하여 추가로 지급받을 금원이 없음.

14) 계약 당시 피신청인은 신청인들이 이미 가집행선고로 일부 배상받은 사실을 인지하였으며, 7억3천만원은 2001.12.31.까지의 채무액(원금 447백여만원, 이자 289백여만원, 비용 9백여만원, 합계 745백여만원)을 기준으로 산정한 금액임. 한국도로공사가 12억원을 공탁하고 상고하여 소송이 장기화되자, 2003.12.16. 피신청인은 신청인들에 대한 일부채권을 근거로 담보부동산에 대한 임의경매 개시결정 및 강제경매 개시결정을 받음.

15) 채권양도양수 계약서의 주요 내용은 다음과 같음.

① 양도인 : A씨 외 2인

② 양수인 : ○○농업협동조합

③ 양도채권 : 양도인들이 한국도로공사로부터 받을 손해배상금 합계 1,731,618,750원 중 730백만원

④ 양도년월일 : 2001.9.17.

⑤ 특약사항 :

- 양수인 ○○농협은 ○○지방법원 2001△△10××호로 한 채권압류 및 추심명령사건을 취하하고, 양수인의 추심채권 중 금 730백만원을 초과하는 부분은 이를 포기함.

- 위 양도는 양도인의 양수인에 대한 동액상당의 채무변제로 양도하는 것이므로 본 양도로서 그 양수인에 대한 채무는 소멸되는 것이나, 만일 양도인의 귀책사유로 양수인이 그 양수한 채권을 지급받지 못하였을 경우에는 그 소멸한 구채권은 부활하는 것으로 하고, 양도인은 조속한 시일 내에 위 양도사실을 내용증명 우편으로 채무자에게 통지할 것이며, 위 계약을 더욱 확실히 하기 위하여 양도인은 양도한 채권의 증서를 양수인에게 교부함.

나. 당사자의 주장

(1) 신청인 주장

피신청인은 2001.9.17. 기존채무의 지급에 갈음하여 신청인으로부터 7억3천만원의 손해배상채권을 양도받았으므로 기존채무는 소멸되었다고 할 것임. 따라서 피신청인이 신청인들 소유의 토지에 대하여 임의경매 및 강제경매를 신청한 것은 부당함.

(2) 피신청인 주장

신청인 주장과 같은 채권양도계약을 체결한 사실이 있으나, 이는 2001년도 중에 소송이 종료되어 상환받을 수 있으리라는 전제하에 체결된 것이므로, 2001년중 소송이 종료되지 않은 이상 구채권이 부활한다고 할 것이어서 부동산경매신청에는 아무런 하자가 없음.

다. 위원회의 판단

◆ 본 건의 쟁점은 채권양도계약에 따른 구채권의 소멸여부임.

본건 채권양도계약상 “채무변제로 양도하는 것”이라거나 “본 양도로서 그 양수인에 대한 채무는 소멸되는 것”이라는 문구가 있어 일응 대물변제로 볼 여지가 있으나, 아래의 점을 종합하면, 당해 채권양도계약은 대물변제 그 자체가 아니라 “대물변제의 예약”으로서, 환송판결의 내용이 그대로 확정되어야 비로소 변제의 효과가 발생하는 “정지조건부 채권양도”라고 판단됨.

① 피신청인이 손해배상채권에 대해 압류 및 추심명령을 받아 불리한 조건으로 양도계약을 체결할만한 별다른 사유가 존재하지 않는 상황¹⁶⁾에서, 신청인들로부터 미확정된 채권을 양도받고 압류신청을 취하하는 것에서 더 나아가 기존의 대출금 채권 및 담보권을 모두 소멸시키기로 약정하였다는 것은 심히 형평에 어긋나는 점.

② 채권양도계약 체결을 전후하여 동일한 채권에 대한 “추심”이 “양도” 형식으로 변

16) 피신청인이 손해배상채권에 대해 압류 및 추심명령을 받아 신청인들이 이를 취하시키고자 먼저 채권양도계약의 체결을 제안하여 채권양도계약이 체결됨.

하였다는 점을 제외하고는 별다른 사정변경이 없었으므로, 구채권의 추심이나 담보목적
으로 양도계약이 체결되었다고 해석하는 것이 합리적인 점.

③ 당사자가 동 계약으로 구채권을 곧바로 소멸시키고자 의도하였다면 그에 따른 저
당권등기말소등에 관하여도 합의하였을 것이라 추정되나, 당사자간에는 채권압류신청의
취하외에 별도로 담보권소멸에 관하여 약정한 사실이 없는 점.

④ 대법원은 채무자가 채무변제와 관련하여 다른 채권을 채권자에게 양도한 경우, ‘특
단의 사정이 없는 한’ 그 채권양도는 채무변제에 갈음한 것이 아니라 채무변제를 위한
담보 또는 변제의 방법으로 양도되는 것으로 추정하고 있는 점.¹⁷⁾

신청인들의 소송수행결과 한국도로공사로부터 추가로 지급받을 금원이 존재하지 않는
본건은, “정지조건부 채권양도계약”에 있어 정지조건이 불성취된 경우에 해당하므로, 결
국 채권양도로 인한 대물변제의 효력이 인정되지 않는다고 할 것임.

라. 결 론

위에서 본 바와 같이 채권양도계약으로 인해 기존채권이 소멸되었다는 신청인들의 주
장은 이유 없음.

1-7 금융기관이 신청인의 채무인수 합의에 승낙해야 할 의무가 있는지 여부

[기각] 채무인수 합의가 있었는지 여부도 명확하지 않을 뿐 아니라 그러한 채무인수 합의가
효력을 발생하기 위해서는 민법상 채권자인 피신청인의 승낙이 필요하며, 이 경우 피신청인
으로서는 다른 특별한 약정이 없는 한 신청인과 인수인 사이에 행해진 채무인수 합의에 승낙
하여야 할 의무를 부담한다고 볼 수 없음.(2006.2.14. 조정번호 제2006- 4호)

가. 사실관계

2001.7.3. 신청인은 서울특별시 ○○구 소재 부동산(이하 “본건 부동산”이라 함)을 담

17) 대법원 1995.9.15. 선고 95다13371 판결, 1990.2.13. 선고 89다카10385 판결 등 참조.

보로 ◇◇은행(이하 “피신청인”이라 함) 지점으로부터 금 4.7억원의 대출(이하 “본건 대출”이라 함)을 받았고, 2001.9.28. 신청인은 본건 부동산을 A씨에게 매도한 후 피신청인에 대해 본건 대출을 매수인에게 채무인수토록 요청하였음.

동 채무인수 요청에 대해 피신청인은 처음에는 이를 수용하지 않고 있다가 신청인의 계속적인 요청에 따라 매수인에 대한 채무인수 절차를 진행하였으나, 이 때에는 A씨가 채무인수에 대한 동의를 하지 않아 결국 채무인수 절차가 중단되었음.

이와 관련하여 피신청인은 신청인의 채무인수 요청에 대하여 인수인인 A씨의 신용상태가 양호하지 않아 일부 변제후 채무인수가 가능하다고 통보하였으나, 신청인이 동일담보의 동일한 금액의 대출이 취급되었으므로 과다대출이 아님을 주장하며 일부 변제없이 채무인수를 계속 요청하여 민원해소 차원에서 채무인수 절차를 진행키로 하고 당시 교도소에 수감 중이던 A씨를 찾아갔으나 A씨가 채무인수에 동의의사를 표시하지 않았다고 함.

이후 본건 대출이 연체되자 피신청인은 2002.5.11. 법원에 본건 부동산을 경매신청하였고, 2004.7.23. 금2.5억원의 배당금을 수령하는 한편, 잔액 금2.2억원(미수이자 금2.7억원 제외)에 대해 신청인에 대해 상환을 청구하였음.

나. 당사자의 주장

(1) 신청인 주장

신청인은 피신청인이 당초 본건대출금이 과다하다는 사유를 들어 채무인수를 거절하지 않았다면 본건 부동산의 매수인인 A씨에 대한 채무인수가 원만히 진행되었을 것이므로 피신청인이 본건 대출금을 신청인에게 상환청구하고 있는 것은 부당함.

(2) 피신청인 주장

신청인이 채무인수를 요청하였으나 A씨의 신용상태가 양호하지 않아 채무인수를 위해서는 본건대출의 일부 변제가 필요하다고 통보하였으며, 이후 신청인이 일부 변제 없이 채무인수를 요청함에 따라 민원 해소차원에서 채무인수 절차를 진행키로 결정하였으나 결국 매수인이 채무인수를 동의하지 않았으므로 신청인의 주장을 수용할 수 없음.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 피신청인의 신청인에 대한 본건 대출의 상환청구가 정당한지 여부라 하겠음.

다음과 같은 점에 비추어 볼 때 신청인으로서 본건 대출의 상환책임을 면하기 어려운 것으로 판단됨.

① 본건에 있어 당초 신청인과 매수인간에 본건 대출에 관한 채무인수 합의가 있었는지 여부도 명확하지 않을 뿐 아니라, 그러한 채무인수 합의가 있었다 하더라도 신청인과 A씨간의 채무인수 합의가 효력을 발생하기 위해서는 민법상 채권자인 피신청인의 승낙이 필요하며, 이 경우 피신청인으로서 다른 특별한 약정이 없는 한 신청인과 인수인간에 행해진 채무인수 합의에 승낙하여야 할 의무를 부담한다고 해석할 수 없다는 점.

② 피신청인은 A씨의 신용상태를 이유로 일부변제를 요청하는 등 신청인과 인수인사이의 채무인수 합의에 대해 사실상 승낙을 거절하였다고 볼 수 있는 점.

③ 또한 피신청인이 채무인수 절차를 진행하기로 한 이후에는 A씨가 동의를 하지 않아 본건대출의 채무인수가 이루어지지 아니한 점.

라. 결 론

신청인의 피신청인에 대한 대출금 채무는 유효하게 존재한다 할 것이므로 신청인의 청구는 이유 없어 이를 기각함.

1-8 중첩적 계약인수와 관련한 대출채무 존재 여부

[기각] 면책적 채무인수의 효력이 발생하기 위해서는 채권자의 합의 내지 승낙을 요한다 할 것인데, 본건 계약인수약정서에 중첩적 인수형이라고 기재되어 있고 채권자가 본건 계약인수가 면책적 채무인수를 부인하고 있으며, 본건 계약인수약정은 부동산매매계약에 따른 소유권이전과 상호관련성이 큰데, 매매계약이 해지되어 소유권이전 자체가 이루어지지 아니한 점 등을 감안시 본건을 면책적 인수형으로 보기 어려움.(2009.10.15. 조정번호 제2009-86호)

가. 사실관계

신청인은 부동산분양대행업 등을 목적으로 설립된 회사로, 신청인의 대표이사 A씨, B씨가 대표이사를 겸하고 있는 신청외 C기업이 D기업 소유 부동산을 매수함에 있어 그 잔금 지급을 위하여 2005.11.14. 상호저축은행(이하 “피신청인”이라 함)으로부터 80억원을 대출받음.

이와 관련하여 C기업은 본건 부동산을 부동산신탁회사에 담보신탁하고 피신청인에게 1순위 수익권을 설정(수익권증서 123억 5,000만원)하였고, 신청인회사 대표이사 A씨의 모친 소유 아파트 및 대표이사 B씨의 형 소유 아파트에 각 채권최고액 11억원의 근저당권을 설정하였으며, 신청인 소유의 의왕시 소재 아파트 및 용인시 소재 상가에 각 채권최고액 65억원의 근저당권을 설정하였음.

신청인은 2006.6.9. 본건 대출원금 32억원을 상환하여 잔액은 48억원이 되었고, 그 후 C기업이 본건 부동산을 E기업에 매도하기로 하여 2008.3.10. 가계약을 체결한 후 동년 6.24. 정식 매매계약을 체결¹⁸⁾하였으며, 위 계약금 4억원은 당일 피신청인측에 지급되어 본건 대출 잔액은 44억원으로 감소함.

위 2008.6.24.자 매매계약 체결과 동시에 E기업이 본건 대출채무를 인수하기로 하는 계약인수약정을 체결하였는데, 계약서상에 “중첩적 인수형”으로 명기하고 E기업 대표이사 가 연대보증인으로 추가 입보하였으며, E기업은 동사 소유 ‘공장부지·건물’을 추가 담보로 제공(2순위 근저당 설정)하기로 하고 담보설정 관련서류를 제공하였음(해당 서류는 2008.8.15. 반환하여 실제로 담보 설정은 되지 않음).

한편 위 부동산매매계약은 세금, 본건 부동산 상의 가압류 등기 등의 사유로 이행되지 못하자,¹⁹⁾ E기업은 2008.8.14. 피신청인에게 부동산인수포기 의사를 밝히며 건물 인수전 납입 대출금 및 이자 반환을 요구하는 공문을 발송하였고, 이에 피신청인은

18) 매매계약 내용 : 매매대금 72.8억원(계약금 4억원, 중도금 44억원, 잔금은 24.8억원으로 소유권 이전시에 지급).

19) 본건 부동산에 다른 가압류가 있었으며, 2008.8.12. 건물이전등기를 하기 위해 ○○시청에 토지거래신고를 하였으나 본건 부동산이 과밀지역 내에 있어 ‘취·등록세 3배중과’ 통보를 받음(6억 이상의 추가 자금 소요).

2008.8.20. E기업이 신청인의 대출금채무를 중첩적으로 인수하였으므로 ‘매매당사자간 분쟁을 원인으로 기 납입 대출금 및 이자를 반환할 수는 없다’는 취지의 회신문을 발송하였음.

그 후 피신청인은 2008.9.1.과 2009.5.4.에 E기업에 대하여 ‘기한이익상실 및 법적절차 착수예정’ 사실을 통지²⁰⁾하였고, 매도인인 C기업은 2008.11.18. E기업에 계약해지²¹⁾를 통보하였으며, E기업은 2008.12.1. C기업에 건물인수 포기통지문²²⁾을 발송하였음

그 후 신청인 회사는 2009.6.25.자 공문을 통하여 피신청인에게 본건 부동산 공매중지(2009.6.18.자 본건 부동산 공매공고) 및 대출만기 6개월 연장 요청과 아울러 본건 대출의 상환을 약속하였고, 2009.6.29. 본건 부동산의 조속한 분양 또는 전체매각을 통하여 대출을 상환할 것이며 2009.9.말까지 한건도 분양하지 못할시 기한이익상실을 감내하겠다는 확약서를 제출하였으며, 2009.6.30. 기발생이자 9.3억원중 1.5억원을 상환하면서 나머지 대출원리금의 기한을 유예해줄 것을 요청하였음. 이에 피신청인은 동 요청을 수용하여 본건 대출의 기한을 연장하고 추가운영자금 2.5억원을 대출하였으며, 신청인은 2009.8.3. 금감원에 분쟁조정을 신청함.

나. 당사자 주장

(1) 신청인 주장

본건 계약인수약정은 면책적 계약인수(채무인수)이며, 피신청인이 이를 명시적 내지는 묵시적으로 승낙하였으므로 신청인의 피신청인에 대한 대출금 채무는 존재하지 아니함. 계약인수약정서 작성시 “중첩적 채무인수”라는 문구를 본적도 없고, 이에 관한 설명을 들은 바도 없으며, 계약인수약정서상 “중첩적 인수형”이란 문구의 기재가 신청인의 대표이사 A씨, B씨의 필적이 아니라는 필적감정서를 제출하였음. 설사 계약인수약정이 해제

20) E기업은 2009.5.14. 피신청인을 상대로 금감원에 분쟁조정신청을 하였으나, E기업은 기 납입금의 반환 청구를 포기하고 피신청인은 E기업에 본건 대출금추심을 하지 않기로 하여 2009.6.10. 당사자간 합의가 성립됨.

21) 본건 부동산매매계약을 해지하되 채무인수는 유효하다는 취지임.

22) 건물인수포기와 함께 본건 대출에 대한 책임도 신청인 회사에 있음을 주장함.

되었다고 하더라도 이는 피신청인과 E기업의 귀책사유에 의한 것이므로 2008년 8월분부터 2009년 6월분까지 대출이자에 대해서는 책임이 없다 할 것임.

(2) 피신청인 주장

본건 계약인수 약정의 형태는 중첩적 계약인수였으며, 인수형태를 고려할 필요도 없이 채무인수의 전제조건인 본건 부동산의 소유권이전 자체가 이루어지지 않았으므로 피신청인의 채권에는 영향이 없다 할 것임. 또한 신청인은 2009.6.29. 확약서를 제출하면서 자신의 채무를 승인한 바 있고, 다음 날 기발생이자 9.3억원 중 1.5억원을 상환하고 나머지 대출원리금의 기한유예 및 정상화를 요청하였기에, 피신청인이 이를 수용하여 기한 연장 및 운영자금 2.5억원을 추가대출까지 하였는 바, 신청인의 주장을 수용하기 어려움.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 ① 본건과 관련한 계약인수(채무인수)약정을 면책적 계약인수로 볼 것인지, 중첩적 계약인수로 볼 것인지 여부와 ② 신청인의 채무승인 여부 및 이자지급 책임여부라 할 것임.

(1) 본건 계약인수(채무인수)의 성격

신청인은 본건 계약인수가 면책적 계약인수이므로 신청인의 대출금채무가 존재하지 않는다고 주장하나 다음과 같은 점에 비추어 신청인의 주장을 인정하기 어렵다 할 것임.

① 처분문서의 진정성립이 인정되면 그 기재 내용을 부인할 만한 분명하고도 수긍할 수 있는 반증이 없는 한 원칙적으로 그 처분문서에 기재되어 있는 문언대로의 의사표시의 존재와 내용을 인정하여야 하는 것이 원칙이라 할 것인 바²³⁾, 본건 계약인수약정서상 채권자 상호저축은행, 채무자 신청인 회사, 계약인수인 E기업의 법인 명판과 직인이 찍혀 있으며, 동 약정서에는 ‘채무자 및 계약인수인의 지위(제2조)’에 대하여 중첩적 인수형이라고 기재²⁴⁾되어 있는 점.

²³⁾ 대법원 2005.5.27. 선고 2004다60065 판결 참조.

²⁴⁾ 신청인은 위 약정서상 중첩적 인수형이라는 문구가 신청인 대표이사 A씨, B씨의 필적이 아니라는 감

② 채무인수가 면책적인가 중첩적인가 하는 것은 채무인수계약에 나타난 당사자 의사
의 해석에 관한 문제이나 면책적 채무인수는 구채무자의 채무를 면책시키는 처분행위를
수반하는 것이므로 이에 관한 명백한 의사가 있음을 인정할 수 있거나 또는 그렇게 볼
만한 특별한 사정이 있는 경우에만 면책적 채무인수로 인정할 것이고, 채무인수에 있어
서 면책적 인수인지, 중첩적 인수인지 분명하지 아니한 때에는 이를 중첩적 인수라고 보
는 것이 판례의 입장인 점.²⁵⁾

③ 또한 면책적 채무인수의 효력이 발생하기 위해서는 채권자의 합의 내지 승낙을 요
한다 할 것인데, 채권자인 피신청인은 본건 계약인수가 면책적 채무인수라는 점을 부인
하고 있고, 본건 계약인수 이후에도 채무자를 신청인에서 E기업으로 변경하는 기표를
하지도 않았고 신청인에 대해서도 원리금 상환을 청구하고 있으며, 피신청인이 2008.9.1.,
2009.5.4. E기업에 대해 대출원리금 상환을 청구할 때에도 통지문에 차주를 신청인 회사,
E기업으로 표시하고 중첩적 계약인수임을 명시하고 있는 점.

④ 본건 계약인수약정은 부동산매매계약 및 이에 따른 소유권이전과 상호관련성이 크
다 할 것인데, 본건의 경우 매매계약이 해지되어 소유권이전 자체가 이루어지지 아니한 점.

⑤ 신청인이 제출하고 있는 필적감정서 만으로 본건 계약인수를 면책적 인수형으로
보기 어렵고 달리 신청인 주장을 인정할만한 명백한 증거를 찾기 어려운 점.

(2) 신청인의 채무승인 여부

한편 신청인은 2009.6.25.자 공문을 통하여 피신청인에게 대출기간 연장을 구하며 대출
상황에 노력할 것이라는 입장을 표명한 바 있고, 동년 6.29. 신청인이 제공한 담보물을
분양 또는 전체 매각하여 대출을 상환하겠다는 취지의 약속서를 제출한 바 있으며, 동년
6.30. 신청인이 기 발생이자 9.3억원중 1.5억원을 상환하면서 나머지 대출원리금의 기한
을 연장 받았고 추가운영자금 2.5억원까지 대출받은 점 등의 사정에 비추어 신청인은 피
신청인에 대한 신청인의 대출금채무의 존재를 승인하고 있다고 할 것임.

정서를 제출하고 있으나, 계약인수의 경우 인수인척이 이를 기재하는 것도 금융거래상 통용되는 것으
로 보이며, 인수인인 E기업 또한 본건 계약인수가 중첩적 인수형이라는 것에 대해 특별히 반대하고
있지 아니함

25) 대법원 2002.9.24. 선고 2002다36228 판결 참조.

(3) 신청인의 예비적 청구에 대하여

신청인은 예비적으로 2008년 8월부터 2009년 6월분까지의 연체이자 채무의 부존재를 구하나, 위에서 본바와 같이 본건 계약인수(채무인수)를 중첩적인 계약인수(채무인수)로 보고 신청인이 대출금채무의 존재를 승인하고 있다고 볼 때 신청인은 피신청인에 대하여 대출원리금 상환의무가 있다고 할 것이므로 연체이자 채무의 부존재를 구하는 신청인의 예비적 주장 또한 이유 없다 할 것임. 중첩적 채무인수의 경우 채무자와 인수인간의 관계를 학설상 연대채무 내지 부진정연대채무로 보고 있어 신청인이 E기업과 피신청인간에 생긴 사유로서 지체책임을 면한다고 보기 어려울 뿐만 아니라 본건 매매계약등의 불이행에 피신청인의 귀책사유가 있다는 점을 확인하기도 어려움.

라. 결 론

신청인의 피신청인에 대한 대출원리금 채무는 유효하게 존재한다 할 것이므로 신청인의 청구는 이유 없어 이를 기각함.

1-9 이해관계 있는 제3자의 변제 해당 여부

[인용] “이해관계 있는 자”란 변제를 함에 있어 법률상 이해관계 있는 제3자를 말하고 단순한 사실상의 이해관계자는 이에 해당하지 아니함. 본건의 경우 신청인은 법원의 확정판결에 의해 소유권이전등기 말소청구권을 부여받았고 동 권리를 행사하기 위해서는 근저당권자인 피신청인의 승낙이 필요하며, 근저당권자인 피신청인의 승낙이 없는 관계로 법원의 판결에 의해 취득한 정당한 권리를 보호받을 수 없게 되는 결과가 야기되는 점에 비추어 신청인은 대위변제할 수 있는 제3자에 해당한다 할 것으로 판단됨.(2010.10.20. 조정번호 제2010-86호)

가. 사실관계

2005.12.1. 신청인은 자신 소유의 부동산(이하 “제1부동산”이라 함)과 신청 외 A씨 및 B씨(A씨의 아들)가 공동 소유한 부동산(이하 “제2부동산”이라 함)을 대상으로 하는 교

환계약을 체결하였음. 다음 날 신청인은 제1부동산에 대한 소유권이전 등기(공유지분: A씨 1/2, B씨 1/2)를 완료한 후 2006.5.11. 본건 교환계약 해제하였으나,²⁶⁾ 2006.9.12. B씨는 ○은행(이하 “피신청인”이라 함)으로부터 20억원을 대출받으면서 제1부동산 전체에 대하여 근저당권을 설정함(채권최고액 : 26억원).

2008.4.30. 신청인, 신청외 A씨와 B씨를 상대로 교환계약해제를 원인으로 한 제1부동산 소유권이전등기 말소소송을 제기하여 일부승소 판결을 받았으며, 신청인이 위 확정판결문에 기해 제1부동산에 대한 소유권이전등기를 말소하기 위해서는 「부동산등기법」상 근저당권자인 피신청인의 승낙이 필요하게 되었음.²⁷⁾

신청인은 근저당권자인 피신청인의 승낙을 받기 위해 근저당권 피담보채무에 대해 대위변제를 하겠다고 하였으나, 피신청인은 채무자측(A씨 및 B씨)에서 신청인의 대위변제를 반대한다는 이유로 신청인의 대위변제를 거절하였으며, 신청인은 피신청인의 대위변제 거절로 인해 소유권이전등기의 말소등기를 할 수 없게 되었다며 본건 분쟁조정을 신청함.

나. 당사자 주장

(1) 신청인 주장

신청인이 법원의 확정판결문에 따라 제1부동산에 대한 소유권이전등기말소등기를 하기 위해서는 근저당권자인 피신청인의 승낙서가 필요하며, 피신청인의 승낙서를 받기 위해서는 근저당권 피담보채무를 대위변제 하여야 함.

신청인은 판결에 의해 확정된 소유권이전등기 말소청구권이라는 자신의 권리를 행사하기 위해서는 위와 같이 대위변제가 반드시 필요한 자로서 법률상 이해관계 있는 제3자에 해당하므로 채무자의 의사에 반해서도 대위변제할 권한이 있음에도(민법 제469조

26) 해제사유 : 신청인은 교환계약 당일 A씨, B씨에게 소유권이전등기에 필요한 서류를 교부하여 제1부동산의 소유권이전등기가 이루어졌으나, A씨와 B씨가 제2부동산에 대한 소유권이전등기에 필요한 서류를 미교부하여 소유권이전등기절차를 이행하지 아니함.

27) 「부동산등기법」 제171조(이해관계 있는 제3자가 있을 때) 등기의 말소를 신청하는 경우에 그 말소에 대하여 등기상 이해관계 있는 제3자가 있을 때에는 신청서에 그 승낙서 또는 이에 대항할 수 있는 재판의 등본을 첨부하여야 한다.

제2항)²⁸⁾ 피신청인이 이를 거절하는 것은 부당함.

(2) 피신청인 주장

신청인의 소송 상대방이었던 A씨와 B씨(본건 근저당 채무자)이 신청인의 대위변제를 강하게 반대하고 있고, 신청인이 채무자의 의사에 반해서도 변제할 수 있는 이해관계 있는 제3자에 해당되는지 여부가 명확하지 않아 신청인의 주장을 수용하기 곤란함.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 신청인이 법률상 이해관계 있는 제3자로 채무자의 의사에 반하여 대위변제를 할 수 있는지 여부라 할 것임.

우리 민법은 제3자의 변제를 제한하여 이해관계 없는 제3자는 채무자의 의사에 반하여 변제하지 못하도록 하고 있는데, 법원은 이해관계가 있는 자란 변제를 함에 있어 법률상의 이해관계가 있는 제3자를 말하고 단순한 사실상의 이해관계가 있는 제3자는 이에 해당하지 아니한다고 판시하고 있음.²⁹⁾

본건의 경우 신청인은 법원의 확정판결에 의해 소유권이전등기 말소청구권을 부여받았고 동 권리를 행사하기 위해서는 근저당권자인 피신청인의 승낙이 필요하며, 근저당권자인 피신청인의 승낙이 없는 관계로 법원의 판결에 의해 취득한 정당한 권리를 보호받을 수 없게 되는 결과가 야기되는 점에 비추어 신청인은 채무자의 의사에 반하여 대위변제할 수 있는 제3자에 해당한다 할 것으로 판단됨.

라. 결 론

피신청인이 신청인의 대위변제를 받고 소유권이전등기 말소청구에 대한 승낙을 하여야 한다는 신청인의 청구는 이유 있으므로 이를 인용함.

28) 「민법」 제469조(제3자의 변제) ① 채무의 변제는 제3자도 할 수 있다. 그러나 채무의 성질 또는 당사자의 의사표시로 제3자의 변제를 허용하지 아니한 때에는 그러하지 아니하다.

② 이해관계 없는 제3자는 채무자의 의사에 반하여 변제하지 못한다.

29) 대법원 1995.3.24. 선고 94다44620 판결 참조.

제3절 수수료의 환급 등

1-10 건설사에 대한 PF대출 확인서 발급과 관련한 수수료의 반환 요청

[기각] 확인서에서는 피신청인이 수수료를 반환하지 않아도 되는 사유로 신청인이 증권사에 대한 대출을 모두 변제하여 피신청인이 신청인에게 대출할 필요가 없게 된 경우를 들고 있는데, 이는 피신청인이 확인서를 발급하고, 수수료를 수취한 후 자신의 의사와 관계없는 외부적 요인에 의하여 수수료를 반환하게 되는 경우를 사전에 차단하기 위한 목적으로 마련된 조항으로 보이는 바, 동 사유를 열거적 사항이 아닌 예시적 사항으로 보는 것이 타당하므로 신청인이 수수료 반환을 요구할 수 있는 명시적인 근거가 없고, 수수료와 대가관계에 있는 것은 확인서를 통한 증권사의 대출 실행이 아니라 “PF대출을 받을 수 있는 지위의 획득”에 있다고 보이며, 또한 본 건 거래가 불공정한 거래에 해당된다고 보기 어려운 바, 신청인의 청구는 이유없어 이를 기각함이 타당함.(2008.9.9. 조정번호 제2008-66호)

가. 사실관계

2007.10월 중순, ○○증권(이하 “증권사”라 함)의 직원이 ◇◇상호저축은행(이하 “피신청인”이라 함)을 방문하여 신청인의 부동산 개발사업에 대한 자금지원 계획을 설명하며, 담보대출 확인서(이하 “확인서”라 함)를 발급해 줄 수 있는 지 여부를 문의함.

증권사는 A건설사가 추진하는 충남 소재 아파트의 개발사업과 관련하여 27억원의 자금을 지원하고(PF대출)³⁰⁾ 완공된 아파트의 분양대금으로 상환 받을 계획이었으나, 아파트의 미분양으로 동 계획에 차질이 생길 것을 우려하여 “피신청인은 완공된 아파트가 미분양될 경우 증권사가 상환받지 못한 대출채권 금액을 한도로 미분양 아파트를 담보로 A건설사에 대해 대출을 취급하겠다”는 내용의 확인서가 필요하였음.

2007.10월 하순에 피신청인은 신청인 및 증권사 직원과 함께 사업장을 방문하였고,

30) 여기서 “PF대출”이란 증권사가 다른 금융회사로 하여금 A건설사에 대하여 대출을 취급하게 하고, 동 대출채권을 양수하는 방식으로 자금지원을 하는 것을 말하는데, 대출이 아니라는 점에서 적절한 표현은 아니나, 확인서상에 동 용어가 사용되었는 바, 본 조정 결정서에서도 이에 따라 동 용어를 사용함.

2007.11.30. 피신청인이 확인서³¹⁾를 신청인에게 교부하며 그에 대한 대가로 신청인으로 부터 수수료 120백만원을 수취하였음.

2007.12.24. 증권사는 신청인과 건축중인 아파트의 소유자 간에 매입가격에 대한 합의가 지연되자 이를 이유로 대출을 취급할 수 없음을 신청인에게 통보하였고, 신청인은 피신청인에게 증권사의 PF대출이 취소된 사실을 유선상으로 통보하였음.

2007.12.27. 피신청인은 신청인의 수수료 반환 요청을 거절하였고, 2008.2.12. 증권사는 신청인 및 피신청인에 대해 본건 PF대출의 추진이 2007.12.24.자로 취소되었음을 서면으로 통지하였음.

나. 당사자 주장

(1) 신청인 주장

신청인이 피신청인으로부터 확인서를 발급받은 이유는 이를 증권사에 제시하여 자금지원(27억원)을 받아 건설중인 아파트를 인수하여 부동산개발 사업을 하기 위함이었는 데, 증권사가 대출취급기간이 경과하였다는 등의 이유로 일방적으로 대출취급 불가 의사를 밝힘에 따라 확인서는 무용지물이 되었고, 피신청인으로서는 향후 담보대출을 취급해야 할 의무를 면하게 되어 어떠한 리스크를 부담하지 않게 되었음에도 특별한 근거도 없이 동 수수료의 반환을 거부하는 것은 부당함.

(2) 피신청인 주장

본건 수수료는 확인서³²⁾ 발급 자체에 대한 수수료의 성격을 가지고 있으며, 신청인은

31) 확인서는 계약서 형식으로 작성되었고, A건설사, 증권사, 피신청인이 계약당사자로서 연명·날인함.

32) 확인서의 주요 내용은 다음과 같음.

제1조(목적) 본 확인서의 목적은 주식회사 OO증권(이하 ‘병’이라고 함)이 ‘이 건 사업’에 대하여 주식회사 A건설(이하 ‘갑’이라고 함)에게 프로젝트 파이낸싱(PF) 대출을 실행하고, ‘이 건 건물’이 준공된 후, ◇◇상호저축은행(이하 ‘을’이라고 함)이 ‘이 건 건물’중 미분양 물건을 담보로 ‘갑’에게 대출할 것을 확인하고자 함에 있다.

제5조(수수료) ① ‘갑’은 ‘을’로부터 본 확인서를 발급받음과 동시에 ‘을’에게 본 확인서 발급에 대한 수수료 120백만원을 지급하기로 한다.

확인서를 발급받아 PF대출 자금을 확보하는 소기의 목적을 달성하였고, 동 확인서 제5조 제2항에 의하면 확인서 발급 이후 이에 근거한 대출 요청이 없어 피신청인이 담보대출을 실행하지 않더라도 이미 수령한 수수료를 반환하지 않는 것으로 규정하고 있음에 비추어 볼 때, 피신청인이 담보대출을 실행하지 않게 되었다고 하더라도 피신청인에게 귀책사유가 없으므로 수수료의 반환 의무는 없다고 판단됨.

다. 위원회의 판단

◆ 본 사건의 쟁점은 수수료와 대가관계에 있는 것이 무엇인지, 본 건 거래가 불공정거래에 해당하는 지 여부임.

(1) 확인서 제5조의 해석(수수료의 대가성)

확인서 제5조 제1항에 의하면, 신청인은 확인서를 발급받음과 동시에 수수료를 지급한다고 규정하고 있을 뿐, 수수료의 발생 요건에 대해 특별히 규정하고 있지 않은 점에 비추어 볼 때, 수수료와의 대가관계는 확인서의 발급 자체에 있지, 확인서의 발급을 통한 대출의 실행에 있다고 보이지 않으며, 즉 수수료는 확인서를 통하여 PF대출을 받을 수 있는 지위를 획득한 데 대한 대가로 보는 것이 타당함.

확인서 제5조 제2항에서는 피신청인이 수수료를 반환하지 않아도 되는 사유로 신청인이 증권사에 대한 대출을 모두 변제하여 피신청인이 신청인에게 대출할 필요가 없게 된 경우를 들고 있는데, 이는 피신청인이 확인서를 발급하고, 수수료를 수취한 후 자신의 의사와 관계없는 외부적 요인에 의하여 수수료를 반환하게 되는 경우를 사전에 차단하기 위한 목적으로 마련된 조항으로 보이는 바, 동 사유를 열거적 사항이 아닌 예시적 사항 즉, 하나의 사례를 적시한 것으로 보는 것이 타당함.

(3) 불공정거래 해당 여부

PF대출이 취급되지 아니한 경우에도 수수료의 반환을 거부할 수 있도록 규정하고 있

② 본 확인서가 발급된 후에는 ‘병’이 ‘이 건 사업’과 관련하여 ‘갑’에게 대출한 27억원을 전액 회수하여 ‘을’이 ‘갑’에게 ‘이 건 대출을 실행하지 않게 되는 경우가 발생하더라도 ‘을’은 ‘갑’으로부터 수령한 수수료를 ‘갑’에게 반환하지 아니한다.

는 확인서 제5조의 규정이 불공정한 조항으로 인정될 경우 모든 법률행위는 무효가 되므로 이에 대해 살펴 볼 필요가 있는데, 다음과 같은 점을 고려할 때, 동 규정은 불공정한 내용을 포함하고 있지 않는다고 판단됨.

불공정성이 인정되기 위해서는 신청인의 궁박, 경솔 또는 무경험을 이용한 현저하게 공정을 잃은 것으로 평가되어야 하는데(민법 제104조) 우리나라에는 은행, 신탁, 상호저축은행, 새마을금고, 농협, 수협, 보험, 증권 등 많은 종류의 금융회사가 있고, 업종별로 그 숫자도 적지 않으므로 신청인에게 선택의 여지가 전혀 없었다고 보기 어렵고, 신청인은 부동산 개발업체로서 건축중인 건물을 인수한 후, 이를 완공하여 분양하는 사업을 성공적으로 수행하기 위하여 이러한 금융거래에 관하여 전문적인 인력을 갖춘 증권사와 충분히 협의한 후 본 건 거래를 추진하였으며, 본 건 수수료를 부동산 개발 사업이 성공적으로 수행되었을 때 기대되는 수익과 비교할 때 현저히 불균형하다고 보기 어려운 바, 본 건의 거래가 궁박, 경솔 또는 무경험에 의한 것으로 보기 어려움.

라. 결 론

본 건 거래가 불공정한 거래에 해당된다고 보기 어려운 바, 신청인의 청구는 이유 없어 이를 기각함이 타당함.

1-11 대출금 임의변제와 관련한 중도상환 수수료 반환 청구

[기각] 기한의 이익 상실 등의 사유로 조합이 대출금을 회수하는 경우란 대출채무의 기한의 이익이 상실되었음에도 대출채무자가 임의로 변제하지 않아 조합이 강제적인 방법으로 대출금을 회수하는 경우 즉, 법적 절차를 통하여 대출금을 회수하는 경우를 말하는 것으로 해석하는 것이 합리적이라 할 것임. 신청인은 담보부동산에 대한 경매가 신청됨에 따라 이를 모면하기 위하여 대출 원리금을 변제하였다고 하나, 그렇다 하더라도 이는 임의변제로서 대출채무자가 기한의 이익 상실 전에 임의로 변제한 것과 본질적으로 다르다고 보기 어렵다 할 것임.(2008.11.11. 조정번호 제2008-82호)

가. 사실관계

2006.8.18. 신청인은 대출거래약정서 및 추가 대출거래약정서를 작성하여 ○○협동조합(이하 “피신청인”이라 함)에 제출하였음.(대출금액 116백만원, 만기일 2011.8.18)

< 추가 대출거래약정서 내용 >

- 대출취급일부터 3년 이내에 상환하는 경우 상환시기에 따라 상환금액의 1~2% 중도상환수수료 지급
- 중도상환수수료 면제사유 : 기한의 이익상실 등의 사유로 은행이 대출금을 회수하는 경우

2008.3.19. 신청인은 대출이자의 연체로 기한이익을 상실하였고, 이에 2008.6.12. 피신청인이 담보부동산을 경매 신청하자, 2008.6.20. 신청인은 담보부동산을 제3자에게 매각함.

2008.6.23. 피신청인은 신청인으로부터 연체이자(5,531,007원)를 지급받은 후, 2008.6.24. 담보부동산에 대한 경매를 취하하였고, 2008.8.18. 신청인으로부터 대출금(116백만원) 및 중도상환수수료(116만원)를 지급받음.

나. 당사자 주장

(1) 신청인 주장

신청인이 대출금을 중도상환한 것은 피신청인이 기한이익의 상실을 이유로 담보부동산의 경매를 신청하였기 때문이고, 이러한 사유는 추가 대출거래약정서의 규정상 중도상환수수료의 면제 사유에 해당되는 바, 피신청인이 일방적으로 수취한 중도상환수수료(116만원)는 당연히 반환하여야 할 것임.

(2) 피신청인 주장

추가 대출거래약정서 제1조 제2항³³⁾은 법적 절차가 진행되어 배당금 등으로 대출 채

33) 추가 대출거래약정서 제1조의 내용은 다음과 같음.

제1조(중도상환수수료) ① 이 약정에 의한 대출금을 대출기간 만료일(기한 연기로 만기일이 연장된 경우 포함) 전에 상환(일부 상환, 약정금액 포함)할 경우에는 다음 각호의 기준에 의한 중도상환수수료를 조합에 지급하기로 합니다.

1. 대출 실행일부터 1년 이내 상환하는 경우 상환금액(약정 금액) × 2.0%

권을 정리하는 경우에 적용되는데, 신청인은 경매 절차가 진행되자 이를 피하기 위하여 담보부동산을 매매하고, 그 매각대금으로 대출채무를 변제한 것이므로 동 규정을 적용할 수 없음. 또한 신청인은 근저당권 설정 비용을 면제받는 대신 중도상환수수료를 부담하기로 한 것이므로 더 이상의 양보는 불가함.

다. 위원회의 판단

◆ 본건은 추가 대출거래약정서 제1조 제2항의 해석에 관한 문제임.

추가 대출거래약정서 제1조 제2항에서는 중도상환수수료의 면제 사유로 “기한의 이익 상실 등의 사유로 조합이 대출금을 회수하는 경우”를 들고 있는데, 동 규정의 의미가 기한의 이익이 상실되면 경매 실행 여부와 관계없이 면제 사유에 해당한다는 것인지 아니면, 기한의 이익의 상실로 경매 절차가 착수되어 담보부동산 경락대금의 배당금으로 변제 충당되는 경우에 비로소 면제가 된다는 것인지가 명확치 않아 합목적적인 해석이 요구됨.

그런데, 전자(前者)의 의미로 해석할 경우, 기한의 이익이 상실되기 전에 임의로 변제하는 대출채무자는 중도상환수수료를 부담하게 되는 반면, 이자를 연체하여 기한의 이익이 상실되는 경우에는 동 수수료가 면제되어 기한의 이익 상실 사실 즉, 대출원금 연체 사실을 특별히 우대하는 결과가 되는데, 일반적으로 금융기관은 자산 건전성을 무엇보다 중요시한다는 사실에 비추어 볼 때, 그러한 의사(의도)로 동 규정을 마련한 것으로 보기 어려움.

2. 대출 실행일부터 2년 이내 상환하는 경우 상환금액(약정 감액 금액) × 1.5%
3. 대출 실행일부터 3년 이내 상환하는 경우 상환금액(약정 감액 금액) × 1.0%
- ② 다음 각호의 사유에 따라 대출기간 만료일 전(기한연기로 만기일이 연장된 경우 포함)에 상환(일부 상환 포함)하는 경우에는 중도상환수수료를 지급하지 않습니다.
 1. 정상적인 할부 상환 원금을 납입하는 경우
 2. 기한의 이익 상실 등의 사유로 조합이 대출금을 회수하는 경우
 3. 대출 실행일로부터 3년이 경과하여 상환하는 경우
 4. 기타 조합에서 정한 중도상환수수료 면제에 해당하는 경우

따라서 “기한의 이익 상실 등의 사유로 조합이 대출금을 회수하는 경우”의 의미를 대출채무의 기한의 이익이 상실되었음에도 대출채무자가 임의로 변제하지 않아 조합이 강제적인 방법으로 대출금을 회수하는 경우 즉, 법적 절차를 통하여 대출금을 회수하는 경우를 말하는 것으로 해석하는 것이 합리적이라 할 것이고, 이 규정은 채무자측이 자기의 의사에 반하여 담보부동산의 소유권을 잃게 되는 경우에도 그에게 동 수수료를 부담하게 하는 것은 지나치게 가혹하다는 판단 하에 마련된 것으로 이해할 수 있을 것임.

신청인은 피신청인이 담보부동산에 대하여 경매를 신청함에 따라 이를 모면하기 위하여 대출 원리금을 변제하였다고 하나, 그렇다고 하더라도 이는 임의변제로서 대출채무자가 기한의 이익 상실 전에 임의로 변제하는 것과 본질적으로 다르다고 보기 어려움.

라. 결 론

추가 대출거래약정서 제1조 제2항의 규정은 기한의 이익이 상실되었다는 이유만으로 중도상환수수료가 면제된다는 것이 아니라 기한의 이익의 상실로 경매 절차가 착수되어 담보부동산 경락대금의 배당금으로 변제 충당되는 경우에 비로소 면제가 된다는 의미로 해석되는바, 신청인의 청구는 이유없음.

1-12 과도하게 수취한 PF대출 취급수수료의 환급

[일부인용] PF대출의 취급수수료율은 그 사업 내용에 따라 편차가 있으나, 상호저축은행의 경우 평균 이자율 및 취급수수료율이 각각 연 10% 및 3.3%에 불과하다는 점, 본건 PF대출 약정서 상에는 취급수수료율의 구체적 부과 내역이 명시되지 않아 업계평균 수수료율 보다 10%p를 더 수취할 만한 특별한 사정을 인정하기 어렵다는 점, 해외 은행권 PF대출의 경우 참여은행수가 주간사은행, 간사은행, 참여은행 등으로 다양하고, 사업성공 여부에 대한 예측이 보다 까다로움에도 취급수수료율이 본 건의 경우보다 크게 낮은 사실 등을 감안시 그 취급수수료 15% 중 10%는 건전한 금융관행 범위를 초과하는 부분이므로 환급 처리함이 타당함.(2008.10.7. 조정번호 제2008-62호)

가. 사실관계

2007.1.25. 신청인이 상호저축은행(이하 “피신청인”이라 함)에 경기도 소재 토지의 매매와 관련하여 그 소유자와 매매계약을 체결하기로 합의하였다고 설명하고 PF대출 40억원을 신청³⁴⁾하였으며, 1.30. 피신청인의 여신심의위원회에서 본건 대출이 승인됨.³⁵⁾

2007.2.1. 피신청인은 신청인과 PF대출 약정(40억원)을 체결하고, 일반자금대출 40억원을 실행하여 대출취급수수료 6억원 등을 공제한 34억원을 신청인의 보통예금계좌에 입금함(입금 직후 선이자 명목으로 3.3억원 인출).

한편, 신청인의 대표이사인 A씨는 그의 딸 등의 부동산을 담보로 제공하고, 동 대출 채무에 대해 연대보증함³⁶⁾.

2007.2.14. 신청인, 토지매매계약 체결을 위해 보통예금 30억원을 인출한 후, 피신청인 직원과 함께 토지 소유자를 만났으나 협상 결렬로 이를 다시 입금함.

2007.3.15. 피신청인은 토지매매 계약이 계속 지연되자 상계예정통지서를 발송³⁷⁾하고, 같은 취지의 내용이 포함된 확인서상에 신청인의 서명을 받았으나, 2007.3.19. 신청인은 상계예정통지서 내용에 동의할 수 없고, 현재 지주와의 협의가 거의 완료된 상태이므로 조속히 토지계약을 체결할 것임을 약속한다는 취지의 내용증명 우편을 발송하였음.

2007.3.30. 신청인은 토지매매계약을 4.20.까지 체결할 예정이므로 동 일자까지 상계처리를 연기하여 줄 것을 재차 요청하였고, 2007.4.5. 피신청인은 신청인의 연기 요청을 수용하되, 4.20.까지 매매계약이 체결되지 않을 경우 그 날자에 상계처리할 예정임을 통지하였음.

그 후 2007.4.19. 신청인은 토지 소유주와 계약조건에 대한 합의가 미진하여 2007.4.20.

34) 신청인은 아파트 사업부지의 매매 계약금을 마련하기 위하여 PF대출을 신청하였음.

35) 대출승인조건 : 지자체로부터 아파트 개발사업에 대한 허가를 얻지 못할 경우 대출금으로 지급한 계약금을 토지 소유자로부터 반환받을 수 있도록 만전을 기할 것(지주, 시행사, 피신청인 3자간 약정).

36) 피신청인은 신청인이 동 대출금을 타 용도로 사용할 가능성을 사전 차단하기 위하여 통장을 교부하지 않았고 다만, 신청인의 요청에 따라 입금 통장의 사본을 교부함(계약금 지급 능력 확인용).

37) 통지내용 : 2007.3.19.까지 토지의 매매계약이 체결되지 아니하는 경우 2007.2.1 취급된 대출금과 보통예금을 상계할 예정임.

까지 토지계약을 체결할 수 없게 되었으나 상계처리에 대해서는 동의할 수 없다는 취지의 통지서를 발송하였고, 2007.6.27. 피신청인은 대출채권을 대출금이 입금된 보통예금 채무와 상계 처리하였음.

나. 당사자 주장

(1) 신청인 주장

신청인은 피신청인과 40억원의 대출계약을 체결한 사실은 있으나, 이는 아파트 개발 사업부지의 매입에 필요한 자금(계약금)을 마련하기 위한 것으로서 토지매매계약이 확정적으로 체결될 것을 전제조건으로 하는 것이었음.

또한 피신청인은 2007.2.1. 신청인의 명의로 개설된 피신청인 예금계좌에 취급수수료(6억원) 등을 제외한 금 34억원을 형식상 입금한 것처럼 하였으나, 피신청인만이 입출금을 자유롭게 할 수 있는 위치에서 위 대출금을 독자적으로 지배하고 있었고, 신청인은 어떠한 권한도 행사할 수 없었던 점 등을 감안할 때, 본 대출약정은 무효인바, 피신청인이 요구하는 대출취급수수료 및 선이자 명목의 783백만원은 지급할 의무가 없음.

더욱이 피신청인은 계약금의 처리와 관련하여 토지 소유자에게 새로운 계약 조건을 추가하였고, 토지 소유자가 이를 받아들이지 아니함으로써 매매계약이 체결되지 아니하였는 바, 피신청인도 계약 무산에 대한 책임을 면할 수 없음.

(2) 피신청인 주장

신청인은 피신청인과의 충분한 협의를 거쳐 대출거래 약정서를 작성하였을 뿐만 아니라 대출취급수수료 등을 공제한 나머지 대출금액을 신청인의 예금계좌에 입금하는 방식으로 지급하였으며, 또한 신청인은 피신청인의 상계예정통지에 대해 수차례에 걸쳐 이의를 제기함으로써 대출계약을 스스로 인정한 바 있음에도 토지매매계약이 무산되자 대출계약의 무효를 주장하는 것은 전혀 설득력이 없음. 한편, 피신청인이 토지매매계약과 관련하여 새로운 조건을 추가함으로 인해 동 계약이 무산되었다는 주장은 사실무근임.

다. 위원회의 판단

◆ 본 사건의 쟁점은 대출 계약의 성립 여부 및 대출취급수수료의 법적 성격을 어떻게 볼 것인지 여부라 할 것임.

(1) 대출 계약의 성립 여부 등

본 건 대출계약은 다음과 같은 점을 종합적으로 고려할 때, 유효하게 성립된 것으로 판단되고, 또한 ‘토지 매매계약이 확정적으로 체결될 것’을 정지조건으로 하는 계약에 해당한다고 볼만한 어떠한 근거도 찾기 어려움.

① 대출계약은 금전소비대차 계약의 일종으로서 요물계약이 아닌 낙성계약에 해당하므로 통장 원본의 교부 등이 요구되는 것은 아니고, 계약 당사자간의 의사적 합치로 유효하게 성립되는데, 신청인은 2007.2.1. 여신거래약정서를 작성하고, 날인한 사실이 있다는 점.

② 신청인은 토지매매계약의 체결을 위해 대출금이 입금된 보통예금 계좌에서 30억원을 인출한 사실이 있으며, 피신청인의 상계예정통지에 대해 내용증명우편 등을 통해 수차례에 걸쳐 강하게 이의를 제기했다는 점.

(2) PF대출의 취급수수료율(15%)의 적정성

본건 PF대출이 유효하게 성립하므로 일응 피신청인은 약정 내용대로 선이자 및 취급수수료를 수취할 권한이 있는 것으로 보이나, 본건 PF대출의 취급수수료율 15%가 적정한 것으로서 유효한 것인지 여부는 별도로 살펴 볼 필요가 있는데, 다음과 같은 점을 종합적으로 고려할 때, 취급수수료율 15%는 다소 과도한 것으로 평가되는 바, 건전한 금융관행의 범위를 초과하지 않는 범위(5%)내에서 그 유효성을 인정하는 것이 타당함.

① PF대출의 취급수수료율은 그 사업 내용에 따라 편차가 있으나, 상호저축은행 PF대출의 경우 평균 이자율 및 취급수수료율이 각각 연 10% 및 3.3%에 불과하다는 사실.

② 상호저축은행의 『PF대출 취급규정』(제11조)은 건전한 금융관행의 범위내에서 구체적인 부과 내역을 명시하고 취급수수료를 수취하도록 규정하고 있는데, 본건 PF대출 약정서상에는 취급수수료율의 그 구체적인 부과내역이 명시되어 있지 않아 업계평균 수수료율 보다 10%p 이상을 더 수취할 만한 특별한 사정이 있는지 여부가 불분명하고 그

타당성을 인정하기 어렵다는 점.

③ 해외 은행권 PF대출의 경우 그 참여은행 수가 주간사은행, 간사은행, 참여은행 등으로 다양하고, 프로젝트 사업의 규모가 비교적 크며, 사업의 성공 여부에 대한 예측이 보다 까다로움에도 그 취급수수료율이 미국은 0.1~2.0%, 일본은 5%(Arrange Fee), 홍콩은 1~7%에 불과한 사실.

④ 피신청인이 대출을 취급한 사실은 인정되나, 대출금이 신청인에게 실제지급된 것이 아니라 예금형식으로 다시 예치됨에 따라 피신청인이 이 자금을 운용할 수 있었다는 점.

(3) 기 타

피신청인은 2007.6.27 상계일을 기준으로 미경과분에 대한 선이자로 138,395,270원을 환급처리하였으나, 이를 정확히 계산하면 다음과 같으므로 그 차액인 32,563,633원을 추가로 환급처리하여야 함.

(계산방식) $332,054,794원 \div 303일(선이자수취 대상기간: 2007.2.1 \sim 11.30) \times 156일(상계 일기준 잔여일수: 2007.6.28 \sim 11.30) = 170,958,903원$

신청인은 대출 계약 무효의 근거중의 하나로 피신청인의 추가적인 요구로 인하여 토지 매매계약이 체결되지 않았음을 들고 있으나, 다음과 같은 점을 고려하여 이에 대한 사실적 판단을 유보함이 타당함.

① 신청인의 주장이 사실인지 여부를 확인하기 곤란할 뿐만 아니라 설령 사실이라고 하더라도 이것은 대출 계약 성립 및 효력 여부와 무관함.

② 다만, 손해배상 책임 여부에 대해서는 다룰 수는 있겠으나, 신청인이 이를 주장하고 있지 아니할 뿐만 아니라 손해배상 책임에 관한 사항은 사법부의 고도의 사실적 및 법적 판단이 요구되는 것이므로 금융분쟁조정 대상으로 보기에 적합하지 아니함.

라. 결 론

본건 PF대출 계약은 유효하게 성립하였으나, 그 취급수수료 15% 중 10%는 건전한 금융관행 범위를 초과하는 부분으로서 그 타당성이 인정되지 아니하므로 4억원(40억원

의 10%)을 환급처리하는 것이 타당하며, 한편 계산상의 오류로 선이자 환급금액에서 누락된 32,563,633원도 추가로 환급처리하는 것이 타당함.

1-13 대출연장 합의 성립 여부와 중도상환수수료 등 반환청구

[인용] 대출의 기간연장이 성립하기 위하여는 당사자 사이에 당해 계약의 본질적인 사항이나 중요사항에 관하여는 구체적으로 의사의 합치가 있거나 적어도 장래 구체적으로 이를 특정할 수 있는 방법 등에 관한 합의가 있어야 할 것인데, 본건 대출계약의 기간연장여부와 관련하여 당사자간 대출기간 연장시 이자율, 기간 등에 대한 구체적 합의가 없으며, 신청인이 본건대출의 이자율이 타은행보다 높은 점을 이유로 피신청인과 이자율에 대해 다투고 있어 기간연장에 대한 유효한 의사합치가 있다고 보기 어려운 점 등을 감안시 피신청인은 중도상환수수료 등을 반환할 의무가 있다 할 것임.(2010.12.14. 조정번호 제2010-107호)

가. 사실관계

신청인은 피신청인으로부터 2006.10.20. 8억원, 같은 해 10.27. 6억원, 2009.10.20. 3억원, 총 17억원의 중소기업자금대출(이하 “본건 대출”이라 함)을 받았는데, 대출만기는 모두 2010.10.20.임.

2010.10.18. 본건 대출의 만기 직전에 피신청인 직원이 신청인에게 전화로 본건 대출의 만기도래를 안내하고 기간연장에 대해 문의하였고, 신청인은 부인이 암치료를 입원 중이어서 경황이 없으므로 2010.10.21. 피신청인 지점에 내점하겠다고 답변함.

2010.10.20. 피신청인은 신청인의 위와 같은 답변을 기간연장에 대한 동의로 보고 연 6.95% 이율을 적용하여 본건 대출기간을 1년 연장하였고, 2010.10.21. 신청인이 피신청인 지점에 내점하여 본건 대출의 이자율이 타 은행보다 높음을 이유로 피신청인에게 이자율 조정을 요청하였으나 동 요청이 수용되지 않자 신청인은 거래조건변경·추가약정서 작성을 거부함.

이후 신청인과 피신청인간 본건 대출의 이자율에 대한 합의가 이루어지지 않아 신청인이 2010.10.26. 본건 대출의 상환의사를 표시하자, 피신청인은 신청인에게 대출기간이

유효하게 연장되었고, 연장후 기한전상환을 이유로 대출원금(17억원), 대출이자(2,265,890원) 및 중도상환수수료(8,500,000원) 합계 1,710,765,890원을 상환 요구하여 2010.10.27. 신청인이 타 은행에서 대출을 받아 1,710,765,890원을 상환함.

나. 당사자 주장

(1) 신청인 주장

신청인은 담당직원과 전화통화시 본건 대출기간 연장을 명시적으로 동의한 사실이 없고 단지 피신청인 지점에 내점하여 이를 결정하겠다고 하였을 뿐이며, 대출기간 연장서류에 서명을 하지도 않았는데 피신청인이 임의로 대출기간을 연장처리하여 중도상환수수료 등을 부과하는 것은 부당함.

(2) 피신청인 주장

본건 대출의 기간이 연장되지 않으면 연체이자 발생하는 등 기간연장을 해 주는 것이 오히려 신청인에게 유리한 상황이었고, 담당직원의 대출기간 연장 문의시, 신청인이 보류 또는 거절의사를 표시하지 않고 지점에 내점하겠다고 하였으며, 내점시에도 기간연장 자체는 문제 삼지 않고 이자율에 대해서만 불만을 표시하였을 뿐이므로 대출기간 연장에 대해서는 신청인이 구두상 동의한 것으로 보아야 할 것임.

본건 대출의 기간연장이 유효하게 체결되었고, 신청인이 중도상환을 하였으므로 기한전상환수수료규정에 따라 중도상환수수료를 부담하는 것은 정당하다 할 것임.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 본건 대출의 기간연장 여부 및 그에 따른 중도상환수수료 부과 등의 적정성 여부라 할 것임.

(1) 본건 대출의 기간연장 및 중도상환수수료 부과 등의 적정성 여부

피신청인은 신청인이 본건 대출의 이자율에 대해서만 불만을 표시하였을 뿐 본건 대

출의 기간연장에 대해서는 구두로 동의한 것이므로 기간연장 및 중도상환수수료 부과가 적절하게 이루어진 것이라고 주장하나, 다음과 같은 점에 비추어 본건 대출의 기간연장 및 중도상환수수료 부과를 타당한 것으로 보기 어려움.

① 우선 본건 대출의 기간연장에 대한 신청인과 피신청인의 전화통화시, 신청인이 피신청인 지점에 내점하겠다고 통화한 것만을 가지고 신청인이 본건 대출의 기간연장에 대해 확정적인 동의의 의사를 표시한 것으로 보기 어렵고, 계약이 성립하기 위하여는 당사자 사이에 의사의 합치가 있을 것이 요구되고 이러한 의사의 합치는 당해 계약의 내용을 이루는 모든 사항에 관하여 있어야 하는 것은 아니나, 그 본질적인 사항이나 중요 사항에 관하여는 구체적으로 의사의 합치가 있거나 적어도 장래 구체적으로 이를 특정할 수 있는 방법 등에 관한 합의가 있어야 할 것인데,³⁸⁾ 본건 대출계약의 기간연장여부와 관련해서 신청인과 피신청인간 대출기간 연장시 이자율, 기간 등에 대한 구체적 합의가 없으며, 신청인이 본건대출의 이자율이 타은행보다 높은 점을 이유로 피신청인과 이자율에 대해 다투고 있어 기간연장에 대한 유효한 의사합치가 있다고 보기 어려운 점.

② 피신청인의 「여신업무취급세칙」 제500조에 의하면 여신의 기간연장시에는 고객으로부터 거래조건변경·추가약정서를 받도록 규정되어 있는데, 신청인은 대출 이자율에 불만을 표시하며 기간연장 서류인 거래조건·추가약정서의 자서를 거부하고 이를 작성하지 않은 점.

③ 더욱이 본건 대출의 여신거래약정서, 거래추가약정서상 중도상환수수료 부분은 신청인이 피신청인 직원의 설명을 듣고 해당란에 체크하도록 되어 있는데, 본건 약정서에는 이에 대한 체크가 없어 본건 대출과 관련하여 신청인이 피신청인으로부터 중도상환수수료에 대한 설명을 듣고 이를 약정의 내용으로 삼았다고 보기도 단정하기 어려운 점.

(2) 피신청인이 반환해야 할 금액

본건 대출의 기간연장이 유효하게 이루어졌다고 보기 어려우므로 피신청인은 신청인의 본건 대출 상환시 신청인으로부터 지급받은 중도상환수수료 등을 반환할 의무가 있다 할 것임.

38) 대법원 2003.4.11. 선고 2001다53059 판결 참조.

피신청인이 신청인에게 반환할 금액은 본건 대출의 기간연장이 유효하게 이루어진 것을 전제로 신청인으로부터 지급받은 금액 10,765,890원³⁹⁾(이자 및 중도상환수수료)에서 기간연장이 되지 않았을 경우 신청인이 상환할 금액 4,609,496원(상환시까지 이자)을 차감한 6,156,394원이라 할 것임.

라. 결 론

피신청인은 신청인에게 금6,156,394원을 반환할 의무가 있다 할 것이므로 이를 인용함.

1-14 타행대환대출금 중도상환과 관련한 수수료 징수 특약의 적용 여부

[인용] 중도상환수수료에 대하여 본건 ‘대출특약사항 약정서’외에 조합이 달리 정하고 있는 사항은 없고, 중도상환수수료는 당사자 간의 약정(약관 포함)에 의해 정해지는 바 약정서에 없는 사항에 대해 신청인이 거래경험상 본건과 같은 경우에 중도상환수수료가 부과된다는 것을 알았을 것이라고 막연히 주장하는 것은 근거가 없으므로 당사자간 약정이 없는 중도상환수수료 부과는 부당하다고 할 것임.(2011.7.12. 조정번호 제2011-44호)

가. 사실관계

신청인은 2010.12.28. 자신 소유의 부동산을 담보로 피신청인들로부터 총 18억원(○○신청 11억원, △△신청 7억원)을 대출(이하 “본건 대출”이라 함)받았고, 대출 당시 피신청인들에게 각각 작성해준 “대출특약사항 약정서”에는 중도상환수수료와 관련하여 “약정 기간내 타행대환대출시 상환원금의 1.5% 중도상환수수료가 부과됨”이라고 기재됨.

신청인은 2011.3.30. 상기 부동산을 제3자(A씨)에게 36억원에 매도(2011.3.31. 소유권이전 등기)하여 매수인으로부터 받은 매매대금으로 위 대출금을 상환하였는데, 매수인(A씨)은 ◇◇은행으로부터 본건 부동산을 담보로 대출(대출금 28억원, 담보설정일 2011.3.31.)받아 그 중 일부를 신청인에게 매매잔금으로 지급⁴⁰⁾한 것임에도, 피신청인들이 중도상환수수

39) 기간연장이 된 것으로 보아 은행에서 받은 금액(10,765,890원)

료를 납부하지 않으면 근저당권을 말소해 줄 수 없다고 하여 신청인은 불가피하게 피신청인들에게 중도상환수수료(이하 “본건 중도상환수수료”라 함)를 납부함.

나. 당사자 주장

(1) 신청인 주장

신청인은 본건 담보부동산을 매도하고 매수인으로부터 받은 매매대금으로 본건 대출금을 중도상환한 것으로 타행대출금으로 상환한 것이 아님에도 피신청인들이 중도상환수수료를 납부받은 것은 부당함. 신청인은 매수인(A씨)과 아무 관계가 없고(주주명부 및 회사등기부등본 참조), 실제 본건 부동산이 매수인에게 이전등기 되었으며, 본건 토지거래와 관련한 매수인의 세금부담(취득세, 등록세) 등을 감안하면 본건 부동산 매매는 중도상환수수료 회피를 위한 가장매매가 아님이 명백함.

피신청인들이 본건 중도상환수수료를 납부하지 않으면 근저당권을 해지해 줄 수 없다고 하여 매매계약의 이행을 위해 어쩔 수 없이 본건 중도상환수수료를 납부한 것으로 피신청인들은 근거 없이 부당하게 납부받은 본건 중도상환수수료를 반환하여야 함.

(2) 피신청인들 주장

중도상환수수료는 모든 금융기관에서 상환사유를 불문하고 공통적으로 운용하고 있고, 중도상환수수료의 취지가 대출금융기관의 안정적인 자금운용에 있는 것임.

본건 특약서의 내용은 다의적으로 해석될 수 있으나 본건 대출시 신청인에게 중도상환수수료의 내용에 대해 분명히 설명하였고, 본건 대출금의 상환자원이 타행대출로 조달된 자금이므로 신청인이 중도상환수수료를 부담하는 것은 정당함. 또한 신청인은 사업체를 운영하는 사람으로 금융기관과 여러 차례 거래를 통해 중도 상환시 중도상환수수료가 부과된다는 사실을 충분히 알 수 있었을 것이므로 신청인의 주장은 수용이 곤란함.

다. 위원회의 판단

40) 본건 부동산 매매대금(36억원): 2011.3.30. 계약금 4억원 및 중도금 24억원 지급, 2012.3.31. 잔금 8억원은 매수인이 ◇◇은행으로부터 받은 대출금으로 지급함.

◆ 본건의 쟁점은 피신청인이 신청인으로부터 받은 본건 중도상환수수료가 ‘대출특약사항 약정서’ 등에 비추어 볼 때 정당한 것인지 여부라 할 것임.

본건의 경우, 다음과 같은 점에 비추어 볼 때 피신청인이 신청인으로부터 받은 본건 중도상환수수료는 근거가 없는 것으로 판단됨.

① 중도상환수수료는 대출 취급시 당사자 간의 약정(약관 포함)에 의해 정해지는 것인데, 본건 여신거래약정서에는 중도상환수수료는 조합이 정하는 바에 따른다고 되어 있으나 중도상환수수료에 대하여 본건 ‘대출특약사항 약정서’ 외에 조합이 달리 정하고 있는 사항은 없는 점.⁴¹⁾

② 본건 대출취급시 작성된 ‘대출특약사항 약정서’에 따르면 중도상환수수료는 “타행 대환대출”에 의한 중도상환시 부과된다고 규정되어 있는데, 문리해석상 “타행대환대출”은 대출자가 대출금융기관 외의 금융기관으로부터 대출을 받아 그 자금으로 대출금을 상환하는 것을 의미한다고 보아야 할 것인 바, 본건에서 타행(◇◇은행) 대출자는 신청인이 아닌 본건 부동산 매수인(A씨)이고 신청인은 매수인으로부터 부동산 매매대금을 받아 본건 대출금을 상환한 것이 명백하므로 신청인의 본건 대출금상환을 “타행대환대출”에 의한 중도상환으로 보기 어려운 점.

③ 피신청인들은 대부분의 금융기관에서 중도상환수수료를 폭넓게 적용하고 있으므로 본건 중도상환수수료 부과도 정당하다는 취지로 주장하나, 타 금융기관의 경우 또한 당사자 간의 약정(약관 포함)에 의해 중도상환수수료를 정하고 있는 것으로 타 금융기관의 사례를 본건에 바로 적용할 수는 없는 것이므로 피신청인들의 위와 같은 주장은 타당하지 않은 점.

41) 관련 약정내용은 다음과 같음.

「여신거래약정서」 제5조(중도상환 및 약정한도 미사용수수료) ① 본인이 약정한 대출기한 이전에 대출금 전액을 상환하였을 경우에 상환되는 자금 또는 우대금리 등으로 혜택을 받은 금액에 대하여 상환시점부터 당초 약정기간 동안 재운용하지 못함에 따라 발생하는 조합의 손실을 보전하기 위해 귀 조합이 정하는 바에 따라 기한전 중도상환수수료를 납부하기로 합니다.

「대출특약사항 약정서」 제3항(중도상환수수료) 약정기간내 타행대환대출시 상환원금의 1.5% 중도상환수수료가 부과됨.

④ 피신청인은 신청인이 사업체(법인)로서 금융기관과의 거래경험을 통해 중도상환시 이유를 불문하고 중도상환수수료가 부과된다는 사정을 알았을 것이라고 주장하나, 중도상환수수료는 당사자 간의 약정(약관 포함)에 의해 정해지는데 약정서에 없는 사항에 대해 막연히 신청인이 거래경험상 본건과 같은 경우에 중도상환수수료가 부과된다는 것을 알았을 것이라고 주장하는 것은 근거가 없고 설득력도 없어 보이는 점.

라. 결 론

본건 중도상환수수료 부과는 근거가 없다고 할 것이므로 피신청인들은 근거없이 부당하게 납부받은 본건 중도상환수수료를 신청인에게 각각 반환할 의무가 있다 할 것임.

제4절 시설대여(리스)

1-15 리스기간 만료시 리스이용자의 리스물건 인수 의무

[일부인용] 본건 리스기간의 만료시 리스이용자가 리스물건을 인수할 의무를 부담하는지의 여부를 판단함에 있어 유효하게 변경된 계약서의 문언적 의미와 달리 해석할 만한 명시적·묵시적 약정의 존재를 인정할 만한 증거가 없으므로 리스기간 만료시 신청인의 리스물건 인수 의무는 없다고 판단됨. 또한 리스이용자는 리스물건을 선량한 관리자의 주의의무를 다하여 보관 사용하여야 하므로 리스이용자인 신청인은 특별한 사정이 없는 한 리스물건의 멸실·훼손에 대한 비용을 부담할 책임이 있다고 할 것임.(2001.4.24. 조정번호 제2001-22호)

가. 사실관계

1994.9.12. 신청인은 피신청인과 시설대여(리스)계약(이하 “당초 계약서”라고 함)을 체결하고 의료장비를 대여받았으며, 같은 해 10.4.(이하 “1차 변경계약서”), 10.18.(이하 “2차 변경계약서”), 10.20.(이하 “3차 변경계약서”), 12.9.(이하 “4차 변경 계약서”)에 걸쳐 위 당초 계약이 변경되었으며 2000.12.10. 리스이용기간이 만료됨.

나. 당사자의 주장

(1) 신청인의 주장

리스계약서는 수차례에 걸쳐 변경되었고 현재 유효한 리스계약서에 의하면 리스기간 만료시 리스이용자의 리스물건의 인수는 의무사항이 아님. 리스물건을 인수할 의무가 있다고 할지라도 피신청인이 요구하는 금액은 현저히 과다하므로 감액 조정하여야 할 것임.

(2) 피신청인의 주장

제3차 및 제4차 변경계약서에 의하면 리스기간 만료 후 리스이용자가 리스물건을 인수할 의무가 있는지의 여부에 대하여 논란이 있을 수 있으나, 당초 리스계약서상 채리스 조항 및 물건의 반환조항이 배제된 점을 감안할 때 위 변경계약서 조항은 인수 의무조항

으로서 취득원가 확정에 따른 인수가액을 확정된 것으로 해석되어야 할 것임. 신청인의 요구대로 리스물건 반환을 허용한다 할지라도 현재 고장상태인 리스물건에 대한 수리비용 및 리스물건의 이전비 등을 포함 5천만원 상당을 피신청인에게 납부하여야 할 것임.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 리스기간 만료시 리스물건 이용자가 리스물건을 인수할 의무가 있는지 여부 및 리스물건의 반환을 인정한다고 할 때 리스이용자가 리스물건의 멸실훼손에 따른 비용을 부담하는지 여부라 할 것임

리스기간 만료시 리스물건 이용자가 리스물건을 인수할 의무가 있는지 여부 및 리스물건의 반환을 인정한다고 할 때 리스이용자의 멸실·훼손 및 반환시의 비용부담 여부에 대하여 살펴보면, 『여신전문금융업법』 제2조 제10호는 “시설대여라 함은 대통령령이 정하는 물건을 새로이 취득하거나 대여받아 거래상대방에게 대통령령이 정하는 일정기간 이상 사용하게 하고, 그 기간에 걸쳐 일정대가를 정기적으로 분할하여 지급받으며, 그 기간 종료후의 물건의 처분에 대하여는 당사자간의 약정으로 정하는 방식의 금융을 말한다.”라고 규정하고 있음.

리스기간 만료시 리스물건의 처분에 관하여는 통상 ①재리스 약정에 따른 재리스, ②양도조건부리스 약정에 따른 양도, ③리스이용자의 리스회사에 대한 리스물건의 반환 중 어느 하나의 방법을 채택하게 되는 바, 본건 리스계약의 당사자간에 리스기간 만료시 리스물건의 처분에 관하여 어떠한 약정이 있었는지가 문제된다고 할 것임.

리스계약의 변경과정을 살펴보면, 당초계약서에는 특약사항 제1조에서 제9조(재리스) 및 제10조(물건의 반환)를 삭제하였고, 특약사항 제10조에서는 리스물건 이용자가 리스기간 만료시 리스물건을 인수할 의무가 있는 것으로 규정하고 있었음. 그런데 제3차 변경계약서 특약사항 제4조 및 제4차 변경계약서 특약사항 제6조에서는 “을이 별표(1) 기재 리스물건을 양도받고자 할 때에는 취득원가의 10% 상당액을 현금으로 지급하고 양수하기로 하되, 기타 조건은 본 계약서 제조항을 따르기로 한다”고 변경하고, 특약사항 제7조에서는 “본 변경계약서에서 새로이 정하거나 변경한 사항을 제외하고는 당초 계약서

의 제조항이 그대로 적용되는 것으로 한다.”고 규정하고 있음.

피신청인은 리스물건의 인수여부를 이용자의 선택에 따르도록 규정한 것으로 해석하는 것은 리스이용자가 리스물건의 인수를 선택하지 아니하는 경우 리스물건의 처리 문제에 관하여 아무런 약정이 없는 불합리한 결론에 도달한다고 주장하나,

① 리스 약관(계약서)의 변경에 의하여 리스기간 만료시의 리스물건의 처리에 관한 약정이 없는 것으로 되었다 하더라도 이는 피신청인이 스스로 자초한 것이고 약관을 작성함에 있어 피신청인은 훨씬 더 큰 영향력을 가지고 있으므로 피신청인이 약관을 작성함에 있어 명확하고 일의적(一義的)인 표현을 위해 노력하여야 하는 점.

② 약관작성에 있어 피신청인은 이러한 불명료한 약관조항을 스스로 삽입한 것이므로 “의심스러울 때는 작성자에게 불리하게 해석하여야 한다”라는 약관해석의 일반원칙과, “약관의 뜻이 명백하지 아니한 경우에는 고객에게 유리하게 해석하여야 한다”라는 『약관의 규제에 관한 법률』 제5조 제2항 규정의 취지 및 당사자의 의사에 비추어 변경된 리스계약서의 조항을 해석함이 타당한 점.

③ 셋째, “진정성립이 인정되는 처분문서를 해석함에 있어서는 먼저 특별한 사정이 없는 한 그 처분문서에 기재되어 있는 문언에 따라 당사자의 의사표시가 있었던 것으로 객관적으로 해석하여야” 하는 점⁴²⁾ 등을 종합할 때 피신청인의 주장은 타당성이 없는 것으로 판단됨.

그렇다면 본건 리스기간의 만료시 리스이용자가 리스물건을 인수할 의무를 부담하는지의 여부를 판단함에 있어 유효하게 변경된 계약서의 문언적 의미(율이 리스기간 만료시 별표(1)기재 리스물건을 양도받고자 할 때에는)와 달리 해석할 만한 명시적·묵시적 약정의 존재를 인정할 만한 증거가 없으므로 리스기간 만료시 신청인의 리스물건 인수 의무는 없다고 판단됨.

리스기간 만료시 리스이용자에게 리스물건을 인수할 의무가 없다고 해석하는 경우 리스이용자는 리스물건을 지체없이 반환할 책임이 존재한다고 할 것이고, 리스물건의 반환을 지체한 경우에는 물건의 반환완료시까지 리스료 상당액을 피신청인에게 지급하여야

42) 대법원 1999.2.12. 선고 98다45744 판결 참조.

하고, 반환시의 비용은 신청인이 부담함이 원칙임(당초 계약서 제10조).

또한 리스이용자는 리스물건을 선량한 관리자의 주의의무를 다하여 보관·사용하여야 하고(당초계약서 제14조 제3항), 리스물건을 정상적 운전상태 또는 충분히 기능을 발휘할 수 있는 상태로 유지·보존하여야 할 의무(당초 계약서 제15조) 및 리스물건의 멸실·훼손에 대한 책임(당초 계약서 제19조)이 있으므로 신청인은 특별한 사정이 없는 한 리스물건의 멸실·훼손에 대한 비용을 부담할 책임이 있다고 할 것임.

라. 결 론

리스기간의 만료시 리스물건을 인수할 의무는 없으나, 리스물건의 멸실·훼손 및 반환시의 비용은 신청인이 부담하여야 할 것으로 판단됨.

1-16 리스사가 받은 선수금의 이자수익이 부당이득에 해당하는지 여부

[인용] 신청인과 피신청인이 신청인의 중도납입금을 선수금 명목으로 처리한 사유는 기존 담보부동산의 근저당권을 해지하는 조건으로 이루어진 것으로 실질상 담보물 대체의 성격을 가진다고 할 것이어서 피신청인이 담보물의 과실인 이자수익에 대해서까지 당연히 소유권을 취득한다고 보기 어렵고, 달리 피신청인이 본건 선수금의 이자수익까지 취득하기로 하였다는 합의를 인정할 명백한 자료가 없으므로 피신청인은 본건 선수금의 운용에 따른 이자수익을 신청인에게 반환할 의무가 있다 할 것임.(2010.9.14. 조정번호 제2010-77호)

가. 사실관계

2007.10.29. 신청인과 리스회사인 피신청인은 대출금액 3억원, 만기 48개월, 규정손실금을 원금잔액의 10%로 하는 의료기 리스계약을 체결하고 신청인 소유 부동산에 근저당권을 설정함.

2008.6.4. 신청인이 233,059,351원을 피신청인의 입금전용계좌(가상계좌)에 입금한 후 리스 중도해지 및 근저당권 말소를 요청하였으나, 신청인의 입금액이 규정손실금 등 중

도상환금액에 미달함에 따라,⁴³⁾ 신청인과 피신청인은 본건 근저당권을 해지하는 조건으로 납입금액을 선수금으로 대체시키고 선수금에서 리스료 원리금을 납입하기로 합의함.

이후 선수금으로 매월 리스료를 대체납입하던 중, 2010.7.26. 전액 중도상환하였음. 한편, 신청인이 선수금으로 입금한 금액은 피신청인의 모계좌인 하나은행 MMDA계좌로 입금되었었고, 전액 상환시까지 MMDA 계좌에서 잔존 선수금을 기준으로 6,754,829원의 이자수익이 발생하였음.

나. 당사자 주장

(1) 신청인 주장

피신청인은 2008.6.4.부터 2010.7.26. 신청인의 리스금 전액상환시까지 신청인이 납입한 선수금으로 부당하게 이자수익을 얻은 것이므로 신청인에게 이를 반환하여야 함.

(2) 피신청인 주장

본건 선수금은 신청인이 제공한 담보부동산의 근저당권을 해지하는 조건으로 신청인과 합의하여 받은 것이므로 신청인 주장을 수용할 수 없음.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 피신청인이 받은 선수금의 이자수익이 부당이득에 해당하는지 여부라 할 것임.

43) 2008.6.4. 중도금 납입시 부족액 산정내역은 다음과 같음.

구 분	금 액 (단위: 원)	비 고
미회수 원금	262,435,981	
규정손실금	26,243,598	미회수 원금의 10%
기간이자	623,375	
납입하여야 할 금액(A)	289,302,954	
보증금(계약시)	30,000,000	
입금액	233,059,351	
납입한 금액(B)	263,059,351	
부족금액(B-A)	26,243,603	

민법 제741조는 법률상 원인 없이 타인의 재산 또는 노무로 인하여 이익을 얻고 이로 인하여 타인에게 손해를 가한 자는 그 이익을 반환하여야 한다고 규정하여 부당이득 반환제도를 정하고 있음.

본건에서 신청인과 피신청인이 신청인의 중도납입금을 선수금 명목으로 처리한 사유는 기존 담보부동산의 근저당권을 해지하는 조건으로 이루어진 것으로, 실질상 담보물 대체의 성격을 가진다고 할 것이어서 피신청인이 담보물의 과실인 이자수익에 대해서까지 당연히 소유권을 취득한다고 보기 어렵고, 달리 피신청인이 본건 선수금의 이자수익까지 취득하기로 하였다는 합의를 인정할 명백한 자료가 없음.

설령, 본건 선수금의 이자수익을 피신청인에게 귀속시키기로 하는 합의가 있었다 하더라도 피신청인의 금융기관으로서의 공공성, 신뢰성에 비추어 신청인의 중도납입금을 선수금계정(재무제표상 부채계정)으로 하여 실질상 담보의 성격을 가지는 선수금의 이자수익을 피신청인이 취득하는 것을 적정하다고 보기 어렵다 할 것임.

따라서 피신청인이 본건 선수금의 이자수익 취득하는 것은 부당하다 할 것이므로 피신청인은 본건 선수금의 운용에 따른 이자수익을 부당이득으로 반환하여야 할 것임.

라. 결 론

피신청인은 신청인에게 본건 선수금의 운용에 따른 이자수익 6,754,829원을 신청인에게 반환할 의무가 있다 할 것임.

제5절 기 타

1-17 경매배당금의 변제충당순서

[기각] 경매배당금의 변제충당순서는 민법 제477조(법정변제충당) 등에 의거 결정됨. 본건은 피신청인이 경매배당금으로 법정변제충당을 함에 있어, 채무의 이행기가 모두 도래하였고 변제이익이 같으므로 그 이행기가 가장 빠른 어음할인에 우선 변제충당함이 타당하므로 신청인의 청구를 기각함.(2001.12.11. 조정번호 제2001-55호)

가. 사실관계

신청인이 대표이사로 있는 A기업은 1994.11.25.~1999.8.9. 기간중 B기업(대표이사 C씨, 신청인의 동생)의 대출금 846백만원(대출잔액 687백만원)에 대하여 연대보증을 하였으며, 2001.3.16. ○○은행(이하 “피신청인”이라 함)은 B기업에 대하여 어음할인 3건 147백만원을 취급함. 차주의 채무연체 등으로 2001.7.2. 법원은 담보제공된 차주의 부동산에 대하여 임의경매 개시결정을 하였고, 같은 해 9.27. 담보부동산이 제3자에게 경락(834백만원)되었으나 세입자가 배당금에 대하여 현재 이의신청중임.

나. 당사자의 주장

(1) 신청인의 주장

피신청인이 경락대금으로 채무변제에 충당할 시는 이행기의 도래시기를 순차적으로 고려하여야 하며, 보증인이 있는 채무보다 보증인이 없는 채무의 변제가 채무자에게 변제이익이 많다는 근거가 없으므로, 어음할인 채무에 비하여 연체이율이 월등히 높은 신청인이 연대보증한 원화표시외화자금대출 등의 채무부터 우선 충당하여야 할 것임.

(2) 피신청인의 주장

「여신거래기본약관」 제12조 제1항에서 “채무자의 채무전액을 소멸시키기에 부족한 때에는 은행이 적정하다고 인정하는 순서, 방법에 의하여 변제 또는 상계에 충당할 채무를

지정할 수 있다”라고 하고 있으며 “은행의 채권보전에 지장이 없는 범위내에서 보증인의 정당한 이익을 고려하도록” 규정하고 있으므로 은행의 채권보전에 지장이 있다고 판단 되는 경우까지 보증인의 이익을 고려할 수는 없음. 경매배당금 수령시 채무자의 대출금 일체가 기한이익상실 상태로 각 대출금의 연체이율은 연 19%로 변제이익면에서 차이가 없으므로 이행기가 먼저 도래한 어음할인채무부터 우선 변제충당하는 것이 타당함.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 변제충당에 관한 규정과 피신청인의 변제충당이 적정한 지 여부라 할 것임

민법 제477조(법정변제충당)에서는 “당사자가 변제에 충당할 채무를 지정하지 아니한 때에는 다음 각호의 지정에 의한다. 1. 채무중에 이행기가 도래한 것과 도래하지 아니한 것이 있으면 이행기가 도래한 채무의 변제에 충당한다. 2. 채무전부의 이행기가 도래하였거나 도래하지 아니한 때에는 채무자에게 변제이익이 많은 채무의 변제에 충당한다. 3. 채무자에게 변제이익이 같으면 이행기가 먼저 도래한 채무나 먼저 도래할 채무의 변제에 충당한다. 4. 전2호의 사항이 같은 때에는 그 채무액에 비례하여 각 채무의 변제에 충당한다.”라고 규정하고 있음.

「여신거래기본약관」 제7조에 의하면 “채무자가 제공한 담보재산에 대하여 경매개시 결정이 있는 때에는 채무자는 은행으로부터의 독촉·통지 등이 없어도 당연히 은행에 대한 채무의 기한의 이익을 상실하여 곧 이를 변제(또는 이행)할 의무를 지기로 한다”고 규정되어 있고, 「어음할인약정서」 제5조에는 “채무자 및 할인받은 어음의 주된 채무자(약속어음 발행인, 환어음 인수인을 말한다)가 은행의 여신거래기본약관 제7조 제1항 각호의 1에 해당한 때에는 그가 할인받은 모든 어음에 대하여 은행으로부터의 최고·통지 등이 없어도 당연히 어음면 기재금액에 대한 환매채무를 지고 곧 변제하기로 한다.”라고 규정하고 있음.

채주의 대출금중 이행기가 도래한 것과 도래하지 아니한 것을 살펴보면, 어음할인에 있어서는 어음할인약정서 및 여신거래기본약관에 의하여 C기업 발행어음은 동사가 거래

정지처분을 당한 2001.3.30.에, D기업 발행어음은 2001.6.1.에, 여타 차주의 대출금은 법원의 경매개시결정이 있는 2001.7.2.에 그 이행기가 도래되어 모든 대출금의 이행기가 도래되었다고 보아야 함. 대출금 모두가 이행기가 도래하였으므로 채무자에게 변제이익이 많은 채무의 변제에 충당하여야 하는 바, 본건 대출금들은 연체이율이 연 19%로 이율의 고저가 없고, “변제자가 주채무자인 경우에 보증인이 있는 채무와 보증인이 없는 채무 사이에 전자가 후자에 비하여 변제이익이 더 많다고 볼 근거는 전혀 없으므로 양자는 변제이익의 점에서 차이가 없다”라고 판시⁴⁴⁾하고 있어, 차주의 모든 대출금 사이에는 변제이익의 구분이 서로 없음.

그렇다면, 본건 채무자 B기업의 모든 채무의 이행기가 도래하였고 채무자에게 변제이익의 점에서 차이가 없으므로 민법 제477조 제3호에 의하여 채무의 이행기 도래의 순으로 변제에 충당하여야 할 것인 바, 피신청인이 경매배당금으로 이행기가 먼저 도래한 차주의 어음할인 채무에 우선 변제충당하는 것이 타당한 것으로 판단됨.

라. 결 론

피신청인이 경매배당금으로 법정변제충당을 함에 있어, 채무의 이행기가 모두 도래하였고 변제이익이 같으므로 그 이행기가 가장 빠른 어음할인에 우선 변제충당함이 타당함으로 신청인의 청구를 기각함.

1-18 신용회복지원 조정결정에 기한 부당이득 반환청구

[인용] 신용회복지원결정은 무담보채권액 과반수의 동의와 담보채권액 2/3의 동의가 있음으로써 확정되며, 이때 채권금융기관의 동의 여부는 채무자의 변제능력, 채권의 성격 등을 고려하여 금융기관 스스로 결정을 하는 것이고, ‘신용위원회’가 별도로 채권금융기관의 내부사정을 심사하는 것이 아니므로, 채권금융기관의 착오는 동의 착오에 불과하여 신용회복지원결정에 영향을 미친다고 할 수 없음.(2005.10.18. 조정번호 제2005-68호)

44) 대법원 1999.8.24. 선고 99다26481 판결 참조.

가. 사실관계

신청인은 1999.9.15. ○○아파트 24평형에 대한 분양계약(대금 119,964,000원)을 신청외 A건설사와 체결하였고, 2002.2.19. 피신청인과 A건설사와의 「대출업무협약」에 따라 중도금대출 금35백만원을 받은 후 같은 해 9.19.부터 이에 대한 연체를 시작하여 피신청인은 2004.7.26. 채권회수를 위하여 A건설사를 상대로 위 「대출업무협약」⁴⁵⁾에 기한 대위변제청구를 하였으며, 같은 해 12.30. A건설사로부터 대위변제금으로 금49,955,914원을 수령하였음.

한편, 신청인은 다음과 같이 신용회복지원 절차를 밟았으며, A건설사로부터 구상청구를 받자 2005.4.11. 위 분양권을 제3자에게 매도하여 수취한 금원으로 금 51,456,333원의 구상채무(대위변제금+이자)를 변제함.

- 다 음 -

- 2004.10.16. : 신용회복지원신청(총채무액 금104,200,000원)
- 2004.10.24. : 피신청인의 채권신고 및 의견서 제출
- 2004.12.13. : '신용위원회'의 채무조정안에 대한 피신청인의 동의
- 2004.12.29. : '신용위원회'의 채무조정안 승인결정 및 통지
- 2005. 1.20. : 채무조정합의서 서명날인

※ 채무조정합의서 중 피신청인 관련

대출과목	조정 전				조정 후
	원금	이자(연체)	비용	합계	
대출 및 카드	36,919,967	14,436,866	99,500	51,456,333	33,834,327

나. 당사자의 주장

45) 「대출업무협약」 제6조(“갑”의 채권회수) ①“병”에게 취급한 대출금에 “을”의 은행여신거래기본약관상 기한이익 상실에 해당하는 사유가 발생하여 “을”이 “병”에게 대출금 상환을 청구했음에도 불구하고 “병”이 상환을 지체할 경우, “갑”은 “병”이 “을”로부터 대출받은 원리금에 대하여 “병”과 연대하여 “을”의 청구서 발송일로부터 3개월 이내에 “을”에게 변제하기로 한다.(“갑”은 피신청인, “을”은 A건설사, “병”은 신청인에 해당)

(1) 신청인의 주장

신용회복지원 신청시 분양권이 있음을 명시하였고, 피신청인은 ‘신용위원회’의 채무조정안에 동의를 한 이상, ‘신용위원회’의 지원승인결정은 유효하게 확정되었으므로, 피신청인이 받은 대위변제금 중 승인결정액을 초과하는 부분은 반환하여야 할 것임.

(2) 피신청인의 주장

신청인은 분양권을 소유하고 있으므로 「신용회복지원협약」(이하 “협약”이라 한다) 운영세칙 제6조(신청제외대상자)자에 해당하고, 피신청인은 해당 채권이 이미 상각채권으로 변형되어 분양권 담보사실을 미처 파악하지 못하고 채무조정안에 동의를 하였으므로 신용위원회의 지원승인결정은 중대한 하자가 있으며, A건설사에 대해 대위변제를 청구한 시점은 신청인의 신용회복지원신청 사실을 통지받기 이전이었고, A건설사는 자발적으로 대위변제한 것이므로 이를 수령한 것은 정당함.

다. 위원회의 판단

◆ 본건에 있어서의 쟁점은 ① 해당 채권이 분양권 담보부 채권임이 고려하지 않은 ‘신용위원회’의 지원승인결정의 효력상실 여부 등이라 할 것임.

(1) ‘신용위원회’의 지원승인결정의 효력 상실 여부

피신청인은 신청인이 ‘협약’ 운영세칙 제6조 제5호의 신청제외 대상자이고 채무조정안에 대한 피신청인의 동의는 하자있는 의사표시에 의한 것이므로 조정결정은 무효라는 취지로 주장하나, 이는 다음과 같은 사유로 타당하지 아니함.

① 협약 제6조의 제5호는 신청제외대상자로서 ‘채무자의 재산 및 수입에 비추어 신용회복지원없이 총 채무를 충분히 변제할 수 있다고 인정되는 경우’를 규정하고 있으나, 신청인이 이에 해당하는지 여부는 명백하지 아니하여 ‘신용위원회’ 내 「심의위원회」의 판단이 필요한 사항인 점.

② 협약 제18조가 조정결정의 효력상실 사유와 그 절차를 별도로 정하고 있음에 비추어 설사 신청인이 신청제외대상자라고 할지라도, 신용회복지원절차를 규율하는 ‘협약’에

정하여진 절차에 의하여 동 위원회가 이를 직권취소하지 않는 한 본건 채무조정결정의 효력은 그대로 유효한 것으로 보아야 하는 점. 신청인은 지원신청서상 재산목록에 분양권을 명백히 기재하였기 때문에 직권취소사유를 규정한 협약 제18조 제4호에 규정한 “채무자가 신용회복지원 내용을 이행하는 과정에서 허위사실 신고, 재산의 도피, 은닉 기타 책임재산의 감소행위 등의 사실이 발견되는 경우”에 해당하지도 아니함 .

③ 협약 제9조 제3항에 의하면, ‘신용위원회’ 내 「심의위원회」가 채권금융기관이 제출한 채권신고서를 심의하여 의결한 채무조정안은 무담보채권액 과반수의 동의와 담보채권액 2/3의 동의가 있음으로써 확정된다고 규정하고 있는바, 이때 채권금융기관의 동의 여부는 채무자의 변제능력, 채권의 성격 등을 고려하여 금융기관 스스로 결정을 하는 것이고, ‘신용위원회’가 별도로 채권금융기관의 내부사정을 심사하는 것이 아니므로, 채권금융기관의 착오는 채권금융기관이 동의에 이르게 된 내부사정에 불과하여 ‘신용위원회’의 채무조정결정의 확정에 어떠한 영향을 미친다고 할 수 없는 점.

(2) A건설사의 대위변제에 의한 피신청인의 부당이득반환의무의 발생

본건 신용위원회 채무조정안은 협약 제9조 제3항에 의한 채권금융기관 동의절차를 밟음으로써 유효하게 확정되었고, 신청인의 피신청인 앞 채무는 조정채무액으로 변경되었으므로 이를 초과하여 수령한 대위변제금은 부당이득에 해당함. 한편 피신청인은 신용회복지원신청일 이전에 A건설사에 대위변제를 청구하였고, A건설사가 자발적으로 변제했으므로 이는 유효한 대위변제라 주장하나, 이는 다음과 같은 사유로 타당하지 아니함.

① 협약 제15조에 의하면 ‘신용위원회’의 지원 확정은 채무자 및 그 보증인에 대하여도 그 효력이 미친다고 규정하고 있고, 본건 채무조정안은 채권금융기관의 동의절차를 밟아 위 대위변제일 이전에 확정된 것이 기록상 명백하므로, 발생한 채무변경의 효력은 A기업에도 미치는 점.

② 피신청인이 변경된 채무액을 초과하여 대위변제받은 행위는 본건 채무조정안에 동의를 한 행위와 모순되는 것으로서 이는 협약 제7조가 채권금융기관은 신용회복지원 신청사실을 통지받은 이후에는 일체의 채권행사를 금지하고 있고, 채무자가 임의변제 요청을 하더라도 이를 거절하여야 한다고 규정한 취지에 반하는 점.

라. 결 론

피신청인은 A건설사가 대위변제한 금49,955,914원 중 위 조정채무액 금33,834,327원을 초과하는 부분인 금16,121,587원을 신청인에게 반환하여야 할 것임.

1-19 대출계약조건 번복으로 인한 금융기관의 손해배상책임 유무

[기각] 부동산 구입자금에 총당하기 위하여 금융기관으로부터 대출을 받고자 하였으나 금융기관 대출담당직원이 대출조건 안내를 제대로 하지 못하여 대출계약이 유효하게 이루어지지 않았고 이로 인해 부동산 매매계약이 해약된 경우 대출계약이 이루어지지 않은 사실 및 부동산 매매계약이 해약됨으로써 발생하는 해약금 상당의 손해는 밀접한 개연성을 갖지 않으므로 통상의 손해범위에 해당하지 않음.(2005.11.8. 조정번호 제2005-71호)

가. 사실관계

신청인은 근린상가 매수자금 마련을 위하여 피신청인 대출담당팀장 A씨 및 부팀장 B씨와 신청인이 거주하는 연립주택을 담보로 부동산담보대출(대출금액 4.7억원, 3년거치 30년 원금분할상환조건)을 진행하였으며 그 경위는 다음과 같음.

- 2005.7. 1.(금) 신청인, 전단지를 보고 위 B씨에게 전화로 대출문의 및 감정신청
- 2005.7. 4.(월) 한국감정원의 현장 감정 평가
- 2005.7. 6.(수) 대출신청서 및 대출약정서에 서명 날인
- 2005.7. 7.(목) 소득증빙을 위하여 신청인과 신청외 C씨 간의 매매계약서 사본⁴⁶⁾ 추가 제출받아 심사부서에 접수
- 2005.7. 8.(금) 여신심사부서가 거치기간 오류로 반려
- 2005.7. 9.(토) 위 B씨는 거치기간이 없는 상환조건으로 수정 제의
- 2005.7.10.(일) 신청인은 위 B씨에게 대출철회를 통보하고 위 C씨에게 상가 매매계약의 해약을 통보하여 계약금의 일부인 금17백만원을 반환받음
- 2005.7.11.(월) 위 A씨는 신청인에게 전화하여 예외승인절차를 밟아 원래조건대로 대출을 받게 해주겠다고 제의하였으나 신청인은 이를 거절함

나. 당사자의 주장

(1) 신청인의 주장

본건 대출계약은 대출담당부서 팀장 등과 합의에 의하여 성립하였으므로 피신청인은 합의된 대출조건인 3년 거치 분할상환조건으로 대출을 실행하여야 함에도 이를 거절함으로써 동 조건에 따라 대출이 실행될 것을 믿고 체결한 상가매매계약이 해약되어 발생한 해약금 상당의 손해를 배상하여야 함.

(2) 피신청인의 주장

본건 대출계약은 여신심사부의 승인 통보가 없었으므로 성립하였다고 볼 수 없고, 신청인의 상가매매계약 해약금 상당 손실은 동 대출과 직접적인 관련을 인정할 수 없어 그 손해를 배상할 수 없음.

다. 위원회의 판단

◆ 본건에 있어서의 쟁점은 ① 대출계약에 기한 채무불이행 책임 인정 여부 ② 대출계약조건의 번복으로 인한 사용자배상책임의 인정 여부임.

(1) 대출계약에 기한 채무불이행 책임 인정 여부

신청인은 본건 대출계약은 불요식 낙성계약으로서 대출담당팀장과 3년거치 상환조건으로 합의를 하였으니 계약이 성립하였다고 주장하나, 본건 대출계약은 다음의 사유에 비추어 성립하지 아니하였으므로 계약에 의한 채무불이행 책임은 인정되지 아니함.

① 은행대출은 통상 은행 측의 대출 관련 홍보 및 대출상담 등으로 유인된 고객들이 대출신청서 및 대출약정서에 서명날인을 하고 피신청인의 내부승인 절차를 거쳐 약정일자에 대출금액을 고객에게 이전하여 주고 있는데, 고객의 대출신청서 및 대출약정서에 대한 서명날인 행위는 청약에, 은행의 승인 통보 행위를 승낙으로 볼 수 있는 점.

46) 한편 신청인은 2005.7.5.(화) C씨와 이전에 보아둔 물건인 근린상가에 관하여 매매계약(대금 885백만원 잔금지급일 2005.7.12.)을 체결하고 즉석에서 매매예약금 2백만원을 지급한 후, 2005.7.7.(목) 나머지 계약금 28백만원을 지급함.

② 본건의 경우 피신청인이 2005.7.9.(토) 신청인에게 빌라를 담보로 한 대출은 3년 거치 원금분할상환 조건으로는 승인이 어려우므로 거치기간을 수정요구한 것은 기존 청약에 대하여는 승낙거절로 보아야 하는 점.

③ 대출담당직원 B씨 등은 본건 계약을 다시 성립시키려고 2005.7.11.(월) 여신심사부서로부터 구두로 예외적 승인 여부를 확인하고 신청인에게 기존 조건대로 대출을 받을 것을 권유하였으나 신청인이 이를 거절한 점.

(2) 대출계약조건 반복으로 인한 사용자배상책임의 인정 여부

대출담당직원이 대출조건 안내를 제대로 하지 못한 과실은 있으나, 신청인이 상가매수계약을 해약함으로써 발생한 해약금 상당 손해에 대한 피신청인의 사용자배상책임은 다음의 사유에 비추어 인정하기 어려움.

① 일반적으로 대출계약이 유효하게 체결되지 않은 사실과 부동산매매계약이 해약됨으로써 발생하는 해약금 상당의 손해는 밀접한 개연성을 갖지 않으므로 통상의 손해범위에 해당하지 않는 점.

② 설사 본건 대출 약정서의 소득증빙서류로 상가 매수계약서가 첨부되는 등 피신청인측이 상가매수계약이 체결되었음을 알고 있었다고 하더라도, 신청인이 선택한 본건 대출 상환방법은 30년 분할상환조건으로서 3년 거치기간의 유무는 대출계약의 형태를 변경하는 정도가 아닌 부수적인 조건에 해당하고, 피신청인 담당직원이 이를 잘못 안내한 사실과 신청인이 대출을 철회하고 부동산 매수계약을 해제하여 해약금 손실이 발생한 사실과는 상당한 인과관계가 인정되지 않아 특별손해의 범위에도 해당하지 않는 점.

라. 결 론

본건 대출계약은 성립된 것으로 볼 수 없어 피신청인의 채무불이행 책임은 인정되지 않고, 본건 대출계약의 유효하게 체결되지 않은 사실과 신청인이 상가매수계약을 해제하여 발생한 해약금 상당의 손해와는 상당한 인과관계가 인정되지 않아 피신청인의 사용자배상책임을 인정할 수 없으므로 신청인의 신청을 기각함.

1-20 외화대출의 원화대출 전환에 따른 금융기관의 손해배상책임 유무

[기각] 외화대출을 받을 때 미리 “통화전환옵션부 외화대출 원화대출 전환신청서”에 자필서명 하였는데 이는 외환시장의 변동의 급격성, 의외성을 감안하여 필요시 원화대출로 전환하기로 미리 합의한 일종의 정지조건부 계약으로 판단되나, 대출 신청인의 동의가 없을 경우까지 유효하다고 볼 수는 없음. 그러나 피신청인의 원화전환과 관련하여 신청인과의 통화내역 등으로 볼 때 신청인이 구두에 의한 전환청구가 있었던 것으로 판단되므로 그에 대하여 피신청인은 손해배상 책임이 없다 할 것임.(2007.12.4. 조정번호 제2007-92호)

가. 사실관계

신청인은 2006.8.29. ○○은행(이하 “피신청인”이라 함)으로부터 만기일을 2007.8.24.로 하는 외화대출(일본법화 7,290만엔⁴⁷⁾)을 받았으며, 동일자에 “통화전환옵션부 외화대출 원화대출 전환신청서”에 전환내용을 공란으로 하여 자필로 서명날인함.

피신청인은 2007.8.17. 엔화환율이 급등하자 신청인과 전화통화한 후 엔화대출을 원화대출로 전환 처리함.⁴⁸⁾ 2007.8.21. 신청인의 배우자가 신청인의 동의 없이 원화대출로 전환되었다며 이의제기하였고, 신청인은 2007.8.24. 타행대출을 받아 본건 원화대출금을 전액 상환하였음.

2007년 8월중 엔화 환율 추이(100엔당 전신환매도율을 기준, 단위:원)

구 분	1일	6일	14일	16일	17일	20일	24일
최고환율	793	795.63	798.53	824.41	855.76	841.12	821.81
최종고시	792.67	791.68	798.53	824.41	844.44	825.30	820.04

47) 최초 취급시 100엔당 전신환매도율은 816.71원으로써 원화환산금액은 5억9,538만원이며, 대출이자율은 변동금리이나 대출기간 금리는 1.84~2.21%임.

48) 피신청인이 제출한, ○○통신사 통화사실 확인내역서에 의하면 2007.8.17. 15:46:12에 49초 동안 신청인 휴대전화로 통화한 기록이 있고, ◇◇통신회사의 전화이용 내역서에 의하면 15:47:50에 팩스를 발송한 전화번호가 있으며, 피신청인의 IT운영부 자료에는 신청인의 휴대전화로 13:56:43에 5분36초간, 16:16:17에 34초간 각각 통화한 기록이 있으며, 2007.8.17. 원화대출 6억2,600만원(금리: 연 7%)을 신청인의 통장에 입금하고, 외화대출금(6억2,239만원 : 7,290만엔 X 100엔당 전신환매도율 853.76), 이자(41만원), 통화옵션전환 수수료(242만원), 수입인지대금(15만원)을 대체 공제(공제 후 잔액 63만원)함.

나. 당사자 주장

(1) 신청인 주장

2007.8.17. 유선으로 엔화 환율변동 폭이 커서 상환시 원화부담이 가중될 염려가 있으니 원화대출로 전환 할 것을 피신청인 담당자로부터 제의 받은 사실은 있으나, 전환해 달라고 요청한 적이 없음에도 피신청인이 임의로 전환하였는 바, 전환시점과 만기시점과의 환율차이 및 원화대출금리 인상적용으로 인해 발생한 피해를 피신청인은 보상할 책임이 있음.

(2) 피신청인 주장

2007.8.17. 원화대출전환은 신청인과 전화로 협의하여 진행하였으며 전환 후 신청인에게 팩스로 전환내역을 송부하였음. 또한 팩스 수령사실을 유선으로 확인하였으며 통신기록으로 전화 및 팩스를 송부한 사실을 확인할 수 있음. 최초 대출취급시 은행여신거래 약정서 및 “통화전환옵션부 외화대출 원화대출 전환신청서”에 신청인의 자서날인을 받아놓고 언제든지 전환 가능토록 하였으며, 실제 대출통화 전환 시에도 전환의사를 직원 이 유선확인한 후 전환하는 등 본건 대출통화 전환처리는 하자 없는 적정한 업무처리임.

다. 위원회 판단

◆ 본 건의 쟁점은 당초의 외화대출을 중도에 원화대출로 전환하면서 취한 절차의 적법 여부라 할 것임.

신청인은 2006.8.29. 피신청인으로부터 외화대출을 받을 때 미리 “통화전환옵션부 외화대출 원화대출 전환신청서”에 자필서명 하였는데 이는 외환시장의 변동의 급격성, 의외성을 감안하여 필요시 원화대출로 전환하기로 미리 합의한 일종의 정지조건부 계약으로 판단되나, 대출 신청인의 동의가 없을 경우까지 유효하다고 볼 수는 없음.

그러나 2007.8.17. 피신청인의 원화전환과 관련하여 신청인이 구두(전화)에 의한 전환청구가 있었는지 여부에 대하여 양 당사자의 주장이 상반되고 있는데, 다음과 같은 정황을 볼 때 신청인의 구두에 의한 전환청구가 있었던 것으로 판단됨.

① 전환당일인 2007.8.17. 신청인과 피신청인이 엔화 환율 급등으로 인한 상담을 하였고, 피신청인은 2007.8.17. 15:47:50 신청인에게 원화전환 내용을 기재한 문서를 팩스로 송부한 내역이 있다고 주장하여 ○○통신회사의 통화사실 확인내역서, ◇◇통신회사의 전화이용내역서 등을 확인한 바, 기재된 문서의 내용은 알 수 없으나 팩스 송부한 내역은 확인되는 점.

② 이에 대하여 신청인이 이의를 제기하지 않다가 엔화환율이 급락한 2007.8.21. 비로소 신청인의 배우자가 이의를 제기하였고, 신청인의 배우자는 2007.8.18. 또는 8.20.경에 인터넷뱅킹으로 외화대출금과 환율을 조회하고 원화대출로의 전환사실을 알았다고 주장하나 피신청인이 제출한 인터넷뱅킹 접속기록 및 세부조회 기록상으로는 확인이 되지 않는 점.

라. 결 론

신청인과 피신청인간의 원화대출 전환은 유효하게 성립된 것으로 판단되는바, 피신청인은 신청인에 대하여 손해를 배상할 책임이 없다 할 것임.

1-21 대물변제를 통한 PF대출 원리금 상환의 적정성 및 정산비용의 범위

[일부인용] 신청인이 PF대출약정에 따라 피신청인에게 미분양물건의 소유권이전에 필요한 서류를 송부하고 사업정산(대출원리금 상환) 완료를 통보한 경우, 비록 당초 약정내용이 여신전문금융업법 제46조, 제49조에 위반된다 하더라도 동 조항은 단속규정이므로 계약의 사법적 효력을 부인하기는 어렵다 할 것임. 또한 정산비용은 사업종료시 분양수입에서 본건 대출금을 초과하여 지급된 비용만이 대상이 되고, 남은 금액은 지분율대로 배분하는 것이 상당하다고 판단됨(2010.6.8. 조정번호 제2010-53호).

가. 사실관계

2007.6월경 여신전문금융회사인 피신청인은 신청인(부동산업, 건설시행사)과 신청인 소유의 서울 ○○동 소재 토지에 중고차 쇼핑몰 개발사업을 위한 업무제휴협약을, 2007.7.25.

“사업약정 및 자금관리약정서(이하 “사업약정서”라 함)”, 대출약정서를 작성하고 PF대출 총 192억원⁴⁹⁾을 취급함.

본건 대출시 A씨, B씨, C씨가 연대보증 겸 주식담보(근질권)를 제공하였고 담보주식 9,070주는 피신청인이 보관 중이며, 동 대출금은 본 사업의 수행과 관련하여 공사비, 금융비용, 기타 초기 사업비 등 본 사업의 원활한 진행을 위한 제반 비용의 지급 목적으로만 사용하는 것으로 약정(대출약정서 제2조)하였고, 사업자금의 관리인으로 ○○은행이 신청인과 피신청인의 서면동의하에 사업자금으로 집행하였음.

2010.1.5. 신청인은 피신청인에게 사업완료 후 당초 계약에 따른 정산⁵⁰⁾을 요구하였고, 1.29. 피신청인은 대출원리금 상환을 위한 부동산을 취득하되 여신전문금융업법에 위반됨을 사유로 “미분양 부동산 교차선택을 통한 소유권 취득 후 신청인과 임대사업약정을 배제한 상태에서 피신청인이 매각을 진행한다”는 수정안을 제시하였음.

2010.2.24. 신청인은 사업정산이 지연됨에 따라 피신청인에게 소유권이전에 필요한 서류 등을 송부하고 사업정산완료료를 통보하였고, 2010.3.12. 피신청인은 미분양물건의 50%를 취득하기로 한 대출약정은 여신전문금융회사의 비업무용 부동산취득을 금지하고 있는 『여신전문금융업법』 제46조(업무), 제49조(부동산의 취득제한)⁵¹⁾에 위반되어 사법상

49) 2007.7월이후 총 5차례 대출 실행(192억원), 이자 연리 8%(지급이자 총 29.9억원), 만기일 201.3.26.

50) 분양대금수입(121.6억원 상당, 미수금 64억원 포함, 부가세 별도) 보다 총사업비용(272억원 상당)이 과다하여 대출약정서에 따라 미분양물건의 50% 소유권 이전을 통한 대출원리금 상환(대물변제). 사업정산 완료후 3년간 신청인이 캐피탈 소유의 물건에 대하여 임대사업 운영(사업약정서 제6-1조) 및 임대수익금은 임대관련 비용 공제 후 50:50으로 분기별 배당.

51) 여신전문금융업법 제46조 및 제49조는 다음과 같음.

제46조(업무) ① 여신전문금융회사가 할 수 있는 업무는 다음 각 호의 업무로 제한한다.

1. 제3조에 따라 허가를 받거나 등록을 한 여신전문금융업
2. 기업이 물품과 용역을 제공함으로써 취득한 매출채권(어음을 포함한다)의 양수·관리·회수업무
3. 대출(어음할인을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)업무
- 4.~7. (생략)

② 제1항제3호에 따른 대출업무는 대통령령으로 정하는 기준에 따라 하여야 한다.

제49조(부동산의 취득제한) ① 여신전문금융회사가 취득할 수 있는 업무용 부동산은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 제한한다.

1. 본점(本店)·지점(支店), 그 밖의 사무소

무효임을 사유로 신청인에게 대물변제 등 사업정산 거부를 통보함.

나. 당사자 주장

(1) 신청인 주장

신청인은 본건 사업약정서, 대출약정서의 내용대로 대물변제를 통해 대출원리금을 상환하고자 하는 것인데 피신청인이 여신전문금융업법 위반을 이유로 계약이행을 거부하는 것은 부당함.

분양대금수입(121억원, 미수금 64억원) 보다 총사업비용(272억원)이 과다하여 신청인이 피신청인에게 현금으로 대출원리금을 상환할 수 없음에도, 대출약정서 제5조제2항에서 정하고 있는 분양대금수입에서 정산할 사업비의 범위에 대하여, 피신청인은 그 동안 한 번도 신청인에게 이의 제기를 하지 않다가 신청인이 분쟁조정 신청을 제기하자 갑자기 피신청인의 대출금으로 지급된 공사비(192억원)는 정산대상에 포함되지 않는다고 주장하는 것은 억지이며, 본건 대출약정 체결 당시에 관여한 피신청인의 전 임직원들도 분양대금 수입에서 정산할 사업비의 범위에 피신청인의 대출금액을 차감하기로 계약을 체결하지 않았다고 확인해 주었음.

대출원리금 상환 및 지급조건에 관해서는 대출약정서(사업약정서 제1-5조, 대출약정서 제17조 제5항)가 우선하며, 대출약정서에도 분양대금수입에서 정산할 공사비용에서 피신청인의 대출금을 차감한다는 표현이 없으므로, 신청인이 분양대금 수입 중 피신청인에게 상환할 대출원리금은 없음.

신청인이 피신청인에게 미분양물건의 소유권이전에 필요한 서류를 송부하고 사업정산

2. 임직원용 사택(社宅), 합숙소 및 직원 연수원

3. 그 밖에 업무에 직접 필요한 부동산으로서 총리령으로 정하는 것

②~③ (생략)

④ 여신전문금융회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 업무용 부동산 외의 부동산을 취득할 수 있다.

1. 해당 부동산이 시설대여나 연불판매의 목적물인 경우

2. 담보권(擔保權)을 실행하여 부동산을 취득하는 경우

(대출원리금 상환) 완료를 통보한 시점(2010.2.24.)에 신청인의 대출원리금 상환의무는 소멸하였으므로, 피신청인은 대출원리금이 상환되었음을 수용하고 담보 제공된 주식에 대한 근질권을 해지하고 담보제공자에게 주식을 반환함과 아울러 보증책임도 소멸되었음을 확인하여야 함.

(2) 피신청인 주장

대물변제를 통한 대출원리금의 상환을 규정하고 있는 대출약정서 제5조 제2항은 여신전문금융업법 제46조, 제49조에 위반되어 사법상 무효이고, 이는 피신청인의 여신승인 조건에도 반하며, 당시 본건 업무에 관여했던 피신청인 직원이 피신청인을 속여 본건 약정을 체결하였고 퇴사 후 신청인의 회사에 재직중에 있는 바, 본건 대물변제약정은 무효라 할 것이어서 신청인은 대출원리금을 현금으로 상환해야 함.

분양수입대금의 정산을 위하여 공제하여야 할 비용은 토지매입비 192억원 및 피신청인의 대출금으로 지급되는 공사비 외에 추가로 소요된 비용을 의미하는 것이며, 이는 신청인과 수차례에 걸쳐 협의된 내용이므로 분양대금수입에서 추가로 소요된 비용을 차감하고 남은 분양수입금을 50:50으로 배분해야 함.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 ① 여신전문금융회사의 비업무용 부동산취득을 금지하고 있는 여신전문금융업법 제46조, 제49조의 성격 및 그에 따른 본건 약정의 사법적 효력여부 ② 사업정산 시 분양수입금에서 차감할 비용의 범위라 할 것임

(1) 여신전문금융업법 제46조, 제49조의 성격 및 그에 따른 본건 계약의 효력

1) 단속규정과 효력규정의 구별

어떤 행정법규를 효력규정으로 보아 이에 위반한 계약의 효력을 부인하기 위해서는 법규의 체제나 입법취지, 당해 행위의 사회적 비난가능성의 정도, 이에 위반한 행위를 무효로 하여 상대방 내지 사회 전반에 미치는 영향 등을 고려하여 결정하여야 할 것이고, 당해 법규의 위반이 현저히 반사회성이나 반도덕성을 가지는 경우 또는 입법목적 달

성을 위해 사법상의 효력을 부인할 필요성이 있는 때에는 당해법규를 효력규정으로 보아 위반행위의 효력을 부인할 수 있다 할 것임.⁵²⁾

2) 여신전문금융업법 제46조, 제49조의 성격 및 본건 계약의 효력

다음과 같은 점에 비추어 본건 관련 여신전문금융업법 제46조, 제49조는 단속규정으로 보는 것이 상당하다 할 것이고 본건 사업약정 및 대출약정이 이에 저촉된다고 하더라도 그 사법적 효력을 부인하기는 어렵다 할 것임.

① 여신전문금융회사의 비업무용부동산취득을 금지하고 있는 여신전문금융업법 제46조, 제49조는 비업무용 부동산의 과다취득에 따른 유동성 부족, 자금고정화의 방지 등을 통한 여신전문금융회사의 건전경영 유도에 그 취지가 있는 것으로 보이며 이에 위반한 행위의 사법적 효력까지 부인할 정도로 현저히 반사회성이나 반도덕성을 가지는 규정이라고 보기 어려운 점.

② 대법원도 본건과 같이 비업무용부동산 취득금지를 규정하고 있는 구 상호신용금고법(1999.2.1. 법률 제5738호로 개정되기 전의 것) 제18조의⁵³⁾에 대해 이를 단속규정으로 보아 이에 저촉되는 행위의 사법상 효력에는 아무런 영향이 없다고 판시하고 있는 점.

(2) 사업정산시 분양수입금에서 차감할 비용의 범위

한편, 사업정산시 분양수입금에서 차감할 정산비용의 범위에 본건 대출금으로 지급된 공사비가 포함되는지 여부에 대해 당사자간 다툼이 있고 이에 따라 신청인이 분양수입금에서 피신청인에게 상환할 금액에 차이가 발생함.

위와 같이 법률행위의 내용이 명확하지 아니한 경우에, 우리 민법은 법률행위의 해석의 기준을 명문으로 마련하지는 않았지만 ‘당사자의 내심적 의사의 여하에 관계없이 그 서면의 기재내용에 의하여 당사자가 그 표시행위에 부여한 객관적 의미를 합리적으로 해석하여야 하고, 당사자가 표시한 문언에 의하여 그 객관적인 의미가 명확하게 드러나지 않는 경우에는 그 문언의 내용과 그 법률행위가 이루어진 동기 및 경위, 당사자가 그

52) 대법원 2008.12.24. 선고 2006다53672 판결 참조.

53) 제18조의2(금지업무) 상호저축은행은 다음 각호의 행위를 하여서는 아니된다.

2. 업무용부동산외의 부동산의 소유. 다만, 담보권의 실행으로 인하여 취득하는 경우는 제외한다.

법률행위에 의하여 달성하려는 목적과 진정한 의사, 거래의 관행 등을 종합적으로 고려하여 사회정의와 형평의 이념에 맞도록 논리와 경험칙, 사회일반의 상식과 거래의 통념에 따라 합리적으로 해석하여야 할 것임.⁵⁴⁾

신청인은 정산비용의 범위에 피신청인으로부터 대출받아 지급한 공사비 192억원 상당이 포함된다고 주장하나, 다음과 같은 점에 비추어 사업종료시 분양수입에서 본건 대출금을 초과하여 지급된 비용만을 정산하고, 남은 금액은 지분율대로 배분하는 것이 상당하다고 판단됨.

① 신청인은 본건 대출약정 당시에 관여한 피신청인의 전 임직원들도 분양대금 수입에서 정산할 사업비의 범위에 캐피탈의 대출금액을 차감하기로 계약을 체결하지 않았다고 확인해 주었으며, 대출원리금 상환 및 지급조건에 관해서는 대출약정서(사업약정서 제1-5조, 대출약정서 제17조 제5항) 우선하므로 신청인이 분양대금 수입 중 피신청인에게 상환할 대출원리금은 없다고 주장하나, 피신청인 전 임직원의 사실확인서 만으로 신청인 주장사실을 인정하기 부족하며, 대출약정서상 정산범위가 명확하지 않아 본건 대출의 구조 및 관련 자료를 종합적으로 검토하는 것을 위 사업약정서나 대출약정서에 반한다고 보기 어려운 점.

② 본건 사업은 신청인의 토지 및 피신청인의 대출을 이용하여 이루어진 것이고, 본건 사업약정 및 대출약정의 지분율 50:50은 대출금(192억원 상당) 및 신청인의 토지가치(192억원 상당⁵⁵⁾)를 고려한 것으로 보이며, 신청인이 피신청인에게 제출한 사업계획서상 피신청인의 대출금으로 지급된 공사비를 제외하고 수지분석이 이루어지고 있는 점.

③ 본건 사업약정서 제4-5조(사업비집행방법) 제3항은 “본 사업에 투입된 갑(신청인)의 자본금 및 대출약정금을 초과하여 투입된 자기자금 등은 프로젝트금융의 대출원리금이 상환되는 시점에 정산 지급하는 것을 원칙으로 하되, 갑이 지출한 명도 관련 비용 중 5억원에 이르는 금액은 우선 정산하여 상환”하기로 규정⁵⁶⁾하고 있는 점.

54) 대법원 2002.4.23. 선고 2001다84794 판결 참조.

55) 피신청인의 여신심사서 및 신청인 작성한 사업계획서상 토지비가 192억원으로 표시되어 있음.

56) 분양대금수입이 대출원금을 초과하여 지급된 공사비용과 명도비용 중 5억원을 합한 금액보다 적을 경우에도 동 차액을 정산해야 할 것임.

라. 결 론

신청인은 사업약정서 제5-2조, 대출약정서 제5조 제2항에 따라 분양대금 수입에서 피신청인의 대출원금을 초과하여 지급된 본건 사업 관련 비용 등을 정산하고 남은 금액의 50%를 피신청인에게 지급할 의무가 있고, 피신청인은 미분양물건의 50% 대물변제를 통한 대출원리금 상환 및 소유권이전등기 약정을 이행할 의무가 있다 할 것임.

1-22 연체이자 과다징수 여부

[기각] 연체이율 적용에 대해서는 원칙적으로 대출 취급시 당사자간에 합의한 개별약정이 우선하여 적용되어야 할 것이고, 본건 연체이자율 및 징구방법에 의하면 피신청인의 기한이익상실 조치 등과 관계없이 연체기한 경과에 따라 원금에 대해 연체이율이 적용될 수 있도록 규정되어 있고, 신청인이 동 서류에 서명날인하고 있으며, 기한이익 상실에 관한 약관 또한 반드시 연체이자 징수를 위해 기한이익 상실조치를 취해야 한다고 보기 어려운 점 등을 감안시 피신청인의 연체이자 부과가 부당하다고 보기 어려움.(2010.10.20. 조정번호 제2010-88호)

가. 사실관계

신청인은 2009.6.29. ○○신용협동조합(이하 “피신청인”이라 함)과 대출약정(110백만원)⁵⁷⁾을 체결하고 대출을 취급함.

< 연체이자율 및 징구방법 >

연체경과기간	연체이자율
1개월(31일까지)	약정금리
1개월이상 2개월이내(32일~61일)	약정금리이자액 X 연체이자율(17%)
2개월 이상(62일부터)	대출원금 X 연체이자율(17%)
약정기한 경과대출	<원칙> ① 대출원금 X 연체이자율(17%) ② 정상이자납입한 대출로 연기수속 미이행시 (약정기간내 3개월 이상 연체사실이 없는 경우) 2개월까지는 연체이자액 X 연체이자율

57) 만기 5년, 금리 8.2%(공제가입조건 0.5% 감면), 만기일시상환.

신청인은 매월 이자를 납입하던 중에 2010.3월분(납부일 2010.3.29.) 이자를 연체한 후, 2010.4.16. 75만원을 자동이체계좌에 입금하여 3월 정상이자(716,657원)와 동 이자에 대한 연체이자(6,008원)가 정리되어 대출금이 정상화 되었음. 또한 2010.5.26. 자동이체계좌에 50만원이 입금되어 4.16.까지의 이자금액(469,534원)과 동 이자에 대한 연체이자(5,904원)가 정리되었으나 4.29. 납부일까지의 이자금액은 미달되어 연체됨.

2010.7.2. 155,000원을 자동이체계좌에 입금(계좌잔액 93만원)하여 4.17. 하루분 정상이자(24,712원)와 동이자상당액에 대한 연체이자(345원)와 5.29.부터 7.1.까지의 원금잔액에 대한 연체이자(901,608원)가 정리됨.

2010.7.29. 신청인의 자동이체 계좌에서 4.18.~6.28. 기간중 정상이자와 4.18.~4.28. 기간중 정상이자 271,835원에 대한 연체이자(4,051원)와 7.2.~7.28. 기간중 원금잔액에 대한 연체이자(716,054원)가 정리됨.

피신청인은 2010.4.26., 6.16., 7.26., 7.30. SMS 메시지로 신청인에게 이자납입을 안내함.

나. 당사자 주장

(1) 신청인 주장

기한이익상실통보서나 원금연체 등 연체에 대한 안내를 받은 바도 없음에도 원금에 대한 연체이율이 적용되는 등 과도한 연체이자가 징수된 것은 부당함.

(2) 피신청인 주장

연체로 인해 기한이익상실조치를 취해야만 원금에 대한 연체이율을 적용할 수 있는 것은 아니며, 피신청인은 대출취급시 신청인과 별도로 약정한 ‘연체이율 및 징구방법’에 의하여 연체이자를 징수한 것이므로 신청인 주장을 수용하기 어려움.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 원금잔액에 대한 연체이율을 적용하기 위해 피신청인의 기한이익상실 조치 등이 요구되는지 여부 및 이에 따른 연체이자의 과당징수 여부라 할 것임.

신청인은 원금에 대한 연체이율을 적용하기 위해서는 피신청인의 기한이익상실조치 등이 전제되어야 하며 별도의 통보 등 조치없이 연체이자가 과다징수 되었다는 취지로 주장하나, 다음과 같은 점에 비추어 이를 인정하기 어려움.

① 연체이율의 적용에 대해서는 원칙적으로 본건대출 취급시 당사자간에 합의한 개별 약정이 우선하여 적용되어야 할 것이고, 본건 연체이자율 및 징구방법에 의하면 피신청인의 기한이익상실 조치 등과 관계없이 연체기한 경과에 따라 원금에 대해 연체이율이 적용될 수 있도록 규정되어 있고, 신청인이 동 서류에 서명날인하고 있는 점.

② 채권에 대한 기한이익상실여부 및 기한이익상실에 따른 채권회수조치 여부는 피신청인이 판단하여 결정할 수 있는 사항으로 기한이익상실조치와 연체이율의 적용여부가 반드시 결합되어 해석되어야 한다고 보기 어려우며, 「여신거래기본약관」 제7조⁵⁸⁾ 또한 기한이익상실에 관한 사항을 규정한 조항으로 동 규정이 반드시 연체이자 징수를 위해 기한이익 상실조치를 취해야 한다고 보기 어렵고, 「여신업무방법서」상의 “기한이익상실 일(1개월)까지”란 내용⁵⁹⁾은 기한이익을 상실조치를 취한 날을 의미하는 것이 아니라, 이자 등을 지급해야 할 때부터 계속하여 1개월간 지체되어 기한이익 상실조치를 하는 것이 가능한 날을 의미하는 것으로 해석할수 있고 기한이익상실조치를 취해야만 원금에 대한 연체이자를 받을 수 있다고 단정하기 어려운 점. 만약 원금전액에 대해 연체이율을 적용하기 위해 채권자인 피신청인이 반드시 기한이익상실조치를 취해야 한다고 보면 오히려 대출채무자에게 불리한 결과가 야기될 수 있는 점.

58) 「여신거래기본약관」 제3조 ①이자등과 지연배상금(이하“이자등”이라고 합니다)의 율, 계산방법, 지급의 시기 및 방법에 관하여는 채무자는 법령이 허용하는 한도내에서 조합이 정하는 바에 따르기로 합니다. 제7조 ②채무자에 관하여 다음 각 호에서 정한 사유 중 하나라도 발생한 경우 채무자는 당연히 당해 채무의 기한의 이익을 상실하여 곧 이를 갚아야 할 의무를 집니다. 다만, 조합은 기한의 이익상실일 3영업일전까지 다음 각 호의 채무이행 지체사실과 이에 따라 기한의 이익이 상실된다는 사실을 채무자에게 통지하여야하며, 기한의 이익상실일 3영업일전까지 통지하지 않은 경우 실제 통지가 도달한 날부터 3영업일이 경과한 날에 기한의 이익을 상실하여 채무자는 곧 이를 갚아야 할 의무를 집니다.

1. 이자를 지급하여야 할 때부터 계속하여 1개월간 지체한 때

59) 「여신업무방법서」 제15조(지연배상금) 제2항 1. 일시상환대출 : 이자의 입금 약정기일에 이자가 입금 되지 않는 때에는 이자 입금 약정일로부터 기한이익상실일(1개월)까지는 입금하여야 할 기한내이자액에 대하여, 그 다음날부터는 당해 대출금 잔액에 대하여 연체이율을 적용한 지연배상금을 받는다.

③ 2007.4.3. 신협중앙회는 회원조합에게 대출금 지연배상금제도와 관련하여 “이자를 지급하여야 할 때부터 계속하여 1개월간 지체한 때” 등의 사유가 발생한 경우 대출금 잔액 전부에 대하여 연체이자 적용되도록 지도한 사실이 있는 점.

④ 피신청인이 SMS를 통해 신청인에게 이자납입을 안내한 사실이 있는 점.

라. 결 론

피신청인은 신청인에 대하여 연체이자를 과다징수했다고 보기 어려우므로 신청인의 청구는 이유 없어 이를 기각함.

1-23 대출금 분할상환 약정시 연체이자 감면의 합의가 있었는지 여부

[인용] 피신청인 담당직원과 신청인이 대출금 분할상환을 내용으로 하는 확약서를 작성한 사안에 대하여 채무의 면제 또는 면책은 반드시 명시적인 의사표시만에 의하여야 하는 것이 아니고 의사표시의 해석에 의하여 그것이 채무의 면제 또는 면책이라고 볼 수 있는 경우에도 인정할 수 있는 바(대법원 2013.5.9. 선고 2013다7516 판결), 확약서 작성당시 신청인과 피신청인 사이에 연체이자 감면에 대한 합의가 있었다고 판단하면서 가사 이러한 합의가 인정되지 않는다 하더라도 신청인에게 연체이자 감면에 대한 신뢰를 준 피신청인이 그 신뢰에 반하여 일방적으로 연체이자를 회수한 것은 신의칙에 반하는 부당한 권리행사라고 판단한 사례(2014.3.11. 조정번호 제2014-7호)

가. 사실관계

2011.12.12. 신청인은 사업자금 용도로 피신청인으로부터 일수대출 30백만원(이자율 25.55%, 연체이자율 39%, 매일 21,000원 이자 납부, 2013.1.15. 일시상환 조건, 이하 ‘본건 대출’이라 함)을 받음.

본건 대출과 관련하여 피신청인의 요구에 따라 신청인은 피신청인에게 사업장에 대한 임차보증금반환채권(30백만원)을 양도하고, 사업매출금이 입금되고 있던 상호부금계

좌에 질권을 설정해 주었으며, 신청인의 남편과 모친을 연대보증인으로 입보시킴.

본건 대출 이후 신청인은 매일 21,000원의 이자를 정상적으로 납부하여 왔으며, 대출 만기 이전인 2013.1월 초경 대출연장을 요청하였으나, 피신청인은 신청인의 신용등급이 하락하였음을 이유로 대출 연장이 불가함을 통보함.

본건 대출의 만기도래 이후인 2013.1.23. 피신청인은 신청인의 질권 계좌 잔액을 대출 채무 대등액과 상계하여 대출잔액이 20,127,065원으로 감소함.

2013.1월 하순경 신청인은 본건 대출 연장을 위해 피신청인 담당직원 K(이하 ‘담당직원’이라 함)를 방문하여 개인회생을 준비 중이며, 그간 성실히 이자를 납부한 점을 감안하여 연체이자 감면을 요청함.

피신청인 담당직원은 신청인에게 본건 대출과 관련하여 개인회생 채권자목록에서 제외해 줄 것을 요청하고, 지점장 지시에 따라 신청인에게 대출원금을 분할상환하는 조건을 제시함.

2013.1.31. 신청인은 피신청인 담당직원이 제시한 분할상환 조건에 동의⁶⁰⁾하여 “2013.2.1.부터 4주간 매주 15만원씩, 그 후 매주 35만원씩 원금상환하겠다”는 확약서(이하 ‘본건 확약서’라 함)를 제출하고 확약서대로 대출원금을 상환함.

피신청인은 2013.2.7.~6.27. 기간 중 신청인이 분할상환한 금원⁶¹⁾을 여신원장상의 대출원금에서 차감처리하여 대출원금이 13,577,065원으로 축소됨.

확 약 서⁶²⁾

본인 甲은 S저축은행의 대출금 총 삼천만원 중 대출잔액 20,127,065원에 대해 2013년 2월 1일부터 2013년 2월 28일까지 매주 일십오만원을 원금상환 하겠으며, 2013년 3월 1일부터 채무잔액 전체 상환시까지 매주 삼십오만원을 원금상환할 것임을 확약합니다. 만일 확약 내용을 이행하지 않을 시 귀행에서 진행하는 모든 민, 형사상

60) 신청인은 담당직원이 연체이자를 감면해 주기로 하여 확약서를 작성했다고 하나, 담당직원은 대출원금이 완납되면 본점 승인을 받아 연체이자 감면을 추진하기로 했다고 주장하는 등 연체이자 감면 조건에 대하여는 당사자 주장이 상이

61) 매주 15만원(4회), 35만원(17회) 총 21회(6,550,000원)을 수령

의 조치에 대해서도 이의를 제기하지 않을 것임을 확약합니다.

2013년 1월 31일

확약인 甲

2013.7.3. 피신청인은 채권양도받은 신청인의 임차보증금 15,580,000원을 임대인으로부터 수령⁶³⁾한 후 본건 대출잔액 13,577,065원과 연체이자 2,002,969원을 상환 처리함(미상환 연체이자 580,845원 남음).

당시 피신청인은 관리인에 의한 경영정상화⁶⁴⁾를 추진 중이었으며, 연체이자 감면을 위해서는 관리인의 승인이 필요하나 피신청인 담당 직원은 임차보증금을 수령한 후 관리인 승인 절차를 거치지 않고 연체이자를 수납하라는 부지점장 지시에 따라 위 임차보증금에서 연체이자 부분까지 상환처리함.

신청인은 피신청인이 본건 확약서 내용과 달리 연체이자까지 회수한 것은 부당하다며 2013.9.24. 금융감독원에 분쟁조정을 신청함.

금융감독원은 2013.12.16. 피신청인에게 기수령한 연체이자를 반환하도록 합의권고하였으나, 피신청인이 이를 거부하였고, 2014.1월 피신청인에게 재검토를 요청하였으나 또다시 수용거부 의사를 밝힘.

나. 당사자 주장

(1) 신청인 주장

연체이자 감면을 조건으로 본건 확약서를 작성하고 신청인은 확약 내용대로 이행하였는데, 담보로 제공한 임차보증금이 반환되자 피신청인이 처음 약속과 달리 연체이자까지 회수한 것은 부당함.

62) 피신청인이 제공한 양식에 밑줄 친 부분을 신청인이 자필 기재하여 작성됨

63) 신청인의 사업장 임차기간은 2014.9월까지고 월세는 206만원인데, 본건 확약서 작성시 이미 4개월의 월세를 체납한 상태로 피신청인은 2013.7.3. 8개월여의 월세를 공제한 15,580,000원을 수령

64) 피신청인은 부채의 자산 초과로 2013.5.3. 금융위원회로부터 부실금융기관 지정(임원의 직무집행 정지) 및 경영개선명령을 부과받은 후 경영정상화에 실패하여 2013.11.1. 영업정지되었음(예금 및 정상 자산은 ○○○저축은행으로 계약 이전됨)

본건 확약이 연체이자 감면 조건이 아니었다면 개인회생 신청시 본건 대출을 제외할 이유가 없었음.

(2) 피신청인 주장

신청인과 협의 당시 본건 확약서에 따라 신청인이 대출원금 전액을 변제하고 내부 심의에서 연체이자 감면이 승인되면 연체이자를 감면 해줄 수 있다고 하였을 뿐 연체이자 감면을 약속한 적이 없음.

임대차보증금반환채권에 의하여 담보되는 채권은 별제권⁶⁵⁾(別除權)에 준하여 처리되므로 채권자목록에서 제외해달라고 한 것에 불과하며 연체이자 감면을 조건으로 확약서를 작성한 것은 아님.

다. 위원회의 판단

◆ 본 사건의 쟁점은 본건 확약서 작성 당시 당사자간에 본건 대출에 대한 연체이자를 감면하기로 하는 합의가 있었는지 여부임

(1) 관련 법령 및 판례

민법 제479조(비용, 이자, 원본에 대한 변제충당의 순서) ① 채무자가 1개 또는 수개의 채무의 비용 및 이자를 지급할 경우에 변제자가 그 전부를 소멸하게 하지 못한 금액을 한 때에는 비용, 이자, 원본의 순서로 변제에 충당하여야 한다.

저축은행 표준 여신거래기본약관 제13조(저축은행의 변제 등의 충당지정) ①채무자가 기한의 이익을 상실한 채무를 변제하거나, 저축은행이 제10조에 의한 상계 또는 대리 환급변제충당을 하는 경우에 채무자의 채무 전액을 소멸시키기에 부족한 때에는 비용, 이자, 원금의 순서로 충당하기로 한다. 그러나 저축은행은 채무자에게 불리하지 않는 범위 내에서 충당순서를 달리할 수 있다.

법률행위의 해석은 당사자가 그 표시행위에 부여한 객관적인 의미를 명백하게 확정하

65) 전세권, 질권, 저당권자 등 담보채권자는 담보가 설정된 채무자의 특정재산에 대해 다른 채권자보다 우선하여 변제를 받을 수 있는 권리를 가짐

는 것으로서, 사용된 문언에만 구애받는 것은 아니지만, 어디까지나 당사자의 내심의 의사가 어떤지에 관계없이 그 문언의 내용에 의하여 당사자가 그 표시행위에 부여한 객관적 의미를 합리적으로 해석하여야 하는 것이고, 당사자가 표시한 문언에 의하여 그 객관적인 의미가 명확하게 드러나지 않는 경우에는 그 문언의 형식과 내용, 그 법률행위가 이루어진 동기 및 경위, 당사자가 그 법률행위에 의하여 달성하려는 목적과 진정한 의사, 거래의 관행 등을 종합적으로 고려하여 사회정의와 형평의 이념에 맞도록 논리와 경험의 법칙, 그리고 사회일반의 상식과 거래의 통념에 따라 합리적으로 해석하여야 함(대법원 2001.03.23. 선고 2000다40858 판결).

(2) 연체이자 감면에 대한 합의가 있었는지 여부

채무의 면제 또는 면책은 반드시 명시적인 의사표시만에 의하여야 하는 것이 아니고 의사표시의 해석에 의하여 그것이 채무의 면제 또는 면책이라고 볼 수 있는 경우에도 인정할 수 있는 바(대법원 2013.5.9. 선고 2013다7516 판결), 아래와 같은 점을 감안시 본건 확약서 작성시 신청인과 피신청인 사이에 연체이자 감면에 대한 합의가 있었다고 할 것임.

피신청인 담당직원과 신청인은 대출금 분할상환을 내용으로 하는 본건 확약서 작성에 합의하였는 바, 이는 대출에 관한 새로운 약정을 내용으로 하는 것으로 처분문서에 준하는 것으로 볼 수 있고, 이러한 처분문서의 해석에 있어서는 그 문언의 형식과 내용뿐만 아니라 그 법률행위가 이루어진 동기 및 경위, 당사자가 그 법률행위에 의하여 달성하려는 목적과 진정한 의사, 거래의 관행 등을 종합적으로 고려하여 처분문서의 내용을 합리적으로 해석해야 하는 바, 본건 확약서의 문언을 보면, “대출금 총 3천만 원 중 ①대출잔액 20,127,065원에 대해 2013.2.1.부터 2013.2.28.까지 매주 15만원의 원금상환, 2013.3.1.부터 ②채무잔액 전체 상환시까지 매주 35만원을 원금상환한다”는 내용으로 ①의 ‘대출잔액’은 그 당시까지의 대출원금을 의미하며, ②의 ‘채무잔액’도 ①의 대출잔액 중 상환하고 남은 대출원금으로 보이는 등 본건 확약서 문언 자체만으로는 연체이자의 채무면제에 대한 명시적 합의가 있었다고 보기는 어려우나 본건 확약서의 작성동기 및 경위를 살펴보면, 신청인은 본건 대출에 대한 담보를 제공하고 대출만기시까지 연체없이 이자를 성실히 상환해 왔으나, 신용등급 하락으로 피신청인이 대출 연장을 거부하자

일시상황이 어려웠던 신청인이 피신청인에게 본건 대출금 분할상환과 만기 이후 이자 부분에 대한 감면을 요청한 점, 신청인은 본건 확약서 작성 당시 채무초과로 개인회생 절차를 준비하고 있었고 피신청인 담당직원에게 이를 고지하여 담당직원도 이러한 정황을 알고 있었던 점, 피신청인 담당직원이 신청인에게 피신청인을 개인회생 채권자 목록에서 제외시켜 달라고 요청하고 본건 대출에 대한 분할상환 조건을 제안한 점, 신청인이 대출잔액 분할상환을 내용으로 하는 본건 확약서를 작성하고 본건 대출과 관련하여 피신청인을 개인회생 채권자목록에서 제외⁶⁶⁾한 점, 피신청인 담당직원의 경위서 등에 의할 때, 피신청인도 신청인이 이미 채무초과 상태로 개인회생을 준비하고 있고, 부동산 매각 지연으로 임차보증금 상황도 늦어지는 등 본건 대출원리금 전액 회수가 불분명하였음을 알고 있었던 점, 신청인과의 면담시 연체금액 축소와 원금회수가 중요하다는 회사차원의 방침에 따라 지점장 지시로 신청인이 상환할 수 있는 금액 범위 내(매월 150만원 이상의 원금 회수)에서 분할상환하고, 대출금 원금이 전액 변제되면 이자감면 상신을 하여 이자를 면제하기로 합의하였다고 진술하고 있는 점 등을 볼 때 피신청인이 연체이자 감면에 동의하지 않았다면 채무초과 상태에 있던 신청인이 굳이 우선변제 의무도 없는 본건 대출과 관련하여 피신청인에게만 이익이 되는 본건 확약서를 작성할 특별한 유인이 없었던 점, 나아가 일반적인 대출취급 관행 및 대출원리금의 회수·충당경위 등을 비교해 보건대, 대출만기시 만기연장이 어려운 채무자에게 상환연기 또는 분할상환 약정을 체결하고 연체이자를 감면하는 방식의 여신관리가 저축은행 업계에 드물지 않은 관행이었던 점, 피신청인은 본건 대출 만기 직후 질권설정된 신청인의 상호부금 잔액을 본건 대출원금과 상계하고, 신청인이 본건 확약서에 따라 납부한 금액도 대출원금에서 계속 차감해 왔는 바, 민법과 피신청인 여신거래약관에 따라 피신청인은 신청인으로부터 수령한 금액을 연체이자에 먼저 충당할 수 있었음에도 오히려 자신에게 불리한 대출원금에 먼저 충당한 사실 등을 고려 할 때 연체이자 부분에 대한 감면 합의가 있었다고 볼 수 있는 점, 피신청인은 임대차보증금반환채권에 의하여 담보되는 채권은 파산절차에서 별제권에 준하여 처리되므로 채권자목록에서 제외해달라고

66) 신청인은 2013년 1월경 개인회생 개시결정을 받았으나, 2013.2월 조건이 더 유리한 신용회복제도(이자면제 및 원금 장기분할상환)로 전환하였고, 2013.3월 국민행복기금(원금일부 및 이자전액 감면)으로 변경하여 채무조정 중에 있음

한 것에 불과한 것이며, 연체이자 감면을 조건으로 채권자목록에서 제외해 줄 것을 요청한 것은 아니라고 주장하나, 별제권은 파산선고 당시에 파산재단에 속하는 재산에 관하여 담보권자가 그러한 권리의 목적인 재산에 관하여 파산절차에 따르지 않고 행사할 수 있는 권리로, 별제권자라도 그 별제권의 행사에 의하여 변제를 받을 수 없는 채권액에 대하여는 일반 채권자와 동일하게 개인회생 절차를 따를 수 밖에 없는 바, (채무자회생 및 파산에 관한 법률 제411조, 413조, 586조) 피신청인이 담보로 양도받은 임대차보증금 반환채권은 본건 확약서 작성 당시 4개월 동안 월세를 체납하고 있어 체납된 월세 등을 공제시 임차보증금을 통한 본건 대출 전액의 환수 자체가 상당히 불분명하였던 점, 신청인은 이미 채무초과 상태로 피신청인도 임차보증금을 통한 회수액을 초과하는 부분에 대하여는 개인회생 절차 등을 통해 변제받을 수 밖에 없었던 점, 법원이 채권자목록에 기재된 채무의 원금 및 연체이자 등에 대해서는 채무조정 할 가능성이 높았던 점 등을 감안할 때 피신청인으로서도 신청인과의 합의를 통해 물적 담보부분을 초과한 대출금에 대한 안정적인 상환계획을 확보할 필요가 있었다고 할 것이므로 피신청인의 채권자목록 제외 요청이 신청인에 대한 아무런 양보없이 법률상 인정되는 별제권자로서의 권리를 당연히 행사하는 것으로 보기 어렵다 할 것임.

(3) 피신청인이 당초 약속과 달리 연체이자를 회수한 것이 신의칙에 반하는 행위로 부당한지 여부

가사 피신청인 주장대로 본건 확약서 작성 당시 연체이자 감면에 대한 약정없이 대출원금을 상환한 후에 본부 승인을 거쳐 연체이자를 감면해 주기로 하였다 하더라도, 아래와 같은 점을 감안할 때 신청인에게 연체이자 감면에 대한 신뢰를 준 피신청인이 그 신뢰에 반하여 일방적으로 연체이자를 회수한 것은 신의칙에 반하는 부당한 권리행사라 할 것임.

상대방에게 신의를 공여하였다거나 객관적으로 보아 상대방이 신의를 가짐이 정당한 상태에 있음에도 이러한 상대방의 신의에 반하여 당사자 일방이 권리를 행사하는 것이 정의관념에 비추어 용인될 수 없는 경우 그 권리행사는 신의칙에 반하여 부정된다고 할 것인 바(대법원 2007.11.29. 선고 2005다64552 판결) 신청인은 연체이자 감면에 대한 피신청인의 약속을 신뢰하고 피신청인을 개인회생 채권자목록에서 제외함으로써 본건 대

출에 대한 채무조정 기회를 상실한 반면, 채무초과 상태임에도 확약서 내용대로 성실하게 본건 대출을 이행하여 피신청인에게 사실상 우선변제로 인한 경제적 이익을 주는 등 연체이자 감면에 대한 신청인의 신뢰는 보호 필요성이 크다고 할 수 있는 점, 피신청인은 대출원금만 상환하면 문제없이 연체이자 감면될 것 같은 태도를 보임으로써 이를 신뢰한 신청인의 일련의 대출금 상환 등으로 대출원금 전액을 회수하였음에도 연체이자 감면을 위한 내부 승인절차를 일체 거치지 않은 채 연체이자까지 회수하는 등 신청인에게 연체이자 감면에 대한 신뢰를 주었음에도 담보로 제공받은 임차보증금 상환을 기회로 당초 입장과 달리 일방적으로 연체이자까지 회수함으로써 자신의 선행행위를 신뢰한 신청인의 이익을 부당하게 침해한 점.

라. 결 론

그렇다면 피신청인의 신청인에 대한 연체이자 회수는 법률상 원인없는 것으로 신청인의 청구는 전부 이유있다 할 것임.

1-24 고객보호의무 위반 등에 따른 대출사기에 대한 손해배상책임

[일부인용] 명의모용에 의한 대출사기가 일어난 사안에 대하여 명의모용인이 신청인의 신분증을 이용하여 계좌개설을 할 때 동일인이 아님을 의심할 만한 사정이 있었음에도 불구하고 재차 본인임을 확인하는 절차를 거치지 아니한 채 신청인들 명의 계좌를 개설해 주었으므로 피신청인은 본인확인 의무를 다하지 못한 과실이 있다고 판단한 사례(2014.10.28. 조정번호 제2014-19호).

가. 사실관계

신청인 甲(23세, 대학생)과 乙(22세, 대학생)은 휴대전화 대리점 영업을 하고 있는 최○○이 실적제고를 위해 휴대전화 개통을 요청하면서 새로운 휴대전화 번호를 부여받기 위해서는 신분증 등이 필요하다고 하자 최○○에게 운전면허증(乙은 주민등록증)과 기존의 휴대전화 유심칩을 전달해 주었음.

최○○은 '14.5.27. 및 같은 해 6.2. A은행 모지점을 방문하여 상기 甲과 乙의 신분증을 이용하여 甲과 乙 명의의 예금계좌를 각각 개설하고 공인인증서를 발급받았음.

최○○은 계좌를 개설한 후 신청인들 명의로 B저축은행과 C저축은행 홈페이지에 접속하여 인터넷 대출을 신청하고, 신청인들의 주민등록초본과 졸업증명서⁶⁷⁾를 제출함과 동시에 신청인들의 공인인증서를 사용하여 대출거래 약정서를 작성 제출하고 전자서명을 하였음.

최○○은 신청인들로부터 전달받은 휴대전화 유심칩을 본인의 유심칩과 교환한 뒤 B저축은행과 C저축은행으로부터 신청인들의 휴대전화 번호로 본인확인 전화가 오자 자신이 마치 신청인인 것처럼 직접 통화하고 본인확인 절차에 응함으로써 대출(B저축은행 1,000만원, C저축은행 500만원)이 실행되었으며, 그 후 신청인들 명의의 A은행 계좌로 입금된 돈을 인출하여 잠적함.

나. 당사자 주장

(1) 신청인 주장

최○○이 휴대전화 개통을 위해서는 신분증, 유심칩 등이 필요하다고 하여 전달해 주었을 뿐이며, 본인 명의의 통장 및 공인인증서가 신규 개설되었던 사실과 대출이 진행되었다는 사실을 전혀 몰랐으므로 해당 대출피해에 대한 구제를 요청함.

(2) 피신청인 주장

(A은행) 계좌개설 관련 업무 처리과정에서 개인정보를 확인하고 신분증상의 사진과 외모를 비교하는 등 본인확인에 대한 주의의무를 성실히 이행하였음.

(B저축은행, C저축은행) 신청인의 주민등록초본, 졸업증명서, 통장사본 등이 제출되었고, 공인인증서 및 휴대전화 통화 등의 철저한 본인 확인 절차를 거쳐 정상적으로 대출계약이 성립되었으며, 공인인증서 등을 제3자에게 대여하였으므로 신청인의 중대한 과실이 있어 피신청인의 책임이 없음.

67) 최○○이 A은행에서 발급한 공인인증서를 이용해 인터넷으로 발급

다. 위원회의 판단

◆ 본 사건의 쟁점은 사기범 최○○이 신청인들로부터 전달받은 신분증 등을 이용하여 신청인들 명의 계좌를 개설한 후 인터넷대출을 받아 편취한 것과 관련하여, 신청인과 피신청인인 B저축은행 및 C저축은행간 대출계약이 유효하게 성립 되었는지와 피신청인인 A은행이 계좌개설시 주의의무를 위반하였는지, 주의의무 위반과 본건 손해발생 사이에 인과관계가 인정되는지 및 피신청인들의 「전자금융거래법」에 따른 배상책임 인정 여부임.

(1) 대출계약의 성립 여부

타인의 명의를 임의로 사용하여 계약을 체결한 경우에는 누가 계약의 당사자인가를 먼저 확정하여야 하며, 행위자와 상대방의 의사가 일치한 경우에는 일치하는 의사대로 행위자의 행위 또는 명의자의 행위로서 확정하여야 하지만, 그러한 일치하는 의사를 확정할 수 없을 경우에는 계약의 성질, 내용, 목적, 체결경위 및 계약체결을 전후한 구체적인 제반 사정을 토대로 상대방이 합리적인 사람이라면 행위자와 명의자 중 누구를 계약 당사자로 이해할 것인가에 의하여 당사자를 결정하고 이에 따라 계약의 성립 여부와 효력을 판단하여야 함(대법원 2012.10.11. 선고 2011다12842 판결 등).

최○○이 신청인들의 명의를 임의로 모용하여 신청인들 명의로 피신청인과 본건 대출 계약을 체결한 것이므로 피신청인인 B저축은행과 C저축은행으로서는 최○○이 신청인들인 줄 알고 계약을 체결한 것이며 비록 그 명의가 모용되었다 할 지라도 그 사실을 알지 못한 피신청인으로서 신청인들을 대출계약 당사자로 인식하여 대출계약을 체결한 것으로 봄이 타당함.

한편, 피신청인들이 신청인들을 정당한 대출계약 당사자로 인식하였다 할 지라도 최○○이 아무런 권한 없이 임의로 신청인 명의로 대출계약을 체결한 것이므로 신청인들 명의로 직접 법률행위를 한 것만으로는 특별한 사정이 없는 한 표현대리가 성립될 수 없어 신청인과 피신청인간 대출계약이 유효하게 체결된 것으로 보기 어렵다고 볼 것이나,

살피건대, 신청인들은 휴대전화 가입을 위하여 최○○에게 신분증 등을 교부함으로써 최○○에게 휴대전화 가입과 관련한 대리권을 수여한 것으로 볼 수 있으며, 「전자문서

및 전자거래 기본법」 제7조 제2항 제2호는 ‘수신된 전자문서가 작성자 또는 그 대리인과의 관계에 의하여 수신자가 그것이 작성자 또는 그 대리인의 의사에 기한 것이라고 믿을 만한 정당한 이유가 있는 자에 의하여 송신된 경우 그 전자문서의 수신자는 전자문서에 포함된 의사표시를 작성자의 것으로 보아 행위할 수 있다’고 규정하고 있는 바, 공인인증서는 전자문서에 서명하는 용도 이외에 본인확인 수단으로도 사용되며(「전자서명법」 제18조의2) 공인인증서 및 그 비밀번호 정보를 제3자가 알고 있음은 이례적이므로 신청인들은 최○○에게 신분증, 휴대전화 유심칩 등을 제공하여 중요한 개인정보를 알려주었고, 대출신청 과정에서 공인인증서로 전자서명 및 휴대전화 인증 등의 본인확인 절차를 거친 후 대출 심사 과정에서 본인확인을 위해 복수의 질문을 통한 심층확인 절차를 거치는 바, 그 질문 내용이 단순 주민번호 확인이 아니라 본인이 아니라면 쉽게 답변하기 어려운 내용들이 포함되어 있어 피신청인으로서의 주의의무를 다하여 실명인증 및 본인확인 절차를 거쳐 본건 대출계약을 승낙하였으므로 최○○을 신청인으로 믿는데 정당한 사유가 있었음을 인정⁶⁸⁾할 수 있으며 따라서 신청인들과 피신청인간 대출계약이 유효하게 성립되었다고 할 것임.

인터넷대출시 본인확인을 위한 질문내용(B저축은행)

- 성명, 주민번호
- 태어난 동물띠
- 운전면허증의 지역이름 면허번호 10자리 등을 인터넷으로 진위 여부
(주민등록증 발급일자로 인터넷으로 진위 확인)
- 현재 거주중인 주소 확인, 휴대전화 연체여부 및 사용기간
- 이메일 주소
- 자동차 보유여부, 직장 상세주소지

68) 피신청인의 대출심사시 녹취내용을 확인한 결과, 다른 대출채무 여부를 확인하면서 대출기관 및 금액에 대해서도 확인하고, 특히 B저축은행은 신용정보조회상에서 확인되는 다른 계좌가 있음에도 대출신청일에 개설한 A은행 계좌로 대출금을 신청한 이유에 대해서도 질문하고 최○○은 이에 자연스럽게 답변

인터넷대출시 본인확인을 위한 질문내용(C저축은행)

- 실명증표 사본 내용
- 성명, 주민번호
- 태어난 동물띠
- 운전면허증의 지역이름 면허번호 10자리 등을 인터넷으로 진위 여부
(주민등록증 발급일자로 인터넷으로 진위 확인)
- 현재 거주중인 주소 확인 및 자가여부
- 이메일 주소
- 타금융기관 이용여부
- 본인 휴대폰으로 발송된 인증번호
- 나이스 신용정보조회 고객 식별정보에서 주소지가 상이한 경우 그 이유

※ 한편 신청인들은 최○○을 고소하였고, 최○○은 경찰에 자수한 후 최근 기소되어 현재 형사재판 진행중이며, 피신청인 B저축은행 및 C저축은행은 재판이 진행되고 있어 채권추심을 중지한 상태임.

(2) 피신청인 A은행의 고객보호의무 위반에 따른 배상책임 여부

다음과 같은 점을 종합적으로 고려할 때, 피신청인은 본인임을 자처하는 자가 예금계좌를 개설함에 있어서 본인확인 절차 등을 소홀히 한 점이 인정되므로 본건 사고에 대한 배상책임이 일부있다 할 것임.

1) 금융기관의 본인여부 확인 의무

금융기관은 거래자의 실지명의로 금융거래를 하여야 하며, 개인의 경우에는 주민등록증 등 실지명의로의 확인이 가능한 증표를 통해 확인해야 하고(「금융실명거래 및 비밀보장에관한법률」 제3조 제1항), 금융기관에 개설된 예금계좌는 단순히 그 계좌를 개설한 자가 금원을 입출금하는 데 사용됨에 그치는 것이 아니라, 제3자에 대한 채권·채무 등을 추심하거나 변제하기 위한 수단 등으로도 활발히 이용되고 있으므로 금융기관이 본인 또는 대리인을 자처하는 자에게 예금계좌를 개설하여 주는 과정에서 본인의 신분증을 확인하거나 위임장과 인감증명서를 제출받고 대리인의 신분증을 확인하는 등의 최소한

의 확인절차마저 모두 생략한다면, 피모용자 명의로 임의로 개설된 계좌가 범죄행위 등에 용이하게 이용될 수 있음은 누구나 쉽게 예견할 수 있다 할 것이므로 범죄 등으로 부터의 피해를 방지하기 위하여 모용계좌의 개설을 막을 수 있는 적절한 지위에 있는 자인 금융기관은 주의의무를 다해야 할 것임(대법원 2006.1.13. 선고 2003다54999 판결 등).

따라서, 예금계좌의 개설에 임하는 금융기관으로서는 계좌개설시 최소한의 조치를 취함으로써 모용자가 권한없이 임의로 개설한 계좌가 범죄행위에 이용되거나 도움을 주지 않아야 할 주의의무가 있다 할 것이며, 금융기관이 거래상대방의 본인 여부를 확인할 필요가 있는 경우에 담당직원으로 하여금 그 상대방이 거래명의인의 주민등록증 등을 소지하고 있는지 여부를 확인하는 것만으로는 부족하고 그 직무수행상 필요로 하는 충분한 주의를 다하여 주민등록증 등의 진정 여부 등을 확인함과 아울러 그에 부착된 사진과 실물을 대조하여야 할 것인바, 최○○이 신청인의 신분증을 이용하여 계좌개설하면서 동일인이 아님을 의심할 만한 사정이 있었음에도 불구하고 재차 본인임을 확인하는 절차를 거치지 아니한 채 신청인들 명의 계좌를 개설해 주었으므로 피신청인은 본인확인 의무를 다하지 못한 과실이 있다 할 것임.

2) 주의의무위반과 손해발생간의 인과관계

계좌개설시 본인확인을 위한 주의의무를 위반한 결과 개설된 모용계좌가 범죄행위에 이용되어 피모용자가 수령하여야 할 금원이 모용계좌에 송금됨으로써 제3자나 피모용자가 손해를 입게 되었다면, 모용자의 주된 기망수단은 바로 금융기관에 의하여 잘못 개설된 모용계좌의 존재 그 자체이고 피기망자인 제3자로서는 그 모용계좌를 정당한 계좌로 오신하여 잘못 송금함에 따라 손해가 발생한 것이어서, 금융기관의 위와 같은 주의의무 위반과 제3자나 피모용자가 입게 된 손해 사이에는 상당인과관계가 있다고 보아야 할 것임(대법원 2007.7.13. 선고 2005다23599 판결 등).

피신청인은 계좌개설시 실명확인 증표상의 사진과 인상착의를 대조하였고 신분증의 진위 여부를 확인하여 본인확인을 위한 주의의무를 이행하였다고 주장하나, 금융기관 직원은 그 직무수행상 필요로 하는 충분한 주의를 다하여 주민등록증 등의 진정 여부를 확인함과 아울러 그에 부착된 사진과 실물을 대조하여야 할 것인바, 만일 실제로 거

래행위를 한 상대방이 주민등록상의 본인과 다른 사람이었음이 사후에 밝혀졌다고 한다면, 특별한 사정이 없는 한, 금융기관으로서는 위와 같은 본인확인 의무를 다하지 못한 과실이 있는 것으로 사실상 추정되며(대법원 1998. 11. 10. 선고 98다20059 판결), 피신청인이 계좌개설시 본인확인을 위한 주의의무를 위반한 결과, 신청인들의 계좌가 최○○의 사기대출에 이용되어 대출금액만큼의 피해를 입게 되었으므로 위와 같은 주의의무 위반과 신청인들이 입게 된 손해 사이에는 상당인과관계가 있다고 보아야 할 것임.

(3) 전자금융거래법상 배상책임 여부

「전자금융거래법」에서는 접근매체의 위·변조, 계약체결 또는 거래지시의 전자적 전송이나 처리과정에서 발생한 사고 등에 대하여 금융회사에 무과실 책임을 인정하고 있으며(제9조 제1항), 다만 접근매체 유출에 이용자의 중과실이 있는 경우 이용자에게 그 책임의 전부 또는 일부를 부담시키고 있음.

최○○이 신청인들의 신분증을 이용하여 접근매체인 공인인증서를 발급받은 진실에 반하는 접근매체의 발급으로 시스템 운영주체의 의사에 반하여 권한없는 자에 의해 공인인증서가 발급된 것이므로 「전자금융거래법」상 ‘접근매체 위조’에 해당됨(대법원 2014.1.29. 선고 2013다86489 판결 등)

따라서, 피신청인 A은행은 본인확인을 위한 주의의무를 위반하여 본인이 아닌 제3자(최○○)에게 공인인증서를 발급해 주었으며 최○○은 위 공인인증서를 이용하여 본건 대출을 받았는바, 「전자금융거래법」 제9조 제1항에 따른 대출금 상당액의 손해를 배상할 의무가 있다고 할 것임.

한편, 금융회사에 책임이 인정되는 경우라도 접근매체 유출에 이용자의 중과실이 있는 경우 이용자에게 그 책임의 전부 또는 일부를 부담시키고 있으나(「전자금융거래법」 제9조 제2항) 신청인들이 최○○에게 양도한 신분증, 휴대전화 유심칩은 「전자금융거래법」에서 양도를 금지하는 전자접근매체에 해당하지 아니하므로 본 건 대출사기 관련 금융사고 발생에 신청인들의 중대한 과실이 있다고 보기는 곤란하다 할 것임.

아울러, 피신청인 B저축은행과 C저축은행 역시 공인인증서 위조에 따른 「전자금융거래법」상 배상책임이 있다고도 볼 수 있으나 앞서 살펴본 바와 같이, 명의도용에 의한

불법대출을 방지하기 위해 복수의 심층적인 본인확인 절차를 거쳐 비대면거래인 전자금융거래에 있어서의 본인확인을 위한 주의의무를 다하였다고 볼 수 있으며, 공인전자서명은 본인의 서명, 서명날인 또는 기명날인으로 추정되며 본인 확인을 위한 주의의무를 다한 경우에는 사실상 접근매체가 양도된 것인지 위조된 것인지 사전적으로 알 수 없고 최근 보이스피싱 등에 의한 금융사고가 빈번하게 발생하여 금융회사에서 본인확인 절차를 강화하고 있을 뿐만 아니라 비대면 거래를 통한 전자금융거래의 안정성을 고려할 필요성이 있는바, 금번 조정결정에서 B저축은행 및 C저축은행에 대하여 「전자금융거래법」에 따른 배상책임을 묻는 것은 적절치 않다고 판단됨.

(4) 손해배상액 산정

1) 손해금액

신청인들의 손해액은 인터넷 대출이 각각 실행되어 신청인들의 은행계좌로 입금되어 출금된 15,000,000원(B저축은행 10,000,000원, C저축은행 5,000,000원)이라 할 것임.

2) 과실상계

신청인들은 지인인 최○○의 기망행위에 유인되어 신분증 및 휴대전화 유심칩을 제공하였으나 신청인들은 각각 대학교에 재학 중인 자들로서 기존에도 휴대전화를 개통한 경험이 있으며, 휴대전화 개통시 신분증 및 유심칩을 요구하여 이를 직접 전달함은 일반인의 상식에 비추어 이례적인 것으로 신청인들로서는 최○○이 휴대전화 개통이 아닌 다른 목적으로 신분증 등을 요청할 수 있다는 의심을 충분히 할 수 있다고 보여지는데, 피신청인 A은행의 책임비율을 40%로 제한하는 것이 상당하다 할 것임.

라. 결 론

그렇다면, 피신청인 A은행은 신청인들에게 발생한 손해금액 15,000,000원 중 피해액의 40%에 해당하는 금액을 배상할 책임이 있다 할 것이므로 신청인의 청구는 이유 있어 이를 인용하고, 피신청인 B저축은행, C저축은행에 대한 신청인의 각 신청은 이유없어 기각함.

1-25 은행 직원의 대출이자 손실보전약정 등에 따른 은행의 책임인정 여부

[기각] 신청인과 피신청인 직원 사이에 ‘대출 초과이자 지급 합의서’를 작성한 사안에 대하여 합의서 어디에도 피신청인 직원이 피신청인을 대리하여 합의한 것으로 인정할 만한 기재내용을 찾아볼 수 없어 이자차액을 보전해 주어야 하는 등의 책임이 피신청인에게 있다고 보기는 어렵고 피신청인 직원의 행위가 피신청인의 사무집행행위에 해당하지 않음을 신청인이 알았거나 또는 알지 못한 것에 대한 중대한 과실이 있다고 판단한 사례(2016.11.9. 조정번호 제 2016-29호).

가. 사실관계

2015.6월 초순경(일자 미상) 신청인은 피신청인 모지점 직원 乙(이하 ‘피신청인 직원’이라고 함)와 대출금액 4억원, 금리 3.1%, 5년거치 포함 30년 분할상환 조건으로 주택담보대출을 상담하였음.

이 때 피신청인 직원은 신청인이 성명과 주민등록번호를 작성하고, 자필서명한 대출약정서류⁶⁹⁾를 미리 징구하였음.

2015.6.12. 피신청인 직원은 당초 상담했던 조건으로 대출실행이 어렵게되자 당초 조건보다 불리한 거래조건(금리 3.53%, 1년 거치 포함 30년 분할 상환)⁷⁰⁾을 미리 징구하여 보관하고 있던 대출 약정서류에 자신이 직접 기재한 후 3.5억원의 주택담보대출을 실행.

2015.6.19. 신청인과 피신청인 직원은 1년후 당초 상담했던 조건(금리 3.1%, 5년거치)으로 대출을 대환하고, 대환에 따른 중도상환수수료 및 대환 이전에 발생하는 이자차액⁷¹⁾은 피신청인 직원이 부담한다는 내용의 ‘대출 초과이자 지급 합의서’를 신청인과 피신청인 직원 명의로 작성.

피신청인 직원은 상기 합의서 내용대로 2015. 7월부터 2016. 6월 기간 동안 매월 116,000원씩 이자차액 총 1,384,000원을 신청인이 지정한 계좌로 송금하였음.

69) 금리, 상환조건 등 주요 대출조건은 공란으로 되어 있음

70) 최초 상담했던 조건으로는 대출가능금액이 3억원으로 제한되어, 피신청인의 최대 대출가능금액인 3.5억원 대출이 가능한 상품으로 대출 실행

71) 실행된 대출금리(3.53%)와 당초 상담시 제시한 금리(3.1%) 차이에 따른 이자차액

신청인과 피신청인 직원이 작성한 합의서

대출 초과이자 지급 합의서

갑 : 장

을 : 박

이 합의서는 을의 진행하에 이루어진 2015년 6월 12일 갑과 을 사이의 대출계약과 관련하여, 당초 을이 갑에게 제시한 이자율 연 3.5%를 초과하여 연 3.5%로 대출계약이 이루어짐에 따라 갑이 부담하게 되는 초과이자분을 을이 전보하기 위한 것입니다.

제1조 갑이 을과 이루어진 대출계약의 내용은 다음과 같습니다.

1. 채권자 :
2. 채무자 : 장
3. 원금 : 금 3억 5천만원
4. 상환방법 : 5년 거치 30년 상환
5. 이자율 : 연 3.5%

제2조 을은 2015년 7월부터 매월 12일 위 제1조 5. 이자율 연 3.5%로 계산한 원 이자액에서 연 2.9%로 계산한 원 이자액을 차감한 금액(금 116,665원)을 갑의 계좌()로 송금합니다.

제3조 을의 위 2조의 의무는 을이 갑의 대출을 팔아타기 등의 방법으로 이자율을 연 2.9% 이하로 변경시키거나 위 제1조의 대출계약이 상환완료 등으로 소멸될 때까지 계속됩니다.

제4조 을이 위 제2조의 지급의무를 소홀히 할 경우 연 10%의 비율로 연체이자율 지급하고, 을의 지급의무 소홀로 위 대출계약과 관련하여 갑에게 손해가 발생할 경우 을이 이를 배상합니다.

1년 후 피신청인 장도 상환수수료를 부담하고, 대출 상환수수료를 부담합니다.

2015년 6월 19일

갑 : 장 (인)

을 : 박

1년 후 장도 상환수수료를 부담하고, 대출 상환수수료를 부담합니다.

6.19. 박

나. 당사자 주장

(1) 신청인 주장

피신청인은 2015.6.19. 신청인과 피신청인 직원이 합의한 ‘대출 초과이자 지급 합의서’ 내용대로 손실이자를 보전하고 대출을 대환해야 함.

(2) 피신청인 주장

신청인이 주장하는 ‘대출 초과이자 지급 합의서’는 피신청인 직원이 개인적으로 신청인과 합의한 것이므로 피신청인이 이행할 책임이 없음.

다. 위원회의 판단

◆ 본 사건의 쟁점은 ① 대출계약이 유효하게 성립되었는지, ② 신청인과 피신청인 직원이 체결한 별도 약정 등에 대해 피신청인의 책임이 인정되는지 여부라고 할 것임.

(1) 대출계약이 유효하게 성립하였는지 여부

계약이 성립하기 위하여는 당사자의 서로 대립하는 수개의 의사표시의 객관적 합치가 필요하고 객관적 합치가 있다고 하기 위하여는 당사자의 의사표시에 나타나 있는 사항에 관하여는 모두 일치하고 있어야 하는 한편, 계약 내용의 ‘중요한 점’ 및 계약의 객관적 요소는 아니더라도 특히 당사자가 그것에 중대한 의의를 두고 계약성립의 요건으로 할 의사를 표시한 때에는 이에 관하여 합치가 있어야 계약이 적법·유효하게 성립함(대법원 2003.4.11. 선고 2001다53059 판결 등).

대출금리, 상환방식 및 기간 등의 대출조건은 대출계약의 본질적이고 중요한 사항이라고 할 것인데, 2015. 6.12. 이루어진 대출거래 약정은 신청인과 피신청인 간에 위와 같은 대출조건에 대한 합의없이 피신청인 직원이 미리 징구하여 보관하고 있던 대출약정 서류에 대출금리 등의 조건을 기재하였으므로 대출계약의 중요 내용에 대한 합의가 없어 대출계약이 유효하게 성립되었다고 볼 수는 없다고 할 것임.

한편, 무효행위 또는 무권대리행위의 추인은 무효행위 등이 있음을 알고 그 행위의 효

과를 자기에게 귀속시키도록 하는 단독행위로서 묵시적인 방법으로도 할 수 있으므로, 본인이 그 행위로 처하게 된 법적 지위를 충분히 이해하고 그럼에도 진의에 기하여 그 행위의 결과가 자기에게 귀속된다는 것을 승인한 것으로 볼 만한 사정이 있는 경우에는 묵시적으로 추인한 것으로 볼 수 있음(대법원 2011.2.10. 선고 2010다83199 판결 등).

2015.6.19. 신청인이 작성하고 피신청인 직원이 자필 서명한 ‘대출 초과이자 지급 합의서’에는 ‘2015년 6월 12일에 신청인과 피신청인 사이의 대출계약과 관련하여 당초 피신청인 직원이 신청인에게 제시한 이자율 연 3.1%를 초과하여 연 3.5%⁷²⁾로 대출계약이 이루어짐(이하 생략)’으로 기재되어 있음을 고려할 때, 신청인은 당초 상담한 대출조건과 다르게 본건 대출이 실행되었음을 알고 있었다고 보이는 점, 신청인은 당초 상담한 대출조건과 다르게 실행된 본건 대출에 대하여 대출이자 차액 보전 등을 위한 별도의 약정을 피신청인 직원과 체결하였으나 피신청인에게는 2015.6.12. 실행된 대출약정의 이자율 지급한 점 등을 고려할 때, 비록 본건 대출약정 당시 신청인이 대출조건 등에 대하여 합의한 사실은 없었다 하더라도 신청인이 본건 대출조건을 묵시적으로 추인한 것으로 볼 수 있다 할 것임(「민법」 제139조 유추적용).

(2) 별도의 이자보전 약정 등에 대한 피신청인의 책임 인정 여부

계약당사자 사이에 어떠한 계약 내용을 처분문서인 서면으로 작성한 경우에는 그 서면에 사용된 문구에 구애받는 것은 아니지만 그 서면의 기재 내용에 의하여 당사자가 그 표시행위에 부여한 객관적 의미를 합리적으로 해석하여야 하며, 이 경우 문언의 객관적인 의미가 명확하다면, 특별한 사정이 없는 한 문언대로의 의사표시의 존재와 내용을 인정하여야 함(대법원 2002.5.24. 선고 2000다72572판결 등).

본건 ‘대출 초과이자 지급 합의서’에 기재된 당사자는 신청인과 피신청인 직원이고, 합의서 어디에도 피신청인 직원이 피신청인을 대리하여 합의한 것으로 인정할 만한 기재 내용을 찾아볼 수 없는 점을 고려할 때, 본건 합의서의 내용대로 이자차액을 보전해주거나 당초 상담한 조건으로 본건 대출을 대환해 주어야 하는 등의 책임이 피신청인에게 있다고 보기는 어렵다 할 것임.

72) 3.53%를 잘못 기재한 것임

(3) 피용자의 불법행위에 따른 사용자책임 인정 여부

타인을 사용하여 어느 사무에 종사하게 한 자는 피용자가 그 사무집행에 관하여 제3자에게 가한 손해를 배상할 책임이 있음(「민법」 제756조 제1항 본문).

사용자책임의 요건인 ‘사무집행에 관하여’는 피용자의 불법행위가 외형상 객관적으로 사용자의 사업활동 내지 사무집행행위 또는 그와 관련된 것이라고 보일 때에는 행위자의 주관적 사정을 고려없이 이를 사무집행에 관하여 한 행위로 본다는 것이고, 외형상 객관적으로 사용자의 사무집행에 관련된 것인지 여부는 피용자의 본래 직무와 불법행위와의 관련 정도 및 사용자에게 손해발생에 대한 위험창출과 방지조치 결여의 책임이 어느 정도 있는지를 고려하여 판단하여야 하고, 피용자의 불법행위가 외관상 사무집행의 범위 내에 속하는 것으로 보이는 경우에도 피용자의 행위가 사용자나 사용자에게 갈음하여 그 사무를 감독하는 자의 사무집행행위에 해당하지 않음을 피해자 자신이 알았거나 중대한 과실로 인하여 알지 못한 경우에는 사용자책임을 물을 수 없음(대법원 2010.12.9. 선고 2009다 101824 판결 등).

본건에서 피신청인 직원이 대출 초과이자 지급 및 대환시 중도상환수수료를 부담할 것을 신청인에게 약속한 것은 2015.6.12. 대출약정과 관련된 것이므로 민법 제756조에서 규정하는 피용자의 ‘사무집행에 관한 행위’라고 봄이 상당하나 은행이 대출약정과 다르게 별도 약정으로 이자의 일부를 보전하는 행위는 정상적인 금융거래 행위가 아니고, 피신청인 직원 명의로 ‘대출 초과이자 지급 합의서’가 작성된 점 등을 고려할 때, 본건 이자 차액을 보전하고 중도상환수수료를 부담하면서 대환해 줄 것을 별도로 약속한 피신청인 직원의 행위가 피신청인의 사무집행행위에 해당하지 않음을 신청인이 알았거나 또는 알지 못한 것에 대한 중대한 과실이 있다고 할 것임.

라. 결 론

그렇다면, 신청인의 청구에 이유가 없다고 할 것이므로 신청인의 청구를 기각함.

제2장

담보 책임

제1절 포괄근저당의 피담보채무 범위

2-1

잔존채무가 존재하는 경우 근저당권 설정등기 말소청구의 타당성

[기각] 본건은 포괄근저당권의 피담보채무의 범위를 제한할 만한 사정이 존재하지 아니하고, 채무자의 대출원금이 전액 변제되었다거나 대출채무가 시효로 소멸하였음을 인정할 만한 증거가 없으므로 신청인의 포괄근저당권설정등기 말소청구를 기각함.(2001.3.27. 조정번호 제 2001-16호)

가. 사실관계

채무자 A씨는 1981.10.16.~2000.9.5. 기간중 본건 부동산(대지, 건물, 담 등 5건)에 포괄 근저당권(채권최고액 합계 : 30,800천원)을 설정하거나 기타의 방법으로 피신청인으로부터 대출을 받음(현재 채무잔액 79,645천원). 신청인은 2000.12.16. 포괄근저당권이 설정된 본건 부동산 5건을 A씨로부터 양수 받음.

나. 당사자의 주장

(1) 신청인의 주장

부동산을 담보로 채무자 A씨가 대출한 금원이 전액 변제되었을 뿐만 아니라 포괄근저당권이 설정된 5건 중 4건은 이미 채권소멸시효기간 10년이 경과된 것으로서 피신청인의 근저당권설정등기는 말소되어야 함.

(2) 피신청인의 주장

포괄근저당권이 설정되어 있는 본건 부동산을 양수하였고 차주 A씨의 채무가 채권최고액의 범위내에서 변제되지 않은 상태이므로 신청인의 포괄근저당권설정등기 말소청구를 응할 수 없음.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 포괄근저당권의 피담보채무의 범위를 제한 해석할 수 있는지 여부라 할 것임.

근저당권설정계약서가 금융기관 등에서 일률적으로 일반거래약관의 형태로 부동산으로 인쇄해 두고 사용하고 있는 경우에 동 계약서는 소위 처분문서로서 그 진정성립이 인정되면 원칙적으로 설정계약서에서 정하여진 피담보채무의 범위에 관한 계약 문언대로 의사표시의 존재와 내용을 인정함이 원칙임. 다만, 당해 대출금채무와 장래 채무의 각 성립경위 등 근저당권설정계약 체결의 경위와 목적, 피담보채무액, 근저당권 설정자와 채무자 및 채권자와의 상호관계, 담보제공자가 본인인지 제3자인지의 여부 등 제반사정에 비추어 당사자의 의사가 계약서 문언과 달리 일정한 범위내의 채무만을 피담보채무로 약정한 취지라고 해석하는 것이 합리적이라고 인정되는 경우에 당사자의 의사에 따라 그 담보책임의 범위를 제한할 수 있다고 할 것임.

포괄근저당권⁷³⁾의 경우 차주인 A씨 본인의 담보제공에 의하여 포괄근저당권설정계약이 체결되었고, 20년간 14차례에 걸쳐 여러 종류의 대출이 이루어진 사실에 비추어 채권자 및 채무자가 본건 근저당권을 계속적 거래시 원용하는 등 포괄근저당권으로 활용할 의사가 있었다고 추정되며, 달리 본건 피담보채무의 범위를 합리적으로 제한할 만한 개별적·구체적 사정은 존재하지 아니하는 것으로 판단됨.

일반적으로 근저당권의 설정 후 부동산의 소유권이 제3자에게 이전된 경우 현재의 소유자는 자신의 소유권에 기하여 피담보채무의 소멸을 원인으로 근저당권설정등기의 말소를 청구할 수 있음. 그렇다면, 포괄근저당권이 설정된 본건 부동산을 위 A씨로부터

73) 포괄근저당권은 채무자가 채권자에 대하여 현재 및 장래에 부담하는 일체의 채무를 채권최고액을 한도로 담보하는 것을 내용으로 하며, 채권이 증감·변동하다가 채무가 일시적으로 0이 된다 하더라도 근저당권은 이로 인하여 소멸되지 아니한 특질을 지님.

양수한 신청인의 피담보채무의 소멸 등의 주장이 정당한 근거가 있는지가 문제됨.

신청인은 본건 부동산을 담보로 채무자 A씨가 대출한 금액이 전액 변제되었을 뿐만 아니라 포괄근저당권이 설정된 5건 중 4건은 이미 채권소멸시효기간 10년이 경과된 것으로서 근저당권설정등기가 말소되어야 한다고 주장하나, 채무자 A씨는 본건 부동산에 포괄근저당권 설정계약을 체결하여 약 20년간 14차례에 걸쳐 피신청인으로부터 대출을 받은 바 있고 현재 대출금 잔액이 79,645,860원인 사실이 확인되는 바, 위 대출금 전액 변제의 주장은 그 근거가 없으며, 담보물권인 근저당권은 그 피담보채권에의 부종성으로 인하여 피담보채권이 소멸하면 그에 따라 소멸하고 반대로 피담보채권이 존속하는 한 독립하여 소멸시효에 걸리지 아니함.

그런데 피신청인은 본건 대출원금에 대하여 계속적으로 권리행사를 하여 원금 및 이자를 변제받은 사실 및 채권최고액의 범위내에서 아직 잔존채무가 존재하는 사실이 확인되고, 채무자 A씨도 이에 응하였던 점에 비추어 신청인의 원인채권의 소멸시효 주장도 법적 근거가 없음.

라. 결 론

포괄근저당권의 피담보채무의 범위를 제한할 만한 사정이 존재하지 아니하고, 채무자 A씨의 대출원금이 전액 변제되었다거나 대출채무가 시효로 소멸하였음을 인정할 만한 증거가 없으므로 신청인의 포괄근저당권설정등기 말소청구를 기각함.

2-2 은행내규에서 금지하고 있는 포괄근저당권 설정의 피담보채무 범위

[기각] 비록 은행내규에 포괄근저당을 운용할 수 없도록 규정하고 있으나 이를 이유로 동 계약의 사법적 효력을 제한할 수는 없어 포괄근담보의 피담보채무를 제한 해석할 수 있는 특별한 묵시적, 명시적인 개별약정의 요소가 존재한다고 인정하기 어려우므로, 신청인이 제3자에게 제공한 포괄근담보의 피담보채무에 해당하는 대출금을 은행에서 대위변제 한 것이 부당하다고 볼 수 없으므로 신청인의 청구를 기각함.(2002.3.12. 조정번호 제2002- 5호)

가. 사실관계

신청인은 A기업(대표자: 김○○)이 1999.4.10. 피신청인 지점에서 20억원(기업운전자금대출, 보증인: 김○○)을 대출받는데 B종합상가를 담보제공(피담보채무의 범위: 한정근담보, 채권최고액: 26억원)하였음. 신청인은 1999.4.22. C기업(대표: 이○○, 1999.9.20. D기업으로 상호 변경)이 피신청인 지점에서 3.3억원(대출과목: 기업일반자금대출, 연대보증인: 이○○)을 대출(이하 “C기업 일반대출”이라 함)받는데 B종합상가를 담보제공(피담보채무의 범위: 포괄근담보, 채권최고액: 6억원)하였음.⁷⁴⁾

C기업은 동 대출금을 동사의 기존대출 상환(79.2백만원), 제3자 앞 송금(8백만원), 자기앞수표 발행(226.5백만원) 등의 재원으로 사용하였음.

피신청인은 1999.10.20. C기업의 무역금융 재약정(5.4억원)시 신용보증서(3억원, 기술신용보증기금 발행)를 정식담보로 B종합상가를 견질담보로 운용하였음. 신청인은 2001.10.19. B종합상가에 대해 근저당권을 말소하면서 A기업의 기업운전자금대출(20억원)을 전액 상환하고 C기업 일반대출과 관련하여 3.3억원을, C기업의 무역금융 등과 관련하여 2.7억원을 대위변제(총 6억만원)하였음.

나. 당사자 주장

(1) 신청인 주장

신청인은 A기업의 설립연도가 일천하고 매출액이 적어 A기업의 명의로는 추가로 대출을 받을 수 없게 되자 C기업의 명의를 빌려 3.3억원을 대출받았는데 당시 취급점장 박○○이 5억원을 대출해 준다고 하여 B종합상가에 6억원을 담보설정 하였는 바, 피신청인이 B종합상가에 설정된 근저당권을 말소해 주면서 B종합상가의 피담보채무범위에 속하지 않는 C기업의 무역금융 등 2.7억원을 대위변제 받은 것은 부당하므로 동 금액을 반환해야 함.

74) 피신청인은 해당 은행의 내규에 따라 제3자 담보제공시에 포괄근담보로 운용할 수 없음에도 B종합상가를 포괄근담보로 운용한 것임.

(2) 피신청인 주장

C기업 일반대출은 C기업의 기존대출 상환재원(79.2백만원) 등으로 사용된 것으로 보아 신청인이 C기업의 명의로 차명대출을 받았다는 주장은 사실이 아님. 신청인은 B종합상가를 C기업의 대출 모두에 대해 채권최고액(6억원) 범위까지 담보효력이 있는 포괄근담보로 담보제공 하였기 때문에 B종합상가의 근저당권을 말소하면서 C기업 일반대출을 포함하여 C기업의 잔여대출 중 6억원을 자발적으로 대위변제 한 것임.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 B종합상가에 설정된 C기업을 주채무자로 하는 근저당권(이하 “C사 근저당권”이라 함)의 피담보채무범위가 C기업 일반대출(1999.4.22. 취급된 C기업 기업일반자금대출 3.3억원)에 한정된 것으로 볼 수 있는지 여부라 할 것임.

근저당권의 피담보채무 범위에 관하여 대법원 및 금융분쟁조정위원회는 근저당권설정계약서가 정당하게 작성되었으면 원칙적으로 그 기재된 내용에 따라 피담보채무의 범위를 인정하고 있는 바, 피담보채무의 범위가 제한해석 되기 위해서는 그 기재내용과 다른 특별한 묵시적, 명시적인 개별약정의 요소가 존재해야 함.⁷⁵⁾

신청인의 주장대로 C기업의 명의를 빌려 대출을 받았다고 하면 동 대출금의 대부분을 A기업이 사용하여야 하는 것이 마땅함에도 신청인은 동 대출금을 사용한 사실을 입증하지 못하고 있을 뿐만 아니라, 당시 취급점장 박○○ 및 여신담당과장 최○○는 차명대출이라는 사실을 부인하고 있으므로 C기업 일반대출의 실제차주가 A기업이라는 신청인의 주장은 인정하기 곤란함.

취급점장 박○○은 “B종합상가는 신청인이 경락 받은 부동산인 관계로 경락대금(14.3억원) 범위 내에서 대출이 가능하여 C기업 일반대출 취급시 3.3억원만을 대출(1999.4.22.)해 주었으며, 경락일(1998.9.21.)로부터 1년(1999.9.21.)이 경과하면 추가로 대출해 줄 수 있는 여지가 있어 피담보채무의 범위를 포괄근담보로, 채권최고액을 통상적인 설정비율

75) 대법원 1997.9.26. 선고 97다22768 판결, 금융분쟁조정위원회 조정번호 제1999-33호 참조.

(130%)보다 높은 600백만원(181.8%)을 설정했다.”고 진술하였음.

그러나 취급점장 박○○의 진술대로라면 경락일로부터 1년이 경과되지 않아 경락대금인 1.4억원 범위 내에서 대출되어야 함에도 A기업의 대출금 20억원과 C기업의 대출금 3.3억원을 합할 경우 B종합상가의 경락대금을 훨씬 상회하는 것으로 나타남. 또한 최○○는 “1999.10.20. C기업의 무역금융한도(5.4억원) 재약정시 C기업 측에 추가담보의 제공 또는 한도축소를 요구했는데 동사의 자금담당업무를 수행했던 자가 B종합상가를 외환여신에 담보로 사용하기 위해 여유 있게 설정해 두었으니 담보로 활용해 달라고 요청했다.”며 박○○과 상반된 진술을 하고 있으므로 박○○의 진술은 인정하기 어려움. 또한 신청인은 박○○이 500백만원까지 대출해 준다고 하여 채권최고액을 높게 설정했다고 주장하면서도 박○○이 은행을 퇴직(1999.7.8.)한 후 2001.1월까지 피신청인에게 채권최고액의 하향조정 또는 추가대출을 요청한 사실이 없는 것으로 보임.

한편 피신청인은 금감원의 『은행업감독업무시행세칙』 제64조에서 정한 지침에 따라 내부규정(『여신담보취득 및 관리지침』 제8조)상 제3자 담보취득시 포괄근담보로 운용할 수 없음에도 B종합상가를 포괄근담보로 제공받았으나, 내부규정을 위반하였음을 이유로 신청인과 피신청인 사이에 체결된 근저당권설정계약의 사법적 효력을 제한한다고 볼 수 없음.

따라서 C기업 근저당권의 피담보채무범위를 제한해석 할 수 있는 특별한 목시적, 명시적인 개별약정의 요소가 존재한다고 인정하기 어려우므로 C기업 근저당권은 채권최고액 6억원 범위 내에서 C기업의 무역금융을 포함한 동사의 여타대출에 대해 담보효력이 있는 것으로 판단됨.

라. 결론

C기업 근저당권은 채권최고액 6억원 범위 내에서 C기업의 무역금융을 포함한 동사의 여타대출에 대해 담보효력이 있으므로 신청인이 B종합상가를 담보해지하면서 C기업 일반대출과 관련하여 3.3억원을, C기업의 무역금융 등과 관련하여 2.7억원(총 6억원)을 대위변제한 것은 부당하다고 볼 수 없으므로 신청인의 청구를 기각함.

2-3 담보말소 협의사실을 근저당권의 결산기 지정으로 볼 수 있는지 여부

[기각] 신청인이 사업체 양도 후 대표이사직을 퇴임하였음을 거래은행에 통지하고 은행에 담보로 제공한 부동산의 근저당권 말소를 요청하였으나, 사업체를 양도받은 제3자가 관련 대출을 상환하거나 그에 상응하는 대체담보를 제공하지 않은 상태에서, 신청인의 담보부동산에 대한 담보말소 요청을 근저당권 결산기의 지정에 따른 피담보채무의 확정절차로 해석하기는 곤란함. 따라서 본건 담보부동산이 포괄근저당권으로 담보제공 된 점과 신청인이 결산기의 지정을 통해 피담보채무의 확정을 청구한 사실이 있다고 보기 어려운 점을 고려할 때 신청인이 사업체를 양도하고 대표이사직을 퇴임하였다고 하더라도 기존 담보부동산의 근저당권에 대한 법적 효력에는 영향을 미치지 아니함이 타당함.(2002.4.9. 조정번호 제2002-10호)

가. 사실관계

A기업의 대주주 및 대표이사이었던 신청인은 동사의 무역금융 등 대출과 관련하여 자신 소유 아파트(이하 “아파트”라 함)를 1987.4월~2000.7월 기간중 3차례에 걸쳐 담보로 제공(총 채권최고액:10억원, 피담보채무범위: 포괄근담보, 결산기: 장래지정형)하였고, 2000.9.2. 개인자격으로 연대보증(피보증채무범위: 포괄근보증, 보증한도: 10억원)을 입보하였음.

A기업은 2000.3.18. 피신청인과 무역금융(한도: 6.5억원, 2000.7.18. 9.5억원으로 한도증액) 및 수입신용장 발행(한도: 미화 10만달러)에 대한 한도거래약정을 체결하고 한도범위 내에서 대출거래 및 수입신용장 발행을 지속하였음. 신청인은 2000.9.30. A기업의 경영권을 B씨에게 양도하는 ‘법인 및 부동산 매매계약’을 체결하고, 2000.10.2. 대표이사직을 퇴임하였음.

피신청인은 2000.11.16. 신청인으로부터 연대보증 해지를 요구하는 내용증명서를 접수하고 2000.12.4. 연대보증을 신청인에서 A기업의 신임 대표이사인 C씨로 교체하였음. 신청인은 2000.10월부터 피신청인 지점에 아파트의 담보말소를 계속 요청(구두 및 서면)했다고 주장하고 있는 반면, 피신청인은 신청인이 아파트의 담보말소에 대해 수 차례 협의를 하여 와 기 취급여신의 상황 또는 대체담보의 제공 없이는 담보말소가 불가능하다고

설명하였으며, 2000.10.4. 이전에 서면으로 담보말소 요청을 받은 적이 없다고 주장함.

피신청인은 2001.3.29. A기업 신임 대표이사 C씨와 동사의 무역금융(대출한도: 9억원) 및 수입신용장 발행(대출한도: 미화 10만불, 2001.9.3. 미화 127,725불로 한도증액)에 대한 한도거래약정을 다시 체결하고 아파트를 담보로 계속 운영하였으며, 2001.10.4. A기업의 무역금융(대출한도: 9억원) 및 수입신용장 발행(대출한도: 미화 127,725달러)에 대한 한도거래약정을 재차 연장하였고 아파트도 담보로 계속 운영하였음.

신청인은 2001.10.25. “아파트의 담보제공을 2001.10.31.부로 철회한다”는 내용증명서를 피신청인에게 발송하였고, 2001.11.2. 담보제공 철회를 취소하는 내용증명서를 피신청인에게 재발송하였음.

A기업은 2001.12.12. 부도가 발생하였으며, 동사의 미상환 채무액은 2002.3.14. 현재 982,939,227원(원금 957,158,832원, 연체이자 25,780,395원)임.

나. 당사자 주장

(1) 신청인 주장

신청인은 A기업의 경영권을 C씨에게 양도한 후 대표이사직을 퇴임하였음을 피신청인에게 통지하고 2000.10월부터 아파트의 담보말소를 계속 요청하였음. 담보말소 요청 전에 취급된 A기업의 무역금융 등 대출은 모두 정상적으로 상환되었기 때문에 동사의 신임 대표이사 C씨가 2001.3.29. 및 2001.10.4. 한도거래약정을 다시 체결하고 재대출 받은 무역금융 등에 대해서는 아파트가 담보책임이 없음에도 피신청인이 신청인의 동의 없이 아파트를 담보로 계속 운영한 것은 부당함.

(2) 피신청인 주장

신청인은 이미 취급된 A기업의 무역금융 등 관련대출을 상환하거나 동 아파트에 상응하는 대체담보를 제공해야 아파트의 담보말소가 가능하다는 피신청인의 설명을 듣고 이를 이행하기 곤란하여 담보말소를 계속 요청하지 못하였음. 신청인은 A기업을 양도하고 대표이사직을 사임한 이후에도 동사의 신임 대표이사인 C씨가 아파트를 계속 담보

로 제공하고 있다는 사실을 인지하고 있었으므로 아파트를 현재 진행중인 경매절차에 따라 처분하여 동사의 잔여채무를 모두 회수할 예정임.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 신청인과 피신청인이 2000.10월 이후 아파트의 담보말소에 대해 협의한 사실이 있는데 이를 동 아파트에 대한 근저당권의 결산기 지정을 통한 근저당권의 피담보채무 확정 절차로 볼 수 있는지 여부라 할 것임.

신청인은 아파트의 근저당권 결산기를 장래지정형으로 선택하였기 때문에 근저당권 설정계약일로부터 3년이 경과하면 서면통지에 의하여 근저당권의 결산기를 지정할 수 있으며, 1989.10.4. 및 1987.4.27.에 체결된 근저당권설정계약의 경우 서면통지 도달일로부터 45일이 경과한 날에, 2000.7.18. 체결된 근저당권설정계약의 경우 통지 도달일로부터 14일 이후 또는 14일되는 날에, 근저당권의 결산이 이루어지면 근저당권의 피담보채무가 확정됨.

신청인과 C씨 사이에 체결된 “법인 및 부동산매매계약서” 제3조에 의하면 “甲은 A기업의 부채 27억원을 인수하여 이자불입 등 채무자로서의 의무를 이행하고 조속히 완전상환하거나 C씨의 명의로 이관하며, A기업 이외의 자(신청인 등)가 제공한 담보(아파트 등)를 2001.6.30. 이내에 해지하기로 한다.”고 규정되어 있는 바, 아파트는 A기업의 무역금융 등 관련대출에 대한 유일한 물적담보이므로 동사의 경영권을 양도받은 신임 대표이사 C씨가 관련대출을 상환하거나 그에 상응하는 대체담보를 제공하지 않는 한 담보말소가 이루어질 수 없었던 것으로 보여지므로, 관련대출의 상환 또는 대체담보의 제공이 없는 상태에서 신청인의 아파트에 대한 담보말소 요청을 근저당권 결산기의 지정에 따른 피담보채무의 확정 절차로 해석하기는 곤란하다고 보여짐.

따라서 아파트는 A기업이 현재 및 장래에 부담하는 모든 대출에 대해 포괄적으로 담보효력이 있는 근저당권으로 담보제공 된 점과 신청인이 결산기의 지정을 통해 피담보채무의 확정을 청구한 사실이 있었다고 보기 어려운 점을 고려할 때 신청인이 동사의 경영권을 C씨에게 양도하고 대표이사직을 퇴임하였다고 하더라도 기 체결된 아파트의 근

저당권에 대한 법적 효력에는 영향을 미치지 아니하므로 피신청인은 신청인의 동의가 없어도 동사의 신임 대표이사 C씨와 무역금융 등에 대한 한도거래약정 체결시 아파트를 담보로 계속 운영할 수 있다고 판단됨.

라. 결 론

A기업은 2002.3.14. 현재 아파트의 피담보채무범위에 포함되는 무역금융 등 관련대출 982,939,227원(원금 957,158,832원, 연체이자 25,780,395원)을 상환하지 않고 있어 아파트에 대한 근저당권 설정등기를 말소하기는 곤란하므로 신청인의 청구는 기각함.

2-4 포괄근저당 피담보채무에 타기관 보증부대출이 포함되는지 여부

[인용] 비록 근저당권설정계약서에는 피담보채무의 범위가 ‘포괄근담보’로 기재되어 있으나, 신용보증기금이 보증한 대출금을 포함하는 경우 채권최고액을 상당히 초과하게 되는 점, 신용보증서가 제출되어 있는 경우 금융기관이 추가적인 담보를 요구할 필요가 사실상 없으며 신용보증기금의 보증범위에서 제외되는 부분만을 보충하는 것이 일반금융관행에 가까운 점, 피신청인 직원이 신청인에게 보증이 없는 대출금만 상환하면 본건 근저당권을 말소해 주기로 하였다고 진술하고 있는 점 등을 종합적으로 고려해 볼 때, 본건 근저당권의 피담보채무는 이에 따라 제한해석 하는 것이 타당함.(2011.4.12. 조정번호 제2011-21호)

가. 사실관계

2007.1.16. 신청인은 피신청인으로부터 기업운전자금 47백만원을 대출받고, 다음 날 신청인 소유 부동산에 관하여 피담보채무의 범위를 ‘포괄근담보’, 채권최고액을 ‘65백만원’으로 하는 근저당권설정계약을 체결하여, 피신청인 앞으로 근저당권 설정등기를 마침.

2008.6.26. 신청인은 위 47백만원 대출금 상환한 후, 2009.4.27.에 기업운전자금 50백만원을 대출(2007.1.17.자 기존 근저당을 이용)받았으며, 동년 6.26에 신용보증기금의 신용보증서를 담보(보증비율 100%)로 하여 기업운전자금 100백만원을 대출 받음.

2010.12.3. 신청인은 본건 부동산을 제3자에게 매각하였는데, 본건 부동산 매각 당시, 신청인이 피신청인 직원에게 2009.4.27.자 50백만원 대출금을 상환할 경우 근저당권 말소가 가능한지를 문의하여 근저당권 말소가 가능하다는 답변을 들음.

2011.1.11. 매수인은 본건 부동산에 관해 ○○신용협동조합에 저당권(채권최고액 65백만원)을 설정하여 주고 대출을 받아 신청인의 2009.4.27.자 대출금 50백만원을 상환하였으며, 당일 근저당권 말소를 위해 법무사가 피신청인을 방문하기로 하였는데 법무사가 방문하지 않아 근저당권 말소절차가 이루어지지 않음.

2011.1.12. 신용보증기금, 신청인의 사업장 폐업(2010.12.31.)을 이유로 부실발생사실 및 기금의 동의 없이 본건 근저당권 해지가 불가함을 피신청인에게 통지함.

나. 당사자 주장

(1) 신청인 주장

피신청인 직원이 대출금 상환시 본건 근저당권을 말소해 준다고 하였음에도 신용보증기금이 근저당권 말소에 동의하지 않는다는 사유로 근저당권 말소를 거부하는 것은 부당함.

(2) 피신청인 주장

신용보증기금이 본건 근저당권의 피담보채무 범위를 계약서 문언대로 포괄근담보로 해석하고 신용보증 부실사유 발생(신청인 폐업)을 이유로 본건 근저당권 말소를 동의해 주지 않은 상황으로, 기금의 동의 없이 본건 근저당권을 말소하기 어려움.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 본건 근저당권의 피담보채무 범위가 신청인의 2009.4.27.자 대출금 50백만원에 한정되는지 여부라 할 것임

(1) 근저당권의 피담보채무 범위에 관한 일반적인 해석

근저당권의 피담보채무 범위에 관하여 대법원 및 금융분쟁조정위원회는 근저당권설정 계약서가 정당하게 작성되었으면 원칙적으로 처분문서의 기재된 내용에 따라 피담보채무의 범위를 인정하고 있으나, 그 기재내용과 다른 특별한 목시적, 명시적인 개별약정의 요소가 있는 경우에는 그 개별약정의 요소에 따라 피담보채무의 범위를 제한해석하고 있음.⁷⁶⁾ 따라서 근저당권 설정계약서는 그 계약문언대로 효력을 발생하는 것이 원칙이지만 당해 대출금채무와 다른 채무의 각 성립경위 등 근저당권설정계약 체결의 경위, 대출관행, 각 채무액과 그 근저당 채권최고액과의 관계, 다른 채무액에 대한 별도의 담보 확보 여부 등 제반 사정에 비추어 당사자의 의사가 계약서 문언과는 달리 일정한 범위 내의 채무만을 피담보채무로 약정한 취지라고 해석하는 것이 합리적이라고 인정되는 경우에는 당사자의 의사에 따라 그 담보책임의 범위를 제한할 수 있다고 할 것임.

(2) 본건 근저당권의 피담보채무 범위

본건 근저당권의 피담보채무 범위에 관하여 살펴보면, 비록 근저당권설정계약서에는 피담보채무의 범위가 ‘포괄근담보’로 기재되어 있으나, 본건 근저당권의 채권최고액(65백만원)이 2007.1.16. 최초 대출상당액(50백만원), 동 금액 상환 이후 2009.4.27. 본건 근저당권을 이용하여 이루어진 대출액(50백만원)에 대한 피신청인 소정의 담보취득비율(130%)에 상응하는 반면, 신용보증기금이 보증한 2009.6.26.자 대출금 100백만원을 포함하는 경우 위 채권최고액을 상당히 초과하게 되는 점.

신용보증기금의 신용보증서는 채권회수의 확실성 및 보증채무 이행에 대한 신뢰도가 일반인의 다른 보증이나 기타의 채권담보수단에 비하여 현저히 높기 때문에 신용보증서가 제출되어 있는 경우, 그 부분에 대하여 금융기관이 추가적인 담보를 요구할 필요가 사실상 없으며 신용보증기금의 보증범위에서 제외되는 부분만을 보충하는 것이 일반금융관행에 가깝다 할 것인데, 신청인의 2009.6.26.자 대출금 100백만원은 신용보증기금의 신용보증서에 의하여 보증비율 100%로 별도로 담보되어 있으며 담보현황, 채권보전조치와 관련한 대출 승인신청서, 대출승인장 기재상으로도 신청인의 2009.4.27.자 50백만원

76) 대법원 2005.7.28. 선고 2005다22565 판결, 금융분쟁조정위원회 조정번호 제2000-18호, 제2003-1호 등 참조.

대출에 대해서는 담보로 본건 토지, 기 설정된 본건 근저당 이용조건이 기재되어 있는 반면, 2009.6.26.자 100백만원 대출에 대해서는 담보로 신용보증기금의 신용보증서(100백만원)만 기재되어 있고, “본건 담보 신용보증기금보증서 100% 담보건으로 채권회수 이상 없으리라 판단됨”으로 영업점 의견이 기재되어 있는 점.

피신청인 직원이 신청인에게 2009.4.27.자 대출금 50백만원만 상환하면 본건 근저당권을 말소해 주기로 하였다고 진술하고 있는 점 등을 종합적으로 고려해 볼 때, 본건 근저당권의 피담보채무는 신청인의 2009.4.27.자 대출금 50백만원에 한정되는 것으로 제한 해석하는 것이 타당하다고 할 것임.

라. 결 론

그렇다면 본건 근저당권의 피담보채무의 범위는 2009.4.27.자 대출금 50백만원에 한정된다고 제한 해석하는 것이 타당하다 할 것이고 신청인이 이미 위 대출금을 모두 상환하였으므로 피신청인은 본건 근저당권설정등기를 말소할 의무가 있다 할 것임.

제2절 한정근저당의 피담보채무 범위

2-5 한정근저당의 피담보채무 범위가 본건 대출금에 한정되는지 여부

[인용] 본건 근저당권은 한정근담보이고, 근저당권 취득일자가 대출금의 취급일자와 근접하고 있고, 채권최고액(78백만원)이 대출금의 최소 채권보전금액(담보권설정비율 130%)에 상응하고, 피신청인의 직원이 본건 대출금을 담보하기 위하여 근저당권을 설정하였다고 진술하고 있고, 또한 직원이 본건 부동산을 매수한 신청인의 대리인으로부터 근저당권과 관련하여 대출금 확인을 요청받고 대출금의 잔액 및 이자 내역을 통지한 사실 등이 있음에 비추어 볼 때 본건 근저당권의 피담보채무범위는 1996.5.29. 취급된 일반자금대출 60백만원에 국한되는 것으로 판단됨.(2000.3.14. 조정번호 제2000-18호)

가. 사실관계

1996.5.29. 피신청인은 신청외 A씨(이하 “차주”라 함) 소유 부동산(이하 “본건 부동산”이라 함)을 담보(한정근담보, 채권최고액 78백만원, 이하 “본건 근저당권”이라 함)로 취득하고 차주에게 일반자금대출 60백만원(이하 “본건 대출금”이라 함)을 취급함.

또한, 피신청인은 1996.10.21. 강원도 ○○시 소재 전답을 담보(한정근담보, 채권최고액 117백만원)로 취득하고 차주에게 일반자금대출 90백만원을, 1997.10.27. 강원도 ○○시 소재 주택을 담보(포괄근담보, 채권최고액 26백만원)로 취득하고 차주에게 가계일반자금대출 20백만원을, 1999.9.4. 신청외 B씨를 연대보증인으로 하여 차주에게 가계일반자금대출 10백만원을 각각 취급함.⁷⁷⁾

1999.7.9. 신청인은 차주와 본건 부동산의 매매계약⁷⁸⁾을 체결하고, 동년 8.12. 본건 부동산에 대하여 소유권이전청구권 가등기를 하였으며, 동년 9.8. 피신청인에게 대출금 잔액을 확인한 후 9.10. 소유권이전등기를 마침.

1999.10.22. 피신청인은 본건 부동산을 매수한 신청인에게 경매실행 예정사실 통지서⁷⁹⁾

77) 2000. 2. 10. 현재 피신청인의 차주 앞 대출금 잔액은 5건, 188.4백만원임.

78) 신청인은 본건 대출금 60백만원을 승계하기로 하고, 피신청인을 방문하여 대출 관련 사항을 확인함.

를 발송함.

나. 당사자의 주장

(1) 신청인의 주장

신청인은 본건 부동산을 매수하면서 근저당권의 피담보채무범위가 본건 대출금에 한정됨을 피신청인에게 확인하였으며, 피신청인은 경매실행 예정사실 통지서에 본건 대출금만을 기재하고 있었던 점 등에 비추어 신청인은 본건 대출금에 대하여만 담보책임이 있음.

(2) 피신청인의 주장

차주의 다른 대출금에 보증한 연대보증인들이 본건 부동산에 설정되어 있는 근저당권 해지에 반대하고 있어 신청인이 본건 대출금을 상환하더라도 채권최고액 78백만원을 회수하지 아니하고는 근저당권을 해지할 수 없음.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 본건 부동산에 설정되어 있는 근저당권의 피담보채무범위가 본건 대출금에 한정된 것으로 볼 수 있는지 여부임.

(1) 근저당권의 일반적인 해석 기준

근저당권의 피담보채무 범위에 관하여 대법원 및 금융분쟁조정위원회는 근저당권설정 계약서가 정당하게 작성되었으면 원칙적으로 그 기재된 내용에 따라 피담보채무의 범위를 인정하고 있으나, 그 기재내용과 다른 특별한 묵시적, 명시적인 개별약정의 요소가 있는 경우에는 그 개별약정의 요소에 따라 피담보채무의 범위를 제한해석하고 있음.⁸⁰⁾

(2) 본건 근저당권의 피담보채무 범위

피신청인은 차주의 다른 대출금에 대한 연대보증인들이 민원을 제기할 우려가 있으며

79) 통지서상에 채권액으로 본건 대출금(원금 60백만원, 이자 67만원)만을 기재함.

80) 대법원 1997.9.26. 선고 97다22768 판결, 금융분쟁조정위원회 조정번호 제1999-33호 참조.

로 신청인이 채권최고액까지 담보책임을 부담하여야 한다고 주장하나 다음과 같은 제반
정황에 비추어 볼 때 본건 근저당권의 피담보채무범위는 1996.5.29. 취급된 일반자금대출
60백만원에 국한되는 것으로 판단됨.

① 피신청인의 직원은 본건 대출금을 담보하기 위하여 본건 근저당권을 설정하였다고
진술하고 있으며, 1999.9.8. 피신청인이 본건 부동산을 매수한 신청인의 대리인으로부터
본건 근저당권과 관련하여 대출금 확인을 요청받고 본건 대출금의 잔액 및 이자 내역을
통지한 바 있으며 이는 본건 근저당권의 피담보채무범위를 본건 대출금으로 국한한 것
으로 보이는 점.

② 본건 근저당권은 한정근담보이고 근저당권설정자가 차주이기는 하나 근저당권 취
득일자(1996.5.22.)가 본건 대출금의 취급일자(1999.5.29.)와 근접하고 있고 채권최고액(78
백만원)이 피신청인이 차주에게 취급한 본건 대출금(60백만원)에 대하여 피신청인의 여
신업무방법서에서 정하고 있는 당해 대출금의 최소 채권보전금액(담보권설정비율 130%)
에 상응하는 점.

③ 피신청인이 차주의 여타 대출금에 대하여 각각 담보를 취득하거나 연대보증인을
세우는 등 별도의 채권보전조치를 강구하였을 뿐만 아니라 여타 대출금 취급시 본건 근
저당권이 원용된 사실이 없는 점.

④ 1999.10.22. 차주가 여타 대출금을 연체하게 되자 신청인에게 경매실행 예정사실 통
지서를 발송하면서 채권청구액을 채권최고액으로 하지 아니하고 본건 대출금으로 한정
하여 통보하였으며, 또한, 피신청인이 본건 근저당권의 피담보채무의 범위에 차주의 여
타 대출금이 포함된다는 사실을 적극적으로 주장하지 아니하고 오히려 여타 대출금에
대한 연대보증인들이 민원을 제기할 것을 우려하여 신청인의 요청을 거절하고 있는 점.

라. 결 론

위에서 살펴본 바와 같이 1996.5.22.자 근저당권설정계약서에 의하여 설정된 본건 근저
당권의 피담보채무범위는 1996.5.29.자 일반자금대출 60백만원(본건 대출금)으로 제한함
이 타당한 것으로 판단됨.

2-6 한정근저당권 설정계약서 문언의 성격

[기각] 근저당권의 피담보채무 범위에 관하여 근저당권설정계약 체결의 경위와 목적, 피담보채무액, 근저당권설정자와 채무자 및 채권자와의 상호관계 등에 비추어 일정한 범위내의 채무만을 피담보채무로 약정한 취지라고 해석하는 것이 합리적이라고 인정되는 경우에는 당사자의 의사에 따라 그 담보책임의 범위를 제한할 수 있으나, 본건의 경우 신청인의 서류 기재내용, 이후의 대출 및 담보유지 상황 등을 볼 때 피담보채무 범위를 계약서 문언과는 달리 특정 채무만을 담보하기로 당사자가 약정하였다거나 계약서 문언이 단순한 예문에 불과하다고 볼 수는 없다 할 것임.(2005.1.11. 조정번호 제2004-78호)

가. 사실관계

1995.8.28. 신청인은 ○○은행(이하 “피신청인”이라 함) 지점에서 채무자인 신청인의 처남(A씨)의 일반자금대출, 신탁자금대출을 위하여 피신청인과 한정근저당설정계약(채권 최고액 52백만원, 담보목적물 : 신청인 소유 아파트, 이하 “본건 부동산”이라 함)을 체결하였고(이하 ‘본건 근저당권’이라 함), 1995.9.5. 주채무자 A씨의 일반자금대출 20백만원, 부동산저당대출 20백만원(이하 “본건 대출금”이라 함)에 대하여 연대보증설정계약을 피신청인과 체결하였음.

위 2건의 대출채무와 관련하여 피신청인은 주채무자 A씨 명의의 정기적금 및 적립신탁을 각 예금질권으로 입보하고 각 대출채무 만기시⁸¹⁾ 위 각 대출금과 예금을 상계처리한 사실이 있음.

1996.5.18.~1999.7.26. 기간중 피신청인은 주채무자 A씨의 추가대출(4건 69백만원) 취급시에도 신청인을 연대보증인으로 입보⁸²⁾하였고, 동대출금은 기일도래시 전액 상환되었고, 각 대출취급시 마다 본건 근저당권을 원용한 사실이 있으며, 2000.9.26.~2002.8.30. 기간중 피신청인은 채무자 A씨에게 6건 90백만원을 추가대출 취급하였고 이중에서 37

81) 정기적금은 1997.11.17. 만기해지하여 위 일반자금대출에, 적립신탁예금은 1998.8.20. 해지하여 위 부동산저당대출(신탁자금대출)에 각각 상환되었음.

82) 대출기한 연장포함 13건, 236백만원에 대하여 연대보증인으로 신청인을 입보하였음.

백여만원을 상환하고 52.2백만원은 현재 연체중임.

한편, 신청인은 본건 부동산을 이용하여 1999.4.2. 본인명의로 피신청인으로부터 80백만원을 대출받았고 2001.3월 이후 사건외 ◇◇은행에서 4건 채권최고액 합계 244백만원의 근저당권을 설정하였음.

나. 당사자의 주장

(1) 신청인 주장

신청인은 처남인 A씨의 대출을 위하여 아파트를 담보로 제공하였고 몇 차례 신규 및 대출기한 연장시 연대보증을 한 사실은 있으나, 2000.9월 이후부터는 피신청인과 채무자 A씨와의 대출거래에 대하여 부동산 담보 및 연대보증한 사실이 없고, 근저당권설정계약서 상의 “일반자금대출” 및 “신탁자금대출”이라는 대출과목란의 기재는 작성 당시에는 없었으며, 그 이후 피신청인의 담당직원이 임의로 기입한 것이므로 피신청인이 A씨가 연체중인 52백만원의 회수를 요구하며 근저당설정등기의 말소절차를 이행하지 아니함은 부당함.

(2) 피신청인 주장

1995.8.28. 신청인이 제공한 한정근담보는 동일대출과목에 대한 채권한도액 범위내에서 신규 및 기한연장 대출에 대하여 현재·미래채무에 대하여 담보로서의 효력이 있고, 보증인은 최초 대출실시 이후 수차례에 걸쳐 채무자 A씨의 담보 및 연대보증을 제공하였을 뿐 만 아니라 피신청인 성동지점에서 본인대출 80백만원 취급시 별도로 추가 근저당권을 설정(104백만원)하였으며, 또한 수차례 신청외 ◇◇은행 대출취급시 근저당설정 당시에도 피신청인에게 담보운용에 대한 이의나, 근저당권의 확정, 근저당권말소등기 등을 요청한 사실이 없으므로 신청인의 청구를 수용할 수 없음.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 본건 근저당설정 등기의 말소 여부와 관련하여 본건 근저당권의 피담보채무 범위가 본건 대출금에만 한정된 것으로 볼 수 있는지 여부라고 할 것임.

(1) 근저당권의 피담보채무 범위에 대한 일반적인 해석 기준

근저당권의 피담보채무 범위에 관하여 대법원 및 당 위원회는 근저당권설정계약서가 정당하게 작성되었으면 원칙적으로 처분문서의 기재된 내용에 따라 피담보채무의 범위를 인정하고 있으나, 그 기재내용과 다른 특별한 묵시적, 명시적인 개별약정의 요소가 있는 경우에는 그 개별약정의 요소에 따라 피담보채무의 범위를 제한해석하고 있음.⁸³⁾ 따라서 처분문서의 내용대로 효력을 발생하는 것이 원칙이지만 근저당권설정계약 체결의 경위와 목적, 피담보채무액, 근저당권설정자와 채무자 및 채권자와의 상호관계 등 제반 사정에 비추어 당사자의 의사가 계약서 문언과는 달리 일정한 범위내의 채무만을 피담보채무로 약정한 취지라고 해석하는 것이 합리적이라고 인정되는 경우에는 당사자의 의사에 따라 그 담보책임의 범위를 제한할 수 있다고 할 것임.

(2) 본건 근저당권의 피담보채무 범위

신청인은 비록 처분문서인 근저당권설정계약서에 한정근담보라고 부동문자로 명시되었다고 하더라도 본건 대출금에 대하여 일반자금 및 신탁자금의 대출과목을 한정하는 근저당을 설정한 사실이 없고, 본건 대출금에 대한 담보만을 위하여 근저당권을 설정하여 준 것이므로 본건 대출 원리금을 차주가 변제한 이상 피담보채무가 소멸되었다고 주장하나, 아래의 각 점을 종합하면, 본건 근저당권의 피담보채무 범위를 계약서 문언과는 달리 특정 채무만을 담보하기로 당사자가 약정하였다거나 계약서 문언이 단순한 예문에 불과하다고 볼 수는 없음.

① 신청인이 본건 근저당권설정계약을 특정근저당으로 인식하고 계약을 체결하였다고 주장하나, 신청인이 작성한 근저당권설정계약서상 동 계약의 내용을 “잘 읽었음”이라고 자필로 기재한 점 및 대출과목의 사후 기입여부와 관련한 필적감정조회결과 “일반자금대출”, “신탁자금대출”의 필적이 신청인의 필적과 유사한 것으로 감정된 점.

② 1999.3.29. 피신청인 성동지점에서 신청인 본인에게 80백만원의 대출금 취급과 관련하여 근저당권설정계약이 이루어지고 본건 부동산에 대하여 채권최고액 104백만원의 근저당권 설정 등기가 본건 근저당권의 후순위로 이루어진 후, 2001.3.21. 동 대출금의 변

83) 대법원 2000.3.28. 선고 99다32332 판결, 금융분쟁조정위원회 조정번호 제2000-18호 등 참조.

제에 따른 근저당권설정등기가 말소된 사실 및 신청인이 2001.3월 이후 신청의 ◇◇은행으로부터 본건 부동산을 담보로 제공하고 대출을 받은 사실이 있는 바, 이러한 각 대출시 본건 근저당권 등기가 말소되지 아니하고 있음에도 피신청인에게 근저당권설정등기의 말소나 근저당권의 확정 등을 요구한 사실이 없는 점.

③ 본건 대출 이후에 취급된 대출금은 모두 본건 근저당권의 담보가치를 감안하여 취급되고 있으며, 각 대출시마다 본건 근저당권이 원용되고 있는 점.

④ 신청인은 2000.9.26.~2002.8.30.까지의 기간에는 연대보증을 한 사실이 없으므로 물상보증 역시 책임이 없다고 주장하나, 물상보증과 연대보증은 법리상 별개의 담보일 뿐만 아니라, 동 기간 동안 신청인을 연대보증인으로 입보하지 아니한 이유가 제3자 담보 제공자에 대하여 연대입보를 요구하는 행위를 금지하는 『은행업감독업무시행세칙』(제 64조 제4호)에 따른 것이며, 동 기간의 여신처리는 모두 본건 근저당의 담보가치액을 기준으로 별도의 연대보증인 입보나 신용으로 취급한 것으로 확인되는 점.

라. 결 론

결국 신청의 A씨가 피신청인에게 현재 부담하고 있는 나머지 채무 52백만원도 본건 근저당권의 피담보채무 범위에 포함되는 것으로 봄이 상당하여, 본건 근저당권설정등기는 유효한 등기이므로 신청인의 청구는 이유 없어 이를 기각함이 타당함.

2-7 한정근저당권의 피담보채무 범위가 특정되지 않은 경우

[인용] 근저당권의 피담보채무 범위에 관하여 근저당권설정계약서가 정당하게 작성되었으면 원칙적으로 처분문서의 기재된 내용에 따라 피담보채무의 범위를 인정하고 있으나, 근저당권설정계약 체결의 경위와 목적, 피담보채무액, 근저당권설정자와 채무자 및 채권자와의 상호관계 등 제반 사정에 비추어 당사자의 의사가 계약서 문언과는 달리 일정한 범위내의 채무만을 피담보채무로 약정한 취지라고 해석하는 것이 합리적이라고 인정되는 경우에는 당사자의 의사에 따라 그 담보책임의 범위를 제한할 수 있다고 할 것임.(2009.4.14. 조 정번호 제2009-42호)

가. 사실관계

신청인⁸⁴⁾은 A기업이 피신청인으로부터 1억 5,000만원의 ‘중소기업자금대출’을 받음에 있어 자신 소유의 경기도 김포시 소재 부동산을 담보로 제공하기 위하여 2006.11.9. 피신청인과 근저당권설정계약을 체결하고 11.10. 설정등기를 완료함.

위 근저당권설정계약서에는 근저당권의 내용으로 피담보채무의 범위 “한정근저당”, 채권최고액 “3.5억원”, 결산기 “장래지정형”으로 명기되어 있고, 근저당권설정자인 신청인의 자필서명과 날인이 되어 있으며, ‘은행여신거래기본약관 및 계약서 사본의 수령’과 ‘약관 및 계약서의 중요한 내용을 설명 들었음’을 각각 확인하는 신청인의 자필이 기재되어 있음.

한편, 위 근저당권설정계약서의 ‘피담보채무의 범위’ 란에는 본건 근저당권의 종류가 “한정근저당”으로 명시되어 있으나, 한정근저당의 필수적인 요소인 “기본거래내용”에 관한 기재가 누락되어 피담보채무의 범위를 전혀 특정할 수 없음.

또한 위 ‘중소기업자금대출’ 심사당시 미화 161만불의 ‘외화지급(이행)보증’도 동시에 여신심사를 받았으나 실제 실행되지는 않았고, 그 후 2006.11.28. A기업에 대하여 위 ‘외화지급보증’이 아닌 ‘7.6억원의 원화지급보증’이 실행된 것으로 확인되었으며, 피신청인은 보증처 변경 등의 사정으로 위 ‘외화지급(이행)보증’이 ‘원화지급보증’으로 변경 실행된 것이라는 입장임.

2008.3.25. A기업이 발행한 약속어음(1억 409만원)의 부도가 발생하였고, 피신청인이 2008.6.19., 8.21. 및 9.17. 3차에 걸쳐 신청인에게 경매실행예정사실통지서를 발송하자 신청인은 본건 근저당권의 피담보채무에 위 ‘원화지급보증’ 부분이 포함되는 것은 부당하다고 주장하여 본건 분쟁이 발생하였으며, 본건 근저당권을 기초로 2008.9.26. ○○지방법원의 부동산임의경매 개시결정이 내려져 현재 경매 진행 중임.

나. 당사자 주장

(1) 신청인 주장

84) 신청인은 A기업 대표이사의 친인척임.

2006.11.9. 본건 근저당권설정계약을 체결할 당시 “한정근저당”으로 명시한 이유는 피담보채무를 당시 약정한 ‘중소기업자금대출’에 국한하기 위한 것이었으므로, 2006.11.28.에야 실행되었고 종류도 전혀 다른 ‘원화지급보증’은 본건 근저당권에 의하여 담보되지 않는 것으로 보아야 함.

본건 근저당권의 채권최고액을 ‘중소기업자금대출’ 1.5억원을 2배이상 초과하는 3.5억원으로 설정한 것은 장차 동종의 ‘중소기업자금대출’이 추가 실행되는 경우를 대비한 것이지 ‘지급보증’ 부분까지 담보하기 위한 것이 결코 아니었음.

(2) 피신청인 주장

본건 근저당권은 “한정근저당”으로 표시되어 있기는 하나 그 피담보채무를 구체적으로 특정하고 있지 않으므로, 채무자가 현재 및 장래에 부담하는 모든 채무를 담보하는 ‘포괄근저당’과 마찬가지로 해석해야 함.

본건 ‘중소기업자금대출’을 심사할 당시 미화 161만불의 ‘외화지급보증’도 동시에 여신 심사를 실시하였던 이유는 위 ‘외화지급보증’ 부분도 본건 근저당권의 피담보채무에 포함시키기로 하는 당사자 간의 합의가 있었기 때문임. 따라서 위 ‘외화지급보증’은 비록 사정상 실제 실행되지 않았으나 그 직후인 2006.11.28. ‘7.6억원의 원화지급보증’으로 변경 실행되었던 것이므로 위 ‘원화지급보증’은 본건 근저당권의 피담보채무에 포함되는 것으로 보아야 함.

본건 근저당권의 채권최고액을 3.5억원으로 설정한 것은 위 1.5억원의 ‘중소기업자금대출’ 뿐만 아니라 ‘지급보증’ 부분도 담보하기로 약정하였기 때문으로서, “신청인 소유 부동산의 담보가치에 대한 최종심사가격 2.9억원의 120%”를 설정한 것임.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 근저당권설정계약서에 “한정근저당”으로 기재되어 있으면서도 한정근저당의 필수적인 요소인 “기본거래내용”에 관한 기재가 누락되어 피담보채무의 범위가 전혀 특정되어 있지 않은 경우 본건 근저당권 설정당시 당사자가 지급보증 등 ‘중소기업자금대출 외의 채무’까지 담보하기로 합의한 것으로 해석할 수 있는지 여부라 할 것임.

(1) 본건 근저당권의 성격

위에서 본 바와 같이 본건 근저당권설정계약서의 “기본거래내용”에 관한 기재가 누락되어 피담보채무를 정확히 특정하고 있지는 못하나 그 종류에 관하여는 명백히 “한정근저당”으로 명시하고 있는바, 그렇다면 위와 같은 기재사항 누락에도 불구하고 본건 근저당권은 일응 “한정근저당”으로 해석하여야 할 것이고, 다만 그 피담보채무를 어떻게 한정할 것인가의 문제만 남는다 할 것임.

이에 관하여 피신청인은 대법원 1994.9.30. 선고 94다20242 판결⁸⁵⁾을 인용하면서 본건 근저당권의 피담보채무는 채무자의 현재 및 장래의 일체의 채무를 담보하는 “포괄근저당”과 마찬가지로 해석되어야 한다고 주장하나, 위 판결의 사안은 ‘본건과 같이 한정근저당임을 명시한 경우가 아니므로’ 본건에 있어 원용할 수 없는 것임.

(2) 피담보채무의 범위

피신청인은 본건 “한정근저당”의 피담보채무의 범위에 당사자 사이에 다툼이 없는 ‘중소기업자금대출’ 외에 ‘지급보증’ 부분도 포함된다고 주장하나, 아래와 같은 이유로 본건 근저당권의 피담보채무는 위 ‘중소기업자금대출’에 한정된다고 판단됨.

① 일반적으로 여신거래에 있어 담보로 근저당권을 설정함에 있어서 채권최고액은 “대출원금의 약 120% 정도”로 설정하는 것이 통상적인데, 본건의 경우 ‘지급보증채무’부분까지 포함하면 대출원금이 채권최고액을 수배이상 초과한다는 점.

② 약관의 뜻이 명백하지 아니한 경우에는 고객에게 유리하게 해석되어야 한다는 것이 일반법리라는 점(약관규제법 제5조 제2항 참조).

85) 대법원 1994.9.30. 선고 94다20242 판결에서는, 은행과 물상보증인 사이에 근저당권설정계약을 체결할 때 작성된 근저당권설정계약서에 “주채무자가 은행에 대하여 기왕, 현재 또는 장래에 부담하는 모든 채무를 담보하기 위하여 부동산에 근저당권을 설정한다”라는 취지의 기재가 있는 경우 그 기재는 주채무의 종류나 성립시기에 관계없이 모든 채무를 담보하기로 하는 이른바 포괄근저당권을 설정한다는 문언이라 할 것이라고 판시함. 위 판결의 사실관계는, 피고은행은 1988.3.14. 소외 ○○○과의 사이에 동인 소유인 부동산에 관하여 근저당권설정계약을 체결하면서, “피담보채권은 채권 최고액의 범위 내에서 위 ◇◇기업이 기왕, 현재 또는 장래 부담하는 모든 채무”로 하기로 약정하고, 위 ○○○에게 위 근저당권이 포괄근담보에 해당함을 재확인시키는 의미로 “제3자담보제공상담표의 포괄근담보란에 날인”까지 받은 사안임.

③ 본건 근저당권으로 위 ‘지급보증채무’ 부분의 만족까지 구하고자 한다면 입증책임 분배의 원칙상 이를 주장하는 피신청인이 위 근저당권의 피담보채무에 ‘지급보증채무’ 부분까지 포함시키기로 하는 당사자의 합의가 있었음을 입증해야 할 것인데, 현재 피신청인은 그에 관한 ‘객관적인 증거’를 제출하지 못하고 있는 점.

④ 무엇보다 현재 실제로 문제되고 있는 ‘원화지급보증’은 위 ‘중소기업자금대출’과 동시에 여신심사를 받은 ‘외화지급보증’과 동일성이 인정된다고 볼 수 없는 점 등.

결국 본건 근저당권의 피담보채무의 범위에는 위 ‘중소기업자금대출 1.5억원 및 그에 대한 이자 또는 지연손해금’ 만이 포함되는 것으로 한정적으로 해석하지 않을 수 없다 할 것임.

라. 결 론

그렇다면, 2006.11.10. 완료된 신청인 소유의 경기도 김포시 소재 부동산에 관한 피신청인의 근저당권의 피담보채무는 A기업의 2006.11.10.자 중소기업자금대출 채무 1.5억원 및 그에 대한 약정이자 또는 지연손해금에 한정된다는 취지의 신청인의 주장은 이유 있으므로 이를 인용함.

2-8 한정근저당 피담보채무 범위의 일부를 금융회사가 보충한 경우

[기각] 피신청인이 근저당권의 피담보채무의 내용이 될 거래내역 기재란을 공란으로 하였다가 추후 이를 보충한 것은 적정한 업무행태라고 보기 어렵다 할 것이나, 근저당권설정계약 체결의 경위와 목적, 피담보채무액, 근저당권설정자와 채무자 및 채권자와의 상호관계 등 제반 사정에 비추어, 그러한 사유만으로 본건 근저당권의 피담보채무가 특정대출에만 한정된다고 보기는 어렵다 할 것임.(2010.6.8. 조정번호 제2010-52호)

가. 사실관계

2008.4.16. 피신청인은 신청외 A기업(개인회사) 대표 ‘B씨’와 중소기업자금대출 20백만

원을 약정하였고, 2008.7.30. 신청인⁸⁶⁾은 자신 소유의 경기도 ○○시 소재 아파트에 관하여 채무자를 'B씨', 채권최고액을 '1.2억원', 근저당 결산기를 '장래지정형'으로 하는 근저당권설정계약을 체결한 후 피신청인 앞으로 근저당을 설정하여 줌.

한편, 위 근저당권설정계약서 기재사항 중 피담보채무 범위 기재란의 '한정근저당', 채권최고액 기재란의 '일억이천만원', 근저당권 결산기 기재란의 '장래지정형' 부분은 신청인이 자필기재 하였으나, 한정근저당권의 피담보채무의 내용이 될 거래내역 기재란은 공란으로 하였다가 추후 피신청인 직원이 '여신거래약정서'라고 보충 기재하였음.

2008.7.31. 피신청인은 B씨에게 중소기업자금대출 70백만원(대출A)을 신규 취급하고, 기존 2008.4.16.자 중소기업자금대출 한도를 20백만원에서 50백만원으로 증액(대출B)하였는데, 동 대출 취급시 채무자로부터 '여신거래약정서', '거래조건변경·추가약정서'를 징구하였으나, 동 약정서의 담보제공자란에 별도로 신청인의 서명을 받지는 아니하였으며, 피신청인의 담보현황표에 의하면, 신청인이 제공한 담보부동산의 여신가능금액은 50백만원 상당⁸⁷⁾이었음.

2010.1.18. 채무자에게 당좌부도가 발생하자, 피신청인은 본건 근저당권을 근거로 대출A(70백만원) 및 대출 B의 증액부분(30백만원)에 대해 신청인에게 경매실행예정임을 통지하였고, 신청인은 본건 근저당권의 피담보채무는 위 대출A에 한하며 대출B의 증액부분까지 포함하는 것은 부당하다고 주장하며 본건 분쟁조정을 신청함.

나. 당사자 주장

(1) 신청인 주장

신청인은 채무자의 동생인 C씨(신청인의 사위)의 부탁과 담보부동산의 담보여력이 70백만원 밖에 안된다는 이야기를 듣고 70백만원의 대출에 대해서만 담보제공할 의사로 은행직원이 불러주는 대로 근저당권설정계약을 작성하였던 것이지 채권최고액 1.2억원

86) 신청인은 채무자 B씨 동생인 C씨의 장인임.

87) 담보부동산(아파트)의 여신가능금액 : 80백만원(감정가격) × 담보인정비율(80%) - 선순위(12백만원)
= 50백만원.

까지 담보책임을 부담할 의사는 없었으며, 피신청인 직원이 임의로 본건 근저당권의 피담보채무의 내역을 ‘여신거래약정서’라고 기재한 것이므로 신청인이 부담할 담보책임은 대출A 70백만원의 잔액에 한정됨.

(2) 피신청인 주장

본건 저당권은 채무자로부터 대출금 1억원의 차용신청을 받은 후 담보제공자의 담보제공의사에 따라 대출A 70백만원과 대출B의 증액부분 30백만원을 합한 1억원에 대해서는 은행 소정의 담보설정비율(120%)을 적용하여 채권최고액을 120백만원으로 하는 한정근저당권을 설정한 것이고, 계약당시 한정근저당권의 성격 및 위와 같은 피담보채무의 내용을 신청인에게 분명히 설명하고 계약서에 자필서명을 받았으며, 한정근저당권의 피담보채무의 내용이 될 거래내역 부분을 공란으로 하였다가 추후 피신청인 직원이 ‘여신거래약정서’라고 보충기재하였다고 하여 담보제공자가 자서한 한정근저당권의 피담보채무가 영향을 받는 것은 아니므로 본건 한정근저당권의 피담보채무 범위에 대출A 70백만원과 대출B의 증액부분 30백만원이 포함되는 것임.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 본건 근저당권의 피담보채무 범위가 대출A 70백만원에 한정되는 것으로 볼 수 있는지 여부라 할 것임.

(1) 근저당권의 일반적인 해석

근저당권의 피담보채무 범위에 관하여 대법원 및 금융분쟁조정위원회는 근저당권설정 계약서가 정당하게 작성되었으면 원칙적으로 처분문서의 기재된 내용에 따라 피담보채무의 범위를 인정하고 있으나, 그 기재내용과 다른 특별한 묵시적, 명시적인 개별약정의 요소가 있는 경우에는 그 개별약정의 요소에 따라 피담보채무의 범위를 제한해석하고 있음.⁸⁸⁾ 따라서 근저당권 설정계약서는 그 계약문언대로 효력을 발생하는 것이 원칙이지만 근저당권설정계약 체결의 경위와 목적, 피담보채무액, 근저당권설정자와 채무자 및

88) 대법원 2000.3.28. 선고 99다32332 판결, 금융분쟁조정위원회 조정번호 제2000-18호 등 참조.

채권자와의 상호관계 등 제반 사정에 비추어 당사자의 의사가 계약서 문언과는 달리 일정한 범위내의 채무만을 피담보채무로 약정한 취지라고 해석하는 것이 합리적이라고 인정되는 경우에는 당사자의 의사에 따라 그 담보책임의 범위를 제한할 수 있다고 할 것임.

(2) 본건 근저당권의 피담보채무 범위

본건에서 피신청인이 근저당권의 피담보채무의 내용이 될 거래내역 기재란을 공란으로 하였다가 추후 이를 보충한 것은 적정한 업무행태라고 보기 어렵다 할 것이나, 다음과 같은 점에 비추어, 동 사유만으로 본건 근저당권의 피담보채무가 대출A 70백만원에 한정된다고 보기는 어렵다 할 것임.

① 앞서 본 바와 같이 근저당권설정계약서는 처분문서이므로 그 진정성립이 인정되는 때에는 계약문언대로 효력을 발생하는 것이 원칙이라 할 것이고, 본건 근저당권설정계약서의 피담보채무의 범위는 특정근저당, 한정근저당, 포괄근저당중 하나를 선택하도록 되어 있고 신청인은 그 중 ‘한정근저당’을 선택하여 이를 기재한 것이며, 한정근저당권을 설정하는 경우 통상 특정한 종류의 금융거래에서 발생하는 채무 전부를 담보하는 것이 일반적이고 피담보채무의 범위를 그 중 일부만으로 한정한다는 것은 오히려 이례적이라 할 것이며, 본건 근저당권설정계약서에 특정채무를 담보하는 것으로 이를 제한하는 취지의 기재가 없는 점.

② 본건 대출A와 대출B는 중소기업자금대출로서 대출과목이 동일하고 모두 여신거래 약정서를 체결하고 취급되었으며, 대출A 70백만원과 대출B의 증액부분 30백만원 대출 모두 저당권설정계약일 바로 다음날 동일한 날짜에 이루어진 점.

③ 일반적으로 여신거래에 있어 담보로 근저당권을 설정함에 있어 채권최고액은 “대출원금의 약 120%정도”로 설정하는 것이 통상적인데, 본건 근저당권의 채권최고액(120백만원)은 대출A 70백만원과 대출B의 증액부분 30백만원을 합한 대출금의 120%에 해당하는 점.

④ 피신청인의 ‘여신상담 및 심사기준표’에 의하면 애초에 채무자로부터 1억원의 차용신청이 있었던 것으로 보이며, ‘여신품의서’상 담보현황에 각각 본건 근저당권이 설정된 것으로 기재되어 있는 점.

⑤ 신청인은 본건 대출의 차주인 B씨의 동생인 C씨의 장인이며, 본건 근저당권 설정일 이전인 2005.2.17. B씨를 채무자로 하여 채권최고액 65백만원의 근저당권을 설정해 준 사실이 있고, 본건 근저당설정일 이후인 2010.1.21.에도 B씨를 채무자로 하여 채권최고액 60백만원의 근저당권을 설정한 사실이 있는 등 신청인과 B씨, C씨간의 관계를 상호 무관한 것으로 보기 어려운 점.

⑥ 기타 신청인 주장사유 만으로 본건 근저당권의 피담보채무를 대출A의 대출금으로 제한해석하여야 할 특별한 사정을 찾기 어려운 점.

라. 결 론

그렇다면 신청인의 청구는 이유 없어 이를 기각함이 타당함.

2-9 한정근저당권의 피담보채무를 증서대출로 기재한 경우

[인용] 피담보채무의 범위를 특정하지 않은 한정근저당이라 하더라도 대출경위, 담보 설정 관행, 근저당권 채권최고액 등을 감안하여 신용대출까지 담보하는 것으로 보기 어려운 경우, 담보대출과 별도로 취급한 신용대출에는 대하여는 담보의 효력이 미치지 않는다고 할 것임.(2013.9.10. 조정번호 제2013-23호)

가. 사실관계

2010.9.15. 신청의 A씨는 대출금 담보 목적으로 피신청인과 본인 소유 아파트(이하 ‘본건 부동산’)에 대한 근저당권설정계약(한정근담보, 채권최고액 127백만원)을 체결하고, 다음 날 피신청인 앞으로 근저당권(이하 ‘본건 근저당권’)을 설정해 주었으며, 그 다음 날 본건 부동산을 담보로 하여 피신청인으로부터 ○○모기지론(담보대출, 금리 6.4%) 106백만원을 대출받음.

한편 같은 날인 2010.9.17, A씨는 ○○모기지론과 별도로 가계자금용으로 피신청인으로부터 신용대출(무입보대출, 금리 9.0%) 12백만원을 추가로 대출받았는데, 피신청인이

작성한 동일자 담보물심사표에 의하면 본건 부동산의 담보물평가액은 152백만원이고 담보인정비율(70%) 적용시 담보가능금액은 106백만원으로 산정됨. 또한 동일자 ○○모기지론 개인여신심사표에는 위 담보물평가액과 동일한 106백만원을 담보대출로 취급하는 것으로 기재되어 있는 반면, 신용대출 개인여신심사표에는 신청금액 12백만원 전액에 대하여 아무런 담보가 없는 것으로 기재되어 있음.

2013.1.11. 신청인은 A씨로부터 본건 부동산을 매수하면서 본건 ○○모기지론은 채무 인수하고 신용대출은 A씨가 상환하기로 함.

나. 당사자 주장

(1) 신청인 주장

신청인은 신청외 A씨로부터 본건 부동산을 매수하면서 해당 등기부등본을 확인한 후 본건 근저당권의 피담보채무를 인수하기로 하고 본건 부동산을 매수하였는데, 피신청인은 본건 근저당권에 의하여 담보되지 않는 신용대출 채무까지 상환하여야 한다고 주장하고 있어 신청인에게 불측의 피해를 주고 있음.

(2) 피신청인 주장

본건 근저당권은 한정근저당이고 채무자가 증서대출로 인한 채무를 담보하는 것으로 약정하였으며, 피신청인 승낙없이 임의로 소유권을 이전받았으므로 신청인도 채무자의 신용대출을 포함한 대출채무 일체를 상환하여야 함.

다. 위원회 판단

◆ 본건의 쟁점은 본건 근저당권의 피담보채무 범위가 A씨의 2010.9.17.자 신용대출에까지 미치는지 여부라 할 것임

(1) 근저당권의 피담보채무 범위에 관한 일반적인 해석

근저당권의 피담보채무 범위에 관하여 대법원 및 우리 원 분쟁조정위원회는 근저당권 설정계약서가 정당하게 작성되었다면 원칙적으로 처분문서의 기재된 내용에 따라 피담

보채무의 범위를 인정하고 있으나, 그 기재내용과 다른 특별한 묵시적, 명시적인 개별약정의 요소가 있는 경우에는 그 개별약정의 요소에 따라 피담보채무의 범위를 제한해석하고 있음.⁸⁹⁾

한정근저당의 피담보채무와 관련하여 대법원은, 당해 대출금채무와 장래 채무의 각 성립 경위 등 근저당 설정계약 체결의 경위, 대출 관행, 각 채무액과 그 근저당권의 채권최고액과의 관계, 다른 채무액에 대한 별도의 담보확보 여부 등 여러 사정에 비추어 인쇄된 계약 문언대로 피담보채무의 범위를 해석하면 오히려 금융기관의 일반 대출 관례에 어긋난다고 보여지고 당사자의 의사는 당해 대출금채무만을 그 근저당권의 피담보채무로 약정한 취지라고 해석하는 것이 합리적인 경우에는 근저당권설정계약서의 피담보채무에 관한 포괄적 기재는 부동산자로 인쇄된 일반거래약관의 예문에 불과한 것으로 보아 그 구속력을 배제하는 것이 타당하다고 판단함.⁹⁰⁾

(2) 본건 근저당권의 피담보채무 범위

본건 근저당권의 피담보채무 범위에 관하여 살펴보면, 비록 근저당권설정계약서에는 피담보채무의 범위가 ‘한정근담보’로 기재되어 있으나, 아래와 같이 본건 대출경위, 일반적인 담보설정 관행, 근저당권의 채권최고액과의 관계 등을 종합적으로 고려할 때 본건 근저당권이 A씨의 2010.9.17.자 신용대출까지 담보한다고 볼 수는 없다고 할 것임.

① 금융회사의 대출관행상 대출금액의 120% 또는 130%에 해당하는 금액을 근저당권의 채권최고액으로 설정하는데, 이 사건 근저당권의 채권최고액은 127백만원으로 ○○모기지론의 대출금액 106백만원의 120%에 해당하며, 2010.9.17.자 신용대출(12백만원)을 포함할 경우 자체 채권최고액 기준에 미달하게 되는 점.

② 주택담보대출 취급시 LTV규제에 따라 담보평가물의 70% 이내에서만 대출이 가능한 바, LTV한도를 적용한 본건 부동산의 대출가능 금액이 106백만원으로 신용대출 12백만원 포함시 적정 대출한도를 초과하는 등 LTV규제를 사실상 위반하는 결과⁹¹⁾가 되는 점.

89) 대법원 2005.7.28. 선고 2005다22565 판결, 금융분쟁조정위원회 조정번호 제2000-18호 등 참조.

90) 대법원 2005.7.28. 선고 2005다22565 판결 등 참조.

91) 신용협동조합법 제83조의3 및 동법시행령 제20조의2, 상호금융업감독규정 제16조의4 제1항에 의하여,

③ 2010.9.17.자 신용대출과 관련하여 피신청인이 작성한 여신심사서류에 의하면 본건 신용대출은 ‘무입보신용’으로 신청한 대출로서 신청인에 대한 신용대출 가능금액 25백만원 중 12백만원이 실행되었고, 동 대출금리 또한 9.0%로 담보대출인 ○○모기지론의 대출금리(6.4%)보다 2.6%p가 높게 설정되어 있으며, 대출경위와 관련하여 신청외 A씨가 피신청인에게 과일 소매업 운영자금으로 120백만원을 신청하였으나 전액 담보대출이 어려워 피신청인이 시키는 대로 주택담보대출 106백만원과 신용대출 12백만원으로 나누어 대출받았다고 진술하고 있는 점 등을 감안시 계약 당사자간에 본건 신용대출 채무를 이 사건 근저당권의 피담보채무에서 제외하기로 하는 개별약정이 있었다고 볼 수 있는 점.

④ 한정근저당은 특정 종류의 여신거래 채무에 한정하여 담보하는 근저당으로 모든 채무를 담보하는 포괄근저당과 달리 피담보채무 범위를 정함에 있어 구체적으로 담보하는 여신거래 종류를 한정하여야 하는 바, 본건의 경우 피담보채무 범위가 ‘증서대출’로만 기재되어 있고 개인여신 대부분이 증서대출에 해당하는 등 피담보채무 범위가 명확치 아니한 바, 본건 근저당권이 주택담보대출과 그 성격을 달리하는 신용대출까지 포함하기로 하는 당사자 합의가 있었다고 보기 어려운 점.⁹²⁾

라. 결 론

그렇다면 본건 근저당권의 피담보채무는 2010.9.17.자 ○○모기지론 대출에 한정된다고 봄이 타당하다 할 것임.

조합의 신규 주택담보대출 취급시 담보가치에 대한 대출취급가능금액의 비율인 “담보인정비율”(LTV, Loan-to-Value ratio) 규제가 적용되는데, 본건 부동산의 경우 수도권 아파트로서 70%가 적용됨.

92) 금감원에서는 2013.7.12. 부적절한 한정근저당 운영으로 인한 소비자피해를 방지하기 위해 한정근저당 설정시 피담보채무 범위를 특정종류 여신으로 구체적으로 기재하도록 하며, 피담보범위를 지정하지 않거나 포괄적으로 정한 기존 근저당에 대하여는 대출내용에 맞게 담보범위를 축소·제한하도록 지도하였음.

제3절 제3자담보 제공

2-10 제3자담보인 경우 피담보채무 범위에 차주의 보증채무가 포함되는지

[인용] 차주의 보증채무는 다음과 같은 점에 비추어 볼 때 본건 근저당권의 피담보채무범위에 포함되지 아니함. 채권최고액이 대출금액에 신탁 소정의 담보취득비율(150%)을 적용한 금액과 정확히 일치하고 있는 점, 제3자가 담보제공한 점, 차주가 보증한 대출에 대하여 연대보증을 세우는 등 별도의 채권보전대책을 강구한 점, 근저당권 설정계약서의 피담보채무 범위에 차주의 보증채무가 포함된다는 내용이 명시적으로 기재되어 있지 아니한 점. 또한 신청인이 차주 명의 대출을 전액 대위변제하였으므로 본건 근저당권에 의한 피담보채무는 존재하지 아니하는 것으로 판단됨.(1999.8.24. 조정번호 제1999-33호)

가. 사실관계

○○신용협동조합(이하 “피신청인”이라 함)은 1991.8.23. A씨와 근저당권설정계약⁹³⁾(채권최고금액 30백만원, 이하 “본건 근저당권”이라 함)을 체결하고 B씨에게 일반대출금 20백만원⁹⁴⁾(이하 “대출A”라 함)을 취급함.

피신청인은 1994.3.23. 본건 근저당권에 터 잡아 B씨에게 일반대출금 20백만원(이하 “대출B”라 함)을 취급하였고, 신청인은 1994.6.12. 본건 부동산을 매수하였으며 그 이후 신청인은 대출B에 대한 이자 및 원금을 분할상환하여 왔음.

1999.4.17. 피신청인이 본건 부동산을 경매 신청하였고, 1999.7.7. 신청인이 B씨 명의의 대출금(대출B) 잔액을 전액 대위변제한 후 근저당권 말소를 요청하였으나, 피신청인은 B씨의 보증채무가 2건⁹⁵⁾ 남아 있다며 신청인의 요청을 거절함.

93) “채권자의 채무자에 대한 증서대출...(중략)... 기타 각종의 원인으로 채무자가 채권자에 대하여 현재 부담하고 있거나 또는 장래 부담하게 될 모든 채무를 공동담보하기 위하여...(이하 생략)”라고 기재되어 있는 포괄근저당권임.

94) 1994. 3. 23. 이전에 상환되었으나 전산시스템 변경으로 상환일자를 확인할 수 없다 함.

95) 피신청인이 1994.1.18.과 1994.2.15에 취급한 2건의 일반대출금(합계 20백만원)에 B씨가 타인과 함께 연대보증하였음.

나. 당사자의 주장

(1) 신청인의 주장

1991. 8. 23. 근저당권설정계약을 체결할 당시 담보제공자 A는 차주와는 제3자의 관계에 있었으므로 차주의 보증채무에 대하여까지 담보를 제공할 사유가 없었으므로 차주의 보증채무까지 담보책임을 요구하는 것은 부당함.

(2) 피신청인의 주장

담보제공자인 신청의 A가 본건 근저당권설정계약서에 자서날인하였으므로 “채무자가 채권자에 대하여 현재 부담하고 또는 장래 부담하게 될 모든 채무를 담보”한다는 본건 근저당권설정계약서의 문언에 따라 B의 보증채무도 본건 근저당권의 피담보채무범위에 포함됨.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 1991. 8. 23. 작성된 근저당권설정계약서에 의한 피담보채무범위에 채무자의 보증채무가 포함된다고 볼 수 있는지 여부임.

(1) 근저당권의 피담보채무범위에 관한 일반적 해석기준

근저당권의 피담보채무범위에 관하여 대법원 및 금융분쟁조정위원회는 근저당권설정계약서가 정당하게 작성되었고 실질적인 증거능력이 있으면 원칙적으로 그 기재된 내용에 따라 피담보채무의 범위를 인정하나, 담보제공 동기와 경위, 피담보채무의 내용, 은행의 담보운용내용 및 대출취급 관행 등에 비추어 그 기재된 내용과는 달리 개별약정의 요소가 있었던 것으로 볼 수 있는 경우에는 그 개별약정의 내용에 따라 피담보채무의 범위를 제한적으로 해석하고 있음.⁹⁶⁾

따라서 본건 근저당권 설정계약에 있어서도 개별약정으로 볼 수 있는 사정의 유무에 따라 피담보채무의 범위를 판단하여야 할 것임.

96) 대법원 1994.11.25. 선고 94다8969 판결, 금융분쟁조정위원회 조정번호 제1997-20호 등 참조.

(2) 본건 근저당권의 피담보채무범위

피신청인은 본건 근저당권의 피담보채무범위는 근저당권설정계약서의 문언대로 채무자 B의 보증채무까지 포함된다고 주장하고 있으나, 아래와 같은 제반정황에 비추어 볼 때 본건 근저당권의 피담보채무범위는 B명의 대출A 및 대출B에 국한되는 것으로 판단됨.

① 본건 근저당권의 채권최고금액(30백만원)은 피신청인이 B명으로 취급한 대출A(20백만원) 및 대출A가 상환된 후 취급한 대출B(20백만원)에 대하여 적용한 담보취득 내용을 살펴 볼 때 피신청인의 내규에 의한 소정의 담보취득비율(대출금액의 150% 해당액)을 적용한 금액(30백만원)과 일치하므로 차주의 보증채무까지 담보범위에 포함시킨 것으로 보기 어려운 점.

② B가 보증한 피신청인의 1994.1.18.자 및 2.15.자 대출과 관련하여 피신청인이 본건 근저당권을 원용한 사실이 없을 뿐만 아니라 다른 연대보증인을 세우는 등 별도의 채권 보전조치를 강구하였으며, 상기 대출이 1996.1.18. 및 2.15.에 각각 상환기일이 경과하였음에도 1999.4.17.에 이르러서야 피신청인이 본건 부동산에 대하여 경매를 신청한 점에 비추어 볼 때, 피신청인이 B의 보증채무를 본건 근저당권의 피담보 채무로 인식하고 있었다고 보기 어려운 점.

③ 본건 근저당권 설정계약서의 피담보채무범위에 차주의 보증채무가 포함된다는 내용이 명시적으로 기재되어 있지 아니한 바, 약관의 내용이 불명료한 경우에는 작성자에게 불리하게 해석하여야 한다는 약관해석의 일반원칙에 따라 차주의 보증채무가 피담보채무범위에 포함된다고 해석하기 어려운 점.

라. 결 론

위에서 살펴본 바와 같이 본건 부동산의 매수자인 신청인이 부담하여야 할 담보책임은 피신청인이 B에게 취급한 일반대출금(대출A 및 대출B)에 국한되는 것으로 판단되며, B명의의 대출금은 현재 전액 상환되었으므로 본건 근저당권에 의한 피담보채무는 존재하지 아니하는 것으로 판단됨. 따라서 본건 근저당권은 말소되어야 하며 본건 근저당권에 터 잡은 경매진행도 취하되어야 할 것으로 판단됨.

2-11 근저당권 전용(유용) 허락을 받지 않은 제3자 포괄근저당의 담보 효력

[인용] 본건 대출을 취급시 “근저당권설정계약 전용신청서”를 신청인이 작성하지 않은 점, 본건 대출금으로 신청인 명의의 대출금을 상환한 사실은 인정되나 이러한 사정만으로 신청인이 본건 근저당권의 전용을 허락한 것으로 보기는 어려운 점, 신청인이 그 동안 본건 근저당권에 대하여 이의제기를 하지 않다가 최근 前 남편의 도피 이후에 근저당권의 말소를 구하고 있다는 사정만으로 신청인이 본건 근저당권의 전용을 허락하였다거나 사후추인을 하였다고 보기 어려운 점 등을 감안시 본건 대출시 전용되었다고 보기 어려워 본건 근저당권이 본건 대출채무를 담보한다고 볼 수 없음.(2011.7.12. 조정번호 제2011-43호)

가. 사실관계

2000.5.2. 피신청인은 신청인을 채무자로 하여 가계자금대출 120백만원을 취급하고, 신청인 소유의 본건 부동산에 1순위의 포괄근저당을 설정(채권최고액 : 144백만원, 이하 “제1근저당권”이라 함)하였음.

2000.12.30. 피신청인은 A기업⁹⁷⁾을 채무자로 하고 신청인을 담보제공자로 하여 본건 부동산에 2순위 포괄근저당권을 설정(채권최고액 91백만원, 이하 “본건 근저당권”이라 함)⁹⁸⁾하였고, 2003.1.3. A기업의 기업일반자금대출 할인어음의 만기도래시 상환되어 본건 근저당권의 피담보채무는 소멸함.

2003.4.23 피신청인은 신청인을 채무자로 하여 가계자금대출(○○○○대출) 90백만원을 취급(제1근저당권 활용, 신청인의 기존 가계일반자금대출금 상환)하였음.

2006.7.25. 피신청인은 A기업을 채무자로 하여 기업통장대출 80백만원(이하 ‘본건 대출’이라 함)을 취급하고, 본건 근저당권을 활용⁹⁹⁾하였으며, 그 다음날(2006.7.26.) 위 A기

97) A기업의 대표자 B씨는 신청인의 전 배우자(‘07.12월 이혼)임.

98) A기업에 대한 대출은 기업일반자금대출(할인어음 취급을 위한 한도거래)이며, 본건 근저당권은 근저당권설정계약서는 ‘포괄근저당’이나 은행 내부 전산망에는 ‘한정근저당’으로 등록되어 있음.

99) 본건 대출취급 당시 신청인 명의의 ‘근저당권설정계약전용신청서’가 작성되어 있는데 은행은 신청인이 직접 자필서명 및 날인을 하지는 않았으나 당일 남편과 같이 지점을 방문하여 뒷자리에 앉아서 대기하였다고 주장하는 반면, 신청인은 본건 대출에 대하여 전혀 알지 못하며 본건 대출당시 은행에

업의 기업통장대출 실행계좌에서 70,267,304원이 인출되어 신청인의 위 가계자금대출금(○○○○대출) 전액이 상환되었음.

2011.4.15. 피신청인은 A기업 및 대표자의 예금 등에 대해 지급정지 조치(사유 : 대표자 도피)를 취하였고, 같은 해 5.7. 신청인은 본건 부동산을 제3자에게 매도(2011.7.29. 잔금일)하였으며, 같은 해 5.11. 피신청인은 신청인의 요청에 의해 피담보채무가 존재하지 않는 제1근저당권 말소등기를 이행하였음.

한편, 2011.5.11. 신청인은 2006.7.25.자 A기업의 기업통장대출은 본인이 모르는 것이라고 하면서 금융감독원에 본건 근저당권의 말소를 구하는 분쟁조정을 신청하였음.

나. 당사자 주장

(1) 신청인 주장

신청인은 2000.12.29. 前남편이 은행에서 사업자금대출을 받을 때 본건 부동산을 담보로 제공하여 본건 근저당권이 설정되었고, 2003년 前남편이 동 대출금을 전부 상환하였지만 은행직원이 향후 재대출시 설정비용을 다시 부담해야 하므로 본건 근저당권을 해지하지 말 것을 권유하여 해지하지 않은 것임.

신청인은 前남편과 2004년 이후 별거 중(2007.12월 이혼)이었으며, 최근 가족의 분가 때문에 본건 부동산(아파트)을 매도하기 위해 피신청인에게 본건 근저당권의 해지를 요청하였으나, 피신청인은 신청인과 관계없는 A기업에 대한 본건 대출금을 이유로 본건 근저당권의 말소를 거부하고 있음.

신청인은 前남편과 별거 이후 이루어진 A기업의 본건 대출에 대해 전혀 알지 못하고, 본건 대출 당시 은행에 방문한 사실도 없으며, 본건 근저당권과 관련된 ‘근저당권설정계약전용신청서’에 자필서명 및 날인을 한 사실이 없어 A기업에 대한 본건 대출은 본건 근저당권의 피담보채무로 볼 수 없으므로 본건 근저당권은 말소되어야 함.

(2) 피신청인 주장

방문한 사실도 없고, ‘근저당권설정계약전용신청서’에 자필서명 및 날인을 한 사실이 없다고 주장함.

2006.7.25. A기업에 대한 본건 대출 취급 당시 신청인은 A기업의 대표자인 前 남편과 동행하여 은행을 방문하여 뒷자리에 대기하고 있었고, 당시 신청인이 본건 ‘근저당권 설정계약전용신청서’에 직접 자필서명 및 날인을 하지는 않았으나, A기업의 대표자인 前 남편이 대신하여 자필서명 및 날인을 한 것이며, 본건 대출취급 다음날 본건 대출금으로 신청인 명의의 대출금(2003.4.23. 취급된 ○○○○대출)이 전액 상환되었으므로 본건 근저당권 전용은 신청인의 前 남편이 신청인을 대리하여 이루어진 것으로 유효함.

또한 지금까지 전혀 이의제기가 없다가 前 남편이 잠적한 이후에 본건 근저당의 말소를 신청한 점에 비추어 볼 때 신청인은 본건 근저당의 전용을 인지하고 있었을 것으로 판단되는바, 신청인의 주장은 수용 곤란함.

다. 위원회 판단

◆ 본건의 쟁점은 본건 근저당권이 2006.7.25.자 A기업의 본건 대출채무를 담보한다고 볼 수 있는지 여부라 할 것임.

(1) 근저당권의 피담보채무 범위에 관한 일반적인 해석

근저당권의 피담보채무 범위에 관하여 대법원 및 우리 원 분쟁조정위원회는 근저당권 설정계약서가 정당하게 작성되었으면 원칙적으로 처분문서의 기재된 내용에 따라 피담보채무의 범위를 인정하고 있으나, 그 기재내용과 다른 특별한 묵시적, 명시적인 개별약정의 요소가 있는 경우에는 그 개별약정의 요소에 따라 피담보채무의 범위를 제한해석하고 있음.¹⁰⁰⁾

계속적 거래계약에 기한 채무를 담보하기 위하여 존속기간의 약정이 없는 근저당권을 설정한 경우에 그 거래관계가 종료됨으로써 피담보채무로 예정된 원본채무가 더 이상 발생할 가능성이 없게 된 때에는 그 때까지 잔존하는 채무가 근저당권에 의하여 담보되는 채무로 확정되며, 이 때 근저당권을 설정한 채무자나 물상보증인은 근저당권자에 대한 의사표시으로써 피담보채무의 확정을 구할 수 있고 그 확정 당시에 피담보채무가 존재하

100) 대법원 2005.7.28. 선고 2005다22565 판결, 금융분쟁조정위원회 조정번호 제2000-18호, 제2003-1호 등 참조.

지 아니하게 되었다면 근저당권의 말소를 구할 수 있음.¹⁰¹⁾

(2) 본건 근저당권이 2006.7.25.자 본건 대출채무를 담보한다고 볼 수 있는지 여부

본건의 경우, 다음과 같은 점에 비추어 볼 때 본건 근저당권이 2006.7.25.자 A기업의 대출채무를 담보한다고 볼 수 없다고 판단됨.

① 포괄근저당은 채권최고액의 범위 내에서 채무자의 현재 및 장래의 모든 채무를 담보하는 것이 원칙이나, 피신청인의 여신업무지침 제132조(근저당권설정계약서의 전용)에는 “피담보채권이 소멸된지 상당기간이 경과하였으나 근저당권설정등기가 말소되지 않은 경우, 이 저당권설정등기를 담보로 신규여신을 취급하고자 할 경우에는 「근저당권설정계약 전용신청서」를 징구하고 확정일자를 받은 후 종전 설정계약서와 함께 편철 보관한다.”고 규정되어 있는 바, 동 규정은 근저당권의 피담보채무가 소멸된 지 상당기간이 경과한 때에는 해당 근저당권은 효력이 소멸된 것으로 보아 「근저당권설정계약 전용신청서」 없이는 근저당권의 전용을 하지 못하도록 한 것으로 보이는 점.

② 그런데, 본건에 있어서는 피담보채무가 소멸된 시점(2003.1.3.)으로 3년 6개월여가 지난 시점(2006.7.25.)에 피신청인이 채무자 A기업에 대해 본건 대출을 취급하면서 신청인 명의의 「근저당권설정계약 전용신청서」를 징구하기는 하였으나, 동 「근저당권설정계약 전용신청서」는 신청인이 작성하지 않은 것으로 양 당사자가 인정하고 있어 신청인이 대리권을 수여하였다거나 표현대리를 인정할 만한 객관적 사정이 입증되지 않아 그 효력을 인정할 수 없는 점.¹⁰²⁾

③ 또한, 2006.7.21.자 채무관계인 본인확인서에 前남편의 신분증과 신청인의 신분증(주민등록증)이 나란히 복사되어 있으나, 신청인은 운전면허증만 주로 이용하고 있어 주민등록증이 복사되어 첨부된 경위를 알지 못한다고 주장하고 있는 점.

④ 본건 대출금으로 신청인 명의의 대출금(2003.4.23. 취급된 뉴스피드대출)을 상환한 사실은 인정되나 이러한 사정만으로 신청인이 본건 근저당권의 전용을 허락한 것으로

101) 대법원 1996.10.29. 선고 95다2494 판결 참조.

102) 피신청인은 본건 대출 당시 신청인이 내점하여 뒷좌석에서 대기하고 있었다고 주장하나 신청인은 이를 부인하고 있고, 달리 이를 입증할 증거가 없어 피신청인의 주장은 인정하기 곤란함.

보기는 어려운 점.¹⁰³⁾

⑤ 신청인이 그 동안 본건 근저당권에 대하여 이의제기를 하지 않다가 최근 前 남편의 도피 이후에 근저당권의 말소를 구하고 있다는 사정만으로 신청인이 본건 근저당권의 전용을 허락하였다거나 사후추인을 하였다고 보기 어려운 점.¹⁰⁴⁾

라. 결 론

그렇다면 본건 근저당권은 피담보채무가 소멸된 지 상당한 기간이 경과하였으나 유효한 「근저당권설정계약 전용신청서」가 작성되지 않아 본건 대출시 전용되었다고 보기 어려워 본건 근저당권이 본건 대출채무를 담보한다고 볼 수 없으므로, 피신청인은 본건 근저당권설정등기를 말소할 의무가 있다 할 것임.

2-12 제3자담보인 경우 근저당권 설정 이전의 기존채무까지 포함하는지 여부

[인용] 근저당권 설정경위 및 담당직원 진술 등을 감안할 때 본건 근저당권 설정 당시 신청인과 피신청인 간에는 해당기업의 기존채무는 피담보채무 범위에 포함시킬 의사가 없었던 것으로 보이는 점, 만약 피신청인이 근저당권 설정 당시 해당 기존채무를 피담보채무로 포함시킬 의도였다면, 담보제공자인 신청인에게 기존 채무의 내용을 알려주는 것이 합리적인데도 그러한 사실이 확인되지 않고, 기존채무와 새로운 담보대출금을 합한 금액의 120%를 채권최고액으로 기재토록 권유하여야 할 것인데도 이 보다 훨씬 적은 금액을 채권최고액으로 기재토록 권유한 점 등을 감안시 본건 포괄근저당의 효력은 해당기업의 기존채무는 제외되고 책임범위 또한 이에 한정되는 것으로 보는 것이 타당하다고 할 것임.(2011.9.6. 조정번호 제2011-50호)

103) 신청인은 前 남편과 별거 이후 前 남편에게 신청인 명의의 대출금(2003.4.23. 취급된 ○○○○대출)을 상환하도록 지속적으로 요청하여 동 대출이 상환된 것이라고 주장하고 있는 점에 비추어 볼 때, 신청인이 또 다시 前 남편과 관련된 채무에 근저당권의 전용을 허락하였다고 가정하기는 곤란함.

104) 신청인은 최근 본건 부동산(아파트)을 매도하기 위해 본건 근저당권의 피담보채무가 없는 것으로 생각하고 말소를 구하였으나 피신청인이 본건 대출채무 때문에 말소가 불가하다고 하여 비로소 본건 대출채무에 대해 알게 되었다고 주장함.

가. 사실관계

2009.5.26. 신청인은 A기업의 부탁을 받고 동 회사가 피신청인으로부터 5억원(이하 ‘본건 담보대출’이라 함)을 대출받을 때 신청인 소유의 부동산을 담보로 제공하여 근저당권을 설정¹⁰⁵⁾(포괄근저당, 채권최고액 8.4억원, 이하 “본건 근저당권”이라 함)하여 주었음.

피신청인의 담당직원의 경위서에 따르면, “본건 근저당권 설정 당시 담당 직원은 신청인에게 본건 담보물로 7억원 정도 대출이 가능하다고 하였고, 대출금 5억원의 120%인 6억원을 채권최고액으로 기재할 것으로 권유하였으나 신청인이 추가대출을 고려하여 채권최고액을 8.4억원으로 기재하였다.”고 함.

2010.1.29. 신청인은 A기업이 신청인의 동의 없이 피신청인으로부터 추가로 2억원을 대출할 것을 걱정하여 본건 근저당권의 채권최고액을 2억원 만큼 감액하기 위해 피신청인 담당직원과 협의하였는데, 피신청인이 채무자(A기업) 명의로 대출받을 수 있는 금액이 1.2억원¹⁰⁶⁾이라고 하자 신청인은 채무자 명의로 1.2억원을 대출받고 신청인의 여유자금 80백만원을 합하여 2억원의 중금채를 피신청인으로부터 구입 후 동 중금채를 피신청인에게 담보로 제공(질권설정)하고 본건 근저당권의 채권최고액을 2.4억원 만큼 감액(8.4억원 → 6억원)하여 변경 등기함.

2010.9.30. 신청인은 A기업 명의의 2010.1.29.자 대출금 1.2억원을 변제하고, 2010.10.11. A기업 명의의 2008.11.12.자 대출금 80백만원 및 2009.5.26.자 대출금 5억원을 각각 변제하였으며, 2010.10.11 A기업의 나머지 채무에 대하여 A기업의 예금담보액으로 모두 상계처리하여 A기업 명의의 모든 채무는 소멸됨.

나. 당사자 주장

(1) 신청인 주장

105) 본건 근저당권 설정 당시 A기업의 피신청인에 대한 기존채무는 1.7억원이 존재하고 예금담보(질권 설정)는 71백만원이 존재함.

106) 2010.1.29. 채무자(A기업) 대출금: 6.7억원(기존대출 1.7억원, 본건 담보대출 5억원), 채무자 예금담보: 92백만원.

신청인이 본건 근저당권을 설정한 것은 A기업이 피신청인으로부터 5억원을 대출받을 수 있도록 하기 위한 것이고, 근저당권 채권최고액을 8.4억원으로 한 것은 채무자나 신청인이 향후에 추가로 2억원을 대출받기 위한 것이었고, 피신청인 담당 직원도 동 사실을 알고 있었음.

본건 근저당권 설정 당시 피신청인 담당직원은 차주(A기업)의 기존 채무에 대하여 아무런 설명도 하지 않았고, 신청인도 A기업의 기존 채무에 대하여 알지 못하였으므로 본건 근저당권이 A기업의 기존 채무까지 담보하는 것으로 보는 것은 부당함.

또한, 중금채 2억원을 피신청인에게 담보로 제공한 것은 본건 근저당권에 기해 A기업이 추가로 2억원을 대출받지 못하도록 하기 위해서 본건 근저당권의 채권최고액을 2.4억원 만큼 감액하기 위한 것인데, 당시 피신청인 담당직원은 채무자 명의로 추가대출이 1.2억원 밖에 안 된다고 하여 어쩔 수 없이 신청인의 자금 80백만을 추가하여 피신청인으로부터 중금채(2억원)를 구입한 후 이를 담보로 제공한 것으로 동 사실만으로 본건 근저당권이 A기업의 기존 채무까지 담보한다고 보기는 어려움.

그런데도 피신청인은 본건 근저당권이 단순히 포괄근저당권이라는 이유로 차주의 기존대출금 중 80백만원까지 상환하라고 하여 상환하였는바, 이는 부당한 상환이므로 반환하여야 함.

(2) 피신청인 주장

본건 근저당권 설정 당시 피신청인 담당직원은 신청인에게 본건 근저당권의 피담보채무가 현재 또는 장래의 모든 채무라고 설명하였으므로 채무자(A기업)의 기존 채무까지 담보의 효력이 미치는 것이고, 중금채를 담보로 제공할 당시 피신청인 담당직원이 A기업 명의로 1.2억원 밖에 대출이 안 된다고 한 것은 채무자의 기존 대출금과 예금담보를 고려할 때 본건 근저당권에 기해서는 1.2억원 밖에 담보여력이 안되었기 때문에 신청인이 자발적으로 80백만원을 추가로 제공하여 중금채를 구입하여 담보로 제공한 것이며, 신청인이 80백만원을 상환한 것은 2010.2.4.자 중금채 2억원의 근질권설정계약에 의한 담보책임의 일부로, 2008.11.12.자 대출금 중 80백만원과 2010.1.29.자 대출금 1.2억원을 상환함으로써 근질권의 담보책임을 이행한 것이므로 신청인의 주장은 수용할 수 없음.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 본건 근저당권이 근저당권 설정 이전부터 존재하던 채무자의 대출채무를 담보하여 신청인이 이에 대한 상환책임이 있는지 여부라 할 것임.

(1) 근저당권의 피담보채무 범위에 관한 일반적인 해석

근저당권의 피담보채무 범위에 관하여 대법원 및 금융분쟁조정위원회는 근저당권설정계약서가 정당하게 작성되었으면 원칙적으로 처분문서의 기재된 내용에 따라 피담보채무의 범위를 인정하고 있으나, 그 기재내용과 다른 특별한 묵시적, 명시적인 개별약정의 요소가 있는 경우에는 그 개별약정의 요소에 따라 피담보채무의 범위를 제한해석하고 있음.¹⁰⁷⁾

따라서 근저당권 설정계약서는 그 계약문언대로 효력을 발생하는 것이 원칙이지만 당해 대출금채무와 다른 채무의 각 성립경위 등 근저당권설정계약 체결의 경위, 대출관행, 각 채무액과 그 근저당 채권최고액과의 관계, 다른 채무액에 대한 별도의 담보확보 여부 등 제반 사정에 비추어 당사자의 의사가 계약서 문언과는 달리 일정한 범위내의 채무만을 피담보채무로 약정한 취지라고 해석하는 것이 합리적이라고 인정되는 경우에는 당사자의 의사에 따라 그 담보책임의 범위를 제한할 수 있다고 할 것임.

(2) 본건 근저당권의 피담보채무 범위 및 신청인의 책임범위

본건 근저당권의 피담보채무 범위에 관하여 살펴보면, 비록 근저당권설정계약서에는 피담보채무의 범위가 ‘포괄근저당’로 기재되어 있고, 통상 포괄근저당은 채무자의 채권자에 대한 현재 및 장래의 모든 채무를 담보하나, 신청인은 본건 근저당권 설정은 A기업이 피신청인으로부터 5억원을 대출받을 수 있도록 하기 위한 것이고, 근저당권 채권최고액을 8.4억원으로 한 것은 채무자나 신청인이 향후에 추가로 2억원을 대출받기 위한 것이며, 피신청인 담당 직원도 동 사실을 알고 있었다고 주장하고 있고, 피신청인의 담당 직원도 경위서에서 “본건 근저당권 설정 당시 신청인에게 본건 담보물로 7억원 정도 대

107) 대법원 1984.6.12. 선고 83다카2159 판결, 2005.7.28. 선고 2005다22565 판결, 금융분쟁조정위원회 조정번호 제2000-18호, 제2003-1호, 제2011-21호 등 참조.

출이 가능하다고 하였고, 대출금 5억원의 120%인 6억원을 채권최고액으로 기재할 것으로 권유하였으나 신청인이 추가대출을 고려하여 채권최고액을 8.4억원으로 기재하였다.”고 진술하고 있어 본건 근저당권 설정 당시 신청인과 피신청인 간에는 A기업의 기존채무는 본건 근저당권의 피담보채무 범위에 포함시킬 의사가 없었던 것으로 보이는 점.

만약 피신청인이 본건 근저당권 설정 당시 A기업의 기존 채무(1.7억원)를 피담보채무로 포함시킬 의도였다면, 담보제공자인 신청인에게 기존 채무의 내용을 알려주는 것이 합리적인데도 그러한 사실이 확인되지 않는 점.

또한, 본건 피신청인이 근저당권 설정 당시 A기업의 기존 채무를 피담보채무의 범위에 포함시킬 의도였다면, 기존채무와 새로운 담보대출금(5억원)을 합한 6.7억원의 120%인 8.4억원을 채권최고액으로 기재토록 권유하거나 당시 A기업의 예금담보액(71백만원)을 고려하여 733백만원을 채권최고액으로 기재토록 권유하여야 할 것인데도, 이 보다 훨씬 적은 6억원을 채권최고액으로 기재토록 권유하였다는 것은 거래관행에 비추어 합리적이지 않은 점.

피신청인은 신청인이 중금채 2억원을 구입하여 담보로 제공할 당시 신청인이 자발적으로 80백만원을 추가로 제공하였다고 주장하나, 이는 피신청인이 본건 근저당권의 피담보채무의 범위에 포함되지 않은 기존 대출금을 피담보채무의 범위에 포함시켜 1.2억원 밖에 추가대출이 안된다고 하여 신청인이 어쩔 수 없이 80백만원을 추가로 투입한 것으로 이를 신청인의 자발적인 추가 자금제공이라고 보기는 어려운 점.

피신청인은 신청인의 80백만원 상환은 2010.2.4.자 중금채 2억원의 근질권설정계약에 의한 담보책임의 일부로, 근질권의 담보책임을 이행한 것이므로 본건 근저당권의 피담보채무의 범위와는 별개라는 취지로 주장하나, 신청인이 2억원의 중금채를 구입하여 담보로 제공하게 된 것은 채무자인 A기업이 2억원의 추가대출을 받을 것을 우려하여 동 액수만큼 중금채로 담보를 제공하고 본건 근저당권의 채권최고액을 감액하고자 한 것인데, 피신청인 담당직원이 A기업의 기존 대출금을 본건 근저당권의 피담보채무의 범위에 포함시켜 1.2억원 밖에 담보여력이 없다고 하여 신청인이 하는 수 없이 80백만원을 추가로 투입하게 된 것으로 80백만원의 상환은 근본적으로는 본건 근저당권의 피담보채무의 범

위와 직결되어 있어 피신청인의 주장은 타당하지 않은 점 등을 종합적으로 고려해 볼 때, 본건 근저당권의 피담보채무는 A기업의 기존채무는 제외되고 5억원의 담보대출금과 향후 대출금에 한정되며 책임범위 또한 이에 한정되는 것으로 보는 것이 타당하다고 할 것임.

라. 결 론

그렇다면, 피신청인은 신청인에게 책임범위를 초과하여 부당하게 변제받은 80백만을 반환할 의무가 있다 할 것이므로 이를 인용함.

제4절 기타

2-13 담보제공자의 담보물 처분 요청권과 처분지체에 따른 담보권자의 책임

[일부인용] 신청인은 주식을 담보로 제공하고 금고로부터 대출을 받은 후 대출금이자를 납부하지 못하여 담보주식을 처분하여 대출금을 상환하고 잔액을 반환하여 줄 것을 요청하였음에도 금고가 담보주식을 처분하지 아니한 것은 부당하므로 담보주식 처분을 요청한 날의 종가를 적용하여 산정한 금액에서 대출금을 차감하고 잔액을 반환하여 줄 것을 요청하고 있는 바, 신청인에게 본건 담보주식의 처분요청권이 있다고 보기는 어려운 것으로 판단되나 피신청인이 상당한 사유없이 본건 담보주식 처분을 지연한 사실과 당사자간에 대환이 이루어진 사실이 각각 인정되므로 대환 이후의 대출금 이자에 대하여는 신청인에게 상환책임을 물을 수 없음.(1999.2.19, 조정번호 제99-1호)

가. 사실관계

신청인은 1995.2.10. ○○상호신용금고(이하 “피신청인”이라 함)로부터 50백만원의 「부금대출」(만기 2년, 이하 “본건 대출”이라 함)을 받으면서 A기업 주식 6천주 및 B기업 주식 4천주를 피신청인에게 담보로 제공¹⁰⁸⁾하였으며, 같은 해 10.20. 신청인은 위 대출금 50백만원중 27백만원을 상환하고 A기업 주식 6천주를 반환받음.

신청인은 1995.11.10.부터 본건 대출금 잔액 23백만원에 대한 이자를 납입하지 못하게 되자 1996.2.2. 피신청인을 방문하여 담보제공한 B기업 주식 4천주(이하 “본건 담보주식”이라 함)를 담보해지하여 자신에게 반환하거나 피신청인이 동 주식을 처분하여 본건 대출금을 회수하고 차액을 반환하여 줄 것을 피신청인에게 구두요청하였으나, 피신청인은 본건 대출금이 상환되지 않은 상태에서 담보를 해지해 줄 수 없다며 신청인의 요청을 거절함.

1996.4.19. 및 4.20.¹⁰⁹⁾ 신청인은 본건 담보주식을 같은 해 4.22.자로 처분하여 대출금을

108) 신청인은 위 담보제공시 담보제공증서, 양도증서, 처분위임장, 처분승낙서 및 주식실물을 피신청인에게 제출하고 피신청인으로부터 주식보관증을 교부받음.

회수하고 차액을 반환하여 줄 것을 피신청인에게 재차 구두요청하였으나, 피신청인은 피신청인 명의의 계좌를 이용하여 처분할 경우 주식매각시 발생하는 세금 등의 회계처리가 곤란하며 담보물건의 처분권은 담보권자에게 있다는 이유로 신청인의 요청을 거절함.

신청인은 1996.6.25. 본건 대출과 관련하여 납입한 부금(예금액 3,830,000원)을 해약하여 본건 대출의 연체이자를 정리하고 잔액 399,158원을 수령함과 함께 본건 대출원금 23백만원을 「계약금액내대출」¹¹⁰⁾(만기 2년)로 대환함.

1997. 9. 23. 피신청인의 여신담당직원이 신청인의 집을 방문하여 1997. 9. 30.까지 부족담보를 보충하고 연체이자를 정리할 것을 독촉하였으며 이에 대해 신청인은 담보주식 중 500주를 처분하여 연체이자를 정리해 줄 것을 요청하고 1997. 10월부터는 매월 대출이자를 납부하겠다고 1998. 3월말까지는 위 「계약금액내대출금」을 상환하겠다고 하는 내용의 이행각서를 작성해 주었으나 피신청인은 담보주식 중 일부 처분시 담보부족액의 발생이 확실시 된다고 신청인의 요청에 응하지 않음.

나. 당사자의 주장

(1) 신청인의 주장

1995.10.20. 본건 대출금 중 일부 상환후 본건 대출금 이자가 장기간 연체되어 대출채무의 기한이익이 상실됨에 따라 1996.2.2.부터 수차례 본건 담보주식을 처분할 것을 피신청인에게 요청하였으므로 피신청인은 이에 따라 담보권을 실행하여 대출금을 정리 하여야 함에도 정당한 이유없이 이를 거절하였으므로, 본건 담보주식 가격의 하락으로 인한 손해를 신청인에게 배상하여야 함. 따라서 피신청인은 본건 담보주식 4천주에 신청인이 주식처분을 요청한 1996.4.22.자 증권거래소의 종가인 주당 10,200원을 적용하여 산출한 금액으로 동 주식매매대금의 수도결제일인 1996.4.24. 현재를 기준으로 대출금을 정리하고

109) 신청인은 본건 담보주식 처분요청 일자에 대하여 처음에는 1996.3.29. 및 3.30.이라고 주장하다가 1998.11.23. 분쟁조정신청시에는 1996.4.19. 및 4.20.이라고 주장하고 있으며, 피신청인은 1996.3월경 동 구두요청을 받았다고 진술하고 있음.

110) 본건 대출과 관련하여 담보제공된 B기업 주식 4천주는 신청인이 동일자로 양도증서, 처분승낙서, 처분위임장 및 근질권설정계약을 작성·제출하여 계속 담보로 제공함.

그 잔액을 신청인에게 반환하여야 됨.

한편 1996.6.25. 본건 대출을 계약금액내대출로 대환하게 된 것은 피신청인이 결산업무 처리에 필요하다고 요청함에 따라 이뤄진 것이므로 이로써 피신청인이 담보주식 처분을 거절한데 따른 책임이 소멸된 것은 아니며, 1997.9.23. 이행각서 제출시 본건 담보주식 4천주중 5백주를 피신청인이 임의처분하여 연체이자를 정리해 줄 것을 요청하면서 앞으로 매월 이자를 정상납부할 것을 약속하였으나 피신청인이 담보주식 일부처분요청을 받아들이지 않음에 따라 이자납입 약속도 이행하지 아니함.

(2) 피신청인의 주장

신청인은 본건 주식을 담보해지하여 주거나 피신청인이 임의처분하여 대출금을 정리하고 차액을 반환하여 달라고 요청하였으나 피신청인의 대출규정상 대출금이 상환되지 않은 상태에서 담보해지가 불가능하고 피신청인 명의의 계좌를 이용하여 본건 담보주식을 처분할 경우 세금 발생시 회계처리가 곤란하며, 담보물건의 처분권은 담보권자에게 있으므로 이를 거절함.

다만, 신청인이 지정하는 날짜에 신청인 명의의 증권계좌를 개설하여 본건 담보주식을 처분하기로 신청인과 합의하였으나 신청인이 증권계좌 개설을 지연함에 따라 본건 담보주식을 처분하지 못하였으며 1996.5월초 신청인이 본건 담보주식의 처분시점을 피신청인에게 통보할 경우 신청인과 피신청인의 직원이 증권회사에 동행하여 본건 담보주식을 처분하기로 신청인과 합의하였으나 신청인이 처분 시점을 통보하지 아니함에 따라 본건 담보주식을 처분하지 못함.

또한 1996.6.25. 신청인은 본건 대출의 대환에 필요한 제반서류를 제출하고 동 서류에 자서날인한 후 본건대출을 “계약금액내대출”로 대환하였으므로 본건 분쟁이 종결되었다고 보아야 함.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 대출관련 담보설정자가 담보권자에게 동 담보물건을 처분하여 관련대출금을 정리하여 줄 것을 요청할 수 있는 권한이 있는지 여부라고 할 수 있음.

(1) 신청인의 담보물건 처분요청권 유무

신청인은 대출금의 기한이익이 상실됨에 따라 피신청인에게 본건 담보주식을 처분할 것을 요청하였으므로 피신청인이 이에 응하여 본건 담보주식을 처분하여 대출금을 회수하고 그 차액을 반환하여야 한다고 주장하나, 다음과 같은 점에 비추어 당사자간에 별도 약정이 없는한 신청인에게 담보물건 처분요청권이 있다고 보기는 어려운 것으로 판단됨.

① 신청인은 담보제공증서, 양도증서, 처분승낙서 등과 함께 본건 주식실물을 피신청인에게 제출하여 양도담보로 제공하였는바, 대법원은 이러한 경우 양도담보권자는 채무불이행시 담보물건을 처분하여 그 매각대금에서 채권원리금의 변제에 충당하고 나머지를 채무자에게 반환할 수 있으나 이는 담보권의 실행을 위하여 채권자에게 부여된 권리이지 채무자가 채권자에게 적극적으로 위와 같은 정산을 요구할 청구권을 가지는 것은 아니며 채무자가 채무를 변제하지 아니한 채 담보권을 실행한 후 그 정산금을 지급할 것을 청구한다 하더라도 이는 정산절차의 이행을 촉구하는 의미밖에 없다고 판시하고 있는 점.¹¹¹⁾

② 채무자가 양도담보물을 처분하여 채무변제에 충당할 것을 요청할 수 있다고 인정할 경우 이는 대물변제권을 인정하는 결과가 될 뿐만 아니라 사실상 담보물건의 처분시기를 담보설정자가 지정하게 되어 동 담보물건의 저가처분이 불가피할 수도 있어 채권자의 이익을 해할 수 있는 점.

(2) 피신청인이 담보물건 처분을 장기간 지연한데 따른 책임 여부

비록 신청인에게 양도담보물 처분요청권을 인정하기는 어렵다고 하더라도 금융기관은 이와 관계없이 대출금이 장기간 연체되고 대출채무자가 자력으로 대출금을 변제할 전망이 없는 때에는 특별한 사정이 없는한 통상적인 절차에 따라 적정한 가격으로 담보물건을 처분하여 대출금을 정리하여야 할 주의의무가 있다고 할 수 있는바, 본건의 경우 다음과 같은 점에 비추어 볼 때 피신청인이 본건 담보주식의 처분을 지연하고 있는데 대하여 객관적으로 합리적인 사유가 있다고 인정하기는 어려운 것으로 판단됨.

① 피신청인은 세금발생 등의 문제로 본건 담보주식의 처분이 곤란하였다고 주장하나

111) 대법원 1994.5.24. 선고 93다44975 판결 참조.

「상호신용금고여신거래기본약관」(제4조)에 의하면 담보처분과 관련하여 발생한 비용은 채무자가 부담한다고 규정되어 있으며, 대법원도 양도담보권자가 양도담보의 실행으로 양도담보의 목적물을 제3자에게 처분한 경우에 양도담보권자가 양도소득세를 납부하였다고 하더라도 이를 양도담보설정자에게 반환하여야 할 담보목적물의 처분대금에서 공제할 수 있다고 판시하고 있는 점.¹¹²⁾

② 피신청인의 「급부금 및 대출금정리규정」(제2조 및 제3조)에 의하면 6개월이상 연체된 정리대출금은 담보권의 실행 기타 법적 절차에 의하여 지체없이 회수정리한다고 규정되어 있으며, 더욱이 본건 대출의 경우 6개월이상 연체된 시점(1996. 5. 10.) 이전부터 신청인이 수차례 본건 담보주식 처분을 피신청인에게 요청하고 있었던 점.

③ 피신청인은 신청인이 증권계좌 개설, 본건 담보주식 처분일자 통보 등의 담보물건 처분을 위한 협조를 하지 않음에 따라 이를 처분하지 못하였다고 주장하나 본건 담보주식 취득시 양도증서, 처분승낙서, 위임장 등을 청구하였으므로 신청인의 협조가 없더라도 특별한 절차없이 본건 담보주식의 임의처분이 가능하였던 점.

이와 같이 피신청인이 본건 담보주식처분을 상당한 이유없이 지연한 점이 있으나 주식의 가격변동을 예견하는 것은 사실상 불가능에 가깝다고 할 수 있으므로 피신청인에게 본건 담보주식의 가격하락으로 인한 손해에 대하여 책임이 있다고 할 수는 없다고 판단되며, 다만 피신청인이 신청인의 요청 및 자체 대출금정리규정에 따라 적절한 시기에 본건 담보주식을 처분하였다면 대출금 이자가 더 이상 발생하지 않았을 것이라는 점을 감안할 때, 통상적인 절차에 따라 담보물건을 처분하여 본건 대출금을 정리할 수 있었던 때 이후에 발생하는 대출금 이자에 대하여는 그 상환책임을 신청인에게 묻는 것이 곤란하다고 보여짐.

따라서 다음과 같은 점에 비추어 볼 때 1996.6.25. 이후의 대출금 이자에 대하여는 그 상환책임을 신청인에게 물을 수 없다고 하는 것이 합리적이라고 판단됨.

신청인이 1996.2.2.부터 수차례 본건 담보주식 처분을 요청하고 있었으므로 본건 대출금이 정리대출금¹¹³⁾에 해당하게 된 1996.5.10. 본건 담보주식을 처분하였다면 본건 대출

112) 대법원 1994.8.26. 선고 93다15267 판결 참조.

원리금을 전액 정리¹¹⁴⁾할 수 있었던 점을 감안할 때 원칙적으로 동일자 이후의 대출금 이자에 대하여 상환책임을 물을 수 없다고 할 것이나, 1996.6.25. 신청인이 대출신청서 및 금전소비대차약정서 등 대환서류에 자서날인하여 본건 대출을 대환하고 당일까지의 연체이자를 정리하였다는 점.

라. 결 론

위에서 살펴 본 바와 같이 신청인에게 본건 담보주식의 처분요청권이 있다고 보기는 어려운 것으로 판단되나 피신청인은 상당한 사유없이 본건 담보주식 처분을 지연한 사실과 1996.6.25. 당사자간에 대환이 이루어진 사실이 각각 인정되므로 1996.6.25. 이후의 대출금 이자에 대하여는 신청인에게 상환책임을 물을 수 없다고 보는 것이 정당하다고 판단됨.

2-14 폐업한 차주사의 근질권 설정계약의 유효 여부

[기각] 은행이 예금담보대출 및 대환을 함에 있어 차주사의 폐업상태가 대출 및 대환 그리고 근질권설정계약의 효력에 영향을 미치는지 여부가 중요판단사항인 바, 사업자등록은 법인세법, 소득세법, 부가가치세법에 의하여 납세의무자에 해당하는 사업자를 정부(세무관서)의 대장에 수록하는 것을 말하는 것으로 법인격의 존속여부와는 무관한 것이므로 주채무자가 더 이상 영업을 하지 않는다는 이유만으로 본 건 대출계약을 무효라고 할 수는 없는 점 등으로 볼때 신청인의 청구를 기각함.(2003.6.10. 조정번호 제2003-21호)

가. 사실관계

2001.6.28. 당시 신청인의 대표이사 A씨는 피신청인 ○○은행(이하 “피신청인”)이

113) 피신청인의 「급부금 및 대출금 정리규정」(제2조 및 제3조)에 의하면 6개월이상 연체된 대출금은 정리대출금으로 분류하고 동 대출금은 지체없이 회수정리토록 되어있음.

114) 1996.5.10. 주식처분시 대금 : 1996.5.10.종가 9,580원 × 4,000주 = 38,320,000원
1996.5.13.(주식처분대금 수도결제일) 기준 본건 대출원리금 : 25,471,081원

라한다) 지점에서 피신청인과 주채무자를 B기업¹¹⁵⁾으로 하는 기업일반자금대출 40억원(변제기일 2001.8.28)에 대하여, 신청인 소유의 피신청인 발행 표지어음 40억원을 담보로 제공하는 근질권설정계약을 체결함.

피신청인은 당시 신청인 대표이사 A씨로부터 위 근질권설정계약 당시 이사회 의사록¹¹⁶⁾을 교부받고 근질권설정계약서에 자서날인을 받았으며, 입보시에는 사업자등록증, 법인인감증명서, 법인등기부등본, 정관의 각 서류를 징구하였음.

피신청인은 위 대출금을 2001.8.28. 외 5회(2001.9.28, 10.29, 2001.11.29, 12.29, 2002.1.28)에 걸쳐 기한연장을 하여 주었으며, 각 기한연장시 차주사의 사업자등록증, 이사회결의서 및 신청인 회사의 이사회입보결의서를 별도로 징구하지는 아니함.

2001.7.21. 위 A씨는 피신청인 지점에서 피신청인과 주채무자를 C기업으로 하는 기업일반자금대출 20억원(변제기 2001.10.20)에 대하여, 신청인 소유의 표지어음 20억원을 담보로 제공하는 근질권설정계약을 체결하였으며, 동 대출 건 역시 A씨가 이사회 의사록을 제출하였음.

피신청인은 위 대출금을 2001.10.20. 외 3회(2001.12.20, 12.29, 2002.1.28)에 걸쳐 기한연장을 하여 주었으며, 각 기한연장시 차주사 및 신청사의 이사회결의서를 징구함이 없이, 대출금 기한연장신청서에 차주사 대표이사의 자서날인과 담보제공자인 신청인 대표이사 A씨의 자서날인을 받았음.

2002.5.8. 피신청인은 신청인의 요청으로 기존의 대출금채무와 근질권설정계약을 B기업을 주채무자로 하는 기업일반자금대출 60억원을 취급함에 있어, 신청인의 이사회입보결의서를 징구하고 신청인의 대표이사 A씨부터 근질권설정계약서에 자필서명을 받고 신청사의 정기예금 60억원을 담보로 취득함.¹¹⁷⁾

115) 신청인의 대표이사 A씨(2003.2.17. 사임)는 1999.4.30.부터 2001.6.22.까지 B기업의 이사로 등기된 사실이 있음.

116) 본 건과 관련한 모든 대출과 대환에 제공된 신청인의 이사회 의사록에 대하여 신청인은 당시 대표이사 A씨가 이를 위조하여 피신청인에게 제출하였다고 주장함에 대하여 A씨는 이를 부인하고 있으며, 현재 신청인의 전 대표이사 A씨에 대하여 업무상배임, 업무상횡령 혐의로 수사 중에 있음.

117) 조사결과, 동 대출금은 주채무자 B기업의 기존대출금 40억원 및 C기업의 대출금 20억원에 대한 대

피신청인은 위 대환대출금 만기일(2003.1.6.)에 대출금이 상환되지 아니하자 2003.1.10. 신청인이 담보제공한 예금 원리금 합계 60억4천4백만원을 동 대출원리금과 상계 처리함 (미회수이자 6,127,000원).

나. 당사자의 주장

(1) 신청인의 주장

본건 대출 주채무자 B기업은 실제 영업행위를 하지 않는 전형적인 Paper Company로서 2001.6.30.자로 폐업된 회사이므로 실존하지 아니한 회사에 대한 2002.5.8.자 대출은 무효이므로 신청인의 근질권설정계약 역시 무효임. 피신청인 지점장은 당시 신청인 대표이사와의 친분관계 만으로 신규대출에 대한 적법한 절차에 의한 적격심사 없이 직권 폐업된 회사인 B기업에 대출을 하여 줌.

따라서 피신청인의 무효 내지는 부당한 업무처리에도 불구하고 2003.1.6. 피신청인이 신청인의 예금담보금과 B기업의 대출금을 상계 처리한 것은 부당하므로 예금 60억원의 반환을 요구함.

(2) 피신청인의 주장

신청인의 주장과는 달리 대출당시 신청인의 대표이사를 통하여 대출규정상 요구되는 모든 서류를 징구하였음. 사업자등록, 폐업여부는 세무상의 문제일 뿐, 법인의 존속여부와는 관계가 없는 것이므로 업무처리에는 부당함이 없음. 결국, 피신청인은 상계당시 담당 변호사의 의견을 기초로 하여 상계처리 한 것이므로 신청인의 청구를 수용할 수 없음.

다. 위원회의 판단

◆ 본 건의 쟁점은 은행이 예금담보대출 및 대환을 함에 있어 차주사의 폐업상태가 대출 및 대환 그리고 근질권설정계약의 효력에 영향을 미치는지 여부와 함께 피신청인이 신용조사를 하지 않은 것이 업무처리상 부당한 지 여부라고 할 것임.

환대출 성격임.

아래의 점을 종합하여 볼 때, 본 건 대출·근질권설정계약 및 이에 따른 대환계약은 유효하고 피신청인이 신청인의 예금과 본 건 대출금을 상계 처리한 것은 정당함.

① 신청인은 주채무자인 B기업이 실제 영업을 하지 않은 회사로서 2001.6.30.자로 폐업된 것으로 확인됨에도 불구하고 이를 확인하지 않고 소멸한 법인에게 2002.5.8.자 대출을 하여 준 것이므로 본 건 대출 및 대환은 무효이고 근질권계약의 부종성상 근질권설정계약도 무효라고 주장하나, 본래 사업자등록은 법인세법, 소득세법, 부가가치세법에 의하여 납세의무자에 해당하는 사업자를 정부(세무관서)의 대장에 수록하는 것을 말하는 것으로 법인격의 존속여부와는 무관한 것이므로 주채무자가 더 이상 영업을 하지 않는다는 이유만으로 본 건 대출계약을 무효라고 할 수는 없는 점.

② 피신청인의 대출담당직원은 각 차주사 및 신청인에 대하여 피신청인 여신규정 및 은행의 여신 실무상 요구되는 근질권설정계약서, 사업자등록증사본, 법인인감증명서, 법인등기부등본, 정관, 이사회 의사록(법인인감증명서 인감으로 원본확인대조필) 등의 법인의 권리능력확인서류와 대표이사의 대표권확인서류 및 제반 서류를 모두 징구하였으며, 그 업무에 절차상 하자가 없는 점.

③ 본 건 대출의 각 기한연장에 있어 피신청인은 담보증서를 점유하고 피담보채권 기타 조건의 변동 없이 근질권의 효력범위내에서 단순히 대출기한만의 연장을 해주었고 기한연장신청서의 기재에도 대표이사의 자필서명과 법인인감날인 등을 확인하였을 뿐 아니라 최초 담보제공에 대한 신청인 이사회의사록에 담보제공의 기한이 명시되어 있지 않아 기한연장시에는 별도로 이사회의사록을 신청인에게 요구하지 않은 것은 정당하다고 판단되는 점.

④ 나아가 신청인은 주채무자에 대한 신용조사를 하지 않은 점을 이유로 피신청인의 중과실 내지는 부당한 업무임을 주장하나, 본래 금융기관의 신용조사의 목적은 대손을 사전에 방지함으로써 은행의 자산건전성을 제고하고 부수적으로 건전한 여신의 확대와 수신거래의 기반을 확대하는데 있는 것임. 또한 「은행업감독규정」 제78조와 「은행업감독업무시행세칙」 제48조에 따른 피신청인의 여신규정에 의하면 채권의 회수가 확실한 예금담보대출의 경우 주채무자의 신용조사가 생략대상으로 되어 있어 현장방문에 의한 신

용조사가 이루어지지 않은 것이고, 여신의 범위에 있어서도 운전자금 한도를 별도로 산출하지 않고 있으며, 예금담보대출의 경우 기한연장시 사업자등록증을 별도로 금융기관이 요구하지 않는 것이 실무의 관행이라는 점에서 피신청인이 차주사에 대한 별도의 신용조사를 하지 않은 것으로 판단되는 점.

⑥ 피신청인이 2002.5.8. 위 40억과 20억의 각 대출과 관련하여 변제기에 이르러 차주사와 신청인의 요청에 따라 형식적으로는 신규대출시에 받는 약정서 등 통상의 대출관계서류를 제출 받으면서, 실질적으로는 새로운 신용조사를든지 구채무 변제와 신규대출의 실행으로서 자금의 수수 없이 다만 전표와 장부에 의하여 대체처리하고 단지 대출기간만을 연장하여 준 행위는 이른바 대환에 해당하고 이러한 대환의 법적 성격은 특별한 사정이 없는 한 기존채무가 여전히 동일성을 유지한 채 존속하는 준소비대차로 보아야 할 것¹¹⁸⁾이므로 앞서 본 바와 같이 각 본 건 대출과 근질권설정계약의 무효사유가 없으므로 위 대환 역시 유효하다고 판단되는 점.

라. 결 론

그렇다면 본 건 각 대출 및 근질권설정계약과 대환계약은 유효하다고 할 것이므로 결국, 2003.1.6. 피신청인이 신청인의 예금담보금과 B기업의 대출금을 상계처리한 것은 정당하므로 신청인의 청구는 이유 없어 이를 기각함.

2-15 부동산담보신탁에 있어 제2순위 우선수익자의 최우선 수익권 인정 여부

[기각] 동산담보신탁계약서 특약에 의하면, 수탁자는 신탁원본 수익자 및 우선수익자가 동의하고 신탁부동산에 대한 채권자의 이익을 해하지 않는 범위 내에서 적정하다고 인정될 경우에는 수익계약 방식 등으로도 처분할 수 있는 바, 신탁원본 수익자(건설사)와 제1순위 우선수익자(저축은행)가 수익계약 등에 의한 처분에 동의하였고 신청인은 우선수익자의 지위에 있지 아니하므로 본건 신탁부동산의 처분방법은 신탁계약에 부합됨.(2008.7.15. 조정번호 제2008-57호)

118) 대법원 1998.2.27. 선고 97다16077 판결 참조.

가. 사실관계

2004.11.5. 부동산 담보신탁계약을 체결하여 2004.11.8. 신탁 등기를 완료하였고, 동일자에 부동산 담보신탁 변경 계약을 체결하여 변경등기까지 완료함.

2004.12.14.~2005.5.6. 기간중 A부동산신탁은 신탁원본 수익자(B건설) 및 1순위 우선수익자(C저축은행, D저축은행)의 요청에 따라 공매가 아닌 수익계약 방식으로 신탁부동산 중 지하 101호, 지하 102호, 201호, 202호, 203호, 204호, 702호, 701호 등 총 8개(이하 “8개 신탁부동산”라 함)를 처분하고 부동산 담보신탁 등기를 말소함.

<처분대금 처리내역>

- 1순위 우선수익자(저축은행)에 대한 채무변제 : 1,100백만원
- 신탁원본 수익자(B건설)에 대한 지급 : 1,394백만원

2008.2.18. A부동산신탁은 공매절차에 의하여 신탁부동산 중 102호(421백만원) 및 105호(440백만원)를 매각하였으며, 신탁부동산 중 106호는 저가 매각을 방지하기 위하여 공매 진행을 중단함(공사 하도급업체가 유치권 행사 중).

2008.4.30. A부동산신탁은 제1순위 우선수익자인 C저축은행에 매각대금(861백만원) 중 부가세 등 제비용을 공제하고, 680백만원을 지급함.

나. 당사자 주장

(1) 신청인 주장

피신청인들은 신청인¹¹⁹⁾의 동의 없이 부당한 방법으로 “8개 신탁부동산”을 처분하였고, 또한 그 처분대금중 상당 금액을 신탁원본 수익자에게 근거없이 지급함으로써 제1순위 우선수익자에 대한 채무변제 금액이 축소되었고, 이 결과 제2순위 우선수익자인 신청인의 권리가 침해되었는 바, 상가 102호, 105호, 106호의 대각대금중 5억원은 신청인에게 우선적으로 지급되어야 할 것임.

신탁계약서상 우선수익자를 처분 대상 부동산(“8개 신탁부동산”)에 관한 우선수익자로

119) 신청인은 「부동산담보신탁 변경계약서」상의 2순위 우선수익자임(수익권리금 5억원).

제한하는 것은 타당하지 않고, 신청인의 경우에도 “8개 신탁부동산”의 처분에 관하여 많은 이해관계가 있으므로 A부동산신탁이 제2순위 우선수익자의 동의 없이 일방적으로 처분한 것은 부당함.

(2) 피신청인 주장

1) C 및 D저축은행

“8개 신탁부동산”은 신청인과 무관한 부동산이므로 신청인은 동 부동산의 처분 등과 관련하여 어떠한 권리도 주장할 수 없음.

2) A부동산신탁

“8개 신탁부동산”을 처분할 당시, 1순위 우선수익자에 대한 잔존채무 금액이 6억만원에 불과한 데 반해, 102호, 105호, 106호 등 총 3개 상가에 대한 감정평가 금액은 총 1,220백만원에 달하였는 바, 그 시점에서는 위의 3개 상가의 처분대금으로 1순위 및 2순위 우선수익자에 대한 채무 완제가 가능하였으나, 그 후 신청인과 신탁원본 수익자 사이의 민·형사상 법적 분쟁, 제3자의 유치권 행사 등으로 위 3개 상가에 대한 공매가 지연되어 연체이자가 급격히 증가하였고, 이로 인하여 2순위 우선수익자에 대한 채무 변제가 불가능하게 된 것이므로 신청인의 주장은 타당하지 아니함.

다. 위원회의 판단

◆ 본 사건의 쟁점은 신탁부동산의 처분 방법 및 신탁원본 수익자에 대한 처분대금의 지급이 불법 또는 부당한 지 여부임.

(1) 계약관련 특약사항

1) 부동산담보신탁 계약서

제2조 (처분방법등) 수탁자는 신탁원본 수익자 및 우선수익자가 동의하는 경우 신탁부동산에 대한 채권자의 이익을 해하지 않는 범위내에서 적정하다고 인정되는 방법으로 신탁부동산을 처분할 수 있다.

제7조 (신탁부동산의 처분) 수탁자와 신탁원본수익자는 이 신탁계약에 의한 신탁등기와 동시에 신탁부동산에 대한 처분 활동을 하기로 하며, 처분대금의 처리는 우선수익자와 협의하여 채무변제에 우선 충당하고, 나머지 금액은 신탁원본 수익자에게 교부하기로 한다.

2) 부동산담보신탁 변경계약서

제10조 (처분대금의 채무변제) ① 수탁자는 102호 매각시 150백만원, 105호 매각시 175백만원, 106호 매각시 175백만원을 제2순위 우선수익자에게 변제하기로 한다.

② 전1항에도 불구하고 제1순위 우선수익자의 채무변제 및 부대비용 집행 후 잔여금액이 호수별 변제금액에 미달하는 경우 제2순위 우선수익자에게 잔여금액 범위 내에서 채무를 변제하되, 수탁자는 동 신탁부동산 또는 타 신탁부동산 처분대금으로 제2순위 우선수익자의 채무가 완제될 수 있도록 제2순위 우선수익자에게 최대한 협조하여야 한다.

(2) “8개 신탁부동산”의 처분방법의 불법 또는 부당 여부

부동산담보신탁계약서의 특약사항 제2조에 의하면, 수탁자는 첫째, 신탁원본 수익자 및 우선수익자가 동의하고 둘째, 신탁부동산에 대한 채권자의 이익을 해하지 않는 범위 내에서 적정하다고 인정될 경우에는 수의계약 방식 등으로도 처분할 수 있는데, 다음과 같은 점을 고려할 때 8개 신탁부동산의 처분방법은 신탁계약에 부합됨.

① 신탁원본 수익자(B건설)와 제1순위 우선수익자(C저축은행, D저축은행)는 “8개 신탁부동산”의 수의계약 등에 의한 처분에 동의하였음.

② 신청인은 “8개 신탁부동산”에 대하여 우선수익자의 지위에 있지 아니하므로 신청인의 동의가 필요한 것은 아니고, 또한 신청인은 “8개 신탁부동산”에 대한 채권자에 해당되지 아니함.

(3) “8개 신탁부동산”의 처분대금을 신탁원본 수익자에게 지급한 것이 타당한 지 여부

본 신탁계약서의 특약사항 제7조 제1항은 “처분대금의 처리는 우선수익자와 협의하여 채무변제에 우선 충당하고, 나머지 금액은 신탁원본 수익자에게 교부하기로 한다”고 규정하고 있으므로 수탁자(A부동산신탁), 신탁원본수익자(B건설) 및 우선수익자(C저축은행

및 D저축은행)가 서로 협의하여 우선수익자에 대한 채권 충당액을 결정하고, 나머지 대금을 신탁원본 수익자에게 교부한 것은 신탁계약에 부합함.

다만, 신탁변경계약서 제10조 제2항은 “수탁자는 동 신탁부동산 또는 타 신탁부동산 처분대금으로 제2순위 우선수익자의 채무가 완제될 수 있도록 제2순위 우선수익자에게 최대한 협조해야 한다”고 규정하고 있으나, 신청인은 “8개 신탁부동산”에 대해서는 아무런 권한도 없고, 당해 조문이 단지 “협조하여야 한다”고 규정하고 있는 점 등에 비추어 볼 때, 신청인에게 “8개 신탁부동산”의 처분대금 중 일부를 지급할 의무가 발생한다고 보기 어려움.

라. 결 론

“8개 신탁부동산”의 처분방법이 불법 또는 부당하다고 보기 어렵고, “8개 신탁부동산”의 처분대금을 신탁원본 수익자에게 지급한 것은 당해 부동산 신탁계약에 부합되는 바, 피신청인들의 신탁계약 위반을 전제로 한 신청인의 청구는 이유없어 이를 기각함이 타당함.

2-16 소유권 변경으로 인한 근저당권의 효력 변경 여부

[기각] 근저당권이 소유권에 시간적으로 먼저 성립하였으므로 근저당권자인 피신청인은 신청인의 소유권에 구매받음이 없이 담보부동산에 대한 근저당권을 행사하여 그 경락대금으로부터 자기의 채권을 우선적으로 변제받을 수 있다 할 것임.(2009.2.10. 조정번호 제2009-8호)

가. 사실관계

2004.3.17. 피신청인은 A기업에 20억원의 대출을 취급하였고, 동일자에 A기업 및 B기업의 대표이사인 신청 외 C씨와 그의 소유 아파트를 담보물로 하는 포괄근저당권 설정계약(채권최고액 15.6억원, 채무자 A기업)을 체결하였으며, 2006.5.22. 상기 아파트에 대해 추가로 포괄근저당권(채권최고액 7억원, 채무자 B기업)을 설정하였음.¹²⁰⁾

2008.1.28. D기업은 위의 담보부동산에 대해 매매예약을 원인으로 소유권이전청구권을 가등기함(2008.4.23. D기업, 위의 가등기에 기해 소유권이전 등기 완료).

나. 당사자 주장

(1) 신청인 주장

신청인이 대표이사로 재임중인 D기업은 신청 외 E기업(대표이사 C씨)과 거래를 하던 중, E기업의 부도로 150억원의 손해를 보게 됨에 따라 채권의 일부라도 회수하기 위하여 신청인외 C씨 소유의 아파트에 대하여 2008.1.28. “소유권이전 청구권 가등기”를 완료하였고, 2008.4.23.에는 동 아파트의 근저당권자인 피신청인 지점으로부터 피담보채무가 14억원 정도인 것으로 확인한 후 본등기를 완료하였음(2차 분쟁조정 신청시에는 가등기 이전에 피신청인으로부터 그의 채권금액이 12억원임을 확인했다고 주장). 이로써 동 아파트의 소유권자가 C씨에서 D기업으로 바뀌었음에도 피신청인은 새로운 소유권자인 D기업에 아무런 통보도 없이 5억원 이상의 대출을 추가 취급한 것은 부당함. 따라서 피신청인은 신청인이 14억원을 대위변제할 경우 응당 동 아파트에 설정된 근저당권 등기를 말소해야 할 것임.

(2) 피신청인 주장

당 은행이 피담보채무를 14억원으로 안내했다는 신청인의 주장은 전혀 사실 무근이고, 오히려 2008.4월 중순경 신청인이 “C씨의 아파트에 가등기한 사람”이라고 밝히며 문의를 하였을 때, 당 은행이 피담보채무가 약 19~20억원 정도라고 안내하였고, 이에 신청인은 “부동산가격 감안시 14억원 정도 대출을 해주어야지 왜 초과해서 대출을 해 주었느냐?”고 항의까지 한 사실이 있음. 또한 당 은행은 동 아파트에 대한 저당권자로서 대출을 취급할 수 있는 것은 법적으로 당연하며, 정당한 대출취급에 대해 제3자인 신청인이 부당 운운하는 것은 타당하지 아니함.

120) 피신청인은 동일자에 B기업에 대해 통장자동대출(일명 ‘마이너스통장 대출’) 2억원을 취급하였고, 2006.8.25.에는 B기업과 지급보증거래약정서(한도 795백만원)를 체결한 후, 이를 근거로 2007.12.13.~2008.2.15. 기간중 4건의 수입신용장을 개설함(대지급금 577백만원).

다. 위원회 판단

◆ 본건의 쟁점은 담보물에 대한 소유권자가 변경되었을 경우 선순위의 근저당권자가 대출을 취급함에 있어 새로운 소유권자의 허락을 받아야 하는 지 여부임.

(1) 물권의 우선적 효력

동일물 위에 성립하는 물권(소유권, 저당권 등) 상호간에 있어서는 시간적으로 먼저 성립한 물권이 뒤에 성립한 물권에 우선함. 따라서 신청 외 C씨의 소유 부동산에 대한 근저당권의 등기일이 2004.3.17. 및 2006.5.22.이고, 신청인은 그 이후인 2008.1.28. “소유권이전 청구권 가등기”를 한 후, 같은 해 4.23. 본등기를 완료하였는바, 근저당권이 소유권에 시간적으로 먼저 성립하였으므로 근저당권자인 피신청인은 신청인의 소유권에 구애받음이 없이 담보부동산에 대한 근저당권을 행사하여 그 경락대금으로부터 자기의 채권을 우선적으로 변제받을 수 있다 할 것임.

또한, 근저당권자인 피신청인이 추가로 대출을 취급함에 있어 새로운 소유권자에 대해 이를 통보하거나 허락을 받아야 할 의무가 없음은 법리상 명백함. 다만, 피신청인은 피담보채무를 1,949백만원으로 파악하고 있으나, 제2순위 근저당권의 채권최고액은 7억원에 불과하고, 이를 초과하는 금액은 피담보채무의 범위에 포함되지 아니하는 바, 정확한 피담보채무는 1,872백만원임.(2008.8.29. 원금 기준)

(2) 손해배상 책임 유무

신청인의 전화 문의 당시(가등기 또는 본등기 이전) 피신청인이 피담보채무를 12억원 또는 14억원으로 안내했음을 이유로 피신청인에게 일정한 법적책임이 있다고 주장하고 있으나 이를 인정할 만한 증거가 없고, 설령 이것이 사실이라고 하더라도 피신청인이 적극적으로 채무자에게 추가대출을 취급하지 않았다고 확약한 사실이 입증되지 않는 한 피신청인의 손해배상책임을 인정하기 어려움.

라. 결 론

신청인의 청구는 이유가 없으므로 이를 기각함이 타당함.

2-17 아파트사업부지에 설정한 근저당의 효력이 상가부지에도 미치는지 여부

[기각] 당사자간 의사가 본건 근저당권의 목적물에서 상가부지를 제외시킬 의사였다면 근저당권설정계약시 향후 상가부지를 근저당권의 목적물에서 제외시키기로 유보하는 약정을 체결하거나, 상가부지의 분할시 상가부지를 근저당권의 목적물에서 제외하는 조치를 취하는 것이 상당함에도 이러한 조치들이 취해지지 않은 사정을 고려해 보면 신청인이 주장하는 사유만으로 본건 근저당권의 목적물에서 상가부지를 제외시키기로 하는 당사자들의 묵시적 합의가 있다고 단정하기도 어려움.(2011.5.17. 조정번호 제2011-32호)

가. 사실관계

2005.12.16. 피신청인은 신청외 A건설사에 임대주택건설자금 목적으로 2,780백만원을 대출하고 담보로 ○○시 소재 19필지(이하 “본건 사업부지”)에 대하여 채권최고액 36억 원의 근저당권을 설정함.

본건 대출당시, 피신청인은 공부상 본건 사업부지(9,937㎡)중 아파트부지(9,657㎡, 10억원) 및 건축될 아파트 170세대(6.7억원)에 대한 담보조사가격을 기준으로 담보물 평가를 하고 건축될 아파트 170세대의 전용면적을 기준으로 대출금을 안분적용하였으나, 근저당권은 아파트사업부지 및 상가부지(270㎡)를 포함한 본건 사업부지 전체(9,937㎡)에 대하여 설정하였음.

2007.4.11. A건설사는 본건 사업계획을 임대에서 분양으로 변경하고, 2009.2.16. 본건 아파트 준공검사를 마쳤으며, 2009.8.25. 피신청인은 대출조건을 임대주택자금대출에서 후분양자금대출로 조건변경하였음.

한편, 본건 사업부지는 2009.2.23. 전체 부지(9,937㎡)에 합병되었다가, 2009.3.3. 상가부지(270㎡)가 분할되었고, 2009.12.8. A건설사가 이자연체에 따라 기한이익을 상실함.

2010.4.30. ○○자산관리회사의 신청에 의해 지방법원에서 본건 아파트에 대한 부동산 임의경매 개시결정이 났고, 2011.2.1. 신청인은 지방법원의 화해권고결정¹²¹⁾에 따라 본건

121) 2008.6.16.자 신청인과 A건설사간 양도담보약정에 의한 소유권이전등기 절차를 이행하라는 결정임.

상가건물 및 상가부지에 대한 소유권을 취득하였으며, 2011.2.17. 상가부지 부분에 대한 근저당권의 말소를 구하면서 금융감독원에 분쟁조정을 신청함.

나. 당사자 주장

(1) 신청인 주장

본건 대출은 아파트건설자금 대출로 대출당시 아파트 관련 부분에 대해서만 담보물 평가가 이루어졌고 대출금도 아파트 세대별로 안분하여 적용되었으며, 본건 아파트 준공 후에도 아파트에 대해서는 세대별로 대출금을 안분한 후 별도의 근저당권을 설정하였으나 상가부분에 대해서는 대출금을 안분 적용하지 않는 등 본건 대출금의 담보물은 본건 사업부지 중 아파트 관련부분에 한정된 것으로 보아야 하며, 본건 근저당권 설정당시 아파트부지와 상가부지가 분할등기가 되어 있지 않아 어쩔 수 없이 상가부지를 포함한 전체 사업부지에 대해 저당권이 설정된 것일 뿐이므로 아파트 준공 후 분할등기된 상가부지에 대한 근저당권은 당연히 말소되어야 함.

(2) 피신청인 주장

본건 근저당권은 사업부지 전체에 설정된 것이고 저당권의 효력은 목적물인 토지가 분할되더라도 그 전체에 미치는 것이므로 상가부분에 대한 저당권도 유효하다 할 것이며, 현재 본건 대출금이 연체 중이고 아파트부분 또한 경매 진행 중에 있어 채권회수가 불분명한 상태이므로 채권회수 이전에 상가부지에 대한 근저당권 말소는 수용하기 어려움.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 본건 근저당권의 효력이 상가부지를 포함한 사업부지 전체에 대하여 미치는지 여부라 할 것임.

신청인은 본건 근저당권 설정시 아파트관련 부분에 대해서만 담보물 평가가 이루어졌다는 점 등을 이유로 상가부지는 근저당권의 목적물에 포함되지 않는다고 주장하나 다음과 같은 점에 비추어 신청인 주장을 인정하기 어렵다 할 것임.

① 담보물권의 불가분성에 의하여 저당권자는 피담보채권의 전부를 변제받을 때까지 목적물 전부에 대하여 그 권리를 행사할 수 있다 할 것인데(민법 제370조, 제321조 참조), 본건 근저당권은 등기부등본에 나타난 바와 같이 본건 사업부지 전체에 대하여 설정된 것으로 원칙적으로 분할된 상가부지에 대해서도 그 효력을 미친다고 할 것인 점.

② 처분문서의 진정성립이 인정되면 그 기재 내용을 부인할 만한 분명하고도 수긍할 수 있는 반증이 없는 한 원칙적으로 그 처분문서에 기재되어 있는 문언대로의 의사표시의 존재와 내용을 인정하여야 하는 것이 원칙이라 할 것인 바,¹²²⁾ 본건 근저당권설정계약서에 의하면 A건설사와 피신청인은 본건 대출에 대한 담보로 본건 사업부지 전체에 대하여 근저당권을 설정하는 것으로 약정하고 있고, 피신청인이 아파트관련 부분에 대하여만 담보물 평가를 하고 대출금을 아파트 세대별로 안분적용한 것은 임대주택건설사업의 시행에 따른 대출금의 회수가능성을 우선적으로 고려하고 있는 것이지 상가부지를 당연히 근저당권의 목적물에서 배제하고 있는 것이라고 보기 어려운 측면이 있으며, 오히려 당사자간 의사가 본건 근저당권의 목적물에서 상가부지를 제외시킬 의사였다면 근저당권설정계약시 향후 상가부지를 근저당권의 목적물에서 제외시키기로 유보하는 약정을 체결하거나, 상가부지의 분할시 상가부지를 근저당권의 목적물에서 제외하는 조치를 취하는 것이 상당하다고 볼 수 있는 여지가 크다 할 것인데 이러한 조치들이 취해지지 않은 사정을 고려해 보면 신청인이 주장하는 사유만으로 본건 근저당권의 목적물에서 상가부지를 제외시키기로 하는 당사자들의 묵시적 합의가 있다고 단정하기도 어려운 점.

③ 신청인도 2008.6.16. A건설사와 양도담보약정을 체결할 당시 본건 사업부지의 등기부등본을 통하여 상가부지가 본건 근저당권의 목적물에 속하고 있는 사실을 충분히 알 수 있었을 것으로 보이는 점.

라. 결 론

그렇다면 피신청인의 본건 사업부지에 대한 근저당권은 유효하다 할 것이므로 신청인의 청구는 이유 없어 이를 기각함.

122) 대법원 2005.5.27. 선고 2004다60065 판결 참조.

제1절 보증인에 대한 보증의사 미확인

3-1 금융기관이 직접 보증의사를 확인하지 아니한 경우의 보증책임 유무

[인용] 신청인이 알지도 못하는 자를 위하여 보증할 의사가 있었다고 인정할 만한 사정을 발견할 수 없고, 인감도장이 날인되고 인감증명서가 첨부된 사실만으로는 보증서류 작성과 관련하여 표현대리가 성립된다고 인정하기 어려운 점 등을 감안시 대출에 대한 보증계약이 유효하게 성립하였다고 볼 수 없음.(2000.2.15, 조정번호 제2000-11호)

가. 사실관계

신청인은 1997.3월 A씨(신청인의 친구)로부터 신청외 ○○신용협동조합에서 받은 대출(잔액: 4백만원)을 기한연장하는데 연대보증해줄 것을 요청받고 채무자 및 금액이 공란인 대출관련서류¹²³⁾에 인감을 날인하여 동 서류와 함께 인감증명서를 A씨에게 교부함.

1997.3.5. B씨(A씨의 친구)가 A씨로부터 상기 대출관련서류를 건네받아 차주를 B씨, 연대보증을 신청인 및 D씨로 하여 피신청인에게 적금대출 15백만원을 신청하였고, 3.7. 피신청인은 B씨에게 적금대출 15백만원(이하 “본건 대출”이라 함)을 취급하고 같은 해 4.16. 공정증서를 작성함.

1998.7.5. 차주 B씨가 대출금이자 및 적금 납입을 연체하자, 1998.10.2. 피신청인은 신청인에게 대출금 상환 독촉 최고서를 발송함.¹²⁴⁾

123) 대출서류의 연대보증인란에 A씨가 신청인의 주소와 성명을 기재하였다 함.

124) 피신청인은 1997.9.1. 및 1998.3.2.에도 차주 B씨가 대출금이자 및 적금납입을 일시 연체하여 신청인에게 대출금 상환 독촉 최고서를 발송한 바 있음.

1999.2.19. 차주 B씨가 대출금이자 및 적금 납입을 장기연체하자 피신청인이 지방법원에 신청인 소유 아파트(이하 “본건 아파트”라 함)에 대한 집행증서에 의하여 강제경매를 신청(1999.2.24. 지방법원이 강제경매개시결정을 함)하였고, 같은 해 3.22. 신청인은 금융감독원에 금융분쟁조정을 신청함.¹²⁵⁾

1999.6.21. 피신청인은 본건 아파트를 가압류하고 1999.7.1. 강제 경매신청을 취하였 으며, 같은 해 12.31. 본건 대출이 다시 연체되자 피신청인이 신청인에게 법적절차 착 수 통지서를 발송함.

나. 당사자의 주장

(1) 신청인의 주장

신청인은 A씨가 ○○신용협동조합에서 받은 대출금(4백만원)을 기한연장하는데 보증 하고자 서류에 인감을 날인하고 인감증명서를 교부하였으나 피신청인이 신청인으로부터 자서를 받거나 보증의사를 확인하지도 아니하고 신청인이 전혀 모르는 B씨에게 대출을 취급하였으므로 동 대출에 대하여 신청인에게 보증책임이 없음.

(2) 피신청인의 주장

신청인으로부터 직접 자서날인을 받지는 아니하였으나 통상적인 업무 처리관행에 따 라 차주에게 대출서류를 교부하여 채무관계자의 자서날인을 받아 오도록 하였고 관련 서류의 인감이 채무관계자의 정당한 인감과 일치함을 확인하고 대출을 취급하였으므로 표현대리에 의하여 신청인에게 보증책임이 있음. 또한, 신청인은 1999.3.22.자 금융분쟁조 정신청과 관련하여 본건 대출이 다시 연체될 경우에는 본건 아파트에 대하여 다시 강제 경매절차를 진행하기로 동의하였는 바, 이는 신청인이 보증책임을 인정한 것임.

다. 위원회의 판단

125) 1999.4.24. 금융분쟁조정위원회에 회부하였으나, 차주 B씨가 대출금을 매월 상환하기로 약속하여 피 신청인이 경매를 취하기로 함에 따라 1999.5.4. 신청인이 조정신청을 취하였고, 피신청인은 본건 아파트에 대한 경매를 취하나 채권보전을 위하여 본건 아파트를 가압류할 예정임을 안내함.

◆ 본건의 쟁점은 본건 대출관련 서류에 연대보증인으로 기재되어 있는 신청인과 피신청인간에 연대보증계약이 유효하게 성립되었는지 여부임.

(1) 본건에 대한 판단기준

금융기관은 타인이 차주나 보증인을 대리하여 서명날인을 하는 경우에는 동 대리행위가 본인의 의사에 따른 것인지를 확인한 후 대출취급하는 것이 일반적인 업무관행이며, 금융기관이 본인의 의사를 확인하지 아니하였으나 민법상의 표현대리가 성립됨을 주장하기 위하여서는 타인에게 대리권이 있다고 믿을 만한 정당한 사유가 있어야 함(민법 제126조).

대법원에서는 “보증인으로부터 직접 서명날인을 받거나 보증인의 보증의사가 객관적으로 표명된 인감증명서를 제출받도록 규정한 금융기관의 규정·지침을 위배하여 대출관련서류의 인영과 인감증명서의 인영만을 서류상으로 대조하여 계약을 체결한 경우 대리권이 있다고 믿은 데에는 정당한 이유가 없다”고 판시¹²⁶⁾하고 있음.

금융분쟁조정위원회에서도 금융기관이 보증인으로부터 자필서명을 받거나 본인에게 보증의사를 확인하지 아니하고 채무자가 보증인의 인감도장이 날인된 대출서류와 인감증명서를 소지하였다는 사실만으로는 연대보증계약의 표현대리가 성립하였다고 볼 수 없으므로 보증책임이 없다고 조정결정¹²⁷⁾한 바 있음.

(2) 본건 대출에 대한 연대보증계약의 유효성 여부

피신청인은 본건 대출관련 서류에 신청인의 인감도장이 날인되어 있고 인감증명서가 첨부되어 있어 신청인의 보증책임을 부인하기 어렵다고 주장하고 있으나, 다음과 같은 점에 비추어 볼 때 피신청인이 신청인의 연대보증의사를 확인하지 아니하고 취급한 본건 대출에 대하여 보증계약이 유효하게 성립하였다고 볼 수 없으므로 신청인에게는 보증책임을 존재하지 아니하는 것으로 판단됨.

① 피신청인의 「여신규정」 제58조 제1항에 의하면 대출서류의 금액과 주소, 성명은

126) 대법원 1998.7.10. 선고 98다15835 판결, 1976.7.13. 선고 76다1155 판결 참조.

127) 금융분쟁조정위원회 조정번호 제1999-3호 참조.

채무관계자(채무자, 연대보증인)가 자서날인하도록 되어 있음에도, 동 규정을 위배하여 신청인의 자서를 받거나 신청인의 보증의사를 확인하지 아니하고 대출취급한 사실이 확인되는 점.

② 피신청인은 본건 대출과 관련하여 공정증서를 작성하였으므로 신청인이 보증책임을 부담하여야 한다고 주장하나 피신청인의 직원이 채무자 및 채권자를 대리하여 공정증서를 수령한 후 동 공정증서를 신청인에게 교부한 사실이 없어 신청인이 본건 대출에 대한 보증계약이 성립된 사실을 알고 있었다고 보기 어려운 점.

③ 대법원은 “보증계약의 성립을 인정하려면 당연히 그 전제로서 보증인의 보증의사가 있어야 하고, 보증은 이를 부담할 특별한 사정이 있을 경우에 이루어지는 것이므로 보증의사의 존재나 보증범위는 엄격하게 제한하여 인정하여야 할 것이다”라고 판시¹²⁸⁾한 점에 비추어 신청인이 알지도 못하는 B씨를 위하여 보증할 의사가 있었다고 인정할 만한 사정을 발견할 수 없는 점.

④ 피신청인이 신청인에게 차주 B씨에 대한 연대보증의사를 확인하였음을 입증할 수 있는 자료가 없는 상황에서 대법원 판례 및 금감원 금융분쟁조정위원회의 조정입장에 비추어 볼 때 인감도장이 날인되고 인감증명서가 첨부된 사실만으로는 피신청인이 채무자에게 대리권이 있다고 믿을 만한 정당한 사유가 된다고 인정하기 어려우므로 피신청인은 연대보증인의 의사확인을 소홀히 한 과실이 있어 보증서류 작성과 관련하여 표현대리가 성립된다고 인정하기 어려운 점.

라. 결 론

위에서 살펴본 바와 같이 피신청인이 신청인의 자서날인을 받거나 보증의사를 확인하지 아니하고 취급한 본건 대출에 대하여 신청인에게 보증책임을 존재하지 아니하는 것으로 판단됨.

128) 대법원 1998.12.8. 선고 98다39923 판결 참조.

3-2 보증관련 서류가 도용된 경우의 보증계약의 효력

[인용] 제3자가 본인의 인감도장 및 인감증명서 등을 가지고 있었다는 점만으로는 제3자가 본인을 위하여 연대보증 등 계약을 체결할 권한이 있다고 믿는데 정당한 사유가 있었다고 보기 어려우며 타인의 대출에 대한 연대보증은 부부간의 일상가사대리권의 범위를 초과한 행위여서 배우자에게 보증의사를 확인한 것은 유효한 보증의사 확인방법이라고 볼 수 없음.(2005.9.13. 조정번호 제2005-66호)

가. 사실관계

피신청인은 2005.4.19. 신청인을 연대보증인으로 하여 신청외 A씨에 대하여 자동차할부금융 25백만원을 취급하였음.

본건 대출취급 경위와 관련하여 피신청인은 본건대출 취급시 인감증명서와 인감도장 및 주민등록등본 등 관련서류를 ○○자동차판매(주) 영업사원으로부터 징구한 후 신청인에게 보증의사를 확인하기 위해 신청인의 휴대폰으로 통화를 시도하였으며, 당시 신청인과 직접 통화는 하지 못하였으나 신청인의 배우자(조사결과 사채업자로 추정되는 제3자로 확인)와 통화하여 동 사실을 알려주었다고 주장하고 있는데 반해, 신청인은 상기 관련서류를 사채업자인 B씨(현재 신청인의 고소로 수배중)에게 대출을 받기 위해 건네 주었을 뿐 본건대출 취급사실을 알지 못한다고 주장하고 있음.

차주인 A씨도 2005.6.17. 자신의 인감증명서 등이 도용되어 본건 대출이 취급되었다며 본건 대출채무를 부인하는 내용의 민원을 피신청인에게 제기하였음.

나. 당사자의 주장

(1) 신청인 주장

신청인은 사금융회사로부터 대출을 받기 위해 인감증명서, 인감도장 등을 타인에게 준 사실이 있으나 본건 대출에 대해서는 전혀 알지 못하였고, 피신청인이 신청인을 연대보증인으로 하여 본건 대출을 취급하면서 신청인의 연대보증 의사도 확인하지 않고 본건

대출을 취급하였으므로 신청인에 대하여 보증책임을 청구하는 것은 부당함.

(2) 피신청인 주장

본건 대출은 피신청인과 ○○자동차판매(주)간에 체결된 업무위임계약에 따라 ○○자동차판매(주)가 신청인의 대리인으로부터 관련서류를 제출받았다고 하며, 피신청인도 본건대출 취급당시 전화를 통해 신청인의 배우자로부터 보증의사를 확인하였음. 아울러, 대출서류에 신청인의 인감증명서가 첨부되어 있고 인감이 날인되어 있는 점으로 미루어 본건 연대보증계약은 정당하게 이루어진 것이므로 신청인의 보증채무를 면제하기는 어려움.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 본건대출에 대하여 신청인과 피신청인간 연대보증계약이 유효하게 성립되었는지 여부라 하겠음.

피신청인의 경우 신청인이 본건대출과 관련하여 직접 연대보증 행위를 하거나 연대보증의사를 표시하지 않았다는 점은 인정하면서도 본건대출 관련서류에 신청인의 인감도장이 날인되어 있고 인감증명서가 첨부되어 있는 이상 신청인이 표현대리 책임을 부담하여야 한다고 주장하고 있으나, 다음과 같은 점에 비추어 피신청인은 타인에게 대리권이 있다고 믿을 만한 정당한 사유가 있다고 보기 어려워 피신청인의 주장은 이유 없음.

① 판례¹²⁹⁾에 따르면 제3자가 본인의 인감도장 및 인감증명서 등을 가지고 있었다는 점만으로는 제3자가 본인을 위하여 연대보증 등 계약을 체결할 권한이 있다고 믿는데 정당한 사유가 있었다고 보기 어렵다고 판시하고 있는데, 본건에 있어서 제출된 인감증명서상 사용용도란이 공란으로 되어 있어 신청인의 연대보증 의사가 객관적으로 표명되었다고 볼 수 없다는 점.

② 피신청인은 신청인의 배우자를 통하여 보증의사를 확인하였다고 하나 제3자의 대출채무에 대한 연대보증은 부부간의 일상가사대리권의 범위를 초과한 행위여서 보증인

129) 대법원 1998.4.11. 선고 88다카13219 판결 참조.

에 대한 유효한 보증의사 확인으로 볼 수 없으며, 조사결과 실제 배우자가 아닌 제3자임이 확인되는 등 신청인의 연대보증의사를 제대로 확인하였다고 보기 어려운 점.

라. 결 론

그렇다면 본건은 신청인이 직접 연대보증을 한 사실이 없을 뿐만 아니라 신청인의 표현대리 책임도 성립되지 않으므로 피신청인은 신청인에게 본건대출에 대한 보증책임을 묻기 어려운 것으로 판단됨.

3-3 이사 명의의 근보증서를 대표이사가 대필한 경우 표현대리의 성립 여부

[일부인용] 신청인이 이미 종합통장대출에 연대보증인으로 입보되어 있었고, 동 대출금이 상환되지 않은 상황에서 그 3배에 달하는 일반자금대출에 대하여 다시 연대보증할 것을 기대하기 어려운 점, 동 일반자금대출은 이미 만기상환이 되지 못하여 한 차례 연장된 바 있고 연대보증인을 추가해야 3개월 연장이 가능할 정도로 차주사의 자금사정이 좋지 않았던 점, 피신청인은 일반자금대출 보증서의 신청인 기명날인을 기존 신청인의 자필서류와 대조하였다고 주장하나, 양 서류의 필적은 육안으로 보기에 동일하다고 보기는 어려운 점 등을 감안시 일반자금대출에 대한 신청인의 보증채무는 존재하지 아니한다고 판단됨.(2010.3.9. 조정번호 제2010-25호)

가. 사실관계

(1) 종합통장대출 관련

피신청인은 2006.9.25. 신청외 A기업(이하 “차주사”라 함)¹³⁰⁾에 1억원의 종합통장대출을 하였는데, 차주사 대표이사 B씨(신청인의 처남)와 신청인이 함께 연대보증인으로 입보¹³¹⁾하였으며, 신청인은 위 연대보증 입보를 위하여 2006.9.5.자 근보증서를 자필로 작

130) 신청인은 2007.2.20.~2009.12.8. 기간중 차주사의 법인등기부등본에 ‘이사’로 등재되어 있었으며, 차주사가 2008.5. 및 2009.6.경 피신청인에 제출한 신용평가의뢰서에는 ‘주주’(주식수 1만주, 지분율 9%)로 표시되어 있었음(2007.7.자 신용평가의뢰서에는 주주로 나타나지 않음).

131) 2006.9.5.자 근보증서 기재내역

성하고 9.25. “본인 발급”의 인감증명서를 제출하였음.

그 후 위 종합통장대출은 2007.9.21.(1차) 및 2008.9.19.(2차) 각각 기한연장후 2009.9.18. 대환대출이 실행되었는데, 위 2007.9.21.자 “여신거래조건변경추가약정서”의 연대보증인란은 신청인이 자필로 작성하였으나, 2008.9.19.자 “여신거래조건변경추가약정서”의 연대보증인란과 2009.9.18.자 근보증서는 위 B씨의 대필로 작성되었으며, 인감증명서는 모두 “대리 발급”되어 제출됨.¹³²⁾

(2) 「일반자금대출」 관련

피신청인은 2008.4.10. 차주사에 4억원의 일반자금대출을 하였는데, 위 B씨가 연대보증인으로 입보하였으며, 10.15.(1차) 대출금을 3억원으로 감액하여 기한이 연장되었음.

2009.1.12.(2차) “연대보증인 추가입보”를 조건으로 위 일반자금대출의 기한이 다시 연장되었는데, 이 때 신청인이 연대보증인으로 입보되었음. 이 당시 B씨는 자신이 대필로 작성한 신청인 명의의 2009.1.12.자 근보증서(한정근보증, 한도액 3.9억원, 장래지정형)와 1.15.자 신청인 “본인 발급”의 인감증명서를 피신청인에 제출하였고, 피신청인은 이를 근거로 신청인을 연대보증인으로 추가 입보시켰음.

그 후 위 일반자금대출은 2009.4.13.(3차) 및 같은 해 10.13.(4차, 대출금액 2.4억원으로 감액) 각각 기한연장 되었는데, 2009.4.13. 및 10.13.자 각각의 “여신거래조건변경추가약정서”상 연대보증인란은 위 B씨의 대필로 작성되었으며, 인감증명서는 모두 “대리 발급”되어 제출됨.¹³³⁾

나. 당사자 주장

① 피보증채무의 범위 : 한정근보증, ② 근보증 한도액 : 1.3억원, ③ 근보증 결산기 : 장래지정형

132) B씨는 2010.2.22.자 확인서에서, 위 대필 부분은 모두 자신이 신청인의 동의 없이 임의작성한 것이며, 인감증명서 ‘대리 발급’ 부분은 차주사의 세무신고 명목으로 신청인으로부터 인감도장 및 신분증을 교부받아 발급받은 것임을 인정하였음.

133) B씨는 2010.2.22.자 확인서에서, 위 대필 부분은 모두 자신이 신청인의 동의 없이 임의작성한 것이며, 인감증명서 “대리 발급”부분은 차주사의 세무신고 명목으로 신청인으로부터 인감도장 및 신분증을 교부받아 발급받은 것임을 인정하였고, 한편 신청인은 위 2009.1.15.자 “본인 발급” 인감증명서는 B씨가 차주사의 세무신고에 이사의 인감증명서가 필요하다고 하여 발급받아준 것이라고 주장함.

(1) 신청인 주장

차주사의 종합통장대출 1억원에 관한 연대보증을 위하여 2006.9.5.자 근보증서를 작성하고 9.25.자 인감증명서를 발급받아 제출하였으며 그 후 2007.9.21.자 “여신거래조건변경추가약정서”도 직접 작성한 것은 사실이나, 그 이후의 추가약정서나 근보증서 및 일반자금대출 3억원과 관련한 모든 서류는 신청인의 의사와 무관하게 대필로 작성된 것으로서, 본건 관련 보증책임은 모두 인정할 수 없음.

2009.1.15.자 인감증명서는 차주사의 세무신고에 필요하다는 차주사 대표이사 B씨의 요청에 따라 신청인이 직접 발급받아준 것으로서 보증과는 무관한 것이었고, 나머지 인감증명서는 모두 대리 발급되었으므로 신청인의 보증책임의 근거가 될 수 없음.

신청인은 주식이나 지분을 받은 바 없어 주주로 등재된 것을 알지 못하였고, 법인등기부에 이사로 등재된 것은 명의만 빌려준 것으로서, 실제 회사운영이나 수익에 관하여 권리를 행사한 바 없으며, 2008.9월부터 시행된 「보증인 보호를 위한 특별법」(이하 “특별법”이라 함)에서도 보증의사는 보증인의 기명날인 또는 서명이 있는 서면으로 표시되어야 효력이 발생하는 것으로 규정하고 있음.

(2) 피신청인 주장

신청인은 차주사 종합통장대출 1억원에 관한 연대보증을 위하여 2006.9.5.자 근보증서를 자필로 작성하고 본인 발급의 9.25.자 인감증명서를 제출하였으며, 그 후 2007.9.21.자 “여신거래조건변경추가약정서”도 직접 작성하였으므로 보증의사가 명백히 존재하였음.

차주사의 일반자금대출에 관하여는 2009.1.12. 3개월 연장 당시 여신심사과정에서 연대보증인 추가입보를 조건으로 하게 되었는데, 차주사 대표이사 B씨가 “신청인이 업무상 출장이 잦아 시간을 맞추기가 어렵고 아쉬운 부탁을 하기 미안하니 대신 받아주겠다”고 하므로 신청인이 B씨의 인척이며 이미 위 종합통장대출의 보증인인 점을 감안하여 B씨를 통하여 근보증서를 제출받은 것은 사실이나, 당시 위 근보증서에 신청인의 기명·날인이 되어 있는 점을 확인하고 기존 신청인의 자필서류와 필적 및 인영을 대조하였으며 본인 발급의 인감증명서와 신분증 사본을 제출받았으므로, B씨가 적법한 대리인의 요건을 갖추었다고 판단하여 신청인을 연대보증인으로 추가입보시킨 조치는 적법함.

위 종합통장대출과 일반자금대출의 기한연장 및 대환대출 관련 서류도 위와 같은 이유로 위 B씨를 통하여 징구하였고, 매번 인감증명서를 제출받아 확인한 바, 민사소송법 제358조에 의하면 사문서는 본인 또는 대리인의 서명이나 날인 또는 무인이 있는 때에는 진정한 것으로 추정되며, 신청인의 각 근보증서 효력은 당해 채무의 연기는 물론 같은 종류로 대환된 때에도 미치므로, 보증의 효력은 존속함.

신청인은 차주사의 주주 및 이사로서, 이사는 특별법의 보증인에 해당하지 않으며, 또한 특별법상 보증의 의사표시는 보증인의 기명날인이 있으면 되고 반드시 자필서명이 있어야 하는 것은 아님.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 ① 「보증인 보호를 위한 특별법」이 본건에 적용되는지 여부, ② 종합통장대출의 2차 만기연장 및 대환대출시 관련 서류가 대필로 작성되고 인감증명서가 대리 발급된 경우 신청인의 보증책임이 존속하는지 여부 및 ③ 일반자금대출3억원에 대한 신청인의 연대보증 추가입보시 근보증서가 대필로 작성된 것에 관한 민법상 표현대리의 성립여부라 할 것임.

(1) 「보증인 보호를 위한 특별법」의 적용 여부

특별법이 본건에 적용되기 위해서는 선결문제로 신청인이 동법 소정의 “보증인”의 범위에 포함된다고 볼 수 있어야 할 것인데, 이와 관련하여 특별법 제2조는 특별법상 보증인에서 제외되는 경우를 제한적으로 열거¹³⁴⁾하고 있음. 그런데, 위 사실관계에서 본 바와 같이 신청인은 특별법 시행일(2008.9.22.) 이전인 2007.2.20.부터 2009.12.8.까지 차주사의 법인등기부등본에 이사로 등재되어 있었으므로, 특별법 제2조 제1호 나목에 의할 때 신청인은 보증인의 범위에서 제외되는 바, 결국 본건은 특별법의 적용대상이 아니라 할 것임.

134) 「보증인 보호를 위한 특별법」 제2조 제1호는 다음과 같이 규정하고 있음.

1. “보증인”이란 민법 제429조 제1항에 따른 보증채무(이하 “보증채무”라 한다)를 부담하는 자로서 다음 각 목에서 정하는 경우를 제외한 자를 말한다.
나. 기업의 대표자, 이사, 무한책임사원, 국세기본법 제39조제2항에 따른 과점주주(과점주주) 또는 기업의 경영을 사실상 지배하는 자.

다만 신청인은 자신은 이사로 명의만 빌려주었을 뿐 경영에 참여한 사실이 없다고 주장하나, 특별법이 이사의 실제 직무수행여부를 법 적용의 판단기준으로 명시하지 않고 있는 이상, 신청인이 차주사의 이사로 실제 직무를 수행했는지 여부는 특별법의 적용에 있어 영향을 미치지 않는다 할 것임.

(2) 2006.9.25.자 종합통장대출 관련 보증책임의 존부

신청인은 위 종합통장대출이 2008.9.19. 2차 만기연장될 당시 작성된 “여신거래조건변경추가약정서”와 2009.9.18. 대환대출이 실행될 당시 작성된 근보증서는 자신의 의사와 무관하게 대필로 작성된 것이고 인감증명서도 대리 발급된 것이므로 위 종합통장대출 관련 보증책임은 인정할 수 없다는 취지로 주장하나, 아래와 같은 점에 비추어볼 때 신청인의 위 종합통장대출 관련 보증책임은 부인하기 어렵다 할 것임.

① 신청인은 위 종합통장대출이 2006.9.25. 최초 실행될 당시 유효한 연대보증인으로 입보하였고, 그 후 2007.9.21. 위 대출의 1차 만기연장에 동의까지 하였던 점.

② 신청인이 위와 같이 연대보증인으로 입보할 당시 작성된 근보증서를 보면 결산기는 “장래지정형”으로서, 보증약정일로부터 3년이 경과하면 보증인은 서면통지에 의하여 근보증 결산기를 지정할 수 있도록 되어 있는데, 현재까지 신청인이 위 서면통지를 한 사실이 없는 점.

③ 대법원 판례¹³⁵⁾ 및 민법의 일반이론에 의하면, 채권자가 주채무자에 대하여 변제기를 연장하여 준 경우, 보증채무에 대하여도 그 효력이 미친다고 해석되는 점.

④ 대법원 판례¹³⁶⁾에 의하면, ‘대환대출’에 있어서 특별한 사정이 없는 한 기존채무에

135) 보증계약 체결 후 채권자가 보증인의 승낙 없이 주채무자에 대하여 변제기를 연장하여 준 경우, 그것이 반드시 보증인의 책임을 가중하는 것이라고는 할 수 없으므로 원칙적으로 보증채무에 대하여도 그 효력이 미친다(대법원 1996.2.23. 선고 95다49141 판결).

136) 현실적인 자금의 수수 없이 형식적으로만 신규대출을 하여 기존채무를 변제하는 이른바 대환은 특별한 사정이 없는 한 형식적으로는 별도의 대출에 해당하나 실질적으로는 기존채무의 변제기의 연장에 불과하므로 그 법률적 성질은 기존채무가 여전히 동일성을 유지한 채 존속하는 준소비대차로 보아야 하고, 이 경우 채권자와 보증인 사이에 보증인의 보증책임을 면제하기로 약정을 한 경우 등 특별한 사정이 있는 경우를 제외하고는 기존채무에 대한 보증책임이 존속된다(대법원 1994.6.10. 선고 94다3445 판결).

대한 보증책임이 존속되는 점.

(3) 2008.4.10.자 일반자금대출 관련 보증책임의 존부

1) 2009.1.12.자 근보증서에 대한 법적 판단

피신청인의 주장과 같이 민사소송법 제358조에 의하면 사문서는 본인 또는 대리인의 서명이나 날인 또는 무인이 있는 때에는 진정한 것으로 추정되므로, 본건에 있어서도 위 일반자금대출이 2009.1.12. 만기연장되면서 신청인이 연대보증인으로 추가입보될 당시 징구된 근보증서에 신청인의 인감이 날인되어 있는 이상 그 진정성립이 추정되고, 또한 처분문서인 위 근보증서의 진정성립이 인정되는 이상 그 내용대로 신청인의 보증계약이 유효하게 성립된 것으로 판단해야 하지 않느냐의 문제가 있을 수 있으나, 위에서 본 바와 같이 차주사 대표이사 B씨가 본건 관련 서류중 대필이 문제되는 부분은 모두 자신이 임의 작성(인감날인 포함)하였음을 인정하고 있는 이상, 위와 같은 진정성립의 추정은 깨어진다¹³⁷⁾ 할 것이어서, 결국 위 근보증서만으로 신청인의 보증책임을 판단할 수는 없다 할 것임.

2) 민법상 표현대리의 성립여부

신청인이 공법상 행위인 차주사의 세무신고 관련 업무처리를 위하여 자신의 인감도장과 신분증을 B씨에게 교부하여준 것은 대법원 판례¹³⁸⁾의 취지에 의할 때 민법 제126조

137) 문서에 날인된 작성명의인의 인영이 그의 인장에 의하여 현출된 것이라면 특별한 사정이 없는 한 그 인영의 진정성립, 즉 날인행위가 작성명의인의 의사에 기한 것임이 사실상 추정되고, 일단 인영의 진정성립이 추정되면 그 문서 전체의 진정성립이 추정되나, 위와 같은 사실상 추정은 날인행위가 작성명의인 이외의 자에 의하여 이루어진 것임이 밝혀진 경우에는 깨어지는 것이므로, 문서제출자는 그 날인행위가 작성명의인으로 부터 위임받은 정당한 권원에 의한 것이라는 사실까지 증명할 책임이 있다(대법원 2009.9.24. 선고 2009다37831 판결).

138) ① 피고 갑이 피고 을에게 지역사회개발관계서류에 사용하라고 하여 인장을 임치하였다면, 갑은 을에게 특별한 사정이 없는 한 지역사회개발관계행위의 대리권을 부여하였다고 볼 것이고, 정당하게 부여받은 대리권의 내용되는 행위와 표현대리행위는 반드시 같은 종류의 행위에 속할 필요는 없다(대법원 1969.7.22. 선고 69다548 판결). ② 기본대리권이 등기신청행위라 할지라도 표현대리인이 그 권한을 유월하여 대물변제라는 사법행위를 한 경우에는 표현대리의 법리가 적용된다(대법원 1978.3.28. 선고 78다282, 283 판결).

의 표현대리에 있어 “기본대리권의 수여”로 평가할 수 있고, 한편 B씨는 “그 범위를 넘어” 임의로 신청인 명의로 2009.1.12.자 근보증서를 작성하여 피신청인에 제출한 사실을 인정하고 있으므로, 결국 민법 제126조의 표현대리의 성립여부에 따라 신청인의 위 일반자금대출 관련 보증책임의 존부를 판단해야 할 것임.

그렇다면, 본건은 결국 위 민법 제126조 소정의 “정당한 이유”가 인정되는지 여부, 즉 피신청인의 입장에서 B씨가 신청인을 대리하여 위 2009.1.12.자 근보증서를 작성하여 보증의사를 표시한 것이 적법한 권한 내의 행위라고 믿을 만한 “정당한 이유”가 있는지 여부에 귀결된다 할 것이며, 본건과 같은 금융기관의 연대보증계약에 있어 대법원 판례는 “사무처리규정의 준수여부”를 위 “정당한 이유”의 존부에 있어 중요한 판단기준으로 제시¹³⁹⁾하고 있음. 이 같은 대법원 판례의 취지에 따라 본건을 살펴보면, 아래와 같은 이유로 피신청인에게는 “정당한 이유”가 인정되기 어렵다고 판단됨.

① 신청인의 입장에서는 이미 2006.9.25. 위 종합통장대출 1억원에 대하여 연대보증인으로 입보되어 있었고 위 대출금이 상환되지도 않은 상황에서, 신청인이 차주사의 이사이자 주주였음을 감안하더라도 대출금액이 3배에 달하는 위 일반자금대출 3억원에 대하여

139) 민법 제126조의 “정당한 이유”의 존부는 자청 대리인의 대리행위가 행하여 질 때에 존재하는 모든 사정을 객관적으로 관찰하여 판단하여야 하고(대법원 1987.7.7. 선고 86다카2475 판결, 2002.6.28. 선고 2001다49814 판결 등), 금융기관이 채무자 본인의 서명날인 또는 채무자의 보증의사 확인 등 계약체결에 관한 사무처리규정을 마련하여 둔 경우에는 연대보증계약을 체결하면서 그와 같은 사무처리규정을 준수하였는지 여부가 표현대리에서 정당한 이유가 있는지 여부를 판단하는 요소가 될 수 있다(대법원 1999.3.12. 선고 98다51626 판결, 2000.1.28. 선고 99다57461 판결 등).

본건과 유사한 사안에서 대법원은, 위 판시 내용을 인용하며, “甲(은행 직원)은 A사의 연대보증에 필요한 서류에 A사 대표이사의 자필서명을 받고자 하였던 점, 乙(A사 상무)은 A사 대표이사를 대리하거나 대행하여 직접 甲과의 사이에 이 사건 연대보증계약을 체결한 것이 아니라 A사 대표이사의 자필서명인 듯 기재되어 있는 이 사건 근보증서 등을 甲에게 전달한 것에 불과한 점, 甲은 이 사건 근보증서 등에 A사 대표이사의 자필서명을 받아 주겠다는 乙의 말만 듣고 A사의 대표이사나 자금담당 직원에게 A사 대표이사가 자필서명을 하였는지 또는 연대보증의 의사가 있는지 등에 관하여 직접 면접하거나 전화를 걸어 확인하는 등의 표준대출규정에 따른 조치를 취하지 아니한 점 등을 비추어 보면, 甲이 당시 乙에게 A가 대표이사를 대리하거나 대행하여 이 사건 연대보증계약을 체결할 권한이 있다고 믿을 만한 정당한 이유가 있다고 보기는 어렵다”고 판시하였음(대법원 2009.2.26. 선고 2007다30331 판결).

다시 연대보증을 할 것을 기대하기는 어려움은 경험칙상 쉽게 예상할 수 있는 점.

② 위 일반자금대출은 2008.4.10. 최초 실행된 후 만기에 상환되지 못하고 10.15. 한차례 연장되었고, 2009.1.12.에는 연대보증인을 추가 입보시켜야 3개월 연장이 가능할 정도로 차주사의 자금사정이 좋지 않았던 점.

③ 피신청인은 2009.1.12.자 근보증서에 신청인의 기명·날인이 되어 있는 점을 확인하고 기존 신청인의 자필서류와 필적과 인영을 대조하였다고 주장하나, 위 근보증서의 필적과 신청인이 직접 작성한 2006.9.5.자 근보증서의 필적은 육안으로 보기에 동일하다고 보기는 어려운 점.

④ 무엇보다도, 피신청인 「여신업무규정」 제1편 제7장 제1절 “약정서 작성요령”은 아래와 같이 “대리인과 거래시의 준수사항”을 규정하고 있는데, 피신청인은 2009.1.12.자 근보증서를 징구함에 있어 이를 준수하지 아니한 바, 위 대법원 판례의 취지에 의할 때 피신청인에게 “정당한 이유”가 있다고 판단하기 어려운 점.

3. 서명날인 및 인감

가. 어음·약정서·계약서·기타 채권관계 서류는 모든 채무관계자로 하여금 직접 서명·날인하게 하여야 하며, 대조용으로 인감증명서를 징구하여야 한다.

나. 전항에 불구하고 영업점장이 부득이하다고 판단하는 경우, “대리인과 거래”할 수 있으나, 이 경우에는 채무관계자로부터 대리인 지정을 위한 위임장과 사용용도(보증용, 담보제공용, 위임용 등)가 기재된 인감증명서를 징구하여야 한다.¹⁴⁰⁾

라. 결 론

그렇다면, 위 2008.4.10.자 ‘일반자금대출’과 관련한 보증채무를 부인하는 신청인의 주장은 이유 있으므로 이를 인용하고, 위 2006.9.25.자 ‘종합통장대출’과 관련한 보증채무를 부인하는 주장은 이유 없으므로 이를 기각함.

140) 피신청인은 2009.1.12.자 근보증서를 차주사 대표이사 B씨를 통하여 제출받으면서도 “대리인 지정을 위한 위임장”을 징구하지 않았고, “인감증명서의 사용용도 란이 공란”으로 되어 있어 어떠한 용도로 발급된 것인지 알 수 없음에도, 본인인 신청인의 의사를 확인하기 위하여 직접 면담하거나 전화를 하는 등의 어떠한 조치도 취하지 않았음.

3-4 남편 명의의 근보증서를 부인이 대필한 경우 보증계약의 효력

[인용] 본건 보증계약은 차주인 배우자가 근보증서를 대신 작성하여 은행에 제출한 것으로 차주와 신청인 모두 신청인의 작성사실을 부인하고 있으며, 신청인이 제출한 서류상 필체와 본건 근보증서상의 신청인의 필체가 육안상 상이하여 신청인이 이를 작성했다고 보기 어려운 점, 근보증서 작성시 피신청인이 신청인에게 보증의사를 확인한 사실이 없고 신청인의 보증의사를 입증할 자료도 찾기 어려운 점, 부부 일방이 자신의 사업상의 채무에 대하여 연대보증행위를 한 행위를 일상가사대리권의 범위에 속한다고 보기 어려운 점 등을 감안시 차주가 보증인 명의로 체결한 보증계약은 효력이 없다 할 것임.(2010.10.20. 조정번호 제2010-87호)

가. 사실관계

2006.2.23. 차주 A씨(신청인의 처, 독서실 운영업)는 피신청인과 여신거래약정서를 체결하고 외화대출(JPY 28,100,000)을 취급받아 사용하였음.

2009.8.24. 동 대출 기한연장시, 피신청인은 환율상승 등 리스크 증가에 따른 채권보전 강화를 위해 차주의 배우자인 신청인을 연대보증인으로 하는 추가약정을 체결하고 근보증서를 받았는 바, 근보증서에 신청인의 기명날인이 되어 있으나, 이는 차주 A씨가 신청인의 자필을 받아왔다고 하여 은행에 제출한 것이며 은행이 신청인에게 보증의사를 확인한 적은 없음. 신청인의 처 A씨는 금감원에 제출한 서면확인서에 본인이 지인에게 부탁하여 근보증서를 작성하여 은행에 제출하였다고 주장하고 있으며, 신청인이 제출한 ○○캐피탈 대출신청서, ◇◇증권사 계좌신청서 및 은행이 제출한 자유저축예금거래신청서상의 신청인의 자필과 본건 근보증서상의 신청인의 자필이 육안상 상이함.

나. 당사자 주장

(1) 신청인 주장

신청인은 근보증서에 자필서명한 적이 없고, 이를 허락한 적도 없으므로 본건 보증계약은 무효임.

(2) 피신청인 주장

근보증서 작성시 차주 A씨가 신청인의 자필을 받아 왔다고 하였으나, 여신약정서상 차주의 필체와 보증인의 필체가 서로 상이하여 신청인의 필체일 가능성이 있으며, 신청인은 차주의 배우자로 보증에 대해 사전에 협의를 거쳐 보증서를 작성한 것으로 보임으로 신청인 주장을 수용하기 어려움.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 차주의 배우자로서 피신청인과 체결한 근보증 계약의 유효성 여부라 할 것임.

(1) 근보증계약의 유효성 여부

피신청인은 신청인이 차주의 배우자로 본건 보증계약이 유효하다고 주장하나, 아래와 같은 이유로 본건 보증계약은 신청인에게 효력이 없다 할 것임.

① 「보증인보호를 위한 특별법」 제3조 제1항은 보증의 방식과 관련하여 “보증은 그 의사가 보증인의 기명날인 또는 서명이 있는 서면으로 표시되어야 효력이 발생한다”라고 정하고 있는데, 본건 보증계약은 신청인이 피신청인에 내점하여 작성된 것이 아니라 차주가 근보증서를 받아간 다음 이를 작성하여 은행에 제출한 것으로서 차주와 신청인 모두 신청인이 이를 작성한 사실을 부인하고 있으며, 신청인이 제출한 서류상 필체와 본건 근보증서상의 신청인의 필체가 육안상 상이하여 신청인이 이를 작성했다고 보기 어려운 측면이 있고, 본건 근보증서 작성시 피신청인이 신청인에게 보증의사를 확인한 사실이 없으며 달리 신청인의 보증의사를 입증할 자료를 찾기 어려운 점.

② 부부간 일상가사대리권이 있다 하더라도, 부부 일방이 자신의 사업상의 채무에 대하여 연대보증행위를 한 행위를 일상가사대리권의 범위에 속한다고 보기 어렵고, 법원은 금융기관이 본인 아님을 아는 어떤 사람이 본인의 인감도장과 그 인감증명을 가지고 있다 하여 계약체결의 권한이 있다고 믿었어도 정당한 이유가 되지 않는다고 판시하고 있으며,¹⁴¹⁾ 본건 차주는 신청인의 부인으로 신청인의 도장을 쉽사리 입수할 수 있고 종래

141) 대법원 1980.4.8. 선고 80다188 판결 참조.

신청인이 차주에게 별도의 대리권을 부여하거나 차주의 채무를 보증한 사실도 없으며 피신청인도 이러한 사정을 쉽게 알 수 있다고 보이는 점¹⁴²⁾ 등을 고려하면 차주가 신청인을 대리하여 본건 근보증 계약을 체결할 대리권이 있다고 믿은 데에 정당한 이유가 있다고 보기 어려워 일상가사대리권을 넘는 표현대리의 성립을 인정하기도 어려운 점.

라. 결 론

그렇다면, 신청인의 피신청인에 대한 2009.8.24.자 근보증서에 기한 보증채무는 존재하지 아니한다는 신청인의 주장은 이유 있으므로 이를 인용함.

3-5 위조된 근보증서에 따라 전화확인만을 거친 경우 보증계약의 효력

[인용] 「보증인 보호를 위한 특별법」에 따라 보증인의 서면동의 없는 보증계약의 효력을 인정하기 어렵고, 수사결과 등에서 채무자가 신청인 명의로 근보증서를 작성하여 제출한 점이 인정되는 등 본건 연대보증 체결경위, 계약형식 등을 종합적으로 고려할 때 본건 보증계약은 신청인에게 효력이 미치지 않는다고 할 것임.(2013.9.10. 조정번호 제2013-25호)

가. 사실관계

2012.12.20. 신청외 A씨는 피신청인에게 5백만원의 대출을 신청하였으며, 같은 날 신청인 명의의 근보증서(한도액 6.5백만원)가 피신청인에게 제출되었음.

본건 대출과 관련하여 피신청인은 신청인에게 전화 녹취를 실시하였는 바, 약 2분에 걸쳐 보증채무액, 이자율, 자필서명 여부 등을 빠르게 알리고 이에 대해 신청인이 짧게 “네”라고 대답하였으며, 피신청인은 전화 녹취 이후 신청인을 동 대출의 보증채무인으로 신용정보 등록하고 A씨에게 5백만원을 대출해 줌.

2013.2월경 자신이 보증인으로 등록되었음을 알게 된 신청인은 2013.7.4. A씨를 보증서 자필서명 위조 등으로 ○○경찰서에 고소하였고, 동 경찰서는 2013.7.26. A씨에 대하여

142) 대법원 1997.4.8. 선고 96다54942 판결 참조.

사문서위조 등으로 ○○지검에 기소의견으로 송치하였음.

A씨는 신청인과의 문자메세지 교환과정에서 본인이 대출받는 과정에서 신청인 명의로 보증서를 작성하였음을 인정¹⁴³⁾하였으며, A씨의 대출채무는 2013.7.8. 연체가 시작되어 2013.8.9. 기한이익이 상실되었음.

나. 당사자 주장

(1) 신청인 주장

지인인 A씨가 도와달라고 하여 통장과 신분증을 빌려 준 적이 있을 뿐 A씨의 대출에 대해 보증을 한 적이 없음. 상담원과 통화시 6개월만 이름이 같이 있을 뿐 6개월 뒤에는 자연히 빠지는 것으로 피해는 전혀 없다고 하여 전화 녹취를 진행하였을 뿐, 보증 관련 서류는 일체 작성하지 않았음. 보증의사 녹취시 자필서명 여부에 대한 질문에 쓰지 않았다고 하였더니 그러면 진행이 안된다고 두 번이나 녹음이 취소되었고 “네”라고 답변하여 세 번째에 녹취를 마쳤으나, 녹취 후 취소하겠다는 의사를 유선상 전달한 바 있음.

A씨 대출은 이미 기한이익 상실 중으로 보증인으로 되어 있다는 이유로 채무독촉에 시달리고 있는 바, 자필서명 없이는 보증 계약은 무효이므로 피해를 구제해 주기 바람.

(2) 피신청인 주장

대출 진행시 신청인에게 A씨에 대한 연대보증의사 및 보증서자필서명 여부 등을 확인하였는 바, 신청인이 보증서에 자필서명하였음을 명확히 확인하는 등 정상적인 보증채무이므로 연대보증해지는 불가함.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 신청인이 연대보증서에 자필서명하지 않았음에도 피신청인 전화 상담원에게 보증서에 자필서명하였다고 확인해 준 경우 신청인에게 본건 보증계약의 효력을 인정할 수 있는 지 여부라 할 것임.

143) A씨는 피신청인을 포함하여 총 3개의 저축은행으로부터 대출을 받는 과정에 신청인의 명의로 된 보증서를 제출하였는 바, 피신청인 외 2개 저축은행에서는 보증서가 위조되었음을 인정하고 신청인의 보증채무를 면제하였음.

(1) 판례의 입장

「보증인 보호를 위한 특별법」(이하 “특별법”이라 함) 제3조 제1항은 “보증은 그 의사가 보증인의 기명날인 또는 서명이 있는 서면으로 표시되어야 효력이 발생한다.”고 규정¹⁴⁴⁾하고 있는 바, 이와 같이 보증의 의사표시에 보증인의 기명날인 또는 서명이 있는 서면을 요구하는 것은 한편으로 그 의사가 명확하게 표시되어서 보증의 존부 및 내용에 관하여 보다 분명한 확인 수단이 보장되고, 다른 한편으로 보증인으로 하여금 가능한 한 경솔하게 보증에 이르지 아니하고 숙고의 결과로 보증을 하도록 하려는 취지에서 나온 것이다. 따라서 보증의 의사표시에 관하여 법률행위의 해석에 관한 일반 법리가 적용됨은 물론이나, 거기에서 더 나아가 위의 법규정이 정하는 방식이 준수되었는지 여부는 위와 같은 취지를 충족하는지 여부에 좇아 판단할 것이다. 그리고 이를 판단함에 있어서는 작성된 서면의 내용 및 그 체제 또는 형식, 보증에 이르게 된 경위, 주채무의 종류 또는 내용, 당사자 사이의 관계, 종전 거래의 내용이나 양상 등을 종합적으로 고려할 것임.¹⁴⁵⁾

(2) 본건 연대보증의 효력 여부

본건 연대보증과 관련하여 비록 신청인이 피신청인의 계약 확인을 위한 전화 녹취에

144) 「보증인 보호를 위한 특별법」은 다음과 같이 규정하고 있음.

제1조(목적) 이 법은 보증에 관하여 「민법」에 대한 특례를 규정함으로써 아무런 대가 없이 호의(好意)로 이루어지는 보증으로 인한 보증인의 경제적·정신적 피해를 방지하고, 금전채무에 대한 합리적인 보증계약 관행을 확립함으로써 신용사회 정착에 이바지함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

3. “금융기관”이란 다음 각 목에서 정하는 것을 말한다.

바. 「상호저축은행법」에 따른 상호저축은행

제3조(보증의 방식) ①보증은 그 의사가 보증인의 기명날인 또는 서명이 있는 서면으로 표시되어야 효력이 발생한다.

②보증인의 채무를 불리하게 변경하는 경우에도 제1항과 같다.

③보증인이 보증채무를 이행한 경우에는 그 한도에서 제1항과 제2항에 따른 방식의 하자를 이유로 무효를 주장할 수 없다.

제8조(금융기관 보증계약의 특칙) ① 금융기관이 채권자로서 보증계약을 체결할 때에는 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」에 따라 종합신용정보집중기관으로부터 제공받은 채무자의 채무관련 신용정보를 보증인에게 제시하고 그 서면에 보증인의 기명날인이나 서명을 받아야 한다.

145) 대법원 2013.6.27. 선고 2013다23372 판결 참조.

응하였다 하더라도 아래와 같이 특별법의 입법취지, 본건 연대보증 체결경위, 연대보증 계약 형식 등을 종합적으로 고려할 때 신청인이 보증 계약서에 자필서명을 하지 않은 이상 본건 보증 계약은 신청인에게 효력이 미치지 않는다고 할 것임.

① 보증형식에 제한을 두지 않고 있는 민법의 특례로서 특별법 제3조에서는 보증인의 기명날인 또는 서명이 있는 서면으로 보증의사가 표시된 경우에만 보증계약의 효력을 인정하고 있는 바, 경솔한 보증계약을 방지하고 보증의 존부 및 내용을 명확히 하고자 하는 동법의 입법취지 등을 감안시 제3조는 보증인 보호를 위한 효력규정으로 이에 위반하여 보증의사가 자필서명이 있는 서면으로 확인되지 않는 경우 설사 당사자간 보증 의사의 합치가 있다고 하더라도 그 사법상 효력을 인정하기 어려운 점.

② 피신청인은 보증서에 자필서명이 있는 이상 보증서의 무효를 주장하는 신청인이 자필서명에 대한 입증책임이 있으며, 전화녹취상 신청인이 자필서명을 명확하게 인정하였으므로 보증계약은 유효하게 성립되었다고 주장하므로 살피건대, 특별법에서는 보증인의 기명날인 또는 서명 여부를 보증계약의 권리발생요건으로 하고 있어 보증인의 자필서명에 대한 입증책임은 보증계약 성립을 주장하는 피신청인에게 있다고 할 것인 바,¹⁴⁶⁾ ○○경찰서 수사결과에 의하면 A씨가 신청인의 동의없이 신청인 명의를 위조하여 피신청인에게 본건 보증서를 제출한 것으로 확인되며, A씨도 신청인과의 문자메세지 교환 과정에서 본인이 신청인 명의로 보증서를 작성하여 피신청인에게 제출하였음을 인정하고 있는 점, 필적감정 결과 등 신청인의 자필서명 여부를 확인할 수 있는 자료의 제출을 요청하였음에도 현재까지 피신청인이 신청인의 자필서명 여부를 객관적으로 확인할 수 있는 자료를 제출하지 못하고 있는 점 등을 감안시 신청인이 피신청인의 전화녹취에 응한 것만으로 피신청인이 신청인의 자필서명에 대해 충분한 입증을 하였다고 보기 어려운 점.

② 특별법에서는 금융회사가 보증계약을 하는 경우주채무자의 채무 관련 신용정보를 보증인에게 제시하고 그 서면에 서명날인을 받도록 하고 있는 바, 신청인은 지인인 A씨의 부탁으로 아무런 대가없이 전화녹취에 응하였을 뿐 본건 보증의 내용이나 A씨의 신

146) 서울중앙지방법원 2012.11.15 선고. 2011가단371969 판결 등 참조.

용정보를 서면으로 교부받은 사실이 없다고 진술하고 있는 반면, 피신청인은 A씨의 신용정보를 신청인에게 제공하거나 자필서명 받았다고 인정할 만한 객관적 증거를 전혀 제출하지 못하고 있는 등 피신청인이 본건 보증과 관련하여 신청인에게 A씨의 신용정보를 제공하거나 신청인의 자필서명을 확인하였다고 보기 어려운 점.

③ 한편, 특별법과 달리 「대부업법」에서는 음성녹음에 의한 보증계약 성립을 인정하고 있으나,¹⁴⁷⁾ 동법은 대부업자와 여신금융기관(상호저축은행은 이에 해당)를 명확히 구분하고 있으며 대부업자가 체결한 보증계약에 한하여 예외적으로 서면이 아닌 음성녹음에 의한 보증계약 성립을 인정하고 있는 반면, 특별법에서는 금융회사의 모든 보증계약에 대해 보증인의 서면동의를 의무화하면서 상호저축은행을 금융회사의 종류로 명시하고 있는 점 등을 감안시 저축은행인 피신청인의 보증계약에 대하여는 「대부업법」이 우선 적용된다고 보기 어려운 바, 특별법에 따라 신청인의 자필서명이 서면으로 입증된 경우에 한하여 보증계약이 성립된다고 보아야 할 것임.

라. 결 론

그렇다면 신청인 자필서명이 없는 본건 보증은 「보증인 보호를 위한 특별법」 제3조에 위반되어 신청인에게 효력이 없다 할 것이므로 신청인의 피신청인에 대한 본건 보증채무는 존재하지 아니한다 할 것임.

147) 「대부업 등의 등록 및 금융이용자 보호에 관한 법률」에서는 다음과 같이 규정하고 있음.

제2조(정의) 1. “대부업”이란 금전의 대부를 업(業)으로 하거나 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자로부터 대부계약에 따른 채권을 양도받아 이를 추심하는 것을 업으로 하는 것을 말한다.

가. 제3조에 따라 대부업의 등록을 한 자, 나. 여신금융기관

4. “여신금융기관”이란 다른 법령에 따라 인가 또는 허가 등을 받아 대부업을 하는 금융기관을 말한다.

제6조의2(중요사항의 자필 기재) ③대부계약 또는 이와 관련된 보증계약을 체결할 때 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 대부업자는 제1항 각 호의 사항 또는 제2항 각 호의 사항을 거래 상대방 또는 보증인이 자필로 기재하게 한 것으로 본다.

2. 그 밖에 거래상대방 또는 보증인이 본인인지 여부 및 제1항 각 호의 사항 또는 제2항 각 호의 사항에 대한 거래상대방 또는 보증인의 동의 의사를 음성 녹음 등 대통령령으로 정하는 방법으로 확인하는 경우

제2절 담보제공자 겸 연대보증인의 보증 책임

3-6 근보증서 제출이 의례적·형식적인 절차에 불과한 것인지 여부

[기각] 보증계약은 근저당권설정계약과 별개의 계약이라는 전제하에 “특별한 사정”이 인정되는 경우에 한하여 보증한도액을 근저당권 채권최고액으로 제한하는 해석을 하고 있으나, 진정성립이 인정되는 “보증계약 자체의 효력을 부인”하는 예는 찾아보기 어려운 바, 본건은 이미 근보증서 자체에 보증한도액이 근저당권 채권최고액과 동일하게 설정되어 있으므로 보증책임을 제한할 실익도 없으며, 본건의 경우 선순위 근저당권의 과다로 담보부동산의 유효담보가 ‘0원’인 점을 감안할 때 신청인의 주장을 받아들이기 어려움.(2009.5.12. 조정번호 제2009-48호)

가. 사실관계

피신청인은 신청의 A기업(대표이사 B씨, 이하 “차주사”라 함)에 2008.5.29.자로 2억원의 일반자금대출(이하 “본건 대출”이라 함, 상환기일 2009.5.29.)을 취급하였으며, 차주사는 2007.3.19. 설립되어 당해 매출액 5.6억원, 당기순이익 1,700만원을 기록한 영세법인으로서 담보로 제공할 물적 자산이 없었음(2009.1.15.자로 폐업함).

본건 대출과 관련하여 신청인¹⁴⁸⁾은 2008.5.28. B¹⁴⁹⁾씨 및 그 부인인 C씨와 함께 피신청인 영업점에 방문하여 “근저당권설정계약서”에 자필서명·날인하였는데, 본건 담보부동산에는 ○○은행(제1순위, 채권최고액 1.5억만원)과 ◇◇상호저축은행(제2순위, 채권최고액 3.9억원)의 선순위 근저당권 합계 5.4억원이 설정되어 있었으며, 담보설정 당일 탁상감정 결과 담보목적물의 감정가액은 3.2억원이었음(6.2.자 정식 감정평가서에는 3.5억원으로 평가됨). 결국 본건 담보목적물의 ‘유효담보가’는 위 담보설정 당시부터 ‘0원’이었음.

동일자에 신청인은 근보증서에도 자필서명·날인하였는데, 신청인은 ① 근보증서 상단의 “연대보증인 표시”란에 인쇄된 “연대보증인”이라는 문구 바로 옆에 성명과 주소를

148) 신청인은 차주사 대표이사 B씨의 여동생으로서, 차주사의 임직원 또는 주주는 아님.

149) B씨는 본건 대출을 취급한 피신청인 은행 지점의 부지점장 ○○○ 및 본건 대출을 소개한 동 영업점 직원 ◇◇◇과는 고교동문 관계임.

자필 기재하였고, ② “피보증채무의 종류 및 범위”란에 “특정근보증”, “2008.5.29.자 여신거래약정서”, ③ “근보증 한도액”란에 “이억육천만원”, ④ “근보증 결산기”란에 “장래 지정형” 등 근보증서의 모든 기재사항을 자필 기재하였으며, 또한 “여신거래기본약관과 계약서의 중요한 내용 및 채무자의 부채현황, 연체유무 등의 내용에 대한 설명 확인”란에 “들었음”이라고 자필 기재함.

본건 근보증서 작성시 피신청인은 전산상 “고객 종합 정보조회표”를 출력하여 보증인 신청인과 C씨의 여신현황 등을 확인하였으나, 별도로 보증인들의 책임재산현황을 확인하기 위한 조사는 실시하지 않았음.

본건 대출이 실행된 2008.5.29. 당일 대출금 중 1.8억원(91%)이 신청인이 감사로 재직 중인 D기업(대표이사 E씨)으로 이체되었는데, E씨는 본건 담보부동산의 감정평가를 위해 2008.5.30. 감정평가사가 현지를 방문하였을 때 위 담보부동산에 현재 임대차 관계가 존재하지 않는다는 확인서를 작성해주면서 소유자란에 “신청인 명희와 C씨”, 확인자란에 자신을 “소유자(C씨) 남편(A씨) 대표이사 A기업 관리이사”로 기재한 바 있음.

본건 대출이 2008.7월경부터 지속적으로 연체가 발생하자 피신청인은 보증인인 신청인 소유의 아파트에 관한 가압류 절차에 착수하였는 바, ○○지방법원은 2008.11.7. “신청인에 대한 보증채권”을 피보전채권으로 인정하여 부동산 가압류결정을 내렸고 현재 등기를 마친 상태임.

나. 당사자 주장

(1) 신청인 주장

대출을 위한 담보를 제공해달라는 오빠(A씨)의 부탁을 받고 지점에 가서 근저당권설정계약서 및 여신거래약정서 등 관련 서류에 자필기재 및 서명·날인을 마치고 창구에서 기다리던 중, 은행직원이 “대출관련 서류 중 일부가 누락되었다”고 말하여 제시된 서류를 보니 보증금액도 같고 하여 본건 담보에 관한 서류인 것으로 생각하고 자필기재 및 서명·날인하였던 것임.

당시 은행직원으로부터 보증을 위해 서류를 작성하는 것이라는 취지의 설명을 듣지

못하여 연대보증인으로 입보한다는 사실에 대하여는 전혀 알지 못하였고, 만약 담보제공 외에 별도의 보증책임까지 부담해야 한다는 설명을 들었다면 결코 서류에 자서하지 않았을 것이며, 위 추가 작성한 서류가 근보증서였다는 사실은 피신청인이 본인 거주 아파트에 가압류를 마친 후에야 알게 되었음.

본인은 차주사와 전혀 무관하고 경제적 이익을 공유하고 있지도 않음에도 담보제공자로서의 책임 외에 보증책임까지 묻는 것은 부당함.

(2) 피신청인 주장

본건 근보증서 작성 당시 연대보증인인 신청인 및 C씨에게 취급예정 여신에 관한 제반 사항을 충분히 설명하였고, 보증계약의 구체적인 내용을 상세히 설명한 후 근보증서의 해당란에 모두 자필기재 및 서명·날인을 받은 바, 보증 입보사실을 알지 못한 채 근보증서에 자서하였다는 신청인의 주장은 전혀 사실이 아님. 또한 본건 근보증서를 작성 받는 과정에서 해당 직원이 “대출관련 서류 중 일부가 누락되었다”고 말한 사실이 결코 없으며, 근저당권설정계약서와 근보증서를 동시에 작성 받았음.

본건 담보목적물은 감정가보다 선순위채권액이 커서 근저당권 설정만으로는 채권보전이 불가능함에 따라, 기업의 이익에 실질적 관련이 있는 신청인 및 C씨의 연대보증을 받아야 본건 대출을 취급할 수 있는 상황이었음.

본건 대출실행 당일 대출금 대부분이 신청인이 감사로 재직 중인 D기업으로 이체되었는데, D기업 대표이사 E씨는 “차주사 관리이사” 직함도 사용한 것으로 보아 두 회사는 경제적 실체가 동일하다고 볼 것이므로, 결국 본건 대출금은 신청인과 직·간접적으로 관련이 있다 할 것이어서 신청인을 “단순한 제3자 담보제공자”와 같이 보아 보호할 수는 없음.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 ① 본건 보증계약 자체가 유효하게 성립되었다고 볼 수 있는지 여부와, ② 보증계약 자체는 유효하게 성립되었다고 하더라도 담보제공자인 신청인이 동시에 연대보증인의 책임을 부담하는 것이 정당한지 여부로 볼 수 있음.

(1) 본건 보증계약의 성립 여부

법원은 “처분문서의 진정성립이 인정되면 법원은 그 기재 내용을 부인할 만한 분명하고도 수궁할 수 있는 반증이 없는 한 원칙적으로 그 처분문서에 기재되어 있는 문언대로의 의사표시의 존재와 내용을 인정하여야 한다”고 판시하고 있음.¹⁵⁰⁾

앞서 본 바와 같이 신청인은 본건 근보증서의 ‘연대보증인 표시’란에 자신의 성명·주소를 자필 기재한 사실과 ‘피보증채무의 종류 및 범위’, ‘근보증 한도액’ 및 ‘근보증 결산기’ 등 근보증서의 모든 기재사항을 자필 기재한 사실을 인정하고 있는 바, 본건 근보증서는 진정성립이 인정됨. 그렇다면, 위 판례의 취지에 따를 때 본건 근보증서의 기재내용을 부인하는 신청인 측의 “분명하고도 수궁할 수 있는 반증”이 없는 한 본건은 원칙적으로 “근보증서에 기재되어 있는 문언대로” 보증계약이 성립하였다고 인정되어야 함.

이에 대하여 신청인은 본건 근보증서 작성 당시 보증의사가 없었음을 입증하는 자료로 2008.12.4.자 B씨 및 C씨의 각 확인서 및 12.18.자 ‘녹취서’를 제출하였으나, 진술자인 B씨와 C씨는 신청인의 오빠 및 그 배우자로서 친인척 관계에 있고, 그 내용상으로도 신청인의 주장을 그대로 반복하고 있는 것으로서 객관적인 증거가치가 있다고 보기 어려운 바, 이를 처분문서의 기재내용에 대한 “분명하고도 수궁할 수 있는 반증”이라고 평가할 수 없음.

따라서, 현재로서는 신청인의 주장을 입증할 다른 증거를 발견할 수 없는 이상 본건 보증계약은 근보증서의 기재내용대로 일응 유효하게 성립한 것으로 판단됨.

(2) 신청인에 대한 연대보증책임 인정의 정당성 여부

법원은 “동일한 사람이 동일채권의 담보를 위하여 연대보증계약과 근저당권설정계약을 체결한 경우라 하더라도, 위 두 계약은 별개의 계약이므로 연대보증책임의 범위가 근저당권의 채권최고액의 범위내로 제한되기 위해서는 이를 인정할 만한 특별한 사정이 입증되어야 한다”고 판시하고 있고,¹⁵¹⁾ 금융분쟁조정위원회는 근보증서가 담보제공을 확인하는 의례적, 형식적인 절차에 지나지 않는다고 볼 수 있는 경우에는 물상보증인 겸

150) 대법원 2005.5.27. 선고 2004다60065 판결 등 참조.

151) 대법원 1993.7.13. 선고 93다17980 판결 등 다수 판례 참조.

연대보증인은 담보책임만을 부담한다는 취지의 조정결정을 한 바 있음.¹⁵²⁾

신청인은 담보제공자인 자신에게 연대보증책임까지 부담시키는 것은 부당하다는 취지로 주장하나, 아래와 같은 이유로 결국 신청인에게는 본건 근보증서에 따른 보증책임이 인정된다고 판단됨.

① 관련 판례들을 보면, 보증계약은 근저당권설정계약과 별개의 계약이라는 전제하에 “특별한 사정”이 인정되는 경우에 한하여 ‘보증한도액’을 근저당권 채권최고액으로 ‘제한’하는 해석을 하고 있으나, 진정성립이 인정되는 ‘보증계약 자체의 효력’을 ‘부인’하는 예는 찾아보기 어려움. 본건은 이미 근보증서 자체에 보증한도액이 근저당권 채권최고액과 동일하게 설정되어 있으므로 보증책임을 제한할 실익도 없음.

② 본건 관련 금융분쟁조정사례들의 핵심 판단기준은 “근보증서가 담보제공을 확인하는 의례적, 형식적인 절차에 지나지 않는다고 볼 수 있는지 여부”라 할 것인데, 본건의 경우 선순위 근저당권 채권최고액의 과다로 본건 담보부동산의 유효담보가가 ‘0원’인 점을 감안할 때 피신청인이 의례적, 형식적으로 근보증서에 자서를 요구하였다고 보기는 어려움.

③ 또한 위 조정사례들은 ‘대출의 이익은 향유하지 못하면서 책임만을 부담하는 단순한 제3자 담보제공자’를 보호하기 위한 취지라 할 것이므로, 본건 대출금 대부분이 신청인이 감사로 제직 중인 D기업으로 이체된 본건에 있어서는 신청인을 “단순한 제3자 담보제공자”와 같이 보아 보호할 수는 없음.

라. 결 론

그렇다면, 2008.5.29.자 근보증서에 의한 보증채무가 존재하지 아니한다는 신청인의 주장은 이유 없으므로 이를 기각함.

152) 금융분쟁조정번호 제1995-15호, 제1997-3호, 제1997-18호 등. 참고로 동 사례들은 금융회사가 담보 부동산 경매를 실시하여 배당금을 지급받아 연체대출금 상환에 충당한 후 부족채권이 발생하자 별도의 보증책임을 청구한 사안이었고(즉 담보부동산이 ‘유효한 담보가치’를 갖는 것이었음), 주채무자와 담보제공자 사이에 경제적 이익을 공유하고 있는 밀접한 관계에 있다고 보기 어려운 건들이었음.

3-7 담보가액이 충분함에도 물적담보책임외에 보증책임을 지운 경우

[인용] 부동산 유효담보가액이 대출금을 훨씬 초과하고 근저당권설정계약서와 근보증서가 동시에 작성되었으며 채권최고액과 보증한도가 정확히 일치하고 있는 점, 피신청인 내규에 의하면 ‘담보물건의 가치하락에 대비한 담보제공자의 연대입보는 할 수 없다’고 되어 있고, 신청인의 재산 및 신용상태 등에 대하여 별도 신용조사를 하지 아니한 점 등을 감안시 신청인이 별도의 보증책임까지 부담할 의사가 있었다고 보기 어려움.(2010.4.13. 조정번호 제2010-36호)

가. 사실관계

2008.3.18. 신청외 A씨가 B기업의 피신청인에 대한 대출채무 46억원을 면책적으로 채무인수하고, 같은 날 신청인은 자신 소유의 토지¹⁵³⁾를 A씨를 위한 담보로 제공하는 내용의 근저당권 설정계약 및 근보증계약(이하 ‘본건 근보증계약’)을 피신청인과 체결하였으며, 동 채무인수 당시 본건 대출과 관련하여 존재한 담보의 채권최고액은 34.5억원, 유효담보가는 124.4억원임. 피신청인은 2008.6.30. 본건 대출잔액 39억원에 대하여 기한 연장(연장기일 2009.5.12.)을 하였고, 2008.8.5. 본건 대출의 기한이익이 상실되자 피신청인은 신청인의 담보 부동산에 대한 경매를 실행¹⁵⁴⁾하였음.¹⁵⁵⁾

한편 본건 근보증서 작성시 보증인들에 대한 별도의 신용조사는 실시하지 않았음.

나. 당사자 주장

(1) 신청인 주장

신청인은 A씨 측에게 본건 담보부동산을 매도하기로 한 상태에서 등기부상 소유권자

153) 신청인과 A씨 측은 2008.3.29. 본건 부동산에 대해 매매계약을 체결하였음.

154) 2필지는 배당완료(90백만원), 나머지 2필지는 경매 진행중(현물담보 처분금액: 약 15억원).

155) 신청외 C씨(A씨의 동업자) 진술내용 : “신청인은 담보부동산의 매도인 위치에서 단순히 담보제공 의사만 있었을 뿐 별도의 보증채무까지 부담할 의사는 없었으며, 피신청인 직원이 신청인으로부터 근저당권설정계약서 및 근보증서에 자서받을 때 신청인에게 연대보증인을 겸한다는 설명을 하지 않았음. 이후 2008.9.14. 14:30경 신청인으로부터 ‘자신이 본건 대출의 연대보증인이 되어 있다’는 항의전화를 받고 피신청인 직원에게 시정을 요구했으며, 이에 직원은 시정하겠다고 약속한 사실이 있음”.

로 되어 있는 관계로 근저당권설정계약서에 서명할 때 피신청인 직원(차장 D씨)이 시키는 대로 근보증서의 연대보증인 란에 서명하였으나, 은행직원으로부터 담보책임 이외에 별도의 보증책임까지 부담해야 한다는 설명 등을 듣지 못하였으며 담보책임 이외에 보증채무까지 부담할 의사가 없음.

(2) 피신청인 주장

신청인이 담보제공과 아울러 대학 교수로 재직 중인 점을 감안할 때 보증능력이 있다고 판단되어 근보증에 대하여 신청인에게 설명하고 신청인으로부터 직접 근보증서에 자필 서명을 받았으므로 신청인에게 보증책임을 청구하는 것은 당연함.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 피신청인이 ‘담보제공자 겸 연대보증인’으로 되어 있는 신청인에게 물적 담보 책임 외에 보증책임까지 묻는 것이 정당한지 여부라 할 것임.

(1) 관련 판례 및 조정 사례

법원은 “보증계약의 성립을 인정하려면 당연히 그 전제로서 보증인의 보증의사가 있어야 하고, 이러한 보증의사의 존부는, 당사자가 거래에 관여하게 된 동기와 경위, 그 관여 형식 및 내용, 당사자가 그 거래행위에 의하여 달성하려는 목적, 거래의 관행 등을 종합적으로 고찰하여 판단하여야 할 당사자의 의사해석 및 사실인정의 문제이지만, 보증은 이를 부담할 특별한 사정이 있을 경우 이루어지는 것이므로, 보증의사의 존재나 보증범위는 이를 엄격하게 제한하여 인정하여야 할 것”이라고 판시¹⁵⁶⁾하고, “근보증약정과 근저당설정계약은 별개의 계약으로서 원칙적으로 그 성립과 소멸이 따로 다루어져야 할 것이나, 근보증의 주채무와 근저당의 피담보채무가 동일채무인 이상 근보증과 근저당권은 특별한 사정이 없는 한 동일채무를 담보하기 위한 중첩적인 담보로서 근저당권 실행으로 변제를 받은 금액은 근보증의 한도액에서 공제되어야 한다”고 판시하고 있음.¹⁵⁷⁾

금감원 분쟁조정위원회는 주채무자가 아닌 제3자가 주채무자를 위하여 담보를 제공함

156) 대법원 1998.12.8. 선고 98다39923 판결 참조.

157) 대법원 2004.7.9. 선고 2003다27160 판결 참조.

과 동시에 근보증서에 서명날인 하였다고 하더라도 그 보증계약이 담보제공을 확인하는 의례적, 형식적인 절차에 지나지 않는다고 볼 수 있는 경우에는 담보책임만을 부담한다는 취지의 조정결정을 다수 한 바 있음.¹⁵⁸⁾

(2) 신청인의 보증책임 여부

위 조정사례 등에 비추어 볼 때, 아래와 같은 이유로 신청인에게 본건 근보증서에 따른 보증책임을 묻는 것은 부당하다고 판단됨.

① 본건 대출 취급시 피신청인이 취득한 담보물건의 유효담보가액이 대출금액보다 적게 산정되었다면 신청인에게 보증책임을 부담시킬 진정한 의도로 근보증서를 작성받았다고 볼 수도 있겠으나 동 대출관련 유효담보가액이 대출금액을 훨씬 초과하고 있으며, 본건 근저당권설정계약서와 근보증서가 동시에 작성되었고 채권최고액과 보증한도가 정확히 일치하고 있는 점.

② 피신청인의 대출규정 제26조에 의하면 ‘제3자가 담보제공과 동시에 연대보증을 할 경우에는 담보제공자 본인의 자유의사에 따라 연대입보케 하여야 한다. 다만 담보물건의 가치하락에 대비한 담보제공자의 연대입보는 할 수 없다’고 되어 있고, 제27조에 채무자 및 보증인에 대하여는 소정양식에 의하여 재산, 신용 및 사업실태를 조사하여야 한다고 규정하고 있음에도 신청인의 재산 및 신용상태 등에 대하여 별도의 신용조사를 하지 아니한 점.

③ 신청인이 본건 부동산을 담보제공하게 된 경위가 A씨에게 부동산을 매도하기로 한 상태에서 등기부상 소유권자로 되어 있는 관계로 담보를 제공하게 된 점을 감안해 볼 때, 신청인이 담보책임 이외에 별도의 보증책임까지 부담할 의사가 있었다고 보기 어려운 점.

라. 결 론

그렇다면, 본건 2008.3.18.자 보증채무는 존재하지 아니한다는 할 것임.

158) 금융분쟁조정위원회 조정번호 제1996-5호, 제1996-12호, 제1997-3호, 제1997-18호 등 참조.

제3절 퇴직임원의 보증책임

3-8 퇴직 고용임원의 보증책임 범위

[인용] 신청인은 차주사의 이사로 재직하던중 차주사의 은행대출과 관련하여 포괄근보증한 후 퇴사하였고, 이후 은행은 신청인의 동의없이 수차례 대출기한을 연장하거나 신규 대출을 취급해오다 차주사가 부도처리되자 신청인의 예금을 지급정지하였는 바, 신청인이 고용임원 퇴임후 보증해지 의사표시를 명시적으로 하지는 아니하였으나 은행은 신청인의 퇴사사실을 알고 있었고, 신청인의 퇴임후 신청인의 동의없이 기한연장하거나 신규취급으로 인하여 피보증채무의 동일성이 상실됨에 따라 신청인의 재임중 발생한 보증채무는 소멸되었다고 인정되므로 은행은 신청인의 예금지급정지를 해제하여야 함.(1999.7.20. 조정번호 제1999-25호)

가. 사실관계

신청인은 A기업(이하 “차주사”라 함)의 이사로 재직¹⁵⁹⁾할 당시인 1988.8.8. 차주사가 ○○은행(이하 “피신청인”이라 함)과 무역금융 여신거래약정(한도 2억원)을 체결함에 있어 연대보증(보증한도 2.5억원의 포괄근보증)을 함.

1988.8.8. 이후에 차주사와 피신청인 사이에 작성된 여신거래서류상에도 신청인은 차주사의 연대보증인으로 기재되어 있으며, 1998.3.16. 신청인은 차주사의 이사직을 퇴임함.

1998.6.3. 피신청인은 차주사의 무역어음대출 여신거래약정(한도 2억원) 체결시 신청인이 차주사 이사직을 퇴임한 사실을 인지하였으나 신청인 앞 보증채무를 확정하여 청구한 사실이 없을 뿐만 아니라, 1998.11.13.~1999.2.8. 기간중 차주사의 여신을 신청인의 동의 없이 기한연장(10건, 261백만원)해 주거나 신규 취급(2건, 198백만원)함.

1999.3.26. 차주사가 부도처리되었으며, 동일자에 피신청인은 신청인의 예금 4백만원을 지급정지함.¹⁶⁰⁾

159) 피신청인은 1988.8.8. 작성된 근보증서를 근거로 하여 1988.8.8.이후의 차주사와 피신청인간의 여신거래시 별도의 보증서를 작성하지 아니하고 신청인을 차주사 앞 여신거래에 대한 연대보증인으로 관리해 옴.

나. 당사자의 주장

(1) 신청인의 주장

1988.8.8. 근보증계약 체결시 작성한 연대보증상담표상의 기록에 의하면 동 근보증서의 보증기간은 최장 5년임. 동 근보증서는 작성후 10년이 경과하였으므로 피신청인의 보증채무청구권이 시효소멸하였을 뿐만 아니라 차주사의 여신은 신청인이 차주사를 퇴임한 이후 기한연장되거나 신규 취급됨. 따라서 신청인은 차주사의 대출채무에 대한 상환의무가 없으므로 피신청인이 신청인의 예금계좌에 행한 지급정지 조치를 해제하여야 함.

(2) 피신청인의 주장

연대보증상담표에 기재된 보증기간 문언은 보증인이 보증기간을 한정시키는 경우 최장 5년 이내로 보증기간을 설정할 수 있음을 의미하므로 본건 근보증서와 같이 동 보증서 작성시 보증기간을 정하지 아니한 보증계약은 보증인이 해지의사를 표시할 때까지 유효한 것임.

신청인은 근보증서 작성시에 본인이 자서날인하였으며 보증계약일로부터 3년이 경과한 후에는 동 보증계약을 해지할 수 있었음에도 신청인의 예금을 지급정지할 때까지 피신청인에게 아무런 의사표시도 없었음.

한편, 본건 근보증서의 소멸시효 기산점은 근보증서를 작성한 때(1988.8.8.)가 아니라 피신청인이 신청인의 피보증채무를 확정시킨 날¹⁶¹⁾(1998.6.3.)가 되므로 상법상의 소멸시효기간(5년)이 경과되지 아니함.

다. 위원회의 판단

160) 피신청인은 신청인 소유 부동산에 대한 채권보전조치를 하려 하였으나 1999.3.27.자로 동 부동산에 소유권이전 청구권 가등기가 설정되어 있어 이에 대한 채권보전조치를 중지하였으며, 1999.6.30.현재 피신청인의 차주사 앞 대출금잔액은 4.6억원이며 피신청인이 신청인에게 청구한 보증채무금액은 2.5억원임.

161) 신청인의 차주사 이사직 퇴임사실을 피신청인이 인지한 때(즉 신청인의 차주사 퇴임 후 차주사와 피신청인간의 최초 여신거래가 있었던 날)를 말함.

◆ 본건 쟁점은 본건 근보증계약의 존속기간을 5년으로 보아 보증채무청구권의 소멸시효가 완성된 것으로 볼 수 있는지 여부와 회사 재직중 회사를 위하여 보증한 자에 대하여 퇴직후에도 보증채무를 부담토록 하여야 할 것인지 여부임.

(1) 소멸시효 완성 여부

신청인은 연대보증상당표상 보증기간에 관한 문언이 “보증계약일로부터 최장 5년 이내에 설정하실 수 있으며, 보증기간을 정하지 아니한 경우에는 보증계약일로부터 3년이 경과하면 피보증채무의 확정을 청구하실 수 있습니다”로 표시되어 있으므로 1988.8.8자 근보증계약에 의한 신청인의 보증책임은 1993.8.8.자로 종료되었으며, 그 후 상법상의 소멸시효기간인 5년이 경과하였으므로 피신청인의 신청인에 대한 보증채무청구권은 소멸시효가 완성되었다 주장함.

그러나, 신청인과 피신청인이 체결한 근보증계약은 채권자와 주채무자 사이에 계속적인 거래관계로 인한 현재 및 장래에 발생하는 불확정적인 채무에 관하여 보증책임을 부담하는 계약으로 보증기간을 한정하는 경우에는 5년 이내의 기간내에서 보증기간을 설정할 수 있다는 의미내용이며 본건과 같이 보증기간을 정하지 아니한 경우에는 보증계약일로부터 3년이 경과한 후에 보증인이 보증계약해지의 의사를 표시할 때까지는 차주사를 위한 보증책임을 있다고 판단됨.

신청인은 동 근보증계약서상 보증계약일로부터 3년이 경과하면 보증계약을 해지할 수 있는 것으로 약정되어 있으므로 보증계약일인 1988.8.8.부터 3년이 경과한 1991.8.8.부터는 보증계약을 해지할 수 있었음에도 보증계약일 이후 피신청인이 신청인의 예금을 지급정지하기전까지 동 근보증계약 해지와 관련하여 피신청인에게 어떠한 조치도 요청하지 아니한 점으로 보아 동 보증계약은 계속 유지되어 온 것이며 따라서 소멸시효가 완성되었다고 보기 어려움.

(2) 고용임원 퇴임후 기한연장시 보증채무 부담 여부

피신청인은 신청인이 차주사를 퇴직(1998.3.16.)한 후에도 피신청인에 대하여 퇴직사실 통보 또는 동사의 보증채무 해지를 요청한 바 없어 신청인의 보증채무는 금융분쟁조

정신청일 현재까지 유효하게 존재하므로 피신청인은 신청인의 차주사 채무에 대하여 보증한도(250백만원) 범위내에서 보증채무를 부담하여야 한다 주장하나, 아래와 같은 점에 비추어 볼 때 신청인의 보증채무는 존재하지 아니한다고 볼 것임.

① 차주사의 대출금은 신청인이 퇴직한 이후 모두 기한연장이 되거나 신규 취급되었을 뿐만 아니라 관련 차입신청서의 연대보증인란에 신청인의 성명이 기재되어 있지 아니한 점.

② 피신청인은 신청인의 차주사 퇴직사실을 인지(1998.6.3.)하고 있었음에도 신청인에게 아무런 통보나 보증의사를 확인한 사실이 없었던 것으로 볼 때 신청인을 차주사의 대출금에 대한 보증인으로 인식하고 있었다고 보기 어려운 점.

③ 고용임원의 보증책임은 재직시에 발생한 채무에 국한된다는 판례¹⁶²⁾ 및 은행감독원 금융분쟁조정위원회의 조정결정¹⁶³⁾의 취지에 비추어 볼 때, 차주사의 고용임원이었던 신청인이 퇴직한 후 피신청인이 신청인의 동의없이 차주사의 대출금을 기한연장해준 후 동 채무에 대해서까지 포괄근보증서를 근거로 하여 신청인에게 보증 채무를 부담하도록 하는 것은 당사자의 진의에 맞지 아니한다 판단되는 점.

④ 신청인은 차주사의 임원으로 재직하고 있었다는 사실 때문에 피신청인에 대하여 보증채무를 부담하기로 약정하게 된 것으로 인정되는 바, 신청인이 퇴직한 이상 신청인에게는 더 이상 보증채무를 부담시킬 만한 이유가 없다고 봄이 거래관념에 적합한 점.

라. 결 론

위에서 살펴본 바와 같이 신청인이 차주사 재직중 약정한 보증채무는 소멸시효가 완성되지 않은 것으로 보이나 신청인이 차주사를 퇴직한 사실을 인지하고도 기한연장시 신청인에게 보증의사를 확인하지 아니하였으므로 신청인의 보증채무는 존재하지 않음.

162) 대법원, 1987.4.28. 선고 82다카789 판결 참조.

163) 금융분쟁조정위원회 조정번호 제1991-15호 참조.

3-9 기존 대표의 보증 해지 및 신규 대표 임보가 보증인 교체에 해당하는지

[인용] 신청인이 차주사의 이사(과점주주)로 재직할 당시 차주사를 위하여 연대보증한 후 차주사를 제3자에게 양도하면서 피신청인에게 보증인 교체를 요청하여 피신청인이 신청인과의 보증계약을 해지하고 신임 대표이사로 연대보증을 교체한 사실이 인정되므로 신청인의 보증채무는 존재하지 아니함.(1999.5.11. 조정번호 제1999-14호)

가. 사실관계

신청인은 A기업(이하 “차주사”라 함)의 이사(과점주주)로 재직할 당시인 1990.7.27. 차주사가 ○○은행(이하 “피신청인”이라 함)에서 시설자금대출 3억원(만기일: 2000.6.19.)을 받는 데 대하여 연대보증(포괄근보증, 보증한도 4.5억원)하였으며, 1990.9.28. 차주사가 피신청인으로부터 시설자금대출 2억원(만기일: 2000.6.19.)을 받는 데 대하여 연대보증(포괄근보증, 보증한도 3억원)함.

1992.10.10. 신청인은 차주사를 B씨(신임 대표이사 C씨의 동생)에게 양도하고— 다음 해 3.29. 차주사의 대표이사직(1991.7.1. 취임)을 퇴임함.

1994.2.15. 신청인은 피신청인에게 차주사를 B씨에게 양도하였다는 이유로 시설자금대출 총5억원에 대한 연대보증인 교체를 요청하였으며, 이에 피신청인은 1994.3.4. 신임 대표이사 C씨(차주사 양수인 B씨의 형)과 연대보증계약(한정근보증, 보증한도 7억원)을 체결하면서 신청인과의 연대보증계약을 해지하고 1994.2.18. 기준(연대보증인 교체요청서 접수일)으로 피보증채무액¹⁶⁴⁾을 확정하여 신청인에게 통보함.

1996.2.28. 차주사가 부도처리되자 피신청인은 1996.3.4. 차주사 및 연대보증인에게 기한이익 상실을 통지하고 채무관계자에 대한 채권보전 조치를 하였으며, 1997.8.8. 신청인 소유의 아파트를 가압류함.

동 기한이익상실통지서상에 차주사 여신의 연대보증인으로 B씨, C씨, D씨, E씨, F씨, G씨가 기재되어 있으며, 1996.4.23. 피신청인은 차주사 여신을 동 지점내 대부계에서 채

164) 1994.2.18. 현재 피신청인의 차주사 앞 대출잔액 : 시설자금대출 2건, 5억원.

권관리계로 이관하였는 바, 그 “불건전채권이관조서” 상에도 연대보증인으로 C씨, D씨, E씨, F씨 등 4인이 기재되어 있고 신청인의 이름은 기재되어 있지 않음.

피신청인은 차주사 부도후 1996.3.4.~4.15.기간중 연대보증인 B씨, C씨, D씨, E씨, F씨에 대하여 재산조사를 실시하여 B씨의 부동산을 가압류하고 1996.3.9. 신청인 소유 부동산에 근저당권 설정되어 있는 B씨 명의의 채권을 가압류함.

피신청인은 이건 대출과 관련하여 ○○기금의 대위변제금 2억원, 차주상환금 30백만원, 담보물 경락배당금 72백만원을 회수하여 1999.4.15. 현재 미회수 대출금은 198백만원(원금기준)임.

나. 당사자의 주장

(1) 신청인의 주장

1994.2.15. 차주사 양도를 이유로 보증인 교체를 요청하자 피신청인이 신임 대표이사가 연대보증인으로 입보하면 신청인의 연대보증책임을 해지해주겠다고 하여 신임 대표이사(C씨)가 연대보증 하였는데, 1994.3.4. 피신청인으로부터 보증계약해지 및 피보증채무 확정통보를 받고 이에 대한 이의가 있어 피신청인을 방문, 연대보증인에서 제외되었다는 구두확인을 받았고, 또한 1996.2.28. 차주사 부도시 피신청인이 기한이익상실통지를 한 적이 없음에도 신청인에 대하여 보증책임을 묻는 것은 부당함.

(2) 피신청인의 주장

1994.3.4. 신청인과의 연대보증계약을 해지하고 피보증채무를 확정하여 통보하였고 신청인은 이에 대하여 이의제기한 사실이 없으며, 차주사 부도 당시에는 ○○기금 대위변제 및 담보물건 경매를 통하여 채권회수에 지장이 없을 것으로 판단하여 1997.8월 이전까지 신청인에게 보증채무를 청구하지 않았던 것임.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 피신청인이 신청인과의 연대보증계약을 해지하고 차주사의 신임 대표이사를 연대보증인으로 입보한 것이 종전 대출에 대한 연대보증인을 교체한 것으로 볼 수 있는지 여부임.

일반적으로 회사임원이 회사의 채무에 대하여 연대보증한 후 임원직을 퇴임하여 신입임원이 연대보증계약을 체결한 경우에는 보증계약을 체결하게 된 동기와 목적, 보증서 작성시기와 경위, 회사임원과 회사의 관계, 피보증채무의 종류 등을 종합적으로 고려하여 보증책임의 범위, 보증인의 추가·교체 여부 등을 판단해야 할 것인 바, 1994.3.4. 피신청인은 보증계약을 해지할 때 피보증채무액을 확정하여 통보하였으므로 연대보증인을 교체한 것이 아니라고 주장하나, 다음과 같은 점에 비추어 피신청인은 종전 대출에 대한 연대보증인을 교체한 것으로 판단됨.

① 피신청인은 신청인이 차주사를 양도하였다는 이유로 차주사의 대출에 대한 연대보증인 교체를 요청함에 따라 차주사 양수도 이후 신규여신거래가 없음에도 신청인의 보증채무와 동일한 내용으로 신임 대표이사(C씨)와 연대보증계약을 체결하고 신청인과 의 연대보증계약을 해지한 것인 바, 이러한 사실에 비추어 볼 때 신임 대표이사(C씨)는 차주사 양수도계약¹⁶⁵⁾에 따라 신청인의 연대보증채무를 승계할 목적으로 피신청인과 연대보증계약을 체결한 것이며 피신청인도 이러한 사정을 알고¹⁶⁶⁾ 신임 대표이사(C씨)와 보증계약을 체결한 것으로 인정되는 점.

② 1996.2.28. 차주사가 부도처리되자 피신청인은 차주사에 대한 대출채권 회수절차에 착수하여 신청인을 제외한 신임 대표이사(C씨) 등 다른 연대보증인에 대해서만 기한이익 상실을 통보하였으며, 동 지점의 채권관리계로 이 건 관련서류를 이관할 때 채권이관 조서의 인적담보(연대보증인)란에도 신청인은 기재되어 있지 아니한 점.

③ 차주사 부도직후 채무관계자의 재산에 대한 채권보전조치를 하면서 1996.3.9. 피신청인은 이 건 외의 차주사에 대한 채권보전을 위하여 차주사 채무의 연대보증인 B씨가 신청인 소유 부동산에 근저당권을 설정한 B씨 명의의 채권에 대해서는 가압류를 하면서도 신청인의 부동산 자체에 대하여는 아무런 조치를 취하지 아니한 점.

165) 1993.2.15.자 신청인과 B씨간의 약정서에 의하면 차주사 양수도와 관련하여 B씨는 신청인의 연대보증채무를 승계하는 것으로 되어 있음.

166) 1994.3.4.자 피신청인의 내부품의서류에도 신청인과의 연대보증계약을 해지하더라도 채권보전에 지장이 없을 것으로 판단하고 보증계약을 해지한 것으로 되어 있는 바, 당시 차주사 채무가 이 건 대출 5억원 뿐인 점을 볼 때 이는 다른 담보·보증인 및 신임 대표이사의 신규입보로 채권보전을 하고 신청인을 연대보증인에서 제외하는 것이라고 해석됨.

라. 결 론

따라서 피신청인은 신청인과의 연대보증계약을 해지하면서 신임 대표이사(C씨)로 연대보증을 교환한 것으로 인정되므로 피신청인은 신청인에게 차주사의 시설자금대출에 대한 보증책임을 물을 수 없는 것으로 판단됨.

제4절 기타

3-10 금융기관 직원에게 단순히 명의만 제공한 형식상 보증인의 보증책임

[인용] 신청인은 피신청인의 지점장으로부터 변제하겠다는 각서를 받고 제3자를 명의차주로 하고 신청인이 형식적으로 연대보증하였음에도 피신청인이 신청인에게 보증책임을 청구함은 부당하다고 주장하고 있는 바, 피신청인과 신청인간 체결된 연대보증계약은 피신청인이 보증책임을 물을 의사없이 신청인을 형식상으로 연대보증인으로 한 사실이 인정되므로 신청인에게 보증책임을 청구할 수 없음.(1999.7.20. 조정번호 제1999-26호)

가. 사실관계

1994.6.10. 신청인은 신청외 A씨가 ○○은행(이하 “피신청인”이라 함) ○○출장소에서 30백만원¹⁶⁷⁾을 대출(이하 “대출A”이라 한다) 받음에 있어 신청외 A씨의 연대보증인으로 피신청인의 지점에 가서 금전소비대차약정서에 자서하고 날인함.

피신청인은 대출A가 기한의 이익을 상실하자 1994.12.5. 신청인 소유 교회 건물 및 토지(이하 “본건 부동산”이라 함)를 가압류하며 보증채무를 이행토록 청구하였고, 1995.8.23.에는 차주 A씨의 부친 B씨로부터 보증한도를 36백만원으로 하는 한정근보증서를 받음.

피신청인의 ○○출장소장 C씨는 1995.12.30. 대출A의 연체이자 등을 포함한 총 40백만원 중 20백만원을 변제하겠다는 각서를 신청인에게 제공하고, 동일자로 차주 D씨(보증인: 신청인, 이하 “대출B”¹⁶⁸⁾라 함), 차주 E씨(보증인: △△△)에게 각각 20백만원을 대출하여 대출A을 회수·정리하였으며 1996.1.15. 본건 부동산에 행한 가압류를 말소함.

그 후 대출B가 연체되자 피신청인은 1997.6.25. 차주 D씨를 신용불량거래자(적색거래처)로 등록하고, 같은 해 11.24. 본건 부동산에 대하여 가처분(1998.6.19. 본건 가처분 해

167) 신청인은 차주인 신청외 A씨로부터 10백만원의 보증 부탁을 받았으며 대출금액만이 공란이었으나 동 금액은 10백만원인 것으로 알고 자서날인하였다고 주장함.

168) 대출B는 C씨가 피신청인의 ◇◇지점으로 전입(1996.1.26.)한 후 ○○출장소에서 ◇◇지점으로 이관(1997.1.10.)함.

제) 조치함.

피신청인은 ◇◇지점에 대한 자체 정기검사(1998.2.19.~2.26.) 과정에서 대출B를 포함한 6건, 1.2억원의 대출취급과 관련하여 잘못이 있음을 인정하고 C씨를 면직(1998.4.29.)시킴.

나. 당사자의 주장

(1) 신청인의 주장

피신청인의 ○○출장소장 C씨가 대출B에 대하여 원금 및 이자를 상환하겠다는 각서를 신청인에게 제출하였고 차주 D씨 및 신청인은 단순히 채무자 및 연대보증인으로 등록되어 있을 뿐 실질채무자는 C씨임.

피신청인의 자체검사에서 C씨에게 책임이 있다는 결정을 하고 본건 부동산에 대한 가처분을 해제한 바 있으므로 피신청인은 차주와 신청인에게 대출채무 및 보증채무를 청구할 수 없으며, 또한 피신청인의 출장소장이 대출업무와 관련하여 신청인에게 손해를 입혔으므로 피신청인은 사용자로서 책임을 부담하여야 함.

(2) 피신청인의 주장

대출B 취급시 C씨가 원금 및 이자를 본인이 상환하겠다는 각서를 작성하여 신청인에게 제공하였으나 동 각서는 그 내용 및 표현을 볼 때 개인적으로 작성한 것일 뿐 피신청인의 대리인 자격으로 작성한 것으로는 볼 수 없음. 또한 출장소장이 대출에 대하여 피신청인을 대리 또는 대표하여 대출금 변제를 약속하는 것은 내부규정이나 금융관행에 비추어 볼 때 인정되지 아니하므로 피신청인이 사용자책임을 부담할 수 없음.

피신청인의 출장소장에 대한 부책결정으로 인하여 차주의 채무가 소멸되는 것은 아니며, 차주와 신청인은 대출서류에 자필서명하였으므로 채무상환책임을 면할 수 없음.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 1995.12.30.자 금전소비대차약정서에 의하여 취급한 차주 D씨의 대출채무 및 신청인의 보증채무가 존재하느냐의 문제임.

(1) D씨의 대출채무 존재 여부

대법원은 금융기관이 동일인에 대한 대출한도를 회피하기 위하여 실질적인 채무자가 제3자를 형식상의 주채무자로 내세우고, 금융기관도 이를 양해하여 제3자에 대하여는 채무자로서의 책임을 지우지 않을 의도하에 제3자 명의로 대출관계서류를 작성받은 경우에는 제3자는 형식상의 명의만을 빌려준 자에 불과하고 그 대출계약의 실질적인 당사자는 금융기관과 실질적 채무자이므로 제3자 명의로 되어 있는 대출약정은 통정허위표시에 해당하는 무효의 법률행위라고 판시¹⁶⁹⁾하고 있음.

본건과 관련하여 아래와 같은 점을 감안할 때 1995.12.30.자 대출B 계약은 실제차주 C씨와 피신청인 사이에 이루어진 계약으로 보아야 하고 명의 차주 D씨는 단순한 차주명의를 제공한 자로서 동 대출채무를 부담할 의사 없이 대출 관련 서류에 자서날인하였으며 피신청인도 이와 같은 사실을 알고 있었으므로 통정허위표시에 해당하는 무효의 법률행위에 해당되어 대출채무는 존재하지 아니하는 것으로 판단됨.

① 대출B 취급시 출장소장이 원금 및 이자를 본인이 상환하겠다는 각서를 작성하여 신청인에게 제공한 점. ② 1998.2.19.~2.26. 기간중의 피신청인의 자체 검사에서 동 대출금을 C씨가 사용하였고 동 대출금이자도 C씨가 납부하였음을 인정하고 있는 점.

(2) 신청인의 보증채무 존재 여부

① 대출B 취급시 출장소장이 원금 및 이자를 본인이 상환하겠다는 각서를 작성하여 신청인에게 제공한 점, ② 대출B가 연체되자 피신청인이 신청인 소유 부동산에 대하여 가처분하였다가 ◇◇지점에 대한 정기검사 과정에서 대출B를 포함한 6건, 1.2억원의 대출 취급과 관련하여 C씨가 제3자 명의를 이용하여 대출받아 사용한 사실을 적발하여 C씨를 면직처분하고 신청인 소유 부동산에 행한 가처분을 해제한 점 등을 감안시 신청인이 보증책임을 부담할 의사가 있거나 은행에서 신청인에게 보증책임을 청구할 의사가 있었던 것으로는 판단되지 아니함.

라. 결 론

따라서 피신청인은 대출B와 관련하여서는 신청인에게 보증책임을 물을 수 없음.

169) 대법원, 1992.6.12. 선고 92다10722 판결, 1999.3.12. 선고 98다48989 판결 등 참조.

3-11 후취담보로 인한 포괄근보증 효력의 소멸 여부

[기각] 포괄근보증계약에 있어서 동 포괄근보증계약서가 처분문서이고 당사자가 포괄근보증서에 서명날인 한 사실은 인정하고 있는 경우 결국 포괄근보증에 있어 처분문서로서의 효력발생 여부는 당해 포괄근보증이 체결된 것이 은행대차관계에 있어 이례에 속하고 관례를 벗어나는 것인지 여부와 피담보채무의 범위를 제한하는 개별약정이 있었는지 여부에 따라 결정될 것임.(2004.2.10. 조정번호 제2003-67호)

가. 사실관계

A기업(대표이사 B씨)과 개인 B씨(이하 “신청인들”이라 함)는 사건외 C기업(대표이사 B씨, 이하 “채무자”라 함)¹⁷⁰⁾이 피신청인 ○○은행(이하 “피신청인”이라 함)으로부터 받은 시설자금대출 58억원(1994.2.19. 36억원, 1994.6.25. 22억원, “본건 대출금”이라 함)에 대해 1994.2.19. 각각 포괄근보증(보증한도 75.4억원, 이하 “본건 포괄근보증”이라 함)을 하였음.

1994.6.24. 피신청인은 채무자 소유의 공장시설에 대해 후취담보(채권최고액 104억원)를 취득하였으며, 공장시설의 토지에 대해서는 채무자 명의로 소유권 이전이 늦어짐에 따라 1996.7.5. 근저당권을 추가 설정함.

2000.6.16.자로 채무자 명의의 본건 대출금 58억원이 전액 상환되었고, 다음 해 1.4. 피신청인은 채무자의 대출금이 증가함에 따라 본건 공장시설 및 대지에 근저당권(채권최고액 16억원)을 추가 설정함.

2003. 9. 5. 신청인들은 피신청인이 채무자 소유의 공장시설에 대해 후취담보를 취득하였고, 본건 대출금은 전액 상환되었으므로 피신청인에게 본건 대출금에 대한 신청인들의 연대보증채무는 존재하지 않는다고 통보함.

2003.9.19. 피신청인은 신청인들의 상기 통보에 대해 상기 연대보증은 포괄근보증이고, 현재 동 포괄근보증의 피보증채무가 남아 있어 보증채무가 소멸되지 않았음을 통보함.

170) 2002.7.16. C기업의 대표이사는 D씨로 변경됨.

나. 당사자의 주장

(1) 신청인 주장

채무자가 피신청인으로부터 시설자금 58억원을 대출 받음에 있어서 담보부족분에 대해 채무자의 공장시설에 대해 후취담보를 취득할 때까지 신청인들이 한시적으로 연대보증을 한다는 사실에 대해 피신청인과 협의를 한 사실이 있고 현재 피신청인은 채무자의 공장시설에 대해 후취담보를 취득하였음. 나아가 본건 대출금도 전액 상환되어 보증채무가 소멸되었으므로 피신청인은 신청인들의 본건 포괄근보증을 해지해 주어야 함.

(2) 피신청인 주장

피신청인은 채무자 명의로 본건 대출금 취급시 담보부족분에 대해 신청인들과 채무자 소유의 공장시설에 대해 후취담보를 취득 할 때까지 한시적으로 신청인들을 연대보증인으로 입보한다는 사실에 대해 협의한 적이 없으며, 상기 연대보증은 채무자의 현재 및 장래에 부담하는 모든 채무를 보증한도액(75.4억원) 내에서 연대보증하는 포괄근보증인바, 현재 동 포괄근보증의 피보증채무(2003.11.30. 현재 64.1억원)가 전액 상환되지 않았으므로 본건 포괄근보증을 해지할 수 없음.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 근보증채무의 소멸원인과 관련하여 ① 본건 근보증이 후취담보의 취득으로 소멸한 것인지 여부, ② 본건 근보증의 피보증채무의 범위가 채무자의 현재 및 장래의 모든 채무를 보증한도 내에서 보증하는 포괄근보증인지 여부라 할 것임.

(1) 본건 근보증이 후취담보의 취득으로 인하여 소멸하였는지 여부

신청인들은 1994.2.19. 피신청인과 본건 포괄근보증계약 체결시 본건 대출금인 시설자금으로 완공된 채무자의 공장시설에 근저당권(후취담보)을 설정하면 그 시점에서 신청인들의 보증책임은 소멸하는 것으로 피신청인과 협의를 하였고, 1994.6.24. 상기 공장시설에 피신청인이 근저당권을 설정하였으므로 본건 포괄근보증의 효력은 소멸하였다고 주장하나, 아래의 점을 종합하여 볼 때 신청인들의 보증책임이 소멸하였다고 보기 어려움.

① 본건 포괄근보증계약서 제2조(보증기간)에 의하면 그 보증기간은 “정하지 아니한다”라고 규정되어 있고, 본건 포괄근보증계약서는 처분문서에 해당하므로 동 처분문서의 내용을 부정하려면 그 보증기간이 C기업의 공장시설 완료시까지로 한정하기로 하는 당사자간의 합의가 있었다는 사실이 입증되어야 하나 이를 입증할 수 있는 자료를 발견할 수 없는 점.

② 상기 보증계약서 제2조에 “보증약정일로부터 3년이 경과한 때에는 보증인은 서면에 의하여 이 보증약정의 해지의 의사표시를 할 수 있고, 그에 의한 해지의 효력발생은 의사표시가 은행에 도달한 날로부터 45일이 경과한 때로 하며 이때 피보증채무가 확정된다.”라고 규정되어 있으나, 연대보증인인 A기업 및 채무자인 C기업의 실질적인 경영주인 B씨는 1994.6.24. 피신청인이 채무자의 공장시설에 대해 후취담보 취득을 완료한 사실을 인지할 수 있는 지위에 있었음에도 동 후취담보 제공 이후에도 피신청인과 계속 금융거래를 하면서 수년 동안 피신청인에게 보증채무 해지를 요청한 사실이 없는 점(2003.9.5. 신청인들은 서면으로 보증채무 소멸을 주장함).

(2) 본건 근보증의 피보증채무의 범위

신청인들은 본건 포괄근보증서의 문언에 불구하고 2000.6.16.자로 본건 대출금 58억원이 전액 상환되었으므로 신청인들의 보증채무는 소멸되었다고 주장하므로 본건 포괄근보증의 피보증채무의 범위를 본건 대출금 58억원에 한정하여 제한해석 할 수 있는지 여부가 문제되는 바, 은행과 근저당권설정자와의 사이에 근저당권설정계약을 체결할 때 작성된 근저당권설정계약서에 은행의 여신거래로부터 생기는 모든 채무를 담보하기로 하는 이른바 포괄근저당권을 설정한다는 문언이 기재된 경우에, 계약서가 부동산자로 인쇄된 약관의 형태를 취하고 있다 하더라도 이는 처분문서라고 할 것이므로 그 진정성립이 인정되는 때에는 은행의 담보취득행위가 은행대차관계에 있어서 이례에 속하고 관례를 벗어나는 것이라고 보여지거나 피담보채무를 제한하는 개별약정이 있었다는 등의 특별한 사정이 없는 한, 그 문언대로 의사표시의 존재와 내용을 인정해야 하는 바,¹⁷¹⁾ 본건 포괄근보증계약의 경우 동 포괄근보증계약서가 처분문서이고 신청인들은 포괄근보증서

171) 대법원 2003.4.11. 선고 2001다12430 판결 참조.

에 서명날인 한 사실은 인정하고 있으므로 결국 본건 포괄근보증에 있어 처분문서로서의 효력발생여부는 본건 포괄근보증에 체결된 것이 은행대차관계에 있어 이례에 속하고 관례를 벗어나는 것인지 여부와 피담보채무의 범위를 제한하는 개별약정이 있었는지 여부에 따라 결정될 것임.

조사결과, 아래의 각 점을 종합할 때 본건 포괄근보증의 피보증채무 범위를 제한하여 본건 대출금 58억원의 상환만으로 신청인들의 포괄근보증 채무가 소멸되었다고 보기는 어려운 것으로 판단됨.

① 본건 포괄근보증과 관련하여 신청인들과 피신청인 사이에 피보증채무의 범위를 제한하는 개별약정이 있었다는 증거를 발견할 수 없는 점.

② 1994.2.14. 본건 대출금에 대한 연대보증의 건으로 개최된 甲주식회사의 이사회 회의록에도 보증종류에 “포괄근보증”으로 명시되어 있는 점.

③ 1994.2.19. 신청인들이 본건 대출금에 대해 포괄근보증시 신청인들은 채무자인 C기업(대표이사 B씨)의 대주주(주식보유비율 : A기업 50%, B씨 45.8%)로서 실질적으로 채무자의 경영을 책임지는 지위에 있었으므로 고용임원의 경우와 달리 피신청인이 신청인들에게 포괄근보증 책임을 지운 것이 은행실무상¹⁷²⁾ 이례에 속하거나 관례를 벗어난 것이라고 볼 수 없는 점.

라. 결 론

그렇다면 본건 포괄근보증에 후취담보의 취득으로 소멸하였음을 인정할 사정이 존재하지 아니하고 또한 피보증채무의 범위를 처분문서의 문구에도 불구하고 이를 제한할 개별약정의 정황을 찾기 어려우므로 결국 신청인들의 주장을 기각하는 것이 타당한 것으로 판단됨.

172) 피신청인의 “기업금융여신지침”에 의하면 기업여신을 취급할 때는 자산 및 신용상태가 양호한 1인 이상의 연대보증인을 세워야 하며 보증인은 차주사의 과점주주나 실질적인 기업주, 주력계열기업을 우선적으로 입보하여야 한다고 규정하고 있음.

3-12 채무자의 채무관련 신용정보 제공절차 불이행과 보증계약 효력과의 관계

[기각] 「보증인 보호를 위한 특별법」 제8조 해석상 금융기관이 보증계약 체결 당시 채무자의 채무관련 신용정보 제공절차를 이행하지 않았다 하여 바로 보증계약 자체의 효력이 “무효”가 되는 것은 아니고, 다만 보증인은 금융기관에 위 신용정보를 제시할 것을 “요구”할 수 있으며, 금융기관이 7일 이내에 보증인의 요구에 응하지 않는 경우에 비로소 보증계약의 “해지를 통고”할 수 있을 뿐이라고 해석됨.(2009.12.8. 조정번호 제2009-101호)

가. 사실관계

2009.3.2. ○○은행(이하 “피신청인”이라 함)은 여신거래처인 신청의 A기업(이하 “차주사”라 함)이 수입L/C대금 3.8억원을 미결제함에 따라 동 금액을 대지급하였고, 2009.3.17. 피신청인은 차주사에 중소기업자금대출 3.7억원(만기 3년)을 취급하고(이하 “본건 대출”이라 함), 동 대출금으로 위 대지급금을 정리함. 동 대출취급 당시 차주사 대표이사(B씨)¹⁷³⁾ 및 신청인이 연대보증인으로 입보하였음(한정근보증, 보증한도액 4억 45백만원(대출금의 약 120%), 이하 “본건 보증계약”이라 함).

신청인 명의의 ‘2009.3.17.자 근보증서’의 주요 내용은 신청인의 ‘자필’로 작성되었는데, ① 연대보증인란에 “김OO” 및 서명, ② 채무자란에 “A기업”, ③ 피보증채무 범위란에 “한정근보증”, “중소기업자금대출”(거래종류), ④ 근보증한도액란에 “사역사천오백만원”, ⑤ 근보증결산기란에 “장래지정형”이 각 기재되어 있으며, 신청인이 원격지인 부산에 거주하는 관계로, 대출 취급점인 “서울○○지점”이 아닌 “부산◇◇지점” 직원이 대신 신청인을 방문하여 근보증서를 작성 받음.

한편, 피신청인은 본건 보증계약 체결과정에서 「보증인 보호를 위한 특별법」 소정의 “종합신용정보집중기관(본건: 은행연합회)으로부터 제공받은 채무자의 채무관련 신용정보”를 신청인에게 제시하지 않았음. 동 “채무자의 채무관련 신용정보”에는 ① 대출정보, ② 채무보증정보, ③ 연체정보(연체금액·등록일·해제일 표시), ④ 대위변제·대지급정보

173) B씨와 신청인은 고교동창으로서, 신청인은 B씨로부터 “환율상승으로 인한 자금압박으로 긴급하게 대출을 받아야 하니 보증을 서 달라”는 부탁을 받고 보증계약을 체결하게 되었다 함.

(연체금액·등록일·해제일 표시), ⑤ 부도정보가 포함되는바, 그 중 ③, ④항목이 “채무자의 신용상태(위험성)”를 판단할 수 있는 항목인데, 본건 보증계약이 체결된 2009.3.17.에는 해당 항목에 표시될 내용이 없었음(3개월이상 연체시 정보 등재됨).¹⁷⁴⁾

또한, 피신청인은 본건 보증계약의 보증한도액을 “은행내규상 보증가능한도 20백만원”을 초과한 4억 45백만원(대출금의 약 120%)으로 설정하였음.

차주사는 2009.8.18.자로 폐업하였고, 2009.9.18. 본건 대출 원리금의 연체가 발생한 바, 피신청인은 9.28.자 ‘연체대출금정리촉구통지서’ 및 10.2.자 ‘연체대출금 안내장(연대보증인용)’을 발송하며 신청인에게 보증채무¹⁷⁵⁾ 이행을 청구함.

나. 당사자 주장

(1) 신청인 주장

피신청인은 본건 보증계약 체결 당시 「보증인 보호를 위한 특별법」에 규정된 “채무자의 신용정보를 보증인에게 제시하고 그 서면에 보증인의 기명 날인이나 서명을 받는 절차”를 위반하였는 바, 위 법률에 따라 본건 보증책임은 부인되어야 함(주위적 청구).

피신청인은 은행 내규인 「여신업무취급세칙」상 보증한도가 20백만원으로 제한되어 있음에도 이를 위반하였을 뿐만 아니라, 당시 위 보증한도 제한을 고지 받았더라면 당연히 그 한도액에 따라 보증계약을 체결하였을 것이므로, 본건 보증책임은 최소한 위 보증한도 20백만원으로 제한되어야 함(예비적 청구).

(2) 피신청인 주장

본건 보증계약 체결 당시 「보증인 보호를 위한 특별법」 제8조 제1항의 주채무자의 신용정보 제공절차를 이행하지는 않았으나 그 이유만으로 보증계약 자체가 무효로 되는 것은 아니며, 신청인은 차주사 대표이사로부터 보증입보의 부탁을 받고 본건 대출의 내용 및 차주사의 사정에 대하여 충분히 설명을 듣고 이미 “4억 45백만원의 연대입보 의

174) 2009.10.26.자로 신용카드의 3개월 연체가 발생하여 비로소 “은행연합회 관리대상정보”에 등재된 것으로 확인됨.

175) 2009.10.1. 기준 대출잔액 3억 1,837만원, 연체 원리금 합계 1,709만 6,935원.

사결정”을 스스로 내린 상태에서 자발적으로 근보증서를 자필 작성하였는 바, 본건 보증계약은 신청인의 자유의사에 따라 성립한 유효한 계약임.

은행 내규인 「여신업무취급세칙」상 규정된 보증한도를 초과하여 보증을 취급한 것은 사실이나, 그 이유만으로 보증계약의 사법상 효력이 부인 내지 제한된다고 해석할 수는 없음,

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은, ① 「보증인 보호를 위한 특별법」 제8조 제1항 소정의 절차를 이행하지 않은 경우 보증계약 자체가 무효로 되는지 여부와, ② 은행 내규인 「여신업무취급세칙」상 보증한도 제한(20백만원)을 고지하지 않고 이를 초과하여 보증계약을 체결한 경우 보증한도를 제한할 수 있는지 여부라 할 것임.

(1) 「보증인 보호를 위한 특별법」(이하 ‘법’이라 함) 위반의 법적 효력

위에서 본 바와 같이, 법 제8조(금융기관 보증계약의 특칙) 제1항은 “금융기관이 보증계약을 체결할 때에는 채무자의 채무관련 신용정보를 보증인에게 제시하고 그 서면에 보증인의 기명 날인이나 서명을 받아야 한다”고 규정함으로써, 금융기관의 보증인에 대한 “신용정보집중기관으로부터 제공받은 채무자의 신용정보 제시의무”를 인정하고 있음.¹⁷⁶⁾

한편, 법 제11조(편면적 강행규정)는 이 법에 위반하는 약정으로서 보증인에게 불리한 것은 효력이 없다고 명기하고 있는 바, 그렇다면 본건 보증계약이 위 “이 법에 위반하는 약정”에 해당하여 “무효”라고 볼 것인지가 문제됨.

금융기관이 법 제8조 제1항 소정의 채무자의 채무관련 신용정보 제공절차를 이행하지 않은 경우의 효과에 관하여, 위 법은 다음과 같은 ‘직접적인 규정’을 두고 있음. 즉, 금융기관이 보증인에게 채무관련 신용정보를 제시하지 아니한 경우에는 보증인은 금융기

176) 위 법 제정 전의 대법원의 판례는 “일반적인 신용상태 고지의무”를 부정하는 입장이었다(보증제도는 본질적으로 주채무자의 무자력으로 인한 채권자의 위험을 인수하는 것이므로 보증인이 주채무자의 자력에 대하여 조사한 후 보증계약을 체결할 것인지의 여부를 스스로 결정하여야 하는 것이고, 채권자가 보증인에게 채무자의 신용상태를 고지할 신의칙상 의무는 존재하지 아니한다.(대법원 2002.7.12. 선고 99다68652 판결)).

관에 대하여 보증계약 체결 당시 채무자의 채무 관련 신용정보를 제시하여 줄 것을 요구할 수 있고(제8조 제3항), 금융기관이 위 신용정보의 제시요구를 받은 날부터 7일 이내에 요구에 응하지 아니하는 경우에는 보증인은 그 사실을 안 날부터 1개월 이내에 보증계약의 해지를 통고할 수 있고, 금융기관이 해지통고를 받은 날부터 1개월이 경과하면 해지의 효력이 발생함(제8조 제4항).

위와 같은 규정을 종합할 때, 해석상 금융기관이 보증계약 체결 당시 채무자의 채무 관련 신용정보 제공절차를 이행하지 않았다 하여 바로 보증계약 자체의 효력이 “무효”가 되는 것은 아니고, 다만 보증인은 금융기관에 위 신용정보를 제시할 것을 “요구”할 수 있으며, 금융기관이 7일 이내에 보증인의 요구에 응하지 않는 경우에 비로소 보증계약의 “해지를 통고”할 수 있을 뿐이라고 해석됨.

위와 같은 법 제8조의 “직접적인 규정”을 전제로 제11조의 “편면적 강행규정”의 의미에 대하여 살펴보면, 제11조는 금융기관이 보증계약 체결시 “보증인은 채무자의 채무 관련 신용정보의 제시를 요구할 권리를 포기한다”거나 “신용정보 제시요구를 받은 날로부터 7일을 경과하여도 보증인은 보증계약을 해지할 수 없다”는 식으로 약정하더라도 그러한 약정은 보증인에게 불리하여 무효로 된다는 취지라 할 것임.¹⁷⁷⁾

그렇다면, 본건에 있어서도 비록 피신청인이 법 제8조 제1항 소정의 절차를 이행하지 않은 것은 사실이나, 그로써 본건 보증계약 자체가 무효로 된다고 판단하기는 어려울 뿐만 아니라, 만일 본건 보증계약이 체결된 2009.3.17.에 피신청인이 신청인에게 “은행연합회로부터 제공받은 차주사의 신용정보”를 제시하였더라도, 당시에는 위에서 본 바와 같이 차주사의 ‘연체정보’ 또는 ‘대위변제·대지급정보’ 등 “채무자의 신용상태를 판단할 수 있는 항목”에 표시될 내용이 없었으므로¹⁷⁸⁾, 위 서면의 제시여부와 신청인의 본건 보

177) 당초 법무부가 입법예고한 법률안에는 금융기관이 보증계약을 체결할 때 채무자의 신용정보조회서를 보증인에게 제시하고 그 서면에 보증인의 기명 날인이나 서명을 받지 않은 경우 “보증계약이 무효”가 되는 것으로 규정되어 있었으나, 법 제정 과정에서 ‘삭제’됨.

178) 2009.3.17. 기준으로 ‘3개월이상 연체된’ 대출 또는 대지급정보가 없었고, 10.26.에 이르러서야 ‘OO신용카드의 3개월 연체’를 이유로 “은행연합회 관리대상정보”에 등재되었으며, ‘본건 대출 연체’로 인한 관리대상정보 등재는 최소한 연체발생일인 9.18.로부터 3개월이 경과한 12.18. 이후에 이루어지는 것으로 확인됨.

증계약 체결의 의사결정과는 직접적인 연관이 있다고 보기 어려움.

(2) 은행내규인 「여신업무취급세칙」(이하 “세칙”이라 함) 위반의 법적효력

위에서 본 바와 같이 세칙 제346조(연대보증의 방법 및 설명) 제3항은 본건과 같이 주채무자가 기업고객인 경우 연대보증인의 보증가능한도를 “20백만원”으로 한정하고 있는 바, 피신청인이 위 보증가능 한도를 위반한 경우 본건 보증채무가 위 세칙 규정을 근거로 금 20백만원으로 제한될 수 있는지 여부는 결국 “내규의 법적효력 내지 대외적 구속력의 문제”로 귀결된다 할 것임.

“내규”의 사전적 의미는 “어떤 개별 단체나 조직에서 그 실정에 따라 내부에서만 시행할 목적으로 만든 규정” 등으로 정의되고 있고, ‘금융기관의 내규의 효력’에 관한 대법원 판례를 살펴보면 아래와 같음.

일반적으로 금융기관의 업무규정이나 내규 등은 금융기관 내부의 직무수행지침에 불과하여 그것이 보통거래약관으로 되었다는 사정이 나타나고 있지 않다면 금융기관이 제3자에 대하여 반드시 그 규정에 따라 업무를 처리할 의무를 부담하는 것은 아니고,¹⁷⁹⁾ 상호신용금고가 업무운용준칙 등 내규를 위반하여 약속어음을 할인함으로써 이를 계기로 하여 어음발행자가 약속어음금채무를 부담하게 되는 손실을 입게 된 것이라 하더라도 특별한 사정이 없는 한 상호신용금고의 규정위배행위와 어음발행자의 손실과의 사이에 상당인과관계가 있다고 볼 수 없다고 판시함.¹⁸⁰⁾

위와 같은 내규의 의미 및 대법원 판례의 취지를 종합하면, 본건 피신청인의 “세칙” 또한 “금융기관 내부의 업무취급에 대한 지침 내지 가이드라인”의 성격을 갖는 것으로서 “피신청인 내부적으로 효력”을 갖는 것에 지나지 않고, “대외적 효력”을 갖는 규정이라고 보기는 어려움.

그렇다면, 비록 본건 보증계약이 위 세칙규정에 위반된 것이라 하더라도 보증계약의 효력에는 영향을 미치지 않는다 할 것이며, 또한 신청인은 위 세칙규정으로 반사적 이익을 보는 지위에 있는 것에 불과하고 위 규정의 내용을 피신청인에 대하여 적극적으로

179) 대법원 2000.3.28. 선고 99다56253 판결 참조.

180) 대법원 1996.10.11. 선고 95다43679 판결 참조.

주장할 수 있는 것은 아니므로, 피신청인이 신청인에게 위 세칙규정의 내용을 고지해야 할 법적 의무가 있다거나 신청인이 피신청인에게 위 세칙규정을 근거로 본건 보증한도를 제한할 것을 요구할 권리를 갖는 것은 아니라 할 것임.

라. 결 론

그렇다면, 2009.3.17.자 근보증서에 의한 보증채무는 존재하지 아니한다는 신청인의 주위적 주장과 위 보증채무는 금 20백만원을 초과하여서는 존재하지 아니한다는 신청인의 예비적 주장은 모두 이유 없으므로 이를 기각함.

3-13 대출 관련 목적물이 특정된 경우의 보증채무 부존재 확인

[인용] 피신청인이 신청인들에게 송부한 통지문에 보증대상 차량 등록번호가 명백히 표시되어 있고, 본건 할부금융약정서에는 차량 제작년도가 “2006년”으로 명시되어 있는데, 피신청인이 본건 할부대출의 목적물로 주장하는 차량은 2007.6.13. 제작되어 등록된 점 등을 감안시 동 차량에 대한 신청인의 보증채무는 존재하지 아니함.(2010.2.9. 조정번호 제2010-17호)

가. 사실관계

2006.8.29. ○○캐피탈(이하 “피신청인”이라 함)은 신청인들을 연대보증인으로 하여 신청외 A물류사(대표이사 B씨, 이하 “물류사”라 함)에 차량할부대출 1억 8백만원을 취급(약정번호 201*****301, 이하 “본건 할부대출”이라 함)하였으며, 할부금융약정서상의 ‘구입물품’ 란에는 “16톤 초장축+냉장왕바디 1대, 제작년도 2006년”으로 명기됨.

신청외 C씨(신청인의 아들이며 D씨의 오빠임)는 물류사의 화물차량 지입차주로서, 물류사 명의로 차량을 구입하기 위한 할부대출을 받기 위해 신청인들을 연대보증인으로 입보시킨 것이며, C씨가 실제 배차받아 운행한 차량은 “경기**바1234 25톤 화물차”로서, 본건 할부대출의 목적물과 상이함.

2006.9.6. 피신청인은 신청인들에게 본건 할부대출의 연대보증인으로 입보되었음을 확

인하는 내용의 “연대보증 확인 통보” 문서를 송부하였으며, 해당서면에는 “약정번호 : 201*****301”이 명기됨

2006.12.1. 피신청인은 신청인들에게 “○○○에 따른 계약상 권리귀속 주체의 변경 통지”를 송부한 바 있는데, 해당 서면에는 아래와 같이 관련계약의 내용이 명기되어 있음.

2. 관련 : 할부계약서[할부이용자 : A물류사]

- 계약번호 : 201*****30-001(할부금융 약정번호 “201*****301”과 동일)
- 계약일자 : 2006-8-29
- 등록번호 : 경기**바1235
- 물건명 : 카고트럭

2007.5.7. C씨는 자신이 운행하던 “경기**바1234 25톤 화물차”를 물류사에 반납한 후, 5.25. 20백만원을 물류사에 송금하면서 “위 20백만원으로 모든 채무의 변제를 완료하고 추후 어떠한 이의제기도 하지 않기로 한다”는 내용의 확인서를 교부 받았으며, 동 확인서 상단에는 “경기**바1234 C씨”라는 문구가 명기됨.

물류사는 2008.6.30. 폐업하였는데, 그 후 피신청인은 신청인들이 “경기**바1775” 차량에 관한 할부금융에 연대보증인으로 입보한 것이라고 주장¹⁸¹⁾하며 2009.11.12. 신청인의 부동산에 대한 강제집행에 착수하였음.

나. 당사자 주장

(1) 신청인 주장

C씨는 실제로는 물류사로부터 “경기**바1234” ‘25톤 화물차’를 배차 받아 운행하였으

181) 참고로 본건 관련 차량내역을 정리하면 다음과 같음.

구 분	차량번호	차종	제작일자	등록일자	소유자
실제운행	경기**바1234	25톤 화물차 (. . . 트럭)	‘06.8.10.	‘06.10.23.	A물류
신청인 주장	경기**바1235	16톤 화물차 (. . . 트럭)	‘06.9.2.	‘06.11.16.	A물류 → B물류(‘08.6.) → C물류(‘09.9.)
피신청인 주장	경기**바1775 (분실됨)	16톤 화물차 (*****트럭)	‘07.6.13.	‘07.7.6.	A물류

나, 신용등급이 낮은 관계로 '16톤 화물차'를 목적물로 하는 본건 할부대출을 진행하였음. 2006.8.29. 본건 할부대출 약정 후 실제 출고된 차량은 같은 해 9.2. 제작되어 11.16. 등록된 "경기**바1235" '16톤 화물차'였는 바, 본건 할부대출의 목적물은 위 "경기**바1235" 차량으로 특정된 것임. 2006.12.1. 피신청인이 신청인들에게 송부한 "○○○에 따른 계약상 권리귀속 주체의 변경 통지"에도 본건 할부대출의 목적물이 "경기**바1235"로 명시되어 있음.

2007.5.7. C씨는 위 "경기**바1234" 25톤 화물차를 물류사에 반납하였고, 5.25.에는 20백만원을 물류사에 송금하여 모든 채무의 변제를 완료한 것으로 하고 물류사가 본건 할부대출을 정리하기로 하는 확인서를 작성 받았으며, 그 후 2008.6.4. 본건 할부대출의 목적물인 "경기**바1235" 차량은 B물류사로 매각됨으로써 신청인들의 연대보증채무가 종결된 것으로 알고 있었음. 그러나 피신청인은 본건 할부대출 취급일(2006.8.29.)로부터 1년 가까운 시간이 경과한 2007.6.13.에야 제작되어 7.6. 등록된 "경기**바1775" 차량과 관련하여 신청인들이 연대보증을 하였다고 부당한 주장을 하며 강제집행을 하고 있음.

(2) 피신청인 주장

차량할부금융의 특성상 할부금융약정 성립시에는 차량이 특정되지 않으므로 할부금융사는 고객이 자동차 등록 및 근저당 설정을 이행했는지 확인하고 그 과정에서 특정된 차량번호로 할부금융을 관리하게 되는 바, 본건 할부대출의 대상 차량은 "경기**바1775" 차량으로 특정되었음.

피신청인은 물류사와 2006.8.경부터 80건의 할부계약을 한꺼번에 체결하였고 물류사가 장기간에 걸쳐 차량들의 등록과 근저당 설정업무를 이행하였는 바, 그 과정에서 대상 차량이 다수인 관계로 본건과 같이 계약일자(2006.8.29.)와 차량등록일자(2007.7.6.)가 크게 상이한 경우가 존재하게 된 것임.

2006.12.1. 피신청인이 신청인들에게 통보한 "○○○에 따른 계약상 권리귀속 주체의 변경 통지"에 표시된 차량번호 "경기**바1235"는 사무착오로 인한 것으로서 사실과 상이하며, 신청인들이 본건 할부대출의 대상으로 주장하는 "경기**바1235" 차량은 신청외 D씨의 차량구입을 위한 할부대출(약정번호 201*****888)에 관련된 것으로서, D씨는

2006.10.18.부터 현재까지 정상적으로 차량을 운행하고 있음.

C씨는 자신이 실제로 운행하던 차량을 반납한 것이 아니고 물류사에 지입되어 운행 중인 차량에 대해 서류상 반납을 요청하며 보증인 삭제를 요청한 것으로, 이후 물류사에서 피신청인으로 차량 반납 및 보증인 삭제요청을 제대로 이행하지 않아 연대보증인인 신청인 소유의 부동산에 강제집행을 하게 된 것으로서, C씨가 5.25. 20백만원을 송금함으로써 모든 채무의 변제를 완료하였다는 신청인들의 주장은 피신청인과는 무관한 것임.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 본건 할부대출의 목적물이 피신청인의 주장과 같이 “경기**바1775” 화물차로 특정되었는지 여부라 할 것임

피신청인은 본건 할부대출의 목적물은 “경기**바1775” 차량으로 특정되었으므로 연대보증인인 신청인들이 위 차량에 관한 할부대출금에 대한 책임이 있다고 주장하나, 아래와 같은 점을 볼 때 피신청인의 위 주장은 받아들이기 어렵다고 판단됨.

① 피신청인이 2006.12.1. 신청인들에게 송부한 “○○○에 따른 계약상 권리귀속 주체의 변경 통지”를 보면 본건 할부대출의 일자(2006.8.29.)와 약정번호(201*****301)가 명시되어 있는데, 위 서면에는 차량등록번호가 “경기**바1235”로 명백히 표시되어 있는 점.

② 본건 할부금융약정서에는 차량 제작년도가 “2006년”으로 명시되어 있는데, 피신청인이 본건 할부대출의 목적물로 주장하는 “경기**바1775” 차량은 2007.6.13. 제작되어 등록된 점.

③ 위와 같이 “경기**바1775” 차량은 본건 할부대출 취급일자(06.8.29.)로부터 약 10개월 가까운 장시간이 경과한 후인 2007.6.13. 제작되었는데, 자동차할부금융에 있어 할부약정시에는 차량이 특정되지 않고 그 후에 제작 내지 등록될 수 있다는 점을 고려하더라도 위와 같이 10개월 상당의 차이가 나는 것은 납득하기 어려운 점.

④ 피신청인은 위 2006.12.1.자 “○○○에 따른 계약상 권리귀속 주체의 변경 통지”에 ‘사무착오’로 차량번호를 잘못 기재하였다고 주장하나, 대표이사 직인이 날인된 정식 공

문에 할부금융의 핵심 요소인 목적물을 착오로 잘못 기재하였다는 주장은 신빙성이 떨어지고, “1235”과 “1775”는 2개의 숫자가 다르므로 이를 ‘단순한 오타’로 해석할 수도 없는 점.

⑥ 피신청인은 우리 원에 제출한 답변서에서, 신청인들이 본건 할부대출의 대상으로 주장하는 “경기**바1235” 차량에 관한 할부금융은 신청외 D씨의 차량구입을 위한 “약정번호 206IF103897” 할부대출에 관련된 것이고 D씨는 2006.10.18.부터 현재까지 정상적으로 차량을 운행하고 있다고 항변하였으나, 금융감독원이 관련 자료를 요구하여 확인한 결과 위 “약정번호 201*****888” 할부대출은 D씨가 아닌 신청외 E씨에 관한 것으로 밝혀진 점.

⑦ 신청인이 실제로 운행한 차량을 2007.5.7. 물류사에 반납하고 5.25. 2천만원을 추가 부담금으로 정산하면서 신청인과 관련된 할부금융을 물류사가 정리하기로 약정하고 확인서를 작성한 사실이 인정되는데, 그 후 물류사가 2008.6.4. B물류로 매각함으로써 할부금융을 정리한 차량은 신청인들이 주장하는 “경기**바1235” 차량이었던 점.

사정이 위와 같다면, 본건 할부대출의 목적물이 “경기**바1775” 차량으로 특정되었다는 피신청인의 주장은 받아들이기 어렵다 할 것이고, “경기**바1235” 차량으로 특정되었다는 신청인들의 주장이 더 신빙성 있다 할 것임.

라. 결 론

그렇다면, 경기**바1775 차량 관련 할부대출에 관한 신청인들의 보증채무는 존재하지 아니한다고 판단됨.

제4장

예금 등 수신거래

제1절 계좌개설 및 입금

4-1

위조신분증에 의한 예금계좌 부당개설에 따른 책임 여부

[인용] 금융기관이 거래상대방의 본인여부를 확인할 필요가 있는 경우에 그 상대방이 거래 명의인의 주민등록증을 소지하고 있는지 여부를 확인하는 것만으로는 부족하고 그 직무수행상 필요로 하는 충분한 주의를 다하여 신분증의 진정 여부 등을 확인하여야 할 것인 바, 만일 실제로 거래행위를 한 상대방이 신분증상의 본인과 다른 사람이었음이 사후에 밝혀졌다고 한다면, 특별한 사정이 없는 한, 금융기관으로서 위와 같은 본인확인무무를 다하지 못한 과실이 있는 것으로 사실상 추정됨.(2005.9.13. 조정번호 제2005-61호)

가. 사실관계

2004.8.30. 신원미상의 제3자(이하 “제3자”라 함)가 신청인 명의의 위조 공무원증¹⁸²⁾을 이용하여 A은행 ○○지점(이하 “피신청인”이라 함)에서 신청인 명의의 예금계좌(이하 “본건 계좌”라 함)를 개설하였으며, 같은 날 제3자는 사전에 미리 알아낸 신청인 명의 B카드사의 신용카드번호 및 비밀번호 등을 이용하여 동 카드사 자동음성응답시스템(ARS)을 통해 현금서비스 금4백만원을 신청하고, 동 금액을 본건 계좌에 입금하게 한 후 현금자동지급기에서 6회에 걸쳐 전액 인출하였음.

나. 당사자의 주장

(1) 신청인 주장

182) 공무원증 발급기관은 “○○시장”이어야 하나 본건의 경우 “◇◇구청장”으로 되어 있음.

신청인이 B카드사에 4백만원을 변제하게 된 것은 피신청인이 본건계좌 개설시 본인확인을 소홀히 한 데 기인하므로 피신청인은 신청인이 입은 손해액 4백만원을 배상하여야 함.

(2) 피신청인 주장

본건 계좌 개설시 제3자로부터 제시받은 공무원증의 확인결과 육안상 이상이 없다고 판단되었으며, 공무원증상의 사진과 개설인의 얼굴이 동일하였으므로 신청인의 주장을 수용할 수 없음.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 피신청인의 제3자에 대한 예금지급이 정당한지 여부라 하겠음.

(1) 본건의 판단기준

민법의 일반원칙에 의하면 은행은 예금주 본인·대리인에게 지급하면 정당한 변제가 되어 예금채권은 지급범위내에서 소멸된다고 볼 수 있음. 그러나 정당한 권리자가 아닌 경우에도 변제자가 사회일반의 거래관념상 진실한 채권을 가진 자라고 믿을만한 외관을 구비한 자에게 선의이며 과실 없이 변제한 경우에는 채권의 준점유자에 대한 변제로서 유효하다고 규정하고 있음(민법 제470조).

한편, 자금이체나 예금지급이 기계에 의하여 순간적으로 이루어지는 거래에 관하여 금융기관이 채권의 준점유자에 대한 변제로서 금융기관에 대하여 요구되는 주의의무를 다하였는지 여부를 판단함에 있어서는 자금이체시의 사정만을 고려할 것이 아니라 그 이전에 행하여진 제반사정을 총체적으로 고려하여야 하며, 금융기관이 거래상대방의 본인 여부를 확인할 필요가 있는 경우에 그 상대방이 거래 명의인의 주민등록증을 소지하고 있는지 여부를 확인하는 것만으로는 부족하고 그 직무수행상 필요로 하는 충분한 주의를 다하여 신분증의 진정 여부 등을 확인하여야 할 것인 바, 만일 실제로 거래행위를 한 상대방이 신분증상의 본인과 다른 사람이었음이 사후에 밝혀졌다고 한다면, 특별한 사정이 없는 한 금융기관으로서는 위와 같은 본인확인 의무를 다하지 못한 과실이 있는 것으로 사실상 추정된다는 것이 대법원의 관례임.¹⁸³⁾

(2) 피신청인의 예금지급이 정당한지 여부

본건은 다음과 같은 점에 비추어 볼 때 피신청인이 선의이며 과실 없이 예금을 지급하였다고 볼 수 없으므로 피신청인의 예금지급은 정당하지 아니한 것으로 판단됨.

① 본건계좌의 경우 확인결과 신청인이 아닌 제3자가 위조된 공무원증을 이용하여 개설되었는 바, 따라서 피신청인은 동 공무원증의 진정여부 등 본인확인 의무를 다하지 못한 과실이 추정된다 할 것이며 이에 대하여 피신청인이 충분한 주의의무를 다하였다고 인정할 만한 정황은 발견하기 어려운 점.

② 예금계좌 신규개설시 개설인이 주민등록증 이외의 신분증을 제시할 경우 금융기관은 재직증명서나 의료보험증 등 본인만이 소지할 수 있는 성격의 2차 증빙자료를 징구하여 본인여부를 2중으로 확인하도록 한 금융감독원의 지침¹⁸⁴⁾에 비추어 볼 때 본건 계좌 개설과 관련한 피신청인의 업무처리는 정당하다고 보기 어려운 점.

라. 결 론

그렇다면 피신청인은 제3자가 위조된 신청인의 신분증을 이용하여 본건 계좌를 개설하였음에도 이를 제대로 확인하지 않은 과실이 인정되어 본건예금 지급이 채권의 준점유자에 대한 변제로서 유효하다고 보기 어려움.

4-2 실명확인 없는 예금계좌 개설 및 인출에 따른 손해배상책임 유무

[일부인용] 대리인을 통해 예금계좌를 개설하여 주는 경우 위임장과 인감증명서를 제출받고 신분증을 확인하는 등 최소한의 확인조치를 취함으로써 그것이 범죄행위에 이용될 가능성을 미연에 방지해야 할 주의의무가 있고, 피신청인 업무방법서상 종업원계좌 일괄 개설시에는 사업주가 실명확인한 서류를 제출받아 확인하도록 규정하고 있음에도, 이러한 서류가 없는 점 등에 비추어 피신청인의 사용자배상 책임이 인정된다 할 것임.(2006.4.11. 조정번호 제2006-17호)

183) 대법원 1998.11.10. 선고 98다20059 판결 참조.

184) “위조신분증 등에 의한 금융사고 예방대책 통보”(2003.4.8.)

가. 사실관계

신청인 A기업(이하 “회사”라 함)의 경리직원 B씨는 2003.4.10. ○○은행(이하 “피신청인”이라 함) 지점을 방문하여 같은 회사 직원인 신청인 C씨 등 4인 명의의 예금계좌 개설을 신청하였는데, 위 지점 예금 담당자(이하 “취급직원”이라 함)는 이들의 실명확인증표 사본과 도장을 제출받고 이들 명의의 계좌를 개설하여 주었고, 2003.11.20. B씨는 위와 동일한 방법으로 같은 회사 직원인 신청인 D씨 명의의 예금계좌를 개설함.

B씨는 2003.8.25.~2004.6.7. 기간중 회사 직원들의 퇴직금을 관리하고 있던 ◇◇생명보험사에 신청인 C씨 등 5인의 퇴직보험금에 대한 중간정산을 신청하여 위에서 개설한 계좌들로 지급케 한 후, 입금된 퇴직금을 B씨 본인계좌로 이체하거나 현금으로 출금하여 모두 편취함. 신청인 C씨 등 5인은 회사에 퇴직금 중간정산을 신청한 사실이 없으며, B씨는 회사의 법인인감을 무단으로 사용하여 퇴직금 지급청구서를 작성한 것임.

2005.11월 중순경 회사 대표는 B씨가 관리비 및 세금 등을 횡령한 사실을 알게 되어 2005.11.14. 본건 통장개설에 관한 B씨의 자인서를 받고 같은 달 16일 영등포경찰서에 B씨를 고소하였는데, 이후 B씨의 도주로 기소중지 상태임.

나. 당사자의 주장

(1) 신청인 주장

피신청인의 예금 개설 취급직원은 신청인 회사 여직원 B씨에게 실명확인 없이 신청인 C씨 등 5인 명의의 예금계좌를 불법으로 개설하여 주었으며, 동 예금계좌에 입금된 퇴직금을 신청인 C씨 등 본인확인 없이 B씨에게 인출 또는 계좌이체 하여 주었는 바, 피신청인에게 퇴직금 상당의 손해배상을 청구함.

(2) 피신청인 주장

편취사고의 직접적인 원인은 ◇◇생명보험사의 퇴직금 지급에 따른 것인데, ◇◇생명보험사가 신청인 회사의 정상적인 퇴직금 지급요청서를 받고 지급을 하였다면 이는 위 신청인 회사가 책임질 사항이며, ◇◇생명보험사가 B씨에 의해 위조된 지급요청서를 받

고 지급 하였다면 이는 ◇◇생명보험사가 책임질 사항이라 할 것인 바, 계좌개설시 취급 직원에게 실명확인 절차상의 하자가 있다고 해도 위 계좌가 단지 퇴직금의 지급수단으로 이용되었을 뿐인 경우에는 퇴직금 편취로 인한 손해와의 사이에 인과관계가 없어 피신청인은 손해배상 책임이 없음.

다. 위원회의 판단

◆ 본건은 예금계좌 개설시 은행에게 요구되는 주의의무의 정도 및 금융기관이 개설한 예금계좌가 범죄행위에 이용되어 발생한 제3자의 손해와 위 주의의무 위반 사이에 상당인과관계가 인정되는지 여부가 쟁점이라 할 것임.

(1) 손해배상책임 인정 여부

금융기관으로서는 대리인을 자처하는 자에게 예금계좌를 개설하여 주는 과정에서 위임장과 인감증명서를 제출받고 대리인의 신분증을 확인하는 등의 최소한의 확인조치를 취함으로써 그것이 불특정 다수의 잠재적 피해자에 대한 범죄행위에 이용될 가능성을 미연에 방지함으로써 타인의 불법행위에 도움을 주지 않아야 할 주의의무가 있다고 볼 것이고, 그러한 조치를 전혀 취하지 아니한 결과 개설된 모용계좌가 범죄행위에 이용되어 모용자가 제3자로부터 계좌에 금원을 입금받는 방법으로 제3자에게 손해를 가하였다면, 금융기관의 그와 같은 주의의무 위반은 해당 금융기관이 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률에서 정한 실명확인 의무를 이행하였는지 여부와는 무관하게 위법한 것으로서, 제3자가 입게 된 손해와 사이에 상당인과관계가 있음.¹⁸⁵⁾

본건 예금의 취급직원은 평소 알고 지내던 신청인 회사 경리담당직원 B씨로부터 동사 종업원들의 일괄 계좌개설 신청을 받고, 동사 직원인 신청인 C씨 등 5인의 실명확인증표 사본과 도장 및 단체 신규계좌개설 관련 서류(사업주가 실명확인한 서류)를 제출받아 동인들 명의의 계좌를 개설하여 주었으므로 주의의무위반이 없다고 주장하나, 다음과 같은 점에서 위 주장은 이유 없어 피신청인의 사용자배상 책임이 인정된다 할 것임.

185) 대법원 2006.1.13. 선고 2003다54599 판결 참조.

피신청인의 예금업무방법서상 종업원 계좌를 일괄 개설하는 때에는 사업주가 실명 확인한 서류를 제출받아 실명을 확인하도록 규정하고 있으나, 피신청인의 자체 감사 결과 사업주인 신청인 회사의 실명확인 서류는 존재하지 않았고, 달리 신청인 C씨 등 5인 명의의 위임장이나 인감증명서 등이 첨부된 사실도 없으며, 제출된 동인들의 도장은 한글 이름이 간단하게 조각된 목도장이었고, 비밀번호는 서로 동일하여 대리인에 의한 예금계좌 개설시 금융기관에게 요구되는 최소한의 확인조치가 취하여졌다고 볼 수 없으며, 이러한 확인조치를 취하지 아니한 결과 개설된 위 신청인 C씨 등 5인의 통장이 B씨의 편취행위에 도움을 주었다고 할 것임.

(2) 손해배상 청구권자

근로자퇴직급여보장법 제8조는 근로자의 요구가 있는 경우 퇴직금 중간정산을 할 수 있도록 규정하고 있는데, 신청인 C씨 등 5인은 신청인 회사에 퇴직금 중간정산을 신청한 사실이 없을 뿐만 아니라 실제로 신청인 C씨 등 5인에게 퇴직보험금이 지급된 것도 아니므로 신청인 C씨 등 5인의 신청인 회사에 대한 퇴직금 청구권은 소멸되지 않고 유효하게 존재한다고 보아야 할 것인 바, 본건 사고와 관련하여 실제 손해를 입은 자는 종업원인 신청인 C씨 등 5인이 아니라 사업주인 신청인 회사라 할 것임.

(3) 과실상계

B씨는 신청인 회사의 직원으로서 고의로 다른 직원의 퇴직금을 편취한 자이고, 피신청인은 예금계좌 개설에 관한 과실로 위 손해발생에 가담한 것이므로, 피신청인과의 관계에서 신청인 회사는 B씨의 사용자로서 그 관리·감독상의 책임등을 이유로 이 사건 손해의 일정 부분을 감수하여야 한다고 봄이 손해분배의 공평의 원리에 부합한다고 할 것인데, B씨는 장기간에 걸쳐 신청인 회사의 인감이나 서류 등을 이용하여 동 사무소의 여러 자금을 횡령하였을 뿐만 아니라 본 건 퇴직금 편취 이후에도 1년여가 넘게 계속 출근을 하였음에도 신청인 회사는 이러한 편취사실을 전혀 알지 못하였는 바, 신청인 회사의 직원 감독 및 재산관리상의 과실이 중대하여 70%의 과실상계를 함.

라. 결 론

그렇다면 피신청인은 신청인 회사에게 손해금액 94백만원에서 70%의 과실상계를 한 금 28.2백만원을 배상할 책임이 있어 이를 인용하고, 나머지 청구는 이유없어 기각함.

4-3 조합명의 예금통장의 재발급시 은행의 주의의무 위반 여부

[일부인용] 예금개설시 법인인감이 아니라 업무집행자들이면 쉽게 사용할 수 있는 사용인감과 대표권자인 이사장의 서명이 함께 신고된 경우, 피신청인은 업무집행권만 있는 전무이사가 사용인감만을 날인한 통장으로 재발급해줄 것을 요청하는 때에는 예금주의 의사확인을 위해 신청인의 위임장에 대한 확인 외에 이사장에 대한 확인이 필요하였음에도 이를 다하지 못한 주의의무 위반이 있음.(2006.4.11. 조정번호 제2006-19호)

가. 사실관계

○○○○협동조합(이하 “신청인”이라 함)의 이사장인 A씨는 2005.1.10. ◇◇은행(이하 “피신청인”이라 함) 지점에서 신청인 명의로 250백만원의 정기예금(만기일 2006.1.10.)을 개설하였고, 동 예금 개설시 A씨는 거래신청서와 통장에 신청인의 사용인감과 함께 이사장인 본인의 서명을 함께 기재하였음.

2005.3.21. 신청인의 전무이사 B씨는 피신청인 지점을 방문하여 위 정기예금의 통장 분실신고를 하고 통장을 재발급 받았는데, 통장 분실신고 당시 B씨는 신청인 명의의 통장재발급용 위임장(법인인감 날인)과 신청인의 법인인감증명서, 사업자등록증, B씨 본인의 신분증을 피신청인의 취급직원에게 제시하였으며, 재발급된 통장에는 신청인의 사용인감만 날인하였음(비밀번호는 그대로 유지함).

2005.3.24. B씨가 피신청인 지점을 방문하여 위 재발급된 통장과 사용인감을 제시하며 정기예금의 해지를 요청하자, 피신청인의 취급직원은 통장에 날인된 인영과 제시한 사용인감의 동일성과 Pin-Pad에 입력한 비밀번호의 일치여부를 확인하고 예금을 해지처리한 후 B씨에게 예금액을 지급하였음.

B씨는 위 예금인출 후에도 신청인의 회사에 출근하여 업무를 하였으나 2005.12월 개

인채무 등을 이유로 도주하였고, 이후 확인 결과 B씨는 신청인 명의의 채권을 임의매도 하여 약 1천여만원의 대금을 횡령한 사실이 있음.

A씨는 2006.1.10. 정기예금시 약정했던 만기일이 도래하자 피신청인에게 예금지급을 청구하였다가, 위와 같은 사고를 알게 되어 분쟁조정을 신청함.

나. 당사자의 주장

(1) 신청인 주장

신청인의 이사장 A씨는 정기예금개설 당시 신청인의 사용인감 외에 본인의 서명을 함께 신고하면 본인만이 동예금을 해지하거나 인출할 수 있다는 피신청인 취급직원의 설명을 듣고 본인의 서명을 함께 신고하였음에도, B씨의 통장재발급 신청시 A씨에 대한 확인 없이 사용인감만을 날인하여 통장을 재발급한 것은 피신청인의 명백한 본인확인 의무 위반인 바, 부정한 통장재발급으로 인하여 B씨에게 인출된 예금액 2.5억원에 대한 손해배상을 청구함.

(2) 피신청인 주장

피신청인의 예금 취급자는 A씨에게 인감과 서명이 모두 있어야만 예금인출이 가능하다고 얘기한 사실이 없고, B씨는 ○○○○협동조합법상 조합의 상근임원으로서 신청인의 실질적인 업무집행자이며, B씨의 통장재발급 요청시 고객정보등록(변경·해제)표, 사업자등록증, 조합인감이 날인된 위임장, 조합인감증명서, 대리인인 전무이사의 신분증을 모두 제출받아 위임여부를 확인한 후 통장을 재발급하였으며, 예금해지시에도 B씨로부터 통장, 통장에 날인된 인감과 일치된 청구서 제시 및 비밀번호의 확인을 통하여 정당해지 처리후 예금액을 지급하였는 바, 피신청인은 손해배상 책임이 없음.

다. 위원회의 판단

◆ 본건은 피신청인의 손해배상 책임의 성립여부와 관련하여 통장재발행 과정에 있어 취급직원의 주의의무 위반 여부가 쟁점이라 할 것임.

(1) 피신청인의 손해배상책임 성립 여부

피신청인의 예금거래기본약관 제14조는 거래처가 통장이나 도장의 분실·도난등 사고 신고를 한 때에는 신고인이 거래처 본인임을 확인하는 등 필요한 조치를 마친 뒤에 재발급하거나 지급하도록 규정하고 있는데, 판례는 단체명의 예금의 인감변경 신고시 거래처 본인확인과 관련하여 다음과 같이 은행의 주의의무를 엄격히 인정하고 있음.

주식회사는 대표이사만이 대외적으로 회사를 대표할 권한이 있다는 점 등에 비추어, 그 신고자가 예금주인 주식회사의 상무이사로서 평소 신고된 인감을 사용하는 거래의 담당 책임자임을 확인하는 것만으로는 예금주 본인임을 확인한 것으로 볼 수 없고, 인감변경신고를 수리하려는 은행으로서는 그 예금규정에 따라 적절한 방법으로 회사의 대표이사에 대하여 확인을 하는 등 예금주의 의사에 의하지 아니한 인감 변경으로 인한 부정행위의 발생을 방지할 주의의무가 있음.¹⁸⁶⁾

피신청인은 신청인 명의의 위임장과 인감증명서를 통하여 본인확인을 하였으므로 통장재발급시 주의의무 위반이 없다고 주장하나, 다음과 같은 점에서 피신청인의 사용자배상 책임이 인정된다 할 것임.

최초 예금개설시 통장에 인감과 서명을 모두 기재한 이유를 명확히 입증할 자료는 없으나, 본건 예금은 신청인의 대표자인 A씨가 직접 은행에 내점하여 개설한 것으로, 수시 입·출금을 목적으로 하지 않은 정기예금임에도 A씨 본인의 서명을 함께 신고하였는바, 예금개설시 법인인감이 아니라 업무집행자라면 쉽게 사용할 수 있는 사용인감과 대표권자인 이사장의 서명이 함께 신고된 경우, 피신청인은 업무집행권만 있는 전무이사가 사용인감만을 날인한 통장으로 재발급해줄 것을 요청하는 때에는 예금주의 의사확인을 위해 신청인의 위임장에 대한 확인외에 이사장인 A씨에 대한 확인이 필요하였음에도 이를 다하지 못한 주의의무 위반이 있음.

(2) 신청인의 과실에 따른 과실상계

불법행위에 있어서 과실상계는 공평 내지 신의칙의 견지에서 손해배상액을 정함에 있

186) 대법원 1996.8.23. 선고 95다39472 판결 참조.

어 피해자의 과실을 참작하는 것으로서, 그 적용에 있어서는 가해자와 피해자의 과실의 정도, 위법행위의 발생 및 손해의 확대에 관하여 어느 정도의 원인이 되어 있는가 등의 제반 사정을 고려하여 배상액의 범위를 정하는 것이며, 불법행위에 있어서의 가해자의 과실이 의무위반의 강력한 과실임에 반하여 과실상계에 있어서 과실이란 사회통념상, 신의성실의 원칙상, 공동생활상 요구되는 약한 부주의까지를 가리키는 것임.¹⁸⁷⁾

신청인의 전무이사인 B씨는 ○○○○협동조합법상 조합의 업무집행자일 뿐만 아니라 이사장인 A씨가 원격지에 거주하는 이유로 실질적으로도 조합의 업무를 주로 집행하여 왔는데, B씨가 이러한 지위를 남용하여 신청인의 인감등을 무단으로 사용하여 왔음에도 사용자로서의 지휘·감독을 제대로 하지 못한 신청인의 과실이 본건 사고발생의 주된 원인이 되었다 할 것이며, 정기예금의 비밀번호를 일반 통장의 비밀번호와 같이 사용함으로써 본건 예금의 인출을 용이하게 하는 등 신청인의 과실이 이 사건 손해의 발생 및 확대에 중요한 요인이 되었다고 할 것인 바, 이러한 점에 비추어 70% 과실상계를 함.

라. 결 론

그렇다면 피신청인은 신청인에게 손해금액 250백만원에서 70%의 과실상계를 한 75백만원을 배상할 책임이 있어 이를 인용하고, 신청인의 나머지 청구는 이유 없어 기각함.

4-4 폐지된 「주택청약예금 자동적금통장」 교부에 따른 손해배상 책임

[일부인용] 피신청인이 이미 폐지된 통장을 부득이하게 사용하는 경우 통장 표지상의 기재 등이 현실과 다르면 예금자가 오인하지 않도록 이를 충실히 안내하여야 할 신의칙상 의무가 있음에도, 기존 통장을 그대로 사용하면서 이러한 내용에 대한 설명을 하지 않은 점 등을 감안시 신청인이 자동적금에 가입한 것으로 오인하여 10여년이 지나도록 주택청약예금의 이자를 찾지 않고 방치함으로써 이를 바로 찾거나 정기적금에 가입함으로써 얻을 수 있는 이자 상당의 손해를 입혔으므로 이에 따른 손해배상책임(50%)이 있다고 할 것임.(2011.9.6. 조정번호 제2011-49호)

187) 대법원 2004.7.22. 선고 2001다58269 판결 참조.

가. 사실관계

1999.12.27. 신청인은 ○○은행(이하 “피신청인”이라 함)에서 주택청약예금(15백만원)을 가입하였는데, 당시 피신청인으로부터 통장표면에 “주택청약예금 자동적금통장”으로 인쇄된 통장¹⁸⁸⁾(이하 “본건 통장”이라 함)을 교부 받았으며, 본건 청약예금은 가입 후 1년 단위로 자동연장 되었고, 이자에 대해 별도의 자동이체 약정을 하지 아니하였으며 중간에 인출하지도 아니함.

2010.11.9. 신청인은 피신청인으로부터 “주택청약 예·부금 이자지급 안내문”을 수령하고, 2011.2.8. 그 동안의 이자를 단리로 계산하여 수령(세후 5,532,185원)¹⁸⁹⁾하였으며, 2011.5.30. 청약예금의 이자가 자동적금에 가입되었는데도 피신청인이 이자를 단리로 적용하여 지급된 것은 부당하다며 본건 분쟁조정을 신청함.

나. 당사자 주장

(1) 신청인 주장

본건 청약예금 가입시 피신청인 직원은 신청인에게 주택청약예금에 가입하면 매월별 이자가 정기적금에 자동으로 입금된다는 취지로 설명하였을 뿐 이자가 단리로 지급된다고 설명한 사실은 없음. 또한 통장에 “주택청약예금 자동적금통장”으로 기재되어 있고, 통장 내면에 기재된 「주택청약예금 자동적금약관」에 “매월별 이자를 정기적금으로 자동 입금한다”고 되어 있음에도 은행이 그 동안 아무런 안내를 하지 않고 단리로 이자를 지

188) 본건 통장은 표면에 “주택청약예금 자동적금통장”이라고 기재되어 있고, 내면의 안내말씀에는 “이 주택청약예금 자동적금통장은 주택청약예금과 정기적금을 같이 거래할 수 있는 통장으로서 자동적금에 가입하시면 주택의 정기예금의 계약기간까지 발생하는 월별이자를 매월 적금으로 자동납입하여 드립니다.”라고 기재되어 있으며, 통장 내면의 “주택청약정기예금” 란에는 “거래금액 15백만원”, “월별이자는 자동이체 바랍니다.” 라고 인자되어 있고, 통장 내면의 “자동적금등록내역” 란에는 계좌번호, 계약금액, 계약기간 등이 인쇄되어 있으나 모두 빈칸으로 되어 있음. 통장 내면에 「주택청약예금 자동적금통장 약관」이 인쇄되어 있으며, 동 약관 제4조에는 “은행은 주택청약 정기예금의 매월별 이자를 정기적금으로 자동 입금한다.”는 내용이 인쇄되어 있음.

189) 주택청약예금 이자가 정기적금에 자동으로 입금된 것으로 가정할 경우 신청인이 받을 수 있는 금액과 신청인이 실제 수령한 금액과의 차액은 476,940원임.

급하는 것은 부당함.

(2) 피신청인 주장

본건 “주택청약예금 자동적금통장”은 주택청약예금과 정기적금을 각각 개별통장으로 사용하지 않고 한 개의 통장으로 사용할 수 있도록 만들어진 것으로, 주택청약예금과 자동적금 동시가입은 신청인이 본건 청약예금을 가입(1999.12.27.)하기 이전인 1999.1월 폐지되었는데, 본건은 기존에 인쇄된 통장 양식을 사용한 것임.

본건 통장에는 “자동적금에 가입하시면 월별이자를 매월 적금으로 자동 납입하여 드립니다.”라고 기재되어 있는데, 신청인은 자동적금을 가입하지 않았으므로(통장 내면의 “자동적금 등록내역”란이 모두 공란) 신청인에게 자동적금이 가입된 것을 전제로 이자를 지급할 수 없음. 또한 본건 청약예금 가입시 은행직원은 신청인에게 청약예금의 이자가 자동적으로 운영된다는 설명을 한 사실이 없고, 이자는 단리 지급이 원칙이므로 신청인의 주장은 수용이 곤란함.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 신청인이 자동적금에 가입한 것으로 볼 수 있는지 여부 및 피신청인에게 본건 통장의 교부에 따른 손해배상책임이 있는지 여부라 할 것임.

(1) 신청인이 자동적금에 가입한 것으로 볼 수 있는지 여부

신청인이 자동적금에 가입하였는지 여부는 신청인과 피신청인 사이에 자동적금 가입에 관한 계약이 있었는지 여부로 판단하여야 할 것인 바, ① 본건에서 통장 내면의 안내말씀에 “..... 자동적금에 가입하시면 월별이자를 매월 적금으로 자동 납입하여 드립니다.”라고 기재되어 별도로 자동적금을 가입하여야 한다는 것이 명시되어 있는 점, ② 통장의 주택청약정기예금란에는 내용이 인자되어 있으나, 자동적금등록내역에는 아무런 내용이 인자되어 있지 않은 점, ③ 신규가입신청서에 정기예금 청약만 기재되어 있고 자동적금에 관한 청약은 기재되어 있지 않은 점, ④ 통장 내면에 「주택청약예금 자동적금통장 약관」이 기재되어 있으나 약관은 계약이 성립된 경우에 적용되는 것으로 통장

에 약관이 기재되어 있다는 사정만으로 계약이 성립된 것으로 볼 수는 없는 점 등을 종합적으로 고려해 볼 때 신청인이 자동적금에 가입한 것으로 볼 수 없다고 판단됨.

(2) 피신청인에게 본건 통장 교부에 따른 손해배상책임이 있는지 여부

1) 손해배상책임 성립여부

본건의 경우, 다음과 같은 점에 비추어 볼 때 피신청인은 신청인에게 본건 통장의 교부에 따른 손해배상책임을 부담한다고 판단됨.

① 주택청약예금과 자동적금 동시가입이 폐지되었다면 피신청인으로서 기존에 사용하던 ‘주택 청약예금 자동적금 통장’은 거래 고객이 자동적금에 가입된 것으로 혼동을 줄 수 있으므로 이를 사용하지 말아야 하는 점.

② 만약 피신청인이 이미 폐지된 본건 ‘주택 청약예금 자동적금 통장’을 부득이하게 사용하게 된 경우에는 신청인이 오인하지 않도록 본건 통장은 표지상의 기재나 내면의 약관과 달리 자동적금이 자동으로 가입되는 것이 아니므로 별도로 적금을 가입하거나 이자에 대한 자동이체를 신청하도록 충실한 안내를 하여야 할 신의칙상 의무가 있다고 할 수 있는 점.

③ 그런데도, 피신청인은 이미 폐지된 ‘주택청약예금 자동적금통장’을 사용하여 신청인으로 하여금 자동적금에 가입된 것으로 오인하게 한 점.

④ 또한, 피신청인 담당직원이 신청인에게 본건 통장은 표지상의 기재나 내면의 약관과 달리 자동적금이 자동으로 가입되는 것이 아니므로 별도로 적금을 가입하거나 이자에 대한 자동이체를 신청하도록 충실한 안내를 하였다는 사정도 확인되지 않은 점.

따라서, 피신청인은 위와 같은 신의칙상의 주의의무를 위반하여 신청인이 자동적금에 가입한 것으로 오인하여 10여년이 지나도록 주택청약예금의 이자를 찾지 않고 방치함으로써 이를 바로 찾거나 정기적금에 가입함으로써 얻을 수 있는 이자 상당의 손해를 입혔으므로 이에 따른 손해배상책임이 있다고 할 것임.

2) 손해배상액 산정

본건에 있어서 신청인의 손해금액은 본건 주택 청약예금의 이자가 정기적금에 자동으

로 입금된 것으로 가정시 신청인이 받을 수 있는 금액과 신청인이 실제 수령한 금액과의 차액인 금 476,940원이라 할 것임.

다만, 다음과 같은 점 등을 고려하여 피신청인의 책임을 50%로 제한하는 것이 상당하다 할 것임. 신청인으로서 본건 통장명칭이 “주택청약예금 자동적금통장”이라고 되어 있다 하더라도 통장 내면의 안내말씀에 “…… 자동적금에 가입하시면 …… 월별이자를 매월 적금으로 자동 납입하여 드립니다.”라고 기재되어 별도로 자동적금을 가입하여야 한다는 것이 명시되어 있고, 통장의 주택청약정기예금란에는 내용이 인자되어 있으나 자동적금등록내역에는 아무런 내용이 인자되어 있지 않아서 통장 내용을 잘 살펴보거나 피신청인 직원에게 물어보았더라면 자동적금이 가입되어 있지 않다는 사실을 쉽게 알 수 있었던 점 등을 고려하여 신청인의 과실비율을 50%로 보고 피신청인의 책임을 50%로 제한함이 타당함.

라. 결 론

그렇다면 피신청인은 신청인에게 손해금액 476,940원에서 책임비율 50%에 해당하는 238,470원을 배상할 책임이 있어 이를 인용하고, 신청인의 나머지 청구는 이유 없어 기각함.

제2절 금리 적용

4-5 자유적립예금 적용이율의 해석 및 이에 따른 손해배상청구

[기각] 약관에 정하여진 사항이라 하더라도 거래상 일반적이고 공통된 사항이거나 이미 법령에 의하여 정해진 것을 되풀이하거나 부연하는 정도에 불과한 사항이라면 그러한 사항에 대하여서까지 사업자에게 명시·설명의무가 인정된다고 할 수 없다.”고 한 판례 등에 비추어 볼 때 본 건 예금의 금리부분에 대한 약관의 명시·설명의무 위반을 이유로 하거나 피신청인의 창구 직원의 과실을 이유로 하는 신청인의 피신청인에 대한 이자차액 상당의 손해배상청구는 그 이유가 없다고 판단되므로 신청인의 청구를 기각함.(2002.12.3. 조정번호 제2002-47호)

가. 사실관계

신청인은 2001.9.12. 피신청인 영업점에서 1년 만기 자유적립예금(이하 “본건 예금”이라 함)을 개설하고 금 1억원을 예치한 후 피신청인 직원으로부터 이율 연 7%로 인자된 예금통장을 교부 받음. 신청인은 그 후 2002.1.7. 금 2억원, 같은 해 6.24. 금 14억원, 7.10. 금 2억원, 8.2. 금 1억을 총 4회에 걸쳐 본건 예금에 각각 추가 예치하였음.

신청인은 본건 예금의 만기일인 2002.9.12.자에 피신청인으로부터 원리금 합계 금 2,033,130,867원(= 원금 20억원 + 이자 33,130,867원)을 수령하였음. 피신청인은 신청인이 2001.9.12. 예치한 금 1억원에 대하여는 연 7%, 2002.1.7. 예치한 금 2억원에 대하여는 연 6%, 2002.6.24. 예치한 금 14억원에 대하여는 연 5%, 2002.7.10. 예치한 금 2억원에 대하여는 연 5%, 2002.8.2. 예치한 금 1억원에 대하여는 연 4.5%의 이율을 각각 적용하여 이자를 계산하였음.

신청인은 2002.9.12. 피신청인의 위 이자 계산은 잘못되었다고 판단하고 위 각 예치금원에 대하여 모두 연 7%의 이율을 적용하여 계산한 금 41,872,153원이 피신청인이 지급해야 할 이자라고 주장하며 그 차액 금 8,741,286원(= 41,872,153원 - 33,130,867원)을 피신청인에게 손해배상 청구함.

나. 당사자 주장

(1) 신청인 주장

신청인이 본건 예금을 개설할 당시 피신청인의 창구직원은 본건 예금이 1년 만기 연 7%의 확정금리라고 설명하였고 본건 예금의 통장에 이율 연 7%를 기표함으로써 확정금리임을 표시하였으므로, 피신청인은 신청인이 총 5회에 걸쳐 예치한 각 금원에 대하여 모두 연 7%의 이율을 적용한 이자를 지급해야 할 것임.

(2) 피신청인 주장

본 건 예금은 피신청인의 적립식예금약관 및 상품안내문에 따라 최초가입 당시 이미 확정된 예치기간별 이율을 차등 적용한 것으로서 단순히 통장에 이율 연 7%라고 표기되어 있다는 이유만으로 신청인이 예치한 각 금원에 대하여 모두 연 7%의 이율을 적용한 이자를 지급해 주어야 한다는 것은 부당함. 신청인은 새마을금고에서 14년 이상 근무한 자로서 새마을금고에서도 본 건 예금과 유사한 자유적립예금을 취급하고 있으므로, 통상의 자유적립예금의 특성과는 달리 만기일에 가까운 날짜에 예치한 금원에 대해서도 언제나 최초 가입당시 이율을 적용해 달라는 신청인의 요구는 억지임.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 본건 자유적립예금과 관련하여 당사자가 약정한 예금에 대한 적용이율이 무엇인지에 대한 객관적 의사표시의 해석과 피신청인의 약관 명시·설명 의무를 해태한 사실이 있는지 여부 및 피신청인에게 사용자책임을 물을 수 있는지 여부라 할 것임.

아래의 점을 종합할 때, 본건 예금은 만기를 정하여 두고 예치금의 액수나 예치횟수에 상관없이 자유로이 저축할 수 있는 예금으로서, 본건 예금의 이율은 1년 기간동안 연 7%로 고정되어 있는 것이 아니라, 1년 기간 내에 각 예치한 금원에 대하여 최초 가입당시 이미 확정된 예치기간별 이율을 차등 적용해야 하는 것으로 판단되며, 신청인은 이러한 이율 적용에 대하여 잘못 이해하였던 것으로 보여짐.

① 피신청인의 「적립식예금약관」 제7조 제2항에 의하면 “자유적립식예금은 입금횟수

에 관계없이 저축금마다 입금일부터 만기일 전날까지의 기간에 대하여 계약일 당시 영업점에 게시한 이율로 썬한 이자와 원금을 만기지급금으로 한다.”라고 규정되어 있고, 피신청인의 본 건 예금에 대한 상품안내문의 기재내용에 의하면 본건 예금의 이자는 최초 가입당시 예치기간별 이율을 차등 적용하여 계산한다고 설명되어 있는 점.

② 「자유적립식예금 표준약관」상에도 위와 같은 식으로 상품이 설계되어 있는 점.

③ 신청인의 예금상품 중 피신청인의 자유적립예금과 유사한 상품의 경우에도 각 예입금마다 실제 예치기간별 약정이율을 적용하는 것으로 상품을 설명하고 있는 점.

④ 통상 자유적립예금의 특성으로 볼 때 만기일에 가까운 날짜에 예치한 금원도 예치기간에 상관없이 최초 가입당시의 고정금리를 적용하는 상품은 일반적으로 존재하지 않는다는 점.

⑤ 신청인이 주장하는 신청인 금고의 예금상품 중 자유적립적금은 법인이 계약할 수 없을 뿐만 아니라 일적수에 의한 단리상품인 점에서 본 건 예금과는 성격을 같이 할 수 없는 점.

나아가 신청인은 피신청인이 「약관의 규제에 관한 법률」 제3조 제1항의 약관의 명시·설명의무를 위반하였으므로 본 건 예금의 적용이율은 1년 기간 동안 연 7%로 고정되어 있는 것이라고 주장하나 아래의 점을 종합하여 볼 때, 금리부분에 대한 약관의 명시·설명의무 위반은 인정되지 아니함.

① 사업자에게 약관의 명시·설명의무가 인정되는 것은 어디까지나 계약자가 알지 못하는 가운데 약관에 정하여진 중요한 사항이 계약 내용으로 되어 계약자가 예측하지 못한 불이익을 받게 되는 것을 피하고자 하는데 그 근거가 있다고 할 것이므로 약관에 정하여진 사항이라 하더라도 거래상 일반적이고 공통된 사항이거나 이미 법령에 의하여 정해진 것을 되풀이하거나 부연하는 정도에 불과한 사항이라면 그러한 사항에 대하여서까지 사업자에게 명시·설명의무가 인정된다고 할 수 없음.¹⁹⁰⁾

② 모든 금융거래에서 사업자의 위 약관의 명시·설명의무는 동일한 주의의무 정도를 요구하는 것은 아니고 본건 자유적립예금의 통장에 의하면 “이 통장 거래에는 예금거래

190) 대법원 2000.12.22. 선고 99다1352 판결 참조.

기본약관 및 예금종류별약관과 특약이 적용되며, 신용금고 창구 어디에서나 해당약관과 특약을 열람하시거나 교부 받으실 수 있습니다.”라고 기재되어 있고, 대법원 역시 위 부동산문자에 대한 효력을 긍정하는 전제하에 은행에게는 적극적인 명시·설명의무를 요구하고 있지 아니한 점¹⁹¹⁾ 및 새마을금고는 고객으로부터 예치 받은 금원을 운용함에 있어 타 금융기관 예치시 금리부분에 대하여 면밀히 검토, 분석하여 관리하여야 할 주의의무가 있어 신청인의 주장을 믿기 어려운 점.

③ 은행이나 금고에는 별도의 상담창구가 마련되어 있어 상품이율에 관한 자세한 안내를 받을 수 있도록 되어 있는 점.

④ 동 상품 취급일 이후 현재까지 금리적용 착오로 인한 분쟁사례가 없는 등 일반고객도 동 상품의 특성을 잘 알고 있다고 판단되는 점.

⑤ 신청인이 새마을금고의 중견간부이고 금융업무 전문가로서 자유적립예금의 특성을 누구보다도 더 잘 알 수 있고, 새마을금고에도 이러한 성격의 상품을 판매하고 있는 점.

⑥ 신청인은 본건 예금을 개설하고 난 후 4회에 걸쳐 추가 예치하는 때에 본건 예금의 상품안내문이나 약관에 대해서 한 번도 이를 확인한 사실이 없는 점.

피신청인의 피용자인 창구직원의 과실로 인하여 신청인이 금리부분에 대해서 착오하였고 이로 인하여 손해배상이 발생하였는지 여부에 대하여 살펴보면, 창구직원은 신청인이 본건 예금상품에 대하여 질문하는 사항에 대하여 설명하고 은행의 일반관행에 따라 정상적으로 예금입금 처리한 점 및 위에서 밝힌 사유 등을 비추어볼 때, 피신청인의 창구직원이 동 상품에 대하여 설명을 부족하게 하여 신청인으로 하여금 금리부분에 대해 착오를 유발케 한 과실이 있다고 인정하기는 어렵다고 판단됨.

라. 결 론

그렇다면 본건 예금의 금리부분에 대한 약관의 명시·설명의무 위반을 이유로 하거나 피신청인의 창구직원의 과실을 이유로 하는 신청인의 피신청인에 대한 이자차액 상당의 손해배상청구는 그 이유가 없다고 판단되므로 신청인의 청구는 기각함.

191) 대법원 2001.12.11. 선고 2001다61852 판결 참조.

4-6 근로자우대저축에 대한 확정금리 지급 여부

[기각] 은행과의 예금거래계약은 당사자간에 개별약정이 없는 경우 통상 약관에 편입된 내용에 의해 이루어지며 모든 예금은 동 약관에 명시된 예금이자율의 적용을 받고 있는 바, 본건 예금의 적용이율은 관련 약관인 예금거래기본약관, 적립식예금약관 및 근로자우대저축특약에 의하여 영업점에 비치된 예금이율표의 근로자우대저축예금에 대한 이자율이 적용되는 것으로 해석할 수 있을 것이며, 은행은 수신영업에 있어서 약관의 비치, 상담창구와 상담전문직원의 배치, 정확한 상품안내장의 작성 등 고객에 대한 약관설명 가능성을 부여하고 있다면, 담당직원의 부당권유나 잘못된 상품설명이 인정되는 등 특별한 사정이 없는 한 약관의 명시·설명의무 위반은 없다고 할 수 있을 것이므로 신청인의 청구를 기각함.(2003.11.4. 조정번호 2003-50호)

가. 사실관계

신청인은 2000.5.23. 피신청인의 ○○지점에서 5년 만기 근로자우대저축(이하 “본건 예금”이라 함)을 개설하고 월불입금 50만원을 예치한 후 피신청인의 창구담당직원 A씨(이하 “담당직원”이라 함, 퇴직직원)로부터 이율 연 10%로 인자된 예금통장을 교부받았음.

신청인은 그후 매월 50만원씩 불입하여 2003.10.6. 현재 총 21백만원의 예금을 예치하였고, 신청인은 동년 6.3. 본건 예금에 대해 인터넷뱅킹으로 이율을 확인한 바, 본건 예금의 연이율이 가입후 3년 경과시점에서 연 4.8%로 변경된 사실을 확인하였음.

신청인은 본건 예금의 연이율이 변경된 것은 가입 당시 담당직원의 설명내용(만기까지 확정이율 10% 적용)과 다르다며 피신청인에게 이의를 제기하였으나, 피신청인은 가입 당시 담당직원이 만기까지 연 10%의 확정이율이 적용된다고 설명한 사실이 없다고 주장함.

나. 당사자의 주장

(1) 신청인의 주장

신청인은 본건 예금의 약관인 「근로자우대저축특약」에는 3년 경과시 금리가 변경된다는 내용이 없으며, 예금을 개설할 당시 피신청인의 담당직원이 본건 예금은 5년 동안

연 10%의 확정금리가 적용된다고 설명하였고, 본건 예금의 거래통장에도 적용이율이 연 10%로 표시되어 있으므로 피신청인은 본건 예금에 대해 만기(2005.5.23.)까지 연 10%의 이율을 적용하여 이자를 지급하여야 함.

(2) 피신청인의 주장

본건 예금은 피신청인의 예금거래기본약관, 적립식예금약관, 근로자우대저축특약이 적용되는 상품으로 동 예금은 가입후 3년까지는 연 10%, 3년 초과 5년 이하는 3년경과 당시의 3년제 가계우대정기적금의 이율이 적용되는 상품임.

본건 예금 가입 당시 신청인에게 상품안내장에 의거 본건 예금의 금리에 대해 상기와 같이 상세히 설명하였으므로 단순히 통장에 이율 연 10%라고 표기되어 있다는 이유만으로 신청인이 가입한 본건 예금에 대해 만기까지 연 10%의 이율을 적용한 이자를 지급해 주어야 한다는 신청인의 청구는 수용할 수 없음.

다. 위원회의 판단

◆ 본건에 있어서의 쟁점은 본건 근로자우대저축의 적용이율과 관련하여 ① 당해 약관의 내용 및 적용이율의 해석, ② 피신청인이 신청인에게 약관 명시·설명 의무를 위반하여 피신청인에게 사용자배상책임을 물을 수 있는지 여부라 할 것임.

(1) 본건 예금의 약관내용 및 적용이율의 해석

은행과의 예금거래계약은 당사자간에 개별약정이 없는 경우 통상 약관에 편입된 내용에 의해 이루어지며 모든 예금은 동 약관에 명시된 예금이자율의 적용을 받고 있음.

신청인은 본건 예금의 약관인 근로자우대저축특약에는 본건 예금에 대해 3년 경과시점에서 예금금리가 변경된다는 내용이 기재된 사실이 없다고 주장하는 바, 본건 예금의 적용이율과 관련된 약관의 내용을 살펴보면, 「근로자우대저축특약」의 금리조항인 제4조 제1항에는 “은행은 이 적금을 가입한 거래처에게 계약일 당시 영업점에 게시한 특별이율로 셈한 이자를 계약금액에 더하여 지급한다.”라고만 되어 있고 금리변경에 대한 내용은 없으나, 동 특약 제1조에 “이 특약에서 정하지 않은 사항은 예금거래기본약관 및 적

립식예금약관과 조세특례제한법, 동시행령 등 법령에서 정하는 바에 따른다.”라고 규정되어 있음.

상기 「예금거래기본약관」의 제9조 제2항에는 “은행은 예금종류별 이율을 적은 예금이율표를 영업점에 놓아두거나 게시하며, 이율을 바꾼 때는 그 바꾼 내용을 영업점에 1개월 동안 게시한다.”라고 규정되어 있으며, 「적립식예금약관」 제4조 제1항에는 “이 예금의 월저축액을 매월 약정한 날짜에 입금하였을 때에는 은행은 저축금마다 입금일부터 만기일 전날까지의 기간에 대하여 계약일 당시 영업점에 게시한 이율로 셈한 이자를 저축금 총액에 더한 금액을 만기지급금으로 지급한다.”고 규정되어 있음.

「예금거래기본약관」 제9조 제2항에 기재된 예금이율표는 통상 은행의 객장에 비치되어 있으며, 동 이율표에는 본건 예금에 대해 3년까지는 연이율 10%, 3년 초과 5년까지는 3년 경과시점의 3년제 가계우대정기적금 이율이 적용되는 것으로 명시되어 있음.

따라서 본건 예금의 적용이율은 관련 약관인 예금거래기본약관, 적립식예금약관 및 근로자우대저축특약에 의하여 영업점에 비치된 예금이율표의 근로자우대저축예금에 대한 이자율이 적용되는 것으로 해석할 수 있을 것임.

(2) 약관의 명시·설명의무 위반에 따른 피신청인의 사용자배상책임 여부

신청인은 본건 예금가입시 중요사항인 금리변경(예금가입 후 3년경과시 금리변경)에 대해 설명을 하지 않았다고 주장하고 있으므로 「약관의 규제에 관한 법률」 제3조 제2항의 중요한 내용에 대한 설명의무를 위반하였는지에 대해 살펴보건대, 계약 당시 금융회사가 계약자에게 약관을 교부하고 그 약관의 중요한 내용을 알려주어야 할 의무를 규정한 동 법률의 취지는 본래 보통약관은 사업자가 일방적으로 미리 작성하여 계약자와의 계약체결시 사용하는 것이어서 계약자는 동 약관을 제대로 알지 못하여 불이익을 받을 수 있으므로 금융회사로 하여금 계약자에게 동 약관을 교부하고 설명하도록 하여 이러한 불이익을 사전에 예방하기 위한 것임. 다만, 약관에 정하여진 사항이라고 하더라도 거래상 일반적이고 공통된 것이어서 계약자가 별도의 설명 없이도 충분히 예상할 수 있었던 사항이거나 이미 법령에 의하여 정하여진 것을 되풀이하거나 부연하는 정도에 불과한 사항이라면 그러한 사항에 대하여서까지 사업자에게 명시·설명의무가 인정된다고

할 수는 없음.¹⁹²⁾

모든 금융거래에서 사업자의 명시·설명의무는 동일한 주의의무 정도를 요구하는 것이 아니라 개별 상품에 따라 그 설명정도를 달리 하고 있는 것으로, 은행의 수신영업에 있어서 은행은 약관의 영업장내 비치, 상담창구와 상담전문직원의 배치, 정확한 상품안내장의 작성 등 고객에 대한 약관설명 가능성을 부여하고 있다면, 담당직원의 부당권유 내지는 기망, 잘못된 상품설명이 인정되는 등의 특별한 사정이 없는 한 약관의 명시·설명의무 위반은 없다고 할 수 있을 것임.

신청인은 통장에 연 10%라고 인자된 점을 근거로 피신청인의 약관 명시·설명의무 위반을 주장하나, 위 인정사실 만으로는 이를 인정하기 부족하고 오히려 아래의 각 점을 종합할 때 금리부분에 대한 피신청인의 약관의 명시·설명의무 위반은 인정되기 어려운 것으로 판단됨.

① 본건 근로자우대저축통장에는 “이 통장 거래에는 예금거래약관과 예금종류별약관이 적용되며, 저희은행 어디에서나 해당약관을 열람하시거나 교부받으실 수 있습니다.”라고 기재되어 있어 당해 약관의 내용을 인지할 가능성이 충분히 보장되어 있는 점.¹⁹³⁾

② 당해 상품은 정책적 차원에서 다른 은행에서도 취급한 상품으로서 상품의 금리 적용부분이 사회일반인의 예견가능성을 침해할 정도로의 기습조항으로 보기 어려운 점.

③ 은행에는 별도의 상담창구가 마련되어 있어 상품이율에 관한 자세한 안내를 받을 수 있도록 되어 있으며, 통상 창구직원은 신규 상품이 나왔을 경우 상품안내장을 근거로 상품을 설명하고 있는 점.

④ 본건 예금은 조세특례제한법에 의한 비과세상품으로 일반적으로 고객의 입장에서 볼 때 세금감면이나 이자율에 관한 부분은 예금 가입시 가장 우선하여 확인할 수밖에 없는 사항으로써 그 자체가 당해 상품에의 가입여부를 결정짓는 중요한 요소이므로 상품안내장의 금리 기재내용을 확인하는 것은 예금고객의 일반적인 행위의 범주에 속하는 것으로 보이며, 신청인은 담당직원으로부터 본건 예금의 금리는 만기까지 10% 확정금리

192) 대법원 1999.9.7. 선고 98다19240 판결 참조.

193) 대법원 2001.12.11. 선고 2001다61852 판결, 금융분쟁조정위원회 조정번호 제2002-47호 등 참조.

가 적용된다고 설명 받은 사실을 입증하지 못하는 점.

나아가 본건의 경우에 있어 사용자배상책임을 인정하기 위해서는 신청인이 3년 초과 후 금리가 변동된다는 것을 인식하지 못한데 대하여 피신청인의 담당직원이 위법한 행위를 하였고, 고의 또는 과실이 있었다는 사실이 입증되어야 하는데 현재 담당직원이 신청인에게 5년간 연리 10%의 이자율을 제시하였다는 증거자체를 찾기 어려운 상태이므로 담당직원의 불법행위나 이에 따른 피신청인의 사용자배상책임을 성립하기 어려운 것으로 판단됨.

라. 결 론

그렇다면 피신청인은 신청인에게 본건 예금의 만기까지 연 10%의 확정이율을 지급할 책임이 없다고 할 것이어서 신청인의 청구는 이유 없어 이를 기각함.

제3절 예금 지급 및 해지

4-7 일부 상속자의 동의만으로 상속예금을 지급한 경우의 정당성 여부

[일부인용] 금융실명제 실시에 따라 특별한 사정이 없는 한 금융기관이 실명확인을 한 명의 자를 예금주로 해석하고 있으므로 본건 예금의 예금주는 피상속인인 것으로 판단되나, 은행이 상속예금 지급시 신청인의 동의를 받지 아니하고 본건 예금 전액을 지급한 것은 잘못이므로 신청인의 법정상속지분인 5.5분의 1에 대하여는 신청인에게 반환하여야 함.(1999.6.22. 조정번호 제1999-18호)

가. 사실관계

1995.2.21. 신청인의 부친인 A씨는 ○○은행 지점(이하 “은행”이라 함)에 월복리 ◇◇◇신탁계좌를 개설(거치기간 12개월, 이하 “본건 예금”이라 함)하고 10백만원을 입금함.

1997.9.8. A씨가 사망하자, 은행은 1998.3.4. A씨의 사망사실 및 상속인¹⁹⁴⁾자격을 확인하고 신청인을 제외한 상속인 전원과 신청인의 처¹⁹⁵⁾로부터 호적등본, 상속예금지급·명의변경의뢰서, 인감변경·통장재발행의뢰서, 계좌해약청구서, 각자의 인감증명서, 본건 예금 전액을 B씨(A씨의 아들)에게 지급하여도 이의를 제기하지 않겠다는 동의서를 제출받아 본건 예금 원리금 13,714,252원을 B씨에게 지급함.

나. 당사자의 주장

(1) 신청인의 주장

은행이 신청인을 제외한 나머지 상속인들의 동의만을 근거로 본건 예금을 지급하였는 바 이는 부당하며, 본건 예금의 실제 예금주는 신청인의 할머니이며, 할머니의 사후 장

194) 상속인(5인) : C씨(A씨의 처), 신청인을 포함한 A씨의 자녀 4명.

195) 당시 신청인은 행방불명으로 연락두절된 상태(1996.8.7.자 ○○일보에 심인광고 게재)였으므로 부득이 신청인 대신 신청인의 처가 예금청구서에 날인하였으며, 본건 예금 청구자는 C씨(A씨의 처), 신청인의 처, 신청인을 제외한 A씨의 자녀 3명 등 5인이었음

레비로 사용하기 위해 A씨에게 관리시킨 것이므로 실제 예금주가 사용할 수 있도록 예금전액을 환급해주기 바람.

(2) 피신청인의 주장

상속예금은 상속인 전원의 청구를 받아 지급하여야 하나 당시 신청인은 행방불명으로 연락이 두절된 상태였으며 신청인의 가족들이 생활이 어렵다며 선처를 요청해 왔고, 상속인의 부탁으로 은행 □□지점 직원(1998.10.26. 퇴직)이 추후 문제발생시 책임을 지겠다는 각서도 제출함에 따라 고객의 입장에서 부득이 신청인의 처와 나머지 상속인의 예금청구에 의해 본건 예금을 지급하였음.

본건 예금은 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 긴급재정경제명령」(이하 “긴급명령”이라 함) 시행(1993.8.12) 이후에 예금주에 대한 실명확인을 거쳐 개설하였으므로 실제 예금주가 신청인의 할머니라는 주장은 타당하지 아니함.

고객편의 차원에서 본건 예금을 지급하였으나 상속인인 신청인의 지급청구 없이 예금을 지급한 것은 정당한 업무처리로 볼 수 없으므로 신청인의 법정상속분(5.5분의 1)에 대하여 상속예금을 지급받은 나머지 상속인이 동 금액을 신청인에게 지급하지 아니할 경우 은행이 책임지고자 함.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 본건 예금의 실제 예금주가 누구인지 및 은행이 신청인의 동의없이 본건 예금 전액을 지급한 데 따른 책임유무임.

(1) 본건 예금의 실제 예금주

금융실명제 시행이후 금융기관 예금계약의 예금주에 관하여 대법원은 “긴급명령이 시행된 후에는 금융기관에 예금을 하고자 하는 자는 원칙적으로 직접 주민등록증과 인감을 지참하고 금융기관에 나가 자기 이름으로 예금을 하여야 하고, 이 경우 금융기관으로서 특별한 사정이 없는 한 주민등록증을 통하여 실명확인을 한 예금명의자를 긴급명령 제3조 제1항 소정의 거래자로 보아 그와 예금거래를 체결할 의도라고 보아야 한

다”고 판시¹⁹⁶⁾하고 있는 바, 본건의 경우 달리 본건 예금 반환채권을 예금명의인이 아닌 신청인의 할머니에게 귀속시키기로 하는 명시적 또는 묵시적 약정이 있다고 인정할 근거가 없으므로 본건 예금의 예금주는 예금명의자인 A씨로 보아야 함.

(2) 은행이 신청인의 동의없이 본건 예금 전액을 지급한 데 따른 책임

비록 은행은 신청인이 행방불명된 상태에서 고객의 입장을 최대한 고려하여 예금을 지급하게 된 것이라고 하더라도 민법(제1006조)에 의하면 상속인이 수인인 때에는 상속재산은 그 공유로 한다고 되어 있고, 피신청인의 「예금총칙」에도 상속예금 지급시에는 공동상속인 전원의 명의로 예금청구서를 받아 지급하도록 되어있고 은행 역시 예금지급 절차상 하자가 있었음을 인정하고 있음에 비추어 은행이 신청인의 동의없이 신청인에 대한 실종선고 등의 조치도 없는 상태에서 신청인의 지분을 포함한 본건 예금 전액을 지급한 것을 정당하다고 하기 어려우며, 이에 따른 은행의 책임범위는 민법상 신청인의 법정상속분(5.5분의 1)에 상당하는 금액으로 보는 것이 타당한 것으로 판단됨.

라. 결 론

위에서 살펴본 바와 같이 본건 예금의 실제 예금주를 달리 볼 근거가 없으나, 은행은 본건 예금 원리금의 공동상속인인 신청인의 동의없이 예금 전액을 지급한 잘못이 인정됨.

4-8 예금주의 해외체류중 배우자 요청에 의한 예금계좌 해지의 정당성 여부

[기각] 신청인은 배우자의 요청만으로 예금을 해지하여 준 것은 부당하다 하나, 신청인이 출국시 주민등록증, 예금통장 등을 배우자에게 준 점, 신청인이 해외 체류기관중 동 계좌가 개설되었고 동 납입금은 배우자가 관리하던 신청인의 예금계좌에서 인출된 점, 배우자에게 가사대리권이 있고 신청인의 해외체류기간중 생활비 등에 사용코자 해약을 요청한 점 등에 비추어 표현대리가 성립되므로 해지가 부당하다고 보기 어려움.(1999.10.12. 조정번호 제1999-46호)

196) 대법원 1998.11.13. 선고 97다53359 판결, 1998.6.12. 선고 97다18455 판결, 1996.4.23 선고 95다55986 판결 참조.

가. 사실관계

(1) A은행

신청인은 1994.10.7. A은행에 ○○예금계좌를 개설한 후, 1995.9.19. 취업을 위하여 일본으로 출국하였으며, C씨(신청인의 여동생)은 동년 12.15. A은행 지점에서 신청인 명의로 ◇◇◇◇신탁(2년제, 월납입금 1백만원)계좌를 개설하고, 월납입금은 상기 ○○예금계좌에서 자동이체되도록 약정을 체결함.

1997.1.8. 신청인의 통장, 인감 및 주민등록증을 지참한 D씨(신청인의 처)의 요청에 따라 A은행은 신청인 명의 ◇◇◇◇신탁을 해약하고 동 해약금 13,482,983원을 신청인 명의 ○○예금 계좌로 대체 입금함.

1997.1.20. D씨는 A은행 지점에 개설된 신청인 명의 ○○예금계좌에서 1백만원을 인출하여 동 금원을 동일 개설한 신청인 명의 □□□□적금¹⁹⁷⁾계좌에 50만원을 입금하고 아울러 △△△△저축계좌에 50만원을 입금하였음.

1997.4.21. D씨의 요청에 따라 A은행 지점은 신청인 명의 □□□□적금계좌 해약금 1,003,589원과 △△△△저축계좌 해약금 502,493원을 신청인 명의 ○○예금계좌로 대체 입금하였으며, 신청인은 그 후 1999.2.7. 귀국함.

(2) B은행

신청인의 해외체류기간(1995.9.19.~1999.2.7.)중인 1996.1.11. E씨(신청인의 아들)가 B은행에 신청인 명의 ▽▽▽▽부금(2년제, 월납입액 10만원)계좌를 개설함.

B은행 지점은 1998.1.11. D씨(신청인의 배우자)의 요청을 받고 신청인 명의 ▽▽▽▽부금계좌를 1999.1.11.까지 1년간 기간연장 등록함.

1998.3.11. 신청인의 통장, 인감 및 주민등록증을 지참한 D씨의 요청에 따라 B은행이 신청인 명의 ▽▽▽▽부금을 해약하여 동 해약금 2,677,924원을 지급(자기앞수표 2백만원, 나머지 현금)함.

197) 매월 납입액은 각각 50만원임.

나. 당사자의 주장

(1) 신청인의 주장

A은행이 신청인의 의사를 확인하지 않고 신청인 명의 ◇◇◇◇신탁, □□□□적금 및 △△△△저축을 해약함으로써 신청인이 대출을 받지 못하는 등 피해를 보고 있음. 또한 B은행이 신청인의 의사를 확인하지 않고 신청인 명의 ▽▽▽▽부금을 해약함으로써 아파트분양 신청자격을 상실하게 되었으므로 이를 원상회복하여야 함.

(2) 피신청인의 주장

신청인이 출국한 후 신청인의 처인 D씨가 신청인의 주민등록증과 인감을 지참하고 예금거래를 지속하여 왔으므로 D씨를 신청인의 대리인으로 인정하고 본건 ◇◇◇◇신탁, □□□□적금, △△△△저축 및 ▽▽▽▽부금을 해약하여 신청인 ○○예금계좌에 대체 입금 또는 현금 및 자기앞수표로 지급하였는 바, 표현대리의 법리에 의해 처의 법률 행위는 신청인에게 귀속됨.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 신청인의 처가 신청인 명의로 개설된 A은행의 신탁, 적금 및 저축계좌와 B은행의 부금계좌를 해약한 행위가 표현대리로 인정되는지 여부임.

대법원은 표현대리 성립여부를 판단함에 있어 다음과 같은 입장을 표명하고 있음. 즉, “일반적으로 표현대리의 경우 상대방이 본인을 대리할 권한이 있다고 믿음에 상당한 사유가 있는지 여부는 거래당시의 사정으로부터 객관적으로 거래의 관념에 따라 판단하여야 한다”라고 판시하고 있고,¹⁹⁸⁾ “처가 해외체류중인 남편의 대리인으로 부동산을 매수하여 남편 명의로 소유권이전등기를 하였다가 남편의 인감도장, 등기권리증 및 부동산명의변경용 인감증명서를 교부하여 소유권이전 등기를 마친 경우 처가 남편을 대리할 대리권이 있다고 믿을 만한 정당한 이유가 있었다고 볼 것이다”라고 판시하고 있으며,¹⁹⁹⁾

198) 대법원 1987.11.10. 선고 87다카1325 판결 참조.

199) 대법원 1984.11.27. 선고 84다310, 84다카1283 판결 참조.

“일상가사에 관하여 남편을 대리할 권한이 있는 처가 남편 몰래 인감도장, 인감증명서 등을 소지하고 그 대리인인 양 행세하여 금원을 차용하고 그 담보로 남편 소유의 부동산에 가등기를 경료 하여준 경우에 그 상대방이 위 처에게 남편을 대리할 권한이 있다고 믿음에 정당한 이유가 있다”라고 판시하고 있음.²⁰⁰⁾

따라서 위의 대법원 판례의 취지와 다음과 같은 점에 비추어 볼 때 피신청인이 신청인의 처 D씨에게 신청인을 대리할 권한이 있다고 믿음에 대하여 정당한 사유가 있는 것으로 보여지므로 D씨의 신청인 명의 예금 해약 및 인출행위의 효력을 부인하는 신청인의 요청을 받아들이기 어려운 것으로 판단됨.

① 신청인이 해외로 출국하면서 신청인이 A은행에 개설한 ○○예금통장, 거래인감 및 주민등록증 등을 처 D씨에게 교부하여 D씨가 ○○예금거래를 하도록 하였고 이에 따라 신청인의 해외체류기간중 D씨가 ○○예금을 입금, 출금한 사실에 비추어 볼 때 신청인이 D씨에게 예금거래에 대한 대리권을 부여하였던 것으로 보이는 점.

② 신청인의 해외체류기간중 ◇◇◇◇신탁계좌 등이 개설되었고 동 납입금을 D씨가 관리하고 있던 신청인 명의 ○○예금계좌에서 인출하여 납입하는 등 ◇◇◇◇신탁 등과 관련된 거래를 D씨가 대리한 것으로 보이는 점.

③ D씨에게 가사대리권이 있었고 신청인의 해외체류기간중 생활비 등으로 사용하고자 D씨가 ◇◇◇◇신탁 등의 해약을 요청하면서 예금통장, 거래인감 및 신청인의 주민등록증을 지참하고 있었으며, 동 해약금을 생활비 등에 사용할 것이라고 피신청인의 직원에게 말한 점.

라. 결 론

위에서 살펴본 바와 같이 예금계약 해지와 관련하여 피신청인이 신청인의 처 D씨에게 신청인을 대리할 권한이 있다고 믿음에 대하여 정당한 사유가 있는 것으로 판단되어 표현대리가 성립된다 할 것이므로 피신청인이 D씨의 요청에 따라 본건 관련 ◇◇◇◇신탁 등을 해약한 것이 부당하다고 보기 어려운 것으로 판단됨.

200) 대법원 1981.6.23. 선고 80다609 판결 참조.

[일부인용] 신청인이 VIP고객이라는 이유로 신청인의 경리직원이 제출한 예금청구서상의 인영과 신고된 인감과의 동일성을 전혀 확인하지 아니한 과실이 인정되는 점 등에 비추어 볼 때 피신청인의 예금지급은 정당하지 아니하므로 부당지급으로 인하여 신청인에게 발생한 손해를 배상하여야 할 것이지만 신청인도 예금 부당인출을 쉽게 인지할 수 있었음에도 조치를 취하지 아니한 과실이 있는 바 50%의 손해배상금액을 산정함.(2000.5.16. 조정번호 제2000-23호)

가. 사실관계

1992.3.21. 신청인이 대표로 있는 A기업은 ○○은행 지점에 예금계좌를 개설하였고, 동 은행 직원은 1996.1.3.~1998.5.15. 기간중 신청인회사 경리직원인 D씨에게 신청인 명의의 예금을 예금청구서상 날인된 인영이 은행에 신고된 인감²⁰¹⁾과 상이함에도 불구하고 25회에 걸쳐 금 705,520,720원을 현금 및 수표 등으로 지급함. 동 금원 중 금 470,913,720원은 신청인의 타은행 계좌나 신청인을 위하여 사용되었음이 조회결과 확인되었으나, 나머지에 대하여는 사용내역 확인이 곤란함.

1998.2.19. B기업이 납입한 주식청약증거금 2억원을 출금전표에 날인된 도장이 주금납입시 제출한 법인인감증명서상의 인감²⁰²⁾과 상이함에도 위 D씨에게 지급함. 동 금원 중 금 183,675,870원은 신청인 C씨 개인계좌에 입금되었다가 세무소에 세금으로 납부되었으나 나머지 금액은 확인이 곤란함.

1998.9.18. D씨와 내연관계인 자의 계좌로부터 A기업 계좌로 금 91백만원이 입금²⁰³⁾되었으며, 확인결과 A기업과 D씨의 내연관계인 자 사이에 채권채무관계는 없는 것으로 확인됨.

201) 확인결과, 은행에 신고된 인감은 도장 가장자리가 “株式會社 A”로 되어있으나 본건 예금청구서상 날인된 인영은 “주식회사 A”로 되어 있음.

202) 확인결과, 법인인감증명서상의 인감은 도장 가장자리가 “주식회사 B”로 되어 있으나 출금전표상 날인된 인영은 “B 주식회사”로 되어 있음

203) 위 금원은 D씨의 횡령사실이 인지된 이후 신청인의 추궁이 있자 횡령액에 대한 배상명목으로 입금된 것으로 추정됨.

나. 당사자의 주장

(1) 신청인의 주장

피신청인의 직원은 은행에 신고된 인감과 예금지급청구서 및 출금전표상 날인된 인영이 상이함에도 불구하고 이를 주의 깊게 확인하지 않은 과실로 신청인의 예금을 부당지급 하였으므로 그로 인하여 신청인에게 발생한 손해액 금905,520,720원을 배상하여야 함.

피신청인이 부당지급한 금액중 상당액이 신청인의 타은행 계좌로 다시 입금되었거나 신청인의 세금 등으로 납부된 사실은 인정하지만 이는 은행의 부당지급과는 구분되어야 하므로 피신청인은 부당지급액 전액을 신청인에게 배상하여야 함.

(2) 피신청인의 주장

피신청인의 직원이 은행에 인감의 동일성을 주의 깊게 확인하지 아니하고 예금을 지급한 것은 인정함. 그러나 자체조사결과 부당지급된 금액중 신청인을 위하여 사용된 것이 확인된 금 654,589,590원과 경리직원 D씨와 내연관계에 있는 자로부터 회수받은 금 91백만원은 손익상계되어야 하고, 예금의 부당지급에 있어 신청인의 과실이 상당하므로 과실상계한 범위내에서만 손해배상을 할 수 있음.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 피신청인의 예금지급이 정당하다고 볼 수 있는지와 손해배상금액의 산정 기준이라 할 것임.

(1) 예금지급이 정당한지의 여부

민법의 일반원칙에 의하면 은행은 예금주 본인·대리인·使者에게 지급하면 정당한 변제가 되어 예금채권은 지급범위내에서 소멸된다고 볼 수 있음. 그러나 정당한 권리자가 아닌 경우에도 변제자가 사회일반의 거래관념상 진실한 채권을 가진 자라고 믿을만한 외관을 구비한 자에게 선의이며 과실없이 변제한 경우에는 채권의 준점유자에 대한 변제로서 유효하다고 규정하고 있음.²⁰⁴⁾

204) 민법 제470조.

그러나 아래와 같은 사정을 종합할 때 피신청인의 직원이 선의이며 과실없이 예금을 지급하였다고 볼 수 없으므로 피신청인의 예금지급은 정당하지 아니함.

① 본건 「예금거래약관」 제16조에 의하면 “은행은 예금지급청구서 등에 찍힌 인영을 신고한 인감과 육안으로 주의 깊게 비교대조하여 틀림없다고 여기고, 비밀번호가 신고한 것과 같아서 예금을 지급한 경우에는 인감의 위조 등으로 인하여 손해가 발생한 경우에도 은행은 그 책임을 지지 아니한다”고 규정하고 있는 점.

② 문답서 및 피신청인의 직원이 작성한 경위서에 의하면 신청인이 VIP고객이라는 이유로 신청인의 경리직원이 제출한 예금청구서상의 인영과 신고된 인감과의 동일성을 전혀 확인하지 아니한 과실이 인정되는 점.

③ 대법원도 예금청구서에 날인한 인영과 은행에 신고한 인감을 대조 확인할 때에는 인감대조에 숙련된 은행원으로 하여금 그 직무수행상 필요로 하는 충분한 주의를 다하여 인감을 대조하도록 할 것이지만, 단지 세심히 살펴보았다라면 인영의 상위를 어렵지 않게 육안으로 판별할 수 있는 경우에 채권의 준점유자에 대한 변제로 면책을 주장할 수 없다고 판시하고 있는 점.²⁰⁵⁾

(2) 손해배상금액의 산정기준

대법원은 손해배상은 실손해의 전보를 목적으로 하는 것인 만큼 피해자로 하여금 실손해 이상의 이익을 취득하게 하는 것은 손해배상의 본능에 반하는 것이므로 손해를 입은 것과 동일한 원인으로 인하여 이익을 얻을 때에는 그 이익은 공제되어야 한다고 판시하고 있음.²⁰⁶⁾ 따라서 부당인출된 금원중 신청인의 타은행계좌로 다시 입금되었거나 신청인을 위하여 세금 등으로 납부된 것임이 명백히 확인된 금액(금 654,589,590원) 및 D씨의 횡령사실이 적발된 이후 그와 내연관계에 있는 자로부터 신청인계좌로 입금이 확인된 금액(금 91,000,000원)은 손해액의 범위에서 공제함이 상당함.

피신청인의 예금지급이 정당하다고 볼 수 없으므로 부당지급으로 인하여 신청인에게 발생한 손해를 배상하여야 할 것이지만 아래와 같은 사정을 종합하여 신청인의 과실비

205) 대법원 1992.2.14. 선고 91다9244 판결 참조.

206) 대법원 1978.3.14. 선고 76다2168 판결 참조.

율을 50%로 적용·산정하여야 할 것임.

① 예금의 부당인출은 통장 등을 통해 쉽게 발견할 수 있음에도 약 2년 5개월 동안이나 위 사실을 인지하지 못하였다고 주장함은 주식회사의 회계관리체계상 쉽게 납득이 되지 아니하는 점.

② 신청인이 대표이사로 재직중인 A기업은 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」에 의하여 외부감사대상기관인 점에서 회계법인이 은행거래상황확인서에 의하여 결산을 실시하는 과정에서 D씨의 예금 부당인출사실을 인지할 가능성이 충분히 존재하였던 점.

③ 신청인측의 경리부장에 대한 문답서에 의하면 신청인은 A기업의 ○○은행 계좌에 대한 D씨의 예금 부당인출 사실을 최소한 1998.5월 초순경 인지하였던 사실이 인정되나, 신청인이 피신청인에게 이를 알려 손해배상을 요구한 시기는 2000.2.17.로 확인되는 점.

라. 결 론

피신청인이 본건 예금을 정당하게 지급하였다고 보기 어려워 피신청인은 신청인이 입은 손해에 대하여 위에서 산정한 기준에 의하여 배상책임이 있는 것으로 판단됨.

4-10 예금통장 이월시에 인감을 날인하지 않아 발생한 손해에 대한 배상책임

[일부인용] 금융기관이 예금통장을 이월하면서 통장에 인감을 날인하지 않은 채 재발급하고 서도 지급정지 등 금융사고 예방을 위한 조치를 취하지 않은 경우 이러한 부당한 업무처리와 제3자에 의한 불법인출 간에는 상당한 인과관계가 있음.(2005.11.8. 조정번호 제2005-74호)

가. 사실관계

충청남도 소재 ○○아파트 입주자들은 동 아파트 관리비를 예치하기 위해 동 아파트 입주자대표회의 회장명의로 1998.2.4. ◇◇농업협동조합(이하 “계좌개설점”이라 함)에 예금계좌(이하 “본건 통장”이라 함)를 개설²⁰⁷⁾하였음.

한편, 2005.6.23. 계좌개설점은 본건 통장의 거래내역이 많아 이월재발급하였는데 이때 관리사무소 직원이 상기 신고인감을 소지하지 않아 무인감 통장을 이월재발급²⁰⁸⁾한 바 있으며, 2005.7.4. 제3자가 동 아파트 관리사무소에 침입하여 사무실내 서랍에 보관중이던 본건통장을 절취하였고, 다음날인 2005.7.5. 09:06~09:32에 걸쳐 본건통장을 이용해 인근 □□농업협동조합 등 3개 농협(이하 “예금인출점”이라 함)에서 총 94백만원을 부당 인출하였음.

나. 당사자의 주장

(1) 신청인 주장

예금인출점은 피신청인에게 신고된 인감과 예금지급청구서상 날인된 인영이 상이할 뿐 아니라 아파트관리비 예치통장의 경우 계좌개설점 외에는 사실상 거래를 하지 않고 있고 본건통장을 통한 거래의 현금거래는 이루어지지 않고 있음에도 예금인출점 직원이 인출자의 신분확인이나 예금자에 대한 문의가 전혀 없이 예금을 지급한 것은 부당함으로 부당인출된 예금을 반환하여야 함.

계좌개설점은 본건통장의 경우 2005.6.23. 이월재발급시 사용인감이 날인되어 있지 않은 무인감상태인 바, 계좌개설점에서 규정에 따라 거래정지조치를 하였다면 부당인출을 막을 수 있었음에도 이러한 조치를 취하지 않은 것은 부당하므로 신청인의 피해를 배상하여야 함.

(2) 피신청인 주장

예금인출점은 본건예금 지급시 예금인출점으로서 본건통장에 대한 도난사실과 인감

207) 본건통장은 입출금이 자유로운 보통예탁금이며, 2002.2.1.부터 한글로 양각된 “○○아파트입주자대표회의 회장의인” 및 “△△주택관리(주) 대표이사”의 복수인감을 사용하고 있었음.

208) 피신청인 및 관리사무소 경리직원에게 따르면 본건 통장의 사용인감을 입주자 대표회의 회장과 △△주택관리(주) 대표이사가 따로 보관하고 있어 통상 통장 이월재발급시마다 무인감통장을 미리 교부하고 인감은 사후에 이를 보완하는 등의 방법으로 업무를 처리하였다고 하며, 상기 관리사무소 경리 직원은 무인감 상태로 이월발급된 본건통장을 수령한 후 우선 입주자 대표회의 회장인감 하나만 날인해 놓았다고 함.

의 위변조 여부를 알 수 없었으며, 본건통장에 날인된 인감과 지급청구서에 날인된 인감을 육안상 주의 깊게 상호비교·대조한 결과 일치한다고 판단하였고 인출자도 비밀번호를 오류없이 한번에 입력하였는 바, 「예탁금거래기본약관」 제16조(면책)²⁰⁹⁾에 따라 면책되므로 신청인의 주장을 수용할 수 없음.

계좌개설점은 무인감통장 이월발급 후 사후날인은 그동안 관례상 해왔던 것이며, 결국 본건은 예금주가 통장 및 비밀번호 관리를 소홀히 한 데 귀책사유가 있으므로 신청인의 청구를 수용할 수 없음.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 ① 예금인출점의 예금지급이 채권의 준점유자에 대한 변제로서 유효한지 여부와 ② 계좌개설점의 무인감통장 이월발급후 거래정지조치를 하지 않는 업무처리가 정당하였는지 여부라 하겠음.

(1) 예금인출점의 예금지급이 채권의 준점유자에 대한 변제로서 유효한지 여부

민법의 일반원칙에 의하면 금융기관은 예금주 본인·대리인·사자(使者)에게 지급하면 정당한 변제가 되어 예금채권은 지급범위내에서 소멸됨. 그러나 정당한 권리자가 아닌 경우에도 변제자가 사회일반의 거래관념상 진실한 채권을 가진 자라고 믿을 만한 외관을 구비한 자에게 선의이며 과실없이 변제한 경우에는 채권의 준점유자에 대한 변제로서 유효하다고 규정하고 있으며,²¹⁰⁾ 대법원의 경우 “예금청구서에 날인한 인영과 금융기관에 신고하여 예금통장에 찍힌 인감을 대조확인할 때에는 인감대조에 숙련된 직원으로 하여금 그 직무수행상 필요로 하는 충분한 주의를 다하여 인감을 대조하도록 할 것

209) 예탁금거래기본약관 제16조(면책) ① 조합은 예탁금지급청구서, 증권 또는 신고서 등에 찍힌 인영(또는 서명)을 신고한 인감(또는 서명)과 육안으로 주의깊게 비교·대조하여 틀림없다고 여기고, 예탁금지급청구서 등에 적힌 비밀번호나 PIN-Pad기를 이용하여 입력된 비밀번호가 신고 또는 등록한 것과 같아서 예탁금을 지급하였거나 기타 거래처가 요구하는 업무를 처리하였을 때에는 인감이나 서명의 위조·변조 또는 도용이나 그 밖의 다른 사고로 인하여 거래처에 손해가 생겨도 그 책임을 지지 않는다. 다만, 조합이 거래처의 인감이나 서명의 위조·변조 또는 도용사실을 알았거나 알 수 있었을 때에는 그러하지 아니하다.

210) 민법 제470조.

이고, 그러한 주의의무를 다하지 못하여 예금수령의 권한이 없는 자에게 예금을 지급하였다면 금융기관으로서 그러한 예금지급으로서 채권의 준점유자에 대한 변제로서의 면책을 주장할 수 없다”²¹¹⁾고 하는 한편, 예금지급시 대조할 인감에 대하여는 “채권의 준점유라고 하려면 채권의 사실상 귀속자와 같은 외형을 갖추어야 하므로 예금채권의 준점유자는 예금통장과 그에 찍힌 인영과 같은 인장을 소지하여야 한다”고 판시²¹²⁾하고 있음.

따라서, 본건의 경우 예금인출점의 채권의 준점유자에 대한 변제로서 유효한지 여부를 판단함에 있어서는 예금인출점 직원이 본건통장에 날인된 인감과 지급청구서에 날인된 인감을 비교·대조함에 있어서 과실이 있었는지 여부가 관건인 바, 현재로서는 본건통장의 실물이 없어 본건통장의 위변조 여부, 위변조 방법, 인감날인 상태 등을 확인할 수 없어 예금인출점의 과실을 입증할 만한 구체적인 증거를 확보하기 어렵고 예금인출자에 대한 직접 조사도 어려운 점을 감안할 때 현재로서는 예금인출점의 과실여부를 판단하기 곤란하다 할 것임.

(2) 무인감통장 이월발급후 거래정지를 취하지 않는 업무처리가 정당한지 여부

계좌개설점의 경우 본건 무인감통장 이월이 그동안 관행적으로 이루어지고 있었고 예금주도 그러한 요청이 있었다고 주장하나, 다음과 같은 점에 비추어 볼 때 계좌개설점의 업무처리는 정당하다고 보기는 어려움.

① 예금통장의 경우 증거증서에 지나지 않아 민법상 무인감에 의한 지급이 가능하다 하더라도 무인감통장의 경우 제3자가 예금주를 사칭하여 인출하는 등의 금융사고 발생 가능성이 높다는 점을 감안할 때, 계좌개설점으로서 그러한 금융사고 예방을 위해 별도의 대책을 마련하여야 할 주의의무가 있다고 보여지는 점.

② 이에 따라 단위농협의 “수신업무방법서” 상에도 무인감 통장발급시 무인감 이월코드를 등록하여 사후에 거래인감 확인시까지 예금지급을 정지(제1편 제4장(제신고처리) 제2절 제5조)하도록 하고 있는 바, 계좌개설점의 경우 본건통장의 무인감 이월시 예금지

211) 대법원 1992.2.14. 선고 91다9244 판결 참조.

212) 대법원 1985.12.24. 선고 85다카880 판결 참조.

금정지를 하지 않아 동 규정의 위반이 인정되는 점.

③ 설사 본건통장의 무인감 이월이 통상의 거래관행이라거나 예금주의 묵인하에 이루어졌다고 하더라도 무인감통장 발급시 지급정지조치는 금융사고 예방 및 예금주 보호를 위하여 농협측에 부여되는 주의의무로써 동 조치를 취하지 않은 계좌개설점의 행위는 적절한 업무처리로 보기 어렵다는 점.

(3) 계좌개설점의 부당한 업무처리로 인해 예금주에 대해 배상하여야 할 금액

위에서 본 바와 같이 무인감 통장이월시 지급정지조치를 취하지 않은 계좌개설점의 업무처리는 정당하다고 보기는 어렵고 결국 이러한 부당한 업무처리와 제3자에 의한 불법인출로 인한 예금주의 손해간에 상당한 인과관계가 있다고 보여지므로 계좌개설점은 예금주가 입은 손해를 배상할 책임이 있다고 할 것임. 상기 손해의 발생과 관련하여 예금주의 과실이 있을 경우에는 동 과실은 손해배상 청구시 적절히 평가·반영되어야 할 것인 바, 신청인도 다음과 같은 점에 있어서 과실이 인정되고 동 과실비율은 50%로 산정함이 타당하다고 판단됨.

① 본건통장의 경우 무인감 이월이 되더라도 지급정지조치가 취하여지지 않은 것이 예금주의 묵인하에 예금주의 편의를 위해 관행적으로 이루어진 것으로 인정되고 예금주도 이에 대하여 그동안 아무런 이의를 제기한 사실이 없었다는 점.

② 신청인도 본건통장을 관리사무소 직원의 개인서랍에 보관하고 있었을 뿐 아니라 비밀번호를 본건계좌 개설시부터 사무실 전화번호를 사용하여 제3자가 쉽게 알 수 있게 하는 등 금융기관 이용자로서의 통장관리를 소홀히 하였던 점.

이와 같은 신청인의 금융기관 거래상의 행위로 보아 신청인의 과실을 상계함이 인정되고 동 과실비율은 50%로 산정함이 타당하다고 판단되며, 결국 계좌개설점이 신청인에게 대해 배상하여야 할 손해액은 금 94,000,000원에서 과실상계(50%)를 한 금 47,000,000원이라 할 것임.

라. 결 론

피신청인인 계좌개설점은 무인감 이월통장에 지급정지조치를 취하지 않은 과실이 인정되므로 신청인에 대하여 금 47백만원을 배상하는 한편, 예금인출점인 피신청인들에 대한 신청인의 청구는 예금지급시 농협 직원의 과실여부를 확인할 만한 증거채택이 어려워 사실관계 확정이 곤란하므로 이를 각하하고자 함.

4-11 이월발급한 통장을 제3자에게 교부하여 발생한 손해에 대한 배상책임

[일부인용] 금융기관은 진정한 예금주에게 통장을 이월발급하여야 할 주의의무가 있고, 이러한 주의의무란 예금통장의 마지막 면까지 사용되었는지 여부나 인감의 상위여부만을 식별하는데 그칠 것이 아니고 금융기관이 일반적으로 간편하게 사용할 수 있는 기기를 이용하는 등 성실한 업무처리로서 예금통장의 진위여부와 예금주의 의사에 의하지 아니한 통장의 이월로 인한 부정행위의 발생을 방지할 주의의무가 있다고 할 것임.(2006.1.10. 조정번호 제2005-98호)

가. 사실관계

신청인은 1997.8.5. 신청인 명의로 ○○협동조합 지점에서 예금계좌를 개설하였는데, 2005.10.27. 12:31경 신원미상의 제3자가 피신청인2의 지점(이하 “통장이월점”이라 함)에 와서 위조된 상기 예금계좌의 통장213)과 인감214)을 제시하며 통장의 여백부족을 사유로 이월재발급을 요청하였음.

이에 통장이월점 담당직원은 통장의 마지막 면까지 사용한 것을 확인한 후 통장을 이월재발급하여 동 제3자에게 교부하였고, “홍길동”를 사칭하는 또 다른 제3자가 같은 날 13:29경 상기 이월재발급된 통장을 이용해 피신청인1의 A지점(이하 “예금인출점”이라

213) 확인결과 신청인이 본건계좌 통장을 분실하거나 도난사실이 없고 당시 직접 소지하고 있어 동 통장은 위조된 것으로 보임.

214) 현재 위조된 통장 및 이월재발급된 통장이 없어 인감란을 확인할 수 없으나, 예금인출점의 출금청구 서상에는 고객명은 “최○○(신청인)”이나 인감은 한자로 “李◇◇印”으로 되어 있는 바, 이와 관련하여 예금인출점은 상기 제3자가 제시한 본건 예금통장의 인감과 출금전표의 인영의 일치하였다고 진술하고 있는데 반해, 통장이월점 담당직원은 이월당시 기존 통장상의 인감과 제3자가 제시한 인감이 일치한 것 같았으나 사용인감의 명의인은 누구인지 기억나지 않는다고 진술하고 있음.

함)에서 금 50백만원을 인출한 후 B지점에 개설된 동 홍길동 명의로 개설된 계좌로 송금하였으며, 동 금액은 같은 날 인터넷뱅킹을 통해 동 홍길동 명의의 ◇◇은행 및 ○○은행 계좌에 각각 금 25백만원씩 분산이체된 후 전액인출되었음.

한편, 예금인출점은 B지점으로 송금처리시 상기 제3자로부터 “홍길동” 명의의 운전면허증(수사결과 위조된 신분증)으로 신분확인을 한 바 있음.

나. 당사자의 주장

(1) 신청인 주장

신청인은 본건 예금통장을 소지하고 있었고 분실한 적도 없는데 피신청인2는 통장의 이월재발급시 위조통장을 제시한 자의 정확한 신분확인이나 전산단말기 조작을 통한 통장 뒷면의 마그네틱스트라이프테이프의 확인도 없이 통장을 이월 재발급하였고, 피신청인1은 예금주와 출금청구서상 날인된 인영의 명의인이 상이할 뿐 아니라 예금주가 아닌 제3자가 인출을 하는데도 불구하고 임의로 예금을 지급한 것은 부당하므로 피신청인1 및 피신청인2는 신청인이 입은 손해 금 50백만원을 배상하여야 함.

(2) 피신청인 주장

1) 피신청인1의 경우

본건 예금 지급시 본건통장에 날인된 인감과 지급청구서에 날인된 인감을 육안상 주의 깊게 상호비교·대조한 결과 일치한다고 판단하였고 인출자도 비밀번호를 오류 없이 한번에 입력하였는 바, 「예탁금거래기본약관」 제16조(면책)²¹⁵⁾에 따라 면책되므로 신청인의 주장을 수용할 수 없음.

215) 「예탁금거래기본약관」 제16조(면책) ① 조합은 예탁금지급청구서, 증권 또는 신고서 등에 적힌 인영(또는 서명)을 신고한 인감(또는 서명)과 육안으로 주의깊게 비교·대조하여 틀림없다고 여기고, 예탁금지급청구서 등에 적힌 비밀번호나 PIN-Pad기를 이용하여 입력된 비밀번호가 신고 또는 등록한 것과 같아서 예탁금을 지급하였거나 기타 거래처가 요구하는 업무를 처리하였을 때에는 인감이나 서명의 위조·변조 또는 도용이나 그 밖의 다른 사고로 인하여 거래처에 손해가 생겨도 그 책임을 지지 않는다. 다만, 조합이 거래처의 인감이나 서명의 위조·변조 또는 도용사실을 알았거나 알 수 있었을 때에는 그러하지 아니하다.

2) 피신청인2의 경우

본건 통장의 이월은 고객으로부터 이월요청을 받고 통장의 마지막 면까지 사용한 것을 확인하고 제시된 인감과 통장상의 인감을 대조한 후 단말기에 계좌번호 및 통장발급번호를 입력하여 재발급하는 등 내부적으로 정하여진 절차에 따라 이루어진 것으로 부당한 업무처리에 의한 사고는 아니므로 신청인의 청구를 수용할 수 없음.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 ① 예금인출점의 예금지급이 채권의 준점유자에 대한 변제로서 유효한지 여부 ② 통장이월점의 본건 통장 이월재발급 업무처리가 정당한지 여부라 할 것임.

(1) 예금인출점의 예금지급이 채권의 준점유자에 대한 변제로서 유효한지 여부

민법의 일반원칙에 의하면 금융기관은 예금주 본인·대리인·사자(使者)에게 지급하면 정당한 변제가 되어 예금채권은 지급범위내에서 소멸됨. 그러나 정당한 권리자가 아닌 경우에도 변제자가 사회일반의 거래관념상 진실한 채권을 가진 자라고 믿을 만한 외관을 구비한 자에게 선의이며 과실없이 변제한 경우에는 채권의 준점유자에 대한 변제로서 유효하다고 규정하고 있으며,²¹⁶⁾ 대법원의 경우 “예금청구서에 날인한 인영과 금융기관에 신고하여 예금통장에 찍힌 인감을 대조확인할 때에는 인감대조에 숙련된 직원으로 하여금 그 직무수행상 필요로 하는 충분한 주의를 다하여 인감을 대조하도록 할 것이고, 그러한 주의의무를 다하지 못하여 예금수령의 권한이 없는 자에게 예금을 지급하였다면 금융기관으로서는 그러한 예금지급으로서 채권의 준점유자에 대한 변제로서의 면책을 주장할 수 없다”²¹⁷⁾하는 한편, 예금지급시 대조할 인감에 대하여는 “채권의 준점유라고 하려면 채권의 사실상 귀속자와 같은 외형을 갖추어야 하므로 예금채권의 준점유자는 예금통장과 그에 찍힌 인영과 같은 인장을 소지하여야 한다”고 판시²¹⁸⁾하고 있음.

216) 민법 제470조.

217) 대법원 1992.2.14. 선고 91다9244 판결 참조.

218) 대법원 1985.12.24. 선고 85다카880 판결 참조.

따라서, 본건의 경우 예금인출점의 채권의 준점유자에 대한 변제로서 유효한지 여부를 판단함에 있어서는 예금인출점 직원이 이월재발급된 본건통장에 날인된 인감과 지급청구서에 날인된 인감을 비교·대조함에 있어서 과실이 있었는지 여부가 관건인 바, 현재 이월 재발급된 본건통장의 실물도 없고 예금의 부정인출자에 대한 경찰의 수사가 진행 중에 있는 점을 감안할 때 현재로서는 예금인출점의 과실여부를 판단하기 곤란하다 할 것임.

(2) 통장이월점의 본건 통장 이월재발급 업무처리가 정당한지 여부

예금통장의 이월발급이란 예금주의 기존 계좌정보를 그대로 유지한 채 통장의 발급번호만 변경하여 발급하는 것을 의미하는 것으로 금융기관은 진정한 예금주에게 통장을 이월발급하여야 할 주의의무가 있고, 이러한 주의의무란 예금통장의 마지막 면까지 사용되었는지 여부나 인감의 상위여부만을 식별하는데 그칠 것이 아니고 금융기관이 일반적으로 간편하게 사용할 수 있는 기기를 이용하는 등 성실한 업무처리로서 예금통장의 진위여부와 예금주의 의사에 의하지 아니한 통장의 이월로 인한 부정행위의 발생을 방지할 주의의무가 있다고 할 것임.

본건에 있어서 피신청인2는 통장의 이월재발급시 인감의 일치여부 및 통장의 소지여부 등을 확인하는 등 내부 업무절차에 따른 통상의 주의로써 업무를 처리하였다고 주장하나, 다음과 같은 점에 비추어 볼 때 통장이월점의 업무처리는 정당하다고 보기는 어렵고, 결국 이러한 부당한 업무처리와 제3자에 의한 불법인출로 인한 예금주의 손해간에 상당한 인과관계가 있다고 보여지므로 피신청인2는 예금주가 입은 손해를 배상할 책임이 있다고 할 것임.

① 예금통장의 마그네틱스트라이프테이프에는 계좌번호, 예금액, 통장의 사용행수, 통장발급번호 등 계좌의 기본정보가 내장되어 있어 금융기관 직원은 제시된 통장의 진정성 여부의 확인을 위해서는 육안으로 식별하는 것 보다는 전산단말기를 사용하는 것이 정상적인 업무처리라는 점.

② 본건에 있어서 통장이월점 직원이 제시된 통장의 마그네틱스트라이프테이프를 전산단말기로 확인하였더라면 동 통장이 위조된 것임을 쉽게 알 수 있었을 것임에도 이에

대한 확인을 하지 않은 점.

③ 통장의 재발급 절차를 규정한 은행의 「수신업무방법서」상 통장이월발급시 본인의 진정한 의사를 확인(제1편 제4장(제신고처리) 제2절 제1조)하도록 하고 있는 바, 통장이 월점의 경우 인감의 일치여부 및 통장의 소지여부 등에 대한 형식적인 확인에 그칠 뿐 본건 통장의 이월재발급과 관련한 본인의 의사를 확인하지 아니하는 등 동 규정에 따라 적절한 방법으로 업무를 처리하였다고 보기 어렵다는 점.

라. 결 론

피신청인2는 통장이월시 주의의무를 다하지 아니한 과실이 인정되므로 신청인에 대하여 금 50백만원을 배상하는 한편, 피신청인1에 대한 신청인의 청구는 예금지급시 은행 직원의 과실여부를 확인할 만한 증거채택이 어려워 사실관계 확정이 곤란하므로 이를 각하하고자 함.

4-12 은행의 전산입력 하자로 종중예금이 특정인에 의해 인출된 경우 배상책임

[일부인용] 피신청인은 본 건 예금이 사실상 종중 소유의 예금이라는 사실을 알고 있었고, 신청인이 예금주란에 종중명을 부기함과 아울러 공동회장 4인의 도장을 공동날인함으로써 특정인이 단독으로 예금을 인출하는 것을 제한하고자 하는 특별한 사정이 있음을 인지하고 있었으므로, 이러한 경우에는 일반 예금과 달리 인출에 제한이 있음을 표시하여야 할 업무상 주의의무를 진다고 할 것인데, 피신청인이 본 건 예금을 전산입력하면서 예금거래신청서상 부기된 종중명을 누락하고, 달리 인출에 제한이 있음을 나타낼 수 있는 어떠한 표시도 하지 않음으로써 특정인이 본 건 계좌를 인터넷뱅킹 출금계좌로 등록하여 인터넷뱅킹을 통해 인출하도록 방치한 과실이 있다 할 것임.(2007.3.13. 조정번호 제2007-4호)

가. 사실관계

2002.5월초 ○○종중(이하 “신청인”이라 함) 총무 A씨가 경기도 소재 피신청인의 지점에 방문하여 피신청인 직원 B씨에게 종중 명의의 예금계좌 개설에 관하여 문의하였고,

B씨는 A씨에게 종종 명의로 예금계좌를 개설하려면 금융실명거래법에 따라 임의단체임을 확인할 수 있는 서류²¹⁹⁾를 제출해야 한다고 설명하였음.

이 때 A씨가 임의단체 확인서류가 준비되지 않은 경우의 예금계좌 개설방법에 대해 재차 문의하자, B씨는 그런 경우 임의단체 명의로 아닌 종종대표 개인 명의로 계좌를 개설할 수 밖에 없으며, 공동소유자금의 경우 명의로는 대표자의 명의를 사용하고 도장은 공동소유자 각자의 도장을 모두 사용하여 계좌를 개설한 후 통장과 도장을 서로 분리하여 보관함으로써 서로간의 신뢰를 바탕으로 계좌관리를 분산시키는 방법도 있음을 안내하였음.

2002.5.11. 신청인 공동회장 C씨, D씨, E씨와 총무 A씨(이하 “C씨 외 3인”이라 함)는 함께 피신청인 지점을 방문하여, 임의단체 확인서류가 준비되지 않아 종종명의로 예금계좌 개설이 불가능하므로 A씨 개인 명의로 예금계좌를 개설하겠다는 의사를 밝혔음.

C씨 외 3인은 예금거래신청서 상의 예금주란에 “A씨”, 그 하단에 “○○종종”이라고 기재하고, 공동회장 4인의 도장 4개를 공동 날인하여 수시입출금식 예금계좌(이하 “본건 계좌”라 함)를 개설한 후, 본 건 계좌에 금 12억2,390만원을 입금하였음.

B씨는 당시 C씨 외 3인에게 개인 명의로 통장을 개설하면 향후 인터넷뱅킹을 통해 출금될 수 있음을 고지하였다고 주장하며, C씨 외 3인은 종종의 돈이므로 공동회장의 도장을 날인하지 않고는 어떠한 방법으로든 인출을 할 수 없도록 해줄 것을 요구했다고 주장함.

피신청인측은 본건 계좌를 전산상 등록함에 있어 예금거래신청서상 예금주 하단에 부기된 종종명을 제외한 “A씨”만을 예금주로 등록하였음. 2002.5.17.~2003.1.20. 기간 동안 본건 계좌에서 15회에 걸쳐 4인 공동명의 도장을 날인한 정상적인 인출(총 2억2,968만원)이 이루어진 후, A씨는 2003.3.3. 본건 계좌를 본인 명의 인터넷뱅킹 출금계좌로 등록하였고, 2003.3.7.~2006.3.22. 기간 동안 인터넷뱅킹을 통해 본건 계좌에서 총 10억6,200만원을 타행으로 이체(총 21회)한 후 도주하였음.

219) 임의단체 확인서류 : 단체정관 또는 조직과 운영에 관한 규정, 대표자임을 입증할 수 있는 서류(등록증, 회의록, 의사록 등), 조직구성원 명부.

한편, 신청인은 종중재산 회계문제와 토지 명의신탁 문제로 소송이 진행 중이어서 2003.1.25. 종중총회에서 종중의 결산 및 감사를 대법원 확정판결 이후로 연기하였고, 따라서 대법원 선고(2006.1.26.) 이후에야 A씨의 불법인출 사실을 확인할 수 있었다고 주장함.

나. 당사자 주장

(1) 신청인 주장

본 건 예금계좌 개설시 예금주에 “A씨”와 종중명을 함께 기재하고, 공동회장 4인의 도장을 공동날인하여 종중의 예금임을 명확히 하였으며, 피신청인측에 A씨가 종중의 동의 없이 임의로 출금할 수 없도록 요청하였음에도 불구하고, 피신청인은 인터넷뱅킹 출금계좌 등록을 통해 불법 예금인출을 방조하였으므로 이를 반환하여야 함.

(2) 피신청인 주장

신청인측에 임의단체 예금 개설 방법에 대하여 설명하였는데, 신청인측이 임의단체 확인 서류의 제출을 거부하여 개인 명의의 예금으로 개설되었으며, 개인명의 예금으로 개설시 인터넷뱅킹 등을 통해 출금될 수 있음을 충분히 고지하였고, 정상거래기간 이후 불법적인 거래기간이 37개월에 이르는데도 이를 장기간 방치한 것은 신청인의 중대한 과실에 해당하므로 신청인의 주장을 수용할 수 없음.

다. 위원회의 판단

◆ 본 건의 쟁점은 피신청인이 A씨에게 예금을 지급한 것이 채권의 준점유자에 대한 변제로서 유효한지 여부와 변제로서의 효력이 없는 경우 그 변제책임의 범위임.

(1) 본건 예금의 실제 예금주

금융실명제 시행이후 금융기관 예금계약의 예금주에 관하여 판례는 “금융기관으로서 특별한 사정이 없는 한 주민등록증을 통하여 실명확인을 한 예금명의자를 위 명령 제3조 제1항 소정의 거래자로 보아 그와 예금계약을 체결할 의도라고 보아야 할 것이지

만, 특별한 사정으로서 출연자와 금융기관 사이에 예금명의인이 아닌 출연자에게 예금반환채권을 귀속시키기로 하는 명시적 또는 묵시적 약정이 있는 경우에는 출연자를 예금주로 보아야 할 것”이라고 판시²²⁰⁾하고 있는 바, 다음과 같은 점에 비추어 볼 때, 신청인과 피신청인간에는 예금명의자인 A씨가 아닌 신청인에게 본 건 예금반환채권을 귀속시키기로 하는 묵시적 합의가 있었던 것으로 보여지며, 따라서 본건 예금의 실제 예금주는 신청인으로 보는 것이 타당하다 할 것임.

① 피신청인은 최초 A씨로부터 종종 명의의 예금계좌 개설에 관하여 문의를 받았고, A씨가 임의단체 확인서류가 준비되지 않을 경우에 대해 문의하자 도장을 공동날인하여 공동소유자금으로 관리하는 방법도 있음을 안내하였던 점.

② 신청인이 A씨의 임의 출금을 방지하기 위하여 예금거래신청서상 예금주란에 종종 명을 함께 부기하고, 공동회장 4인의 도장을 공동날인하였던 사정을 피신청인도 인지하고 있었던 점.

(2) 채권의 준점유자에 대한 변제의 유효 여부

본건 예금의 예금주를 신청인으로 보는 경우, A씨는 본건 예금의 예금명의인으로서 채권의 준점유자라 할 것이므로, 피신청인이 A씨에게 예금을 지급한 것이 선의이며 과실 없는 때에 한하여 채권의 준점유자에 대한 변제로서 유효하다 할 것이며, 특히 본건과 같이 전자적 지급방법에 의하여 예금을 지급한 경우 변제자의 선의·무과실에 대한 판단기준과 관련하여 판례는 “소위 폰뱅킹에 의한 자금이체신청의 경우 은행의 창구직원이 직접 손으로 처리하는 경우와 달리 그에 따른 자금이체가 기계에 의하여 순간적으로 이루어지지만, 그것이 채권의 준점유자에 대한 변제로서 은행에 요구되는 주의의무를 다하였는지 여부를 판단함에 있어서는 자금이체시의 사정만을 고려할 것이 아니라 그 이전에 행하여진 폰뱅킹의 등록을 비롯한 제반사정을 총체적으로 고려하여야 한다.”라고 판시²²¹⁾한 바 있음.

위 판례에 비추어 인터넷뱅킹을 통한 예금 인출시점 뿐 아니라 인터넷뱅킹 등록을 비

220) 대법원 2000.3.10. 선고 99다67031 판결 참조.

221) 대법원 1998.11.10. 선고 98다20059 판결 참조.

릇한 제반사정을 총체적으로 판단하여 보건대, 다음과 같은 이유로 피신청인의 예금지급이 채권의 준점유자에 대한 변제로써 유효하다고 볼 수 없다 할 것임.

피신청인은 최초 종종 명의의 예금계좌 개설에 관하여 문의를 받고, 예금계좌 개설방법에 대해 안내를 하였으므로 본건 예금이 사실상 신청인 소유의 예금이라는 사실을 알고 있었고, 신청인이 예금주란에 종종명을 부기하고, 공동회장 4인의 도장을 공동날인함으로써 A씨가 단독으로 예금을 인출하는 것을 제한하고자 하는 특별한 사정이 있음을 인지하고 있었으므로, 이러한 경우에는 일반 예금과 달리 인출에 제한이 있음을 표시하여야 할 업무상 주의의무를 진다고 할 것인데, 피신청인이 본 건 예금을 전산상 입력함에 있어, 예금거래신청서상 부기된 종종명을 누락하고, 달리 인출에 제한이 있음을 나타낼 수 있는 어떠한 표시도 하지 않음으로써 A씨가 본건 계좌를 인터넷뱅킹 출금계좌로 등록하여 인터넷뱅킹을 통해 인출하도록 방치한 과실이 있다 할 것임.

(3) 피신청인의 예금지급의무와 신청인의 손해배상책임

위와 같이 피신청인의 A씨에 대한 예금지급이 채권의 준점유자에 대한 변제로써 유효하지 못하여 피신청인은 신청인에게 금 10억6,200만원을 지급하여야 할 것인 바, 이에 대하여 피신청인은 신청인에게 그의 피용자인 위 A씨의 불법예금인출에 관하여 사용자로서의 중대한 과실이 있으므로 위 금원을 지급할 수 없다는 취지로 주장하므로 살피건대, 위 A씨의 불법예금인출에 대하여 신청인은 피신청인으로부터 임의단체 예금계좌개설 방법을 안내받았음에도 임의단체 예금이 아닌 개인 명의로 예금계좌를 개설하고, 또한 신청인의 총무로서 예금통장을 관리하던 A씨가 37개월에 이르는 기간 동안 불법인출을 하였음에도 이에 대한 지휘·감독을 제대로 하지 못한 과실이 인정되는 바, 피신청인이 위 A씨에게 한 예금지급이 유효한 변제가 되지 못하여 이중의 변제책임을 지게 됨으로써 발생한 손해는 신청인의 피용자인 A씨의 불법행위에 기한 것으로 신청인은 그의 사용자로서 그와 연대하여 피신청인에게 위 손해 중 과실비율에 따른 금원을 배상할 책임이 있다 할 것임.

결국 본건 예금의 부당인출에 대하여 위에서 본 여러 사정을 참작하여 보면, 신청인과 피신청인은 50:50의 책임을 부담함이 타당하다 할 것인 바, 피신청인은 신청인에게 금

5억3,100만원을 반환할 책임이 있다 할 것임.

라. 결 론

따라서 피신청인은 신청인에게 금 5억3,100만원을 반환하여야 할 것임.

4-13 예금인출자가 본인이 아닌 것으로 사후에 밝혀진 경우 은행의 배상책임

[인용] 인출자가 신청인의 주민등록증상의 사진과 비슷한 모습(동일한 헤어스타일)이어서 육안상 본인이 아님을 알기 어려웠던 사안이므로 은행은 과실이 없다고 주장하나, 만일 실제로 거래행위를 한 상대방이 주민등록상의 본인과 다른 사람이었음이 사후에 밝혀졌다면 특별한 사정이 없는 한 은행으로서는 본인확인 의무를 다하지 못한 과실이 있는 것으로 사실상 추정되는 바, 은행이 달리 이를 반복할 만큼 충분한 입증이 되었다고 보기 어려우므로 부당인출액 전액에 대해 반환 의무가 있다 할 것임.(2011.7.12. 조정번호 제2011-45호).

가. 사실관계

신청인은 ○○은행, △△농업협동조합에 신청인 명의의 예금을 보유하고 있는 상황에서 2003.10.9. 해외에 출국하여 2011.4.13. 귀국하였는데, 제3자(A씨, 신청인 오빠의 처)가 신청인의 해외체류기간 중 신청인을 가장하여 계좌비밀번호 변경, 통장 재발행, 현금카드 재발급 등을 거쳐 신청인 명의의 예금계좌에서 다액의 예금을 인출함.²²²⁾ 2011.5.6. 신청인은 신청인 명의 예금의 원상복구를 주장하면서 본건 금융분쟁조정을 신청함.

<○○은행 건>

신청인은 해외에 출국하기 전 ○○은행에 2개의 요구불 예금계좌(이하 ‘본건 ○○은행 계좌’라 함)를 가지고 있었고, 해외체류 중(2003.10.9~2011.4.13.)에는 동 계좌에 타행(◇◇은행) 텔레뱅킹을 통한 입금만 이루어졌고, 출금한 사실은 없음.

222) 신청인은 2011.4.22. 위 A씨를 경찰에 고소하여 ◇◇경찰서에서 수사결과 A씨를 기소의견(사기, 사문서위조, 위조사문서행사, 공문서위조, 위조공문서행사 혐의 인정)으로 ◇◇지검에 송치함.

신청인 명의의 ○○은행 요구불예금 계좌

구분	계좌번호	신규일	해지일	잔액(원)	
				2003.10.9. 기준	2010.10.11. 인출전
1	123-456-789023	1999.04.20.	-	50	121,771,141
2	123-123-123456	2003.09.22.	2010.10.11.	99,945,296	117,749,768
합 계				99,945,346	239,520,909

2010.10.11. A씨는 ○○은행에 신청인의 주민등록증을 제시하고, 신청인 명의로 “제신고 및 재발행신청서”를 작성하였는데, 1번 계좌에 대해서는 통장 및 인감 분실신고, 비밀번호변경신고(중전 비밀번호 미제시), 통장재발행을 하고, 2번 계좌에 대해서는 통장 및 인감 분실신고 후 비밀번호만 변경하고, 통장 재발행 없이 당일 계좌를 해지하여 117,837,655원(이자포함)을 인출한 후 이중 117백만원을 재원으로 신청인 명의로 아래와 같이 2개의 정기예금을 개설함(837,655원은 현금인출).

신청인 명의의 ○○은행 정기예금 계좌

구분	계좌번호	신규일	해지일	잔액	비고
3	234-***-123456	2010.10.11.	-	30,000,000	월복리정기예금
4	234-***-123789	2010.10.11.	-	87,000,000	○○정기예금
합계				117,000,000	

A씨는 4번 계좌에 대하여 2011.3.4. 45백만원을 중도해지(이자포함 45,150,204원 인출)하였고, 2011.4.4. 20백만원을 중도해지함(이자포함 20,081,130원 인출)하였으며, 1번 계좌에 대하여는 신청인의 해외체류 기간(2003.10.9.~2011.4.13.) 동안 총 51회에 걸쳐 총 121,787,546원을 인출하였음. 신청인은 귀국 다음날인 2011.4.14. 본인 계좌의 불법인출을 인지하고 ○○은행에 계좌 지급정지를 신청함.

신청인 명의의 ○○은행 계좌 잔액 (2011.4.13. 귀국일 기준)

구분	계좌번호	신규일	해지일	잔액(원)	비고
1	123-456-789023	1999.04.20.	-	169,519	요구불예금
3	234-***-123456	2010.10.11.	-	30,000,000	월복리정기예금
4	234-***-123789	2010.10.11.	-	22,000,000	○○정기예금
합계				52,169,519	

<○○농업협동조합 건>

2002.6.14. 신청인은 △△농업협동조합(이하 “△△농협”이라 함) 지점에서 신청인명의의 자립예탁금통장(이하 “본건 농협계좌”라 함)을 개설하고 현금카드를 발급받음.

2004.5.28. A씨는 □□농업협동조합(이하 “□□농협”이라 함) 지점을 방문하여 위조된 신청인의 여권(A씨 사진으로 위조)을 제시하고, “제신고서”를 작성하여 신청인 명의의 위 계좌 비밀번호(종전 비밀번호 미제시)를 변경하였고, 현금카드 분실을 사유로 “현금 즉발카드신청서”를 작성하여 신청인 명의로 현금카드를 재발급 받았으며,²²³⁾ 이렇게 재발급된 현금카드로 2004.5.28.~2007.3.15. 기간중 총 20,475,800원을 인출함(동 기간중 신청인 명의의 현금카드를 통해 위 계좌에 560만원이 입금).²²⁴⁾

2007.12.16. A씨는 △△농협 지점을 방문하여 신청인 명의의 위조여권(사진 위조)을 제시하여 “제신고서”를 작성하고, 통장 및 인감 분실신고, 비밀번호변경(종전 비밀번호 미제시) 신청을 하여 통장을 재발행 받았으며, 재발급 받은 예금통장으로 2007.12.18.~2008.4.2. 기간중 총 1,282,600원을 인출함. 이후 본건 계좌는 매월 전화료만 5,660원씩 자동출금되다가 2008.6.25. 이후에는 잔고가 “0”인 상태로 존속함.

나. 당사자 주장

(1) 신청인 주장

신청인이 해외에 출국하면서 A씨에게 본건 예금과 관련하여 위임장을 주거나 예금관리를 허락한 사실이 없고 은행 및 농협에도 아무런 부탁도 하지 않았는데, 은행 및 농협에서 본인확인을 소홀히 하여 제신고를 받아주어 A씨가 본건 예금을 무단히 인출하게 되었으므로 피신청들은 신청인의 모든 예금액에 대해 원상복구를 해주어야 함.

신청인은 해외에 출국하면서 주민등록증 등을 본인의 방에 남의 눈에 띄지 않는 곳에 감춰놓았으므로 신청인은 신분증 관리 등에 아무런 잘못이 없음.

223) 회원농협 수신업무방법서에는 “사고 기타의 신고는 모든 사무소에서 처리할 수 있다”고 되어 있어 회원농협 간에 제신고업무 대리수행이 가능함.

224) 카드 및 통장을 통한 순인출액 : 16,158,400원(카드 순인출액 14,875,800원 + 통장인출액 1,282,600원)

(2) 피신청인들 주장

1) ○○은행의 주장

본건은 제3자가 타인의 신분증을 도용하여 본인임을 사칭한 사기 등 범죄행위로 발생한 것으로 은행의 주의의무만을 내세워 은행에게 책임을 묻는 것은 부당함.

당행 「예금거래기본약관」 제18조(면책) 제3항에 따르면 “은행이 주민등록증 등 실명확인증표로 주의 깊게 실명확인하거나 실명전환한 계좌는 거래처가 실명확인증표 또는 서류의 위조·변조·도용 등을 한 경우, 이로 인하여 거래처에 손해가 생겨도 은행은 책임을 지지 않는다.”라고 규정하고 있는 바, 본건은 담당직원이 “행정안전부 주민등록증 음성확인시스템”(ARS 1382)을 통해 주민등록증의 진위여부를 확인하였고, 신분증의 사진과 실물의 일치여부를 육안으로 확인하였는데도, A씨가 신청인의 주민등록증상의 사진과 비슷한 모습(동일한 헤어스타일)이어서 본인이 아님을 알기 어려웠던 사안으로 은행은 주의의무를 다한 것이므로 책임이 없으며, 본건은 신청인이 주민등록증의 관리를 소홀히 하여 발생한 것이므로 신청인의 주장은 수용할 수 없음.

2) 농협의 주장

본건은 제신고서 접수시 A씨가 위조된 신청인의 여권(A씨의 사진으로 위조)을 제시하였던 것으로, 여권상의 사진과 실물이 일치하여 본인이라고 생각할 수밖에 없어 농협의 과실이 없으므로 민법 제470조(채권의 준점유자에 대한 변제)의 규정에 따라 면책되어야 함.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 본건 예금인출이 채권의 준점유자에 대한 변제로서 유효하다고 할 수 있는지 여부라 할 것임.

(1) 관련 법령 및 판례

1) 민법 제470조(채권의 준점유자에 대한 변제) 채권의 준점유자에 대한 변제는 변

제자가 선의이며 과실 없는 때에 한하여 효력이 있다.

2) 관련 판례

이른바 폰뱅킹(phone-banking; tele-banking)에 의한 자금이체신청의 경우에는 은행의 창구직원이 직접 손으로 처리하는 경우와는 달리 그에 따른 자금이체가 기계에 의하여 순간적으로 이루어지지만, 그것이 채권의 준점유자에 대한 변제로서 은행에 대하여 요구되는 주의의무를 다하였는지 여부를 판단함에 있어서는, 자금이체시의 사정만을 고려할 것이 아니라 그 이전에 행하여진 폰뱅킹의 등록을 비롯한 제반 사정을 총체적으로 고려하여야 함. 한편, 은행이 거래상대방의 본인 여부를 확인할 필요가 있는 경우에 담당직원으로 하여금 그 상대방이 거래명의인의 주민등록증을 소지하고 있는지 여부를 확인하는 것만으로는 부족하고 그 직무수행상 필요로 하는 충분한 주의를 다하여 주민등록증의 진정 여부 등을 확인함과 아울러 그에 부착된 사진과 실물을 대조하여야 할 것인바, 만일 실제로 거래행위를 한 상대방이 주민등록상의 본인과 다른 사람이었음이 사후에 밝혀졌다고 한다면, 특별한 사정이 없는 한, 은행으로서는 위와 같은 본인확인 의무를 다하지 못한 과실이 있는 것으로 사실상 추정됨.²²⁵⁾

(2) 채권의 준점유자에 대한 변제로서 유효한지 여부

본건 예금지급은 제3자가 신청인을 가장하여 신청인 명의의 계좌에 대한 제신고를 통해 비밀번호변경, 통장재발급, 현금카드 재발급 등을 거쳐 예금해지 또는 CD기를 통한 예금인출이 이루어졌는바, 위 판례에 비추어 예금해지 또는 CD 기를 통한 예금 인출시점 뿐만 아니라 제 신고서 접수를 비롯한 제반사정을 총체적으로 고려하여 채권의 준점유자에 대한 변제로서 유효성 여부를 판단함.

1) ○○은행의 경우

본건의 경우, 다음과 같은 점에 비추어 볼 때 신한은행의 예금지급이 채권의 준점유자에 대한 변제로서 유효하다고 볼 수 없다 할 것임.

① ○○은행은 “행정안전부 주민등록증 음성확인시스템”을 통해 제시된 주민등록증이

225) 대법원 1998.11.10. 선고 98다20059 판결 참조.

진정한 것임을 확인하였으므로 본인확인절차상의 주의의무를 다하였다고 주장하나, 주민등록증 진위확인시스템의 경우 단순히 주민등록증의 위조여부 등 진위여부만을 확인(주민등록번호와 발급일자 일치여부 확인)해 주는 것으로 제시된 주민등록증이 제3자에 의해 도용되고 있는지 여부까지 확인해주는 것은 아니므로 이것만으로 본인확인 의무를 다하였다고 볼 수 없는 점.

② ○○은행은 담당직원이 육안상으로 확인했으나 A씨가 신청인의 주민등록증상의 사진과 비슷한 모습(동일한 헤어스타일)이어서 본인이 아님을 알기 어려웠던 사안이므로 은행은 과실이 없다고 주장하나, 법원에서는 본인확인 의무와 관련하여 “만일 실제로 거래행위를 한 상대방이 주민등록상의 본인과 다른 사람이었음이 사후에 밝혀졌다고 한다면, 특별한 사정이 없는 한 은행으로서는 위와 같은 본인확인 의무를 다하지 못한 과실이 있는 것으로 사실상 추정된다.”고 판시하고 있는 바, 본건에 있어 A씨가 주민등록증상의 본인과 다른 사람이었음이 밝혀졌으므로 ○○은행의 본인확인상의 과실은 추정되고, ○○은행이 과실 없음을 입증하여야 하는데, 본건에서 과실추정을 번복할 만큼 충분한 입증이 되었다고 보기 어려운 점.

③ 본건에 있어서 신청인은 해외에 거주하면서 텔레뱅킹을 통한 이체거래만 하고 있었는데, 갑자기 지점을 방문하여서 모든 계좌에 대해 통장 및 인감 분실신고, 비밀번호 변경, 통장재발행 등의 행위를 하고, 비밀번호 변경시에는 종전의 비밀번호도 제시하지 못하였으므로 좀 더 주의를 기울여 본인확인을 하였어야 함에도, 단순히 외관상 헤어스타일이 유사하다는 등의 사유로 본인 여부를 식별하지 못하였다면 이를 두고 본인확인 의무를 다하였다고 보기 어려운 점.

④ ○○은행은 신청인이 주민등록증 관리를 소홀히 하여 본건이 발생하였으므로 신청인도 책임이 있다고 주장하나, 신청인은 이를 부인하고 있고 달리 증거도 없어 신청인이 주민등록증 관리에 있어 잘못이 있다고 보기도 어려운 점.

⑤ ○○은행은 본건이 A씨가 사기 등 범죄행위로 이루어진 것인데 은행의 책임만 묻는 것은 부당하다고 주장하나, ○○은행이 사기 등 행위자인 A씨에게 본건 관련 손해에 대해 배상청구를 할 수 있는 것은 별론으로 하고, 그렇다고 ○○은행의 본인확인 소홀에

따른 신청인에 대한 책임이 면제되는 것은 아닌 점.

2) 농협의 경우

본건의 경우, 다음과 같은 점에 비추어 볼 때 농협의 예금지급이 채권의 준점유자에 대한 변제로서 유효하다고 볼 수 없다 할 것임.

① 농협의 수신업무방법서에는 “인감과 통장을 모두 분실하고 비밀번호도 모르는 등 본인여부가 극히 의심스러운 경우 및 행동이 부자연스러운 경우 등은 실명확인증표의 위변조 여부를 다시 확인하고 연대보증인을 입보시키거나 예금거래신청서의 필적과 대조하는 등 대비책을 강구하여야 한다.”고 규정하고 있는 바, 농협은 본건과 관련하여 A씨가 신청인 명의의 통장을 재발급 받는 과정에서 종전의 비밀번호도 제시하지 못하고 통장, 인감을 모두 분실하였다고 하는 등 심히 의심스러운 경우인데도 예금거래신청서를 통하여 필적대조, 주소, 전화번호 확인 등의 추가적인 확인조치를 하지 아니한 점.

② A씨는 본건 신청인의 여권위조와 관련하여 신청인의 사진을 떼어내고 자신의 사진을 붙였다고 하는 바, 본인 확인시 여권사진 상의 태극문양 등 위조방지 문양의 일치 여부 등을 면밀히 살펴 위조여부를 확인하였어야 하는 점.

③ 법원에서는 본인확인 의무와 관련하여 제3자의 신분증 도용 및 위조된 사안에서 ‘만일 실제로 거래행위를 한 상대방이 주민등록상의 본인과 다른 사람이었음이 사후에 밝혀졌다고 한다면, 특별한 사정이 없는 한 은행으로서는 위와 같은 본인확인 의무를 다하지 못한 과실이 있는 것으로 사실상 추정된다.’고 판시하고 있는 바, 본건에 있어 A씨가 여권상의 본인과 다른 사람이 밝혀졌으므로 농협의 본인확인상의 과실은 추정되고, 농협이 과실 없음을 입증하여야 하는데, 본건에서 과실추정을 번복할 만큼 충분한 입증이 되었다고 보기 어려운 점.

라. 결 론

그렇다면 본건과 관련하여 피신청인들의 A씨에 대한 예금지급(카드인출 포함)은 모두 채권의 준점유자에 대한 변제로서 유효하다고 할 수 없으므로 모두 원상복구 하여야 할 의무가 있다고 할 것임.

4-14 정당한 권리자 아닌 자에 대한 정기에금 지급의 책임 여부

[인용] 피신청인은 甲이 본건 정기에금을 인출할 권한이 있는지 여부를 신청인 또는 신청인 대표 乙을 통해 확인해야 할 주의의무가 있음에도 이를 확인하지도 않고 甲에게 정기에금을 인출하여 주었으므로 피신청인은 甲이 위 정기에금을 인출할 권한이 있다고 믿은 데에 과실이 있다고 할 것인 바, 甲이 신청인 대표 乙의 위임 범위를 초과하여 본건 정기에금을 해지한 것에 대한 표현대리(「민법」 제126조)는 성립하지 않는다고 볼 것이며, 결국 피신청인의 예금주 아닌 甲에 대한 본건 정기에금의 지급은 정기에금 인출 권한 없는 자에 대한 변제로서 유효하지 않다고 판단한 사례(2015.9.8. 조정번호 제2015-18호)

가. 사실관계

1997. 12.7. B중고 재학생 및 졸업생에게 장학금 지급 등을 목적으로 설립한 재단법인 B중고재경동문회장학회(이하 ‘신청인’이라고 함)는 출연금 360,000,000원을 2000.2.18. ~ 2009.9.9. 기간 중 피신청인의 정기에금(주로 1년 만기)에 예치하여 출연재산을 운용하였음.

신청인 명의 정기에금, 보통예금 계좌내역

순번	계좌번호	상품명	거래기간	취급점
1	976615-10-00***	파워특별우대이자지급식	‘00.2.18. ~ ‘01.2.19.	B지점
2	528115-10-31***	리콜이자지급식	‘01.2.19. ~ ‘04.7.28.	A지점
3	035815-20-38***	K수퍼고정금리형(월이자지급식)	‘04.7.28. ~ ‘07.8.28.	A지점
4	035815-20-85***	K수퍼고정금리형(만기일시지급식)	‘07.8.28. ~ ‘08.9.3.	A지점
5	035801-04-03****	보통예금	‘08.2.15. ~ 현재	A지점
6	035815-21-06***	K수퍼고정금리형(만기일시지급식)	‘08.9.3. ~ ‘09.9.9.	A지점
7	035815-21-27***	K수퍼고정금리형(만기일시지급식)	‘09.9.9. ~ ‘10.5.19.	A지점

① 2008.2.15. 신청인은 피신청인 A지점 지점에서 신청인 명의로 출연금 이자를 관리하기 위해 보통예금 계좌(#035801-04-03****)를 개설하였음.

신규거래신청서 및 통장에는 신청인 명의 인장이 날인되어 있으며 신청인 이사장(이하 ‘대표’라고 함) 乙의 주민등록증 사본이 첨부되어 있음.

② 2009.9.9. 신청인은 2008.9.3. 가입한 K수퍼고정금리형 정기예금(#035815-21-06***) 만기가 도래하자 피신청인 A지점 지점에서 신청인 명의로 K수퍼정기예금(계약기간 1년, 연이율 4.0%, 이하 ‘본건 정기예금’이라고 함) 계좌(#035815-21-27***)를 개설한 후 신청인 소유 출연 장학기금 360,000,000원을 재예치하였음.

신규거래신청서 및 통장에는 신청인의 임원 3인(乙, 유○○, 윤○○, 이하 ‘乙 등’이라고 함)의 인장이 공동으로 날인되어 있으며, 대표 乙의 주민등록증 사본이 신규거래신청서에 첨부되어 있음.

③ 2010.5월 중순경(일자미상) 신청인의 사무국장으로 재직중이던 甲은 본건 정기예금을 해지하여 동 자금을 개인적으로 사용하기 위해 乙 등을 차례로 찾아가 “2009.9.9. 가입한 정기예금 이자를 찾기 위함이다”라고 하면서 출금전표에 인장을 각각 날인받음.

④ 2010.5.19. 甲은 피신청인 A지점 지점에 내방하여 본건 정기예금 중도해지한 후 정기예금 전액 (362,137,519원)을 보통예금(#035801-04-03****)계좌로 대체처리하기 위해 제신고서²²⁶⁾를 작성(12:10경)하여 상기 보통예금 계좌의 비밀번호와 인감을 변경하고 통장을 재발행 받고 현금카드를 신규 발급하였음.

상기 제신고서에는 신청인 대표 乙과 甲의 주민등록증 사본 및 신청인의 고유번호증 사본이 첨부되어 있으며, 乙의 주민등록증 사본과 신청인 고유번호증 사본이 3등분으로 접혀 있었음.

같은 날 12:19경 甲은 乙 등의 인장이 날인된 출금(해지)전표를 이용하여 신청인 명의 본건 정기예금(#035815-21-27***)을 중도해지한 후 원금 및 이자를 포함한 362,137,519원 전액을 2008.2.15. 개설된 신청인 명의 보통예금 계좌(#035801-04-03****)로 대체입금하였음.

2009.9.9. 작성된 정기예금 가입신청서의 필체와 상기 출금(해지)전표상의 필체는 상이하고, 다만 비밀번호는 오류 없이 일치함.²²⁷⁾

⑤ 2010.5.19. ~ 2011.7.15. 기간 중 甲은 47여 차례에 걸쳐 신청인 명의 보통예금 계

226) 통장, 비밀번호 및 인감을 변경하기 위한 신고서

227) 제신고 및 본건 정기예금 해지시 신청인의 위임장은 없었음

좌(#035801-04-03****)에서 甲 명의의 계좌로 361,964,200원을 이체한 후 개인적으로 사용하였음.

⑥ 2014.9월 △△교육청의 신청인에 대한 감사로 甲의 횡령사실이 밝혀지자, 신청인은 甲을 △△경찰청 △△경찰서에 고발함.

⑦ 2015.5.22. △△지방법원은 甲에 대하여 사문서위조 및 위조사문서행사²²⁸⁾ 등을 유죄로 인정하여 징역 3년 6월 선고하였고, 甲은 △△지방법원이 인정한 사문서위조 및 위조사문서 행사 사실에 대해서는 모두 인정하면서 양형부당을 이유로 항소하여 현재 항소심 진행중임.

나. 당사자 주장

(1) 신청인 주장

2010. 5. 19. 피신청인의 직원은 대리권 없는 자인 甲에게 정기예금을 중도해지하여 주었으므로 정기예금 362,137,519원 전액을 신청인에게 반환해야 함.

(2) 피신청인 주장

2010. 5. 19. 신청인 대표 乙이 직접 내방하여 정기예금을 중도해지 하는 등 정상적으로 업무처리가 이루어졌으므로 책임이 없으며²²⁹⁾, 설령 변제의무가 있다하더라도 신청인이 소속 직원 관리를 소홀히 하는 등 피해 확대에 과실이 있으므로 원상회복시 이를 반영하여야 할 것임.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 정기예금 중도해지 및 그 지급이 채권의 준점유자에 대한 변제로서 유효한지 여부와 그 책임범위라고 할 것임.

228) 甲이 乙 등을 기망하여 출금전표에 인장을 날인받고 동 출금전표를 이용하여 정기예금을 중도해지한 사실을 인정

229) 피신청인의 당시 업무처리 직원들은 정상적인 업무처리절차에 따라 본건 정기예금 해지업무를 처리했다고 주장

(1) 2010.5.19. 신청인 대표 乙의 내방여부

甲의 사문서위조 등에 대하여 △△지방법원은 甲이 乙 등을 찾아가 ‘재경동문회 장학금 정기예금 이자를 찾기 위해서 필요하다’고 거짓말하여 乙 등으로부터 출금전표에 인장을 날인받은 후 피신청인 A지점 지점에 내방하여 본건 정기예금을 해지한 사실을 인정하였음.

형사사건의 판결에서 인정된 사실은 특별한 사정이 없는 한 민사재판에서 유력한 증거자료가 되나, 민사재판에서 제출된 다른 증거 내용에 비추어 형사판결의 사실판단을 그대로 채용하기 어렵다고 인정될 경우에는 이를 배척할 수도 있다 할 것임(2010.5.27. 선고 2009다12603 판결 등).

살피건대, 甲은 검찰 및 법원에서 본인이 피신청인 A지점 지점에 내방하여 본건 정기예금을 중도해지하였다고 일관되게 진술하고 있고, 항소이유도 1심에서 인정한 사실관계를 다투는 것이 아닌 단지 양형이 부당함을 주장하고 있으며, 2009.9.9. 작성된 본건 정기예금 가입신청서상의 필체와 2010.5.19. 작성된 중도해지 전표상의 필체가 상이하고, 2010.5.19. 甲이 통장비밀번호 변경 및 통장 재발행 등을 위해 작성한 제신고서 서류상에 신청인 대표 乙과 甲의 주민등록증 사본 및 신청인 고유번호증 사본이 첨부되어 있으며, 甲의 주민등록증 사본과는 달리 乙 주민등록증 사본과 신청인 고유번호증 사본은 접혀져 있는 바, 甲의 주민등록증 사본이 첨부되어 있는 이유와 乙 주민등록증 및 고유번호증 사본이 접혀져 있는 이유에 대하여 당시 피신청인의 제신고 및 정기예금 중도해지 업무처리 직원 안민수는 “기억은 없지만, 같이 보관되어 있다면 재단법인에 대한 은행업무 특성상 乙과 甲이 같이 내점하였을 것이다. 기억은 없지만 본인확인 후 재복사의 필요성이 없어 그대로 사용한 것 같다”라고 진술하고, 현금카드발급 업무처리 직원 도○○은 “甲, 乙을 기억하지 못한다. 오래돼서 정확히 기억은 나지 않지만, 본인확인 절차는 성실히 수행했다”고 진술하는 등 그 진술내용이 모두 불분명한 바, 위와같이 확인된 사실에 의할 때 △△지방법원(형사판결)에서 인정한 사실판단을 배척할 만한 특별한 사유는 없다고 볼 것이며, 신청인 대표 乙이 아닌 甲이 내방하여 본건 정기예금을 중도해지한 것으로 봄이 사회통념에 비추어 타당하다 할 것임.

(2) 채권의 준점유자에 대한 변제의 유효여부

채권의 준점유자에 대한 변제는 변제자가 선의이며 과실 없는 때에 한하여 효력이 있으며(「민법」 제470조), 채권의 준점유자라 함은 변제자의 입장에서 볼 때 일반의 거래 관념상 채권을 행사할 정당한 권한을 가진 것으로 믿을 만한 외관을 가지는 사람을 말하고 채권자의 대리인도 채권의 준점유자에 해당함(2004.4.23. 선고 2004다5389 판결 등).

신청인 대표 乙은 甲에게 본건 정기예금 이자를 수령할 권한은 위임하였으나 정기예금 이자 수령 권한을 위임받은 자가 가지는 대리권에 당연히 정기예금을 해지할 수 있는 대리권이 포함되어 있지는 아니하므로 甲이 본건 정기예금 해지권한이 있는 신청인의 대리인으로 볼 수는 없다 할 것임.

한편, 은행은 예금이 인출될 경우에는 반드시 예금주 또는 대리인으로부터 예금통장, 신고인감, 대리권을 증명할 수 있는 서류 등을 제출받아 예금주 본인 여부와 인출의사 여부를 확인한 후 예금을 지급하여야 할 업무상 주의의무가 있으며, 은행이 예금청구자에게 예금 수령의 권한이 있는지 없는지를 판별하는 방법의 하나로 예금청구서에 찍은 인영과 은행에 신고하여 예금통장에 찍힌 인감을 대조 확인할 때에는 인감 대조에 숙련된 은행원으로 하여금 그 직무수행상 필요로 하는 충분한 주의를 다하여 인감을 대조하도록 하여야 할 것이고, 그러한 주의의무를 다하지 못하여 예금 수령의 권한이 없는 자에게 예금을 지급하였다면 은행으로서 그 예금지급으로서 채권의 준점유자에 대한 변제로서의 면책을 주장할 수는 없음(2013.1.24. 선고 2012다91224 판결 등).

아울러, 정기예금은 그 만기일이 정하여져 있고 보통예금보다 이율이 고이율로 예금자는 만기일까지 예금을 보유하는 것이 일반적이므로 정기예금 중도해지의 경우에는 만기 후 인출의 경우보다 더 높은 수준의 본인확인 의무 등 주의의무가 부여되어 있다 할 것이므로 정기예금 중도해지의 경우에는 예금을 인출하려는 자로부터 중도해지 하여 예금을 인출하는 특별한 사유 등을 청취하여 이를 판단하여야 할 것임.

살피건대, 甲이 정기예금 출금(해지) 전표와 신청인 대표 乙의 주민등록증 사본을 소지하고 있으며, 신규거래신청서에 찍힌 乙 등의 인장과 출금(해지)전표상의 인장을 대조하고 비밀번호가 일치하여 피신청인이 甲에게 본건 정기예금을 지급하였다 하더라도 ①

甲이 비밀번호 분실, 인감 및 통장분실 등을 이유로 신청한 보통예금 계좌(#035801-04-03****) 제신고시 위임장을 소지하지도 않았음에도 대리인 여부에 대한 아무런 의심없이 정상적으로 처리해 준 점 ②신청인은 앞서 살펴본 바와 같이 2000.2.18. 이후 피신청인의 정기예금에 가입하여 중도해지한 후 출금 사실이 없으며, 만기 도래시에는 다시 유사한 상품의 정기예금에 재가입한 점 ③중도해지 금액이 362,137,519원으로 고액이며, 甲이 직접 乙 등의 인장을 직접 가지고 오지 않고 乙 등의 인장이 이미 날인된 출금전표를 이용하는 것은 일반적인 금융거래 관행으로는 보이지 아니하는 점 ④본건 정기예금 신규거래신청서상의 필체와 출금(해지)전표상의 필체가 서로 상이하며, 고이율이 보장되는 정기예금을 중도에 해지하여 보통예금으로 이체하는 것은 상당히 이례적인 점 ⑤2001.2.19. ~ 2009.9.9. 기간 중 신청인은 피신청인 A지점 지점에서 4회에 걸쳐 정기예금을 가입하였고 2004.7.28. 이후 가입한 K수퍼고정금리 정기예금(#035815-20-38****) 등 계좌개설 서류상에는 본건 정기예금 해지와는 달리 신청인 대표 乙의 주민등록증 사본만이 첨부되어 있어 甲이 아닌 乙이 직접 거래한 것으로 보이는 점과 ⑥신청인이 피신청인 A지점 지점에서 K수퍼고정금리 정기예금(#035815-20-38****) 등과 보통예금(#035801-04-03****) 계좌개설 이외에 빈번하게 거래하지 않았던 점 등을 종합적으로 고려하면 피신청인의 입장에서 甲이 진실한 예금채권자라고 믿을 만한 외관을 갖추었다고 볼 수는 없을 것임.

그렇다면, 피신청인은 甲이 본건 정기예금을 인출할 권한이 있는지 여부를 신청인 또는 신청인 대표 乙을 통해 확인해야 할 주의의무가 있음에도 이를 확인하지도 않고 甲에게 정기예금을 인출하여 주었다고 할 것인 바, 피신청인은 甲이 위 정기예금을 인출할 권한이 있다고 믿은 데에 과실이 있다고 보아야 할 것임.

따라서, 甲이 신청인 대표 乙의 위임 범위를 초과하여 본건 정기예금을 해지한 것에 대한 표현대리(「민법」 제126조)는 성립하지 않는다고 볼 것이며, 결국 피신청인의 예금주 아닌 甲에 대한 본건 정기예금의 지급은 정기예금 인출 권한 없는 자에 대한 변제로서 유효하지 않다고 보아야 할 것임.

(3) 과실상계 등 인정 여부

채무불이행 또는 불법행위에 있어서 채권자 또는 피해자에게도 손해의 발생이나 확대에 관하여 과실이 있는 경우에 이를 참작하여 책임을 부정하거나 배상액을 감경할 수 있음(「민법」 제396조, 제763조).

과실상계는 채무불이행 내지 불법행위로 인한 손해배상책임에 대하여 인정되는 것이고, 채무 내용에 따른 본래의 급부의 이행을 구하는 경우에 적용하지 않음이 확립된 원칙이며(2000.4.7. 선고 99다537452 판결 등), 계약이 해제되어 소급적으로 효력을 잃은 결과 계약당사자에게 당해 계약에 기한 급부가 없었던 것과 동일한 재산상태를 회복시키기 위한 원상회복의무의 이행으로서 급부의 반환을 구하는 경우에는 적용되지 아니하며, 계약의 해제로 인한 원상회복청구권에 대하여 해제자가 그 해제의 원인이 된 채무불이행에 관하여 원인의 일부를 제공하였다는 등의 사유를 내세워 신의칙 또는 공평의 원칙에 기하여 일반적으로 손해배상에 있어서의 과실상계에 준하여 그 권리의 내용이 제한될 수 있다고 하는 것은 허용되어서는 아니됨(2014.3.13. 선고 2013다34143 판결 등).

살피건대, 피신청인은 甲에 대한 본건 정기예금 중도해지 및 예금지급에 대한 면책을 주장할 수 없으므로 피신청인은 신청인에게 정기예금 계약에 따른 금액 전부를 지급할 의무가 있다고 할 것이며 이는 채무 내용에 따른 원상회복을 구하는 것으로 보아야 할 것임.

따라서, 신청인이 장학회 자금 관리를 적절히 관리하지 못하여 피해금액이 일부 확대되었다 하더라도 이를 이유로 피신청인의 지급해야 할 금액을 감액할 수는 없다고 할 것임.

다만, 신청인의 피해금액은 본건 정기예금 중도해지금액 362,137,519원 중 甲이 횡령하여 개인적으로 사용한 361,964,200원으로 보아야 할 것이므로 피신청인의 반환 금액은 361,964,200원으로 봄이 상당함.

따라서, 피신청인은 361,964,200원을 신청인에게 지급해야 할 것임.

라. 결 론

그렇다면, 피신청인은 신청인에게 정기예금을 일부 반환할 책임이 있다 할 것이므로 신청인의 청구는 이유 있어 이를 인용함.

4-15 정당한 권리자가 아닌 자에 대한 예금지급의 효력 여부

[일부인용] 본인이 무권대리행위가 있었음을 알고 바로 자기에게 효력이 없다고 이의를 제기하지 아니하고, 이를 장기간에 걸쳐 방치하였다고 하여 무권대리행위를 추인하였다고 볼 수 없는 바(대법원 1998.2.10.선고 97다31113판결 등), 신청인에게 예금인출 문자가 통지된 이후 신청인이 피신청인에게 장기간(1년 6개월) 이의를 제기하지 않았다는 점만으로 무권대리행위에 대한 묵시적 추인으로 볼 수는 없다고 판단한 사례(2016.4.27. 조정번호 제 2016-9호).

가. 사실관계

2014. 4. 2. (주)B토건 대표이사 乙(이하 ‘신청인’이라고 함)은 I은행(이하 ‘피신청인’이라고 함) 모지점에서 피신청인과 여신거래 약정(계정과목 : 할인어음, 한도 : 3억원)을 체결²³⁰⁾하고 보통예금계좌를 개설하여 보통예금통장을 교부받음.

신청인은 어음할인대금 91,487,154원을 위 보통예금계좌에 입금하였고, 이 중 58,307,300원은 직원 급여명목으로, 2,950,000원은 대체출금하여 (주)H교역에 송금하였음.

2014.4.3. 신청인은 피신청인의 △△지점에서 21,000,000원을 대체출금하였고, 4.10. 피신청인의 □□지점에서 2,122,420원을 대체출금 하였음.²³¹⁾

2014. 4. 30. (주)B토건 직원 甲은 피신청인 모지점에 내방하여 전자어음 할인 및 인터넷뱅킹 일일이체 한도변경(1억원→2억원)을 요청하였음.

피신청인 모지점 직원 丙은 위 甲으로부터 전자어음 할인요청을 받고 15:10경 신청인 대표이사 乙에게 전화하여 전자어음 배서양도 후 할인이 가능한 점과 인터넷뱅킹 일일이체 한도를 변경²³²⁾할 것을 안내하였고, 이에 신청인이 직접 인터넷뱅킹에 접속하여 전자어음에 배서함으로써 피신청인에게 양도하였음.

230) 2014.4.2. 여신거래 약정 이전에는 신청인과 피신청인간 일체의 거래관계가 없었음

231) 상기 일자 거래는 통장을 지참하여 출금(유통거래)하였고 통장과 출금전표상의 인감이 일치함

232) 일일이체 한도변경은 등록계좌의 인터넷뱅킹 출금한도 범위를 정하는 것임

피신청인 모지점 직원 丙은 16:33경 어음할인 금액 192,517,048원을 신청인 명의 보통예금계좌에 입금처리하였음.

한편, 甲은 (주B토건 실경영자로 추정²³³⁾되는 丁으로부터 직원급여 및 장비대금 지급 지시를 받고 급하다고 하면서 출금을 요청함.

16:41경 피신청인 모지점 직원 丙은 위 甲이 보통예금계좌의 통장을 소지하고 있지 않았음에도 甲이 작성한 출금전표에 찍힌 인감과 은행거래서에 날인된 인감(컴퓨터 모니터상 화면)을 비교·확인한 후 甲이 Pin-Pad기에 직접 입력한 비밀번호가 일치하자 174,906,000원을 출금 처리²³⁴⁾하였음.

甲은 174,906,000원을 3건으로 나누어 송금하면서, 이중 120,000,000원을 丁에게 송금하였고, 丁은 96,503,000원을 D산업개발 경리담당자인 신○○ 개인 계좌로 송금하는 등 5명에게 총 110,606,200원을 송금하였음.

신○○은 丁으로부터 받은 96,500,000원을 D산업개발에게 다시 송금하였음.

한편, 丁이 신○○에게 송금한 96,500,000원의 자금명목에 대하여 신청인은 D산업개발에 대여한 대여금이라고 주장하는 반면, D산업개발은 토석채취도급공사 관련 선급금을 신청인으로부터 변제받은 것이라고 주장.²³⁵⁾

丁 송금내역

일자	수취인	금 액(원)
2014.4.30.	신○○	96,503,000
	서○○	5,000,800
	이○○	5,000,800
2014.5.1.	C종합	3,000,800
	최○○	1,100,800
합계		110,606,200

233) 2013.12.10. D산업개발과 체결한 토석채취도급공사계약서에 실경영자로 기재

234) 출금 사실 내용은 신청인 乙에게 문자로 통지

235) D산업개발의 거래처원장에는 2014.4.30. 96,500,000원 선급금 일부 회수로 기재되어 있으며, 2016.2.24. D산업개발 대표이사 김○○은 동 자금이 선급금으로 신청인으로부터 받았다는 내용의 확인서를 작성

나. 당사자 주장

(1) 신청인 주장

피신청인 직원이 대리권이 없는 甲에게 예금을 지급하였으므로 인출금 174,906,000원 중 직원 급여명목으로 지급한 54,906,000원을 제외한 120,000,000원 및 이자 37,528,000원 등 157,528,000원을 신청인에게 반환해야 함.

(2) 피신청인 주장

은행거래상 신고된 인감과 전표에 찍힌 인영이 육안으로 쉽게 구분되지 않고 비밀번호가 일치하여 甲에게 예금을 지급하는 등 업무처리상의 주의를 다하였고, 신청인이 일부 자금에 대해 이의를 제기하지 않는 등 甲에게 출금권한이 없다고 볼 수 없으며, 설령 변제 의무가 있더라도 실제 신청인의 이익으로 귀속된 금원이 있다면 이를 공제해야 할 것임.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 ① 피신청인의 예금지급이 준점유자에 대한 변제로 유효한지, ② 무권대리 행위에 대한 추인으로 볼 수 있는지, ③ 피신청인의 예금지급분 중 일부를 신청인의 이익으로 보아 피해금액에서 공제할 수 있는지 여부라 할 것임.

(1) 채권의 준점유자에 대한 변제의 유효여부

채권의 준점유자에 대한 변제는 변제자가 선의이며 과실 없는 때에 한하여 효력이 있으며(「민법」 제470조), 채권의 준점유자라 함은 변제자의 입장에서 볼 때 일반의 거래 관념상 채권을 행사할 정당한 권한을 가진 것으로 믿을 만한 외관을 가지는 사람을 말하고 채권자의 대리인도 채권의 준점유자에 해당함(대법원 2004.4.23. 선고 2004다5389 판결 등).

은행은 예금이 인출될 경우에는 반드시 예금주 또는 대리인으로부터 예금통장, 신고인

감, 대리권을 증명할 수 있는 서류 등을 제출받아 예금주 본인 여부와 인출의사 여부를 확인한 후 예금을 지급하여야 할 업무상 주의의무가 있으며, 은행은 예금청구서에 날인된 인장과 통장에 날인된 인장이 동일하고, 비밀번호가 같다고 인정될 경우에만 예금을 지급해야 하므로 금융실명제가 시행된 이후에는 특별한 사정이 인정되지 않는 한 예금 명의자도 아니고 예금통장도 소지하지 않은 자는 예금채권을 준점유하는 자에 해당된다고 할 수 없음.

신청인은 직원 甲에게 이건 전자어음의 할인에 대한 권한을 위임한 것으로 전자어음의 할인 권한을 위임받은 자가 가지는 대리권에 예금을 인출할 수 있는 대리권까지 포함되어 있다고 할 수 없으므로 甲이 이건 예금인출 권한이 있는 신청인의 대리인으로 볼 수는 없다 할 것임.

피신청인의 내부 ‘예금규정’ 제16조(지급)에 의하면 예금을 지급할 때에는 통장·증서와 청구서를 받는다고 정하고 있으며, ‘업무처리방법서’에도 ① 예금주로부터 통장 및 전표를 받고 ② 정당한 인감을 제시하고 ③ 비밀번호가 일치하는 경우 예금을 지급하고 세가지를 모두 갖추고 있는 경우 표현대리가 성립하며, 원거리 고객인 경우 등에 해당하는 경우 예금주에게 확인하는 등의 추가적인 절차가 반드시 필요하다고 정하고 있음.

2014.4.2. 여신거래 약정과 보통예금계좌 개설 및 2014.4.30. 예금인출을 담당했던 직원(丙)이 동일하고, 여신거래 약정 당시 내방했던 신청인이 아닌 甲이 통장을 소지하지 아니한 채 예금출금을 요청하였음에도 대리인 여부에 대한 확인 절차를 이행하지 아니하고 정상적으로 처리해 준 점, 은행 입·출금 거래관행상 입금과 출금거래가 동시에 이루어진다고 볼 수도 없으므로 신청인에게 인터넷뱅킹 일일이체 한도변경 및 전자어음 배서양도에 대해 확인하였다는 사실만으로 甲의 출금권한 유무에 대하여 확인한 것으로 볼 수 없는 점, 은행거래서에 작성된 (주)B토건 주소지가 경남 **시 **면으로 되어 있는 등 신청인이 원거리 고객으로 피신청인 내부 규정에 따라 신청인에게 확인하는 등의 추가 절차가 반드시 필요하였음에도 이를 이행하지 아니한 점, (주)B토건은 2014.4.2. 피신청인과의 여신거래 약정 및 보통예금계좌 개설 이전 피신청인과 거래관계가 없었으며, 계좌개설 이후 2014.4.30. 이건 예금을 인출할 때까지 피신청인 모지점에서 거래한 사실도 없는 점 등을 종합적으로 고려하면 피신청인의 입장에서 甲이 진실한 예금채권자라고

믿을 만한 외관을 갖추었다고 볼 수는 없을 것임.

그렇다면, 피신청인은 甲이 본건 예금을 인출할 권한이 있는지 여부를 신청인을 통해 확인해야 할 주의의무가 있음에도 이를 확인하지 않고 甲에게 예금을 인출하여 주었다고 할 것인 바, 피신청인은 甲이 위 보통예금을 인출할 권한이 있다고 믿은 데에 대한 과실이 있다고 보아야 할 것임.

따라서, 甲이 신청인의 위임 범위를 초과하여 이건 보통예금을 인출한 사실에 대하여는 표현대리(「민법」 제125조, 제126조)가 성립하지 않는다고 볼 것인 바, 피신청인이 예금주가 아닌 甲에 대하여 이건 보통예금을 지급한 것은 예금인출 권한이 없는 자에 대한 변제로서 유효하지 않다고 보아야 할 것임.

(2) 무권대리 추인 인정 여부

무권대리행위 일부에 대한 추인은 상대방의 동의가 없는 한 원칙적으로 무효이며, 무권대리행위에 대한 추인은 묵시적으로도 가능하나 이를 인정하기 위해서는 무권대리행위의 결과가 본인에게 귀속된다는 것을 알고 승인한 것으로 볼 만한 사정이 있어야 함(대법원 2013.4.26. 선고 2012다99617 판결 등).

신청인이 甲이 인출한 자금 중 54,906,000원에 대하여 이의를 제기하지 않았다고 하여 甲의 무권대리행위 전부에 대하여 추인한 것으로 볼 수 없는 점.

아울러, 본인이 무권대리행위가 있었음을 알고 바로 자기에게 효력이 없다고 이의를 제기하지 아니하고, 이를 장기간에 걸쳐 방치하였다고 하여 무권대리행위를 추인하였다고 볼 수 없으므로(대법원 1998.2.10. 선고 97다31113판결 등), 2014.4.30. 신청인에게 예금인출 문자가 통지된 이후 신청인이 피신청인에게 장기간(1년 6개월) 이의를 제기하지 않았다는 점만으로 무권대리행위에 대한 묵시적 추인으로 볼 수는 없다 할 것임.

(3) 신청인의 피해금액

변제받을 권한 없는 자에 대한 변제는 채권자가 이익을 받은 한도에서는 효력이 있으며(「민법」 제472조), 채권자가 이익을 받은 것이라 함은 변제의 수령자가 진정한 채권자에게 채무자의 변제로 받은 급부를 전달한 경우와 권한 없는 자의 변제수령을 채권자

가 사후에 추인하는 등 권한없는 자의 변제수령이 채권자의 이익으로 인정되는 경우를 의미함(2012.10.25. 선고 2010다32214 판결 등).

丁이 D산업개발 경리담당자 신○○에게 송금한 96,500,000원이 D산업개발 명의계좌에 실제 입금된 점, 동 자금에 대하여 D산업개발의 거래처원장에는 선급금 회수로 기재되어 있고, D산업개발 대표이사 김○○은 96,500,000원을 丁으로부터 선급금으로 변제받았다고 일관되게 주장하는 점 등을 비추어 볼 때 신청인이 동 금액상당에 대한 채무면제의 이익을 얻었다고 볼 수 있으므로 신청인의 이익으로 귀속되었다고 봄이 상당할 것임.

한편, 피신청인은 丁이 최○○, 서○○, 이○○, C종합에게 송금한 14,103,200원 역시 급여 및 거래처 거래비용이라고 주장하나 보통예금 거래내역 및 신청인이 제출한 급여대장에 2014.4.4. 2,500,000원, 5.10. 2,740,000원을 최○○의 급여로 지급한 사실이 있어 2014.5.1. 丁이 최○○에게 송금한 1,100,800원을 급여로 보기는 어려운 점, 서○○, 이○○은 (주)B토건 직원명부에 등재되어 있지 않으며, C종합 역시 (주)B토건 장비임대현황 명부에 없는 점을 고려할 때 위 14,103,200원은 丁이 개인적으로 사용한 금원으로 보여지는 바, 신청인의 이익으로 귀속된다고 볼 수 없다 할 것임.

따라서, 피신청인이 甲에게 지급한 174,906,000원 중 신청인이 직원급여 명목으로 지급되었다고 인정하는 54,906,000원과 D산업개발로 지급된 96,500,000원(선급금 명목)은 신청인의 이익으로 귀속된 것이므로 이를 공제한 23,500,000원을 지급할 책임이 있다고 할 것임.

라. 결 론

그렇다면, 피신청인은 신청인에게 보통예금 일부에 대하여 반환할 책임이 있다 할 것이므로 신청인의 청구는 이유 있어 이를 일부 인용함.

제4절 예금 지급정지, 상계 및 착오송금

4-16 유치원 명의 예금의 지급정지 가능 여부

[가각] 신청인은 유치원 운영자금을 관리하기 위한 ○○○(◇◇유치원) 명의 예금에 대하여 피신청인이 ○○○의 개인 보증채무와 상계하기 위하여 지급정지한 것은 부당하다며 구제를 요청하는 바, 유치원은 재단의 실체가 없으므로 예금주가 될 수 없으며 사립학교(유치원)를 운영하는 경영자가 사립학교 운영을 위하여 별도로 관리하는 예금에 대하여도 압류가 가능하므로 피신청인의 지급정지 조치가 부당하다고 볼 수 없음.(1999.12.7. 조정번호 제1999-61호)

가. 사실관계

1988.6.24. 신청인 A씨는 ○○교육청의 인가를 받아 ◇◇유치원을 설립한 후 1991.6.10. 서울특별시로부터 유치원 건물을 불하받아 소유권을 취득하였으며, 1993.9.17. 유치원은 피신청인의 지점에서 보통예금²³⁶⁾(이하 “본건 예금”이라 함) 계좌를 개설함.

1993.4.2.~1994.4.11. 기간중 A씨는 피신청인의 B기업 앞 여신에 대하여 연대보증하였고, B기업은 1994.6.30. 부도발생함.

신청인은 B기업 부도발생후 피신청인의 지점을 방문하여 예금주를 “A씨(◇◇유치원)”에서 “◇◇유치원”으로 변경하여 줄 것을 제안하였으나 피신청인의 직원이 그대로 사용하여도 아무런 문제가 없다고 답변하여 변경하지 아니하였다고 주장하며, 피신청인은 당시 담당자(지점장: 퇴직, 대리: 사망)가 없는 관계로 사실을 확인할 수 없으나 ◇◇유치원은 사업자등록을 하지 아니하여 ◇◇유치원 명의로 예금계좌를 개설할 수 없었다고 주장함.

1996.7.30. ◇◇유치원은 세무서에 사업자 등록을 신청하여 사업자등록증을 교부받아 ◇◇유치원 명의로 예금계좌 개설이 가능해졌으며, 1999.9.9. 피신청인은 본건 예금에 대하여 지급정지등록을 함.

236) 예금주는 A씨(◇◇유치원)이며, A씨 개인으로 실명 확인함.

나. 당사자의 주장

(1) 신청인의 주장

본건 예금계좌는 ◇◇유치원의 운영자금을 관리하기 위한 계좌로서 1999.9.9. 현재 잔액은 1999년 3/4분기 교육비와 2학기분 재료비, 급식비가 입금된 것임에도 피신청인이 B기업 앞 여신과 관련한 A씨 개인의 보증채무를 청구하여 본건 예금을 지급정지한 것은 부당함.

(2) 피신청인의 주장

본건 예금은 A씨 개인의 실명확인을 거쳐 개설된 A씨의 예금이며 본건 예금이 유치원생의 수업료, 기타 납부금 등 유치원 운영과 관련하여 별도 계좌로 관리되는 예금이라 할지라도 압류를 금지하는 규정이 없으므로 압류 및 상계가 가능함.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 본건 예금의 실제예금주가 A씨 개인인지 또는 유치원인지 여부와 본건 예금이 압류금지채권에 해당되는지 여부 및 본건 예금과 A씨 보증채무를 상계할 수 있는지 여부임.

(1) 본건 예금의 실제 예금주

신청인은 본건 예금계좌가 유치원의 운영자금을 별도로 관리하기 위하여 개설한 계좌이므로 본건 예금이 ◇◇유치원 소유의 예금이라고 주장하나, 다음과 같은 점에 비추어 볼 때 본건 예금의 실제 예금주는 A씨 개인으로 보아야 할 것임.

① ◇◇유치원은 이사회가 구성되어 있지 아니하는 등 재단의 실체를 인정할 수 없어 A씨와 독립하여 독자적으로 존재하거나 활동을 할 수 없는 점.²³⁷⁾

② 피신청인이 본건 예금계좌개설을 위한 실명확인시 A씨 개인으로 한 점.

237) 대법원에서는 유치원은 설립자에 의하여 설립, 유지, 운영되고 있는 유치원시설의 명칭에 불과하고 그 자체로서 설립자와 독립하여 독자적인 존재와 활동을 할 수 있는 “법인아닌 재단” 이라고 볼 수 없다고 판시(1965.8.31, 선고 65다693 판결)한 바 있음.

(2) 본건 예금이 압류금지채권에 해당되는지 여부

학교법인은 수업료 기타 납부금(입학금, 학교운영지원비 또는 기성회비)은 별도계좌로 관리하여야 하며(「사립학교법」 제29조 제2항), 별도 계좌로 관리되는 수입에 대한 예금채권은 압류하지 못한다(동법 제28조 제3항)라고 규정하고 있어 학교법인이 별도계좌로 관리하는 수업료 기타 납부금은 압류금지채권에 해당됨. 그러나, 사립학교 경영자의 경우 학교법인과 마찬가지로 수업료 기타 납부금은 별도 계좌로 관리(동법 제51조 및 제29조 제2항)하여야 하나 사립학교경영자가 별도 관리하는 계좌에 대하여는 압류금지 규정이 없어²³⁸⁾ 압류금지채권에 해당되지 아니하는 것으로 판단됨.

(3) 본건 예금과 A씨의 보증채무를 상계할 수 있는지 여부

채무자가 그 채권자에 대하여 같은 종류의 채권을 보유하고 있는 경우에 쌍방의 채권이 변제기에 도달되어 있는 때에는 그 채권과 채무를 상계할 수 있는 바(「민법」 제492조), 다음과 같은 점에 비추어 볼 때 상계적상에 해당되어 본건 예금과 A씨의 보증채무를 상계할 수 있는 것으로 판단됨.

① 피신청인은 A씨에 대하여 연대보증채권을 보유하고 있고, A씨는 본건 예금의 예금주로 피신청인에 대하여 예금반환채권을 보유하고 있는 점.

② 피신청인이 A씨에 대하여 보유하고 있는 연대보증채권은 주채무자인 B기업이 1994.6.30. 부도처리되어 변제기에 도달되어 있는 점.

③ 본건 예금의 예금주는 A씨 개인이며, 예금의 성격은 언제든지 반환을 요구할 수 있는 보통예금채권이므로 변제기에 도달되어 있으며, 본건 예금이 압류금지채권에 해당되지 아니하는 점.

라. 결 론

위에서 살펴본 바와 같이 본건 예금의 예금주는 A씨이며 압류금지채권에 해당되지도 아니하고 피신청인의 A씨에 대한 연대보증채권과 본건 예금이 모두 변제기에 도달되어

238) 학교법인이 수업료 등을 관리하기 위하여 개설한 계좌는 사립학교법 제28조 제3항에 의거 압류금지 대상에 해당되나 사립학교 경영자에게는 동 조항이 적용되지 아니함.

있어 상계가 가능한 상태이므로 피신청인이 상계를 주장하며 본건 예금을 지급정지한 것을 부당한 업무처리라고 볼 수 없음.

4-17 예금주 결정 및 상계처리 적정 여부

[기각] 대법원은 특별한 사정으로서 출연자와 금융기관 사이에 예금명의인이 아닌 출연자에게 예금반환채권을 귀속시키기로 하는 명시 또는 묵시의 약정이 있는 경우에는 출연자를 예금주로 보아야 한다고 판시하고 있는 바, 예금명의자 아닌 자에게 예금채권을 귀속시키기로 하는 묵시적 약정이 있는지 여부는 은행이 예금계약 체결 당시 출연자와 명의자가 다르다는 사정을 알았다고 하는 것만으로는 부족하고, 당해 예금계약의 개설경위, 당해 예금상품의 특성, 출연금원의 성격, 은행측의 권유과정, 예금계약의 성립장소 및 기타 종합적인 사정을 고려하여 판단하여야 할 것임.(2004.7.13. 조정번호 제2004-36호)

가. 사실관계

A노회(이하 “신청인”이라 함)는 목사와 장로 등 440여명으로 구성된 자선목적단체로서, 대표자와 회칙의 정함이 있고 납세번호가 부여된 임의단체이며, 신청외 B씨는 1999.4.29.부터 2001.3월말경까지 A노회의 회계담당자로서 입출금업무를 담당하던 자임.

1999.4.29.~2000.8.22. 기간중 당시 신청인의 회계담당자 B씨는 피신청인 지점에서 신청인의 전 회계담당자인 C씨로부터 받은 자금으로 ○○신탁 4구좌 82백만원 및 정기예금 3구좌 73백만원 합계 155백만원의 예금을 개설함. 동 예금개설시 B씨는 예금주란에 “A노회(B씨)” 또는 “B씨(A노회)”로 기재하고, 거래인감으로 “A노회 회계의인”을 날인하였으며, B씨의 주민등록증으로 실명확인을 하였음. 직전 회계담당자인 C씨도 예금가입시 예금주란에 “C씨(A노회)” 또는 “A노회(C씨)”로 기재한 후, 거래인감으로 “A노회 회계의인”을 날인하였으며, C씨의 주민등록증으로 실명확인을 하였음²³⁹⁾

239) 은행업무처리상 납세번호 있는 임의단체가 대리인을 통해 계좌개설할 때에는 납세번호증 원본, 대표자의 실명확인증표, 위임관계를 알 수 있는 서류 등을 제출케 하여 실명확인하는 반면, 개인예금의 경우 실명확인증표로서 원칙적으로 주민등록증만을 요구하고 있음.

한편 피신청인 지점은 B씨가 예금을 개설한 1999.4.29.부터 2003.4.30.까지 수회에 걸쳐 위 예금 및 신용을 담보로 B씨에게 대출 및 대환대출을 하였는데, 가계대출거래약정서 또는 근질권설정계약서의 차주 및 담보제공자는 “B씨”로 기재되어 있으며, 서명 옆에 “A노회 회계의인”을 날인하거나, “A노회 회계의인” 및 “B씨” 인장을 함께 날인함.

피신청인은 B씨에 대한 대출취급시 B씨가 담보제공한 예금을 B씨의 개인예금으로 간주하여 A노회에 담보제공 의사를 확인한 사실이 없으며, 2003.9.1. 및 2003.12.10. B씨의 연체대출금과 담보제공된 예금을 상계처리 하였음(상계예금액: 185,611,862원).

나. 당사자의 주장

(1) 신청인 주장

A노회의 회계담당 장로 B씨가 예금개설시 법인의 실명확인증표를 제출하지 못하자 은행직원이 예금주 A노회 옆에 B씨 이름을 부기하고 B씨의 실명확인증표로 실명확인을 하자고 하여 예금주란에 B씨 이름을 부기한 것이며, 은행은 B씨에게 개인대출 취급시 A노회의 담보제공 동의를 받은 사실이 없는데도 B씨의 연체대출금과 A노회의 예금을 상계처리한 것은 부당함.

(2) 피신청인 주장

예금개설시 B씨는 본건 예금이 특정단체의 예금이라고 말한 적이 없고 본인의 주민등록증으로 실명확인을 하였으며 예금주에 A노회 명칭을 부기한 것은 본인자금을 구분 관리할 목적으로 본인요청에 따른 것에 불과하고, 이후 수차례 예금 연장시에도 B씨는 본인 주민등록증을 제출하여 실명확인을 하는 등 단독으로 모든 업무처리를 한 것으로 볼 때 본건 관련 예금주는 B씨 개인이라고 판단되므로 신청인의 주장은 수용이 불가함.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 본건 예금주가 누구인지 여부 즉 신청인과 피신청인 사이에 예금반환채권을 예금명의자인 신청외 B씨가 아닌 신청인 A노회에게 귀속시키기로 하는 명시 또는 묵시적 약정이 있었다고 볼 수 있는지의 여부라 할 것임.

(1) 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 시행 이후 예금계약상의 예금주

「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 시행 이후 예금계약상의 예금주 결정에 대하여 동법 제3조 제1항은 “금융기관은 거래자의 실지명의로 하여야 거래를 하여야 한다”고 규정하고 있고 위 규정의 해석상 금융기관은 특별한 사정이 없는 한 원칙적으로 주민등록증을 통하여 실명확인을 한 예금명의자와 예금계약을 체결할 의도가 있다고 보아야 할 것이며,²⁴⁰⁾ 그러나 특별한 사정으로서 출연자와 금융기관 사이에 예금명의인이 아닌 출연자에게 예금반환채권을 귀속시키기로 하는 명시 또는 묵시의 약정이 있는 경우에는 출연자를 예금주로 보아야 할 것임.²⁴¹⁾

(2) 신청인을 본건 예금계약상의 예금주로 볼 수 있는지 여부

예금명의자 아닌 자에게 예금채권을 귀속시키기로 하는 묵시적 약정이 있는지 여부는 은행이 예금계약 체결 당시 출연자와 명의자가 다르다는 사정을 알았다고 하는 것만으로는 부족하고, 당해 예금계약의 개설경위, 당해 예금상품의 특성, 출연금원의 성격, 은행측의 권유과정, 예금계약의 성립장소 및 기타 종합적인 사정을 고려하여 판단하여야 할 것임.

본건의 경우 아래와 같은 사정을 종합할 때, 피신청인과 신청인 사이에 본건 예금채권 귀속에 관한 묵시적약정이 있었다고 볼 만한 사정이 존재하지 아니하여 가사 피신청인이 출연자와 명의자가 다르다는 사정을 알았다고 하더라도 본건 예금의 예금주는 예금명의자인 사건의 B씨라고 할 것임.

① 조사결과 피신청인 지점은 신청인측의 회계담당자와 본건의 2차례 거래를 하였는바, 2차례 모두 개인명의로 예금계좌를 개설하고, 실명확인 역시 회계담당자의 주민등록증으로 한 점.

② 본건 금전신탁신청인 단체의 규약이 본건 예금계약시 피신청인에게 제출되거나 납세번호 등이 현출된 사실이 없는 점.

③ 신청인의 회계담당자인 B씨는 당해 자금의 성격을 은행직원에게 고지한 바 없을

240) 금융분쟁조정위원회 조정번호 제2001-9호 참조.

241) 대법원 1998.11.13. 선고 97다53359 판결 참조.

뿐만 아니라, 본건 예금가입 장소 및 경위 역시 은행의 영업점 내에서 신청인 회계담당자의 자발적인 의사로 이루어진 점.

④ 은행이 출연자와 명의자가 다르다는 사정을 알았다고 하더라도 은행 스스로 예금채권의 실질 귀속주체를 밝혀서까지 업무를 수행하여야 할 주의의무가 있다고 볼 수 없는 점.

라. 결 론

그렇다면 본건 예금계좌의 개설경위와 당시의 정황 및 입금된 금원의 성격 등에 비추어 본건 예금계약상의 예금주를 신청인으로 볼 만한 특별한 사정이 존재한다고 볼 수 없어 피신청인이 본건 예금에 대하여 사건외 B씨의 대출금과 상계처리를 한 것은 정당한 것으로 판단됨.

4-18 압류결정 송달일 이후 입금된 예금채권의 압류대상 해당 여부

[기각] 장래의 채권 또는 미확정채권이라 하더라도 적어도 그 기초가 되는 법률관계가 압류 당시 존재하여 채권의 발생근거나 제3채무자를 특정할 수 있고, 또 가까운 장래에 발생할 가능성이 상당한 정도로 확실하다면 압류대상이 될 수 있다는 것이 판례의 입장인 바, 압류 결정 송달일 이후 입금되어 발생한 예금채권도 압류의 대상에 포함된다고 판단됨.(2007.10.9. 조정번호 제2007-69호)

가. 사실관계

신청인은 2007.7.25. 모바일뱅킹²⁴²⁾을 이용하여 본인의 A은행 계좌에서 B은행(이하 “피신청인”이라 함) 지점에 개설된 신청 외 C씨의 계좌에 180만원을 이체하였으며, 그

242) 이용자는 A은행으로부터 발급 받은 모바일칩을 휴대폰에 장착하여 각종 조회, 이체 등의 금융서비스 및 부가서비스를 제공 받음. 단, 모바일뱅킹 거래시 본인확인을 위해 정당한 PIN·계좌비밀번호, 보안매체 비밀번호 등을 입력하여야 함.

다음 날 A은행은 신청인이 계좌이체를 잘못하였다며 이의를 제기함에 따라 피신청인에게 동 금액의 반환을 의뢰함. 그러나 피신청인은 법원의 결정문²⁴³⁾에 의거하여 이미 2006.7.24. 신청 외 C씨의 계좌를 압류 등록하였다며 그 반환에 응하지 않음.

나. 당사자 주장

(1) 신청인 주장

본인의 휴대폰에 등록되어 있던 신청 외 C씨의 계좌에 실수로 계좌이체 하였으나, 수취인이 그 반환에 동의하였는 바, 동 금액을 돌려주어야 할 것임.

(2) 피신청인 주장

신청인은 이미 2006.3.9. 96만원, 2006.5.2. 184만원을 신청 외 C씨의 계좌에 이체한 적이 있어 거래관계가 없다는 주장은 설득력이 없으며, 압류명령서가 장래에 입금될 예금채권에 대하여까지 발부되었다며 압류권자인 ○○카드사가 동 금액의 반환에 동의할 수 없음을 통보하였는 바, 피신청인이 임의로 동 금액을 반환할 수 없음.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 타인의 계좌로 이체된 금원을 반환받을 수 있는지 여부라 할 것임.

다음에 비추어 볼 때, 신청인은 피신청인에게 이체된 금원을 반환받을 수 없다고 판단됨.

① 판례에 따르면 과오 송금한 송금의뢰인이 은행을 상대로 한 부당이득 반환 청구는 인정하지 아니하였고, 송금수취인을 상대로 부당이득금 반환 청구 소송을 제기하여야 한다고 판시하고 있는 점.²⁴⁴⁾

② 또한 「A은행 모바일 서비스 이용약관」 제10조 및 「A은행 전자금융거래 기본약관」

243) 채권압류 및 추심명령서, 채권자: ○○카드사, 피압류채권의 범위: 채무자가 각 제3채무자에 대하여 가지는 다음 예금 채권 중 현재 및 장래에 입금될 예금채권.

244) 전주지방법원 2005.9.1. 선고 2005나1585 판결 참조.

제15조, 제16조는 계좌이체의 경우에는 수취인의 계좌원장에 입금기록을 마친 때에 지급의 효력이 생기며, 이후에는 거래지시의 철회를 할 수 없다고 하고 있는 점.

③ 본 사안의 경우 압류명령을 결정한 법원이 대상 피압류 채권에 “장래의 채권”을 포함시켰으므로 다음의 판례에 의하여 압류 결정 송달일 이후 입금되어 발생한 예금채권도 압류의 대상에 포함된다고 판단되는 점.²⁴⁵⁾

라. 결 론

그렇다면 피신청인이 오류 송금액을 반환할 책임이 없다 할 것이므로 신청인의 청구는 이유 없어 기각함.

4-19 금융기관이 착오송금임을 알면서도 추심권을 행사한 경우의 반환 의무

[일부인용] 원칙적으로 수취은행의 상계권을 인정하면서도, 송금의뢰인과 수취인이 착오송금을 인정하고 있는 경우에는 수취은행의 상계권 행사를 신의칙 위반 내지 권리남용으로 보아 송금의뢰인을 보호하는 예외를 인정하고 있는 바, ○○카드가 착오송금임을 알면서도 본건 계좌에 대한 추심권을 행사한 것은 정당한 권리행사라고 받아들이기 어렵고, 신의칙에 반한다고 해석할 여지가 다분하며, 본건의 경우 압류채권자가 ○○카드 뿐이고 다른 이해관계자가 없어 추심금 배당이나 반환에 따른 복잡한 법률관계를 야기하지 않을 것으로 보이므로 ○○카드는 동 금원을 신청인에게 반환할 의무가 있음.(2010.9.14. 조정번호 제2010-76호)

245) 법원은 “예외적으로 장래의 채권 또는 미확정채권이라 하더라도 적어도 그 기초가 되는 법률관계가 압류 당시 존재하여 채권의 발생근거나 제3채무자를 특정할 수 있고, 또 가까운 장래에 발생할 가능성이 상당한 정도로 확실하다면 압류의 대상이 될 수 있다. ~ 중략 ~ 예금채권은 그 채권 채무 발생의 기초적인 법률관계가 형성되어 있고, 또한 제3채무자가 특정되어 있는 채권이며, 또한 특정된 계좌에 수시로 입출금이 이루어지는 경우가 많아 장래에 발생할 가능성이 상당한 정도로 확실하므로 현재 특정 계좌의 장래에 입금될 예금 채권도 압류 대상이 되는 채권으로 봄이 상당하다”라고 판시하고 있고(대법원 2001.9.25. 선고 2001다48583 판결), 또한 “장래의 예금채권이 가압류 또는 압류의 대상이 되었는지 여부는 원칙적으로 가압류(압류)명령에 기재된 가압류(압류)할 채권의 표시에 장래의 예금 채권도 포함되었다고 볼 수 있는지 여부에 따라 결정될 것이다”라고 판시하고 있음(부산고등법원 2003.6.27. 선고 2003나1755 판결).

가. 사실관계

2008.7.29. ○○카드사는 신청인에 대한 카드채권을 피보전권리로 하여 신청인의 ◇◇은행 계좌(이하 “본건 계좌”라고 함)에 대해 지방법원으로부터 압류 및 추심명령(압류금액: 6,680,591원)을 받았으며, 2008.8.7. 위 압류 및 추심명령에 따라 신청인의 본건 계좌에서 1차로 2,359,265원을 추심함.

한편, 2010.6.7. 신청외 A씨는 B씨의 ◇◇은행 계좌에 차량매매대금 750만원을 입금하려다가 실수로 신청인의 본건 계좌로 750만원을 착오송금하였으며, 2010.6.8.과 6.11. 송금의뢰인과 수취인은 ○○카드사에 착오송금임을 인정하고 그 반환을 요청함.

2010.6.25. ○○카드사는 신청인의 본건 계좌에서 2차로 6,679,091원을 추심하였고, 간은 해 7.15. 압류금액 6,680,591원을 초과하여 추심한 2,357,765원(압류금액 - 1, 2차 추심금 합계)을 신청인의 본건 계좌로 환급함.

신청인은 2010.6.25.에는 ◇◇은행을 상대로, 2010.7.20.에는 ○○카드사를 상대로 착오송금액의 반환을 구하는 민원을 제기함.

◆ 분쟁금액 : 4,321,326원 = 2차 추심금(6,679,091원) - 신한카드 환급금(2,357,765원)
* 착오송금액 중 신청인의 본건계좌에 남은 금액(3,178,674원)은 당사자간 합의로 송금의뢰인에게 반환하기로 하였으므로 분쟁금액에서 제외함.

나. 당사자 주장

(1) 신청인 주장

본건 계좌에 대한 압류 및 추심명령이 있다 하더라도 우연히 입금된 착오송금액에 대해서까지 추심권을 행사하여 채권을 회수해 가거나 그 반환을 거부하는 것은 금융시장에서 공공적 역할을 하는 금융기관으로서 권리남용에 해당하고 공평의 원칙에도 반하므로 피신청인들은 이를 송금의뢰인에게 반환하여야 함.

(2) 피신청인 주장

1) ◇◇은행

본건은 ○○카드사에서 압류 및 추심명령에 근거하여 추심권을 행사한 것으로 은행에서 관여할 수 있는 사안이 아님.

2) ○○카드사

법원 판례에 의하면, 착오송금으로 인한 자금이체의 경우 수취인이 예금채권을 취득하고, 송금의뢰인은 수취인을 상대로 부당이득반환청구권을 가지는 것에 그치며, 송금의뢰인이 수취인의 채권자가 행한 예금채권에 대한 강제집행의 불허를 구할 수 없는 것이 원칙이므로,²⁴⁶⁾ 피신청인이 법원의 압류 및 추심명령에 따라 수취한 금원을 반환할 법적 인 의무가 없음. 최근 대법원 판결²⁴⁷⁾ 또한 자금이체시스템 운영자인 수취은행의 상계처리를 신의칙 위반 내지 권리남용이라고 하고 있을 뿐이므로, 피신청인과 같이 자금이체시스템의 운영자가 아닌 제3자의 추심행위까지 신의칙 위반 등을 확대적용해서는 안 됨.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 착오송금에 대한 금융기관의 반환거부 및 채권추심행위의 적정성 여부라 할 것임.

(1) 관련 판례

1) 대법원 2010.5.27. 선고 2007다66088 이전 판결

계좌이체는 은행 간 및 은행점포 간의 송금절차를 통하여 저렴한 비용으로 안전하고 신속하게 자금을 이동시키는 수단이고, 다수인 사이에 다액의 자금이동을 원활하게 처리하기 위하여, 그 중개 역할을 하는 은행이 각 자금이동의 원인인 법률관계의 존부, 내용 등에 관여함이 없이 이를 수행하는 체제로 되어 있음. 따라서 현금으로 계좌송금 또는 계좌이체가 된 경우에는 예금원장에 입금의 기록이 된 때에 예금이 된다고 예금거래기

246) 대법원 2006.3.24. 선고 2005다59673 판결, 2009.12.10. 선고 2009다69746 판결 참조.

247) 대법원 2010.5.27. 선고 2007다66088 판결 참조.

본약관에 정하여져 있을 뿐이고, 수취인과 은행 사이의 예금계약의 성립 여부를 송금의 퇴인과 수취인 사이에 계좌이체의 원인인 법률관계가 존재하는지 여부에 의하여 좌우되도록 한다고 별도로 약정하였다는 등의 특별한 사정이 없는 경우에는, 송금의 퇴인이 수취인의 예금구좌에 계좌이체를 한 때에는, 송금의 퇴인과 수취인 사이에 계좌이체의 원인인 법률관계가 존재하는지 여부에 관계없이 수취인과 수취은행 사이에는 계좌이체금액 상당의 예금계약이 성립하고, 수취인이 수취은행에 대하여 위 금액 상당의 예금채권을 취득함. 이때, 송금의 퇴인과 수취인 사이에 계좌이체의 원인이 되는 법률관계가 존재하지 않음에도 불구하고, 계좌이체에 의하여 수취인이 계좌이체금액 상당의 예금채권을 취득한 경우에는, 송금의 퇴인은 수취인에 대하여 위 금액 상당의 부당이득반환청구권을 가지게 되지만, 수취은행은 이익을 얻은 것이 없으므로 수취은행에 대하여는 부당이득반환청구권을 취득하지 아니함.²⁴⁸⁾

송금인이 오류로 타인의 은행계좌로 계좌이체하자 수취은행이 그 수취인에 대한 대출금반환채권을 위 예금반환채권과 상계한 경우, 계좌이체한 송금인이 수취은행에 대하여 부당이득반환을 청구할 수 없음.²⁴⁹⁾

2) 대법원 2010.5.27. 선고 2007다66088 판결

예금거래기본약관에 따라 송금의 퇴인이 수취인의 예금계좌에 자금이체를 하여 예금원장에 입금의 기록이 된 때에는 특별한 사정이 없는 한 송금의 퇴인과 수취인 사이에 자금이체의 원인인 법률관계가 존재하는지 여부에 관계없이 수취인과 수취은행사이에는 위 입금액 상당의 예금계약이 성립하고, 수취인이 수취은행에 대하여 위 입금액 상당의 예금채권을 취득함. 그리고 수취은행이 수취인에 대한 대출채권 등을 자동채권으로 하여 수취인의 계좌에 입금된 금원 상당의 예금채권과 상계하는 것은 신의칙 위반이나 권리남용에 해당한다는 등의 특별한 사정이 없는 한 유효함. 그러나 송금의 퇴인이 착오송금임을 이유로 거래은행을 통하여 혹은 수취은행에 직접 송금액의 반환을 요청하고 수취인도 송금의 퇴인의 착오송금에 의하여 수취인의 계좌에 금원이 입금된 사실을 인정하

248) 대법원 2006.3.24. 선고 2005다59673 판결, 2009.12.10. 선고 2009다69746 판결 참조.

249) 전주지방법원 2005.9.1. 선고 2005나1585 판결 참조.

고 수취은행에 그 반환을 승낙하고 있는 경우, 수취은행이 수취인에 대한 대출채권 등을 자동채권으로 하여 수취인의 계좌에 착오로 입금된 금원 상당의 예금채권과 상계하는 것은, 수취은행이 선의인 상태에서 수취인의 예금채권을 담보로 대출을 하여 그 자동채권을 취득한 것이라거나 그 예금채권이 이미 제3자에 의하여 압류되었다는 등의 특별한 사정이 없는 한, 공공성을 지닌 자금이체시스템의 운영자가 그 이용자인 송금의뢰인의 실수를 기화로 그의 희생하에 당초 기대하지 않았던 채권회수의 이익을 취하는 행위로서 상계제도의 목적이나 기능을 일탈하고 법적으로 보호받을 만한 가치가 없으므로, 송금의뢰인에 대한 관계에서 신의칙에 반하거나 상계에 관한 권리를 남용하는 것임.

(2) ◇◇은행에 대한 판단

계좌이체시 원인관계가 존재하는지 여부에 상관없이 수취인은 위 금액 상당의 예금을 취득하고, 원인관계없이 계좌이체에 의하여 수취인이 예금채권을 취득한 경우 송금의뢰인은 수취인에 대하여 부당이득반환청구권을 가지게 되지만 수취은행에 대해서는 부당이득반환청구권을 취득하지 아니한다는 것이 판례의 기본 입장이며, 더욱이 본건은 이미 착오송금 이전에 제3자인 ○○카드사에 의하여 신청인의 본건 계좌가 압류되어 있는 점, ○○카드사의 추심권행사로 ◇◇은행이 실질상 이익을 보고 있다고 보기 어려운 점 등을 고려할 때, ◇◇은행이 본건 오류송금액을 반환할 책임은 없다 할 것임.

(3) ○○카드사에 대한 판단

다음과 같은 점을 고려해 볼 때 ○○카드사가 착오송금을 기화로 추심권을 행사하는 것은 적정하지 아니하다고 판단됨.

① 법리상, 형식상 착오송금에 따른 수취인의 예금채권 취득이 인정된다 하더라도, 금융기관인 ○○카드사가 착오송금이라는 우연적 상황을 기화로 사실상 송금의뢰인에 속하는 재산²⁵⁰⁾으로 채권의 만족을 얻는 것이 금융기관의 공공성, 신뢰성에 비추어 적정하다고 보기 어려운 점.

② ○○카드사는 송금의뢰인의 재산을 통하여 채권의 만족을 얻는 반면, 송금의뢰인은

250) 착오송금된 금원을 임의로 사용한 경우 횡령죄가 성립(대법원 2004.10.28. 선고 2005도5975 판결).

수취인의 무자력을 고스란히 부담하게 되고, 수취인으로서도 본인의 의사와 무관하게 변제를 강요받게 됨과 동시에 송금의뢰인이라는 또 다른 채권자를 두게 되는 결과를 야기하게 되어 공평에 반한다고 보이는 점.

③ 신청인은 송금의뢰인의 남편(신청인의 선배)에게 기존채무 약 30백만원이 있지만 변제자력이 없어 상환해 줄 처지도 못되는데, 이번 착오송금 건으로 인해 심하게 빚독촉을 받아 극심한 스트레스를 받고 있다고 주장하는데, 위에서 본 바와 같이 최근 대법원 판결²⁵¹⁾ 또한 원칙적으로 수취은행의 상계권을 인정하면서도, 송금의뢰인과 수취인이 착오송금을 인정하고 있는 경우에는 수취은행의 상계권 행사를 신의칙 위반 내지 권리남용으로 보아 송금의뢰인을 보호하는 예외를 인정하고 있고, 본건의 경우도 ○○카드사가 본건 계좌에 대한 추심권 행사 이전인 2010.6.8., 2010.6.11. 송금의뢰인과 수취인이 ○○카드에 착오송금임을 인정하고 그 반환을 요청한 사실이 인정되는 바, ○○카드사가 착오송금임을 알면서도 본건 계좌에 대한 추심권을 행사한 것을 정당한 권리행사라고 받아들이기 어렵고 신의칙에 반한다고 해석할 여지가 다분한 점.

④ 또한 본건의 경우 압류채권자가 ○○카드사 뿐이고 다른 이해관계자가 없어 추심금 배당이나 반환에 따른 복잡한 법률관계를 야기하지 않을 것으로 보이는 점.

라. 결 론

그렇다면, 피신청인2(○○카드사)가 신청외 A씨에게 착오송금액을 반환하여야 한다는 신청인의 주장은 이유 있으므로 이를 인용하고, 피신청인1(◇◇은행)에 대한 청구는 이유 없어 이를 기각함.

4-20 착오송금 반환요청 전에 상계효력이 발생하지 않은 경우의 반환 의무

[인용] 송금의뢰인의 착오송금임을 이유로 송금액의 반환을 요청하고 수취인도 수취은행에 그 반환을 승낙하고 있음에도 수취은행이 수취인에 대한 대출채권 등을 자동채권으로 하여 착오송

251) 대법원 2010.5.27. 선고 2007다66088 판결 참조.

금된 금원 상당의 예금채권과 상계하는 것은 공공적 역할을 하는 은행이 송금의뢰인의 실수를 기화로 당초 기대하지 않았던 채권회수의 이익을 취하는 행위로서 위법하다고 판시하고 있고, 본 건 또한 상계 효력 발생 이전에 이미 신청인의 반환청구에 따라 채권압류추심명령이 통지되고 상계의 효력도 발생하였다고 보기 어려우므로 피신청인은 신청인에게 착오송금액을 반환할 의무가 있음.(2013.2.19. 조정번호 제2013-1호).

가. 사실관계

신청인은 2012.4.22.(일요일) 남편에게 A씨 명의 계좌(○○은행)로 12백만원을 송금하도록 부탁하였으나, 남편이 현금지급기를 통해 계좌이체를 하면서 실수로 신청 외 B씨 명의의 본건 계좌(◇◇은행)로 송금하였으며, 신청인은 4.23. 이러한 착오송금 사실을 확인하고 수취은행인 피신청인(◇◇은행) 지점을 방문하여 그 직원과 회수절차에 대해 상담하였고, 피신청인 직원은 위 B씨 명의 계좌에 지급제한²⁵²⁾이 걸려 있어 입금된 자금이 대출금 상환에 사용될 수 있으니 조속히 가압류 신청을 하라고 안내하였음.

신청인은 피신청인 직원의 안내에 따라 2012.4.24. 법원에 채권가압류를 신청하여 동 가압류 결정문이 피신청인에게 송달(송달일자 2012.5.7)되었고, 2012.4.25. B씨를 상대로 한 지급명령을 신청하여 동 지급명령이 6.5. B씨에게 송달되었으나, B씨가 동 지급명령에 이의를 제기하지 않음에 따라 6.20. 확정됨. 신청인은 지급명령 확정 후인 같은 해 7.11. 가압류를 본압류로 이전하는 압류 및 추심명령을 신청하였고, 동 결정문이 7.23. 송달되었음.

한편, 피신청인은 2012.5.7. 가압류 결정문을 수령한 후 2012.6.12. B씨 앞으로 예금상계 통지서를 발송하고, 동일자로 B씨 계좌에 남아있던 예금 12,026,900원을 회수 처리하였으나, 동 상계 통지서는 2012.6.24. 주소불명으로 반송되어 B씨에게 전달되지 않았음.

나. 당사자 주장

(1) 신청인 주장

252) B씨의 대출금(50백만원)이 연체로 특수채권에 편입되어 예금계좌가 지급 제한됨.

착오송금 직후 피신청인에게 찾아가 착오송금 사실을 고지하고 회수절차까지 안내받았음에도 피신청인이 착오송금된 금원에 대해 상계처리한 것은 부당함. 신청인은 착오송금 신고시 은행 담당자에게 B씨(착오 수취인)과 아는 사이(전 직장 동료)임을 밝혔음에도 피신청인은 가압류 절차만 안내하였을 뿐 수취인의 동의가 있다면 반환이 가능하다는 설명이나 수취인의 반환의사를 확인하는 등 기본적인 절차도 거치지 않았음.

(2) 피신청인 주장

착오송금 수취인의 대출 계좌는 연체로 인해 2011.6.28.부터 특수채권에 편입된 상태에서 관련 예금과 상계적상에 있었고, 관련 판례에 의하더라도 수취인이 착오송금 사실을 인정하거나 예금 반환을 승낙한 사실이 없으므로 본건 상계 처리는 적법함.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 신청인이 착오송금한 금원에 대한 수취은행의 반환거부가 적정한지 여부라 할 것임.

(1) 착오송금시 수취은행의 반환의무에 대한 법원의 입장

예금거래기본약관에 따라 송금의뢰인이 수취인의 예금계좌에 자금이체를 하여 예금원장에 입금의 기록이 된 때에는 특별한 사정이 없는 한 송금의뢰인과 수취인 사이에 자금이체의 원인인 법률관계가 존재하는지 여부에 관계없이 수취인과 수취은행 사이에는 위 입금액 상당의 예금계약이 성립하고, 수취인이 수취은행에 대하여 위 입금액 상당의 예금채권을 취득하며, 수취은행이 수취인에 대한 대출채권 등을 자동채권으로 하여 수취인의 계좌에 입금된 금원 상당의 예금채권과 상계하는 것은 신의칙 위반이나 권리남용에 해당한다는 등의 특별한 사정이 없는 한 유효하나, 송금의뢰인이 착오송금임을 이유로 거래은행을 통하여 혹은 수취은행에 직접 송금액의 반환을 요청하고 수취인도 송금의뢰인의 착오송금에 의하여 수취인의 계좌에 금원이 입금된 사실을 인정하고 수취은행에 그 반환을 승낙하고 있는 경우, 수취은행이 수취인에 대한 대출채권 등을 자동채권으로 하여 수취인의 계좌에 착오로 입금된 금원 상당의 예금채권과 상계하는 것은, 수취은

행이 선의인 상태에서 수취인의 예금채권을 담보로 대출을 하여 그 자동채권을 취득한 것이라거나 그 예금채권이 이미 제3자에 의하여 압류되었다는 등의 특별한 사정이 없는 한, 공공성을 지닌 자금이체시스템의 운영자가 그 이용자인 송금의뢰인의 실수를 기화로 그의 희생하에 당초 기대하지 않았던 채권회수의 이익을 취하는 행위로서 상계제도의 목적이나 기능을 일탈하고 법적으로 보호받을 만한 가치가 없으므로, 송금의뢰인에 대한 관계에서 신의칙에 반하거나 상계에 관한 권리를 남용하는 것으로 볼 수 있을 것임.²⁵³⁾

(2) 수취은행의 착오송금액 반환거부의 적정성 판단

아래와 같은 점을 종합할 때 신청인이 피신청인 안내에 따라 착오송금을 이유로 가압류를 신청하고 동 가압류 결정문이 피신청인에게 송달되어 착오송금 가능성을 알고 있었음에도 수취인 승낙 여부를 확인하지 않은 채 착오송금액과 임의로 상계하였고, 상계통지는 내용증명으로 하여야 함에도 규정과 달리 일반등기로 통지하였고 동 상계통지가 수취인에게 송달되지도 않는 등 신청인의 반환청구 이전에 상계의 효력이 발생하였다고 보기 어려워 피신청인의 상계처리는 부적절하다고 할 것임.

① 신청인은 2012.4.22. 수취인 계좌로 착오송금한 직후인 그 다음 날(4.23.) 피신청인 인천지점을 방문하여 회수절차에 대해 문의하였고 이에 피신청인 직원이 수취인 계좌에 지급정지가 걸려 있어 조속히 가압류를 신청하도록 안내하였고, 피신청인의 안내에 따라 2012.4.24. 착오송금을 이유로 수취인 계좌에 대해 채권가압류를 신청하여 2012.5.7. 동 가압류 결정문이 피신청인에게 도달된 점 등을 감안시 피신청인도 수취인 예금에 대한 상계(2012.6.12.) 이전에 착오송금 가능성을 알고 있었던 점.

② 위에서 본 바와 같이 대법원에서는 착오송금에 대해 수취인이 승낙하는 경우 수취은행에게 착오송금액을 반환해야 할 의무가 있다고 인정하고 있는 바, 착오송금 가능성을 알고 있는 피신청인으로서 수취인 승낙시 착오송금액을 반환해야 할 의무가 있으므로 적어도 신청인에게 수취인 승낙 등 착오송금액의 반환절차에 대해 안내하거나 신청인의 반환청구에 대한 수취인의 승낙 여부를 확인한 후 상계하여야 할 신의칙상 의무가 있다 할 것임에도 수취인 승낙 등 반환절차에 대한 설명이나 수취인 승낙의사에 대

253) 대법원 2010.5.27. 선고 2007다66088 판결 참조.

한 확인 등을 거치지 않은 채 수취인 계좌에 착오송금액이 입금되었음을 기화로 임의로 수취인에 대한 채권과 상계한 점.²⁵⁴⁾

③ 특히, 상계는 채권자와 채무자가 서로 동종의 채권·채무를 가지고 있는 경우에 채권·채무 대등액을 상계적상시에 소멸시키는 상대방이 있는 의사표시로서 상대방에게 도달되어야 효력이 발생하는 바(민법 제111조), 피신청인은 수취인에게 2012.6.12. 상계통지서를 발송함과 동시에 착오송금액이 입금된 예금에 대해 상계처리하였으나, 동 상계통지서가 주소불명으로 반송되어 수취인에게 도달되지 않는 등 상계의 효력이 있다고 보기 어렵고, 피신청인 「여신거래기본약관」 제17조에 의하더라도 상계 통지 등 중요 의사표시는 반드시 배달증명부내용증명으로 통지해야 함에도 피신청인은 2012.6.12. 일반등기로 채무자에게 상계통지서를 보냈으며, 신청인의 채권압류 및 추심명령이 피신청인에게 송달(2012.7.23.)된 이후인 2012.8.31.에야 내용증명으로 수취인에게 상계통지서를 재송달하였으나 또다시 반송되는 등 상계통지 절차도 제대로 이행하지 못했으며, 설사 이 때에 상계 효력이 발생하였다고 하더라도 상계 효력 발생 이전에 이미 신청인이 반환청구를 인용한 판결에 기하여 피신청인에게 채권 압류·추심명령이 통지되는 등 신청인의 반환청구 이전에 상계의 효력이 발생하였다고 보기 어려운 점.

라. 결 론

그렇다면, 피신청인이 착오송금액이 입금된 수취인 계좌에 대해 상계하였음을 이유로 신청인의 반환청구에 불응하는 것은 부당하다 할 것이므로 신청인의 주장을 인용함이 타당함.

254) 여타 판례를 볼 때도 수취인과 계좌이체의 원인이 되는 법률관계가 없음에도 착오로 송금하는 경우 수취인은 착오송금된 금액 상당의 부당이득 반환의무를 지게 되며(대법원 2007다51239 판결), 착오송금액을 반환하지 않고 임의로 사용하는 경우 횡령죄가 성립(대법원 2005도5975 판결 등)되는 바, 신청인이 2012.4.25. 수취인을 상대로 착오송금액의 반환을 청구(지급명령)하여 지급명령이 2012.6.20. 확정되는 등 법원에서도 수취인에게 착오송금액 반환의무가 있다는 점을 인정함.

[일부인용] 피신청인 K은행은 □□공단의 압류해제로 14,600,000원이 부당인출 될 수 있음을 인지하고 있었음에도 타행환자금반환요청 명세가 도착하지 않았다는 이유만으로 자금반환을 거부한 채 지급정지 요청 등의 조치를 취하지 않아 착오송금액이 부당인출되는 피해가 발생하였으므로 선관주의 의무 위반에 따른 배상책임이 인정된다고 판단한 사례(2016.4.27. 조정번호 제2016-10호).

가. 사실관계

2015. 12. 29. 신청인은 N은행(이하 ‘피신청인 N은행’이라고 함) △△교육청지점에 내방하여 (사)△△총연합회인쇄사업소 명의 K은행 계좌(#****01-04-071396)에 송금하려 하였던 14,600,000원을 계좌명이 유사한 (사)△△연맹인쇄사업소 명의 K은행 계좌(#****37-04-001808, 이하 ‘이 사건 계좌’라고 함)로 송금하였음.

2016. 1. 20. 신청인은 위 착오송금 사실을 인지하고 피신청인 N은행에 타행환자금반환 신청서를 제출.

2016. 1. 21. K은행(이하 ‘피신청인 K은행’이라고 함)은 피신청인 N은행의 자금반환 신청에 대하여 이 사건 계좌가 □□공단압류 및 한○○로부터 가압류되어 있음을 이유로 자금반환을 거부함.

2016. 1. 22. 신청인은 피신청인 K은행 소비자보호부에 자금반환방법을 문의하였으며, 피신청인 K은행은 수취인을 상대로 부당이득반환청구 소송을 통한 회수를 안내함.

2016. 1. 25. 신청인은 피신청인 K은행 소비자보호부에 부당이득 반환청구 소송을 하기에 앞서 자금반환 방법을 다시 문의하였고, 피신청인 K은행은 예금주의 동의, 압류·가압류채권자의 환급 동의 또는 압류·가압류해제가 필요하다고 설명함.

2016. 1. 27. 피신청인 K은행 중부지점 직원 甲은 신청인에게 자금반환을 위해 압류 및 가압류채권자, 예금주로부터 착오송금에 따른 자금반환동의서를 받아오도록 유선 안내함.

2016. 1. 28. 피신청인 K은행 중부지점 직원 甲은 (사)△△연맹인쇄사업소가 (사)△△연맹

지점으로 등록되어 있어 이 사건 계좌 관리인인 (사)△△연맹의 자금반환 동의로도 가능하다고 안내²⁵⁵⁾하고 신청인은 위 (사)△△연맹을 직접 방문하여 자금반환에 동의를 받음.

2016. 1. 29. 가압류채권자인 한○○가 피신청인 K은행의 ▽▽지점을 방문하여 착오송금액 반환동의서를 제출함.

신청인은 피신청인 N은행 △△교육청지점에 내방하여 타행환자금반환 신청에 대해 문의하였고, 피신청인 N은행은 압류중인 계좌에 대해서는 자금반환신청을 하여도 반환처리가 되지 않을 수 있으므로 압류해제 후 자금반환신청을 하도록 안내함.

2016. 2. 1. 09:19경 압류채권자 □□공단이 전자송달로 압류해제함.

2016. 2. 1. 09:40경 (사)△△연맹 담당자가 피신청인 K은행 ○○부에 방문하여 자금반환 동의서를 제출하였고, 10:20경 피신청인 K은행 ○○부는 위 자금반환동의서를 ▽▽지점 직원 甲에게 팩스로 송부.

甲은 신청인에게 압류 등이 해제되었음을 알리고 피신청인 N은행에 타행환자금반환요청을 의뢰할 것을 통보.

11:00경 신청인은 피신청인 N은행 △△교육청지점에 내방하여 타행환자금반환을 신청하였으나, 피신청인 N은행은 타행환자금반환 신청이 피신청인 K은행에 도달하는데 1일이 소요됨을 안내함.

11:06~30경 신청인은 피신청인 K은행 중부지점 직원 甲에게 신속한 자금반환을 요청하였으나 타행환자금반환신청 명세가 도착하지 않았음을 이유로 자금반환 요구를 거부하였음.

14:30경 피신청인 K은행 ◇◇지점에서 이 사건 계좌 예금주인 (사)△△연맹인쇄사업소 대표 乙가 14,626,000원을 인출하여 도주함.

나. 당사자의 주장

255) 피신청인 K은행은 (사)△△연맹인쇄사업소가 폐쇄되어 계좌관리인 (사)△△연맹의 자금반환동의서 제출로 자금반환이 가능한지 준법감시인 검토를 거침

(1) 신청인 주장

피신청인 N은행은 타행환자금반환 신청시 처리기간에 대하여 올바르게 설명해주지 않았고, 피신청인 K은행은 압류해제에 따른 부당인출 가능성이 있음을 알고 있었음에도 계좌관리인에게 지급정지 요청 등 조치를 취하지 않아 피해가 발생하였으므로 이를 배상해야 함.

(2) 피신청인 주장

(N은행) 2016.1.20. 피신청인 K은행에 타행환자금반환 신청을 하였으나 압류계좌임을 이유로 자금반환이 거부된 이후 신청인은 피신청인 K은행과 자금반환 방법을 협의하여 피신청인 N은행은 이견 진행내용을 몰랐으며, 2016.1.29. 신청인에게 압류상태의 계좌에 자금반환청구를 하여도 반환처리가 되지 않는다고 설명하는 등 정상적으로 타행환자금반환 업무를 처리하였으므로 배상책임이 없음.

(K은행) 2016.2.1. 피신청인 N은행으로부터 타행환자금반환요청 명세를 받지 못하여 타행환공동망업무시행세칙 제53조에 따라 자금반환을 거부하는 등 정상적으로 타행환자금반환 업무를 처리하였으므로 배상책임이 없음.

「타행환공동망업무 시행세칙」

제52조(자금청구기관의 처리) ① 자금의 청구가 필요한 참가기관은 청구내역 및 사유가 포함된 타행환자금청구반환명세를 19시까지 결제원에 일괄전송하여야 한다. 다만, 장애 또는 긴급을 요하는 경우와 제51조 제2호의 대상거래는 별지양식 9의 「타행환자금 청구/반환 명세표」에 청구내역 및 사유를 기재하여 상대기관에 FAX로 통보할 수 있다.

② ~ ③ (생략)

제53조 (자금반환기관의 처리) ① 결제원으로부터 타행환자금청구반환명세를 일괄전송으로 수신한 참가기관은 해당 거래내역을 확인한 후 동 명세에 반환내역을 포함하여 수신일의 익영업일 19시까지 결제원에 일괄전송하여야 한다.

② 제52조에 따라 별지양식 9의 「타행환자금 청구/반환 명세표」를 FAX로 수신한 참가기관은 해당 거래내역을 확인한 후 동 명세표에 반환내역을 포함하여 수신일의 익영업일 19시까지 결제원에 일괄전송하여야 한다.

③ 자금반환기관은 제51조 제3호의 착오송금거래에 따른 반환 처리를 할 경우 사전에 수취인에게 반환처리에 대한 동의를 받아야 한다.

④ 자금반환기관은 청구반환 처리를 한 경우 수취인에게 청구반환 사유 및 내역을 지체없이 통지하여야 한다.

다. 위원회의 판단

◆ 이건의 쟁점은 피신청인들이 착오송금된 자금의 반환업무 처리과정에서 선관주의 의무를 위반하여 손해배상책임이 인정될 수 있는지 여부라 할 것임

(1) 선관주의 의무 위반에 따른 배상책임 인정 여부

금융회사는 일반 회사와는 달리 고객의 재산을 보호하고 자금중개 기능의 효율성 유지를 위하여 금융시장의 안정성에 이바지해야 하는 공공적 역할을 담당하는 위치에 있으므로 일반적인 선관의무 이외에 그 공공적 성격에 부합하는 내용의 선관의무를 다할 것이 요구됨(대법원 2002.3.15. 선고 2000다 9086 판결 등).

피신청인 K은행은 신청인이 (사)△△연맹인쇄사업소 계좌(#****37-04-001808)에서의 무단인출 가능성이 있는지 문의하였으나, ‘압류채권자인 □□공단에서 전산상으로 압류해제 통보시 예금부정 인출 가능성이 있다고 설명하였다’고 사실관계 확인서를 제출하였는 바, □□공단의 압류해제로 14,600,000원이 무단인출 될 수 있음을 인지하였다고 보아야 할 것임.

신청인은 2016. 1. 21. ~ 21. 기간 동안 피신청인 K은행에게 착오송금 반환에 필요한 절차를 지속적으로 문의하였고, 피신청인 K은행이 안내한 절차대로 자금반환동의에 필요한 조치를 취하면서 피신청인 K은행과 지속적으로 상의하였으므로 피신청인 K은행은 일련의 진행상황을 상세히 알고 있었으며, 이 사건 계좌 관리인 (사)△△연맹이 피신청인 서여의도영업점에 직접 내방하여 자금반환동의서를 작성해 주는 등 신청인을 위해 협조적이었던 사실 또한 알고 있었던 점을 고려할 때, 압류해제시 무단인출 가능성을 알고 있었던 피신청인 K은행은 (사)△△연맹에게 이 사건 계좌의 지급정지를 요청하거나 신청인으로 하여금 요청하게 하는 등의 조치를 취할 수 있었던 점, 타행환자금반환청구 방법으로 긴급을 요하는 경우에 FAX 통보가 가능²⁵⁶⁾하므로 피신청인 N은행 △△교육청지점

에 연락하여 FAX 통보하도록 조치하거나 신청인에게 이를 안내할 수 있었음에도 이를 이행하지 않은 점, 압류 또는 가압류가 해제되면 통신비 등 자동이체 신청된 비용 등이 출금될 수 있으며, 그 사실이 예금주에게 문자통지²⁵⁷⁾된다면 예금주가 압류해제 등이 있었음을 알 수 있어 부당인출 할 가능성도 배제할 수 없었던 점 등을 종합적으로 고려할 때, 피신청인 K은행이 타행환자금반환요청 명세가 도착하지 않았다는 이유만으로 자금반환을 거부한 채 지급정지 요청 등의 조치를 취하지 않아 착오송금액이 부당인출되는 피해가 발생하였으므로 선관주의 의무 위반에 따른 배상책임이 인정된다고 할 것임.

한편, 신청인은 피신청인 N은행이 타행환자금반환 신청시 소요되는 기간에 대하여 올바르게 설명해주지 않았다고 주장하나, 신청인이 착오송금 사실을 인지한 2016.1.20. 피신청인 N은행 △△교육청지점에 내방하여 타행환자금반환을 신청하여 동 타행환자금반환 신청서를 피신청인 K은행에게 전문으로 통보한 바 있으나, 2016.1.21. 피신청인 K은행이 압류계좌임을 이유로 자금반환 청구를 거부한 이후부터는 신청인이 수취은행인 피신청인 K은행과 자금반환 절차를 협의한 사실 등에 비추어 피신청인 N은행이 이 건 진행상황을 구체적으로 알고 있었다고 단정할 수 없는 점 등을 고려할 때 피신청인 N은행이 선관주의 의무 내지 고객보호 의무를 위반했다고 볼 수는 없다고 할 것임.

(2) 피신청인 K은행의 손해배상범위

이 건 손해는 신청인이 송금전 수취인 명의 및 계좌번호를 제대로 확인하지 않은 부주의로 수취인 계좌를 잘못 입력하여 발생하였고, 착오송금 사실을 20여일이 지나 확인하는 등 신청인의 과실이 이 건 사고의 발생 원인이 되었으므로 이를 고려할 때 피신청인 K은행의 책임을 60%로 제한함이 타당하다 할 것임.

따라서, 피신청인 K은행은 신청인에게 발생한 손해금액 14,600,000원의 60%에 해당하는 8,760,000원을 배상할 책임이 있다 할 것임.

256) 자금의 청구가 필요한 참가기관은 긴급을 요하는 경우 상대방기관에 FAX로 통보할 수 있음(「타행환 공동망업무 시행세칙」 제52조)

257) 2015.2.1. 09:19경 □□공단의 압류해제 이후 10:03경 이 사건 계좌 예금주 乙에게 2015.12월 ~ 2016. 1월 입출금 통지수수료 1,800원 출금 및 잔액 16,059,895원 내용이 문자로 통지됨

라. 결 론

그렇다면, 신청인의 피신청인 K은행에 대한 청구는 이유 있어 이를 일부 인용하고, 피신청인 N은행에 대한 신청은 이유없어 기각함.

4-22 은행의 선관주의의무 위반 여부

[조건부인용] 수출대금 지급 청구에 대하여 제재조치를 이유로 그 지급을 거부할 수 있으나, 이는 제재조치 해제 전까지 거부할 수 있는 지급 유예에 불과한 것으로서 지급 유예 사유가 해소되는 경우에는 신청인의 지급청구에 즉시 응해야 하므로 제재조치를 이유로 피신청인의 책임이 면책된다고 볼 수는 없다고 판단한 사례(2016.11.9. 조정번호 제2016-28호).

가. 사실관계

2014.2.10. 신청인은 미국의 對이란 제재(이하 ‘제재조치’라고 함)대상 항만²⁵⁸⁾인 이란의 Khorramshahr(코람샤르) 항만을 이용하여 이란 국적 수입업체인 A(이하 ‘수입업체’라 함)에게 후라이팬 등 주방용품을 수출하였음.

對이란 제재조치 주요 내용

- UN안전보장이사회는 이란의 핵무기 및 탄도미사일 개발을 저지하기 위한 일련의 제재 결의를 채택하여 세계 각국으로 하여금 이란제재 이행을 의무화하고 있으며, 이에 따라 수출기업들은 제재대상자가 운영하는 선사와 항만을 이용해서는 안됨.
- 미국 재무성 산하기구인 OFAC(Office of Foreign Asset Control)이 제재대상자 리스트를 관리하고 있고, 제재대상자와의 거래가 적발되는 경우 거래 당사자는 미국과의 교역이 금지되며, USD 외환거래가 불가.

2014.3.31. 이란 BANK B(이하 ‘이란은행’이라고 함)는 피신청인에게 수출대금(KRW

258) 제재대상자 운영항구 및 터미널 : Bandar Abbas Shahid Rajaei항 내 Container 터미널 및 일부 Bulk 터미널, Bandar Iman Khomeini 항 내 Grain 터미널 및 Container 터미널, Bandar Anzali항, Khorramshahr항, Assaluyeh항, Aprin항, Amir항

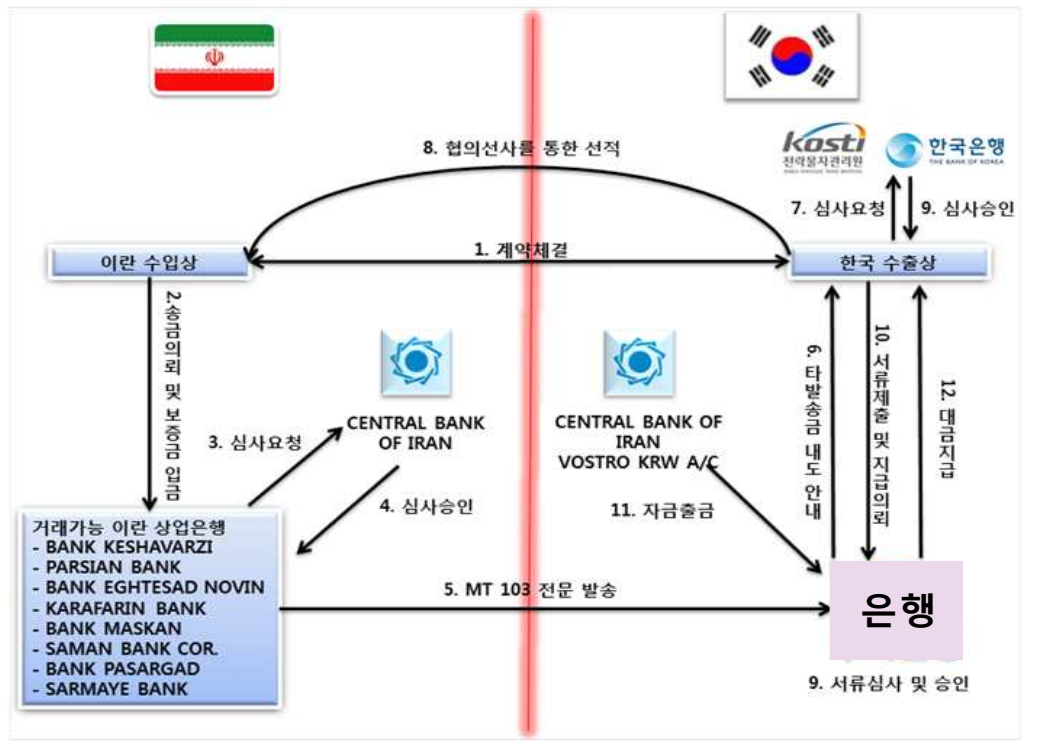
43,554,822)을 입금.

피신청인은 신청인에게 타발송금(해외에서 들어오는 외화송금) 내도사실 및 자금인출에 필요한 서류 제출²⁵⁹⁾을 안내.

2014.4.25. 신청인은 전략물자관리원²⁶⁰⁾으로부터 발급받은 「이란교역 및 투자비금지 확인서」 등을 피신청인에게 제출.

<참고 : 對이란 거래 및 원화결제의 구조>

- 이란과의 거래에서 미국 달러화(USD)의 사용금지로 한국과 이란간 교역 및 투자대금 결제는 원화결제시스템(가능은행 : A은행, B은행)을 반드시 이용.



259) 전략물자관리원 「이란 교역 및 투자 비금지 확인서」, 한국은행 「이란관련자와의 지급등에 대한 신고·허가신청서」 및 상업송장, PROFORMA INVOICE(계약사실 확인) 등

260) 전략물자관리원은 거래 금지품목 여부에 대해 심사하며 홈페이지 등을 통해 제재대상자가 운영하는 항만, 이용가능 선사에 대해 공지

2014.5.23. 피신청인은 신청인이 제재 대상인 부적격 항만(Khorramshahr, 코람샤르)을 이용하였음을 이유로 수출대금 지급을 거절.

2015.2.9. 이란은행은 피신청인에게 ‘미정리 자금에 대한 확인요청’ 1차 전문²⁶¹⁾을 발송.

2015.2.12. 피신청인은 미국의 이란제재 완화 가능성이 있을 것으로 판단하여 자금 반환 보류 전문(신청인이 정부에서 발행한 공인서류를 준비중으로 제출 즉시 지급예정)을 이란은행에 회신.

2015.9.7. 이란은행은 피신청인에게 ‘미정리 자금에 대한 확인요청’ 2차 전문²⁶²⁾을 발송.

2015. 9. 7. 피신청인은 1차 전문 회신(2015.2.12.)과 동일한 내용으로 회신.

2016. 1.12. 이란은행은 피신청인에게 ‘미정리 자금에 대한 확인요청’ 3차 전문²⁶³⁾을 발송.

2016. 1.13. 피신청인 외환업무센터는 이란은행의 확인요청에 대해 ‘신청인 의사를 확인하여 회신달라(거절시에도 회신요망)’고 모지점에 요청하였으나 피신청인 모지점 직원(차장 최○○)은 신청인에게 자금반환에 대한 안내 및 동의절차를 구하지 않았음에도 ‘신청인의 지급취소 요청’이 있었다고 외환업무센터에 회신.

2016.1.15. 외환업무센터는 모지점 회신내용을 토대로 ‘수취인의 지급취소 요청으로 퇴결’ 한다는 내용의 전문을 이란은행에 회신하고 자금을 반환.²⁶⁴⁾

2016. 5월경 신청인은 본인의 동의없이 피신청인이 이란은행에게 수출대금을 반환한 사실을 알고 피신청인에게 민원을 제기.

261) (전문요약) 귀행이 우리의 지급지시에 응해서 지급했다는 확인을 받지 못함. 문제를 조사하여 공인된 메시지를 보내주고 7영업일 동안 답변을 받지 못하면 송금 지급지시에 대해 없었던 것으로 간주하겠음

262) (전문요약) 귀행이 우리의 지급지시에 응해서 지급했다는 확인을 받지 못함. 문제를 조사하여 공인된 메시지를 보내주고 7영업일 동안 답변을 받지 못하면 송금 지급지시에 대해 없었던 것으로 간주하겠으며 즉각적으로 긴급히 알려줄 것

263) (전문요약) 몇 번의 독촉에도 우리의 지급지시가 이행되지 않았음. 귀행이 수취인과 필요한 조치를 하도록 요청하고, 언제 공인된 서류가 제공될 수 있는지 알려주길 원하며 만족할 만한 답변이 7영업일내로 수신되지 않으면 송금 지급지시에 대해 없었던 것으로 간주하겠음

264) 피신청인의 확인에 따르면, 2014.1. ~ 2016.6월 기간 동안 피신청인의 對이란 수출대금 자금반환과 관련한 207건중 206건은 수취인 동의를 받은 후 자금반환하였고, 수취인 동의없이 자금을 반환한 건은 본건이 유일한 것으로 확인

피신청인은 2016.5.17 및 6.9. 이란은행에게 반환자금의 회수를 요청 하였으나 반환자금의 송금이 완료되어 불가²⁶⁵⁾하다는 내용의 전문을 수신.

2016.6.27. 피신청인은 신청인이 對이란제재 대상 항만을 이용하여 수출대금을 지급할 수 없었던 것이며, 이란은행으로부터 세 차례에 걸쳐 확인요청을 받고 자금을 반환한 것이므로 책임이 없다고 신청인에게 안내.

2016.7.6. 신청인 분쟁조정 신청.

나. 당사자의 주장

(1) 신청인의 주장

피신청인이 신청인의 동의없이 수출대금 43,554,822원을 이란은행으로 반환하였으므로 동 금원을 원상회복하거나 이를 배상해야 함.

(2) 피신청인의 주장

신청인이 제재대상인 부적격 항만을 이용하여 수출대금을 지급할 수 없었으며, 외국환업무 관련 내규상 송금은행의 자금반환(퇴결) 요청시 수취인에게 미지급된 상태에서는 수취인의 동의가 없어도 자금반환이 가능하므로 책임이 없음.

피신청인 외국환업무 관련 내규

- **외국환업무매뉴얼 제183조(퇴결)** ①송금은행으로부터 퇴결 또는 지급정지요청서를 접수한 경우에는 지급지시서에 동 사실을 기입하고 합철한 후 해당 송금대금의 미지급 여부를 확인한다.
- ② 퇴결 또는 지급정지요청서 접수 당시 이미 지급을 하였을 경우
 1. 그 사실을 지체없이 송금은행앞으로 통지한다.
 2. 수취인이 퇴결에 동의할 경우에는 송금대금을 환입받음과 함께 타발송금 퇴결동의서를 받고 상대방은행 지시대로 처리한다.

265) 이란은행으로 반환된 자금은 환전상 계좌를 경유하여 수입업체 계좌로 송금되는데, BANK MELLAT에 개설된 환전상 계좌가 압류되어 수입업체에 반환자금이 송금되지 않은 상태이며, 환전상은 현재 이란에서 구속 수감중임

③ 미지급상태에서 퇴결요청 또는 지급정지요청을 받은 경우 1. 퇴결요청을 받은 경우에는 퇴결동의 전신문을 보내고 지급정지요청을 받은 경우에는 송금은행의 조치에 따른다. 2. 당행계좌에서 이미 송금대금이 입금되어 있는 경우에는 상대방은행의 요청에 따라 차기 수권전문 등을 발송하여 지급한다.	○ 외국환업무지침 제45조(타발송금환 퇴결) 타발송금환의 퇴결 또는 지급정지 요청이 있는 경우에는 다음과 같이 처리한다. 1. 접수당시 이미 지급을 마쳤을 경우 가. 지급사실을 지체없이 송금은행 앞으로 통지한다 나. 수취인이 퇴결에 동의할 경우에는 송금대금을 환입하고 타발송금 퇴결동의서를 받은 후 상대방은행 지시대로 처리한다 2. 미지급상태인 경우 가. 퇴결요청을 받은 경우에는 퇴결수락통지서를 보내고 지급정지요청을 받은 경우에는 송금은행의 조치에 따른다. 나. 당행계좌에 이미 송금대금이 입금되어 있는 경우에는 상대방은행의 요청에 따라 차기 수권 전문 등을 발송하여 지급한다.
○ 외환업무프로세스 中 (업무명) 타발송금 사후관리 5. 리펀드 처리 나. 지점전금처리 후 타발송금건 (1) <u>고객지급 전</u> (가) 리펀드요청전문 내도 후 수취인 동의 혹은 수취인 리펀드 요청 (나) 수취인으로부터 리펀드동의서 징구 : MT103전문 여백에 수취인이 작성 상기송금건(당행 레퍼런스번호 기재)에 대한 REFUND에 동의합니다. 수수료 부담자 : (해외송금인 또는 국내수취인) 업체명판, 인감 혹은 지점명판, 지점명판, 직인 (다) 외환서비스센터로 타발송금 지급지변경 :계정전 FT32(AA:20084, BB:2번)거래실행 (라) 외환서비스센터로 리펀드업무요청(리펀드동의서 스캔) ※ 단, 계좌오류건 또는 수취인/예금주 불일치건은 동의서 징구없이 리펀드 업무요청 영업점 전달사항에 ‘수취인계좌오류(또는 수취인/예금주 불일치) 및 송금은행 리펀드요청’으로 기재후 외환업무요청 의뢰	

다. 위원회의 판단

- ◆ 본건의 쟁점은 외국환거래업무 처리과정에서 선관주의의무 위반 여부와 그 손해배상책임 범위라고 할 것임

(1) 피신청인의 선관주의의무 위반 여부

신수입인은 위임의 본지에 따라 선량한 관리자의 주의로써 위임사무를 처리하여야 하며(「민법」 제681조), 금융회사는 일반 회사와는 달리 고객의 재산을 보호하고 자금중개 기능의 효율성 유지를 위하여 금융시장의 안정성에 이바지해야 하는 공공적 역할을 담당하는 위치에 있으므로 일반적인 선관의무 이외에 그 공공적 성격에 부합하는 내용의 선관의무를 다할 것이 요구됨(대법원 2002.3.15. 선고 2000다 9086 판결 등).

피신청인은 외국환업무 내규인 「외국환업무매뉴얼」과 「외국환업무지침」에서는 송금은행이 입금한 자금이 수취인에게 미지급 상태인 경우 송금은행의 자금반환 요청시 수취인의 동의없이 자금반환이 가능하다고 정하고 있으므로 책임이 없다고 주장하나 ① 피신청인 외환업무센터가 외환업무취급 지침으로 정한 「외환업무프로세스」에 따르면 계좌오류 내지 수취인이 불분명한 경우를 제외하고는 자금반환시 수취인의 동의를 받도록 정하고 있는 점 ② 2016. 1. 13. 위 외환업무센터가 피신청인 모지점에게 본건 자금반환에 대하여 신청인의 의사를 확인하도록 요청하였음에도 모지점은 신청인에게 자금반환에 대한 안내 및 동의 절차를 이행하지 않고 신청인이 동의한 것으로 회신한 점 ③ 피신청인은 2015. 2. 9. 및 2015. 9. 7. 이란은행의 미정리 자금에 대한 처리 요청에 대해 ‘신청인이 정부에서 발행한 공인 서류를 준비중으로 제출 즉시 지급예정’이라고 회신한 사실이 있고, 이전과 다른 사정변경이 없는 한 피신청인은 이란은행의 자금반환 요청에 응해야 할 의무가 없으며, 피신청인이 자금을 반환하지 않는 한 이란은행도 일방적으로 본건 자금을 회수할 수 없는 점 ④ 피신청인은 과거 對이란 수출대금 관련 자금반환 업무를 취급하면서 본건을 제외하고는 모두 수취인으로부터 동의를 받고 자금을 반환한 점 ⑤ 피신청인이 신청인의 동의없이 수출대금을 이란은행에게 지급하여 제재 해제 여부와 무관하게 신청인이 수출대금을 지급받을 수 없게 하여 조건의 성취에 따른 신청인의 이익을 해하였다고 볼 수 있는 점(「민법」 제148조) 등을 종합적으로 고려할 때, 피신청인은 신청인으로부터 위임을 받아 수출대금 지급 업무를 대행하여 수출대금을 보관하고 지급해야 할 선량한 관리자로서의 주의의무를 다하지 못한 것으로 보아야 할 것임.

(2) 손해배상범위

불법행위로 인하여 가해자가 배상책임을 지는 손해액의 범위는 그 불법행위와 상당인
과관계에 있는 모든 손해라 할 것이고, 그 중 재산상 손해는 위법한 가해행위로 인하여
발생한 재산상 불이익, 즉 그 위법행위가 없었더라면 존재하였을 재산상태와 그 위법행
위가 가해진 현재의 재산상태의 차이를 말하는 것이며 그 손해액은 원칙적으로 불법행
위시를 기준으로 산정해야 함(대법원 2011.4.28. 선고 2010다106702 판결 등).

이란은행으로 반환된 수출대금은 정상적인 경우 BANK C에 개설된 환전상 계좌를
경유하여 수입업체로 송금되어야 하나 위 환전상 계좌가 압류되어 반환된 수출대금이
수입업체에게 송금될 가능성이 불투명하고 수입업체는 이란은행을 통해 피신청인에게
수출대금 43,554,822원을 정상적으로 입금하는 등 채무내용에 좇아 변제 (「민법」 제390
조, 제460조)한 것으로 인정할 수 있으며, 변제의 효과로서 수출대금 채권 소멸을 주장
하는 경우 신청인이 수입업체로부터 수출대금을 지급받을 수 없다고 봄이 상당하므로
43,554,822원 전체를 회수불가능한 손해액으로 보아야 할 것임.

본건에서 피신청인이 신청인의 동의를 받지 않고 임의로 43,554,822원을 반환하였으며,
피해자에게 손해발생 또는 손해의 확대에 아무런 원인을 주지 않았다면 원칙적으로 과
실상계를 할 수 없으므로(대법원 1987.5.12. 선고 86다카819판결), 피신청인은 신청인에게
43,554,822원 전액을 배상할 책임이 있다고 할 것임.

(3) 제재조치에 따른 피신청인의 책임면제 여부

피신청인은 신청인의 수출대금 지급 청구에 대하여 제재조치를 이유로 그 지급을 거
부할 수 있으나, 이는 제재조치 해제 전까지 거부할 수 있는 지급 유예에 불과한 것으로
서 지급 유예 사유가 해소되는 경우에는 신청인의 지급청구에 즉시 응해야 하므로 제재
조치를 이유로 피신청인의 책임이 면책된다고 볼 수는 없다 할 것임.

라. 결 론

그렇다면, 신청인의 피신청인에 대한 청구는 이유 있어 이를 인용하나, 피신청인은 본
건 관련 제재조치가 해제되기 전까지는 신청인에게 43,554,822원을 지급할 의무가 없으
므로 제재조치가 해제된다면 피신청인은 신청인에게 43,554,822원을 지급해야 할 것임.

제5절 수표대금 지급

4-23 자기앞수표의 사고신고 전산등록 지연처리로 인한 손해배상책임 유무

[일부인용] 자기앞수표의 최종소지인은 발행은행의 본지점에서 해당 수표금의 지급제시가 가능하므로 다수의 영업점포를 갖추고 있는 은행은 특정점포 등 국지적인 전산장애 발생으로 인해 사고수표 전산등록이 지연처리 되는 과정에서 사고신고 된 수표가 무권리자에게 지급되지 않도록 하는 대체수단 확보 등의 대처요령을 미리 수립해 두어 금융이용자의 피해를 사전에 예방하는데 노력해야 할 주의의무가 있음. 피신청인은 특정점포의 국지적인 전산장애 발생시 예견되는 금융이용자의 피해에 대한 예방대책을 소홀히 하여 무권리자가 본건 자기앞수표를 현금으로 찾아감으로써 신청인이 입은 손해를 배상할 책임이 있음.(2002.7.2. 조정 번호 제2002-30호)

가. 사실관계

신청인은 2001.7.8.(일) 18:00경 ○○은행(이하 “피신청인”이라 함) A지점이 발행한 1천만원권 자기앞수표 3매(이하 “본건 자기앞수표”라 함)를 포함하여 1억원권 1매, 1백만원권 4매, 1십만원권 10매 등 총 135백만원의 자기앞수표를 도난 당하였음.

본건 자기앞수표 등은 B씨가 2001.7.7.(토) ◇◇증권 영업본부점에서 인출하였으며, 신청인은 2001.7.8.(일) B씨로부터 전세보증금의 반환금으로 본건 자기앞수표 등을 수령하여 핸드백 속에 보관해 두었는데 같은 날 서울 서초구 소재 강남버스터미널 지하상가에서 소매치기를 당하였다고 주장함.

C씨(신청인의 남편)는 2001.7.9. 09:00경 피신청인의 A지점에 전화를 걸어 본건 자기앞수표 등에 대해 사고신고를 접수시켰는데, 도난일(2001.7.8.)이 휴무일(일요일)인 관계로 수표번호를 확인할 수 없어 다음날 사고신고를 접수하였다 함.

피신청인의 A지점은 폭우로 인해 전산장애가 발생하여 사고수표 전산등록을 할 수 없어 같은 날 09:05경 ARS센터에 대신 전산입력을 해 줄 것을 요청하였고, 피신청인의 ARS센터는 본 건 자기앞수표 등에 대해 사고신고 전산등록을 실시하였으나, ARS센터

의 전산단말기에서도 원인불명의 전산장애가 발생하여 전산입력이 지연처리되다가 같은 날 09:25~09:45경 1억원권(1매), 1백만원권(4매), 1십만원권(10매) 자기앞수표만 정상적으로 전산입력이 완료됨.

사고신고 등록이 누락된 본 건 자기앞수표(1천만원권 3매)는 같은 날 09:45경 피신청인의 D지점에서 제3자(수표뒷면 배서인: E씨)가 현금으로 찾아감. 신청인은 사고수표 전산등록이 정상적으로 완료되어 미지급된 1억원권, 1백만원권 및 1십만원권 자기앞수표를 제권판결 등을 통해 모두 회수함. 본건 자기앞수표(1천만원권 3매)를 현금으로 찾아간 제3자에 대해서는 2002.6.19. 현재까지 수사기관에서 수사 중에 있음.

나. 당사자 주장

(1) 신청인 주장

피신청인은 본 건 자기앞수표(1천만원권 3매)에 대한 사고신고를 접수받고도 전산등록을 약 45분간 지연처리 하여 동 수표금이 무권리자에게 부당 지급됨.

(2) 피신청인 주장

A지점 및 ARS센터는 사고수표 전산등록에 최선을 다하여 1억원권, 1백만원권 및 1십만원권의 자기앞수표에 대해 전산입력을 완료하였으나, 그 과정에서 원인불명의 전산장애가 발생하여 본 건 자기앞수표(1천만원권 3매)의 사고신고 전산등록이 지연처리 되던 중 다른 지점에서 제3자가 수표금을 현금으로 찾아간 것이므로 업무처리에 하자가 없음.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 자기앞수표 전산등록을 지체한 피신청인이 무권리자에 대한 자기앞수표 지급과 관련하여 과실이 있는지 여부라 할 것임.

약속어음, 당좌수표, 가계수표의 발행인은 지급인인 은행과 체결한 지급위탁계약에 근거하여 자기가 발행한 어음, 수표의 지급위탁을 취소하겠다고 은행(지급인)에 지시할 수 있으나, 자기앞수표는 은행이 발행하는 수표로서 발행인(은행)이 지급인(은행)의 자격을

검하는 수표인 바, 발행의뢰인(은행고객)은 은행으로부터 자기앞수표를 구입한 자에 불과하므로 당좌수표 등과는 달리 분실·도난을 당하여도 은행 앞 지급위탁 취소를 요청할 권한이 없음. 다만 「수표법」 제35조는 수표의 지급인은 배서의 연속을 조사할 의무만 있다고 규정하고 있으나, 유가증권에 관한 일반법리상 수표의 지급인에게는 수표소지인의 실질적 자격을 조사할 수 있다고 해석되며, 「어음법」 제40조 제3항²⁶⁶⁾의 지급인의 면책 사유 역시 수표의 경우에도 유추 적용된다고 할 것이므로 지급인이 보통의 조사를 하기만 하면 어음의 소지인이 무권리자이고 또 그 무권리자임을 입증할 수단을 확실히 획득하였을 것인데 이 조사를 사소한 부주의로 게을리 하여 무권리자인 줄을 모르고 지급한 경우에는 지급인이 수표금 지급에 대한 책임이 면책되지 아니한다 할 것임.

따라서 자기앞수표의 사고신고는 동 수표의 발행인 및 지급인인 은행에 대해 단순히 “자기앞수표에 사고가 발생했다는 사실” 및 “사고신고 된 수표를 지급할 때 주의하라”고 통지하는 것에 불과하며, 은행이 수표금 지급 시 최종소지인이 무권리자인가를 확인하는데 그 주의 정도를 가중하는 의미를 지닌다고 보는 것이 일반적 견해임.

자기앞수표의 사고신고 전산등록을 지연처리 한 피신청인에게 손해배상 책임이 있는지 여부에 대해 살펴보면, 금융기관에는 자기앞수표의 사용에 대한 안정성 확보와 정당한 소지인에게 해당 수표금이 지급되도록 하기 위하여 사고신고제도가 운용되고 있음. 자기앞수표의 최종소지인은 발행은행의 본지점에서 해당 수표금의 지급제시가 가능하므로 다수의 영업점포를 갖추고 있는 은행은 특정점포 등 국지적인 전산장애 발생으로 인해 사고수표 전산등록이 지연처리 되는 과정에서 사고신고 된 수표가 무권리자에게 지급되지 않도록 하는 대체수단(예: 전산센터 앞 직접 입력의뢰, 은행 전체 자기앞수표 지급 일시정지 등) 확보 등의 대처요령을 미리 수립해 두어 금융이용자의 피해를 사전적으로 예방하는데 노력해야 할 주의의무가 있음.

피신청인이 시행중인 “전산장애 발생시 대처요령”을 살펴보면 은행 전체의 전산장애 발생시 대처요령 등은 수립되어 있으나 사고수표 전산등록 등 신속한 전산입력을 요하는 업무의 처리 중에 국지적인 전산장애 발생 시에 대한 대처요령은 마련되어 있지 않음.

266) 「어음법」 제40조 제3항은 만기에 지급하는 지급인은 사기 또는 중대한 과실이 없으면 그 책임을 면한다고 규정하고 있음.

또한 피신청인의 ARS센터는 원인불명의 전산장애로 인해 사고수표 전산등록이 계속 지연처리 되고 있어 사고신고가 접수된 사실을 인지할 수 없는 영업점포에서 수표지급이 가능하다는 사실이 충분히 예견됨에도 전산센터에 직접 사고수표의 전산입력을 요청하거나 은행 전체의 자기앞수표 지급을 일시정지 해 줄 것을 요청하는 등의 적절한 조치를 취하지도 않았음.

따라서 피신청인은 특정점포의 국지적인 전산장애 발생시 예견되는 금융이용자의 피해에 대한 예방대책을 마련하는데 소홀했음은 물론 본건 자기앞수표의 사고신고 전산등록을 담당한 ARS센터의 업무처리과정도 적절했다고 보기 어려우므로 무권리자가 본 건 자기앞수표(1천만원권 3매)를 현금으로 찾아감으로써 신청인이 입은 손해를 배상할 책임이 있음.²⁶⁷⁾

신청인은 본 건 자기앞수표의 도난에 대한 관리소홀 책임을 면할 수 없는 점과 신청인이 고액의 자기앞수표를 보관하고 있었음에도 분실 또는 도난에 대비하여 수표번호를 기록해 두지 않아 사고신고 접수가 약 15시간 늦어진 점등에 비추어 신청인 또한 상당한 과실이 있다고 보여지므로 손해액에 대해 50%의 과실상계를 함이 타당함.

라. 결 론

신청인 및 피신청인 모두는 본 건 분쟁발생과 관련하여 적지 않은 과실이 있었다고 인정되므로 피신청인은 본 건 자기앞수표금(30백만원)의 50%에 해당하는 15백만원을 신청인에게 손해배상 함이 책임형평에 적합한 것으로 판단됨.

4-24 자기앞수표 소지인의 이득상환청구권 인정 여부

[기각] 자기앞수표 소지인은 수표의 소지라는 사실만으로 형식적 자격을 갖게 되어 적법한 권리자로 추정되나, 수표금 지급사무를 처리하는 은행은 선량한 관리자로서의 주의를 기울여 그

267) 구 은행감독원 금융분쟁조정위원회는 본 건 유사사례에 대해 금융회사에 손해배상 책임을 묻는 조정결정을 한 바 있음(1990년, 조정번호 제1990-6호).

사무를 처리할 의무를 부담하므로 통상적인 거래기준이나 경험에 비추어 당해 수표가 분실 혹은 도난·횡령되었을 가능성이 예상되거나 또는 수표소지인이 수표를 부정한 방법으로 취득하였다고 의심할 만한 특별한 사정이 존재하는 경우에는 그 실질적 자격에 대한 조사의무를 지는 바, 피신청인이 본건 수표가 금융사고에 연루되어 있다는 사실을 알고 있는 이상, 형식적 자격 이외에 실질적 자격을 조사하여 수표금의 지급 여부를 결정하여야 하므로, 피신청인이 수표금의 지급을 거절한 것은 이유있다 할 것임.(2008.10.7. 조정번호 제2008-73호)

가. 사실관계

2003.8.27. A기업은 지방법원에 4,281백만원 변제 공탁을 하였으며,²⁶⁸⁾ 2004.11.5. 변제 공탁금 부당 인출 사고가 발생하였음. 이 당시 인출 사기범은 신분증을 위조하는 수법으로 공탁금이 예치되어 있는 ○○은행으로부터 자기앞수표 1매(42억원)를 불법으로 출급하여 동일자에 ◇◇은행(이하 “피신청인”이라 함) C지점에 A기업 및 B기업 공동명의로 예금계좌를 개설한 뒤 예치하였다가 동 지점에서 예금을 인출하였음.²⁶⁹⁾

2004.11.11. 피신청인, 임의로 자기앞수표 분실 코드를 등록하였고, 2004.11.15. △△지방경찰청에서 수사에 착수하였으며, 같은 해 12.10에는 동 지방경찰청이 수표금 지급정지 협조를 요청하고, 2005.1.5.에는 ◇◇지방법원 공탁공무원이 수표금 지급정지 협조를 요청함.

2005.1.18. 양도성예금증서 소지인(D씨)은 피신청인을 상대로 예금청구의 소(5억원)를 제기하였고, 2006.8.11. 피신청인의 패소로 양도성예금이 지급됨

2006.9.7. 대법원은 사기범들에 대하여 유죄(징역 10월~7년)를 선고하였고, 2007.8.3. A기업은 피신청인을 상대로 예금반환청구의 소(33억원)를 제기하였는데, 2008.4.17. 공탁하라는 법원의 화해권고 결정이 있었으나, 법원 공탁계는 피공탁자를 지정할 수 없음을 이유로 공탁을 거절하였고, 2008.5.26. A기업은 소를 취하함.

268) 공탁자: A기업, B기업, 피공탁자: OO건설. 2004.7.29 B기업은 공탁금회수청구권을 A기업에 양도함.

269) 자기앞수표(35억4천만원) 1억원권 15매, 3천만원권 68매.

양도성예금증서 1억원권 5매, 나머지 금액은 송금 및 현금 인출.

2007.11월경 신청인의 E씨는 사고수표 사본을 피신청인에게 우편으로 송부한 후 수표금 지급 가능 여부를 문의하였고, 2008.2월경 A기업은 사고수표(530백만원) 소지인 E씨를 장물취득죄로 고소하였으며, 그 후 포기각서(E씨로부터 수표에 관한 일체의 권리를 포기함)와 수표를 양도받고 고소를 취하함.²⁷⁰⁾

2008.6월경 A기업은 E씨로부터 회수한 수표(530백만원)로 수표금 지급을 청구하였으나 피신청인이 이를 거절함.

나. 당사자 주장

(1) 신청인 주장

피신청인은 A기업이 공탁금 사기사건의 피해자임과 본건 사고수표(530백만원)의 성격을 잘 알고 있으며, 신청인이 수표 前소지인으로부터 제출받은 포기각서(수표에 관한 일체의 권리를 포기함)와 함께 수표를 정상적으로 지급제시하였음에도 피신청인이 아무런 근거도 없이 그 지급을 거절하고 있음.

(2) 피신청인 주장

前소지인인 E씨가 정당한 소지인인 지 여부가 불명확한 상황에서 신청인이 그로부터 사고 수표를 양도받아 실물을 소지하고 있다는 이유로 수표금을 지급할 경우 예기치 못한 법적 분쟁에 휘말릴 우려가 있으므로 일단 신청인이 30백만원권 수표 1매로 소송을 제기하여 그 결과가 나오면 나머지 금액도 동일하게 처리하는 것이 바람직함.

다. 위원회의 판단

◆ 본 사건의 쟁점은 신청인을 정당한 소지인으로 볼 수 있는 지 여부 및 이득상환청구권이 인정되는 지 여부임.

(1) 실질적 자격을 갖춘 정당한 소지인인 지 여부

270) 신청인은 2008.2.25. 공탁공무원의 과실로 손해를 입었다는 이유로 국가를 상대로 손해배상 청구 소송을 제기함.

자기앞수표를 교부받은 소지인은 수표의 소지라는 사실만으로 형식적 자격을 갖게 되어 적법한 권리자로 추정되나, 수표금 지급사무를 처리하는 은행은 선량한 관리자로서의 주의를 기울여 그 사무를 처리할 의무를 부담하므로 통상적인 거래기준이나 경험에 비추어 당해 수표가 분실 혹은 도난·횡령되었을 가능성이 예상되거나 또는 수표소지인이 수표를 부정한 방법으로 취득하였다고 의심할 만한 특별한 사정이 존재하는 경우에는 그 실질적 자격에 대한 조사의무를 지게 됨.²⁷¹⁾

따라서 피신청인은 본건 수표가 금융사고에 연루되어 있다는 사실을 알고 있는 이상, 형식적 자격 이외에 실질적 자격을 조사하여 수표금의 지급 여부를 결정하여야 하는데, 다음과 같은 점을 고려할 때, 신청인을 정당한 수표소지인으로 단정하기 어려운바, 피신청인이 수표금의 지급을 거절한 것은 이유 있다 할 것임.

수표의 지급제시 기간은 10일에 불과함에도 본 건 관련 수표는 2004.11.5 발행되어 3년 5개월이 넘는 상당히 오랜기간 동안 전전유통되었고, 이 과정에서 본 건 수표를 선의 취득한 자가 존재했을 가능성을 배제할 수 없는 반면, 前소지인인 E씨는 장물취득죄로 고소되자 별다른 민사상 다툼없이 본 건 수표를 신청인에게 양도한 점으로 볼 때 적법한 원인에 기하여 수표를 취득하였다고 보기 어렵고, 또한 A기업이 공탁금 사기사건의 피해자로 추정된다고는 하나, 동 사를 본건 수표의 발행의뢰인 또는 본 건 수표 발행의 재원이 된 예금의 예금주로 단정할 수 없다는 점.

(2) 이득상환청구권 인정 여부

수표의 지급제시 기간(10일)이 도과하여 수표상의 권리가 소멸한 경우라도 수표소지인은 「수표법」 제63조에 의하여 이득상환청구권을 행사할 수는 있으나, 여기서 이득상환청구권이 있는 수표소지인이라 함은 그 수표상의 권리가 소멸할 당시의 정당한 소지인으로서 그 수표상의 권리를 행사할 수 있었던 자를 말하며,²⁷²⁾ 자기앞수표의 제시기간 경과 당시 그 소지인이 누구인지 또 그 소지인이 정당한 수표소지인인지 알 수 없는 경우에는 동 수표의 이득상환청구권을 양수함에 있어서는 지명채권 양도의 방법에 따른

271) 대법원 2002.2.26. 선고 2000다71494 판결 참조.

272) 대법원 1978.6.13. 선고 78다568 판결 참조.

절차를 밟아야만 동 양수를 발행인에게 주장할 수 있음.²⁷³⁾

본 사건에 있어서 본건 수표상의 권리가 소멸할 당시의 정당한 소지인이 누구인지 그리고, 수표의 양도인이 정당한 소지인인지 여부가 명확하지 아니한 바, 신청인이 양도인으로부터 본건 수표를 양도받은 사실만으로 이득상환청구권이 신청인에게 양도되었다고 볼 수 없음.

라. 결 론

신청인을 실질적 자격을 갖춘 정당한 소지인으로 보기 어렵고, 신청인에게 수표금의 이익상환청구권이 있다고 보기 어려운 바, 신청인의 신청은 이유 없어 이를 기각함이 타당함.

273) 대법원 1981.6.23 선고 81다167 판결 참조.

제6절 기 타

4-25 예금보장범위 설명 오류와 관련한 은행의 손해배상책임 유무

[기각] 신청인은 은행직원이 예금보장범위에 대하여 정확하게 설명하였다면 설명 당일 예금을 입금하거나 투자신탁에 예치하여 높은 수익률을 올릴 수 있었음에도 불구하고 부정확한 설명으로 인하여 손해가 발생하였다며 손해배상을 청구하였는 바, 은행직원이 예금보장범위를 잘못 설명한 사실은 인정되나 신청인이 은행직원의 잘못된 예금보장범위 설명으로 인하여 발생한 손해가 없으므로 은행에게 손해배상책임은 없음.(1999.3.16. 조정번호 제1999-4호)

가. 사실관계

신청인은 1998.7.31. A은행 지점(이하 “피신청인”이라 함)을 방문하여 피신청인의 예금담당대리 B씨에게 예금자보호법상 예금보장이 되는 은행예금에 대해 문의하자 위 B씨는 △△저축예금을 소개하면서 1998.7.31.까지 예금계좌를 개설하면 1998.8.1.이후 입금액에 대하여도 2000년말까지 원리금 전액이 보장된다고 설명하였으며 신청인은 동 예금계좌를 개설하고 133,106,051원을 입금함.

그 이후 신청인은 피신청인에게 1998.8.1. 이후 입금액의 이자에 대하여는 예금자보호법상 보장이 되지 않는데도 원리금 전액이 보장된다고 잘못 설명하였다는 항의함.²⁷⁴⁾

1998.11.19. 피신청인의 지점장은 신청인에게 1998.7.31. 신청인이 △△저축예금을 개설할 때 1998.8.1. 이후 입금되는 금액은 2000년말까지 원금만 보장됨에도 이자부분도 보장된다고 잘못 설명한 것을 인정하며 설명을 잘못된 부분에 대하여는 신청인에게 손해가 나지 않도록 해줄 것을 약속한다는 내용의 경위서를 작성해 줌.

나. 당사자의 주장

274) 신청인은 △△저축예금 개설 한달후에 1998.8.1.이후 입금액은 원금만 보장된다는 사실을 알게 되었다고 주장하고 있으며, 피신청인은 1998.8.1. 13:40분경 신청인이 전화로 동 예금의 예금보장범위를 잘못 설명한 데 대하여 항의하였다고 주장함.

(1) 신청인의 주장

사적으로 제3자로부터 위탁받아 관리운용하던 자금 약 530백만원의 운용방법과 관련하여 동 자금의 위탁자들이 투자신탁회사의 2년만기 펀드 또는 은행의 원리금전액 보장이 되는 예금중에서 좋은 상품을 선택하여 운용하라고 요청함에 따라 1998.7.31. 위 B씨와 상담하고 위 자금중 투자신탁회사에 예치하고 있던 일부 자금을 인출하여 피신청인에게 133백만원을 예금하였으며 나머지 자금 400백만원은 후에 입금할 계획이었음.

피신청인이 △△저축예금의 예금보장범위를 정확히 설명하였으면 1998.7.31. 위 자금 530백만원 전액을 예금하거나 투자신탁회사에 예치하여 높은 수익을 얻을 수 있었음에도 피신청인의 잘못으로 1998.7.31. 입금한 금액을 제외한 나머지 자금 400백만원에 대하여 원리금 전액보장을 받을 수 없게 되었으며 그동안 투자신탁회사의 수익률이 크게 하락하여 높은 수익을 얻을 수도 없게 됨.

따라서 피신청인은 1998.11.19. 확약한대로 1998.8.1. 이후 입금예정액에 대해서도 원리금 전액보장을 한다는 정부의 확약서를 발급해주거나 530백만원 전액에 대하여 당시 투자신탁회사에 예치하였으면 얻을 수 있었던 수익률인 연 17%에 상당하는 금액을 배상해 주어야 하며, 이 건과 관련하여 피신청인에게 항의하는 과정에서 피신청인의 본점 직원이 신청인 및 신청인의 모친에게 폭행을 가한데 따른 손해를 배상해 주어야 함.

(2) 피신청인의 주장

1998.7.31. △△저축예금의 예금보장범위와 관련하여 위 B씨가 1998.8.1.이후 입금액은 2000년까지 원금만 보장되는데도 이자까지 보장된다고 잘못 설명한 사실은 있으나 1998.8.1. 이후 신청인이 추가 입금한 금액이 없으므로 신청인에게 현실적으로 발생한 손해가 없으며, 신청인이 1998.8.1. 동 예금의 이자는 예금보장 범위에 포함되지 않는다고 알게된 이후 언제라도 동 예금액을 인출하여 나머지 400백만원과 함께 투자신탁회사에 예치할 수 있었음.

설령 신청인이 추가 입금하였다고 하더라도 △△저축예금계좌는 매월 발생이자만 원금에 가산되는 방식으로 운용되므로 결과적으로 이자도 대부분 예금보장이 되며, 다만 피신청인의 파산시 원금에 가산되지 않은 이자(최장 1개월)만 예금보장범위에서 제외되나

이에 따른 손해는 피신청인이 파산하여 예금이자 지급되지 않을 경우에 현실화되는 것인 바, 피신청인이 우량은행인 점 등을 감안할 때 지급불능 가능성은 거의 없다고 판단되므로 신청인의 요청을 수용할 수 없음.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 피신청인이 예금보장범위에 관한 설명을 잘못된데 따라 신청인에 대하여 손해배상책임이 있는지 여부임.

피신청인의 직원이 △△저축예금의 예금보장범위를 잘못 설명한 것과 관련하여 손해배상책임이 발생하기 위해서는 피신청인의 고의 또는 과실로 인한 위법행위 또는 채무불이행으로 신청인에게 손해가 발생하여야 하며, 이러한 신청인의 손해와 피신청인의 행위 사이에 상당한 인과관계가 있어야 됨.

먼저 피신청인의 위법행위가 있었는지 여부에 대하여 살펴보면, 예금자보호법시행령상 1998.8.1.이후 가입한 예금의 원금액이 20백만원 이상인 경우에는 2000년말까지 원금만 보장됨에도 피신청인은 1998.8.1. 이후 추가입금액에 대해서도 원리금 전액이 보장된다고 잘못 설명한 점이 인정됨.

그러나 △△저축예금은 매월 발생이자가 예금원금에 가산되는 방식으로 운용되므로 매월 원금에 가산되는 이자는 예금보장범위²⁷⁵⁾에 포함되어 결국 피신청인의 설명은 대부분 정확하다고 할 수 있고,²⁷⁶⁾ 다만 피신청인의 파산시 원금에 가산되지 않은 이자(최장 1개월)의 보장 여부에 대한 설명만 잘못되었다고 할 수 있음.

다음으로 피신청인이 △△저축예금의 예금보장범위에 대하여 일부 잘못 설명한데 따

275) 2000년말 이전에 금융기관이 지급정지되거나 파산하는 경우에

- 1998.7.31. 이전에 가입한 예금은 2000년말까지 원리금 전액 보장
- 1998.8.1. 이후에 가입한 예금은 2000년말까지 다음과 같이 보장 : 예금원금이 20백만원 미만인 경우에는 20백만원 한도내에서 예금원금과 예금보험공사 운영위원회가 정하는 금리수준의 이자를 보장하고, 예금원금이 20백만원 이상인 경우에는 예금원금만 보장

276) 예금보험공사의 질의회신(기부 0105-223, 1999.2.22.) : “매월 발생하는 이자가 원가되는 상품의 경우에 원가된 이자는 원금에 준하여 보호됩니다.”

라 신청인에게 손해가 발생하였는지에 대하여 살펴보면, 신청인이 1998.7.31. 예금한 금액 133백만원에 대하여는 예금자보호법상 예금원리금 전액이 보장되며 1998.8.1. 이후에는 신청인이 동 예금에 추가 입금하지 않아 예금원리금 지급불능상황이 있을 수 없으므로 예금보장여부와 관련하여 신청인에게 현실적으로 손해가 발생한 사실이 없음.

또한 신청인은 위 B씨가 △△저축예금의 예금보장범위에 대해 잘못 설명함에 따라 투자신탁회사에 자금운용할 수 있는 기회를 상실하였으므로 신청인이 투자신탁회사에 운용하였으면 얻을 수 있었을 수익상당액의 손해를 배상하여야 한다고 주장하고 있으나, 신청인이 주장하는 나머지 자금 400백만원에 대하여 신청인이 동 금액을 입증할 수 있는 증빙을 제출하지 않고 있어 신청인이 주장하는 손해가 발생하였는지 여부를 객관적으로 확인할 수 없을 뿐만 아니라 설령 나머지 자금 400백만원이 확인된다고 하더라도 다음과 같은 점을 감안할 때 신청인의 주장을 인정하기 어려운 것으로 판단됨.

① △△저축예금은 매월 이자가 원금에 가산되는 방식의 예금이므로 만일 신청인이 1998.8.1. 이후 나머지 400백만원을 동 예금에 추가입금하였다면 원리금 대부분이 보장되는 점.

② 1998.7.31.에 예금한 133백만원에 대해서도 신청인은 1998.8.1. 이후 입금액부터는 예금자보호법상 예금원리금만 보장된다는 사실을 알게된 시기(1998.8.1. 또는 1998.8월중)에 언제라도 동 금액을 인출하여 투자신탁회사에 예치 운용할 수 있었다는 점.

신청인의 요청내용중 예금원리금 전액보장에 관한 정부의 확약서 발급, 피신청인 직원의 폭행에 따른 손해배상 등은 금융분쟁조정위원회의 조정대상이 아니므로 이에 대하여는 살필 필요가 없음.

라. 결 론

그렇다면 피신청인이 예금보장범위를 정확하게 설명하지 아니함으로 인하여 신청인에게 객관적으로 발생한 손해는 없다 할 것임.

[기각] 피신청인 직원이 신청인이 아닌 제3자에게 비밀번호를 임의로 변경해 줌에 따라 피신청인에 대하여 민법 제750조(불법행위의 내용)에 따른 손해배상책임을 묻기 위해서는 당해 타인과 신청인과의 관계, 변경당시 신청인이 처한 상황, 비밀번호를 변경처리하게 된 경위 등을 종합적으로 고려하여 피신청인이 신청인에 대한 보호의무를 위반하여 위법성을 띤 행위여야 할 뿐 아니라, 이러한 위법한 행위로 인해 신청인에게 손해가 발생하여야 할 것임.(2006.2.14. 조정번호 제2006-2호)

가. 사실관계

신청인이 2002.11.21. 교통사고로 인하여 뇌사상태에 있는 상황에서 ○○은행(이하 “피신청인”이라 함) 지점은 2002.12.2. 신청인의 누나인 A씨의 요청에 따라 신청인 명의 예금계좌(이하 “본건 예금”이라 함)의 비밀번호를 변경하였음.

은행에 따르면 A씨는 신청인의 신분증, 입원확인서, 호적등본 등을 소지하고 내접하여 신청인이 배우자와 이혼하였고 연로한 부모님(父 82세, 母 76세)과 미성년자 자녀 3명(15세, 13세, 7세)만 있어 A씨가 집안의 모든 일을 처리해야 한다며 본건 예금의 비밀번호를 변경해 줄 것을 요청하였고, 이에 피신청인 담당직원은 신청인이 입원한 병원에 전화하여 신청인이 뇌사상태에 있음을 확인한 후 비밀번호를 변경처리하였다고 함.

수사결과 통장 및 카드의 경우 신청인의 어머니가 A씨에게 “병원에 필요한 게 많은데 난 까막눈이고 글도 모르니까 신청인에게 들어가는 돈을 사용하라”고 하면서 주었다고 하며, A씨는 2002.12.23~2003.3.3. 기간중 신청인 명의 카드(현금카드 기능 포함) 및 통장을 이용해 총 21건, 금 11,464,000원을 인출한 바 있음.²⁷⁷⁾

A씨는 수사과정에서 자신이 인출한 금액을 신청인의 보험료, 간병인비, 생활비, 신청

277) 부정인출 금액과 관련하여 신청인은 수사기관에 A씨가 2002.12.23.~2004.3.22. 기간중 총 104회, 금 52,071,000원을 부정인출 하였다고 주장하고 있는데 반해, 수사결과 상기 기간중 91회, 금44,997,900원이 인출되었으나 이중 A씨는 2002.12.23.~2003.3.3.기간중 금11,464,000원을 인출하였고 동 기간이후 인출된 금액은 A씨와는 무관하다고 함.

인 명의 타금융기관 적금불입 등으로 사용하였으며, 2003.3.3. 통장과 도장은 B씨(A씨의 언니)에게, 카드는 신청인의 어머니에게 주었다고 진술한 바 있음.

한편, B씨에 따르면 2003.8월경 신청인이 카드를 이용해 은행에서 현금을 인출한 것을 목격한 사실이 있다고 함.

나. 당사자의 주장

(1) 신청인 주장

교통사고로 뇌사상태에 있다가 14일만에 의식을 회복하였는데, 그 사이 은행에서 본인 의사를 확인하지도 않고 임의로 타인에게 예금계좌의 비밀번호를 변경해 주어 타인이 무단으로 예금을 인출하여 사용하였으므로 피신청인은 신청인이 입은 손해를 배상하여야 함.

(2) 피신청인 주장

비밀번호 변경시 신청인이 뇌사상태임을 확인하였고, 신청인을 보호해 줄 보호자가 없는 상황에서 누나 A씨가 병원비 및 생활비를 인출하기 위하여 비밀번호 변경을 신청하였고, 신청인이 수사기관에 A씨를 고발하였으나 무혐의로 결정되었는 바, 은행의 업무 처리에 과실이 있었다고 할 수 없으므로 신청인의 주장을 수용할 수 없음.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 예금계좌의 비밀번호 임의변경과 관련하여 피신청인에 대하여 불법행위로 인한 손해배상책임이 발생하는지 여부라 할 것임.

본건과 같이 피신청인 직원이 신청인이 아닌 제3자에게 비밀번호를 임의로 변경해 줌에 따라 피신청인에 대하여 민법 제750조(불법행위의 내용)에 따른 손해배상책임을 묻기 위해서는 당해 타인과 신청인과의 관계, 변경당시 신청인이 처한 상황, 비밀번호를 변경처리하게 된 경위 등을 종합적으로 고려하여 피신청인이 신청인에 대한 보호의무를 위반하여 위법성을 띤 행위여야 할 뿐 아니라, 이러한 위법한 행위로 인하여 신청인에게

손해가 발생하여야 할 것임.

본건에 있어 신청인은 피신청인의 비밀번호 임의변경에 따라 손해가 발생하였으므로 피신청인이 이를 배상하여야 한다고 주장하나, 다음과 같은 점에 비추어 볼 때 피신청인의 손해배상책임을 인정하기 어려움.

① 다음과 같은 제반상황을 감안할 때 본건에 있어서 피신청인이 비밀번호를 변경해 준 것이 사회일반의 정의관념에 반하여 위법하거나 고객에 대한 보호의무를 저버린 행위로 보기 어려운 점.

② 당시 신청인은 뇌사상태로 의식불명이어서 사회통념상 일정범위내에서 대리관계를 인정할 필요성이 있는 점.

③ A씨가 비록 적법하게 대리권을 부여받지는 않았으나, 부모가 연로하고 자녀가 미성년이어서 신청인에게 있어서는 사실상 보호자 역할을 담당하고 있었다고 보여지고, 당시 신청인의 병원 치료비는 물론 부모 및 자녀의 생활비 등에 충당하기 위해서는 예금인출이 불가피하였다고 인정되며, 또한 수사결과 A씨의 이러한 비밀번호 변경 및 예금인출에 대해 무혐의처분이 내려진 점.

④ 피신청인으로서도 호적등본을 확인함은 물론 신청인이 입원중인 병원에 문의하여 신청인의 상태까지 확인하는 등 업무처리에 있어 고객보호의무를 위배하였다고 볼 수 있을 만한 정황이 보이지 않는 점.

⑤ 한편, 설령 피신청인이 비밀번호를 변경한 업무처리에 위법성이 인정된다고 하더라도 다음과 같은 제반정황에 비추어 볼 때 본건에 있어 신청인에게 손해가 발생하였다고 보기 어려운 점.

⑥ 수사결과 A씨가 2002.12.23.~2003.3.3.중 인출한 21건, 금 11,464,900원의 경우 신청인의 보험료, 간병인비, 생활비, 신청인 명의 타 금융기관 적금불입 등으로 사용한 내역과 거의 일치하고 있어 동 기간중 인출된 금액이 신청인을 위하여 사용된 것으로 보이며, 2003.3.3. 이후 인출된 금액에 대해서도 신청인이 계속적으로 치료를 받고 있었고 신청인이 부모와 동거하면서 부양하고 있었던 점을 감안할 때 신청인의 치료비용은 물론 생활비 및 자녀 양육비 등으로 사용되었을 개연성이 크다는 점.

⑦ 신청인도 2003.8월 같은 해 11월 및 12월 세 차례에 걸쳐 직접 본건 예금을 인출하는 등 2003.3.3. 이후 일정시점부터는 신청인이 직접 본건 예금을 관리하고 있었던 것으로 보이는 점.

라. 결 론

피신청인의 비밀번호 임의변경에 따라 손해가 발생하였다는 신청인의 주장과 그에 따른 손해배상청구는 이유 없어 기각함.

4-27 계좌비밀번호 유출 등에 따른 텔레뱅킹 계좌이체금 반환청구

[기각] 전자금융서비스 이용약관상 피신청인은 자금이체를 수반하는 텔레뱅킹의 경우 자금이체 비밀번호, 보안카드 비밀번호 등이 사전에 등록된 자료와 일치할 경우 서비스 이용자를 본인으로 인정하고 서비스를 제공한다고 정하고 있는 점, 지정번호가 접근매체에 해당한다 하더라도, 전자금융거래법상 접근매체의 누설, 노출, 방치 등 접근매체의 위조, 변조에 대한 이용자의 고의나 중대한 과실이 있는 경우 금융기관은 면책되는 바, 본건의 경우 신청인이 텔레뱅킹에 필요한 계좌번호, 비밀번호 등을 알려준 데 대한 중대한 과실이 있는 점 등을 감안시 피신청인이 전자금융거래법상 책임을 진다고 보기는 어렵다 할 것임.(2010.9.14. 조정번호 제2010-78호)

가. 사실관계

2010.5.27. 신청인은 보이스피싱 사기범에 속아 피신청인 텔레뱅킹서비스에 가입(집전화번호를 지정번호로 등록)하고, 텔레뱅킹 거래시 필요한 정보 등을 유출함.

◆ 텔레뱅킹 이용 절차 : 지정번호로 1588-**** 등으로 전화(ARS)

- 신규이용절차: 서비스코드 등록 → 주민번호 → 보안카드번호 → 가입자번호 → 이체 비밀번호 등록 → 이체비밀번호 재입력
- 이체선택 → 자금이체 → 자행, 타행이체 선택 → 주민번호 → 텔레뱅킹이체비밀번호 → 보안카드번호 → 계좌비밀번호 → 이체금액 → 입금계좌번호 → 이체내용 확인 → 이체실행
- 지정번호 등록시 지정번호로만 텔레뱅킹 거래 가능

사기범은 당일 11:02~11:34경 텔레뱅킹으로 신청인의 계좌에서 3회에 걸쳐 14,140,000 원을 타인계좌로 이체하였는데, 본건 텔레뱅킹 거래시 발신번호는 ○○은행(이하 “피신청인”이라 함) 전산화면상으로는 지정번호로 확인되었으나, 통신회사의 “통화사실 확인 내역”에 의하면 신청인이 지정번호로 통화한 사실이 없음이 확인됨.

신청인이 당일 11:55에 피신청인 직원에게 전화하여 본인 예금은 검찰청에서 보안설 정하여 이상이 없다고 하자 피신청인 직원이 보이스피싱을 의심하여 신청인계좌에서 이 체된 사실을 확인한 후 상대계좌를 지급정지하였고, 신청인은 12:10 ◇◇경찰서에 피해 내용을 신고함.

나. 당사자 주장

(1) 신청인 주장

신청인이 보이스피싱 사기단에 속아 개인정보를 유출하였다 하더라도 본건 텔레뱅킹서 비스는 가입시 등록된 지정번호를 통해서만 거래가 가능한 것인데, 본건은 지정번호에서 통화된 사실이 없고 피신청인의 전산보안망 허술로 인하여 발생된 것이므로 인출액 전 액의 보상을 구함.

(2) 피신청인 주장

신청인이 사기범에게 속아 신청인의 예금계좌 및 비밀번호 등 거래에 필요한 정보를 유출하였고, 본건 거래 또한 피신청인 전산에 기 등록된 지정번호로 접속되어 거래가 이 루어진 것이며, 피신청인은 지정번호 조작여부를 알 수 없고 이에 대한 책임도 없으므로 피해금액을 보상하여 줄 수 없음.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 전자금융거래기본법상, 일반 민사상 금융기관의 책임여부라 할 것임.

(1) 「전자금융거래기본법」상 피신청인의 책임여부

본건의 경우, 신청인이 지정번호를 통해 텔레뱅킹 거래를 한 사실이 없다고 하더라도 다음과 같은 점에 비추어 피신청인이 전자금융거래법상 책임을 진다고 보기는 어렵다 할 것임.

① 「전자금융거래법」은 전자금융거래시 접근매체의 위조나 변조로 발생한 사고, 계약 체결 또는 거래지시의 전자적 전송이나 처리과정에서 발생한 사고로 인하여 이용자에게 손해가 발생한 경우, 원칙적으로 금융기관이 책임을 지도록 규정하고 있으나, “접근매체”라 함은 전자금융거래에 있어서 거래지시를 하거나 이용자 및 거래내용의 진실성과 정확성을 확보하기 위하여 사용되는 「전자금융거래법」 제2조 10호 각 목의 수단 또는 정보를 말하는데, 지정번호가 동법에서 말하는 접근매체에 해당한다고 단정적으로 말하기 어려운 측면이 있고 피신청인의 「전자금융거래 기본약관」 제12조(거래지시의 처리기준)에 의하면 피신청인은 이용자의 거래지시에 포함된 계좌번호, 비밀번호, 이용자번호 등의 접근매체 정보를 신고된 것과 대조하여 그 일치여부를 확인한 후에 거래지시를 처리하도록 규정하고 있고, 피신청인 「전자금융서비스 이용약관」 제5조(이용자 확인방법)에 따르면 피신청인은 자금이체를 수반하는 텔레뱅킹의 경우 자금이체비밀번호, 보안카드 비밀번호 또는 일회용비밀번호발생기(OPT)에서 생성되는 비밀번호, 출금계좌 비밀번호가 사전에 피신청인에 등록된 자료와 일치할 경우 서비스 이용자를 신청인 본인으로 인정하고 서비스를 제공한다고 정하고 있으며, 지정번호제도는 전자금융거래의 보안강화 차원에서 도입된 것으로 볼 여지가 있는 점.

② 지정번호가 접근매체에 해당한다 하더라도, 「전자금융거래법」 제9조 제2항 및 피신청인 「전자금융거래약관」 제20조에 의하면 접근매체의 누설, 노출, 방치 등 접근매체의 위조, 변조에 대한 이용자의 고의나 중대한 과실이 있는 경우 금융기관의 면책을 규정하고 있는 바, 본건의 경우 신청인이 텔레뱅킹 거래에 필요한 계좌번호, 비밀번호 등을 알려준데 대한 중대한 과실이 있다 할 것인 점.

(2) 일반 민사상 손해배상책임 여부

통상의 예금 인출의 경우 예금청구인이 예금통장을 제시하고, 예금청구서의 비밀번호가 신고된 비밀번호와 일치하며, 예금청구서에 날인된 인영과 예금통장의 그것을 대조해

보아 사회통념상 일반적으로 기대되는 업무상의 상당한 주의를 기울여 세심하게 살펴 보았을 때 그 상위를 발견할 수 없을 정도라면 은행이 정당한 예금주나 그로부터 예금을 인출한 권한을 수여받은 자가 아닌 자에게 예금을 지급하였다 하더라도 이는 채권의 준점유자에 대한 변제로서 선의로 과실 없이 지급한 것으로 유효하다 할 것임.

한편, 피신청인의 「전자금융거래 기본약관」 제12조(거래지시의 처리기준)는 피신청인은 이용자의 거래지시에 포함된 계좌번호, 비밀번호, 이용자번호 등의 접근매체 정보를 신고된 것과 대조하여 그 일치여부를 확인한 후에 거래지시를 처리하도록 규정하고 있고, 「전자금융서비스 이용약관」 제5조에 의하면 자금이체를 수반하는 텔레뱅킹의 경우 자금이체비밀번호, 보안카드 비밀번호 또는 일회용비밀번호발생기(OPT)에서 생성되는 비밀번호, 출금계좌 비밀번호가 사전에 피신청인에 등록된 자료와 일치할 경우 서비스 이용자를 신청인 본인으로 인정하고 서비스를 제공한다고 정하고 있음.

텔레뱅킹의 경우, 은행은 예금주의 확인을 예금통장의 제시, 통장의 비밀번호의 확인 및 예금청구서에 날인된 인영의 비교 등의 방법을 통하지 않는 대신 주민등록번호, 예금계좌번호 및 비밀번호등을 컴퓨터를 통하여 확인하고 있고, 본건은 피신청인에게 접수된 지정번호, 텔레뱅킹 거래시 필요한 정보가 모두 일치하여 계좌 이체를 한 것이므로, 피신청인의 계좌이체에 대한 책임을 묻기 어렵다 할 것임.

라. 결 론

피신청인은 신청인에 대하여 손해를 배상할 책임이 없다 할 것이므로 신청인의 청구는 이유 없어 이를 기각함.

제5장

신용카드 등

제1절 신용카드의 제3자 부당사용

5-1 카드 분실 후 카드 부정사용 대금에 대한 회원의 책임

[가각] 신청인은 카드부정사용의 매출전표를 확인하면 신청인의 이름조차 모르는 권한 없는 자에 의하여 사용되었음이 명백하고 서명 상이를 확인하지 아니한 피신청인 측에 과실이 있다고 주장하나, 신청인의 주장을 인정할 만한 증거가 부족하고, 카드가맹점이 여신전문금융업법을 위배하여 카드거래를 하였다고 볼 수 없는 점 등에 비추어 신청인의 청구는 이유가 없는 것으로 판단됨.(2000.9.5. 조정번호 제2000-35호)

가. 사실관계

1993.10.12. 신청인은 A은행 ○○지점에서 ◇◇신용카드(이하 “피신청인”이라 함) 회원으로 가입하였고, 카드발급 이후 7회에 걸쳐 사용한 내역이 확인되었으며, 전표상의 서명중 2건은 다른 전표와 상이하게 나타남²⁷⁸⁾.

1996.8.4. 카드가 갱신 발급되었고 신청인은 1996.10.5. A은행 ○○지점에서 동 카드를 직접 수령하였으며, 신청인의 카드로 1999.7.27. 금 28만원의 물품을 구입한 사실이 확인되었고 카드사는 신청인에게 카드사용 대금을 청구함.

신청인은 1999.12.30. 위 카드사용 대금을 납입하였고 피신청인은 신청인의 요구에 의해 2000.1.7. 탈회처리를 함.

나. 당사자의 주장

278) 5건은 영문으로 2건은 한문으로 기재되어 있음.

(1) 신청인의 주장

1996년 카드수령 직후 타사카드 사용으로 본건 카드를 사용할 필요성이 없어 카드사에 전화로 분실신고 및 해지신청을 하였음에도 카드사의 전산장애 등으로 타인의 카드 사용 대금이 부당하게 청구되었으므로 납입한 카드사용대금은 신청인에게 반환되어야 함. 카드전표상의 서명을 살펴보면 “AAa”으로 되어있어 신청인의 이름조차 잘 모르는 자에 의하여 사용되었음이 명백하므로 신청인이 카드사용 대금을 부담하는 것은 부당함.

(2) 피신청인의 주장

신용카드의 해지신청은 거래은행에서 신청하여야 해지가 가능하므로 당사로 해지신청을 하였다는 주장은 설득력이 없음. 카드분실신고가 당사의 전산장애로 인해 처리되지 않았다고 주장하나, 당시 전산시스템상 그러한 장애가 발생할 여지가 없고 전산장애가 발생한 경우에는 사고기록부에 기재한 후 추후 절차에 의해 처리되므로 신청인의 주장은 막연한 추측에 불과함.

가맹점의 불법매출(현금대출이나 매출전표 유통 등)이 아닌 한 단지 자신의 서명과 상이하다는 주장만으로 가맹점이 약관에 위배한 거래를 하였다거나 카드사가 책임을 진다고 할 수는 없음.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 신청인의 카드분실신고 및 해지신청에 대하여 피신청인의 업무처리가 적정하였는지의 여부와 카드 부정사용에 있어 가맹점의 과실여부라 할 것임.

(1) 피신청인의 업무처리의 적정성 여부

신청인은 카드 수령직후 본건 카드를 사용할 필요성이 없어 카드사에 전화로 분실신고 및 해지신청을 하였으나 카드사의 전산장애 등 업무처리상 과실로 인해 본건 카드가 권한없는 자에 의하여 부정사용 되었다고 주장하나, 다음과 같은 사정을 종합할 때 신청인의 주장을 인정할 만한 증거가 부족함.

① ◇◇카드 회원약관 제17조에 의하면 “카드의 분실 및 도난신고는 소정양식에 의한

서면신고를 하여야 한다. 이 경우 카드사나 은행은 접수사실을 확인할 수 있는 사항을 알려야 하며, 이 경우 회원은 이러한 사항을 확인 하여야 한다.”라고 규정하고 있는 점에 비추어, 서면신고가 아닌 전화상의 신고의 경우에는 고객이 접수사실을 확인할 만한 증거를 확보하여야 하는 의무를 진다고 볼 수 있는 점.

② 피신청인의 전산장애로 인하여 신청인의 분실신고가 적절하게 처리되지 않았는지의 여부는 관련서류 등이 보존기간(3년)의 만료로 모두 폐기되어 사실상 확인이 불가능한 점.

③ ◇◇카드 업무협약 제62조 제8항에 의하면 “카드해지신청은 회원은행에서 일정한 절차에 의하여야” 하므로 신청인이 피신청인에게 해지신고를 하였다 하더라도 피신청인에게 대항할 수 없는 점.

(2) 카드 가맹점의 과실여부

「여신전문금융업법」 제19조 제2항은 “신용카드가맹점은 신용카드에 의한 거래를 할 때마다 신용카드상의 서명과 매출전표상의 서명이 일치하는지를 확인 하는 등 당해 신용카드가 본인에 의하여 정당하게 사용되고 있는지 여부를 확인하여야 한다.”라고 규정하고 있음. 가맹점이 위와 같은 주의의무를 게을리 하여 손해를 자초하거나 확대하였다면 그 과실의 정도에 따라 회원의 책임을 감면함이 거래의 안전을 위한 신의성실의 원칙상 정당하다고 할 것임.²⁷⁹⁾

신청인은 카드부정사용의 매출전표를 확인하면 “AAa”으로 기재되어 있어 신청인의 이름조차 모르는 권한 없는 자에 의하여 사용되었음이 명백하고 서명 상이를 확인하지 아니한 피신청인측에 과실이 있다고 주장하나, 다음과 같은 사정을 종합할 때 본건 카드 부정사용에 대하여 가맹점의 과실을 인정하여 신청인의 책임을 감면할만한 증거가 부족하다고 할 것임.

① 카드가맹점이 신용카드거래를 가장하여 매출전표를 작성하는 등 「여신전문금융업법」 제19조(가맹점의 준수사항) 제4항을 위배하여 카드거래를 하였다고 볼 수 없는 점.

279) 대법원 1991.4.23. 선고 90다15129 판결 참조.

② 카드가맹점이 카드상의 서명과 매출전표상의 서명이 일치하는 지를 확인하였는지에 대하여는, 본건 카드의 소재를 알 수 없고 동 카드에 어떻게 서명이 되어 있는지를 확인할 수 없어 신청인의 서명이 아니라는 주장만으로는 가맹점의 과실을 단정할 수 없는 점.

③ 본건 카드로 갱신 발급되기 전 신청인이 사용한 매출전표 확인결과, 총 7회의 사용 중 5건은 영문으로 기재되어 있으나 2건은 한문으로 기재되어 있어 신청인이 카드거래를 함에 있어 서명의 일관성을 유지하였다고 볼 수 없는 점.

라. 결 론

카드 부정사용대금이 피신청인이나 카드가맹점의 「여신전문금융업법」 및 ◇◇카드 회원약관에 위배되어 발생하였다고 볼 수 없으므로 신청인의 청구는 이유가 없는 것으로 판단됨.

5-2 신용카드의 제3자 보관으로 인한 카드 부정사용의 해당 범위

[인용] 신용카드개인회원규약 제20조(카드의 분실·도난신고와 보상)에는 “대여, 양도, 담보제공, 불법대출, 제3자 보관 등으로 인한 부정사용”의 경우 카드사가 보상을 하지 않도록 규정하고 있는데, 여행을 함께 하면서 공동으로 관리하고 있는 동행자의 가방에 잠시 보관한 경우는 규약에서 정하는 “제3자 보관”에 해당한다고 보기 어려움.(2006.1.10. 조정번호 제2005-95호)

가. 사실관계

신청인은 2005.8.27. 가족과 함께 태국을 여행하던 중 피신청인이 발급한 신청인 명의의 신용카드(이하 “본건 카드”라 함)를 분실하여 같은 날 20:06 피신청인에게 분실신고하였으나 신고전인 19:56경 제3자에 의해 2,038,370원(미화 1,927달러)이 부정사용되었음.

나. 당사자의 주장

(1) 신청인 주장

태국 여행중 분실이나 도난이 염려되어 해외에서는 사용하지 않는 본건 카드를 남편이 소지하고 있는 가방에 넣어 두었다가 분실하였는 바, 이를 제3자 보관으로 보아 카드사가 보상을 거절하는 것은 부당함.

(2) 피신청인 주장

「신용카드회원규약」상 제3자 보관 등으로 인한 부정사용시 카드사는 보상하지 않도록 규정되어 있는 바, 남편도 제3자에 해당하므로 신청인의 주장을 수용할 수 없음.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 본건 카드분실에 따른 부정사용이 신용카드 규약상 회원의 책임으로 규정된 제3자 보관으로 인한 부정사용에 해당하는지 여부라 할 것임.

(1) 관련 약관의 내용

본건 「신용카드개인회원규약」(이하 “규약”이라 함) 제20조(카드의 분실·도난신고와 보상) 제3항 제2호에는 “대여, 양도, 담보제공, 불법대출, 제3자 보관 등으로 인한 부정사용”의 경우 카드사가 보상을 하지 않도록 규정하고 있고, 규약 제3조 제2항은 “카드의 소유권은 카드사에 있으므로 회원은 이 카드를 타인에게 대여하거나 양도 또는 담보의 목적으로 이용할 수 없으며, 선량한 관리자로서 주의를 다하여 카드를 이용, 관리하여야 한다.”고 규정하고 있음.

(2) “제3자 보관”으로 인한 부정사용에 해당하는지 여부

피신청인은 제3자인 남편이 본건 카드를 보관하고 있었으므로 규약 제20조에 따라 신청인에 대한 보상을 거절하고 있으나, 다음과 같은 점에서 피신청인은 본건 카드 부정사용금액을 신청인에게 보상할 책임이 있다고 할 것임.

① 규약 제20조 제3항 제2호상의 “대여, 양도, 담보제공”은 신용카드의 사용·수익에 관한 권한을 제3자에게 부여하는 것으로 규약 제3조에서 금지하는 행위일 뿐 아니라 제

3자로 하여금 부정사용의 기회를 제공하는 전형적인 경우에 해당된다고 볼 수 있는 반면, “제3자 보관”은 신용카드의 사용수익권이 아닌 사실상의 점유만을 타인에게 위탁하는 행위로 규약 제3조에서 금지하는 사항은 아니라는 점.

② 보상거절사유로서의 “제3자 보관”은 신용카드를 타인의 점유 관리하에 둠으로써 부정사용의 위험이 증가하거나 용이해질 수 있는 경우를 의미한다고 해석하는 것이 신의 성실의 원칙에 따른 합리적인 해석이라고 할 것인 점.

③ 본건과 같이 신용카드를 함께 여행하는 남편의 가방에 넣어둔 경우에는 신용카드를 신청인의 지배권이 미치지 않는 영역에 놓아두거나 위탁하였다고 볼 수 없고, 신청인의 공동점유로 볼 수 있어 신용카드의 부정사용 위험을 증가시켰다고 할 수 없어 신청인이 선량한 관리자의 주의의무를 다하지 않았다고 보기 어려운 점.

라. 결 론

그렇다면 본건의 경우 규약에서 정하는 “제3자 보관”에 해당한다고 보기 어려우므로 피신청인은 신청인에게 본건 카드의 부정사용금액 금2,038,370원을 배상할 책임이 있음.

5-3 임의 발급된 가족카드 부정사용에 따른 책임 유무

[인용] 신청인 또는 신청인의 배우자가 본건 가족카드 갱신발급을 신청한 사실이 없으며, 갱신발급예정일로부터 6개월간 사용하지 않았음에도 피신청인이 본건 가족카드를 발급하였는 바, 신청인이 단순히 가족회원 신용카드를 1주일간 보관했다는 사실만으로 피신청인의 책임을 제한하는 곤란하다고 판단되므로 본건 가족카드 이용계약은 성립되지 않은 것으로 판단됨.(2008.4.15. 조 정번호 제2008-21호)

가. 사실관계

신청인은 1990.2.7. 신청인 명의의 계좌에서 결제가 이루어지는 ○○카드의 본인카드와 배우자 A씨 명의의 가족카드(이하 “본건 가족카드”라 함)를 피신청인으로부터 발급받아 사용해 왔음.

2007.11.22. 피신청인은 갱신발급 예정일로부터 과거 6개월 이상 사용하지 않아 발급대상이 아닌 본건 가족카드와 신청인 명의의 신용카드를 갱신발급²⁸⁰⁾하여 2007.12.3.(월) 서울특별시 광진구 구의동 소재 신청인의 사무실에 근무하는 직원에게 교부하였고, 동 직원은 신청인에게 본건 가족카드를 전달함.

신청인이 자신의 사무실 서랍 속에 본건 가족카드를 보관하던 중 2007.12.8.(토) 불상의 피의자가 동 가족카드 등을 절취하여 도주하였고, 같은 날 20:19:01 ◇◇은행 영업부 현금지급기에서 현금서비스로 50만원, 그 다음 날 15:14:32 ◇◇은행 지점 현금지급기에서 현금서비스로 70만원, 15:15:46 같은 현금지급기에서 현금서비스로 70만원, 같은 날 15:32:17 △△은행 지점 현금지급기에서 현금서비스로 60만원, 총 250만원이 인출²⁸¹⁾되었고, 신청인은 같은 날 22:46:01 신용카드 분실신고를 하고, 관할 경찰서에 도난신고를 함.

나. 당사자 주장

(1) 신청인 주장

가족카드 갱신발급에 대하여 서면 동의하지 않았는 바, 피신청인이 임의 발급한 가족카드의 부정사용에 따른 책임을 부담할 수 없음.

(2) 피신청인 주장

임의 발급된 신용카드를 반송하거나 폐기하지 않고 1주일 동안 사무실 서랍 속에 둬으로써 본건 신용카드 교부를 추인하였음은 물론 단 한 번의 비밀번호 입력 오류 없이 현금서비스 금액이 인출된 것은 신용카드 관리에 대하여 신청인에게 과실이 있음이 명백한바, 「○○카드 개인회원 약관」에 따라 신청인에게도 책임이 있음.

280) 「여신전문금융업법」 제14조 및 동 시행령 제6조의6 그리고 「○○카드 회원약관」 제4조 제2항 및 제3항은 본인 및 가족회원의 갱신발급과 관련하여 갱신발급예정일로부터 6개월 이내 카드사용 실적이 없는 회원에 대해서는 회원의 서면동의를 있는 경우에 한하여 갱신할 수 있도록 명기하고 있음.

281) 2007.12.9. 15:34:32 △△은행 지점 현금지급기에서 본건 가족카드를 이용한 현금서비스 인출시(50만원을 입력)에는 1일 이용한도인 200만원 초과로 승인이 거절됨.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 신청인의 신용카드 교부에 대한 추인 여부 및 신용카드 관리책임 유무라 할 것임.

신청인 또는 가족회원인 신청인의 배우자 A씨가 본건 가족카드 갱신발급을 신청한 사실이 없으며, 갱신발급 예정일로부터 6개월간 사용하지 않았음에도 피신청인이 본건 가족카드를 발급하였는바, 이는 「여신전문금융업법」 제14조 제1항,²⁸²⁾ 「여신전문금융업법 시행령」 제6조의6,²⁸³⁾ 「○○카드 개인회원약관」 제4조 제2항 및 제3항²⁸⁴⁾에 반하므로 본건 가족카드 이용계약은 성립되지 않은 것으로 판단됨.

그러나 피신청인은 신청인이 임의 발급된 본건 가족카드를 반송하거나 폐기하지 않고 1주일 동안 사무실 서랍 속에 둬으로써 본건 가족카드 교부를 추인하였음은 물론 한 번의 비밀번호 입력 오류도 없이 현금서비스 금액이 인출된 것은 신용카드 비밀번호 관리에 대하여 신청인에게 과실이 있으므로 「○○카드 개인회원약관」 제19조 제2항 및 제9

282) 제14조(신용카드·직불카드의 발급) ① 신용카드업자는 발급신청이 있는 경우에 한하여 신용카드 또는 직불카드를 발급할 수 있다. 다만 이미 발급한 신용카드 또는 직불카드의 갱신 또는 대체발급에 대하여 대통령령이 정하는 바에 따라 신용카드회원 또는 직불카드회원의 동의를 받은 경우에는 그러하지 아니하다.

283) 제6조의6(신용카드·직불카드의 갱신 또는 대체발급) 법 제14조제1항 단서의 규정에 의하여 신용카드업자는 다음 각호의 1에 해당하는 경우 신용카드·직불카드를 갱신 또는 대체 발급할 수 있다.

1. 갱신 또는 대체발급 예정일전 6월 이내에 사용된 적이 없는 신용카드·직불카드는 당해 신용카드·직불카드 회원으로부터 갱신 또는 대체발급에 대하여 서면동의(「전자서명법」 제2조 제1호의 규정에 의한 전자문서로서 동법 제2조제3호의 규정에 의한 공인전자서명이 있는 전자문서에 의한 동의를 포함한다)를 얻은 경우
2. 갱신 또는 대체발급 예정일전 6월 이내에 사용된 적이 있는 신용카드·직불카드는 갱신 또는 대체발급 예정일부터 1월 이전에 당해 신용카드·직불카드 회원에게 발급 예정사실을 통보한 후 20일 이내에 당해 신용카드·직불카드 회원으로부터 이의제기가 없는 경우

284) 제4조(카드의 유효기간 및 재발급) ② 카드의 유효기간이 도래한 경우 은행은 회원으로서 적당하다고 인정하는 회원에게 갱신발급예정일로부터 1월 이전에 회원에게 발급예정사실을 통보한 후 20일 이내에 회원으로부터 이의제기가 없는 경우 새로운 유효기간이 기재된 카드를 갱신 발급하여 드립니다. 단, 갱신발급예정일로부터 6개월 이내 카드사용 실적이 없는 회원에 대해서는 회원의 서면동의를 있는 경우에 갱신 발급합니다.

③ 유효기간이 도래한 가족회원의 경우 전항의 본인회원 갱신절차에 준하여 발급한다.

조 제5항²⁸⁵⁾에 의거 신청인에게도 책임이 있다고 주장하나, 다음과 같은 점으로 볼 때 신청인에게 본건 가족카드의 부정사용대금에 대하여 책임이 있다고 하기 어려움.

① 먼저 신청인은 임의 발급된 본건 가족카드에 대하여 사용을 하는 등 주인을 했다고 볼만한 행위를 하지 않았는바, 단지 신청인이 “1주일간” 신용카드를 보관한 사실만으로 무효인 신용카드 이용계약을 주인했다고 볼 수 없는 점.

② 한편 신용카드 관리책임 유무와 관련하여서는, 본건 관련 법률 및 약관에 의해 본건 가족카드 이용계약은 무효인바, 원칙적으로 동 신용카드 이용계약의 약관을 적용하여 신청인의 비밀번호 관리 소홀에 대한 고의·과실을 다룰 수 없는 점.

③ 또한 본건 가족카드가 임의발급 되었음은 물론 신용카드 회원이 사용자등록을 하지 않아도 바로 사용할 수 있도록 발급되는 등 피신청인이 부정사용에 대한 개연성을 크게 하였는바, 신청인이 단순히 가족회원 신용카드를 1주일간 보관했다는 사실만으로 피신청인의 책임을 제한키는 곤란하다고 판단되는 점.

라. 결 론

그렇다면 본건 신용카드의 부정사용과 관련하여 신청인에게 부정사용금액 금250만원에 대한 지급책임이 없어 이를 인용함.

285) 제9조(현금서비스 및 현금지급기의 이용) ⑤ 현금인출을 하거나 현금서비스 이용시 비밀번호 취급부주의에 따른 모든 책임은 회원에게 귀속됩니다. 단, 현금서비스 이용시 저항할 수 없는 폭력이나 자기 또는 친족의 생명, 신체에 대한 위해로 인하여 비밀번호를 누설한 경우 신용카드 회원의 고의 또는 과실이 없는 경우에는 그러하지 아니합니다.

제19조(카드의 분실·도난신고와 보상) ② 제1항의 절차를 이행한 경우 회원은 분실·도난신고 접수일로부터 60일전 이후(현금인출, 현금서비스 및 제6조 제2항에서 정한 거래의 경우는 신고시점 이후)에 발생한 제3자의 카드 부정사용금액에 대하여는 다음 각호에서 정한 회원의 과실사유를 제외하고 은행으로부터 보상을 받을 수 있습니다. 단, 회원은 은행 및 ○○카드(주)가 정한 양식에 의해 보상신청을 접수하여야 하고 카드 1매당 최고 2만원의 부정사용조사수수료를 부담하여야 합니다.

6. 카드비밀번호 유출로 인한 부정사용의 경우 동 약관 제9조 제5항에 따릅니다.

5-4 음주후 분실한 겸용카드의 부정사용에 대한 회원의 책임

[일부인용] 대부분 카드사의 경우 전자금융거래법의 입법 취지를 고려하여 본인 이외에 가족들의 분실 신고도 접수처리하고 있으며, 피신청인의 내부기준에도 현금 인출용 비밀번호의 경우 입력오류가 3회 연속하여 발생하면 거래정지 조치를 취하도록 되어 있음에도 사건 당일 3회 연속하여 입력오류가 발생하였음에도 적절한 조치를 취하지 않아 대출금 인출사고가 발생한 점 등 감안시 피신청인에게 사고발생의 책임이 있다 할 것임. 다만, 신청인은 사고 당시의 상황을 기억하지 못할 정도로 만취된 상태에서 귀가하던 중 사고를 당한 점으로 볼 때, 선량한 관리자의 주의으로써 겸용카드를 관리·이용하였다고 보기 어렵고, 신청인이 범인에게 비밀번호를 유출한 책임을 감안하여 피신청인 책임을 80%로 제한함.(2009.1.6. 조정번호 제2009-03호)

가. 사실관계

01:30분경 신청인, 만취상태에서 택시에 승차한 이후에 강도사건을 당하여 겸용카드(신용카드, 현금카드 겸용) 등을 빼앗김.

02:48:15 강도혐의자가 ARS로 접속을 1차 시도하였으나 비밀번호의 입력 오류로 이용이 불가하였으며(비밀번호 오류 입력 사실이 신청인 배우자의 휴대폰으로 1차로 통보됨), 02:50:06 ARS로 접속을 2차 시도하였으나, 또 다시 비밀번호 입력 오류로 이용이 불가하였음(비밀번호 오류 입력 사실이 신청인의 배우자의 휴대폰으로 2차로 통보됨).

02:55:49 신청인의 배우자가 ARS로 접속을 시도하였으나, 비밀번호를 잘못 입력하였으며(비밀번호 오류 입력 사실이 신청인의 배우자의 휴대폰으로 3차로 통보됨), 02:58:31 신청인의 배우자가 신청인의 주민등록번호와 비밀번호를 입력하고, 신용카드용 ARS를 통해 상담원과 대화를 나눔.²⁸⁶⁾

286) [신청인 배우자] “남편이 귀가를 안했는데, 휴대폰도 안되고, 비밀번호 오류라고 계속 문자가 오거든요. 그래서 지금 혹시나 하는 마음에 지금 이거 신고하려고 하는 거거든요.”

[직원] “고객님 죄송합니다만 고객님의 카드가 아니시고, 정확하게 분실한 상태가 아니신데, 다른 분의 카드를 분실등록하시기는 어렵습니다.”

[신청인 배우자] “아 네 그래요? 만약 이렇게 된 상황에서 착오가 생기면 어떻게 되나요? 지금 비밀번호 오류라고 문자가 계속 오거든요.”

[직원] “분실하신 게 확실하시다면, 저희가 분실등록을 도와드릴 수가 있는데요. 그게 아니고 짐작으

03:41~03:53 강도협박자, ATM에서 4,819,200원(수수료 포함)의 대출금을 인출(이른바 “마이너스 통장 대출”)한 후, 03:55~03:56 ATM에서 600,000원의 현금서비스 금액²⁸⁷⁾을 인출함. 04:08 신청인의 배우자, 귀가한 신청인으로부터 검용카드 분실 사실을 확인하고, ARS를 통해 분실신고를 등록함(이 때의 상담직원은 당초 상담한 직원과 동일 인물임).

나. 당사자 주장

(1) 신청인 주장

비밀번호는 가족이 아니면 알기 어렵고, 피신청인의 콜센타와 통화를 하려면 카드번호나 주민등록번호를 입력한 후 비밀번호를 입력하여야 하는데, 비밀번호 오류 입력을 알리는 문자서비스를 받고 수상하게 생각한 가족이 이러한 절차를 거쳐 신고를 했음에도 상담직원이 사고신고의 접수를 거절한 것은 피신청인의 명백한 잘못인 바, 이로 인한 피해는 당연히 피신청인이 책임져야 할 것임.

(2) 피신청인 주장

「전자금융거래법」 제10조에 의하면, “금융기관은 이용자로부터 접근매체의 분실이나 도난 등의 통지를 받은 때에는 그 때부터 제3자가 그 접근매체를 사용함으로써 인하여 이용자에게 발생한 손해를 배상할 책임을 진다.”라고 규정함으로써 그 통지의 주체를 이용자로 한정하고 있고, 또한 「현금카드이용약정서」 제3조에서도 “이용자가 카드의 분실, 도난, 훼손, 오손하였을 때에는 즉시 은행 영업점에 신고하여야 한다.”고 규정함으로써 그 신고의 주체를 이용자로 국한하고 있는데, 신청인의 배우자의 경우 그 이용자에 해당하지 아니하므로 상담 직원이 이를 이유로 분실 등록을 거부한 것은 정당하다 할 것임.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 피신청인이 선관주의 의무를 다했다고 볼 수 있는 지 여부임.

로 고객센터서 그 분실등록하시거나 고객님의 본인이 아니시고 지금…….”

287) ○○은행은 현금서비스 부정사용 금액(600,000원)에 대해서는 여신전문금융업 관계 법령에 따라 보상 조치함.

(1) 선관주의의무 위반 여부

「전자금융거래법」 제10조 제1항은 카드등 접근매체 분실시의 책임 문제와 관련하여 “금융기관은 이용자로부터 접근매체의 분실이나 도난 등의 통지를 받은 때에는 그 때부터 제3자가 그 접근매체를 사용함으로써 인하여 이용자에게 발생한 손해를 배상할 책임을 진다.”라는 규정을 두고 있는데, 여기서 가족회원(신청인의 배우자)이 ‘이용자’의 범위에 포함되는 지 여부에 대해 논란이 있을 수 있으나, 설령 동 법 제10조 제1항을 엄격히 해석하여 가족회원이 ‘이용자’의 범위에 포함되지 않는다고 하더라도 동 규정은 이용자의 통지가 있는 경우에만 금융기관이 손해배상책임을 부담하고, 그 이외에는 당연히 면책된다는 의미가 아니므로 이용자의 통지가 없었음을 이유로 당연히 피신청인의 손해배상 책임이 부인된다고 해석하는 것은 적절치 않으며, 이용자의 통지가 없었다고 하더라도 피신청인에게 손해배상 책임이 있는지 여부는 약관 등 각종 규정 및 신의칙 등을 고려하여 별도로 판단해야 하는데, 다음과 같은 점을 고려할 때, 피신청인은 예금거래기본약관 제17조 제4항 단서조항에서 규정하고 있는 선관주의 의무를 다한 것으로 보기 어려운바, 피신청인은 손해배상 책임을 면하기 어려울 것임(부정 인출된 돈은 예금이 아닌 대출금의 성격을 갖고 있으나, 대출거래의 경우도 대출거래약정서에 의하여 예금약관이 적용됨).

① 대부분 카드사의 경우 전자금융거래법의 입법 취지를 고려하여 본인 이외에 그 가족들의 분실 신고도 접수·처리하고 있는 점.

② 피신청인의 내부기준에 의하면, 현금(예금 또는 대출금)인출용 비밀번호의 경우 그 입력 오류가 3회 연속하여 발생하면, 거래정지 조치를 취하도록 되어 있음에도 본건에 있어 사건 당일 02:48, 05:50, 05:55 3회 연속 입력오류가 발생하였음에도 대출금이 인출되는 사고가 발생하였다는 점. 이에 대해 피신청인은 비밀번호의 오류 입력 횟수가 현금인출용은 연속하여 3회, 현금서비스용은 연속하여 5회인 경우 거래정지 조치를 취하도록 내부기준이 정해져 있는데, 본건에 있어 가족회원은 은행용 전화가 아닌 카드용 전화번호를 통하여 비밀번호를 입력하였기 때문에 후자의 기준(5회)이 적용된다고 주장하고 있으나, 신청인의 비밀번호는 현금인출용과 현금서비스용이 동일하고, 전화번호를 2개로 구분하여 운영하는 것은 피신청인의 편의 또는 사정에 의한 것에 불과하므로 단지 카드

용 전화번호로 전화를 걸었다는 이유만으로 5회를 기준으로 삼는 것은 타당하지 아니함.

③ 본건에 있어 분실·도난 신고자(신청인의 배우자)가 본인회원의 주민등록번호와 비밀번호를 알고 있고, 피신청인이 보낸 문자메시지를 그의 휴대폰으로 수신받은 것으로 볼 때, 그는 본인회원의 가족이거나 최소한 본인회원과의 경제적 이해관계가 매우 밀접한 자임을 쉽게 알 수 있을 뿐만 아니라 그 신고시점이 새벽 3시경이고, 신고 당시 신고자가 ‘비밀번호 오류 입력 메시지가 계속 휴대폰으로 전송된다는 사실’과 ‘본인회원인 남편이 아직 귀가를 하지 않고 있고, 휴대폰으로도 연락이 되지 않는다는 사실’ 등을 피신청인의 상담 직원에게 자세히 설명한 점 등을 종합적으로 고려할 때, 피신청인이 조금만 주의를 기울였다면, 본인회원인 신청인의 사고 개연성을 충분히 예견할 수 있었음에도 만연히 이를 게을리하여 잠정적인 사용정지 조치도 취하지 아니한 것은 고객의 재산을 안전하게 관리하는 것이 은행의 중요한 업무임을 감안할 때, 피신청인이 선량한 관리자로서의 주의의무를 다하였다고 평가하기 어렵다는 점.

(2) 손해배상 책임 및 그 책임의 배분

피신청인은 상기와 같이 선관주의 의무를 위반하여 신청인에게 손해를 가하였으므로 그 손해를 배상할 책임이 있으나, 신청인에게도 다음과 같은 잘못이 있으므로 피신청인의 책임비율을 80%로 제한함이 타당하다 할 것임.

신청인은 사고 당시의 상황을 기억하지 못할 정도로 만취된 상태에서 귀가하던 중 사고를 당한 점으로 볼 때, 선량한 관리자의 주의로써 겸용카드를 관리·이용하였다고 보기 어렵고(『개인회원 표준약관』 제3조 제2항 위반), 또한 신청인이 범인에게 비밀번호를 유출한 책임²⁸⁸⁾을 면하기 어렵다는 점.

라. 결 론

그렇다면, 피신청인은 신청인의 손해금액 4,819,200원중 80%에 해당하는 금액을 배상할 책임이 있어 이를 인용하고, 신청인의 나머지 청구는 이유 없어 기각함.

288) 신용카드 비밀번호의 경우 그 누설이 저항할 수 없는 폭력이나 자기 또는 친족의 생명·신체에 대한 위해로 인한 것으로 인정되는 경우에는 여신전문금융업법(제16조 제3항 단서)에 의하여 보호를 받을 수 있으나, 현금카드의 비밀번호 사용과 관련해서는 이러한 보호규정이 없음.

제2절 신용카드의 도용 및 위·변조 사용

5-5 제3자가 카드번호를 도용하여 전자상거래에 이용한 경우 회원의 책임

[인용] 제3자가 신용카드에 내장된 정보와 카드회원의 개인정보를 도용, 안심클릭서비스에 가입한 후 전자상거래를 통해 물품을 구입하는 등 부정사용한 경우 카드사가 회원이 비밀번호를 고의 또는 중대한 과실로 유출하였음을 입증하여야 하며, 안심클릭 암호의 경우 전자상거래상에서 사실상 신용카드 대용으로 사용되고 있어 카드사로서는 안심클릭서비스 가입시 신용카드 발급시에 준하는 본인확인 의무가 있음.(2005.3.8. 조정번호 2005-6호)

가. 사실관계

신청인은 2004.10.4. 신청인 명의의 신용카드의 사용내역을 확인하던 중 신청인이 모르는 카드거래내역(1건, 2,134,000원)이 있음을 알게 되었는데, 확인결과 같은 해 9.20. 신청인 명의로 안심클릭서비스에 가입되어 있었고 동 서비스를 통한 본인확인을 거친 후 온라인 거래로 노트북컴퓨터가 판매되었으며 주문자 및 수령자는 제3자인 A씨이며 물품은 신청인의 주소지가 아닌 제3의 장소로 배송된 것으로 나타났음.

나. 당사자의 주장

(1) 신청인 주장

본건은 제3자가 신청인의 신용카드번호 및 비밀번호 등을 도용하여 안심클릭서비스에 가입한 후 전자상거래를 통해 본건 카드를 부정사용한 것인 바, 신청인에게 카드 부정사용대금을 청구하는 것은 부당함.

(2) 피신청인 주장

안심클릭서비스 가입을 위해서는 신용카드번호, 주민등록번호, 신용인증코드(CVC) 외에 카드 비밀번호까지 입력하도록 되어 있는 바, 본건 거래가 신청인의 의사에 반한 제3자에 의한 거래였다고 하더라도 비밀번호 누출에 대한 책임은 신청인이 부담하여야 함.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 제3자의 본건 카드 부정사용에 대한 신청인의 책임 여부임.

(1) 본건의 판단기준

「여신전문금융업법」(이하 “여전법”이라 함)은 도난·분실 또는 위조·변조에 의해 신용카드가 제3자에 의해 부정사용되는 경우 카드사 및 회원간의 책임관계 등은 규율하고 있으나, 전자상거래에서는 제3자에 의해 신용카드에 내장된 정보와 카드회원의 개인정보를 도용하여 부정사용될 위험에 노출되어 있으며, 이는 기본적으로 비대면성이고 물리적 카드실물 등을 전제로 하지 않으므로 카드의 도난·분실이나 위조·변조를 규율하는 여전법의 규정이 그대로 적용된다고 보기는 어렵고 현재 이를 규율할 수 있는 별도의 다른 법령이 존재하지 않음.

따라서 현금서비스나 카드로 등 자금유통거래가 아닌 온라인을 통해 물품이나 용역을 제공받는 거래와 관련하여 제3자가 비밀번호 등 카드정보를 도용하는 경우에 있어서 책임소재에 대해서는 이에 관한 당사자간의 약정이 있는 경우에는 동 약정에 따라야 하나 그러한 약정조차 없는 경우에는 전통적인 형태의 부정사용에 대한 책임관계를 규율하고 있는 여전법 제16조(신용카드 회원 등에 대한 책임)의 취지²⁸⁹⁾를 감안하여 카드사가 비밀번호 등의 유출에 대하여 회원의 고의나 중과실을 입증하지 못하는 한 그 책임이 있는 것으로 해석하는 것이 타당할 것으로 판단됨.

한편, 피신청인은 「신용카드개인회원규약」 제18조(비밀번호 관련 책임)²⁹⁰⁾을 들어 카드

289) 여전법상 카드사는 카드의 분실·도난과 관련하여 신고시점 이후에 발생한 사용대금 및 신고전 60일 이내 발생된 카드사용에 대한 책임을 지되 신고전 60일 이내의 카드사용분에 대해서는 회원의 고의 또는 과실이 있는 경우에 한해 회원부담으로 할 수 있도록 하고 있고, 한편 위·변조의 경우에 있어서는 카드사의 책임으로 하되 회원의 고의 또는 중과실로 비밀번호가 유출되었음을 카드사가 입증하는 경우 회원에게 책임을 지울 수 있도록 규정하고 있음(동법 제16조, 동법시행령 제6조의9, 제6조의10).

290) 「신용카드 개인회원규약」 제18조(비밀번호 관련 책임) 카드사는 현금서비스, 카드로 등 비밀번호를 이용하는 거래시 입력된 비밀번호와 카드사에 신고된 비밀번호가 같음을 확인하고 조작된 내용대로 현금서비스, 카드로 등 거래를 처리한 경우 카드사의 과실이 아닌 도난, 분실 기타의 사고로 회원에

사가 과실이 있음을 신청인이 입증하여야 한다고 주장하고 있으나 동 규정은 문언상 현금 서비스, 카드론 등 자금융통거래에 한하여 제한적으로 적용되는 조항이므로 이러한 점에서 피신청인의 주장은 이유 없음.

(2) 본건 카드 부정사용에 대한 신청인의 책임 여부

다음과 같은 점을 감안할 때 피신청인이 본건 카드 부정사용금액을 신청인에게 청구함이 정당하다고 보기 어려움.

① 피신청인은 2004.9.20. 안심클릭서비스 가입시 신청인 본인만 알 수 있는 신청인의 주민등록번호, 본건 카드번호, 신용인증코드 및 카드 비밀번호가 정확히 입력된 점으로 미루어 신청인이 비밀번호 등의 유출에 대해 신청인의 책임이 있다고 주장하고 있으나, 전술한 바와 같이 현금서비스나 카드론과 같이 자금융통거래가 아닌 경우 피신청인으로서 신청인이 비밀번호를 고의 또는 중대한 과실로 유출하였음을 입증하여야 하며 이를 입증하지 못하는 한 본건 카드사용으로 인한 책임을 신청인에게 부과할 수 없다고 할 것인 바, 이와 관련하여 신청인의 고의·중과실 여부를 인정할 만한 별다른 증거자료를 제시하지 못하고 있는 점.

② 안심클릭 암호의 경우 전자상거래상에서 사실상 신용카드 대용으로 사용되고 있어 피신청인으로서 안심클릭서비스 가입시 신용카드 발급시에 준하는 본인확인 의무가 있는 바, 동 서비스 가입이 별도의 본인확인 확인절차 없이 온라인을 통한 비대면으로 이루어지고 있어 피신청인으로서 이러한 신원확인 의무를 다하였다고 보기 어려운 점.

라. 결 론

그렇다면 피신청인은 본건 카드 부정사용금액 2,134,000원을 신청인에게 청구할 정당한 권리가 있다고 보기 어려움.

5-6 위조카드에 의한 예금의 부당인출과 비밀번호 누설 책임

[인용] 위조 또는 변조된 신용카드의 사용으로 인한 책임을 원칙적으로 신용카드업자가 지도록 한 여신전문금융업법의 규정에 따라 카드회원이 고의 또는 중대한 과실로 비밀번호를 누설한 경우 은행이 책임을 면한다는 신용카드 약관의 면책사유에 대한 입증책임은 은행에게 있음. 또한 신용카드의 마그네틱에는 비밀번호에 대한 정보가 없어 물건 구입 당시 결제를 위해 신용카드를 제공한 사실만으로는 비밀번호 누설에 대하여 신청인에게 고의 또는 중대한 과실이 있다고 보기 어려워 위조카드 사용으로 인한 책임은 은행에게 있다할 것임.(2006.11.7. 조정번호 제2006-69호)

가. 사실관계

신청인은 2006.2.15. ○○은행(이하 “피신청인”이라 함) 지점을 통하여 신청인 명의의 은행 계좌에서 결제가 이루어지는 신용카드를 발급받음.

신청인이 위 신용카드를 계속 소지하고 있던 중, 2006.7.16. 피신청인의 홈페이지를 통하여 신청인의 휴대폰 번호가 변경 등록된 후, CD기1에서 2,103,600원, CD기2에서 2,244,800원, 총 4,348,400원이 카드를 통하여 신청인의 계좌에서 현금인출 되었는데, CD기에 찍힌 카드실물의 사진에 따르면, 인출에 사용된 카드는 ◇◇은행 체크카드를 통하여 신청인의 위 신용카드로 위조된 카드였음.²⁹¹⁾

나. 당사자의 주장

291) 예금인출시 비밀번호 입력오류는 없었음. 신청인은 2006.6월말 인터넷 쇼핑몰에서 건강식품을 주문하였는데, 같은 달 28일 판매자가 신청인의 직장을 방문하여 쇼핑몰 판매수수료가 너무 높아 직거래로 저렴하게 판매하기 위해 방문하였다며 휴대용 신용카드 조회기를 통한 결제요청을 하였고, 2회에 걸쳐 카드승인(swipe)을 시도 하였으나 “뽐” 소리가 나며 승인이 되지 않았고, 결국 현금으로 입금을 한 사실이 있음. 수사결과 현재까지 본건을 포함하여 11건의 동일 범죄가 발생된 것으로 조사되었으며, 범인 중 1명이 검거되어 물품대금 결제를 위한 카드조회기 승인 시도시 피해자 카드의 정보를 알아내어 카드를 위조한 사실은 확인되었으나, 비밀번호 사용경위에 대하여는 밝히지 못함. 또한 범인들에게 비밀번호를 알려주었다는 피해자는 1인이고, 나머지 피해자들은 비밀번호를 알려준 사실이 없다고 진술하였음.

(1) 신청인 주장

신청인이 비밀번호를 유출한 사실이 없고 또한 카드를 계속 소지하고 있는 상태에서 타인이 위조카드를 사용하여 예금을 무단인출 하였던 바, 이에 대하여는 은행이 책임을 져야 함.

(2) 피신청인 주장

「은행예금거래약관」 제16조 제2항은 “전산통신기기등의 이용과 관련하여 은행이 책임질 수 없는 사유로 계좌번호, 비밀번호 등의 금융정보가 새어나가 거래처에 손해가 생겨도 은행은 그 책임을 지지 않는다.”고 규정하고 있으며, 「현금카드이용약정서」 제3조 제2항은 “당행에 책임이 없는 카드의 위조, 변조, 도용으로 인하여 발생한 사고나 손해에 대하여 당행은 책임을 지지 아니한다.”고 규정하고 있는 바, 본건은 당행의 책임없는 사유로 발생한 사고이므로 피신청인은 아무런 책임이 없음.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 위조카드에 의한 예금의 무단인출과 관련하여 카드소유자와 은행간에 어떠한 약관을 적용할 것인지와 약관에 따른 책임의 배분 문제라 할 것임.

(1) 본건 관련 적용 약관

피신청인은 본건 사고가 신용카드를 이용한 것이더라도 예금이 인출된 것이므로 예금거래기본약관과 현금카드이용약정서가 적용되어야 한다고 주장하므로 살피건대, 예금거래기본약관이 모든 예금에 적용되는 것은 분명하나, 본건 신용카드 발급시 적용된 「개인회원규약」 제8조는 “은행계좌를 카드결제계좌로 지정하신 회원의 경우 현금카드기능을 부여하여 드리며, 이 경우 회원은 카드로 현금자동지급기를 이용하여 제7조의 현금서비스 외에 결제계좌로부터 예금을 인출할 수 있습니다.”라고 규정하여 신용카드의 기능 중 하나로 예금인출 기능을 부여함과 동시에 신용카드를 통한 예금인출을 포함하여 신용카드 사용과 관련한 내용을 별개로 규정하고 있는 바, 동 규약 제26조의 “이 규약에서 정하지 아니한 사항과 이 규약의 해석에 관하여는 은행여신거래기본약관 및 관계법령 또

는 상관례에 따릅니다.”라는 규정에 비추어, 신용카드의 사용과 관련하여 발생한 예금인출에 대하여는 일반규정의 의미를 갖는 예금거래기본약관 보다 특별규정의 의미를 갖는 신용카드 개인회원규약이 우선하여 적용된다고 할 것이며, 현금카드이용약정서의 내용은 본건 신용카드 이용계약의 내용으로 편입되었음을 인정할 근거가 없는 바, 피신청인의 위 주장은 이유 없음.

(2) 약관에 따른 책임의 배분

「신용카드 개인회원규약」 제8조²⁹²⁾는 정상카드를 이용한 예금인출에 대한 규정인므로, 위조된 카드의 부정사용과 관련한 본건의 경우는 제19조²⁹³⁾가 적용된다 할 것인데, 인출당시 현금자동지급기에 압인된 카드전표와 수사결과에 따르면, 제3자가 신청인 명의의 카드를 위조하여 사용한 사실은 인정된다 할 것이어서 이로 인한 책임은 피신청인에게 있다 할 것이고, 「여신전문금융업법」 제16조 제5항 및 제6항²⁹⁴⁾의 취지 및 개인회원규약 제19조의 규정 형태상 위조카드의 사용으로 인한 책임을 면하기 위하여는 회원의 고의 또는 중대한 과실에 의하여 비밀번호가 누설되었음을 은행이 입증하여야 할 것인데, 신용카드의 마그네틱에는 비밀번호에 대한 정보가 없어 건강식품 구입 당시 결제를 위하여 신용카드를 제공한 사실만으로는 비밀번호 누설에 대하여 신청인에게 고의 또는 중대한 과실이 있다고 보기 어려우며, 그 밖에 달리 이를 인정할 만한 객관적인 증거가 없음.

292) 제8조(현금자동지급기의 이용) ⑤ 지급기를 이용하여 예금인출을 하거나 현금서비스를 받은 경우 비밀번호 누설에 따른 모든 책임은 회원에게 귀속됩니다.

293) 제19조(위·변조 카드에 대한 책임) 위·변조된 카드로 인한 부정사용에 따른 책임은 은행에 있습니다. 다만, 다음 각호의 1의 사항에 해당되는 부정사용에 따른 모든 책임은 회원이 부담합니다.

1. 고의 또는 중대한 과실에 의한 비밀번호 누설
2. 카드의 양도 또는 담보목적으로의 제공

294) 제16조 (신용카드회원등에 대한 책임) ⑤ 신용카드업자는 신용카드회원등에 대하여 위조 또는 변조된 신용카드등의 사용으로 인한 책임을 진다.

⑥ 제5항의 규정에 불구하고 신용카드업자가 신용카드등의 위조 또는 변조에 대하여 그 신용카드회원등의 고의 또는 중대한 과실을 입증하는 경우 그 책임의 전부 또는 일부를 신용카드회원등의 부담으로 할 수 있다는 취지의 계약을 신용카드회원등과 체결한 때에는 당해 신용카드회원등에 대하여 그 계약내용에 따른 책임을 부담하게 할 수 있다.

라. 결 론

그렇다면 위조카드로 인한 부정사용에 따른 책임은 피신청인에게 있다고 할 것이므로, 피신청인은 신청인에게 부당인출된 예금액 4,348,400원을 보상할 책임이 있어 이를 인용함.

5-7 위조 직불카드의 부정사용에 따른 책임 유무

[일부인용] 신청인이 본건 카드를 자녀에게 양도한 사실이 있고, 카드가 태국에서 부정 사용된 10명의 회원이 모두 뉴욕의 제휴 자동화기기에서 사용한 사실이 있음을 비추어 볼 때, 신청인의 자녀가 사용하던 중 그 정보가 누출되어 위·변조 사고가 발생하였다고 추정할 수 있으므로 신청인은 본건 부정사용에 대하여 카드의 양도에 따른 책임을 부담하여야 할 것임. 다만, 신청인 등이 본건 직불카드의 정보누설에 직접 관여하지 않고 제3자에 의하여 불법적으로 위조되어 사용된 것으로 파악되고, 신청인이 카드를 자녀에게 양도한 후 2년 이상 경과한 점 등을 감안하여 신청인의 책임을 40%로 제한함.(2008.6.10. 조정번호 제2008-48호)

가. 사실관계

신청인은 2005.7.22. 신청인 명의의 계좌에서 결제가 이루어지는 직불카드(이하 “본건 카드”라 함)를 피신청인으로부터 발급받았으며, 미국에서 어학연수 중인 자녀 A씨에게 본건 직불카드를 우편으로 송부함.

2005.9.16.~11.10. 기간중 A씨는 미국에서 본건 카드를 사용²⁹⁵⁾하용한 후, 2005.11.11. 귀국하였으며, 이후 본건 직불카드의 사용내역이 없었으나 2008.1.6. 태국에서 총 9건, 금 3,455,232원의 예금이 인출²⁹⁶⁾되자 2008.1.7. 신청인은 본건 카드 사고신고를 함.

295) 총 35회, 미화 약 5,948 달러가 예금인출 또는 물품구입의 형태로 사용됨.

296) 피신청인의 조사결과 직불카드 회원 15명의 카드가 위조되어 태국 방콕에서 예금이 인출되었으며, 인출 당시 회원들은 태국을 방문한 사실이 없고, 공통적으로 2005~2006년 사이에 뉴욕에서 직불카드를 사용한 내역이 있음. 그 중 10명의 회원이 뉴욕의 제휴 자동화기기에서 직불카드를 사용한 사실이 있음.

나. 당사자 주장

(1) 신청인 주장

위조된 직불카드에 의해 예금이 인출되었는 바, 동 인출액을 보상 바랍.

(2) 피신청인 주장

본건 부정사용은 신청인이 자녀에게 본건 직불카드를 양도하여 발생한 사안인 바, 「직불카드 회원약관」²⁹⁷⁾에 따라 부정사용에 따른 책임을 부담할 수 없음.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 위조된 직불카드에 의해 예금이 인출된 경우, 신청인이 책임을 부담하는지 여부라 할 것임.

「여신전문금융업법」 제16조 제5항에서 제7항,²⁹⁸⁾ 「여신전문금융업법 시행령」 제6조의

297) 제4조(카드 및 비밀번호의 관리) ① 카드의 소유권은 은행에 있으며, 회원은 발급 받은 카드를 타인에게 대여하거나 양도 또는 담보의 목적으로 이용할 수 없고 선량한 관리자로서 주의를 다하여 카드를 이용, 관리하여야 한다.

제10조(카드의 분실, 도난 신고) ② 회원은 제1항의 분실·도난 신고 이전에 발생한 손해에 대한 모든 책임을 부담하며 은행은 신고 접수 이후에 발생한 손해에 대한 모든 책임을 부담한다. 다만 은행이 회원의 고의 또는 중대한 과실을 입증할 수 있는 다음 각 호의1의 경우 회원이 책임을 부담한다.

2. 카드의 미 서명, 양도, 대여, 보관, 이용위임, 담보제공, 불법대출 등으로 인한 부정사용의 경우
3. 회원의 가족·동거인(사실상의 동거인 포함)에 의한 부정사용 또는 이들에 의한 위 제2호의 사유로 생긴 부정사용의 경우

제11조(카드의 위·변조 시 책임소재) 회원 이외의 제3자가 카드를 위·변조하여 카드를 사용하여 회원에게 손해가 발생한 경우 은행은 원칙적으로 책임을 부담한다. 다만 은행이 회원의 고의 또는 중대한 과실을 입증할 수 있는 제10조 제2항의 각 호의 1의 경우 회원이 책임을 부담합니다.

298) 제16조 (신용카드회원등에 대한 책임) ⑤ 신용카드업자는 신용카드회원 등에 대하여 위조 또는 변조된 신용카드 등의 사용으로 인한 책임을 진다.

⑥ 제5항의 규정에 불구하고 신용카드업자가 신용카드 등의 위조 또는 변조에 대하여 그 신용카드 회원 등의 고의 또는 중대한 과실을 입증하는 경우 그 책임의 전부 또는 일부를 신용카드회원 등의 부담으로 할 수 있다는 취지의 계약을 신용카드회원등과 체결한 때에는 당해 신용카드회원 등에 대하여 그 계약내용에 따른 책임을 부담하게 할 수 있다.

10,²⁹⁹⁾ 「전자금융거래법」 제9조 제1항에서 제3항,³⁰⁰⁾ 「전자금융거래법 시행령」 제8조³⁰¹⁾는 직불카드가 위·변조되어 회원에게 손해가 발생하였을 경우 원칙적으로 금융회사가 책임을 부담하나, 금융회사가 회원의 고의 또는 중과실을 입증할 수 있는 경우 회원에게 그 책임을 전부 또는 일부 부담시킬 수 있도록 되어 있음.

본 사안에 있어 신청인이 본건 직불카드를 자녀에게 양도한 사실이 있고, 직불카드가 태국에서 부정 사용된 10명의 회원이 모두 뉴욕의 제휴 자동화기기(Money Marketing Inc 운영)에서 사용한 사실이 있음을 비추어 볼 때, 신청인의 자녀가 이를 뉴욕의 제휴 자동화기기에서 사용하던 중 그 정보가 누출되어 위·변조 사고가 발생하였다고 추정할 수 있는 바, 신청인은 본건 부정사용에 대하여 직불카드의 양도에 따른 책임을 부담하여야 할 것임.

다만, 최근 판례가 “도난카드 사용과 관련한 회원과 카드사의 관계는 쌍무계약에 따른

⑦ 제3항 및 제6항의 규정에 의한 계약은 서면에 의한 경우에만 효력이 있으며, 신용카드회원 등의 중대한 과실은 계약서에 기재된 것에 한한다.

299) 제6조의10 (고의 또는 중대한 과실의 범위) 법 제16조제9항의 규정에 의한 고의 또는 중대한 과실의 범위는 다음 각 호와 같다.

1. 고의 또는 중대한 과실에 의한 비밀번호의 누설
2. 신용카드 또는 직불카드의 양도 또는 담보목적으로의 제공

300) 제9조(금융기관 또는 전자금융업자의 책임) ① 금융기관 또는 전자금융업자는 접근매체의 위조나 변조로 발생한 사고, 계약체결 또는 거래지시의 전자적 전송이나 처리과정에서 발생한 사고로 인하여 이용자에게 손해가 발생한 경우에는 그 손해를 배상할 책임을 진다.

② 제1항의 규정에 불구하고 금융기관 또는 전자금융업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 책임의 전부 또는 일부를 이용자가 부담하게 할 수 있다.

1. 사고 발생에 있어서 이용자의 고의나 중대한 과실이 있는 경우로서 그 책임의 전부 또는 일부를 이용자의 부담으로 할 수 있다는 취지의 약정을 미리 이용자와 체결한 경우

③ 제2항 제1호의 규정에 따른 이용자의 고의나 중대한 과실은 대통령이 정하는 범위 안에서 전자금융거래에 관한 약관(이하 "약관"이라 한다)에 기재된 것에 한한다.

301) 제8조(고의나 중대한 과실의 범위) 법 제9조제3항에 따른 고의나 중대한 과실의 범위는 다음 각 호와 같다

1. 이용자가 접근매체를 제3자에게 대여하거나 그 사용을 위임한 경우 또는 양도나 담보의 목적으로 제공한 경우(법 제18조에 따라 선불전자지급수단이나 전자화폐를 양도하거나 담보로 제공한 경우를 제외한다)

채무의 이행에 관한 문제가 아니라, 제3자에 의한 신용카드의 부정사용에 따른 책임의 귀속에 관한 문제이므로 그 기여도에 따라 책임의 분배를 함이 상당하다”고 판시하고 있는 바,³⁰²⁾ 다음과 같은 점을 고려하여 신청인의 본건 부정사용대금에 대한 책임을 40%로 제한하여야 할 것임.

신청인 및 자녀 A씨가 직접 본건 직불카드의 정보누설에 직접 관여한 것이 아니며, 또한 제3자에 의하여 불법적으로 본건 직불카드가 위조되어 부정 사용된 것으로 파악되고, 신청인이 본건 직불카드를 자녀 A씨에게 양도한 후 2년 이상 경과한 점.

라. 결 론

피신청인은 신청인에게 손해금액 금3,455,232원 중 40%를 차감한 금2,073,139원을 배상할 책임이 있어 이를 인용하고, 신청인의 나머지 청구는 이유 없어 기각함.

5-8 복제카드 부정사용 및 카드 비밀번호 누설에 따른 회원의 책임

[기각] 신청인은 본건 카드를 교부하고 비밀번호를 알려줌에 있어 카드가 복제될 것이라고는 생각하지 못했다고 주장하나, 적어도 본건 카드가 제3자에 의해 비정상적인 방법으로 사용될 가능성이 있음을 충분히 알 수 있었다고 봄이 상당하다 할 것이므로, 본건의 경우 신청인이 업소 종업원에게 카드를 교부하고 비밀번호까지 알려주는 등 본건 카드의 이용·관리 및 비밀번호 유출에 고의 내지 중대한 과실이 있어 피신청인의 책임을 묻기는 어렵다고 판단됨.(2011.4.12. 조정번호 제2011-23호)

가. 사실관계

2007.6.6. 신청인은 ○○은행(이하 “피신청인”이라 함) 지점에서 신용카드를 발급받았으며, 2010.11.28. ◇◇동 소재 업소에서 이용료 지불을 위해 종업원에게 신용카드를 교부하고 비밀번호를 알려주며 현금인출 심부름을 시킴.

302) 서울중앙지방법원 2005.4.22 선고 2004나25771 판결 참조.

동 종업원은 당일 인근 슈퍼에 설치된 △△△ 자동화기기에서 현금 20만원을 인출하고, 미리 준비한 복제기를 이용하여 신청인의 카드정보를 복제한 후, 비밀번호를 기재해 두었다가, 2011.2.13. 신청인의 신용카드 정보를 복제한 카드로 ○○은행 모 지점 자동화기기에서 현금서비스 1백만원을 인출함.

수사기관 확인 결과, 업소에서 서비스비용을 현금결제시 할인해 준다고 하여 고객이 종업원에게 현금인출 심부름을 시키면 종업원이 현금인출 심부름 도중에 미리 준비한 복제기로 카드마그네틱 정보를 복제하고 비밀번호를 기록해 놓은 다음, 일정기간이 지난 후에 복제카드로 예금 또는 현금서비스를 받아 이를 인출하였고, 본건을 포함하여 8건의 동일 범죄가 발생된 것으로 조사됨.

나. 당사자 주장

(1) 신청인 주장

본건 사고는 복제카드에 의해 부당하게 발생한 것이고 신청인은 이와 무관하므로, 피신청인이 이를 보상하여야 함.

(2) 피신청인 주장

본건 사고는 신청인이 타인에게 신용카드를 건네주고 비밀번호를 알려주어 발생한 사고이므로 카드 회원약관 제3조, 제21조 등에 의해 보상이 불가함.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 복제카드에 의한 현금서비스 부당 이용시 책임배분 관계라 할 것임.

「여신전문금융업법」, 「전자금융거래법」 및 본건 약관에 의하면 신용카드의 위조나 변조로 인하여 발생한 사고로 이용자에게 손해가 발생한 경우 원칙적으로 금융기관인 피신청인이 책임을 지도록 규정하고 있음.

그러나, 「여신전문금융업법」 제16조 제6항, 동법 시행령 제6조의 10, 피신청인 「개인회

원약관」 제21조 및 「전자금융거래법」 제9조 제2항, 동법 시행령 제8조, 피신청인 「전자금융거래약관」 제20조 등에 의하면, 신용카드의 대여나 양도, 비밀번호의 누설 등 그 위조·변조에 대한 이용자의 고의나 중대한 과실이 있는 경우 손실의 전부 또는 일부를 이용자에게 부담토록 하여 금융기관의 면책을 규정하고 있는 바, 신용카드를 원래 타인의 수중에 넘어가면 쉽게 부정사용될 수 있는 것이므로 카드회원은 현금과 같은 정도의 주의를 기울여 카드를 보관하여야 할 책임이 있고, 현금서비스 등에 있어서는 비밀번호가 그 부정사용을 막을 수 있는 수단이므로 카드회원은 그 설정 및 관리에 상당한 주의를 기울여야 할 것이고,³⁰³⁾ 신청인은 본건 카드를 교부하고 비밀번호를 알려줌에 있어 카드가 복제될 것이라고는 생각하지 못했다고 주장하나, 적어도 본건 카드가 제3자에 의해 비정상적인 방법으로 사용될 가능성이 있음을 충분히 알 수 있었다고 봄이 상당하다 할 것으로, 본건의 경우 신청인이 업소 종업원에게 신청인의 카드를 교부하고 비밀번호까지 알려주는 등 본건 카드의 이용·관리 및 비밀번호 유출에 고의 내지 중대한 과실이 있다고 보이며, 달리 본건 현금서비스 부당이용에 대한 피신청인의 과실을 찾기 어려운 점 등에 비추어 피신청인의 책임을 묻기는 어렵다고 판단됨.

라. 결론

그렇다면 신청인의 청구는 이유 없어 이를 기각함.

303) 서울중앙지법 2004.6.18. 선고 2003나52790 판결, 피신청인 「신용카드개인회원약관」 제3조, 제12조, 제22조 참조.

제3절 기타

5-9 카드대금 할부전환에 따른 할부항변권 인정여부

[인용] 신청인이 가맹점과 아기성장앨범을 촬영하는 계약을 체결하고 피신청인의 B카드를 이용하여 일시불로 결제하였으나 할부결제로 변경하였고 이후 가맹점이 폐업하자 잔금에 대하여 할부항변권을 행사한 사안에 대하여 피신청인이 할부전환시 할부항변권이 제한됨을 신청인에게 설명하지 않은 이상 할부계약에 따른 권리를 신청인이 행사할 수 있음을 용인한 것으로 해석될 뿐만 아니라 할부거래에 있어 최초 할부결제든 일시금 결제 후 할부변경의 경우든 가맹점은 동일한 할부수수료를 지급하는 사정 등을 살펴볼 때 계약 당사자의 의사를 고려하지 아니한 채 일방적으로 피신청인에게 유리하도록 할부전환의 경우에는 할부항변권이 배제된다고 해석함은 사회일반의 상식과 거래의 통념에 비추어 합리적이지 아니하므로 신청인은 할부거래법 및 신용카드 개인회원 약관에 따라 지급기일이 지나지 않은 할부금에 대한 지급을 거절할 수 있다고 판단한 사례(2015.2.10. 제2015-5호).

가. 사실관계

2014. 3. 13. 신청인은 P스튜디오(이하 ‘가맹점’이라 함)와 아기성장앨범을 촬영하기로 하는 계약을 체결하고 피신청인의 A카드를 이용하여 대금 1,090,000원을 3개월 할부로 결제(결제일 25일).

2014.3.21. 신청인은 피신청인에 3개월 할부를 12개월로 변경가능한지 문의하였으며, 피신청인의 상담직원은 “할부변경은 가능하나 기처리된 전표를 취소처리한 후 재결제해야 하므로 결제일(25일)에 결제내용이 반영되기 위해서는 금일 중 할부변경 내용이 확인되어야 한다”고 안내.

이에 2014.3.21. 신청인의 처가 가맹점을 방문하여 1,090,000원의 결제를 취소한 후 피신청인의 B카드를 이용하여 759,000원³⁰⁴⁾을 일시불로 결제.

그러자 신청인은 다시 피신청인에게 759,000원의 일시불 결제를 할부변경 요청하였고

304) 신청인은 앨범상품 구성을 달리하면서 759,000원으로 결제

피신청인의 상담직원은 “신용카드 전표 매입 전이므로 가맹점에 방문하여 취소 후 할부로 재결제하거나 3~4일 후 전표매입 처리되면 피신청인에게 전화 요청하여 할부변경 가능하다”고 안내³⁰⁵⁾.

피신청인의 할부전환 서비스 내용

- ▶대상 : 10만원이상 이용한 일시불 매출건 또는 10만원 이상 이용한 2~3개월의 할부매출건
- ▶조건 : 일시불 매출은 매출확정일로부터 2일이 경과한 시점 이후의 매출부터, 할부매출은 매출확정 이후 즉시 연장 가능
- ▶신청기간 : 매출확정(전표접수일) + 2일 ~ 결제일 전 3영업일까지
- ▶신청방법 : 유선 또는 홈페이지

2014.3.25. 신청인은 피신청인에게 전화하여 2014.3.21. 결제한 금액을 할부거래로 변경해 줄 것으로 요청하였고, 10개월 할부로 전환됨.

2014.9.12. 가맹점은 폐업하였고 신청인은 계약내용에 따른 서비스를 받지 못하자 나머지 잔금 303,600원에 대해 할부항변권을 행사하였으나 피신청인이 이를 거부.

2014.9.15. 신청인은 금융감독원에 민원을 신청하였으며, 나머지 할부금(2014.10월 이후) 도 할 수 없이 전액 납부하였음.

신청인의 할부대금 납부현황

회차	청구일자	청구할부원금	할부수수료	총입금금액	청구후 잔액	비고
1	2014.4.25.	75,900	14,483	90,383	683,100	기납입
2	2014.5.12. ³⁰⁶⁾	75,900	6,331	82,286	607,200	
3	2014.6.12.	75,900	10,262	86,162	531,300	
4	2014.7.12.	75,900	8,690	84,590	455,400	
5	2014.8.12.	75,900	7,696	83,596	379,500	
6	2014.9.12.	75,900	6,414	82,314	303,600	
7	2014.10.12.	75,900	4,965	80,865	227,700	할부항변 주장
8	2014.11.12.	75,900	3,848	79,787 ³⁰⁷⁾	151,800	
9	2014.12.12.	75,900	2,482	78,382	75,900	
10	2015.1.12.	75,900	1,282	77,182	-	
합계		759,000	66,453	825,547	-	

305) 온라인으로 할부전환 신청시 ‘할부전환시 할부항변권이 적용되지 않는다’는 주의사항이 안내사항으로 공지되나, 신청인의 전화상담시 할부항변권이 적용되지 않는다는 설명이 없었음

306) 신청인이 2014.4.3. 결제일을 매월 12일로 변경

나. 당사자 주장

(1) 신청인 주장

가맹점에서 할부결제 하는 것과 일시불 결제후 할부전환하는 것 사이에 변제일정 및 할부수수료에 차이가 없는 바, 전자에 대하여만 할부항변권을 인정함은 불합리하며, 피신청인은 할부항변권이 적용되지 않는다는 내용을 안내해 주지 않았으므로 P스튜디오 폐업이후 나머지 할부금에 대하여는 지급의무가 없음.

(2) 피신청인 주장

할부전환서비스는 신청인과 피신청인간 변제의 방식을 변경하기 위한 별도의 특약에 해당되므로 「할부거래에 관한 법률」은 적용되지 아니하므로 할부항변권은 인정되지 않음.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 「할부거래에 관한 법률」(이하 「할부거래법」이라 함) 상 할부거래에 해당하는지 및 할부항변권이 인정될 수 있는지라 할 것임.

(1) 「할부거래법」상 할부거래 해당여부

“할부계약”이란 계약의 명칭·형식이 어떠하든 재화나 용역에 관한 계약(「할부거래법」 제2조 제1호)을 말하고, “간접할부계약”이라 함은 소비자가 신용제공자에게 재화 등의 대금을 2개월 이상의 기간에 걸쳐 3회 이상 나누어 지급하고, 재화 등의 대금을 완납하기 전에 사업자로부터 재화등의 공급을 받기로 하는 계약이며(「할부거래법」 제2조 제1호 나목), “할부거래”란 할부계약에 의한 거래를 말함(「할부거래법」 제2조 제3호).

따라서, 「할부거래법」상 할부계약은 ① 매도인과 매수인 사이의 매매계약 ② 매도인과 신용제공자 사이에 위 매매계약과 관련된 보증이나 채권양도 등의 약정 및 ③ 신용제공자와 매수인 사이의 할부금의 지급 등에 관한 약정이라는 3면 계약에 의하여 이루어

307) 지연배상금 39원 포함

어진 계약을 의미함(2008.7.10.선고 2006다57872판결 등).

살피건대, 신청인은 피신청인과 신용카드 가맹점계약을 체결한 가맹점으로부터 사진촬영 등 서비스를 공급받는 계약을 체결하였고, 피신청인에게 위 카드결제대금을 10개월 동안 10회에 나누어 분할지급하기로 하였는바, 동법은 계약의 명칭이나 형식과 무관하게 할부계약에 해당될 수 있음을 정하고 있으므로 할부계약인지 여부는 실질에 따라 판단해야 할 뿐만 아니라 분할지급 약정시기를 물품구입시에만 해야한다고 특별히 정하고 있지 아니하므로 할부약정이 사후적으로 이루어졌다 할지라도 이는 「할부거래법」 제2조 제1호 나목 및 제3호 소정의 간접할부거래에 해당된다고 볼 수 있음.

(2) 할부항변권 행사가능 여부

소비자는 재화등의 전부 또는 일부가 재화등의 공급 시기까지 소비자에게 공급되지 아니한 경우 또는 할부거래업자의 채무불이행으로 인하여 할부계약의 목적을 달성할 수 없는 경우 그 할부금의 지급을 거절할 수 있음(「할부거래법」 제16조 제1항 제3호, 제5호)³⁰⁸).

살피건대, 피신청인과 가맹점은 신용카드 가맹점 계약에 따라 가맹점의 피신청인에 대한 물품대금 결제에 관한 약정이 존재하는 상황에서 신청인과 피신청인간 분할지급 약정을 체결하였는 바, 「할부거래법」상 간접할부계약 해당요건으로 ① 소비자(신청인)과 신용제공자(피신청인)간 재화등의 대금을 2개월이상 기간에 걸쳐 3회 이상 나누어지급하기로 하는 약정과 ② 재화등의 대금을 완납하기 전 사업자(가맹점)로부터 재화등의 공급을 받기로 할 것만을 정하고 있으므로 법문언상 신청인과 가맹점 사이에 분할지급 약정은 필요하지 아니하고, 「할부거래법」 제43조에서는 소비자에게 불리한 약정은 효력이 없다고 정하고 있는 바, 피신청인의 신용카드 개인회원 약관에도 할부전환시 할부항변권이 인정되지 아니함이 기재되어 있지 아니하고 약관은 신의성실의 원칙에 따라 공정하게 해석되어야 하며, 약관의 뜻이 명백하지 아니한 경우에는 고객에게 유리하게 해석되어야 하는 점(「약관의 규제에 관한 법률」 제5조 제1항, 제2항)에서 약관상 명백하지 아니함에도 신청인에게 불리하게 해석할 수는 없다고 할 것임.

308) 피신청인의 신용카드 개인회원 약관에도 위 법률과 동일한 내용으로 할부항변권에 대해 기재되어 있음

한편, 법률행위의 해석은 당사자가 표시행위에 부여한 객관적인 의미를 명백하게 확정하는 것으로서, 당사자가 표시한 문언에 의하여 객관적인 의미가 명확하게 드러나지 아니하는 경우에는 문언 내용과 법률행위가 이루어지게 된 동기 및 경위, 당사자가 법률행위에 의하여 달성하려고 하는 목적과 진정한 의사, 거래관행 등을 종합적으로 고찰하여 사회정의와 형평의 이념에 맞도록 논리와 경험의 법칙 그리고 사회일반의 상식과 거래의 통념에 따라 합리적으로 해석하여야 함(2011.10.27. 선고 2011다53645 판결 등).

신청인이 일시불 결제를 할부로 전환하여 분할지급하기로 피신청인과 약정할 때의 신청인의 의사는 할부기간 동안 대금을 분할지급하고 할부거래업자(가맹점)의 폐업 등으로 재화를 공급받을 수 없는 경우에 할부항변권 등 관련 법령에서 정하고 있는 권리를 행사하고자 하는 것으로 보아야 하며, 피신청인 역시 할부전환시 할부항변권이 제한됨을 신청인에게 설명하지 않은 이상 할부계약에 따른 권리를 신청인이 행사할 수 있음을 용인한 것으로 보아야 할 것임.

또한, 피신청인은 일시금결제 또는 할부결제 등 대금결제방식과 무관하게 가맹점에 거래대금 전액을 미리 지급하며, 가맹점의 수수료에도 차이가 없을 뿐만 아니라 할부거래에 있어 신청인은 최초 할부결제이든 일시금 결제후 할부변경하는 경우이든 동일한 할부수수료를 지급함에도 계약당시 당사자의 의사를 고려하지 아니한 채 피신청인에게 유리하도록 할부전환의 경우에만 할부항변권이 배제된다고 해석함은 사회일반의 상식과 거래의 통념에 비추어 합리적이지 아니함.

그렇다면, 신청인은 「할부거래법」 제16조 및 피신청인의 「신용카드 개인회원 약관」 제13조에 따라 지급기일이 지나지 않은 할부금에 대한 지급을 거절할 수 있다고 할 것임.

라. 결 론

피신청인은 신청인이 2014.10.12. ~ 2015.1.12. 기간 중 납부한 316,216원을 반환할 책임이 있다 할 것이므로 신청인의 청구는 이유 있어 이를 인용함.

제6장

금융투자상품 판매

제1절 펀드의 불완전판매

6-1

특정금전신탁 가입시 고객보호의무 위반 여부

[인용] 투자권유자로서 은행이 고수익 고위험의 금융상품을 특정금전신탁으로 판매할 경우, 이를 고객에게 권유하면서 당해 금융상품에 필연적으로 수반되는 위험성에 관한 정당한 인식형성을 방해하거나 일반투자자의 투자상황에 비추어 과대한 위험성을 수반하는 거래를 적극적으로 권유한 경우에는 고객에 대한 보호의무를 저버린 위법행위로 인정될 것임.(2004.7.13. 조 정번호 제2004-33호)

가. 사실관계

2003.1.17. 신청인은 대여금고를 이용하기 위하여 ○○은행(이하 “피신청인”이라 함) 지점을 방문하였다가 동 지점 직원인 C씨(이하 “담당직원”이라 함)로부터 “A통신” CP(이하 “본건 CP”라고 함) 매입을 권유받게 되었음. 당시 신청인은 여유자금에 있지만 2003.5월경 반드시 사용될 돈이니 A통신 CP가 1%의 리스크도 없는 상품이라면 가입하겠다고 말한 사실이 있음.

이에 담당직원은 피신청인 본점 신탁부에 전화를 걸어 A통신에 대하여 문의하였고, A통신이 B통신 등과 초고속인터넷사업 부문을 매각 추진 중에 있고 2001년도 당기순이익을 142억원 시현하는 등 문제가 없는 회사라는 견해를 듣고 신청인에게 재차 매입을 권유하였으며, 2003.1.20. 신청인은 본건 특정금전신탁계약(신탁금액: 3.1억원, 신탁기간: 2003.1.20.~2003.4.21. 원본교부일: 2003.4.22.)을 신청인의 조카인 D씨 명의로 체결함.

한편, A통신은 2003.4.11. 회사정리절차 개시신청에 이어 2003.12.1. 회사정리계획안이

인가되었으며, 채권자별 채권금액이 2.3억원 초과 4.3억원 이하의 채권(신청인 해당)에 대해서는 매년 말에 원금을 분할변제³⁰⁹⁾ 하는 것으로 되어 있음.

나. 당사자의 주장

(1) 신청인 주장

지점직원 및 본점 담당부서에서 A통신 CP에 투자하면 1%의 손해도 보지 않는다고 확신해 줌에 따라 이를 믿고 투자한 것이므로 피신청인은 즉시 투자원금을 반환하는 것이 마땅함.

(2) 피신청인 주장

특정금전신탁은 신탁재산의 운용실적에 따라 이익배당이 달라질 수 있고 경우에 따라서는 원본의 손실이 발생할 수도 있는 상품이며, 신청인의 과거 특정금전신탁 가입경험 등을 볼 때 신청인의 주장은 수용이 불가함.

다. 위원회의 판단

◆ 본건에 있어서의 쟁점은 본건 CP를 신청인에게 판매하면서 고객에 대한 보호의무를 준수하였는지 여부라고 할 것임.

(1) 특정금전신탁의 판매시 은행의 고객보호의무

위탁자인 고객이 신탁재산인 금전의 운용방법을 지정하는 특정금전신탁은 신탁재산의 운용결과가 위탁자인 고객에게 모두 귀속되므로 신탁재산의 수탁자이자 운용자인 은행은 위탁자인 고객의 지시대로 신탁재산을 운용하였다면 설령 그 운용결과 원본손실이 발생하였다고 하더라도 「신탁업감독규정」 제6조 및 「특정금전신탁계약서」 제8조에 의거 그 손실을 보전해 줄 책임이 없음이 원칙³¹⁰⁾이며, 본건 CP가 회사정리계획에 따라 그

309) 2003년 3천만원, 2004년 5천만원, 2005년 5천만원, 2006년 1억원, 2007년 나머지 금액임.

310) 「신탁업감독규정」 제6조 신탁회사(은행)는 신탁당시에 인수한 재산에 대하여 원본 또는 이익의 보전 계약을 할 수 없다.

이행이 이루어지기로 하여 인가가 된 이상 계약법적으로 원본의 반환을 구하는 신청인의 주장은 이유 없으나, 투자권유자로서 은행이 고수익 고위험의 금융상품을 특정금전신탁으로 판매할 경우, 이를 고객에게 권유하면서 당해 금융상품에 필연적으로 수반되는 위험성에 관한 정당한 인식형성을 방해하거나 일반투자자의 투자상황에 비추어 과대한 위험성을 수반하는 거래를 적극적으로 권유한 경우에는 고객에 대한 보호의무를 저버린 위법행위로 인정될 것임.³¹¹⁾

이러한 고객보호의무로서의 부당권유 등의 금지가 적용되는 근거는 은행이 특정금전신탁으로 CP를 판매하는 행위는 증권회사의 CP 중개업무와 유사하고, 실무상 특정금전신탁에 관한 거래관행은 신탁업을 겸영하는 은행이 특정금전신탁으로 판매 가능한 금융상품(예: 국채, 회사채, CP 등)을 발굴하고 위탁자인 고객에 대하여 그에 가입할 것을 권유하는 방식으로 이루어지고 있으며, 은행이 특정금전신탁을 판매하면서 고객에게 제공하는 금융상품에 대한 정보는 동 상품의 투자위험에 대한 정보 수집력이 상대적으로 부족한 일반고객의 투자의사결정에 미치는 영향력이 매우 크다고 볼 수 있고, 또한 신탁계약의 수탁자는 “신탁의 본지에 따라 선량한 관리자의 주의로써 신탁재산을 관리”하여야 할 의무를 지며(신탁법 제28조) 이러한 수탁자의 선관의무는 본건에서처럼 계약체결시 신청인과 피신청인이 신탁재산의 운용대상을 CP로 지정하는 과정에까지 확대 적용된다고 해석할 수 있는 점에 기인함.

(2) 피신청인의 고객보호의무 준수 여부

유가증권 등의 투자권유자가 고객에게 금융상품을 권유함에 있어서는 고객의 직업, 연령, 투자목적, 자산상황, 유가증권 투자경험유무, 거래의 종류 등을 종합하여 당해 권유상품과의 적합성을 면밀히 검토하여야 할 뿐 만아니라, 당해 상품의 상품구조 및 위험요소 등을 사전에 정확하게 설명하여야 할 의무가 있다고 할 수 있음.

「특정금전신탁계약서」 제8조 이 신탁은 원본과 이익의 보전을 하지 아니하며 경우에 따라서는 원본의 손실이 발생할 수 있다.

「회사정리법」 제112조 정리채권에 관하여는 정리절차에 의하지 아니하고 변제하거나 변제받거나 기타 이를 소멸하게 할 행위를 하지 못한다.

311) 금융분쟁조정위원회 조정번호 제2003-6호 참조.

조사 결과, 피신청인의 담당직원은 아래와 같은 점을 종합할 때, 불확실한 정보에 터 잡아 본건 CP의 매입을 권유한 점이 인정되어 신청인의 투자목적과의 적합성 및 설명 의무 등 고객보호의무를 다했다고 할 수 없으므로, 피신청인은 신청인에 대하여 고객보호의무위반에 따른 책임이 있다고 판단됨.

① 신청인은 단기투자목적 및 그 안정성추구에 대하여 이를 설명하였음에도 담당직원은 신청인에게 A통신(주)의 최근 재무제표 등을 기초로 설명하지 아니하고 막연히 ◇◇ 신용정보사의 기업어음 신용평가등급 등 회사의 일반적인 상황만을 설명한 점.

② 나아가 본건 특정금전신탁 가입 이틀 전 본사의 “특정금전신탁 운용자산 안내”에 의하면, 업체에 대한 최근 재무제표를 KIS-LINE을 통하여 확인하도록 지침을 각 지점에 통보하였는데도, 피신청인의 담당직원은 이를 확인하지 않음으로써 가입시점으로부터 2년 전 자료인 2001년도 재무제표상의 당기순이익 142억원 시현 사실만을 설명하고, 가입 당시 최근자료인 2002년도 상반기 재무제표상의 당기순손실 약 3억원의 시현 사실에 대하여는 전혀 이를 설명한 사실이 없는 점.

③ 본건 CP 발행회사의 신용평가등급이 당시 B+등급으로 그 평가등급의 변동이 없기는 하지만, 앞서 본 바와 같이 2002.11.14. 분기보고서 상으로도 2002.1.1.부터 2002.9.30.까지의 당기순손실이 27억원에 이르는 등 수익성지표가 급격히 전기 대비 떨어지고 있고, 유동비율³¹²⁾ 역시 산업표준 비율에 크게 못 미치고 있는 점에서 신청인이 목적으로 하고 있던 단기적 안정성의 추구에 적합하지 아니한 점.

라. 결 론

그렇다면, 피신청인은 피신청인 직원이 고객보호의무를 게을리하여 신청인의 투자판단을 그르치게 한 책임이 있음.

312) 위 기간 중 A통신의 유동비율은 43.19%, 당좌비율은 42.50%인데 비해 산업표준비율은 81.95%임

6-2 관련 투자경험이 부족한 고객에 대한 파생상품의 불완전판매

[일부인용] 피신청인 직원이 본건 파생상품을 권유함에 있어 투자신탁설명서나 약관을 교부하지 않은 점이 인정되며, 투자설명확인서 등에 담당직원이 대필한 점, 간접투자상품을 권유할 경우에는 투자위험에 관한 사항 등을 구체적으로 명확히 설명하였어야 하나 피신청인이 이를 이행한 것으로 인정할 증거가 없는 점, 신청인은 만64세이며, 과거 10여년 간 여유자금을 신탁형 저축상품이나 단순 정기예금 등으로 거래하여 왔으며, 과거 주식형펀드에 1천만원을 가입한 적은 있으나 소액으로써 본건과 같은 파생상품에 투자한 경험이 전혀 없는 점 등을 감안시 당해 권유행위가 경험이 부족한 일반 투자자에게 거래행위에 필연적으로 수반되는 위험성에 관한 올바른 인식을 방해하거나 또는 고객의 투자성향에 비추어 과대한 위험성을 수반하는 거래를 적극적으로 권유한 경우에 해당한다고 판단됨.(2008.3.11. 조정번호 제2008-20호)

가. 사실관계

2007.5.17. 신청인은 본인 명의의 특정금전신탁(4.9억원)을 만기 해지할 때, ○○은행(이하 “피신청인”이라 함) 지점에서 직원의 권유로 신청인 명의의 △△△△오일파생상품투자신탁³¹³⁾ 제6호(이하 “본건 파생상품”이라 함)에 3억원을 가입하고, 본인 명의로 정기예금(1년, 5.16%, 3천만원)을 가입함.

본건 파생상품 가입시 작성된 「투자설명서 교부 및 주요내용 설명확인서」상의 “투자설명서를 교부 받고 그 주요내용을 설명 들었음”의 필체는 피신청인 직원 A씨의 것으로 확인되고, 피신청인 직원이 본건 파생상품을 권유함에 있어 투자신탁설명서나 약관을 교

313) △△△△오일파생상품투자신탁의 개요는 다음과 같음.

- ① 뉴욕상업거래소에서 거래되는 서부텍사스중질유(WTI, West Texas Intermediate) 원유 최근월물 선물에 연계되어 수익이 결정되는 장외파생상품에 주로 투자하며, 투자기간(6개월) 동안 WTI 원유 선물가격이 최초기준가격에 연계하여 40%초과 상승한 적이 없으면 연 9.3%의 수익을 기대할 수 있으나, 40% 초과 상승한 적이 장중 포함하여 한번이라도 있으면 만기가격에 투자원금의 손실이 발생.
- ② 만기시 가격이 최초 기준가격 대비 상승한 경우는 수익률이 9.3%보다 낮아지며, 상승폭이 4.65%를 초과하면 원금손실이 발생함 → 손실액 = 원금×(1 - WTI 원유선물가격 상승률 + 4.65%).
- ③ 피신청인은 2007.5.~6.중 △△△△오일파생상품투자신탁 5~8호를 판매하였고 그 이전에 1~4호를 판매하여 모두 목표 수익률을 달성.

부하지 않았음. 2007.10.29. 본건 파생상품의 원금손실이 확정되었으며, 2007.11.21. 신청인이 본건 파생상품을 만기해지 하였고, 189,057,851원을 지급 받음.

나. 당사자 주장

(1) 신청인 주장

담당자로부터 본건 파생상품을 확정금리로 소개 받았고 원금손실에 대한 언급이 없었으며, 투자설명서도 교부받지 못하였음. 더욱이 유가상승으로 수익률이 나빠졌음에도 중간에 연락이나 설명이 없어 결국 만기해지를 하게 되어 손해가 커졌는 바, 원금 손실에 대한 피신청인의 보상을 요청함.

(2) 피신청인 주장

본건 파생상품 가입 당시 담당 직원이 신청인에게 상품 내용을 자세히 설명하였고, 상품안내장을 교부하였음. 신청인은 과거 펀드가입 경험이 있고, 본건 파생상품이 6개월 동안 유가가 40% 초과 상승하지 않으면 9.3%의 이자를 지급하는 상품이라는 설명을 들었다고 인정하고 있음.

다만, 신청인이 가입 후 급하게 퇴점하여 「투자설명서 교부 및 주요내용 설명확인서」상의 “투자설명서를 교부 받고 그 주요내용을 설명들었음”의 자필을 담당직원이 대필한 점은 있으나, 이러한 사유로 신청인에게 원금 보상을 할 수는 없음.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 파생상품 판매시 피신청인의 판매직원이 상품에 대한 설명 등 고객보호 의무를 다하였는지 여부라 할 것임.

(1) 고객보호의무 위반으로 인한 손해배상책임 성립 여부

대법원은 “수익증권 판매회사의 임직원이 고객에게 투자신탁상품의 매입을 권유할 때에는 그 투자에 따르는 위험을 포함하여 당해 투자신탁의 특성과 주요내용을 명확히 설명함으로써 고객이 그 정보를 바탕으로 합리적인 투자판단을 할 수 있도록 고객을 보호

하여야 할 주의의무가 있고, 이러한 주의의무를 위반한 결과 고객에게 손해가 발생한 때에는 불법행위로 인한 손해배상책임이 성립한다고 할 것이며, 일반적으로 공사채형 투자신탁의 경우 투자에 따르는 위험과 관련하여 투자 권유자는 채권시장의 시가 변동에 의한 위험, 발행주체의 신용위험, 그리고 만약 외국 채권을 신탁재산에 편입하는 때에는 환시세의 변동에 의한 위험이 존재하고 이로 인하여 원본손실의 가능성이 있다는 사실 등을 설명하여야 할 것이나, 고객에게 어느 정도의 설명을 하여야 하는지는 투자 대상인 상품의 특성 및 위험도의 수준, 고객의 투자 경험 및 능력 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.”라고 판시하고 있으며,³¹⁴⁾ 또한 “증권회사의 임직원이 고객에게 적극적으로 투자를 권유하였으나 투자결과 손해를 본 경우 당해 권유행위가 경험이 부족한 일반 투자자에게 거래행위에 필연적으로 수반되는 위험성에 관한 올바른 인식을 방해하거나 또는 고객의 투자성향에 비추어 과대한 위험성을 수반하는 거래를 적극적으로 권유한 경우에 해당하여 결국 고객에 대한 보호 의무를 저버려 위법성을 띤 행위인 것으로 평가될 수 있는 경우에는 투자자에 대한 불법행위 책임이 성립된다.”라고 하고 있음.³¹⁵⁾

피신청인은 본건 상품 가입당시 담당 직원이 신청인에게 상품 내용을 자세히 설명하였고, 상품안내장을 교부하는 등 고객보호 의무를 다하였다고 주장하나 다음과 같은 점으로 보아 피신청인의 사용자배상책임이 인정된다고 보아야 할 것임.

① 피신청인 직원이 본건 파생상품을 권유함에 있어 투자신탁설명서나 약관을 교부하지 않은 점이 인정되며, 「투자설명서 교부 및 주요내용 설명확인서」상의 “투자설명서를 교부 받고 그 주요내용을 설명들었음”의 자필을 담당직원이 대필하였는 바, 「간접투자자산 운용업법」 제56조 제2항,³¹⁶⁾ 「간접투자상품 및 판매에 관한 규정」 제4-7조 제1항³¹⁷⁾에 의한 「표준판매행위준칙」 제13조 제1항,³¹⁸⁾ 「간접투자상품 위탁판매 업무지침」 제25

314) 대법원 2003.7.11. 선고 2001다11802 판결 참조.

315) 대법원 2003.1.10. 선고 2000다 50312 판결 등 참조.

316) 제56조(투자설명서) ② 판매회사는 투자자에게 간접투자증권의 취득을 권유함에 있어 제1항의 투자설명서를 제공하고 그 주요내용을 설명하여야 한다.

317) 제4-7조(표준판매행위준칙 및 간접투자증권 취득권유 위탁계약서 등) ① 법 제57조 제6항에 규정한 표준판매행위준칙은 별지 제5호와 같다.

318) 제13조(투자설명서 교부 및 설명의무) ① 회사(판매 임·직원 및 간접투자증권 취득권유자를 포함한

조 제4항³¹⁹⁾을 이행하지 않은 점.

② 「간접투자상품 및 판매에 관한 규정」 제14조³²⁰⁾에 의하면, 피신청인이 간접투자상품을 권유할 경우에는 투자설명서를 이용하여 간접투자기구의 명칭 및 종류, 투자목적 및 주요 투자전략, 투자원금이 보장되지 않는다는 사실 등 투자위험에 관한 사항, 환매방법, 환매수수료 및 환매수수료 부과기간 등 환매에 관한 사항 등을 구체적으로 명확히 설명하였어야 하나, 피신청인이 이를 이행한 것으로 인정할 증거가 없는 점.

③ 신청인은 만64세이며, 과거 10여년간 여유자금을 신탁형 저축상품이나 단순 정기예금 등으로 거래하여 왔으며, 2005.3.22. 주식형펀드에 1,000만원을 가입한 적은 있으나 소액으로써, 본건과 같은 파생상품에 투자한 경험이 전혀 없고, 피신청인 직원의 권유로 본건 파생상품에 가입할 것을 권유 받았고, 기존에 가입해 있던 특정금전신탁을 해지하고 지급받은 금원으로 본건 파생상품에 가입한 사실이 있는 점이 있어 당해 권유행위가 경험이 부족한 일반 투자자에게 거래행위에 필연적으로 수반되는 위험성에 관한 올바른 인식을 방해하거나 또는 고객의 투자성향에 비추어 과대한 위험성을 수반하는 거래를

다)는 법 제56조 제1항에 따른 투자설명서를 시행령 제54조 제4항에서 정한 방법으로 투자자에게 교부하여야 한다.

② 회사(판매 임·직원 및 간접투자증권 취득권유자를 포함한다)는 투자자에게 실적배당 및 원본의 손실가능성 등 간접투자의 특성과 투자위험에 대하여 투자설명서에 기재된 내용을 투자자가 이해할 수 있도록 명확하고 구체적으로 설명하여야 한다.

③ 회사는 간접투자증권 판매 시 판매 임·직원 및 간접투자증권 취득권유자의 투자설명서 교부 및 설명의무가 성실히 이행되었는지 여부에 대하여 투자자로부터 확인을 받아야 한다.

319) 제25조(거래신청서 등의 접수) ④ 제8조에 의해 투자자에게 투자설명서 교부 및 주요내용을 설명한 후 거래신청서 뒷면의 「투자설명서 교부 및 주요내용설명확인서」를 투자자 자필로 징구하여야 한다.

320) 제14조(투자자에 대한 설명) ① 회사의 판매 임·직원 및 간접투자증권 취득권유자가 투자자에게 간접투자증권의 취득을 권유하는 경우에는 투자설명서를 이용하여 다음 각 호의 사항을 명확하게 구체적으로 설명하여야 한다.

1. 간접투자기구의 명칭 및 종류
2. 간접투자기구의 투자목적 및 주요 투자전략
3. 투자원금이 보장되지 않는다는 사실 등 투자위험에 관한 사항
4. 간접투자기구의 환매방법, 환매수수료 및 환매수수료 부과기간 등 환매에 관한 사항
5. 투자자 또는 간접투자기구가 부담하는 각종 보수 또는 수수료
6. 신탁약관 또는 투자회사 정관의 주요 내용 변경 시 공시에 관한 사항

적극적으로 권유한 경우에 해당한다고 판단됨.

(2) 손해배상액의 확정

신청인의 손해금액은 최초 가입금액 3억 원에서 만기 해지된 금액 189,057,850원의 차액인 110,942,150원이라 할 것임. 다만, 본인의 책임 하에 금융상품을 가입하여야 함에도 불구하고, 본건 파생상품에 대해 정확히 알리고 하지 않았는 바, 신청인의 이러한 과실을 물어 70%의 과실상계를 함이 타당함.

라. 결 론

그렇다면 피신청인은 신청인에게 손해금액 110,942,150원에서 신청인의 과실 70%에 해당하는 금액 77,659,505원을 상계한 나머지 금액 33,282,645원을 배상할 책임이 있어 이를 인용하고, 신청인의 나머지 청구는 이유 없어 기각함.

6-3 파워인컴 펀드의 불완전판매에 따른 손해배상책임

[일부인용] 피신청인은 Moody's의 등급이 언제라도 변경 및 철회, 보류될 수 있다는 사실을 알 수 있었음에도 불구하고 이를 의도적으로 도외시 한 채 무디스의 등급(A3)이 확고불변의 진리인양 과대포장하여 “대한민국 국가신용등급으로 국고채금리+1.2%의 수익추구” 등의 문구가 기재된 상품안내장을 사용하여 신청인으로 하여금 동 상품을 중도환매만 하지 않는다면 원금 손실이 없는 것으로 오인케 한 점 등 불완전판매로 인한 손해배상책임이 인정되나, 신청인도 본건 금융상품이 정기예금과는 다른 상품인 것을 인식할 수 있었음에도 적극적으로 상품 내용을 알리고 하지 아니한 잘못이 있으므로 피신청인의 책임 비율을 50%로 제한함.(2008.11.11. 조정번호 제2008-83호)

가. 사실관계

2005.11.9. 신청인은 피신청인으로부터 “○○ Power Income 파생상품 투자신탁³²¹⁾ 제1

321) 상품 설명시 사용된 안내장의 기재 내용은 다음과 같음.

호”의 가입을 권유받고 ‘거래신청서’를 작성 제출하였으며, 2005.11.11. 50백만원을 입금한 후 통장³²²⁾을 교부받았음.

2008.9.5. 신청인은 상기의 금융상품을 중도 해지하였음.³²³⁾

나. 당사자 주장

(1) 신청인 주장

새마을금고에 가입한 정기예금의 만기가 도래함에 따라 피신청인의 지점에 정기예금을 하기 위해 방문하였는데, 창구 직원이 만기가 6년이고, 3개월 마다 70만원씩의 이자를 지급하는 노후 대책을 세우기에 좋은 상품이 있다며, 이의 가입을 권유하기에 파워인컴금융상품에 가입하게 되었음. 가입 당시 펀드라는 설명을 해 주지 않았고, 3개월 마다 이자를 받으러 피신청인 지점에 방문했을 때에도 펀드라는 얘기를 들은 적이 없었으며, 펀드 실적표 같은 우편물을 단 한번도 받아 본 적이 없어 가입 상품이 당연히 정기예금으로 알고 있었는데, 3년이 지난 시점에서 펀드의 손실이 크다는 연락을 받고서야 신청인이 가입한 상품이 펀드라는 사실을 알게 되었음.

(2) 피신청인 주장

“○○파워인컴 파생금융상품 투자신탁” 가입 권유시 대한민국 국가신용등급과 같은 장외파생상품에 투자하여 원금 손실 가능성은 대한민국 국채 부도확률과 유사한 수준으로 안정성이 있다고 설명한 사실은 있으나, 동 금융상품을 정기예금이라고 안내한 사실

① 대한민국 국가신용등급(무디스 “A3”)으로 “국고채 금리 + 1.2%”의 수익 추구

② 6년간 매 분기 고정금리로 지급

③ 만기에 사전에 결정된 방식으로 손익을 확정하는 파생상품 간접투자신탁

322) 통장의 기재내용은 다음과 같음.

① 상품명: 수익증권(○○파워인컴 파생상품투자신탁 제1호)

② 운용회사: ○○자산운용,

③ 펀드종류: 파생상품형

323) 거래내역은 다음과 같음

① 가입 금액 50,000,000원 ② 해지금액 28,074,500원(21,925,500 손실 발생)

③ 수익금 수령액 9,212,500원(= 708,530원 × 13회) ④ 중도환매 수수료 561,490원

은 없고, 오히려 만기 이전에 환매하는 경우 환매수수료가 있음을 설명드린 바 있으며, 더욱이 신청인은 “가입하신 투자신탁 상품은 은행예금이 아니며, 운용 실적에 따라 수익이 배분되는 실적배당상품으로서 투자원금의 손실이 발생할 수 있습니다.”라고 기재되어 있는 「투자신탁상품 가입고객 확인서」상에 서명날인한 사실이 있음에도 동 금융상품을 정기예금으로 알고 가입하였다는 신청인의 주장은 납득할 수 없음.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 피신청인이 파생상품 판매시 고객에 대한 보호의무를 다하였는 지 여부임.

(1) 위법성 여부의 판단 기준에 관한 판례

대법원은 금융회사 권유행위의 위법성 여부 판단기준에 관하여 “증권회사의 임직원이 고객에게 적극적으로 투자를 권유하였으나 투자 결과 손실을 본 경우에 투자자에 대한 불법행위책임이 성립되기 위하여는, 이익보장 여부에 대한 적극적 기망행위의 존재까지 요구하는 것은 아니라 하더라도, 적어도 거래경위와 거래방법, 고객의 투자상황(재산상태, 연령, 사회적 경험 정도 등), 거래의 위험도 및 이에 관한 설명의 정도 등을 종합적으로 고려한 후, 당해 권유행위가 경험이 부족한 일반 투자자에게 거래행위에 필연적으로 수반되는 위험성에 관한 올바른 인식형성을 방해하거나 또는 고객의 투자상황에 비추어 과대한 위험성을 수반하는 거래를 적극적으로 권유한 경우에 해당하여, 결국 고객에 대한 보호의무를 저버려 위법성을 띤 행위인 것으로 평가될 수 있는 경우라야 한다.”고 판시하고 있음.³²⁴⁾

(2) 위험성에 관한 올바른 인식형성의 방해 여부

다음과 같은 점을 종합적으로 고려할 때, “○○파워인컴 파생상품 투자신탁 제1호”를 권유한 피신청인의 행위는 경험이 부족한 신청인에게 거래행위에 필연적으로 수반되는 위험성에 관한 올바른 인식형성을 방해하였다고 판단됨.

324) 대법원 2003.1.10. 선고 2000다50312 판결 참조.

① 피신청인은 Moody's의 등급은 오직 크레딧 리스크에만 초점을 맞추고 있을뿐, 투자자의 수익률에 현저한 영향을 끼칠 수 있는 그 이외의 리스크는 포함되어 있지 않고, 또한 Moody's 등급은 언제라도 변경 및 철회, 보류될 수 있다는 사실을 익히 알고 있었거나 알 수 있었음에도 불구하고(실제로 등급이 계속 하락하여 현재는 B3임), 피신청인은 이를 의도적으로 도외시 한 채 무디스의 등급(A3)이 확고불변의 진리인양 과대 포장하여 “대한민국 국가신용등급으로 국고채금리 + 1.2%의 수익추구”, “매분기 고정금리 지급”, “동일 만기의 시중 고금리 상품과의 비교(시중은행 후순위채, 국민주택 채권)” 등의 문구가 기재된 상품 안내장을 사용하여 “..... 투자되는 종목들이 국가신용등급과 같은 종목이어서 국채 부도확률과 같고 중도환매만 하지 않는다면 원금 손실은 없을 것”라고 설명함으로써 신청인으로 하여금 본건 금융상품이 원금 손실의 위험성이 거의 없는 상품으로 오해하게 하였는데, 이는 허위표시 또는 중요한 사항에 대하여 오해를 유발할 수 있는 표시행위를 금지하고 있는 「간접투자자산운용업법」(이하 “간투법”이라 함) 제57조 제1항 제4호, 투자원금 손실가능성을 반영하지 아니한 단정적인 연수익률의 광고를 허용하지 아니하는 간투법 제59조 제2항 및 비교 광고시 다른 자산운용회사 및 간접투자기구와의 비교만을 허용하고 있는 간투법 제59조 제2항을 위반한 것이고, 더욱이 이자라는 개념은 금전소비대차 거래에 있어 금전의 사용대가를 말하는 것이어서 여·수신 거래에 국한하여 사용하여야 함에도 의도적으로 수익금이라는 표현 대신 이자, 금리, 고정금리라는 표현을 사용하여 설명하였고, 또한 3개월마다 수익금을 지급할 때에도 통장에 이자라는 단어를 印字함으로써 신청인으로 하여금 본건 금융상품을 정기예금 또는 이와 유사한 상품으로서 원금이 보장되는 것으로 오해하게 하였음.³²⁵⁾

간투법 제56조 제2항, 「표준판매행위준칙」 제13조 및 제14조에 따라 피신청인은 신청인에게 투자설명서를 제공하고, 그 주요 내용을 설명하여야 함에도 이를 위반하여 투자설명서를 제공하지 아니하였음은 물론, 본건 금융상품은 대부분의 자산을 장외파생상품

325) 문답서 등을 통하여 확인된 내용 이외에도 상품안내장, 판매당시의 신문 보도기사, 은행직원 내부 교육용 Q&A 등의 내용을 종합적으로 고려할 때, “대한민국 국채의 부도확률과 유사한 수준으로 시중은행채보다 훨씬 안정성이 높다”, “국채 수준의 안전성으로 국채 금리보다 높은 금리를 확정적으로 6년 동안이나 지급한다”, “원금 손실 확률이 0.02%에 불과하다”라는 표현으로 설명이 이루어졌을 것으로 추정됨.

에 투자하여 운용하는 펀드로 “위험 포트폴리오의 이벤트 수”(변동성이 큰 56종목의 주가가 각 종목별로 기준가 대비 65% 초과 하락한 횟수)에서 “보험 포트폴리오의 이벤트 수”(변동성이 작은 56종목의 주가가 각 종목별 기준가 대비 65% 초과 하락한 횟수)를 차감하여 산출되는 “펀드이벤트의 수치”가 58~90 사이일 때 투자원금의 일부가, 91 이상일 때 투자 원금의 전액이 손실된다는 사실을 전혀 설명하지 아니함.

(3) 과도한 위험성 거래를 적극적으로 권유하였는 지 여부

피신청인은 신청인이 가입 당시 나이가 58세(47년생)인 가정주부로 펀드가입 경험이 전혀 없고, 여유자금을 주로 정기예금 등으로 운용하는 보수적 투자성향을 갖고 있다는 사실을 알고 있었거나 알 수 있었음에도 상기와 같이 투자 원금의 전액이 손실될 가능성이 있는 본건 파생상품을 노후자금으로 운용하기에 적합하고, 고정금리에 3개월마다 이자가 지급되며, 안정성이 매우 높다는 식으로 적극적으로 권유하여 신청인으로 하여금 예금담보 대출을 받아 가입하게 한 사실이 인정됨.

(4) 손해배상책임 유무 및 그 범위

이상을 종합해 보면, 피신청인은 경험이 부족한 신청인에게 본건 금융상품 거래행위에 필연적으로 수반되는 위험성에 관한 올바른 인식형성을 방해하고, 신청인의 투자상황에 비추어 과도한 위험성을 수반하는 거래를 적극적으로 권유하는 등 신청인에 대한 보호 의무를 이행하지 아니하여 불법행위 책임이 성립되는 바, 피신청인은 신청인이 입은 손해를 배상하여야 할 것임.

신청인의 손해금액은 가입금액(50백만원)에서 중도 해지시 수령한 금액(28,074,500원)과 그 동안 3개월마다 수령한 수익금(9,212,500원)을 차감한 금액인 12,713,000원이라 할 것임.

다만, 신청인은 ① “가입하신 투자신탁 상품은 은행예금이 아니며, 운용 실적에 따라 수익이 배분되는 실적배당상품으로서 투자원금의 손실이 발생할 수 있습니다”라고 기재되어 있는 「투자신탁상품 가입고객 확인서」상에 서명날인한 사실이 있는 점, ② 본건 통장의 기재 내용을 보면, 상품명란에 “수익증권(○○ 파워인컴 파생상품투자신탁)”이, 그 하단에는 “펀드종류 : 파생상품형” 등이 기재되어 있는 점, ③ 피신청인이 6년 만기 이

전에 해지하는 경우 환매수수료가 발생한다고 설명한 사실이 있는 점 등을 고려할 때, 신청인은 본건 금융상품이 정기예금과는 다른 상품인 것을 인식하였거나 인식할 수 있었음에도 적극적으로 상품 내용을 알리고 하지 아니한 잘못이 있는 점 등을 참작하여 피신청인의 책임 비율을 50%로 제한하는 것이 타당함.

라. 결 론

피신청인은 신청인의 손해금액 12,713,000원중 50%에 해당하는 금액 6,356,500원을 배상할 책임이 있어 이를 인용하고, 신청인의 나머지 청구는 이유없어 기각함.

6-4 고령자에게 충분한 설명 없이 고위험펀드 판매에 따른 손해배상책임

[일부인용] 본건 펀드 가입시 ‘가입신청서’ 등을 담당직원이 작성하고 날인하였으며, 투자설명서도 교부하지 않은 점, 본건 펀드는 투자위험 5등급 중 1등급으로 매우 높은 수준의 투자위험을 지닌 상품임에 반하여 신청인은 고령의 성직자로 본건과 같은 파생상품펀드의 특성 및 위험성을 쉽게 이해할 수 있다고 보기 어려운 점 등을 감안시 본건 상품의 위험성에 대한 충분하고 명확한 설명 없이 신청인의 투자목적, 투자상황 등에 비추어 과대한 위험성을 수반하는 거래를 적극적으로 권유하였다고 판단됨.(2010.9.14. 조정번호 제2010-79호)

가. 사실관계

신청인은 수녀원 원장으로 1996.8월경부터 수녀회 공동자금을 자신 명의 예금으로 관리하여 오던 중, ○○은행(이하 “피신청인”이라 함) 직원 A씨(이하 “담당직원”이라 함)를 통해 “한국한전일본지수 3단위 파생상품 투자신탁 1호”(이하 “본건 펀드”라 함)에 가입하였으며,³²⁶⁾ 2010.7.2. 53,068,336원을 만기 상환받음(-46.9% 손실).

326) 한국한전일본지수 3단위 파생상품 투자신탁 1호의 개요는 다음과 같음.

- ① 기초자산: 한국전력 보통주 / 니케이 225지수
- ② 투자기간 3년 (매 6개월마다 조기상환기회 부여)
- ③ 자동상환조건: 매 6개월 평가일의 기초자산 주가(지수)가 모두 기준주가의 90% 이상인 경우 연 12.5%의 확정수익 지급후 자동청산
- ④ 만기상환조건: 투자기간 중 한번도 두 종목 모두 기준주가 대비 35% 초과 하락한 적이 없는 경

<본건 펀드 가입 경위>

- 2010.7.26. 신청인과 보좌수녀가 함께 피신청인 지점에 내점하여 가입하였으며, 신청인이 기가입한 펀드의 조기상환 자금으로 가입함. 담당직원은 본건 펀드 가입 이전에 자신이 수녀 원을 직접 방문하여 상품설명을 하고 본건 펀드가입을 권유하였다고 진술함.
- 본건 펀드가입시 “가입신청서”, “고객상담서”, “투자설명서 교부 및 주요내용 설명확인서”의 기재는 담당직원이 모두 대필하고 대신 날인하였으며, 신청인은 다른 설명자료를 받지 못하였다고 주장하는 반면 담당직원은 투자설명서 전체를 교부하지는 않았지만 상품요약설명서를 교부하였고 펀드통장에 수익구조를 요약해서 첨부했다고 진술함.

나. 당사자 주장

(1) 신청인 주장

본건 펀드 가입시 은행직원으로부터 원금손실 가능성 등 상품의 위험성에 대한 설명을 듣지 못했고, 신청인은 그간 피신청인 은행과 원금이 보장되는 예금거래를 해 온 것으로 알고 있었으며, 본건 펀드가 원금손실 가능성이 있다는 설명을 들었다면 수녀회 자금으로 본건 펀드에 가입하지 않았을 것임.

(2) 피신청인 주장

담당직원이 신청인(신청인과 보좌수녀³²⁷⁾)에게 본건 펀드의 특성과 원금손실가능성 등 위험성에 대해 충분히 설명을 하였고 이에 따른 신청인의 자발적 가입의사에 따라 본건 펀드에 가입한 것임.

신청인은 본건 펀드 가입 이전에 유사한 구조의 펀드상품에 2차례 가입한 경험이 있을 뿐만 아니라 신청인에게 교부한 통장 등을 통하여 본건 상품이 예금이 아닌 펀드상품임을 알았다 할 것이므로 이를 예금으로 알았다는 신청인의 주장을 받아들이기 어려움.

우 15(연5%)의 수익 지급, 한 종목이라도 기준주가 대비 35% 초과 하락한 적이 있는 경우 만기 시 하락률이 높은 종목의 주가기준으로 수익률 지급(원금손실)

327) 본건 펀드 가입시 신청인과 보좌수녀인 B씨가 같이 내점하였고 담당직원은 두 사람 모두에게 상품 설명을 하였음.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 본건 상품의 펀드 불완전판매로 인한 손해배상책임 유무라 할 것임.

(1) 관련 판례

금융기관의 임직원이 고객에게 적극적으로 투자를 권유하였으나 투자 결과 손실을 본 경우에 투자자에 대한 불법행위책임이 성립되기 위하여는 이익보장 여부에 대한 적극적 기망행위의 존재까지 요구하는 것은 아니라 하더라도, 적어도 거래경위와 거래방법, 고객의 투자상황(재산상태, 연령, 사회적 경험 정도 등), 거래의 위험도 및 이에 관한 설명의 정도 등을 종합적으로 고려한 후, 당해 권유행위가 경험이 부족한 일반 투자자에게 거래행위에 필연적으로 수반되는 위험성에 관한 올바른 인식형성을 방해하거나 또는 고객의 투자 상황에 비추어 과대한 위험성을 수반하는 거래를 적극적으로 권유한 경우에 해당하여, 결국 고객에 대한 보호의무를 저버려 위법성을 띤 행위인 것으로 평가될 수 있는 경우라야 하며,³²⁸⁾ 또한 금융기관의 임직원이 고객에게 금융투자상품 매입을 권유할 때에는 그 투자에 따르는 위험을 포함하여 당해 상품의 특성과 주요 내용을 설명함으로써 고객이 그 정보를 바탕으로 합리적인 투자판단을 할 수 있도록 고객을 보호하여야 할 주의의무가 있다 할 것임.³²⁹⁾

(2) 펀드 불완전판매 해당 여부

다음과 같은 점에 비추어 담당직원의 본건 펀드 가입권유시 충분하고 적합한 설명이나 권유가 있었다고 보기 어려움.

① 금융투자상품 권유시 고객으로 하여금 거래관련 서류를 직접 작성하게 해야 함에도 불구하고, “가입신청서”, “고객상담서”, “투자설명서 교부 및 주요내용 설명확인서”를 담당직원이 작성하고 날인하였으며, 투자설명서도 교부하지 않았고, 담당직원은 상품요약설명서를 교부했다고 주장하나, 신청인은 위와 같은 사실을 부인하고 있고 달리 담당직원의 주장을 입증할 객관적인 증빙이 없는 점.

328) 대법원 2003.1.10. 선고 2000다50312 판결, 2007.7.12. 선고 2006다53344 판결 참조.

329) 대법원 2003.7.25. 선고 2001다10458 판결 참조.

② 담당직원은 본건 상품 가입시 신청인과 같이 내점한 B씨 모두에게 충분한 설명을 하였다고 주장하나, B씨를 신청인의 대리인으로 보거나 B씨가 동 자금을 관리하고 있다고 보기도 어렵고, 신청인은 상품(특정신탁상품)가입 후 다른 수녀들에게 그 내용을 설명하거나 통장을 보여주지 않았다고 진술하고 있으며, B씨 또한 담당직원으로부터 원금 손실 가능성에 대한 설명을 들은 사실이 없고 원금손실 가능성을 알았다면 본건 펀드에 가입하지 않았을 것이라고 주장하고 있고, 달리 담당직원이 설명의무를 다한 사실을 입증할 객관적인 증빙이 없는 점.

③ 본건 펀드는 투자위험 5등급 중 1등급으로 매우 높은 수준의 투자위험을 지닌 상품으로 장외파생상품의 위험 및 손익구조를 잘 이해하는 투자자 및 3년 이상 장기투자자에게 적합한 상품임에 반하여, 신청인은 고령의 성직자로 본건과 같은 파생상품펀드의 특성 및 위험성을 쉽게 이해할 수 있다고 보기 어려워 보이며, 담당직원 또한 신청인 개인적인 자금이었다면 처음부터 가입권유를 하지 않았을 것이라고 진술하고 있는 점.

④ 본건 펀드의 가입자금이 수녀회 공동자금인 점 등에 비추어 신청인이 원금손실 위험을 감수하면서까지 고수익을 바라며 본건 펀드와 같은 고위험 상품에 투자하는 성향 내지 투자목적은 가진다고 보기 어렵고, 담당직원은 신청인과 예금거래를 할 때부터 신청인의 거래자금이 신청인 개인자금이 아닌 수녀회 공동자금이라는 것을 알고 있었음에도 불구하고, 오히려 수녀원에까지 직접 찾아가 상품권유를 하는 등 본건 상품의 위험성에 대한 충분하고 명확한 설명 없이 신청인의 투자목적, 투자상황 등에 비추어 과대한 위험성을 수반하는 거래를 적극적으로 권유하고 있다고 보이는 점.

⑤ 신청인이 담당직원의 권유로 본건과 유사한 구조의 펀드에 2차례 가입한 사실은 있으나 위 펀드 가입으로 손실을 본 경험이 없고 달리 원금손실 위험이 높은 상품에 투자한 경험이 없으며, ELF 상품은 상환조건이 충족되는 경우 확정수익이 지급되는 상품으로 담당직원의 명확한 설명이 없는 경우 오히려 신청인이 이를 확정금리가 지급되는 예금상품으로 오해할 가능성이 있는 점.

⑥ 기존에 2차례 펀드 가입시에도 담당직원이 관련서류의 전부 또는 일부를 대필하는 등 적정한 판매절차를 준수하지 않았으며, 신청인은 신문이나 TV도 보지 않고 일반인

들과 대화도 거의 없어 펀드가 뭔지 몰랐다고 주장하고 있고, 담당직원 또한 신청인이 펀드가 뭔지 알지 못한 상태였고 신청인이 연로하여 의사소통이 제대로 안되었다고 진술하고 있는 점 등에 비추어 점에 비추어 신청인의 기존 펀드 가입 경험으로 신청인이 본건 펀드의 위험성을 알았다고 보기 어려운 점.

(3) 손해배상액 산정

신청인의 손해금액은 투자원금 1억원에서 상환금액 53,068,336원을 차감한 46,931,664원이라 할 것임. 다만, 본질적으로 투자자는 자기책임의 원칙 아래 투자상품의 위험성 등에 관한 내용을 사전에 정확히 파악하여 신중히 검토한 다음 투자하여야 할 것인데도 신청인이 이를 게을리한 점 등을 고려하여 신청인의 과실비율을 50%로 보고 피신청인의 책임을 50%로 제한함.

라. 결 론

피신청인은 신청인에게 손해금액 46,931,664원에서 신청인의 과실 50%를 상계한 나머지 금액 23,465,832원을 배상할 책임이 있어 이를 인용하고, 신청인의 나머지 청구는 이유 없어 기각함.

6-5 선박펀드의 불완전판매에 따른 손해배상책임

[일부인용] 선박펀드는 선박사업에 따른 위험과 손익을 잘 알고 있는 투자자에게 적합하고 신탁기간 또한 4년인 폐쇄형 상품으로 장기적으로 자금을 운용하고자 하는 투자자에게 적합한 상품임에 반하여 신청인은 본건 상품 가입 이전에 예금, MMF, 신탁거래 등 비교적 안정한 상품 위주로 거래를 해왔고 본건과 같은 구조의 상품에 투자한 경험이 없으며, 가입당시 80세의 고령으로 본건 상품의 특성 및 위험성을 쉽게 이해할 수 있다고 보기 어려운 점, 본건 펀드 권유시 담당직원이 신청인을 대신하여 관련서류를 대필하거나 기재하지 않은 점 등을 감안시 피신청인이 원본손실가능성 등 상품의 위험성에 대한 충분하고 적합한 설명이 있었다고 보기 어렵다고 판단됨. (2010.7.13. 조정번호 제2010-60호)

가. 사실관계

신청인은 2005.5.2. ○○은행(이하 “피신청인”이라 함) 지점 직원 A씨(이하 “담당직원”이라 함)의 권유를 받고 본인 및 자녀들 명의로 “△△△△선박 특별자산투자신탁(제2호)”³³⁰⁾에 4억5,000만원을 가입하였음.

<신청인의 과거 투자경험 및 본건 펀드 가입경위>

- 신청인은 본건 펀드 가입이전 주로 예금, MMF, 신탁거래 등을 하여 왔으며 2003.2.5. “***** 혼합투자신탁”에 40백만원을 투자한 경험이 있음.
- 본건 펀드가입은 2005.5.2. 신청인이 피신청인 지점에 내점하여 가입하였으며, 신청인이 2004.5.20. 기가입한 특정금전신탁(CP)을 해지한 자금으로 가입.
- 본건 펀드가입시 “거래신청서”, “투자설명서 교부 및 주요내용 설명확인서”상의 서명은 신청인이 자필날인하였으나, 동 확인서상 “제공받고”, “설명들었음”이라는 문구는 담당직원이 대필하였으며, “투자신탁상품 가입고객확인서”상 체크하도록 되어있는 원금손실발생사실 등의 확인란 체크는 피신청인 직원이 대신 기재하거나 기재되어 있지 않음.
- 신청인은 펀드통장 이외에 다른 설명자료를 받지 못하였다고 주장하는 반면, 담당직원은 상품제안서로 설명을 하고 교부하였지만 신청인이 많은 분량의 투자설명서를 가져가지 않았을 것이라고 진술하고 있음.
- 담당직원은 본건 펀드통장에 선박펀드라고 기재하고 상품제안서상의 원리금지급구조를 정리하여 지급일정을 스티커로 부착하여 교부하였으며, 통장상에는 매 6개월마다 지급되는 수익금이 이자로 표시되어 있음.

330) △△△△선박 특별자산투자신탁(제2호)의 개요는 다음과 같음.

- ① 운용개요: 선박사업자인 A기업(주)가 보유할 특정선박(*****) 운용사업(용선, 선박매도)에 권리 형태로 투자하고 그 수익을 분배받는 특별자산투자신탁(공모형, 폐쇄형)
- ② 투자기간: 4년 ③ 목표수익률: 연 7.3% 수준
- ④ 원금지급: 설정후 6개월 단위로 원금의 8.75%씩 지급하고 설정금액의 약 38.75%는 만기시 지급
- ⑤ 이자지급구조: 설정일로부터 매 6개월 단위로 지급
- ⑥ 기타: - A기업(주)가 보유선박에 담보권 설정 및 보유선박을 ◇◇해운에게 용선하여 수익을 발생
- ◇◇해운이 4년간 용선후 재매입 의무
- 해운사의 파산 및 고의에 의한 계약불이행시 선박회수후 재용선 또는 매각
- ◇◇해운은 4년간 용선료(원금 70%+ 9.2%) 및 재매입에 대한 지급보장

한편, 본건 펀드는 보유선박의 용선거래 위축으로 채용선을 통한 수익확보가 어렵게 되었고 2008.10.30. 용선사 선원들의 임금체불과 관련하여 법원경매가 진행되어 만기일인 2009.5.4. 펀드 상환금이 지급되지 못하고 2009.12.15. 선박경매 매각대금으로 청산됨.

신청인은 본건 펀드 청산시까지 원리금 합계 총413,356,555원을 지급받아 36,643,445원의 손실을 입음.

나. 당사자 주장

(1) 신청인 주장

담당직원이 연 8.75%의 이자가 지급되는 예금이라고 설명하고 해당 내용을 통장에 표시해 주어 예금으로 알고 본건 펀드에 가입하였으며, 만약 담당직원이 원금손실을 입을 수 있는 상품이라고 설명하였더라면 절대로 가입하지 않았을 것임.

담당직원이 시키는 대로 가입신청서 등에 이름을 기재하였을 뿐이며, 원금손실 위험이 있는 펀드에 가입한 줄 모른 채 6개월마다 원금과 이자를 통장으로 지급받아 오던 중 2008.11월 담당직원이 집에 찾아와 이번에는 이자만 주고 원금은 선박회사가 부도나서 배가 팔리면 정산해서 주겠다고 하여 처음으로 원금손실을 볼 수 있다는 설명을 들었음.

(2) 피신청인 주장

신청인이 정기예금(당시 금리 연 4.5% 정도)보다 고금리상품을 선호하였고 고령임에도 불구하고 기억력이 좋고 사리판단이 분명하여 당시의 금융환경이나 경제상황 등을 감안, 선박을 담보로 취득하는 본건 펀드를 추천하였음.

상품제안서를 이용하여 본건 상품은 정기예금이 아닌 펀드상품이고 원금손실 발생가능성은 있으나 선박을 담보로 취득하므로 안전장치가 있다고 설명하였으며, ‘투자설명서 교부 및 주요내용 설명확인서’에 신청인의 자필서명을 받았으나 신청인이 ‘제공받고, 설명들었음’ 이란 기재를 누락하여 신청인의 동의하에 이를 대필로 기재하였을 뿐이며, 신청인이 자산운용보고서를 요청하지 아니하여 이를 통보하지 않았지만 금융거래현황표를 출력하여 수시로 교부하였음

또한 통장표지에 “선박펀드”라고 기재를 하여 주었고, 통장에 원리금지급일정을 기재한 것은 신청인의 이해를 돕기 위해 원리금지급구조를 정리하여 통장에 부착한 것일 뿐이므로 책임이 없음.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 펀드 불완전판매로 인한 손해배상책임 유무 및 그에 따른 구체적인 손해배상액 산정이라 할 것임.

(1) 펀드 불완전판매 여부

금융기관의 임직원이 고객에게 금융상품의 매입을 권유할 때에는 그 투자에 따르는 위험을 포함하여 당해 상품의 특성과 주요 내용을 설명함으로써 고객이 그 정보를 바탕으로 합리적인 투자판단을 할 수 있도록 고객을 보호하여야 할 주의의무가 있고, 이러한 주의의무를 위반한 결과 고객에게 손해가 발생한 때에는 불법행위로 인한 손해배상책임이 성립한다 할 것이고, 투자에 따르는 위험과 관련하여 투자권유자는 투자에 따르는 제반 위험이 존재하고 이로 인하여 원본 손실가능성이 있다는 사실 등을 설명하여야 하는 것이나, 고객에게 어느 정도의 설명을 하여야 하는지는 투자대상인 상품의 특성 및 위험도의 수준, 고객의 투자경험 및 능력 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 할 것임.³³¹⁾

이에 비추어 볼 때, 담당직원의 본건 상품 가입권유행위는 다음과 같은 점에서 원본손실가능성 등 상품의 위험성에 대한 충분하고 적합한 설명이 있었다고 보기 어렵다고 판단됨.

① 본건 상품은 특별자산에 투자하는 간접투자기구로서 선박의 매입 및 용선과 관련된 사업으로부터 발생하는 수익을 분배받을 수 있는 계약상의 출자지분 또는 권리에 투자하는 펀드로서 선박사업에 따른 위험과 손익을 잘 알고 있는 투자자에게 적합³³²⁾하고

331) 대법원 2003.7.25. 선고 2001다10458 판결 참조.

332) 본건 펀드의 수익분배금 및 원금상환은 궁극적으로 용선사인 ◇◇해운의 용선료수입에 의존하고, 용선사의 재매입의무가 있으므로 동 펀드의 거래구조상 핵심적인 위험은 용선사인 ◇◇해운 관련 위험이라 할 것임(◇◇해운의 2003년 매출액 순위 : 9위)

신탁기간 또한 4년인 폐쇄형 상품으로 장기적으로 자금을 운용하고자 하는 투자자에게 적합한 상품임에 반하여, 신청인은 본건 상품 가입 이전에 예금, MMF, 신탁거래 등 비교적 안정한 상품 위주로 거래를 해왔고 본건과 같은 구조의 상품에 투자한 경험이 없으며, 가입당시 80세의 고령으로 본건 상품의 특성 및 위험성을 쉽게 이해할 수 있다고 보기 어려운 점.

② 금융투자상품 권유시 고객으로 하여금 거래관련 서류를 직접 작성하게 해야 함에도 불구하고 담당직원이 신청인을 대신하여 “투자설명서 교부 및 주요내용 설명확인서”상의 “제공받고”, “설명들었음”이라는 문구를 대신 기재하였고, “투자신탁상품 가입고객 확인서”상 체크하도록 되어있는 원금손실발생사실 등의 확인란 체크 또한 담당직원이 대신 기재하거나 기재가 되어있지 아니한 점.

③ 펀드가입시 고객의 입장에서 상품설명자료에 기재된 내용보다 실제 판매업무를 담당하는 직원의 설명이나 동 직원이 명시적으로 기재한 내용에 더 의존한다고 보는 것이 보통이라 할 것인데, 본건의 경우 펀드가입시 담당직원이 본건 상품의 원리금지급구조를 정리하여 이를 스티커로 통장에 부착하고 있고, 앞서 본 신청인의 투자경험이나 연령, 신청인의 주장 등에 비추어 신청인이 이를 원금손실 없이 원리금이 지급되는 상품으로 오해할 여지를 제공하고 있다고 보이는 점.

④ 나아가, 신청인은 펀드통장 이외에 다른 설명자료를 받지 못하였다고 주장하고 있고 담당직원 또한 의견서에서 신청인이 많은 분량의 투자설명서를 가져가지는 않았을 것이라고 진술하고 있는 점.

(2) 손해배상액 산정

신청인의 손해금액은 투자원금 450,000,000원에서 본건 펀드 청산시까지 지급받은 원리금 합계 총413,356,555원을 차감한 36,643,445원이라 할 것임.

한편, 다음과 같은 점을 고려하여 피신청인의 책임을 20%로 제한하는 것이 상당함.

① 투자자는 자기책임의 원칙 아래 투자상품의 개념이나 내용, 손익구조, 투자위험성 등에 관한 사항을 사전에 정확히 파악하여 신중히 검토한 다음 투자하여야 할 것인데도 신청인은 비교적 거액을 투자하면서도 이를 게을리 하였고, 비록 신청인이 본건 펀드와

유사한 상품에 투자한 경험은 없더라도 기존에 원금손실 가능성이 있는 신탁거래 및 혼합형 펀드에 투자한 경험이 있는 점.

② 신청인이 본건 상품 가입시 거래신청서, “투자설명서 교부 및 주요내용 설명확인서” 및 “투자신탁상품 가입고객 확인서”에 자필서명 날인하였으며, 본건 펀드 통장에 “이 예금은 예금자보호법에 의해 보호되지 않습니다.” “이 상품은 은행예금이 아니며 운용실적에 따라 수익이 배분되는 실적배당 상품으로서 투자원금의 손실이 발생할 수 있습니다.”라는 문구가 기재되어 있으며, 담당직원이 본건 펀드통장에 “선박펀드”라고 기재한 사실이 있는 점.

라. 결 론

그렇다면 피신청인은 신청인에게 손해금액 36,643,445원에서 신청인의 과실 80%를 상계한 나머지 금액 7,328,689원을 배상할 책임이 있다 할 것임.

제2절 기 타

6-6 변경된 신탁약관의 임의적용에 따른 손실보상 요청의 건

[인용] 계약상대방인 고객이 약관을 계약의 내용으로 할 것에 동의한 경우에 법적 구속력을 가진다고 할 것인 바, 본건 변경약관에 대하여 신청인이 동의한 사실이 없는 점, 「약관의 규제에 관한 법률」 제12조에서는 작위 또는 부작위가 있을 때 고객의 의사표시가 표명되거나 표명되지 아니한 조항은 무효로 보고 있는데, 피신청인이 신청인에게 동 변경사실을 개별적으로 고지하지 않은 점 등을 감안할 때 약관변경 후 1월이내의 이의신청기간 내에는 신청인이 계약의 유지여부를 결정할 권한을 보유하고 있다고 보는 것이 타당하므로 신청인이 이의를 제기한 본건에 있어서는 변경 전 약관을 적용해야 할 것임.(2008.3.11. 조정번호 제 2008-17호)

가. 사실관계

2007.10.8, 10.15. 신청인은 ○○은행(이하 “피신청인”이라 함) 지점에서 본인 및 자녀 명의로 ◇◇차이나 주식형 자투자신탁³³³⁾(이하 “본건 투자신탁”이라 함) 3건을 가입함.

본건 투자신탁의 자산운용회사인 ◇◇자산운용은 본건 투자신탁의 약관(이하 “본건 신탁약관”이라 함)중 기준가적용일을 환매를 청구한 날부터 4영업일(17시 경과 후 환매청구시 5영업일)에서 3영업일(17시 경과후 환매청구시 4영업일)로 변경(2007.11.9.자)하기로 하고, 본건 신탁약관 변경내용을 2007.11.8. 모 경제신문에 공고하였으며, 2007.11.9. ◇◇자산운용, 피신청인, 자산운용협회는 홈페이지에 변경 내용을 공고하였음.

2007.11.12.(월) 신청인은 본건 투자신탁에 대한 전액 환매신청을 하였고, 변경된 약관에 의해 2007.11.14.을 기준가 적용일로 하여 지급일자인 2007.11.20. 환매대금이 지급(2007.11.15. 기준가는 전일대비 하여 상승)되었는 바, 신청인은 기준가 적용일에 대하여 이의를 제기함.

333) 동 투자신탁은 중국 및 중국관련 지역 및 국가에서 발행된 중국 및 중국 관련 해외주식에 주로 투자하는 ◇◇차이나 주식형 모투자신탁의 자투자신탁임.

나. 당사자 주장

(1) 신청인 주장

피신청인은 변경된 신탁약관을 신청인에게 통보하지 않아 이에 변경사실을 알지 못하고 환매신청 하였고, 본건 신탁약관 변경에 대한 이의신청 기간인 1개월을 초과하지 않았는 바, 변경전의 신탁약관을 적용하여 줄 것을 요청함.

(2) 피신청인 주장

본건 투자신탁의 기준가 적용일 관련 약관변경은 수익자들의 빠른 환매를 돕기 위해 이루어진 것이며, 본건 신탁약관과 관련 「간접투자자산 운용업법」에서 요구하는 약관 변경시 공고하여야 하는 절차를 모두 이행하였음.

또한 간접투자상품의 특성으로 볼 때, 약관에 이의신청 기간을 둔 이유는 이의신청 기간 내에 이의신청서를 제출하더라도 변경된 약관을 적용하고, 환매수수료를 받지 않는다는 것이지 변경 전 약관을 적용한다는 의미는 아닌 바, 신청인의 주장을 수용할 수 없음.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 본건 투자신탁의 약관변경 시 공시일로부터 1월 이내에 고객이 이의신청할 경우 어떠한 약관을 적용해야 하는지 여부라 할 것임.

(1) 본건 투자신탁의 약관변경 시 공시일로부터 1월 이내에 수익자가 이의신청할 경우 어떠한 약관을 적용해야 하는지 여부

본건 「신탁약관」 제49조 제4항³³⁴⁾은 약관변경 공시일로부터 1월 이내의 이의신청기간

334) 제49조(신탁약관의 변경) ④ 수익자가 제2항의 규정에 의한 공시일로부터 1월 이내 또는 제3항의 규정에 의한 게시기간(이하 “이의신청기간”이라 한다) 내에 판매회사에 이의신청서를 제출하지 않은 때에는 신탁약관 변경에 대해 동의한 것으로 본다.

⑤ 수익자가 이 신탁약관 및 모투자신탁의 신탁약관 변경에 대하여 이의신청기간내에 이의신청서를 제출하고 수익증권의 환매를 청구하는 경우에는 제23조의 규정에 불구하고 환매수수료를 받지

안에 이의신청서를 제출하지 아니한 경우에는 신탁약관 변경에 대해 동의한 것으로 본다고 규정하고 있는데, 이는 다음과 같은 점으로 볼 때 수익자가 이의신청기간 안에 이의신청서를 제출하면 신탁약관 변경에 대해 동의하지 않은 것으로 보아, 변경된 약관이 자동으로 계약의 내용에 편입되는 것이 아님을 의미한다고 할 것임.

① 판례는 “약관의 내용이 일반적으로 예상되는 방법으로 명시되어 있지 않다든가 또는 중요한 내용이어서 특히 보험업자의 설명을 요하는 경우에는 위 약관의 구속력은 배제된다.”³³⁵⁾라고 하여 계약의 상대방인 고객이 약관을 계약의 내용으로 할 것에 동의한 경우에 법적 구속력을 가진다고 하고 있으나, 본건에 있어서는 동 변경약관에 대하여 신청인이 동의한 사실이 없는 점.

② 또한 「약관의 규제에 관한 법률」 제12조 제1호³³⁶⁾는 작위 또는 부작위가 있을 때 고객의 의사표시가 표명되거나 표명되지 아니한 조항은 무효로 보고, 다만 고객에게 상당한 기간 내에 의사표시를 하지 아니하면 의사표시가 표명되거나 표명되지 아니한 것으로 본다는 뜻을 명확하게 따로 고지할 경우에만 약관을 무효로 하지 않고 있는데, 본건에 있어서는 피신청인이 신청인에게 동 변경사실을 개별적으로 고지하지 않은 점.

한편 신청인이 본건 투자신탁 약관변경일인 2007.11.9(금) 바로 다음 거래일인 11.12(월)에 피신청인의 인터넷뱅킹을 통해 환매 신청한 사실로 볼 때 약관변경 내용을 알았다고 판단키 어려우며, 또한 약관변경 후 1월 이내의 이의신청기간 내에는 신청인이 약

아니한다.

제51조(수익자에 대한 공고) ② 자산운용회사는 다음 각 호의 1에 해당하는 사항을 그 사유발생 후 지체 없이 자산운용회사·판매회사 및 자산운용협회의 인터넷 홈페이지 또는 자산운용회사·판매회사의 본·지점 및 영업소에 게시하거나 전자우편을 이용하여 수익자에게 통보하여야 한다.

5. 이 신탁약관 또는 투자설명서의 변경.

335) 대법원 2000.4.25. 선고 99다68027 판결 참조.

336) 제12조(의사표시의 의제) 의사표시에 관하여 정하고 있는 약관의 내용 중 다음 각 호의 1에 해당하는 내용을 정하고 있는 조항은 이를 무효로 한다.

1. 일정한 작위 또는 부작위가 있을 때 고객의 의사표시가 표명되거나 표명되지 아니한 것으로 보는 조항. 다만 고객에게 상당한 기간 내에 의사표시를 하지 아니하면 의사표시가 표명되거나 표명되지 아니한 것으로 본다는 뜻을 명확하게 따로 고지하거나 부득이한 사유로 그러한 고지를 할 수 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

관의 변경내용에 대한 동의 여부, 즉 계약의 유지여부를 결정할 권한을 보유하고 있다고 보는 것이 타당하므로 이의신청 기간인 1개월 이내에 신청인이 이의를 제기한 본건에 있어서는 변경 전 약관을 적용해야 할 것임.

(2) 손해배상액의 산정

변경 전 약관을 적용하여 2007.11.15.을 기준가 적용일로 한 환매대금 249,544,080원에서 2007.11.14.을 기준가 적용일로 한 환매대금 234,924,125원의 차액인 14,619,955원이 손해액이라 할 것임.

라. 결 론

피신청인은 변경 전 약관에 의한 기준가로 계산한 환매대금에서 변경된 약관에 의해서 지급한 환매대금을 차감한 금액을 지급할 책임이 있어 이를 인용함.

6-7 당사자간 계약체결 사실이 입증되지 않는 통화옵션계약의 성립 여부

[인용] 일반적으로 은행은 통화옵션계약을 체결할 때 거래상대방으로부터 파생금융상품거래의향서를 사전에 제출받은 후 계약내용을 확정할 때 이를 증거하기 위해 계약내용을 녹취하거나 거래확정 직후에 거래내용이 반영된 통화옵션거래확인서에 상대방의 자서날인을 받고 있는데, 본건의 경우 피신청인은 구두로 계약이 체결되었다고 주장만 할 뿐 달리 이를 입증할 수 있는 객관적 증거자료가 없는 점에 비추어 볼 때 당사자간에 본건 통화옵션계약이 유효하게 성립되었다고 보기는 어려운 것으로 판단됨.(2008.10.16. 조정번호 제 2008-81호)

가. 사실관계

신청인은 2008.3.3. 17:03경 피신청인으로부터 파생금융상품거래의향서(이하 “거래의향서”라 함) 양식을 팩스로 송부받고 회사의 명판과 법인인감을 날인하여 피신청인에게 팩스로 송부함.

파생금융상품거래의향서 양식 내용

당사는 귀행이 제안한 파생금융상품 구조 및 위험에 대하여 충분히 이해하였고, 또한 기업의 정관 및 회사설립근거법, 사규 등에 파생상품거래를 금지하지 않고 있음을 확인합니다. 이에 따라 당사 내부적인 승인과정이 완료되어 아래와 같은 파생금융상품 거래를 체결하고자 하오니 거래를 위한 가격 등 거래조건을 알려주시길 부탁드립니다.

1. 거래상품 : 통화옵션
2. 거래통화/금액 : USD 360만불 / 720만불
3. 만기일 : 2009.3.5.
4. 기타사항 : WKIKO Target Forward 1~12개월, 월 30 또는 60만불 매도
매도 950원, WKO 925원, WKI 990원

피신청인은 거래의향서를 신청인에게 팩스로 보낸시간이 17:03으로 되어 있으나 이는 피신청인의 팩스기 시간이 5분 정도 늦게 설정되어 있기 때문이며, 실제로는 계약이 체결된 16:58경에 이미 거래의향서에 날인을 받았다고 주장함.

피신청인은 신청인과의 통화옵션계약이 체결되었음을 사유로 통화옵션계약 체결시 제출받는 통화옵션거래약정서, 통화옵션거래확인서, 장외파생상품거래 위험고지서 수령확인서, 근보증서(이하 “계약관련 서류”라 함)에 신청인의 자서날인을 요구하였으나, 신청인은 계약 내용이 신청인과 맞지 않아 계약을 체결하지 않겠다며 자서날인을 거부함.

피신청인은 계약관련 서류에 신청인의 자서날인을 받지 못한 상태에서 2008.4.7.~9.5. 기간중 Knock-in 발생한 거래손실금(누계 312백만원)을 신청인에게 결제 요청하였으나 신청인은 계속적으로 통화옵션계약의 성립을 부인하며 피신청인의 결제 요청을 거부함.

나. 당사자 주장

(1) 신청인 주장

신청인은 파생상품거래에 대한 설명이나 계약관련 서류를 보지 못한 상태에서 수출업체에 좋은 상품이 있으니 가입하라는 지속적인 권유를 받고 거래조건을 알아보기 위해 거래의향서에 날인해 주었으나, 이는 거래의향서에 확정적으로 계약을 뜻한다는 문구도 없고 단지 거래의 예비단계로서 제출하는 것으로 생각하였을 뿐이며, 피신청인과 구두로

라도 계약을 체결하지 않았음.

거래의향서 송부 후 20여일이 지난 2008.3.24. 피신청인이 거래약정서 등 계약관련 서류를 가져와 날인을 요구하였으나, 그때서야 계약관련 서류를 본 신청인은 해당상품이 신청인과 맞지 않는 상품으로 판단하여 계약을 하지 않겠다고 하였으므로 신청인과 피신청인간 통화옵션계약이 체결되지 않았음. 그러함에도 피신청인이 거래의향서에 날인을 하였다는 이유 등을 들어 신청인에게 통화옵션거래 손실금액을 청구하는 것은 부당함.

(2) 피신청인 주장

신청인은 거래조건을 알아보고자 거래의향서에 날인하였다고 주장하나, 피신청인은 3.3. 신청인을 방문하여 대표이사과 부사장에게 상품내용을 설명하고 대표이사과 구두 계약을 체결하고 거래의향서를 팩스로 신청인에게 송부하여 날인받은 것임.

통화옵션거래확인서에 거래당일 신청인의 날인을 받지 못한 것은 본점 금융공학센터로부터 18:30경에 동 확인서를 받았기 때문이며, 통화옵션거래약정서도 신청인의 대표이사가 장기 해외출장중인 관계로 사전에 제출받기 힘든 상황이어서 거래가 성사되면 거래확인서와 함께 날인을 받고자 한 것임.

피신청인은 거래상대방의 요구가 없는데도 임의로 통화옵션계약을 체결할 수 없으며, 신청인은 구두 계약이 체결되었다는 점을 부인하지 않으면서도 환율상승으로 불리해지자 계약관련서류에 날인을 거부한 것임.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 신청인과 피신청인 간에 통화옵션계약이 유효하게 성립되었다고 볼 수 있는지 여부라 할 것임.

우리나라 민법상 구두에 의한 계약도 유효한 계약으로 성립할 수 있으나 계약의 체결 여부에 관해 다툼이 생기면 계약의 유효한 성립을 주장하는 자에게 입증책임이 있다고 할 것인데, 일반적으로 거래당사자들이 거래의향서를 준비하는 가장 큰 이유는 장차 전개될 일련의 세부적 계약내용의 출발점의 역할을 하게 함과 동시에 최종계약서에 서명

하기 전에는 구속력이 있는 문서를 체결하는 것을 피하기 위한 것으로 볼 수 있으며, 본건의 경우 통화옵션거래 경험이 없는 신청인 또한 제반 정황상 거래의향서가 구속력이 있는 것으로 알고, 이에 날인한 것으로 보기 어려우며, 일반적으로 은행들은 본건과 같은 통화옵션계약을 체결할 때 거래상대방으로부터 파생금융상품거래의향서를 사전에 제출받은 후 최종적으로 거래상대방과 거래환율을 협의하는 등의 계약내용을 확정하면서 이를 증거하기 위해 계약내용을 녹취하거나 거래확정 직후에 거래내용이 구체적으로 반영된 통화옵션거래확인서에 거래상대방의 자서날인을 받고 있는데, 본건의 경우 피신청인은 신청인과 구두로 계약이 체결되었다고 주장만 할 뿐 달리 이를 입증할 수 있는 객관적 증거자료가 없는 점에 비추어 볼 때, 신청인과 피신청인 간에 본건 통화옵션계약이 유효하게 성립되었다고 보기는 어려운 것으로 판단됨.

라. 결 론

신청인과 피신청인 간에 통화옵션계약이 유효하게 성립되었다고 볼 수 없으므로 이에 주문과 같이 결정함.

6-8 투자신탁 판매회사가 고유재산에 의한 환매의무를 부담하는 지 여부

[기각] 관련 법령상 “자산운용회사는 간접투자재산의 범위안에서 간접투자재산을 매각하여 조성한 현금만으로 환매대금을 지급하여야 한다”고 규정함으로써 판매회사 및 자산운용회사는 자기의 고유재산으로 환매대금을 지급할 의무가 없음을 명백히 하고 있음. 따라서 본건 투자신탁에 편입된 장외파생상품 거래상대방의 청산절차 진행으로 장외파생상품을 매각하지 못하는 사유가 발생하였기에 동 사유로 자산운용사가 수익증권의 환매를 연기한 것은 관련법률에 근거한 것으로 적법·타당하다 할 것임.(2008.12.9. 조정번호 제2008-93호)

가. 사실관계

2006.9.13. 신청인은 “○○ 2STAR 파생상품 투자신탁 3호”³³⁷⁾(이하 “본건 투자신탁”)에 9천만원을 투자하였으며, 2008.9.12. 조기상환 조건의 충족으로 수익금액이 결정됨

(연 11.5%).

2008.9.12. ○○자산운용, ◇◇은행에 대해 아래 내용의 “조기상환 안내문”을 발송하였고, 동일자로 ◇◇은행은 신청인의 휴대폰으로 “안내 문자메시지”를 전송³³⁸⁾하였음.

- 제4차 상환평가일인 2008.9.12. 각 기초자산의 증가가 최초 기준주가의 80%이상으로 조기상환 조건 충족 ⇒ 확정수익률 23.0%(연 11.50%), 조기상환 지급예정일 : 2008.9.19.

2008.9.15. Lehman Brothers Holdings³³⁹⁾가 파산보호 신청을 하였으며, 2008.9.16. 홍콩 증권선물거래소가 LBCCA를 포함한 동사의 홍콩 자회사에 대하여 자산제한조치를 취함(2008.9.19. LBCCA에 대한 청산절차 개시).

2008.9.17. ○○자산운용은 ◇◇은행에 대해 “장외파생상품 발행사의 파산보호 신청에 따른 자산 상각 및 환매 연기 공지의 건” 제하의 문서³⁴⁰⁾를 발송하였으며, ◇◇은행은 9.17.과 9.18. 양일에 걸쳐 신청인의 휴대폰으로 “상환 유예 안내문”³⁴¹⁾을 발송.

2008.10.28. 제1차 수익자 총회가 개최되어 수익증권 환매 등에 관한 의결을 11.28.로 연기하기로 결정되었고, 2008.11.28. 제2차 수익자 총회는 발행된 수익증권 총좌수의 과반수를 보유하는 수익자의 출석이 이루어지지 아니하여 총회가 불성립됨에 따라 12.11.로 재차 연기됨.

337) 본건 “○○ 2STAR 파생상품투자신탁 3호”의 개요는 다음과 같음.

- ① 설정일: 2006.9.20. ② 판매회사: ◇◇은행, ○○○증권 ③ 상환평가일(4차): 2008.9.12
- ④ 기초자산: A기업 보통주, B기업 보통주 ⑤ 투자신탁 만기: 3년(6개월 단위 조기상환)
- ⑥ 조기상환조건: 설정일로부터 매 6개월인 조기상환 평가일에 기초자산 두 종목의 증가가 최초 기준주가 대비 85%(6개월, 1년), 80%(1년6개월, 2년), 75%(2년6개월) 이상일 경우
⇒ 연 11.50%수준으로 조기상환

338) 고객님! 가입하신 “○○ 2Star 파생 3호” 펀드가 연11.5%의 수익률로 조기상환 확정되었습니다. 원리금은 9월 19일에 결제계좌로 입금될 예정입니다.

339) 장외파생상품의 발행사인 LBCCA(Lehman Brothers Commercial Corporation Asia Ltd)의 모회사임.

340) ① 연기 사유: LBCCA의 모회사인 Lehman Brothers Holdings의 파산보호신청

② 연기 기간 : 2008.9.19.부터 자금 회수일까지

③ 향후 절차 : 환매연기일로부터 6주 이내에 수익자총회를 통한 수익증권 환매에 관한 사항 의결

341) 9/19 상환예정이었던 “○○ 2Star 파생상품 3호”는 발행사(리먼브러더스)의 신용상태 악화에 따라 상환이 유예될 수 있습니다.

나. 당사자 주장

(1) 신청인 주장

신청인은 여유자금을 안전하게 운용하기 위해 피신청인 지점을 방문하였을 때, 상담직원이 “A기업 및 B기업 주식이 40% 이하로만 안 떨어지면, 원금도 보장된다”, “우리나라가 망하지 않는 한 이 회사의 주식은 40% 이하로 떨어질 수 없다”라고 설명하며, “○○2Star 파생상품 투자신탁’ 상품을 권유함에 따라 동 상품에 90백만원을 가입하였는데, 리먼의 파산보호 신청으로 투자금을 회수하지 못할 상황이 되었음.

동 상품 가입 당시 피신청인은 동 상품이 리먼사와 관련이 있다는 사실을 전혀 설명한 사실이 없고, 또한 2008.9.12.에는 조기상환 조건이 충족되어 9.19.에 원리금을 지급하겠다는 통보를 한 사실이 있으므로 이에 대한 책임을 져야 할 것임.

(2) 피신청인 주장

본건 투자신탁에 편입된 장외파생상품의 발행사인 LBCCA가 청산 절차에 들어감에 따라 불가피하게 「간접투자자산운용업법」(이하 “간투법”이라 함) 제65조 및 같은 법 시행령 제62조에 의하여 환매를 연기하게 되었는데, 향후 환매에 관한 사항은 수익자 총회에 의해 결정될 것임.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 판매회사가 고유재산에 의한 환매의무를 부담하는 지 여부 및 피신청인의 권유행위가 불완전판매로서 불법행위에 해당되는 지 여부임.

(1) 판매회사가 고유재산에 의한 환매의무를 부담하는 지 여부

간투법은 수익자를 두텁게 보호하고 증권투자신탁을 활성화하기 위하여 정책적으로 판매회사 및 위탁회사에게 고유재산에 의한 환매의무를 부담시킨 종전 「증권투자신탁업법」(1998.9.16 법률 제5558호로 개정되기 전의 것)과는 달리, 제62조 제2항에서 “간접투자자가 간접투자증권의 환매를 청구하고자 하는 경우에는 판매회사에 청구”하도록 규정

하고 있으면서도 같은 조 제3항에서 “환매 청구받은 판매회사는 자산운용회사에 대하여 환매에 응할 것을 요구”하도록 하고, 같은 조 제5항에서 “환매에 응할 것을 요구받은 자산운용회사는 환매에 응해야 한다.”고 규정한 후, 제63조 제1항에서는 “자산운용회사는 간접투자재산의 범위안에서 간접투자재산을 매각하여 조성한 현금만으로 환매대금을 지급하여야 한다”고 규정함으로써 판매회사 및 자산운용회사는 자기의 고유재산으로 환매대금을 지급할 의무가 없음을 명백히 하고 있음.

또한 약관 제5조는 투자신탁의 운용과 관련하여 자산운용회사의 지시에 따라 발생한 이익 및 손실은 모두 이 투자신탁에 계상되고 수익자에게 귀속된다고 규정하고 있음.

따라서 본건 투자신탁의 조기상환 조건이 평가일인 2008.9.12.에 충족됨에 따라 신청인이 조기 상환일인 2008.9.19.에 원금 및 해당 수익을 지급받을 수 있는 계약상의 지위에 있었다고 하더라도 신청인은 판매회사인 피신청인 및 자산운용회사에 대하여 그의 고유재산으로 환매대금을 지급할 것을 요구할 수 없음.

결국 자산운용회사인 ○○자산운용은 본건 투자신탁에 편입된 장외파생상품을 거래상 대방인 LBCCA에 매각한 후, 그 매각대금으로 수익증권을 환매하여야 하는데, LBCCA의 청산절차 진행으로 그에게 장외파생상품을 매각하지 못하는 사유가 발생하였는 바, ○○자산운용이 이러한 사유로 수익증권의 환매를 연기한 것은 간투법 제65조 제1항, 같은 법 시행령 제62조에 근거한 것으로 적법·타당하다 할 것임.

(2) 불완전 판매로 인한 불법행위 책임 성립 여부

피신청인이 투자신탁을 권유함에 있어 수익증권의 매입에 필연적으로 수반되는 위험성에 관한 올바른 인식 형성을 방해하여 투자판단을 그르치게 한 경우 그 권유행위는 고객에 대한 보호의무를 위반한 것으로 위법하다고 평가할 수 있으나,³⁴²⁾ 피신청인의 판매행위는 다음과 같은 점을 고려할 때, 고객에 대한 보호의무를 위반하였다고 보기 어려움.

① 신청인이 투자 당시 서명날인한 “투자설명서 교부 및 주요내용 설명 확인서” 및 “○○ 2Star 파생상품 투자신탁 제3호 고객상담서”의 내용을 보면, 신청인은 상품에 대

342) 대법원 1998.10.27. 선고 97다47989 판결 참조.

한 세부 내용을 직원으로부터 충분한 설명을 듣고 투자설명서를 교부받았음을 확인할 수 있는데, 그 투자설명서에는 다음과 같은 내용이 기술되어 있는 점.

- 판매회사는 수익증권의 판매업무만을 영위할 뿐, 투자신탁의 운용과는 무관하며, 투자자의 이익을 보장하거나 보전하지 않음.
- 신용위험: 거래상대방의 신용상태 악화에 따라 장외파생상품의 원리금을 제때에 받지 못할 위험 [이 펀드에 편입 예정인 장외파생상품의 거래상대방은 LBCCA임(Lehman Brothers의 신용등급은 2006.5.31. 기준 S&P A+, Moody's A1)]
- 환매연기 위험: 투자신탁재산의 매각이 불가능하여 사실상 환매에 응할 수 없거나 환매에 응하는 것이 수익자의 이익을 해할 우려가 있는 경우 및 이에 준하는 경우로서 금감위가 인정하는 경우에는 수익증권의 환매가 연기될 수 있음.

② 또한 대법원은 “상품안내서 등을 교부하여 투자신탁의 운용개념 및 방법과 약관에 서 규정하는 사항 등에 대한 개략적인 정보를 제공한 경우에는 투자신탁설명서나 약관 등을 직접 제시하거나 교부하지 않았다고 하여 설명의무 위반이 된다고 단정할 수 없다”는 입장³⁴³⁾을 나타내고 있는데, 본건 상품안내서에는 “펀드 수익은 상황(장외파생상품 발행사의 디폴트 등)에 따라 원금 손실이 발생할 수도 있다”는 문구가 기술되어 있다는 점.

③ 그 밖에 투자원금의 보장등 수익을 보장하는 권유행위를 하는 등 판매행위준칙을 위반하였다거나, 간투법상 판매광고 규제 조항을 위반했다고 볼 만한 증거가 없는 점.

(3) 원리금 지급 예정 통보(SMS)로 인한 법적 책임 여부

피신청인이 2008.9.12. 휴대폰을 통해 조기상환 결정 사실 및 원리금 지급 예정일을 문자메시지로 발송하였는데, 이는 조기상환 평가일인 2008.9.12.에 조기상환 조건이 충족됨에 따라 조기 상환 수익률이 연 11.5%로 결정되었고, 수익증권 환매대금이 ○○자산운용으로부터 정상적으로 입금되면, 판매회사인 피신청인이 이를 조기상환일인 2008.9.19.에 신청인에게 지급할 예정이라는 것을 통지 수단의 제한으로 인해 간략하게 표현한 것으로 이해되는 바, 문자메시지의 내용이 그 간략성으로 인해 다소 오해의 소지를 제공한

343) 대법원 2006.5.11. 선고 2003다51057 판결 참조.

측면이 전혀 없다고 할 수 없으나, 사실과 전혀 다른 것으로 평가할 수 없음.

설령 그렇게 해석되지 않는다고 하더라도 그 문자메시지의 발송행위는 조기상환 조건이 충족되었음을 알리는 이른바 관념의 통지에 불과할 뿐 새로운 권리·의무를 발생시키는 형성적 법률행위가 아니므로 이로써 판매회사인 피신청인에게 자기의 고유재산으로 환매대금을 지급할 의무가 발생한다고 보기 어려움.

라. 결 론

판매회사인 피신청인은 그의 고유재산으로 환매대금을 지급할 의무가 없고, 자산운용회사의 수익증권 환매 연기는 적법하며, 본건 투자신탁을 판매함에 있어 고객에 대한 보호의무를 위반했다고 단정하기 어려운 바, 신청인의 청구는 이유 없어 이를 기각함.

6-9 이미 성립된 투자 환매금의 지급채권이 환매연기로 실효되는지 여부

[인용] 환매는 투자자의 환매청구와 자산운용사등의 승낙의사표시에 의하여 성립되는 바, 본건의 경우 피신청인은 10.13. 헤지펀드 인덱스가 비정상적으로 급락하자 간투평을 개최하여 직전일 지수로 기준가격을 산출하기로 결정하고, 이렇게 산출된 기준가격을 전산시스템을 통해 판매회사에 고시함에 따라 판매회사는 동 금액을 환매금으로 지급한다고 신청인에게 통보하였고, 더욱이 새로운 간접투자자에 대해서는 그 기준가격으로 수익증권을 판매하였다는 점에 비추어 피신청인1은 이를 승낙한 것으로 볼 수 있으므로 신청인에게 이미 환매금의 지급채권이 발생하였고 동 지급채권은 환매 연기로 실효되었다고 볼 수 없는 바, 피신청인은 동 기준가격으로 환매금을 지급하여야 함.(2009.3.10. 조정번호 제2009-28호)

가. 사실관계

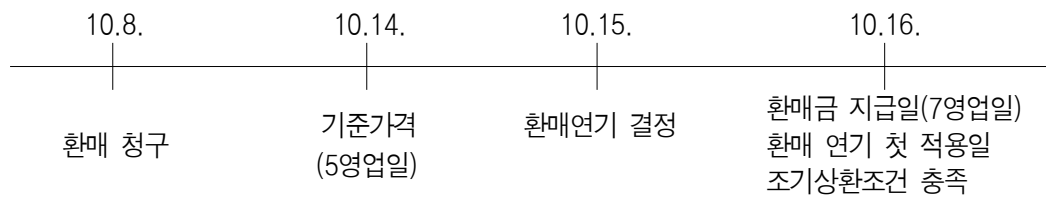
2007.5.7. 신청인은 ○○자산운용(이하 “피신청인1”이라 함)이 운용사인 “△△△△ 헤지펀드인덱스 파생상품투자신탁 제1호”³⁴⁴⁾를 ◇◇은행(이하 “피신청인2”라 함)에서 가입함(가

344) “△△△△ 헤지펀드인덱스 파생상품 투자신탁 제1호”의 주요내용은 다음과 같음.

① 자산운용회사: ○○자산운용 ② 판매회사: ◇◇은행 등 19개사

입금액: 148,415,039원).

2008.10.8. 신청인이 환매 청구를 하였으며, 통상의 경우 약관규정에 의해 5영업일(10.14.)의 기준가격으로 7영업일(10.16.)에 환매대금을 지급하게 됨.



2008.10.13. 19:46 Bloomberg를 통해 헤지펀드 인덱스를 106.83³⁴⁵⁾으로 고시하였으며, 20:00 피신청인1은 헤지펀드인덱스가 비정상적으로 급락하였다고 판단, 간접투자재산 평가위원회(이하 “간투평”이라 함)를 개최하여 10.14.자의 기준가는 직전일(10.10.) 인덱스(115.72)를 적용하여 산출하기로 결정(599.58원)하였으며, 이에 따라 2008.10.14. 피신청인 2는 신청인에게 10.14.자의 공고 기준가 599.58원을 적용하여 산출된 환매대금(87,577,163원)을 10.16. 지급할 예정임을 안내하였음.

2008.10.15. 피신청인1은 인덱스의 급락 사유가 불명확한 상황에서 전일 지수를 계속 사용할 경우 간접투자자의 이익을 해할 우려가 있다고 판단하여 환매 연기를 결정하였다가, 2008.11.6. 환매를 재개(기준가 475.81원)하였는데, 신청인은 10.14 자에 안내받은 87,577,163원 보다 18,078,364원 적은 69,498,799원을 지급받음.³⁴⁶⁾

나. 당사자 주장

- ③ 신탁계약기간: 투자신탁의 최초 설정일로부터 해지일까지
- ④ 종류: 파생상품간접투자기구, 혼합형, 공모형, 추가형, 종류형
- ⑤ 구조: Tremont Investable 헤지펀드인덱스의 가격 변동에 연동하여 사전에 정한 조건에 의해 손익이 결정되는 장외파생상품에 투자
- ⑥ 장외파생상품 발행사: OO International

345) 106.83은 전일(115.72)보다 7.68% 하락한 수치임.

346) 10.16. 장외파생상품 평가액이 50%를 초과하여 하락함에 따라 조기상환 조건이 충족되었고, 이에 10.28. 피신청인1은 장외파생상품 계약을 모두 해지함. 이 때 적용된 헤지펀드인덱스는 112.60인데, 이는 10.10 고지된 인덱스 115.72를 기준으로 Hedge Fund Index의 Rule Book에 따라 산정된 것임.

(1) 신청인 주장

2008.10.8. 신청인은 펀드의 환매를 신청하였고, 피신청인2로부터 10.14.자의 기준가격(599.58원)으로 10.16.에 87,577,163원을 지급할 예정이라는 안내를 받은 바 있는데, 피신청인들은 10.15. 동 펀드의 환매가 연기되었음을 이유로 10.16.에 환매대금을 지급하지 않았고, 11.6.에서야 환매를 재개하면서 그 환매가격을 11.6.자(475.81원)의 기준가격으로 변경하였음. 피신청인들이 환매가격을 정함에 있어 환매연기 전의 신청자와 그렇지 않은 자를 구분하지 아니하고, 획일적으로 환매 재개일인 11.6.자의 기준가격을 적용하는 것은 부당한 바, 당초 안내한 내용대로 599.58원을 환매 기준가격으로 적용하여 환매대금을 지급하여야 할 것임.

(2) 피신청인 주장

환매연기제도의 취지상 환매 재개시의 환매 가격은 연기사유 해소후 최초로 산정하는 기준가격으로 정하는 것이 타당하므로 신청인이 환매 연기결정 전에 환매를 신청하였다고 하더라도 그 연기사유가 해소되어 환매가 재개된 11.6.자의 기준가격을 적용하여 환매금을 지급하는 것이 타당함.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 이미 성립한 환매계약이 환매의 연기로 실효되는 지 여부임.

(1) 환매연기의 적정성 여부

환매연기 제도란 신탁재산의 매각이 불가능하거나 가격평가가 곤란하여 기준가격의 공정한 산정이 불가능한 상황에서 수익증권의 환매 또는 매각을 계속하게 되면 투자신탁의 기본원칙인 수익자 평등주의와 실적배당주의 원칙에 반하게 되는 결과가 초래됨에 따라 천재지변 등 부득이한 사유가 있는 경우 그 사유가 해소될 때까지 환매를 연기할 수 있는 제도를 말하는데, 현행 법령상으로는 「간접투자자산운용업법」(이하 “간투법”이라 함) 제65조 및 동법 시행령 제62조에 그 근거규정을 두고 있음.

본건에 있어 환매 연기의 적법성 여부에 따라 피신청인1의 법적 책임이 달라질 수 있

으므로 이에 대해 살펴볼 필요가 있음.

본건 투자신탁은 Tremont Investable 헤지펀드인덱스의 가격 변동에 연동하여 손익이 결정되는 장외파생상품에 투자되어 있는데, 그 발행사가 10.13. 전일 대비 7.68%를 하락한 인덱스를 고시하자, 피신청인1은 이러한 수치가 과거 일일 변동폭 및 다른 유사 헤지펀드 인덱스와 비교할 때 비정상적이라고 판단하여 발행사에 대해 그 산출 근거를 제시할 것을 요구하였으나, 발행사가 이에 응하지 아니한 상황에서 피신청인1이 이러한 검증되지 아니한 인덱스를 근거로 기준가격을 산정할 경우 자칫 간접투자자의 이익을 해할 우려가 있다고 판단하여 환매를 연기한 것은 간투법 제65조 및 동법 시행령 제62조 제2호 나목에 의한 적법한 행위로 판단됨.

(2) 환매연기 후 환매금의 지급 기준

환매가 연기된 후 수익자총회 개최전에 그 사유가 해소되어 수익자총회를 생략하고 환매를 재개하는 경우에 있어 그 환매금 지급기준에 대해 간투법상 명문의 규정은 없으나, 신탁 약관은 제26조에서 자산운용회사가 이를 정할 수 있도록 규정하고 있는 바, 피신청인1은 자체적으로 지급기준을 정하여 그에 따라 지급하면 될 것이나, 다만 그 기준은 공정성 및 합리성을 가져야 하며 그렇지 않을 경우에까지 그 효력이 당연히 간접투자자에게 미친다고 할 수 없음.

피신청인1은 환매 재개시 그 연기 사유가 해소된 후 최초로 산정되는 기준가격으로 환매가격을 정하는 것이 환매연기 제도의 취지상 부합하므로 환매의 성립 여부와 관계없이 모든 간접투자자에게 환매재개 시점의 기준가격으로 산출된 환매금을 지급해야 한다고 주장하고 있으나, 환매의 연기를 단순히 환매금의 지급연기를 의미하는 것이 아니라 환매 자체를 일정기간 동안 중지하는 것으로 이해한다고 하더라도 환매 연기로 인해 이미 발생한 환매금의 지급채권이 소멸된다고 볼 수 없으므로 환매의 성립으로 간접투자자에게 환매금의 지급채권이 발생한 경우와 그렇지 않은 경우를 구분하여 전자의 경우에는 당초 확정된 환매기준가격으로 산출된 환매금을 지급해야 하고, 후자의 경우에는 환매재개 시점의 기준가격을 적용해야 하는 것으로 해석하는 것이 합리적이라 할 것임.

(3) 환매의 성립 여부

투자신탁의 환매청구권의 법적 성격과 관련하여 이를 수익증권의 매입을 요구할 수 있는 매도선택권(put option)으로서 일방적인 의사표시만으로 그 효력이 발생하는 형성권이라는 학설이 일부에서 제기되고 있으나, 대법원은 환매가 ‘투자자의 환매청구’와 ‘자산운용사등의 승낙의 의사표시’에 의하여 성립된다고 판시하고 있음.³⁴⁷⁾

따라서 본건에서는 피신청인1의 승낙이 있었는지 여부에 따라 환매 성립 여부가 결정되는데, 피신청인1은 2008.10.13. 헤지펀드인덱스가 비정상적으로 급락하자, 간투평을 개최하여 직전일 지수로 기준가격을 산출하기로 결정하고, 이렇게 산출된 10.14.자 기준가격을 전산시스템을 통해 피신청인2 등 판매회사에 고시함에 따라 피신청인2는 동 기준가격을 적용하여 산출한 금액을 환매금으로 지급한다고 신청인에게 통보하였고, 더욱이 새로운 간접투자자에 대해서는 그 기준가격으로 수익증권을 판매하였다는 점에 비추어 볼 때, 피신청인1은 직접 또는 대리인(피신청인2)을 통해 이를 승낙한 것으로 볼 수 있음.

(4) 기 타

본건 투자신탁의 환매와 관련하여 판매회사인 피신청인2의 경우 다음과 같은 점을 고려할 때 그에게 법적 책임이 있다고 보기 어려움.

간투법 제62조는 간접투자자가 판매회사에 대하여 환매를 청구할 수 있도록 허용하고 있으나, 환매 청구를 받은 판매회사는 자산운용회사에 대하여 환매에 응할 것을 요구하도록 하고, 환매는 간접투자자재산을 매각하여 조성한 현금으로만 할 수 있도록 규정함으로써 판매회사의 고유재산에 의한 환매 책임을 부정하고 있고, 환매연기의 주체도 간투법 제65조에서 자산운용회사임을 명백히 하고 있으며, 실제로 환매 연기의 결정도 자산운용회사인 피신청인1이 독자적으로 결정하였다는 점.

라. 결 론

본건의 환매는 신청인의 환매청구와 피신청인1의 승낙으로 성립되어 신청인에게 환매금의 지급채권이 이미 발생하였고, 동 지급채권은 환매 연기로 실효되었다고 볼 수 없는바, 피신청인1은 2008.10.14.자 기준가격으로 환매금을 지급하여야 할 것임.

347) 대법원 2004.1.15. 선고 2001다70825 판결 참조.

6-10 저축은행 후순위채의 불완전판매 여부

[일부인용] 저축은행이 점포별로 목표를 할당하여 분배하고 담당직원들로 하여금 기존 예금자들인 신청인들에게 일일이 전화하여 본건 후순위채를 매입할 것을 적극적으로 권유하게 하고, 기존 예금을 중도 해지시 약정이율을 적용하였으며, 상품안내장에 후순위채 위험성에 대하여는 생략하거나 작게 표시한 반면 수익성, 환금성, 안정성 등에 대해서만 강조하는 등 후순위채 위험성에 대한 충분한 설명 없이 고객에게 과대한 위험성을 수반하는 거래를 적극적으로 권유하여 고객 보호의무를 게을리한 점 등이 인정되므로 신청인들에게 손해를 배상할 책임이 있음.(2011.10.28. 조정번호 제2011-56호)

가. 사실관계

피신청인(○○저축은행)은 2009.3월과 6월에 보완자본 증가 등을 목적으로 후순위채(이하 “본건 후순위채”라 함)를 각각 공모발행 하였으며,³⁴⁸⁾ 2011.2월 금융위원회는 피신청인들에 대해 자본잠식 및 유동성부족 등을 이유로 영업정지 결정을 하였음.

피신청인의 본건 후순위채 판매 경위에 대하여 살펴보면 대략 다음과 같음.

① 본건 후순위채 “청약신청서”, “투자위험고지서” 등에는 신청인들의 자필 서명 또는 날인이 되어 있고, 가입서류의 형식적 하자는 발견되지 않음.

② 피신청인들은 본건 후순위채 발행 2개월 전부터 아래의 내부지침에 따라 기존 예금자를 대상으로 문자메시지 발송, 유선 안내 등의 방법으로 본건 후순위채 청약을 적극적으로 권유하였음.³⁴⁹⁾

③ 후순위채는 만기까지 중도해지가 불가하고 개별 매수인이 나타나지 않으면 양도가

348) ○○저축은행의 후순위채 발행현황은 다음과 같음.

공모기간	발행일	만기일	발행이율	기간	발행금액	형식
2009.3.2.~3.4.	2009.3.6.	2014.9.6.	8.5%	5년6월	294억원	공모
2009.6.22.~6.24.	2009.6.25.	2014.9.25.	8.5%	5년3월	300억원	공모

349) 점포당 기간별 목표를 배정하고 상담실적을 매일 영업부장앞 일일보고 및 임원회의를 거쳐 지점별 영업실적에 반영하는 등 청약권유를 지속적으로 독려하였고, 전화권유는 주로 1억이상 거액예금주(특히 만기예정자)를 대상으로 하되, 2억이상 고객은 지점장이 직접 전화 또는 방문토록 안내함.

불가능한데도 불구하고, 피신청인들은 언제든지 양도가 가능한 것으로 신청인들에게 안내하였음(1개월 전 저축은행에 요청시 언제든지 타인에게 양도 가능함을 강조).

④ 정기에금을 중도해약하는 경우 중도해지금리를 적용하여야 하는데도 피신청인들은 신청인들이 후순위채 매입을 위해 기존 예금을 중도 해약하는 경우 정상만기금리를 적용하는 등 후순위채 판매 촉진을 위한 금리상 혜택을 부여하였음.

⑤ 피신청인들이 작성하여 신청인들에게 나누어준 상품안내장에는 안정성(높은 BIS비율, 자산규모), 수익성(고수익 확정금리, 은행예금금리의 2.6배 등), 환금성, 편리성(이표채)만을 강조하고 위험성에 대한 안내는 거의 없었으며, 위험성에 대해서는 “예금자보호법 미적용”만을 작은글씨로 간단히 표시하고, 손실발생 가능성과 투자위험에 대해서는 전혀 표시하지 않음.

⑥ 판매 직원들조차 위험성에 대한 인식도가 매우 낮았던 것(직원들도 후순위채 다수 매입)으로 판단되고, 위험성과 관련한 내부교육 증빙 및 안내자료를 제시하지 못함. 판매직원들은 BIS비율(판매당시 9%대)의 정당성에 대해서 전혀 의문을 갖고 있지 않았고, 투자자에게 절대 망하지 않을 것임을 강조함.

참고로, 2011.7월 검찰은 ○○저축은행이 분식으로 조작한 재무제표 또는 BIS비율 등을 공시하고 후순위채를 발행하였다는 이유로 전·현직 임원을 “자본시장법 위반(BIS비율 등 허위공시를 통한 사기적 부정거래) 등”으로 기소하여 현재 재판진행중에 있음.

나. 당사자의 주장

(1) 신청인의 주장

피신청인 담당직원이 당시 BIS비율이 9%이상의 우량저축은행이고 업계 최고의 저축은행이니 만큼 절대 망하지 않으므로 안심해도 좋다고 해서 본건 후순위채에 가입하였음. 피신청인 담당직원은 예금보다 높은 이자만을 강조하였으며, 인기가 높으므로 소액을 청약하거나 늦게 청약시 배정이 되지 않을 수도 있다는 말을 믿고 정기에금을 모두 중도 해지하여 본건 후순위채에 가입하였음.

창구직원이 시키는 대로 청약신청서 및 확인서에 표시된 곳에 서명하였고 후순위채의

위험성에 대한 설명은 전혀 없었으며, 투자설명서 교부도 없었음.

(2) 피신청인 주장

피신청인 담당직원은 본건 후순위채권 청약시 신청인들에게 후순위채는 예금이 아니므로 「예금자보호법」의 적용을 받지 않는다는 사실 등 중요한 내용을 설명하였으며, 투자설명서는 신청인이 수령을 원할 경우에는 교부하고 신청인들이 확인서에 자필기재 및 서명을 하였고, 신청인이 투자설명서의 수령을 원하지 않을 경우 확인서를 받았음.

신청인들은 후순위채 투자위험 고지서에 투자위험과 관련한 내용을 충분히 설명 듣고 이해하였음을 자필서명 및 날인하였음.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 저축은행이 본건 후순위채권 판매시 고객에 대한 보호의무를 다하였는지 여부라 할 것임

(1) 관련 판례

금융회사의 임직원이 고객에게 적극적으로 투자를 권유하였으나 투자 결과 손실을 본 경우에 투자자에 대한 불법행위책임이 성립되기 위하여는 이익보장 여부에 대한 적극적 기망행위의 존재까지 요구하는 것은 아니라 하더라도, 적어도 거래경위와 거래방법, 고객의 투자상황(재산상태, 연령, 사회적 경험 정도 등), 거래의 위험도 및 이에 관한 설명의 정도 등을 종합적으로 고려한 후, 당해 권유행위가 경험이 부족한 일반 투자자에게 거래행위에 필연적으로 수반되는 위험성에 관한 올바른 인식형성을 방해하거나 또는 고객의 투자상황에 비추어 과대한 위험성을 수반하는 거래를 적극적으로 권유한 경우에 해당하여, 결국 고객에 대한 보호의무를 저버려 위법성을 띤 행위인 것으로 평가될 수 있는 경우이면 됨.³⁵⁰⁾

또한, 금융회사의 임직원이 고객에게 금융투자상품 매입을 권유할 때에는 그 투자에 따르는 위험을 포함하여 당해 상품의 특성과 주요 내용을 설명함으로써 고객이 그 정보

350) 대법원 2003.1.10. 선고 2000다50312 판결, 2007.7.12. 선고 2006다53344 판결 등 참조.

를 바탕으로 합리적인 투자판단을 할 수 있도록 고객을 보호하여야 할 주의의무가 있다 할 것임.³⁵¹⁾

(2) 고객보호의무 위반 여부

다음과 같은 점을 종합적으로 고려할 때, 피신청인의 본건 후순위채 판매행위는 경험 이 부족한 신청인들에게 거래행위에 필연적으로 수반되는 위험성에 관한 올바른 인식형성을 방해하거나 고객의 투자상황에 비추어 과대한 위험성을 수반하는 거래를 적극적으로 권유한 경우에 해당하여, 결국 고객에 대한 보호의무를 위반하였다고 판단됨

① 피신청인은 점포별로 목표를 할당하여 분배하고 담당직원들로 하여금 기존 예금자들인 신청인들에게 일일이 전화하여 본건 후순위채권의 수익성(저금리시대에 연8.5% 확정고금리), 환금성(언제든지 양도가능), 안정성(계열사자산 5조원, 이익 1,000억원, BIS비율 9.7%)을 강조하면서 기존 예금을 해약하고 본건 후순위채를 매입할 것을 적극적으로 권유하여 신청인들로 하여금 안전한 예금에서 위험한 후순위채로 변경하도록 한 점.

② 「상호저축은행표준업무방법서」에 따르면, 정기예금의 중도해지시에는 중도해지이율을 적용하도록 되어 있음에도 불구하고 피신청인은 신청인들에게 기존예금을 중도 해지하여 후순위채를 매입하면 중도해지이율이 아닌 계약금리(만기금리)를 적용하여 준다고 안내하여 신청인들이 안전한 기존 정기예금을 부담 없이 쉽게 해지하여 위험한 본건 후순위채로 변경하도록 유도한 점.

③ 후순위채는 만기 전에 중도해지가 불가능하고 공식적인 매매시장도 형성되어 있지 않아 개별 매수인이 나타나지 않으면 양도가 불가능한데도 피신청인은 본건 후순위채에 대해 1개월 전에만 요청하면 언제든지 양도가 가능하다고 환금성을 강조하면서 안내하여 신청인들로 하여금 후순위채를 필요시 언제든지 양도하여 현금화가 가능한 상품으로 오인토록 한 점.

④ 투자위험고지서에 투자위험을 충분히 설명 듣고 이해하였다는 신청인들의 자필서명 및 날인이 되어 있기는 하나, 투자위험고지서는 작은 활자체로 여러 가지 사항이 나열식으로 기재되어 있어서 신청인들이 쉽게 알아보기 힘들게 되어 있는 반면, 피신청인

351) 대법원 2003.7.11. 선고 2001다11802 판결 등 참조.

이 본건 후순위채와 관련하여 알기쉽게 정리하여 신청인들에게 나누어 준 상품안내장에는 발행회사의 파산시 후순위로 배당받으므로 채권에 대해 변제받지 못할 위험이 있다는 내용이 전혀 기재되어 있지 않고, 「예금자보호법」이 적용되지 않는다는 내용도 작은 글씨로 표기하고 있으면서 수익성, 환금성, 안정성 등에 대해서만 강조하여 신청인들에게 후순위채의 위험성에 대해 충분히 안내하였다고 보기 어려운 점.³⁵²⁾

(3) 손해배상액 산정

1) 손해금액

신청인들의 손해금액은 후순위채 매입금액에서 그 동안 수령한 후순위채 이자금액과 정기예금의 이자금액의 차액을 공제한 금액이라 할 것임.³⁵³⁾

2) 신청인들의 기본 과실비율

다음과 같은 점 등을 고려하여 신청인들의 기본적인 과실비율은 60%로 봄이 상당하다 할 것임.

① 후순위채가 정기예금에 비해 이율이 높다는 것은 그 만큼 위험성도 높을 수 있다는 것은 누구나 예상할 수 있는 것이므로 신청인들은 본건 후순위채 가입시 그 위험성에 대해서 면밀히 살펴보고 가입여부를 결정해야 할 책임이 있고, 본건 후순위채 가입시 교부된 상품안내장에는 후순위채 이율은 8.5%, 저축은행 예금이율은 5% 또는 6.8%, 시중은행 예금이율은 4.2%로 기재되어 있으므로 신청인들도 후순위채가 이율이 높으므로 위험성도 클 것이라는 것을 예측할 수 있는 점

② 신청인들은 본건 후순위채 가입시 ‘청약신청서’ 및 ‘투자위험고지서’에 ‘투자위험고지서의 내용을 충분히 설명듣고 이해하였음을 확인한다.’고 자필서명 및 날인을 하였으며, ‘투자위험고지서’에는 본 사채는 후순위사채이고 발행회사가 파산 등의 절차가 진행되면

352) 신청인 중 피신청인 소속 임직원의 경우에 대한 판단 : 피신청인 소속 임직원은 내부사정에 밝고 후순위채 판매와 관련하여 고객에게 후순위채의 내용과 위험성에 대하여 설명하여야 할 위치에 있음에도 오히려 피해구제를 주장하는 것은 타당하지 않으므로 신청인 중 피신청인 소속 임직원의 경우는 본건 불완전판매에 따른 손해배상의 대상에서 제외함.

353) 손해액 = 후순위채 매입금액 - (기 수령한 후순위채 이자 - 해당 저축은행의 정기예금의 이자)

주식을 제외한 모든 일반채권 전액에 대해 변제가 완료된 후에 본 사채를 상환한다는 점과 본 사채는 예금자보호법의 적용을 받지 않는다는 점 등의 투자위험이 기재되어 있는 점.

3) 신청인 특성에 따른 과실비율의 조정

일반적으로 금융상품에 대한 이해와 투자위험에 대한 주의능력은 투자자의 나이와 투자금액의 크기에 따라 달라진다고 볼 수 있으므로 나이와 투자금액의 크기에 따라 과실비율의 조정이 필요하다 할 것임.

① 나이의 경우 「노인복지법」에 따르면 65세 이상의 고령자는 경로우대 대상이 되고, 「표준투자권유준칙」에 따르면 만 65세 이상의 고령자에 대해서는 과생상품 등 위험한 상품에 대한 투자권유가 일정한 범위 내에서만 허용하고 있는 점 등을 고려해 볼 때, 만 65세 이상의 고령자에 대해서는 과실비율을 조정하는 것이 합리적이라 판단됨(특히 만 80세 이상의 고령자의 경우 더 많은 과실비율의 조정이 필요).

② 투자금액의 경우 일반적으로는 투자금액이 클수록 투자위험에 대한 주의의무가 높다고 할 수 있고, 예금의 경우 5천만원 이하는 「예금자보호법」에 의해 보호를 받는 점 등을 고려할 때, 본건 후순위채의 경우도 투자금액이 5천만원을 초과한 경우에는 과실비율을 조정하는 것이 합리적이라 판단됨.

4) 기존 예금 중도해지의 경우 고려

본건 후순위채권의 경우 피신청인들의 투자권유에 따라 기존 정기예금을 해지하여 후순위채에 가입한 경우도 상당히 많은 바, 이들의 경우 피신청인들이 중도해지 금리의 혜택 등의 방법으로 적극적인 권유를 하여 기존 예금을 해지하고 후순위채에 가입하여 예금자의 지위를 상실한 경우로서 피해의 정도가 더 크다고 할 것이므로 과실비율을 조정하는 것이 합리적이라 판단됨.

5) 증권회사에서 청약한 경우 고려

신청인들 중 저축은행 본·지점이 아닌 ◇◇증권 본·지점에서 후순위채를 청약한 경우 증권회사에서는 예금을 취급하지 않으므로 후순위채를 예금으로 오인하였을 가능성이 적은 점 등을 고려할 때, 일부 과실비율을 조정하는 것이 합리적이라 판단됨.

따라서 위와 같은 사정을 종합적으로 고려하여 피신청인의 책임을 별지1 기재 비율만큼 제한하는 것이 상당하다 할 것임.

(4) BIS비율 등 허위공시를 통한 후순위채 발행여부에 관한 사항

신청인들은 피신청인들이 본건 후순위채 발행시 BIS비율이 높은 것처럼 허위로 조작하여 이를 공시하여 투자자들이 이를 믿고 매입하게 하였으므로 이는 사기에 해당하므로 손해금액의 전부를 배상하여야 한다고 주장하나, 2011.7월 검찰에서 피신청인들이 분식으로 조작한 재무제표, BIS비율 등을 공시하고 후순위채를 발행하였다는 이유로 전·현직 임원을 “자본시장법 위반 등”으로 기소하여 현재 재판이 진행 중이므로 이에 대한 판단은 법원의 판결내용을 기준으로 처리함이 타당하다 할 것이므로 본 건 조정결정에 있어서는 BIS비율 등 재무관련 사항의 허위공시와 관련된 사항에 대해서는 판단을 유보함.

라. 결론

그렇다면 피신청인들은 본건 후순위채 판매시 고객보호의무를 게을리한 점 등이 인정되므로 신청인들에게 손해를 배상할 책임이 있음.

 제 2 편

금융권역별 주요 조정사례
(금융투자)

제1 장 설명의무 위반 등 부당권유

제2 장 매매주문

제3 장 임의매매

제4 장 과당 일임매매

제5 장 전산장애, 사무처리 오류 등

제1장

설명의무 위반 및 부당권유

제1절 ELS 및 ELF

1-1 청약서 작성시 펀드명칭이 미확정되어 추후 담당자가 이를 보충한 경우

[기각] 신청인이 미리 청약서를 작성하여 주고, 판매직원이 청약일에 펀드가입 처리를 하기로 하였음이 녹취록상 인정되어 판매직원이 펀드에 임의로 가입하였다고 볼 수 없으며, 문답 결과 판매직원이 동 펀드에 대한 기본설명을 하고 자료를 제공하였음이 인정되는 반면 달리 판매직원이 부당권유를 하였다고 볼 만한 자료가 없는 바, 피신청인의 손해배상 책임이 인정되지 않음.(2007.6.5. 조정번호 제2007-44호)

가. 사실관계

신청인은 2005.11.15. ○○증권회사(이하 “피신청인”이라 함) 지점을 방문하여 판매직원으로부터 11월 말경에 판매될 예정인 △△△펀드에 대한 소개를 받은 후, 동 펀드 가입을 위한 상품청약서³⁵⁴)와 투자설명서 제공 및 주요내용 설명확인서³⁵⁵)를 작성하고, 동 펀드 가입대금 천만원을 MMF에 입금하여 이후 △△△펀드 판매가 시작되면 전화로 확인 후 가입을 하기로 함.

△△△펀드 판매가 시작된 같은 달 28일 판매직원은 신청인에게 전화를 하여 동 펀드 가입에 대한 확인을 받은 후, 15일 작성해 두었던 상품청약서의 청약종목명에 “조기상환 △△△”라고 기재하고, MMF에 있던 10,009,493원을 펀드계좌로 대체처리 하였고, 같은 달 30일 신청인은 동 펀드에 가입되었음.

354) 당시에 펀드명칭이 확정되어 있지 않아 청약종목란은 공란으로 두고 신청인이 상품청약서를 작성함.

355) 다만, 신청인에게 실제 제공된 자료는 △△△ 펀드의 출시일정표와 지점에서 만든 자체 설명자료였음.

신청인은 조기상환 여부를 결정하는 2006.5월말과 11월말에 모두 조기상환 조건이 충족되지 못하고, 기준가격이 하락하자 2007.2.1. 금감원에 분쟁조정을 신청하고, 같은 해 3.23. 동 펀드를 환매하여 금 7,805,574원을 인출함.

나. 당사자의 주장

(1) 신청인 주장

천만원을 1년만기 MMF에 가입하였으나 청약종목란에 다른 사람의 필체로 “조기상환 △△△”라고 기재되어 있으며, 동 펀드는 만기도 3년인 바 신청인의 의사와 무관하게 △△△펀드에 가입된 것이고, 1년이내 운용되는 상품을 원한다고 하였음에도 판매직원은 고객 성향을 적절하게 파악하지 않고 위험도가 높은 만기 3년의 금융상품을 권유하여 손해를 입게 하였는 바, 피신청인은 부당권유행위에 따른 손해를 배상할 책임이 있음.

(2) 피신청인 주장

△△△펀드 권유시 판매직원은 신청인에게 수익구조와 원금손실 가능성 및 중도환매시 수수료 부과 등 펀드의 주요특징에 대하여 설명을 하였을 뿐 부당권유를 한 사실이 없으며, 상품 모집 당일에도 신청인에게 전화를 하여 다시 설명을 하고 가입 확인을 받은 후 청약종목란을 기재하였는 바, 피신청인은 손해를 배상할 책임이 없음.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 본건 펀드 임의가입 및 부당권유 여부라 할 것임.

(1) 펀드 임의가입 여부

신청인은 천만원을 1년만기 MMF에 가입하고 동 종목이 기재된 통장을 교부받았으나, 상품청약서의 청약종목란에 다른 사람의 필체로 “조기상환△△△”라고 기재되어 신청인의 의사와 무관하게 △△△펀드에 가입된 것이라고 주장하나, 다음과 같은 점으로 보아 신청인의 주장은 이유 없음.

① 2007.3.19. 금감원에서 작성된 신청인과 판매직원에 대한 문답서(이하 “문답서”라 함)를 보면, 2005.11.15. 판매직원이 향후 판매 예정인 △△△펀드에 대하여 설명을 하고, 동 펀드의 출시일정표와 지점에서 만든 설명자료를 교부하였음을 신청인이 인정하고 있다는 점.

② 2005.11.28. 신청인과 판매직원 사이의 통화내용에 대한 녹취록에 따르면, 판매직원이 11.15.에 미리 작성해둔 청약서로 △△△펀드의 가입처리를 하고, 이후 시간이 될 때 신청인이 지점에 나와 통장을 정리하기로 하였다는 점.

(2) 펀드의 부당권유 여부

수익증권 판매회사의 임직원이 고객에게 투자신탁 재산의 운용방법이나 투자계획 등에 관하여 구체적으로 설명하지 아니한 채 단순히 특별한 고수의 상품이라는 점만을 강조하면서 수익증권의 매입을 적극 권유한 경우, 고객보호의무를 게을리한 것으로 불법행위가 성립함.³⁵⁶⁾ 한편, 신청인은 1년 이내 운용되는 상품을 원한다고 하였음에도 판매직원이 위험성이 높은 만기 3년의 금융상품을 부당하게 권유하여 손해가 발생하였다고 주장하나, 다음과 같은 점으로 보아 신청인의 주장은 이유 없음.

① 문답서를 보면, “6개월 단위로 평가하여 조기상환이 안되면 연장하여 전부 6번 회의를 준다고 설명을 하였습니다. 펀드 전체기간중 두 종목 주가가 모두 시초가 대비 40% 초과 하락한 적이 없으면 원금수준을 유지한다고 설명하였습니다.”라는 담당직원의 진술에 대해 신청인이 “저는 비슷한 얘기를 들었으나 6개월에서 1년 이내에 환매가 가능한 상품을 원했습니다.”라고 진술하고 있으며, 판매직원이 설명자료를 제공한 사실도 신청인이 인정하고 있어 △△△펀드의 기본구조에 대한 설명이 행하여졌음을 인정할 수 있는 반면, 달리 판매직원이 부당하게 동 펀드 가입을 적극 권유하였음을 인정할 만한 자료가 없다는 점.

② 2005.11.28. 신청인과 판매직원 사이의 통화내용에 대한 녹취록에 따르면, 두 종목이 15%이하로 빠질 가능성이 있냐는 신청인의 질문에 대해 판매직원이 “가능성은 6개월 정도 상환된다고 보는데, 만에 하나 빠지게 되면 그냥 손해보고 끝나는게 아니고 6개

356) 대법원 2003.7.11. 선고 2001다11802 판결 참조.

월 뒤에 또 기회를 6개월마다 기회를 계속 드리거든요”라고 대답하면서 “그러니까 중간에 돈이 필요한 것만 아니면 괜찮은 것 같아요”라고 하자 신청인이 “아니고”라고 대답하고 있어, △△펀드의 만기가 3년임을 신청인이 알고 있었던 것으로 보이는 점.

③ 동 펀드 가입이후 피신청인은 총 3회에 걸쳐 신청인에게 자산운용보고서(수익발생구조 등을 기재하고 있음)를 발송하였으며, 신청인도 수령사실을 인정하고 있다는 점.

라. 결 론

그렇다면 피신청인은 신청인에 대하여 손해를 배상할 책임이 없다 할 것이므로 신청인의 청구는 이유 없어 이를 기각함.

1-2 가입자와 협의후 증권사 직원이 가입처리 한 펀드의 임의가입 해당 여부

[기각] 녹취록상 신청인과 판매직원 사이에 향후 판매될 상품에 대한 협의가 있었고, 판매직원이 신청인에게 사모펀드 가입을 통보하고 취소가 가능함을 알렸으나 신청인이 아무런 이의를 제기하지 않았으며, 신청인이 지점에 내점하여 사모펀드의 가입과 관련한 “확인서 및 동의서”에 자필서명을 하였고, 본건 펀드 가입 이전에 다수의 ELS에 투자한 경험이 있다는 점 등에 비추어 피신청인이 신청인의 동의 없이 임의로 본건 펀드를 가입처리 하였다고 보기 어려움.(2008.4.15. 조정번호 제2008-23호)

가. 사실관계

신청인은 2003.10.31. ○○증권사(이하 “피신청인”이라 함) 지점에서 계좌를 개설하고 직원 A씨(이하 “판매직원”이라 함)를 통해 채권이나 ELS³⁵⁷⁾등을 거래하여 왔음.

2005.3.7. 판매직원은 신청인에게 전화를 하여 A기업의 주가를 기초자산으로 하는 상품인 제208회 ELS(공모)에 대한 청약을 권유하였는데, 신청인이 목이 아파서 얘기하기 힘들다며 다음에 다시 통화를 하자고 하여 동 상품에 대한 청약은 이루어 지지 않았고,

357) “ELS(Equity-Linked Securities)”는 개별 주식의 가격이나 주가지수에 연계되어 투자수익이 결정되는 유가증권을 말함.

같은 달 15일 오전 판매직원은 신청인에게 전화를 하여 제208회 ELS가 경쟁률이 10.9대 1로 너무 높아 고객 돈이 다 쪼개져서 이번에는 동일한 내용의 사모펀드를 최저가입금액 2억원 이상으로 선착순 모집을 한다며 A기업 보통주 연계 △△△사모파생상품투자신탁4(이하 “사모펀드4”라 함)에 대한 청약을 권유하였는데, 신청인은 조금 생각해 보고 전화를 하겠다고 하였고, 약 20분 후 판매직원은 신청인에게 다시 전화를 하여 상품에 대한 설명과 신청인의 향후 자금상황 등에 대한 상담을 하였으며, 이에 신청인은 판매직원에게 청약을 하도록 허락하였음.

당시 판매직원은 신청인에게 사모펀드4의 손익구조와 A기업의 주가에 대한 전망 및 ELS 상품들의 1회 조기상환 비율 등에 대한 설명을 하였는데, 손익구조에 대한 설명 중 만기 원금손실이 발생하는 경우와 관련하여, 만기까지 한번도 조기상환 조건을 충족하지 못하고 투자기간 동안 A기업의 주가가 기준가격의 40% 이상 하락한 적이 있는 경우 만기 주가수익률로 손실이 결정됨에도, A기업의 주가가 기준가격의 40% 이상 하락한 적이 있으면서 3년 동안 한번도 기준가격 보다 높지 못한 경우 종가로 손실이 날 수 있다고 잘못 설명하였음. 당일 오후 판매직원은 신청인에게 전화를 하여 선착순 판매에서 밀려 사모펀드4 가입에 실패하였다고 통보함과 동시에 다음주 정도에 비슷한 상품이 나온다고 하니 그때는 먼저 청약접수를 해 주겠다고 하면서, 다음 주에 상품이 나오면 바로 연락을 하고 확인 해주기로 함.

2005.3.18. 판매직원은 신청인에게 전화를 하여 3.15.에 가입 실패하였던 상품과 같은 내용의 상품인 △△△사모파생상품투자신탁6(이하 “사모펀드6”이라 함)³⁵⁸⁾가 나와 2억

358) “△△△사모파생상품투자신탁6”의 개요는 다음과 같음.

- 상품유형 : 파생상품간접투자기구, 단위형(만기 3년, 최저가입금액 2억원 이상)
 - 신탁기간은 2008년 3월 27일(상환금 지급일은 2008년 3월 28일)까지이나 편입된 ELS가 중도에 상환되는 경우 이 투자신탁도 중도에 상환됨.
- 수익구조
 - A기업 주가를 6개월 각 중간가격 결정일에 최초기준가격과 비교하여, 최초기준가격 이상이거나 최초기준가격 보다 낮더라도 투자기간동안 15%이상 상승한 적이 있는 경우 조기상환(6개월 단위 수익률 : 4.5%)
 - 3년 만기시점까지 한번도 조기상환 조건을 충족하지 못한 경우 : 투자기간동안 40%이상 하락한 적이 없는 경우 - 투자원금회수

원을 가입시켰다고 알려면서 당일 취소가 가능하다고 하였는데, 신청인은 담당직원에게 별다른 이의 없이 수고했다고 하였음. 이에 담당직원은 3.18.이나 3.21. 지점에 나와 사모펀드6 가입과 관련하여 날인을 해 달라고 요청하였고, 신청인은 3.21.에 가겠다고 함.

2005.3.21. 판매직원은 피신청인 지점에 내점한 신청인에게 사모펀드6의 투자설명서를 교부하고 수익구조에 대한 설명을 하였으며, 신청인은 첫 번째 중간가격 결정일까지 중도환매를 신청하지 않겠다는 내용의 “확인서 및 동의서”에 자필서명을 하였음.

사모펀드6은 신탁기간중 조기상환조건을 충족하지 못하여, 만기일인 2008.3.21. 종료되었는데, 신청인은 140,596,560원을 상환 받았음.

나. 당사자의 주장

(1) 신청인의 주장

판매직원은 2005.3.15. 전화 통화시 다음주에 상품이 나오면 사전 연락을 하겠다고 하였음에도 같은 주 금요일인 3.18. 임의로 사모펀드6에 먼저 가입을 시킨 후 신청인에게 전화를 하였음. 신청인은 3.15. 남편과 상의하여 판매직원으로부터 연락이 와도 동 상품에 투자하지 않기로 이미 결정한 상태였으나, 3.18. 사무실에서 전화를 받아 같이 작업하는 사람들 앞에서 돈 문제로 통화하는 것이 거북할 뿐만 아니라 사무실이 고압선 밑에 있어 통화상태도 불량하여 정확한 이야기는 판매직원을 방문하여 하려고 했고, 3.21. 판매직원을 방문하여 취소를 요청하였으나, 판매직원이 아주 좋은 상품으로 6개월만에 나올 수 있으니 걱정하지 말라고 하여 내키지 않았지만 달리 방법이 없어 확인서에 날인을 한 것이며, 당시 판매직원으로부터 사모펀드6에 대한 설명을 듣기는 하였으나 신청인이 상품내용을 충분히 알았던 것은 아닌 바, 피신청인은 판매직원의 펀드 임의가입 등으로 인해 신청인에게 발생한 손해를 배상할 책임이 있음.

(2) 피신청인의 주장

판매직원은 2005.3.15. 신청인과 상품가입 여부에 대한 협의를 통해 사모펀드6에 대한

: 투자기간동안 40%이상 하락한 적이 있는 경우 - 만기 추가수익률로 손실결정

○ 환매 : 매월 마지막 증권선물거래소 영업일에만 환매신청 가능(환매수수료 환매금액의 10%)

신청인의 청약의사를 이미 확인한 상태였으며, 차주에 판매될 예정이던 사모펀드6의 모집일이 갑자기 3.18로 변경되자 물량확보를 위해 청약을 먼저 한 것임. 또한 판매직원은 동 펀드 가입 확인 후 바로 신청인에게 사모펀드6의 가입사실을 알리면서 취소 여부를 문의하였는데, 신청인은 취소의 의사표시 없이 오히려 판매직원에게 수고했다고 하였고, 3.21.에는 피신청인 지점을 내방하여 확인서에 날인을 하였는 바, 판매직원이 임의로 동 펀드에 가입하였다고 보기는 어려움.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 담당직원이 신청인 동의없이 임의로 본건 펀드를 가입하였는지 여부라 할 것임

(1) 손해배상 책임 유무

신청인은 판매직원이 상품청약전에 연락을 하기로 하였음에도 사전 연락 없이 임의로 사모펀드6에 가입시켰고, 이후 취소를 하고자 하였으나 판매직원이 아주 좋은 상품이라 하여 상품내용을 충분히 알지 못한 채 확인서에 날인을 한 것이므로 피신청인에게 손해배상 책임이 있다고 주장하나, 다음과 같은 점으로 보아 신청인의 주장은 이유 없음.

① 신청인과 판매직원의 전화통화 내용에 대한 녹취록에 따르면, 2005.3.15. 신청인과 판매직원 사이에 향후 판매될 상품에 대한 협의가 있었던 사실 및 같은 달 3.18. 판매직원이 신청인에게 사모펀드6 가입을 통보하고 취소가 가능함을 알렸으나 신청인이 아무런 이의를 제기하지 않고, 오히려 판매직원에게 “수고하셨습니다”라고 한 사실이 인정되며, 당일 통화내용의 청취결과 통화상태가 불량한 것으로 보이지는 않는다는 점.

② 신청인이 2005.3.21. 피신청인 지점에 내점하여 사모펀드6의 가입과 관련한 “확인서 및 동의서”에 자필서명을 하였다는 점.

③ 녹취록 제6~12면을 보면, 판매직원이 2005.3.15. 사모펀드6과 동일한 내용의 상품인 사모펀드4의 수익구조 및 A기업 주가 전망 등에 대해 신청인에게 설명을 하면서 만기시 원금손실이 발생하는 경우에 대하여 일부 설명을 잘못된 사실이 인정되기는 하나, 2008.1.16. 금감원 문답서 제4면을 보면 판매직원이 2005.3.21. 사모펀드6의 투자설명서를

교부하고 수익구조에 대해 설명한 사실을 신청인이 인정하고 있다는 점.

④ 신청인은 사모펀드6 가입 이전인 2004.6.~2005.1. 기간중 이미 5건의 ELS에 투자한 경험이 있다는 점.

다. 결 론

그렇다면 피신청인은 신청인에 대하여 손해를 배상할 책임이 없다 할 것이므로 신청인의 청구는 이유 없어 이를 기각함.

1-3 펀드 부당권유 및 부당한 반대매매로 인한 손해배상책임 여부

[기각] 신청인은 담당직원이 원금보장 등을 약속하고 법인세 납부자금으로 펀드에 가입하도록 부당하게 권유하였다고 주장하나 담당직원이 원금보장을 약속한 사실이나 대출을 받아 법인세를 납부하도록 권유한 사실을 인정할 수 있는 객관적인 증빙이 없는 점, 신청인이 투자 경험이 상당할 뿐만 아니라, 2005.7월부터 유사한 상품에 15차례 가입한 경험이 있는 점, 예금이 아닌 펀드에서 원금보장이 되지 않는다는 것이 일반의 상식에 가깝고 신청인은 본건 펀드 가입 이전에 투자손실을 본 경험도 있는 점, 신청인이 동 펀드에 가입하면서 작성한 투자 신탁가입신청서에 “상품제안서를 제공받고 약관 및 상품의 주요내용에 대해 설명 들었음”이라고 자필기재하고 날인하고 있는 점 등에 비추어 신청인의 주장을 받아들이기 어려움.(2009.4.14. 조정번호 제2009-38호).

가. 사실관계

신청인은 A기업 이사회 의장으로 A기업 및 신청인의 자녀인 B씨, C씨, D씨의 재산을 관리³⁵⁹⁾하던 중, 담당 PB인 ○○증권사(이하 “피신청인”이라 함) 직원 F씨(이하 “담당 직원”이라 함)와 상담을 하고, 2007.8.9. B씨 명의로 △△△사모파생1호에 565,000,000원을 가입한 것을 비롯하여 A기업 및 자녀들 명의로 총 12,038,437,005원을 ▽▽▽사모파생31호³⁶⁰⁾에 가입함.

359) 펀드 가입현황은 다음과 같음.

신청인은 2008.3.31. ▽▽▽사모과생31호를 담보로 30억원을 대출받은 이후, 같은 해 5.14. ▽▽▽사모과생31호, △△△사모과생1호를 담보로 22억원 추가대출³⁶¹⁾을 받아 총 52억원의 담보대출을 받음.

2008.10.13~11.14. 기간 중, 펀드기준가 하락으로 D씨, B씨, A기업 계좌에서 합계 44회

계좌주	가입펀드	가입금액	환매금액	손해액
B씨	△△△사모과생1호	565,000,000 (2007.8.9)	493,801,303 (2008.10.23)	71,198,697
C씨		360,000,000 (2007.8.9)	314,888,400 (2008.10.23)	45,111,600
D씨	▽▽▽사모과생31호	3,647,065,270 (2007.9.6.)	1,414,140,709 (2008.11.17)	2,856,403,980
		623,479,419 (2007.9.10)		
E씨		424,840,737 (2007.9.6)	보유중	
A기업		6,418,051,579 (2007.9.6)	2,125,401,960 (2008.11.17)	4,292,649,619

360) 가입 펀드의 개요는 다음과 같음.

<△△△사모과생1호>

- 기초자산 : F기업 / G금융지주 ○ 만기 : 3년(2010.8.13.)
- 수익구조 : F기업 보통주와 G금융지주 보통주의 설정일로부터 매 1개월 단위로 측정된 상승률 중 더 낮은 수익률을 Worst 수익률이라 하고, 6개월 마다 도래하는 자동조기상환결정일 및 최종 기준가격 결정일에 이러한 수익률들을 설정일로부터 해당 결정일까지 합산한 누적수익률이 -5%(6개월), -10%(12개월), -15%(18개월), -20%(24개월), -25%(30개월), -30%(36개월) 이상이 되는 경우, 연 11.5% 수준의 수익을 지급하고 자동상환,
 - 상기조건 미충족시, 36회 누적수익률이 -30%보다 작고 -60%보다 크거나 같으면 15%(연 5%)의 수익지급, 36회 누적수익률이 -60%보다 작으면 원금보존 추구

<▽▽▽사모과생31호>

- 기초자산 : H기업 / I은행 ○ 만기 : 3년(2010.9.9.)
- 조기상환 : 6, 12개월 : 기초자산의 주가가 모두 기준주가 대비 90% 이상
18, 24개월 : 기초자산의 주가가 모두 기준주가 대비 85% 이상
30, 36개월 : 기초자산의 주가가 모두 기준주가 대비 80% 이상
- 조기상환 수익률 : 연 14%
- 만기상환 : 한 종목이라도 40% 이상 하락한 적이 없는 경우(연 6%), 있는 경우(원금손실: 만기시 하락률이 큰 종목의 수익률과 동일)

361) 기존의 30억원을 대환하고 52억원을 신규 대출받는 형식으로 처리함.

의 담보부족이 발생하였고, 신청인은 2008.10.23. B씨, C씨 명의의 △△△사모파생1호를 환매하여 대출금상환에 충당하였으며, 이후 대출만기 연장에 대한 신청인과 피신청인 간 협의가 이루어지지 아니하였고, 피신청인은 2008.11.17. 대출만기일 익영업일에 담보대출금 미상환등을 이유로 D씨와 A기업 계좌에 대한 반대매매를 실행하여 대출금을 정산하였음.

나. 당사자 주장

(1) 신청인 주장

피신청인 담당직원의 펀드가입 부당권유 및 부당한 반대매매 등으로 인하여 발생한 손해 및 이에 대한 이자를 구함. 담당직원이 펀드가입시 3년만기 원금이 보장되고 주가가 폭락하여도 연 5%의 이자를 가산하여 준다고 설명하여 이에 안전하다고 생각하고 펀드에 가입한 것이며, 담보대출을 받게 된 경위 또한 본래 A기업 명의로 가입한 64억 원중 50억원을 2007년 법인세 납부를 위해 은행에 예치하려고 하였으나, 담당직원이 은행금리가 낮고, 위 펀드에 가입한 후 세금납부시에 해당 납부액을 대출해 주겠다는 말을 하여 담보대출을 받은 것이며 담보대출시 약관을 받은 바도 없고 대출만기 역시 당연히 3년 또는 담보 상품 만기까지 자동 재연장되는 것으로 알았음.

원금이 보장되는 펀드에 가입하고, 이를 담보로 대출을 받았음에도 담보부족액 납부를 요구하는 것은 부당하며, 대출기간 연장시 모든 대출을 변제하겠다는 탄원에도 불구하고 반대매매를 한 것은 부당함.

2008.10.23. B씨, C씨 명의의 펀드 환매시 담당직원이 환매하는 경우 이익이 난다고 하여 이를 허락하였으나 손실을 보았으며, 펀드환매 및 반대매매의 수수료를 6% 공제한 것은 수탈행위에 해당함.

(2) 피신청인 주장

본건 ELF 가입 및 대출 당시 상품의 수익구조 및 원금손실 가능성에 대하여 충분한 상품설명 및 자료교부가 이루어졌고, 신청인은 담당직원과의 접촉 등을 통하여 관련주식 동향 및 가입상품 평가손을 인지하고 있었으며, 대출만기 및 담보부족에 따라 신청인에

게 충분한 사전고지 후 담보부족 리스크를 감안한 반대매매가 진행된 바, 신청인의 투자 경험, 재산상태, 투자경위, 설명의무의 이행정도 등을 고려할 때 투자상품에서 결과적으로 발생한 손실에 대한 신청인의 보상요구를 수용하기 어려움.

다. 위원회 판단

◆ 본건의 쟁점은 부당한 펀드가입 권유 여부, 담보대출 및 그에 따른 반대매매의 정당 여부 등이라 할 것임.

(1) 부당한 펀드가입 권유 여부

증권회사의 직원이 고객에게 적극적으로 투자를 권유하였으나 투자결과 손실을 본 경우에 투자자에 대한 불법행위책임이 성립하기 위하여는 거래경위와 거래 방법, 고객의 투자상황(재산상태, 연령, 사회적 경험 정도 등), 거래의 위험도 및 이에 관한 설명의 정도 등을 종합적으로 고려한 후, 당해 권유행위가 경험이 부족한 일반투자자에게 거래행위에 필연적으로 수반되는 위험성에 관한 올바른 인식형성을 방해하거나 고객의 투자상황에 비추어 과대한 위험성을 수반하는 거래를 적극적으로 권유한 경우에 해당하는 경우, 고객에 대한 보호의무를 저버려 위법하다 할 것임.³⁶²⁾

신청인은 담당직원이 원금보장 등을 약속하고 법인세 납부자금으로 펀드에 가입하도록 부당하게 권유하였다고 주장하나, 다음과 같은 점에 비추어 신청인의 주장을 받아들이기 어려움.

① 담당직원은 신청인의 주장사실을 부인하고 있고, 녹취록이나 기타 증빙상 신청인 주장과 같이 담당직원이 원금보장을 약속한 사실이나 대출을 받아 법인세를 납부하도록 권유한 사실을 인정할 수 있는 객관적인 증빙이 없는 점.

② 신청인이 89세의 고령으로 일반인에 비해 투자판단 능력이 떨어진다고 볼 수 있는 측면이 있기는 하지만, 분쟁조정신청서에서 신청인이 밝히고 있듯이 “A기업과 본인 및 자제들의 재산을 관리하여 왔다”고 진술하고 있으며, 투자경험이 상당할 뿐만 아니라

362) 대법원 2003.1.10. 선고 2000다50312 판결 참조.

2005.7월부터 유사한 구조의 상품에 15차례 가입한 경험이 있는 점.

③ 본건 펀드가입시 신청인과 담당직원과의 통화내용을 정리한 녹취록(2007.8.22., 8.28., 8.31., 9.3., 9.4.)을 보면 신청인이 담당직원에게 수익률 상향을 원하는 의사표시를 하고 있고, 담당직원과 기초자산 변경 등에 대해 언급하고 있는 등 상품설계시 신청인의 의사가 반영되고 있다고 볼 수 있고, 담당직원은 기초자산 가격변동에 따라 조기상환되는 펀드의 수익구조 등을 설명하고 있고, 원금손해가 나지 않느냐는 신청인의 물음에 대해 담당직원이 “마이너스 40%까지는 상관없습니다.”(2007.8.22. 녹취록) “마이너스 40%까지는 원금이 완전히 보장이 되고요.”(2007.8.31. 녹취록) “마이너스 40%까지는 원금보장이 되면서 21%를 줍니다.”(2007.8.31. 녹취록) “아, 3년에 40%까지는 그거는 원금 플러스 이자가 되고 있지 않습니까?”(2007.9.3. 녹취록)라고 진술하고 있는 점.

④ 예금이 아닌 펀드에서 원금보장이 되지 않는다는 것이 일반의 상식에 가깝고,³⁶³⁾ 신청인은 본건 펀드 가입 이전에 본인 및 E씨, A기업 명의로 가입한 펀드를 환매하면서 투자손실을 본 경험도 있는 점.

⑤ 동 펀드는 사모펀드로, 사모펀드의 경우 구 「간접투자자산운용업법」의 특례규정(제 175조)상 투자설명서 작성, 제공 및 주요내용 설명의무가 면제되며, 한편, 2007.9.6. 신청인이 동 펀드에 가입하면서 작성한 투자신탁가입신청서에 “상품제안서를 제공받고 약관 및 상품의 주요내용에 대해 설명들었음”이라고 자필기재하고 날인하고 있고, “상황에 따라서는 손실액이 펀드 매수금액 전부가 될 수도 있습니다”, “펀드의 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 전부 투자자에게 귀속됩니다”라는 문구가 기재된 위험고지문에 기명날인하고 있는 점.

⑥ 신청인은 2008.2.25., 3.26. 잔고증명서를 발급받은 적이 있으며 동 잔고증명서에는 원금, 평가금액 등이 표기되어 있고, 녹취록상 신청인이 기초자산의 주가를 확인하고 있는 점.

(2) 담보대출 및 그에 따른 반대매매의 정당 여부 및 부당한 환매권유

신청인은 나아가 담보대출 및 그에 따른 반대매매 및 환매권유, 환매수수료 징구가 부

363) 서울지방법원 2008.5.28. 선고 2007가합107069 판결.

당하다고 주장하나 다음과 같은 점에 비추어 신청인의 주장을 인정하기 어려움

1) 담보대출 및 그에 따른 반대매매의 정당 여부

① 2008.3.31. 및 5.14. 담당직원이 대출당시 내방한 A기업 직원에게 대출약정신청서, 예탁증권 담보대출신청서 등을 작성하고 확인서를 교부한 사실이 인정되고, 동 서류에 담보징구방법, 담보부족시 임의상환등 약관의 주요내용이 기재되어 있으며, 예탁증권담보대출 신청서에 대출만기일이 6개월 후로 기재되어 있고, 신청인과 담당직원간의 통화내용을 정리한 녹취록(2008.5.2.)상 대출이자 납입과 관련하여 담당직원이 신청인에게 “기일은 6개월로 해냈습니다”라고 진술하고 있는 점.

② 피신청인측이 제출한 “담보부족발생현황”, “대출거래 담보부족금 납부 요청서”에서 확인되는 바와 같이 담보부족, 신청인의 대출금 미상환에 따른 반대매매 사실이 인정되며 달리 담당직원이 신청인에게 담보대출을 받을 것을 적극적으로 종용하거나 대출연장에 관하여 신청인을 기망하고 있다고 볼 자료가 없고 담보부족, 대출금 미상환에 따른 반대매매를 부당하다고 보기 어려운 점.

2) 부당한 환매권유, 환매수수료 징구 여부

① 신청인이 B씨, C씨 계좌를 환매한 경위가 기존 대출금을 상환하기 위한 것으로 보이고, 신청인과 담당직원간의 통화내용을 정리한 녹취록(2008.10.20.)상 담당직원이 “환매해 가지고 대출 조금 줄이는 게 어떨까요?”라고 조언하자, 신청인이 “그럼 손해가 나지 않아요?”라고 반문하고 있으며, 이에 대해 담당직원은 “3년까지 가시는 거 보다는...”이라고만 답변하고 있으며 달리 신청인 주장과 같이 환매하면 이익이 난다고 속이거나 환매를 부당하게 강권하고 있는 것으로 보기 어려운 점.

② 신청인은 수수료가 6%로 과다하다고 주장하고 있으나, 신청인이 본건 펀드 가입시 자필서명한 위험고지문상 “중도환매시 환매수수료를 징구하기 때문에 원금손실이 발생할 수 있으며”라는 문구가 기재되어 있고, △△△△사모파생1호의 경우 환매수수료가 기존의 6%에서 3%로 변경되었으며, 중도환매수수료는 판매회사나 자산운용사에 귀속하는 것이 아니라 신탁재산에 편입되어 운용되는 점.

라. 결론

그렇다면 피신청인은 신청인에 대하여 손해를 배상할 책임이 없다 할 것이므로 신청인의 청구는 이유 없어 이를 기각함.

1-4 ELF 만기손익구조의 설명 불충분과 관련한 손해배상책임 여부

[일부인용] 신청인이 “투자설명서 교부 및 주요내용 설명확인서”에 자필서명하였으나, 녹취 파일에 따르면 피신청인 직원이 ELF 가입 당시 만기손익구조에 대하여 정확히 설명하지 않은 사실이 인정되고, 신청인이 제공받은 상품안내문중 “만기 손익구조”란의 그래프가 50%초과 하락한 적이 있는 경우 만기에 70%이상이어야 원금손실이 없음에도 50%이상이면 원금손실이 없는 것처럼 잘못되어 있어 신청인의 오해유발 소지가 있는 점에 비추어 신청인이 만기손익구조를 정확히 인식하였다고 단정하기 어렵다 할 것임.(2009.11.23. 조정번호 제2009-93호)

가. 사실관계

신청인은 2007.6.28. ○○증권(이하 “피신청인”이라 함) 지점에 내점하여 본인, 장모(A씨) 및 자녀(B씨) 명의의 6개 계좌를 통해 “△△△△ TWO STAR 파생상품투자신탁 1호”³⁶⁴⁾(이하 “본건 ELF”라 함)에 합계 1,415,791,447원을 투자하였으며, 가입 관련서류는 모두 신청인이 작성하고 지점에서 자체 작성한 “상품 안내문”을 제공받음.³⁶⁵⁾

364) “△△△△ TWO STAR 파생상품투자신탁 1호”의 개요는 다음과 같음.

- 투자신탁기간 : 2년(설정일 2007.7.4. / 만기일 2009.7.6.), 6개월마다 조기상환기회 부여
- 투자신탁의 특징
 - 투자대상 : A기업 및 B은행 보통주를 기초자산으로 하는 ELS에 투자
 - 조기 및 만기상환조건 : 각 평가일의 기초종목 주가가 모두 기준주가(2007.7.4. A기업·B은행의 종가)의 85%(6월), 80%(1년), 75%(1년6월), 70%(만기)이상인 경우 연 12% 수익률로 상환
 - 원금손실조건 : 만기까지 한 종목이라도 기준주가의 50%미만으로 하락한 적이 있으면서 만기에 70%미만인 경우
 - 보너스조건 : 만기에 70%미만인 경우라도 만기까지 한 종목이라도 기준주가의 50%미만으로 하락한 적이 없으면 연 7.5% 수익률로 만기상환

365) “핵심설명서” 제공 여부에 대해서는 확인이 곤란함.

2008.10.10. A기업, B은행 모두 기준주가의 50%를 하회하여 원금손실 조건(Knock-In)이 발동하였으며, 2009.7.6. 본건 ELF의 만기가 도래하여 합계 714,263,436원이 상환되어 손해액 701,528,011원이 확정됨(수익률 : -49.58%).

신청인은 1992.경부터 피신청인 담당직원(C씨, 현재 퇴직)을 통해 주식형펀드 등에 투자해 왔으며, 2005.2.14.부터 본건 ELF 가입 직전까지 “본건 ELF와 조기·만기상환조건, 원금손실조건 등의 구조가 유사한” 총 8건의 ELF에 투자하여 모두 원금손실구간에 진입하지 않고 중도상환을 받은 경험이 있음.

나. 당사자의 주장

(1) 신청인의 주장

피신청인 담당직원이 본건 ELF 투자를 권유할 당시에 중도상환 구조는 설명했으나, Knock-In 조건 등 “만기손익구조”³⁶⁶⁾를 잘못 설명하였음.

신청인은 위 담당직원이 “만기시 기초자산 가격이 기준가 대비 50% 이상이면 무조건 원금 및 연 7.5%의 수익금을 지급하는 것”으로 설명하였으므로, 이에 따라 2009.7.6. 본건 ELF 만기도래시 평가가격이 기준가의 50%를 초과하였으므로 원금 및 연 7.5%의 수익금이 지급되는 것으로 알았음. 따라서 피신청인은 담당직원이 위와 같이 잘못된 설명을 하여 신청인의 투자판단을 그르치게 한 점에 대한 책임을 부담해야 함.

(2) 피신청인의 주장

본건 ELF 가입 당시 상품의 개요, 손익구조 등에 대해 상세히 설명한 후 “투자설명서 교부 및 주요내용 설명확인서”에 신청인의 자필 서명을 받았음. 또한, 신청인이 교부받아 본건 분쟁조정신청서에 첨부한 “상품안내문”에도 기준주가 대비 50%초과 하락한 적이 있는 경우와 없는 경우를 구분하여 만기손익구조가 설명되어 있으므로 만기손익구조를 오해했다는 신청인의 주장을 수용하기 어려움.

366) 만기손익구조 : 기초자산 가격이 기준가 대비 50%미만으로 하락한 적이 없는 경우에는 원금 및 연 7.5%의 수익금을 지급하나, 50%미만으로 하락한 적이 있는 경우 만기에 70%를 하회하면 손실 발생.

신청인은 본건 ELF 가입 이전에 유사한 손익구조인 ELF에 8회 투자하여 이익을 실현한 경험이 있어 이미 ELF의 수익구조에 대하여 잘 알고 있었음.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 ① 피신청인 담당직원이 신청인에게 본건 ELF의 만기수익구조를 정확히 설명하였는지 여부 및 ② 그와 같은 설명 여부와 별개로 신청인의 투자경험에 비추어 신청인 스스로 만기수익구조를 인지(認知)하고 있었다고 볼 수 있는지 여부라 할 것임.

(1) 주요내용 설명의무 위반 여부

수익증권 판매회사의 임직원이 고객에게 투자신탁상품의 매입을 권유할 때에는 그 투자에 따르는 위험을 포함하여 당해 투자신탁의 특성과 주요 내용을 설명함으로써 고객이 그 정보를 바탕으로 합리적인 투자판단을 할 수 있도록 고객을 보호하여야 할 주의의무가 있음.³⁶⁷⁾

신청인이 「투자설명서 교부 및 주요내용 설명확인서」에 “투자설명서를 제공받고 그 주요내용을 설명 들었음”을 자필서명한 사실에 비추어 신청인이 본건 ELF 가입 당시 만기손익구조에 대해 설명을 들었던 것으로 추정된다 할 것이나, 신청인이 제출한 녹취 파일에 따르면, 피신청인 담당직원이 본건 ELF 가입 당시 만기손익구조에 대하여 정확하게 설명하지 않은 사실을 인정하고 있어 위와 같은 추정은 유지되기 어려움.

(2) 신청인의 만기손익구조 인지(認知) 여부

신청인은 본건 ELF 투자 이전에도 총 8회나 유사한 구조의 ELF에 투자한 사실이 있는 점, 본건 분쟁조정신청서 및 위 녹취파일에 기재된 내용 등을 종합할 때 신청인이 “기준시점의 기초자산 평가액에 따라 수익률이 결정되는 ELF의 기본적인 손익구조”는 알고 있었던 것으로 보임. 그러나 “만기손익구조”에 대해서는 그 동안 신청인이 투자했던 8건의 ELF는 모두 Knock-In을 겪지 않고 중도 상환된 점 및 신청인이 제출한 녹취 파일 수록내용을 고려할 때, 단지 투자경험이 많다는 이유만으로 신청인이 만기손익구조

367) 대법원 2006.5.11. 선고 2003다51057 판결 참조.

를 정확하게 알고 있었다고 단정하기는 어려움.

또한, 신청인이 제공받은 「상품안내문」(영업점 자체 작성)중 “만기시 손익구조” 란에는 “기준주가 대비 50%초과 하락한 적이 없는 경우”와 “... 하락한 적이 있는 경우”가 구분 기재되어 있어 신청인이 만기손익구조를 알 수 있었을 가능성은 존재하나, 위 「상품안내장」중 펀드내용란의 “만기시 수익률”에는 “두 종목중 하나라도 50% 초과 하락 없을 때³⁶⁸⁾ ⇒ 만기시 원금 + 15%(연7.5%)”라고 기재되어 있고, 만기시 손익구조 란의 “그래프”도 50% 초과 하락한 적이 있는 경우 만기에 “70%” 이상이어야 원금손실이 없음에도 “50%” 이상인 경우 원금손실이 없는 것처럼 잘못 그려져 있어 신청인의 오해를 유발할 소지가 있는 바, 신청인이 「상품안내문」을 교부받았다는 사정만으로 본건 ELF의 만기손익구조를 정확히 인식하고 있었다고 단정하기도 어렵다 할 것임.

(3) 손해배상액 산정

신청인이 본건 ELF 가입 이전에 유사한 상품에 여러 차례 가입한 경험이 있었다 하더라도, 투자상품의 만기상환조건·원금손실조건 등이 구체적으로 어떻게 설정되어 있느냐(즉, 몇 %를 기준으로 하는가?, Knock-In 조건은 어떠한가? 등)에 따라 당해 상품에 대한 투자자의사는 달라질 수 있는 것으로서, 피신청인이 주요설명사항인 본건 ELF의 만기손익구조를 정확히 설명하지 않았을 뿐만 아니라 오해를 유발할 수 있는 「상품안내장」을 제공함으로써 만기손익구조에 대한 신청인의 잘못된 인식을 초래하였다면, 피신청인의 행위는 투자자에 대한 보호의무를 저버린 위법한 행위로 볼 수 있음.

신청인 손해금액은 본건 ELF 총 가입금액 1,415,791,447원에서 만기상환금 714,263,436원을 공제한 금 701,528,011원이라 할 것임. 다만, 금융투자상품에 대한 투자 결과 발생한 손익은 모두 투자자에게 귀속되는 것이 대원칙이라 할 것이고, 여기에 신청인은 본건 ELF와 유사한 구조의 ELF 상품에 총 8회나 투자한 경험이 있는 점, 가입 당시 만기손익구조가 기재된 ‘상품안내문’을 제공받았음에도 그 내용을 살펴보고 의문점을 담당직원에게 문의하는 등의 방법으로 만기손익구조를 파악하려는 노력을 하지 않은 채 약 14억 원의 거액을 투자하면서도 담당직원의 설명에만 의존하여 투자결정을 한 점 등을 고려

368) “두 종목중 하나라도 50% 초과 하락한 적이 없을 때”로 표현해야 실제 수익구조에 부합함.

할 때 신청인의 과실을 높게 참작하여 80%의 과실상계를 함이 타당함.

라. 결 론

그렇다면, 피신청인은 신청인에게 손해금액 140,305,602원을 배상할 책임이 있어 이를 인용하고, 신청인의 나머지 청구는 이유 없어 이를 기각함.

1-5

고위험상품의 특성을 이해하기 어려운 고객에 대한 적정성 의무 위반

[일부인용] 본건은 담당직원과 신청인 간의 녹취내용에 의하면 본건 상품가입은 신청인의 의사에 따라 이루어진 것으로 임의가입을 인정하기는 어렵다 할 것임. 그러나 신청인은 이전에 본건과 같은 구조의 파생상품에 투자한 경험이 없고, 가입 당시 고령(1937년생)에다 초등학교 미취학으로 본건 상품의 특성 및 위험성을 쉽게 이해할 수 있다고 보기 어렵고, 녹취록에 비추어 볼 때 신청인이 본건 상품의 특성과 위험성을 충분히 이해하고 있다거나 담당직원의 충분하고 적합한 설명이 있었다고 보기 어려움.(2010.5.11. 조정번호 제2010-45호)

가. 사실관계

신청인은 2008.6.5. ○○증권사(이하 “피신청인”이라 함) 지점에 신청인의 관리자로 새로 배정된 직원 A씨(2008.4.1. 동 지점 발령, 이하 “담당직원”이라 함)의 유선연락을 받고 동 지점에 내점하여 보유중인 상품에 대해 상담한 후, 당일 만기 보유중이던 채권형, 채권혼합형 상품을 환매신청함

이후, 2008.6.12. 신청인은 담당직원을 통하여 “파생상품 투자신탁 4호”³⁶⁹⁾(이하 “본건

369) “파생상품 투자신탁 4호”의 개요는 다음과 같음

- 신탁계약기간 : 1년 1개월(매4개월 단위로 조기상환기회 부여)
- 투자신탁의 특징
 - 투자목적 : 신탁재산의 90%이상을 KOSPI200지수 및 NIKKEI225지수와 연계된 장외파생상품에 투자하여 조기상환조건에 부합할 경우 조기에 수익을 확정(투자위험 5등급 중 1등급)
 - 수익구조 : 매4개월 평가일 기초자산의 비교지수가 최초 기준지수 대비 100%(4개월), 95%(8개월), 90%(12개월) 이상인 경우 원금과 연 14.01% 수익

상품”이라 함)에 각 3천만원(비과세), 7천만원, 합계 1억원을 가입하였는데, 본건 상품 가입시 본인이 직접 내점하지 않고 통장과 도장을 지인(세입자)에게 맡기고 신청인 대신 지인이 내점하여 본건 상품에 가입하였으며, 동일자로 작성된 「투자설명서 교부 및 주요내용 확인설명서」의 “제공받고”, “설명들었음” 및 투자고객란 성명을 누가 기재하였는지는 명확하지 아니하며, 담당직원은 투자설명서를 교부하지 아니함(문답서 7쪽 참조).

피신청인은 신청인에게 분기보고서를 발송하였고, 2008.10.23. 본건 상품의 원금보장 조건이 소멸³⁷⁰⁾되자 피신청인은 이를 신청인에게 우편통보하였으며, 신청인은 본건 상품 만기에 합계 72,199,180원을 상환받음.

나. 당사자의 주장

(1) 신청인의 주장

원금이 보장되고 이율이 높다고 하여 피신청인에게 자금을 맡긴 것일 뿐인데 담당직원이 본건 상품에 임의로 가입한 것이며, 본건 상품 가입시 원금손실가능성 등 상품의 특성 및 위험성에 대한 충분한 설명을 받지 못하고 가입한 것임.

(2) 피신청인의 주장

신청인은 2005년경부터 혼합형, 주식형 펀드 등 펀드 상품에 투자한 경험, 손실을 본 경험이 있을 뿐만 아니라 2008.7.21. 본건 상품 가입이후에 본건과 유사한 구조의 파생상품 펀드에 가입하여 만기상환을 받은 경험³⁷¹⁾까지 있는 점 등에 비추어 투자상품의 위험성을 어느 정도 잘 알고 있다 할 것이고, 2008.6.5. 담당직원의 연락을 받고 신청인이 내점하여 기보유중인 상품에 대해 상담을 하는 과정에서, 담당직원은 상품제안서 및 투자설명서를 이용하여 신청인에게 본건 상품의 특성과 위험성을 충분히 설명하고 상품제안서와 투자설명서를 교부하였으며 이에 따라 신청인이 본건 상품에 가입하기로 하였던

* 조기상환되지 않고 만기시 기초자산의 지수(장중포함)가 한 종목이라도 65%미만으로 하락한 적이 있는 경우 원금손실(낮은 수익률 기준)

- 환매수수료 : 환매대금의 5%

370) NIKKEI225 지수가 최초 기준가격 65% 미만 하락

371) 2008.7.22. 파생상품투자신탁, 15,002,274원 가입, 2009.7.22. 상환(1,688,943원 이익)

것이고, 이후 신청인에게 유선상 내점을 요청하였으나 신청인의 사정으로 신청인 대신 신청인의 지인이 내점하여 본건 상품에 가입한 것이므로 임의가입이나 불완전판매에 해당하지 아니함.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 본건 상품의 ① 임의가입 여부 ② 불완전판매로 인한 손해배상책임 유무와 그에 따른 구체적인 손해배상액 산정이라 할 것임

(1) 임의가입 해당 여부

신청인은 본건 상품가입이 임의로 이루어졌다고 주장하나, 담당직원과 신청인간 통화 내용을 정리한 녹취내용에 비추어, 본건 상품가입은 신청인의 의사에 따라 이루어진 것으로 임의가입을 인정하기는 어렵다 할 것임.

2007.6.11.자 녹취록에 의하면, 담당직원이 신청인에게 “오늘, 오시기로 하셨잖아요.” “그러면 지금 그 1년짜리 하시는 게 내일 날짜로 설정이 되는건데.”라고 말하자, 신청인이 담당직원에게 내점하기 어려운 사정을 말하고 “그럼 내일 내가 우리 할머니 보내면 갈려는지 모르겠는데 한번 물어봐서 해볼까?”라고 진술하고 있고, 2008.6.12. 가입 당일 신청인이 유선으로 “거기 할머니 돈 가지고 안 갔어?”라고 문의하고 있고 이에 대해 담당직원이 “300만원 잘 받아서 금액 1억원 맞췄고요.” “계좌가 오늘 두 개로 만들어질 거예요.” “3천만원은 비과세 되는거, 그걸로 들어가고 나머지 7천은 일반과세로 그렇게 해서 넣어드렸어요.”라고 진술하고 있는 사실이 확인됨.

(2) 펀드 불완전판매 여부

금융기관의 임직원이 고객에게 적극적으로 투자를 권유하였으나 투자 결과 손실을 본 경우에 투자자에 대한 불법행위책임이 성립되기 위하여는 이익보장 여부에 대한 적극적 기망행위의 존재까지 요구하는 것은 아니라 하더라도, 적어도 거래경위와 거래방법, 고객의 투자상황(재산상태, 연령, 사회적 경험 정도 등), 거래의 위험도 및 이에 관한 설명의 정도 등을 종합적으로 고려한 후, 당해 권유행위가 경험이 부족한 일반 투자자에게 거래행위에 필연적으로 수반되는 위험성에 관한 올바른 인식형성을 방해하거나 또는 고

객의 투자 상황에 비추어 과대한 위험성을 수반하는 거래를 적극적으로 권유한 경우에 해당하여, 결국 고객에 대한 보호의무를 저버려 위법성을 띤 행위인 것으로 평가될 수 있는 경우라야 하며,³⁷²⁾ 또한 금융기관의 임직원이 고객에게 투자신탁상품의 매입을 권유할 때에는 그 투자에 따르는 위험을 포함하여 당해 투자신탁의 특성과 주요 내용을 설명함으로써 고객이 그 정보를 바탕으로 합리적인 투자판단을 할 수 있도록 고객을 보호하여야 할 주의의무가 있고, 이러한 주의의무를 위반한 결과 고객에게 손해가 발생한 때에는 불법행위로 인한 손해배상책임이 성립하는 것이고, 투자에 따르는 위험과 관련하여 투자권유자는 투자에 따르는 제반 위험이 존재하고 이로 인하여 원본 손실가능성이 있다는 사실 등을 설명하여야 하는 것이나, 고객에게 어느 정도의 설명을 하여야 하는지는 투자대상인 상품의 특성 및 위험도의 수준, 고객의 투자경험 및 능력 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 할 것임.³⁷³⁾

이에 비추어 볼 때, 담당직원의 본건 상품 가입권유행위는 다음과 같은 점에서 상품의 특성 및 위험성 등에 대한 충분하고 적합한 설명이 있었다고 보기 어렵다고 판단됨.

① 담당직원은 본건 상품 가입일(2008.6.12.) 이전인 2008.6.5. 신청인이 동 직원의 유선 연락을 받고 내접하였을 때, 신청인에게 상품의 내용을 충분히 설명하고 투자설명서를 교부하였다고 주장하나, 신청인은 위와 같은 사실을 부인하고 있고 녹취록, 문답서 등에 의해 신청인의 내접 사실만 확인 될 뿐, 담당직원의 설명여부에 대해서는 달리 이를 입증할 객관적인 증빙이 없으며, 나아가 본건 상품 가입일에 신청인을 대신하여 지점을 방문한 신청인의 지인의 경우에도 80세 이상의 고령으로 신청인의 심부름으로 통장과 도장만 전달하였을 뿐 당시 담당직원으로부터 본건 상품에 대한 설명을 받거나 투자설명서를 교부받은 적이 없다고 주장하고 있으며, 담당직원 또한 동인에게 투자설명서를 교부하지 않았다고 진술하고 있는 점.

② 본건 상품은 투자위험 5등급 중 1등급으로 장외파생상품의 거래에 따른 특성 및 위험과 기초자산 지수하락에 따른 위험을 충분히 이해하고 원금손실 위험을 감수하며

372) 대법원 2003.1.10. 선고 2000다50312 판결, 2007.7.12. 선고 2006다53344 판결 참조.

373) 대법원 2003.7.25. 선고 2001다10458 판결 참조.

고수익을 추구하는 투자자에게 적합한 상품임에 반하여, 신청인은 본건 상품 가입 이전에 본건과 같은 구조의 파생상품에 투자한 경험이 없고, 본건 상품 가입 당시 고령(1937년생, 만71세)에다 초등학교 미취학으로 글자해독능력 또한 현저히 떨어지는 상태로서 본건 상품의 특성 및 위험성을 쉽게 이해할 수 있다고 보기 어려우며, 가사 담당직원의 주장처럼 본건 펀드 가입이전인 2008.6.5. 담당직원이 지점에 내점한 신청인에게 어느 정도 상품설명을 하였다고 본다 하더라도, 본건 펀드 가입당시 담당직원과 신청인간 통화 내용을 정리한 녹취록에 비추어 볼 때, 신청인이 본건 상품의 특성과 위험성을 충분히 이해하고 있다거나 담당직원의 충분하고 적합한 설명이 있었다고 보기 어려운 점.

(3) 손해배상액 산정

신청인의 손해금액은 투자원금 1억원에서 상환금액 72,199,180원을 차감한 27,800,820원이라 할 것임. 다만, 다음과 같은 점을 고려하여 피신청인의 책임을 40%로 제한하는 것이 상당하다 할 것임.

① 투자자는 자기책임의 원칙 아래 투자상품의 개념이나 내용, 손익구조, 투자위험성 등에 관한 내용을 사전에 정확히 파악하여 신중히 검토한 다음 투자하여야 할 것인데도 이를 게을리 하였고, 원금이 보장되며 연 14% 수익이 보장되는 상품은 비교적 이례적이라 할 것이고, 금융지식이나 인지능력이 떨어지는 신청인으로서 금융거래에서 상당한 주의를 기울여야 할 것임에도 높은 수익을 기대하고 경솔히 본건 상품에 가입하였고, 상품가입시에도 본인이 직접 내점하지 아니하고 지인을 통하여 본건 상품에 가입한 점.

② 예금이 아닌 펀드는 원금이 보장되지 아니한다는 것이 일반의 상식에 속한다 할 것이고,³⁷⁴⁾ 신청인은 기존에 주식형 펀드 등에 투자하여 손실을 본 경험까지 있어 금융상품 투자의 위험성 등에 대해 어느 정도 인식하고 있다고 보이는 점.

③ 신청인은 피신청인이 발송한 운용보고서, 낙인통보 등을 통하여 본건 상품이 원금 손실이 난다는 것을 알 수 있었던 것으로 보임에도 환매 등 조치를 취하지 아니한 점 등을 고려하여 신청인의 과실비율을 60%로 보고 피신청인의 책임을 40%로 제한함이 타당함.

374) 서울지방법원 2008.5.28. 선고 2007가합107069 판결 참조.

라. 결 론

그렇다면 피신청인은 신청인에게 손해금액 11,120,328원을 배상할 책임이 있어 이를 인용하고, 신청인의 나머지 청구는 이유 없어 기각함.

1-6 ELS 부당권유로 인한 손해배상책임 여부

[기각] 신청인은 30여년간 교사로 재직하여 일반인에 비해 투자판단능력이 떨어진다고 보기 어렵고, 이전에 피신청인을 통하여 본건과 유사한 수익구조의 ELS상품에 다수 투자한 경험 이 있어 ELS상품의 구조 및 위험성을 어느 정도 알 수 있었다고 보이며, 또한 가입당시 ‘핵심설명서를 교부받고 상품특성과 위험성을 충분히 인지하고 청약함을 확인한다’는 내용이 기재된 청약서에 자필서명을 한 점, 녹취록에 의하면 타 증권사 상품을 비교하고 있는 점 등에 비추어 신청인이 본건 ELS 상품의 원금손실 가능성을 몰랐다고 보기 어려우므로 피신청인은 신청인에 대하여 손해를 배상할 책임이 없다 할 것임.(2010.7.13. 조정번호 제2010-59호)

가. 사실관계

신청인은 중학교 교사(2008.2월 퇴직)로 근무했던 사람으로, ○○증권사(이하 “피신청인”이라 함) 지점 직원 A씨(이하 “담당직원”이라 함)의 권유를 받고 2007.10.2. “△△△△ ELS 1호”에 4,150만원을, 2008.5.14. “△△△△ ELS 2호”³⁷⁵⁾에 5,310만원을 가입함.

375) 본건 ELS 상품의 개요는 다음과 같음.

<△△△△ ELS 1호(원금비보장형)>

- 신탁계약기간 : 2년 (매6개월 단위로 조기상환기회 부여)
- 투자신탁의 특징
 - 기초자산 : A기업 보통주, B기업 보통주
 - 조기상환 : 매6개월 평가일 기초자산의 비교지수가 최초 기준지수 대비 80%(6개월), 75%(12개월), 70%(18개월) 이상인 경우 원금과 연 22% 수준의 수익
 - 만기상환 : ① 만기시 기초자산의 지수(장중포함)가 모두 65%이상 이거나, 두 종목 중 한 종목이라도 50%미만으로 하락한 적이 없고 어느 하나라도 65% 미만인 경우 22% 수익
② 만기시 한 종목이라도 50%미만으로 하락한 적이 있고, 어느 하나라도 65%미만인 경우 하락폭이 큰 종목의 하락률 만큼 원금손실

위 상품 가입경위를 보면, 본건 ELS 가입권유는 모두 유선을 통하여 이루어졌는데, △△△△ ELS 1호의 경우 담당직원이 유선으로 신청인에게 상품가입 권유를 한 이후, 2007.9.27. 신청인의 직장 동료인 B씨가 피신청인 지점에 내점, 청약서를 받아 신청인에게 주었고 신청인이 이를 작성하여 B씨로 하여금 다시 담당직원에게 전달하여 가입하였고, 동 청약서에는 “본인은 귀사의 (△△△△ ELS 1호) 청약과 관련하여 핵심설명서를 교부받고 (상품특성 및 위험요소)를 충분히 인지하고 청약함을 확인합니다.”라는 문구가 기재되어 있고 신청인이 밑줄 부분을 자필기재함.

△△△△ ELS 2호의 경우, 담당직원이 유선으로 신청인에게 상품가입 권유를 한 후 나중에 신청인의 집에 방문하여 청약서를 교부받았으며, 청약서상 “본인은 귀사의 (△△△△ ELS 2호) 청약과 관련하여 핵심설명서를 교부받고 (상품특성과 위험요소)를 충분히 인지하고 청약함을 확인합니다.”라는 문구중 밑줄 부분은 담당직원이 대신 기재함.

신청인은 본건 ELS 만기에 합계 42,748,326원을 상환받음(51,851,674원 손해).

나. 당사자의 주장

(1) 신청인의 주장

담당직원이 본건 ELS 가입 권유시 원금손실에 대한 위험 등을 설명하지 않고 수익부분만 강조하며 부당하게 가입을 권유한 것이므로 이로 인한 손해배상을 구함.

< △△△△ ELS 2호(원금비보장형) >

- 신탁계약기간 : 1년 (매3개월 단위로 조기상환기회 부여)
- 투자신탁의 특징
 - 기초자산 : C기업 보통주, D기업 보통주
 - 조기상환 : 매3개월 평가일 기초자산의 비교지수가 최초 기준지수 대비 85%(3개월), 80%(6개월), 75%(9개월) 이상인 경우 원금과 연 24% 수준의 수익
 - 만기상환 : ① 만기시 기초자산의 지수(장중포함)가 모두 70%이상 이면 24% 수익
 - ② 두 종목 중 한 종목이라도 50%미만으로 하락한 적이 없고 어느 하나라도 70% 미만인 경우 18.0% 수익
 - ③ 만기시 한 종목이라도 50%미만으로 하락한 적이 있고, 어느 하나라도 70% 미만인 경우 하락폭이 큰 종목의 하락률 만큼 원금손실

(2) 피신청인의 주장

신청인은 본건 ELS 1호 가입 이전에 상품구조가 유사한 ELS에 다수 가입한 경험이 있고, 본건 ELS 2호 가입이전에도 ELS에 다수 가입한 경험이 있으며, 피신청인과 거래하기 전에도 타 증권사를 통해서 ELS, 펀드, 주식거래를 한 경험이 있고 담당직원이 본건 ELS 가입 권유시 유선으로 상품의 내용을 설명하였고, 신청인이 본건 ELS의 청약서를 자필 기재한 점 등 신청인의 투자경험, 투자경위, 설명의무의 정도 등을 고려할 때 신청인이 원금손실 위험 등을 인지하지 못했다는 주장은 수용하기 어려움.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 담당직원의 부당한 ELS 가입권유로 인해 신청인이 원금손실 위험 등을 인지하지 못하고 본건 투자를 한 것인지 여부라 할 것임.

(1) 관련 판례

금융기관의 임직원이 고객에게 적극적으로 투자를 권유하였으나 투자 결과 손실을 본 경우에 투자자에 대한 불법행위책임이 성립되기 위하여는 이익보장 여부에 대한 적극적 기망행위의 존재까지 요구하는 것은 아니라 하더라도, 적어도 거래경위와 거래방법, 고객의 투자상황(재산상태, 연령, 사회적 경험 정도 등), 거래의 위험도 및 이에 관한 설명의 정도 등을 종합적으로 고려한 후, 당해 권유행위가 경험이 부족한 일반 투자자에게 거래행위에 필연적으로 수반되는 위험성에 관한 올바른 인식형성을 방해하거나 또는 고객의 투자 상황에 비추어 과도한 위험성을 수반하는 거래를 적극적으로 권유한 경우에 해당하여, 결국 고객에 대한 보호의무를 저버려 위법성을 띤 행위인 것으로 평가될 수 있는 경우라야 하며,³⁷⁶⁾ 고객에게 어느 정도의 설명을 하여야 하는지는 투자대상인 상품의 특성 및 위험도의 수준, 고객의 투자경험 및 능력 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 할 것임.³⁷⁷⁾

376) 대법원 2003.1.10. 선고 2000다50312 판결, 2007.7.12. 선고 2006다53344 판결 참조.

377) 대법원 2003.7.25. 선고 2001다10458 판결 참조.

(2) 부당한 ELS가입 권유 여부

본건의 경우, 담당직원의 상품가입 권유를 다소 미흡하게 볼 수 있는 측면은 있다 할 것이나, 다음과 같은 점을 고려해 보면, 신청인이 본건 ELS 상품의 원금손실 위험성을 인지하지 못하였다거나 이로 인하여 투자판단을 그르쳤다고 보기는 어렵다 할 것임.

① 신청인은 2008.2.29. 퇴직하기 전까지 34년간 교사로 재직하여왔던 사람으로 일반인에 비해 투자판단능력이 떨어진다고 보기 어려우며, 본건 ELS 가입 이전에 피신청인을 통하여 본건 ELS와 유사한 수익구조의 ELS상품에 다수 투자한 경험이 있어 ELS 상품의 구조 및 위험성을 어느 정도 알 수 있었다고 보이는 점.

② 신청인은 피신청인을 통한 위와 같은 ELS 투자 이외에 타 증권사를 통해서도 ELS 거래³⁷⁸⁾를 하였으며, 과거에 주식 및 펀드에 투자한 경험이 있는 것으로 확인될 뿐만 아니라, 펀드를 손해를 보고 찾은 경험은 없으나 마이너스 상태를 본 경험이 있고, 주식은 소위 깡통계좌를 통해 손해를 본 경험도 있다고 진술하고 있는 점(2010.4.16.자금감원 문답서 참조).

③ 담당직원이 △△△△ ELS 1호 가입권유시 신청인에게 유선으로 “ELS 22%짜리가 나왔어요” “A기업하고 B기업” “6개월이고, 최소가 80%요” “딱 65%로 상황이 안되는 2년짜리거든요” “50%만 안내려가도 더미가 22%예요”(2007.9.20.자 녹취록)라고 상품을 대략적으로 설명하고 있으며 신청인의 직장동료인 B씨의 답변자료에 의하면, B씨도 담당직원으로부터 본건 ELS 상품을 권유받아 본건 상품에 가입하였고, 가입당시 “핵심설명서를 교부받고 상품특성과 위험성을 충분히 인지하고 청약함을 확인한다”는 내용이 기재된 청약서에 자필서명을 하고 가입한 것으로 보임. 위 B씨는 신청인에게 본건 ELS가입을 제안하여 신청인의 동의를 받고 2007.9.27. 피신청인 지점에 방문하였으며, 신청인은 위 B씨로부터 청약서를 교부받아 이를 작성한 이후 다시 동인을 통해 담당직원에게 청약서를 전달한 것으로 보이는 점.

④ △△△△ ELS 2호 가입시, 담당직원이 유선으로 “3개월 단위로 해 갖고 24%짜리

378) 2008.11.18.자 녹취록에 의하면 신청인은 ○○증권, ◇◇증권 등에 ELS만 5억원을 넘게 투자하고 있다고 진술하고 있음.

하나 나왔어요”라고 상품소개를 하자 신청인이 “◇◇증권에는 21%가 있더라고” “○○증권에 22.6%짜리가 나왔거든” “그냥 ○○증권에다 넣을까, 여기다가 그냥 넣을까?” “왜냐 하면 지금 C기업이 며칠간 좀 떨어졌잖아?” “아니, 근데 이제 거기는 80%부터니까, ○○증권은” “그래서 지금 어떻게 할 까? 둘 중에 들라고 그러는데”라고 말하는 등 타 증권사 상품을 비교하며 투자결정을 하고 있는 것으로 보이는 점(2008.4.30., 5.6., 5.13.자 녹취록).

④ 본건 ELS 2호를 가입하기 이전인 2008.3.17.자 녹취록상 신청인의 통화내용이 확인되며, 동 내용이 어떤 의미인가를 묻는 금감원 직원의 질문에 신청인이 “예전에 ◇◇증권에서 가입한 ELS 상품은 원금손실이 가능한 상품이라는 것을 알고 있었기 때문에 그렇게 말하였습니다.”라고 답변하고 있는 점(동 문답서 9쪽).

④ 예금이 아닌 금융상품에서 원금보장이 되지 않는다는 것이 일반의 상식에 가깝고,³⁷⁹⁾ 원금이 보장되며 연22~24% 수익이 보장되는 상품은 비교적 이례에 속한다 할 것이어서 신청인이 본건 ELS 상품의 원금손실 가능성을 몰랐다고 보기 어려운 점.

라. 결론

그렇다면 피신청인은 신청인에 대하여 손해를 배상할 책임이 없다 할 것이므로 신청인의 청구는 이유 없어 이를 기각함.

379) 서울지방법원, 2008.5.28. 선고, 2007가합107069 판결 참조.

제2절 주식형·채권형·혼합형 펀드

1-7 주식형 수익증권의 부당권유 및 임의가입 여부

[기각] 투자권유시 주식형의 위험성 설명여부 및 수익률보장 약속 여부에 대하여는 양당사자의 주장이 상반되고, 신청인의 주장을 인정할 만한 증거가 없는 점, 비록 주식형으로 전환시 투자신탁설명서가 교부되지 않은 것은 사실이나 신청인의 투자경험 등에 비추어 보았을 때 신청인은 주식형수익증권의 위험성을 충분히 인식할 수 있었을 것이라는 점 등에 비추어 부당권유를 인정할 수 없음. 또한 신청인이 사후에 지점을 방문하여 전환청약서에 기명날인함으로써 전환청약서 없이 전환된 것을 보완한 점, 신청인이 이의제기를 하지 아니하고 새로이 전환된 주식형수익증권의 가치하락에 대하여 문의한 사실 등에 비추어 피신청인이 주식형 수익증권에 임의가입하였다고 보기 어렵다 할 것임.(2001.3.27. 조정번호 제2001-17호)

가. 사실관계

신청인은 ○○증권회사(이하 “피신청인”이라 함) 직원의 권유로 1999.7.2. A공사채형 펀드를 A주식형 펀드로, 7.5. B공사채형 펀드를 C주식형 펀드로 전환하였는데, 7.7. 전환청약서 없이 D공사채형이 C주식형으로 전환된 후, 신청인은 7.31. 전환청약서를 보완한 바 있음. 1999.12월 및 2000.1월 직원은 주가전망을 낙관적으로 보고 신청인에게 위의 주식형수익증권을 계속 보유할 것을 권유하였고, 신청인은 상기 주식형에 약 258백만원을 투자하여 손실금액이 확대되자 피신청인에게 피해보상을 요구하였으나 해결되지 않자 분쟁조정을 신청함.

나. 당사자의 주장

(1) 신청인의 주장

공사채형을 주식형으로 전환한 것은 피신청인의 직원이 공사채형의 수익률을 허위로 낮게 보고하고 동 상품의 수익률이 낮기 때문에 주식형으로 전환하라고 권유하였기 때문이며, 권유시 직원은 원본손실은 절대 발생하지 않고, 10%의 수익률을 보장하겠다고

말하였음. 또한 주식형으로 전환할 때 투자신탁설명서를 교부받은 사실도 없음. 1999.7.7. 직원은 신청인의 동의 없이 임의로 D공사채형을 주식형으로 전환하고, 같은 해 7.31. 신청인이 지점을 방문하였을 때 동 펀드에 대한 낙관적인 전망을 제시하고 손실발생가능성 등을 전혀 설명해주지 않았음. 따라서 신청인은 직원의 말을 신뢰하여 당일 전환청약서를 보완해 준 것임. 이듬 해 1월 전후 환매를 요구하였을 때 직원이 향후 종합주가지수가 1100~1300까지 간다며 주식형수익증권을 계속 보유할 것을 권유하여 환매를 하지 못하였는 바, 피신청인은 위와 같은 직원의 부당권유와 임의가입으로 인한 손해를 배상하여야 함.

(2) 피신청인의 주장

직원이 신청인에게 주식형으로 전환하라고 권유한 것은 사실이나 이는 공사채형의 전망은 나쁠 것으로 보이는 반면 주식시장은 상황이 좋을 것으로 판단하여 권유한 것이며, 이때 원본손실은 절대 발생하지 않는다고 수익률을 보장하겠다고 하지는 않았음. 또한 신청인은 직원이 임의로 D공사채형을 주식형으로 전환하였다고 주장하나 이는 직원이 신청인의 구두동의를 얻은 후 이루어진 것이므로 신청인의 주장을 수용할 수 없음.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 본건 주식형 수익증권 임의가입 및 부당권유 여부라 할 것임.

다음과 같은 점에 비추어 볼 때 직원의 부당권유를 인정하기 어려움.

① 직원이 신청인에게 공사채형을 주식형으로 전환하도록 권유한 사실은 인정되나, 권유시 주식형의 위험성 설명여부 및 수익률보장약속여부에 대하여는 양당사자의 주장이 상반되고, 신청인의 주장을 인정할 만한 증거가 없는 점.

② 비록 주식형으로 전환시 투자신탁설명서가 교부되지 않은 것은 사실이나 신청인의 투자경험³⁸⁰⁾ 등에 비추어 보았을 때 신청인은 주식형수익증권의 위험성을 충분히 인식

380) 신청인은 1997.7.30. 피신청인 주식형상품에 8천만원을 투자하여 1998.1.21. 인출시 약5백만원의 원금 손실이 발생하자 당시 직원이 수익보장각서를 교부하였음을 근거로 원금을 보전받은 경험이 있음.

할 수 있었을 것이라는 점.

③ 2000.1월 전후에 신청인이 환매를 요구하였을 때 직원이 향후 주가가 1100~1300까지 간다면 주식형수익증권을 계속 보유할 것을 권유한 사실은 있으나, 당시까지만 해도 신청인은 이득을 보고 있는 상태였고, 주식형수익증권의 계속 보유여부는 신청인의 투자 판단사항이라는 점.

또한, 다음과 같은 점에 비추어 볼 때 임의가입도 인정하기 어려움.

① 직원이 1999.7.7. 전환청약서 없이 공사채형을 주식형으로 전환한 사실에 대하여 신청인은 임의가입을 주장하고, 직원은 사전에 구두동의가 있었다고 주장함으로써 양당사자의 주장이 상반되나, 신청인이 같은 달 31일에 지점을 방문하여 전환청약서에 기명날인함으로써 전환청약서 없이 전환된 것을 보완한 점.

② 이후에도 신청인은 이에 대하여 이의제기를 하지 아니하고 새로이 전환된 주식형 수익증권의 가치하락에 대하여 문의한 사실에 비추어 최소한 추인하였다고 판단되는 점.

라. 결 론

직원의 부당권유 및 임의가입을 인정하기 곤란하므로 신청인의 손해배상청구는 이유 없다고 할 것임.

1-8 신탁재산 감소에 따라 동일종목 투자한도를 초과하게 된 경우의 책임

[기각] 「증권투자신탁업법」 제33조 및 「공사채형약관」 제19조는 위탁자가 투자신탁재산의 10%를 초과하여 동일종목의 유기증권에 투자하여 수익자에게 손해가 발생하였다면 위탁자는 불법행위 내지 계약위반으로 수익자에게 손해를 배상하여야 하나, 본건의 경우 신탁재산이 지속적으로 감소함에 따라 1999.7월부터 특정 회사채 편입비율이 10%를 초과하게 된 점. 이후 피신청인이 동 회사채 편입금액을 낮추었음에도 불구하고 환매의 증가로 신탁재산의 감소 폭이 더 커졌던 점. 개정된 법률 제33조에서는 불가피하게 투자한도를 초과하게 된 경우 적법한 것으로 보고 있는 점에 비추어 동일종목투자한도 초과로 인한 손해배상책임은 없다 할 것임.(2001.4.24. 조정번호 제2001-25호)

가. 사실관계

1999.7.19. 신청인은 ◇◇증권(이하 “피신청인”이라 함) 지점에 신종 MMF에 가입하고, 7.23. 기가입한 신종 MMF를 해지하면서 출금한 1만원으로 위탁계좌와 연결이 가능한 ○○신탁3-1호(이하 “공사채형”이라 함)에 가입하고, 같은 달 28일 신청인은 공사채형에 1억9천만원을 입금하고, 31일 동 상품에 1천만원을 추가적으로 입금함.

1999.8.12. ○○그룹의 유동성 위기로 인한 환매제한조치³⁸¹⁾가 이루어지고, 신청인은 같은 달 19일 공사채형을 해지하면서 ○○채 관련금액의 95%를 지급받음.

나. 당사자의 주장

(1) 신청인의 주장

1999.7.28. 1억 9천만원, 7.31. 1천만원을 피신청인 지점에 각각 입금하면서 MMF에 가입하겠다고 하였으나 직원이 공사채형에 가입하였고, 당시 가입한 상품이 MMF가 맞는지 확인하였을 때 직원은 MMF라고 설명하였음. 이후 1999.8월 ○○사태 발생시 환매를 요청하니 신청인이 가입한 상품이 MMF가 아닌 공사채형으로써 무보증○○채가 33%나 편입되어 있어 원본손실이 발생하였는 바, 이는 직원이 의도적으로 MMF에 가입시키지 아니하고 공사채형으로 가입시켜 손해를 본 것이므로 피신청인은 이에 대한 배상을 하여야 함.

(2) 피신청인의 주장

신청인은 본인이 가입한 공사채형을 직원이 MMF라고 설명하였다고 주장하나, 신청인이 가입한 공사채형은 MMF와 같이 수시 입출금식이면서 환매수수료가 없어 예상수익률이 더 높을 것으로 기대된다고 상담한 결과 신청인의 판단에 의하여 가입한 것이므로 신청인의 주장을 수용할 수 없음. △△신탁운용회사의 주장은 신청인이 가입한 공사채형에 ○○가 발행한 유가증권이 동일종목투자한도인 10%를 초과하여 투자운용된 것은 사실이나 이는 신탁재산이 급격히 감소하고, 1999.8.12.자로 ○○채권 환매가 사실상

381) MMF를 제외한 모든 공사채형은 ○○채의 편입비율에 따라 환매기간별로 투자원금의 50%, 80%, 95%를 지급함.

금지됨으로써 투자비율을 감소시킬 기회가 없음에 따라 불가피한 상황에서 발생한 것임. 한편, 증권투자신탁제도는 실적배당이 기본원칙이며, 이에 따라 ○○채권투자로 인한 손실은 전액 수익자가 부담하여야 함에도 피신청인들이 손실의 95%를 부담하였음. 사실이 이러함에도 동일종목투자한도를 초과하였다 하여 손해배상을 하기는 곤란함.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 신청인의 의사에 반하여 공사채형에 가입되었는지 여부와 피신청인이 고의로 동일종목투자한도를 위반하였는지 여부라 할 것임.

신청인의 의사에 반하여 공사채형에 가입되었는지 여부와 동일종목투자한도 초과の場合 손해배상책임 인정여부에 대하여 살펴보면, 신청인은 피신청인 직원의 말을 신뢰하여 자신이 가입한 공사채형이 MMF인줄 알았다고 주장하나 다음과 같은 점에 비추어 볼 때 신청인의 주장을 인정하기 곤란함.

① 직원은 신청인과 상담결과 신청인의 판단에 의해 공사채형에 가입하였다고 주장함으로써 양당사자의 주장이 상반되고, 신청인의 주장을 인정할 만한 증거가 없는 점.

② 가입당시의 정황에 비추어 보았을 때 신청인은 위탁자계좌와 대체가능한 상품을 원하였고, 당시 피신청인 지점에서 판매한 투자신탁상품중에서 위탁자계좌와 대체가능한 상품은 공사채형인 ○○신탁3-1호 한 상품뿐이어서 신청인은 기존에 가입한 신종 MMF를 해지하고 공사채형에 가입한 것으로 추정되는 점.

③ 신청인이 공사채형에 입금시 입·출금전표에 “○○신탁3-1호”라고 인자되어 있는 바, 신청인은 동 상품이 MMF가 아니라는 사실을 충분히 인지할 수 있었다는 점.

「증권투자신탁업법」 제33조 제1항 제1호 및 「공사채형약관」 제19조 제1항 제1호는 위탁자(△△신탁운용)가 투자신탁재산의 10%를 초과하여 동일종목의 유가증권에 투자하는 행위를 제한하고 있음. 따라서 위 법 및 약관을 위반하여 투자신탁재산을 운용하고 이로 인하여 수익자에게 손해가 발생하였다면 위탁자는 불법행위 내지 계약위반으로 수익자에게 손해를 배상하여야 할 것임. 불법행위에 기한 손해배상 청구를 하거나, 채무불이행으로 인한 손해배상청구를 하기 위하여는 고의 또는 과실로 인한 위법행위가 있고 이로

인하여 손해가 발생하여야 할 것임.

본건의 경우 아래와 같은 점에 비추어 보았을 때 피신청인이 고의 또는 과실 등 유책성 있는 행위로 동일종목투자한도를 위반하여 운용하였다고 보기 어려운 바, 피신청인에게 손해배상책임을 묻기는 곤란하다고 판단됨.

① 본건의 경우 처음부터 ○○회사채 편입비율이 10%를 초과한 것이 아니라 신탁재산이 지속적으로 감소함에 따라 1999.7.24.부터 ○○회사채 편입비율이 10%를 초과하게 된 점.

② 이후 피신청인이 ○○회사채 편입금액을 낮추었음에도 불구하고 환매의 증가로 신탁재산의 감소폭이 더 커졌고, ○○사태의 여파로 ○○회사채 편입비율을 감소시키기가 사실상 불가능하였다는 점.

③ 2000.1.21. 신설된 「증권투자신탁업법」 제33조 제3항에서는 신탁재산의 일부해지 등으로 인하여 불가피하게 투자한도를 초과하게 된 경우에는 그 투자한도에 적합한 것으로 보고 있는 점.

라. 결 론

피신청인이 신청인의 의사에 반하여 공사채형에 가입하였다고 보기 어려우므로 신청인의 손해배상청구는 이유 없다고 할 것임.

1-9 혼합펀드에 대한 위험설명 부족 등 부당권유로 인한 손해배상책임 여부

[기각] 신청인은 펀드 상품에 투자한 경험이 다수 있으며, 신청인은 원금이 보장되지 않는 펀드의 특성에 대하여는 기본적으로 이해하고 있었던 것으로 보이고, 「투자설명서 교부 및 주요내용 설명 확인서」를 보면, 신청인은 “투자설명서를 제공받고 그 주요내용을 설명 들었음”이라고 자필로 기재하고 있으며, 투자목적기재서에는 “원금보장을 고려하나 투자수익율이 더 중요하다”에 체크하였고, 혼합펀드 가입 후에는 담당직원에게 전화를 하여 수익률을 지속적으로 확인한 사실이 인정되므로 신청인의 주장은 이유 없음.(2008.2.12. 조정번호 제2008-4호)

가. 사실관계

신청인은 1995.3.3. ○○증권사(이하 “피신청인”이라 함) 지점에서 계좌를 개설한 이래, 줄곧 채권형 펀드나 MMF에 투자하여 왔으며, 피신청인의 직원 A씨(이하 “담당직원”이라 함)는 2005.1.17.부터 신청인의 관리자가 되었음.

담당직원은 2006년 6월, 9월 및 12월에 신청인에게 C혼합투자신탁1호(이하 “혼합펀드”라 함)에 대한 소개를 하였고, 신청인은 같은 해 12.8. 동 지점을 방문하여 130백만원을 예약입금하여 같은 달 11일 동 펀드에 가입³⁸²⁾하였으며, 가입 당시 신청인은 투자설명서 교부 및 주요내용 설명확인서를 직접 작성하였으며, 투자목적기재서를 작성함에 있어 「위험에 대한 태도항목」에는 “원금보장을 고려하나 투자수익율이 더 중요하다”에, 「투자권유에 대한 의존도항목」에는 “별도요청이 없는 경우에도 투자권유 희망”에 체크하였음.

신청인은 동 펀드가입 기간중 여러차례 담당직원에게 전화하여 수익률을 확인하였으며, 2007.5.29. MMF 보다 혼합펀드의 수익률이 조금 더 높음을 확인하고 지점을 방문하여 66,728,030원을 예약입금하여 같은 달 30일 동 펀드에 추가로 가입하였음. 이후 혼합펀드의 수익률이 하락하여 원금손실이 발생하자, 신청인은 2007.8.21. 환매를 신청하고 같은 달 30일 190,739,201원을 인출하였음.

나. 당사자 주장

(1) 신청인 주장

담당직원은 원금 손해가 없는 상품에만 투자해 왔다는 본인의 투자성향을 알고 있음에도 불구하고 원금에 손실이 발생할 수 있다는 설명 없이 혼합펀드를 판매하였으며, 이후 혼합펀드의 기준가격이 하락하고 있음에도 이를 알리지 않고 추가 판매를 하였고, 보

382) “C혼합투자신탁1호”의 개요는 다음과 같음

- 투자신탁기간 : 364일
- 투자신탁의 특징 : 고수익채권과 이머징마켓 채권에 주로 투자하며, 시장환경 변화에 따라 탄력적으로 자산 배분하는 채권형투자신탁
- 투자대상 : 채권 및 외국채권에 신탁재산의 60%이상 투자(외국채권에 60%이상), 어음 및 외국어음에 신탁재산의 40%이하 투자

유기간 중 펀드의 손실에 대해 본인이 문의하자 3개월이 지나면 원금이 회복될 것이니 믿고 기다리라고 하여 손실을 더욱 확대시켰는바, 피신청인은 담당직원의 위법행위에 따른 신청인의 손해를 배상할 책임이 있음.

(2) 피신청인 주장

신청인은 MMF외에 채권형 펀드에 수차례 투자한 경험이 있는 자로 혼합펀드 가입 당시에도 원금보장을 고려하나 투자수익율이 더 중요하다고 투자목적을 기재하였고, 신청인은 MMF와 혼합펀드의 수익률을 지속적으로 비교한 후 스스로 혼합펀드에 추가 가입을 하였는 바, 펀드 가입시 담당직원의 잘못이 있다고 볼 수 없으며, 수익증권을 판매한 이후에는 판매자가 고객에 대하여 설명의무를 부담하지 않으며, 혼합펀드 가입 후 손실이 발생할 당시 담당직원은 신청인에게 채권시장의 상황이 나빠져 손실이 발생하였으나 장기로 보유하면 수익률이 좋아질 것이라는 관리자로서의 전망을 하였을 뿐이며 원금손해 사실도 분명하게 고지하였는바, 피신청인은 손해를 배상할 책임이 없음.

다. 위원회 판단

◆ 본건의 쟁점은 담당직원이 펀드 판매시 설명의무 등을 위반하였는지 여부와 부당하게 환매보류를 권유하였는지 여부라 할 것임.

(1) 펀드 판매시 설명의무 등 위반 여부

수익증권 판매회사의 임직원이 고객에게 투자신탁상품의 매입을 권유할 때에는 그 투자에 따르는 위험을 포함하여 당해 투자신탁의 특성과 주요 내용을 설명함으로써 고객이 그 정보를 바탕으로 합리적인 투자판단을 할 수 있도록 고객을 보호하여야 할 주의의무가 있고, 이때 고객에게 어느 정도의 설명을 하여야 하는지는 투자 대상인 상품의 특성 및 위험도의 수준, 고객의 투자 경험과 능력 및 기관투자자인지 여부 등을 종합적으로 고려하여야 하며,³⁸³⁾ 판매직원의 권유행위가 수익증권의 매입에 필연적으로 수반되는 위험성에 관한 고객의 올바른 인식 형성을 방해하여 투자 판단을 그르치게 한 경

383) 대법원 2006.5.11. 선고 2003다51057 판결 참조.

우나 고객에게 과대한 위험성을 수반하는 거래를 적극적으로 권유한 경우에 해당되는 때에는 고객에 대한 보호의무를 저버린 위법행위가 됨.³⁸⁴⁾

신청인은 담당직원이 원금에 손실이 발생할 수 있다는 설명을 하지 않아 펀드에 가입하였으며, 이후에도 혼합펀드의 기준가격이 하락하고 있음을 알려주지 않아 추가 가입을 하여 손해가 발생되었다고 주장하나, 다음과 같은 점으로 보아 위 주장은 이유 없음.

① 신청인은 1995년부터 계속 피신청인과 거래를 하면서 MMF 뿐만 아니라 채권형 펀드 상품에 투자한 경험이 다수 있으며, 분쟁조정 신청서에서도 “이윤이 많이 남는 상품을 직원이 권유해도 원금손해를 볼까 봐 15년 동안 항상 안전한 세금우대나 MMF에 거래를 해왔습니다”라고 기술하고 있으며, 신청인과 담당직원에 대하여 2007.10.30. 금감원에서 작성한 문답서를 보면, 신청인은 2006.6월과 9월 혼합펀드의 가입권유를 받았으나 가입하지 않은 이유에 대해 “마이너스가 될 지도 모른다는 생각이 들어서 가입하지 않은 것이었습니다”라고 진술하였으며, 2007.5.29. 신청인과 담당직원 사이의 대화에 대한 녹취록을 보면, MMF에 있는 돈을 모두 혼합펀드로 옮기는게 어떻냐는 담당직원의 질문에 신청인은 불안해서 그럴 수 없다고 대답하고 있는 바, 신청인은 원금이 보장되지 않는 펀드의 특성에 대하여는 기본적으로 이해하고 있었던 것으로 보이는 점.

② 혼합펀드 가입시 작성된 「투자설명서 교부 및 주요내용 설명확인서」를 보면, 신청인은 “투자설명서를 제공받고 그 주요내용을 설명 들었음”이라고 자필로 기재하고 있으며, 「투자목적기재서」에는 “원금보장을 고려하나 투자수익율이 더 중요하다”에 체크하였고, 혼합펀드 가입 후에는 담당직원에게 전화를 하여 수익률을 지속적으로 확인한 사실이 인정되는 반면, 달리 담당직원의 위법행위에 의해 신청인이 동 펀드에 가입하였다고 볼 만한 자료가 없다는 점.

③ 2007.5.29. 신청인과 담당직원 사이의 대화에 대한 녹취록에 따르면, 신청인은 혼합펀드의 수익률이 MMF의 수익률 보다 높음을 확인한 후 먼저 추가로 동 펀드에 가입하겠다는 의사를 표시하였고, 2007.5.22. 혼합펀드의 기준가격이 1,000으로 조정된 후 28일은 998.83을, 29일은 999.04을 기록하고 있어 29일 당시에는 기준가격의 하락세가 시작되

384) 대법원 1998.10.27. 선고 97다47989 판결 참조.

었다고 판단하기는 어려우며, 따라서 담당직원이 혼합펀드에 발생된 위험을 알면서 고지하지 않았다고 보기는 곤란하다는 점.

(2) 부당한 환매보류 권유 여부

2007.7.10. 신청인과 담당직원 사이의 대화에 대한 녹취록을 보면, 담당직원이 신청인에게 “뭐냐면 빠졌다가 다시 올라가요. 그리고 나중에 보면 MMF 이자율보다 이게 높으실 거예요” 또는 “3개월이 지나면 항상 수익률이 높았으니까 당연히 높으니까, 그리고 현재 잘 나오고 있으니까 넣어드리려고 얘기를 했죠. 지금 잘 나오고 있는 상황이었으니까 그때, 그런데 지금은 좀 변동성이 있어서 좀 빠지네요. 근데 또 놔두면 이게 올라요. 그러니까 그렇게 크게 염려하실 필요 없이 가지고 계시면 되요”라는 진술을 한 사실이 있으나, 당시 담당직원이 시장상황과 손실의 발생 원인 및 원금의 손실 가능성 등을 설명하면서 위와 같은 진술을 함께 한 것으로 보아, 이는 부당한 환매보류 권유라기 보다는 혼합펀드의 향후 전망에 대한 단순한 의견 제시에 해당된다고 봄이 타당하다 할 것임.

라. 결론

그렇다면 피신청인은 신청인에 대하여 손해를 배상할 책임이 없다 할 것이므로 신청인의 청구는 이유 없어 이를 기각함.

1-10 인사이트 펀드의 판매시 설명의무 위반 및 사후관리의무 위반 여부

[기각] 펀드 가입시 작성한 「투자설명서 교부 및 주요내용 설명 확인서」의 투자자 확인사항에 “투자설명서를 제공받고 그 주요내용에 대한 설명을 들었음”을 신청인이 자필로 서명한 사실이 인정되고 녹취록상으로도 신청인 주장내용을 확인하기 어려운 점, 또한 펀드의 자산 운용은 운용사의 재량에 따라 결정되는 사항으로 판매사가 투자자산의 향후 구체적인 운용 여부에 관해서까지 설명할 수는 없다 할 것인 점 등에 비추어 신청인의 주장은 이유 없음.(2009.4.14. 조정번호 제2009-34호).

가. 사실관계

신청인은 ○○증권사(이하 “피신청인”이라 함) 지점직원 A씨의 권유로 2007.10.31. “△△△ 인사이트 혼합형 자투자신탁 A, C호”에 각 10백만원과 5백만원을 가입함.³⁸⁵⁾

나. 당사자 주장

(1) 신청인 주장

펀드가입시 담당직원의 설명은 동 펀드가 글로벌투자상품이며 주로 안정적인 채권에 투자하고 상당한 수익을 낼 수 있다는 내용이 전부였고, 직원 자신도 확정된 것이 없으니 잘 모르겠다고 하였으며, 사전에 청약금을 받으면서도 투자설명서를 교부치 않는 등 상품설명이 불충분했으며, 손실이 계속 발생함에도 사후적인 관리가 전혀 없었음.

(2) 피신청인 주장

담당직원은 신청인에게 상품에 관한 충분한 설명을 하였고, 피신청인은 판매사로서, 향후 이루어질 펀드의 구체적인 자산운용과 관련된 부분은 판매사가 결정하거나 알수 있는 사항이 아니며 안정적인 채권에 주로 투자한다고 하는 등 신청인 주장과 같은 설명을 한 사실도 없음.

다. 위원회 판단

◆ 본건의 쟁점은 ① 펀드 판매시 설명의무 위반 여부, ② 판매사의 사후관리의무 위반 여부라 할 것임.

385) “△△△△ 인사이트 펀드”의 개요는 다음과 같음

- 분류, 투자목적 : 혼합형투자신탁으로 투자대상지역과 자산을 사전에 정해놓지 않고 장기적 시장모멘텀을 고려한 적극적인 자산배분전략을 통하여 자본이득을 추구. 투자신탁재산의 최대 100%까지를 국내외 주식, 채권 등 각 투자증권에 투자하여 투자자에게 장기적인 자본증식을 추구
- 주요투자전략 : 모자형투자신탁의 자투자신탁으로써 모투자신탁인 △△△△ 인사이트 혼합형 모투자신탁에 자산의 대부분을 투자, 주식, 채권 등 각 투자증권의 자산배분비율은 0~100%까지 자산운용사의 자산배분전략에 따라 항시적으로 또한 유동적으로 변동
- 적합한 투자자유형 : 투자위험은 5등급 중 2등급으로 높은 수준의 위험을 가지며, 높은 투자수익을 추구하고 높은 수준의 위험을 감내할 수 있는 장기투자자에게 적합

(1) 펀드 판매시 설명의무 위반 여부

증권회사 직원은 고객에게 상품을 판매하는 경우 투자에 따른 위험을 포함하여 당해 상품의 특성과 주요 내용을 설명함으로써 고객이 그 정보를 바탕으로 합리적인 투자 판단을 할 수 있도록 고객을 보호하여야 할 주의의무가 있다 할 것이나, 고객에게 어느 정도의 설명을 하여야 하는지는 투자대상인 상품의 특성 및 위험도, 고객의 능력과 투자경험 및 기관투자자 여부 등을 종합적으로 고려하여야 함.³⁸⁶⁾

신청인은 펀드가입시 담당직원이 상품설명을 불충분하게 하였다고 주장하나, 다음과 같은 점에 비추어 신청인의 주장은 이유 없다 할 것임.

신청인이 2007.10.29.과 같은 해 10.31. 동 펀드에 가입하면서 작성한 것으로 보여지는 「투자설명서 교부 및 주요내용 설명 확인서」의 투자자 확인 사항에 “투자설명서를 제공받고 그 주요내용에 대한 설명을 들었음”을 신청인이 자필로 서명한 사실이 인정되고, 신청인과 피신청인측 관련직원과의 통화내용을 정리한 녹취록(2007.10.23.)상으로도 관련 직원은 “인사이트 펀드라고 지역하고 기초자산에 관계없이, 제한 없이 막 투자할 수 있는 상품이 하나 나왔어요. 굉장히 공격적인 상품인데,”라고 진술하고 있음을 볼 때, 신청인 주장과 같이 동 펀드가 주로 안정적인 채권에 투자한다고 설명하였거나 동 펀드의 자산운용에 대해 부당한 설명을 한 사실을 인정하기 어려운 점이 있음.

또한 펀드의 자산운용은 운용사의 재량에 따라 결정되는 사항으로, 판매사가 투자자산의 향후 구체적인 운용여부에 관하여까지 설명할 수는 없다 할 것임.

(2) 사후관리의무 위반여부

수익증권을 판매하는 증권회사는 고객에게 거래에 수반하는 위험성에 관하여 충분한 설명의무를 부담하나 이러한 고객보호의무는 고객의 수익을 보장하기 위한 것이 아니며, 투자고객으로서는 증권회사가 제공하는 정보에 기하여 그 위험을 정확히 이해하고 그 위험이 현실화 되었을 때에 이를 감당할 수 있는 지를 스스로 판단한 후에 거래를 하여야 하고, 그 결과에 대하여 책임을 져야하는 것이 원칙으로 판매회사는 투자상품에 관하여 상담을 해주고 이를 판매하는 회사일 뿐이고, 달리 특별한 사정이 없는 한 손실발생

386) 대법원 2006.5.11. 선고 2003다51057 판결 참조.

의 우려가 있다고 해서 중도상환을 권유해야 할 부수적 의무까지는 부담한다고 보기 어려움.³⁸⁷⁾

한편, 피신청인측이 증거자료로 제출한 “자산운용보고서 수령지 정보현황”에 의하면 피신청인은 2007.10.30.과 같은 달 31일 이후 전자우편에 의하여 신청인에게 자산운용보고서를 송부한 사실이 인정되며, 피신청인은 판매회사로서 달리 신청인의 재산관리나 투자대행 등을 위임받은 사실이 없으므로, 특별한 사정이 없는 한 피신청인이 신청인 재산을 사후관리할 주의의무가 있다고 보기 어려움.

라. 결론

피신청인은 신청인에 대하여 손해를 배상할 책임이 없다 할 것이므로 신청인의 청구는 이유 없어 이를 기각함.

387) 대구지방법원 2007.5.8. 선고 2006가합8478 판결.

제3절 부동산펀드

1-11 다년간 펀드투자 경력이 있는 고객에 대한 설명의무 위반 여부

[기각] 신청인은 여러 펀드에 투자한 경험이 약 16년에 이르며, 1년 이상 펀드에 투자하거나 대우채 펀드와 관련하여 손실을 본 경험도 있는 점, 계좌개설신청서와 투자설명서 교부 및 주요내용확인서가 작성되어 있으며, 신청인이 기업을 경영하는 사실, 과거 펀드 투자경험 등에 비추어 볼 때 투자설명서의 기재사항이 담당직원에 의하여 작성되거나 사후에 보완된 사정만으로 담당직원의 펀드가입권유가 신청인에 대한 보호의무를 위반한 것으로 보기 어렵다고 할것임.(2008.7.15. 조정번호 제2008-56호)

가. 사실관계

신청인은 A기업 대표이사로서 1992.8.3. ○○증권(이하 “피신청인”이라 함) 지점에서 최초로 펀드계좌를 개설한 이래 개인 및 법인 명의로 주식형펀드, 해외펀드 등 다양한 펀드에 투자하여 왔으며, 한편 신청인은 이 사건 펀드와 동일, 유사한 펀드와 관련하여 서도 투자경험³⁸⁸⁾이 있음.

피신청인의 직원 B씨(이하 “담당직원”이라 함)은 1999년부터 신청인의 관리자가 되었으며, 2006.11.15. 신청인 및 신청인의 직원 갑 및 담당직원은 신청인의 A기업 공장 매각과 관련하여 공인중개사사무실에서 만나 담당직원의 권유로 동 매각대금을 △△△인컴 혼합투자신탁1호³⁸⁹⁾(이하 “혼합펀드”라고 함)에 가입하기로 하고 다음 날인 16일에 6억원, 2007.2.7.에 2,403,048,074원을 법인명의계좌로 예약 입금함.

한편, 신청인은 2007.3.19. 및 5.7.에 각각 295,857,989원씩을 △△△글로벌리츠재간접투

388) 2005.9.12. 이머징고정수익펀드, 2006.5.4. 글로벌부동산증권펀드 등 4건

389) “△△△인컴혼합투자신탁1호”의 개요는 다음과 같음.

- 고수익채권과 이머징마켓채권에 주로 투자하며, 시장환경 변화에 따라 탄력적으로 자산 배분하는 채권형 투자신탁
- 투자대상 : 채권 및 외국채권에 신탁재산의 60%이상 투자(외국채권에 60%이상), 어음 및 외국어음에 신탁재산의 40%이하 투자(환매수수료 : 90일미만은 이익금의 70%)

자신탁 1호³⁹⁰⁾(이하 “리츠펀드”라고 함)에 개인명의 계좌로 예약입금하여 펀드에 가입하였으며, 같은 해 11.19. 담당직원에게 계좌 평가금액을 문의하는 과정에서 손실발생사실을 인지하고 12.24 및 12.28. 혼합펀드에서 총 2,989,041,795원을 예약 출금함.

나. 당사자의 주장

(1) 신청인의 주장

필요시 언제든지 인출이 가능하도록 3~6개월 단위로 적립하되, 원금손실이 없고 안정위주로 자금을 운용하도록 요청하였음에도 불구하고 담당직원은 원금손실 여부, 수익 및 손실구조 등 펀드의 특성과 위험성에 대한 설명 없이 펀드를 판매하였고, 이후 펀드의 기준가격 하락에도 불구하고 이를 알리지 아니하여 환매기회를 상실하여 손실이 확대되었는 바, 피신청인은 담당직원의 위법행위에 따른 신청인의 손해를 배상할 책임이 있음.

(2) 피신청인의 주장

신청인의 펀드투자경험은 16년 이상으로 개인 및 법인 명의로 수차례 주식형펀드, 해외펀드에 투자한 경험이 있으며, 혼합펀드의 경우 신청인이 이미 과거에 가입한 이머징마켓펀드, 해외펀드, 미국 고수익펀드를 합성한 것과 유사할 뿐만 아니라 신청인이 2006.5.22. 개인 명의로 동 펀드에 가입시 충분한 설명을 하였고 리츠펀드의 경우, 신청인이 기 가입한 글로벌부동산증권펀드와 유사함을 설명하는 등 원금손실 여부나 펀드의 특성과 위험성에 대하여 충분히 설명하였으므로 피신청인은 손해를 배상할 책임이 없음.

다. 위원회의 판단

390) △△△글로벌리츠재간접투자신탁 1호의 개요

- 글로벌리츠 및 부동산관련 주식등에 주로 투자하며 지역별, 섹터별 자산배분을 통하여 이자소득과 자본차익을 포함하는 토털리턴을 추구
- 투자대상 : 신탁재산의 70%이상을 글로벌리츠 및 부동산관련 주식 등에 투자(공모주를 포함하며 리츠에는 50%이상 투자)
- 선취수수료 : 납입금액의 1.4%

◆ 본건의 쟁점은 담당직원의 펀드 판매시 설명의무 등을 위반한 부당권유가 있었는지 여부와 손실발생사실을 통보하지 아니한 관리자로서의 고객보호의무 위반 여부라 할 것임.

(1) 펀드 판매시 설명의무등 위반 여부

수익증권 판매회사의 임직원이 고객에게 투자신탁상품의 매입을 권유할 때에는 그 투자에 따르는 위험을 포함하여 당해 투자신탁의 특성과 주요 내용을 설명함으로써 고객이 그 정보를 바탕으로 합리적인 투자판단을 할 수 있도록 고객을 보호하여야 할 주의의무가 있고, 이때 고객에게 어느 정도의 설명을 하여야 하는지는 투자 대상인 상품의 특성 및 위험도의 수준, 고객의 투자 경험과 능력 및 기관투자자인지 여부 등을 종합적으로 고려하여야 하며,³⁹¹⁾ 판매직원의 권유행위가 수익증권의 매입에 필연적으로 수반되는 위험성에 관한 고객의 올바른 인식 형성을 방해하여 투자 판단을 그르치게 한 경우나 고객에게 과대한 위험성을 수반하는 거래를 적극적으로 권유한 경우에 해당되는 때에는 고객에 대한 보호의무를 저버린 위법행위가 됨.³⁹²⁾

신청인은 담당직원이 원금손실 등 펀드의 위험성과 특성에 대한 충분한 설명을 하지 않아 펀드에 가입하였으므로 손해가 발생하였다고 주장하나 다음과 같은 점으로 보아 신청인의 위 주장은 이유 없음.

① 신청인은 1992.8.3. 최초 펀드 가입이후 주식형 펀드나 해외펀드 등 여러 펀드에 투자한 경험이 약 16년에 이르며, 1년 이상 펀드에 투자하거나 대우채 펀드 관련 “초단기 209펀드” 투자로 손실을 본 경험도 있는 점.

② 「간접투자자산운용업감독규정」 제52조에 의하면 판매회사는 간접투자자가 이미 취득한 간접투자증권과 동일한 간접투자증권을 추가로 취득하는 경우 투자설명서의 제공 및 설명을 생략할 수 있도록 규정하고 있으며, 신청인은 과거 이 사건 펀드와 동일 유사한 펀드에 가입한 경험까지 있는 점.

③ 계좌개설신청서와 투자설명서 교부 및 주요내용확인서가 작성되어 있으며, 신청인의 사회적 지위, 기업을 경영하는 사실, 과거 펀드 투자경험 등에 비추어 투자설명서의

391) 대법원 2006.5.11. 선고 2003다51057 판결 참조.

392) 대법원 1998.10.27. 선고 97다47989 판결 참조.

기재사항이 담당직원에 의하여 작성되거나 사후에 보완된 사정만으로 담당직원의 펀드 가입권유가 신청인에 대한 보호의무를 위반한 것으로 보기 어려운 점.

(2) 손실발생사실 통지 등 고객보호의무 위반 여부

수익증권을 판매하는 증권회사는 고객에게 거래에 수반하는 위험성에 관하여 충분한 설명의무를 부담하나 중도상환을 권유해야 할 부수적 의무까지는 부담한다고 보기는 어렵고, 투자고객으로서는 증권회사가 제공하는 정보에 기하여 그 위험을 정확히 이해하고 그 위험이 현실화 되었을 때에 이를 감당할 수 있는 지를 스스로 판단한 후에 거래를 하여야 하고 그 결과에 대하여 책임을 져야하는 것이 원칙임.³⁹³⁾

현행 「간접투자자산운용법」상으로도 자산운용사에 의한 자산운용보고서 제공의무 이외에 판매회사에게 손익내용의 안내 등을 의무화하고 있지 아니한 점, 신청인이 계좌개설신청서상 자산운용보고서 수신여부에 “아니오”라고 체크하고 있는 점에 비추어 피신청인이 손실발생 사실 통지 등 고객보호의무를 위반하였다고 보기 어려움.

라. 결 론

그렇다면 피신청인은 신청인에 대하여 손해를 배상할 책임이 없다 할 것이므로 신청인의 청구는 이유 없어 이를 기각함.

1-12 부동산펀드의 부당 권유 등으로 인한 손해배상책임 여부

[일부인용] 담당직원이 신탁재산의 운용방법이나, 위험성 등에 관하여 구체적으로 설명하지 아니하고 가입을 권유하고 있는 점, 담당직원 또한 투자자의 성향을 투자수익률을 고려하나 원금보장을 더 중요하다고 여기는 보수적 투자자로 파악하고 있는 점 등을 고려하면 신청인에게 원본손실 가능성 및 위험성에 대해 구체적으로 설명하지 아니하고 수익증권 매입을 권유한 것으로 고객보호의무를 위반하였다고 할 것임.(2008.9.9. 조정번호 제2008-67호).

393) 대구지방법원 2007.5.8. 선고 2006가합8478 판결 참조.

가. 사실관계

신청인은 주로 채권형펀드에 투자하던 자로, 2007.2.5. 유선으로 ○○증권사(이하 “피신청인”이라 함)의 직원 A씨(이하 “담당직원”이라 함)에게 기존에 가입한 “△△△△ 재간접 1호” 펀드의 환매를 요청하였으며, 신청인의 환매요청을 받은 담당직원은 신청인에게 환매자금으로 해외 부동산펀드에 가입할 것을 권유하였고, 같은 달 16일 유선으로 신청인의 펀드 가입의사를 확인하고 “◇◇◇ Global 재간접 1호”에 46,009,617원을 가입함³⁹⁴⁾.

펀드가입이 유선으로 이루어진 연유로, 신청인은 같은 달 23일 지점을 방문하여 투자설명서 등 미비서류의 작성을 완료하였고, 당시 담당자가 연수중인 관계로 동 업무처리 는 피신청인의 직원 B씨가 처리하였으며, 같은 해 3.5. 이후 담당자의 인사발령으로 관리자가 피신청인의 직원 C씨로 변경됨.

신청인은 같은 2007.7.11.경 동 지점을 방문하여 원금손실에 대해 항의한 바 있으며, 같은 해 12.12. 20백만원, 12.20. 나머지 전액을 환매청구하여 총 36,974,086원을 인출함.

나. 당사자 주장

(1) 신청인 주장

담당직원은 펀드판매 권유시 펀드의 명칭이나 투자대상, 신탁재산의 운용방법 등 펀드의 특성과 원본손실 가능성 및 위험성에 대한 설명 없이 펀드를 판매하였고, 신청인의 환매요청시 부당하게 환매보류를 권유하여 손실이 더욱 확대되었는 바, 피신청인은 담당

394) “◇◇◇ Global 재간접 1호”의 내용은 다음과 같음.

- 투자목적: 투자신탁재산의 50%이상을 해외상장 또는 상장예정 부동산관련 간접투자증권 및 Reits 등에 투자하여 안정적인 배당수익을 바탕으로 부동산 가격 상승에 따른 자본이득 추구
- 상품특징: 장기적으로 안정적인 성장이 예상되는 글로벌 부동산시장에 투자하는 펀드로 전세계 Reits 및 부동산투자신탁을 주된 투자대상으로 함
- 투자위험: 세계 부동산경기 및 수급상황, 해외금리변동 등 해외 경제상황의 변화에 따라 변동되는 위험 및 환율변동 등에 따라 손실이 발생할 수 있음
- 적합한 투자자유형: 투자위험은 5등급중 3등급으로 중간수준이며, 원금손실위험을 감수하면서 안정적인 배당수익 및 자본차익을 목표로 해외부동산 투자를 원하는 비교적 장기투자자에게 적합한 상품
- 환매수수료: 180일 미만 환매시 이익금의 70%(전액 신탁재산에 편입)

직원의 위법행위에 따른 신청인의 손해를 배상할 책임이 있음.

(2) 피신청인 주장

신청인은 1999.12.16. 이후 수익증권거래를 계속하여 왔던 고객으로, 담당직원은 펀드 가입권유시 펀드의 주요특성에 대해 충분한 설명을 하였고, 투자자의 환매요청시 계속 보유토록 권유한 것은 시장분석 등을 통한 향후 전망에 대해 의견을 제시한 것으로, 환매보류는 신청인이 잔고확인 등을 통하여 평가금액을 충분히 인지한 가운데 본인의 판단 하에 이루어진 것이라 할 것이므로 신청인의 손해를 배상할 책임이 없음.

다. 위원회 판단

◆ 본건의 쟁점은 담당직원이 펀드 판매시 설명의무 등을 위반하였는지 여부와 부당하게 환매보류를 권유하였는지 여부라 할 것임.

(1) 펀드 판매시 설명의무 위반 등 부당권유 여부

「간접투자자산운용업법」은 판매회사가 투자자에게 간접투자증권의 취득을 권유함에 있어 투자설명서를 제공하고 그 주요내용을 설명하여야 하며(동법 제56조 제2항), 투자자에게 실적배당 및 원본의 손실가능성 등 간접투자의 특성과 투자위험에 관한 신탁약관 또는 투자회사의 정관 및 투자설명서의 주요내용을 충분하고 정확하게 알려야 한다(동법 시행령 제55조 제1항 제3호)고 규정하고 있음.

판례에 의하면, 수익증권 판매회사의 임직원이 고객에게 투자신탁상품의 매입을 권유할 때에는 그 투자에 따르는 위험을 포함하여 당해 투자신탁의 특성과 주요 내용을 설명함으로써 고객이 그 정보를 바탕으로 합리적인 투자판단을 할 수 있도록 고객을 보호하여야 할 주의의무가 있고, 이때 고객에게 어느 정도의 설명을 하여야 하는지는 투자대상인 상품의 특성 및 위험도의 수준, 고객의 투자 경험과 능력 및 기관투자자인지 여부 등을 종합적으로 고려하여야 함.³⁹⁵⁾

다음과 같은 점에 비추어 볼 때, 담당직원은 펀드판매시 신청인에게 신탁재산의 운용

395) 대법원 2006.5.11. 선고 2003다51057 판결 참조.

대상, 방법 등 상품의 특성, 원본손실 가능성 및 위험성에 대해 구체적으로 설명하지 아니하고 수익증권 매입을 권유한 것으로 고객보호의무를 위반한 것이라 할 것임.

① 피신청인이 금감원에 제출한 2007.2.5., 2.16.자 녹취록을 보면, 담당직원은 2007.2.5. 기존 펀드의 환매를 요청하는 신청인에게 동 자금으로 부동산 펀드에 가입할 것을 권유할 때에는 물론, 같은 달 16일 펀드가입처리를 할 때도, 펀드의 명칭, 신탁재산의 운용방법이나, 환매수수료, 위험성 등에 관하여 구체적으로 설명하지 아니하고, 단순히 해외펀드, 부동산펀드라고만 언급하며 부동산펀드의 수익률만을 강조하면서(작년 수익률 30%, 예상수익률 10% 이상) 가입을 권유하고 있는 점.

② 신청인이 같은 달 23일 동 지점에 방문하여 투자설명서 등 미비서류를 작성할 당시 업무를 담당했던 피신청인의 직원 B씨는 경위서상 “본인은 당시 신입사원이었으며, 간접투자상품 판매교육수료 전이었기 때문에 업무처리 이외에 상품에 대한 어떠한 언급도 하지 않았고”라고 진술하고 있는 점으로 볼 때, 투자설명서 교부시에도 주요내용에 대한 설명이 있었다고 보기 어려운 점.

③ 동 펀드는 투자위험이 3등급³⁹⁶⁾으로 원금손실 위험을 감수하면서 안정적인 배당수익 및 자본차익을 목표로 해외 부동산 투자를 원하는 비교적 장기투자자에게 적합한 것으로 분류되고 있음에 반하여, 신청인은 주로 채권형펀드 위주로 투자하여 왔으며, 문답서에 의하면 담당직원 또한 투자자를 투자수익률을 고려하나 원금보장을 더 중요하다고 여기는 보수적 투자자로 성향을 파악하고 있는 점.

(2) 부당한 환매보류 권유 여부

신청인 통장 사본에 “8.20.이후 환매가능”이라는 문구가 기재되어 있으나, 2007.9.17.자 담당직원 경위서에 의하면, 2007.4.10~6.7.중에는 기준가가 양호한 수준이었고, 7.11. 당시 평가금액도 43,660,614원으로 원본손실금이 크지 않았으며, 동 펀드는 180일미만 환매시 이익금의 70%가 환매수수료로 부과되는 점에서 담당직원 등은 환매수수료 면제시점인 8.20.까지 시장추이를 보고 지켜보자고 권유하였다고 진술하고 있고, 9.13.자 녹취록에

396) 3등급(중간위험)은 신탁재산을 주식, 통화, 파생상품, 투자적격 이외의 채권 등과 같은 신용위험 및 시장위험이 높은 투자대상을 포함하고 있음.

의하면, 신청인이 원본손실을 항의하자, 피신청인의 직원 C씨는 “그래서 제가 그때 말씀 드렸잖아요. 이미 손실이 지금 나있는 상황인데 아직 만기가 되지 않은 상황이니깐. 그때까지 한번 기다려 보시는게 어떠시냐고 제가 그때 말씀을 드렸잖아요. 그러니까 만기가 되기 전에 그때 오셔가지고, 이미 만기가 되기 전에 손실이 나있으신 상태였는데, 그때 제가 그래서 지금 상황이 마이너스가 이미 돼 있는데, 지금 이게 만기는 8월이라, 그래서 지금 이미 손실이 나있는 상태다 보니까 어차피 손실이 난 상태로 찾아가실 수는 없으니깐, 일단은 만기까지 한번 뒤보시고 그때 가서가지고 다시 또 올라갈수도 있는 거니까 한번 좀 두고 보시자고 그때 그냥 그렇게 제가 말씀을 드렸었죠.”라고 진술하고 있고, 한편 신청인은 2007.4.30., 7.4., 7.11., 8.28., 11.8. 내점하여 평가금액을 확인하고 있고, 9.13. 환매신청 하였다가 이를 취소한 사실도 있으며, 환매기일도 12.12., 12.20.로 원본손실을 인지한 시점이나 통장에 기재된 8.20.보다 상당기간 경과한 시점인 점 등에 비추어, 당시 담당직원은 시장상황 등을 고려하여 환매보류를 권유한 것으로 보이며, 환매보류는 신청인이 평가금액을 충분히 인지한 가운데 본인의 판단 하에 이루어진 것이라 보이므로 이는 부당한 환매보류 권유라기보다는 펀드의 향후 전망에 대한 의견 제시에 해당된다고 봄이 타당하다 할 것임.

(3) 손해배상액 산정

신청인의 손해금액은 계좌개설시 입금액 46,009,617원에서 출금액 36,974,086원을 차감한 금액 9,035,531원이라 할 것임. 한편, 피신청인 담당직원이 펀드판매시 동 펀드에 대해 충분하고 명확한 설명은 하지 않은 것으로 보이나, 다음과 같은 점을 고려하여 신청인의 과실비율을 산정함이 타당한 것으로 보임.

① 신청인이 종래 펀드에 투자한 경험이 있는 점.

② 담당직원의 펀드에 대한 설명이 구체적이고 명확하지 않은 점은 있으나, 담당직원은 동 펀드가 해외부동산 펀드이고 확정이율로 수익률이 지급되는 것은 아니라고 언급하고 있는 점.

③ 신청인 또한 수차례 지점에 내방하여 평가금액을 확인하였고, 평가금액을 인지하고 있는 상태에서 신청인의 판단하에 환매보류가 이루어졌다는 점에 비추어, 손해의 확대에

신청인이 상당부분 기여하고 있다고 볼 수 있는 점.

④ 본질적으로 투자자는 자신의 판단과 책임으로 투자하여 투자손실을 스스로 부담함이 원칙으로 적어도 담당직원에게 동 펀드의 특성 및 위험성을 확인하거나, 투자설명서를 충분히 검토하는 등 자기재산관리를 하여야 함에도 불구하고 이를 소홀히 한 점 등의 책임을 물어 60% 과실상계를 함이 타당하다고 보임.

라. 결론

피신청인은 신청인에게 손해금액 9,035,531원에서 신청인의 과실 60%를 상계한 나머지 금액 3,614,212원을 배상할 책임이 있어 이를 인용하고, 신청인의 나머지 청구는 이유 없어 기각함.

1-13 고령자에게 위험성 높은 펀드의 특성에 대한 설명 없이 가입시킨 경우

[일부인용] 각 펀드의 가입당시 전화통화 내용 등을 종합할 때 담당직원이 본건 펀드를 임의 가입 한 것으로 보기는 어렵다 할 것임. 그러나 고령(1919년생)의 여성이자 사회적 경험이 많지 않은 신청인(가정주부)에게 고도의 위험성을 수반하는 파생상품에 투자할 것을 권유하였고, 상품의 구조 및 특성에 대한 설명 없이 만연히 전화가입신청 처리한 점 등에 비추어 본건 상품의 구조, 위험성 등에 대해 충분히 설명하였다고 보기 어려움.(2010.1.12. 조정번호 제2010-2호)

가. 사실관계

① 신청인은 2007.6.20. ○○증권(이하 “피신청인”이라 함) 지점에서 A씨(신청인의 조카) 명의로 1억원, 6.25. B씨(신청인의 손자) 명의로 99,998,501원을 “△△특별자산투자신탁 제1호”³⁹⁷⁾펀드에 가입함. 피신청인 담당직원은 6.18. 09:18경에 신청인과 위 펀드가입

397) “△△특별자산투자신탁 제1호”의 개요는 다음과 같음.

- 신탁계약기간 : 2년 9개월(조기상환가능)
- 분류 : 특별자산투자기구, 폐쇄형

관련 통화 후 A씨 명의로 전화가입신청 처리하고 「투자설명서」는 당일 16:25 등기우편으로 송부함. 신청인은 6.21.에 피신청인 지점에 내점하여 B씨 명의로 다시 위 펀드에 99,998,501원 가입신청을 하였는데, 「투자설명서 교부 및 주요내용 설명확인서」는 담당직원이 대신 작성함.

② 신청인은 2008.5.9. 본인 명의로 3천만원, A씨 명의로 9천만원을 “◇◇파생상품투자신탁 제1호”³⁹⁸⁾ 펀드에 가입함. 담당직원은 당일 13:21경 신청인과 위 펀드가입 관련 통화 후 신청인 및 A씨 명의로 전화가입신청 처리하고 「투자설명서」는 당일 15:13 등기우편으로 송부함. 담당직원은 위 통화 직전인 13:10경 신청인에게 전화하여 2007.5.4. 신청인 명의로 3천만원 및 A씨 명의로 9천만원을 투자한 “▽▽부동산투자신탁 제1호”의 만기상환금 수령에 관한 안내를 하였는데, 그 직후 다시 전화하여 위 상환금을 그대로 새로운 상품에 투자할 것을 권유한 것임. 신청인은 위 통화 및 가입신청처리 후인 14:00경 피신청인 지점에 내점한 사실이 있음.

③ 신청인은 2008.6.12. A씨 명의로 43,781,805원, B씨 명의로 43,838,413원을 “△△ 파생상품투자신탁 제2호”³⁹⁹⁾ 펀드에 가입함. 담당직원은 전일 10:18경 신청인과 위 펀드가

○ 투자신탁의 특징

- 투자대상 : ○○동에 공동주택 건설사업을 추진하는 시행사인 C기업에 대한 PF대출채권에 투자 (시공사 D건설)
- 이익분배 : 설정일로부터 매 6개월 단위로 연 7.2%수준에서 지급 예정
(시행사가 대출금의 전부 또는 일부를 만기이전 조기상환할 경우 수익자에게 투자금의 전부 또는 일부의 상환이 이루어질 수 있음)
- 투자위험 : 부동산관련 사업투자에 내재되어 있는 위험에 연동

398) “◇◇파생상품투자신탁 제1호”의 개요는 다음과 같음.

- 기초자산 : KOSPI200 / NIKKEI225
- 투자기간 : 1년 (매 4개월마다 조기상환기회 부여)
- 자동상환조건 : 매 4개월 평가일 기초자산 지수가 모두 기준지수의 95%(4개월째), 90%(8개월째), 85%(만기) 이상인 경우 연 14%의 수익률로 상환
- 원금손실조건 : 투자기간중 기초자산중 하나라도 기준지수의 65% 미만으로 하락한 적이 있는 경우(낮은 수익률 기준으로 상환)

399) “△△파생상품투자신탁 제2호”의 개요는 다음과 같음.

- 기초자산, 투자기간, 원금손실조건은 위 ◇◇파생상품투자신탁 제1호와 같음
- 자동상환조건 : 매 4개월 평가일 기초자산 지수가 모두 기준지수의 100%(4개월째), 95%(8개월째),

입 관련 통화 후 A씨 및 B씨 명의로 전화가입신청 처리하고 「투자설명서」는 당일 등기 우편으로 송부함. 신청인은 위 통화 및 가입신청처리 후 피신청인 지점에 내점하여 도장을 제출함.

④ 2008.10.14. 담당직원이 위 “◇◇파생상품투자신탁 제1호” 및 “△△파생상품투자신탁 제2호”의 기초지수인 일본지수(NIKKEI225)가 35% 초과 하락하여 원금손실조건이 달성되었음을 신청인에게 전화로 통보함. 위 각 펀드의 자산운용보고서는 모두 분기별로 신청인에게 송부됨.

나. 당사자의 주장

(1) 신청인의 주장

담당직원이 신청인의 승낙 없이 위 펀드들을 전화가입신청으로 임의가입 하였음. 설령 위 펀드들이 적법하게 가입처리 되었다 하더라도 고도의 위험성이 있는 파생상품을 권유하면서 상품구조 및 원금손실가능성 등 주요내용에 관하여 정확한 설명을 하지 않았으므로 이로 인해 발생한 손해를 피신청인이 배상하여야 함.

(2) 피신청인의 주장

신청인은 이미 부동산펀드 및 파생상품펀드에 가입한 경험이 있어 위 부동산펀드 및 파생상품펀드 판매시 전화로 가입신청을 받아 처리한 것으로서, 그 후 지점에 내점한 신청인에게 직접 해당 펀드에 대해 충분한 설명을 하였기 때문에 손해배상 책임이 없음.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 피신청인 담당직원의 펀드 임의가입 및 고객보호의무 위반 여부와 그에 따른 구체적인 손해배상액 산정이라 할 것임.

(1) 펀드 임의가입 여부

신청인은 위 각 펀드가 담당직원에 의해 임의로 가입처리 되었다는 취지로 주장하나,

90%(반기) 이상인 경우 연 14.01%의 수익률로 상환

위 각 펀드의 가입당시 신청인과 담당직원의 전화통화 내용들을 종합할 때 위 각 펀드들이 신청인의 의사에 반하여 임의가입 되었다고 보기는 어렵다 할 것임.

신청인은 전화통화 내용 중 “그걸 거기다 도로 집어넣으세요.”의 의미는 “새로운 상품에 투자하지 말고 CMA 통장에 그대로 놔두라”는 의미였으며, 당일 지점에 내점하여 도장을 제출한 사실은 인정하나 위 펀드에 가입할 의사는 아니었다는 취지로 주장하고 있는 바, “그걸 거기다 도로 집어넣으세요.” 자체를 문리적으로 해석하면 신청인의 주장이 타당하다 할 것이나, 대화내용 전체를 종합하면 “펀드 상환금을 신청인에게 교부하지 말고 담당직원이 권유한 새로운 상품(△△과생상품투자신탁 제2호)에 다시 투자하라”는 취지로 해석하는 것 또한 가능하므로, 신청인이 담당직원의 오해 내지 착오를 유발한 소지가 있다 할 것이어서 결국 담당직원이 신청인의 의사에 반하여 위 펀드를 임의가입 한 것으로 보기는 어려움.

(2) 고객보호의무 위반 여부⁴⁰⁰⁾

대법원 판례에 의하면, 투자신탁회사의 임직원이 고객에게 투자신탁상품의 매입을 권유할 때에는 그 투자에 따르는 위험을 포함하여 당해 투자신탁의 특성과 주요 내용을 설명함으로써 고객이 그 정보를 바탕으로 합리적인 투자판단을 할 수 있도록 고객을 보호하여야 할 주의의무가 있고,⁴⁰¹⁾ 증권회사의 임직원이 고객에게 적극적으로 투자를 권유하였으나 투자 결과 손실을 본 경우에 투자가에 대한 불법행위책임이 성립되기 위하여는, 이익보장 여부에 대한 적극적 기망행위의 존재까지 요구하는 것은 아니라 하더라도, 적어도 거래경위와 거래방법, 고객의 투자상황(재산상태, 연령, 사회적 경험 정도 등), 거래의 위험도 및 이에 관한 설명의 정도 등을 종합적으로 고려한 후, 당해 권유행위가 경험이 부족한 일반 투자가에게 거래행위에 필연적으로 수반되는 위험성에 관한 올바른 인식형성을 방해하거나 또는 고객의 투자상황에 비추어 과대한 위험성을 수반하는 거래를 적극적으로 권유한 경우에 해당하여, 결국 고객에 대한 보호의무를 저버려 위

400) “△△특별자산투자신탁 제1호”는 만기(2010.3.)가 도래하지 않아 그 손익 여부가 확정되지 않은 상태로서 금전적 손해배상 여부 판단의 전제조건인 “손해액”을 특정할 수 없으므로, 이하에서는 판단대상에서 제외함.

401) 대법원 2006.5.11. 선고 2003다51057 판결 참조.

법성을 띤 행위인 것으로 평가될 수 있는 경우라야 한다⁴⁰²⁾고 판시함.

그러나 본건에 있어서는 아래와 같은 점들을 종합할 때 담당직원이 위 “◇◇파생상품 투자신탁 제1호” 및 “△△파생상품투자신탁 제2호” 펀드 판매시 판례에서 적시하고 있는 고객보호의무를 다 하였다고 보기 어렵다 할 것임.

① 먼저 “◇◇파생상품투자신탁 제1호” 판매과정을 살펴보면, 담당직원은 위 상품의 가입을 권유한 2008.5.9. 13:21경 통화 직전인 13:10경 신청인에게 전화하여 2007.5.4. 신청인 명의로 3천만원 및 A씨 명의로 9천만원을 투자한 “◇◇부동산투자신탁 제1호”의 만기상환금 수령에 관한 안내를 하였는데, 그 직후인 13:21경 다시 전화하여 “오늘 새로 나온 걸로 가입을 하려면 1시 반까지 해야 한다”는 식으로 고령(1919년생)의 여성이자 사회적 경험이 많지 않은(가정주부) 신청인에게 별다른 설명도 없이 고도의 위험성을 수반하는 파생상품인 “◇◇파생상품투자신탁 제1호”에 위 만기상환금을 그대로 재투자할 것을 권유하였고, 또한 상품의 구조, 특성 및 위험성에 대한 아무런 설명을 하지 않은 채 신청인의 가입의사만을 확인한 후 만연히 전화가입신청 처리하고 투자설명서는 그 이후인 당일 15:13 등기우편으로 송부하였음.

이에 대하여 담당직원은 위 펀드 청약마감시간이 임박하자 전화로 가입동의를 받아 일단 청약을 해놓고 14:00경 내점한 신청인에게 “우리나라 및 일본 주가가 35% 이상 빠지지 않으면 연 14% 수익을 지급하는 펀드”라고 설명하였다고 주장하나, 신청인은 담당직원으로부터 위와 같은 설명을 들은 사실을 부인하고 있을 뿐만 아니라, 만일 담당직원의 주장대로 설명이 이루어졌다고 가정하더라도 복잡한 구조의 파생상품 판매에 있어 그 정도의 설명으로 충분한 설명이 이루어졌다고 보기 어려운 점은 마찬가지라 할 것임.

② 다음으로 “△△파생상품투자신탁 제2호” 판매과정을 살펴보면, 위 상품의 가입을 권유한 2008.6.11. 10:18경 통화 당시 “국내주식하고 일본주식하고 35% 이상만 빠지지 않으면 연 14% 정도 나오는 상품”이라는 정도의 설명만을 한 상태에서 고령의 여성으로서 사회적 경험이 많지 않은 신청인에게 고도의 위험성을 수반하는 파생상품에 투자할 것을 권유하였고, 상품의 구조 및 특성에 대한 추가적인 설명 없이 만연히 전화가입

402) 대법원 2003.1.10. 선고 2000다50312 판결, 2007.7.12. 선고 2006다53344 판결 참조.

신청 처리하고 투자설명서는 그 이후 등기우편으로 송부하였음.

③ 그렇다면, 결국 피신청인 담당직원은 투자에 따르는 위험을 포함하여 당해 펀드의 특성과 주요 내용을 설명함으로써 고객이 그 정보를 바탕으로 합리적인 투자판단을 할 수 있도록 고객을 보호하여야 할 주의의무가 있음에도 이를 위반하였다 할 것인 바, 피신청인은 그에 대한 손해배상책임을 부담한다 할 것임.

(3) 손해배상액 산정

신청인의 손해금액은 금 61,322,379원 상당이라 할 것임.⁴⁰³⁾ 한편, 위에서 본 바와 같이 본건에 있어 피신청인의 손해배상책임을 인정되나, 아래와 같은 이유로 그 구체적인 배상액은 일부 감액함이 상당하다 할 것임.

금융투자상품에 대한 투자결과 발생한 손익은 모두 투자자에게 귀속되는 것이 대원칙이라 할 것이고, 여기에 신청인은 2005.5월경부터 다수의 펀드상품에 투자한 경험이 있으며 특히 위 각 펀드와 유사한 구조의 파생상품펀드인 “◇◇파생상품투자신탁 제1호”에 투자하여 조기상환 받은 경험이 있는 점, 위 각 펀드가입 당시 담당직원의 말에만 의존하여 투자결정을 한 점 및 등기우편으로 “투자설명서”를 제공받았고 각 펀드의 “자산운용보고서”도 모두 분기별로 신청인에게 송부되었음에도 현재에 이르기까지 별다른 이의를 제기하지 않았던 점 등을 고려할 때, 신청인의 과실을 참작하여 50%의 과실상계를 함이 타당함.

라. 결 론

그렇다면, 피신청인은 신청인에게 손해금액 61,322,379원에서 신청인의 과실 50%를 공제한 나머지 금액인 30,661,190원을 배상할 책임이 있어 신청인의 이 부분 청구를 인용하고, 신청인의 나머지 청구는 이유 없어 이를 기각함.

403) ◇◇파생상품투자신탁 제1호 손실액(36,963,240원) + △△파생상품투자신탁 제2호 손실액(24,359,139원) = 61,322,379원

제4절 선물·옵션

1-14 선물·옵션의 위험성을 숨기고 장점만 부각한 경우 부당권유 인정 여부

[일부인용] 본건의 경우 신청인에게 담당직원이 선물·옵션의 투자를 권유함에 있어 주가지수 선물·옵션거래에 필연적으로 수반하는 위험성을 숨기고 오로지 장점만을 부각하여 설명하는 등 적극적 권유 및 위험성에 대한 올바른 인식형성을 방해한 사실이 있다고 할 것이므로 신청인의 이 부분 주장은 이유 있다.(2004.6.8. 조정번호 제2004-20호)

가. 사실관계

2002.1.21. 신청인은 ○○증권사(이하 “피신청인”이라 함)의 A지점(이하 “지점”이라 함)에서 신청인 명의의 주식 위탁매매계좌를 개설하였음. 같은 해 3.18. 신청인은 지점을 찾아가 피신청인의 직원인 대리 B씨(이하 “담당직원”이라 함)를 만나 상담을 하고 위 계좌에 6,500,000원을 입금한 이후, 같은 해 6.21.까지 총16,550,000원을 입금한 사실이 있으며, 위 기간 동안의 매매결과 금 11,412,635원의 손실이 발생함. 조사 결과 같은 해 3월 말경 신청인은 담당직원에게 계좌비밀번호를 알려준 사실이 있음.

한편 2002.6.29. 신청인은 주식매매로 인한 손실(금 11,412,635원)을 만회하고자 담당직원의 권유에 따라 본인명의로 선물·옵션 위탁매매계좌를 개설하고 담당직원에게 매매를 포괄적으로 일임하였으며, 당시 담당직원은 동 지점의 선물·옵션 영업관리자로서 신청인의 선물·옵션 계좌개설시 거래설명서를 교부하지 아니하고 신청인의 기명날인을 받았음.

담당직원은 초기에는 주가지수선물을 매매하였으나, 이후에는 주로 주가지수옵션매매를 하였음. 매매기간 중 증거금부족으로 9회에 걸쳐 금 23,500,000원이 추가입금되었으며, 선물·옵션의 매매결과 추가로 금 27,977,471원의 손실이 발생하였음. 2002.12.20. 담당직원은 신청인에게 손실보전각서⁴⁰⁴⁾를 교부한 사실이 있는 바, 신청인이 선물·옵션

404) 각서에는 임의매매로 인한 손해액 금 40백만원을 담당직원이 책임지며 2002.12.26.까지 변상할 경우 손해액을 금 31백만원으로 감면한다는 내용이 포함되어 있음.

매매종료시부터 손실보전각서를 요구하다가 신청인이 문구를 미리 작성한 후 담당직원의 기명날인을 받은 것으로 확인되었음.

나. 당사자의 주장

(1) 신청인 주장

피신청인의 담당직원은 신청인과 협의없이 매매를 반복하여 3개월만에 금 11,550,000원의 손실을 가하였고, 이에 대한 손실보전을 담당직원에게 요구하자 담당직원은 경험이 없는 신청인에게 선물·옵션에 대한 위험성 등을 설명하여 주지 아니한 상태에서 권유를 하여 결과적으로 손해를 보게 된 것임.

(2) 피신청인 주장

신청인이 관련 지점을 자주 방문한 사실 및 주식위탁매매를 종료한 이후에도 곧바로 선물·옵션 위탁계좌를 개설하여 채투자예 나선 점 등에 비추어 본건 매매는 일임매매임. 신청인은 선물·옵션 위탁계좌개설 당시 선물옵션계좌의 위험성을 충분히 인지하고 선물·옵션 거래설명서에 기명날인하였으므로 신청인의 청구를 수용할 수 없음.

다. 위원회의 판단

◆ 본건에 있어서의 쟁점은 담당직원이 ① 신청인의 동의 없이 현물 주식의 임의매매를 하였는지 여부와, ② 신청인에게 투자권유시 부당권유를 하였는지 여부 등이라고 할 것임.

(1) 임의매매 여부

담당직원이 주식을 위탁인인 고객의 동의 없이 매매한 경우에는 임의매매가 성립하고 이 경우 증권회사는 직원의 불법행위에 대하여 사용자배상책임을 지는 것이 원칙임. 또한 임의매매인지 일임매매인지 여부에 관한 판단은 구체적이고 명백한 증거가 없는 경우가 많으므로 객관적으로 나타난 계약체결당시의 권유방법, 투자목적 내지 동기, 투자자의 거래 경험, 거래원장 상에 나타난 거래내역 등의 여러 정황을 종합하여 합리적으로 판단하여야 함.

신청인은 담당직원이 현물주식을 임의매매하였다고 주장하나, 신청인의 주장을 입증할 만한 증거를 발견하기 어렵고 오히려 녹취록 및 문답결과 등 아래의 각 사실을 종합하면 신청인과 담당직원 사이에는 포괄적 일임매매의 약정이 있었다고 할 수 있어 신청인의 이 부분 주장은 이유 없음.

담당직원이 매수 전 상의를 할 경우 신청인이 담당직원에게 “알아서 하라”고 주로 얘기한 사실, 매매 후 담당직원이 유선상으로 수시로 보고하거나, 신청인이 매매결과를 확인한 사실 및 매매 후 어떠한 이의도 제기를 하지 아니한 사실, 비밀번호를 담당직원에게 알려준 점에 다툼이 없는 사실.

(2) 손실보전각서의 효력 유무

신청인은 담당직원에게 자신의 현물주식위탁계좌를 통하여 매매하게 하고 난 후, 손해가 발생하자, 담당직원으로부터 손실보전각서를 받았으므로 이를 근거로 손해배상을 요구하나, 이러한 손실보전각서나 그 손실보전행위는 「증권거래법」 제52조 제3호 및 동시행령 제36조의3 제2호⁴⁰⁵⁾에서 증권회사의 금지행위로 규정하고 있고, 증권회사 등이 고객에 대하여 증권거래와 관련하여 발생한 손실을 보전하여 주기로 하는 약속이나 그 손실보전행위는 위험관리에 의하여 경제활동을 촉진하는 증권시장의 본질을 훼손하고 안이한 투자판단을 초래하여 가격형성의 공정을 왜곡하는 행위로서, 증권투자에 있어서의 자기책임원칙에 반하는 것이라고 할 것이므로, 정당한 사유 없는 손실보전의 약속 또는 그 실행행위는 사회질서에 위반되어 무효라고 할 것임.⁴⁰⁶⁾

그렇다면 위 무효인 손실보전 각서를 기초로 하여 피신청인에게 그 이행을 요구하는 신청인의 이 부분 주장은 이유 없음.

(3) 선물·옵션 부당권유 인정 여부

증권회사의 임·직원이 「증권거래법」 제52조(부당권유행위등의 금지)에 위반한 방법

405) 「증권거래법」 시행령 제36조의3 제2호는 유가증권의 매매 기타 거래와 관련하여 고객에게 직접 또는 간접적인 재산상의 이익을 제공하는 행위 또는 정당한 사유 없이 당해 거래에서 발생한 손실의 전부 또는 일부를 보전하여 주는 행위를 금지하고 있음.

406) 대법원 2001.4.24. 선고 99다30718 판결, 금융분쟁조정위원회 조정번호 제2003-34호 참조.

으로 투자를 권유하여 투자 결과 손실을 본 경우에 투자자에 대한 불법행위책임이 성립하기 위하여는, 거래행위와 거래방법, 고객의 투자상황, 거래의 위험도 및 이에 관한 설명의 정도 등을 종합적으로 고려한 후 당해 권유행위가 경험이 부족한 일반 투자자에게 거래행위에 필연적으로 수반되는 위험성에 관한 올바른 인식형성을 방해하거나 고객의 투자상황에 비추어 과대한 위험성을 수반하는 거래를 적극적으로 권유한 경우에 해당하여 결국 고객보호의무를 저버려 위법성을 띤 행위인 것으로 인정될 수 있어야 함.

조사 결과, 아래의 각 점에 비추어 신청인에게 담당직원이 선물·옵션의 투자를 권유함에 있어 주가지수 선물·옵션거래에 필연적으로 수반하는 위험성을 숨기고 오로지 장점만을 부각하여 설명하는 등 적극적 권유 및 위험성에 대한 올바른 인식형성을 방해한 사실이 있다고 할 것임.

① 선물옵션에 대한 거래경험 및 그 지식이 전혀 없는 신청인에게 “옵션을 하면 큰 수익을 올릴 수 있다” “대박의 신화를 믿고 한번 베팅해 보자”고 권유하는 등 현물주식 투자로 손실을 입은 바 있는 신청인에게 선물옵션계좌 개설당시 손실을 만회하려는 욕구를 자극하여 주가지수 선물·옵션매매의 장점만을 부각한 점.

② 담당직원은 관련 지점의 선물옵션 영업관리자로서 고객의 선물옵션 계좌개설 전 거래구조 및 위험성 등을 제대로 고지하였는지 확인할 규정⁴⁰⁷⁾상 의무가 존재함에도 불구하고 거래설명서를 교부하지 아니한 채, 형식적인 기명·날인만을 받은 점.

③ 담당직원은 신청인 계좌를 포함하여 총3차례의 선물·옵션 일임매매경험이 있을 뿐이고 담당직원의 권유내용과 달리 본건 매매 이전에 다른 고객으로부터 금 80백만원을 위탁받아 거래하였으나 전액 원금손실을 보는 등 담당직원 자신 역시 선물·옵션 거래경험이 부족했던 것으로 보이는 점.

(4) 손해배상액 산정

피신청인 담당직원의 부당권유행위로 인한 손해금액은 2002.7.2.~9.10. 기간중 신청인이 입금한 금 33,500,000원에서 신청인이 출금한 금 5,500,000원 및 계좌내 잔고 22,529원을 뺀 금 27,977,471원이 손해금액임.

407) 「증권업감독규정」 제4-21조 제2항.

한편, 신청인은 현물주식투자의 경험이 있을 뿐만 아니라 현물주식의 일임매매로 손실이 발생하자 단기간에 손실을 보전하기로 하여 선물·옵션의 일임매매가 이루어진 사실, 선물·옵션매매를 통하여 유지증거금의 부족이 발생하자 담당직원의 요구에 따라 추가적인 증거금의 부족분을 입금하여 준 사실, 매매손익에 대하여 담당직원을 통하여 그 결과를 인지하고 있었던 사실 및 금융업에 종사하는 신청인의 직업 등을 종합하여 보면, 주식매매거래가 자신의 판단 및 책임하에 이루어져야 하며, 설사 그 매매를 담당직원에게 포괄적으로 일임하였다 하더라도 그로 인한 손익은 전부 자신이 부담하여야 한다는 원칙을 망각하고 단순히 담당직원에게만 의존하여 매매거래를 한 사실을 인정할 수 있어 이 사건 손실의 발생 및 확대에 책임이 상당하다고 인정되므로 위 손해금액 중 60%의 과실상계를 함이 타당함.

라. 결론

피신청인의 위 손해금액 금 27,977,471원에서 과실비율에 상응하는 금 16,786,482원을 차감한 금 11,190,989원이 손해배상액이라 할 것임. 그렇다면 피신청인은 피신청인 직원의 고객에 대한 불법행위에 대하여 사용자로서 신청인에게 금 11,190,989원을 배상할 책임이 있다 할 것이고 신청인의 나머지 청구는 이유 없어 이를 기각함.

1-15 선물·옵션, ELW에 대한 부당권유 및 매매주문 불이행 여부

[기각] 신청인은 11년이 넘는 주식거래 경험이 있는 자로서 본인이 원하는 때에 언제든지 스스로 주식매매를 할 수 있는 점, 담당직원은 단순히 향후 전망에 대한 의견을 제시하였을 뿐 매매거래에 관한 최종적인 의사결정은 신청인이 한 점, 신청인이 종합대출약정서, 예탁증권담보대출설명서와 대출약관 교부확인서에 서명하였고, 고객잔고확인서에 의하면 신청인이 수시로 잔고를 확인하고 있는 점 등으로 보아 담당직원이 고객보호의무를 위반하였다고 인정하기 어려움.(2008.7.15. 조정번호 제2008-55호).

가. 사실관계

신청인은 ○○증권사(이하 “피신청인”이라 함) ◇◇지점에서 주식거래를 시작한지 11여년 정도 경험이 있는 자로 1999.12.1. 및 2004.3.19. 위탁계좌를 개설, 피신청인의 직원 A씨(이하 “담당직원”이라고 함)가 이를 관리하였고, 2004.8.13. 선물옵션계좌를 개설하였으며 동 계좌에 대해 2005.7월경까지 담당직원의 지인인 B씨(○○증권 퇴직직원)가 이를 운용하다 그 이후 담당직원이 이를 관리함.

한편 신청인은 2004.7.30. 및 2005.7.15. 신청인의 자녀인 C씨 명의로 위탁계좌 및 선물옵션계좌를 개설하고 A기업 주식을 대상으로 하는 ELW거래와 선물·옵션거래를 함.

이후 동 계좌에서 손해가 발생하자 신청인은 담당직원의 매매주문거부, 부당매도권유, 선물·옵션거래 부당권유, 일임취지 위반 등으로 인하여 손해를 입었다는 이유로 분쟁조정을 신청함.

나. 당사자 주장

(1) 신청인 주장

신청인은 담당직원에게 B기업 주식 1,500주(2005년 2월), A기업 보통주 250주, 우선주 200주(2006년 1월), C기업 주식 120주(2007년 8월)의 매도를 요청하였으나 담당직원이 이를 거부하였고, 담당직원의 부당한 매도권유로 D기업 2,000주(2006년 8월), E기업 주식 5,000주(2006년 12월), F기업 주식 3,000주(2007년 1월)를 매도함으로써 손해를 입음.

2006.2월에는 담당직원의 권유로 대출을 받아 A기업 주식, G기업 주식을 매수하여 손해를 입었고, 담당직원이 2007.11.19. H기업 주식 1200주를 매도하여 선물거래에 사용하여 손해를 입음.

담당직원이 선물·옵션, ELW 거래에 관하여 설명 및 위험고지를 하지 않고 부당권유 행위를 하였으며, 선물·옵션 계좌에 대하여 손실보전을 약속하고 부당하게 거래를 함으로써 고객보호의무를 위반하였으므로 피신청인이 신청인의 손해를 배상할 책임이 있음.

(2) 피신청인 주장

담당직원은 신청인의 매매주문을 거부하거나 부당하게 권유한 적이 없으며, 신청인의

선물·옵션, ELW거래에 대해서 충분한 설명 및 위험고지를 하였고, 손실보전을 약속한 적도 없으며, 기타 고객보호의무를 위반한 것이 아니므로 신청인에 대한 손해배상책임이 없음.

다. 위원회 판단

◆ 본건은 피신청인이 신청인의 주식 매매주문을 불이행하거나 부당하게 권유하였는지 여부, 선물·옵션거래, ELW거래를 부당하게 권유하였는지 여부 등이라 할 것임

(1) 주식 매매주문 불이행 및 부당권유 여부

고객과의 지속적인 거래관계에 적용될 기본적인 위탁매매거래계좌의 설정계약을 체결한 증권회사는 위탁계약의 본지에 따라 선량한 관리자의 주의를 가지고 행동할 의무를 부담하며, 「증권업감독규정」 제4-23조는 “증권회사는 고객으로부터 매매주문을 받은 경우에는 이를 신속·정확하게 처리하여야 한다.”고 규정하고 있는 바, 증권회사가 이러한 의무를 위반하여 고객에게 손해가 발생하였다면 증권회사는 이를 배상할 책임이 있다 할 것임.

신청인은 담당직원의 주식매도거부, 부당한 매도권유, 대출권유, 매각주식 대금의 임의적 선물거래 사용 등으로 손해를 입었다고 주장하나 다음과 같은 점으로 보아 신청인의 위 주장은 이유 없음.

① 담당직원은 신청인의 매도주문을 거부하거나 부당하게 이를 권유한 적이 없다고 진술하여 당사자의 주장이 상반되고 명확한 자료가 없으나, 신청인은 주식거래를 한지 11년이 넘는 경험이 있는 자로서, 피신청인의 목동지점에 상주하여 거래하는 고객으로 본인이 원하는 때에 언제든지 스스로 주식매매를 할 수 있는 점.

② 예컨대, A기업 주식매도 거부와 관련하여 2008.4.4. 금감원에서 신청인의 참고인 D씨에 대해 실시한 문답서를 보면, 참고인은 담당직원이 신청인에게 동 주식의 100만원까지 올라갈 수 있다고 기다리는 것이 좋겠다고 말하였다는 말을 신청인으로부터 들었다고 진술하고 있고, 당시 시장에서도 100만원까지 간다는 이야기가 있었지만 참고인이 신청인에게 팔아보는 게 어떻겠느냐고 이야기한 것으로 진술하고 있음에 비추어 담당직원

이 가격을 거론하며 다소 과장적인 표현을 사용한 경우가 있으나 당시 시황, 신청인의 주식거래경력 등에 비추어 이는 부당한 매도거부라기 보다는 향후 전망에 대한 단순한 의견 제시에 해당되며 매매거래에 관한 최종적인 의사결정은 신청인이 한 것으로 봄이 타당하다 할 것임.

③ 신청인이 종합대출약정서, 예탁증권담보대출설명서와 대출약관 교부확인서에 서명하고 있는 점.

④ H기업 주식의 매도대금의 경우, 2008.3.25. 금감원에서 실시한 문답서를 보면 신청인이 동 주식의 처분에 대해 동의한 것으로 진술하고 있으며 선물·옵션대용연결제와 및 대용증권지정신청서에 신청인이 서명하고 있는 점.

(2) 선물·옵션, ELW거래 부당권유 등 고객보호의무 위반여부

판례는 거래경위와 거래방법, 고객의 투자상황(재산상태, 연령, 사회적 경험 정도 등), 거래의 위험도 및 이에 관한 설명의 정도 등을 종합적으로 고려한 후, 증권회사 임직원의 권유행위가 경험이 부족한 일반 투자자에게 거래행위에 필연적으로 수반되는 위험성에 관한 올바른 인식형성을 방해하거나 또는 고객의 투자 상황에 비추어 과대한 위험성을 수반하는 거래를 적극적으로 권유한 경우에 위법성을 인정하고 있음.⁴⁰⁸⁾

한편 선물·옵션의 위험성을 다소 미흡하게 설명하였다거나 고수익 가능성을 주로 강조하여 권유하였다고 하더라도 그것만으로는 주식투자 경험이 상당한 고객에게 선물·옵션을 부당하게 권유했다고 단정하기 어렵다고 판시하고 있음.⁴⁰⁹⁾

신청인은 선물·옵션, ELW 거래에 관하여 설명 및 위험고지를 받지 못하였고 부당한 ELW 매수권유와 담당직원이 피신청인에게 옵션매도를 하는 방법을 알려줌으로 인하여 손해를 입었다고 주장하나, 신청인의 주장은 다음과 같은 점으로 보아 이유 없다 할 것임.

① 신청인은 1998년 ◇◇지점에서 주식거래를 한 이래 수년간 주식거래를 경험한 자이고, ELW거래 설명서 및 대출약관 교부확인 및 선물·옵션거래설명서, 위험고지서 수

408) 대법원 2003.1.10. 선고 2000다50312 판결 참조.

409) 대전고등법원 2006나2764 판결 참조.

명확인에 서명하고 있는 점.

② 신청인은 본건 이외 ○○증권에서 2004.5.6. 선물옵션계좌를 개설하여 선물거래를 한 경험도 있으며, 금감원에서 작성한 2008.3.25. 문답서를 보면, 신청인은 “2005. 3~4월 경 ○○증권 ◇◇지점에서 1달 정도 선물거래를 해서 290만원 정도 손실이 났습니다. 제가 아는 언니가 1달 정도 친구의 계좌를 이용하여 선물거래를 하여 이익이 나면 10%를 정에게 주고 나머지는 제가 갖고 손해가 나면 손해액을 물어주는 식으로 해서 거래에 참가한 사람이 저를 포함하여 4명으로 6천만원 정도 손해를 보았고 저는 1천만원 정도 손해가 났습니다.”라고 진술하고 있는 점으로 보아 선물·옵션거래로 인한 손실위험을 인식하고 있다고 볼 수 있는 점.

③ 담당직원은 신청인이 옵션매수로 손실을 본 상태에서 매도 및 해지의 중요성에 대해서 설명한 바 있다고 상반된 진술을 하고 있고 달리 담당직원이 부당하게 매도를 권유하였다고 인정할 자료가 없으며, 본질적으로 투자자로서는 자기의 판단과 책임으로 투자를 하여 투자손실을 스스로 부담함이 원칙이며, 단순히 선물·옵션매도를 권유했다고 하여 책임이 있다고 보기 어려운 바, D씨 계좌의 선물·옵션, ELW 거래는 그 대부분이 HTS(Home Trading System)거래로 신청인 스스로에 의하여 실행된 점.

(2) 일임취지 위반 등 고객보호의무 위반 여부

고객과 증권회사 임직원간 증권매매에 대한 일임관계에 있는 경우 동 임직원은 수탁자로서 당연히 충실의무 내지 선관주의 의무가 있다 할 것임.

신청인은 담당직원이 손실보장을 약속하는 등 일임취지 등 고객보호의무를 위반하였다고 주장하나, 다음과 같은 점에 비추어 신청인의 주장은 이유 없다 할 것임.

① 신청인은 담당직원이 손실보전을 약속하며 선물·옵션거래를 지속하였다고 주장하나, 담당직원은 이를 부인하고 있으며 손실보전약정을 인정할 객관적 자료가 없는 점.

② 신청인은 지점에 상주하며 거래하는 자로서 담당직원의 거래를 상시 확인할 수 있었으며 2008.3.25. 금감원에서 작성한 문답서를 보면 담당직원은 고객이 지점에 항시 상주하였고, 매일 장 종료후 잔고를 확인하며 고객이 동의하여 거래를 한 것으로 진술하고 있으며, 고객잔고확인서에 의하면 신청인이 수시로 잔고를 확인하고 있는 점.

라. 결론

그렇다면 피신청인은 신청인에 대하여 손해를 배상할 책임이 없다 할 것이므로 신청인의 청구는 이유 없어 이를 기각함.

1-16 투자경험이 없는 자에게 선물옵션을 부당 권유한 데 따른 손해배상책임

[일부인용] 피신청인 담당직원이 선물옵션 투자경험이 전혀 없는 신청인에게 선물옵션의 내용, 위험성 등에 대하여 자세한 설명없이 안전하다는 취지로 수차례 권유한 점, 신청인의 투자정보확인서 내용을 왜곡한 점, 담당직원이 신청인에게 손익내용을 안내할 때 평가손을 제외하고 실현손만을 주로 보고하는 등 선물옵션 거래손실에 대한 안내를 충실하게 이행하지 않은 점 등에 비추어 피신청인이 설명의무 또는 고객보호의무를 다한 것으로 보기는 어려움.(2011.6.21. 조정번호 제2011-38호)

가. 사실관계

2010.8.9. 신청인은 ○○증권사(이하 “피신청인”이라 함) 직원과 상담 후 기 개설된 계좌를 이용하여 주식거래를 시작하여,⁴¹⁰⁾ 피신청인 직원과 협의하는 방식으로 주식거래를 하였고, 거래기간(2010.8.9.~2011.2.11.)동안 약 95백만원(거래비용 공제시 75백만원)의 수익을 실현함.

2010.10.25. 피신청인 담당직원이 신청인에게 현재 보유하고 있는 주식의 주가하락에 대비한 헷지의 중요성과 선물옵션거래가 안전한 투자라는 점을 수차례 강조하면서 권유하자 신청인은 선물옵션 계좌를 개설하였고, 본건 선물옵션 계좌개설 당시 피신청인 김포지점 지점장(A씨)이 신청인에게 선물옵션거래의 내용 및 위험성에 대하여 설명하여 신청인이 위험성에 대해 걱정을 하자 담당직원은 지점장이 투자신탁에서 온 분이라 선물을 잘 모른다면 안전한 거래라고 하면서 선물옵션 거래를 거듭 권유함.

410) 신청인은 2004.7월 모 기업 근무시절 우리사주로 받은 주식을 위해 증권계좌를 개설한 후 처음으로 주식거래를 한 것으로, 과거에 주식거래 및 선물옵션 거래를 한 경험이 전혀 없다고 주장함.

신청인은 본건 선물옵션계좌를 개설하면서 「개좌개설신청서」 및 「일반투자자 투자정보 확인서」에 자필기재 및 서명을 하였는데, 담당직원은 신청인이 처음에 작성한 「일반투자자 투자정보 확인서」는 선물옵션투자에 적합하지 않다고 하면서 재작성을 요청하여 다시 작성하게 되었음.⁴¹¹⁾

본건 선물옵션거래는 신청인의 기 보유주식을 대응(담보)으로 하여 거래를 하였고, 담당직원에게 거래를 포괄적으로 일임하는 형태로 이루어졌으며, 담당직원은 옵션 매매전략으로 주로 양매도 전략⁴¹²⁾을 취하였음.

2010.11.24. 누적 손실(평가손실 포함) 및 누적 수수료의 합계가 약 53백만원이었으나 담당직원은 신청인과 통화시 평가손실을 제외하는 등 손실을 축소 보고하였고, 이후에도 신청인에게 손실액에 대해 여러 차례 축소 보고(평가손을 제외)함.

담당직원은 2010.11.24 이후 양매도전략을 유지하였는데, 2011.2.7. 지수가 양매도 설정 구간을 벗어나 손실이 크게 발생하였고, 2011.2.8. 담당직원은 손실을 만회하고자 지수 상승시 수익을 극대화하기 위해 콜옵션을 대량으로 매수하였으나 지수가 하락하자 손실이 급격히 확대되었으며, 2011.2.14. 신청인은 금감원에 본건 금융분쟁조정을 신청함.

나. 당사자의 주장

411) 2010.10.25.자 「투자정보 확인서」는 2개월전 신청인이 주식거래 용으로 작성한 것과 크게 차이를 보임.

항목	2010.8.4. 작성(주식거래용)	2010.10.25. 작성(선물옵션계좌)
투자경험과 가장 가까운 금융상품	채권형펀드, 금융채, 신용도가 높은 회사채, 원금보장형 ELS 등	주식 신용거래, 파생상품에 투자하는 펀드, 시장수익률 이상의 수익을 추구하는 주식형 펀드, 선물옵션, ELW 등
금융상품투자에 대한 지식수준	낮은 수준: 주식과 채권의 차이를 구별할 수 있는 정도	높은 수준 : 투자할 수 있는 대부분의 금융상품 차이를 구별할 수 있는 정도
투자원금에 손실 발생시 감내 수준	기대수익이 높다면 위험이 높아도 상관하지 않겠다	기대수익이 높다면 위험이 높아도 상관하지 않겠다
고객 투자성향	적극 투자형	공격 투자형
위험선호도	적극 투자형	공격 투자형
상담자	L씨	직원(담당직원)

412) 양매도 전략은 풋옵션매도와 콜옵션매도를 동시에 하는 방법으로 수익률 및 위험성을 높이는 전략이지 기보유주식의 주가 하락을 헷지하기 위한 것으로 보기는 어려움.

(1) 신청인의 주장

피신청인 담당직원이 선물옵션에 대한 경험이 전혀 없는 신청인에게 자세한 설명도 없이 기존 보유주식의 하락을 대비하기 위한 헷지 차원이고 안전한 투자라고 하면서 선물옵션거래를 수차례 권유하여 거래를 하게 되었으나 큰 손실을 입었으므로 피해를 보상해야 함.

(2) 피신청인의 주장

본건은 선물옵션 계좌개설시 지점장이 신청인에게 선물옵션의 위험성 등에 대해 충분한 설명을 하였고, 신청인이 「개좌개설신청서」 및 「일반투자자 투자정보 확인서」에 자필 기재 및 서명을 하여 적법한 절차에 의해 선물옵션 계좌개설이 이루어졌음.

선물옵션 매매거래시 담당직원이 매매내역 및 손익현황에 대해 설명하였고, 이에 대해 신청인이 이의제기 없이 동의를 한 것이므로 신청인의 주장은 수용하기 곤란함.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 피신청인 담당직원의 부당한 선물옵션 투자권유시 고객보호의무 위반 여부라 할 것임

(1) 관련 판례

금융기관의 임직원이 고객에게 금융투자상품 매입을 권유할 때에는 그 투자에 따르는 위험을 포함하여 당해 상품의 특성과 주요 내용을 설명함으로써 고객이 그 정보를 바탕으로 합리적인 투자판단을 할 수 있도록 고객을 보호하여야 할 주의의무가 있다 할 것임.⁴¹³⁾

금융기관의 임직원이 고객에게 적극적으로 투자를 권유하였으나 투자 결과 손실을 본 경우에 투자가에 대한 불법행위책임이 성립되기 위하여는 이익보장 여부에 대한 적극적 기망행위의 존재까지 요구하는 것은 아니라 하더라도, 적어도 거래경위와 거래방법, 고객의 투자상황(재산상태, 연령, 사회적 경험 정도 등), 거래의 위험도 및 이에 관한 설명

413) 대법원 2003.7.25. 선고 2001다10458 판결 참조.

의 정도 등을 종합적으로 고려한 후, 당해 권유행위가 경험이 부족한 일반 투자자에게 거래행위에 필연적으로 수반되는 위험성에 관한 올바른 인식형성을 방해하거나 또는 고객의 투자 상황에 비추어 과대한 위험성을 수반하는 거래를 적극적으로 권유한 경우에 해당하여, 결국 고객에 대한 보호의무를 저버려 위법성을 띤 행위인 것으로 평가될 수 있는 경우라야 함.⁴¹⁴⁾

(2) 고객보호의무 위반 여부

본건은 다음과 같은 점에 비추어 볼 때 피신청인이 설명의무 또는 고객보호의무를 다한 것으로 보기는 어렵다 할 것임.

① 피신청인 담당직원이 선물옵션 투자경험이 전혀 없는 신청인에게 선물옵션의 내용, 구조 및 위험성 등에 대하여 자세한 설명 없이 안전하다는 취지로 수차례 권유하여 본건 선물옵션거래가 이루어졌으며, 신청인은 지점장이 신청인에게 선물옵션은 위험하다는 취지의 설명을 하여 선물옵션거래를 주저하였으나, 담당직원은 지점장이 투자신탁에서 온 분이라 선물을 잘 모른다고 안전한 거래라고 설득함으로써 신청인의 위험성에 관한 올바른 인식형성을 적극적으로 방해한 점.

② 담당직원은 신청인이 처음에 작성한 「일반투자자 투자정보 확인서」는 선물옵션투자에 적합하지 않다고 하면서 재작성을 요청하여 다시 작성토록 하여 신청인의 투자정보확인서 내용을 왜곡한 점.

③ 피신청인 담당직원은 본건 선물옵션계좌 개설시에는 신청인에게 선물옵션거래가 보유주식의 주가하락에 대비한 헷지를 위한 것이라고 설명하고서 실제로는 주가지수 변동에 따라 손실이 발생할 수 있는 양매도 전략 등을 취한 점.⁴¹⁵⁾

④ 담당직원이 신청인에게 손익내용을 안내할 때 평가손을 제외하고 실현손만을 주로 보고하는 등 고객에게 선물옵션 거래손실에 대한 안내를 충실하게 이행하지 않은 점.

414) 대법원 2003.1.10. 선고 2000다50312 판결, 2007.7.12. 선고 2006다53344 판결 참조.

415) 피신청인은 매매전략을 헷지에서 수익추구로 변경할 때 신청인에게 이를 설명하고 동의를 받았다고 주장하나, 신청인에게 이러한 매매전략 변경을 명시적으로 언급한 사실이 통화내역 등에 확인되지 않고 신청인도 매매전략을 변경하였다는 설명을 들은 바가 없다고 함.

⑤ 선물옵션 매매로 인한 전체 손해액(276,997,150원) 중 수수료(147,393,150원)가 차지하는 비중이 50%를 초과하여 과다하게 발생한 점.

(3) 손해배상액 산정

피신청인은 신청인에게 부당한 옵션투자로 인한 손해를 배상할 책임이 있다 할 것인바, 신청인의 손해금액은 본건 선물·옵션거래로 인한 손실 276,997,150원(= 누적손실 129,604,000원 + 선물·옵션수수료 147,393,150원)이라 할 것임.

한편, 다음과 같은 점 등을 고려하여 피신청인의 책임을 40%로 제한하는 것이 타당함.

① 투자자는 자기책임의 원칙 아래 투자상품의 개념이나 내용, 손익구조, 투자위험성 등에 관한 사항을 사전에 정확히 파악하여 신중히 검토한 다음 투자하여야 할 것인데도 신청인은 비교적 거액을 투자하면서도 이를 게을리 한 점.

② 신청인이 본건 선물옵션계좌 개설시 ‘개좌개설신청서’ 및 ‘일반투자자 투자정보 확인서’에 자필기재 및 서명을 하여 선물옵션 거래가 이루어진 점.

③ 신청인은 지점장으로부터 선물옵션거래의 위험성에 대해 설명을 들어 위험성을 알 수 있었음에도 충분한 검토를 하지 않고 단순히 담당직원의 말만 믿고 위험한 선물옵션 거래를 시작한 점.

④ 신청인은 2010.11월 담당직원으로부터 선물옵션거래로 인한 손실을 안내받아 선물옵션거래가 손실을 입을 수도 있다는 점을 알고도 동 거래를 즉시 중단토록 하지 않아 이후 손실이 확대된 점.

⑤ 투자판단은 본인이 결정함이 원칙인데도 신청인은 본건 선물옵션거래와 관련된 투자판단을 담당직원에게 일임한 점 등을 고려하여 신청인의 과실비율을 60%로 보고 피신청인의 책임을 40%로 제한함이 타당함.

라. 결 론

그렇다면 피신청인은 신청인에게 손해금액 110,798,860원을 배상할 책임이 있어 이를 인용하고, 신청인의 나머지 청구는 이유 없어 기각함.

제5절 펀드 환매 등 기타

1-17 투자신탁 환매거부의 적정성 및 임의가입 여부

[일부인용] 신청인이 그 동안 담당직원과 상의하여 투자신탁 상품에 가입하거나 재가입하는 형태로 거래하여 온 점. 신청인이 환매신청서를 작성하여 제출한 사실이 없고, 환매가 되지 않은 사실을 인지하고도 적극적으로 이익제기를 한 사실이 없는 점 등을 감안시 환매거부가 있었다고 보기 어려움. 한편 D상품가입과 관련하여 담당직원이 가입신청서를 대필하여 가입하였고, 당시 가입신청서에 신청인이 인감날인을 하지 않았을 뿐만 아니라 이후에도 보완되지 않은 점. 신청인이 수차례에 걸쳐 환매요구를 하였음에도 C상품을 D상품으로 대체하였다는 사실을 고지하지 않은 점 등을 감안시 담당직원이 임의가입하였다고 할 것임.(2000.6.13. 조정번호 제2000-28호)

가. 사실관계

1995년부터 신청인은 피신청인의 직원을 알게 되어 동 직원과 상의하여 투자신탁상품에 가입하였고, 2000.1.5. 신청인이 직원에게 주식형상품인 A, B, C상품에 대하여 구두로 환매를 요구하였고, 당일 C상품은 주식형상품인 D상품으로 대체됨.

담당직원이 투자신탁상품인 D상품 가입신청서를 직접 작성하여 동 상품에 가입하였고, 당시 가입신청서에 신청인이 인감날인을 하지 않았을 뿐만 아니라 이후에도 인감날인이 보완되지 않았고, 신청인이 수차례에 걸쳐 환매요구를 하였음에도 C상품을 D상품으로 대체하였다는 사실을 고지하지 않은 점 등에 비추어볼 때 D상품은 임의가입한 것으로 판단됨.

2000.2.11. 신청인이 직원에게 A, B, C상품에 대하여 재차 구두로 환매를 요구하였고, 직원은 2000.2.14. 퇴사함. 2000.2.22. 신청인이 타직원에게 A, B, C상품에 대하여 환매를 요구하다가 D상품에 가입된 사실을 알게 됨.

나. 당사자의 주장

(1) 신청인의 주장

피신청인의 직원이 주식형상품에 대한 환매요구에 응하지 않았고, 2000.1.5. 임의로 D상품에 가입함으로써 손해가 발생하였으므로 피신청인은 이에 대한 배상을 하여야 함.

(2) 피신청인의 주장

신청인은 직원과 상의하여 환매를 하지 않았던 것이고, D상품은 신청인의 승낙하에 가입한 것이므로 신청인의 주장을 수용할 수 없음.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 본건 상품의 ① 임의가입 여부 ② 환매거부의 적정성 유무와 그에 따른 구체적인 손해배상액 산정이라 할 것임.

(1) 환매거부 여부 및 D상품 임의가입 여부

신청인은 자신의 환매요구에도 불구하고 피신청인의 직원이 환매에 응하지 않았다고 주장하고, 담당직원은 신청인이 적극적으로 환매신청을 하지 않고 직원의 권유에 따랐기 때문에 환매를 해주지 않았다고 주장하나 다음과 같은 점에 비추어 볼 때 직원이 환매를 거부하였다고는 보기 어려움.

① 신청인은 그 동안 담당직원과 상의하여 투자신탁 상품에 가입하거나 재가입하는 형태로 거래하여 온 점.

② 환매요구시 신청인이 환매신청서를 작성하여 제출한 사실이 없고, 환매가 되지 않은 사실을 인지하고도 적극적으로 이의제기를 한 사실이 없는 점.

한편, D상품가입과 관련하여서는 다음과 같은 점에 비추어 볼 때 직원이 신청인의 동의 없이 임의가입한 것으로 판단됨.

① 담당직원이 가입신청서를 직접 작성하여 동 상품에 가입하였고, 당시 가입신청서에 신청인이 인감날인을 하지 않았을 뿐만 아니라 이후에도 인감날인이 보완되지 않은 점.

② 신청인이 수차례에 걸쳐 환매요구를 하였음에도 C상품을 D상품으로 대체하였다는 사실을 고지하지 않은 점.

③ 신청인은 2000.2.22. 환매요구를 하다가 D상품 가입사실을 인지한 점.

(2) 손해배상금액의 산정기준

직원의 불법행위로 인하여 신청인이 입은 손해는 신청인이 2000.2.22. C상품을 환매하였을 때 받을 수 있었던 금액과 현재 보유하고 있는 D상품평가액과의 차이라고 할 수 있음. 한편 D상품의 평가액은 계속 변동하기 때문에 어느 일정시점을 정하여 산출하기 곤란하므로 동 상품은 피신청인이 인수하고, 신청인에게는 신청인이 2000.2.22. C상품 환매요구시 받을 수 있는 금액인 47,530,086원을 지급하여야 할 것임.

라. 결 론

그렇다면 직원이 신청인의 동의 없이 D상품에 임의가입한 사실이 인정되므로 피신청인은 D상품을 인수하고, 신청인에게는 신청인이 C상품 환매요구시 받을수 있는 금액인 47,530,086원을 지급하여야 할 것임.

1-18 투자재산의 매각 지연으로 인한 수익증권 환매유예의 적법성 여부

[기각] 2001.10.11.기준 환매청구금액 대비 신탁재산의 유동성 부족이 발생하였고, 잔존 신탁재산의 대부분이 비상장·비등록회사 주식이어서 신탁재산의 일부해지를 위한 투자재산의 매각에 있어 현금화의 지연사유가 발생한 점의 이유로 약관상의 환매유예조치를 취한 점, 그 후 펀드의 유동성확보를 위한 피신청인들의 조치 등을 종합할 때, 피신청인들은 선관주의의무를 위반했다고 볼 수 없음.(2002.12.3. 조정번호 제2002-48호)

가. 사실관계

2000.3.23. 신청인은 신중 MMF1-M펀드⁴¹⁶⁾ 계좌를 ○○증권(이하 “피신청인”이라 함)

416) 동 펀드는 위탁회사를 A신탁운용(주)로, 판매회사를 ○○증권회사로 하고 운용기간 및 펀드의 추가 설정여부는 2000.4.3. 3년 단위형으로 설정되었으며, 중도환매에 관한 제한은 없음. 투자재산의 운용대상은 코스닥 등록기업에 10~20%, 비등록장외주식 및 벤처기업에 50% 수준을 투자하도록 당해 약관과 투자신탁설명서에 규정되어 있음.

에 신규로 개설하고 금 6백만원을 예치한 후, 같은 날 동 계좌의 위 금액 전액을 주식형 펀드에 청약하였음. 신청인은 2001.10.5. 피신청인으로부터 동 계좌를 만기전이라도 중도에 환매하여 다른 종목으로 변경하라는 권유를 받았으나, 며칠이 지난 같은 달 11일에 환매를 청구하였음.

피신청인들은 신청인에게 같은 해 10.16. 환매대금을 지급할 예정이었으나, 2001.8~10월중에 다른 수익자들의 환매청구가 급증하여 동 펀드내의 현금성자산 전액을 환매자금 지급에 사용함으로써 펀드의 유동성 부족상태가 발생하게 되어 10.11. 환매청구분부터 1차로 15일간 환매자금 지급을 연기하였고, 10.25.까지도 환매자금을 마련하지 못하여 환매연기가 해소되는 시점까지 재차 환매연기조치를 취하였음.

나. 당사자의 주장

(1) 신청인의 주장

증권투자신탁에 가입한 소액투자자들은 상품광고를 믿고 거래하는 것이고 광고에 분명히 중도환매를 할 수 있다고 규정하고 있으므로 환매대금을 지급해 주어야 하며, 환매제한 조치가 취해진 후 1년이 넘게 환매대금을 지급하지 아니하는 것은 부당하므로 손해를 배상하여야 함.

(2) 피신청인의 주장

신청인이 가입한 펀드의 환매연기조치는 2001.9월 이후의 국내외 증시폭락 등의 여파로 동 펀드의 환매요청이 급증하였는 바, 코스닥시장 및 장외시장의 위축으로 펀드에 편입된 비등록·비상장주식의 매각이 불가능하여 환매자금을 마련치 못하고 「증권투자신탁업법」 및 동 「투자신탁약관」에 의거 현금자산 확보를 위하여 환매연기사유가 해소되는 시점까지 부득이 환매를 유예한 것임.

현재 펀드의 특성과 최근의 시장상황을 고려하면 조기에 투자자산을 회수하여 모든 가입고객의 환매에 응하여 신청인을 포함한 모든 고객의 기대에 부응하는 것은 현실적으로 어려우나, 투자신탁에 편입된 비상장·비등록주식의 장외매각과 바이백(buy-back)이 가시적인 성과를 얻을 수 있도록 지속적으로 추진하고, 일부 종목의 경우 금년 하반기

기 또는 내년 하반기에 코스닥등록이 가능할 수 있도록 다각적인 노력을 하고 있으며, 향후 만기일 전이라도 회수될 투자자금은 회수시점에 환매를 신청한 모든 고객들을 대상으로 고객들의 가입좌수에 비례하여 균등 배분하는 방식으로 지급할 예정이므로 신청인의 주장을 수용할 수 없음.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 ○○증권사와 A신탁운용사의 환매대금지급 거부가 정당한 것인지 여부라고 할 것임.

(1) “환매유예 행위”의 적법성 여부

다음의 사실을 종합하면 피신청인들이 한 환매유예 및 환매유예 연기는 근거 법령과 당해 약관의 규정(417)에 위반된 사실이 없는 바, 당해 환매유예 및 환매유예연기의 요건을 충족하였으므로 적법하다고 판단됨.

① 2001.10.11. 기준 당일 환매청구금액은 총 60,650,574원으로서 신탁재산의 유동성 부족(현금은 58,873원, 주식 5,923,690,400원)이 발생하였고, 잔존 신탁재산의 대부분이 비상장·비등록회사의 주식이어서 신탁재산의 일부해지를 위한 투자자산의 매각에 있어 현금화의 지연사유가 발생한 점.

② 피신청인들은 「증권투자신탁업법」 제7조제7항, 당해 약관 제16조 제2항에 의하여 환매유예 사실을 2001.10.15. 통지한 점. 다만, 당해 약관 제16조제3항에 따른 환매유예 연기에 대하여는 별도로 수익자에게 통지하지 아니한 사실이 있으나, 당해 펀드의 환매

417) 「증권투자신탁업법」 제7조제7항, 당해 약관 제16조제2항, 제3항은 수익자가 수익증권의 환매를 청구하는 경우 위탁회사 또는 판매회사는 환매청구가 있는 날로부터 제3영업일 기준가격으로 그 수익증권을 환매하되 환매대금은 신탁재산의 일부해지에 의해 조성된 현금으로 환매청구일로부터 제4영업일에 위탁회사 또는 판매회사의 영업점포에서 지급함. 다만, 신탁재산중 유가증권등의 매각지연 등의 사유로 환매에 응할 수 없는 때에는 지체없이 그 사실을 수익자에게 통지하고 환매청구일로부터 15일 이내에 환매대금을 지급할 수 있음(제2항). 위탁회사 또는 판매회사는 제2항의 규정에 불구하고 천재·지변, 유가증권시장의 폐쇄·정지 또는 휴장, 유가증권등의 매각지연등 기타 부득이한 사유로 환매를 연기할 경우에는 지체없이 그 사실을 수익자에게 통지하고 금감위의 승인을 얻어 그 사유가 해소될 때까지 환매를 연기할 수 있음(제3항)라고 규정하고 있음.

제한 사유가 비상장·비등록 주식의 매각지연으로 환매유예와 환매유예 연기에 공통되는 사유이고 당시 상황에 비추어 15일 후에도 이러한 사유가 해소될 수 없다고 판단되므로 일괄적으로 2001.10.15. 환매유예와 환매유예 연기를 통지하였으므로 통지요건을 충족하고 있다고 판단됨.

③ 다만, 피신청인들은 환매유예의 연기에 대하여는 당해 약관 제16조제3항에 따른 금융감독위원회의 승인을 얻지 아니하였으나, 환매 연기 사유가 발생하면 지체없이 환매를 연기하여야만 집합투자기구와 수익자의 이익이 보호될 수 있는 점, 위 승인의 목적이 환매연기의 남용을 방지하기 위한 점, 개정 「증권투자신탁업법」(1998.9.16. 개정)에는 구법과 달리 금융감독위원회의 승인을 환매유예의 요건으로 하지 아니하는 점 등에 비추어 볼 때, 위 효력규정이 아닌 확인적 의미의 승인⁴¹⁸⁾이라 할 것이므로 피신청인들의 환매유예연기행위는 위법하다고 볼 수 없음.

(2) “환매연기상태 지속행위”의 적정성 여부

당해 환매유예 및 환매유예연기 행위가 적법하다 할 지라도 동 펀드는 2001.10.11. 펀드의 유동성 부족으로 환매연기조치가 개시된 이래 현재까지 1년 이상의 기간동안 유동성부족 상태가 지속되고 있는 상황임. 환매유예 연기의 기간에 대하여는 약관에 “그 사유가 해소될 때까지 환매를 연기할 수 있다.”고 정하고 있어 사실상 기간제한에 대한 명시적 규정은 없음. 그러나 「증권투자신탁업법」 제17조제1항은 위탁회사에게 선관주의의무를 부과하고 있는 바, 피신청인 A투신운용(주)가 수익자의 이익을 보호하기 위한 매각지연사유해소를 위하여 선관주의의무를 해태한 사실이 있는 지 문제됨.

당해 펀드의 위탁자인 피신청인 A투신운용(주)는 아래의 사실을 종합하면 수익자 보호를 위하여 환매유예사유를 해소하기 위한 선량한 관리자로서의 주의의무를 해태한 사실이 없다고 판단됨.

① 2002.9.12. 동 펀드의 약관내용 중 신탁보수율을 30/1,000에서 0/1,000으로 변경하여 신탁보수를 받지 아니하기로 한 사실.

② 신탁재산에 편입되어 있는 B기업 주식에 대하여 실적부진으로 자력 IPO를 통한

418) 하급심의 판례도 같은 취지임(서울지방법원 2002.2.8. 선고 2001나27173 판결, 투자자예탁금 반환)

자금회수가 불투명하다는 판단하에 B기업이 소유하고 있는 코스닥 등록업체인 C기업의 주식을 B기업과 포괄적 주식교환 후, 3억7천만원을 회수(회수율 49%)하여 현금화한 사실.

③ 전 투자 종목에 대하여 영업실적 및 현황을 점검하여 IPO 과정에 적극 참여하고, 운용역과 애널리스트를 수시로 방문하고 접촉한 사실 및 일부 투자자산의 회수가 이루어지는 등 가시적인 성과가 나타나고 있는 사실.

④ 피신청인들은 회수한 투자자금에 대하여는 조속한 시일 내에 환매를 신청한 모든 수익자에게 가입좌수에 비례하여 균등 배분하는 방식으로 지급하겠다고 밝히고 있는 점.

라. 결 론

그렇다면 피신청인들이 한 동 펀드에 대한 환매유예는 적법하다 할 것임.

1-19 대량환매사태로 인한 환매유예조치의 적법성 여부

[기각] 증권투자신탁업법과 동시행령, 당해 약관 등에는 환매유예조치에 대하여 판매회사는 이를 수익자에게 통지할 의무만 있을 뿐, 적극적으로 환매기회를 수익자에게 보장해야 하는 의무조항이 없으며, 피신청인이 수익자들에게 ○○의 분식회계 및 환매를 해야 한다는 취지의 통지를 해야 한다면, 이러한 내용의 통지를 모든 수익자에게 동일한 시간대에 할 수도 없을 뿐 아니라 나중에 환매를 청구하거나 환매를 청구하지 못한 수익자들과의 형평성을 해할 수 있고, 대량 환매에 따르는 신탁재산의 소멸은 증권투자신탁의 자본적 성격에도 반한다고 할 것이므로 신청인의 청구는 이유 없다고 할 것임.(2003.11.4. 조정번호 제2003-49호)

가. 사실관계

신청인은 1999년부터 ○○증권사(이하 “피신청인”이라 함)를 통하여 수익증권을 매수·매도한 사실이 있으며, 신청인이 거래한 수익증권의 종류는 모두 MMF임. 신청인은 피신청인 지점(이하 “지점”이라 함)에서 아래의 MMF에 가입한 사실이 있으며, 당시 수익증권매수대금의 입금을 처리한 직원은 A씨(이하 “담당직원”이라 함)임.

아래의 신탁재산 중 MMF104호의 운용사는 사건 외 B투자신탁운용(주)이고 MMF

A8호의 운용사는 사건 외 C투자신탁운용임. 2003.3.11. ○○(주)의 분식회계사건이 발생하자 대량 환매요구로 인한 유동성부족을 원인으로 3.11. B투자신탁운용, 3.12. C투자신탁운용이 판매회사인 피신청인에게 환매유예조치를 각 통보한 사실이 있음.

가입일자	신탁재산명	가입금액	(주)○○ 유가증권 편입 여부
2002.12.27.	MMF104호	12,500,000원	유
2003. 1.14.	MMFD-3호	17,000,000원	무
2003. 1.29.	MMF A8호	141,000,000원	유
계		170,500,000원	

이에 따라 피신청인은 각 영업점에 ○○(주)와 관련한 CP 및 회사채가 편입된 펀드의 수익자에게 2003.3.12.부터 환매유예 사실을 통보하기 시작하였고, 피신청인의 지점은 2003.3.13부터 (주)○○ 유가증권이 편입된 신탁재산 가입자들에게 유선연락을 하였으며, 신청인은 지점으로부터 전화를 받기 전에 스스로 지점에 연락을 하여 환매유예사실을 인지함. 위 MMF의 환매유예조치로 인하여 신청인은 투자원금 대비 아래와 같은 손해를 본 사실이 있음.

신탁재산명	입금액	환매출금액	2003.6.27. 평가액	손실액
MMF104	12,500,000원	12,222,816원	34,014원	243,170원
MMF A8호	141,000,000원	134,411,136원	-	6,588,864원
계				6,832,034원

나. 당사자의 주장

(1) 신청인의 주장

신청인은 피신청인이 판매한 MMF신탁재산에 가입하였으나 가입당시 직원으로부터 신탁재산에 대한 설명을 전혀 받지 못하였고 직원이 임의로 MMF신탁재산에 가입시켰음. 2003.3.11. (주)○○의 분식회계사건이 발생하였음에도 자신에게는 동 사실을 알려주지 않아 환매를 청구할 수 있는 기회를 상실하게 하였으므로 이는 증권회사가 고객재산 보호를 소홀히 한 것인 바, 이에 대한 손해배상을 요구함.

(2) 피신청인의 주장

신청인은 과거부터 직원이 알아서 MMF신탁재산을 매수하여 줄 것을 요청해 왔으며, 가입시 마다 수익증권주문표에 투자신탁설명서 교부에 관한 확인을 받아 온 바 있음. 본 건 2002.12.27. 12.5백만원, 2003.1.14. 17백만원, 1.29. 141백만원 총 170.5백만원의 MMF 신탁재산에 가입할 당시에도 신청인은 직원에게 알아서 MMF신탁재산을 매수하여 달라고 부탁하여 직원이 수익률을 검토한 후 가입하게 된 것으로 신청인은 과거에도 MMF 신탁재산에 가입한 경험이 있는 등 MMF에 대하여는 풍부한 경험과 지식이 있는 자임. 또한 신청인이 이의를 제기한 3개 신탁재산 중 (주)○○ 유가증권이 편입된 신탁재산은 MMF104호와 MMF A8호이며 수익증권의 판매회사인 피신청인은 각 운용사로부터 환매유예를 통보 받은 즉시 수익자들에게 이를 통보하였으므로 선관주의의무를 다하였음.

다. 위원회의 판단

◆ 본건에 있어서의 쟁점은 피신청인 담당직원이 본건 MMF가입시 설명의무를 위반하였는지 여부 및 MMF신탁자산 내에 (주)○○ 관련 유가증권 편입여부를 수익자들에게 미리 알려 주어 환매를 요구할 수 있는 기회를 제공할 의무가 있는지 여부라고 할 것임.

(1) 설명의무 위반여부

수익증권의 판매회사의 임직원이 고객에게 투자신탁상품의 매입을 권유할 때에는 그 투자에 따르는 위험을 포함하여 당해 투자신탁의 특성과 주요내용을 명확히 설명함으로써 고객이 그 정보를 바탕으로 합리적인 투자판단을 할 수 있도록 고객을 보호하여야 할 주의의무가 있고, 이러한 주의의무를 위반한 결과 고객에게 손해가 발생한 때에는 불법행위로 인한 손해배상책임이 성립한다고 할 것임.

일반적으로 MMF의 경우에는 투자에 따르는 위험과 관련하여 투자권유자는 채권시장의 시가변동에 의한 위험, 발행주체의 신용위험, 이로 인하여 원본 손실의 가능성이 있다는 사실 등을 설명하여야 할 것이나, 고객에게 어느 정도의 설명을 하여야 하는지는 투자대상인 상품의 특성 및 위험도의 수준, 고객의 투자 경험 및 능력 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 함.

신청인은 본건 MMF에 가입당시 관련직원으로부터 가입 신탁재산에 대한 설명을 듣

지 못하였다 주장하고, 담당직원 또한 신탁재산에 대한 설명을 하지 않았으나 이는 신청인이 과거와 같이 알아서 MMF에 가입하여 달라고 하여 한 것이라고 주장하므로 살펴 건대, 2003.1.29. 가입한 MMF A8호(가입금액 141백만원)의 수익증권주문표에 신청인의 기명·날인이 누락된 사실은 인정되나 이러한 점만을 가지고는 설명의무를 해태하였다고 인정하기 부족하고, 오히려 아래의 각 점을 종합하면 신청인에게 담당직원이 MMF를 권유함에 있어 필연적으로 수반하는 위험성을 숨기고 오로지 장점만을 부각하여 설명함으로써 위험성에 대한 올바른 인식형성을 기망적 수단으로 방해했거나 적합성원칙에 위배하여 적극적 권유를 하였다고 볼 수 없으므로 신청인의 이 부분 주장은 이유 없다 할 것임.

① 신청인이 비록 노령이기는 하나, 신청인은 1991년부터 주식거래 내지는 공모주청약을 통한 거래를 해 온 경험이 있는 점.

② 신청인은 MMF가 은행의 예금과 같은 개념으로 이해하고 거래하였다고 주장하나, 신청인의 신탁재산 가입현황을 보면 1999.8월부터 모두 MMF신탁재산에만 가입하여 MMF신탁의 상품구조에 대하여 지식이 없는 문외한으로 보기 어려운 점.

③ 이러한 신청인의 MMF투자에 있어 1999.8.6.~2002.12.23. 기간에 MMF거래 중 매수만 83회에 이르고 동종 수익증권 매수 또한 10회에 이르는 점.

④ 조사결과, 신탁재산 가입시 투자신탁설명서를 교부받았다는 내용이 포함된 수익증권 주문표를 작성한 경우와 작성하지 않은 경우가 있으나, 분쟁이 되고 있는 위 3개 신탁재산 중 2002.12.27. MMF104호 및 2003.1.14. MMF D-3호의 경우 신탁재산의 수익증권 주문표가 작성되었을 뿐 아니라 투자신탁설명서를 교부받았다는 확인란에 신청인의 기명·날인이 존재하는 점.

⑤ 신청인이 기존에 가입하여 이익을 제기하고 있지 아니한 다른 MMF와 본건 MMF 사이에는 그 운용방식이나 운용제한, 편입자산의 종류가 차이가 나지 않고, MMF D-3호와 MMF A8호는 과거에도 가입한 경험이 있어 「증권업감독규정」 제54조 제6항에 비추어 판매회사인 피신청인은 투자신탁설명서의 제공을 생략할 수 있는 점.

⑥ 신청인은 문제되는 2002.12.27. 신탁재산 가입 이전에 수익증권 주문표를 작성하지

않고 가입한 신탁재산에 대해서는 이의를 제기하지 않고 있는 점.

⑦ 수익증권주문표상의 신청인의 기명·날인이 없는 MMF A8호(2003.1.29.자 가입금액 141백만원)에 대하여는 피신청인이 제출한 CCTV녹화 비디오 테이프를 보면, 2003.1.29. 11:41~11:46 사이에 신청인이 피신청인 지점을 내방하자 직원들이 인사를 하고 관련직원에게 통장 등을 제시하며 대화를 나누고는 담당직원이 통장정리를 하여 신청인에게 건네주자 이를 확인하고 있어 신청인 주장처럼 임의가입의 여지가 없는 점.

⑧ 문답결과, 담당직원은 신청인의 MMF 가입목적이 공모주 등에 주로 투자하기 위함이며, MMF에 가입하거나 추가로 수익증권 매수를 할 때마다 신청인은 과거와 같이 알아서 MMF에 가입하여 달라고 하고 담당직원이 수익률을 비교하여 가입하였다고 진술하고 있는 점.

(2) 환매에 관련한 선관주의의무 위반 여부

수익증권의 판매회사는 「증권투자신탁업법」과 「수익증권위탁판매계약 및 투자신탁약관」에 따라 수익증권의 판매와 환매 기타 이에 관련된 부수적인 업무를 수행하는 자임.

신청인은 (주)○○의 회계분식 사건에 대해 피신청인 측으로부터 환매에 관한 정보를 제공받지 못하여 환매를 신청할 기회를 상실하였다고 주장하며 고객보호의무 내지는 선관주의의무 위반에 따른 손해배상을 구하고 있으나, 현행 「증권투자신탁업법」과 동 「시행령」, 「증권투자신탁업감독규정」, 당해 약관 등에는 환매유예조치에 대하여 판매회사는 이를 수익자에게 통지할 의무만 있을 뿐, 적극적으로 환매기회를 수익자에게 보장해야 하는 의무조항이 없으며, 신청인의 주장과 같이 피신청인이 수익자들에게 ○○의 분식회계 및 환매를 해야 한다는 취지의 통지를 해야 한다면, 이러한 내용의 통지를 모든 수익자에게 동일한 시간대에 할 수도 없을 뿐 아니라 나중에 환매를 청구하거나 환매를 청구하지 못한 수익자들과의 형평성 즉 집합투자기구로서 증권투자신탁제도가 가지는 수익자평등의 원칙을 해할 수 있고, 대량 환매에 따르는 신탁재산의 소멸은 증권투자신탁의 자본적 성격에도 반한다고 할 것이므로 신청인의 청구는 이유 없다고 할 것임.

라. 결 론

그렇다면 피신청인은 업무처리에 있어 설명의무를 해태하여 고객보호의무를 해한 사실이 없을 뿐만 아니라 (주)○○의 분식회계사태로 촉발된 대량환매유예조치에 있어 선관주의의무를 위반한 사실이 없으므로 결국 신청인에게 배상책임이 없다고 할 것임.

1-20 투자경험이 풍부한 자에 대한 주식 부당권유 손해배상책임 성립 여부

[기각] 신청인은 장기간 투자경험이 있는 자로서 주식매수시에도 주문전표를 직접 작성하였고 다수의 신용거래를 해 온 점, 신청인은 원하는 때에 언제든지 주식매매를 할 수 있는 상황이었던 점 등을 감안시 피신청인이 고객보호의무를 위반하였다고 보기 어려움. 또한 신청인이 특정 주식을 매수하겠다는 주문전표를 제출하였음에도 담당직원이 다른 주식을 매수한 것은 사실이나, 이후 신청인이 해당 주식을 매수가 보다 높은 가격에 매도하여 이익이 발생하였으므로 담당직원의 잘못된 주문 이행으로 신청인에게 손실이 발생하였다고 보기 어려움.(2008.5.20. 조정번호 제2008-33호)

가. 사실관계

신청인은 1987.9.16. ○○증권사(이하 “피신청인”이라 함)에서 위탁계좌를 개설하여 주식거래를 시작하였으며, 1988.8.30. 신용거래를 신청하였음. 위 위탁계좌는 2004.5.17. 현재의 위탁계좌로 전환되었으며, 2007.1.18. 피신청인의 지점에 전입한 A차장(이하 “담당직원”이라 함)은 같은 달 31일자로 피신청인의 관리사원으로 등록되었음.

신청인은 2007년 상반기중에는 주로 직접 작성한 주문전표를 사용하여 주식거래를 하였고, 2007.7.24. 이후에는 HTS⁴¹⁹⁾를 이용하여 주식거래를 하였음.

신청인은 B기업 주식을 거래하여 현재는 동 주식 784주를 보유중인데, 신청인이 금감원에 분쟁조정을 신청한 2008.1.30. 현재 동 주식의 종가 12,700원을 기준으로 한 평가액은 9,956,800원임.

2007.7.16. 신청인은 C기업 주식 1천주를 매수하겠다는 주문전표를 작성하여 담당직원에게 제출하였는데, 담당직원의 실수로 D기업 주식 1천주가 주당 13,700원(매수대금:

419) 신청인이 이용한 HTS 거래의 IP 주소는 모두 피신청인 해당 지점의 컴퓨터 주소임.

13,700,000원)에 매수되었고, 신청인은 같은 해 10.16. D기업 주식 1천주를 주당 14,400원(매도대금: 14,400,000원)에 매도하였음.

신청인은 2007.7.19. E기업 주식 277주를 주당 11,250원(매수대금: 3,116,250원)에, 동 주식 1,223주를 주당 11,300원(매수대금: 13,819,900원)에 매수하여 총 1,500주(총 매수대금: 16,936,150원)를 보유중인데, 2008.1.30. 현재 동 주식의 증가 1,030원을 기준으로 한 평가액은 1,545,000원임.

나. 당사자 주장

(1) 신청인 주장

피신청인의 담당직원이 기업탐방을 갔다 왔는데 장래성이 큰 회사로 주가가 크게 상승할 것이라며 B기업 주식을 신용으로 매수하라고 적극 권유하여 동 주식을 매수하게 되었으나, 이후 동 주식의 주가가 하락함에도 담당직원은 기다려 보라며 아무런 조치 및 관리를 하지 않았고, 담당직원이 ◇◇도청과 연계된 사업을 한다면서 E기업 주식을 매수하도록 적극 권유하여 동 주식을 매수하였으나, 역시 동 주식의 주가가 하락함에도 담당직원은 매도권유도 하지 않는 등 고객보호의무에 따른 조치를 하지 않았으며, 신청인이 C기업 주식을 매수하기 위해 주문전표를 작성하여 제출하였으나 담당직원이 임의로 매수종목을 D기업으로 변경하여 동 종목을 매수하게 되는 등 담당직원의 고객보호의무 소홀로 인하여 신청인에게 약 1억원의 손실이 발생하였는 바, 피신청인은 위 손실액 중 50%를 배상할 책임이 있음.

(2) 피신청인 주장

신청인은 1987.9.16. 위탁계좌를 개설하여 주식거래를 시작하였으며, 1988.8.30. 신용계좌를 개설하여 신용을 주로 이용하여 거래를 하는 등 투자경력이 20년이 넘는 고객으로서, 담당직원의 투자조언을 바탕으로 관련 종목에 대하여 본인이 재차 검토하고 판단한 후 직접 자필로 매매주문표를 작성하여 매매거래를 하였을 뿐만 아니라, 담당직원이 B기업과 E기업 주식에 대해 차익실현 매도 및 손절매 조언을 하였음에도 신청인이 본인의 판단으로 매도를 하지 않아 손실이 발생한 것이며, C기업 주식 주문과 관련하여서는 담당직

원의 단순 착오로 D기업 주식이 매수되었으나, 착오매수 확인 후 담당직원이 신청인에게 원상회복 여부를 문의하자 신청인이 그냥 두라고 하였을 뿐만 아니라 D기업 주식 매수로 인하여 이익이 발생하였는 바, 피신청인은 손해배상 책임이 없음.

다. 위원회 판단

◆ 본건의 쟁점은 피신청인의 담당직원이 고객보호의무를 다하지 않았는지와 임의매매로 인한 손실 발생 여부라 할 것임.

(1) 부당권유 등 고객보호의무 위반 여부

판례는 거래경위와 거래방법, 고객의 투자상황(재산, 연령, 사회적 경험 등), 거래의 위험도 및 이에 관한 설명의 정도 등을 종합적으로 고려한 후, 증권회사 임직원의 권유행위가 경험이 부족한 일반 투자자에게 거래행위에 필연적으로 수반되는 위험성에 관한 올바른 인식형성을 방해하거나 또는 고객의 투자상황에 비추어 과대한 위험성을 수반하는 거래를 적극적으로 권유한 경우 위법성을 인정하고 있음.⁴²⁰⁾

신청인은 담당직원의 적극 권유로 B기업 주식과 E기업 주식을 매수하였으나 주가 하락시 동직원이 매도권유를 하지 않는 등 고객보호의무를 다하지 않아 손실이 발생하였다고 주장하나, 다음과 같은 점으로 보아 신청인의 위 주장은 이유 없음.

① B기업 주식과 퓨처비전 주식 매수 당시 담당직원이 어떠한 설명을 하였는지에 대하여는 당사자의 주장이 상반되고 있을 뿐 명확한 자료가 없으나, 신청인은 1987년부터 주식거래를 시작하여 약 20년의 투자경험이 있는자로서 위 주식들의 매수 당시에도 주문전표를 직접 작성하였을 뿐만 아니라, 1988년 신용계좌를 개설하여 신용거래를 한 이래 2007.6.5. 인프라웨어 주식을 신용으로 매수하기 이전까지 2007년 상반기중에도 이미 22회의 신용거래를 한 사실이 있는 것으로 보아 담당직원이 신청인에 대하여 거래행위에 필연적으로 수반되는 위험성에 관한 올바른 인식 형성을 방해하였다거나 과대한 위험성을 수반하는 거래를 적극적으로 권유하였다고 보기는 곤란하다는 점.

420) 대법원 2003.1.10. 선고 2000다50312 판결 참조.

② 신청인은 2007년 상반기 중에는 주문전표를 직접 작성하여 거래를 하였고, 동년 7.24. 이후에는 HTS를 이용하여 거래를 하였는바, 본인이 원하는 때에 언제든지 주식매매를 할 수 있는 상황이었으며, 특히 2008.3.10. 금감원에서 신청인과 담당직원에 대하여 실시한 문답서(이하 “문답서”라 함) 제10면을 보면, 신청인은 HTS 거래 시작 후에는 담당직원과 접촉을 하지 않았다고 진술하고 있으며, 담당직원도 이 시기에는 신청인이 주도적으로 매매를 하였으며 본인은 가끔 시황에 대하여 얘기했다고 진술하고 있는바, 2007.7.26. 이후 B기업이나 E기업 주식 거래에 대한 판단은 신청인에 의해 행하여진 것으로 볼 수 있다는 점.

③ 신청인과 담당직원 사이의 통화내용에 대한 녹취록(이하 “녹취록”이라 함) 제1~2면을 보면, 2007.6.22. 담당직원은 신청인에게 전화를 하여 B기업 주가가 올라오고 있다며 “오늘 고가에 한번 뒤야죠”라고 하였고, 이에 신청인은 “내가 한번 나가 볼게요”라고 하였는데, 실제 당일 B기업 주식 200주가 매수가 보다 높은 32,750원에 매도되었으며, 이외에도 2007.6.20.~7.23. 사이 4회에 걸쳐 B기업 주식 매도가 있었으나, 오히려 신청인이 HTS를 시작한 이후부터 2007.11.29.까지는 동 주식의 매도가 없었는 바, 담당직원이 매도추천을 하지 않아 신청인이 매도를 할 수 없었던 것이라고 보기는 어렵다는 점.

④ 문답서 제11면을 보면, E기업 주식 매수에 대한 최종적인 의사결정을 누가 하였냐는 질문에 신청인은 본인이 결정하였다고 진술하고 있으며, 동 주식을 매수한 2007.7.19. 직후인 2007.7.24.부터 신청인은 HTS 접속을 시작하여 거래를 하였다는 점.

(2) 임의매매로 인한 손실 발생 여부

2007.7.16. 신청인이 C기업 주식 1천주를 매수하겠다는 주문전표를 작성하여 담당직원에게 제출하였음에도 담당직원이 D기업 주식 1,000주를 매수한 것은 사실이나, 이후 신청인이 2007.10.16. D기업 주식을 매수가 보다 높은 14,400원에 매도하여 이익이 발생⁴²¹⁾하였는 바, 신청인에게 손실이 발생하였다고 보기 어려움.

라. 결론

421) C기업 주가는 종가를 기준으로 2007.7.16.에는 23,900원이었으나, 2007.10.16.에는 16,100원이었음.

그렇다면 피신청인은 신청인에 대하여 손해를 배상할 책임이 없다 할 것이므로 신청인의 청구는 이유 없어 이를 기각함.

1-21 파생결합증권 중도상환에 대한 설명의무 위반 여부

[일부인용] 녹취록에 의하면 담당직원은 신청인과의 통화과정에서 평가금액은 의미가 없고, 중도상환시 원금의 6%가 환매수수료로 적용되는 것으로 오인될 수 있는 표현을 사용하고 있다는 점, 중도상환에 관한 정확한 내용은 신청인의 중도상환여부결정 등 투자판단에 있어서 중요한 사항으로 볼 수 있는 점, 담당직원의 잘못된 설명으로 신청인은 중도상환 기회를 상실하였다고 볼 수 있고, 피신청인으로부터 ‘원금손실조건 해당 안내’를 받고서야 정확한 내용을 알게 되었다는 점 등을 고려하면 피신청인은 중도상환에 관한 설명 잘못 등 고객보호의무 위반으로 인한 손해배상 책임이 있다 할 것임.(2008.11.11. 조정번호 제2008-87호).

가. 사실관계

신청인은 피신청인이 송부한 “파생결합증권(DLS) 제9호”⁴²²⁾ 안내메일을 받고

422) “파생결합증권(DLS) 제9호” 상품의 개요는 다음과 같음.

- 기초자산 : WTI최근월선물, 니켈현물
- 만기지급일 : 2008.6.18(만기 1년, 매4개월마다 자동조기상환부여)
- 수익구조
 - 자동 조기상환/만기상환 : 연 18%
 - ① 첫 번째 자동조기상환평가일에 두 종목의 가격이 모두 최초가격의 85%이상
 - ② 두 번째 자동조기상환평가일에 두 종목의 가격이 모두 최초가격의 80%이상
 - ③ 최종기준가격 결정일에 두 종목의 가격이 모두 최초가격의 75%이상
(장중 최초가격 대비 55%이하로 하락한 적이 있는 경우 포함)
 - 만기상환 : 기준종목의 최종가격이 최초가격×75%미만이고, 두 기초자산 가격(장중가포함)이 모두 최초가격×55%미만으로 하락한 적이 없는 경우 연 5%
 - 만기상환 : $\{(\text{기준종목 최종기준가격} / \text{기준종목 최초기준가격}) - 1\} \times 100\%$
 - [만기까지 한 종목이라도 최초가격의 55%이하로 하락한 적이 있고(장중 포함)]+[두 종목중 한 종목이라도 만기평가가격이 최초기준가격의 75%미만이면] 원금손실(하락률이 큰 종목 기준)
 - 기준종목 : 두 기초자산 중 최초기준가격 대비 상승률이 낮은 종목

2007.6.12. 피신청인 강남지점을 방문하여 직원 A씨(이하 “담당직원”이라 함)와 상담 후 1천만원을 동 상품에 투자하였으며, 신청인은 가입 당시 「핵심설명서」와 「상품안내서」를 수령하고 「설명서교부 및 주요내용 설명확인서」에 자필서명함.

2007.9.13. 신청인은 유선상 담당직원에게 HTS 화면의 DLS 평가금액과 관련된 문의를 하였던 바, 실제 중도상환시 지급금액은 평가금액에 중도상환수수료(6%)를 부과하여 산정함에도 불구하고 담당직원은 평가금액은 의미가 없으며, 중도상환시 원금에 중도상환수수료가 적용된다는 취지로 안내함.

피신청인은 2008.6.2. 기초자산(니켈)가격이 하락하여 하방배리어에 도달하자(2008.5.29. 최초기준가격 대비 55% 하락), 신청인에게 본건 상품이 원금손실조건에 해당함을 통지하면서 주의사항으로 총 평가금액의 6%가 환매수수료로 청구됨을 안내하였고, 신청인은 이에 유선상 항의한 이후, 2008.6.18. 만기에 5,958,014원을 수령함.

나. 당사자의 주장

(1) 신청인의 주장

담당직원이 평가금액은 의미가 없고, 중도상환시 원금에 상환수수료율이 적용된다고 잘못 설명함으로써, 신청인은 중도상환시 평가금액이 아닌 원금에 중도상환수수료를 공제한 금액(940만원 상당)을 수령 가능한 것으로 잘못 알게 되었으며, 담당직원의 잘못된 설명이 없었다면 신청인은 평가금액 추이를 보아 중도상환여부를 결정하여 손실을 줄일 수 있었을 것인데 담당직원의 잘못된 설명으로 중도상환을 통해 손실을 줄일 수 있는 기회를 상실하였으므로 이로 인한 손해를 구함.⁴²³⁾

(2) 피신청인의 주장

신청인은 미리 상품안내장을 보고 내점하여 본 상품에 가입하였고, 가입당시 중도상환

423) 한편, 신청인은 본 상품이 원유와 니켈 2가지 광물에 투자하여 리스크를 감소시키기 위한 상품으로 설계된 것이고, 니켈에서 발생한 손실분을 원유에서 상쇄시킬 수 있음에도 불구하고 피신청인이 손실을 투자자에게 일방적으로 귀속시킨 것은 「공정거래법」 위반이라고 주장하나, 신청인 주장의 근거가 없고, 「공정거래법」 위반 여부는 금융분쟁조정위원회의 소관사항으로 보기 어려움.

에 관한 사항이 명시되어 있는 핵심설명서 등을 수령하였으며, 담당직원의 말을 신뢰했다고 하면서도 이후 HTS화면을 통하여 DLS 평가금액을 10회에 걸쳐 조회한 사실이 있을 뿐만 아니라, DLS와 기초자산만 다를 뿐 손익구조가 비슷한 ELS에 가입한 경험⁴²⁴⁾이 있음에 비추어 본건 상품 및 평가금액관련 사항에 대해 충분히 알고 있었다고 보임.

또한, 신청인은 민원서상 정기예금보다 높은 수익을 얻고자 동 상품에 가입한 것이라고 하고 있는 바, 조기상환 및 만기상환을 통하여 원금손실을 보지 않고 연 18% 또는 5%의 수익을 보고 투자를 결심한 것으로 보이며, 실제로 중도환매를 신청한 적도 없을 뿐만 아니라, 조건성취 여부를 고려하여 중도환매를 하지 않을 가능성도 존재하고, 실제 환매시 원금을 받을 가능성도 없었으므로 중도환매의 가능성은 낮은 것으로 보이며, 설령 중도환매를 했더라도 어느 시점에서 중도상환을 했을 지도 판단하기 어려운 점에 비추어 손해배상책임을 인정하기 어려움.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 파생결합증권 중도상환에 관한 설명잘못 등 고객보호의무 위반으로 인한 손해배상 책임의 인정여부라 할 것임.

(1) 고객보호의무 위반으로 인한 손해배상책임 성립여부

증권회사 직원은 고객에게 상품을 판매하는 경우 투자에 따른 위험을 포함하여 당해 상품의 특성과 주요 내용을 설명함으로써 고객이 그 정보를 바탕으로 합리적인 투자 판단을 할 수 있도록 고객을 보호하여야 할 주의의무가 있고, 중요한 사항에 관하여 올바른 인식형성을 방해하는 경우 고객보호의무를 위반한 것이라 할 것임.

2007.9.13.자 녹취록에 의하면 담당직원은 신청인과의 유선통화과정에서 평가금액은 의미가 없고, 중도상환시 원금에 6%가 환매수수료로 적용(940만원 상당의 상환금액)되는 것으로 오인될 수 있는 표현을 사용하고 있음.

424) 2006.8.29. ELS 220호 가입(1백만원, 조기상환 6만원 이익)

2007.5.30. ELS 374호 가입(2백만원, 조기상환 12만원 이익)

2008.3.11. ELS 510호 가입(2백만원, 조기상환 19만원 이익)

비록 상품판매시 상품설명서에 중도상환에 대한 정확한 내용이 적시되어 있다거나, 담당직원의 의사를 DLS의 경우 평가금액의 등락 보다는 상환조건의 충족여부에 관심을 가질 것을 강조하는 취지로 진술한 것이라고 선해한다고 하더라도, 중도상환에 관한 정확한 내용은 신청인의 중도상환여부결정 등 투자판단에 있어서 중요한 사항으로 볼 수 있고, 담당직원의 잘못된 설명으로 신청인은 최종 중도상환 가능일인 2008.6.2.까지 중도상환을 통하여 940만원 상당을 상환받을 수 있는 것으로 오인하여 중도상환 기회를 상실하였다고 볼 수 있고, 2008.6.2. 피신청인으로부터 “원금손실조건 해당 안내”를 받고서야 정확한 내용을 알게 되어 중도상환을 할 수 없었다고 볼 수 있으므로 피신청인은 이에 대한 책임이 있다 할 것임.

(2) 손해배상액 산정

신청인의 손해금액은 가입시 입금액 1,000만원에서 만기시 출금액 5,958,014원을 차감한 4,041,986원이라 할 것임. 다만, 신청인은 주식투자경험이 있으며, 사전에 상품 안내메일을 받고 내점하여 상품에 가입한 점, 본건 DLS 상품과 손익구조 등이 유사한 ELS에 가입한 경험이 있는 점, “설명서 교부 및 주요내용 설명 확인서”에 자필서명하고 있는 점, 상품설명서를 검토하였다면 중도상환 내용에 대해서 충분히 알 수 있었음에도 이를 확인하지 아니한 점, 담당직원과 유선통화 이후에도 평가금액을 확인을 하고 있으며, 다 소리스크를 감소하더라도 높은 수익을 얻고자 투자를 하였고, 조건성취 여부를 고려하여 중도상환을 신청하지 아니한 것으로 보이는 등 투자수익을 중시하고 있으면서도 자기재산관리를 소홀히 한 책임 등을 고려하여, 70%의 과실상계를 함이 타당함.

라. 결 론

그렇다면 피신청인은 신청인에게 손해금액 4,041,986원에서 신청인의 과실 70%를 상계한 나머지 금액 1,212,596원을 배상할 책임이 있어 이를 인용하고, 신청인의 나머지 청구는 이유 없어 기각함.

1-22 원금보장 약속 등을 통한 환매보류 권유로 인한 손해배상책임 여부

[일부인용] 신청인은 기존에 펀드투자 경험이 있고, 조기상환 및 중도환매한 경험도 있는 등 펀드가입권유시 원금보장 등 적극적인 부당권유를 한 사실을 인정하기 어려운 점 등에 비추어 담당직원이 부당하게 펀드가입을 권유하였다고 보기는 어렵다 할 것이나, 녹취록에 의하면, 신청인의 거둬들인 환매의사 표시에 대한 담당직원이 향후 전망에 대한 단순한 의견표시를 넘은 단정적인 환매보류 권유를 하고 나아가 원금·수익보장을 약속하며 환매보류를 적극적으로 권유하였으므로 이는 위법하다고 할 것임.(2009.2.10. 조정번호 제2009-12호)

가. 사실관계

신청인은 2001년부터 ○○증권회사(이하 “피신청인”이라 함)의 지점에서 거래를 하여 오던 중 2007년경부터 피신청인 직원(이하 “담당직원”이라 함)이 이를 관리하였는데, 동 직원의 권유로 2008.5.9. A씨 명의로 ○○파생상품1호에 1억원을 가입한 것을 비롯하여 자녀 3명의 명의로 총 4개의 ELF에 가입함(총 가입금액 243백만원).

2008.8.5. 신청인은 자녀 C씨 명의의 펀드를 환매하고 채권형펀드로 교체를 요구하였으나, 담당직원은 원금손실조건인 1,200 포인트 이하로 하락할 경우 집을 팔아서라도 책임을 진다고 하는 등 환매보류를 권유하였으며, 이후 신청인이 수차 동 펀드에 대한 환매의사를 표명하였으나 담당직원의 환매보류 권유에 의해 환매를 하지 아니하였다가, 같은 해 10.28. C씨 명의, 12.11. 및 2009.1.22.에 B씨 명의의 펀드를 각각 환매함.

나. 당사자 주장

(1) 신청인 주장

담당직원이 펀드가입 권유시 절대 손해 볼 일이 없고 집을 팔아서라도 보장한다는 등 부당하게 펀드 가입을 권유하였고, ○○○ 명의 펀드의 경우, 담당직원이 신청인이 기가입한 채권형 펀드를 임의로 해지하고 가입시킨 것임. 가입 이후에도 신청인의 환매요구시, 담당직원이 원금보장 등을 약속하고 환매를 거부하여 손실을 입음.⁴²⁵⁾

(2) 피신청인 주장

신청인은 채권형펀드 이외에도 글로벌 부동산펀드, 차이나주식형펀드, ELF 등 다양한 금융상품에 투자하여 중도환매 및 조기상환을 받은 경험이 있는 사람이며, 담당직원은 신청인에게 펀드의 손익구조와 손실위험 등에 대해 충분한 설명을 하였고, 신청인의 환매요청시 담당직원은 향후 펀드의 전망에 대한 의견을 표시를 한 것에 불과하고, 환매여부에 대한 최종적인 결정은 신청인의 의사에 기한 것이라 할 것이므로 배상책임이 없음.

다. 위원회 판단

◆ 본건의 쟁점은 펀드가입 부당권유 및 부당한 환매보류 권유여부라 할 것임.

(1) 펀드가입 부당 권유

수익증권 판매회사의 임직원이 고객에게 투자신탁상품의 매입을 권유할 때에는 그 투자에 따르는 위험을 포함하여 당해 투자신탁의 특성과 주요 내용을 설명함으로써 고객이 그 정보를 바탕으로 합리적인 투자판단을 할 수 있도록 고객을 보호하여야 할 주의의무가 있고,⁴²⁵⁾ 거래 경위와 방법, 고객의 투자상황, 고객의 증권투자경험 및 지식의 정도, 거래의 위험도 및 그 설명정도 등을 종합적으로 고려한 후, 당해 권유행위가 수익증권의 매입에 필연적으로 수반되는 위험성에 관한 올바른 인식 형성을 방해하여 투자판단을 그르치게 한 경우에 해당되거나 고객에게 과대한 위험성을 수반하는 거래를 적극적으로 권유한 경우에 해당하여 결국 고객에 대한 보호의무를 저버린 경우에는 위법하다 할 것임.⁴²⁷⁾

신청인은 담당직원이 부당하게 펀드가입을 권유했다고 주장하나, 다음과 같은 점에 비추어 담당직원이 부당하게 펀드가입을 권유하였다고 보기는 어렵다 할 것임.

① 신청인은 기존에 펀드에 투자한 경험이 있고, 기존에 가입한 펀드도 채권형 펀드에

425) 다만, 분쟁조정신청 대상은 환매한 펀드에 한정하여 66,307,032원의 손해배상을 구함.

426) 대법원 2006.5.11. 선고 2003다51057 판결 참조.

427) 대법원 1998.10.27. 선고 97다47989 판결 참조.

한정되지 않고 주식형, ELF 등을 포함하고 있으며, 조기상환 및 중도환매 한 경험도 있으며, 이전에 ELF 가입시 손실 및 수익구조에 대한 설명을 받고 있는 점.

② 신청인이 “투자설명서 교부 및 주요내용 설명확인서”에 자필서명하고 있으며, 녹취록상 신청인 주장과 같이 담당직원이 펀드가입권유시 원본보장 등 적극적인 부당권유를 한 사실을 인정하기 어려운 점.

③ 각 펀드의 가입경위를 보면, B씨 명의의 경우 기존 펀드를 조기상환 받아 가입하였고, 다만 C씨 명의의 경우 신청인은 담당직원이 기존 펀드를 임의로 중도해지하고 가입한 것이라고 주장하나 이를 확인하기 어렵고, 설령 기존펀드를 임의해지 했다고 하더라도 신청인이 본건 펀드에 가입하여 임의해지를 추인하고 있다고 볼 수 있는 점.

(2) 부당한 환매보류 권유 여부

거래의 중단을 요청하는 고객에게 수익보전 등을 약속하며 계속거래를 적극적으로 권유하는 것은 거래의 위험성에 관한 올바른 인식형성을 방해하는 불법행위에 해당한다 할 것인 바,⁴²⁸⁾ 신청인은 2008.8.5. 담당직원에게 C씨 명의 계좌에 대한 환매의사를 표시한 이후 거듭하여 환매의사를 표시하였는 바, 녹취록에 비추어 보면, 신청인의 거듭된 환매 의사표시에 대한 담당직원의 대응은 향후 전망에 대한 단순한 의견표시를 넘은 단정적인 환매보류 권유에 해당할 뿐만 아니라 원금, 수익보장을 약속하며 환매보류를 적극적으로 권유한 것에 해당하여 위법하다고 할 것임.

(3) 손해배상액 산정

신청인의 손해금액은 신청인이 C씨 계좌에 대해 최초 환매의사를 표시한 2008.8.5.을 기준으로 한 환매예상금액 93,598,418원에서 실제 환매시 출금액 52,024,888원을 차감한 41,573,530원이라 할 것이나, 신청인이 종래 펀드에 투자한 경험이 있는 점, 투자자는 자신의 판단과 책임으로 투자하여 투자손실을 스스로 부담함이 원칙으로 신청인 스스로 펀드의 환매를 결정할 수 있었다는 점을 고려하여 40% 과실상계를 함이 타당함.

428) 대법원 1996.8.23. 선고 94다38199 판결 참조.

라. 결론

피신청인은 신청인에게 손해금액 24,944,118원을 배상할 책임이 있어 이를 인용하고, 신청인의 나머지 청구는 이유 없어 기각함.

1-23 환매보류의 적정성 및 사후관리 소홀로 인한 손해배상책임 여부

[기각] 신청인이 피신청인에게 환매를 신청한 객관적인 증빙이 없고, 피신청인이 신청인의 환매요청을 거부할 특별한 이유를 찾기 어려운 점, 신청인이 과거 펀드를 환매한 경험이 있어 신청인 스스로 환매지시를 할 수 있다고 보이는 점 등에 비추어 신청인의 환매요청을 부당하게 거부했다는 주장은 이유 없음. 또한 펀드 가입시 작성한 “투자설명서 교부 및 주요내용 설명 확인서”에 신청인이 자필서명하였고, 피신청인이 신청인에게 정기적으로 자산운용보고서를 우편 송부하는 등 피신청인의 사후관리가 소홀하였다는 신청인의 주장도 이유 없음. (2009.4.14. 조정번호 제2009-35호)

가. 사실관계

신청인은 2005.7.12. ○○증권(이하 “피신청인”이라 함) 지점에서 투자신탁계좌를 개설한 이래 6개 계좌를 개설하였으며, 2009.3.24. 기준 현재 동 계좌에서 180,332,592의 평가손실⁴²⁹⁾이 발생함.

나. 당사자의 주장

(1) 신청인의 주장

2007년 11월경 주가 최고점일 때 약 5억원의 투자에 대한 수익실현요구를 수차례 했음에도 매번 거절당하여 수익을 실현하지 못하였고 고객의 성향에 따른 고객관리가 이루어지지 않았으므로 이에 대한 보상을 구함.

429) 신청인이 수익실현을 요구했다고 주장하는 2007.11.30. 기준으로는 약 50백만원의 평가이익이 발생.

(2) 피신청인의 주장

신청인은 과거에 환매를 한 경험이 있고, 수익실현을 고려하였다면 환매를 요구하였어야 할 것임에도 신청인은 환매를 요구한 적이 없으며, 신청인 주장과 같이 담당직원이 환매보류를 권유한 적도 없고, 최종 투자의사결정은 투자자의 판단과 책임으로 이루어지는 것이므로 투자결과에 대해 판매사에게 책임을 묻는 것은 수익자 위험부담원칙과 실적배당원칙에 어긋남.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 피신청인의 부당한 환매보류 권유 내지 환매거부 여부 및 사후관리의무 위반여부라 할 것임.

거래의 중단을 요청하는 고객에게 수익보전 등을 약속하는 등 계속거래를 적극적으로 권유하는 것은 거래의 위험성에 관한 올바른 인식형성을 방해하는 불법행위에 해당한다 할 것으로,⁴³⁰⁾ 피신청인이 부당하게 환매보류를 권유하거나 신청인의 환매요청을 거부한 경우 불법행위에 해당한다 할 것임.

다만, 앞서 본바와 같이 2007.11.30. 기준으로 신청인이 약 50,540,903원의 평가이익을 실현한 사실은 인정되나, 피신청인이 신청인의 수익실현요구를 부당하게 거부했다는 주장은 다음과 같은 점에 비추어 이유 없다 할 것임.

우선, 신청인이 피신청인에게 수익실현을 위하여 구체적으로 환매를 신청한 객관적인 증빙이 없고, 신청인은 담당직원이 “지금 빠지면 못들어가요. 두 번 다시 못들어가요. 그런 사람 어디 한 둘인가요. 더 오를테니 두고 봐요.”라고 응대하는 등 신청인의 수익실현 요구를 무시하였다고 주장하나, 관련 직원이 신청인 주장과 같이 진술한 사실 또한 이를 인정할 객관적인 자료가 없음.

달리, 신청인이 환매를 요청하는 경우, 피신청인이 이를 거부할 특별한 이유를 찾기 어렵고, 더욱이 신청인은 과거 펀드를 환매한 경험이 있어 신청인 스스로 환매지시를 할

430) 대법원 1996.8.23. 선고 94다38199 판결 참조.

수 있다고 보이는 점.

한편, 신청인은 수익실현을 위한 피신청인의 고객관리가 제대로 이루어지지 않았다 주장하나, 2005.12.23.부터 2007.10.30까지 펀드에 가입하면서 작성된 것으로 보여지는 「투자설명서 교부 및 주요내용 설명 확인서」에 신청인이 “투자설명서를 제공받고 그 주요 내용을 설명 들었다”라는 투자자 확인사항에 자필로 서명한 사실이 있으며, 피신청인이 제출한 「자산운용보고서 수령정보」에 의하면 피신청인이 자산운용보고서를 우편송달 방법으로 신청인 자택에 송부한 사실이 인정됨.

또한, 수익증권을 판매하는 증권회사는 고객에게 거래에 수반하는 위험성에 관하여 충분한 설명의무를 부담하나 수익 및 손실의 동향을 설명하고 중도상환을 권유해야 할 부수적 의무까지 부담한다고 보기는 어렵고, 최종적인 투자의사결정 주체는 투자자 본인으로, 투자자는 증권회사가 제공하는 정보에 기하여 그 위험을 정확히 이해하고 그 위험이 현실화 되었을 때에 이를 감당할 수 있는 지를 스스로 판단한 후에 거래를 하여야 하며 그 결과에 대하여 책임을 져야하는 것이 원칙이라고 할 수 있는 점에 비추어 신청인의 주장은 이유 없다 할 것임.⁴³¹⁾

라. 결 론

그렇다면 피신청인은 신청인에 대하여 손해를 배상할 책임이 없다 할 것이므로 신청인의 청구는 이유 없어 이를 기각함.

1-24 간투법상 반대주주가 주식매수청구권 행사시 환매연기규정 적용 여부

[일부인용] 간투법상 일반적인 환매청구시 환매연기사유와 반대주주의 주식매수청구시 연기 사유가 다를 뿐만 아니라, 반대주주의 주식매수청구시 매수를 연기하기 위해서는 금융위원회의 승인이라는 요건을 규정하고 있는 점(동법 제73조), 반대주주의 주식매수청구와 환매청구는 투자회사의 재산으로 주식을 매수한다는 점에서는 동일하나 전자는 투자회사의 조직법적

431) 대구지방법원 2007.5.8. 선고 2006가합8478 판결 참조.

의사결정(합병, 정관변경) 과정에서 다수 주주의 의사결정으로부터 소수 주주의 이익을 보호하려는 것임에 반하여, 후자는 주주 개인 사정에 기인한 투자금 회수를 위한 환가방법으로 제도의 취지가 본질적으로 다르다고 볼 수 있는 점 등에 비추어 반대주주의 주식매수청구를 일반적인 환매청구로 보고 환매연기사유를 이유로 주식매수를 연기할 수는 없다 할 것임. (2009.7.13. 조정번호 제2009-64호).

가. 사실관계

피신청인은 구 「간접투자자산운용업법」(이하 ‘간투법’이라 함)상 부동산투자회사로 ○○자산운용이 법인이사로 동사를 대표하고 업무집행 및 자산운용을 담당함.

투자회사 개요

- 성격 : 환매금지형, 공모형 부동산투자회사
 - 간접투자자산을 부동산에 투자하는 간접투자기구로 원칙적으로 주식의 환매청구가 금지
 - 공모형(공모형 환매금지 투자회사는 주주의 환금성 보장을 위해 그 주식을 최초 발행일로부터 90일 이내에 상장)
- 설정일(액) : 2005.*.**.(166억원) 존립기간 : 2009.*.**. 상장일 : 2005.*.**.
- 총 주식주(주주수) : 4,100,378(481명)
 - * 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 부칙 제28조에 의해 동 법 시행당시 종전 간투법에 의해 설립된 투자회사는 간투법에 따름

2009.4.14. 피신청인은 글로벌 금융위기, 부동산시장 침체, 연대보증사인 시공사의 유동성 악화⁴³²⁾ 등으로 펀드의 존립기간인 2009.4.15. 이내에 펀드의 투자원리금 회수가 어려운 상황을 이유로 존립기간연장을 위한 연기주주총회를 개최하였으며, 참석주주(55명, 주식수: 31.42%) 91.27% 찬성으로 동사의 존립기간을 2009.4.15.에서 2010.10.14.로 연장하는 정관변경을 결의함.

신청인은 “주주총회 의결 반대의사 통지서”에 의하여 주주총회 의결에 반대의사를 표시하고 신청인이 소유하고 있는 14,010주에 대하여 주식매수청구권⁴³³⁾을 행사하였으나,

432) 2009.*.**, ◇◇건설(2009.1.20. 신용위험평가 결과 D등급) 대출금 62억원 중 29억원을 부실자산 상각 처리(기준가: 5,064원→4,345원)

피신청인은 신청인의 주식매수청구를 환매청구로 보아 환매연기를 결정⁴³⁴⁾하고 신청인의 주식매수청구에 따른 지급예정일⁴³⁵⁾에 이를 지급하지 아니함.

한편, 피신청인은 2009.5.6. 이사회에서 이익초과분배금(현금 17억원 상당) 지급을 결정하고 2009.6.4. 이익초과분배금을 지급하였고, 6.5. 자산재평가(실물자산: 126억원→94억원, 기준가: 3,944원→3,175원)를 실시함.

나. 당사자의 주장

(1) 신청인의 주장

당초 만기까지만 보유할 목적으로 주식을 매수하였으며 동 주식은 시장에서 정상적으로 거래되고 있지도 않아, 투자금을 회수하기 위해 투자회사 존립기간 연장을 위한 정관 변경 주주총회 의결에 반대의사를 표시하고 주식매수청구권을 행사하였음에도 불구하고 피신청인이 이에 응하지 않은 것은 부당함.

(2) 피신청인의 주장

간투법 제73조 및 제76조에 의하면 투자회사의 존립기간을 변경하는 정관의 변경에 대한 주주총회의 의결에 반대하는 주주는 주식매수청구권을 행사할 수 있으나 매수자금의 부족으로 매수에 응할 수 없는 경우에는 금융위원회의 승인을 얻어 주식의 매수를 연기할 수 있음.

한편, 간투법 시행령 제67조에 의하면, 투자회사재산으로 주식을 매수하는 경우에는 매수청구기간의 종료일에 환매청구한 것으로 보아 정관에서 정하는 바에 따라 매수하여야 한다고 규정하고 있는 바, 동법 제65조에 따르면 환매에 응하여야 하는 투자회사는

433) 주식매수청구권 행사주주: 총7명, 85,067주(행사기간: 2009.4.7~5.4.)

434) 2009.4.27. 피신청인 위험관리위원회는 주식매수청구를 환매청구로 보고 간접투자자의 이익 또는 형평성을 해할 우려가 있는 경우에 해당함을 이유로 반대주주의 주식매수청구에 대하여 환매연기 의결하였고, 5.19. 이사회를 개최하여 “반대주주의 주식매수청구에 대한 환매연기의 건”에 대한 임시주주총회를 7.1. 개최하기로 결정함.

435) 기준가격용일·지급예정일: 2009.5.19.(주식매수청구시 매수청구기간 종료일에 환매청구한 것으로 보고 환매청구일로부터 10영업일에 공고되는 기준가격으로 환매대금을 지급, 정관 제22조, 제37조)

투자증권의 매각이 불가능한 경우 등 대통령령이 정하는 사유(동법 시행령 제62조)로 인하여 투자회사의 정관에서 정한 환매일에 간접투자증권을 환매할 수 없게 된 경우에는 당해 투자회사는 환매를 연기할 수 있다고 규정하고 있으며, 당해 투자회사의 정관 제26조도 동법 시행령 제62조의 환매연기사유가 발생하였을 때는 환매를 연기할 수 있다고 규정하고 있으므로, 동 건의 경우 주식매수청구를 환매청구로 보고 간접투자자의 이익 또는 형평성을 해할 우려가 있는 경우에 해당함을 이유로 반대주주의 주식매수청구에 대하여 환매연기를 한 것임.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 간투법상 투자회사 정관의 중요내용 변경시 인정되는 반대주주의 주식매수청구를 일반적인 환매청구로 보아 간투법 제65조의 환매연기사유를 이유로 주식매수를 연기할 수 있는지 여부라 할 것임

(1) 관련규정

1) 간투법상 반대주주의 주식매수청구관련 규정

간투법상 투자회사의 존립기간 변경 등 정관의 중요한 내용 변경에 대한 주주총회의 의결에 반대하는 주주는 주주총회 전에 당해 투자회사에 대하여 서면으로 그 의결에 반대하는 의사를 통지하고 주주총회 의결일로부터 20일 이내에 주식의 수를 기재한 서면으로 자기가 소유한 주식의 매수를 청구할 수 있고(동법 제76조, 제73조, 제44조), 투자회사는 위 규정에 의한 매수청구가 있는 경우 매수청구기간이 만료한 날부터 15일 이내에 당해 투자회사 재산으로 대통령령이 정하는 바에 따라 그 주식을 매수하여야 하며, 이 경우 매수청구기간의 종료일에 환매청구한 것으로 보아 투자회사의 정관에서 정하는 바에 따라 매수하여야 하되(동법 시행령 제67조), 다만 매수자금의 부족으로 매수에 응할 수 없는 경우에는 금융위원회(금융감독원장에게 위탁)의 승인을 얻어 수익증권의 매수를 연기할 수 있음(동법 제73조).

2) 간투법상 환매연기관련 규정

간접투자자는 언제든지 간접투자증권의 환매를 청구할 수 있되(동법 제 62조), 환매를 요구받은 투자회사가 투자증권의 매각이 불가능한 경우 등 대통령령이 정하는 사유로 인하여 투자회사의 정관에서 정한 환매일에 간접투자증권을 환매할 수 없게 된 경우에는 투자회사는 환매를 연기할 수 있고 이 경우, 투자회사는 환매를 연기한 날로부터 6주 이내에 주주총회에서 대통령령이 정하는 바에 따라 간접투자증권의 환매에 관한 사항을 의결하여야 하는 것으로 규정(동법 제65조).

3) 당해 투자회사 정관

회사 존립기간을 변경하는 주주총회의 의결에 반대하는 주주가 주주총회 전에 회사에 대하여 서면으로 그 의결에 반대하는 의사를 통지하는 경우 그 주주는 주주총회의 의결 일로부터 20일 이내에 주식의 수를 기재한 서면으로 주식의 매수를 청구할 수 있고, 주식 매수청구가 있는 경우 매수청구기간의 종료일에 환매청구한 것으로 보아 제22조(환매가격 및 환매방법)⁴³⁶⁾의 규정에 따라 주식을 매수하며, 다만 매수자금의 부족으로 매수에 응할 수 없는 경우에는 감독원장의 승인을 얻어 주식의 매수를 연기할 수 있도록 규정하고 있으며(제37조), 주주는 원칙적으로 주식의 환매를 청구할 수 없되, 주식 상장 전(최초증자일로부터 90일 이내) 주주가 사망하거나 주주인 법인이 법정관리, 화의신청, 해산하는 때에는 환매를 청구할 수 있고(제21조), 환매를 요구받은 회사의 재산매각이 사실상 불가능하여 사실상 환매에 응할 수 없거나 주주의 이익 또는 주주간의 형평성을 해할 우려가 있는 경우 등에는 환매를 연기할 수 있음(제26조).

(2) 관련규정의 해석

다음과 같은 점에 비추어, 반대주주의 주식매수청구를 일반적인 환매청구로 보고 환매 연기사유를 이유로 주식매수를 연기할 수는 없다 할 것임.

① 간투법상 간접투자자는 언제든지 간접투자증권의 환매를 청구할 수 있고(동법 제 62조), 환매에 응하여야 하는 투자신탁의 자산운용회사나 환매를 요구받은 투자회사가 투자증권의 매각이 불가능하여 환매에 응할 수 없거나 주주의 이익 또는 주주간의 형평성을 해할 우려가 있는 경우 등에는 환매를 연기할 수 있는 것이 원칙이나(동법 제65

436) 주식의 환매가격은 환매청구일부터 10영업일에 공고되는 기준가격으로 하고, 10영업일에 환매대금을 지급

조), 한편, 간투법은 부동산투자회사를 환매금지형으로 할 것을 의무화하고 있어(동법 제143조), 환매금지형 부동산투자회사에 대하여 환매가능한 간접투자기구를 전제로 한 환매연기 관련 규정이 일반적으로 적용된다고 보기 어려운 점.

② 간투법상 일반적인 환매청구시 환매연기사유와 반대주주의 주식매수청구시 연기사유가 다를 뿐만 아니라, 간투법은 환매청구시의 환매연기사유(동법 제65조)와 별도로 반대주주의 주식매수청구시 매수를 연기하기 위해서는 금융위원회의 승인이라는 요건을 규정하고 있으므로(동법 제73조), 반대주주의 주식매수 연기는 매수연기요건을 충족한 경우에 한하여 가능한 것으로 해석되는 점.

	환매 청구시	주식매수 청구시
연기 요건	- 간접투자증권의 매각이 불가능하여 사실상 환매에 응할 수 없는 경우 - 간접투자자의 이익, 간접투자자간 형평성을 해할 우려가 있는 경우 - 이에 준하는 사유로서 금융위가 필요하다고 인정하는 사유	- 매수자금 부족으로 매수에 응할 수 없는 경우 - 금융위원회 승인

③ 간투법상 ‘환매청구한 것으로 보아 정관에서 정하는 바에 따라 매수’하라는 규정(동법 시행령 제67조)은 주식매수청구에 대하여 환매연기 등 환매 관련 규정이 전면적으로 적용된다는 의미라기보다는 주식을 매수할 때 환매시의 절차와 방법을 준용하라는 의미로 해석되는 점. 피신청인 정관도 제37조(반대주주의 주식매수청구권) 제3항에서 주식매수청구가 있는 경우 매수청구기간의 종료일에 환매청구한 것으로 보아 제22조(환매 가격 및 환매방법)의 규정에 따라 주식을 매수하며 다만 매수자금의 부족으로 매수에 응할 수 없는 경우에는 금융감독원장의 승인을 얻어 주식의 매수를 연기할 수 있다고 규정되어 있음.

④ 반대주주의 주식매수청구와 환매청구는 투자회사의 재산으로 주식을 매수한다는 점에서는 동일하나, 전자는 투자회사의 조직법적 의사결정(합병, 정관변경) 과정에서 다수 주주의 의사결정으로부터 소수 주주의 이익을 보호하려는 것임에 반하여, 후자는 주주 개인 사정에 기인한 투자금 회수를 위한 환가방법으로 제도의 취지가 본질적으로 다

르다고 볼 수 있는 점.

라. 결 론

그렇다면 피신청인은 신청인의 주식매수청구에 응할 의무가 있다 할 것이고 신청인의 주식매수청구를 일반적인 환매청구로 보아 환매연기사유를 이유로 이를 거부할 수는 없다 할 것임.

1-25 채권 매입시 거래세에 대한 설명의무 위반 여부

[기각] 담당직원이 채권매입 관련 거래세에 대한 구체적인 설명을 하지 않았다고 하더라도 채권의 예상수익률에는 위 외환거래세가 이미 반영되어 있고, 매수시 발생한 외환거래세가 채권의 가치변동에 영향을 미친다고 보기 어려우며 신청인 또한 거래세의 존재여부나 그 비중을 중요하게 고려하였다고 보기 어려운 점, 거래세 비중(2%)이 예측하기 어려운 수준의 과도한 금액이라고 보기 어려운 점 등에 비추어 담당직원의 설명의무위반을 인정하기 어렵다 할 것임.(2010.9.14. 조정번호 제2010-74호)

가. 사실관계

2010.2.1. 신청인은 ○○증권사(이하 “피신청인”이라 함) 지점에 내점하여 과장 A씨(이하 “담당직원”이라 함)의 설명을 듣고 3억원을 입금한 후, 브라질국채 460,000헤알⁴³⁷⁾을 매수함. 신청인의 채권매입 과정에서 브라질의 금융거래세 부과정책에 따라 5,768,094원의 거래세가 부과되었으며, 본건 투자설명시 담당직원이 신청인에게 헤알화 환전액에 대

437) 본건 브라질국채 상품의 개요는 다음과 같음.

종목명	통화	발행일	만기일	잔존만기	연 이표	신용등급	예상수익률
◇◇◇◇	헤알화	‘06.5.5.	‘14.1.1	4년	10%(년 2회)	S&P BBB+ 무디스 Baa3	10.7%
* 브라질은 2009.10.20.부터 헤알화 환전액에 대해 금융거래세(IOF) 2% 부과							
** 예상수익률은 위 금융거래세 2%를 반영한 후 수익률임							

해 금융거래세가 부과된다는 구체적 설명을 한 사실은 없음.

나. 당사자의 주장

(1) 신청인의 주장

본건 채권 매입시 금융거래세가 부과된다는 설명을 듣지 못하고 이를 매입하였는데 피신청인이 신청인의 동의 없이 거래세를 임의로 출금하였으므로 피신청인은 신청인에게 이를 반환하고 완제일까지 5% 이자를 가산한 손해를 배상할 책임이 있음.

(2) 피신청인의 주장

담당직원이 본건 채권매입시 금융거래세에 대한 구체적인 설명을 하지는 않은 것으로 확인되나, 신청인에게 설명한 본건 채권의 예상수익률은 위 금융거래세를 감안한 수익률로 신청인이 만기에 받는 수익률에 영향을 미치지 않으며, 본건 채권의 거래세는 브라질 정부에 의해 강제적으로 징수되는 세금으로 피신청인에게 귀속되는 수익이 아니며, 이를 설명의무의 대상으로 보기도 어려움.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 채권매입시 거래세에 대한 담당직원의 설명의무 위반여부라 할 것임.

(1) 관련 판례

금융회사의 임직원이 고객에게 금융상품의 매입을 권유할 때에는 그 투자에 따르는 위험을 포함하여 당해 상품의 특성과 주요 내용을 설명함으로써 고객이 그 정보를 바탕으로 합리적인 투자판단을 할 수 있도록 고객을 보호하여야 할 주의의무가 있고, 이때 고객에게 어느 정도의 설명을 하여야 하는지는 투자 대상인 상품의 특성 및 위험도의 수준, 고객의 투자 경험과 능력 및 기관투자자인지 여부 등을 종합적으로 고려하여야 하며,⁴³⁸⁾ 설명의무의 대상이 되는 “중요한 내용”이라 함은 사회통념에 비추어 고객이 계약

438) 대법원 2006.5.11. 선고 2003다51057 판결 참조.

체결의 여부나 대가를 결정하는 데 직접적인 영향을 미칠 수 있는 사항으로 구체적인 사건에서 개별적 사정을 고려하여 판단하여야 함.⁴³⁹⁾

(2) 설명의무 위반 여부

설명 의무의 대상인 중요한 사항이란 투자자가 당해 금융상품을 매수 또는 계속 보유할 것인지, 처분할 것인가를 결정하는데 있어 중요한 가치가 있는 사항으로 이용 가능한 정보를 종합적으로 고려하여 판단하여야 할 것인 바, 다음과 같은 점에 비추어 설명의무 위반을 인정하기 어렵다 할 것임.

① 담당직원이 본건 채권매입 관련 거래세에 대한 구체적인 설명을 하지 않았다고 하더라도 본건 채권의 예상수익률에는 위 외환거래세가 이미 반영되어 있고, 매수시 발생한 외환거래세가 이후 본건 채권의 가치변동에 영향을 미친다고 보기 어려우며 신청인 또한 본건 채권을 매입함에 있어 투자금액, 투자기간 및 이에 따른 수익률 등에 중점을 두어 매입여부를 결정하였다고 보이고 거래세의 존재여부나 그 비중을 중요하게 고려하였다고 보기 어려운 점.

② 신청인은 「투자정보확인서」 등 관련 서류에 자필서명하고, 「투자확인서」의 투자성향에 “적극투자형”으로, 상품등급에 “고위험”으로 기재하고 있으며, 본건 채권 「상품설명서」, 투자분석화면에 예상수익률이 거래세를 반영하고 있다는 내용을 명시하고 있는 점.

③ 본건 외환거래세는 브라질 정부의 조세정책에 의해 부과되는 세금으로 피신청인에게 귀속되는 수익이 아니며, 거래세 비중(2%) 또한 외환거래에 따른 과세에 관하여 신청인이 예측하기 어려운 수준의 지극히 과도한 금액이라고 보기 어려운 점.

라. 결 론

그렇다면 피신청인은 신청인에 대하여 손해를 배상할 책임이 없다 할 것임.

439) 대법원 2008.12.16. 선고 2007마1328 판결 참조.

1-26 [주]△△ 회사채 불완전판매 등에 따른 손해배상책임

[일부인용] △△증권이 △△그룹 계열사가 발행한 회사채 등 판매시 일부 투자자에게 부적합한 투자상품을 권유하거나 충분한 설명을 하지 않는 등 불완전판매 사실 인정하여 투자자별로 피해액의 3~50%를 배상하도록 판단한 사례(2014.7.31. 조정번호 제2014-13호).

가. 사실관계

(1) [주]△△의 회사채 발행 및 기업회생절차

1) 회사채 발행

[주]△△은 '12.3월~'13.8월 기간 중 운영 및 차환자금 조달 등을 목적으로 총 12차에 걸쳐 1조 710억원 상당의 회사채(만기 : 1년 6개월)를 발행하였음.

[주]△△ 회사채의 발행당시 신용등급은 BB⁰~BB⁺로 투자부적격 등급이었음.

[주]△△ 회사채 발행현황

(단위: 억원)

회차	발행금액	발행일	만기일	신용등급	발행수익률
256	1,500	120330	130930	BB ⁺	7.80%
257	800	120504	131104	BB ⁺	7.80%
258	850	120607	131207	BB ⁺	7.80%
260	1,300	120704	140104	BB ⁺	7.40%
261	800	120926	140326	BB ⁺	7.60%
262	550	121029	140429	BB ⁺	7.60%
263	650	121224	140624	BB ⁰	7.80%
264	900	130222	140822	BB ⁰	7.80%
265	1,000	130506	141106	BB ⁰	7.60%
266	610	130619	141219	BB ⁰	7.60%
267	1,000	130717	150117	BB ⁰	7.60%
268	750	130828	150228	BB ⁰	7.60%
합계	10,710				

나) 기업회생절차 진행

(주)△△은 ① 그룹 계열회사에 대한 자금 지원 및 이에 따른 부실 위험의 전이, ② 기업 구조 조정 실패 및 지속적인 영업 실적 부진 및 ③ 개정된 「금융투자업규정⁴⁴⁰⁾」(13.10.24. 시행)으로 인한 회사채 만기 연장 불가 등을 원인으로 '13.9.30. 서울중앙지방법원에 기업회생절차 개시를 신청하였으며, '14.3.21. 서울중앙지방법원은 (주)△△의 회생계획안을 인가하면서 다음과 같이 변제 계획을 결정.

(주)△△ 회생계획안 주요 내용

(단위 : 억원)

구분	채권액	변제	
		현금변제	출자전환
회사채	8,617	3,878 (45%)	4,739 (55%)

1) 원금 및 개시전 이자 55%를 출자전환하고, 45%는 현금으로 변제하되 '14년 ~ '23년까지 10%(14년), 25%(15년), 7%(16년 ~ '22년), 16%(23년)를 순차로 변제.

2) 출자전환 채무는 신주발행의 효력발생일에 회생채권이 변제된 것으로 갈음하여 출자전환 채권액 500원을 액면가 500원의 보통주로 발행하고, 출자전환 발행주식 5주를 액면 500원의 보통주 1주로 재병합하고 1주 미만 단주는 무상소각.

(2) 피신청인의 본건 회사채 판매 경위

피신청인은 계열회사의 자금조달을 위해 전국의 폭넓은 판매채널(약 120개 영업점)을 이용하여 전사적으로 적극적인 영업을 하였는바, 기존 상품의 만기도래 등으로 CMA계좌에 자금 여유가 있는 기존 고객들을 대상으로 문자메시지 발송 또는 유선 안내 등의 방법으로 본건 회사채에 투자할 것을 적극적으로 권유하였음.

피신청인은 계열사가 발행한 무보증사채에 대해서는 물량의 50%를 초과하여 모집·주선할 수 없어⁴⁴¹⁾, 다른 증권사와 50:50의 비율로 (주)△△ 회사채를 모집·주선하기로

440) 일반투자자를 상대로 계열회사가 발행한 증권 중 투자적격등급에 미치지 아니하거나 또는 신용등급을 받지 아니한 사채권 등의 고위험 채무증권의 매매를 권유하는 행위 금지(「금융투자업규정」 제4-20조 제1항 제5호)

한 후, △△그룹 관련 회사가 다른 증권사를 통해 청약한 본건 일부 회사채를 피신청인의 고객에게 중개하여 판매하기도 하였음.

피신청인은 계열사인 (주)△△으로부터 판매요구를 받은 후 리스크검토 절차를 생략한 채, 본건 회사채 판매 실적 제고를 위해 지점별 목표 할당⁴⁴²⁾ 및 비계열사 대비 높은 성과급을 반영⁴⁴³⁾하였음.

한편, 검찰은 '14.1월 피신청인의 전직 임원을 사기 혐의로 기소⁴⁴⁴⁾하여 현재 재판진행 중임.

A(△△증권 前 대표이사) 등에 대한 공소장 내용 일부 (발췌)

◆ (중략) 다른 증권사들은 위험상품으로 판단하여 인수나 판매 중개를 하지 않는 투자부적격 등급의 △△그룹 계열사 CP와 회사채를 △△증권을 통해서만 판매하였다. 피고인들은 그룹 자금수요에 맞춰 CP와 회사채 판매 물량을 정한 다음 지점 별로 할당량을 정해 놓고 다른 상품보다 높은 수수료를 책정하는 등 인센티브를 부여하여 판매를 독려하였고.....
(이하 생략)

피신청인은 본건 회사채 발행사인 (주)△△ 신용등급보다는 인지도가 있는 △△그룹 계열사임을 강조하여 안정성을 홍보하였음.

본건 ‘투자설명서’에는 신용등급 등 투자위험 요소에 대하여 기재되어 있으며, 대부분의 ‘채권청약서’, ‘채권매매 상품 설명서’ 및 ‘상품설명 체크리스트⁴⁴⁵⁾’에는 신청인들의 자

441) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제13조 제2항, 「금융투자업규정」 제4-19조 제7호

442) 피신청인은 피라미드식으로 목표할당을 하였던 바, 리테일전략팀이 각 지역본부별로 목표할당 및 금액을 확정하여 금융상품전략팀에 통보하면 금융상품전략팀은 각 지역본부 담당자에게 우선상으로 할당금액을 통보하고, 각 지역본부에서는 다시 각 지점별로 할당금액을 배정

443) 비계열사 회사채 판매시보다 약 3.7배 높은 성과급률 반영(계열사 회사채 판매시 판매금액의 35.4bp, 비계열사 회사채 판매시 판매금액의 9.6bp)

444) 상환능력이 없음에도 회사채, CP 등을 발행하여 투자자들에게 판매한 혐의

445) 원금손실 가능성, 채무불이행·유동성 위험, 유동성·환금성 위험 및 제공받은 투자설명서에 대한 이해가 부족한 경우 다시 한 번 설명을 요구할 수 있음이 기재되어 있고 이에 대해 설명 들었음을 체크하도록 되어 있음

필 서명 또는 날인이 되어 있는 등 서류상의 형식적 하자는 발견되지 아니함.

채권 매매 상품설명서 주요내용

채권 매매 상품 설명서					
◆ 본인확인사항					
계좌번호	성명(법인명)		주민등록번호		
◆ 대리인확인(대리인 위임시에만 작성)					
대리인성명	주민등록번호		본인과의 관계		
◆ 채권발행정보					
종목명	267	표준코드	KR6001521378		
발행일	2013/07/17	표면금리	7.60 %	이표구분	이표채(고정금리)
만기일	2015/01/17	할인발행율	0 %	신용등급	BB0
◆ 투자자 확인					
1. 본인은 채권매매가 투자위험이 있다는 사실을 인지하고 본인의 책임과 판단으로 채권을 매수하고자 합니다.					
2. 본인은 매수하는 채권의 신용등급을 확인하였고, 동 채권의 신용등급 하락, 발행회사 도산, 부도 등으로 인한 원리금 전부 또는 일부 지급 불능 및 중도 매도시 금리 상승으로 인한 경우 등의 투자손실, 시장 상황에 따라 환매가 불가능할 수 있는 사실을 인지하고 있습니다.					
3. 본인이 매수하고자 하는 채권은 원리금을 보증하지 않는다는 사실을 알고 있습니다.					

나. 당사자 주장

(1) 신청인들의 주장

피신청인의 임·직원은 신청인들의 투자성향이 본건 투자에 적합하게 도출될 수 있도록 관련 답변을 유도하거나 임의로 입력하는 등 투자성향 파악이 형식적으로 이루어짐.

피신청인의 임·직원은 신청인의 CMA계좌 잔고를 확인한 후 신청인의 투자성향과 상관없이 예금보다 높은 이자를 강조하는 내용으로 본건 회사채 관련 문자를 보내거나 유선으로 투자 권유하여 신청인들이 상품 내용을 충분히 이해할 수 없었음.

피신청인의 임·직원은 다음과 같이 상품에 관한 충분한 설명없이 상품계약서에 서명·날인하도록 하는 방법으로 서류를 작성하였음.

① 피신청인은 본건 회사채의 발행인인 (주)△△의 재무구조나 투자원금 손실의 위험성에 관한 설명을 하지 않았으며, 투자설명서를 교부하지 않은 경우도 있음.

② 피신청인은 ‘채권청약서’ 등 투자에 필요한 서류를 미리 구비해 놓은 상태에서 신청인들로 하여금 내방하게 하거나 직접 신청인들을 방문하여 구체적 설명없이 관련 서류에 서명·날인하도록 함.

③ 또한, 가입시 작성하도록 되어 있는 ‘채권청약서’ 및 ‘상품설명 체크리스트’ 등에 신청인들의 서명을 대필·작성하여 우편으로 송부하기도 하였음.

④ 피신청인은 투자 권유를 받은 신청인들이 인터넷을 통해 상품에 가입하고자 하는 경우 유선으로 실시간 가입 절차를 지시하여 신청인들로 하여금 상품에 관한 정보를 인지, 판단할 기회를 제공하지 않은 채 형식적인 동의, 서명만으로 상품에 가입케 하였음.

피신청인의 임·직원은 다음과 같이 본건 회사채가 마치 원금이 보장되거나 회사가 망하더라도 원금은 받을 수 있다는 등으로 투자위험을 축소하여 투자 권유하였음.

① △△그룹이 책임지고, ○○그룹에서도 자금을 지원해 주기로 하였다는 등의 확정되지 않거나 허위의 사실을 말하며 거짓 설명함.

② △△그룹은 재벌 그룹으로 △△시멘트 등 우량 계열사가 많으며 삼척 지역에 화력발전소 사업을 수주하는 등 많은 수익이 예상된다고 설명함.

③ △△그룹이 안전하여 예금과 다름없다고 하거나, 고금리로써 확정금리라고 왜곡 설명함.

따라서, 피신청인은 본건 회사채를 판매함에 있어 해당 상품의 중요내용을 설명하지 않거나, 허위 사실을 말하여 신청인들로 하여금 본건 회사채에 투자케 하였으므로 그로 인하여 발생한 손해금 전액을 배상하여야 함.

(2) 피신청인의 주장

피신청인은 신청인들의 투자 성향에 부합하는 경우에만 본건 회사채를 권유하였으며,

신청인들의 투자 성향과 부합하지 않는 경우는 신청인들이 직접 당해 상품을 특정하여 투자한 것임.

신청인들의 투자 성향에 부합하지 않는 경우, 신청인들로부터 ‘투자권유 불원 확인서’ 또는 ‘부적합 금융투자 상품 거래 확인서’에 서명·날인을 받았는 바, 투자 성향에 맞지 않는 상품을 위법하게 판매한 것이 아님.

신청인들은 회사채, CP 등 상품에 대하여 다수의 투자 경험을 가지고 있어 회사채의 내용에 대하여 기본적인 이해를 하고 있었는 바, 회사채의 원본 손실 위험성에 관하여 인식하고 있었음.

피신청인은 본건 회사채 투자권유시 신청인들에게 상품의 투자성, 수수료, 해제, 해지 등에 관한 사항, 채무불이행 위험, 유동성 위험, 예금자보호법 적용에 관한 사항 등 중요한 내용을 설명하였음.

신청인들은 회사채의 원본 손실 위험, 신용위험, 시장위험 등에 관한 설명의무가 이행되었음을 내용으로 하는 ‘채권청약서’, ‘채권매매 상품 설명서’ 및 ‘상품설명 체크리스트’에 자필서명 및 날인하였음.

신청인이 투자설명서 수령을 원할 경우에 이를 교부하여 신청인들이 확인서에 ‘투자설명서를 교부받았음’을 자필기재 및 서명하였고, 신청인이 투자설명서의 수령을 원하지 않을 경우에는 신청인으로부터 ‘투자설명서 수령거부 확인서’를 받았음.

△△그룹이 업계 수위의 재벌 그룹인 점, △△그룹이 삼척 지역에 화력 발전소 사업을 수주한 점, ○○그룹의 자금지원 가능성 등은 객관적 사실과 언론을 통해 보도되었던 내용을 확인하는 것에 불과하므로 허위의 사실이나, 불확실한 사실에 대한 단정적 표현에 해당하지 아니함.

따라서, 피신청인은 회사채 판매에 있어서 설명의무 등 관련 법규를 모두 준수하였을 뿐만 아니라, 신청인들의 손해는 회사채의 상품에 본질적으로 내재된 신용위험의 실현에 따른 것이므로, 피신청인은 신청인들에게 손해를 배상할 의무가 없음.

※ 한편, 피신청인의 일부 임·직원은 금융감독원이 작성한 문답서 또는 확인서에서 본건 회사채를 불완전판매 하였음을 인정하였음.

(3) 불완전판매 구체적 사례

사례 1

적합성 원칙 및 설명의무 위반

- ◇ 담당직원은 '13.8.27. 신청인에게 유선으로 (주)△△ 268 회사채에 투자할 것을 권유
 - 담당직원은 **상품에 대한 구체적 설명없이** 투자금액 만을 확인한 후 청약일에 전산상 청약 처리
- ◇ 신청인은 63세 여성으로 '13.1.16. 투자자정보확인서 상의 투자성향은 '위험중립형'(본건 투자권유시에는 투자성향을 확인하지 않음)이며 본건 거래 이전에는 18회 투자경험이 있음

【투자권유 대화내용 : 2013.8.27. (15:13:56)】

- 박○○(직원) : (주)△△ 채권하나 나온 것이 있는데요. 세금우대 사채원금 상환되고 현금으로 가지고 계시잖아요? 그 쪽에 일단 채권 쪽으로 하는 것이니까 9개월에 7.6% 정도 나오거든요. 그래서 이거 10개월 정도 가지고 가시면 어떨까 해서요
- 유○○(고객) : 예 해주세요.
- 박○○(직원) : 오늘 내일 양일간 청약을 하는 건데 있는 금액 다 해서 들어갈까요?
- 유○○(고객) : 일억만 남겨놓고요.
- 박○○(직원) : 아니요 제가 지금 보고 있는게 세금 우대 쪽 계좌를 보고 있는데요. 이 계좌가 잔액이 9천4백정도 있거든요.
- 유○○(고객) : 그거 넣어 주세요.
- 박○○(직원) : 알겠습니다. 청약되면 이를 뒤쫓에 들어가는 거라서 일단 9천4백 정도 넣겠습니다. 그리고 MMW는 1억 7천 9백정도 남아 있거든요.
- 유○○(고객) : 일억만 남겨놓고 넣어주세요.
- 박○○(직원) : 예 알겠습니다.

사례 2

부당권유의 금지 위반

- ◇ 담당 직원은 '12..6.29. 신청인에게 유선으로 (주)△△ 260 회사채에 투자할 것을 권유
 - 담당 직원은 "우리 회사니까 끄떡없다.", "부도나면 우리가 책임지니까 걱정하지 마라"라고 왜곡 설명
- ◇ 신청인은 59세 여성으로 '12.5.3. 투자자정보확인서 상의 투자성향은 '적극투자형'이며 본건 거래 이전에는 9회 투자경험이 있음

【투자권유 대화내용 : 2012.6.29. (09:36:18)】

- 전○○(고객) : 뭐 문자가 하나 들어와 있네요
- 강○○(직원) : 예
- 전○○(고객) : 이거 괜찮은 가요?
- 강○○(직원) : 채권 사는 거고요 그건 뭐 우리 회사니까 끄떡없습니다.
- 전○○(고객) : 연 8%이면 지금 7개월 짜리인데
- 강○○(직원) : 7개월만 투자하면 연 7.4% 줍니다. 1천만원 기준으로 매달 이자가 6만 1천원 정도 나오겠네요.
- 전○○(고객) : 그게 아니고 확정금리 연 8%로 했으니까 세금을 떼면 연 7.4%라는 건가요?
- 강○○(직원) : 아니요 7개월까지는 7.4%나오고, 7개월 뒤부터 1년 반까지 놔두면 그때부터 8.5%가 나옵니다.
- (중략)
- 전○○(고객) : 안전하지요?
- 강○○(직원) : 뭐 이거 하는게 낫지요. 웬만한 다른 것보다 이게 낫지요. CMA나 은행이나 다른 채권보다 낫지요. 이자도 더 많이 주고 어차피 우리 회사인데 우리가 잘 아니까
- 전○○(고객) : 부도날 일 없지요?
- 강○○(직원) : 부도나면 우리가 책임지니까 걱정하지 마십시오.

사례 3

적합성 원칙, 설명의무 및 부당권유의 금지 위반

- ◇ 담당직원은 ‘12.9.24. 신청인에게 유선으로 (주)△△ 261 회사채에 투자할 것을 권유
 - 담당직원은 “(주)△△이 지주회사이므로 자금상환에 문제가 없다”, “△△증권에서 차환발행 가능하다”, “부도파산 될 회사가 아니다”라고 왜곡 설명
- ◇ 신청인은 61세 여성으로 ‘12.9.25. 투자자정보확인서 상의 투자성향은 ’위험중립형‘ (본건 투자권유시에는 투자성향을 확인하지 않음)이며 본건 거래 이전에는 투자경험이 없음

【투자권유 대화내용 : 2012.9.24. (11:29:57)】

- 이○○(직원) : (주)△△ 채권 상담해 드릴게요.
- 김○○(고객) : 어디 채권요?

- 이○○(직원) : (주)△△이라고 해서 △△그룹계열사의 지주회사입니다. △△매직회사 아시죠. △△매직과 △△메이저가 합병해서 △△그룹의 지주회사이기 때문에 지주회사가 자금장악하고 이러다 보니까 자금상황은 걱정 안하셔도 되고요. 채권은 확정금리상품이기 때문에 저희 계열사에 △△증권이 있으니까 △△증권에서 계속 차환 발행가능해요. 이때까지 문제가 된 적은 한번도 없었고요. 원래는 1년6개월짜리인데 10개월만 투자하고 나올 수 있습니다. (중략)
- 이○○(직원) : 채권같은 경우는 확정금리고 만기때까지 발행회사만 부도 파산안되면 만기때까지 이자 받으셨었으니까요. 저희가 부도 파산되는 회사는 아니어서요.
- 김○○(고객) : 등급이 있잖아요?
- 이○○(직원) : 등급은 BB+입니다. 등급은 낮는데 예를들어서 건설회사 같은 경우도 A-로 등급은 높지만 자금력이 안되면 등급에 의미가 없거든요. 등급은 수익률 결정한테 미치는 것이고 상환력을 따지면 이 채권이 훨씬 낮죠.
- 김○○(고객) : 상환력이 얼마인데?
- 이○○(직원) : 상환력은 100%죠. 상환 안 된적이 없으니까요.
- 김○○(고객) : △△메이저하고 △△매직이 △△그룹인데 튼튼한 회사인가?
- 이○○(직원) : 저희 계열사 지주회사니까 △△증권이 있는한 계속 차환발행이 가능하여 만기때 자금이 안도는 부분은 걱정안해도 될거예요.
- 김○○(고객) : 후순위채권 그런 거는 아니예요?
- 이○○(직원) : 아니예요.

다. 위원회의 판단

- ◆ 본건의 쟁점은 피신청인이 본건 회사채를 판매함에 있어 ① 적합성 원칙 위반, ② 설명의무 위반, ③ 부당권유의 금지 위반 등의 사실이 있었는지 여부 및 그로 인한 ④ 피신청인의 손해배상책임 유무와 ⑤ 구체적인 손해배상액 산정이라 할 것임.

(1) 적합성 원칙 위반 여부

금융투자업자는 일반투자자에게 투자권유를 하기 전에 면담·질문 등을 통하여 일반투자자의 투자목적·재산상황 및 투자경험 등의 정보를 파악하고, 투자권유를 하는 경우

에는 투자 성향에 비추어 적합하지 아니하다고 인정되는 투자권유를 하여서는 아니됨
(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제46조 제2항 및 제3항).

— <관련 판례> —

* 고객의 자산을 관리하는 금융기관은 고객에 대하여 선량한 관리자로서의 주의 의무를 부담하는 것이므로, 고객의 투자목적·투자경험·위험선호의 정도 및 투자예정기간 등을 미리 파악하여 그에 적합한 투자방식을 선택하여 투자하도록 권유하여야 하고, 조사된 투자 목적에 비추어 볼 때 고객에게 과도한 위험을 초래하는 거래행위를 감행하도록 하여 고객의 재산에 손실을 가한 때에는 그로 인한 손해를 배상할 책임이 있다 할 것임(대법원 2010.11.11. 선고 2010다55699판결 등 참조).

* 단, 투자자가 금융기관의 권유를 받고 어느 특정한 상품에 투자하거나 어떠한 투자전략을 채택한 데에 단지 높은 위험이 수반된다는 사정만으로 일률적으로 금융기관이 적합성의 원칙을 위반하여 부당하게 투자를 권유한 것이라고 단정할 수는 없으며, 투자자로서도 예상 가능한 모든 위험을 회피하면서 동시에 높은 수익률이 실현될 것을 기대할 수는 없고 위험과 수익률의 조합을 스스로 투자목적에 비추어 선택할 수밖에 없는 것임(대법원 2010.11.11. 선고 2010다55699판결 등 참조).

위와 같은 법리에 비추어 피신청인의 임·직원은 본건 회사채를 판매함에 있어 다음과 같은 점을 종합할 때, 별지1의 해당 신청인들에 대하여 적합성 원칙을 위반하였다고 판단됨.

본건 회사채 투자당시 신청인들의 투자성향⁴⁴⁶⁾이 ‘안정형’ 내지 ‘위험중립형’인 경우 투자원금의 손실위험을 최소화하는 저위험 상품에 투자권유 가능하여 발행사의 부도 등에 따라 원금손실이 발생할 수 있고 투자부적격으로 고위험 상품인 본건 회사채 투자권유가 불가능한 상황이었던 점.

피신청인은 신청인의 투자성향 등에 대한 아무런 자료도 갖고 있지 않음에도 신청인의 투자목적, 투자경험, 위험선호, 상품에 대한 이해도 등 신청인의 투자성향을 파악하지

446) 금융투자상품은 투자위험도에 따라 5단계(안정형, 안정추구형, 위험중립형, 적극투자형, 공격투자형)로 구분(금융투자협회 표준투자권유준칙 IV-1)

아니한 채 오히려 신청인 명의의 투자자정보 확인서를 대필·작성하여 보관하는 등 신청인에게 적합한 상품인지에 대한 확인 자체를 하지 아니한 점.

고객의 투자성향을 파악하기 위한 질문을 유선으로 하면서 특정 질문의 답을 고객의 실제 상황과 다르게 답변하도록 유도하고, 투자 권유전 투자자 정보를 확인하지 않거나 정보제공 불원 또는 투자권유 미희망 고객에게 투자 권유하였으며, 투자부적합 확인서도 임·직원 요청에 따라 사후적으로 작성되는 등 신청인이 피신청인의 투자권유없이 독자적으로 본건 회사채의 투자위험을 감수하고 투자를 결정하였다고 보기 어려운 점.

(2) 설명의무 위반 여부

금융투자업자는 일반투자자를 상대로 투자권유를 하는 경우 금융투자상품의 내용, 투자에 따르는 위험, 금융투자상품의 투자성에 관한 구조와 성격, 수수료에 관한 사항, 조기상환조건이 있는 경우 그에 관한 사항, 계약의 해제·해지에 관한 사항을 일반투자자가 이해할 수 있도록 설명하여야 함(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제47조 제1항).

<관련 판례>

* 금융기관의 임·직원이 고객에게 투자상품의 투자를 권유할 때에는 그 투자에 따르는 위험을 포함하여 당해 투자상품의 특성과 주요내용을 명확히 설명함으로써 고객이 그 정보를 바탕으로 합리적인 투자판단을 할 수 있도록 고객을 보호하여야 할 주의의무가 있으며, 투자에 따르는 위험과 관련하여 투자권유자는 투자에 따르는 제반 위험이 존재하고 이로 인하여 원본손실의 가능성이 있다는 사실 등을 설명하여야 하는 것이나(대법원 2010.11.11. 선고 2008다52369판결 등 참조),

* 고객에게 어느 정도의 설명을 하여야 하는지는 투자대상인 상품의 특성 및 위험도의 수준, 고객의 투자 경험 및 능력, 기관투자자인지 여부 등을 종합적으로 고려하여야 할 것임 (대법원 2010.11.11. 선고 2008다52369판결 등 참조).

위와 같은 법리에 비추어 피신청인의 임·직원은 본건 회사채를 판매함에 있어 다음과 같은 점을 종합할 때, 별지1의 해당 신청인들에 대하여 각 상품의 특성 및 위험성 등에 대한 충분한 설명을 하였다고 보기 어렵다 판단됨.

피신청인의 임·직원은 신청인에게 유선 통화 등으로 투자권유하였고, 투자권유 과정에서 본건 회사채의 내용이나 투자위험성 등에 대한 설명 사실은 확인되지 아니한 점.

본건 회사채의 내용이나 투자위험성이 자세히 기재되어 있는 ‘상품설명 체크리스트’ 등 서류 일체를 작성하지 않는 등 본건 회사채의 중요내용에 대해 신청인이 이해하였음을 확인하는 절차도 거치지 아니한 점.

(주)△△의 회사채에 대한 신용등급이 투자부적격 등급임에도 이에 대한 설명이 누락된 점.

(3) 부당권유의 금지 위반 여부

금융투자업자는 투자권유를 함에 있어서 거짓의 내용을 알리는 행위, 불확실한 사항에 대하여 단정적 판단을 제공하거나 확실하다고 오인하게 할 소지가 있는 내용을 알리는 행위를 하여서는 아니됨(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제49조 제1호 및 제2호).

— <관련 판례> —

* 증권회사의 임·직원이 고객에게 유가증권에 대한 투자를 권유할 때는 고객이 합리적인 투자판단과 의사결정을 할 수 있도록 유가증권 및 발행회사의 중요정보를 올바르게 제공하여야 하고, 특히 비상장회사인 증권회사가 자신의 고객을 상대로 자신이 발행하는 유가증권을 공모하면서 그 유가증권 및 증권회사에 대한 정보를 제공하는 경우에는 장래 유가증권 가격의 상승 또는 하락에 대하여 단정적 판단을 제공하거나, 고객의 의사결정에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사실을 합리적인 근거 없이 주장하거나 과장하여서는 아니 되며, 그렇게 함으로써 당해 유가증권 매수의 청약을 권유하는 행위가 거래행위에 필연적으로 수반되는 위험성에 관한 고객의 올바른 인식형성을 방해한 경우에는 불법행위책임이 성립함(대법원 2007다 16007).

* 금융기관의 임·직원이 고객에게 적극적으로 투자를 권유하였으나 투자 결과 손실을 본 경우에 투자가에 대한 불법행위책임이 성립되기 위하여는 이익보장 여부에 대한 적극적 기망행위의 존재까지 요구하는 것은 아니라 하더라도, 적어도 거래경위와 거래방법, 고객의 투자상황(재산상태, 연령, 사회적 경험 정도 등), 거래의 위험도 및 이에 관한 설명의 정도

등을 종합적으로 고려한 후, 당해 권유행위가 경험이 부족한 일반 투자자에게 거래행위에 필연적으로 수반되는 위험성에 관한 올바른 인식형성을 방해하거나 또는 고객의 투자 상황에 비추어 과도한 위험성을 수반하는 거래를 적극적으로 권유한 경우에 해당하여, 결국 고객에 대한 보호의무를 저버려 위법성을 띤 행위인 것으로 평가될 수 있는 경우라야 함(대법원 2000다50312, 2006다53344 판결 등).

위와 같은 법리에 비추어 담당직원은 본건 회사채를 판매함에 있어 다음과 같은 점을 종합할 때, 별지1의 해당 신청인들에 대하여 왜곡 설명 및 불확실한 사항에 대한 단정적인 판단을 제공하였다고 할 것임.

피신청인의 임·직원은 본건 회사채 투자의사가 없던 신청인에게 ‘S은행(또는 ○○그룹)에서 지원하기로 했어요’, ‘△△이라서 안전해요’ 라고 단정적으로 본건 회사채의 안정성을 강조하는 등 상환여부를 걱정하는 신청인에게 어떤 상황에도 원리금 지급이 확실히 보장되는 것으로 오인할 소지를 제공함으로써 본건 회사채의 투자 위험성에 대한 신청인의 올바른 인식형성을 방해한 점.

피신청인의 임·직원은 원금손실 가능성 등에 대한 정확한 설명없이 ‘주식이나 펀드처럼 원금에서 손실나는 상품이 아니다.’, ‘△△그룹이 지원하여 부도가능성이 없다’라고 설명하는 등 신청인들의 투자성향 및 투자목적에 비추어 과도한 위험을 초래하는 상품에 투자하도록 적극적으로 권유한 점.

(4) 손해배상액 산정

1) 손해금액

신청인들의 손해금액은 본건 회사채 최초 투자금에서 회수하였거나 회수가 예상되는 금전의 총액을 뺀 금액⁴⁴⁷⁾이라 할 것임.

신청인은 법원이 인가한 회생계획안에 따라 회생채권액의 45%에 대해서는 향후 10년

447) 금융투자상품의 취득으로 인하여 일반투자자가 지급하였거나 지급하여야 할 금전 등의 총액에서 그 금융투자상품의 처분 등으로 일반투자자가 회수하였거나 회수할 수 있는 금전 등의 총액을 뺀 금액을 손해액으로 추정(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제48조)

간 분할하여 현금변제를 받고, 나머지 55%에 대해서는 출자전환 주식을 배정받게 되었는데, 현금변제 및 출자전환 부분은 향후에 회수될 개연성이 높다 할 것이므로 그 현재 가치 상당액을 투자금에서 공제하는 것이 타당함.

따라서, 신청인들의 손해금액은 본건 회사채 투자금액에서 회생계획안에 따라 10년간 분할하여 현금변제 받을 금액을 현재가치로 환산⁴⁴⁸⁾한 금액과 출자전환 주식의 신규 상장일('14.6.20)로부터 7영업일 동안의 거래량 가중평균가격(총 거래대금 ÷ 총 거래량)을 적용하여 그 가치를 산정한 평가금액⁴⁴⁹⁾을 공제한 금액이라 할 것임.

※ 한편, (주)△△은 '14.10.31. ~ 11.4. 및 '15.10.20. 회사채 채권자 등에 대하여 조기변제하였는 바, 회수예상액 및 손해액 산정시 이를 고려하였음.

2) 피신청인의 책임 제한(과실상계)

신청인들의 기본 과실비율

손해배상비율을 정함에 있어서는 피신청인의 위반행위 뿐만 아니라 신청인의 과실도 고려하여 책임제한 비율을 산정하여야 하는 바, 신청인 측 과실을 반영한 피신청인의 책임제한 비율(손해배상비율)은 기본적으로 다음과 같이 봄이 상당함.

① 적합성 원칙 위반 : 20%

본건 회사채가 다른 발행사의 회사채나 예금 등에 비해 이율이 높은 것은 그 만큼 위험성도 높기 때문이라는 점은 금융기관과 거래를 하는 평균적인 고객의 관점에서 충분히 예상할 수 있는 것이므로 신청인들은 본건 회사채 투자당시 본인의 투자 성향 뿐만 아니라, 금리 및 위험수준 등에 대해서 면밀히 살펴보고 투자 여부를 결정해야 할 기본적인 책임이 있는 점.

② 설명의무 위반 : 20%

금융상품을 청약하거나 계약할 때 관련 서류의 내용을 면밀히 살펴보는 것은 기본이라 할 것이며, 신청인들은 본건 회사채 투자당시 '상품설명 체크리스트', '채권 매매 상품 설

448) 법원이 '14.3.21. (주)△△에 대한 회생계획안 인가시 적용한 현금변제 환가기준(4.43%)을 적용

449) 출자전환으로 배정받은 주식수 × 783.4원(120,729,474,666원 ÷ 154,107,737주)

명서' 및 '투자 설명서'에 투자등급, 원금손실 위험 등의 투자위험이 기재되어 있어 신청인들이 조금만 주의를 기울였다면 회사채의 위험성을 쉽게 알 수 있었다고 보여지는 점.

③ 부당권유의 금지 위반 : 25%

당시 언론 보도 등을 통하여 (주)△△ 등 계열사의 자금사정이 어려움에 있다는 사실을 어느정도 인지할 수 있었으며, '투자설명서' 등에 (주)△△의 주요 재무제표가 기재되어 있어 부채비율 및 유동성 위험이 높다는 점을 알 수 있어 보다 주의 깊게 판단하였다면, 피신청인 임·직원의 설명이 잘못되었다는 것을 알 수 있었다고 보여지는 점.

3) 다수 위반행위의 가중

피신청인의 위반행위가 경합하는 경우에는 위반행위 정도 및 법원에서 인정하는 배상 비율 등을 종합적으로 고려하여 판단.

① 적합성 원칙 위반 + 설명의무 위반의 경우

피신청인의 각 위법 행위는 포괄하여 신청인의 투자 판단 왜곡이라는 결과를 발생하였다 할 것인바, 각 유형 중 한 가지 사항만을 위반한 경우와 비교하여 위반의 정도가 중하므로 피신청인의 책임 비율은 30%로 봄이 상당함.

② 부당권유의 금지 위반 + 적합성 원칙 위반 또는 설명의무 위반의 경우

해당 위반 행위 중 가장 중한 불법성을 가진 부당권유 행위로 인하여 발생한 신청인의 투자 판단 왜곡이 적합성원칙 위반, 설명의무 위반으로 더욱 가중되었다고 볼 수 있는 만큼 피신청인의 책임비율은 35%로 봄이 상당함.

③ 부당권유의 금지 위반 + 적합성 원칙 위반 + 설명의무 위반의 경우

신청인이 투자여부에 대한 합리적인 판단이 곤란하였을 만큼 위반의 정도가 위중하므로 피신청인의 책임비율은 40%로 봄이 상당함.

4) 신청인 특성에 따른 과실 비율의 조정

① 신청인의 연령, 신청인의 투자경험, 투자금액 등 반영

금융상품에 대한 이해와 투자위험에 대한 주의능력은 투자자의 연령, 투자경험, 투자금

액의 크기 등에 따라 달라진다고 볼 수 있으므로 연령, 투자금액의 크기 등에 따라 과실 비율의 조정이 필요하다 할 것임.

연령의 경우 「노인복지법」에 따르면 65세 이상의 고령자는 경로우대 대상이 되고, 「표준투자권유준칙」에 따르면 만 65세 이상의 고령자에 대해서는 파생상품 등 위험한 상품에 대한 투자권유가 일정한 범위 내에서만 허용하고 있는 점 등을 고려해 볼 때, 만 65세 이상의 고령자에 대해서는 신청인의 과실비율을 조정(5%p 감경)하는 것이 합리적이라 판단되고, 특히 만 80세 이상의 고령자의 경우 더 많은 과실비율의 조정(10%p 감경)이 필요.

투자경험의 경우 원금비보장 상품에 대한 투자경험이 많을수록 투자상품에 대한 상당한 정도의 지식과 경험이 축적된 것으로 보아 이해도가 높다고 볼 수 있으므로, 투자경험이 많을수록 자기책임원칙에 따라 신청인의 과실비율을 조정하는 것이 합리적이라 판단됨(투자경험 1~5회는 2%p, 6~10회는 4%p, 11~20회는 6%p, 21~30회는 8%p를 각각 가중하고, 특히 투자경험 31회 이상인 투자경험자의 경우 더 많은 과실비율 조정(10%p 가중)이 필요.

투자금액의 경우 일반적으로 그 금액이 클수록 투자위험에 대한 주의의무가 높다고 할 수 있는데, 「13년 가계금융 복지조사결과(통계청)」에 따르면 우리나라 가구 소득상위 20%의 평균 보유 금융자산금액이 2억원인 바, 이러한 금액 이상을 투자할 경우 투자위험에 대한 보다 신중한 판단이 필요할 뿐만 아니라, 투자위험에 대한 이해도 그 만큼 높은 점을 고려할 때, 투자금액이 2억원을 초과하는 경우에는 초과분에 대해 과실비율을 조정(5%p 가중)하는 것이 합리적이라 판단되고, 5억원 초과시 더 많은 과실비율의 조정(10%p 가중)이 필요(단, 투자금액에 따른 과실비율 조정은 아래 마)항에서 정하는 배상하한선 적용에서 배제).

② 서류구비 여부

신청인이 직접 투자 서류 등을 작성한 경우에는 스스로 자필·서명한 만큼 투자위험에 대한 인식이 높았을 것으로 보이므로 과실비율을 조정(5%p 가중)하는 것이 합리적이라 판단됨.

③ 비상장 영리법인

주권상장법인 등 전문투자자에 대하여 불완전판매에 따른 손해배상책임을 적용하지 않는 바(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제48조 제1항, 제9조), 비상장 영리법인은 개인 투자자와는 달리 이사회 등 일정한 투자 의사결정 체계가 존재하고, 다양한 금융상품을 거래하며 투자규모도 높으며 설명의무를 완화하고 개인투자자보다 과실비율을 높게 인정하는 법원의 입장과 특히 외감법인은 재무제표 작성 및 회계감사가 의무화되어 투자 위험에 대한 이해도가 높은 점을 고려하여 신청인의 과실비율을 조정하는 것이 합리적이라 판단됨(비외감대상 중기업은 5%p 가중, 외감대상 중소기업은 더 많은 과실비율을 조정(10%p) 하되, 대기업은 자산규모 등에 비추어 상장법인과 달리 볼 필요가 없으므로 불완전판매 불 인정).

5) 배상하한선 설정

과실 비율 조정 요소의 중복 적용으로 배상비율이 현저히 낮아져 불완전판매임에도 배상책임은 면제되는 불합리한 점과 법원에서 통상적으로 인정하는 불완전판매에 따른 손해배상 비율을 고려하여 개인은 20%를, 영리법인 가운데 외감대상 중소기업과 비외감대상 중기업은 다양한 거래경험 등으로 개인에 비해 투자지식이 상대적으로 높으며 개인보다 추가 차감사유가 있는 점을 감안하여 10%의 배상하한선을 정함이 합리적이라 판단됨(다만, 31회 이상 투자경험자에 대해서는 자기책임원칙에 따라 배상하한선을 낮출 필요가 있으므로 개인에 대해서는 15%를, 영리법인 가운데 외감대상 중소기업과 비외감대상 중기업에 대해서는 10%를 각각 적용).

6) 소결

따라서, 위와 같은 사정을 종합적으로 고려하여 피신청인의 책임을 별지1 기재 손해배상 산정기준 비율만큼 제한하는 것이 상당하다 할 것임.

라. 기타 고객보호의무 위반

(1) 임의매매 해당 여부

1) 당사자 주장

① 신청인들의 주장

피신청인 임·직원은 신청인들의 동의없이 본건 회사채에 투자하는 등 임의매매하였으므로 그로 인하여 발생한 손해금 전액을 배상하여야 함.

② 피신청인의 주장

신청인들로부터 사전에 투자의사를 확인하거나 동의를 받아 투자하였으며, 적어도 매매에 대하여 포괄위임을 받아 본건 회사채에 투자한 것으로서 임의매매로 볼 수 없으므로 피신청인은 신청인들에게 손해를 배상할 의무가 없음.

2) 위원회의 판단

투자매매업자 또는 투자중개업자는 투자자나 그 대리인으로부터 금융투자상품 매매의 청약 또는 주문을 받지 아니하고는 투자자로부터 예약받은 재산으로 금융투자상품을 매매하여서는 아니되는 바(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제70조), 다음과 같은 점을 종합적으로 고려할 때, 임의매매로 인정된다 할 것임.

신청인들과 피신청인의 임·직원에 대하여 금감원에서 작성한 문답서와 녹취자료 등에 따르면, 피신청인의 임·직원이 신청인들로부터 본건 회사채의 청약 또는 주문을 받지 아니하고 본건 회사채를 임의로 매수하였음이 인정되는 점.

특히, 피신청인의 일부 임·직원은 영업점 전화가 아닌 핸드폰 또는 문자를 통해 신청인에게 투자여부를 사전에 확인하였고 투자내역을 사후에 통지하였다고 주장하나 이를 입증할만한 자료를 제출하지 못하고 있는 점.

신청인들이 본건 회사채 투자에 필요한 청약 서류 등을 작성한 사실도 없는 점.

신청인들과 피신청인의 일부 임·직원간에 일임약정이 체결되었음을 입증할 만한 자료가 없는 점.

3) 손해배상액 산정

불법행위로 인한 재산상의 손해는 위법한 가해행위로 인하여 발생한 재산상의 불이익,

즉 불법행위가 없었더라면 존재하였을 재산상태와 불법행위가 가해진 이후의 재산상태와의 차이를 말하는 것이므로 별지2 신청인들의 손해금액은 본건 회사채 투자금액에서 회수하였거나 회수가 예상되는 금전의 총액을 뺀 금액이라 할 것임.

한편, 임의매매는 신청인들의 동의 없이 매매한 것으로 신청인들에 대한 투자권유가 전제되어야 하는 불완전판매와는 양립할 수 없다 할 것이므로 임의매매가 성립하는 경우에는 별도의 불완전판매에 따른 배상책임은 인정되지 아니함.

(2) 매도지시불이행 여부

1) 당사자 주장

① 신청인들의 주장

신청인들이 매도의사를 명확하게 표시하여 중도환매를 적극 요청하였음에도 피신청인의 임·직원이 이를 거부하거나 ‘△△그룹이 망하지 않는다’고 하는 등 불확실한 사항에 대한 단정적인 판단 제공으로 매도에 대한 판단을 그르치게 하였으므로 그로 인하여 발생한 손해금 전액을 배상하여야 함.

② 피신청인의 주장

신청인들이 가격 및 수량을 지정한 확정적인 의사로 매도요청하지 않았고, 단지 본건 회사채의 보유 필요성을 설명하였을 뿐 신청인들 본인의 자유로운 의사판단에 따라 보유 결정하여 매도하지 않은 것으로 매도지시 불이행으로 볼 수 없으므로 피신청인은 신청인들에게 손해를 배상할 의무가 없음.

2) 위원회의 판단

금융투자업자는 시장에서 매매주문을 받은 경우 투자자가 지정한 주문 내용과 방법에 따라 즉시 주문을 당해 시장에 전달해야 하는 바(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제71조, 동법 시행령 68조 제5항, 「금융투자업규정」 제4-20조 제1항), 다음과 같은 점을 종합적으로 고려할 때, 매도지시 불이행으로 인정된다 할 것임.

신청인들과 피신청인의 임·직원에 대하여 금감원에서 작성한 문답서와 녹취자료에 따르면, 신청인들은 원금 손실을 감수하더라도 즉시 매도해 줄 것을 명확하게 요청하고 있

으며 매도가 가능함에도 중도해지가 안된다거나 중도환매시 매수자가 있어야 한다고 반복하면서 매도지시를 수차례 거부하거나 매도지시를 이행하지 않고 지속적으로 불이행한 점.

피신청인의 일부 임·직원은 신청인들의 매도요청에 이를 이행하겠다고 답변하였음에도 즉시 매도하지 않고 1주일이 지나서야 매도주문을 제출한 점.

녹취자료에 따르면, 피신청인의 일부 임·직원은 ‘△△그룹이 망하지 않는다’, ‘△△증권은 망하지 않는다. 괜찮다. 금융당국에서도 △△증권 자산은 안전하다고 하였다’라고 하는 등 불확실한 사항에 대한 단정적인 판단을 제공하고 본건 회사채가 발행사의 부도여부와는 관계없이 △△증권에서 보장한다는 왜곡된 설명을 함으로써 신청인들의 매도에 대한 판단을 흐리게 한 점.

3) 손해배상액 산정

별지3 신청인들의 손해금액은 본건 회사채 처분가능금액에서 회수하였거나 회수가 예상되는 금전의 총액을 뺀 금액이라 할 것임.

한편, 피신청인에게 불완전판매에 따른 손해배상책임과 매도지시 불이행에 따른 손해배상책임이 중첩적으로 발생한 경우에는 포괄하여 단일한 고객보호의무 위반으로 보아 불완전판매에 따른 손해배상책임만을 인정함.

4) 피신청인의 책임제한(과실상계)

신청인 측 과실을 반영한 피신청인의 책임제한 비율(손해배상비율)은 다음과 같은 점을 고려하여 20%로 함이 상당함.

신청인들의 매도요청은 요청 당일에 한하여 유효한 바, 투자매매업자 또는 투자중개업자는 매매가 체결된 후 지체없이 매매내역을 통지⁴⁵⁰⁾해야 하므로 신청인들은 주문요청 익일 내지 적어도 주문요청 후 수 일내에 매매 체결 여부를 확인하여 매도요청에 따른 주문제출 등이 없었음을 알 수 있었던 점.

투자자는 자신의 판단과 책임으로 투자손실 등에 대한 부담을 지는바, 신청인이 본 건

450) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제73조, 동 법 시행령 제70조 제1항

회사채 매도를 요청할 당시 언론 보도 등을 통하여 (주)△△ 등 계열사의 자금사정이 어려움에 있다는 사실을 어느정도 인지할 수 있었던 점 및 자신의 판단으로 매도의사를 철회한 점.

마. 결론

그렇다면, 별지1 내지 별지3 기재 신청인들의 신청 중 일부는 이유 있어 이를 인용하고, 별지4 기재 일부 신청인들에 대하여는 민원 취하에 따른 조정의 실익이 없어 각하하고, 나머지 신청인들은 신청인들과 피신청인의 주장이 상이하고 신청인이 제출한 자료만으로는 신청인들의 주장을 입증하기에 부족할 뿐만 아니라 금융감독원이 피신청인을 대상으로 실시한 특별검사 과정에서 달리 신청인들의 주장을 입증할만한 자료를 확인할 수 없었는 바, 사실관계 확정이 곤란하여 각하함.

1-27 파생결합증권(DLS) 불완전판매 등에 따른 손해배상책임

[일부인용] 86세의 고령자인 신청인에게 피신청인 담당직원이 파생결합증권 상품에 대해 중도환매 보류를 부당하게 권유하는 등 설명의무 및 고객보호의무를 위반하였다고 판단한 사례 (2016.7.26. 조정번호 제2016-19호).

가. 사실관계

신청인은 86세(1930년생)의 고령자로, 1999.3.19. D증권(이하 ‘피신청인’이라고 함)에 계좌를 개설한 이후 거래해 왔음.

2013.2.20. 피신청인 모지점 이사 남○○(이하 ‘담당직원’이라고 함)은 지수상승으로 신청인이 보유중인 펀드와 랩상품의 수익률이 높아지자 환매를 제안하고, 금·은·원유를 기초자산으로 하는 파생결합증권 DLS(derivative linked securities, 이하 ‘본건 상품’이라고 함)를 소개하면서 투자대상으로 검토 중이라고 안내하였음.

<'13. 2. 20. 11:51경 통화내용 요약 >

(담당직원) 오늘 주가가 많이 올라서 2,012 포인트예요. 그래서 환매를 하는게 좋을거 같아요. 박△△ 사모님 랩갖고 있는 거 하고 석◇◇ 사모님 펀드 가지고 있는 거랑 거의 상단에 와 있는거 같아요. 그런데 거래가 많지 않아요. 거래도 많지 않아서 환매를 하는게 좋은 것 같고요.

(신청인) 이사님이 알아서 하세요. 이사님 판단이 정확하니까. 저는 이사님만 믿고 있고요.

(담당직원) 정확한 것은 아니지만 지금 시점에서는 그렇게 보여지니까요.

(신청인) 네 매도 하시죠.

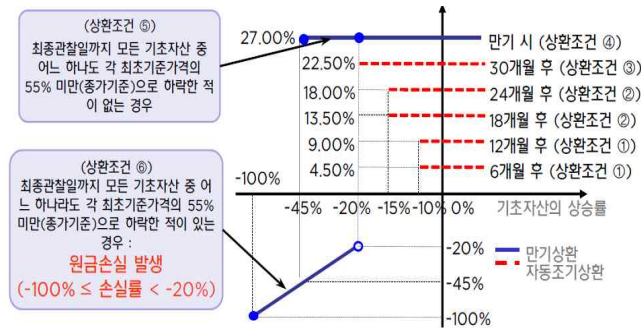
(담당직원) 환매를 박△△, 석◇◇ 사모님거 하시고요. 다음 주 화요일에 우리가 지난번 사장님 들어갔던 식으로... 미국 채권 들어가셨잖아요. 그런식으로 금, 은, 브랜트유를 대상으로 하는 DLS 관창은게 나올 예정이라서요. 금리가 9%로 나올 예정이에요. 그것으로 들어가려고 검토하고 있거든요

(신청인) 네네. 잘 검토해서 차질 없도록 해주세요.

2013. 2. 25. 신청인은 피신청인 담당직원의 투자권유를 받고 D증권 제1109회 DLS에 배우자(석◇◇) 명의로 161백만원을 청약하였음.

D증권 제1109호 DLS 상품구조

기초자산	금 가격지수, 은 가격지수, 브랜트유 선물 최근월물가격 - 금 가격지수 : 런던금시장협회(London Bullion Market Association)의 금 가격지수 - 은 가격지수 : 런던금시장협회(London Bullion Market Association)의 은 가격지수 - 브랜트유선물 최근월물가격 : 런던국제거래소(InterContinental Exchange, (ICE)에서 거래되는 브랜트유 최근월선물 일일 정산가격
원금보장여부	원금비보장
만기/조기상환주기	3년/6개월
목표수익률	연 9.00%(최대손실률 -100%), 이자 만기지급형



구 분	세전 수익률
① 모든 기초자산의 6개월 후, 12개월 후 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 90% 이상일 경우	연 9.00%
★ 자동조기상환 ② 모든 기초자산의 18개월 후, 24개월 후 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 85% 이상일 경우	연 9.00%
③ 모든 기초자산의 30개월 후 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 80% 이상일 경우	연 9.00%
④ 만기평가일에 모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상일 경우	연 9.00% (3년 만기시 27.00%)
⑤ 위 ④의 요건을 충족하지 못하였고, 최종관찰일까지 모든 기초자산 중 어느 하나도 각 최초기준가격의 55%미만(종가기준)으로 하락한 적이 없는 경우	연 9.00% (3년 만기시 27.00%)
★ 만기상환 ⑥ 위 ④의 요건을 충족하지 못하였고, 최종관찰일까지 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 55% 미만(종가기준)으로 하락한 적이 있는 경우 [손실률 계산식 참조]	원금손실 (-100% ~ -20%)

신청인은 본건 상품에 투자하기 이전 본인 명의 계좌와 석◇◇(배우자), 박△△(지인), 남○○(자녀) 명의 계좌를 운용하면서 2000.12.23. ~ 2013.1.18. 기간 중 주식형 펀드 등 총 34회의 금융투자상품에 투자한 경험이 있으며, 본건 상품 청약 직전인 2013.1.17. 및 1.18. D증권 제1023호, 제1016호 DLS에 각각 청약한 사실이 있음.

신청인(甲)의 금융투자상품 투자이력

(단위 : 원, %)

가입일	종목명	위험등급	투자원금	환매금액	수익금액	수익률
'00.12.23	**SAT비과세D-1	4등급(저위험)	20,000,000	21,499,648	1,499,648	7.50
'01.11.15	*****장증A-S2	3등급(중위험)	50,000,000	53,548,637	3,548,637	7.10
'01.11.15	*****장증A-S2	3등급(중위험)	50,000,000	50,065,517	65,517	0.13
'01.12.13	○○index장기증권	3등급(중위험)	50,000,000	102,521,804	52,521,804	105.04
'01.12.13	○○index장기증권	3등급(중위험)	50,000,000	102,521,804	52,521,804	105.04
'05.12.20	○○인디펜던스주식	2등급(고위험)	102,524,093	133,893,190	31,369,097	30.60
'05.12.21	트러스톤◇◇주A	2등급(고위험)	79,869,351	118,715,251	38,845,900	48.64
'05.12.21	○○인디펜던스주식	2등급(고위험)	102,678,453	134,092,402	31,413,949	30.59
'07.7.30	봉쥬르○○자2주식A	2등급(고위험)	40,000,000	35,379,164	-4,620,836	-11.55
'07.7.30	***마켓스타주식A	2등급(고위험)	40,000,000	40,530,002	530,002	1.33

'07.10.9	***수퍼스타주식A	2등급(고위험)	30,000,000	28,937,578	-1,062,422	-3.54
'07.10.9	○○○○솔로몬1주A	2등급(고위험)	70,000,000	41,247,315	-28,752,685	-41.08
'07.10.11	○○○○솔로몬1주A	2등급(고위험)	29,702,971	16,983,082	-12,719,889	-42.82
'07.10.11	◇◇삼바브라질자주A	2등급(고위험)	70,000,000	56,272,147	-13,727,853	-19.61
'09.6.3	트러스트◇◇주A	2등급(고위험)	8,100,000	10,621,607	2,521,607	31.13
'09.6.3	○○○○트러스트자A	2등급(고위험)	1,100,000	1,350,577	250,577	22.78
'09.6.3	한국****적립1주C	2등급(고위험)	81,689,133	109,585,878	27,896,745	34.15
'09.6.8	트러스트◇◇주A	2등급(고위험)	54,023,051	71,977,400	17,954,349	33.23
'09.6.8	○○○○트러스트자A	2등급(고위험)	100,000	151,649	51,649	51.65
'09.6.8	트러스트◇◇주A	2등급(고위험)	100,000	157,833	57,833	57.83
'09.9.2	적립식편드 백만장자	2등급(고위험)	1,400,000	1,526,382	126,382	9.03
'09.9.3	한국****적립2A	2등급(고위험)	200,000	227,644	27,644	13.82
'10.6.28	트러스트◇◇주A	2등급(고위험)	200,000	265,897	65,897	32.95
'10.8.13	** 브레인 Wrap 1-A호	2등급(고위험)	167,006,098	182,488,089	15,481,991	9.27
'10.9.10	** J&J Wrap 1-C호	2등급(고위험)	202,593,077	211,336,110	8,743,033	4.32
'11.2.11	** J&J Wrap 1-C호	2등급(고위험)	97,640,623	77,823,150	-19,817,473	-20.30
'11.2.11	** LEO Wrap 1-C호	2등급(고위험)	100,000,000	73,125,499	-26,874,501	-26.87
'11.2.14	** J&J Wrap 1-C호	2등급(고위험)	30,000,000	24,241,569	-5,758,431	-19.19
'11.4.15	** 브레인 액티브 단위형 1호	2등급(고위험)	50,000,000	39,163,256	-10,836,744	-21.67
'11.6.8	한국****적립1주C3	2등급(고위험)	100,000	140,958	40,958	40.96
'12.6.8	한국****적립1주C4	2등급(고위험)	100,000	152,354	52,354	52.35
'12.6.8	○○○○트러스트자A	2등급(고위험)	94,818,326	142,120,196	47,301,870	49.89
'13.1.17	DLS ****	2등급(고위험)	236,000,000	233,206,873	-2,793,127	-1.18
'13.1.18	DLS ****	2등급(고위험)	135,000,000	142,296,095	7,296,095	5.40

청약 당시 신청인과 신청인 배우자(석◇◇)의 투자성향은 각각 본건 상품(고위험등급) 투자에 적합한 성장추구형, 성장형임⁴⁵¹⁾.

2013.2.25. 본건 상품 청약 당일 신청인은 피신청인 모지점을 내방하여 약 80분(CCTV로 면담시간 확인)간 담당직원과 면담한 것으로 확인됨.

신청인은 본건 상품 청약에 필요한 청약서류를 작성하였고, '투자설명서를 수령함'에 동의하고 '상품특성'과 '위험요소'에 대해 충분히 '설명듣고 이해하였음'을 자필로 기재하고 서명하였음.

451) 피신청인의 투자성향은 5단계 성장형, 성장추구형, 위험중립형, 안정추구형, 안정형으로 구분되며, 금융투자상품 위험도 역시 5단계(초고위험, 고위험, 중위험, 저위험, 초저위험)로 구분

2013.2.26. 본건 상품 청약처리 안내통화 확인결과, 신청인은 “솔직히 ELS 단어에 대해서도 모른다.”며 오히려 피신청인 직원에게 ELS가 무엇인지 질문.

<‘13. 2. 26. 08:55경 통화내용 요약 >

- (직원) 사장님! ELS 경험해보신 게 3년 이상 많으시잖아요. 근데 한번도 한 적이 없다고 체크되어 있어서요. 그거 3년 이상 한 걸로 정정해드릴게요.
- (신청인) 3년 이상 안해요. 안해요. 어제 몇번 얘기했잖아요. 6개월 1년이지 안해요.
- (직원) 그 종목에 대해 말하는 게 아니라, D증권에서 ELS하신 적이 많으시잖아요?
- (신청인) 그동안 10년, 20년 가까이 거래했는데...이제 막 끌고 갈게 아니라..오래 못가지요
- (직원) 앞으로가 아니고요..파생상품, ELS에 투자한 경험이 몇년 되시는지?
- (신청인) 나 솔직히 ELS 단어에 대해서도 잘 몰라. 허OO씨! ELS가 뭐요? E..L...S...?
- (직원) 그럼 상담할 수 있는 분으로 연결해 드릴게요
- (신청인) ELS 본인이 알아야지..본인도 모르는데 나보고 이렇게 하면 내가 알아. 내가 단어 자체도 확실하게 몰라요

2013.2.27. 피신청인의 해피콜에서 원금손실 가능성 등 투자위험에 대한 설명을 들었는지 여부와 투자설명서를 교부받았는지에 대한 질문에 “구체적인 것은 자세하게 못 듣고, 그저 그런게 있는 것 같다. 그것(투자설명서)도 어디 있는지 모르겠네. 자기네들이 가지고 있는거 같던데. 내가 아는 거는 6%인가 9%인가 늘어나고 6개월 내로 도달하고...그 것만 알고 다른 건 무지해”라고 답변.

<‘13. 2. 27. 16:36경 통화내용 요약 >

- (직원) D증권 고객센터 최OO라고 합니다. 甲고객님 맞으십니까? 이번에 DLS 청약 감사드립니다. 상품청약시 충분한 상품설명과 교부서류 수령에 대해 고객님의 확인하는 제도 운영하고 있습니다.
- 이번에 청약하신 DLS상품의 경우 금, 은, 브렌트유를 기초자산으로 발행된 만기3년, 세전 연 9%의 원금비보장형 상품입니다. 상품의 구조와 최초 기준가격의 55% 미만으로 종가 기준으로 하락시에 원금손실 가능성 등의 투자위험에 대한 설명을 들으셨습니까?
- (신청인) 글썄요. 구체적인 것은 자세하게 못 듣고, 그저 그런게 있는 것 같다..그런 정도인데
- (직원) 고객님의 간이투자설명서 및 이 상품에 대한 요약자료 혹시 받으셨습니까?
- (신청인) 그것도 어디있는지 모르겠네. 그것도 자기네들이 가지고 있는 것 같던데.. 그 뭐가

계약 서류인가 그것만 주는 것 같던데. 잔고 확인만 했어요. 잔고확인!

(직원) 잔고만 표시된 걸 받으셨고요?

(신청인) 네. 그러니까 상품의 목적은 최소한 연 8% 늘어나고 길어봐야 6개월이라고 하던데..**솔직히 구체적인 건 모르는데..내가 하나 궁금해서...받아온 잔고 확인밖에 못 받았어요. 그래서 돈이 어떻게 돌아가는지 몰라...그저 그래.. 솔직한 얘기로..**

(직원) 그러십니까? 혹시 관리자분에게 따로 연락드리라고 할까요?

(신청인) **그러니까 내가 아는게 그것 뿐이야. 잔고 확인하고 6%인가 9%인가 늘어나고, 6개월 내로 도달하고..그것만 안다고..다른 것은 무지해! 무지해!**

한편, 2014. 4. 16. 기초자산인 은가격의 지속적인 하락으로 인하여 3천만원의 평가손실이 발생하자 신청인은 피신청인 담당직원에게 문의하였으며, 피신청인 담당직원은 신청인에게 “어차피 상환 받으실거다. 하방이 워낙 낮아서 최악의 경우 3년 가서 다 받을 수 있다. (수익률이) 연 9%인거 아시죠?”라며 본건 상품의 환매보류를 권유하였음.

<‘14. 4. 16. 15:23경 통화내용 요약 >

(담당직원) 그 뒷 페이지 한번 보시면, 석◇◇ 사모님 계좌예요. 밑에 D증권 DLS 1109회가 있죠..이게 박△△ 사모님하고 똑같이 들어간 거예요. 평가를 보면 80.9% 나오죠? 마이너스 3천만원에. 8월달에 조기상환하잖아요.

85% 이상이면 상환되는 거예요. 지금 4.1%밖에 안 남았어요. 4.1% 올라가면 8월에 상환이 되고, 8월에 상환 안되면 내년 2월에 상환될 가능성이 높은 거예요. 박△△ 사모님의 경우 중도환매 하셔서 손해가 너무 크신거죠. 그냥 나왔어야 했는데 다른 분들 다 그냥 갖고 계시거든요. **어차피 상환 받으실거니까. 하방이 워낙 낮아서 최악의 경우 3년 가서 다 받을 수 있거든요. 9%인거 아시죠?**

(신청인) 그러니까 3년 묶인다는 얘기인데, 9%. 그럼 29%, 27%란 거죠?

(담당직원) **27%예요.** 짧게 운용되어 계속 돌아가는것도 좋은데, 길게 가는 것도 좋긴 좋아요. 왜냐하면 9%씩 받기가 쉽지 않거든요. 사모님 같은 경우는 갖고 가시는게 맞거든요. **상환 받으실 거거든요.** 금. 은값이 많이 올라서 상환가능성이 많이 높아진 거예요. 8월이나 내년 2월에는 85% 이상이면 상환이 되고, 내년 8월부터는 80%로 떨어져버려요. 더 높아져버려요.

2016.2.26. 만기에 기초자산 중 은과 브랜트유가 낙인배리어(Knock in barrier)를 터치하여 113,475,646원의 손실이 확정됨.

나. 당사자 주장

(1) 신청인 주장

피신청인 담당직원이 고령자인 신청인에게 상품의 위험성에 대한 구체적 설명없이 투자권유 하였을 뿐만 아니라 원금상환이 가능하다는 중도환매를 만류하여 손실이 발생하였으므로 피신청인은 손해금액을 배상해야 할 것임.

(2) 피신청인 주장

신청인은 본건 상품 가입 직전 상품구조가 동일한 DLS에 투자하는 등 다수의 고위험 상품에 투자한 경험이 있으며, 피신청인 담당직원이 투자설명서를 교부하여 상품의 특징 및 투자위험성을 충분히 설명하였고, 신청인이 'DLS 청약서'에 자필서명하였으므로 신청인의 손해금액에 대해 배상할 책임이 없음.

다. 위원회의 판단

◆ 본 사건의 쟁점은 피신청인이 설명의무와 중도환매보류 부당권유에 따른 고객보호의무를 위반하였는지와 그에 따른 손해배상책임 유무라 할 것임.

(1) 설명의무 위반 또는 고객보호의무 위반 여부

1) 관련법률 및 판례

금융투자업자는 일반투자자를 상대로 투자권유를 하는 경우 금융투자상품의 내용, 투자에 따르는 위험, 금융투자상품의 투자성에 관한 구조와 성격, 수수료에 관한 사항, 조기상환조건이 있는 경우 그에 관한 사항, 계약의 해제·해지에 관한 사항을 일반투자자가 이해할 수 있도록 설명하여야 하며(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제 47조 제1항), 고의 또는 과실로 인한 위법행위로 타인에게 손해를 가한 자는 그 손해를 배상할 책임이 있음(「민법」 제750조).

금융기관의 임직원이 고객에게 투자상품의 매입을 권유할 때에는 그 투자에 따르는 위험을 포함하여 당해 투자상품의 특성과 주요내용을 명확히 설명함으로써 고객이 그

정보를 바탕으로 합리적인 투자판단을 할 수 있도록 고객을 보호하여야 할 주의의무가 있으며, 투자에 따르는 위험과 관련하여 투자권유자는 투자에 따르는 제반 위험이 존재하고 이로 인하여 원본손실의 가능성이 있다는 사실 등을 설명하여야 하는 것이나, 고객에게 어느 정도의 설명을 하여야 하는지는 투자대상인 상품의 특성 및 위험도의 수준, 고객의 투자 경험 및 능력, 기관투자자인지 여부 등을 종합적으로 고려하여야 할 것임(대법원 2010.11.11. 선고 2008다52369판결 등).

또한, 증권회사의 임·직원이 거래행위와 거래방법, 고객의 투자상황(재산상태, 연령, 사회적 경험정도 등), 거래의 위험도 및 이에 관한 설명의 정도 등을 종합적으로 고려한 후 당해 권유행위가 경험이 부족한 일반 투자자에게 거래행위에 필연적으로 수반되는 위험성에 관한 올바른 인식형성을 방해하거나 고객의 투자상황에 비추어 과대한 위험성을 수반하는 거래를 적극적으로 권유한 경우에 해당하여 결국 고객에 대한 보호의무를 저버린 경우에는 위법하다고 할 것임(대법원 2007.4.12. 선고 2004다62641 판결 등).

2) 판단

아래의 사항들을 고려하여 볼 때, 피신청인 담당직원이 본건 상품에 대한 설명을 충분히 하였다고 보기 어려우며 본건 상품의 중도환매 보류를 부당하게 권유하는 등 설명의 무 및 고객보호의무를 위반하였다고 보아야 할 것임.

① 본건 상품의 경우 상품 및 손익구조가 특히 복잡함에도 신청인이 “구체적인 것은 자세히 못 듣고, 그저 그런게 있는 것 같다.”, “잔고 확인하고 6%인가 9%인가 늘어나고, 6개월 내로 도달하고..그것만 안다고..다른 것은 무지해”라고 답변하는 등 청약 당시 고령의 신청인이 담당직원으로부터 알아듣기 쉽게 충분한 설명을 들었다고 보이지 않는 점 ②신청인이 2013.3.25. 본건 상품 가입직전 본건과 유사한 2건의 DLS에 가입(2013.1.17., 2013.1.18.)한 사실은 있으나, 상기 DLS 가입으로 실제 손해를 본 경험이 없으며, 통화기록 등에 비추어 볼 때 담당직원과의 신뢰를 바탕으로 투자를 결정한 것이지 상품의 특징 및 투자위험과 기초자산 등을 설명듣고 투자를 결정한 것으로 보기는 어려운 점 ③신청인은 주로 피신청인 담당직원의 추천에 따라 투자하는 고령의 일반투자자로서 금융상품에 대한 전문성이 높다고 단정하기 어렵고, 다수의 금융투자상품 투자경험이 있다고 하더라도 금융투자상품마다

그 특징과 구조, 위험성 등이 상이하므로 과거 투자경험이 있다는 이유만으로 본건 상품에 대한 피신청인의 설명의무가 면제, 축소된다고 보기 어려운 점 ④2014.4.16. 피신청인 담당 직원이 신청인에게 본건 상품의 손실이 확대되는 시점에서 "만기 3년시 원금을 모두 상환 받을 수 있고, 수익률 또한 9%에 육박할 것으로 예상된다"는 단정적인 표현으로 환매보류를 적극 권유함으로써 본건 거래행위에 수반되는 위험성에 관한 신청인의 올바른 인식형성을 방해하였고, 결과적으로는 피신청인 담당직원의 중도환매 보류 권유를 믿고 본건 상품을 만기시까지 환매하지 않아 손실규모가 확대되었다고 볼 수 있는 점.

(2) 손해배상액 산정

1) 손해금액

신청인의 손해금액은 본건 상품 최초 투자금에서 회수하였거나 회수가 예상되는 금전의 총액을 뺀 금액⁴⁵²⁾이라 할 것임.

따라서, 신청인의 손해금액은 투자원금(161,000,000원)에서 환매금액(47,524,354원)을 공제한 113,475,646원 상당이라 할 것임.

2) 책임의 제한

피신청인은 설명의무 및 고객보호의무를 중첩적으로 위반하였으나 다음과 같은 점을 종합적으로 고려해 볼 때, 피신청인의 책임비율을 30%로 제한하는 것이 상당하다고 할 것임.

①투자자는 자기책임의 원칙 아래 투자상품의 개념이나 내용, 손익구조, 투자위험성 등에 관한 내용을 사전에 정확히 파악하여 신중히 검토한 다음 투자하여야 할 것인데도 신청인이 이를 게을리 한 점 ②신청인은 과거에 원금이 보장되지 않는 고위험 주식형 펀드 등에 여러 차례(34회) 투자한 경험이 있는 점 등을 감안할 때 본건 상품의 투자 위험성 등에 대해 어느 정도 인식하고 있었다고 보이는 점.

452) 금융투자상품의 취득으로 인하여 일반투자자가 지급하였거나 지급하여야 할 금전 등의 총액에서 그 금융투자상품의 처분 등으로 일반투자자가 회수하였거나 회수할 수 있는 금전 등의 총액을 뺀 금액을 손해액으로 추정(자본시장법 제48조)

라. 결 론

그렇다면 피신청인은 신청인에게 손해금액 113,475,646원에서 책임비율 30%에 해당하는 34,042,693원을 배상할 책임이 있어 이를 일부인용함.

1-28 원유선물 ETF 분할매수 랩(Wrap) 상품 불완전판매로 인한 손해 배상책임

[일부인용] 롤오버효과는 본건 상품의 투자수익률에 큰 영향을 주는 등 투자판단 결정에 미치는 중요한 가치사항으로 볼 수 있으므로 설명의무의 대상이 되는 중요한 내용이고, 피신청인 담당직원이 롤오버효과에 대해 충분히 설명하였다고 보기 어렵다고 판단한 사례(2016.7.26. 조정번호 제2016-20호).

가. 사실관계

신청인은 2015. 3. 18. 피신청인 모지점을 내방하여 랩계좌를 개설하여 투자일임형 랩(Wrap) 계약을 체결하고, 원유선물 ETF 분할매수 랩⁴⁵³⁾ 상품(이하 '본건 상품'이라고 함)에 36,651,758원을 투자하였음.

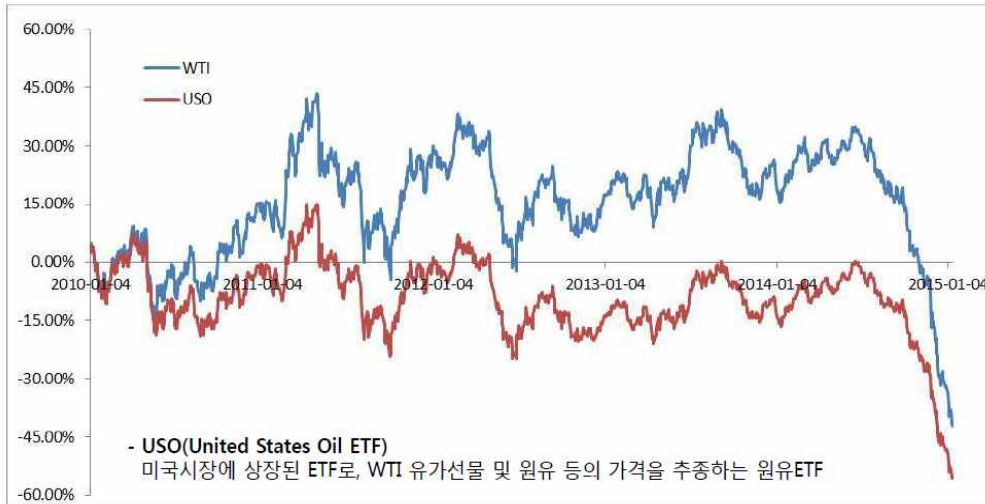
원유선물 ETF 분할매수 랩 상품구조

운용대상	미국시장에 상장된 원유선물 관련 ETF 등(파생 ETF 포함) : 0~ 100%
운용기간	2015.12.31.까지 운용하며, 전환목표수익률 미 도달시 실물보유해지 원칙
위험등급	초고위험
투자방식	고객이 지정한 전환목표수익률(입금액 기준 세전수익률) 달성 이후에 MMW (Money Market Wrap) 자동투자
투자위험	가격괴리 위험, 원금손실 위험, 환율변동 위험 등

453) 국내 및 미국에 상장된 원유선물 ETF(상장지수펀드)를 분할 매수 방식으로 운용하는 랩(Wrap) 상품 (초고위험 등급)

가격 괴리 위험

* 해당 상품에서 투자하는 ETF의 거래가격은 실제 WTI 가격 흐름과 다르게 나타날 가능성이 있습니다.
원유선물을 기초자산으로 하는 ETF의 경우, 원유선물 최근월물에 투자하게 되며
선물과 현물 가격 차이에 따른 롤오버 비용 등으로 WTI 가격과의 괴리가 발생할 수 있습니다.



피신청인 모지점 직원 신○○(이하 ‘담당직원’이라고 함)은 본건 상품 가입이전 신청인
에게 상품 내용, 수수료 등에 대하여 유선으로 일부 설명.

<‘15. 3. 17. 11:23경 통화내용 요약 >

(신청인) 설명을 조금 더 해줘봐요. 이거 어떻게 되는 건지
(담당직원) 일단 그 국제 유가가 많이 빠져있잖아요. 그래서 국제유가 빠진 거에 대해서
국제유가를 직접 매매할 수 없으니까 ETF로 투자를 해보겠다는 것이거든요.
그래서 어쨌든 정식 명칭은 ETF원유선물 분할매수랩이고요. 원유선물ETF분할
매수랩....국제유가 빠져 있는 것 말씀드렸었고 USO라고 있어요. 미국에 상장
되어 있는. 유나이티드스테이트오일이라고 해서 그것을 국제유가랑 연동이 되
가지고 펀드형식으로 만들어 놓은 것인데 주식처럼 거래를 할 수 있다는 것을
이제 안내를 드리는 거구요. 매매가 어떻게 되냐면, 예를 들어, 현재가 50달러
예요. 애네가 투자금액에 10%정도를 우선 매수하고, 국제유가가가 빠지면 또
10%, 또 빠지면 20%. 반면에 국제유가가 계속 등락이 있잖아요. 빠질 때는
많이 매수하고, 올라갈 때는 5%로씩, 정해진 규칙이 있는 것은 아니지만 그
런식으로 매수를 해 놓은 다음에 다 매수가 되었을 때 평균단가를 낮춰 놓고,

	올라가면 일단 차익 실현을 하고 나오는 거죠. 근데 이게 목표 수익률을 정해 놓을 수가 있어요. 처음에 들어가실 때
(신청인)	예.
(담당직원)	목표수익률을 정해 놓는다는 것이 뭐냐면, 만약에 5%, 10%, 15% 이렇게 정하실 수가 있거든요. 예를 들어 5% 목표수익률이면 투자원금에 대해서 수수료는 생각하지 마시고, 내가 만약에 5천만원 투자했다. 5천만원에 5%면 250만원 이거든요. 250만원 나는 시점에서 상품이 그냥 끝납니다. 목표수익률 도 달시에 상품이 끝나고 혹시라도 이게 운용기간을 좀 짧게 잡아놨어요. 애네가 어찌됐든 간에 목표수익률을 달성하겠다는 것이거든요. 그래서 2015년 12월 31일까지만 운용을 해요.
(중 략)	
(신청인)	세금관계는 해외펀드?
(담당직원)	250만원까지 기본공제가 들어간다고 보면 되는거고. 250만원은 5천만원 투자했을 때 5%정도 밖에 안되구요. 5% 수익나면 250만원 공제받고 나오면 되는 거고. 그 이상 목표수익률 원하신다 10% 정하고 들어갔다. 그러면 250만원 기본공제 나머지 250만원은 양도소득세
(신청인)	양도세는 몇 프로라 그랬어요
(담당직원)	양도세는 22%입니다. 수수료는 저희가 선취를 일단은 1%를 떼요. 후취로 해가지고 0.6%하는게 있구요. 근데 기간을 극단적으로 오늘 가입했는데 한달 뒤에 목표수익률을 달성이 되가지고 해지가 됐어요. 그러면 거기서 환급해 드리는 부분도 있어요. 1년 운용을 하지 않았기 때문에

2015.3.18. 피신청인이 확인한 신청인의 투자성향은 본건 상품 투자에 적합한 공격투자형임⁴⁵⁴).

신청인은 본건 상품 투자 직전인 2015.3.11. ELS(원금비보장형)에 직접 청약하여 투자한 이력이 있음.

신청인은 본건 상품 투자에 필요한 파생상품 ETF 거래신청서 등의 서류를 작성하였고, ‘위험고지 안내서를 수령함’에 동의하고 ‘투자원금손실’과 ‘예금자보호 미대상’ 및 ‘손익구조 등 주요위험’에 대해 설명듣고 이해하였음을 자필로 기재하고 서명하였음.

454) 피신청인의 투자성향은 5단계 공격투자형, 적극투자형, 위험중립형, 안정추구형, 안정형으로 구분되며, 금융투자상품 위험도 역시 5단계(초고위험, 고위험, 중위험, 저위험, 초저위험)로 구분

2015.12.31. 본건 상품 운용기간 만료시점 기준 총 16,909,465원의 손해가 발생하였고 이 중 2,362,683원(총손해의 13.9%)이 롤오버비용⁴⁵⁵⁾임.

2016.5.19. 피신청인의 담당직원은 롤오버효과 및 위험성에 대하여는 상품설명서에 기술된 내용만을 신청인에게 설명하였다고 금융감독원 직원과 면담시 진술함.

나. 당사자의 주장

(1) 신청인 주장

담당직원이 투자당시 롤오버효과에 대한 설명을 하지 않았고, 롤오버위험성에 대한 설명을 들었다면 본건 상품에 가입하지 않았을 것이므로 손해금액을 배상해야 할 것임.

(2) 피신청인 주장

담당직원이 본건 상품설명서를 통해 롤오버의 가격괴리 위험에 대하여 설명하였으며, 투자위험성이 기재된 투자일임계약서 등에 신청인이 자필서명하였으므로 손해금액에 대해 배상할 책임이 없음.

다. 위원회의 판단

◆ 본건쟁점은 롤오버효과에 대한 설명의무 위반과 그에 따른 손해배상책임 유무라 할 것임

(1) 설명의무 위반 여부

1) 관련법률 및 판례

금융투자업자는 일반투자자를 상대로 투자권유를 하는 경우 금융투자상품의 내용, 투자에 따르는 위험, 금융투자상품의 투자성에 관한 구조와 성격, 수수료에 관한 사항, 조

455) 롤오버는 WTI 원유선물계약 만기시 차월물에 재투자하는 것을 의미하며, 근월물과 차월물간의 가격 차이로 인하여 발생하는 비용

기상환조건의 있는 경우 그에 관한 사항, 계약의 해제·해지에 관한 사항을 일반투자자가 이해할 수 있도록 설명하여야 함(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제 47조 제1항).

금융기관의 임직원이 고객에게 투자상품의 매입을 권유할 때에는 그 투자에 따르는 위험을 포함하여 당해 투자상품의 특성과 주요내용을 명확히 설명함으로써 고객이 그 정보를 바탕으로 합리적인 투자판단을 할 수 있도록 고객을 보호하여야 할 주의의무가 있으며, 투자에 따르는 위험과 관련하여 투자권유자는 투자에 따르는 제반 위험이 존재하고 이로 인하여 원본손실의 가능성이 있다는 사실 등을 설명하여야 하는 것이나, 고객에게 어느 정도의 설명을 하여야 하는지는 투자대상인 상품의 특성 및 위험도의 수준, 고객의 투자 경험 및 능력, 기관투자자인지 여부 등을 종합적으로 고려하여야 함(대법원 2010.11.11. 선고 2008다52369판결 등).

설명 의무의 대상이 되는 ‘중요한 내용’이라 함은 사회통념에 비추어 고객이 계약체결의 여부나 대가를 결정하는 데 직접적인 영향을 미칠 수 있는 사항으로 구체적인 사건에서 개별적 사정을 고려하여 판단하여야 함(대법원 2008.12.16. 선고 2007마1328 판결 등).

2) 판단

아래의 사항들을 고려하여 볼 때, 롤오버 효과는 설명 의무의 대상이 되는 중요한 내용이며, 피신청인 담당직원이 롤오버효과에 대해 충분히 설명하였다고 보기 어렵다 할 것임.

본건 상품 매매로 발생한 롤오버비용이 신청인의 총 손실금액(16,909,465원)의 13.9%(456)를 차지하는 등 신청인이 예측하기 어려운 과도한 수준의 비용이 발생하고, 본건 상품의 투자수익률에 큰 영향을 미치는 점 등에 비추어 볼 때 롤오버효과는 투자판단 결정에 미치는 중요한 가치사항으로 볼 수 있으므로 설명 의무의 대상이 되는 중요한 내용이라고 할 것임.

본건 상품 관련 상품설명서에는 ‘선물과 현물 가격 차이에 따른 롤오버비용 등으로 ETF 거래가격이 WTI 가격과의 괴리가 발생할 수 있다’고 기재되어 있을 뿐 이러한 롤오버비용이 무엇인지, 그 효과가 어느 정도 되는지 및 WTI 가격과 괴리 발생의 효과가

456) 2016.5.17. 매도시점 기준으로는 손해금액(15,532,354원)의 58.5%를 차지

무엇인지에 대하여는 구체적인 설명이 없어 일반투자자인 신청인이 롤오버효과에 대하여 명확히 이해할 수 있었다고 보기 어려운 점.

2015.3.17. 통화기록에서도 피신청인 담당직원이 신청인에게 롤오버효과에 대하여 설명한 사실을 찾아볼 수 없으며, 피신청인 담당직원도 2015.3.18. 신청인 내방당시 롤오버효과에 대하여 상기 상품설명서에 기재된 내용만을 신청인에게 설명하였다고 진술하고 있는 점.

(2) 손해배상액 산정

1) 손해금액

신청인의 손해금액은 본건 상품 최초 투자금에서 회수하였거나 회수가 예상되는 금액의 총액을 뺀 금액⁴⁵⁷⁾이라 할 것임.

따라서, 신청인의 손해금액은 투자원금(36,651,758원)에서 본건 상품 운용 만료시점 평균금액(19,742,293원)을 공제한 16,909,465원 상당이라 할 것임.

2) 책임의 제한

피신청인은 롤오버효과에 대한 설명의무를 위반하였으나, 다음과 같은 점 등을 종합적으로 고려해 볼 때, 피신청인의 책임비율을 20%로 제한하는 것이 상당하다 할 것임.

투자자는 자기책임의 원칙 아래 투자상품의 개념이나 내용, 손익구조, 투자위험성 등에 관한 내용을 사전에 정확히 파악하여 신중히 검토한 다음 투자하여야 할 것인데도 신청인이 이를 게을리 한 점, 신청인의 투자성형은 공격투자형으로 본건 상품 투자 직전 직접 ELS에 청약하는 등 본건 상품의 투자 위험성에 대해 어느 정도 인식하고 있었다고 보이는 점.

라. 결 론

457) 금융투자상품의 취득으로 인하여 일반투자자가 지급하였거나 지급하여야 할 금전 등의 총액에서 그 금융투자상품의 처분 등으로 일반투자자가 회수하였거나 회수할 수 있는 금전 등의 총액을 뺀 금액을 손해액으로 추정(자본시장법 제48조)

그렇다면, 피신청인은 신청인에게 손해금액 16,909,465원에서 책임비율 20%에 해당하는 3,381,893원을 배상할 책임이 있어 이를 일부인용함.

1-29 해외 원유선물 ETN 불완전판매에 따른 손해배상책임 성립여부

[일부인용] 피신청인 직원은 본건 상품에 대하여 변동성이 크다고만 설명하였을 뿐 별도의 상품설명서도 제공하지 않는 등 설명의무를 위반하였음이 인정되고, 투자권유 당시 신청인의 투자성향이 본건 상품투자에 적합하지 않았던 점 등에 비추어 적합성 원칙을 위반하였음이 인정되나 금융투자의 자기투자 책임 원칙 및 본건 상품 매매거래 도중 신청인의 투자성향이 상향된 사실이 있는 점 등을 고려하여 불완전판매에 대한 피신청인의 책임범위를 30%로 제한한 사례(2017.7.11. 조정번호 제2017-12호).

가. 사실관계

(1) 신청인은 ‘15. 1. 29. 피신청인 직원의 권유로 해외 원유선물 ETN⁴⁵⁸⁾(이하 ‘이 사건 해외 원유선물 ETN’이라고 한다) 3,660증권을 최초 매수하였다.

(2) 이 사건 해외 원유선물 ETN은 해외 원유 선물지수(S&P GSCI CRUDE OIL Index) 일간 변동률 양의 3배(300%)를 추종하는 상품으로, 구체적인 내용은 다음과 같다.

< 이 사건 해외 원유선물 ETN 특성 및 위험(상품설명서 발췌⁴⁵⁹⁾) >

구분	내용
발행회사	■ C 은행
상장	■ 미국 뉴욕증권거래소(NYSE Arca) 상장

458) Exchange Traded Note의 약자로, 상장지수증권이라고 한다. 기초자산의 가격·이자율·지표·단위 또는 이를 기초로 하는 지수 등의 변동과 연계하여 미리 정해진 방법에 따라 이익을 얻거나 손실을 회피하기 위한 계약상의 권리를 나타내는 것으로서 거래소에 상장되어 거래되는 파생결합증권이다.

459) 피신청인이 이 사건 해외 원유선물 ETN 관련 상품설명서를 별도로 구비하고 있지 않은 관계로 발행사 홈페이지를 통해 확인한 사항이다.

상품구조	■ 해외 원유선물지수(S&P GSCI CRUDE OIL Index) 일간변동률의 양의 3배 (300%) 추종
투자 비용	■ 롤오버(Roll Over) 비용 * 보유중인 원유선물 계약의 만기가 도래함에 따라 다음월 만기의 원유선물 계약으로 재투자(롤오버)하는 과정에서 다음월물의 선물가격이 당월물보다 높아 발생하는 비용
위험	■ 투자원금이 보장되지 않으며 투자원금의 전부 또는 일부 손실 발생 가능 ■ 일일 거래위험*을 감수할 수 있는 전문 투자자(Sophisticated Investor)에게 적합 * 일중 해외 원유선물 지수 변동에 민감한 상품으로 지수 변동폭에 따라 ETN 가격 급변 ■ 장기보유에 따른 위험(Long Holding Period Risk)*으로 인해 1일이상 보유하려는 투자자 및 투자원금 변동을 수시로 모니터링할 수 없는 투자자에 부적합 * 원유선물지수가 일정기간 상승하더라도 동 지수가 그 기간중 등락을 반복한 경우 ETN 가격은 오히려 하락(손실발생)할 수 있으며, 장기보유시 원금의 전부 또는 상당부분 손실발생 가능
투자등급 460)	■ 공격투자형 - 초고위험

(3) 이 사건 해외 원유선물 ETN을 최초 매수할 당시 신청인의 투자성향은 ‘적극투자형’(이 사건 ETN 투자불가 등급)이었으나, 이후 ‘15.7.3. ’공격투자형’(이 사건 ETN 투자가능 등급)으로 투자성향이 변경되었고, 신청인의 이 사건 해외 원유선물 ETN 거래 내역 및 이 사건 해외 원유선물 ETN 최초 매수 전후 피신청인 직원과의 주요 통화 내용은 다음과 같다.

< 신청인의 ETN 거래내역 및 손익 현황 등 >

구분	체결일	수량	단가(달러)	체결금액(원화)	손익(원화)	투자성향
매수	2015.01.29	3,660	2.46	9,749,998		적극투자형
매도	2015.02.03	3,660	3.70	14,912,450	5,162,452	
매수	2015.02.04	4,000	3.00	13,179,600		
매수	2015.03.18	3,000	1.82	6,170,006		
매도	2015.04.15	7,000	3.30	25,336,080	5,986,474	
매수	2015.07.02	3,000	2.90	9,730,950		

460) 피신청인은 고객 투자성향을 5단계(공격투자형, 적극투자형, 위험중립형, 안정추구형, 안정형)로 분류하고, 각 단계에 대응한 5개 유형의 투자상품(초고위험, 고위험, 중위험, 저위험, 초저위험)을 권유하고 있으며, 이 사건 해외 원유선물 ETN은 ‘공격투자형’에 적합한 ‘초고위험’ 상품에 해당한다.

매수	2015.07.06	3,500	2.53	9,918,093		공격투자형
매수	2015.07.07	4,500	2.20	11,149,863		
액면병합*	2015.09.10	11,000				
액면병합*	2016.03.14	1,100				
매도	2016.11.18	110	19.11	2,468,706	-28,330,200	
합계					-17,181,274	

* 액면병합비율: 10:1

< 신청인과 피신청인 직원간 통화 내용 >

2015.1.26.

(신청인) 그리고 저번에 유가에 관한 관련주를 사야된다고 하셨잖아요?

(직원) 좀 사놓으시면 괜찮을 것 같아서. 지난주에 좀 하다가 조정받고 있더라고요.

(신청인) 그걸 조금 샀으면 어떨까 하는데.

(직원) 일부 투자하실 금액 3분의1정도는 사놓으셔도. 바로는 못가도 사놓으시면 종합과세 대상이 아니고 분리과세 22% 세금내고 끝나시거든요. 세금 관련 있으신 분들은 사셔도 괜찮을 것 같아요.

(신청인) 그러면 어떻게 하면 되죠?

(직원) 은행에서 환전해서 입금해주시면 되세요. 고객님의 명의로 NH투자증권 외환계좌에 넣어주셔야 돼요.

2015.2.2.

(직원) 그때 유가가 2.46에 체결되셨구요.

(신청인) 네,네.

(직원) 어제 종가 2.99여서 23% 올라왔는데.. 제가 가기 전에, 이대로 올라가면 매도를 한번 해드릴거구요. 만약에 좀 내려간다 싶으면 오늘 종가로 매수 한번 해드릴까요? 사놓으시고 보시는게. 요게 변동성이 그때 말씀드린 것처럼 커요. 단기적으로 50%씩 나실수도 있거든요. 그럼 매도를 해드릴건데. 오늘 종가로 한번 매수는 해드릴게요.

(신청인) 네,네.

나. 당사자의 주장

신청인은 피신청인의 직원이 신청인의 투자성향에 적합하지 아니한 초고위험 금융상품인 이 사건 해외 원유선물 ETN을 투자 권유하였고, 그 과정에서 이 사건 상품의 투자구조 및 위험성 등에 대해 충분히 설명하지 아니하였는 바, 이는 고객 보호의무를 위

반하여 부당한 거래권유를 한 것으로 이로 인한 신청인의 손해를 배상할 의무가 있다고 주장한다.

이에 대하여 피신청인은 신청인이 이 사건 해외 원유선물 ETN 거래를 통하여 수익을 취득한 사실이 있고, 과거 초고위험 상품에 투자한 경험 등에 비추어 적합성 원칙 위반으로 보기 어려우며 투자권유 과정에서 이 사건 상품의 투자구조, 변동성, 원본손실가능성 및 롤오버 비용 등에 대하여 안내하는 등 설명의무를 이행하였다고 주장하여 서로 다툰다.

다. 위원회의 판단

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 ‘자본시장법’이라 한다)」, 신청인의 분쟁조정 신청서류 및 피신청인의 제출자료 등 관련자료 일체를 종합하여 먼저 설명의무 위반여부에 대하여 살펴보면,

금융투자업자가 일반투자자를 상대로 투자권유를 하는 경우 금융투자상품의 내용, 투자에 따르는 위험, 금융투자상품의 투자성에 관한 구조와 성격, 수수료에 관한 사항, 조기상환조건이 있는 경우 그에 관한 사항, 계약의 해제·해지에 관한 사항을 일반투자자가 이해할 수 있도록 설명하여야 하며(자본시장법 제47조 제1항), 법원은 “금융기관의 임직원이 고객에게 투자상품의 매입을 권유할 때에는 그 투자에 따르는 위험을 포함하여 당해 투자상품의 특성과 주요내용을 명확히 설명함으로써 고객이 그 정보를 바탕으로 합리적인 투자판단을 할 수 있도록 고객을 보호하여야 할 주의의무가 있으며, 이때 고객에게 어느 정도의 설명을 하여야 하는지는 투자 대상인 상품의 특성 및 위험도의 수준, 고객의 투자 경험과 능력 및 기관투자자인지 여부 등을 종합적으로 고려하여야 한다”라고 판시하고 있다(대법원 2006. 5.11. 선고 2003다51057 판결 등 참조).

이 사건의 경우, ① 신청인은 이 사건 해외 원유선물 ETN 매수 이전에는 주로 주식, 채권, 증권형 펀드(사모펀드 포함) 등에만 투자하였으며, 원유 등 변동성이 높은 원자재나 선물과 관련한 고위험 상품에 투자한 경험이 전혀 없었다는 점, ② 이 사건 해외 원유선물 ETN 최초 매수 당시(2015. 1. 26, 2. 2.)의 신청인과 피신청인 직원의 통화내용을

확인한 결과, 피신청인 직원은 이 사건 상품에 대하여 변동성이 크다고만 설명하였고, 이 사건 해외 원유선물 ETN이 초고위험 상품임에도 불구하고 상품의 손익구조(해외원유 선물지수 일간변동률의 3배 추종), 롤오버 비용 발생 및 투자 위험 등을 구체적으로 설명한 내용이 확인되지 않는 점, ③ 피신청인은 이 사건 해외 원유선물 ETN 투자권유시 별도의 투자설명서 내지 상품설명서를 구비하고 있지 아니한 관계로 신청인에게 설명서를 제공하지도 아니하였다는 점,⁴⁶¹⁾ ④ 비록 신청인이 이 사건 해외 원유선물 ETN 매매거래 도중에 투자성향이 ‘적극투자형’에서 ‘공격투자형’으로 상향 변경된 사실은 있으나, 이와 같은 사정만으로는 피신청인의 설명의무를 부정⁴⁶²⁾할 수 있을 정도로 신청인이 이 사건 해외 원유선물 ETN의 투자구조와 위험성 등 주요내용을 충분히 알고 있었다고 보기는 어려운 점, ⑤ 이 사건 해외 원유선물 ETN은 초고위험 등급 상품으로 설명의무가 더욱 엄격하게 적용되어야 하는데, 피신청인의 직원이 본 건 상품의 특성 및 투자위험 등을 충분히 설명하였다고 볼만한 다른 사정이 없는 점⁴⁶³⁾ 등을 종합해 볼 때,

461) 이 사건 해외 원유선물 ETN의 발행자인 크레딧 스위스 은행 홈페이지를 통해 확인한 상품설명서에는 투자구조, 위험요소 등이 상세하게 기재되어 있으며, 특히 이 사건 해외 원유선물 ETN이 일일 투자 성과를 추구하는 전문투자자에게 적합하며, 하루 이상 보유하거나 상품을 빈번하게 모니터링할 수 없는 투자자에게는 적합하지 않다고 명시하고 있다.

462) 판례는 “금융투자업자가 투자자에게 어느 정도의 설명을 하여야 하는지는 해당 금융투자상품의 특성 및 위험도의 수준, 투자자의 투자경험 및 능력 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 할 것이나, 투자자나 그 대리인이 그 내용을 충분히 잘 알고 있는 경우에는 그러한 사항에 대하여서까지 설명의무가 인정된다고 할 수는 없다”고 판시하고 있다(대법원 2015.4.23. 선고 2013다 17674 판결 등 참조).

463) 판례는 “금융투자업자에게 요구되는 설명의무의 범위 및 정도는 해당 금융투자상품의 구조, 위험성, 복잡성 및 투자자의 투자 목적, 위험감수의사 및 능력, 경험 등에 따라 개별적·구체적으로 정해져야 하는바, 금융투자상품의 구조가 복잡하고 위험성이 높을수록, 투자자와 금융기관 사이에 정보의 불균형 및 전문성의 차이가 클수록, 설명의무는 더 높은 정도로 요구된다고 봄이 타당하다. (중략) 금융전문가가 아닌 일반 투자자로서는 금융투자상품의 구조와 위험성의 내용을 알기 어려울 뿐만 아니라, 금융기관이 그러한 내용에 대해 설명의무를 다하였는지, 금융기관의 설명의무 위반과 투자자의 손해발생 사이에 인과관계가 있는지를 밝혀내기가 어렵다는 점, (중략) 따라서 금융기관이 서면이나 녹음·녹화자료 등에 의해 설명의무의 이행을 입증하기는 용이한 반면에 투자자 측에서 설명의무가 이행되지 않았음을 입증하기는 성질상 매우 어려운 점 등에 비추어, 금융기관 측에 설명의무를 이행한 데 대한 증명책임이 있다”고 판시하고 있다(서울중앙지법 2013. 1.17. 선고 2011가합71808 판결 등 참조).

피신청인은 자본시장법 제47조의 설명의무를 위반한 것으로 판단된다.

다음으로 적합성 원칙 위반여부에 대하여 살펴본다.

금융투자업자는 일반투자자에게 투자권유를 하기 전에 면담·질문 등을 통하여 일반투자자의 투자목적·재산상황 및 투자경험 등의 정보를 파악하고, 일반투자자의 투자 성향에 비추어 적합하지 아니하다고 인정되는 투자권유를 하여서는 아니된다(자본시장법 제46조 제2항, 제3항). 한편, 금융기관의 임직원이 고객에게 적극적으로 투자를 권유하였으나, 투자결과 손실을 본 경우에 투자자에 대한 불법행위책임이 성립되기 위해서는 이익보장 여부에 적극적 기망행위의 존재까지 요구하는 것은 아니라 하더라도, 적어도 거래행위와 거래방법, 고객의 투자상황(재산상태, 연령, 사회적 경험정도 등), 거래의 위험도 및 이에 관한 설명의 정도 등을 종합적으로 고려한 후, 당해 권유행위가 경험이 부족한 일반 투자자에게 거래행위에 필연적으로 수반되는 위험성에 관한 올바른 인식형성을 방해하거나 또는 고객의 투자상황에 비추어 과대한 위험성을 수반하는 거래를 적극적으로 권유한 경우에 해당하여 결국 고객에 대한 보호의무를 저버려 위법성을 띤 행위인 것으로 평가될 수 있는 경우라야 한다(대법원 2003. 1.10. 선고 2000다50312 판결 등 참조).

본건의 경우, ① 이 사건 해외 원유선물 ETN의 최초 매수시 신청인의 투자성향은 '적극투자형'으로서 초고위험 등급인 이 사건 해외 원유선물 ETN 투자에 적합하지 아니하였다는 점, ② 실제로도 이 사건 해외 원유선물 ETN은 구조가 복잡하고 변동성이 매우 큰 상품으로 유사한 투자경험이 없는 신청인으로서 이해하기 쉽지 않는 등 신청인에게 적합한 상품으로 보기 힘든 점, ③ 비록 신청인이 이 사건 해외 원유선물 ETN 매수 이전에 초고위험 상품인 KODEX 레버리지 ETF 및 증권형 사모펀드에 투자한 경험이 있으나, 당시에는 투자성향 부적합 확인서를 작성하고 투자를 하였으며, 해당 상품들은 상품의 구조나 변동성, 위험요소 등이 이 사건 해외 원유선물 ETN과는 차이가 큰 점⁴⁶⁴⁾에 비추어 해당 투자 경험만을 근거로 신청인의 투자성향이 실질적으로 이 사건 해

464) KODEX 레버리지 ETF는 코스피(KOSPI)200 지수의 일간변동률을 2배씩 추종하는 인덱스 관련 상장지수펀드이며, 신청인이 투자한 사모펀드 역시 주로 국내 중소형주 주식에 투자하는 증권형 펀드로 원유 선물 지수의 일간변동률의 3배를 추종하고 높은 수준의 롤오버 비용이 발생하는 고 위험상품인 이 사건 해외 원유선물 ETN과는 투자구조 및 변동성 등 위험도가 본질적으로 상이하다.

외 원유선물 ETN 투자에 적합한 투자성향으로 상향된 것으로 보기는 힘든 점 등을 종합해 볼 때, 피신청인은 일반투자자인 신청인의 투자목적·재산상황 및 투자경험 등에 비추어 과대한 위험성을 수반하는 거래를 권유한 것에 해당하여 자본시장법 제46조 제3항의 적합성 원칙을 위반한 것으로 판단된다.

마지막으로 구체적인 손해배상액을 산정해보면,

적합성 원칙 및 설명의무 위반으로 인하여 신청인이 입은 손해는 자본시장법 제48조 제2항에 따라 금융투자상품의 취득으로 인하여 일반투자자가 지급하였거나 지급하여야 할 금전 등의 총액에서 금융투자상품의 처분, 그 밖의 방법으로 그 일반투자자가 회수하였거나 회수할 수 있는 금전 등의 총액을 뺀 금액으로 추정된다. 따라서 본건의 경우 신청인은 이 사건 해외 원유선물 ETN의 취득을 위하여 지급한 금액 59,898,510원과 이를 처분하여 회수한 42,717,236원의 차액인 17,181,274원 상당의 손해를 입었다 할 것이다.

다만, 판례는 자본시장법상 적합성 원칙 및 설명의무 위반의 경우에도 손해의 공평한 분담이라는 견지에서 과실상계를 인정하고 있는데(대법원 2015. 1.29. 선고 2013다217498 판결 등 참조), 본건의 경우 ① 금융투자는 기본적으로 투자자인 신청인의 책임 하에 이루어지는 것으로 투자상품의 내용이나 구조, 특성, 위험성 등에 대하여 신중하게 검토한 다음 투자여부를 결정하여야 함에도 이를 게을리 한 채 피신청인 직원의 권유를 막연히 그대로 따른 과실이 있는 점, ② 신청인이 이 사건 해외 원유선물 ETN 매매거래 도중에 투자성향을 이 사건 해외 원유선물 ETN 투자가 가능한 투자성향으로 변경한 사실이 있는 점 등을 참작하여 피신청인의 손해배상책임을 신청인이 입은 손해액의 30%로 제한함이 타당하다.

라. 결 론

그렇다면, 신청인의 청구는 위 인정범위 내에서 이유 있으므로 일부인용하기로 하고 주문과 같이 결정한다.

제2장

매매주문 부당처리

제1절 매매주문 착오

2-1

직원이 신용매수주문을 현금매수로 잘못 처리한 경우 손해배상책임 여부

[일부 인용] 직원이 주의의무를 다하여 매수주문을 수탁하였다면(신용매수주문을 현금매수로 처리함) ○○ 주식 900주를 신청인이 보유할 수 있었으나 그러하지 못하여 동 주식 490주가 반대매도 되었고, 추가적으로 동 주식을 매도하여야 동 주식을 900주만큼 신용매수할 수 있다는 직원의 설명을 듣고 잔여주식 410주를 매도한 사실이 인정되므로 증권회사는 반대매도로 인한 손해액을 배상할 책임이 있다 할 것임.(1999.10.12. 조정번호 제99-49호)

가. 사실관계

신청인은 1999.7.9. 09:02 A기업 주식 1,300주를 1주당 52,000원에 신용매수할 것을 주문하였으나 470주만 매수체결되고 830주는 매수체결되지 아니하자 당일 10:05 매수주문이 체결되지 아니한 부분에 대하여 다시 매수가격을 58,400원으로 하고, 매수수량을 900주로 정정하여 매수주문을 하여 전량이 체결됨(당시 피신청인 직원은 동 주문을 받고 당초주문을 취소한 후 신규 매수주문으로 전산입력하면서 신청인에게는 신용매수 또는 현금매수여부를 확인하지 아니한 채 현금매수주문으로 처리하였음).

직원은 같은 달 14일 08:22 A기업 주식 490주를 시장가로 반대매도주문하고, 08:30 신청인에게 미수금으로 인한 반대매도 예정사실을 통보하면서 반대매도 결제일에 신용매수가 가능하다고 고지함. 신청인은 당일 13:34 신용으로 A기업 주식을 재매수하기 위하여 반대매도된 490주 이외에 410주도 매도함.

A기업 주가가 연 2일째 상한가를 기록하여 동 주식을 재매수하지 못하자 같은 달 16

일 신청인은 직원에게 일주일의 시간적 여유를 주었으나 19일에 이르러 직원은 신청인에게 손해배상이 불가능하다는 사실을 통지함.

나. 당사자의 주장

(1) 신청인의 주장

직원이 A기업 주식 900주의 매수주문을 처리함에 있어 “주당 58,500원의 신용매수주문을 현금매수로 처리”하여 미수금이 발생되어 490주가 반대매도 되었음. 또한 직원이 반대매도 결제일에 신용에 의한 재매수가 가능하다는 재매수 등에 소요되는 수수료 차액 및 주가변동으로 인한 손실에 대하여 책임진다 하여 410주를 추가매도하였으나 동매도후의 주가상승으로 인하여 재매수하지 못하여 손해를 보았음. 따라서 반대매매로 인한 손해 8,823,000원과 매도후의 주가상승으로 인한 기회수익에 대한 손실 38,665,000원을 합한 47,488,000원을 배상하여야 함.

(2) 피신청인의 주장

신청인은 A기업 주식 900주를 매수주문할 때 직원에게 신용매수하라 지시한 사실이 없고, 당시 신청인의 계좌에서 신용매수할 경우 신용증거금이 잡히기 때문에 신청인이 주문한 900주는 주문가능수량을 초과하게 되어 860주만 주문가능하나 직원이 주문을 받으면서 현금, 신용의 매수구분에 대하여 재확인을 받지 않고 현금매수로 처리한 과실은 있는 것으로 판단되어 반대매도로 인한 손해금액 4,230,000원은 변제의를 표시한 적이 있음. 그러나 신청인도 매수주문 당시 매수대금 결제방법에 대하여 정확하게 의사표시를 하지 아니한 과실이 있으며 미수금발생에 따라 반대매도된 수량을 제외한 나머지 410주를 신청인이 신용으로 재매수하기 위하여 매도한 것은 직원의 책임이 아님.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 담당직원이 매수주문 처리시 선량한 관리자로서의 주의의무를 다하였는지 여부라 할 것임.

(1) 매매주문 수탁과 관련한 주의의무 위반 여부

직원은 신청인으로부터 A기업 주식 900주의 매수주문을 수탁함에 있어 신청인이 당일 1,300주를 신용매수할 것을 주문하였으나 이중 470주만 매수체결되고 잔여 830주가 매수 체결되지 않아, 신청인이 다시 매수가격을 올려 매수주문한 사실을 알았음에도 매수대금 결제방법(신용매수, 현금매수)에 대하여 확인을 하지 않고 현금매수로 처리하였는 바, 이는 직원이 선량한 관리자로서의 주의의무를 다하였다고 볼 수 없으므로 피신청인은 이와 같은 업무처리로 인하여 신청인에게 발생한 손해에 대해서 배상책임이 있다고 할 것임.

(2) 손해배상금액의 산정기준

직원이 주의의무를 다하여 매수주문을 수탁하였다면 신청인은 A기업 주식 900주를 보유할 수 있었으나 그러하지 못하여 동 주식 490주가 반대매도 되었고, 신청인은 추가적으로 주식을 매도하여야 동 주식을 신용매수할 수 있다는 직원의 설명을 듣고 잔여 410주를 매도한 사실이 인정되므로 손해배상금은 피신청인의 반대매도로 인한 손해액과 추가매도로 인한 손해액을 합한 8,823,000원으로 산정함이 타당함.

한편, 신청인은 A기업 주식 900주를 매수주문함에 있어 매수대금 결제방법을 현금결제 또는 신용결제중에서 어느 하나로 특정하지 아니한 과실이 있으므로 신청인의 이러한 과실을 참작하되 동 과실비율은 10%로 함이 타당함.

라. 결 론

직원의 매수주문수탁과 관련한 주의의무 위반사실이 인정되므로 피신청인은 이로 인하여 신청인이 입은 손해액중 금7,940,700원을 신청인에게 지급하여야 할 것으로 판단됨.

2-2 직원이 공매도주문을 수탁거부한 경우 손해배상책임 여부

[기각] 공매도는 결제일에 동종의 주식으로 상환이 되지 아니하면 결제불이행에 따르는 위험을 증권회사가 부담하는 거래로서 거래성격상 또는 거래질서의 안정을 도모하기 위하여 증권회사가 공매도주문을 수탁거부할 수 있다고 보아야 함.(1999.11.2. 조정번호 제99-56호)

가. 사실관계

1999.7.15. 08:40 신청인이 직원 A씨에게 B기업 주식 4,250주의 공매도를 요구하자 A씨는 회사의 규정상 담당직원의 책임하에 공매도 주문을 접수하게 되어 있음을 알고 신청인에게 거래담당직원 유무를 확인한 결과 신청인이 거래담당 직원이 없다는 답변을 하자 A씨는 공매도거래의 위험을 부담할 이유가 없다고 판단하여 주문접수를 거부하면서 다른 직원 B씨에게 전화를 돌려줌.

직원 B씨도 08:40~08:50경 신청인의 공매도주문⁴⁶⁵⁾을 접수거부하고 전화를 C씨에게 돌려주었으며, 08:50경 C씨도 주문접수를 거부하면서 규정담당자 D씨에게 전화를 돌려주자 D씨는 08:55경 신청인의 공매도 주문을 접수할 직원이 있는지 여부를 확인한 후 주문을 접수할 직원이 없음을 신청인에게 통보함.

14:40경 신청인이 직접 지점을 방문하여 C씨에게 A기업 주식 공매도 주문을 하고, C씨가 이를 접수하여 A기업 주식 4,250주의 공매도가 이루어짐.

나. 당사자의 주장

(1) 신청인의 주장

직원이 「증권거래법」상 거래방법의 하나인 공매도주문을 접수거부할 명백한 근거가 없으면서 주문접수를 거부하다가 신청인이 직접 지점을 방문하여 주문을 내었을 때 직원이 비로소 증거금을 확인한 후 주문을 접수함에 따라 A기업 주식을 적시에 매도하지 못하여 손해가 발생한 것이므로 이에 대한 배상을 하여야 함.

(2) 피신청인의 주장

공매도의 경우 결제일에 미수유가증권이 대량으로 발생하면 결제불이행의 위험이 있기 때문에 내부지침에 의하여 공매도주문 수탁을 억제하고 있으며, 관련직원도 동 내부지침에 따라 공매도주문 수탁을 거부한 것임. 다만, 공매도주문을 접수한 직원이 결제일

465) 신청인은 1999.7.7. 실권주 청약한 B기업 주식 4,260주가 1999.7.19. 입고될 예정이어서 동일자에 동 주식의 주가가 하락할 것을 예상하여 7.15. 공매도 주문을 하였다고 주장함.

에 미수유가증권 발생시 반대매매에 의한 정리 등 관리에 책임을 질 경우에는 자신의 판단에 의하여 선별적으로 주문접수를 하고 있을 뿐이므로 공매도주문 수탁거부를 이유로 하는 손해배상 청구는 수용하기 어려움.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 담당직원이 공매도주문을 거부한 것이 적정한지 여부라 할 것임.

(1) 공매도주문에 대한 수탁거부 가능 여부

공매도는 장래 특정종목의 주가가 하락될 것으로 예상하는 경우에 비록 자신이 보유하지는 않으나 해당주식을 매도하고 결제일이 도래하면 이미 매도한 주식과 동종의 주식으로 상환하는 거래임. 따라서 결제일에 상환이 되지 아니하면 결제불이행에 따르는 위험을 증권회사가 부담하는 거래임.

따라서 대부분의 증권회사에서는 내부지침 등의 업무방법을 정하여 공매도주문 수탁을 억제하고 있으며, 만약 미수유가증권이 발생하는 경우 담당직원이 정리책임을 질 경우에 한하여 공매도주문을 수탁하도록 허용하고 있음. 이와 같은 공매도의 거래성격상 증권회사에게 고객의 공매도주문에 대하여 반드시 응할 의무는 없다고 판단됨.

한편 「증권거래소 업무규정」 제52조 제1항 제2호 및 피신청인의 「위탁매매약관」 제4조 제1항(수탁의 거부)에 의거하여 판단할 때에도 피신청인은 거래질서의 안정을 도모하기 위하여 공매도주문을 수탁거부 할 수 있다고 판단됨.

또한 상기 「증권거래소 업무규정」 제52조 및 피신청인의 「위탁매매약관」 제4조의 성격은 수탁거부사유를 예시적으로 열거한 조항으로서 여기에서 열거한 사유 이외에는 반드시 수탁하여야 한다고 해석할 성질의 조항이 아니므로 피신청인은 그의 업무수행상의 판단에 따라 주문수탁을 거부할 수 있다고 해석하여야 할 것임.

라. 결 론

위에서 살펴본 바와 같이 피신청인이 신청인의 공매도주문을 수탁거부할 수 있으므로 이를 이유로 한 신청인의 손해배상청구는 받아들이기 어려움.

2-3 주식매수청구권 행사를 약속한 후 이행하지 않은 경우의 손해배상책임

[인용] 피신청인은 신청인에게 주식매수청구권을 행사해주겠다고 약속하고도 이를 행사하지 아니한 사실이 인정되는 바, 선량한 관리자로서의 주의의무를 다하였다고 볼 수 없음. 따라서 피신청인은 신청인의 주식매수청구권 행사신청을 정상적으로 접수·처리하였을 때의 매도할 수 있었던 금액과 익일 시초가로 매도주문하였을 때의 매도할 수 있었던 금액과의 차액을 배상하여야 할 것임.(2000.1.18. 조정번호 제2000-3호)

가. 사실관계

1999.9.6. 신청인이 피신청인의 직원에게 A기업 주식 18,385주에 대한 주식매수청구권 행사 신청서⁴⁶⁶⁾를 제출하였으며, 9.9.~9.10. 신청인이 A기업 주식 3,090주를 주당 8,000원~8,130원에 매도함.

1999.9.15. 직원이 신청인에게 A기업 주식의 주식매수청구권 행사가격(8,600원)에 근접한 가격으로 매도주문하고 매도주문이 체결되지 아니하면 주식매수청구권을 행사하자고 제의하여 신청인으로부터 승낙을 받아 A기업 주식 4천주는 8,500원에, 또 다른 1만주는 8,600원에 매도주문하고, 잔여주식 1,259주에 대하여는 주식매수청구권을 행사함.

1999.9.15. 15:00경 직원은 매도주문이 체결되지 아니한 사실을 신청인에게 보고한 후 주식매수청구권을 신청하려 하였으나 이미 14:00에 전산입력이 마감되어 A기업 주식 1만 4천주에 대하여 주식매수청구권을 행사할 수 없게 됨.

나. 당사자의 주장

466) A기업과 B기업이 합병을 하게 됨에 따라 이에 반대하는 주주는 일정한 가격으로 소유주식을 해당 회사에 매도할 수 있는 권리를 갖게 되며, 이러한 권리를 행사하기 위해서는 주식매수청구권행사 신청서를 해당 회사나 거래하는 증권회사에 제출하여야 함.

(1) 신청인의 주장

A기업 주식의 주식매수청구권 행사 마감일에 직원의 권유에 따라 매도주문을 한 것은 사실이나 A기업 주가가 주식매수청구권 행사가격(8,600원) 이하가 되면 주식매수청구권 행사신청을 재접수하는 조건으로 매도주문한 것임.

따라서 A기업 주가가 매수가격 이하로 형성되었음에도 직원이 주식매수청구권 행사신청을 재접수하지 아니함으로써 주식매수청구권을 행사할 수 없게 되어 손해가 발생하였으므로 피신청인은 이로 인한 손해를 배상하여야 함.

(2) 피신청인의 주장

신청인이 A기업 주식의 주식매수청구권 행사와 관련하여 직원과 협의하여 동 주식을 장중 매도하기로 하고 주식매수청구권 행사를 취소하였음에도 불구하고 이후 동 주식의 가격이 계속 하락하여 손실이 확대되자 직원이 임의로 주식매수청구권 행사를 취소하여 손해가 발생하였다며 손해발생의 책임을 피신청인에게 전가하고 있음.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 주식매수청구권 행사 약속을 미이행한 것이 적정한지 여부라 할 것임.

(1) 손해배상책임 여부

위탁매매인인 피신청인은 선량한 관리자의 주의로써 위탁사무를 처리하여야 할 의무가 있으며 이를 위반하여 고객에게 손해가 발생하면 손해배상책임을 지게 됨.

피신청인은 신청인과 협의하여 A기업 주가가 주식매수청구권 행사가격(8,600원) 이하가 되면 주식매수청구권 행사신청을 재접수하는 조건으로 A기업 주식 4천주를 8,500원에, 1만주를 8,600원에 매도주문하였으나 당일 시세(시가 8,000원, 고가 8,490원, 저가 7,910원, 종가 8,000원)로 보아 매도주문이 체결되지 못할 것이라는 것을 충분히 예상할 수 있었음에도 주식매수청구권을 행사하지 아니한 사실이 있음.

한편, 신청인은 장 종료후 매도주문 미체결 사실을 보고받고 직원에게 주식매수청구권

행사신청 접수여부를 확인하고 재접수를 요구하였으나 이미 14:00에 업무가 마감되어 재접수가 불가능한 상황이었음.

따라서 피신청인은 선량한 관리자로서의 주의의무를 다하였다고 볼 수 없으므로 피신청인의 이와 같은 업무처리로 인하여 신청인에게 발생한 손해에 대해서는 배상할 책임이 있다고 할 것임.

(2) 손해배상금액의 산정기준

신청인은 주식매수청구권을 행사할 수 없게 된 사실을 장 종료후 인지하였으므로 그 익일인 1999.9.16. 시초가로 A기업 주식을 처분할 수 있었음. 따라서 손해배상금은 피신청인이 신청인의 주식매수청구권 행사신청을 정상적으로 접수·처리하였을 때의 매도금액(주당 8,600원)과 1999.9.16.의 시초가(8,000원)로 매도하였을 때의 매도금액과의 차액인 금 8,694,000원으로 산정⁴⁶⁷⁾함이 타당할 것임.

라. 결 론

피신청인의 직원이 선량한 관리자로서의 주의의무를 위반한 사실이 인정되므로 피신청인은 신청인이 입은 손해액중 금 8,694,000원을 지급하여야 할 것으로 판단됨.

2-4 직원이 매수주문과 다른 종목을 매수한 경우 손해배상책임 여부

[일부인용] 피신청인은 신청인으로부터 위탁받은 주문의 내용이 정확하지 아니한 경우에는 신청인의 의사를 다시 확인하고 수탁하여야 함에도 자의적으로 판단하여 신청인이 의도하지 아니하였던 주식을 매수함으로써 신청인에게 손해를 입힌 사실이 있음.(2000.2.15. 조정번호 제2000-13호)

가. 사실관계

467) 주식매수청구권 행사시 매도금액(A): 119,798,000원, 1999.9.16. 매도가능금액(B): 111,104,000원.
→ 손해배상금액(A-B): 8,694,000원

1999.9.3. 아침 신청인이 피신청인의 직원 자택을 방문하여 “A기업 우선주3을 주당 11,200원에 2천주 매수하여 달라”고 요청함. 해당 직원은 출근과 동시에 신청인이 요청한 주식의 매수주문을 처리하려 하였으나 “A기업 우선주3” 주식이 존재하지 아니하여 11:15 A기업 우선주를 주당 4,370원에 6,300주를 매수하고, 동일 13:00경 신청인이 피신청인의 지점을 방문하였을 때 직원은 신청인에게 A기업 우선주 매수체결 사실을 통지하였고, 신청인은 “종목, 가격, 수량이 전부 다른데 어떻게 매수하였느냐”고 이의제기를 함.

나. 당사자의 주장

(1) 신청인의 주장

1999.9.3. 객장에 나갈 수가 없어서 근처에 사는 직원을 찾아가 A기업 우선주3을 매수 주문한 사실은 있으나 직원이 주문과 달리 종목, 가격, 수량을 자의적으로 판단하여 매수한 사실을 알고는 즉시 이의제기를 하였고, 직원도 이로 인하여 발생한 손해에 대하여 한달 정도의 시간을 주면 원상회복을 하여준다고 약속하였음. 그러나 직원은 약속을 지키지 않고 미루다가 1999.11.1. 사표를 제출하였고, 이에 피신청인의 감사실에 이의제기를 하였더니 대안이 없다고 하여 금융감독원에 분쟁조정신청을 하였던 바 직원의 자의적인 매수로 인하여 발생한 손해를 배상하여 주기 바람.

(2) 피신청인의 주장

신청인 계좌의 B기업 우선주 매수는 신청인이 B기업을 A기업으로 착오하여 위탁하였고, 직원은 신청인의 착오사실을 인지하고 신청인의 의사 확인을 위해 노력하였음에도 불가능한 상황에서 주가가격의 가변성과 고객 이익에 대한 의무감에서 B기업 우선주를 매수처리하였음.

신청인의 의도대로 B기업 2우B 주식을 매수하였다 하더라도 신청인이 현재까지 보유하였다면 그 손실액은 A기업 우선주 매수로 발생한 손실액과 비슷한 상황임에도 착오주문으로 인한 책임을 직원에게만 전가하는 것은 형평에 맞지 않는 주장임.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 매수주문 처리시 직원이 주의의무를 다하였는 지 여부라 할 것임.

(1) 선관주의의무 위반여부

위탁매매인인 피신청인은 선량한 관리자의 주의로써 위탁사무를 처리하여야 할 의무가 있으며 이를 위반하여 고객에게 손해가 발생하면 손해배상책임을 지게 됨. 증권거래소의 업무규정 제50조(수탁의 내용)에 의하면 증권회사는 위탁자로부터 매매거래의 위탁을 받을 때에는 종목, 수량, 가격 등을 확인하여 수탁하여야 하는바, 피신청인은 신청인으로부터 위탁받은 주문의 내용이 정확하지 아니한 경우에는 신청인의 의사를 다시 확인하고 수탁하여야 함에도 자의적으로 판단하여 신청인이 의도하지 아니하였던 주식을 매수함으로써 신청인에게 손해를 입힌 사실이 있음.

따라서 피신청인은 선량한 관리자로서의 주의의무를 다하였다고 볼 수 없으므로 피신청인의 이와 같은 업무처리로 인하여 신청인에게 발생한 손해에 대해서는 배상할 책임이 있다고 할 것임.

(2) 손해배상금액의 산정기준

신청인은 자신이 의도하지 아니하였던 B기업 우선주 매수사실을 인지한 1999.9.3. 오후 1시경 하한가인 3,230원으로 동 주식을 매도할 수 있었음. 따라서 피신청인은 B기업 우선주 매수금액과 신청인이 동 주식을 매도할 수 있었던 금액과의 차액을 배상하되, 신청인도 존재하지 아니한 주식에 대하여 매수주문을 한 과실이 있으므로 이러한 과실을 참작하여 동 과실비율을 20%로 적용하여 산정한 금 5,985,958원을 손해배상금으로 지급하여야 할 것임.

라. 결 론

피신청인의 직원이 선량한 관리자로서의 주의의무를 위반한 사실이 인정되므로 피신청인은 신청인이 입은 손해액중 금 5,985,958원을 지급하여야 함.

2-5 계좌주의 동의 없는 매도주문 처리로 인한 손해배상책임 여부

[일부인용] 신청인과 담당직원 사이의 통화내역을 보면, 당사자의 의사는 매도권한의 완전한 일임이 아니라 담당직원이 매도가격·시기를 검토하여 매도 전에 다시 신청인에게 최종 승인을 얻겠다는 의미로 해석함이 타당하므로, 담당직원이 신청인과의 사전 협의를 거치지 않은 채 본건 주식을 전량 매도하는 부적정한 주문처리 업무를 하여 신청인의 의사에 반하여 의도했던 매도가격 이하로 본건 주식을 처분케 하는 결과를 초래하였다면 피신청인은 그에 대한 손해배상책임을 부담한다 할 것임.(2009.12.8. 조정번호 제2009-100호)

가. 사실관계

2009.6.3. 신청인은 “A기업 주식 1,240주”(이하 “본건 주식”이라 함)를 신청 외 ◇◇증권에서 ○○증권(이하 “피신청인”이라 함)으로 대체 입고함.

2009.8.7. 담당직원은 신청인에게 전화를 걸어 본건 주식을 12만원 정도에 매도할 것을 협의하였는데, “12만원 근처에서 (구체적인 매도가격을) 결정하여 다시 전화”하기로 함. 같은 달 12일 담당직원은 신청인에게 연락을 하지 않은 채 본건 주식을 “12만 1천원에 전량 매도”하였고, 해당 주식매도 사실은 신청인에게 통보⁴⁶⁸⁾되지 않았으며, 신청인이 HTS 등을 통하여 거래내역을 조회한 사실도 없었음.

2009.8.13. 담당직원은 신청인에게 전화를 걸어 본건 주식을 “12만 5천원 정도에 매도”할 것을 제의⁴⁶⁹⁾하였고 신청인은 이를 거절하였으며, 같은 해 9.9. 10:18경 담당직원은 신청인에게 전화를 걸어 본건 주식을 “17만 1천원 근처에서 매도”할 것을 제의하였고,

468) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제73조(매매명세의 통지) 투자매매업자 또는 투자중개업자는 금융투자상품의 매매가 체결된 경우에는 그 명세를 대통령령으로 정하는 방법에 따라 투자자에게 통지하여야 한다.

동 「시행령」 제70조(매매명세의 통지 방법) ① 투자매매업자 또는 투자중개업자는 법 제73조에 따라 통지를 하는 경우에는 다음 각 호에서 정하는 방법에 따라야 한다.

1. 매매가 체결된 후 지체 없이 매매의 유형, 종목·품목, 수량, 가격, 수수료 등 모든 비용, 그 밖의 거래내용을 통지하고, 매매가 체결된 날의 다음 달 20일까지 월간 매매내역·손익내역, 월말 현재 잔액현황·미결제약정 현황 등을 통지할 것

469) 2009.8.12. 본건 주식이 이미 매도되었음에도 이를 인식하지 못하고 신청인에게 매도를 제의한 것임.

신청인은 이에 대하여 동의하였음. 그런데, 그 직후 담당직원은 “본건 주식이 8.12. 이미 전량 매도된 사실”을 발견하고 10:28경 이를 신청인에게 통지함.

본건 주식의 2009.9.9. 종가는 16만 5천원(▼500, -0.30%), 고가는 17만 1,500원, 저가는 16만 1,000원⁴⁷⁰⁾이었고, 2009.8.7.~9.9. 기간중 통화내역 기록상 신청인과 담당직원 사이의 별도의 통화사실은 없는 것으로 확인되고, 특히 2009.8.7.이후 본건 주식매도가 있었던 8.12.까지의 기간 중 신청인과 담당직원의 휴대전화 통화내역도 존재하지 않음.

나. 당사자 주장

(1) 신청인 주장

피신청인 담당직원의 역할은 “주식 매도가격 결정”에 관한 조언을 하는 것이고 실제 “매도여부의 결정”은 신청인에게 유보되어 있음에도, 담당직원은 신청인의 승인 없이 2009.8.12. 임의로 본건 주식 전량을 매도하고 그 체결결과를 통보해 주지도 않음으로써 실제로 매도결정을 하였던 9.9.에 매도가 되었다면 얻을 수 있었을 차익 상당의 손해를 발생시켰는 바, 피신청인이 이를 배상하여야 함.

(2) 피신청인 주장

담당직원이 2009.8.12. 본건 주식을 매도하고 그 체결결과를 신청인에게 통보하지 않은 것은 사실이나, 위 주식매도는 2009.8.7. 신청인의 담당직원에 대한 “매도권한의 일임”에 따라 행하여진 것이므로 매도행위 자체는 불법행위라고 볼 수 없는 바, 신청인의 손해배상 주장은 수용할 수 없음.

다. 위원회 판단

◆ 본건의 쟁점은 피신청인 담당직원의 주문처리의 적정 여부(매도권한 일임 여부) 및 그에 따른 구체적인 손해배상액 산정이라 할 것임

470) 당일 본건주식의 거래가격은 09:27경부터 09:29경 사이에 17만원대(최고 17만 1,500원)를 기록하였고, 나머지 시간대(신청인과 담당직원이 17만 1,000원 정도에 매도를 협의한 10:18경 포함)에서는 16만원대에서 거래가 이루어졌음.

(1) 주문처리의 적정 여부(매도권한 일임 여부)

담당직원이 신청인의 개별적 승인 없이 2009.8.12. 본건 주식을 매도한 것이 불법행위를 구성하는지 여부는 결국 “신청인의 담당직원에 대한 매도권한의 일임”이 있었는지 여부에 귀결된다 할 것임.

이와 관련하여 위에서 살펴본 신청인과 담당직원 사이의 2009.8.7., 8.13. 및 9.9.자 각 통화내역 발췌를 종합해 보면, <2009.8.7.자 통화내역>에서 신청인이 담당직원에게 “파세요”, “그렇게 알아서 해 주세요”라는 표현을 사용한 점으로 볼 때 일임 신청인이 담당직원에게 “매도권한을 일임한 것과 같은 외관”이 보이는 것은 사실이나, 한편으로 위 통화 말미에서 담당직원이 “12만원 근처에서 결정을 해 가지고 또 전화 드릴게요”라고 말한 점으로 볼 때, 결국 2009.8.7. 통화 당시의 당사자의 의사는 “매도권한의 완전한 일임”이 아니라 “담당직원이 매도가격·시기를 검토하여 매도 전에 다시 신청인에게 전화를 하여 최종 승인을 얻겠다”는 의미로 해석함이 문언에 부합되고, 실제로 바로 다음 통화인 <2009.8.13.자 통화내역>을 보면 담당직원이 “매도가격에 대하여 신청인과 사전에 협의하여 승인을 구하고 있는 사실”이 나타나고 있으며, <2009.9.9.(10:28경)자 통화내역>에는 담당직원이 “주문을 한번 내자고 그래 결정을 했다 아십니까? 그래 가지고 좀 더 있어보자 하면서 알겠습니다하고 제가 계속 있겠습니다하고 이렇게 말씀을 했는데”, “그때 사실 주문내고 ‘취소’를 제가 분명히 들어갔거든요”라고 말한 사실이 있는 바, 이는 담당직원 스스로 “신청인의 최종 승인이 없는 본건 주식을 매도할 권한이 없음”을 잘 알고 있었음을 나타낸다 할 것임.

위와 같은 사실을 종합할 때, 만약 피신청인의 주장대로 담당직원이 2009.8.7. 신청인으로부터 본건 주식의 매도권한을 일임 받았다고 한다면 피신청인과 사전에 협의를 하여 매도 승인을 구할 필요가 없었음에도 담당직원은 신청인의 승인을 얻어야 함을 인식하고 신청인과 협의하였던 사실이 인정되므로, 피신청인의 “일임매매 주장”은 수용하기 어렵다 할 것임.

그렇다면, 결국 피신청인 담당직원은 약속과 달리 신청인과의 사전 협의를 거치지 않은 채 본건 주식을 전량 매도하는 “부적정한 주문처리 업무”를 함으로써, 신청인의 의사

에 반하여 “의도했던 매도가격 이하로 본건 주식을 처분케 하는 결과”를 초래하였는 바, 피신청인은 그에 대한 손해배상책임을 부담한다 할 것임.

(2) 손해배상액 산정

신청인의 손해금액은 금 5,456만원 상당⁴⁷¹⁾이라 할 것임. 한편, 위에서 본 바와 같이 본건에 있어 피신청인의 손해배상책임을 인정되나, 아래와 같은 이유로 그 구체적인 배상액은 일부 감액함이 상당하다 할 것임.

신청인과 피신청인 담당직원간의 통화내역 등 제반 사정을 살펴볼 때, 담당직원이 본건 주식을 매도한 것은 통상의 고의적인 “임의매매”라기 보다는 “매도 주문처리 상의 업무착오”에 기인한 것으로 보여지고, 신청인도 2009.8.7. 전화통화에서 마치 담당직원에게 본건 주식의 매도권한을 일임하는 것처럼 오해할 만한 의사표시를 한데다 당시에는 “12만원 근처”에서 매도할 의사를 가지고 있었으며, 이에 더하여 “손해의 공평한 부담”을 지도원리로 하는 손해배상 제도의 취지를 고려할 때, 피신청인의 책임을 손해액의 50%로 제한함이 타당함.

라. 결 론

그렇다면, 피신청인은 신청인에게 손해금액 54,560,000원의 50%인 금 27,280,000원을 배상하도록 조정함이 상당함.

471) 본건 주식의 2009.9.9. 종가(16.5만원)와 2009.8.12. 실제 매도가격(12.1만원)의 차액(4.4만원)×1,240주는 5,456만원임. <2009.9.9.(10:18경)자 통화내역>에 비추어 볼 때 신청인과 담당직원은 “2009.9.9. 본건 주식을 매도할 것”은 확정하였던 것으로 보이나, 매도가격은 “17.1만원쯤”으로 “일종의 기준”을 협의하였을 뿐 구체적 매도가격을 특정하지는 않았던 점 및 당일 본건 주식의 거래가격은 09:27경부터 09:29경 사이에 17만원대(최고 17만 1,500원)를 기록하였으나 실제 위 통화가 이루어진 10:18경 이후로는 16만원대(최저 16.1만원)에서 거래가 이루어진 점 등을 고려할 때 결국 당일 종가인 16.5만원을 기준으로 손해액을 산정하는 것이 적절함.

제2절 반대매매 관련

2-6 미수금 규모에 비하여 과도한 옵션 반대매도로 인한 손해배상책임

[인용] 반대매매의 범위를 결정하는 것이 피신청인에게 맡겨져 있다 하더라도 고객의 이익을 고려하지 아니한 과도한 반대매매까지 제한없이 허용되는 것은 아니라고 할 것임. 따라서 본 건의 경우처럼 소액의 미수금(약3만원)이 발생하였음에도 불구하고 신청인의 보유옵션 전체(95백만원)를 반대매매함으로써 신청인에게 손해를 입혔다면 피신청인의 이와 같은 업무처리로 인하여 신청인에게 발생한 손해에 대해서는 배상할 책임이 있다고 할 것임.(2000.2.15. 조정번호 제2000-14호)

가. 사실관계

1999.10.27. 신청인은 콜옵션 11월물(행사가격 105) 590계약과 콜옵션 11월물(행사가격 107.5) 100계약을 매수하여 동일 현재 신청인은 콜옵션 11월물 105: 590계약, 콜옵션 11월물 107.5: 450계약을 보유하게 됨.

1999.10.28. 08:12 피신청인의 직원 A씨가 신청인의 휴대폰에 “손님계좌에서 추가증거금 32,420원이 발생하여 오늘 12시전까지 영업미수금 막으시면 되고, 아니면 반대매매에 나간다고 연락드립니다.”라는 내용의 음성메시지를 남김. 당일 11:58경 신청인은 음성메시지를 확인하고, 피신청인의 직원 B씨와 통화를 하면서 미수금을 대납해달라고 하고, B씨도 이에 응하겠다고 답변함. 이후 13:30경 신청인은 B씨로부터 위 옵션보유량 전부(95,330,000원)가 반대매매 되었다는 전화를 받고 항의를 하고, 상급자인 직원 C씨와 통화를 하면서 원상회복을 요구하고, 피신청인의 영업부 및 감사실을 방문하여 원상회복을 요구하면서 신청인이 보유하였던 포지션을 옵션만기일까지 유지할 의사가 있음을 밝힘. 이후 17:39 피신청인의 영업부장이 신청인에게 전화를 하여 사과하고, 신청인으로부터 옵션 재매수를 일임받음.

그 다음 날 피신청인이 콜옵션을 재매수하였으나 콜옵션가격의 상승으로 11월물 105: 225계약, 11월물 107.5: 330계약 매수하는데 그침.⁴⁷²⁾

1999.11.3. 신청인은 보유옵션을 만기일(1999.11.11)까지 유지할 것이며 옵션부족분(콜 옵션 11월물 105: 365계약, 11월물 107.5: 120계약)의 가격변동에 따른 책임은 피신청인에게 있다는 취지의 분쟁조정신청서를 제출하고, 보유옵션포지션은 만기일까지 유지함.

나. 당사자의 주장

(1) 신청인의 주장

1999.10.27. 홈트레이딩을 통하여 콜옵션을 정상매수하였으나 동 매수에 따른 수수료의 부족으로 발생한 미수금 32,420원을 정리하기 위하여 피신청인이 익일 95,330,000원에 상당하는 보유옵션을 전량 반대매매한 것은 다음과 같은 점에 비추어 볼 때 그 책임이 피신청인에게 있음.

① 수수료를 포함하여 증거금이 부족할 경우에는 당일 매수주문 수락을 거부하였어야 함에도 피신청인이 정상적으로 수탁하였는 바, 이는 피신청인이 미수금 발생을 사전에 막을 수 있는 전산시스템 구축 등의 대책을 갖추지 아니한 잘못 때문임.

② 수수료로 인하여 발생한 미수금을 징수하기 위하여 반대매매를 하는 경우 미수금에 상당하는 금액만을 반대매매하여야 함에도 보유옵션 전체를 반대매매한 것은 잘못임.

따라서 피신청인에게 이의를 제기하면서 만기일까지 옵션포지션을 유지할 것임을 명백히 하고 원상회복을 요구하였으나 피신청인이 이를 거절하였기 때문에 피해구제를 요청하는 것임.

(2) 피신청인의 주장

신청인은 수수료로 인하여 미수금이 발생한 것은 피신청인의 전산시스템 미비라고 주장하나 선물·옵션은 주문시점의 증거금과 매매체결후 증거금이 상이하며, 또한 증거금 산출의 기준이 당일 종가에 따라 변경되기 때문에 주문시에는 수수료를 징수하지 않고 일일정산시에 정산하고 있으며, 전 증권사가 이와 같은 방식으로 업무를 처리하고 있음.

472) 당초수량(콜옵션 11월물 105: 590계약, 11월물 107.5: 450계약)으로 복구하려면 1999.10.28. 종가기준으로는 16백만원이 부족하였으나, 1999.10.29. 종가기준으로는 76백만원이 부족함.

또한 신청인의 경우와 같이 주식위탁계좌에 예탁된 주식을 대용증권으로 지정하지 아니한 상태에서 현금미수가 발생하면 피신청인은 사고의 사전방지를 위하여 “미수채권처리계좌”로 분류하여 미결제약정 전량을 반대매매하고 있음. 따라서 본건과 관련하여 피신청인의 업무처리에 하자나 과실이 없으므로 신청인의 주장을 수용할 수 없음.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 소액 미수발생에 대해 보유옵션 전체를 반대매매한 것이 적정한지 여부라 할 것임

(1) 손해배상책임 여부

위탁매매인인 피신청인은 선량한 관리자의 주의로써 위탁사무를 처리하여야 할 의무가 있으며 이를 위반하여 고객에게 손해가 발생하면 손해배상책임을 지게 됨.

피신청인은 「증권회사의 선물·옵션거래업무에 관한 규정」 제13조 제1항, 「선물·옵션업무규정」 제91조 제1항, 「선물·옵션거래 계좌설정약정서」 제7조 제1항 제2호에 규정한 바에 따라 고객의 동의 없이 반대매매함으로써 미수금 충당에 필요한 조치를 취할 수 있으며, 반대매매 수량의 구체적인 산출기준에 관하여는 명시적인 규정이 없기 때문에 반대매매의 범위를 결정하는 것은 일응 피신청인에게 맡겨져 있다고 볼 수 있음.

그러나 반대매매의 범위를 결정하는 것이 피신청인에게 맡겨져 있다 하더라도 고객에 대한 “선량한 관리자로서의 주의의무”에 비추어 살펴보면 고객의 이익을 고려하지 아니한 과도한 반대매매까지 제한 없이 허용되는 것은 아니라고 할 것임.

따라서 본건의 경우처럼 소액의 미수금(32,420원)이 발생하였음에도 불구하고 신청인의 보유옵션 전체(9,533만원)를 반대매매함으로써 신청인에게 손해를 입혔다면 피신청인은 선량한 관리자로서의 주의의무를 다하였다고 볼 수 없으므로 피신청인의 이와 같은 업무처리로 인하여 신청인에게 발생한 손해에 대해서는 배상할 책임이 있다고 할 것임.

(2) 손해배상금액의 산정기준

신청인이 옵션보유분 전체가 1999.10.28. 반대매도된 사실을 인지한 후 즉시 이의제기

를 한 점, 보유했던 옵션포지션을 만기일까지 유지할 의사가 있었음을 명백히 하면서 원상회복을 요구한 점, 1999.10.29. 재매수한 옵션포지션을 만기일인 같은 해 11.11.까지 유지한 점, 1999.10.29. 옵션부족분(콜옵션 11월물 105: 365계약, 11월물 107.5: 120계약)에 대하여는 신청인이 매수하여 손해금액을 확정시키려고 한 점 등이 모두 인정되므로 옵션만기일의 종가(114.29)를 기준으로 손해배상금액을 산정함이 타당할 것임.

한편, 미수금(32,420원)을 정리하기 위하여 필요한 범위에서 반대매도(콜옵션 11월물 105: 1계약, 11월물 107.5: 1계약) 되었다면 신청인은 콜옵션 11월물 105: 589계약, 콜옵션 11월물 107.5: 449계약 및 미수금 변제후의 예탁금 142,274원을 보유하였을 것임.

따라서 손해배상금은 정상적인 반대매도후의 옵션만기일에 신청인 계좌에 발생하였을 평가액에서 과도한 반대매도후 재매입한 옵션의 만기일에 신청인계좌에 발생한 평가액 및 정상적인 반대매도후에 보유하였을 옵션을 만기일에 권리행사하는 데 소요되는 수수료를 차감한 금 413,399,710원으로 산정함이 타당할 것임.

라. 결 론

피신청인의 직원이 옵션 반대매도와 관련하여 선량한 관리자로서의 주의의무를 위반한 사실이 인정되므로 피신청인은 신청인에게 금 413,399,710원을 지급하여야 할 것으로 판단됨.

2-7 추가증거금 납부통지 없이 한 옵션 반대매매로 인한 손해배상책임 (1)

[기각] 미수계좌에 대한 반대매매제도는 주식투자의 특수성에 따라 반대매매의 절차와 방법에 관하여 이미 10여 년 동안이나 일반적인 상관행으로 확립되어 있고 위 상관행은 모든 증권회사와 증권투자자로부터 승인된 결과, 설령 법적 확신을 얻은 상관습법의 지위에는 이르지 않았더라도 이제는 의사표시해석기준으로서 이른바 사실인 관습의 지위는 획득하였다고 볼 것이며, “담보부족액이 해소되는 금액”의 의미를 4일의 유예기간내에 추가적으로 발생한 담보부족액을 4거래일 익일에 처분할 수 있다는 취지로 보고 반대매매를 행사한 것은 정당함.(2002.5.7. 조정번호 제2002-11호)

1999.11.1. 신청인은 ○○증권사(이하 “피신청인”이라 함)와 유가증권담보대출계약(한도거래제)을 체결하고 금 5천만원(2000.3.11. 3억원으로 한도증액)을 대출 받고 주식거래를 하여 왔으며, 2000.12.19. 아래와 같이 담보부족금이 발생하게 되었음.

대출잔액(a)	담보금액(b)	대출가능금액 (c=b/담보비율)	담보부족 대출금(d=a-c)	담보부족액 ⁴⁷³⁾ (d*110%)
115,796,943원	126,294,880원	114,813,527원	983,416원	1,081,758원

2000.12.19. 피신청인은 신청인에게 “담보물추가납입요청서”를 내용증명 우편의 방법으로 송달하였고,⁴⁷⁴⁾ 이후 신청인이 제공한 담보주식의 주가가 2000.12.19.부터 12.23.까지 지속적으로 하락하자 담보비율이 75.5%로 되어 12.22. 종가기준으로 담보부족대출금이 금36,318,079원으로, 대용증권의 추가담보부족액은 금39,949,887원으로 증가되었음.

한국증권금융은 신청인에게 추가적으로 증가한 담보부족액의 상황을 2000.12.22일 1회, 23일 4회에 걸쳐 전화로 통보하였고, 2000.12.23. 신청인은 한국증권금융에 2000.12.19. 통보한 금1,081,758원만을 입금하였음.

2000.12.26. 피신청인은 23일 당시까지 추가로 발생한 부족담보금액을 확보하기 위하여 신청인이 담보로 제공한 담보주식전량을 금118,449,640원에 매도하고 대출금과 이자를 공제한 후 정산금 1,143,053원을 신청인에게 지급함(단 유가증권담보대출계약은 원리금 공제 후에도 약정기일까지는 한도내에서 신청인이 대출을 받을 수 있음).

나. 당사자 주장

(1) 신청인의 주장

피신청인은 「여신거래기본약관(개인용)」에서 정한 10일의 납부기한을 위배하여 납부기한 일을 일방적으로 적용하였고, 신청인은 담보부족액으로 요청한 금1,081,758원을 담보물추가납입요청서상의 납부기한일내인 2000.12.23.에 납입하였으므로 일단 자신의 의무

473) 담보비율은 110% 이상임(약정서에는 130%로 되어 있으나 2000.11.24부터 110%로 하향조정)

474) 우편송달 내용: “담보부족액 1,081,758원을 납부기한일(2000.12.23.)내에 납입하여야 하며, 만일 미납입시 납부기한일 익일에 귀하의 담보증권을 처분하여 담보부족 대출금의 변제에 충당하겠습니다.”

는 다한 것이 되며, 2000.12.19.부터 12.23.까지 추가하락으로 추가 발생한 담보부족분은 아직 4일의 유예기간이 경과하지 아니하였으므로 피신청인이 일괄하여 담보부족액을 담보주식의 반대매매에 의하여 원리금 변제에 충당한 것은 부당함.

(2) 피신청인의 주장

본 건은 기한이익상실에 따른 처리가 아닌 것이며, 담보부족액 발생시 납입하여야 할 금액은 통지일 당시의 담보부족액만을 납입하면 족한 것이 아니고 납부기한내(4일의 유예기간)의 담보부족액 모두를 추가로 납입하여야 하는 것임. 당시 납입기일까지의 담보부족액과 그 이유를 전화로 상세하게 설명하였으므로 반대매매처리는 정당한 업무수행을 한 것이고, 과거에도 신청인은 위와 같은 방식의 반대매매를 인정하여온 사실이 있으며 회사의 내부적인 업무규정상 적법하게 처리한 것이므로 신청인의 청구는 수용할 수 없음.

다. 위원회 판단

◆ 본건의 쟁점은 ① 증권금융의 담보부족 통지 후 4일의 유예기간 내에 추가적으로 발생한 담보부족액까지 반대매매로 담보주식을 처분하여 대출금원리금에 변제충당할 수 있는지 여부, ② 담보주식을 협회중개시장(KOSDAQ)에서 동시호가시간대에 하한가로 매도주문을 낸 것이 선관주의 의무 위반에 해당하는지 여부 등이라 할 것임.

(1) 「여신거래기본약관」과 「근질권 설정약정서와의」 관계

이 사건 「근질권 설정 및 금전소비대차 약정서」 제5조는 근질권 실행시기에 있어 「여신거래기본약관」 제6조의 기한의 이익상실을 원용하고 있는 바, 피신청인은 담보 부족분을 해소할 수 있는 기간을 위 약관에 따른 납입 통지 도달일로부터 10일 이상으로 신청인에게 부여하여야 하는 것인지 아니면 위 약정서 제3조제1항의 추가납부 청구서를 발송한 날로부터 4일의 기간만을 부여하면 되는 것인지 문제가 되므로 이를 보건대, 「약관규제에관한법률」 제4조의 개별약정 우선의 원칙에 따라 위 쟁점을 검토하면 담보부족비율에 해당하는 담보부족분의 이행을 청구하는 담보물보충청구권에 관하여서는 당사자사이에 별도의 개별약정을 체결한 것으로 판단되고 위 약정서 제5조가 원용한 「여신거래

기본약관」 제6조의 기한의 이익상실규정은 위 담보물보충청구권에 관한 사항 이외의 기한의 이익상실 사유에 적용되는 것이므로 이 부분 신청인의 주장은 이유 없음.

본 사안의 약관과 관련규정을 보면 피신청인은 담보물의 평가에 의하여 담보가액이 부족할 경우에 「근질권 설정 및 금전소비대차약정서」 제3조제2항 및 「증권회사신용공여에 관한 규정」 제21조제3항에 의거 위탁자에게 담보의 추가납부 등 청구서를 발송하고 발송한 날로부터 4일(발송일 및 관공서의 공휴일에 관한 규정에 의한 공휴일은 제외) 이내에 담보부족이 해소되는 금액에 해당하는 대출금을 상환하거나 추가담보를 제공하기로 하고 이를 위반하였을 시에는 동 규정 제21조제1항 및 제2항, 제22조에 의거 반대매매를 통하여 채권회수에 충당할 수 있도록 규정하고 있음.⁴⁷⁵⁾

(2) 반대매매의 적정성 여부

본 건에 있어 “담보부족이 해소되는 금액”의 의미와 관련한 당사자 사이의 명시적 약정이나 규정을 발견할 수 없으므로 의사표시해석에 의하여 본 건 반대매매처분의 적법성여부를 판단하여야 할 것임.

당사자가 표시한 문언에 의하여 그 객관적인 의미가 명확하게 드러나지 않는 경우에는 그 문언의 내용과 그 법률행위가 이루어진 동기 및 경위, 당사자가 그 법률행위에 의하여 달성하려는 목적과 진정한 의사, 거래의 관행 등을 종합적으로 고려하여 사회정의와 형평의 이념에 맞도록 논리와 경험의 법칙, 그리고 사회일반의 상식과 거래의 통념에 따라 합리적으로 해석하여야 할 것임.

먼저, 거래관행에 관하여 보건대, 추가담보납부요구 및 미수금계좌에 대한 반대매매제도(임의상환제도)는 1990년 정부의 5.8. 증시부양조치에도 불구하고 주가가 회복되지 못하고, 개인투자자들의 신용거래 미수금이 계속 증가하는 등 사회적 물의가 증폭되자 당시 정부의 주도아래 증권사에 대하여 미수금계좌의 조속한 정리와 신규발생의 억제 및 미수금 관리에 철저를 기하도록 지도 감독을 강화한 바 있고 이에 따라 증권업계는 증권회사의 신용거래 약정서(1998.3.2.자로 약정서가 약관으로 대체됨), 추가담보납부 및 반

475) 「증권회사신용공여에 관한 규정」은 2000.12.29. 「증권업감독규정」으로 편입됨(증권업감독규정 제5-12조 제3항)

대매매예고 통지 서식 등을 마련하고 미수금계좌 등 담보부족발생 위탁자에 대한 철저한 채권보전을 행하여 왔음. 그 이후로 10여년 동안 증권업계는 “담보부족액이 해소되는 금액”의 의미를 4일의 유예기간내에 추가적으로 발생한 담보부족액을 4거래일 익일에 처분할 수 있다는 취지로 보고 반대매매를 행사함.

다음으로 위와 같은 관행이 선량한 풍속이나 기타 사회질서에 반하지 아니하는가의 여부를 보건대, “담보부족액이 해소되는 금액”의 의미를 4일의 유예기간내에 추가적으로 발생한 담보부족액을 4거래일 익일에 처분할 수 있다는 의미로 해석하는 경우에는 반대매매제도가 민법이나 민사소송법의 예외적 제도이고 이러한 예외적인 제도를 해석하는데 있어서는 이를 엄격하게 해석하여야 한다는 점을 고려할 때 4일의 유예기간은 고객이 부족한 담보금액을 보충할 수 있는 기간으로서 명시적 약정이나 규정이 없는 한 그 기간을 임의로 단축할 수 없다고 볼 수도 있으나, 최고기간 내에 발생한 추가담보부족분을 해소하기에 계약서에서 정한 기간이 신의칙상 현저히 짧은 기간인지 여부를 보면 원래 채권자의 이행의 최고는 상당한 기간을 정하여서 하여야 하고 상당한 기간이라 함은 채무자가 이행을 준비하고 이를 이행하는 데 필요한 기간을 말하며 이행하여야 할 채무의 성질 기타 객관적 사정을 고려하여 결정되는 것이고 채무자의 주관적인 사정은 이를 고려할 필요가 없음.

주식거래는 수익성이 높은 대신 위험성이 큰 투자수단이며 게다가 신용공여에 의한 주식의 거래는 고도의 위험성을 그 전제로 하고 있다는 점, 증권가격의 예견이 불가능한 사정에 비추어 증권회사와 고객은 엄격한 담보비율의 유지와 그 부족분에 대하여 항상 주의를 기울여야 한다는 점, 민법의 채무불이행과 그 효과로서의 해제를 하기 위한 최고에 관한 규정은 임의규정으로서 당사자가 이를 달리 정할 수 있으므로 추가담보납부요구 및 미수금계좌에 대한 반대매매제도의 위 유예기간을 해석할 유일한 기준으로는 볼 수 없는 점등에 비추어 다소 단기간으로 보여진다고 하더라도 신의칙상 추가담보부족분의 해결에 현저히 짧은 기간이라고 말할 수는 없음.

나아가 추가담보납부요구 및 미수금계좌에 대한 반대매매제도는 「증권거래법」 제49조, 「동 시행령」 제35조의15, 「증권업감독규정」에 의하여 증권시장의 안정적 운영을 통하여 유가증권의 유통을 원활히 하고 증권투자자의 무절제한 신용거래로 인하여 초래될 증권

시장의 과당투기화를 억제하는 한편 증권회사로 하여금 채권담보의 충실을 기하고 채권 회수를 신속히 하여 운영의 내실화를 도모하여 궁극적으로 투자자를 보호하는 데 그 본래의 목적이 있음.

또한 증권거래에 있어 주식가격의 변동을 예견하는 것이 사회통념상 불가능하며 위 유예기간내에 주가가 계속 하락시 추가담보가 필요할 때마다 매번 개별적으로 4일이 경과한 후에 반대매매를 하는 것은 유동성이 큰 주식과 현금을 고객의 처분권한이 허용된 채로 담보로 파악하는 증권회사의 신용공여의 특성상 대단히 비효율적인 반대매매제도를 요구하는 것이고 결국 시기 적절한 반대매매 시점의 선택을 원천 봉쇄하여 그로 말미암은 손해는 고객에게 귀속될 수밖에 없다 할 것임. 즉 신속하게 반대매매를 하여 손절매(loss cut)를 하는 것이 오히려 투자자에게 이익이 되는 경우가 많기 때문이라 할 수 있음.

증권회사의 신용공여제도는 고객이 자유로이 대출금을 언제든지 변제할 수 있어 증권회사의 기한의 이익을 제약하고 있는 점, 담보의 처분권능에서도 근질권의 목적물을 채무자가 자유로이 처분할 수 있어 고객에게 유리한 점 등에 비추어 현재의 약관이나 과거부터 형성된 관행이 금융소비자에게 반드시 불리하다고만 말할 수 없음. 결국 증권업계의 위 관행은 증권회사에게만 일방적 이익을 도모하는 제도도 아니며 위 관행에 의하여 증권회사의 도덕적 해이를 가져오거나 반대매매로 인하여 증권회사에게 부당이득을 주는 제도라고는 볼 수 없어 강행법규 기타 민법 제103조에 위반되는 것은 아닌 것으로 판단됨.

현재의 「신용거래표준약관」(2001.3.20.)은 증권업협회가 이러한 일반적인 반대매매제도의 관행을 표준화하여 제정한 것으로 제8조 제2항 단서에는 “회사가 담보의 추가납부요구시 추가담보제공기간(요구일로부터 4일)동안 담보유가증권의 가격변동 등으로 담보부족액이 증가할 수 있다는 사실을 신용거래자에게 통보하였다면 신용거래자는 동기간 동안 변동한 담보부족액까지 확인한 최종담보부족액에 대하여 담보를 제공하여야 한다.”고 규정하고 있어 이러한 관행을 명시적으로 확인하고 성문화한 것임.

그렇다면, 미수계좌에 대한 반대매매제도는 주식투자의 특수성에 따라 반대매매의 절

차와 방법에 관하여 이미 10여 년 동안이나 일반적인 상관행으로 확립되어 있고 위 상관행은 모든 증권회사와 증권투자자로부터 승인된 결과, 설령 법적 확신을 얻은 상관습법의 지위에는 이르지 않는 것이라도 이제는 의사표시해석기준으로서 이른바 사실인 관습의 지위는 획득하였다고 볼 것이며, 위 사실인 관습과 아래의 구체적 사실관계를 보면 일단 증권금융이 4일의 유예기간 동안의 추가담보부족을 해소하기 위하여 반대매매를 한 것은 위법한 처리라고 볼 수 없음.

① 신청인은 본 건 신용거래의 한도를 2번에 걸쳐 그 한도를 크게 확장하고 계속되는 신용거래를 하여 신용거래의 위험성과 그 제도의 운용방법을 상세히 알고 있었다고 보이는 점.

② 과거 8번의 추가 담보를 대용증권으로 납입시 신청인은 4거래일까지의 담보부족분을 일괄하여 납입한 사실과 2번의 임의상환 당시에는 이러한 관행에 대하여 이의를 제기한 적이 없는 점.

③ 담보물추가납입요구서의 “납부기한일내에 담보부족대출금(납부일 현재기준)에 해당하는 추가담보의 제공 또는 대출금을 상환하여야 함”이라는 부동문자가 존재한다는 점.

(3) 담보물 처분시 선관주의 의무 위배 여부

피신청인이 담보주식을 협회중개시장(KOSDAQ)에서 동시호가시간대에 하한가로 매도주문을 낸 것이 담보물의 보관 및 처분에 있어 그 관리자로서의 선관주의의무를 위배한 것이 아닌지에 관하여 보건대, 피신청인은 선량한 관리자로서의 주의를 다하여 고객의 손실을 최소한도에 그치도록 조치하여야 할 일반거래상의 의무를 부담하는 것이지만, 원래 가격변동을 예견하는 일 자체가 매우 곤란한 주식거래에 있어서는 어느 시점에서 담보물 처분을 위한 반대매매를 체결하여 그 신용거래 관계를 종결하는 것이 결국에 있어 고객의 이익을 실현하는 것으로 되는지의 여부에 관하여 예견·판단하기가 사실상 불가능에 가깝다고 할 수 있음.

반대매매는 채권의 회수에 목적이 있으므로 되도록 많은 물량을 처분할 수 있는 계약을 하여야 한다는 점과 동시호가 시간대에서는 개별경쟁매매에 따른 복수가격이 존재하지 아니하고 단일가격으로 결정되고 매매수량은 하한가 주문이 우선하여 가장 많은 물

량을 처분할 수 있으므로 증권금융 및 증권회사는 현재 하한가 주문⁴⁷⁶⁾으로 동시호가에 참여하여 반대매매를 하고 있음, 반대매매를 할 수 있는 주식의 양과 그 금원은 반대 매매한 주식의 매도금액을 대출잔액에 충당한 후, 담보금액이 대출잔액의 110%(담보유지 비율) 이상을 유지하여야 함.

피신청인의 2000.12.26. 반대매매 상황은 각 종목의 반대매매 전일(12.24.)종가에서 가격제한폭까지 하락한 가격(전일종가의 88%)으로 산정한 예상정산금액은 금102,279,119원 이, 잔여담보금액은 금5,685,630원이 되어 약정상의 담보유지의무액인 금14,869,606원을 충족하지 못하므로 별지목록 기재 유가증권전량을 동시호가대에 하한가로 매도주문을 한 것은 적법하다고 볼 것임.

라. 결 론

피신청인이 4일의 유예기간내에 추가적으로 발생한 담보부족분에 대하여 본건 유가증권을 반대매매한 것은 적법하다 할 것이므로 신청인의 청구는 이유 없다고 할 것임.

2-8 추가증거금 납부통지 없이 한 옵션 반대매매로 인한 손해배상책임 [2]

[인용] 추가증거금 납부 통지(margin call)의 성격은 민법상 최고로서 위탁자가 반대매매를 면하기 위해서는 그 추가증거금액이 발생한 날의 다음날 12시까지 추가증거금을 납부하여야 하는 점과 명문의 규정에 비추어 반드시 증권회사는 반대매매에 앞서 위탁자에게 통보를 하여야 하는 법적 의무이자 반대매매를 위한 법률요건이라 할 것임. 옵션의 손해배상 방식은 위탁자의 의도 및 거래의 경위, 거래유형, 거래포지션, 거래경험, 반대매도 후의 신청인의 태도 등 제반 사정을 참작하여 합리적인 투자자의 입장을 전제로 하여 판단하여야 할 것임.(2002.9.3. 조정번호 제2002-37호)

가. 사실관계

476) 동시호가 시간대의 반대매매에 있어서는 하한가 주문의 의미는 하한가체결을 원하는 주문이 아니라 체결순위에만 의미가 있음(따라서 실무에서는 동시호가대에서는 시장가라는 표현을 사용함).

2001.12.24. 신청인은 피신청인을 수탁자로 하는 선물·옵션 계좌를 개설하고 HTS를 통하여 거래를 하여 왔으며, 2002.4.12. 콜옵션 0205 행사가격 112.5를 평균 프리미엄 2.31로 10계약, 콜옵션 0205 행사가격 125.0을 평균 프리미엄 0.34로 3계약을 매도하였음.

2002.4.15. 15:15 거래종료 후 계좌예탁총액(10,981,668원)이 유지증거금총액(12,610,406원)에 미치지 못하여 추가로 납부하여야 하는 유지증거금이 1,628,738원 발생하였는데, 그 다음날 피신청인은 한국증권전산으로부터 원장을 이관 받는 과정에서 전산장애가 발생하여 신청인은 HTS 및 지점용단말기 상에 반대매매관련 현황을 조회할 수 없었음. 또한 피신청인 지점 담당직원 역시 신청인에게 반대매매 관련현황을 통보하지 못한 상태에서 당일 12:00경에 증거금부족에 따른 반대매매로 신청인 보유의 콜옵션 0205 행사가격 112.5 4계약은 프리미엄 4.55로, 콜옵션 0205 행사가격 125.0 1계약은 프리미엄 0.74로 각 시장가로 반대매매(매수)되어 처분되었으며 이에 따라 신청인의 위탁계좌에서 옵션매수대금 1,894,000원과 수수료 18,940원이 인출되었음.

신청인은 아무런 통보 없이 이루어진 반대매매에 대하여 즉시 항의함과 동시에 위 콜옵션 매도분을 만기까지 보유하려 했다고 주장하고, 위 반대매매된 옵션과 동일한 행사가격의 옵션을 옵션만기인 같은 해 5.9.까지 보유하였음. 2002.5.9.의 KOSPI200지수는 104.5로서 위 반대매매된 콜옵션과 동일한 행사가격의 옵션가치는 자동으로 소멸하였음.

나. 당사자 주장

(1) 신청인 주장

신청인은 HTS를 이용하여 옵션거래를 하였는데, 2002.4.16. 전산장애로 인하여 잔고조회가 불가능하였으며 피신청인으로부터 일체의 통보를 받지 못한 상황에서 만기까지 보유하려던 옵션 매도분이 반대매매 되었으므로 손해를 피신청인은 배상하여야 함.

(2) 피신청인 주장

분쟁관련 당일의 반대매매는 정상적으로 이루어졌으나 전산장애로 잔고조회를 하는 것은 불가능하였다는 사실에 관해서는 다툼이 없으나, 동 전산장애 사실에 대하여 피신청인으로서의 당일의 종가와 반대매매된 가격과의 차이를 손해금액으로 보아 15만원 범

위내에서 신청인에게 배상할 의사가 있음.

다. 위원회 판단

◆ 본 건의 쟁점은 반대매매의 가능성과 관련하여 위탁증거금을 추가로 징수하기 위하여 추가 징수금액을 위탁자에게 통지하여야 하는 지 여부와 손해배상 금액의 범위임.

(1) 손해배상 책임

「증권업감독규정」 제4-28조(선물·옵션위탁증거금의 추가납부 요구등)에서 “증권회사는 고객의 선물·옵션위탁증거금의 추가징수 사유가 발생하는 경우 지체 없이 당해 고객과 사전에 합의한 연락방법 등으로 선물·옵션위탁증거금의 추가납부를 요구하고, 그 요구사실 및 내용을 증빙할 수 있는 자료를 유지하여야 한다.”고 규정하고 있음. 또한 「선물·옵션업무규정」 제78조 제2항은 위탁증거금을 추가로 징수하고자 하는 때에는 추가징수금액을 위탁자에게 지체 없이 통지하여야 한다고 역시 규정하고 있음.

이러한 통지(margin call)의 성격은 민법상 최고로서 위탁자가 반대매매를 면하기 위해서는 그 추가증거금액이 발생한 날의 다음날 12시까지 추가증거금을 납부하여야 하는 점과 명문의 규정에 비추어 반드시 증권회사는 반대매매에 앞서 위탁자에게 통보를 하여야 하는 법적 의무이자 반대매매를 위한 법률요건이라 할 것임.

따라서 사건 당일 전산장애가 있었다는 사실 및 신청인의 잔고조회가 불가능했다는 사실, 그리고 추가증거금의 납부를 다른 방법을 통하여 통보한 사실이 없는 점에 당사자 사이에 다툼이 없으므로 피신청인은 신청인에게 손해를 배상할 책임이 있음.

(2) 손해배상액 산정

옵션의 손해배상 방식은 원칙적으로 만기까지 이를 보유할지 아니면 만기전 장중 청산을 할 것인지에 따라 달라질 수 있는 것으로 위탁자의 의도 및 거래의 경위, 거래유형, 거래포지션, 거래경험, 반대매도 후의 신청인의 태도 등 제반 사정을 참작하여 합리적인 투자자의 입장을 전제로 하여 판단하여야 하는 것이 당 위원회의 입장임.

피신청인은 당일의 종가와 반대 매매된 가격과의 차이를 손해금액으로 보아야 한다고

주장하나, 이와 같은 주장은 반대매매가 적법했다는 것을 전제로 한 주장이므로 통지의 무가 법적의무이자 반대매매의 법률요건이라는 점에서 타당하다고 볼 수 없음. 콜옵션 매도분에 있어서 옵션의 반대매매가 위법하다면 먼저 위법한 반대매매로 인한 손해는 유출된 옵션매도분의 기존 현금유입액(958,000원)과 추가로 매수에 의하여 유출된 현금(936,000원), 수수료(18,940원)의 합계가 손해라고 할 것임. 나아가 추가 증거금부족액은 사건 당일인 4.16.에는 반대매매가 나갈 수 없는 것이므로 다시 적법한 통지를 거쳐 4.17. 반대매매가 나갈 수 있는지를 살펴 정산하여야 하므로 4.16. 15:15 장종료시를 기준으로 하여 당사자사이에 별도의 금원으로 정산하여야 할 것임.⁴⁷⁷⁾

그렇다면 반대 매수됨으로써 유출된 옵션매도분의 기존 현금유입액과 반대매수에 의한 추가로 유출된 현금액, 그리고 수수료의 합계인 1,912,940원이 손해라고 할 것이고 이는 결국 반대매수로 유출된 현금의 합계액이 될 것임.

라. 결론

그렇다면 피신청인은 위법한 반대매매 행위에 대하여 신청인에게 금1,912,940원을 배상할 책임이 있다 할 것임.

2-9 반대매매시 비상장주식의 담보가치를 인정하지 않은 것의 적법성 여부

[기각] 예탁증권담보대출과 관련하여 「증권업감독규정」은 상장유가증권 등에 대한 담보사정 가격 산정방법만을 규정하고 그 외의 예탁증권의 담보사정가격 산정방법은 협회가 정하도록 규정하고 있는데, 협회가 추가로 산정방법을 규정하고 있지 않으며, 피신청인의 약관에도 고객의 계좌에 예탁되어 있는 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장된 주권을 담보로 하여 대출을 할 수 있도록만 규정하고 있어, 피신청인이 회사분할로 인하여 발생한 비상장 주식의 담보가치를 인정하지 않은 것을 위법이라 보기는 어려움.(2007.9.4. 조정번호 제2007-58호)

477) 참고로 이러한 반대매매가 없었다면 신청인의 4.16. 예탁총액은 13,464,628원으로서 유지증거금 총액 12,610,406원보다 커 4.17.에는 반대매매가 나갈 수 없으므로 추가증거금징수를 위한 정산문제는 발생되지 않는다고 할 것임.

가. 사실관계

신청인은 1999.10.18. 피신청인의 지점에서 신청인 명의의 위탁계좌를 개설하고, HTS를 이용하여 주식매매 거래를 하여 오고 있으며, 위 위탁계좌를 운영함에 있어 예탁증권 담보대출 및 신용거래를 하였는데, 피신청인은 이러한 신용공여를 위해 2007.4.25.부터 170%의 담보유지비율을 적용하고 있었음.

2007.5.31. 08:21 피신청인의 직원은 “신청인의 위탁계좌에서 7,660,012원의 담보부족액⁴⁷⁸⁾이 발생하였으며, 6월4일까지 부족액을 입금하거나 보유주식을 매각하여 담보부족을 해소하지 않으면 반대매매가 행하여진다”고 신청인에게 전화로 통지하였고, 신청인은 당일 다음과 같은 거래를 하였음(이후 A기업 주가는 하락, B기업 주가는 계속 상승).

(단위 : 주, 원)

종목명	매매구분	체결수량	체결단가	총 액	체결시간
A기업	매 도	5,000	5,090	25,450,000	10:35:14~10:35:32
B기업	매 도	400	64,100	25,640,000	13:05:57~13:06:04
C기업	매 수	300	50,100	15,030,000	13:06:26

신청인은 E기업 주식이 담보가치 산정에서 제외됨으로써 담보부족이 발생하였음을 인지한 후, 2007.6.1. 10:14:51에 피신청인에게 전화를 하여 E기업이 D기업의 분할로 생긴 회사임에도 담보가치 산정에서 제외함은 부당하다고 항의를 하였고, 이에 피신청인은 시가총액과 분할비율을 참고하여 E기업의 주당 대응가를 112,000원으로 산정하고, 반대매매와 관련하여서는 이를 담보비율 산정에 반영하여 2007.6.4.부터 동 주식 상장전일 또는 6월말까지는 한시적으로 반대매매를 유예시키기로 함.

478) 신청인은 예탁증권담보대출을 위해 D기업 주식 1,250주를 담보로 제공하고 있었는데, 동사는 기존의 D기업을 포함한 4개사로 인적·물적분할되었고, 이로 인해 신청인 위탁계좌에는 2007.5.29. 신설법인 E주식 398주가 입고되었고, 5.30. D기업 구주 1,250주가 출고됨과 동시에 신주 851주가 입고되었음. D기업 주식은 기업분할 결정 이후 2007.4.20.~5.29. 거래정지 되었다가 5.30. 변경상장되었으며, 거래정지 전일 55,000원이던 것이 기업분할 등으로 인해 변경상장일에는 종가가 23,400원으로 하락하였고, E기업 주식은 「코스닥시장상장규정」 제17조에 따라 재상장심사를 거쳐 7.2. 재상장되었음(당일 종가 126,500원). 2007.5.31. 신청인 위탁계좌의 담보비율은 168%였으며, 상장주식 등만을 담보로 인정한다는 피신청인의 약관에 따라 상장심사 중이던 E기업 주식은 당시 담보로 인정되지 않았음.

나. 당사자의 주장

(1) 신청인의 주장

피신청인은 회사 분할시 고객의 손익관계에 대한 사전 설명을 한 사실이 없음에도, 분할로 인해 생긴 E기업 주식을 담보에서 제외시켜 신청인의 위탁계좌에 담보부족이 발생하게 하였고, 이로 인해 신청인은 이후 신용 매매를 할 수 없게 되었을 뿐만 아니라 담보부족 해소를 위해 부득이하게 매도한 B기업의 주가가 계속 상승하여 손실을 입게 되었는바, 피신청인은 잘못된 담보가치 산정으로 인해 신청인에게 발생한 손해를 배상할 책임이 있음.

(2) 피신청인의 주장

「증권거래법」과 「증권업감독규정」에 따르면 예탁증권 담보대출은 상장주식을 담보로 하도록 규정하고 있으며, E기업과 같이 회사분할에 따라 미상장된 회사의 주식에 대하여는 담보사정 방법을 규정하고 있지 않은바, 피신청인의 담보부족 통보는 정당하며, 신청인의 항의가 있는 후 피신청인은 내부적으로 논의한 결과 E기업이 확정된 일자는 아니나 6월이내에 상장할 가능성이 높아 고객 편의를 위해 예외적으로 동 주식을 담보로 산정하여 반대매매를 유예하여 주었는 바, 피신청인은 손해배상책임이 없음.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 예탁증권담보대출 관련 피신청인의 담보가치 산정의 적정 여부라 할 것임.

(1) 담보가치 산정의 적정 여부

신청인은 피신청인이 담보비율을 잘못 산정하여 손해가 발생되었다고 주장하나, 다음과 같은 점에 비추어 신청인의 주장은 이유 없음.

① 「증권업감독규정」은 예탁증권담보대출과 관련하여 가치산정이 곤란하거나 담보권의 행사를 통한 대출금의 회수가 곤란한 유가증권을 담보로 징구하지 못하도록 규정함과 동시에 상장된 유가증권 등에 대한 담보사정가격 산정방법만을 규정하고 그 외의 예

탁증권의 담보사정가격 산정방법은 협회가 정하도록 규정하고 있는데, 협회가 추가로 산정방법을 규정하고 있지는 않으며, 피신청인의 약관에도 고객의 계좌에 예탁되어 있는 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장된 주권을 담보로 하여 대출을 할 수 있도록만 규정하고 있어, 피신청인이 회사분할로 인하여 발생된 비상장 주식의 담보가치를 인정하지 않은 것을 위법이라고 보기는 어렵다는 점.

② 주문 위탁만을 받은 증권회사가 고객이 투자한 회사의 분할 등으로 인한 문제점을 미리 파악하여 고객에게 안내할 의무까지 있다고 보기는 어렵다는 점.

③ 피신청인의 담당직원은 2007.5.31. 08:21경에 신청인에게 담보부족을 최초 통지하였는데, 신청인은 이보다 앞선 08:14경에 B와 A기업을 포함하여 보유하고 있던 주식에 대한 매도주문을 하였으며, 동 주문의 계약이 체결되지 않자 10:34 A기업에 대한 정정주문을 하여 매도를 하였고, 13:05 B기업에 대한 정정주문을 하여 매도를 하였으며 이후에는 현금으로 C기업을 매수한 것으로 보아 신청인이 담보부족 해소를 위해 부득이한 선택으로 B기업을 매도하여 손실을 입었다고 보기는 어렵다는 점.

라. 결론

그렇다면 피신청인은 신청인에 대하여 손해를 배상할 책임이 없다 할 것이므로 신청인의 청구는 이유 없어 이를 기각함.

2-10 담보부족 관련 부정확한 반대매매 기준 안내에 따른 손해배상책임 유무

[일부인용] 「증권업감독규정」은 위탁자의 담보부족 시 증권회사는 담보의 추가납부를 요구하고 위탁자가 그 납입기일까지 담보의 추가납부를 이행하지 아니하였을 때에 그 다음날 임의상환 처리를 할 수 있도록 규정(피신청인의 신용거래약관도 동일)하고 있는 등 피신청인에게 신청인이 반대매매를 통한 불측의 손해를 입지 않도록 할 선관주의의무가 있다고 할 것인 바, 피신청인 직원이 잘못된 안내로 시간외 종가 매매를 한 신청인이 추가 자금마련 기회를 놓쳐 손해를 보았다면 피신청인은 이로 인한 손해를 배상할 의무가 있다 할 것임.(2007.12.4. 조정번호 제2007-90호)

가. 사실관계

신청인은 2005.11.3. ○○증권사(이하 “피신청인”이라 함)에서 신청인 명의의 주식위탁계좌를 개설하고, HTS 서비스를 신청하여 주식거래를 하였으며, 위 위탁계좌를 운영하면서 예탁증권담보대출 및 신용거래를 하였는데, 피신청인은 예탁증권담보대출 및 신용거래에 대하여 130%의 담보유지비율을 적용하고 있음.

피신청인은 2007.8.17. 08:35 신청인의 휴대폰으로 “고객님 신용추가담보요청. 금액 22,375,362원. 반대매매예정 2007/8/20”이라는 내용의 메시지를 발송하였음

신청인은 2007.8.20. 07:31 시간외 종가 매매(479)를 통해 A기업 주식 3주(매도금액 17,600원)와 B기업 주식 75주(매도금액 1,282,500원)를 매도하였고, 08:10 6,005,000원을 현금입금한 후, 08:24 피신청인 상담원(이하 “상담직원”이라 함)에게 전화를 하여, 지금 매도를 하면 그 금액만큼은 반대매매를 거부할 수 있는 것인지를 문의하였고, 이에 상담직원은 매도 처리한 부분만 일부 거부 요청이 가능하다고 안내하였음. 이에 신청인은 통화 도중인 08:28~08:29 시간외 종가 매매로 B기업 주식 400주를 주당 17,100원(매도금액 6,840,000원)에, C기업 주식 800주를 주당 2,290원(매도금액 1,832,000원)에 매도하였음

상담직원은 신청인과 통화 후 반대매도처리 부서에 문의하여 일부 반대매도처리가 불가함을 확인하고, 08:32 신청인에게 전화를 하여 현금 입금으로 담보유지비율이 모두 충족되는 경우에만 반대매매가 거부됨을 다시 안내 하였으며, 이후 신청인의 추가 입금이 없어 결국 09:00 D기업 주식 900주를 포함하여 총 45개 종목의 26,078주가 104,133,470원에 반대매도 되었음.

나. 당사자 주장

(1) 신청인 주장

상담직원이 일부 반대매매가 가능하다고 하여 신청인은 시간외 종가 매매를 한 것이

479) “시간외 종가 매매”는 투자자에게 추가적인 매매거래 기회를 제공하기 위하여 정규 매매시간 종료 후 당일 종가로, 다음날 장 개시 전 전일 종가로 일정시간 시간우선의 원칙만 적용하여 매매거래를 성립시키는 제도를 말함(거래시간: 07:30~08:30, 15:10~15:30).

며, 뒤늦게 일부 반대매매가 불가함을 안내하여 추가로 자금을 마련할 기회를 놓쳐 현금 입금도 하지 못하여 약 6천만 원의 손해가 발생하였는 바, 피신청인은 이를 배상할 책임이 있음.

(2) 피신청인 주장

신용거래약관 및 담보관리에 대한 HTS의 안내사항에는 담보부족비율에 대한 충족 시점을 “회사가 요구하는 소정의 기한내”라고 규정하고 있으며, 상담직원이 처음 일부 반대매도처리가 가능하다고 잘못 안내하기는 하였으나 이후 부족금 전액을 현금으로 상환하는 경우에만 반대매도 거부처리가 된다고 다시 안내하였는 바, 반대매매 자체는 잘못이 없음. 다만, 잘못된 안내로 신청인이 시간외 종가 매매를 한 부분에 대하여는 피신청인의 책임을 인정함.

다. 위원회 판단

◆ 본건의 쟁점은 부정확한 담보부족 안내로 인해 신청인에게 손해가 발생하였는지 여부라 할 것임.

(1) 반대매매의 적법 여부

「증권업감독규정」은 위탁자의 담보부족시 증권회사는 담보의 추가납부를 요구하여 위탁자가 그 납입기일까지 담보의 추가납부를 이행하지 아니하였을 때에 그 다음날 임의 상환 처리를 할 수 있도록 규정⁴⁸⁰⁾하고 있고, 피신청인의 「신용거래약관」도 이와 동일하게 규정⁴⁸¹⁾하고 있는 바, 주식위탁거래 및 신용거래의 당사자인 증권사는 상대방인 신청인이 반대매매를 통한 불측의 손해를 입지 않도록 할 선관주의의무가 있다 할 것임.

신청인은 상담직원이 처음에는 주식을 매도하면 일부가 반대매도 된다고 안내를 하였으나 이후 뒤늦게 일부 반대매도가 불가하다고 안내하여 추가로 자금을 마련할 기회를 놓쳐 현금을 입금하지 못해 전량 반대매매를 당해 손해가 발생하였다고 주장하나, 다음

480) 「증권업감독규정」 제5-6조, 제5-12조 및 제5-13조 참조.

481) 「신용거래약관」 제10조.

과 같은 점에 비추어 위 주장은 이유 없다 할 것임.

① 신청인과 상담직원간의 2007.8.20. 통화기록과 통화내용에 대한 녹취록(이하 “녹취록”이라 함) 제1면~제5면에 따르면, 피신청인의 상담직원은 08:24:23에 시작된 통화 도중(6분20초간 통화가 계속됨) 신청인에게 일부 매도 부분에 대하여 반대매매 거부가 가능하다고 안내하였으나, 처음 통화 직후인 08:32:34(2분17초간 통화가 계속됨)에 일부 반대매매 거부가 불가능함을 다시 안내하였다는 점.

② 녹취록 제3면~제4면에 따르면, 상담직원은 08:24:23에 시작된 통화시 신청인에게 08:40 전까지 입금이 가능하다고 안내하였고, 실제 상담직원이 다시 안내한 시점에도 현금 입금이 가능하였다는 점.

③ 녹취록 제7면에 따르면, 신청인은 반대매매가 된 이후인 09:33 상담직원과 통화함에 있어 “그러면 내가 전액 입금해야 된다면 내가 그것을 장전 시간에 왜 거래를 해요?”라고 하여 일부 반대매매 거부가 되지 않는다면 시간외 종가매매를 할 필요는 없었다는 내용의 이의를 제기하고 있다는 점.

다만, 신청인이 08:28~08:29에 행한 시간외 종가 매매는 상담직원이 일부 반대매매 거부가 가능하다고 잘못 안내함으로써 불필요하게 행하여진 것인 바, 이 부분에 대하여는 피신청인의 사용자배상 책임이 인정된다고 할 것임.

(2) 손해배상액 산정

신청인은 8.20. 반대매매가 되자마자 이를 알고 피신청인에게 이의를 제기하였는 바, 신청인의 손해금액은 8.20. 종가를 기준으로 B기업 주식 400주(매수금액 7,860,000원)와 C기업 주식 800주(매수대금 2,104,000원)를 매수하는데 소요되는 금액 9,964,000원에서 8.20. 시간외 종가매매로 체결된 동 주식 매도금액 8,672,000원을 공제한 1,292,000원에 8.20. 소요된 거래비용 32,344원을 더한 1,324,344원이라 할 것임.

라. 결론

그렇다면 피신청인은 신청인에게 손해금액 1,324,344원을 배상할 책임이 있어 이를 인용하고, 신청인의 나머지 청구는 이유 없어 기각함.

2-11 주식담보대출 반대매매 절차에 있어 유선 통지의무가 있는지 여부

[기각] 주식담보대출 만기 도래에 따른 반대매매 통지방법은 내용증명우편, 통화내용 녹취 또는 투자자와 사전에 합의한 방법 중 선택할 수 있으므로, 투자자와 사전에 합의한 방법인 SMS 문자메세지로 통지한 것이 통지의무 위반으로 보기는 어려움. 즉 신청인이 신용거래 유형을 스스로 변경한 점, △△형은 SMS 문자메세지로만 통지된다는 내용이 사전에 공지되어 있는 점, SMS 문자메세지가 사전 합의된 통지방법으로 인정되는 점, 반대매매의 원인이 신청인의 과실(상환자금으로 타 주식 매수)에 주로 기인하는 점 등을 고려할 때 본건에 있어 피신청인의 책임을 묻기는 어렵다 할 것임.(2010.2.9. 조정번호 제2010-5호).

가. 사실관계

신청인은 2007.11.23. 피신청인에 “예탁증권담보대출”을 신청·설정하였는데, 피신청인의 “예탁증권담보대출” 유형(신용거래유형과 동일)에는 “○○형”과 “△△형”이 있어, 동 설정당시 “○○형”으로 설정하였고, 2009.5.12. D기업(A군) 주식 60주를 담보로 77만원을 대출받음(만기: 2009.11.9. - 대출기간 1회 연장).

<○○형과 △△형 비교⁴⁸²⁾>

	○○형	△△형
담보유지비율	140%	좌 동
신용용자 보증금률	50%	40%
담보부족 반대매매시기	D+3일	D+2일
담보부족시 등 통보방법	유선, 내용증명, E-mail	SMS문자
제한사항	“C군 종목” 담보대출 불가 ⁴⁸³⁾	제한 없음

신청인은 2009.9.24. C군 종목인 S기업 주식을 담보로 대출을 받기위해 인터넷으로 <신용거래유형>을 위 “○○형”에서 “△△형”으로 변경하고 <통보방법>으로 “SMS신청”을 선택하였는데, 피신청인 인터넷사이트의 <신용거래유형 변경등록> 화면의 “△△형”란에는 “△△형은 담보유지비율 140%, 신용용자 보증금률 40%, 담보부족반대매매

482) 신용거래 유형의 차이는 “신용거래유형 변경등록화면”을 통해 안내하고 있음.

483) 피신청인은 담보대출 대상주식을 A, B, C군으로 분류하고 대출금리를 각각 연 7.9%, 8.9%, 9.5%로 차등 적용함.

D+2일이 적용됩니다.”, “△△형은 추가담보요구, 만기예정통보가 SMS로만 통보됩니다.”라는 설명이 명기되어 있음. 위 사이트의 <통보방법 조회 및 변경신청> 화면의 “SMS 신청”란 상단에는 “△△형 계좌는 SMS로만 통보됩니다.”라는 설명이 명기되어 있음.

한편 신청인은 9.24. 당일 피신청인 고객센터로 전화하여 담당직원과 위 변경절차에 대하여 상담한 내역이 존재함.

피신청인은 위 2009.5.12.자 예탁증권담보대출 만기 무렵 아래와 같은 SMS 문자메세지를 신청인에게 발송함.

- 2009.11.5.(목) ⇒ “예탁담보대출 만기일 안내(만기일: 20091109 종목: D)” - 2009.11.6.(금) ⇒ “예탁담보대출 만기일 안내(만기일: 20091109 종목: D)” 및 “2009년 11월 10일 반대매매예정”
--

2009.11.9.(월) 07:20경 신청인은 위 대출금 상환을 위해 계좌에 480만원을 입금하였으나, 당일 09:47경 “H기업” 30주를 신규 매수 (대금 502만 5,000원)한 결과 담보대출 상환 자금 부족이 발생하였고, 피신청인은 2009.11.10.(화) 신청인의 “D기업” 주식 60주 전량을 반대매매 실행함.

나. 당사자 주장

(1) 신청인 주장

피신청인은 주식담보대출 만기에 대출금 미상환시 반대매매가 실행된다는 내용 등에 대해 고객인 신청인에게 유선으로 자세히 안내할 의무가 있고, 그에 따라 본건 이전에는 대출연장 등에 대한 자세한 내용을 유선으로 알려주었으나 본건에 있어서는 SMS 문자메세지로만 통보한 상태에서 반대매매를 실행하여 손해가 발생하였으므로 피신청인이 그에 대한 책임을 부담해야 함.

(2) 피신청인 주장

신청인이 “C군” 종목을 담보로 하는 대출을 신청하면서 스스로 거래유형을 “○○형”에서 “△△형”으로 변경(통보방법 SMS)하였는 바, 본건 반대매매 관련 통지가 SMS 문

자메세지를 통하여 이루어진 것은 위와 같은 거래유형변경에 따른 정상적인 조치임.

또한 본건 반대매매가 발생한 주된 이유는 신청인이 대출만기일인 2009.11.9. 상환자금을 입금한 후 스스로 동 자금으로 당일 H기업 주식 30주를 신규 매수하여 상환자금이 부족해졌기 때문이므로 반대매매로 인한 손해에 피신청인의 책임이 있다는 신청인의 주장은 수용할 수 없음.

다. 위원회 판단

◆ 본건의 쟁점은 피신청인이 주식담보대출 만기 도래시 반대매매를 실행함에 있어 신청인에게 이에 대한 유선 통지의무가 있다고 볼 수 있는지 여부라 할 것임.

「금융투자업 규정」에 따르면 임의상환을 위해서는 우선 “투자자에게 상환을 요구(통지)”해야 하며 통지방법은 내용증명우편, 통화내용 녹취 또는 “투자자와 사전에 합의한 방법” 중 선택할 수 있으므로,⁴⁸⁴⁾ 투자자와 사전에 합의한 방법⁴⁸⁵⁾인 “SMS 문자메세지”로 통지한 것이 통지의무 위반으로 보기는 어려움.

가사 신용거래유형이 “○○형”에서 “△△형”으로 변경됨에 따라 통지방법이 기존의 ‘유선안내 등’에서 ‘SMS 문자메세지만 가능’한 것으로 변경된 점이 신청인에게 다소 혼란을 야기했다 하더라도, 신청인이 신용거래 유형을 스스로 변경한 점, “△△형”은 SMS 문자메세지로만 통지된다는 내용이 사전에 공지되어 있는 점, 위에서 본 바와 같이

484) 현행 「금융투자업 규정」 제4-28조 제1항 제1호는 투자매매업자 또는 투자중개업자는 “투자자가 신용공여에 따른 채무의 상환요구를 받고 상환기일 이내에 상환하지 아니하였을 때” 투자자계좌에 예탁된 담보증권 등을 임의 처분하여 변제충당(임의상환)할 수 있도록 규정하고 있으므로 임의상환을 위해서는 우선 “투자자에게 상환을 요구(통지)”해야 하며, 위 “상환요구(통지)” 방법은 내용증명우편, 통화내용 녹취 또는 “투자자와 사전에 합의한 방법” 중 선택할 수 있음. “상환요구(통지)” 방법 자체에 대해서는 직접 규정이 없으나, ‘추가담보 요구’ 및 ‘임의상환 처분내역 통지’ 방법은 내용증명우편, 통화내용 녹취 또는 “투자자와 사전에 합의한 방법”으로 할 수 있다고 규정하고 있음(「금융투자업 규정」 제4-25조 제7항, 제4-28조 제2항).

485) “○○형”에서 “△△형”으로 신용거래유형을 변경하기 위해서는 <신용거래유형 변경등록> 및 <통보 방법 조회 및 변경신청> 화면에 신청인이 접속하여 변경해야 하며, 위 화면에는 “△△형은 추가담보 요구, 만기예정통보가 SMS로만 통보됩니다.”라는 내용이 명기되어 있음.

SMS 문자메세지가 “사전 합의된 통지방법”으로 인정 되는 점, 반대매매의 원인이 신청인의 과실(상환자금으로 타 주식 매수)에 주로 기인하는 점 등을 고려할 때 본건에 있어 피신청인의 책임을 묻기는 어렵다 할 것임.

라. 결 론

그렇다면, 피신청인이 본건 주식담보대출 만기 도래시 신청인에게 유선 통지를 하지 않고 반대매매를 실행함으로써 손해가 발생하였다는 신청인의 주장은 이유 없으므로 이를 기각함.

2-12 증권사에 고객손실 최소화를 위한 적정시점 반대매매의무가 있는지 여부

[기각] 녹취록상 피신청인이 신청인에게 반대매매사항을 고지한 사실이 확인되고 본건 매도는 신청인의 매매주문에 따라 이루어진 것이라는 점, 증권회사가 선물 포지션을 처분할 수 있었던 최초의 시점에 처분하지 않았다고 하여도 당시 선물가격이 하락 혹은 상승하는 경향이 뚜렷하여 고객의 손실 회복을 기대할 수 없는 특별한 사정이 없는 한 그 시점에 처분하는 것이 반드시 고객의 손실을 최소화하는 것이라고 단정할 수 없는 점 등을 감안시 사전에 고객으로부터 위와 같은 시점에 선물 포지션을 처분하여 줄 것을 위임받았다는 등의 특별한 사정이 없는 한 증권회사에게 위와 같은 시점에 선물 포지션을 처분해야 할 법률상 의무가 있다고 볼 수 없다 할 것임.(2010.10.20. 조정번호 제2010-85호)

가. 사실관계

2010.6.22. 신청인, ○○선물회사(이하 “피신청인”이라 함)에 선물계좌를 개설하고 해외파생상품인 CME(시카고상품거래소) 밀선물을 전화주문방식으로 거래함.⁴⁸⁶⁾

486) 해외선물파생상품거래 위탁증거금 미납시 처리 및 반대매매절차는 다음과 같음.

① 위탁증거금 또는 결제대금 미납시 처리 : 장중에 급격한 시세변동으로 인하여 고객의 평가예탁액이 필요한 증거금(수수료 등 기타경비 포함) 상당금액 이하로 하락하는 때에는 회사는 고객으로부터 위탁증거금을 추가로 예탁받아야 하나 고객의 귀책사유로 연락이 안 되는 때에는 고객의 동의없이 고객의 미결제약정 또는 예탁자산을 처분할 수 있음(「해외파생상품거래계좌설정약관」 제13조 제3항)

2010.8.6. 17:07경 신청인, 밀선물 3계약을 매수하였고,⁴⁸⁷⁾ 피신청인은 당일 18:15경 선물가격 급락으로 위험도가 50%에 도달하여 신청인에게 유선통보를 시도하였으나 연락이 되지 않자 음성사서함에 현 위험도, 위험도 80%시 반대매매가 이루어질 수 있는 점, 리스크 관리 요청 등을 통지함.

2010.8.6. 18:58경 신청인은 피신청인과 유선통화를 통해 당시 밀선물 현재가(787.6), 위험도 80% 도달시 강제 반대매매될 수 있는 사실 등을 인지한 후, 밀선물 거래를 본인이 알아서 하겠다고 통화하고, 당일 23:30 본장 시작후 신청인이 피신청인에게 유선으로 “매도” 주문 요청을 하였으며, 피신청인 직원은 계좌명, 비밀번호, 수량 확인 후 시장에 주문을 제출함.

당일 23:31~23:32 시간대의 시세는 756.4~792 수준(위험도는 최저 31~141 수준)으로 가격 급변이 심하였고, 매도결과 23:32:07에 매수 3계약이 760.6(위험도 126%)에 청산됨.

② 추가증거금 납부시한 및 반대매매 절차 : 장중에 시세의 급격한 변동으로 인하여 위탁자의 평가예탁액이 필요한 증거금(수수료 등 기타경비 포함) 상당금액 이하로 하락하여 당해 위탁자의 장중계좌 위험도가 당사가 정한 수준까지 상승할 경우 계좌담당자는 위탁자에게 유선으로 위험도 안내 및 최대위험도 도달시 당사의 임의 반대매매 시행가능성 등을 안내

- 위험도 50% 도달시 위험도 안내 및 임의 반대매매 가능성 통보
- 위험도 70% 도달시 고객 HTS상에 경고창 팝업
- 위험도 80% 도달시 계좌관리자는 당해 고객의 미결제약정 반대매매후 해당사실을 고객에게 통보
- * 장중 위험도 : $100 - [(계좌평가액/위탁증거금) \times 100]$

③ 장중 반대매매는 다음 각호를 따르는 것을 원칙으로 함.

- 장중 반대매매는 시장가 정산을 원칙으로 함
- 장중 반대매매는 모든 미결제포지션 청산을 원칙으로 하나 당해 위탁자가 보유한 종목이 휴장이거나 위험도 80% 도달시에 장마감된 종목은 반대매매를 유예
- 위험도 평가시 모든 통화의 평가예탁액을 원화로 환산한 금액으로 계산함. 단, 위탁자가 위탁증거금을 추가로 예탁할 의사가 있거나 당사의 귀책사유가 있을 경우 해당부서는 컴플라이언스팀의 사전승인을 통하여 위험도 80% 도달시에도 반대매매를 유예할 수 있음(추가증거금 처리지침)

487) 밀선물 매수내용은 다음과 같음.

종목코드	매매	매매가격	수량	약정금액	주문시간	체결시간
ZWU10	매수	810.2	2	81,025.00	17:07:05	17:07:06
ZWU10	매수	810.2	1	40,512.50	17:07:05	17:07:06

나. 당사자 주장

(1) 신청인 주장

위험도가 80% 도달하였으면 즉시 반대매매가 되어야 함에도 피신청인이 반대매매시기를 놓쳐 위험도 126% 수준에서 매도처리되어 손실을 입었으므로 피신청인이 이를 배상해야 함.

(2) 피신청인 주장

본건 매매는 신청인의 매도주문에 따라 적정하게 주문처리된 것이며, 장중 위험도 80% 초과시 반대매매 하는 것은 피신청인의 채무건전성을 위한 리스크 관리차원에서 규정된 것이지 피신청인의 의무사항이 아님.

다. 위원회 판단

◆ 본건의 쟁점은 피신청인의 반대매매관련 손해배상책임여부라 할 것임.

(1) 피신청인 책임여부

신청인은 피신청인이 적시에 반대매매를 하지 않아 손해를 보았다고 주장하나 다음과 같은 점에 비추어 신청인 주장을 받아들이기 어렵다 할 것임.

① 녹취록상 피신청인이 신청인에게 반대매매사항을 고지한 사실이 확인되고 본건 매도는 신청인의 매매주문에 따라 이루어진 것이라는 점.

② 고객이 위탁증거금 부족분을 증권회사에 납부하지 아니하여 증권회사가 고객이 보유하고 있는 선물 포지션을 처분하여 그 처분대금을 선물정산대금에 충당하는 경우에 있어서 증권회사로서 고객의 손실을 최소한도에 그치도록 하여야 할 신의칙상의 주의의무가 있다고 하더라도, 증권회사가 선물 포지션을 처분할 수 있었던 최초의 시점에 처분하지 않았다고 하여도 당시 선물가격이 하락 혹은 상승하는 경향이 뚜렷하여 고객의 손실 회복을 기대할 수 없는 특별한 사정이 인정된다면 모르되 그렇지 않는 한 그 시점에 처분하는 것이 반드시 고객의 손실을 최소화하는 것이라고 단정할 수 없는 것이므로, 증

권회사가 미리 고객으로부터 위와 같은 시점에 선물 포지션을 처분하여 줄 것을 위임받았다는 등의 특별한 사정이 없는 한 증권회사가 위와 같은 시점에 선물 포지션을 지체 없이 처분하지 않았다고 하여 고객 보호의무나 선량한 관리자로서의 주의의무를 위반하였다고 볼 수 없다 할 것인데,⁴⁸⁸⁾ 본건에 있어서 위와 같이 피신청인의 책임을 인정할 특별한 사정을 찾기 어려운 점.

라. 결 론

그렇다면 피신청인은 신청인에 대하여 손해를 배상할 책임이 없다 할 것이므로 신청인의 청구는 이유 없어 이를 기각함.

2-13

투자일임업자의 선관주의 의무 위반에 따른 손해배상책임 인정 여부

[기각] 피신청인이 정당한 사유 없이 신청인의 계약해지 요구에 응하지 않고 투자일임계약을 위반하여 투자일임재산을 운용하는 등 선량한 관리자로서의 주의의무를 다하지 못한 것으로 볼 수 없다고 판단한 사례(2016.4.27. 조정번호 제2016-11호)

가. 사실관계

2014.8.21. 김OO(이하 ‘신청인’이라고 함)은 신청인의 배우자인 유□□을 대리하여 피신청인과 투자일임계약을 체결하였음.

투자일임계약서 주요내용

- ◆ 계약당사자 : 유□□(甲), D투자자문(乙)
- ◆ 계약기간 : 2014년 8월 21일부터 2017년 8월 20일까지(3년)
- ◆ 계약재산 : 일십억원(1,000,000,000)
- ◆ 기본수수료 : 계약재산의 연 1.5%
 - 계약기간은 3년으로 하되, 1년 단위로 평가하여 성과수수료 및 기본수수료를 정산한다.

488) 대법원 2003.1.10. 선고 2000다50312 판결 참조.

- 최초 계약일을 기준으로 1년 단위로 평가하며 평가시점의 순자산총액에서 투자일임수 수료를 제외한 금액을 재계약금액으로 정한다.

◆ 운용지시(제11조)

- 갑은 리스크관리 목적이나 전략상의 변화 등을 이유로 특정증권 등의 취득·처분을 요구할 수 있고, 이를 을에게 대면·서면·전자우편 등의 방법으로 지시를 할 수 있으며, 을은 이에 대한 지시사항에 대하여 기록을 유지, 관리하여야 한다.

2015.8.13. 13:00경 신청인은 피신청인 사무실에 내방하여 피신청인 경영지원 이사 A에게 1차 평가기준일인 2015.8.20.⁴⁸⁹⁾까지 유□□명의 계좌에서 보유 중인 모든 주식⁴⁹⁰⁾을 매도하여 현금화해 줄 것을 요구하였고, A 이사는 유□□ 명의계좌 운용자인 B 상무에게 동 내용을 전달.

2015.8.18. 11:25경 신청인은 유□□ 명의 계좌의 잔고를 확인하였으나 매도가 이루어지지 않은 것을 확인하고, 피신청인에 유선으로 항의.

<‘15. 8. 18. 11:25경 녹취 >

A 예. D투자자문 A입니다.
 신청인 예. 지난주 목요일날 점심 때 갔었던 김OO입니다.
 A 예. 안녕하세요.
 신청인 **그 뭐 주식은 매도를 안했다고 그러네?**
 A 제가 아침에도 매니저한테 가서 말을 했거든요 그랬더니 알고 있다고. (중략)
 신청인 어저께도 안하고. 근데 자꾸 떨어지니 난감하네
 A 그러니까요. 팔면 되는데 빠진다고 기다린 거 같더라고요. 아침에 재촉은 해봤습니다.
 신청인 이제 또 늦었잖아. 괴로운데.
 A 제가 이야기 해보겠습니다.
 신청인 난 어제 판 줄 알았지. 근데 갖고 있는 종목들도 왜 그 모양이야. (중략)오늘 아침에라도 좀 팔았으면은...
 A 아침에 가서 왜 이렇게 안 팔았냐고... 팔아달라고 분명히 말씀드렸는데... (중략)뭐 매니저가 자기 판단으로 그렇게 얘기를 하니까 또 뭐라고 강요하기가 좀 힘들더라구요. 그래서 일단은 빨리 정리 좀 해달라고 얘기는 하고 왔거든요.
 신청인 아니 반은 팔았어야지
 A 그러니까요.. 아.. 참...
 신청인 예. 알았습니다. 하여간.

489) 2015.8.14. ~ 8.16. 기간 중 주식시장은 연휴로 휴장

490) 2015.8.13. 기준 L***** 등 17개종목 123,163주, 평가금액 1,091,411,400원

피신청인은 13:48경부터 14:40경 까지 L***** 등 11개 종목64,054주(445,245,385원, 보유주식 평가금액 대비 42%)를 순차매도 하였음.

‘15.8.18. 주식매도 내역

(단위 : 주, 원)

종목	수량	단가	금액	실현손익	잔고
L*****	3,840	3,270	12,556,920	(3,485,835)	8,000
사*****	2,150	17,250	37,087,500	(6,996,914)	5,000
이*****	531	121,951	64,755,800	18,551,327	-
컴**	543	119,174	64,711,300	(13,439,201)	-
한*****	2,950	22,011	64,931,150	17,038,319	-
유***	4,400	3,850	16,940,000	(6,091,709)	7,000
에*****	21,000	2,322	48,759,355	(6,198,386)	-
텍*****	6,800	1,905	12,954,000	(2,342,507)	20,000
기***	2,040	5,940	12,117,600	(6,932,761)	6,000
M**	13,000	4,021	52,270,000	522,425	-
테*****	6,800	8,553	58,161,760	10,259,502	-
계	64,054		445,245,385	884,260	

신청인은 장종료(신청인은 16시경, 피신청인은 15시경 이라고 주장) 후 피신청인 사무실(서울시 영등포구 여의도동 위치)을 직접 방문하여 피신청인 대표이사 C을 만나 보유주식 매도시기 등에 대하여 재협의⁴⁹¹⁾.

‘15. 8. 19. 09:46 경 녹취>

A 안녕하세요. D투자자문의 A입니다.

신청인 예. 김OO입니다.

A 아. 네네. 안녕하세요.

신청인 오늘 또 빠지네.

A 아. 그러니까요.

신청인 하여간 그 내 계좌. 둘 중에 하나. 두 번째 계좌를 내가 주식으로 뺄게요 그냥.

A 아 그러면...

신청인 그러면 그 사람도 부담이 덜 하자나. 그러고 하여간 고거

A 아. 그거.

491) 2015.8.19. 신청인이 피신청인 경영지원 이사 A에게 유선상으로 일임 계좌 3개 중 1개 계좌의 주식을 출고 요청하는 과정에서 확인됨

신청인 어제 대표님하고 얘기를 했는데 하여간 날짜에 구매 안 받고 최대한 손해 덜 보는 쪽으로 하겠다고 하는데, 오늘 또 빠지네. 이거 골치 아프네

A 그러면 지금 계좌 두 개 있으시잖아요. 2110 그 계좌에 있는 주식은 매도하지 말고 두라고 할까요

신청인 예. 그것은 주식으로 뺄 거니까.

2015.8.19. 09:55 ~ 14:19경 텍***** 잔여주식 20,000주를 전량 분할매도(36,875,000원).

2015.8.20. S증권이 신청인에게 유□□ 명의 계좌의 주문대리인 등록이 만료됨을 통보하자 신청인은 S증권 반포지점에 내방하여 피신청인을 주문대리인으로 1년간 연장 등록하였으며, 피신청인은 2015.8.20. ~ 8.24. 기간 중 한* 등 4개 종목 14,160주(245,331,180원) 매도.

‘15.8.20. 이후 주식매도 내역

(단위 : 주, 원)

일자	종목	수량	단가	금액	실현손익	잔고
2015.8.20.	한*	2,120	26,559	56,305,200	2,916,887	-
	기***	6,000	5,663	33,975,080	(22,048,721)	-
2015.8.21.	대***	1,040	74,809	77,800,900	(2,174,268)	-
2015.8.24.	사*****	5,000	15,450	77,250,000	(3,308,938)	-
계		14,160		245,331,180	(24,615,040)	

나. 당사자의 주장

(1) 신청인 주장

2015.8.13. 피신청인에게 유□□ 명의 보유 주식을 모두 매각하여 2015.8.20.까지 현금 화해줄 것을 요구하였으나, 이를 즉시 이행하지 않아 손실이 발생하였으므로 평가손실액인 109,231,736원을 배상해야 할 것임.

(2) 피신청인 주장

2015.8.18. 신청인과 매도기한에 구매받지 않고 최대한 손실을 줄이는 방향으로 매도하기로 합의하는 등 선량한 관리자로서의 주의의무를 다하였으므로 배상책임이 없음.

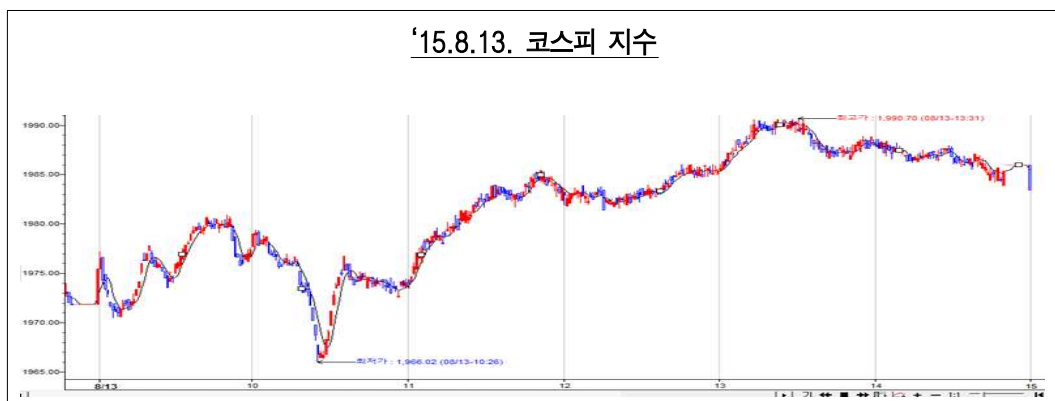
다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 투자일임업자인 피신청인에게 선관주의 의무 위반에 따른 손해배상 책임 인정 여부라 할 것임.

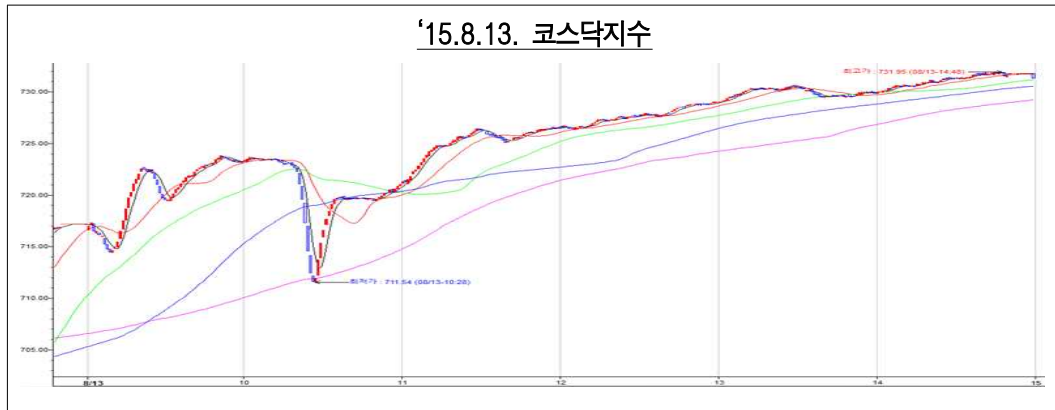
투자일임업자는 정당한 사유 없이 계약의 해지 요구에 응하지 아니하거나, 투자일임계약을 위반하여 투자일임재산을 운용해서는 아니되는 바, 신청인의 보유주식을 전량 매각 및 현금화 요구는 투자일임계약 해지의 의사표시로 볼 수 있으므로 피신청인은 투자일임계약(제 11조) 및 관련 법령⁴⁹²⁾에 따라 신청인의 매도요구시 피신청인은 이에 응할 의무가 있다고 할 것임.

한편, 투자일임업자는 투자자로부터 금융투자상품에 대한 투자 판단의 전부 또는 일부를 일임받아 투자자의 재산상태 등을 고려하여 금융투자상품을 운영하는 것으로 선량한 관리자의 주의로써 일임재산을 운용해야 하나 어느 특정한 상품에 투자하거나 투자에 단지 높은 위험이 수반된다는 사정만으로 일률적으로 선관주의 의무를 위반한 것이라고 단정할 수는 없음(대법원 2008.9.11. 선고 2006다53856 판결 등).

신청인은 2015.8.13. 13:00경 피신청인 사무실에 직접 내방하여 주식을 전부 매도하여 2015.8.20.까지 현금화시켜줄 것을 요구하였으나, 당일 장마감(15:00)까지 1시간 남짓 밖에 남지 않아 신청인의 매도요구 후 보유주식을 즉시 매도하기에는 시간적 여유가 충분하지 않았으며 당일 상승세였던 장상황 역시 13:20경 이후 하락세로 돌아선 점.



492) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제98조 제2항 제1호, 동법 시행령 제99조 제4항 제2호

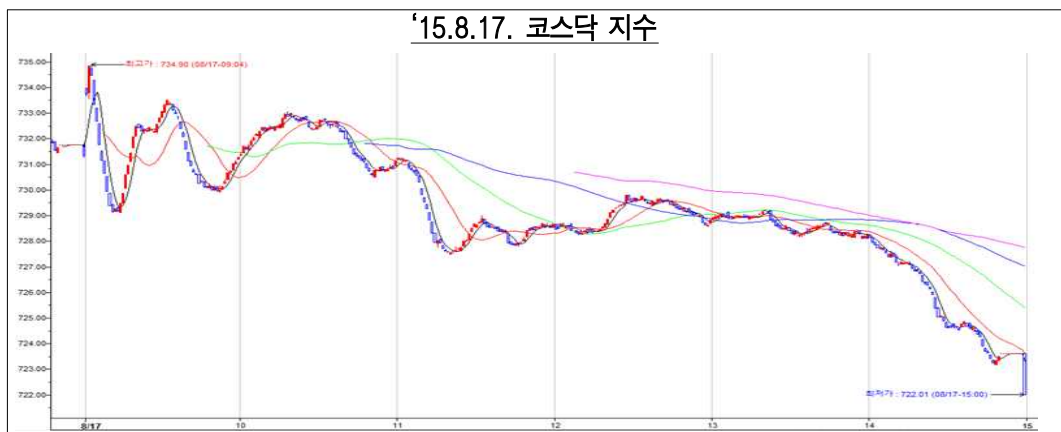
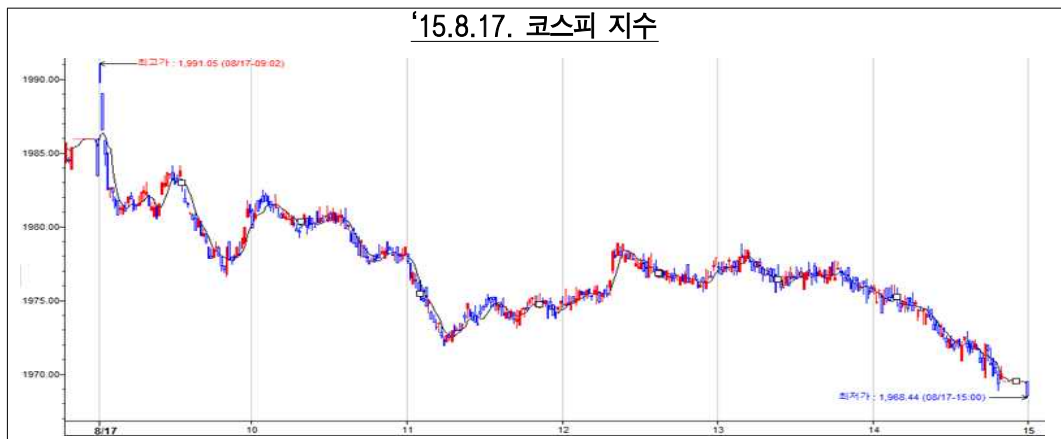


2015.8.14. ~ 8.16.은 연휴기간으로 매도가 불가능하였으므로 2015.8.20.까지 현금화를 위해서는 2015.8.17. 및 2015.8.18. 양 일간에 걸쳐 보유주식을 전량 매도해야 하나, 2015.8.7. 이후 코스피, 코스닥 시장 모두 하락세였고, 유□□ 명의 계좌에서 보유하고 있던 주식 상당 부분 역시 주가가 하락하였을 뿐만 아니라 2015.8.17. 주식시장 역시 하락세로 시작하여 주가가 지속 하락하는 상황에서 선부른 매도는 오히려 손실을 초래할 수 있었던 점.

‘15.8.7. 이후 주가현황

구분	15-8-7	15-8-10	15-8-11	15-8-12	15-8-13	15-8-17	15-8-18	15-8-19	15-8-20
KOSPI	2,010.2	2,003.1	1,986.6	1,975.4	1,983.4	1,968.5	1,956.2	1,939.38	1,914.55
KOSDAQ	751.49	746.34	732.26	717.2	731.36	722.01	699.8	670.55	656.71
I**	41,950	40,950	41,150	39,800	40,100	32,300	25,800	24,600	23,900
L*****	3,100	3,225	3,265	3,300	3,400	3,365	3,300	3,100	3,010
M**	3,925	3,875	4,075	4,005	4,160	4,115	4,035	3,665	3,500
기***	6,040	5,900	5,810	5,700	5,800	6,150	5,920	5,600	5,450
대****	89,200	87,400	85,000	81,500	86,000	86,100	82,400	76,500	76,600
레*****	35,350	34,200	33,200	34,500	33,650	31,900	25,800	25,450	22,550
사*****	17,250	18,250	18,250	19,000	19,000	17,750	17,200	16,800	16,050
에*****	32,100	31,950	30,500	25,150	25,450	25,300	19,400	17,650	17,100
에*****	2,540	2,535	2,425	2,320	2,330	2,360	2,300	2,115	2,000
유***	3,920	3,995	3,690	3,610	4,000	3,845	3,905	3,790	3,455
이*****	122,600	120,500	119,000	117,000	123,500	123,400	124,000	118,700	113,000
차****	15,950	15,550	15,400	15,600	16,350	16,850	16,050	15,200	14,850
컴**	128,400	123,200	120,600	124,400	122,000	120,000	118,200	112,800	111,900

테*****	9,600	9,240	8,800	8,500	8,890	8,500	8,470	7,680	7,550
텍*****	2,185	2,075	2,050	2,000	1,975	1,940	1,890	1,780	1,800
한**	30,850	29,750	28,600	27,000	27,300	27,000	26,050	24,000	25,350
한*****	20,900	20,050	19,450	20,500	20,600	21,900	22,300	21,050	20,000



유□□ 명의 계좌에서 보유하고 있던 주식의 수량 및 동 주식의 거래량에 비추어 2015.8.18. 당일 전량 매도도 가능하므로, 주가반등을 기대하여 2015.8.17. 주식을 매도하지 않았다고 하여 피신청인의 해지 요구에 응하지 아니하였거나, 투자일임계약을 위반하였다고 볼 수는 없는 점.

유□□ 명의 계좌 주식시장 거래량

구분	15-8-11	15-8-12	15-8-13	15-8-17	15-8-18	15-8-19
I**	40,655	127,376	30,729	371,757	990,822	358,560
L*****	182,017	106,988	97,171	70,887	116,238	119,654
에*****	32,105	184,890	58,797	41,746	389,921	312,188
유***	1,045,205	419,565	771,815	533,117	727,354	396,145
차****	481,107	781,791	1,270,957	1,611,224	1,030,090	1,202,716
레*****	255,003	264,989	258,460	245,018	198,165	195,477
M**	4,925,364	5,161,785	2,087,257	1,997,993	1,513,139	2,186,510
에*****	278,502	469,108	255,798	2,287,864	425,483	706,033
이*****	52,885	58,714	76,399	36,279	103,869	94,593
테*****	474,229	686,575	415,112	294,235	833,601	940,185
한*****	202,121	240,726	156,458	462,117	606,738	343,441
컴**	100,149	687,456	251,255	124,079	143,643	183,027
텍****	1,216,570	2,513,050	870,893	854,562	2,178,730	2,373,843
한*	34,221	112,185	98,848	41,879	61,178	102,617
기***	66,687	117,544	66,537	207,214	79,683	150,457
대***	56,845	105,625	63,648	49,435	115,665	155,520
사*****	138,114	256,877	269,409	143,491	176,070	143,502

2015.8.18. 11:25경 신청인으로부터 주식미매도에 대한 불만 요청을 받고 13:48 ~ 14:40경 까지 L***** 등 11개 종목을 순차 매도하였으나, 2015.8.19.에는 텍***** 20,000주만을 매도한 점 및 ‘날짜에 구매 안 받고 최대한 손해 덜 보는 쪽으로 하겠다고 하는데’라는 통화내용에 비추어 2015.8.18. 신청인은 피신청인 대표 C과 매도시기 등에 대해 당초 요구 내용과 다르게 합의하는 등 사정변경(事情變更)이 있었던 것으로 보이는 점, 2015.8.20. 신청인이 아무런 항의를 하지 않고 오히려 주문대리인 기간을 연장 처리하여 2015.8.20. ~ 8.24. 기간 중 한* 등 4개 종목 14,160주를 매도한 것은 피신청인에게 처분일임을 유지한 것으로 보이는 점 등을 종합적으로 고려할 때, 피신청인이 정당한 사유 없이 신청인의 계약해지 요구에 응하지 않고 투자일임계약을 위반하여 투자일임채산을 운용하는 등 선량한 관리자로서의 주의의무를 다하지 못한 것으로 볼 수 없다고 할 것임.

라. 결 론

그렇다면, 신청인의 청구에 이유가 없다고 할 것이므로 신청인의 청구를 기각함.

제3장

임의매매

제1절 임의매매 인정 사례

3-1 임의매매 손해금에 대해 약속어음을 교부한 경우 손해배상액 산정기준

[일부인용] 신청인이 직원으로부터 임의매매임을 인정하는 진술서와 원상회복을 약속하는 각서를 교부받았고, 임의매매손해금 전액에 대한 약속어음을 교부받은 사실이 확인되는 점에 비추어 직원의 임의매매가 인정되나, 손해배상금액은 약속어음상의 금액이 아니라 임의매매종료일의 종가를 적용하여 임의매매 직전의 상태로 원상회복할 때 소요되는 금액으로 함.(1999.9.14. 조정번호 제1999-41호)

가. 사실관계

신청인은 1999.4.7. ○○증권(이하 “피신청인”이라 함) △△지점에서 거래중이던 위탁계좌를 ▽▽지점으로 이관하여 직원과 협의하여 주식매매를 하였으나, 1999.5.6.~5.27. 기간중 직원이 A기업 주식 11,000주 및 B기업 주식 1,350주를 임의매도하고, 또한 동 매도대금을 이용하여 주식을 임의매매 하였다고 주장함.

한편, 피신청인 직원은 1999.5.6.~5.27. 기간중 거래가 임의매매임을 인정하는 진술서와 원상회복을 약속하는 각서를 작성하여 5.27. 신청인에게 교부한 후, 6.5.에는 금 7천만 원을 기재한 약속어음을 발행하여 공증받아 신청인에게 교부하였으며 6.28.에 퇴사함.

나. 당사자의 주장

(1) 신청인의 주장

직원이 1999.5.6.~5.27. 기간중 임의매매를 함으로써 69,138,258원의 손해가 발생하였

고, 이에 이의제기를 하여 5.27. 직원으로부터 임의매매에 대한 진술서와 원상회복에 대한 각서를 교부받았음. 이후 같은 해 6.5. 임의매매 손해금 7천만원에 대한 약속어음을 교부받아 공정증서를 작성하고, 6.29. 진술서에 대하여 인증을 받았으므로 직원이 교부한 약속어음상의 금액대로 손해배상을 하여야 함.

(2) 피신청인의 주장

직원이 퇴사하여 연락이 되지 않는 관계로 매매내역, 각서 및 진술서 작성경위를 정확히 확인할 수는 없음. 그러나 신청인은 피신청인의 양재지점에서부터 직원과 투자상담을 하여온 고객으로 직원이 1999.4월 ▽▽지점으로 전출되자 동 계좌도 ▽▽지점으로 이관하여 거래한 점, 직원의 임의매매를 인지하고도 즉시 회사에 이의제기를 하지 않은 점, 임의매매기간이 정상매매기간에 비하여 거래대금에 큰 차이가 없는 점 등을 감안할 때 신청인으로부터 포괄위임을 받아 이루어진 일임매매로 보아야 함.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 본건거래가 임의매매에 해당하는지 여부와 그에 해당할 경우 손해배상 범위를 어떻게 산정할 것인지의 문제임.

(1) 임의매매 해당 여부

피신청인은 신청인의 포괄적인 위임을 받아 이루어진 일임매매라고 주장하나, 신청인은 직원으로부터 임의매매임을 인정하는 진술서와 원상회복을 약속하는 각서를 교부받았고, 임의매매손해금 7천만원에 대한 약속어음을 교부받은 사실이 확인되는 점에 비추어 직원에 의한 임의매매라고 판단됨.

(2) 손해배상금액의 산정기준

신청인이 직원의 임의매매로 인하여 손해를 보았고 이에 대하여 원상회복을 요구한 사실이 확인되므로 피신청인은 A기업과 B기업 주식을 원상회복하되, 그 배상금액은 임의매매 종료일(1999.5.27.) 종가를 적용한 금액으로 산정함이 타당함.

한편, 임의매매 결과 발생한 예수금(임의매매 종료일인 1999.5.27.자 예수금 53,268,401

원)은 신청인이 피신청인에게 반환하고 임의매매를 하기전의 예수금(임의매매 전일인 1999.5.5.자 예수금 1,906,885원)은 피신청인이 신청인에게 지급하는 방법으로 정산하여야 할 것으로 판단됨.

라. 결 론

직원의 임의매매사실이 인정되므로 피신청인은 이로 인하여 신청인이 입은 손해금 47,238,484원을 지급하여야 함.

3-2 주식매매과정에서 직원의 선관주의의무 위반 여부

[일부인용] 신청인은 주식거래초보자이고, 직원도 신청인이 주식거래 경험이 없다는 사실을 잘 알면서도 매매거래를 위임받았음을 기화로 위임의 본지에 반하여 미수거래를 과다하게 하였고, 신청인의 거래내역 통보요구에도 불구하고 거래내역을 거의 통보해 주지 않았으며, 거래내역을 알려줄 때도 미수거래에 대해서는 언급 없이 마치 현금으로 모든 주식을 매매하고 손실은 거의 없는 것처럼 답변한 점 등에 비추어 피신청인이 선관주의의무를 다하였다고 보기 어려움. 다만, 신청인도 직원에게 매매거래를 알아서 하도록 한 과실 및 거래내역을 직접 확인할 수 있었음에도 직원의 말만 믿고 제대로 확인하지 못한 과실 등이 있으므로 신청인의 과실을 50%로 하여 손해배상금액을 산정함.(2000.10.31. 조정번호 제2000-45호)

가. 사실관계

1999.7.5. 신청인은 피신청인의 지점에 위탁계좌를 개설하면서 담당직원에게 “알아서 잘 운용해 달라”고 하였으며, 이후 같은 해 8.10. 신청인이 담당직원에게 주식매매거래를 중지하도록 지시하였음에도 직원은 8.10~8.25. 기간동안 주식매매를 계속함.

1999.8.25. 신청인이 직원의 임의매매사실을 인지한 후, 직원으로부터 1999.10월말까지 손실금액의 보전을 구두로 약속받고, 약속이 이행되지 않자 1999.12.30까지 기간을 연장해 줌. 그 후 1999.12.30. 직원이 약속을 이행하지 않자 신청인은 직원으로부터 각서를 징구받고 손실보전기간을 2000.3.31까지 재연장해 주었으나 손실보전이 이루어지지 않음.

나. 당사자의 주장

(1) 신청인의 주장

계좌 개설후 담당직원에게 “알아서 잘 운용해 달라”고 한 사실은 있으나 직원이 상의도 없이 매매한 사실을 알고는 본인과 상의하여 매매할 것을 요구하였고, 직원도 그렇게 하기로 약속을 하고도 계속하여 상의 없이 매매를 하였음.

이에 1999.8.10. 직원에게 항의하고 계좌잔고를 문의하자 직원은 미수거래를 하고서도 이에 대해서는 전혀 언급도 없이 미수로 매입한 주식잔고를 알려주었음. 당시 미수거래를 몰랐던 본인은 손실이 아주 크지는 않다고 판단하여 다시는 본인계좌를 통해 매매를 하지 말라고 하였음. 만약 당시 주식잔고가 미수로 매입한 것이었다는 것을 알았다면 직원의 매매를 인정하지 않고 손해배상을 청구하였을 것임.

주식매매 중지요구에도 불구하고 직원이 계속적으로 임의매매한 사실 및 미수거래한 사실을 1999.8.25 인지하고 이에 대하여 이의 제기후 손해배상을 약정받았으나 직원이 이를 이행하지 않고, 수수료 수입만을 목적으로 과도하게 매매함으로써 손해금액이 확대되었는 바, 피신청인은 이에 대한 배상을 하여야 함.

(2) 피신청인의 주장

위탁계좌 개설 후인 1999.7.5~8.10. 기간중 매매는 신청인의 일임에 의한 매매이거나 신청인의 추인을 받은 매매임. 다만 8.10.~8.25.의 매매는 담당직원의 임의매매임을 인정하나, 신청인이 동 사실을 인지한 8.25.이후의 매매는 신청인으로부터 매매권한을 일임 받은 매매이므로 이에 대하여는 배상하기 곤란함.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 본건 주식매매과정에서 직원이 선관주의의무를 다하였는지 여부 등이라 할 것임.

(1) 기간별 주식매매의 손해배상책임 유무

1) 1999.7.5.~8.10. 기간중의 주식매매

금융감독위원회의 『증권회사의 위탁매매업무등에 관한 규정』 제3조(신의성실의무) 제1항에서는 “증권회사는 위탁매매업무를 취급함에 있어서 고객의 이익을 위하여 신의성실의 원칙에 따라 공정하게 수행하여야 한다.”고 규정하고 있음. 따라서 위탁매매인인 피신청인은 선량한 관리자의 주의의무를 다하여 위탁사무를 처리할 의무가 있는 바, 신청인이 직원에게 매매거래를 일임하였다할지라도 이러한 의무를 다하지 못하여 손해가 발생하였다면 이에 대한 배상책임이 있다고 할 것임.

본건의 경우 아래와 같은 점에 비추어 보았을 때 피신청인이 선관주의 의무를 다하였다고 볼 수 없으므로 피신청인의 손해배상책임이 인정됨.

① 신청인은 주식거래 초보자(1999.7.5. 위탁계좌를 처음 개설함)이고, 직원도 신청인이 주식거래를 해 본 경험이 없다는 사실을 잘 알면서도 매매거래를 위임받았음을 기화로 위임의 본지에 반하여 미수거래를 과다하게 하였으며, 약 1개월 동안의 기간중 종합주가 지수는 0.5% 상승한 반면 신청인은 오히려 56.7%의 손실을 본 점.⁴⁹³⁾

② 신청인의 거래내역 통보요구에도 불구하고 직원은 거래내역을 거의 통보해 주지 않았고, 거래내역을 알려줄 때도 미수거래에 대해서는 전혀 언급없이 마치 현금으로 모든 주식을 매매하고 있고, 손실은 거의 없는 것처럼 답변한 점.⁴⁹⁴⁾

2) 1999.8.10.~8.25. 기간중의 주식매매

피신청인도 임의매매를 인정하는 점에 비추어 직원에 의한 임의매매라고 판단되며, 이로 인한 손해에 대하여는 배상책임이 있음.

3) 1999.8.25. 이후의 주식매매

일임매매의 경우에는 원칙적으로 매매거래에 따른 손익이 모두 투자자에게 귀속되는 것이나, 증권회사의 약정제고 위주의 경영풍토를 지양시키고 투자자를 보호하기 위하여 금감원 및 법원은 투자자의 이익을 무시한 채 증권회사의 수수료수입이나 직원개인의 약정실적을 증대시키기 위한 목적으로 빈번한 매매를 함으로써 발생한 손해에 대하여는

493) 기간중 신청인계좌의 미수금발생률은 632.3%에 달함.

494) 문답시 직원이 “○○○씨로부터 미수거래를 승낙받은 사실은 없었으나 손실이 발생하여 만회하고자 미수로 거래하였고 미수거래 사실을 사후에도 보고한 사실이 없었다.”라고 인정하고 있음.

증권회사에게 사용자책임을 묻고 있음.

본건의 경우 신청인은 과다일임매매를 주장하고 있으나 아래와 같은 점에 비추어 보았을 때 과다일임매매가 인정되지 않으므로 피신청인에게 손해배상책임이 있다고 보기 어려움.

① 신청인의 손해가 매매거래를 빈번하게 함으로써 발생한 것이라고는 보기 어려운 점(손해금액대비 수수료비율: 25.7%).

② 직원이 약정실적을 증대시키기 위해서라기 보다는 신청인과의 약속에 따라 손실금액을 보전하기 위하여 매매하였다고 판단되는 점.

③ 신청인이 직원의 이러한 매매사실을 알고서도 이를 제지하지 아니하고 방치한 점.

(2) 손해배상금액 산정기준

1) 1999.7.5.~8.10. 기간중의 주식매매

피신청인은 1999.8.10. 평가액(17,302,708원)과 신청인이 투자한 금액(40,000,000원)과의 차액인 22,697,292원을 배상하여야 하나, 신청인도 직원에게 매매거래를 알아서 하도록 한 과실 및 거래내역을 직접 확인할 수 있었음에도 직원의 말만 믿고 제대로 확인하지 못한 과실 등이 있으므로, 이러한 과실을 참작하되 동 과실비율을 50%로 하여 손해배상금액을 11,348,646원으로 산정함이 타당함.

2) 1999.8.10.~8.25. 기간중의 주식매매

임의매매종료일(1999.8.25.) 평가액(14,262,707원)과 임의매매개시일(1999.8.10.) 평가액(17,302,708원)과의 차액인 3,040,001원을 손해배상금액으로 산정함이 타당함. 따라서 피신청인은 1999.7.5.~8.10. 및 1999.8.10.~8.25. 기간중 직원의 매매로 인한 손해액 중 14,388,647원을 배상하여야 할 것임.

라. 결 론

피신청인의 선관주의 의무 위반 및 임의매매가 인정되므로 피신청인은 이로 인하여 신청인이 입은 손해액중 금14,388,647원을 지급하여야 함.

3-3 형사재판에서 주식의 임의매매로 인정된 경우의 민사상 배상책임 여부

[일부인용] 담당직원과 피신청인은 법원으로부터 증권거래법위반 및 업무상배임으로 각각 벌금에 처하는 약식명령을 받고 같은 해 담당직원과 피신청인에게 법원명령이 송달되고 확정된 사실이 있는 바, 민사재판에 있어서 형사재판에서 인정된 사실에 구속을 받는 것은 아니라 할지라도, 이미 유죄로 확정된 형사사건의 판결에서 인정된 사실은 유력한 증거자료가 되므로, 민사재판에 제출된 다른 증거들에 비추어 형사판결의 사실판단을 채용하기 어렵다고 인정되는 특별한 사정이 없는 한 이를 배척할 수는 없는 것이어서 피신청인은 담당직원의 임의매매로 인한 손해를 배상할 책임이 있다 할 것임.(2003.9.2. 조정번호 제2003-37호)

가. 사실관계

2000.6.22. 신청인은 ○○증권사(이하 “피신청인”이라 함) 사이버지점에서 신청인 명의의 위탁계좌를 개설하고, 같은 해 12.14. 동 계좌의 관리직원으로 A씨(이하 “담당직원”이라 함)가 등록된 사실이 있음. 다음 해 3.7. 신청인은 자신이 보유하고 있던 주식을 전부 매도하고 대금 34,358,600원을 인출하였으며, 동 계좌를 통하여 거래를 하지 아니하다가 그 해 6.18.에 1,400만원, 7.4.에 500만원을 각각 입금하였음.

동 위탁계좌를 통하여 담당직원은 B기업 주식 1,220주 매수를 시작으로 C기업, D기업 등의 주식을 매수·매도하였으며, 2001.8.24. 신청인이 계좌잔고를 확인하는 과정에서 직원의 임의매매가 있다고 주장하고, 담당직원으로부터 1,900만원을 같은 해 12.10.까지 신청인에게 지불하겠다는 약속어음⁴⁹⁵⁾을 교부받음.

2001.12.12. 신청인은 피신청인의 감사실에 담당직원이 임의매매를 하였고, 유예기간을 주어 이를 보전토록 하였음에도 직원이 이를 지키지 아니하였다는 사실을 알렸음. 다음 날 신청인은 금융감독원에 분쟁조정신청을 제기하였으나, 2002.2.15. 위 약속어음의 배서란 기재사항을 주요근거로 기각결정을 받았음.

495) 약속어음의 배서기재란에는 “고객 ○○○씨의 계좌를 관리함에 있어 5:5로 이익분과 손실분을 나누기로 하였지만 8.24.자로 잔고가 미흡하여 본인 A가 12.10. 원금 ₩19,000,000원을 주기로 약속함. 그 동안에 계좌는 계속 관리하기로 약속함. 그 이상 금액의 초과시 이익분을 5:5로 분할함”이라고 기재되어 있음.

이에 신청인은 검찰에 담당직원의 임의매매 등을 이유로 고소장을 제출하였고, 담당 직원과 피신청인은 2003.2.24. 지방법원으로부터 담당직원은 증권거래법 위반 및 업무상 배임으로, 피신청인은 증권거래법 위반으로 각 벌금 3백만원에 처하는 약식명령을 받고, 같은 해 4.28. 담당직원과 피신청인에게 위 명령이 송달되었음에도 더 이상 이의를 제기 하지 아니하여 동 명령이 확정된 사실이 있음.

2003.5.13. 신청인은 이러한 확정된 형사재판을 근거로 재차 금융감독원에 임의매매에 따른 피신청인의 사용자배상책임을 요구하는 분쟁조정을 신청함.

나. 당사자의 주장

(1) 신청인의 주장

담당직원은 당시 자신이 추천한 종목으로 이익이 나면 이익금의 50%를 달라고 하면서 투자를 권유하였으나, 이에 응하지 아니하고 담당직원이 추천하면 신청인이 결정을 하여 매매를 하기로 하였음에도 담당직원은 임의로 매매를 하였음. 이러한 상황은 금융감독원 1차 조사시 담당직원이 이를 적극 부인하였으나, 검찰에서 수사시에는 모두 자백한 사실이 있고, 임의매매 발견직후 담당직원에게 원금의 배상을 요구하자 담당직원은 약속어음을 교부하여 주었으나, 당시 약속어음 뒷면의 기재는 담당직원의 기망에 의하여 담당직원이 기재한 것으로 이 또한 검찰에서 담당직원이 모두 인정한 사실이 있음.

(2) 피신청인의 주장

신청인은 약식명령을 가지고 재차 민원을 제기하였으나, 법원의 약식명령에서 담당직원이 임의매매를 하였다는 결과에 대한 객관적인 근거를 확인할 수 없고 담당직원은 신청인의 위탁계좌를 통하여 포괄적 일임매매를 하였으며, 신청인도 월거래내역서를 정상 수령하여 매매결과를 인지하고 있었으므로 신청인의 손해배상청구를 인정할 수 없음.

다. 위원회의 판단

◆ 본건에 있어서의 쟁점은 담당직원이 신청인의 동의 없이 임의매매를 하였는지 여부라고 할 것임.

(1) 임의매매 여부

담당직원이 주식을 위탁인인 고객의 동의 없이 매매한 경우에는 임의매매가 성립하고 이 경우 증권회사는 사용자배상책임을 지는 것이 원칙임. 또한 임의매매인지 일임매매인지 여부에 관한 판단은 구체적 증거가 없는 경우가 많으므로 객관적으로 나타난 계약 체결당시의 권유방법, 투자목적 내지 동기, 투자자의 거래 경험, 거래원장 상에 나타난 거래내역 등의 여러 정황을 종합하여 객관적이고 합리적으로 판단을 하여야 하는 것이 원칙이라고 할 것임.

민사재판에 있어서, 형사재판에서 인정된 사실에 구속을 받는 것은 아니라 할 지라도, 이미 유죄로 확정된 형사사건의 판결에서 인정된 사실은 유력한 증거자료가 되므로, 민사재판에서 제출된 다른 증거들에 비추어 형사판결의 사실판단을 채용하기 어렵다고 인정되는 특별한 사정이 없는 한 이를 배척할 수는 없는 것임.⁴⁹⁶⁾

아래의 각 점을 종합하면, 피신청인의 담당직원은 신청인의 동의 없이 임의매매를 한 것이 인정된다 할 것임.

① 담당직원과 피신청인은 2003.2.24. ○○지방법원으로부터 담당직원은 증권거래법 위반 및 업무상배임으로, 피신청인은 증권거래법 위반으로 각 벌금 3백만원에 처하는 약식명령을 받고 같은 해 4.28. 담당직원과 피신청인에게 위 명령이 송달되고 확정된 점.

② 피신청인 스스로도 위 약식명령 중 「증권거래법」 제215조에 의하여 벌금형을 받고도 더 이상 이의를 제기하지 아니하여 동 명령이 확정된 점.

③ 담당직원 자신이 임의매매에 대하여 2003.1.14. 검사가 작성한 피의자신문조서(이하 “피의자신문조서”라 함)의 기재에 의하면 스스로 수수료의 실적 때문에 신청인의 결정이나 승낙 없이 임의로 거래하였다고 진술하여 이를 인정하고 있는 점.

④ 위 형사사건의 피의자신문조서에 의하면 약속어음의 배서란에 기재되어 있는 문구 중 “이익분과 손실분에 대하여 5:5로 나누고 통장을 계속 관리한다” 부분에 대하여 당시 담당직원이 약속어음의 필요적 기재사항을 작성한 후, 읽어 볼 것이 있다고 하면서 달라고 한 후 뒷면에 담당직원이 일방적으로 이를 기재하였고, 신청인에게 별 뜻 없이 기재

496) 대법원 1991.1.29. 선고 90다11028 판결, 1997.8.29. 선고 96다14470 판결 참조.

한 것으로 신경 쓰지 말라고 하면서 향후 발생할 수 있는 수익에 대하여 5:5로 나누겠다고 하는 등 신청인을 적극적으로 기망하였다는 신청인의 주장에 대하여 담당직원도 스스로도 이를 인정하고 있는 점.

⑤ 또한 위 약속어음 교부일 이후 매매에 있어서는 검찰에서 대질신문 당시 담당직원 스스로 위 약속어음을 임의매매에 따른 손해액의 지급을 목적으로 작성·교부한 것이고, 또한 약속어음 배서란의 기재내용 중 동 계좌의 일임을 통한 수익분배약정 부분 역시 담당직원이 신청인을 기망하여 동 문구를 기재하였다고 스스로 인정하는 이상, 당해 약속어음교부행위 자체를 무효행위인 임의매매를 추인한 것으로 볼 수 없을 뿐 아니라, 이러한 수익분배약정 자체에도 법률행위로서의 효력발생요건을 갖추지 아니한 것이므로 동 약속어음 교부는 오로지 임의매매로 비롯된 책임을 모면하거나 임의매매를 계속하기 위한 수단에 지나지 아니하므로 임의매매의 위법성이 치유되었다고 할 수 없는 점.

(2) 손해배상액 산정

신청인은 동 위탁계좌에 19백만원을 입금하였으나, 이 중 신청인 자신의 매매지시에 따른 B기업 1,200주, C기업 2,000주, D기업 150주, E기업 5000주의 매매손실 1,052,500원을 차감한 17,947,500원에서 신청인이 금융감독원에 민원을 제기하고 매매가 종료된 2001.12.13. 당시의 잔고 평가액 1,319,444원(F기업 290주 및 예수금 43,444원)을 차감한 16,628,056원이 손해액이라 할 것임. 이와 관련하여, 피신청인은 검찰수사 과정에서 인정한 13,479,645원이 손해액이라고 주장하나, 위 금액은 2001.8.24.까지의 임의매매로 인한 손해액이며, 앞서 본 바와 같이 임의매매의 위법성은 담당직원의 매매종료 시점인 2001.12.13.까지 계속되고 있어 위 약속어음 교부일 이후의 손해도 손해배상액 산정에 포함된다 할 것이어서 이 부분 주장은 이유 없음.

한편, 신청인이 임의매매 사실을 인정한 이후, 지점장에게 이러한 사실을 알리고 적극적으로 손해복구를 위하여 노력한 사실이 있다 할지라도, 기망을 당하여 약속어음의 기재를 정확히 확인하여 보지 아니한 점 역시 본건 손해를 확대시킨 한 원인이 되었음에 비추어 10%의 과실상계를 함이 타당함.

결국 신청인의 손해배상액은 손해액 16,628,056원에서 과실상계를 한 1,662,806원을 뺀

14,965,250원이며, 피신청인은 신청인에게 이를 배상할 책임이 있다 할 것임.

라. 결 론

그렇다면 피신청인은 신청인에게 금14,965,250원을 배상할 책임이 있어 이를 인용하고 신청인의 나머지 청구는 이유 없어 이를 기각함.

3-4 고객의 손실이 확대되는 과정에서 선관주의의무를 위배하였다고 본 사례

[일부인용] 신청인이 담당직원에게 처음에는 알아서 해 달라고 하였으나 보름 쯤 지난 후 상의하고 매매를 하자고 했는데 담당직원이 상의 없이 임의매매를 하였다고 진술하고 있어 계좌 개설시 신청인이 포괄일임을 하였던 것으로 인정되고, 이후 신청인이 거래내역 등을 확인하면서도 2억원을 추가로 입금하고 거래를 지속하였던 점 등으로 보아 담당직원이 임의매매를 하였다는 신청인의 주장은 이유 없음. 그러나 본건 거래로 인한 손실이 확대되고 있음에도 담당직원이 신청인에게 신용기간의 만기나 담보비율 유지 및 반대매매 등에 대한 설명은 하지 않고 이자를 대납하겠다고 신용거래를 다시 권유한 것은 선관주의의무에 위배된다고 보아야 할 것임.(2008.5.20. 조정번호 제2008-37호).

가. 사실관계

신청인은 평소 알고 지내던 A씨로부터 ○○증권사(이하 “피신청인”이라 함) 지점 B 대리(이하 “담당직원”이라 함)를 소개 받은 후, 2007.6.11. 동 지점에 신청인 명의의 주식 위탁계좌를 개설하고 담당직원을 관리자로 등록하였음.

신청인은 위탁계좌에 계좌개설 당일 1억원을 입금한 것을 비롯하여 같은 해 7.24. 1억원, 8.17. 4천만원, 9.3. 8천만원을 추가로 입금(총 입금액: 3억 2천만원)하였고, 11.9. 6천 5백만원을 출금하였음. 계좌개설 당시 담당직원은 신청인에게 시장이 긍정적이어서 연말까지 30% 정도의 수익이 가능하다고 함과 동시에 수익률을 높이기 위해 신용거래를 할 것을 권유⁴⁹⁷⁾하였고, 이에 신청인은 계좌개설시 신용거래를 함께 신청하였음.

2007.6.11. 담당직원은 거래를 시작하면서부터 신용을 사용하였는데, 신청인이 위험하

다며 정리해 달라고 하여 7.13. 사용중이던 신용거래를 모두 정리하였으나, 10월초 담당 직원은 시장이 하락하였다가 상승하면서 위탁계좌의 주식비율이 높고 현금이 없어 추가 매수가 곤란해지자, 손실을 빨리 회복하기 위해선 신용이 필요하다는 신청인에게 신용거래를 재권유하여 10.9. 신용거래를 다시 시작하였음.

2007.11월 이후 손실이 확대되자, 12월 초순경 신청인은 시동생과 함께 피신청인 지점 장실을 방문하여 담당직원이 임의로 매매를 하는 등 선관주의의무를 위배하여 손실이 발생하였다는 이의를 제기하였고, 이에 담당직원은 시장상황이 나빠서 손실이 발생한 것이니 기회를 더 달라면서 C기업 주식을 추천하고, 시장이 많이 하락한 상황이니 여기서 신용을 더 쓸 수 있도록 허락해 주면 최선을 다해서 회복해 보겠다고 리스크 분담 차원에서 6개월 동안 추가적으로 신용매수하는 부분에 대한 이자는 본인이 대납하겠다고 하였음.

신청인은 담당직원의 제안을 받은 며칠 후에 동 제안을 수락하였고, 이에 담당직원은 2008.1.10. C기업 주식 5,000주를 6,220만원에 신용으로 매수하였으며, 동일자에 512,100 원, 2.1.에 1,187,200원의 이자를 대납하였음.

한편, 신청인은 2008.1.30. 담보부족 발생으로 “2.1. 반대매매가 실행된다”는 문자메시지를 받고 1.31. 1천만원을 입금하였으며, 2008년 1월말~2월초 신용만기가 돌아오자 담당직원은 신청인이 사용중이던 신용을 주식담보대출로 전환시켜 주었음. 2008.2.26.을 기준으로 신청인 명의 위탁계좌의 예수금총액은 2,619,766원이며, 사용중인 신용금은 6,220만원, 주식담보대출금은 7,700만원이었음.

거래 초기 담당직원은 매매내역을 이메일이나 전화 및 문자를 통해 신청인에게 통보해 주었고, 2007.7.18. 이후에는 신청인이 HTS를 개설하여 잔고현황 등을 조회하였음.

나. 당사자 주장

(1) 신청인 주장

497) 신용거래 권유시 담당직원은 이자에 대한 설명은 하였으나, 담보유지비용 및 반대매매 등에 대하여는 설명하지 않았음.

매매를 시작한지 보름쯤 지나 담당직원에게 주식을 매매하기 전에 의논해 달라고 하였음에도 담당직원은 상의 없이 임의매매를 하였고, 만기나 반대매매와 같은 신용거래에 따른 위험을 충분히 설명하지 않고 신용 사용을 종용하였으며, 시장이 좋을 때만 설명을 하고 시장이 좋지 않을 때는 연락도 없는 등 담당직원이 고객보호를 제대로 하지 않아 원금손실이 발생하였는 바, 피신청인은 원금 손실액을 배상할 책임이 있음.

(2) 피신청인 주장

신청인과 담당직원 사이의 통화내용에 대한 녹취록을 보면, 신청인이 담당직원에게 포괄일임을 하였음을 알 수 있으며, 특히 신청인이 HTS를 통하여 잔고와 손익을 조회하면서도 2007.9.3.까지 3회에 걸쳐 추가 입금을 하고, 계속 담당직원과 거래를 한 점으로 보아 담당직원이 임의매매를 하였다는 신청인의 주장은 이유 없으며, 신용계좌 개설시 작성하는 신청서에는 신용융자비율, 융자기간, 담보부족 발생시 처리방법 등이 모두 기재되어 있는데, 신청인은 동 신청서 “본인은 신용거래약관 확인 및 신용거래설명서를 교부 받고 그 내용을 충분히 이해하며, 본인의 판단과 책임으로 신용거래를 할 것을 승낙합니다.”란 문구 아래 자필서명 및 날인을 하였는 바, 신청인은 신용제도의 위험성에 대해 알고 있었다 할 것이고, 매매기간 동안 발생한 주요지표를 보면, 수수료율이 10%, 매매회전율이 149%에 불과하여 담당직원이 신청인에 대한 보호의무를 위반한 것으로도 볼 수 없는 바, 피신청인은 손해배상책임이 없음.

다. 위원회 판단

◆ 본건의 쟁점은 피신청인의 담당직원이 임의매매를 하였는지와 선관주의의무를 위반하였는지 여부라 할 것임.

(1) 임의매매 여부

담당직원이 주식 등을 위탁인인 고객의 동의 없이 매매한 경우에는 임의매매가 성립하고 이 경우 증권회사는 사용자배상책임을 지는 것이 원칙임. 또한 임의매매인지 여부에 대하여는 구체적 증거가 없는 경우가 많으므로 객관적으로 나타난 계약체결 당시의 권유방법, 투자목적 내지 동기, 투자자의 거래경험, 거래원장상에 나타난 거래내역 등의

여러 정황을 종합하여 객관적이고 합리적으로 판단하여야 할 것임.

신청인과 담당직원에 대하여 금감원에서 작성한 문답서(이하 “문답서”라 함) 제3면에 따르면, 신청인은 계좌 운용과 관련하여 담당직원에게 처음에는 알아서 해 달라고 하였으나 보름쯤 지난 후 꼭 사고 팔기 전에 상의하고 매매를 하자고 했는데 담당직원이 상의 없이 임의매매를 하였다고 진술하고 있는 바, 계좌 개설시 신청인이 포괄일임을 하였던 것으로 인정되고, 이후 신청인이 담당직원의 거래보고나 HTS를 통해 거래내역 등을 확인하면서도 2007.7.24.~9.3. 기간중 2억2천만원을 추가로 입금하고 거래를 지속하였던 점과 거래기간 중 담당직원과 신청인이 위탁계좌 운용과 관련한 통화를 계속 하였던 점으로 보아 신청인의 포괄일임이 지속된 것으로 보아야 할 것인 바, 담당직원이 임의매매를 하였다는 신청인의 주장은 이유 없음.

(2) 선관주의의무 위반으로 인한 손해배상책임 성립여부

일반적으로 고객과 증권회사 임직원간에 유가증권의 매매에 대한 포괄적 일임관계에 있는 경우 동 임직원은 수탁자로서 당연히 충실의무 내지 선관주의의무가 있으므로, 이에 따라 매매 대상 유가증권이 고객의 투자목적·재산상태·투자경험에 비추어 적합한지를 고려하여 거래를 하여야 함.⁴⁹⁸⁾

담당직원의 매매거래내역을 살펴보면, 손실금액 대비 수수료율이 9.6%, 매매회전율이 149%, 미수금 발생율이 1%에 불과하여 과당매매가 성립하지는 않으나, 2007.12월 초순경 신청인이 피신청인 지점을 방문하여 이의 제기를 한 이후의 거래에 대하여 살펴보면, 손실이 확대된 상황이었음에도 담당직원이 신청인에게 신용기간의 만기나 담보비율 유지 및 반대매매 등에 대한 설명은 하지 않은 채 이자를 대납하겠다고 신용거래를 다시 권유한 것은 선관주의의무에 위배된다고 보아야 할 것인 바, 2008.1월에 행하여진 C기업 주식 5,000주의 신용거래에 따른 손실에 대하여는 피신청인의 손해배상책임이 인정된다고 보아야 할 것임.

(3) 손해배상액 산정

498) 금융분쟁조정위원회 조정번호 제2006-62호 등 참조.

담당직원은 2008.1.10. C기업 주식 5천주를 6,220만원에 신용으로 매수하였는데, 신청인이 금감원에 분쟁조정을 신청한 2008.1.31. 동 주식의 평가금액은 3,950만원(2008.1.31. 종가 기준)이었던 바, 신청인의 손해금액은 6,220만원에서 3,950만원을 차감한 2,270만원이라 할 것임.

한편, 신청인은 본건 주식투자시 다른 증권사를 통해서도 주식거래를 하고 있었으며, 2002년경에도 주식투자를 한 경험이 있는 자로서 주식거래의 위험성을 상당 정도 인지할 수 있었음에도 담당직원에게 주식거래를 포괄적으로 일임하였고, 담당직원의 통보나 HTS를 통해 잔고 등을 확인하면서도 적극적으로 거래를 중지시키지 않고, 오히려 신용이자 대납을 제안 받고 담당직원에게 신용매매를 계속 일임하였는 바, 신청인에게 이러한 자기재산 관리 소홀에 따른 과실을 물어 60%의 과실상계를 함이 타당함.

라. 결론

그렇다면 피신청인은 신청인에게 손해금액 9,080,000원을 배상할 책임이 있어 이를 인용하고, 신청인의 나머지 청구는 이유 없어 기각함.

3-5 임의매매 여부 및 손해배상청구권의 소멸시효 완성 여부

[기각] 검찰의 피의사건처분결과 통지서, 담당직원 확인서 및 담당직원과 신청인의 진술 등에 비추어 피신청인 담당직원이 임의매매를 한 점이 인정되나, 한편으로 2003.3월경 신청인이 피신청인 지점에 내점하여 계좌부원장거래내역을 출력하는 등 신청인은 늦어도 2003.3월 경에는 담당직원의 임의매매 및 손해발생사실을 알고 있었음에도 이를 안 날로부터 3년이 경과하도록 별도의 조치를 취하지 아니한 점 등에 비추어 피신청인에 대한 손해배상청구권은 소멸시효가 완성되었다 할 것임.(2009.11.10. 조정번호 제2009-92호)

가. 사실관계

신청인은 1996년경 모 증권사에 계좌를 개설하고 동사 직원 A씨(이하 “담당직원”이라 함)를 관리자로 하여 주식거래를 하여 오다가, 담당직원이 ○○증권(이하 “피신청인”이

라 함) 회사로 이직함에 따라 담당직원의 권유로 1999.7.24. 피신청인의 지점으로 계좌를 이관하였으며, 담당직원과 신청인의 진술에 의하면, 계좌이관 초기 얼마간은 신청인이 직접 유선으로 거래를 하였으나, 이후 담당직원이 유선거래를 통해 알고 있는 비밀번호를 이용하여 주식을 매매함.

신청인이 1999.7.26. 및 2001.2.20. ‘잔고 및 거래내역, 채권통보’와 ‘매매보고서’ 불원을 신청한 관계로 매매기간 중 월간거래내역 및 잔고현황 등의 통보가 이루어지지 않는 아니 하였는데, 2001년 초에 신청인은 창업준비를 위한 자금이 필요하여 담당직원에게 잔고현황을 요청함에 따라 담당직원이 워드를 이용하여 임의로 작성한 잔고확인서를 제공하자, 신청인이 이를 이상하게 여겨 다른 직원을 통해 잔고를 확인하고 임의매매사실을 인지 하였으며, 2001.2.20.자 예탁잔고를 확인하고 서명함.

2002.3.23. 담당직원이 B증권사로 이직하자, 신청인은 피신청인 지점에 내점하여 예수금 46,859,000원을 출금하고 남은 주식을 B증권사로 대체출고하였으며, 이후 2003.3월경 담당직원과 연락이 되지 않자 피신청인 지점에 내점하여 계좌거래내역을 출력함.

2009.7월경 신청인은 담당직원을 임의매매, 업무상 배임 혐의로 검찰에 고소하였고, 같은 해 8.21. 담당직원이 신청인에게 임의매매사실을 인정하는 확인서를 작성·교부하였으며, 9.29. 검찰은 동 고소사건에 대해 혐의사실은 인정되나 공소시효가 완성되었다는 이유로 불기소(공소권없음) 처분함.

나. 당사자 주장

(1) 신청인 주장

담당직원의 임의매매로 손해를 입었으며 담당직원이 이를 인정하는 확인서를 제출하였음. 소멸시효의 기산점이 되는 “손해 및 가해자를 안 날”이라 함은 손해를 현실적이고 구체적으로 인식하여야 하고 단순한 손해발생의 추정이나 의문만으로는 부족하다 할 것인 바, 신청인이 불법행위를 구체적으로 확인하고 인식할 수 있었던 시점은 담당직원이 검찰진술을 함으로써 확인할 수 있었던 것이므로 소멸시효 완성이라는 주장은 부당함.

(2) 피신청인 주장

신청인은 고액을 투자한 투자자로서 임의매매임을 인지하였다면 피신청인 지점이나 감사팀에 이의를 제기하거나, 민·형사상의 법적인 조치를 취했어야 함이 통상적이라고 할 것인데, 이후 계속적인 매매행위를 하였던 점으로 보아 신청인과 담당직원은 서로 협의하여 매매를 하였다고 할 것임.

설사 임의매매가 인정된다고 하여도 신청인이 임의매매로 인한 손해 및 가해자를 안 날로부터 3년이 경과하였으므로 신청인의 손해배상청구권은 시효로 소멸하였다고 할 것임.

다. 위원회 판단

◆ 본건의 쟁점은 피신청인 담당직원의 임의매매 해당 여부 및 임의매매로 인한 손해배상청구권의 소멸시효 완성여부라 할 것임.

(1) 임의매매 여부

검찰의 피의사건처분결과 통지서, 담당직원이 신청인에게 작성한 확인서 및 담당직원과 신청인의 진술 등에 비추어 피신청인 담당직원이 임의로 주식을 매매한 점은 일응 인정된다고 보임. 다만 아래에서 보는 바와 같이 신청인의 임의매매로 인한 손해배상청구권이 인정된다고 하더라도 소멸시효가 완성되었다 할 것이므로 이에 관하여 구체적으로 판단, 적시하지 아니함.

(2) 소멸시효 완성 여부

민법 제766조 제1항은 불법행위로 인한 손해배상 청구권은 피해자나 그 법정대리인이 그 손해 및 가해자를 안 날로부터 3년간 행사하지 아니하면 시효로 소멸한다고 규정하고 있음.

한편, 피해자 등이 언제 불법행위의 요건사실을 현실적이고도 구체적으로 인식한 것으로 볼 것인지 여부는 개별적 사건에 있어서의 여러 객관적 사정을 참작하고 손해배상청구가 사실상 가능하게 된 상황을 고려하여 합리적으로 인정하여야 할 것인 바, 다음과 같은 점에 비추어 담당직원의 임의매매가 인정된다 하더라도 이에 대한 신청인의 손해배상청구권은 소멸시효가 완성되었다 할 것임.

① 불법행위로 인한 손해배상청구권의 단기소멸시효 기산점이 되는 민법 제766조 제1항 소정의 손해 및 가해자를 안날이라 함은 손해의 발생, 위법한 가해행위의 존재, 가해행위와 손해의 발생 사이에 상당인과관계가 있다는 사실 등 불법행위의 요건에 대하여 현실적이고도 구체적으로 인식하였을 때를 의미한다 할 것이지만 손해의 액수나 정도를 구체적으로 알아야 할 필요까지는 없다 할 것인 점.⁴⁹⁹⁾ 임의 매매와 같이 피해자의 의사 없이 이루어지는 불법행위의 경우에는 피해자가 임의매매사실을 인지하고 동 임의매매결과 발생한 손실을 인지하였다는 것으로 시효가 진행된다고 할 것인 바, 2001.1월초 신청인은 창업자금 준비를 위해 잔고를 확인하는 과정에서 임의매매 사실을 인지하였고, 2001.2.20. 예탁잔고확인서에 서명하여 임의매매사실, 잔고현황, 그에 따른 손해발생사실을 알 수 있었다고 보이는 점, 2002.3.23. 신청인이 피신청인 지점에 내점하여 예수금을 출금하고 보유주식을 A증권에 이관한 사실이 있는 점, 2003.3월경 신청인이 피신청인 지점에 내점하여 계좌부원장거래내역을 출력한 점.

② 담당직원과 신청인을 상대로 금감원에서 실시한 문답에서, 신청인은 “2001년 초 사업구상을 하던 중 자금이 필요하여 전화로 여직원에게 잔고확인을 하면서 임의매매사실을 인지하였다면 본인의 계좌 거래내역을 조회하여 임의매매 기간 동안의 손해와 이러한 손해가 담당직원의 임의매매로 인하여 발생하였다는 사실을 알았습니까?”라는 물음에 대해 “당시 임의매매거래 사실을 확인하고 손해가 발생한 사실을 인지하였고 대략적으로 손해액도 산정해 보았습니다. 담당직원의 임의매매로 인하여 손해가 발생했다는 사실을 인지하였습니다.”라고 답변하고 있으며, “2001년 초 사업구상을 하던 중 자금이 필요하여 전화로 여직원에게 잔고확인을 하면서 임의매매 사실을 알게 되었다고 하였는데 당시 발생한 손해액은 어느 정도였으며 이와 관련하여 피신청인에게 이의를 제기하거나 민사소송을 제기하는 등 다른 법적 구제절차를 행사하지 않은 이유는 무엇입니까?”라는 물음에 대해 “약 12억에서 13억 정도로 기억하고 있습니다. 이러한 행위에 대한 법적인 구제 절차를 몰랐습니다.”라고 답변하고 있고, “2002.3.23. 신청인이 지점에 내방하여 예수금을 출금하고 남은 주식을 타사대체 출고한 사실이 있는데, 당시 본인의 계좌 거래현황을 파악하여 임의매매 사실을 확인한 후 손해발생 사실을 확인하였습니

499) 대법원 1995.11.14. 선고 95다30352 판결 참조.

까? 확인하였다면 당시 피신청인에게 이의를 제기하거나 다른 법적 구제절차를 행사하지 않은 이유는 무엇입니까?”라는 물음에 대해 “네 확인하였습니다. 법적 구제절차를 알지 못하였기 때문입니다.”라고 답변하고 있어 신청인은 2001.2.20. 또는 늦어도 2002.3.23.이나 2003.3월 경에는 담당직원의 임의매매 사실 및 손해발생 사실을 알고 있었다 할 것이며 시효중단 조치를 취함에 특별한 법적, 사실적 장애가 있다고 보기 어려움에도 이를 안날로부터 3년이 경과하도록 별도의 조치를 취하지 아니한 점.

라. 결론

그렇다면 신청인의 피신청인에 대한 손해배상청구권은 소멸시효가 완성되었다 할 것이므로 신청인의 청구는 이유 없어 이를 기각함.

제2절 임의매매 불인정 사례

3-6 고객 지인의 지시로 매매한 경우 임의매매 해당 여부

[기각] 담당직원이 주식을 위탁인인 고객의 동의 없이 매매한 경우에는 임의매매가 성립하고 이 경우 증권회사는 사용자배상책임을 지는 것이 원칙임. 또한 임의매매인지 협의매매인지에 관한 구별에 있어서 구체적인 증거가 없는 경우가 많으므로 객관적으로 나타난 계약체결당시의 권유행위, 투자목적 동기 등의 여러 정황을 살펴 합리적으로 판단하여야 하는 것이 원칙이라 할 것임.(2001.7.24. 조정번호 제2001-41호)

가. 사실관계

1999.5.4. 신청인은 자신의 운전사로 근무하던 A씨의 소개로 A씨와 함께 ○○증권(이하 “피신청인”이라 함) △△지점을 방문하여 위탁계좌를 개설하고, 동 지점의 직원인 B씨를 계좌관리자로 하여 주식매매거래를 시작함.

2000.2.9. 신청인은 B씨의 소개로 피신청인의 ▽▽지점 직원 C씨가 근무하는 ▽▽지점으로 관리점을 변경하고, C씨를 계좌관리자로 하여 주식매매거래를 계속함.

2000년 7월말 신청인이 근무처를 옮겼으나 운전사인 A씨는 옛 근무처에 잔류하였고, 2000.8.1~2001.2.5 기간중에도 A씨는 피신청인의 직원인 C씨와 상의하여 매매거래를 하였으며, 거래대금 중에는 뮤추얼펀드 청산대금도 포함⁵⁰⁰⁾되어 있음.

나. 당사자의 주장

(1) 신청인의 주장

2000.2.9. 피신청인의 △△지점에서 ▽▽지점으로 관리점을 옮겼을 때 평가금액은 11.9억원(뮤추얼펀드 4.6억원, 주식 7.3억원)이었음. 이후 같은 해 4월, 5월 및 6월에 걸쳐 평

500) 1999.11.3. 신청인이 청약한 뮤추얼펀드 85,400주가 신청인의 위탁계좌에 입고되어 있다가 다음 해 10.25. 및 11.2. 동 주식이 만기 청산되어 386,593,757원이 신청인의 위탁계좌로 자동적으로 입금됨.

가금액이 각 14억원, 12억원 및 11억원에 달하여 3회에 걸쳐 매도요구를 하였으나 직원이 이를 이행하지 않았음. 계속되는 주가하락과정에서 직원이 신청인과 아무런 상의 없이 매매거래를 하였고, 이후 2001년 2월에 잔고확인을 해 보니 뮤추얼펀드가 주식으로 전환되어 있었고, 신청인도 모르게 매매거래가 빈번하게 이루어짐으로써 현시세로 환산하면 3.3억원에 불과한 예수금만 남게 되었음.

(2) 피신청인의 주장

신청인이 운전사인 A씨에게 대리권을 부여하였고, 신청인의 근무처가 2000.7월말경 변경되면서 양인간의 대리권 관계가 없어졌다 하더라도 당시 A씨에 대한 대리권 부여를 철회한다는 신청인의 언급이 없었고, A씨가 마치 신청인과 계속 근무하는 것처럼 지속적으로 잔고확인 및 매매에 관하여 문의를 해왔다는 점에서 A씨의 대리행위를 표현대리로 본 직원의 매매행위는 선의 및 무과실로서 정당한 것임.

또한 뮤추얼펀드 상환자금으로 주식매매를 한 것도 A씨와 상의하여 한 것이므로 임의매매가 아님. 2000.4월~6월경 3회에 걸친 매도지시를 불이행하였다는 신청인의 주장에 대해 직원은 부인하고 있고, 신청인 또한 매도지시 불이행에 대한 이의제기를 한 사실이 없는 점에 비추어 신청인의 주장을 인정하기 곤란함.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 특정기간중의 매매가 임의매매에 해당하는지 여부 및 피신청인이 신청인의 매도지시를 불이행하였는지 여부라 할 것임.

2000.2.9.~2001.2.5. 기간중 매매가 임의매매에 해당하는지 여부와, 같은 해 4월, 5월 및 6월의 매도지시 불이행 여부에 대하여 살펴보건대, 신청인은 자신의 운전사인 A씨에게 주식매매에 대한 대리권을 부여한 사실이 없다고 하나 아래와 같은 점에 비추어 보았을 때 위 A씨에게 대리권을 부여한 것으로 직원이 믿을 만한 정당한 사유가 있는 것으로 판단됨.

① 1999.5.4. 신청인이 위탁계좌개설당시 직원인 B씨는 신청인이 A씨에게 매매상담 및

보고를 하라고 하였다고 진술하고 있고 A씨도 이를 시인하고 있으며, 신청인은 당시 주식매매권한을 A씨에게 수여한 것이 아니라 자신에게 계좌의 잔고평가액을 보고하라는 의미였다고 하면서도 점차 A씨를 통한 포괄일임 형태로 변해 가게 되었고, 신청인 또한 C씨와 A씨가 상의하여 매매하고 있다는 사실을 알고도 아무런 이의 제기가 없었고, 오히려 B씨로 하여금 A씨에게 매매보고 및 상담을 하라고 한 사실이 있는 점.

② 2000.2.9. 신청인이 관리점을 ▽▽지점으로 변경시 상기와 같은 매매방식에 대하여 이의제기 없이 관리점을 변경한다는 “사고신고 및 정보정정신청서”에 자필로 기재하였고, 이후 B씨가 소개한 직원인 C씨가 기존과 같은 방식으로 A씨에게 매매상담 및 보고를 지속해 왔으며, 신청인도 A씨와 C씨가 상의하여 매매하고 있다는 사실을 인지하고 있는 상태에서 한 달에 1번 정도 지점을 방문하여 예탁잔고를 확인해 왔다는 것을 인정하고 있는 점.

③ 2000.7월말 신청인이 근무처를 옮기고 A씨는 옛 근무처에 잔류하였으나, 신청인이 A씨에게 수여한 대리권을 철회한 사실이 없고, A씨는 마치 신청인과 계속 근무하고 있는 것처럼 매매상담 및 잔고확인을 지속하였고, 피신청인이 매월 발송하는 월별 매매거래내역서도 반송된 사실이 없는 점.

위와 같은 정황에 비추어 볼 때 2000.2.9.~2001.2.5. 기간중 매매는 신청인의 위탁계좌 매매대리권을 부여받은 A씨에 의한 매매이거나 A씨가 직원에게 일임한 매매이므로 임의매매는 아니라고 판단됨. 신청인은 뮤추얼펀드 상환자금(386,593,757원)으로 주식투자를 한 것에 대하여 이의제기를 하고 있으나 A씨가 신청인의 위탁계좌에 대한 대리권을 부여받았다고 판단되는 이상 동 상환자금을 통한 주식거래 또한 임의매매는 아니라고 보임. 신청인은 직원이 과다하게 매매하였다고도 주장하나 기간중 매매회전율이 0.12회, 손해금액대비 수수료비율이 7.5%에 불과한 점 등에 비추어 보았을 때 과다일임매매로 보기도 어려움.

신청인은 2000.4월, 5월 및 6월 예탁자산이 각 14억원, 12억원 및 11억원에 달하여 3회에 걸쳐 매도를 요구하였음에도 직원(C씨)이 이를 불이행하였다고 주장하고 있으나, 아래와 같은 점에 비추어 보았을 때 직원이 매도지시를 불이행하였다고는 보이지 않음.

① 신청인은 동 기간중 1개월에 1회정도 지점을 방문하여 매매상황 및 예탁잔고를 확인하고 매수매도 타이밍을 상담하였고, 특히 6월 이후인 7월에도 동 지점을 방문한 사실을 인정하면서도 실제 매도지시 불이행을 입증할 만한 정황증거를 제시하지 못하고 있는 점.

② 대리권을 부여받은 것으로 볼 수 있는 A씨도 이에 대하여 별다른 문제제기를 하고 있지 않는 점.

③ 2001.2.6. 신청인이 예탁잔고를 확인한 후 뮤추얼펀드 상환자금에 대하여만 이의 제기를 하였을 뿐 그 전에 이루어진 매매거래에 대하여는 이의제기를 한 사실이 없는 점.

라. 결 론

피신청인의 직원이 임의매매 등을 하였다고 보기 어려우므로 신청인의 손해배상청구는 이유 없다고 할 것임.

3-7 임의매매와 협의매매와의 구별

[기각] 임의매매인지 협의매매인지에 관한 구별에 있어서 구체적인 증거가 없는 경우가 많으므로 객관적으로 나타난 계약체결 당시의 권유행위, 투자목적 동기 등의 여러 정황을 살펴 합리적으로 판단하여야 하는 것이 원칙이라 할 것인 바, 본건의 경우 담당직원이 주식을 고객의 동의 없이 매매하였다고 볼 수 있는 객관적 사정이 부족하다 할 것임.(2003.6.10. 조정 번호 제2003-22호)

가. 사실관계

2000.3월경 신청인은 신청인이 운영하는 식당에서 ○○증권사(이하 “피신청인”이라 함) △△지점의 A씨⁵⁰¹⁾(이하 “담당직원”이라 함)을 알게 되었고, 담당직원을 통하여 주

501) 담당직원이 신청인을 알게 될 당시에는 담당직원은 피신청인 △△지점에서 근무하면서 현물증권과 수익증권의 영업을 담당하였으며, 신청인이 투자를 개시한 2001.4.26.에는 ▽▽지점에서 근무를 하고 있었음.

식거래에 대한 투자권유를 받은 사실이 있음.

신청인은 2001.4.26. 피신청인 ▽▽지점에서 신청인 명의의 위탁계좌를 개설하고 3,500 만원을 투자금으로 입금하였으며, 관리직원은 담당직원으로 하였음. 담당직원은 같은 해 4.28. 동 위탁계좌를 통하여 B증권 주식 1,000주를 매수하고 같은 해 5.2. 매도하였으며, 이후에도 금융주와 코스닥종목을 2001.12.10.까지 거래하였음. 신청인이 임의매매라며 이의를 제기한 2002.1.30. 당시 동 계좌에는 예수금 24,186원과 B증권 보통주 480주(평가금액 1,872,000원)가 남아 있어 신청인이 입은 총 손실액은 33,123,565원에 이름.

나. 당사자의 주장

(1) 신청인의 주장

담당직원으로부터 주식투자를 하도록 부당권유를 받아 위탁계좌를 개설하고 담당직원에게 B증권 주식의 매수를 지시한 후, 피신청인으로부터 수령한 거래내역서를 통하여 담당직원이 미수거래를 하는 등 임의매매를 하였음을 알게 되었으며 또한 빈번한 매매를 통하여 막대한 수수료 이익을 피신청인은 얻었음. 이에 담당직원에게 원금보상을 요구하였고, 담당직원이 조금 기다리면 장이 좋아 손실이 회복된다고 하였으나, 원상복구를 하지 아니하고 퇴직하였음.

(2) 피신청인의 주장

담당직원은 주식투자를 하도록 부당권유를 한 사실이 없고, 담당직원은 신청인의 위탁계좌를 통하여 포괄적 일임매매를 하였으며, 신청인도 월거래내역서를 정상 수령하여 매매결과를 인지하고 있었으므로 신청인의 손해배상청구를 인정할 수 없음.

다. 위원회의 판단

- ◆ 본건에 있어서의 쟁점은 담당직원이 ① 신청인의 동의 없이 임의매매를 하였는지 여부와 ② 신청인에게 투자권유를 하면서 부당권유를 하였는지 여부 등이라 할 것임.

(1) 임의매매 여부

담당직원이 주식을 위탁인인 고객의 동의 없이 매매한 경우에는 임의매매가 성립하고 이 경우 증권회사는 사용자배상책임을 지는 것이 원칙임. 또한 임의매매인지 일임매매인지 여부에 관한 판단은 구체적 증거가 없는 경우가 많으므로 객관적으로 나타난 계약 체결당시의 권유방법, 투자목적 내지 동기, 투자자의 거래 경험, 거래원장 상에 나타난 거래내역 등의 여러 정황을 종합하여 객관적이고 합리적으로 판단을 하여야 하는 것이 원칙이라고 할 것임.

2001.4.26. 신청인은 담당직원에게 B증권 보통주의 매수지시만을 하였고 위 보유주식의 매도지시를 한 사실이 전혀 없는데도 담당직원이 임의로 위 보유주식을 매도했으며, 이 후의 매매와 관련하여서도 이를 담당직원과 상의한 바가 없다고 주장하나, 신청인의 주장을 입증할 만한 증거를 발견하기 어렵고, 오히려 담당직원 및 지점장 C씨가 작성한 각 경위서, 월간 매매내역서 발송자 명단, 녹취록의 각 기재 그리고 문답결과를 종합하면, B증권 주식의 매수와 관련하여서 입금과 동 주식의 매수시기와의 차이가 있는 점, B증권의 매도사실을 담당직원이 신청인에게 보고를 한 사실이 있는 점, 또한 이후의 매매에 있어서도 담당직원이 미리 투자종목을 선정하고 매수·매도를 한 후, 신청인에게 이에 대한 보고를 하는 등의 사실을 인정할 수 있으므로 신청인의 이 부분 주장은 이유 없음.

(2) 부당권유 여부

증권회사 임직원이 「증권거래법」 제52조(부당권유행위등의 금지)에 위반한 방법으로 투자를 권유하여 투자결과 손실을 본 경우에 투자자에 대한 불법행위책임을 성립하기 위하여는, 거래행위와 거래방법, 고객의 투자상황, 거래의 위험도 및 이에 관한 설명의 정도 등을 종합적으로 고려한 후 당해 권유행위가 경험이 부족한 일반 투자자에게 거래행위에 필연적으로 수반되는 위험성에 관한 올바른 인식형성을 방해하거나 고객의 투자상황에 비추어 과대한 위험성을 수반하는 거래를 적극적으로 권유한 경우에 해당하여 결국 고객에 대한 보호의무를 저버려 위법성을 띤 행위인 것으로 인정될 수 있어야 함.

신청인이 투자금 3,500만원을 입금할 당시에 부당권유가 있었는지 여부에 대하여는, 신청인의 주장을 입증할 만한 증거를 발견하기 어렵고, 오히려 주식투자를 권유하면서

이익보장이나 손실보전을 약속한 사실이 없음에는 당사자 사이에 다툼이 없고, 매매거래 원장 및 위탁계좌개설신청서(고객 투자 목적 기재서 포함)의 각 기재와 문답결과를 종합하면, 2000년부터 담당직원은 신청인에게 객관적 자료에 기초하여 금융시장의 종합적인 사항과 수익증권의 수익률, 주식시장의 상황에 대한 정보를 제공한 사실이 있으므로 신청인의 이 부분 주장 역시 인정할 수 없다고 할 것임.

(3) 기타 포괄적 고객보호의무 위반 여부

나아가 신청인은 담당직원이 과도한 미수거래를 하고, 나아가 과당회전매매를 하였다고 주장하나, 2001.4월~12월경 사이에 신청인의 계좌에서 이루어진 총 매매회수는 96회, 월 평균매매회전율 1,113%(11회)이고, 동 계좌에서 발생한 수수료는 7,893,545원에 불과하며, 월평균 미수금발생을 역시 4.5%로 과다하지 아니한 점을 종합할 때, 신청인의 이 부분 주장 또한 이유 없다 할 것임.

라. 결 론

그렇다면 피신청인은 신청인에 대하여 배상할 책임이 없다 할 것이므로 신청인의 청구는 모두 이유 없어 이를 기각함.

3-8 신청인이 거래내역을 인지하고 수차례 협의한 경우 임의매매 성립 여부

[기각] 담당직원이 주식을 위탁인인 고객의 동의없이 매매한 경우에는 임의매매가 성립하고 이 경우 증권회사는 사용자배상책임을 지는 것이 원칙이며, 임의매매인지 여부에 대하여는 구체적 증거가 없는 경우가 많으므로 객관적으로 나타난 계약체결 당시의 권유방법, 투자목적 내지 동기, 투자자의 거래경험, 거래원장상에 나타난 거래내역 등의 여러 정황을 종합하여 판단하여야 할 것임. 본건은 신청인이 빈번하게 입출금을 하였고 직원과 수차례씩 전화로 협의를 하였던 바, 신청인의 임의매매 주장은 이유 없음.(2005.9.13. 조정번호 제2005-60호)

가. 사실관계

신청인은 2002.10.30. ○○증권사(이하 “피신청인”이라 함) A지점에서 신청인 명의의

위탁계좌를 개설하여 금 3백만원을 입금하는 등 2004.7.12.까지 총 131회에 걸쳐 금 555,350,000원을 주식투자금으로 입금하였으며, 동 계좌에 대하여는 피신청인의 직원 B 씨(이하 “담당직원”이라 함)가 관리를 담당하였고, 담당직원이 2002.11.01.~2004.08.04. 기간동안 위 계좌를 운용하던 중 총 178,193,500원의 손실이 발생하였음.

그리고 신청인은 2004.12.14. 피신청인의 C지점⁵⁰²⁾에서 위 위탁계좌에 금 600만원을 입금하는 등 2005.04.08.까지 총10회에 걸쳐 금 45,900,000원을 주식투자금으로 입금하였으며, 위 담당직원이 2005.04.19.까지 동계좌를 운용하던 중 총 9,953,153원의 손실이 발생하였음.

나. 당사자의 주장

(1) 신청인 주장

피신청인의 담당직원은 신청인의 위탁이 없는 종목에 대하여 임의로 매매를 하였을 뿐만 아니라 계좌 운영기간 내내 대량의 미수거래 및 빈번한 단타거래를 하여 과도한 수수료를 발생시키고, 불법적인 작전성 매매로 신청인에게 손해를 발생시켰는 바, 불법 임의매매 및 단타매매로 인한 손실 93,443,294원에 대한 손해배상을 청구함.

(2) 피신청인 주장

신청인은 하루에 수차례씩 담당직원과 전화통화에 의하여 협의에 의한 주식매매거래를 하였으며, 매매회전율이 높거나 미수거래가 발생되었다 해도 이는 신청인의 거래지시에 의한 것으로 담당직원의 선관주의의무 위반에 따른 것은 아니라 할 것이므로 피신청인에게는 손해배상 책임이 없음.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 ① 피신청인의 임의매매 여부 및 ② 과도한 일임매매 여부라 할 것임.

502) 담당직원은 2004.10.25. C지점으로 전근을 하였는데, 신청인이 관리점 변경을 하고 입금을 하여 다시 거래를 시작하였음.

(1) 임의매매 여부

담당직원이 주식을 위탁인인 고객의 동의 없이 매매한 경우에는 임의매매가 성립하고 이 경우 증권회사는 사용자배상책임을 지는 것이 원칙임. 또한 임의매매인지 여부에 대하여는 구체적 증거가 없는 경우가 많으므로 객관적으로 나타난 계약체결 당시의 권유 방법, 투자목적 내지 동기, 투자자의 거래경험, 거래원장상에 나타난 거래내역 등의 여러 정황을 종합하여 객관적이고 합리적으로 판단하여야 할 것임.

신청인은 2002년 거래 초기 D기업과 2004년 중반의 E기업, F기업 외에는 거의 본인이 알지 못하는 종목으로 신청인과의 사전협의 또는 사후보고 없이 담당직원이 임의로 매매를 하였다고 주장하나, 이를 입증할 만한 증거를 발견하기 어렵고, 오히려 입출금 내역서를 보면 신청인은 A지점 거래에서는 21개월 동안 약 200회, S지점 거래에서는 4개월 동안 약 18회에 걸쳐 입출금을 하고 있으며, 피신청인이 발송한 월별거래내역서의 일부 도달사실은 신청인도 인정하고 있어 신청인이 거래내역을 인지하고 있었던 것으로 보일 뿐만 아니라, A지점 거래기간 동안의 녹취록을 전반적으로 살펴보면, 신청인과 담당직원은 거래기간동안 내내 하루에 수차례씩(4회이상 통화) 있었는 날도 다수) 전화통화를 하여 신청인이 먼저 거래할 종목을 지정하거나 담당직원이 추천하는 종목을 신청인과 협의하여 매매종목으로 선택하였으며, 거래후에도 담당직원이 거래결과를 신청인에게 보고하고 있고, 신청인이 스스로 단타매매 종목에 대한 추천을 의뢰하거나, 담당직원으로부터 미수정리에 대한 보고를 받고 있음을 확인할 수 있어, A지점에서의 거래는 신청인과의 협의에 의한 매매로 보아야 할 것이고, C지점 거래기간 동안의 녹취록을 살펴보면, 신청인과 담당직원은 여전히 하루에 수차례씩 전화통화를 하여 매매종목에 대한 협의를 하고, 거래후 담당직원이 보고를 하고 있는 것을 확인할 수 있어 C지점에서의 거래도 신청인과의 협의에 의한 매매로 보아야 할 것임.

(2) 고객보호의무(충실의무) 위반으로 인한 손해배상책임 성립 여부

증권회사가 고객과 포괄적 일임매매 약정을 하였음을 기화로 그 직원이 충실의무를 위반하여 고객의 이익을 무시하고 회사의 영업실적만을 증대시키기 위하여 무리하게 빈번한 회전매매를 함으로써 고객에게 손해를 입힌 경우에는 과당매매행위로서 불법행위

가 성립됨.

증권회사의 직원이 과당매매행위를 한 것인지의 여부는 고객 계좌에 대한 증권회사의 지배여부, 주식매매의 동기 및 경위, 매매주식 중 단기매매가 차지하는 비율, 운용액 및 운용기간에 비추어 본 수수료액의 과다 여부 등 제반 사정을 참작하여 주식매매의 반복이 전문가로서의 합리적인 선택이라고 볼 수 있는지 여부를 기준으로 판단하여야 함.

A지점 매매거래내역을 살펴보면, 거래기간 평균 매매회전율이 1,863%, 손실금액 대비 수수료율이 31.59%, 미수금 발생율이 1,035.35%로 지표상으로는 과당매매로 볼 여지가 있으나, 위에서 살펴본 바와 같이 빈번한 단타매매나 미수거래가 신청인의 투자성향에 따라 협의에 의하여 행해진 것인 이상 담당직원의 고객보호의무 위반에 따른 것으로 볼 수 없다 할 것이며, C지점 매매거래 내역상으로도 거래기간 평균 매매회전율이 5,214%, 손실금액 대비 수수료율이 91.90%, 미수금 발생율이 1,135.65%로 지표상 과도하기는 하나, 신청인과의 협의에 의해 매매를 행한 이상 담당직원의 고객보호의무 위반에 따른 것으로 볼 수 없다 할 것임.

라. 결 론

그렇다면 피신청인은 신청인에 대하여 배상할 책임이 없다 할 것이므로 신청인의 청구는 모두 이유 없어 이를 기각함.

3-9 타인명의 금융투자상품 거래가 무권대리로서 무효인지 여부

[기각] 피신청인은 신청인의 남편명의 금융투자상품 거래는 그 권한을 위임받은 거래이므로 무권대리에 해당하지 않는다고 주장하나, 본인이 뇌병변 상태에서 유효한 의사로 처에게 대리권 수여의사를 표시했다고 보기 어려운 점, 처가 남편의 인감이나 비밀번호를 입수하는 것은 비교적 용이하고, 더욱이 담당직원 또한 병의 병세를 알고 있는 상태에서 거래가 이루어졌으며 신청인이 계좌개설시 비밀번호를 설정하고 상품을 가입하는 등 신청인의 금융투자상품 거래가 무권대리가 아니라고 단정하기 어렵다 할 것임. 그러나 남편명의 금융투자상품 거래가 무권대리로서 무효라고 하여도 신청인이 무권대리를 한 당사자로서 책임이 있고(민법 제135

조), 남편 사망 후 신청인들이 별다른 이의제기 없이 남편 명의로 가입된 금융상품을 상속한 사실이 확인되어 신청인들이 무권대리 행위를 추인한 것으로 인정할 여지가 있는 점 등을 고려하면 피신청인의 책임을 인정하기는 어려움.(2011.4.12. 조정번호 제2011-25호)

가. 사실관계

신청외 망(亡) A씨⁵⁰³)는 1993년경부터 피신청인과 금융투자상품 거래를 시작하였고 피신청인 직원(이하 “담당직원” 이라 함)이 1998년경부터 A씨의 담당자로 이를 관리하여 왔으며, 2001.10월 A씨는 뇌병변으로 의사소통이 어려운 채 병원에 장기입원을 반복하다 2009.8.6.에 사망하였음.

A씨의 뇌병변 발병 후 사망시 까지의 기간중, A씨의 배우자인 신청인 B씨는 A씨 명의로 2008.5.23. ◇◇파생상품 1호⁵⁰⁴)에 가입한 것을 비롯하여 A씨 명의로 종합계좌를 개설하고 다수의 금융상품에도 가입함.(◇◇파생상품 1호의 손실을 포함하여 총 투자손익은 +189,742,104원임).

2009.8.24. 신청인들, A씨의 사망을 원인으로 A씨 명의로 가입된 금융투자 상품을 신청인 명의로 상속재산 명의변경 후 상속함.

나. 당사자의 주장

(1) 신청인의 주장

“◇◇파생상품 1호” 가입 등 신청인에 의한 A씨 명의의 금융투자상품 거래는 대리권 없이 이루어진 무권대리 행위로서 무효임.

(2) 피신청인의 주장

503) 신청인들은 A씨의 상속인들로, 신청인 B씨는 A씨의 배우자, 기타 신청인들은 A씨와 전(前) 배우자 사이의 자녀들임.

504) 기초자산 : A지수, B지수, C지수 / 신탁계약기간 : 1년(매3개월 단위로 조기상환기회 부여) / 투자위험등급 : 1등급(원금손실 위험을 감수하며 고수익을 추구하는 투자자에게 적합), 손익내역 : 61,187,947원 손실

A씨는 뇌병변 발병 전 영업점 내방시 갑과 동행하여 거래를 하였고, 2001년 담당직원이 A씨의 병실을 방문하여 앞으로 거래를 신청인이 대신하여도 되겠는지 묻자 A씨가 고개를 끄덕여 동의한 바 있으며, 본건 거래들은 신청인 B씨로부터 병의 주민등록증, 인감, 비밀번호 등을 징구하여 거래를 한 것으로 B씨가 A씨로부터 정당하게 권한을 위임받아 이루어진 거래이고 무권대리가 아님.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 신청인 B씨에 의한 남편 명의의 금융투자상품 거래가 무권대리에 해당하는지 여부 및 그에 따른 피신청인의 원상회복의무 인정여부라 할 것임.

(1) 무권대리 해당여부

피신청인은 신청인에 의한 A씨 명의의 금융투자상품 거래는 A씨의 권한을 위임받은 거래이므로 무권대리에 해당하지 않는다고 주장하나, 다음과 같은 점에 비추어 신청인 갑의 금융투자상품 거래를 무권대리가 아니라고 단정하기 어렵다 할 것임.

① 대리가 적법하게 성립하기 위해서는 대리행위를 한 자, 즉 대리인이 본인을 대리할 권한을 가지고 그 대리권의 범위 내에서 법률행위를 하였음을 요하며, 부부의 경우에도 일상 가사가 아닌 법률행위를 배우자가 대리하여 행함에 있어서는 별도의 대리권을 수여하는 수권행위가 필요하며 부부의 일방이 의식불명 상태에 있어 사회통념상 대리관계를 인정할 필요가 있다는 사정만으로 그 배우자가 당연히 모든 법률행위에 관하여 대리권을 갖는다고 볼 것은 아니라 할 것임 점.⁵⁰⁵⁾

② 피신청인은 담당직원이 A씨의 병실을 방문하여 앞으로 거래를 신청인이 대신하여도 되겠는지 묻자 A씨가 고개를 끄덕여 동의한 바 있다고 주장하나, 위와 같은 주장만으로 A씨가 뇌병변으로 입원한 상태에서 유효한 의사⁵⁰⁶⁾를 가지고 신청인에게 대리권 수여의사를 표시했다고 보기 어렵고, 달리 신청인에게 대리권을 수여했다고 볼 객관적 자료를 찾기 어려운 점.

505) 대법원 2000.12.8. 선고 99다37856판결 참조.

506) 2001.10.11. 병의 뇌병변을 이유로 △△△병원에서 장애1급 진단을 받음.

③ 피신청인은 신청인으로부터 A씨의 인감과 비밀번호 등을 징구하였다고 주장하나, 처가 남편의 인감이나 비밀번호를 입수하는 것은 비교적 용이하다 할 것이어서 위와 같은 사정만으로 대리권이 존재한다고 믿을 만한 정당한 사유가 있다고 단정하기 어렵다 할 뿐만 아니라,⁵⁰⁷⁾ 더욱이 본건의 경우, 담당직원 또한 A씨의 병세를 알고 있는 상태에서 신청인에 의한 A씨 명의 거래가 이루어졌으며 B씨가 종합계좌 개설시 비밀번호를 설정한 후, 이에 따라 상품가입이 이루어진 사실이 있는 점 등에 비추어 B씨가 A씨를 대리할 권한이 있었다고 믿을 만한 정당한 사정이 있다고 보기 어려운 점.

④ 또한 신청인 B씨가 A씨의 배우자로 일상가사대리권이 있다 하더라도, 일상가사 대리권은 부부가 공동체로서 가정생활상 행하여지는 행위를 말하므로 B씨의 본건 금융투자상품 거래가 일상가사대리권의 범위에 속한다고 보기도 어려운 점.

(2) 피신청인의 원상회복의무 인정여부

다만, 신청인 B씨의 A씨 명의 금융투자상품 거래가 무권대리로서 무효의 법률행위에 해당한다 할지라도 다음과 같은 점에 비추어 피신청인의 책임을 인정하기는 어렵다고 판단됨.

① 우선 신청인의 경우, 무권대리를 한 당사자로서 책임이 있을 뿐만 아니라(민법 제 135조) 무권대리인이 본인인 A씨를 상속한 경우에 해당한다 할 것이어서 본인이 한 무권대리 행위의 무효를 주장하는 것은 금반언의 원칙이나 신의칙에 반한다고 보이는 점.⁵⁰⁸⁾

② 무권대리 행위 또는 무효행위의 추인은 무효행위 등이 있음을 알고 그 행위의 효과를 자기에게 귀속시키는 단독행위로서 일정한 방식이 요구되지 않고 묵시적으로도 가능하다 할 것인 바, A씨의 사망 후, 2009.8.24. 신청인들이 피신청인에게 별다른 이의제기 없이 A씨 명의로 가입된 금융상품을 신청인 명의로 상속재산 명의변경을 신청하고 이를 상속한 사실이 확인되는 바, 이에 비추어 신청인들이 무권대리 행위를 추인한 것으로 인정할 여지가 크다고 보이는 점.

507) 대법원 1998.7.10. 선고 98다18988 판결 참조.

508) 대법원 1994.9.27. 선고 94다20617 판결 참조.

③ 나아가, 신청인 B씨의 A씨 명의 금융투자상품 거래를 무권대리로 인한 무효인 법률행위로 보아 피신청인의 책임을 인정하는 경우, 피신청인은 이에 따른 원상회복의무를 부담한다 할 것인데, A씨의 입원이후 사망시까지 신청인 B씨에 의한 A씨 명의의 전체 금융투자상품 거래로 오히려 +189,742,104원의 이익이 발생하고 있어 피신청인의 원상회복의무를 인정하기 어려운 점.

라. 결 론

그렇다면 신청인 B씨에 의한 A씨 명의의 금융투자상품 거래를 무권대리로서 무효라고 보더라도 피신청인의 원상회복책임을 인정하기 어렵다 할 것이므로 신청인의 청구는 이유 없다 할 것임.

3-10

포괄적 일임을 받은 증권사 직원이 퇴사한 이후 다른 직원을 통해 주식매매 주문을 한 경우 임의매매에 해당하는지 여부

[기각] 신청인은 피신청인 직원에게 주식매매를 해줄 것을 부탁하며 공인인증서, 계좌 비밀번호 등을 알려주었고 해당직원은 이를 이용하여 주식거래를 하였으나, 퇴사 이후에도 신청인의 신규 계좌관리 직원에게 해당직원이 주식매매 주문을 지시하였으며 계좌관리 직원은 이를 그대로 이행한 사안에 대하여, 퇴사 이후에는 신청인과 피신청인 직원 사이의 묵시적 포괄적 일임관계가 인정되지 않으나 신청인이 임의매매를 묵시적으로 추인한 것으로 판단한 사례(2017.7.11. 조정번호 제2017-13호)

가. 사실관계

(1) 신청인은 2011.3.18. 피신청인 모지점에서 위탁계좌를 개설하고 3억원을 입금하였으며, 피신청인 직원 장○○가 신청인 계좌의 관리직원으로 등록되었다. 한편, 신청인과 장○○는 군대 선후배 관계로 계좌개설 이전부터 잘 알고 지내던 사이였다.

(2) 신청인은 위탁계좌 개설 이후 2011.4.12. 피신청인 모지점에 내방하여 HTS 거래를 위해 전자금융거래를 신청하면서 장○○에게 공인인증서, 계좌 비밀번호 및 개인정보 등

을 알려주었고, 장○○는 이를 이용하여 2011.4.14. ~ 2012.11.23. 기간 동안 총 20개 종목에 대하여 372회 주식거래(매수 199회, 매도 173회)를 진행하였으며, 거래 직후 해당 거래내역이 SMS 문자를 통해 신청인에게 통보되었다. 또한 월 또는 반기 단위로 매매 거래 내역 및 계좌 잔고, 손익 현황 등이 신청인의 주소지로 우편 발송된 사실이 있다.

(3) 한편, 장○○는 2012.12.31. 피신청인 회사를 퇴사하였고, 2013.3.20. 피신청인의 다른 직원 노○○가 신청인 계좌의 관리직원으로 지정되었다.

(4) 장○○는 퇴사 이후인 2013.2.18., 2013.2.20. 피신청인 소속 직원 노○○에게 전화 하여 신청인 계좌의 H산업 주식을 매도한 후 C인터넷셔널 주식(10,000주, 6,250만원)을 매수토록 지시하였고, 노○○는 이를 그대로 이행하였다. 이 과정에서 노○○는 신청인에게 매매주문 지시 여부 내지 일임 의사를 확인한 사실은 없으나, 거래직후 해당 거래 내역이 SMS 문자를 통해 신청인에게 통보되었다.

(5) 신청인은 현재까지 C인터넷셔널 주식을 보유하고 있으나, 2015.5.6 해당 주식이 상장폐지됨에 따라 현재 신청인 보유 C인터넷셔널 주식의 평가금액은 0원이다.

나. 당사자 주장

신청인은 본인이 새로운 계좌 관리직원인 노○○와 주식거래에 관한 어떠한 일임약정을 한 적이 없음에도 노○○가 이미 퇴사한 장○○의 지시에 따라 C인터넷셔널 주식을 임의로 매매하여 손실이 발생하였으므로 피신청인이 이를 배상할 의무가 있다고 주장한다.⁵⁰⁹⁾

이에 대하여 피신청인은 신청인과 장○○ 사이에 개인적 친분 관계에 기한 포괄적 일임약정이 있었으며, 이로 인하여 신청인 계좌의 매매는 장○○가 신청인으로부터 개별적인 주문지시를 받거나 신청인의 묵시적 일임에 따른 것으로 임의매매로 보기 어렵고, 이는 장○○가 퇴사한 이후에도 마찬가지이므로 노○○가 신청인과 묵시적 일임관계에 있는 퇴사한 장○○의 지시에 따라 본건 C인터넷셔널 주식을 매수한 것도 임의매매로 볼

509) 신청인은 장○○의 퇴사 이전에 이루어진 거래도 임의매매라고 주장하고 있으나, 이하 설시와 같은 이유로 장○○의 퇴사 이전에는 양자간 묵시적 포괄적 일임약정이 존재함이 비교적 명백한바, 임의매매 여부는 장○○의 퇴사 이후 거래를 중심으로 살펴보기로 한다.

수 없다고 주장하여 서로 다툰다.

다. 위원회 판단

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 ‘자본시장법’이라 한다)」, 신청인의 분쟁 조정 신청서류 및 피신청인의 제출자료 등 관련자료 일체를 종합하여 먼저 임의매매 해당 여부에 대하여 살펴보면,

원칙적으로 투자자나 그 대리인으로부터 금융투자상품의 매매의 청약 또는 주문을 받지 아니하고는 투자자로부터 예약받은 재산으로 금융투자상품의 매매를 하여서는 아니 되는데(자본시장법 제70조, 임의매매의 금지), 해당 주식거래가 고객의 주문이 없는데도 직원이 임의로 주식거래를 한 임의매매인지 아니면 고객이 직원에게 주식의 종목, 수량 및 가격 등에 관한 결정을 위임하여 고객의 계산으로 주식거래를 한 일임매매인지를 판단하기 위해서는 주식계좌의 개설 경위, 고객이 담당직원을 계좌 관리자로 지정한 경위, 임의매매라고 주장하는 주식거래 행태 및 고객의 인지여부와 태도, 문제의 거래를 알고 난 후 고객이 취한 행동 등 임의매매라고 주장하는 거래 전후의 모든 사정을 종합적으로 고려하여야 한다(광주고등법원 2016.3.31. 선고 2014나3004판결 등 참조).

본건의 경우① 신청인이 계좌개설 이후 장○○에게 공인인증서, 계좌 비밀번호 및 개인정보 등을 알려준 점, ② 평소 신청인 계좌의 주식거래 내역은 거래직후 SMS 문자를 통해 신청인에게 통보되었고, 월간 거래 및 잔고내역, 손익현황 등이 신청인의 주소로 월 또는 반기별 총 9회 우편으로 통보되었으며, 별도로 반송된 사실이 없었던 점, ③ 신청인과 장○○의 유선통화 녹취파일 등에 의할 때 신청인이 주식매매 상황을 전혀 모르고 있었다고 보기는 어려운 점⁵¹⁰⁾ 등을 고려하면 장○○ 퇴사 이전까지는 신청인과 장○○ 사이에 묵시적 포괄적 일임매매 약정이 일응 존재한다고 볼 여지는 있다.

510) 2011.4.26. 신청인은 장○○과의 통화에서 “**주식은 왜 확 떨어졌어?”라고 묻자, 장○○은 “이유가 있다, 히스토리가 있으니 걱정말고 있어라” 라고 대답하였으며, 이에 신청인은 “예”라고 말하고 통화를 종료하였다. 또한, 금감원 분쟁조정신청 후인 2016.1.14. 신청인은 피신청인측 민원담당자와의 통화에서 매월 우편으로 발송된 주식거래 내역과 계좌 잔고현황을 받은 적이 있으며, 이를 통해 장○○의 매매사실은 알고 있었다는 취지로 이야기한 사실이 있다.

그러나, ① 신청인이 장○○가 재직중이던 모지점에서 주식매매 위탁계좌를 개설하고, 장○○를 계좌 관리직원으로 등록한 사실 등에 비추어 볼 때, 주식매매에 관한 양자간 포괄적 일임관계는 단순한 군대 선후배 사이라는 개인적 친분관계에 기인한 것이 아니라 고객과 주식매매에 관한 경험이 풍부한 증권회사 직원으로서 그 직무상 신임관계에 기초하였다고 봄이 상당한 점, ② 증권회사 직원이 퇴사 이후에도 별도의 약정 없이 개인적인 지위에서 관리 고객을 대리하여 제3자에게 주식매매 주문을 지시할 권한이 있다고 보기는 힘든 점, ③ 신청인은 장○○ 퇴사 이전에 장○○와의 사이에 성립된 포괄적 일임관계를 노○○가 승계하도록 하는 별도의 의사표시를 한 사실이 없는 점, ④ 자본시장법에서 엄격하게 금지하고 있는 묵시적 포괄적 일임약정의 존재는 한정적으로 해석하는 것이 타당한 점 등을 고려할 때, 신청인과 장○○ 사이의 묵시적 포괄적 일임관계는 장○○의 퇴사로 인하여 종료된 것으로 봄이 타당하다. 따라서 노○○가 장○○의 지시로 C인터넷서날 주식을 매수한 것은 권한 없는 자로부터 주식매수 주문을 받고 이를 그대로 이행한 것으로 임의매매에 해당하는 것으로 판단된다.

다만, 임의매매의 경우에도 사후에 추인이 있는 경우 그 법률효과는 모두 고객에게 귀속되고, 그 임의매매행위는 불법행위를 구성하지 않게 되는 바, 대법원은 “무권대리행위는 그 효력이 불확정 상태에 있다가 본인의 추인 유무에 따라 본인에 대한 효력발생 여부가 결정되는 것으로서, 추인은 무권대리행위가 있음을 알고 그 행위의 효과를 자기에 귀속시키도록 하는 단독행위인바, 증권회사의 고객이 그 직원의 임의매매를 묵시적으로 추인하였다고 하기 위하여는 자신이 처한 법적 지위를 충분히 이해하고 진의에 기하여 당해 매매의 손실이 자기에 귀속된다는 것을 승인하는 것으로 볼 만한 사정이 있어야 할 것이고, 나아가 임의매매를 사후에 추인한 것으로 보게 되면 그 법률효과는 모두 고객에게 귀속되고 그 임의매매행위가 불법행위를 구성하지 않게 되어 임의매매로 인한 손해배상청구도 할 수 없게 되므로, 임의매매의 추인, 특히 묵시적 추인을 인정하려면, 고객이 임의매매 사실을 알고도 이의를 제기하지 않고 방치하였는지 여부, 임의매수에 대해 항의하면서 곧바로 매도를 요구하였는지 아니면 직원의 설득을 받아들이는 등으로 주가가 상승하기를 기다렸는지, 임의매도로 계좌에 입금된 그 증권의 매도대금을 인출하였는지 또는 신용으로 임의매수한 경우 그에 따른 그 미수금을 이의 없이 변제하

거나, 미수금 변제독촉에 이의를 제기하지 않았는지 여부 등의 여러 사정을 종합적으로 검토하여 신중하게 판단하여야 한다”고 판시한 바 있다(대법원 2003.12.26. 선고 2003다 49542 판결 등 참조).

이 사건의 경우, ① 장○○가 퇴사(2012.12.31.)한 이후 피신청인은 장○○가 관리하던 고객을 대상으로 장○○의 퇴사 사실 및 고객의 현재 계좌 잔고를 통보한 사실이 있는 점, ② 신청인은 장○○의 퇴사 사실을 알고 있었음에도 장○○에 대하여 공인인증서 회수 또는 계좌 비밀번호 변경 등의 조치를 전혀 취하지 않았던 점, ③ 노○○가 C인터넷서날 주식을 매수한 내역도 거래직후 신청인에게 SMS 문자로 통보되었고, 월간 거래 및 잔고내역, 손익현황 등이 신청인의 주소로 월 또는 반기별 총 14회 우편으로 통보된 사실이 있음에도 신청인은 약 1년 6개월 이상 이를 방치하고 피신청인에게 별도의 이의를 제기한 사실이 없는 점 등을 종합적으로 고려할 때, 신청인은 이 사건 노○○의 임의매매를 사후에 추인한 것으로 봄이 상당하다고 할 것이다.

이에 대해 조정위원회 소수의견은 신청인과 장○○ 사이의 묵시적 포괄적 일임약정은 개인적 신임관계에 기초한 것으로, 신청인이 장○○의 퇴사사실을 알고 있었음에도 장○○에 대한 수권행위를 철회하지 않았음은 물론 공인인증서 회수 또는 계좌 비밀번호 변경 등의 조치를 전혀 취하지 않았던 점, 노○○가 C인터넷서날 주식을 매수한 내역도 거래직후 신청인에게 SMS 문자로 통보된 사실이 있음에도 신청인은 피신청인에게 별도의 이의를 제기한 사실이 없는 점 등에 비추어 볼 때, 신청인과 장○○ 사이의 묵시적 포괄적 일임매매 약정은 장○○가 퇴사한 이후에도 여전히 유지된 것으로 보아 노○○가 신청인을 대리하여 매매주문을 지시할 권한 있는 장○○의 지시로 C인터넷서날 주식을 매수한 것은 임의매매로 보기 어렵다는 의견을 피력한 바 있다.

다음으로 과당매매 해당 여부에 대하여 살펴본다.

포괄적 일임약정이 있는 경우에도 이를 기화로 직원이 충실의무를 위반하여 고객의 이익을 등한시하고 무리하게 빈번한 회전매매를 함으로써 고객에게 손해를 입힌 경우에는 과당매매행위로서 불법행위⁵¹¹⁾가 성립한다. 이 때 직원이 충실의무를 위반하여 과당매

매행위를 한 것인지의 여부는 고객 계좌에 대한 증권회사의 지배 여부, 주식매매의 동기 및 경위, 거래기간과 매매횟수 및 양자의 비율, 매입주식의 평균적 보유기간, 매매주식 중 단기매매가 차지하는 비율, 동일 주식의 매입·매도를 반복한 것인지의 여부, 수수료 등 비용을 공제한 후의 이익 여부, 운용액 및 운용기간에 비추어 본 수수료액의 과다 여부, 손해액에서 수수료가 차지하는 비율, 단기매매가 많이 이루어져야 할 특별한 사정이 있는지의 여부 등 제반 사정을 참작하여 주식매매의 반복이 전문가로서의 합리적인 선택이라고 볼 수 있는지 여부를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2007.4.12. 선고 2004다 4980 판결 등 참조).

이 사건의 경우, ① 2011.4.14. ~ 2013.3.22. 기간동안 신청인의 본건 위탁계좌에서는 총 378회(월평균 16회)의 매매거래가 있었는데 거래종목은 총 20개에 불과하고, 동일한 종목을 같은 날 분할하여 거래한 것이 많은 등 이를 과도하게 빈번한 거래라고 보기는 힘든 점, ② 신청인의 전체 손실금(290,813,405원) 가운데 거래 수수료(13,240,600원)가 차지하는 비율이 4.6% 수준에 그치는 점, ③ 해당 기간 중 월평균 예탁자산 대비 수수료를 이 최대 2%를 초과한 적이 없는 점, ④ 월평균 매매회전율이 67%⁵¹²⁾에 불과한 점 등을 종합적으로 고려해 볼 때, 장○○가 신청인의 이익을 무시하고 피신청인의 영업 실적만을 위하여 무리하게 회전매매를 한 것으로 볼 수는 없다 할 것이다.

511) 舊 증권거래법 제107조를 위반한 포괄적 일임약정의 사법상 효력과 관련하여 고객에 의하여 매매를 위임하는 의사표시가 된 것이 분명한 이상 그 사법상 효력을 부인할 이유가 없고, 만일 그 효력을 부인할 경우 거래상대방과의 사이에서 법적 안정성을 해하는 부당한 결과를 초래하므로 일임매매에 관한 증권거래법 제107조 위반의 약정도 사법상으로는 유효하다는 것이 대법원(2002.3.29. 선고 2001다49128 판결 등 참조)의 견해이다. 이에 대하여 자본시장법상 포괄적 일임금지 규정을 위반한 경우에는 이를 무효로 봐야한다는 견해가 있으나, 자본시장법 시행 이후에도 포괄적 일임금지 규정을 위반한 일임약정의 사법상 효력을 인정하는 전제하에서 과당매매의 불법행위 성립여부를 판단한 하급심 판례(서울남부지법 2013.7.12. 선고 2012가합8476 판결 참조)가 있다.

512) 2011.4월~2013.3월까지의 월평균 매매회전율[(매매거래대금/2)/예탁자산평균잔*100]의 단순평균 값이며, 분쟁조정 실무상 과당매매의 계량적 판단기준으로는 월평균 매매회전율(400% 초과), 손실금액대비 수수료율(40% 초과), 월평균 예탁자산 대비 수수료율(4% 초과) 등이 있다.

라. 결론

그렇다면, 피신청인은 신청인에 대하여 배상할 책임이 없다 할 것이므로 신청인의 청구는 이유없어 주문과 같이 결정한다.

4-1 매매거래를 일임하였으나 과도한 매매거래로 손해를 본 경우

[일부인용] 일임매매는 원칙적으로 손해배상책임이 발생하지 아니하나 위임의 내용, 투자 목적, 투자자금의 성격 및 매매거래양태 등을 종합적으로 고려할 때 일임의 본질을 일탈하여 과도하게 매매거래하여 선량한 관리자로서의 주의의무를 다하지 아니하는 경우에는 부분적으로 손해배상책임을 인정하고 있음. 그러나 손해배상금액은 고객의 과실비율을 반영하여 산정한 금액과 증권회사 수탁수수료 중 작은 금액으로 한정함.(1999.7.20. 조정번호 제1999-27호)

가. 사실관계

신청인은 1998.1.8. ○○증권사(이하 “피신청인”이라 함)의 영업부에 위탁계좌를 개설하면서 직원에게 주식매매를 일임하였고, 단기간에 550백만원의 매매수익이 발생하였음. 같은 해 3.23. 신청인은 550백만원을 출금하여 이중 100백만원을 직원에게 수고비로 교부하였고, 그 후 주가하락으로 손실을 보게 되자 같은 해 11.30. 위탁계좌 잔고를 출금하고 거래를 종결함.

나. 당사자의 주장

(1) 신청인의 주장

직원에게 매매를 일임하였으나 직원은 고객이익을 무시하고 회사의 수수료수입 증대만을 위해 비정상적으로 거래하여 8억원 이상의 손해가 발생하였으므로 동 결과로 인하여 발생한 회사의 수수료수입 및 거래세 등 거래비용 금 497,976,169원을 반환하여야 함.

(2) 피신청인의 주장

직원이 고객의 일임에 따라 매매거래를 체결하여 단기간에 550백만원의 매매수익을

실현하고 신청인에게 출금을 권유하였고, 이에 따라 신청인은 1998.3.23. 동 금액을 출금하였음. 그 후 주가가 장기간 조정을 받으면서 매매시마다 큰 손실이 발생하자 동 매매손실을 줄이기 위하여 직원은 단기매매에 치중하게 되었고, 신청인은 수시로 유선 등을 통하여 주식상황 및 잔고를 직접 확인하였으며 매월 거래내역도 이상 없이 통보되었음.

또한 신청인은 매매이익이 실현되었을 때에는 모든 거래내역을 전면 수용하였으면서도 매매손실이 발생되었을 때에는 회사가 영업실적을 올리기 위하여 의도적으로 신청인에게 손실을 발생시키는 비정상적인 매매주문을 하였다고 주장하나 신청인의 이와 같은 주장은 논리적 타당성이 없음.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 신청인 계좌의 거래가 과도한 일임매매에 해당하는지 여부 및 그에 해당할 경우의 피신청인의 손해배상 범위라 할 것임

(1) 과도한 일임매매로 볼 수 있는지 여부

일임매매는 원칙적으로 손해배상책임이 발생하지 아니하나 위임의 내용, 투자목적, 투자자금의 성격 및 매매거래양태 등을 종합적으로 고려할 때 일임의 본질을 일탈하여 과도하게 매매거래하여 선량한 관리자로서의 주의의무를 다하지 아니하는 경우에는 부분적으로 손해배상책임을 인정하고 있음.⁵¹³⁾

신청인과 직원에 대한 문답조사, 신청인 계좌의 거래내역서 조사 등을 실시한 결과 신청인계좌에서의 매매거래는 신청인으로부터 매매권한을 수여 받은 직원의 일임매매로 판단되며, 일임으로 인한 투자수익의 결과는 신청인에게 귀속하는 것이 타당한 것으로 보여짐. 또한 신청인계좌에서의 매매거래내역을 보면 일임매매 기간중(1998.1월~11월)의 월평균 매매회전율이 12.1회에 달하고 손해금액 대비 거래비용비율도 439%에 이르는 등 과도한 일임매매로 인정되며 이로 인하여 발생한 손해에 대하여는 피신청인에게 배상책임이 있다고 판단됨.

513) 서울고등법원 1997.8.28. 선고 96나5911 판결.

(2) 손해배상금액의 산정기준

신청인은 800백만원 이상의 매매손실을 보았다고 주장하나 아래 방법으로 산정한 실제 손해금액은 신청인이 계좌 개설후 투자한 금액 1,025,878,243원에서 출금된 909,128,142원을 차감한 116,750,101원임. 과도한 일임매매로 인한 손해배상금액을 산정함에 있어서는 투자기간 동안의 전반적인 주가수준을 감안하고 피신청인이 획득한 수탁수수료 수입을 초과하지 않는 범위내에서 결정되는 것이 합리적이므로 손해배상금액은 58,375,051⁵¹⁴⁾원으로 하는 것이 타당함.

라. 결 론

직원이 위임의 본지를 일탈하여 수수료 수입을 증대시킬 목적으로 과도하게 주식을 매매한 점이 인정되므로 피신청인은 이로 인하여 발생한 손해액중 58,375,051원을 신청인에게 지급하여야 함.

4-2 증권투자경험이 전혀 없는 고객에 대한 과다 일임매매 손해배상책임

[일부인용] 신청인의 남편은 증권투자경험이 전혀 없어 직원의 매매행태를 제대로 이해하였다고 보기 어렵고 직원 또한 이런 점을 알고 빈번히 매매거래를 하였다 판단되며, 동 기간중 월평균 매매회전율, 손해금액 대비 수수료비율, 미수금발생률 등 고려시 신청인의 위임 본지를 벗어나서 과도하게 일임매매를 한 것으로 판단됨. 한편, 신청인의 남편은 직원에게 매매거래를 포괄적으로 일임하고 피신청인 지점에서 1년 가까이 상주하다시피 하면서도 직원의 매매거래를 방치함으로써 손해가 확대되었는 바, 자기재산 관리소홀에 따른 과실이 있으므로 동 과실을 참작하여 손해금액을 산정함.(2000.11.28. 조정번호 제2000-52호)

- 514) ○ 실제손해금액(A) : 116,750,101원
○ 종합주가지수하락률(B) : 0%(기간중 종합주가지수는 414P에서 447P로 상승)
○ 지수하락률감안 손해금액(C) : 116,750,101원
○ 과실상계 50%(D) : 58,375,051원
○ 수탁수수료(E) : 392,159,080원
○ 손해배상금액 : D와 E중 작은 금액(58,375,051원)

가. 사실관계

1998.12.8. 신청인은 ○○증권사(이하 “피신청인”이라 함)의 지점에 위탁계좌를 개설한 후 1999.4.29.까지는 본인이 직접 매매거래를 하였고, 4.30.에 남편과 함께 피신청인 지점에 방문하여 직원에게 남편과 협의하여 매매해 달라고 하였으며, 남편은 직원에게 알아서 매매해 달라고 함.

1999.4.30.~2000.3.21. 기간중 신청인의 남편은 당해 지점에 상주하다시피 하였고, 동 기간중 14,073,002원의 투자손실을 보았으며, 2000.3.22. 신청인이 피신청인의 지점에 방문하여 거래내역을 확인한 후 이날부터 본인이 직접 매매를 함. 이후 2000.6.16. 신청인은 1999.4.30.~2000.3.21. 기간중의 매매에 대하여 피신청인에게 이의제기를 함.

나. 당사자의 주장

(1) 신청인의 주장

1999.4.30. 남편과 함께 피신청인의 지점에 방문하여 직원에게 남편과 협의하여 매매해 달라고 하였지, 직원에게 매매거래를 일임한 것은 아님. 1999.4.30.~2000.3.21. 기간중 직원이 수수료 수입을 위하여 미수금까지 발생시키며 수수료 수입을 제외하면 손실이 발생하는 거래 등을 과다하게 함으로써 손해가 발생하였는 바, 피신청인은 이로 인한 손해를 배상하여야 함.

(2) 피신청인의 주장

신청인의 남편은 1999.4.30.~2000.3.21. 기간중 하루도 빠짐없이 지점에 상주하면서 빈번한 입출금거래를 하여 왔는 바, 이러한 상태에서 관련직원이 임의매매하였다는 신청인의 주장은 설득력이 없음. 또한 신청인은 상기 기간중의 매매가 과도하였다고 주장하나 신청인 남편이 지점에 상주하면서 순간 순간 변화하는 시세를 보면서 직원에게 매매주문을 하였을 것이라는 점, 매월 발송되는 거래내역 수령 후에도 신청인의 어떠한 이의 제기도 없었을 뿐더러 2000.4월 이후 신청인 또한 신청인 남편과 같이 Day-Trading 위주의 거래행태를 보인다는 점 등에 비추어 1999.4.30.~2000.3.21. 기간중의 매매는 정상 매매라고 판단되는 바, 신청인의 요구를 수용할 수 없음.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 신청인 계좌의 거래가 과도한 일임매매에 해당하는지 여부 및 그에 해당할 경우의 피신청인의 손해배상 범위라 할 것임.

(1) 1999.4.30.~2000.3.21. 기간중 매매가 일임매매에 해당하는지 여부

신청인은 직원에게 남편과 협의해서 매매하라고 하였지 일임한 적은 없다고 주장하나, 아래와 같은 점에 비추어 보았을 때 상기 기간중의 매매는 일임매매라고 판단됨.

- ① 일임약정이 없다 할지라도 “알아서 매매해 달라”는 말 자체가 포괄적인 일임인 점.
- ② 신청인의 남편이 1999.4.30.~2000.3.21. 기간중 지점에 상주하다시피 하였고, 동 기간중 빈번한 입출금거래가 있었던 점.
- ③ 상기 기간중의 거래내역이 매월 발송되어 반송되지 않은 점.

(2) 1999.4.30.~2000.3.21. 기간중 매매가 과도일임매매에 해당하는지 여부

본건의 경우 신청인의 남편은 증권투자경험이 전혀 없어 직원의 매매행태를 제대로 이해하였다고 보기 어렵고, 직원 또한 이러한 점을 알고 매매거래를 빈번하게 하였다고 판단되며, 동 기간중 신청인 계좌에서의 매매거래내역을 살펴보면, 월평균 매매회전율이 57.2회, 손해금액 대비 수수료비율이 599%, 미수금발생률이 327%에 이르는 등 피신청인의 직원은 신청인의 위임 본지를 벗어나서 과도하게 일임매매를 한 것으로 판단됨.

(3) 손해배상금액의 산정기준

손해금액을 산정함에 있어서는 투자기간중 주식시장의 전반적인 주가수준을 감안하여 야 하나 당해 기간중 종합주가지수는 752.59p에서 863.41p로 상승하였으므로 따로 손해금액에서 차감할 필요는 없음.

다만 신청인의 남편이 직원에게 매매거래를 포괄적으로 일임하고, 피신청인의 지점에서 1년 가까이 상주하다시피 하면서도 직원의 매매를 제지하지 아니한 사실이 인정되고, 신청인은 매매거래내역을 통지받은 후 충분하게 거래내역을 확인할 수 있었음에도 직원이 매매거래를 계속하도록 방치함으로써 손해금액이 확대되었는 바, 신청인에게는 자기

재산 관리소홀에 따른 과실이 있으므로 이러한 과실을 참작하되 그 과실비율을 70%로 하여 손해금액을 책정함이 타당하다 판단됨.

따라서 손해배상금액은 피신청인의 수탁수수료 수입을 한도로 하여 수탁수수료 84,319,730원과 70% 과실상계후의 손해금액 4,221,900원중 적은 금액인 금4,221,900원으로 정함이 타당한 것으로 판단됨.

라. 결 론

피신청인의 직원에 의한 과다일임매매사실이 인정되므로 피신청인은 이로 인하여 신청인이 입은 손해액중 금 4,221,900원을 지급하여야 함.

4-3 매매회전율은 다소 과다하나 고객이 거래내용을 충분히 인지한 경우

[기각] 일임매매의 경우에는 원칙적으로 매매거래에 따른 손익이 모두 투자자에게 귀속되는 것이나, 과다일임매매는 수탁수수료 수입을 높일 목적으로 발생한 결과라 평가되므로 증권회사에게 그 책임을 묻는 것이 타당함. 본건은 기간중 매매회전율이 다소 과다한 측면은 있으나 신청인의 손해가 직원이 약정실적을 증대시키기 위하여 매매거래를 빈번하게 함으로써 발생한 것이라고는 보기 어려운 점. 신청인이 수시로 직원과 통화하였고, 매월 거래내역이 발송되어 반송되지 아니한 사실에 비추어 신청인이 직원의 매매거래를 충분히 인지할 수 있었다는 점. 본건 매매형태가 비슷함에도 신청인은 이익이 발생한 기간에 대하여는 이의제기를 하지 않는 점 등에 비추어 신청인의 청구를 기각함.(2001.1.30. 조정번호 제2001-5호)

가. 사실관계

1999.4.19. 신청인은 ○○증권사(이하 “피신청인”이라 함)의 A지점에 5,000만원을 입금하면서 담당직원을 알게 되어 담당직원과 상의하여 주식매매를 함. 같은 달 30일 담당직원이 B기업 주식을 미수거래하자, 신청인은 미수거래를 하지 말 것을 지시하면서 1억 3천만원을 입금함.

1999.4.19~2000.1.4. 기간중 신청인은 302,959,559원을 순투자하여 2000.1.4.자 평가금액

은 503,955,713원이 되었고, 동 일자에 담당직원이 C지점으로 인사이동하자 신청인도 동 지점으로 계좌를 이관하였고, 담당직원은 2000.6.16.까지 신청인계좌를 통해 매매하여 동 일자 평가금액은 97,042,024원이 됨.

2000.7.24. 신청인은 담당직원에게 2000.1.4.부터의 매매거래로 인하여 발생한 손해에 대하여 이의제기를 함.

나. 당사자의 주장

(1) 신청인의 주장

2000.1월 담당직원에게 주식을 매매할 때에는 사전승인을 받을 것을 요구하였으나, 담당직원이 빈번한 매매와 미수거래를 함으로써 손해가 발생하였음.

(2) 피신청인의 주장

신청인과 담당직원과의 전화통화 녹음기록에 의하면, 신청인은 담당직원과 수시로 통화하면서 거래내역과 잔고상황에 대하여 상담한 사실과 고객이 수시로 계좌운용에 대하여 “알아서 하세요”라고 언급한 사실 및 직원이 단기매매에 대하여 고객과 협의하여 승낙을 득한 사실이 확인되고, 매월 발송하는 월간거래내역이 한 번도 반송된 사실이 없는 점 등에 비추어 담당직원이 신청인의 의사에 반하여 매매하였다고 보기 어려움.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 신청인 계좌의 거래가 과다한 일임매매에 해당하는지 여부 및 그에 해당할 경우의 피신청인의 손해배상 범위라 할 것임

일임매매 해당 여부와 과다일임매매 해당여부에 대하여 살펴보건대, 신청인은 직원에게 주식매매시 사전승인을 받고 매매할 것과 미수거래를 하지 말 것을 요구하였음에도 직원이 신청인의 의사를 일체무시하고 미수거래를 하는 등 과다하게 매매하였다고 주장하나, 아래와 같은 점에 비추어 보았을 때 본건 매매는 일임매매라고 판단됨.

① 금감원의 문답시 신청인이 매매를 담당직원에게 일임하였다고 시인한 점.

② 신청인이 미수거래를 하지 말라고 하였다고 하나 담당직원이 미수거래에 대하여 신청인에게 보고하였을 때 신청인이 아무런 이의제기를 하지 않은 사실이 인정되고, 1999.4.19.~2000.1.4. 기간중 2,056,806,880원의 미수거래가 있었음에도 신청인은 이의제기를 하지 않고 오히려 2000.1.4. 담당직원이 C지점으로 인사이동하자 신청인도 동 지점으로 계좌를 이관한 점.

일임매매의 경우에는 원칙적으로 매매거래에 따른 손익이 모두 투자자에게 귀속되는 것이나, 증권회사의 약정제고 위주의 경영풍토를 지양시키고 투자자를 보호하기 위하여 금감원 및 법원은 투자자의 이익을 무시한 채 증권회사의 수수료수입이나 직원개인의 약정실적을 증대시키기 위한 목적으로 빈번한 매매를 함으로써 발생한 손해에 대하여는 증권회사에게 사용자책임을 묻고 있음.

신청인은 직원이 과다하게 매매하였다고 주장하나 아래와 같은 점에 비추어 보았을 때 과다일임매매를 인정하기 곤란함.

① 기간중 매매회전율이 다소 과다한 측면은 있으나 신청인의 손해가 직원이 약정실적을 증대시키기 위하여 매매거래를 빈번하게 함으로써 발생한 것이라고는 보기 어려운 점(손해금액대비 수수료비율: 22.5%).

② 신청인이 수시로 직원과 통화하였고, 매월 거래내역이 발송되어 반송되지 아니한 사실에 비추어 신청인이 직원의 매매거래를 충분히 인지할 수 있었다는 점.

③ 1999.4.19.~2000.1.4. 기간중 매매와 2000.1.4.~6.16. 기간중 매매형태가 비슷함에도 신청인은 이익이 발생한 1999.4.19.~2000.1.4. 기간중 매매에 대하여는 이의제기를 하지 않고 손해가 발생한 2000.1.4.~6.16. 기간중 매매에 대하여만 이의제기를 하는 점.

라. 결 론

본건은 직원의 과다 일임매매를 인정하기 곤란하므로 신청인의 주장을 받아들일 수 없음.

4-4 과다 일임매매 인정 여부 및 손해배상금액 산정기준

[일부인용] 일임매매의 경우에는 원칙적으로 매매거래에 따른 손익이 모두 투자자에게 귀속 되는 것이나, 과다일임매매는 수탁수수료 수입을 높일 목적으로 발생한 결과라 평가되므로 증권회사에게 사용자책임을 묻고 있으며 손해배상금액의 산정은 수탁수수료의 범위 내로 한정하고 있음. 손해배상금액 산정에 있어서는 투자기간중 전반적인 주가수준을 감안하고, 손해금액에서 신청인의 과실비율만큼 상계한 후의 금액과 증권회사의 수탁수수료 수입과 비교하여 적은 금액을 손해배상금액으로 함이 합리적임.(2001.4.24. 조정번호 제2001-24호)

가. 사실관계

신청인 A씨는 1999.7.2. 피신청인 영업부에 위탁계좌를 개설하고 주식매매를 하던 중 2000.3.15. 지인으로부터 피신청인의 투자상담사(이하 “직원”이라 함)를 소개받아 매매거래를 직원에게 일임하였고, 직원은 2000.10.16까지 매매거래를 하였으며, 동 기간중 98,130,000원을 순투자하여 88,981,777원의 투자손실을 봄.

신청인 B씨는 2000.9.21. A씨의 소개로 피신청인 영업부에 위탁계좌를 개설한 후 직원에게 매매거래를 일임하였고, 직원은 2000.10.24까지 매매거래를 하였으며, 동 기간중 102,595,450원을 순투자하여 69,990,445원의 투자손실을 봄.

나. 당사자의 주장

(1) 신청인의 주장

(A씨의 주장) 직원의 부당권유로 매매거래를 일임하였고, 이후 계속적인 투자권유로 추가적으로 입금하였으나 직원의 과도한 매매거래로 손해금액이 확대되었는 바, 피신청인은 이로 인한 손해를 배상하여야 함.

(B씨의 주장) 직원이 자신을 통해 7억원을 투자한 사람이 40억원을 벌었다며 투자를 권유하여 매매거래를 일임하였으나 직원은 수수료 수입만을 위하여 과다하게 매매함으로써 손해가 발생하였는 바, 피신청인은 이로 인한 손해를 배상하여야 함.

(2) 피신청인의 주장

A씨는 직원에게 매매거래를 일임하고 수시로 방문하여 매매내역 등을 확인하였고, 2000.7월 하순경 당해계좌에 전액손실이 발생하였음에도 아무런 이의제기 없이 미수금 변제 후 계속적인 추가투자를 한 점 등에 비추어 볼 때, 본건 매매거래가 과다하게 이루어졌다 하더라도 이를 충분히 인지하였음에도 불구하고 방치하여 손실이 확대되도록 한 신청인의 과실이 상당함.

한편 B씨는 A씨가 직접 소개하였을 뿐만 아니라 동인과 사촌관계로 증권거래 현황을 공유하면서 함께 영업점을 수시로 방문하여 거래내역을 확인하였고, 당사 거래직전까지 타 증권사에서 직접매매를 하여 거액의 투자손실을 경험한 증권투자경력자이므로 신청인의 과실 또한 상당하다고 사료됨.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 신청인 계좌의 거래가 과다한 일임매매에 해당하는지 여부 및 그에 해당할 경우의 피신청인의 손해배상 범위라 할 것임.

과다일임매매 해당 여부와 손해배상금액의 산정기준에 대하여 살펴보건대, 일임매매의 경우에는 원칙적으로 매매거래에 따른 손익이 모두 투자자에게 귀속되는 것이나, 증권회사의 약정제고 위주의 경영풍토를 지양시키고 투자자를 보호하기 위하여 과도한 일임매매로 인하여 발생한 손해에 대하여는 증권회사에게 사용자책임을 묻고 있음.

본건의 경우 아래와 같은 점에 비추어 보았을 때 피신청인의 직원이 위임 본지를 벗어나서 과도하게 일임매매를 한 것으로 판단됨.

① A씨건의 경우 신청인이 자주 피신청인의 영업점에 방문한 사실은 있으나 직원의 매매행태를 제대로 이해하였다고 보기 어렵고, 직원은 손실을 보고 있으면서도 마치 이득을 보고 있는 것처럼 허위로 보고하였다고 판단되는 점.

② 직원은 신청인이 거의 매일 옆자리에 앉아 매매주문현황 및 그 손익일체를 확인하였다고 주장하나, 신청인이 직원에게 점심을 사주고, 보약을 선물하였으며, 2000.9월경 직원의 매매를 통해 수익이 났다며 B씨를 직원에게 소개한 점 등에 비추어 볼 때 직원의 말만 믿고 자신계좌에서 이득을 본 것으로 알았다는 신청인의 주장이 설득력이 있음.

며, 직원 또한 이러한 점을 알고 위임의 본지에 반하여 매매거래를 빈번⁵¹⁵⁾하게 하였다고 판단되는 점.

③ B씨의 경우 2000.9.21.부터 10.24.까지 약 1개월 동안의 기간중 매매회전율이 108.9회, 미수금발생률이 876%에 달하는 등 직원이 신청인의 위임 본지를 벗어나서 과도하게 매매⁵¹⁶⁾를 한 것으로 판단됨.

과다일임매매는 수탁수수료 수입을 높일 목적으로 발생한 결과라 평가되므로 손해배상금액의 산정은 수탁수수료의 범위내로 한정하고 있음. 따라서 손해배상금액을 산정함에 있어서는 투자기간중 주식시장의 전반적인 주가수준을 감안하고(손해금액에서 기간중 종합주가지수 하락률의 1/2을 손해금액에 곱한 금액을 차감함), 손해금액에서 신청인의 과실비율만큼 상제한 후의 금액과 증권회사의 수탁수수료 수입과 비교하여 적은 금액을 손해배상금액으로 함이 합리적임.

신청인중 A씨는 직원에게 매매거래를 포괄적으로 일임하였고, 피신청인의 지점에 자주 방문하고, 거래내역을 통지받았으면서도 직원의 말만 믿고 거래내역을 제대로 확인하지 못하였으며, 이로 인하여 직원이 매매거래를 계속하도록 함으로써 손해금액이 확대되도록 하였는 바, 신청인의 이러한 과실을 70%로 하여 산정한 금액과 수탁수수료중 적은 금액인 22,113,916원을 손해배상금액으로 산정하고, 신청인중 B씨는 타 증권회사에서 약 7개월동안 2억원을 주식투자하여 손실을 본 경험이 있음에도 불구하고 돈을 벌게 해준다는 직원의 말을 믿고 직원에게 매매거래를 포괄적으로 일임하였고, 피신청인의 지점에 자주 방문하면서도 직원이 돈을 벌었다는 말만 믿고 거래내역을 제대로 확인하지 못한 과실이 있는 바, 신청인의 이러한 과실을 70%로 하여 산정한 금액과 수탁수수료중 적은 금액인 20,099,809원을 손해배상금액으로 산정함.

라. 결 론

515) 기간중 신청인계좌의 월평균 매매회전율은 73.7회, 미수금발생률은 437%, 손해금액 대비 수수료비용은 36.3%에 달함.

516) 2000.3월부터 10월까지 직원이 관리하는 12계좌를 통하여 매월 수령한 실적성과급 중 이들 2명의 위탁계좌에서 발생한 성과급이 80%를 초과하고 있으며, 특히 9월 및 10월에는 그 비중이 99%, 99.5%에 달함.

피신청인의 직원에 의한 과다일임매매 사실이 인정되므로 피신청인은 이로 인하여 신청인들이 입은 손해액 중 금22,113,916원을 A씨에게, 금20,099,809원을 B씨에게 지급하여야 할 것으로 판단됨.

4-5 과당매매와 관련해 주식매매 반복이 전문가의 합리적 선택이었는지 여부

[일부인용] 과당매매 여부는 고객 계좌에 대한 증권회사의 지배 여부, 주식 매매의 동기 및 경위, 거래기간과 매매횟수 및 평균적 보유기간, 매매 주식 중 단기매매가 차지하는 비율, 수수료 등 비용을 공제한 후의 이익 여부, 운용액 및 운용기간에 비추어 본 수수료액의 과다 여부, 손해액에서 수수료가 차지하는 비율, 단기매매가 많이 이루어져야 할 특별한 사정이 있는지의 여부 등을 참작하여 주식 매매의 반복이 전문가로서의 합리적인 선택이라고 볼 수 있는지의 여부를 판단하여야 함. (2002.6.4. 조정번호 제2002-25호)

가. 사실관계

2000.2.10. 신청인은 ○○증권(이하 “피신청인”이라 함)의 A차장(이하 “담당직원”이라 함)을 운용자로 하는 주식의 일임매매계약을 체결하고 피신청인에게 위탁계좌를 개설하여 투자금 명목으로 150백만원을 입금하였으며, 같은 달 29일에 200백만원을 추가로 주식 일임매매의 투자금 명목으로 입금함.

담당직원은 2000.2.10~2001.2.28. 기간중 신청인의 투자금 350백만원을 거래소 종목과 KOSDAQ 종목에 투자하였으나, 주식위탁매매 결과 신청인의 위 계좌의 잔고 평가액이 3,806,364원이 되게 하였음. 2000.4월 초순경 신청인은 주식매매 월간거래내역서를 받고 담당직원과 통화를 한 사실이 있음.

2001.2.28. 신청인은 담당직원에게 발생한 손실에 대하여 처음으로 이의를 제기하고 손실의 보전을 요구하자 담당직원은 2001.3.26.~6.28. 기간중 4회에 걸쳐 14,300,000원을 신청인의 위탁계좌에 입금함.

나. 당사자 주장

(1) 신청인 주장

신청인이 피신청인의 직원인 담당직원에게 이 사건 일임매매를 위임할 당시 구두로 비교적 안정적인 거래소 종목만을 투자종목으로 선정할 것을 제한적으로 일임한 사실이 있음에도 KOSDAQ 종목에도 투자하여 손해를 입었으며, 또한 담당직원은 수 차례의 투자권유를 통하여 신청인에게 1년 뒤에는 투자수익을 150백만원이 되게 해주겠다고 하여, 주식거래 경험이 전혀 없는 신청인은 그저 은행금리보다 좀 높으면 만족한다면서 투자금 명목으로 금350백만원을 입금하고 주식거래를 하게 된 것임.

담당직원은 위임의 취지와는 반대로 오로지 자신의 약정고에 따른 성과급과 피신청인의 수수료 수입의 증대만을 위하여 신청인의 투자자금을 운용하여 막대한 손해를 입혔으므로 이에 대하여 피신청인은 담당직원의 사용자로서 배상책임이 있음.

(2) 피신청인 주장

신청인은 매매거래를 시작한 익월(2000.3월)부터 거래 종료일 까지 매월 20회에 걸쳐 매매거래내역 및 매매에 관한 이상유무 확인을 우편통보로 요청하였으며, 한 번도 반송된 사실이 없고, 신청인은 민원 제기 전까지 매매거래에 대하여 한번도 당사에 이의를 제기한 사실이 없으며, 2000.3월에 신청인이 이의를 제기하였다면 손해가 발생하지 않았을 것임. 또한 신청인은 주식거래의 내용을 충분히 알고 있었다고 보아야 하며 과당회전매매라고 하더라도 이의를 제기하지 않은 것으로 보아 주식매매 내용을 추인한 것으로 볼 수 있고 또한 신청인 계좌의 손실은 대부분 전체적인 주식시장의 하락 등에 기인한 투자손실인 것으로 판단되어 신청인의 주장을 수용할 수 없음.

다. 위원회 판단

◆ 본건의 쟁점은 ①신청인과 직원사이에 주식위탁거래의 일임에 있어 거래대상 종목을 제한하여 일임한 것인지 여부 ②직원이 투자수익 보장약정을 했는지 여부 ③직원이 고객이익을 무시하고 회사 영업실적 증대만을 위해 무리한 과다 회전매매를 했는지 여부라 할 것임.

(1) 손해배상 책임

1) 쟁점1의 판단

신청인은 담당직원에게 이 사건 투자자금을 제공하고 일임매매 약정을 체결할 당시 구두로 비교적 안정적인 거래소 종목만을 투자종목으로 선정하고 KOSDAQ 종목은 이를 투자하지 말 것을 약속하여 제한적으로 일임한 사실이 있다고 주장하나, 이를 인정할 아무런 증거가 없으므로, 결국 신청인과 담당직원사이의 계약은 주식거래에 있어 포괄적인 일임매매로 볼 것이어서 이 부분 주장은 이유 없음.

2) 쟁점2의 판단

신청인은 담당직원이 수 차례의 투자권유를 통하여 신청인에게 1년 뒤에는 투자수익을 150백만원 정도로 해주겠다고 부당한 권유를 하여 주식에 투자경험이 전혀 없는 신청인이 투자금 명목으로 350백만원을 입금하고 주식거래를 하게 된 것이라고 주장하나, 이를 인정할 아무런 증거가 없으므로 이 부분 주장 역시 이유 없음.

3) 쟁점3의 판단

포괄적 일임매매는 원칙적으로 손해배상책임이 발생하지 아니하나 위임의 내용, 투자 목적, 투자자금의 성격 및 매매거래의 유형 등을 종합적으로 고려하여 위임의 본질을 일탈하여 고객의 이익을 무시하고 회사의 영업 실적만을 증대시키기 위하여 무리하게 빈번한 회전매매를 하는 경우 과당매매행위로 불법행위가 성립된다고 할 것이고 당 위원회는 부분적으로 손해배상 책임을 인정하고 있음.

한편 증권회사의 직원이 과당매매행위를 한 것인지의 여부는 고객 계좌에 대한 증권회사의 지배 여부, 주식 매매의 동기 및 경위, 거래기간과 매매횟수 및 양자의 비율, 매입 주식의 평균적 보유기간, 매매 주식 중 단기매매가 차지하는 비율, 동일 주식의 매입·매도를 반복한 것인지의 여부, 수수료 등 비용을 공제한 후의 이익 여부, 운용액 및 운용기간에 비추어 본 수수료액의 과다 여부, 손해액에서 수수료가 차지하는 비율, 단기매매가 많이 이루어져야 할 특별한 사정이 있는지의 여부 등 제반 사정을 참작하여 주식 매매의 반복이 전문가로서의 합리적인 선택이라고 볼 수 있는지의 여부를 기준으로 판단하여야함.

아래의 사실을 종합하면 피신청인의 담당직원은 피신청인의 사무집행에 있어 과도한

회전매매를 반복함으로써 신청인에게 손해를 가한 위법이 있다고 판단됨.

① 신청인은 주식투자의 경험이 전혀 없는 자로서 담당직원과 같은 교회에 다니는 개인적인 친분만을 신뢰하여 주식거래를 일임한 점.

② 매매 전후의 매매내역에 대한 구체적인 설명이나 그 경위를 담당직원이 설명을 회피하여 신청인의 합리적인 투자판단을 어렵게 한 점.

③ 적법한 일임매매의 경우에도 일임매매의 투자종목수를 10개 종목으로 한정하고 있는 점에 비추어 담당직원의 투자종목이 월별로 32개에서 78개까지 확장되는 등 전문가로서의 합리적인 투자대상 선정을 하였다고 보기 어려운 점.

④ 2000년 3월부터 6월까지 단기간 사이에 총 투자금의 73%, 총 손실의 73.9%에 해당하는 255,605,196원의 손해가 발생한 점.

⑤ 4월에서 6월까지의 매도·매수의 횟수를 살펴보면 4월에는 275건(하루 평균 15.3회), 5월에는 389건(하루 평균 16.2건), 6월에는 411건(하루 평균 17.1건)에 이르는 등 매매횟수가 지나치게 빈번하여, 거래기간 전체 매매회전율이 평균 1,596%로 나타나 매매자체가 과도한 점.

⑥ 위와 같은 회전매매로 피신청인이 얻은 수수료 수익은 147,957,320원으로서 손해금에서 차지하는 비율이 42.73%에 이르고 또한 담당직원이 신청인 계좌를 운용하여 피신청인으로부터 취득한 성과급은 38,105,306원에 달하여 위 직원의 총 성과급 중 58%를 신청인계좌를 운용함으로써 수익한 점.

⑦ 일임매매 기간 동안의 주가가 일반적으로 하락세임을 감안하면 굳이 같은 종목의 매수·매도를 단기간에 반복하여 손해를 확대시킬 이유가 없었다고 판단되고, 달리 단기매매를 하여야 할 사정이 보이지 아니하는 점.

(2) 손해배상액의 산정

신청인은 투자손실 전액의 배상을 구하나, 과도한 일임매매로 인한 손해배상금액을 산정함에 있어서는 투자기간 동안의 전반적인 주가수준을 감안하고 피신청인이 획득한 수탁수수료 수입을 초과하지 아니하는 범위 내에서 결정되는 것이 당 위원회의 합리적인

기준임.⁵¹⁷⁾

한편, 신청인은 주식투자 경험이 전혀 없어 매매를 일임하였다 하더라도 고액의 위탁금을 투자하였다면 그 거래 손익에 대하여 관심을 기울이고 감독하여야 함에도 자신의 위탁계좌에 대한 관리를 소홀히 하고 더욱이 2000. 4월경 매매거래의 내역을 피신청인으로부터 송달 받고 피신청인의 직원에게 전화를 하였음에도 이에 대한 자세한 거래내용, 손실의 규모 등을 알려고 노력하지 아니하고 전적으로 담당직원의 말만을 신뢰하여 손해를 확대시킨 점에 비추어 50%의 과실상계를 함이 타당함.

아울러 피신청인 담당직원으로부터 2001.3.26.~6.28. 기간중 4회에 걸쳐 14,300,000원을 손실보전의 명목으로 받은 사실이 있어 이를 공제하여야 할 것이고,⁵¹⁸⁾ 피신청인의 수수료 수입액과 위와 같이 산정된 손해배상액 중 적은 금액을 손해로 볼 것이므로 111,662,555원이 손해라 할 것임.

라. 결론

그렇다면 피신청인은 피신청인 직원의 고객인 투자자에 대한 불법행위에 대하여 사용자로서 신청인에게 금111,662,555원을 배상할 책임이 있다할 것임.

4-6 수수료 수입을 위한 선물·옵션의 과당매매에 따른 손해배상책임 여부

[일부인용] 본건 매매회전율이 5개월간으로 단기간임에도 월 평균 108,706%에 달하여 지나치게 과도한 점, 단기간 사이에 총 투자금(71,104,842원)의 98.25%에 해당하는 69,863,095의 손해가 발생한 점, 피신청인이 얻은 수수료 수익이 손해금의 62%에 이르고 있는 점 및 담당직원이 지점장으로 근무하던 지점의 약정실적이 해당 지역사업부내에서 하위 3위에 위치하여 외형실적을 증대시키려한 점 등을 감안할 때 담당직원이 선물·옵션의 과당매매행위를 하였다고 판단하여 배상함이 타당함.(2002.6.4. 조정번호 제2002-26호)

517) 계좌상 손실액(투자금액 - 이익제기일자 잔고) × 주가지수하락률(23.23%) = 251,925,109원.

518) ① 주가하락을 감안한 손실액 251,925,109원, ② 과실상계후 손실액 125,962,555, ③ 손실보전(△14,300,000원)후 손실액 111,662,555원, ④ 수수료 147,957,320원

가. 사실관계

2000.7월 신청인은 ○○증권사(이하 “피신청인”이라 함)의 지점장 A씨(이하 “담당직원”이라 함)를 운용자로 하는 주식의 일임매매계약을 체결하여 주식매매거래를 일임하였으나 투자금 210백만원의 절반 이상에 해당하는 손실을 입었음.

담당직원은 현물거래로는 원금을 만회하기 어려우니 2~3배의 이익을 낼 수 있는 선물·옵션거래를 해보라고 여러 차례 권유하여 2000.12.26. 피신청인의 지점에 신청인 명의의 선물·옵션계좌를 개설하고 HTS를 통하여 포괄적 일임매매를 하였으며, 신청인이 이후 전화로 매매현황을 문의하였으나 위 직원은 손해를 보고 있으니 조금만 기다려 달라고만 할 뿐 정확한 잔고 현황을 알려주지 않았음.

투자상담사 1종 자격증을 가지고 있지 않은 담당직원은 선물·옵션거래가 시작된 2001.1.2.~5.30. 기간중 69,863,095원의 손해를 발생시켰고, 선물·옵션계좌의 매매실적에 따라 회사에서 지급한 성과급을 신청인의 선물·옵션계좌에 입금(2001.2.26.~6.1.기간중 총 9,693,820원)한 사실이 있으며, 매매거래가 종료된 이후인 2001.6.1. 신청인에게 손실 보상차원에서 1,800,000원을 입금함.

2001.6월 초순경 신청인은 거래내역을 확인하고 담당직원에게 항의하자 같은 해 6.15. 담당직원으로부터 2001.10.30.까지 50백만원을, 2002.2.28.까지 10백만원을 상환할 것을 약속 받음.

나. 당사자 주장

(1) 신청인 주장

신청인은 신청인은 선물·옵션거래에 대한 거래의 특성과 위험성을 설명 받지 못한 채 직원의 일방적인 권유에 의하여 선물·옵션 위탁계좌를 개설한 것임.

담당직원은 매매거래 내역을 단 한 번도 매매기간 중 신청인에게 알려준 사실이 없을 뿐만 아니라, 피신청인의 직원은 지점의 약정을 높이기 위하여 수수료 수입을 목적으로 빈번한 회전매매를 한 것이므로 피신청인은 사용자로서 손해배상책임이 있음.

(2) 피신청인 주장

신청인이 주장하고 있는 변제약정은 담당직원의 개인적인 차원에서 변제의 의사표시를 한 것으로 볼 것임. 또한 선물·옵션계좌개설시 신청인은 선물거래위험설명서 및 옵션거래 위험설명서⁵¹⁹⁾에 각각 자필기명, 날인한 사실이 있으므로 담당직원의 권유에 따라 선물·옵션이 무엇인지도 모르고 서명을 하였다는 주장은 부당함.

선물·옵션매매의 특성상 과다한 손실위험을 피하기 위해서는 매매주기를 짧게 하는 단기매매에 치중할 수밖에 없는 상황과 담당직원은 거래비용을 줄일 목적으로 HTS를 이용하여 거래를 하였으며 담당직원에게 담당직원으로부터 6천만원을 변제 받기로 약정한 사실이 있으므로 이를 근거로 손해배상을 청구함.

피신청인이 선물·옵션계좌의 매매실적에 따라 지급한 성과급을 담당직원이 신청인에게 입금한 사실이 있어 “고객의 이익을 무시하고 자신과 회사의 이익을 증대시킬 목적으로 한 매매”와는 거리가 있으므로 신청인의 주장을 수용할 수 없음.

다. 위원회 판단

◆ 본건의 쟁점은 ① 신청인과 담당직원사이에 체결된 매매손실 보전약정의 효력 유무, ② 담당직원이 신청인에게 선물옵션의 투자를 권유하면서 주가지수선물, 주가지수옵션에 대한 거래의 특성과 위험성을 설명하였는지 여부 ③ 담당직원이 신청인과의 위임의 취지와는 반대로 무리하게 빈번한 회전매매를 하였는지 여부 등이라 할 것임.

(1) 손해배상 책임

1) 쟁점1의 판단

손실보전각서(차용증)를 담당직원이 피신청인의 지점장으로서 부분적 포괄대리권을 가진 사용인(상법 제15조)의 지위에서 작성한 것이라고 볼 경우에는 「증권거래법」 제52조 제3호와 동 시행령 제36조의3에 따라 정당한 사유 없이 당해 거래에서 발생한 손실

519) 선물거래 위험 설명서와 옵션거래 위험설명서에는 각 “투자원금의 전부 또는 일부를 손해 볼 수 있으며 손실이 투자원금을 넘어설 수도 있다” “손실액이 무제한적으로 확대될 수 있다”는 내용이 명시되어 있음.

의 전부 또는 일부를 보전하여 주는 행위로서 증권회사 등의 금지행위에 해당할 뿐만 아니라 위험관리에 의하여 경제활동을 촉진하는 증권시장의 본질을 훼손하고 안이한 투자판단을 초래하여 가격형성의 공정을 왜곡하는 행위로서, 증권투자에 있어서의 자기책임원칙에 반하는 것이라고 할 것이므로, 정당한 사유 없는 손실보전의 약속 또는 그 실행행위는 사회질서에 위반되어 무효라고 할 것임.

손실보전각서(차용증)를 작성하게 된 경위와 담당직원의 진술을 종합하면 손실보전을 위한 차용증의 교부는 담당직원이 개인적으로 변제 의사를 표시한 것으로 판단되므로 결국 담당직원과의 손실보전각서를 근거로 피신청인에 대하여 손해배상을 청구할 수는 없다 할 것임.

2) 쟁점2의 판단

신청인이 선물거래위험설명서 및 옵션거래 위험설명서에 각각 자필기명, 날인한 사실은 인정되므로 일반적으로 특별한 사정이 없는 한 선물·옵션의 위험성과 거래방법 등에 대한 명시·설명의무를 피신청인이 이행하였다고 볼 것임.

그러나 담당직원에 대한 문답서에 의하면 간략한 설명만을 하였을 뿐, 거래에 대한 위험성 등에 대한 특별한 설명은 하지 않았다고 진술하고 있는 점과 담당직원 자신이 투자상담사 2종 자격증만을 가지고 있어 선물·옵션거래에 대하여는 전문가가 아니었던 점등에 비추어 신청인에게 선물·옵션매매거래의 특성과 위험성에 대한 설명의무를 피신청인이 다하였다고 볼 수 없음. 결국, 담당직원의 고객에 대한 계좌개설권유행위는 경험이 부족한 투자자인 신청인에게 거래행위에 필연적으로 수반되는 위험성에 대한 올바른 인식형성을 방해하고 오로지 현물주식거래에서 발생한 손해를 단기간에 회복할 수 있다는 점만을 부각한 것으로 부당 권유행위라 할 것임.

3) 쟁점3의 판단

증권회사의 직원이 과당매매행위를 한 것인지의 여부는 고객 계좌에 대한 증권회사의 지배 여부, 주식 매매의 동기 및 경위, 거래기간과 매매횟수 및 양자의 비율, 매입 주식의 평균적 보유기간, 매매 주식 중 단기매매가 차지하는 비율, 동일 주식의 매입·매도를 반복한 것인지의 여부, 수수료등 비용을 공제한 후의 이익 여부, 운용액 및 운용기

간에 비추어 본 수수료액의 과다 여부, 손해액에서 수수료가 차지하는 비율, 단기매매가 많이 이루어져야 할 특별한 사정이 있는지의 여부 등 제반 사정을 참작하여 주식 매매의 반복이 전문가로서의 합리적인 선택이라고 볼 수 있는지의 여부를 기준으로 판단하여야함. 아래의 사실을 종합하면 피신청인의 직원은 위임의 취지에 반하여 과다한 회전매매를 한 것으로 판단됨.

① 피신청인은 선물·옵션매매의 특성상 과다한 손실위험을 피하기 위해서는 담당직원이 가격변동에 따른 시세차익을 얻기 위한 전략(방향성매매전략)을 구사하여 매매주기를 짧게 하는 단기매매에 치중한 것이라고 항변하나 매매회전율이 5개월간으로 단기간임에도 월 평균 108,706%에 달하여 지나치게 과도한 점.

② 단기간 사이에 총 투자금(71,104,842원)의 98.25%에 해당하는 69,863,095의 손해가 발생한 점.

③ 피신청인이 얻은 수수료 수익은 42,211,090원으로서 손해금에서 차지하는 비율이 62%에 이르고 있는 점 및 담당직원이 지점장으로 근무하던 지점의 약정실적이 해당 지역사업부내에서 하위 3위에 위치하여 외형실적을 증대시키려한 점.

④ 피신청인은 수수료가 저렴한 HTS를 통하여 거래를 했고 담당직원의 성과급을 선물·옵션계좌에 입금시킨 행위에 비추어 과당회전매매가 아니라고 주장하나, 담당직원은 투자상담사 2급 자격증 밖에 없어 HTS로 거래할 수밖에 없었고, HTS로 거래하면 매매실적이 높다 하더라도 일임매매로 의심을 받지 아니하며, 담당직원은 신청인이 친구의 부인이라는 점에서 손실에 대한 보전차원에서 성과급을 입금시킨 것이라고 진술하고 있는 점 등에 비추어 위 주장은 이유 없음.

한편, 기타 포괄적 보호의무 위반 여부와 관련해서는, 담당직원이 신청인에게 매매내역을 알려준 사실이 없을 뿐 아니라 거래기간 중 투자원금과 당초 위임목적에 부합하는 수익이 일시적이거나 발생하였음에도 다시 무리한 투자를 반복하여 손해를 확대한 사실 등에 비추어 고객에 대한 포괄적 보호의무를 위반한 사실이 있다고 할 것임.

(2) 손해배상액의 산정

피신청인 담당직원의 부당권유행위 및 과다한 회전매매 등 고객에 대한 포괄적 보호

의무 위반이 인정되므로 2001.1.2.부터 매매거래가 중단된 2001.5.30.까지 신청인 위탁계좌에서 선물·옵션계좌에 대체입금된 71,104,095원에서 2001.6.15. 계좌를 폐쇄하고 출금한 금1,241,747원을 뺀 69,863,095원이 손해금액임.

한편, 신청인은 주식투자의 경험이 있을 뿐만 아니라 현물주식의 일임매매로 손실이 발생하자 단기간에 손실을 보전하기로 하여 선물·옵션의 일임매매가 이루어진 사실, 위탁계좌를 타 지점에서 담당직원의 근무지인 지점으로 이전하면서 까지 위험성을 수반하는 주가지수 선물·옵션에 투자한 사실, 증권거래에 있어 자기책임에 수반하는 매매거래 내역, 손익상황 등을 확인할 의무를 게을리 하고 담당직원의 말만을 신뢰하여 손해를 확대시킨 점등에 비추어 60%의 과실상계를 함이 타당함.

아울러 담당직원이 매매거래 종료 이후인 2001.6.1. 신청인에게 손실보상차원에서 180만원을 입금한 사실이 있어 이를 공제하여야 하는 바, 피신청인의 손해금액 69,863,095원에서 과실비율 상당의 41,917,857원 및 위 180만원을 공제한 26,145,238원이라 할 것임

라. 결론

그렇다면 피신청인은 피신청인 직원의 고객에 대한 불법행위에 대하여 사용자로서 신청인에게 금 26,145,238원을 배상할 책임이 있다 할 것임.

4-7 일임약정이 있었으나 무리한 과다회전매매로 인한 손해배상책임 여부

[일부인용] 주식의 과다한 일임매매는 증권회사 직원이 고객의 이익을 무시하고 회사의 영업 실적만을 증대시키기 위하여 무리하게 빈번한 회전매매를 하는 등의 주관적·객관적 요건이 충족될 때 예외적으로 불법행위가 인정되며, 고객으로서는 비록 손해 및 가해자를 알았다 하더라도 그 손해가 직원의 과다한 일임매매에 기인한 것이고, 그 행위가 불법행위에 해당한다는 사실을 인식하는 것은 매우 어려우므로 단지 손실이 발생했다는 사실을 알았다는 이유로 시효가 진행된다고 볼 수 없음.(2005.3.8. 조정번호 제2005-20호)

가. 사실관계

1999.6.28. 신청인은 ○○증권사(이하 “피신청인”이라 함)의 지점에서 신청인 명의로 주식위탁매매계좌를 개설하고, 같은 해 7.26. 다른 증권사에 위탁되어 있던 A기업 주식 25천주(주식 단가 8,530원, 당시 시가 합계 213,125,000원)를 동 계좌에 계좌대체하여 입고하였음.

신청인은 현직 교사로서 주식투자 경험이 없으나, 신청외 C씨는 일반회사에서 자금업무를 담당하던 자로서, 1998년경부터 주식위탁매매를 하는 등 주식투자 경험이 있어 신청인은 C씨에게 위 증권계좌 관리를 일임하였고, C씨는 피신청인의 타 증권사에서 전직하여 1999.8.2.부터 피신청인의 지점에서 현재까지 근무중인 담당직원 D씨에게 위 증권계좌관리를 일임하였고, C씨는 D씨에게 동 계좌 관리를 맡기며 사전에 협의를 하여 매매하기로 하되 급한 일이 있으면 사후적으로 보고하는 것으로 구두 합의한 사실에 당사자간 다툼이 없음. 한편 1999.7월이후 주식거래 현황은 다음과 같음.

거래기간	거래초 평가자산	총 거래대금	월간 평균 예탁자산	월간 회전율(%)	이익금	수수료
1999.7.26.~9.2.	213,125	0		0	34,500	0
1999.9.3.~9.20.	248,025	1,940,490	189,659	1,023	-46,279	9,523
1999.9.21.~2000.2.21.	201,746	0	184,403	0	-62,511	0
2000.2.21.~2.29.	92,782	826,695	105,825	781	-54,744	3,302
2000.3월	66,915	612,684	73,544	833	2,460	3,894
2000.4월	69,775	706,422	60,630	1,165	-13,872	1,507
2000.5월	54,403	3,565,333	48,024	7,424	-12,904	15,008
2000.6.1.~6.7.	41,498	190,588	38,292	497	-5,346	5,635
계	-	7,842,213	515,974	1,519	-165,509	38,872

나. 당사자의 주장

(1) 신청인의 주장

신청인은 보유하던 A기업 주가가 계속 하락하여 더 이상의 손해를 막기 위해 담당직원에게 매도 문의를 하였으나, 동 직원은 A기업의 시베리아 유전 개발 등 막대한 품문에 기대어 동 주식의 투자를 권유하였고 이로 인하여 손실이 확대되었음. 담당직원은 위 손실을 만회하고 피신청인 회사의 영업실적을 증대시키기 위하여 고객에 대한 선량한

관리자의 주의의무를 위반하여 무리하게 빈번한 단기매매, 미수거래 등을 반복하였음.

(2) 피신청인의 주장

신청인은 2000.6.7. 본건 위탁계좌에서 잔고를 출금할 당시 동 계좌에서의 매매손실을 충분히 인식한 것이므로 불법행위로 인한 손해배상청구권의 단기소멸시효인 3년이 경과되었고, 담당직원이 1999.11월말경 남북해빙무드와 시베리아 가스전에 대한 신문보도가 있으므로 A기업의 주식이 수혜주로서 주가상승이 예상된다는 정도로 설명하였을 뿐이지 부당 권유한 것은 아니며, 2000.2월부터 2000.6월까지 종합주가지수가 급락하는 시장 상황에 유연히 대처하기 위하여 손절매 등 최선을 다하였을 뿐이지 영업실적 제고를 위한 과당매매를 한 것은 아님.

다. 위원회의 판단

◆ 본 건의 쟁점은 ① 손해배상청구권의 소멸시효 도과 여부, ② 부당권유 해당 여부 ③ 과다한 일임매매 등 고객 보호의무 위반 여부라고 할 것임.

(1) 손해배상청구권의 소멸시효 도과 여부

불법행위로 인한 손해배상청구권의 단기시효는 피해자나 법정대리인이 그 손해 및 가해자를 현실적이고도 구체적으로 인식한 날로부터 기산하며, 그 손해를 안 날이라 함은 불법행위의 요건사실인 위법한 가해행위의 존재, 가해행위와 손해의 발생 사이에 상당인 과관계 등이 있다는 사실까지 알았을 때를 의미함.

과다 일임매매의 경우에는 증권회사 직원이 고객의 이익을 무시하고 회사의 영업실적만을 증대시키기 위하여 무리하게 빈번한 회전매매를 하는 등의 주관적·객관적 요건이 충족될 때 예외적으로 불법행위가 인정되는 것이므로, 일반인은 비록 손해 및 가해자를 알았다 하더라도 그 손해가 담당직원의 과다한 일임매매에 기인한 것이고, 그 행위가 불법행위에 해당한다는 사실을 인식하는 것은 매우 어려우므로 단지 손실이 발생했다는 사실을 알았다는 이유로 시효가 진행된다고 볼 수 없는 바, 신청인이 2000.6월경 위탁계좌의 손실을 인식하고 잔고를 출금하였다는 사실만으로는 소멸시효가 도과되었다는 피

신청인의 주장은 받아들일 수 없음.

(2) 부당권유 해당 여부

신청인은 A기업 주식이 하락하여 담당직원에게 매도를 문의하였으나 담당직원은 현대건설이 시베리아 유전을 개발한다는 풍문을 막연히 믿고 투자를 권유하여 손실이 확대되었다고 주장하고 있으나, 이는 담당직원이 신문보도 등을 통하여 형성한 개인적 의견을 제시한 것에 불과하여, 동 주장만으로는 신청인의 투자 판단에 필연적으로 수반되는 위험성에 관한 올바른 인식의 형성을 방해하였다거나 과도한 위험성 있는 거래를 적극적으로 권유한 경우에 해당한다고 보이지 아니함.

(3) 과다일임매매 등 고객보호의무 위반 여부

신청인과 담당직원은 계좌관리 위탁시 “사전에 협의하여 거래를 하되 급한 경우에는 사후에 보고하도록” 하는 내용의 일임매매 약정을 체결하였음에도, 담당직원은 신청인과 일임매매약정의 내용에 반하여 대부분의 매매거래에 있어서 사전 협의를 하지 않았거나 사후 보고도 없었고, 미수거래가 여러 차례 반복되었음에도 미수거래의 형태를 모르는 신청인에게 그에 대한 위험성 등 설명이 없었으며, 미수거래나 단기매매의 구체적인 거래내역에 대한 설명이나 경위 등을 알리지 아니함으로써 고객보호의무를 위반하였다고 판단됨.

또한 담당직원은 일임약정에 기하여 동 계좌에 사실상의 지배권을 행사하고 있었고, 실제로 매매가 이루어진 기간 동안(약 4개월)의 월평균매매회전율은 1,519%이고, 위탁거래로 인한 손실금 대비 수수료비율은 약 43%에 이르며, 실거래기간 동안 총 미수금은 금700,932,878원으로서 평균예탁자산에서 차지하는 비율이 135%이며, 나아가 2000.4월부터 2000.6.5.까지의 매매거래형태를 살펴보면, 전 매매가 매수당일 또는 매수익일에 매도하는 등의 단기매매에 해당되고, 일정기간 한 종목의 빈번한 매수 매도에 예탁자산을 전부 이용하는 등 일임약정에 기하여 무리한 회전매매를 한 것으로 인정됨.

(4) 손해배상액 산정

본건 위탁매매와 관련하여 실질 거래 기간의 총 손실금 합계는 금90,311,037원임⁵²⁰).

한편 C씨는 담당직원이 피신청인 회사로 전직하기 전부터 증권계좌의 관리를 위탁하였고, 주식매매 경험도 있어 주식투자의 위험성을 알고 있음에도 동 직원이 매수전 상의를 하거나 사후보고를 할 경우 “알아서 하라”고 주로 말하였을 뿐 별도의 세부내역을 구체적으로 확인하거나 이의를 제기하지 아니한 과실이 인정됨. 따라서 신청인은 본건 매매거래위탁과 관련하여 사후관리 및 감독을 소홀히 하고 그대로 방치하여 이 사건 손해발생이나 그 확대의 한 원인이 되었다고 할 것이어서 위 손해배상액에 이를 참작하기로 하여 손해금액 중 70%의 과실상계를 함이 타당함.

결론적으로, 피신청인이 배상하여야 하는 손해금액은 위 손실금 90,311,037원에서 신청인 측 과실비율에 상응하는 금63,217,725원을 차감한 금27,093,312원임

라. 결 론

그렇다면 피신청인은 담당직원의 고객에 대한 불법행위에 대하여 사용자로서 신청인에게 금 27,093,312원을 배상할 책임이 있다 할 것이고 신청인의 나머지 청구는 이유 없어 이를 기각함.

4-8 주식의 과당 일임매매와 손해배상청구권의 시효 완성 여부

[일부인용] 과당일임매매는 증권회사 직원이 고객이익을 무시하고 영업실적만을 증대시키기 위하여 무리하게 빈번한 회전매매를 하는 등의 주관적·객관적 요건이 충족될 때 예외적으로 불법행위가 인정되며, 손해배상청구권은 피해자가 그 손해 및 가해자를 안 날로부터 3년간 이를 행사하지 아니하면 시효로 인하여 소멸하는데, 손해를 안 날이란 위법한 가해행위의 존재, 가해행위와 손해의 발생 사이에 상당인과관계 등이 있다는 사실까지 피해자가 알았을 때를 의미하는 바, 투자자가 단순히 손실보상을 요구하거나 매매거래내역을 통보받았다는 사실만으로는 소멸시효가 완료되었다고 볼 수 없음.(2005.6.14. 조정번호 제2005-37호)

520) 1999.9.3.~9.20. 기간중 위탁거래 손실금액은 금41,278,176원(거래초 예탁자산 금248,025,000원 - 거래말 예탁자산 금201,746,824원 - 1999.9.16. 출금 5,000,000원)이고, 2000.2.21.~6.7. 기간중 위탁거래 손실금액은 금49,032,861원(거래초 예탁자산 금92,782,861원 + 2000.3.7. B기업 미수금 입금 400,000원 - 2000.2.3. 출금 6,500,000원 - 2000.4.26. 출금 1,500,000원 - 2000.6.7. 출금 36,150,000원)임.

가. 사실관계

신청인은 1999.5.14. 친구로부터 ○○증권사(이하 “피신청인”이라 함) 지점에 근무하는 투자상담사 A씨(이하 “담당직원”이라 함)를 소개받아, 동 지점에서 신청인 명의의 위탁계좌를 개설하여 금 5백만원을 입금하는 등 2000.1.10.까지 총 12회에 걸쳐 금234,990,000원을 주식투자금으로 입금하였으며, 2000.1.17. B기업 주식 30주, C기업 주식 8주, D기업 주식 60주(평가금액 총합계 12,418,224원)를 대체 입고하였음.

신청인은 계좌개설 당시 위 담당직원에게 본인 명의 계좌를 통한 주식거래 일체에 대하여 포괄적 일임을 하였으며, 담당직원이 2001.10.15.까지 위 계좌를 운용하던 중 총 206,055,884원의 손실이 발생하였음.

신청인은 계좌의 손실발생에 대하여 담당직원에게 항의하던 중 담당직원이 피신청인 회사를 퇴사하기 직전인 2001.10월 중순경 매매손실을 변상하겠다는 각서⁵²¹⁾를 동 직원으로부터 교부받았는데, 담당직원이 15백만원을 지급한 이후 더 이상 각서내용을 이행하지 못하자 2005.2.28. 분쟁조정을 신청함.

나. 당사자의 주장

(1) 신청인 주장

신청인은 2001년 7~8월경 담당직원에게 매매중단을 요청하였음에도 동직원이 허락 없이 거래를 하였을 뿐만 아니라 계좌 운영기간 내내 빈번한 주식거래를 하여 과도한 수수료를 발생시키는 등으로 투자원금 대부분에 손실이 발생하였는 바, 손실금의 절반에 해당하는 1억원의 손해배상을 청구함.

(2) 피신청인 주장

신청인은 수차례의 지점방문 및 입출금(고) 거래, 정상적으로 발송된 월간 거래내역

521) 담당직원은 “○○증권 △△지점 소속 A는 본 지점 계좌의 매매손실분 2억3천만원에 대해서 1차적으로 2001.12.31.까지 1억원을 변상하고 2차적으로 2002.12.31.까지 나머지 잔액 1억3천만원을 변상할 것임을 약속 드립니다.”라는 내용의 각서를 교부함.

및 잔고통보 등을 통하여 관련계좌의 매매거래 및 손실내역을 인지하였을 뿐만 아니라 분쟁조정 신청서상에서도 담당직원의 과도한 수수료 발생사실을 매매기간중에 알고 있었던 점을 자술하고 있어 본 건 담당직원의 가해행위가 적법한 행위가 아님을 신청인은 충분히 인식하고 있었던 것으로 판단되므로, 신청인이 위탁계좌에서 잔고를 대체출금함으로써 손해가 구체적으로 확정된 2001.11.2.부터 손해배상청구권의 소멸시효가 진행되었다 할 것이고, 이후 별다른 소멸시효 중단사유가 발생하지도 않았으므로 신청인의 손해배상청구권은 소멸시효가 완성되었음.

다. 위원회의 판단

◆ 본 건의 쟁점은 ① 담당직원이 신청인의 동의없이 임의매매를 한 사실이 있는지 여부, ② 과다한 일임매매등 고객 보호의무를 위반하였는지 여부 및 ③ 신청인의 손해배상청구권에 대한 소멸시효가 완성되었는지 여부라 할 것임.

(1) 임의매매 성립여부

담당직원이 주식을 위탁인인 고객의 동의 없이 매매한 경우에는 임의매매가 성립하고 이 경우 증권회사는 사용자배상책임을 지는 것이 원칙임. 또한 임의매매인지 여부에 대하여는 구체적 증거가 없는 경우가 많으므로 객관적으로 나타난 계약체결당시의 권유방법, 투자목적 내지 동기, 투자자의 거래경험, 거래원장상에 나타난 거래내역 등의 여러 정황을 종합하여 객관적이고 합리적으로 판단하여야 할 것임.

신청인은 2001년 7~8월경 정도에 담당직원에게 대하여 매매중단을 요청하였음에도 담당직원이 임의로 매매를 하였다고 주장하나, 이를 입증할 만한 증거를 발견하기 어렵고, 오히려 신청인과 담당직원에게 대한 문답내용 및 월간 거래내역서 발송자 명단과 특수 우편물 수령증에 의하면 거래내용이 신청인에게 모두 통보 되었음에도 신청인이 매매내용에 대하여 명시적인 이의제기를 한 사실이 없으며, 신청인 스스로도 “담당직원 입장에서 본인이 거래중지를 요청했다기 보다는 손실 난 것에 대해 단순 불만을 표시하는 정도로 생각했을 수도 있었다고 본다”고 진술하고 있는 점에 비추어 신청인의 이 부분 주장은 이유 없음.

(2) 고객보호의무(충실의무) 위반으로 인한 손해배상책임 성립여부

증권회사가 고객과 포괄적 일임매매 약정을 하였음을 기화로 그 직원이 충실의무를 위반하여 고객의 이익을 무시하고 회사의 영업실적만을 증대시키기 위하여 무리하게 빈번한 회전매매를 함으로써 고객에게 손해를 입힌 경우에는 과당매매행위로서 불법행위가 성립됨.

증권회사의 직원이 충실의무를 위반하여 과당매매행위를 한 것인지의 여부는 고객 구좌에 대한 증권회사의 지배여부, 주식매매의 동기 및 경위, 거래기간과 매매횟수 및 양자의 비율, 매입 주식의 평균적 보유기간, 매매주식 중 단기매매가 차지하는 비율, 동일 주식의 매입·매도를 반복한 것인지의 여부, 수수료 등 비용을 공제한 후의 이익 여부, 운용액 및 운용기간에 비추어 본 수수료액의 과다 여부, 손해액에서 수수료가 차지하는 비율, 단기매매가 많이 이루어져야 할 특별한 사정이 있는지의 여부 등 제반 사정을 참작하여 주식 매매의 반복이 전문가로서의 합리적인 선택이라고 볼 수 있는지의 여부를 기준으로 판단하여야 함.⁵²²⁾

다음의 거래내역에 비추어 볼 때, 담당직원은 고객에 대한 충실의무에 위반하여 신청인의 이익을 무시하고 회사의 영업 실적만을 증대시키기 위한 무리한 과당매매를 하였다고 인정되는바, 피신청인은 담당직원의 사용자로서 신청인에 대하여 손해배상책임이 있다 할 것임.

포괄적 일임을 받아 신청인 계좌에 대하여 사실상의 지배권을 행사하고 있었던 담당직원의 1999.5월~2001.10월 사이의 매매거래내역을 살펴보면, 거래자체에서는 73,314,615원의 수익이 발생하였음에도 거래비용으로 281,375,500원(수수료 215,730,780원, 세금 65,644,720원)이 지급되어 계좌 전체적으로는 208,060,885원의 손실이 발생되었고(손실금액 대비 수수료율이 103.69%), 매매회전율이 거래기간 평균 1,589%(1999.12월~2001.10월 동안은 2,107%이고 최대 5,440%), 미수금 발생율이 121.52%에 달하며, 단기매매를 하여야 할 특별한 사정이 없음에도 거래의 상당부분이 매수(또는 매도)한 당일 또는 5일 이내의 단기간에 매도(또는 매수) 되었음.

522) 대법원 1997.10.24. 선고 97다24603 판결, 2002.03.29. 선고 2001다49128 판결 참조.

(3) 손해배상청구권의 소멸시효 완성여부

불법행위로 인한 손해배상청구권은 피해자가 그 손해 및 가해자를 안날로부터 3년간 이를 행사하지 아니하면 시효로 인하여 소멸하는데, 여기에서 말하는 손해를 안 날이란 불법행위의 요건사실에 대한 인식으로서 위법한 가해행위의 존재, 가해행위와 손해의 발생 사이에 상당인과관계 등이 있다는 사실까지 피해자가 알았을 때를 의미함.⁵²³⁾

과당매매 등을 통한 불법행위 성립여부는 거래 관련 자료 일체에 대한 통계(거래비용 등 합계, 매매회전율, 수수료율, 단기매매 비율등)와 계좌를 운영하던 담당직원의 투자기준 및 거래 당시 주식시장의 상황 등을 모두 고려하여 판단하여야 하는데, 투자전문가도 아닌 일반인으로서 이러한 사정을 모두 고려하여 담당직원에게 과실이 있는지와 그 과실과 손해 사이에 인과관계가 있는지 여부 등을 쉽게 알 수 없다 할 것인 바, 투자자가 단순히 손실보상을 요구하거나 매매거래내역을 통보받았다는 사실만으로는 3년의 소멸시효가 진행된다고 볼 수 없을 것임.

신청인이 월간거래내역서나 담당직원과의 대화를 통하여 거래 내역이나 수수료 발생 사실 등을 대략적으로 알고 있었던 것은 사실이나, 본건 일임을 통한 주식투자의 별다른 투자 경험이 전혀 없던 신청인이 이러한 단편적인 사실 등만으로 담당직원의 거래행위가 과당매매에 해당하여 위법하거나 이러한 위법행위와 손해 사이에 인과관계가 있다는 것을 알았다고 보기는 어려우며, 또한 피신청인의 담당직원이 손실보상각서를 작성해 주는 등 신청인의 손해배상청구를 지연시켰는 바, 2001.11.2.부터 시효가 진행되어 3년이 경과됨으로써 소멸시효가 완성되었다는 피신청인의 주장은 받아들일 수 없다 할 것임.

(4) 손해배상액 산정

신청인의 손해금액은 거래기간 중 신청인이 입금한 238,953,400원에 입고한 주식의 당시 평가금액 12,418,224원을 합한 251,371,624원에서 신청인이 출금한 25,962,005원과 출고주식의 평가금액 19,353,735원을 차감한 206,055,884원이라고 할 것임.

다만, 신청인은 고액의 위탁금을 투자하면서도 담당직원에게 매매거래를 포괄적으로 일임하였고, 피신청인의 지점을 방문하거나 거래내역을 통지 받아 대략의 매매거래 상

523) 대법원 1997.12.26. 선고 97다28780 판결 참조

황 및 매매기간중 손해가 지속적으로 발생되고 있는 사실을 인지하고도 거래를 중지시키거나 적극적으로 이의를 제기하지 않고 오히려 손실을 회복시켜주겠다는 담당직원의 말만 믿고 2년 6월이나 되는 장기간 동안 위 직원이 매매거래를 계속하도록 하였는바, 신청인에게 이러한 자기재산 관리 소홀에 따른 과실을 물어 60%의 과실상계를 함이 타당함. 아울러 신청인은 피신청인의 담당직원으로부터 2002년초 5백만원을, 2003년 1월에 1천만원을 손실보전의 명목으로 받은 사실이 있어 이를 공제함.

라. 결 론

그렇다면 피신청인은 신청인에게 손해금액 206,055,884원에서 신청인의 과실 60%를 상계한 나머지 금액 82,422,353원에서 15,000,000원을 공제한 금 67,422,353원을 배상할 책임이 있어 이를 인용하고, 신청인의 나머지 청구는 이유 없어 기각함.

4-9 임의매매에는 해당하지 않으나 과당일임매매로 인한 손해배상책임 발생

[일부인용] 본건은 묵시적이고 포괄적인 매매의 일임에 해당하고, 담당직원의 손실보전각서는 사회질서에 위반되어 무효이나, 매매회전율, 손실금 대비 수수료율, 미수금발생을 등에 비추어 과당매매가 인정됨. 단, 신청인의 과당매매 방치과실을 인정하여 70%과실 상계함.(2006.5.9. 조정번호 제2005-25호)

가. 사실관계

신청인은 2004.11.18. ○○증권사(이하 “피신청인”이라 함) 지점에서 담당직원을 A씨(이하 “담당직원”이라 함)로 하여 위탁계좌를 개설하고 같은 달 30일 금 9백만원을 입금 하였으며, 2004.12.1.부터 2005.10.10.까지 주식매매를 하였음. 매매거래 방법은 대부분 신청인이 전화로 담당직원에게 매매거래에 대하여 문의를 하면 동 직원은 매매내역을 사후보고하는 형태였고, 피신청인은 매월 “거래내역 및 잔고현황”을 신청인의 자택으로 발송하였음.

담당직원은 신청인이 2005.3.14. 매매가 너무 빈번함을 이유로 향후 매도만 하고 매수는 하지 말 것을 요청하자 본건 매매거래를 중단하였다가, 신청인의 손실보전 요구로 시간을 주면 손실을 회복시켜 주겠다는 약속을 하고 같은 해 4.15. 매매를 재개하였음.

같은 해 5.19. “일금 9백만원을 2005.12.31.까지 신청인에게 지불하기로 하여 이 각서를 작성함”이라는 내용의 각서를 신청인에게 제공하였으나, 이를 이행하지 않자 신청인은 2005.12.28. 분쟁조정을 신청함.

나. 당사자 주장

(1) 신청인 주장

담당직원은 신청인과 협의 없이 A기업 주식 등을 임의매매하였고, 가사 일임이 인정된다고 하더라도 과도한 일임매매에 해당할 뿐 아니라 이에 대하여 담당직원이 9백만원을 변제하겠다는 손실보전각서를 작성하였으므로 9백만원을 배상하여야 함.

(2) 피신청인 주장

담당직원은 신청인의 포괄적 일임을 받아 매매하였으므로 임의매매라는 주장은 부당하며, 동 직원이 제공한 각서가 손실보전각서라고 하더라도 이는 「증권거래법」상 무효이므로 이를 이유로 사용자배상책임을 질 수는 없음.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 담당직원이 신청인의 동의 없이 임의매매를 하였는지 여부, 동 직원이 제공한 각서의 효력 여부, 과당매매에 해당하는지 여부 등이라 할 것임.

(1) 본건 매매가 임의매매에 해당하는지 여부

다음의 각 사실에 비추어 신청인의 묵시적인 포괄적 매매일임이 있었던 것으로 판단되므로 본건 매매가 임의매매라는 신청인의 주장은 이유가 없음.

신청인은 계좌개설당시 협의 후 매매거래 할 것을 담당직원에게 요청하였다고 주장하고 있으나, 동 직원은 신청인에게 “본인에게 매매거래를 맡기고 한 달정도 결과를 지켜

본 후 본인에게 계속 일임할 지 여부를 결정하라”고 말하여 신청인이 계좌를 개설하였다고 진술하고 있어 양 당사자의 주장이 상이함.

① 매매거래와 관련된 녹취록을 살펴보면 담당직원이 매수사실을 사후에 보고하면 신청인은 이의제기 없이 “예”, “그러면 알아서 하시고” 등 매매사실을 수용하고 있거나, 오히려 “오늘은 어떤가?”, “우리가 산 건 어떤가?”라며 매매거래 내역을 묻고 있는 점.

② 2005.3.14. 주식을 매수하지 말라는 신청인의 요청이 있는 후에는 거래가 없었고, 손실보전 약속이 있는 후 매매가 재개된 이후에도 “하는 일은 잘 돌아가나?”, “재미 좀 봤나?” 등 매매를 일임한 취지의 말을 언급하고 있는 점.

③ 매매거래기간 동안 거래내역서가 정상적으로 발송되었고 신청인은 주식경험이 있어 그 내역을 충분히 인지하고 있었던 점 등에 비추어 묵시적이고도 포괄적인 매매의 일임에 해당함.

(2) 직원이 제공한 각서의 법적 효력 여부

신청인은 담당직원이 2005.5.19. 제공한 각서는 임의매매에 대한 손해배상책임을 인정한 것이라고 주장하고 있으나, 동 각서는 다음의 사실에 비추어 그 효력을 인정할 수 없음.

법원은 “주식의 거래로 인한 손해가 발생하자 증권회사 직원이 고객에게 특정일자까지 계좌를 책임지고 운영하여 손실을 보전하되, 그렇지 못할 경우 금전으로 이를 배상하기로 약정한 경우, 위 약정이 「증권거래법」 제52조 제1호의 적용대상이라고 보기는 어려우나 「증권거래법」 제52조 제3호, 동법 시행령 제36조의3 제3호에 위반되는 것으로 이는 위험관리에 의하여 경제활동을 촉진하는 증권시장의 본질을 훼손하고 안이한 투자판단을 초래하여 가격형성의 공정을 왜곡하는 행위로서, 증권투자에 있어서의 자기책임원칙에 반하는 것이라고 할 것이므로, 사회질서에 위반되어 무효”라고 판시함.⁵²⁴⁾

본건 매매는 위에서 본 바와 같이 임의매매라는 불법행위가 성립되지 않을 뿐 아니라 각서를 작성한 시점에 신청인의 투자손실금은 약 490만원임에 비하여 각서상 담당직원

524) 대법원 2001.4.24. 선고 99다30718 판결 참조.

은 12.31.까지 9백만원의 지급을 약속하고 있는 바, 동 각서는 손해배상의 약속이 아니라 약속기일까지 신청인의 증권계좌를 운용하여 투자원금 9백만원을 회복하겠다는 것을 약정한 취지로 보이며 「증권거래법」 제52조 제3호 및 동법 시행령 제36조의3 제3호⁵²⁵⁾에 위반되어 무효라 할 것임.

(3) 본건 매매가 위법한 일임매매에 해당하는지 여부

1) 포괄적 일임매매의 경우 과당매매 판단기준

증권회사 직원이 고객으로부터 증권거래에 관한 포괄적인 승낙을 얻어 주식거래를 하는 이른바 일임매매의 경우 증권회사의 직원에게는 고객에 대하여 선량한 관리자로서의 주의의무(충실의무)가 있어, 증권회사 직원이 일임매매약정을 하였음을 기화로 고객의 이익을 무시하고 회사의 영업실적만을 증대시키기 위하여 무리하게 빈번한 회전매매를 함으로써 고객에게 손해를 입힌 경우에는 불법행위가 성립함.

과당매매 여부를 판단하는 기준으로는 고객이 부담하는 수수료, 고객의 재산상태나 투자목적, 고객의 투자지식이나 경험에 비추어 당해 고객이 주식매매거래에 수반되는 위험을 잘 이해하고 있는지 여부, 개별 매매거래 권유내용의 타당성 등을 고려하여야 함.

2) 본건 매매거래가 과당매매로 불법행위에 해당하는지 여부

본건 위탁계좌와 관련하여 다음의 각 점에 비추어 담당직원이 신청인의 묵시적인 포괄일임을 받아 과당매매를 한 것으로 판단됨.

525) 「증권거래법」 제52조(부당권유행위 등의 금지) 증권회사 또는 그 임·직원은 다음 각호의 행위를 하여서는 아니된다.

1. 유가증권의 매매거래에 있어서 고객에 대하여 당해 거래에서 발생하는 손실의 전부 또는 일부를 부담할 것을 약속하고 권유하는 행위...(중략)...
2. 제1호 및 제2호의 행위 이외에 유가증권의 발행 또는 매매 기타 거래와 관련하여 투자자의 보호 또는 거래의 공정성을 저해하거나 증권업의 신용을 추락시키는 것으로서 대통령령이 정하는 행위.

「증권거래법시행령」 제36조의3(증권회사등의 금지행위) 법 제52조제3호에서 "대통령령이 정하는 행위"라 함은 다음 각호의 행위를 말한다.

3. 유가증권의 매매 기타 거래와 관련하여 고객에게...(중략)...정당한 사유없이 당해 거래에서 발생한 손실의 전부 또는 일부를 보전하여 주는 행위.

① 본건 매매거래기간 중 담당직원이 신청인에게 손실보전을 약속하며 매매가 재개된 시점부터 이전과는 달리 매매가 빈번하게 이루어졌는데, 동 기간(2005.4.1.~10.10.) 월 평균 매매회전율이 1,343%, 손실금 대비 수수료 비율이 월평균 61.19%, 미수금발생율이 397.79%에 이르렀던 점.

② 특히 5월, 6월, 9월 매매회전율은 각각 2,065%, 2,530%, 2,251%를 기록하고 있고, 매매거래의 형태는 매수당일 또는 매수익일에 매도하는 단기매매기법이 사용되었던 점 등에 비추어 고객의 이익보다는 회사의 수수료 이익 제고에 편중된 과도한 매매에 해당하는 것으로 판단됨.

비록 담당직원은 신청인의 요구에 의하여 계좌를 운용하여 투자원금을 회복하라는 취지의 일임을 받았다고 하더라도 손실보전각서는 증권거래법상 그 효력을 인정할 수 없으므로 이후의 과도한 일임매매의 위법성이 치유될 수 없고, 신청인 역시 향후 과도한 일임매매에 대한 손해배상청구권을 포기한 것으로 볼 수 없음.

(4) 손해배상액 산정

과당매매가 인정되는 기간(2005.4.1.~2005.10.10.)의 투자손실금은 금 3,354,423원⁵²⁶⁾임. 다만, 본질적으로 주식거래는 여러 불확정요소에 의한 위험성을 동반할 수밖에 없는 것이어서 투자자로서는 자신의 투자로 인해 발생할지 모르는 손실을 스스로 부담함이 원칙이고, 신청인은 증권거래경험이 있는 자로서 거래내역서를 통하여 빈번한 거래 및 수수료 상황을 인지하고 있음에도 담당직원의 손실보전각서를 믿은 채 동 직원의 과당매매를 그대로 방치하여 자기재산 관리를 소홀히 한 점 등에 비추어 70% 과실상계함.

라. 결론

그렇다면 피신청인은 담당직원의 사용자로서 본건 손해금액에 신청인의 과실을 상계한 금1,006,327원의 배상책임이 인정되고, 신청인의 나머지 청구는 이를 기각함.

526) 투자손실금 계산식 : 4,902,353원(2005.3.31.잔고) - 1,547,930원(2005.12.28.잔고) = 3,354,423원

4-10 단기매매에 주력하는 등 과당매매로 인한 손해배상책임 유무

[일부인용] 담당직원이 일임 받을 당시 신청인에게 투자금의 50%는 우량주를 매입하여 장기 보유하고, 나머지는 단기매매를 하는 방법으로 운영하겠다고 하였음에도 실제로는 대부분의 투자금을 단기매매로 운영하였으며, 거래내역상 투자원금보다 많은 16,845,202원이 거래비용으로 지급되었고, 손실금액 대배 수수료가 144%, 매매회전율이 거래기간 평균 1,645%에 달하여 과당매매가 인정됨. 다만, 신청인은 거래상황을 알았음에도 거래를 중지시키거나 적극적으로 이익을 제기하지 않았는 바, 70%의 과실상계를 함이 타당함.(2007.10.9. 조정번호 제2007-67호)

가. 사실관계

신청인은 2003.4.8. ○○증권(이하 “피신청인”이라 함) △△지점에서 신청인 명의의 주식위탁계좌를 개설하고, 동 지점 직원에게 일임을 하여 거래를 하다가, 2005.5.9. 동 계좌를 ▽▽지점으로 이관하였음.

계좌이관 당시 신청인은 ▽▽지점의 창구 여직원에게 주식을 잘 하는 사람을 소개시켜 달라고 하여 동 지점 담당직원을 소개 받았으며, 이관 당시 위 위탁계좌에는 A기업 주식 8천주⁵²⁷⁾와 예탁금 493,699원이 예탁되어 있었는데, 2005.5.17.경부터 A기업 주가가 계속 하락하자 신청인과 담당직원은 서로 협의하여 2005.5.26.과 2005.5.30. A기업 주식을 모두 매도하였음

담당직원은 2005. 5월말경 신청인의 포괄일임⁵²⁸⁾하에 A기업 주식 매각대금(11,310,295원)과 남아 있던 예탁금을 합한 총 11,803,994원을 가지고 매매를 시작하였는데, 매매를 종료한 2007.5.22. 현재 위탁계좌에는 B기업 주식 310주(평가금액 : 2,824,100원)와 예탁금 13,336원이 남아 있음

신청인은 2005.5.26.~11.18. 담당직원으로부터 전화로 거래내역을 일부 보고 받았으며,

527) 2005.5.9. A 종가(4,510원) 기준 평가금액은 36,080,000원임.

528) 담당직원은 신청인에게 투자원금의 반은 우량주를 매입하여 장기로 보유하고, 나머지 반은 2~3일 정도에서 단기로 매매를 하여 운영을 하겠다고 하였음.

2005.6.~2007.5. 총 16회에 걸쳐 피신청인이 보낸 거래내역서를 수령하여 손익 여부를 확인하였고, 손실이 발생한 때에는 담당직원을 찾아가 항의를 하였으나, 손실을 만회하겠다는 담당직원의 말에 계속 일임을 유지하였음.

나. 당사자 주장

(1) 신청인 주장

신청인은 담당직원이 투자금의 50%는 우량주로, 50%는 단기매매로 운영하여 10~20%의 수익을 내 주겠다고 하여 일임을 하였으나, 담당직원은 투자금의 대부분을 우량주가 아닌 다른 주식으로 단기매매를 하여 손실을 발생시켰는 바, 피신청인은 신청인의 위탁계좌를 강서지점으로 이관할 당시의 동 계좌에 있던 주식등의 평가금액을 기준으로 하여 발생한 손해액 33,736,263원을 배상할 책임이 있음.

(2) 피신청인 주장

매매기간 중 신청인과 담당직원 사이의 통화내용에 대한 녹취록에 따르면 신청인은 담당직원과 상담매매 및 일임매매를 하였으며, 피신청인의 월간잔고내역 통보 및 담당직원의 매매보고 등을 통해 모든 거래사실을 알고 있었는 바, 피신청인에게는 손해배상 책임이 없음.

다. 위원회 판단

◆ 본건의 쟁점은 피신청인의 담당직원이 과다한 주식매매 등을 하여 고객보호의무를 위반하였는지 여부라 할 것임.

(1) 고객보호의무 위반으로 인한 손해배상책임 성립 여부

포괄적 일임매매 약정이 있는 경우에도 증권회사의 직원이 고객에 대하여 선량한 관리자로서의 주의의무(충실의무)를 위반하여 고객의 이익을 무시하고 회사의 영업실적만을 증대시키기 위하여 무리하게 빈번한 회전매매를 함으로써 고객에게 손해를 입힌 경우에는 불법행위가 된다고 할 것이며, 증권회사의 직원이 과당매매행위를 한 것인지의

여부는 고객 계좌에 대한 증권회사의 지배여부, 주식 매매의 동기 및 경위, 거래기간과 매매횟수 및 양자의 비율, 운용액 및 운용기간에 비추어 본 수수료액의 과다 여부등 제반 사정을 참작하여 주식 매매의 반복이 전문가로서의 합리적인 선택이라고 볼 수 있는지 여부를 기준으로 판단하여야 함.

다음과 같은 점에 비추어 담당직원의 고객보호의무 위반이 인정된다 할 것이므로, 피신청인은 담당직원의 사용자로서 신청인에 대하여 손해배상 책임이 있다 할 것임.

① 담당직원은 처음 일임을 받을 당시 신청인에게 투자금의 50%는 우량주를 매입하여 장기보유하고, 나머지는 단기매매를 하는 방법으로 운영하겠다고 하였음에도 실제로는 이와 다르게 거의 대부분의 투자금을 단기매매로 운영하였다는 점

② 포괄적 일임을 받아 신청인 계좌에 대하여 사실상의 지배권을 행사하고 있었던 담당직원의 2005.5.27.~2007.5.22. 사이의 매매거래내역을 살펴보면, 투자원금보다 많은 16,845,202원이 거래비용으로 지급되었으며, 손실금액 대비 수수료율이 144%, 매매회전율이 거래기간 평균 1,645%(특히 2005.6.~2005.12.은 최대 2,045%에 달함)이며, 거래의 상당부분이 매수(또는 매도)한 2~3일 내에 매도(또는 매수)되었는데, 이러한 단기매매는 거래수수료와 거래세액을 공제하면 고객에게는 거의 이익이 없거나 오히려 손해가 발생할 정도로 가격 상승이 소폭인 수익성 없는 거래행위가 대부분이었음.

(3) 손해배상액 산정

신청인은 위탁계좌를 강서지점으로 이관할 당시에 동 계좌에 있던 A기업 주식 8천주에 대한 평가금 36,080,000원을 기준으로 손해금액을 산정하여야 한다고 주장하나, 녹취록과 문답서에 따르면 A기업 주식은 가격이 하락하자 당사자의 협의로 담당직원이 매도주문을 낸 것일 뿐, 실제 담당직원이 일임과정에서 운영을 하였던 것은 아니므로 A기업 주식 매도에 따른 손실은 손해금액에 포함되지 않는다고 할 것인 바, 신청인의 손해금액은 A기업 주식 매도 후 담당직원이 거래를 시작한 시점의 예탁금액 11,803,994원에서 거래를 종료한 시점의 예탁금액 2,837,436원을 차감한 8,966,558원이라 할 것임.

다만, 신청인은 2003년경부터 위탁계좌를 개설하여 주식투자를 한 경험이 있는 자로서 주식거래의 위험성을 상당 정도 인지할 수 있었음에도 담당직원에게 주식거래를 포괄적

으로 일임하였고, 잔고내역통보서나 담당직원의 전화보고를 통해 거래상황을 알았음에도 거래를 중지시키거나 적극적으로 이의를 제기하지 않았는 바, 신청인에게 이러한 자기재산 관리 소홀에 따른 과실을 물어 70%의 과실상계를 함이 타당함.

라. 결론

그렇다면 피신청인은 신청인에게 손해금액 2,689,967원을 배상할 책임이 있어 이를 인용하고, 신청인의 나머지 청구는 이유 없어 기각함.

4-11 고령자에 대한 부당 매매권유, 과당매매 등으로 인한 손해배상책임 유무

[일부인용] 신청인은 고령(90세)에다 난청으로 유선상 의사소통이 어려워 담당직원의 매매권유에 대한 충분한 투자판단이 이루어졌다고 보기 어렵고, 신청인이 신용거래를 포함하여 무리하게 과도한 매매거래를 할 특별한 필요성을 인정하기 어려우며, 녹취록상 담당직원이 계좌에 대한 사실상의 지배로 볼 수 있는 영향을 미치고 있다고 보이는 점, 신청인의 계좌는 총 2,098회 857억원 상당(신용거래 포함)의 거래가 이루어졌고, 월평균 매매회전율이 758%에 이르며 피신청인 감사실로부터 과당매매권유 소지 계좌로 선정된 사실까지 있는 점, 담당직원의 전체 수수료 수익 중 신청인 계좌로 발생된 수수료가 63.5%를 차지하고 있는 점 등에 비추어 담당직원의 고객보호의무 위반이 인정됨.(2008.11.11. 조정번호 제2008-88호)

가. 사실관계

신청인은 1999년부터 피신청인의 위탁계좌를 이용하여 매매거래를 하던 중, 2004.10월 경 피신청인의 △△지점에서 피신청인의 직원 A(이하 “담당직원”이라 함)를 알게 되었고 이후 2006년 4월경까지 담당직원이 동 계좌를 관리함.

담당직원이 2006.4월 ▽▽지점 지점장으로 인사이동한 후, 신청인도 관리점을 동 지점으로 변경하였으나, 초기에는 담당직원이 관리하고 이후 다른 영업직원이 관리함.

2007.4월 담당직원은 ○○지점으로 인사이동되었고, 신청인은 담당직원의 권유에 의해 2007.4.2. ○○지점으로 계좌이관을 하였으며, 이후 담당직원이 동 계좌를 관리함. 이관

당시 위 위탁계좌에는 예수금 4,739,796원, B기업 주식 등 13종목 평가금액 513,200,000원, 합계 517,939,796원 상당이 예탁되어 있었음.

2007.6.15. 담당직원은 신청인에게 신용거래계좌 개설을 권유하고, 이후 신용거래를 행하였으며, 담당직원의 매매가 종료된 2008.6.11. 기준, 동 계좌 평가금액은 91,057,442원으로, 신청인은 동 기간 매매결과 손실을 입음.

나. 당사자 주장

(1) 신청인 주장

담당직원은 신청인이 난청이며, 나이가 많아 주식매매에 있어 판단력이 떨어진 상태임에도 불구하고 부당하게 매매 및 신용거래를 권유하였고, 이를 계기로 일임계좌에 대해 과당매매를 한 결과 손해가 발생하였으므로 피신청인은 담당직원의 사용자로서 신청인에 대하여 손해배상 책임이 있음.

(2) 피신청인 주장

신청인은 주식투자 경험이 상당한 상주고객으로 주식투자 및 신용거래의 위험성을 충분히 알고 있었다 할 것이고, 신청인 계좌의 매매는 포괄일임을 받은 담당직원이 과당매매를 한 것이 아니라, 신청인과 담당직원의 상담을 통해 이루어진 정상적인 매매에 해당하므로 피신청인에게는 손해배상 책임이 없음.

다. 위원회 판단

◆ 본건의 쟁점은 피신청인의 담당직원이 부당하게 매매를 권유하였는지 여부, 이에 따른 과다한 주식매매 등을 하여 고객보호의무를 위반하였는지 여부라 할 것임.

(1) 고객보호의무 위반으로 인한 손해배상책임 성립 여부

증권회사 직원이 고객의 투자목적, 재산상황 및 투자경험 등에 비추어 부당한 거래를 권유하거나, 고객에 대하여 선량한 관리자로서의 주의의무(충실의무)를 위반하여 고객의

이익을 등한시하고 무리하게 빈번한 회전매매를 함으로써 고객에게 손해를 입힌 경우 불법행위가 된다고 할 것이며, 과당매매행위를 한 것인지의 여부는 고객 계좌에 대한 증권회사의 지배여부, 주식 매매의 동기 및 경위, 거래기간과 매매횟수 및 양자의 비율, 매입주식의 평균적 보유기간, 매매주식 중 단기매매가 차지하는 비율, 동일 주식의 매입·매도를 반복한 것인지, 운용액 및 운용기간에 비추어 본 수수료액의 과다 여부, 손해액에서 수수료가 차지하는 비율, 단기매매가 많이 이루어져야 할 특별한 사정이 있는지 등 제반 사정을 참작하여 주식 매매의 반복이 전문가로서의 합리적인 선택이라고 볼 수 있는지 여부를 기준으로 판단하여야 함.⁵²⁹⁾

피신청인은 신청인계좌의 매매는 포괄일임을 받은 계좌에서의 과당매매가 아니라 신청인과 담당직원간의 상담을 통하여 이루어진 정상적인 매매이므로 손해배상책임이 없다고 주장하나, 증권회사는 고객이 부담하는 수수료, 고객의 재산상태나 투자목적, 고객의 투자지식이나 경험에 비추어 당해 고객이 주식매매거래에 수반되는 위험을 잘 이해하고 있는지 여부, 개별 매매거래 권유내용의 타당성 등을 감안하여, 일반고객을 대상으로 빈번하거나 과도한 규모의 주식매매거래를 권유하여서는 안될 뿐만 아니라(『증권업감독규정』 제4-14조), 과당매매로 인한 불법행위 책임은 위탁계좌의 성격 내지 동 계좌에 대한 증권회사의 실질적인 지배여부를 본질로 하는 것으로, 반드시 명시적인 일임계약을 요한다거나 고객과 담당직원간의 형식적인 상담이 있었다는 사정만으로 이에 대한 책임을 면한다고 보기 어렵다 할 것임.⁵³⁰⁾

한편, 다음과 같은 점에 비추어 담당직원의 고객보호의무 위반이 인정되므로, 피신청인의 책임이 있다 할 것임.

① 피신청인은 매매건에 대해 신청인의 승인을 받은 정상매매라고 주장하고 있고, 신

529) 대법원 2007.4.12. 선고 2004다4980 판결 참조.

530) 참고로 미(美)법원이나 SEC의 경우, 일임계좌가 아니더라도 증권사 직원의 권유의 결과로서 과도한 거래가 발생하는 경우 과당매매를 인정할 수 있고, 고객이 직원의 권유에 기꺼이 따름에 기하여 직원이 거래를 결정하고, 과당매매에 의해 고객의 신뢰를 악용하는 경우 불법행위가 성립될 수 있으며, 고객계좌에 대한 지배여부는 고객의 전문성, 고객이 직원에게 부여한 신뢰, 직원이 거래를 유인했는지 여부, 고객이 직원의 추천을 신뢰하고 통상적으로 이를 따랐는지 여부, 고객의 독립적인 판단여부 등을 고려하여 결정할 수 있다는 입장임(Mihara v. Dean Witter 619 F.2d 814(9th Cir. 1980)등 참조).

청인 또한 주식투자경험이 상당한 상주고객으로, 일부 매매주문은 신청인에 의하여 이루어지고 있으며, 신청인과 담당직원과의 상호연락이 있었던 점으로 보아 동 직원의 계좌 지배를 단정적으로 말할 수 없는 측면이 있으나, 신청인은 고령(90세)에다 난청으로 유선상 의사소통이 어려워 담당직원의 매매권유에 대한 충분한 투자판단이 이루어지고 있다고 보기 어렵고, 신청인의 연령 등 제반 상황에 비추어 신청인이 신용거래를 포함하여 무리하게 과도한 매매거래를 할 특별한 필요성을 인정하기 어려우며 녹취록⁵³¹⁾의 전체적인 맥락에 비추어 볼 때, 신청인이 독자적인 투자판단을 하고 있다기보다 담당직원의 의견을 신뢰하여 직원의 매매권유를 추종하고 있는 것으로 보이며, 더욱이 신청인이 상주 고객임에도 불구하고 담당직원은 특별한 사유 없이 신청인이 객장에 나오기 전에 유선상 매수, 매도를 빈번히 권유하고 있는 점 등에 비추어 담당직원이 계좌에 대한 사실상의 지배로 볼 수 있는 상당한 영향을 미치고 있다고 보이는 점.

② 담당직원이 계좌관리인이 아닌 2002.7월부터 2004.9월까지 월평균 매매회전율은 약 12%로 매매거래가 극히 미미한 수준이었으며, 2006.5월부터 2007. 3월까지 매매회전율은 57%에 불과했음에 반하여, 담당직원이 계좌를 관리한 2007.4.3.부터 2008.6.11. 기간 중 신청인의 계좌는 총 2,098회(영업일 기준으로 7.1회/일)의 매매거래를 통해 총 857억원 상당(신용거래 383억원 포함)의 거래가 이루어졌으며, 월평균 매매회전율이 758%에 이르고, 특히, 2007.10월중 매매회전율은 1651%, 11월 1577%, 12월 1023%, 2008.4월의 경우 1142%에 이르며, 이로 인하여 2007.11월에는 피신청인 감사실로부터 과당매매거래 권유소지계좌로 선정된 사실까지 있는 점.

③ 신청인의 거래경향, 연령, 자산 등에 비추어 무리한 자산운용의 필요성이 인정되기 어렵다고 보임에도, 담당직원은 2007.6.15. 신청인에게 신용거래계좌개설을 권유하고, 총 383억원 상당의 신용매매거래를 일으켜 거래규모를 확대하고 있는 점.

④ 동 기간 중 거래로 인하여 484백만원 상당의 손실이 발생하였는 바, 이 중 수수료가 428백만원 상당(88%)에 이르고, 수수료를 포함한 거래비용이 583백만원 상당을 차지하는 점.

531) 상주고객인 관계로 일부 유선통화 녹취록만 제출되었고, 객장내 구체적 상담내용에 관하여는 명확한 자료가 없음.

⑤ 단기매매를 주로 일으킬 특별한 사정이 보이지 아니함에도 매입한 주식을 3영업일 이내에 처분한 횟수가 총 1,217회의 매도거래 중 605회(71회는 당일 매매)를 차지하며, 거래금액은 27,818백만원이고 이로인한 거래비용(수수료 포함)이 약 2.3억원에 이르는 점.

⑥ 담당직원의 전체 수수료 수익 중 신청인 계좌로 발생한 수수료가 63.5%를 차지하며, 2007. 10월부터 2008년 1월 까지 발생한 수수료의 경우, 전체 수수료의 80%를 초과하고 있는 점.

참고로, 피신청인은 상담을 통한 정상적인 협의매매 및 투자종료를 권유한 사실이 있음을 주장하며 손익종합평가내역서상 확인서명을 받은 사실, “매매시 사전동의사실 확인서”, “주식투자종료 권유사실 확인서” 등을 제시하고 있으나, 손익종합평가내역서 확인은 손실이 본격적으로 발생한 2007.11월 말경에 이르러 행해진 것이며, 2008.2월경 감사실의 지적을 받기 이전에는 매매주문표 없이 거래가 이루어 졌고, 이후 주문표 작성도 장마감후 일괄적으로 작성된 것으로 보이며, 기타 서류도 2008.2월 경에야 작성되었으며, 2건의 주식투자종료권유사실에 대해서는 신청인이 이를 부인하여 서명날인을 하지 않았을 뿐만 아니라, 위에서 언급한 전체적인 매매행태 등에 비추어 피신청인의 주장을 인정하기 어려움.

(2) 손해배상액 산정

신청인의 손해금액은 484,626,742원 상당⁵³²⁾이라 할 것임. 다만, 담당직원의 고객보호 의무위반이 인정되나, 다음과 같은 점을 고려하여 신청인의 과실비율을 산정함이 타당한 것으로 보임.

① 신청인은 상당한 기간의 주식투자경험을 가진 상주고객으로 주식거래의 위험성을 어느 정도 인지할 수 있었다고 보이는 점.

② 담당직원과 상당기간 주식거래를 하였으며, 일부 매매는 신청인에 의해 이루어지고 있는 것으로 보이며, 담당직원이 사실상 계좌지배를 하였다고 하더라도 담당직원과 신청

532) 담당직원이 ○○지점에서 신청인의 계좌를 관리한 시점의 평가금액 517,939,796원 + 입금 635,400,704원 - 출금 577,656,316원 - 거래종료 시점의 평가금액 91,057,442원.

인간 사전·사후 유선통화 등을 통하여 거래가 이루어졌던 점에 비추어 통상적인 일임의 경우보다는 신청인의 과실이 크다고 보이는 점.

③ 신청인은 2005.10.24. 유가증권 종합대출약정을 체결한 바 있고, 2005.11.16. 신청금액을 50백만원에서 100백만원으로 증액하여 주식거래를 한 사실이 있으며, 신용계좌 개설신청서에 자필서명하고 있는 점.

④ 신청인이 과거 기자생활을 한 사회적 경력이 있는 점.

⑤ 본질적으로 투자자는 자신의 판단과 책임으로 투자하여 투자손실을 스스로 부담함이 원칙으로, 잔고확인서·거래내역통보서나 담당직원과의 유선통화 등을 통해 거래상황을 확인하고 거래를 중지시키거나 적극적으로 이의를 제기할 수 있었을 것임에도 불구하고 비교적 큰 금액을 투자하면서도 자기재산 관리를 소홀히 한 과실을 물어 50%의 과실상계를 함이 타당함.

라. 결론

그렇다면 피신청인은 신청인에게 손해금액 484,626,742원에서 신청인의 과실 50%를 상계한 나머지 금액 242,313,371원을 배상할 책임이 있어 이를 인용하고, 신청인의 나머지 청구는 이유 없어 기각함.

제5장

전산장애, 사무처리 오류 등

제1절 전산장애

5-1 전산장애로 예수금을 초과하여 매수한 경우 손해배상액 산정기준

[일부인용] 위탁매매인인 증권회사는 선량한 관리자의 주의로써 위탁사무를 처리할 의무가 있는 바, 전산·통신설비의 장애로 말미암아 고객의 주문을 부적절하게 처리(예수금 초과매수)한 때에는 고객에 대하여 주의의무 위반에 따른 손해배상책임이 있음. 그러나 고객도 옵션매수 이후 옵션 매수가격 보다 고가로 매도를 주문하는 등 운용한 사실이 있으므로 손해배상금액은 예수금 초과분만큼 반대매도됨으로써 발생한 손실액과 동 매매와 관련된 수수료를 합한 금액으로만 봄이 타당함.(1999.7.20. 조정번호 제1999-28호)

가. 사실관계

신청인은 1999.2.22. ○○증권사(이하 “피신청인”이라 함)의 전산장애로 인하여 그 직원에게 비상단말기로 “풋옵션 65” 계약을 매수주문하고, 전산시스템이 복구된 후 다시 풋옵션 매수주문을 함. 이때 직원은 전산장애로 인한 비상주문사실을 인식하고 있었으나 단말기에 나타난 주문가능 수량(132계약)만큼 매수주문을 입력함으로써 예수금을 초과하여 152계약이 매수 체결됨.

이후 신청인은 매수된 풋옵션(152계약)을 매수가보다 높은 가격으로 다시 매도하는 주문을 하였으나 체결되지 않았고, 피신청인은 1999.2.23 및 2.24 예수금 초과분(31계약)을 매도함. 잔여 풋옵션(121계약)은 옵션만기일인 1999.3.11. 가치가 없어짐.

나. 당사자의 주장

(1) 신청인의 주장

옵션거래는 예수금범위내에서만 매매주문을 할 수 있으나 피신청인의 전산장애와 직원의 주문수량 계산착오로 인하여 예수금범위를 초과하여 풋옵션을 매수하였으므로 이로 인한 손해(약 25백만원)를 배상하여야 함.

(2) 피신청인의 주장

직원은 비상매수주문 후 체결확인이 되지 않은 상태에서 신청인이 주문가능한 수량만큼 매수해 달라고 하므로 단말기상 132계약이 주문가능함을 신청인에게 확인시킨 후 매수하였기 때문에 예수금을 확인하지 않았다 하여 신청인의 자발적 의사에 의한 주문이 무효가 되는 것은 아님.

또한 신청인이 예수금을 초과한 주문을 한데 대하여 위험축소를 위해서 청산을 권유하였음에도 불구하고 신청인은 매수한 풋옵션을 팔지 않아 손실이 확대되었으며 그 후에도 정상적인 거래를 계속한 점 등에 비추어 신청인의 손해배상청구는 타당성이 없음.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 전산장애와 관련하여 증권회사의 주의의무 위반 여부라 할 것임.

(1) 옵션거래 업무처리와 관련한 주의의무 위반 여부

『증권회사의선물·옵션거래업무에관한규정』 제7조(매매주문의 공정처리) 제2항에서는 “증권회사는 전산·통신설비의 장애로 말미암아 고객주문의 처리가 불가능 또는 부적절하게 되는 사태등이 발생되지 않도록 합리적인 대책을 수립하여야 한다”고 규정하고 있음. 즉 주가지수 옵션거래에 있어 위탁매매인인 증권회사는 선량한 관리자의 주의로써 위탁사무를 처리할 의무가 있는 바, 전산·통신설비의 장애로 말미암아 고객의 주문을 부적절하게 처리한 때에는 고객에 대하여 주의의무 위반에 따른 손해배상책임이 있음.

신청인과 담당직원에 대한 문답조사, 신청인 계좌의 거래내역서 및 입출금내역서, 주문표, 전산오류발생경위서 등을 토대로 조사한 결과, 1999.2.22. 신청인계좌에서 이루어진 예수금 초과부분의 매매는 당일 오전 9시이전 신청인으로부터 주문을 받아 피신청인의 금융공학팀에 비상주문처리를 한 직원이 신청인의 예수금을 제대로 확인하지 않아 발생

한 것이므로, 이로 인하여 발생한 손해에 대하여 피신청인은 배상책임이 있다고 판단됨.

(2) 손해배상금액 산정기준

신청인은 전산장애 및 직원의 부주의로 본인이 원하지 아니하는 “풋옵션 55” 132계약이 체결되었고, 이후 KOSPI 200의 상승으로 동계약 전부가 권리소멸함에 따라 발생한 손실 25백만원에 대한 손해배상을 주장하고 있으나, 1999.2.22자 비상주문내역 및 전산주문표 등을 통하여 볼 때 신청인은 풋옵션을 매수할 의사가 있었음이 확인되고, 또한 전산주문표를 조사한 결과 확인된 당일 매수된 “풋옵션 55” 매수가격보다 고가로 매도주문한 사실 등(각각 200천원과 193천원으로 매수된 것을 210천원으로 매도할 것을 주문)을 볼 때 매수이후에 “풋옵션 55”를 운용한 사실이 확인되므로 신청인이 주장하는 손해배상금액은 이를 그대로 인정하기 어려움.

따라서 피신청인이 신청인에게 배상하여야 할 손해금액은 예수금을 초과하여 매수된 “풋옵션 55”를 예수금 부족사유로 1999.2.23 및 2.24 피신청인에 의해 매도됨에 따라 발생한 손실액과 동 매매와 관련된 옵션매매수수료를 합한 2,154,440원으로 봄이 타당함.

라. 결 론

피신청인의 직원이 옵션거래업무 처리시 고객예수금 확인을 소홀히 한 사실이 인정되므로, 피신청인은 이러한 주의의무 위반으로 인하여 발생한 손해액 금2,154,440원을 신청인에게 지급하여야 함.

5-2 전산장애로 주문이 체결되지 아니한 경우 손해배상금액 산정기준

[일부인용] 전산장애로 인한 손해배상이 이루어지기 위하여는 주문이 체결가능한 호가이어야 하고, 장애 종료후 동일종목의 매도나 매수의 계속된 의사로 매도매수주문을 하여 결과적으로 불리한 가격에 주문이 체결됨으로써 고객이 추가적 비용을 지불하였어야 할 것임. 한편 전산장애가 발생하였어도 실제로 동 종목을 매수매도한 사실이 없는 가운데 단순히 거래하지 못한 주식의 가격이 유리하게 되었다고 하는 등의 기회비용 내지 손해는 특별한 사정으로 인한 손해라고 할 것임.(2003.10.7. 조정번호 제2003-48호)

가. 사실관계

2003.1.20. 신청인은 ○○증권회사(이하 “피신청인”이라 함)로 신청인 명의의 위탁계좌를 이관하고, HTS를 통하여 매매를 하여 왔음.

2003.5.28. 09:12경 피신청인의 DR센터 데이터 복제처리용 LHOB(라인핸들러) 프로그램 장애로 전산주문시스템의 메인센터 HOST 시스템 CPU(#4)에서 과부하가 발생하였음. 결국 이러한 장애는 전반적인 CPU 과부하로 이어져 코스닥주문프로세스 8개중 4개 프로세스가 지연처리 되었으며, 이후 이에 따른 데이터 급증으로 인하여 피신청인 주문 시스템 전체에 장애가 발생하여 모든 주문에 대한 처리업무가 마비되었고, 이러한 장애 상태는 10:03경까지 계속되었음.

위 장애발생 시간부터 종료시까지 신청인은 아래와 같은 주문을 낸 사실이 있으며, 이 중 실제 전산장애 종료 후 당일 체결된 거래내역은 A기업 5,000주 매수로서 체결가는 1,660원임.

장애발생 시간중 신청인의 주문 현황

매 수					매 도				
시간	종목	수량	가격	비고	시간	종목	수량	가격	비고
09:16:59	A기업	2,000	1,660		09:14:28	D기업	200	23,450	
09:18:32	B기업	2,000	13,050		09:32:18	E기업	100	71,200	
09:20:30	B기업	2,000	12,900		09:34:24	E기업	100	71,200	
09:25:11	A기업	2,000	1,670		09:41:44	F기업	200	130,000	
09:27:34	A기업	2,000	1,680		09:50:18	G기업	500	16,450	
09:30:35	A기업	2,000	1,670		10:03:50	H기업	250	16,450	
09:38:57	C기업	100	44,650						
10:00:04	A기업	2,000	1,630						

나. 당사자의 주장

(1) 신청인의 주장

2003.5.28 위와 같이 매매주문을 내었으나 동 매매가 처리되지 않아 손해가 발생하였음. 이에 피신청인 전산시스템에 남아 있는 자신의 주문에 대한 기술적 사실여부를 공개

하여야 하며, 전산장애로 인한 손해배상은 장애시간대의 가장 유리한 가격으로 산정되어야 함.

(2) 피신청인의 주장

전산장애가 발생한 사실에 대하여는 다툼이 없음. 따라서 금융감독원의 행정권고에 따라 내부적으로 만든 보상기준에 따라 지급할 용의는 있음. 그러나 신청인이 주장하는 것처럼 장애시간대의 가장 유리한 가격으로 손해를 배상하는 것은 합리적이지 못한 것이므로 신청인의 손해배상청구를 인정할 수 없음.

다. 위원회의 판단

◆ 본건에 있어서의 쟁점은 전산장애시 매매주문 불이행에 따른 손해배상액 산정과 피신청인 내부 손실보상기준에 따른 손실액의 산정 그리고 양자의 관계 등이라고 할 것임.

(1) 전산장애시 손해의 개념 및 배상액 산정

전산장애시의 손해배상에 있어 손해란 결국 민법상의 채무불이행 내지는 불법행위손해에 따른 개념이라고 할 것임. 이러한 손해배상의 범위에 있어 민법 제393조와 제763조는 통상의 손해를 그 한도로 하며, 특별손해의 경우에는 채무자나 가해자가 그 사정을 알았거나 알 수 있었던 경우에 한하여 배상한다고 규정하고 있음.

따라서 본건 전산장애시 매수·매도주문의 불이행에 따른 통상손해는 전산장애가 없었더라면 체결될 수 있었던 매수·매도 호가임에도 전산장애로 인하여 동 주문이 증권거래소에 호가가 접수되지 못해 결국 전산장애가 종료한 후 다시 동종의 종목을 매수·매도하는데 지출된 추가적 비용이라고 할 것임. 결국 전산장애상태에서의 손해배상이 이루어지기 위하여는 주문이 체결 가능한 호가이어야 하며, 장애 종료 후에 동일종목의 매도나 매수의 계속된 의사로 매도·매수주문을 하여 결과적으로 더 불리한 가격에 주문이 체결됨으로써 고객이 추가적 비용을 지불하였어야 할 것임.

나아가 전산장애가 없었다면 동 주식을 전매도·환매수 함으로써 얻을 수 있었던 이득 또는 전산장애가 발생하였어도 실제로 동 종목을 매수·매도한 사실이 없는 가운데

단순히 매수·매도하지 못한 주식의 가격이 유리하게 되었다고 하는 등의 기회비용 내지 손해는 특별한 사정으로 인한 손해라고 할 것임.⁵³³⁾

원래 주식은 가격변동을 예견하는 일 자체가 매우 곤란한 것이어서 증권회사가 전산장애를 일으켰을 당시 그와 같은 특별한 사정을 알았거나 알 수 있었고, 또 고객이 주식의 가격이 올랐을 때 주식을 매도하여 그로 인한 이익을 확실히 취득할 수 있었던 경우에 한하여 고객은 그와 같이 오른 가격에 의한 손해배상을 청구할 수 있을 뿐임.

신청인이 전산장애시 낸 매수주문 중 A기업의 경우는 장애 종료후 1,660원에 5천주가 체결되었는 바, 09:16:59, 09:25:11, 09:27:34, 09:30:35의 매수주문은 전산장애 종료 후의 체결가인 1,660원보다 같거나 불리한 주문으로서 신청인이 본 손해가 없으며, 10:00:04의 매수주문은 호가가 1,630원으로서 전산장애 종료후의 체결가보다 유리하기는 하나, 동종목의 주문체결내역을 보면, 1,630원은 당일 거래에서 그 체결가능성이 없는 것으로 밝혀 손해가 없다고 할 것임.

다음으로 F기업 매도주문의 경우 전산장애가 종료되고 난 다음 날에 매도가 된 사실은 있으나, 매도주문의 체결가가 130,000원 1백주, 130,500원 2백주, 131,500원 1백주, 132,500원 1백주로서 전산장애시의 주문호가보다 같거나 유리하게 가격이 체결되어 손해가 없다고 할 것임.

나아가 신청인이 전산장애시 주문한 나머지 주식은 그 후 매매가 체결된 사실이 없어 통상손해는 없다 할 것임. 결국 신청인은 전산장애 기간 중 가장 유리한 가격을 적용하여 손해를 배상하여야 한다거나 전매차익을 주장하는 것은 특별손해에 대해 그 배상을 요구하는 것이나, 단순히 체결 가능한 로그파일의 존재만으로는 특별손해를 인정하기 부족하고 달리 증거가 없는 이상 신청인의 이 부분 청구는 이유 없다고 할 것임.

(2) 피신청인 손실보상기준에 따른 보상여부

1) 손실보상기준

위에서 본 피신청인의 손해배상책임과는 별도로 피신청인은 전자금융사고예방을 위해

533) 대법원 1995.10.12. 선고 94다16786 판결 참조

금융감독원이 행정권고를 한 “전자금융거래 안전성제고를 위한 유의사항”에 따라 피신청인 스스로 별지목록 기재 보상기준을 정하여 고객의 손실을 전보하고 있음.

동 보상기준을 보면 신청인의 매도주문 중 체결이 가능하였던 종목에 대하여 전산장애가 종료한 이후의 가격을 비교하여 동 종목의 가격이 하락한 경우 그 차액을 보상하는 것으로 되어 있는 바, 아래와 같이 매도주문 중 체결 가능한 주문의 매도주문 가격에서 장애종료시점의 가격의 차에 주문수량을 곱한 금액인 170,000원이 보상액으로 산정된다고 할 것임.

보상액 산정 내역

시간	종목	주문수량	주문가격	장애종고가	장애종료시가	보상금액
09:14:28	D기업	200	23,450	23,450	23,100	70,000
09:32:18	E기업	100	71,200	71,300	70,700	50,000
09:34:24	E기업	100	71,200	71,300	70,700	50,000
09:50:18	G기업	500	16,450	16,450	16,450	0
계						170,000

2) 손실보상기준과 손해배상액의 관계

피신청인의 손해배상책임과 위 손실보상기준에 따른 보상액의 관계에 있어서는 당 위원회의 조정기능을 감안하고 전자금융거래에 있어 안전성과 신뢰성을 확보하기 위한 금융회사의 주의를 촉구하는 의미에서 손해배상책임에 따른 손해배상액과 손실보상기준에 따른 보상액 중 그 액수가 많은 금액을 고객에게 지급함이 타당하다고 판단됨.

따라서 피신청인은 신청인에게 피신청인의 손실보상기준에 따른 금원을 지급할 책임이 있음.

라. 결론

그렇다면 피신청인은 신청인에게 금170,000원을 지급할 의무가 있다 할 것이므로 신청인의 이 부분 청구는 이유 있어 이를 인용하고 신청인의 나머지 청구는 이유 없어 이를 기각함이 타당함.

5-3 HTS 오류로 주문이 실행되지 아니한 경우 손해배상책임 여부

[기각] 매매거래의 위탁을 받은 증권회사는 위탁계약의 본지에 따라 선량한 관리자의 주의를 가지고 행동할 의무를 부담하며 증권회사가 이러한 의무를 위반하여 고객에게 손해가 발생되었다면 증권회사는 이를 배상할 책임이 있다고 할 것임. 특정일자 HTS 이용시 “착오주문 확인”창이 나타난 것은 신청인의 컴퓨터 프로그램에서 오류가 발생하였기 때문이므로 피신청인의 손해배상 책임이 인정되지 않는다 할 것임. 또한 그 몇 개월 후 피신청인의 HTS에서 간헐적으로 고객의 주문 입력이 지연 처리되는 장애가 발생된 것은 사실이나 주문이 제대로 실행되었다 하더라도 신청인이 매수한 콜을 더 높은 가격에 매도하여 이익을 얻을 수 있었을 것이라고 추정하기는 곤란하고, 신청인의 매도주문은 체결가능성이 없었던 것으로 보이는 등 피신청인의 손해배상 책임을 인정하기는 어렵다 할 것임.(2008.2.12. 조정번호 제2008-6호)

가. 사실관계

신청인은 2004.5.19. ○○증권회사(이하 “피신청인”이라 함)에서 신청인 명의의 주식위탁계좌를 개설하고, HTS서비스를 통하여 주식거래를 하여 왔음.

신청인은 2007.7.19. ELW 매수주문시 “착오주문 확인”창이 자주 떠 매매를 할 수 없으며 피신청인에게 문의를 하였고, 피신청인의 직원 A씨는 신청인이 주장하는 오류내용의 캡처파일을 받고 확인 결과 신청인의 컴퓨터에 설치되어 있는 Visual Script Engine에서 Script 해석을 잘못하여 발생한 문제로 Microsoft사 홈페이지에서 Script Engine을 다운로드하여 설치하면 해결된다고 안내하였음.

2007.10.29. 08:01:34~15:00 피신청인의 HTS에서 고객의 주문 입력시 일부 주문건에서 처리지연이 발생하여 주문이 입력되지 않는 현상이 간헐적으로 발생하였는데, 이는 IT-HUB 1단계 작업 적용후(선물/옵션 프로세스 10 → 14개) 메모리 DB에서 과부하가 발생하여 주문 프로세스에서 처리지연이 발생하였기 때문임.

신청인은 같은 날 09:01:04에 △△7366KOSPI200콜 1만개를 600원에 매수주문 하였으나, 코스콤의 장애로 주문이 접수되지 않았음. 이후 신청인은 동 종목에 대하여 09:02:49에 3천개(575원), 09:03:50에 5천개(585원)를 각각 매수주문 하였다가 09:03:56에 동 주문

을 모두 취소하였음.

신청인은 같은 날 10:19:20에 ▽▽7022KOSPI200푼 5천개를 270원에 매수하였음. 이후 10:20경 신청인은 동 종목 5천개에 대하여 275원에 매도주문을 하였는데, 전산장애로 인하여 10:22:10에 매도주문이 처리되었고, 신청인은 동 주문을 10:27:41에 가격을 270원으로 정정하였다가 10:32:29에 취소하였음.

같은 날 ◇◇7004KOSPI200콜과 관련하여, 신청인의 위탁계좌에서 10:36:55에 1백개(985원)의 매도주문이, 10:38:14에 5천개(985원)의 매도주문이, 10:39:13에 2,570개(980원)의 매도주문이 되었고, 이들 주문은 10:38:42와 10:38:43 및 10:39:18에 각각 체결되었음.

신청인은 위 매도주문 후 주문취소를 하고자 하였으나 전산오류로 인하여 취소가 되지 않다가 계약이 체결되어 손실을 입었다며 피신청인에게 이의를 제기하였고, 피신청인은 당일 주문을 하는데 있어 고객에게 불편을 초래하였던 점을 감안하여 신청인이 요구한 37,150원을 2007.11.1. 신청인의 계좌로 입금하여 주었으나, 신청인은 협의했던 금액보다 13,350원이 부족하다며 금감원에 분쟁조정을 신청하였음. 한편, 신청인의 로그기록상 위 매도주문에 대한 취소주문의 내역은 확인되지 아니하였음.

나. 당사자 주장

(1) 신청인 주장

2007.7.19. ELW 매수주문시 착오팝업이 자주 떠 매수시기를 놓쳐 금전적 손실이 발생되었고, 2007.10.29. 거래와 관련하여서는 09:01:04 △△7366KOSPI200콜 매수주문이 접수되지 않았으며, 10:20경에 한 ▽▽7022KOSPI200푼 5천개에 대한 매도주문이 10:22:10에야 처리되었고, 10:36~10:39에 한 ◇◇7004KOSPI200콜 7,670개 매도주문을 이후 취소하려 하였으나 취소주문이 되지 않는 등 피신청인의 전산장애로 인하여 신청인에게 손해가 발생하였는 바, 피신청인은 이를 배상할 책임이 있음.

(2) 피신청인 주장

2007.7.19. 착오주문 팝업창이 뜬 것은 신청인의 컴퓨터에 설치되어 있는 프로그램에서

오류가 발생하였기 때문인데, 피신청인의 담당직원은 이러한 문제를 해결해 주었고, “착오주문 확인”창에서도 “주문전송” 버튼을 누르면 주문은 그대로 실행되므로 매수가 불가능하였던 것은 아니며, 2007.10.29. 간헐적으로 주문입력시 오류가 발생한 것은 사실이나, △△7366KOSPI200콜에 대하여 신청인은 09:01에 한 주문이 접수되지 않은 사실을 인지하고 09:02에 다시 주문하였으며, ▽▽7022KOSPI200풋에 대한 매도주문이 지연되었던 것은 사실이나 당시 주문가격 275원은 체결불가능한 가격이었고, ◇◇7004KOSPI200콜과 관련하여서는 신청인의 로그기록상 취소주문의 내역이 확인되지 않을 뿐만 아니라 피신청인은 원만한 합의차원에서 신청인이 요구한 금액을 이미 지급하였는바, 피신청인은 손해배상 책임이 없음.

다. 위원회 판단

◆ 본건에 있어서의 쟁점은 HTS의 오류로 인해 신청인에게 손해가 발생하였는지 여부라 할 것임.

(1) 피신청인의 손해배상 책임 유무

고객과 계속적인 거래관계에 적용될 기본계약인 위탁매매거래계좌의 설정계약을 체결하여 고객으로부터 자금이나 주식의 위탁을 받고 구체적인 매매주문을 통해 매매거래의 위탁을 받은 증권회사는 위탁계약의 본지에 따라 선량한 관리자의 주의를 가지고 행동할 의무를 부담한다고 할 것이며, 『증권업감독규정』 제4-23조는 “증권회사는 고객으로부터 매매주문을 받은 경우에는 이를 공정하고 신속·정확하게 처리하여야 한다”고 규정하고 있는바, 증권회사가 이러한 의무를 위반하여 고객에게 손해가 발생되었다면 증권회사는 이를 배상할 책임이 있다고 할 것임.

2007.7.19.자 거래와 관련해서는 신청인이 HTS를 이용함에 있어 “착오주문 확인”창이 나타난 것은 사실이나, 이는 신청인의 컴퓨터에 설치되어 있던 프로그램에서 오류가 발생하였기 때문인 바, 피신청인의 손해배상 책임이 인정되지 않는다 할 것임.

2007.10.29.자 거래와 관련해서는 피신청인의 HTS에서 간헐적으로 고객의 주문 입력이 지연 처리되는 장애가 발생된 것은 사실이나, 다음과 같은 점에서 피신청인의 손해배

상 책임을 인정하기는 어렵다 할 것임.

① △△7366KOSPI200콜 관련하여, 신청인이 09:01:04에 입력한 콜 1만개(600원) 매수 주문이 전산장애로 인하여 실행되지 않은 것은 사실이나, 이후 신청인은 09:02:49와 09:03:50에 매수주문을 하였다가 09:03:56에 동 매수주문을 모두 취소한 기록만 있는 바, 09:01:04의 주문이 제대로 실행되었다 하더라도 신청인이 매수한 콜을 더 높은 가격에 매도하여 이익을 얻을 수 있었을 것이라고 추정하기는 곤란하며, 달리 어떠한 손해가 발생하였다고 인정할 만한 자료가 없다는 점.

② ∇∇7022KOSPI200풋 관련하여, 신청인이 10:20경 입력한 매도주문의 매도가는 275원이었으나, 10:19:30~10:33:30 동 종목의 체결가격은 270원을 넘지 않았는 바, 신청인의 매도주문은 체결가능성이 없었던 것으로 보이는 점.

③ ◇◇7004KOSPI200콜 관련하여, 신청인은 10:36~10:39에 한 매도주문을 취소하려 했으나 취소가 되지 않았다고 하나, 로그기록상 취소주문의 내역이 확인되지 않을 뿐만 아니라, 동 매도주문의 체결가격이 985~980원 이었고, 10:36~10:43 동 종목의 시장 전체 체결가격이 대체로 980~985원이었음에도 피신청인이 이미 5원씩을 추가로 산정한 37,150원을 지급하였다는 점.

라. 결론

그렇다면 피신청인은 신청인에 대하여 손해를 배상할 책임이 없다 할 것이므로 신청인의 청구는 이유 없어 이를 기각함.

5-4 전산장애와 관련하여 주장하는 특별손해의 상당 인과관계 유무

[기각] 증권회사의 손해배상책임이 성립하기 위해서는 전산장애로 인한 주문불이행과 손해 사이에 상당인과관계가 있어야 하는데, 신청인은 전산장애가 복구된 이후에 동 종목을 추가적으로 매수한 사실이 없이, 오히려 동 매수주문을 취소하고 있어 신청인에게 통상손해가 있다고 보기 어렵고, 문답서에 의하면, 매수당시부터 주가의 상승을 예상하고 매도를 계획한 것인지 여부에 대해, 신청인도 그렇게까지 오를 줄은 몰랐고 다만 호재가 있어 관심을 갖고

있다가 매수한 것이며 그 같은 내용을 피신청인에게 알린 사실도 없다고 진술하고 있음을 볼 때, 신청인이 주장하는 전매이익의 상실 또는 증가에 따른 손실 등은 특별손해로서 전산장애와 상당인과관계가 있다고 보기 어려움.(2008.10.7. 조정번호 제2008-68호)

가. 사실관계

2008.3.11. 신청인은 ○○증권회사(이하 “피신청인”이라 함)에 신청인 명의 위탁계좌를 이관하고 주식매매를 하여 왔음. 같은 해 6.9. 피신청인이 한전으로부터 공급받는 전원의 이상 과전류 발생으로 전원공급이 중단되었고, 복구과정에서 실수로 전산관련 UPS(무정전 전원공급장치) 전원이 차단되어 09:00~09:23까지 모든 주문매체를 통한 주문이 불가하거나 지연처리되는 전산장애가 발생함.

전산장애 발생시 신청인의 매매주문 및 주가추이는 다음과 같음.

- ① 09:04경, 유선으로 담당직원에게 A기업 주식 5천주를 3,080원에 매수주문 의뢰
- ② 담당직원이 즉시 주문을 입력하였으나, 전산장애로 09:17경 거래소에 접수⁵³⁴⁾
- ③ 09:40경 신청인은 동 주문을 취소하고, 대신 B기업 주식 4백주를 45,950원에 매수

2008.6.9. A기업 주가 추이

시 간	주 가	비 고
09:00	3,100원	시가
09:04	3,085원	매수주문 5천주(주문단가 3,080원)
09:05	3,100원	담당직원과 통화(장애사실 인지)
09:05~09:16	3,065원(최저) ~ 3,100원(최고)	전산장애가 없었다면 체결 가능
09:17	3,085원	매수주문 거래소 접수
09:23	3,100원	전산장애 복구
09:25	3,120원	담당직원과 통화(복구사실 인지)
09:40	3,240원	취소주문
15:00	3,475원	종가

* 시가 3,100원/ 종가 3,475원/ 최고가 3,505원/ 최저가 3,050원

534) 신청인의 매수주문이후 거래소 접수시까지 당해 주식의 체결가가 3,080원 이하로 형성되고 있어 전산장애가 없었다면 동 매수주문은 체결되었을 것으로 판단됨. 한편 신청인은 09:11경, A기업 주식 6천주에 대해 3,050원에 추가 매수주문을 의뢰하였으나 당시에는 전산장애로 주문입력 자체가 불가하였고, 동 주문시각이후 주가가 3,050이하로 하락한 적이 없어 체결가능성이 없음.

한편, 신청인은 2008.6.11. 기보유중이던 A기업 주식 1만주(매수일 6.5. 평균단가 3,240 원)를 4,250원에 매도함.

나. 당사자의 주장

(1) 신청인 주장

전산장애가 없었더라면 A기업 주식 5천주에 대한 3,080원의 매수주문이 모두 체결되었을 것이고, 동 주식을 기 보유 중이던 A기업 주식 1만주와 함께 2008.6.11. 4,250원에 매도하여 585만원의 이익⁵³⁵⁾을 추가로 실현하였을 것임. 한편, 신청인은 피신청인에게 2008.6.9. 종가를 기준으로 1,975,000원⁵³⁶⁾의 손해배상을 청구하였으나 거절당한 바 있음.

(2) 피신청인 주장

전산장애 사실에 대해서는 다툼이 없고, 전산장애가 없었다면 신청인의 매수주문이 체결되었을 것이라고 판단됨. 그러나 피신청인의 “온라인거래 장애발생시 보상기준·절차”상 장애로 인한 보상은 장애시간 중 체결가능했던 주문가격과 장애로 인하여 체결되지 않았던 주문을 장애복구후 고객이 직접 체결시킨 가격에 대한 차액만을 보상하도록 규정하고 있음.

신청인의 경우, 장애가 복구된 09:23경 이후 관련종목이 3,090~3,100원(신청인의 매수주문가 대비 +10~20원)에서 시세를 형성하고 있어 충분히 동 종목의 매수체결이 가능했음에도 불구하고 동 매수주문을 정정하여 체결하거나 추가매수를 하지 않고 오히려 09:40경 매수주문을 취소하여 손실액이 확정되지 않아 동 기준상 손해배상요건을 충족시키지 못함.

또한 민법의 일반원칙상 손해배상은 통상의 손해를 한도로 하는 바, 동 매수주문은 신규 매수주문이고 이로 인한 기회비용의 상실은 예견가능성을 벗어난 특별손실에 해당하므로 손해배상의 범위에 속하지 아니함.

535) 4,250원(6.11. 매도가격) - 3,080원(장애시 체결가능했던 매수가격) × 5,000주

536) 3,475원(장애당일 종가) - 3,080원(장애시 체결가능했던 매수가격) × 5,000주

다. 위원회의 판단

◆ 본건에 있어서의 쟁점은 전산장애시 매매주문 불이행에 따른 손해의 개념 내지 손해배상의 범위라 할 것임.

고객과 증권회사 사이에 계속적인 거래관계에 적용될 기본계약인 주식매매거래계좌의 설정계약과 함께 구체적인 주식의 매매거래에 관한 위탁계약이 체결된 이상 증권회사는 위와 같은 위탁계약의 본지에 따라 고객의 주문을 성실하게 이행하여야 할 의무를 부담하고 이에 위반하여 고객의 주문을 집행하지 아니할 경우 불법행위를 구성한다 할 것이고, 주문불이행의 사유가 당해 증권회사의 전산장애인 경우에도 고객에게 손해가 발생하였다면 증권회사의 책임이 인정된다고 할 것임. 다만 증권회사의 손해배상책임이 성립하기 위해서는 전산장애로 인한 주문불이행과 손해 사이에 상당인과관계가 있어야 할 것임.

손해배상의 범위에 관하여, 민법 제393조와 763조는 통상의 손해를 그 한도로 하며, 특별손해의 경우 채무자나 가해자가 그 사정을 알았거나 알 수 있었던 경우에 한하여 배상하는 것으로 규정하고 있음.⁵³⁷⁾

주식은 가격변동을 예견하는 일 자체가 매우 곤란한 것으로, 전산장애시 매수주문 불이행으로 인한 통상손해는 전산장애가 없었다면 체결될 수 있었던 매수호가 임에도 전산장애로 동 주문이 거래소에 접수되지 못하고 전산장애가 복구된 이후 다시 동종의 종목을 매수하는데 지출된 추가적 비용이라 할 것이고, 전산장애가 발생하였어도 실제로 동 종목을 매수한 사실이 없는 가운데 단순히 매수하지 못한 주식의 가격이 유리하게 되었다고 하는 등의 기회비용 내지 손해는 특별한 사정으로 인한 손해라 할 것임.

판례의 경우도, 주가지수 콜옵션 매수주문을 하였음에도 증권회사의 전산장애로 거래가 이루어지지 않은 사안에서, 주가지수옵션거래는 투기성과 위험성이 필연적으로 수반

537) 「민법」 제393조(손해배상의 범위) ①채무불이행으로 인한 손해배상은 통상의 손해를 그 한도로 한다.

②특별한 사정으로 인한 손해는 채무자가 그 사정을 알았거나 알 수 있었을 때에 한하여 배상의 책임이 있다.

제763조(준용규정) 제393조, 제394조, 제396조, 제399조의 규정은 불법행위로 인한 손해배상에 준용한다.

되는 거래라는 점에 비추어 볼때, 옵션 종목에 관하여 정상적으로 매매거래가 이루어졌다 하더라도 고객이 후에 이를 전매하여 이익을 얻을 수 있었을 것이라고 추정하기 어렵다고 보아 증권회사의 손해배상책임을 인정하지 아니함.⁵³⁸⁾

이에 비추어 볼 때, 신청인의 A기업 주식 5천주에 대한 3,080원의 매수주문이 체결가능한 것이라 할지라도 신청인은 전산장애가 복구된 이후에 동 종목을 추가적으로 매수한 사실이 없고 오히려 동 매수주문을 취소하고 있는 바, 신청인에게 통상손해가 있다고 보기 어렵고, 금감원에서 작성한 문답서에 의하면, 매수당시부터 주가의 상승을 예상하고 매도를 계획한 것인지 여부에 대해, 신청인도 그렇게까지 오를 줄은 몰랐고 다만 호재가 있어 관심을 갖고 있다가 매수한 것이며, 그와 같은 내용을 피신청인에게 알린 사실도 없다고 진술하고 있음을 볼 때, 신청인이 주장하는 전매이익의 상실 또는 종가에 따른 손실 등은 특별손해로서 전산장애와 상당인관관계가 있다고 보기 어려움.

라. 결론

그렇다면 피신청인은 신청인에 대하여 손해를 배상할 책임이 없다 할 것이므로 신청인의 청구는 이유 없어 이를 기각함.

5-5 전산장애로 주식계좌대체 서비스가 중단된 경우 손해배상액 산정기준

[일부인용] 전산장애에 따른 손해배상액 산정은 일반적으로 ‘위법행위가 없었다면 존재하였을 재산상태’에서 ‘위법행위가 제거된 시점의 재산상태’를 공제하는 방법으로 이루어짐. 먼저 위법행위가 없었다면 존재하였을 재산상태와 관련하여, 주식은 수시로 가격이 변하는 것이므로 장애기간 중에 실제 체결된 거래들을 거래량을 고려해서 평균가격을 산정하는 거래량 가중평균가격을 기준으로 보상액을 산정하는 것이 합리적이라고 판단됨. 위법행위가 제거된 시점의 재산상태와 관련해서는, 전산장애 복구시점은 신청인이 주식을 입고 받아 거래할 수 있는 시점임을 고려해 볼 때 신청인 계좌로 계좌대체가 완료된 시점의 현재가를 기준으로 보상액을 산정함이 합리적이라 판단됨. (2011.9.6. 조정번호 제2011-51호).

538) 서울지방법원 1998.9.2. 선고 98가합5079 판결 참조.

가. 사실관계

신청인은 상장예정인 A기업 주식을 장외 매매거래 등을 통해 제3자(B씨)로부터 매수 약정하였으며, 동 종목의 신규상장일(2011.1.24.)에 정상적으로 주식을 거래하기 위해서 개장시간 이전인 08:35경 매도인의 증권사(△△증권) 계좌에서 신청인의 증권사(▽▽증권) 계좌로 주식의 계좌대체⁵³⁹⁾를 신청함.

그러나, 같은 날 오전 08:10~10:55 사이에 피신청인의 전산장애로 주식 계좌대체 서비스가 일시 중단되어 신청인의 증권사 계좌로의 계좌대체가 이루어지지 않아 주식거래를 못함.⁵⁴⁰⁾ 같은 날 10:51경 피신청인의 전산장애는 복구되었으나, 본건 매도인의 증권사(△△증권)는 실시간 계좌대체 약정이 체결되어 있지 않아 수작업 방식으로 계좌대체를 처리한 결과, 본건 주식이 신청인의 증권사 계좌로 계좌대체(입고)가 완료된 시점은 같은 날 11:09임.⁵⁴¹⁾

신청인은 전산장애로 보유주식을 매도하지 못하다가(매도예정가격은 확인불가) 장애가 복구된 이후에 주식을 매도(매도가 12,665원)하였으나 이미 주가가 하락되어 손해를 보았고, 피신청인은 자체보상기준⁵⁴²⁾에 따라 손해배상을 하려고 하였으나 신청인이 동 기준에 대해 이의를 제기하면서 수용을 거부하고 금감원에 본건 분쟁조정을 신청함.

나. 당사자 주장

(1) 신청인 주장

A기업의 주가는 전산장애 시간 중 상한가를 기록하였으며, 피신청인의 전산장애가 없었다면 상한가에 주식을 매도할 수 있었음. 한편, 장애복구 후 주식의 계좌대체가 완료된 시점에 주식을 매도하려 하였으나 매도주문 잔량이 너무 많아 그 다음 날 매도한 것

539) 주식수 1천주, △△증권(B씨, 인도)→ ▽▽증권(신청인, 인수)

540) 녹취록에 따르면, 신청인은 장애시간 중인 2011.1.24. 09:17경 본건 주식의 매도의사를 밝히고 있음.

541) 수작업 방식으로 처리하여 계좌입고가 되는데 걸리는 시간은 통상 10~20분 정도 소요됨.

542) 주당 보상가격은 전산장애 시간중(09:00~10:55) 거래량 가중평균가격에서 전산장애 복구시점(10:55)의 현재가를 뺀 주당 1,266원(=18,116원-16,850원)으로서 보상결정액은 총 1,266,000원임.

임. 따라서, 전산장애 시간중 동 종목의 상한가(19,550원)와 실제 매도가격(12,665원)과의 차액을 기준으로 보상(총 보상요청액 6,885,000원)하여야 함.

(2) 피신청인 주장

신청인이 상한가에 주식을 매도할 수 있었다고는 하나 매도주문 기록 등 관련 근거가 부족하여 수용하기 곤란하므로 거래량 가중평균가격을 적용하는 것이 타당하며, 신청인이 주식을 입고 받은 후 바로 매도하지 않고 지연한 데 따른 손실은 투자자의 판단에 속하는 사항이고 전산장애와 인과관계가 없는 만큼 장애복구 후 실제 매도가격을 기준으로 보상할 수는 없음.

피신청인의 전산장애에 따른 책임은 복구 후 주식이 최초로 투자자계좌부에 입고된 시점(10:55)까지로 판단되므로 피신청인의 보상기준은 타당하며, 증권사가 수작업으로 처리하여 신청인 계좌로의 입고가 늦어져 실제 입고된 시점(11:09)을 기준으로 보상하는 것은 부당하므로 신청인의 주장은 수용이 곤란함.

다. 위원회 판단

◆ 본건의 쟁점은 전산장애에 따른 적정한 손해배상금 산정기준이라 할 것임.

(1) 손해배상금액 산정기준

불법행위에 따른 손해배상액 산정은 일반적으로 “위법행위가 없었다면 존재하였을 재산상태”에서 “위법행위가 제거된 시점의 재산상태”를 공제하는 방법으로 이루어지는 바, “위법행위가 없었다면 존재하였을 재산상태”의 기준과 관련해서는,

① 주식은 수시로 변하는 성질을 가지고 있고, 투자자가 최고가에 주식을 팔아서 최대의 이익을 얻는 경우는 드물기 때문에 장애기간 중 최고가를 기준으로 보상하는 것은 합리적이지 않은 점.

② 전화녹취록에 따르면 신청인이 장애시간 중인 2011.1.24. 09:17경 본건 주식의 매도 의사를 밝히고 있기는 하나, 매도주문을 낸 자료가 없어 동 시점에 실제 매도주문을 내

있을지 여부 및 체결가능성을 알기 어려우므로 동 시점을 기준으로 삼기는 곤란한 점.

③ 실시간으로 수많은 거래가 이루어지는 주식거래에 있어서 실제 체결가능성 등을 고려해 볼 때 장애기간 중에 실제 체결된 거래들을 거래량을 고려해서 평균가격을 산정하는 피신청인의 기준이 합리성을 결여하였다고 보기는 어려운 점 등을 종합적으로 고려할 때 거래량 가중평균가격을 기준으로 보상액을 산정하는 것이 합리적이라 판단됨.

“위법행위가 제거된 시점의 재산상태”의 기준과 관련해서는,

① 전산장애 상태가 복구되어 신청인이 주식을 거래할 수 있는 시점 이후부터 실제 매도한 시점까지의 가격변동 부분은 신청인의 투자판단에 의한 것으로 전산장애와 인과관계가 있다고 보기 어려운 점.⁵⁴³⁾

② 피신청인은 최초로 계좌대체가 이루어진 시점(10:55, 실시간 계좌대체방식의 경우 입고시점)을 기준으로 하여야 한다고 주장하나, 신청인의 계좌로의 입고가 늦어진 이유가 신청인의 잘못으로 인한 것이 아닌 점.

③ 신청인은 전산장애 발생일의 08:35경 계좌대체를 신청하였고, 수작업방식으로 계좌대체가 처리되는데 통상 10분~20분정도 소요되는 점을 고려해 볼 때 본건 전산장애가 없었다면 당일 주식거래 개장시간(09:00) 이전에 신청인은 주식을 입고 받아 정상적인 거래를 할 수 있었을 것으로 보이는 점.

④ 신청인의 입장에서 실질적으로 볼 때 전산장애의 복구시점은 신청인이 주식을 입고받아 주식을 거래할 수 있는 시점인 점 등을 종합적으로 고려해 볼 때 신청인의 계좌로 계좌대체가 완료된 시점(11:09)의 현재가를 기준으로 보상액을 산정하는 것이 합리적이라 판단됨.

따라서, 본건에 있어서 손해배상액의 산정기준은 “장애시간 중 거래량 가중평균가격”에서 “신청인의 계좌로 계좌대체가 완료된 시점(11:09)의 현재가”를 공제한 가격을 기준

543) 신청인은 전산장애가 복구된 시점에 주식을 매도하려 하였으나 매도주문 잔량이 너무 많아 매도할 수 없어서 다음날 매도하게 되었다고 주장하나, 동 주장이 사실이라 하더라도 이와 같은 사정은 특별한 사정에 해당되어 전산장애시 피신청인이 예견할 수 있는 손해라고 보기 어려워 손해배상의 대상이 되지 어렵다고 판단됨.

으로 하는 것이 타당할 것으로 판단됨.

(2) 손해배상금액 산정

위와 같은 손해배상금액 산정기준을 적용한 본건 신청인에 대한 손해배상금액은 1,916,000원⁵⁴⁴⁾이라 할 것임.

라. 결론

그렇다면 피신청인은 신청인에게 전산장애로 인한 손해금액 1,916,000원을 배상할 책임이 있어 이를 인용하고, 신청인의 나머지 청구는 이유 없어 기각함.

544) {전산장애 시간 중 거래량 가중평균가격(18,116원) — 신청인 계좌로의 입고 완료시점(11:09)의 현재가(16,200원)} × 주식수(1,000주) = 1,916,000원

제2절 사무처리 오류

5-6 협회의 잘못된 부도공시로 투자자들이 주식을 매도하여 손해를 본 경우

[일부 인용] 잘못된 부도공시에 따라 해당 주식을 매도한 후 부도공시가 오보임을 알고 동 주식을 다시 매수한 투자자에 대하여는 재매수가격과 매도가격과의 차액을 손해배상하도록 하고, 해당 주식을 매도만 하고 재매수하지 아니한 투자자에 대하여는 부도공시 당일의 종가를 기준가격으로 하여 매도가격과의 차액을 손해배상하도록 하여야 할 것임. 한편 투자자도 해당 기업이 과거에 부도가 나 투자유의종목으로 지정되었고, 부도관련 공시내용을 검토하면 과거의 내용이었음을 알 수 있었음에도 불구하고 이를 제대로 확인하지 못한 과실이 있으므로 이러한 과실비율을 20%로 하여 손해배상금액을 산정함.(1999.11.2. 조정번호 제99-57호)

가. 사실관계

1999.8.11. 10:07:39 한국증권업협회 직원의 실수로 인하여 1998.9.30.에 이미 공시된 “A기업의 최종부도 및 당좌거래정지” 공시가 6개 증권회사에 전송됨.

1999.8.11. 09:00 주당 5,550원에 거래가 시작되어 본건 잘못된 부도공시 전까지 주당 5,800원에서 5,350원 사이에서 거래되던 A기업 주식이 부도공시가 전송된 후인 10:09~10:33사이에 하한가(4,800원)로 급락하면서 약 73.9만주가 거래되었으며, 10:34 이후부터는 동 부도공시가 오보라는 사실이 유포되면서 하한가에서 반등하여 5,000원대에서 거래되다가 11:44 A기업의 해명공시가 있자 5,550원까지 상승하였으나 시장의 전반적인 약세 분위기로 5,040원에 마감됨.

나. 당사자의 주장

(1) 신청인의 주장

1999.8.11. 오전 10시경 단말기에 “A기업 최종부도 및 당좌거래정지” 공시가 나와 이를 확인하고자 하였지만 확인이 되지 아니함에 따라 하한가에 매도함으로써 손해가 발생하였으므로 이로 인한 손해액을 배상하여야 함.

(2) 피신청인의 주장

동 사고는 직원의 전산조작오류로 인하여 과거에 공시한 내용이 잘못 전송되자 39개 회원 증권사중 6개사⁵⁴⁵⁾가 잘못 전송된 내용을 검색함이 없이 이를 공시함으로써 발생되었기 때문에 정식 공시가 아닌 사항을 공시로 오인한 투자자에 대하여 손해배상책임을 부담할 수 없음. 또한 공시내용을 검토해 보면 부도일이 1998.9.29.로 되어있으므로 그 내용을 정확히 알고 투자에 임하였다면 손해를 피할 수 있었음.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 협회직원의 전산조작오류로 과거의 부도공시가 재공시된 경우 이를 신뢰한 투자자들이 해당 종목을 매도하여 손해를 본 경우 손해배상책임의 인정 여부라 할 것임,

(1) 피신청인의 주의의무 위반 여부

피신청인은 어느 회사의 주식을 투자유의종목으로 공시함에 있어 당해 공시가 투자자들의 판단에 미치는 영향의 정도를 고려할 때 해당 사실을 정확히 공시하여 투자자들의 공시내용에 대한 신뢰를 보호하여야 하는 주의의무를 부담하고 있음.

따라서 피신청인의 직원이 전산조작 오류로 인하여 과거의 공시사항을 잘못 전송한 것은 해당 사실을 정확히 공시하여야 할 주의의무를 다하지 못한 것으로 판단되므로 이로 인하여 신청인이 입은 손해에 대하여 피신청인은 배상책임이 있다고 할 것임.

(2) 증권회사의 책임 여부

6개 증권회사를 통하여 A기업의 과거 부도공시 내용이 여과 없이 공시되었으나 이는 해당 증권회사의 자체 프로그램이 한국증권업협회에서 송부하는 내용을 그대로 게재하게 되어 있으므로 이를 이유로 해당 증권회사에 손해배상책임을 묻기는 곤란한 것으로 판단됨.

또한, 증권거래의 특성상 해당 증권회사에서 거래하는 투자자가 아니더라도 A기업 부

545) 여타 33개 회원사에서는 자체 전산의 검색과정에서 공시내용이 1998.9.30. 당시의 공시내용과 동일하다고 인식하여 공시하지 않음

도관련 풍문을 들은 투자자라면 A기업 주식을 매도할 수 있으므로 본건 잘못된 부도공시로 인하여 보호받아야 할 투자자는 모든 증권회사에서 거래하는 투자자로 확대되어야 할 것이며, 이에 대한 책임은 과거의 공시사항을 잘못 전송함으로써 투자자의 판단에 혼란원인을 제공한 한국증권업협회에서 지는 것이 타당하다고 판단됨.

(3) 손해배상의 기준가격 결정

잘못된 부도공시에 따라 A기업 주식을 매도한 후 부도공시가 오보임을 알고 A기업 주식을 다시 매수한 신청인에 대하여는 동 매매수가격과 매도가격의 차액을 손해배상의 기준가격으로 정할 수 있을 것임.

그러나 A기업 주식을 매도만 하고 매매수하지 아니한 신청인에 대하여는 손해배상의 기준이 되는 가격을 다음과 같이 산정할 수 있을 것임.

즉, 손해배상기준가격을 산정함에 있어 ① 최근일 현재의 A기업 주가를 기준가격으로 하는 방안, ② 부도공시 시점인 1999.8.11. 10:07:39의 주가(5,420원)를 기준가격으로 하는 방안, ③ 1999.8.11. 종가(5,040원)를 기준가격으로 하는 방안 등을 고려할 수 있음.

그러나 최근일 현재의 종가를 기준으로 하려면 신청인이 현재까지 A기업 주식을 보유하려 하였다는 투자방침이 전제되어야 하고 이를 확인할 수 있어야 하나 이를 객관적으로 확정할 수 없는 문제가 있음. 또 부도공시시점의 주가를 손해배상기준가격으로 하게 되면 신청인이 A기업 주식을 본건 부도공시와 관련 없이 부도공시가 있었던 10:07 전후의 시간대에 매도하려는 의사가 있었다는 사실이 전제되어야 할 것임.

따라서 A기업 주식을 하한가인 4,800원에 매도후 매매수하지 않은 신청인에 대하여는 1999.8.11. 10:07:39에 부도공시가 없었다면 신청인이 동 주식을 하한가인 4,800원에 매도하지 않고 보유하였을 것이고, 당일 동 주식을 보유하였다면 그 날의 주식가치는 11:44 기업의 해명공시후 정상화된 뒤 마감된 종가인 5,040원일 것이라는 가정하에 1999.8.11. 종가인 5,040원을 손해배상기준가격으로 정함이 타당할 것임.

한편 신청인들에게도 A기업이 과거에 부도가 나서 투자유의종목으로 지정되었고, 부도관련 공시내용을 검토하면 과거의 내용이었음을 알 수 있었음에도 불구하고 이를 제대로 확인하지 못한 과실이 있으므로 신청인들의 이러한 과실을 참작하되 동 과실비용

은 20%로 하여 손해배상금액을 산정하여야 할 것임.

라. 결 론

피신청인의 공시관련 주의의무 위반사실이 인정되므로 피신청인은 이로 인하여 신청인이 입은 손해액을 지급하여야 할 것임.

5-7 전산입력 오류와 주식매수청구권 불행사외의 인과관계 여부

[기각] 직원이 신청인의 주소전산입력을 잘못된 것은 사실이나, 주소로서 번지까지는 정확히 특정되었고, 동 번지에는 위 건물이외에는 전혀 존재하지 아니하고, 피신청인이 잘못 입력된 신청인의 주소로 1999.4~7월분 주식거래내역을 발송하고 우편물이 반송된 사실이 없는 점 등에 비추어 전산 입력된 주소가 신청인의 주소로 배달되지 않을 정도로 잘못된 주소는 아니라고 판단됨. 또한 주식매수청구권 관련내용이 일간신문에 수차례 보도되어 신청인이 이러한 내용을 인지할 수 있었을 것이라는 점 등에 비추어 전산입력오류와 주식매수청구권 불행사외는 인과관계가 없다고 판단됨.(2000.12.19. 조정번호 제2000-57호)

가. 사실관계

1999.4.14. 신청인은 ○○증권사(이하 “피신청인”이라 함) 지점에 위탁계좌를 개설하면서 주소를 “서울시 △△구 △△동 xx-x 한국 860 O/T 2402호”라고 기재하였으나 직원은 “서울시 △△구 △△동 xx-x호 한국아파트 860동 2402호”로 전산입력하였고, 같은 해 5.12. 신청인은 A기업 보통주 3,700주를 주당 1,160원에 매수하고, 5.15. 동 주식 200주를 주당 1,190원에 매도함.

1999.5.31. 증권예탁원⁵⁴⁶⁾은 A기업 실질주주들에게 A은행 주주총회 소집 통지서(주식

546) 증권예탁원은 피신청인이 전산입력한 “서울시 △△구 △△동 xx-x호 한국아파트 860동 2402호”의 주소로 신청인에게 아래와 같은 사항을 우편발송함.

주식매수청구권 행사에 대한 사항

- A기업과 B기업의 합병에 대한 이사회 결의(1999.5.10.)에 반대하는 주주는 자기소유 주식의 매수를

매수청구권에 관한 사항 포함)를 인근 우체국을 통해 발송함.

나. 당사자의 주장

(1) 신청인의 주장

1999.6월말경 A기업 주식매수청구권 관련 사실을 처음 들었으나 이 때는 이미 주식매수청구권 행사기간이 경과한 때임. 이에 피신청인에게 확인해 본 결과 피신청인의 직원 이 신청인의 주소를 잘못 전산입력함에 따라 증권예탁원이 잘못된 주소로 우편물을 발송한 사실을 알게 됨. 결국 신청인이 주식매수청구권 행사를 하지 못하게 된 이유는 피신청인이 신청인 주소를 잘못 전산입력하였기 때문이므로 피신청인은 이로 인하여 발생한 손해를 배상하여야 함.

(2) 피신청인의 주장

전산 입력된 주소로 4, 5, 6, 7월분 총 4차례에 걸쳐 잔고내역이 발송되었음에도 반송 사례가 없어 모두 배달된 것으로 추정됨.

A기업과 B기업의 합병과 관련된 사실은 이미 1999.3.24경부터 중앙일간지들을 통하여 계속적으로 널리 보도된 사안이며, 5월 이후에는 합병에 반대하는 주주들은 주식매수청구권을 행사하여야 한다는 기사가 각 언론매체를 통하여 보도되고 있어 신청인이 6월말쯤 A기업 주식매수청구권에 대한 소식을 처음 들었다는 진술도 의문스러움.

따라서 신청인이 A기업 주식매수청구권을 행사하지 못하게 된 이유로 피신청인의 주소 착오입력만을 거론하는 신청인의 주장은 수용할 수 없음.

청구할 수 있는 권리가 있음.

- 1999.5.18. 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주를 대상으로 하여 합병에 대한 이사회결의에 반대하는 주주는 이사회결의 반대의사표시 통지서를 기재한 후, 주주총회 결의일 전일(1999.6.7)까지 거래 증권회사에 제출하여야 함.
- 이사회결의 반대의사표시 통지서를 제출한 주주는 주식매수청구서에 주식의 종류와 수를 기재하여 주주총회 결의일(1999.6.8)로부터 10일 이내 거래증권회사에 제출하여 매수청구할 수 있음.
- 매수예정가격 : 주당 1,252원

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 피신청인의 주소 착오입력이 신청인의 주식매수청구권 불행사와 인과관계가 있는지 여부라 할 것임.

(1) 전산 입력된 주소가 신청인에게 배달되지 않을 정도로 잘못된 주소인지 여부

상법 제363조 제1항 및 제3항은 주총 소집통지 등에 관하여 발신주의를 취하고 있는 것으로 해석됨. 그러므로 회사는 주주명부상의 주소 또는 주주가 회사에 통지한 주소로 소집통지를 발송하였음을 입증하면 족하고 도달되지 않음으로 인한 불이익은 주주의 부담이 된다고 할 것임.

신청인은 피신청인의 직원이 신청인의 주소를 잘못 입력하였다고 주장하나, 아래와 같은 점에 비추어 보았을 때 신청인의 주소로 배달되지 않을 정도로 잘못된 주소는 아니고, 주식매수청구권 관련 우편물이 신청인의 주소로 도달되었다고 추정됨.

① 신청인이 회사에 통지한 주소는 서울시 △△구 △△동 xx-x “한국 860 O/T” 2402 호이고, 피신청인의 직원이 잘못 입력한 부분은 “한국아파트 860동”이나, 주소로서 번지까지는 정확히 특정되었고 동 번지에는 위 건물 이외에는 전혀 존재하지 아니하여 사실상 도달하지 않을 정도로 전산입력이 잘못 되었다고 보이지 아니하는 점.

② 피신청인이 잘못 입력된 신청인의 주소로 1999. 4월, 5월, 6월, 7월분 주식거래 내역을 발송하였고, 이러한 우편물이 반송된 사실은 없는 점.

③ 본건과 관련하여 증권예탁원에서 신청인의 주소로 주식매수청구권 관련내용을 1999.5.31. 우편으로 발송한 바 있고, 이러한 통지서가 주소불명 등의 사유로 반송된 사실이 없는 점.

(2) 피신청인의 신청인주소 오류입력과 매수청구권 불행사와의 인과관계 여부

피신청인의 직원이 신청인의 주소를 잘못 전산입력하였다 할 지라도 아래와 같은 사정에 비추어 신청인이 이로 인해 주식매수청구권을 행사하지 못하였다고 보기는 어려움.

① 위에서 언급한 바와 같이 주소의 번지까지 구체적으로 특정된 이상 “한국 860 O/T”의 건물명이 “한국아파트”로 잘못 기재되었다 하여 우편 통지물이 신청인의 실제주

소로 배달되지 아니할 가능성은 거의 없는 점.

② A기업이 1개의 일간신문에 주주총회사항을 1회 공고하였고, 주식매수청구권 관련 내용이 일간신문에 수차례 보도⁵⁴⁷⁾되어 신청인이 이러한 내용을 충분히 인지할 수 있었던 점.

라. 결 론

피신청인의 직원이 신청인주소 전산입력을 잘못하여 신청인이 주식매수청구권을 행사할 수 없었다고 보기 어려우므로 신청인의 손해배상청구는 이유 없다고 할 것임.

5-8 ELS 최초기준지수 결정일 임의변경의 적정성 여부

[일부인용] NIKKEI225는 정상적으로 산출되어 엄연히 종가가 존재함에도 피신청인은 HSCEI가 산출되지 않음을 이유로 NIKKEI225의 최초기준지수 결정일을 변경하였는 바, 유가증권신고서, 사업설명서 등에 이에 관한 명시적 규정이 없고, 달리 피신청인 주장과 같은 상관습이 존재한다고 보기 어려운 점, 피신청인이 투자자에게 변경사실에 대한 명확한 통보 없이 불리한 조건으로 최초기준지수 결정일을 변경한 점 등을 감안시 본건 ELS 최초기준지수 결정일 변경이 타당하다고 할 수 없음.(2010.9.14. 조정번호 제2010-73호)

가. 사실관계

2008.8.25. 피신청인은 NIKKEI225, HSCEI(Hang Seng China Enterprises Index)를 기초자산으로 하는 만기 2년의 “○○증권 △△△ELS 제70회”(이하 “본건 ELS”라 함)를 발행함. 본건 ELS는 매 3개월마다 자동조기상환 기회가 부여되며 조기상환조건을 달성하면 연 18%의 수익, 만기시 두 기초자산 모두 최초기준지수의 80%이상인 경우 36%의 수익이 발생하는 구조이며, 신청인은 인터넷을 통하여 본건 ELS 4천만원을 매입하였음.

피신청인은 2008.8.22.(금) 태풍으로 인한 홍콩증시의 임시휴장으로 당일 HSCEI 종가

547) 1999.5.28. A기업은 주식매수청구권 관련내용을 ○○신문에 공고하였고, 1999.5.9.자 △△일보, 5.10.자 ▽▽경제, 5.31.자 ◇◇경제신문, 6.7.자 ◎◎일보 등에 주식매수청구권 관련내용이 보도됨.

가 존재하지 아니하자, 일본증시는 정상적으로 거래되었음에도 HSCEI, NIKKEI225⁵⁴⁸⁾ 최초기준지수 결정일을 모두 익영업일인 2008.8.25.(월)로 변경함.

피신청인은 최초기준지수 변경과 관련하여, ① 2008.8.27. 금융위원회에 제출한 발행실 적보고서에 “기준가 결정일이 8월22일에서 25일로 변경(8월22일 악천후로 인한 홍콩증권거래소 휴장으로 당일 종가가 발표되지 않음)”이라고 기재하고, ② 2008.10.27. 투자자에게 발송한 원금손실조건 발생 안내문에 “최초기준지수: 2008.8.25. 각 기초자산의 종가(8.22. 홍콩시장 휴장)”라는 문구를 기재하였으며, ③ 2008.11.19. 이후 3개월마다 조기상환 연장 안내문을 홈페이지를 통해 게시하면서 NIKKEI225의 최초기준지수를 2008.8.25. 지수로 게시함.

한편, 2010.5.18. 조기상환평가일에 NIKKEI225가 10,242.64, HSCEI가 11,426.18을 기록하였는데, 이는 2008.8.22. NIKKEI225 종가(12,666.04)를 최초기준지수로 하면 최초기준지수 대비 평가일 종가가 80.9%로서 자동조기상환 조건을 충족⁵⁴⁹⁾하는 반면, 변경된 2008.8.25. 종가를 최초기준지수로 하면 자동조기상환 조건을 충족하지 못하는 상황임.

2010.8.19. 본건 ELS의 만기평가일에 기초자산인 NIKKEI225가 9,362.68을 기록하여, 만기상환시 원금손실을 봄.

나. 당사자의 주장

(1) 신청인의 주장

최초 상품설명서 및 유가증권신고서에 기재된 최초기준지수(2008.8.22.종가)에 의하면 2010.5.18. 조기상환조건이 충족되었음에도 피신청인이 최초기준지수 결정일을 임의로 변경하여 조기상환금 지급을 거부하는 것은 부당함.

(2) 피신청인의 주장

본건 ELS의 최초기준지수 결정일 변경은 2008.8.22. 홍콩증시 휴장으로 정상적인 위험

548) 2008.8.22. 당시 NIKKEI225는 12,666.04였으나 2008.8.25. 변경된 종가는 12,878.66을 기록함.

549) HSCEI의 경우, 모두 조기상환조건을 충족함.

회피거래에 제한이 발생함에 따라 안정적인 위험회피거래를 위하여 불가피하게 이루어진 것으로, 유가증권신고서, 사업설명서에 그 근거를 찾을 수 있으므로 이를 부당하다고 보기 어려움. 또한 유가증권발행실적보고서, 홈페이지 게시, 원금손실조건 도달 안내문, 조기상환연장 안내문 등을 통하여 기준지수결정일 변경사실을 공지하였는 바, 신청인이 최초기준지수결정일 변경사실을 알 수 있었음에도 지금까지 아무런 이의를 제기하지 않은 것은 이에 대한 묵시적 합의 내지 추인에 해당함.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 ① 피신청인의 NIKKEI225 최초기준지수 결정일 변경의 적정성 여부 및 ② 이에 대한 신청인의 합의 내지 추인여부라 할 것임.

(1) 최초기준지수 결정일 변경의 적정성 여부

구 「증권거래법」은 유가증권(본건 ELS도 이에 해당)을 모집 또는 매출하는 때에는 유가증권신고서를 제출하고, 사업설명서를 비치하여 일반인에게 공람하게 하고 유가증권을 취득하고자 하는 자의 청구가 있는 때에는 이를 교부한 후가 아니면 당해 유가증권을 취득하게 하거나 매도하지 못하도록 규정하고 있어, 투자자는 이를 통하여 유가증권의 구체적 내용을 알고 유가증권을 취득하게 되며, 최초기준지수는 ELS 수익구조의 핵심적 내용을 이룬다는 점에 비추어 신청인과 피신청인간에는 최초 유가증권신고서, 사업설명서 내용대로 본건 ELS 최초기준지수 결정일을 2008.8.22로 하는 약정이 성립한다 할 것이고, 특별한 사정이 없는 한 최초기준지수 결정일을 피신청인이 임의대로 변경할 수는 없다 할 것임.

한편, 피신청인은 본건 ELS 최초기준지수 결정일 변경이 타당하다고 주장하나 다음과 같은 점에 비추어 이를 인정하기 어렵다 할 것임.

① 2008.8.22. NIKKEI225는 정상적으로 산출되어 엄연히 종가가 존재함에도 불구하고, 피신청인은 HSCEI가 산출되지 않음을 이유로 NIKKEI225의 최초기준지수 결정일을 변경하였는 바, 유가증권신고서, 사업설명서 등에 두 기초자산 중 어느 하나의 기초자산 지수가 산출되지 않음을 이유로 다른 기초자산의 최초기준지수 결정일을 변경할 수 있

다는 명시적 규정이 없고⁵⁵⁰⁾, 달리 피신청인의 주장과 같은 상관습이 존재한다고 보기 어려운 점.

② 피신청인은 사업설명서상 권리내용의 조정항목 제13호를 근거로 최초 기준지수 결정일 변경이 타당하다고 주장하나, 제13호는 문언상 발행사가 만기일을 재지정하거나 만기상환금액의 산출에 필요한 조건들을 조정하여 만기상환금액 산출에 사용할 수 있다고 규정하고 있어 동 규정이 최초기준지수 결정일 변경의 경우에도 당연히 적용된다고 보기 어려운 측면이 있고, 사업설명서상 권리내용 조정항목[(3) 권리내용의 조정]은 해외지수계산 발표상의 오류, 거래소·청산소의 부도, 금융시장의 거래중지사태 등 발행사가 지배하기 어려운 사유들을 규정하고 있으며, NIKKEI225는 2008.8.22. 종가로 특정이 되므로 이를 기준으로 위험회피거래를 하면 될 것으로 판단되며 달리 NIKKEI225의 기준일을 HSCEI의 기준일과 맞추어야 할 불가피한 사유가 있다고 볼 만한 사정을 찾기 어려운 점.

③ 위험회피거래의 관리 여부는 피신청인의 책임에 속하는 것이고, 위험회피의 구체적 내용 또한 투자자에게 알려지거나 투자자가 관여할 수 없는 사항임에 비추어, 피신청인이 최초기준지수 결정일을 변경하는 경우 신청인에게 그 사실을 알리고 그 변경에 관한 동의를 받는 것이 상당하다 할 것임에도 피신청인은 투자자에게 변경사실에 대한 명확한 통보 없이 투자자에 불리한 조건⁵⁵¹⁾으로 최초기준지수 결정일을 변경하였다 할 것이므로 피신청인 주장을 인정하기 어려운 점.

(2) 최초기준지수 결정일 변경에 대한 묵시적 합의(추인) 여부

신청인이 장기간 이의를 제기하지 아니하였다는 사유만으로 최초기준지수 결정일 변경을 묵시적 합의 내지 추인하였다고 보기 어렵다 할 것임.

묵시적 합의 내지 추인을 인정하기 위해서는 투자자가 장기간 이의를 제기하지 아니

550) 피신청인은 유가증권신고서 등에서 최초기준지수가 해당일의 거래소 종가로 규정되어 있으므로 기초자산이 두 가지인 경우 양 거래소 모두가 정상적으로 거래되는 영업일의 종가를 의미한다고 주장하나, 위 규정을 정상적으로 거래되어 산출된 기초자산의 최초기준지수 결정일 변경의 근거로 보기 어렵다 할 것임.

551) (2008.8.22. NIKKEI225) 12,666.04 → (2008.8.25. NIKKEI225) 12,878.66

한 사정만으로 부족하고, 투자자가 자신이 처한 법적 지위를 충분히 이해하고 진의에 기해 당해 손실이 자기에게 귀속된다는 것을 승인한 것으로 불만한 사정이 있어야 할 것인데,⁵⁵²⁾ 본건 ELS 사업설명서상 권리내용의 변동이 발생한 경우 발행사는 홈페이지에 이를 게재하고 지체없이 e-mail 등의 방법으로 보유자에게 개별통지하도록 규정⁵⁵³⁾되어 있음에도 불구하고 피신청인은 신청인에게 최초기준지수 결정일 변경을 개별적으로 통지한 사실이 없으며, 발행실적보고서⁵⁵⁴⁾, 원금손실조건 안내문, 조기상환연장 안내문의 내용만으로 신청인이 최초기준지수 결정일 변경사실이나 그 사유를 쉽게 알았다고 보기도 어려우며, 신청인이 최초기준지수 결정일 변경이 근거가 없다는 사실 및 그러한 변경의 불이익을 인식하고, 그 불이익을 용인하였다고 보기 어려움.

라. 결 론

그렇다면, 피신청인은 신청인에게 본건 ELS의 최초 사업설명서 기재내용대로 최초기준지수결정일(2008.8.22.)에 따라 산출된 조기상환금을 지급할 의무가 있다 할 것임.

5-9 ELS 가격변동추이 미통지로 인한 손해배상책임 유무

[기각] 신청인은 피신청인이 본건 ELS의 변동추이를 알려줄 의무를 위반하여 손해가 발생하였다고 주장하나, 신청인은 과거 수회에 걸쳐 ELS 투자경험이 있어 위험성을 알고 환매여부를 스스로 결정할 수 있다고 보이며, HTS 부가서비스 신청을 하여 직접 잔고조회가 가능한 점, 피신청인이 고객안내문을 신청인에게 등기로 통지한 사실이 있어 신청인도 원금손실 발생 가능성을 알고 있었던 점 등에 비추어 달리 피신청인의 책임을 인정할 특별한 사정을 찾기 어려움.(2010.11.9. 조정번호 제2010-96호).

552) 대법원 2003.12.16. 선고 2003다49542 판결 참조.

553) 사업설명서 5.(4) 권리내용의 통지.

554) 발행실적보고서는 관련법상 공시의무를 이행한 것에 불과하고 이러한 사실만으로 신청인에 대한 통지의무를 이행했다고 보기 어렵고, 원금손실조건 안내문이나 조기상환연장안내문의 기재 또한 최초기준지수 결정일 변경내용, 그 사유 등이 독립적, 구체적으로 적시되어 있지 않아 적정한 통지로 보기 어려우며 신청인이 이를 쉽게 인식할 수 있다고 보기도 어려움

가. 사실관계

신청인은 2004.12월부터 2007.8월까지 총 9건의 ELS에 가입한 경험이 있는 사람으로 2007.8.27. ○○증권 제1328회 ELS(이하 “본건 ELS”⁵⁵⁵)라고 함)에 21백만원 가입하였으며, 2010.4.16. 피신청인 직원 A씨(이하 “담당직원”이라 함)와 신청인이 보유중인 금융상품의 수익률 및 향후 전망 등에 관하여 전화통화를 함.(2010.4.16. 본건 ELS 평가금액 21,199,500, 수익률 0.95%)

신청인은 본건 ELS 만기일인 2010.8.26.에 13,883,772원을 상환(7,116,228원 손해, 손실을 33.89%)받았으며, 2008.10.10. 기초자산 모두 최초기준가격의 60% 미만 하락으로 원금손실조건에 도달함.

나. 당사자의 주장

(1) 신청인의 주장

2010.4.16. 만기 4개월 전, 피신청인 담당직원이 본건 ELS의 추후 변동폭에 대해 신청인에게 알려준다고 약속했는데 만기시점까지 34% 상당의 가격변동이 있었음에도 이를 알려주지 않아 중도환매할 수 있는 기회를 상실하여 추가손실을 입음.

(2) 피신청인의 주장

신청인은 과거 9회에 걸쳐 ELS에 가입한 경험이 있고, 본건 ELS 가입시에도 중도환

555) “○○증권 제1328회 ELS(원금비보장형)”의 주요 내용은 다음과 같음.

- 만기일 : 2010.8.26.(만기 3년, 매6개월 단위로 자동조기상환기회 부여)
- 기초자산 : 한국전력 보통주, 국민은행 보통주
- 조기상환 : 조기상환 평가일에 두종목의 자동조기상환 평가가격이 90%, 85%, 80% 이상인 경우 연 18.20% 수준의 수익
- 만기상환 : ① 두 종목 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우 연 18.20% 수익 ② 두 종목 중 한 종목이라도 최초기준가격의 80%미만이고 투자기간 중 60% 미만으로 하락한 종목이 없는 경우 연 5.00% 수익 ③ 만기까지 한 종목이라도 최초기준가격의 60%미만으로 하락한 적이 있고, 한 종목이라도 만기 평가가격이 80% 미만이면 원금손실
- 중도상환 : 발행 후 6개월까지는 평가금액의 90%, 6개월 이후에는 95%이상을 지급

매에 대한 설명을 들어 이를 잘 알고 있었으며 2010.4.16. 통화시 신청인 보유펀드의 수익률 등에 대해 언급한 사실은 있으나, 담당직원이 본건 ELS변동 추이에 대해 신청인에게 알려주기로 약속한 사실이 없음.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 피신청인이 신청인에게 본건 ELS의 가격변동 추이를 알려줄 법적 의무가 있는지 여부라 할 것임.

(1) 피신청인 책임여부

신청인은 피신청인이 신청인에게 본건 ELS의 변동추이를 알려줄 의무를 위반하여 손해가 발생하였다고 주장하나 다음과 같은 점에 비추어 그 주장을 받아들이기 어려움.

① 신청인은 과거 9회에 걸쳐 ELS에 투자한 경험이 있어 ELS의 특성과 위험성을 알고 환매여부를 스스로 결정할 수 있다고 보이며, HTS 부가서비스 신청을 하여 직접 잔고조회가 가능한 점.

② 본건 ELS는 2008.10.10. 원금비보장조건에 해당되어 피신청인이 고객안내문을 신청인에게 등기로 통지한 사실이 있어 신청인도 본건 ELS가 원금손실이 발생할 수 있다는 사실을 알고 있었던 점.

③ 녹취록상 신청인과 담당직원간 대화내용만으로 피신청인이 신청인의 환매기회를 보장하기 위해 신청인에게 본건 ELS의 가격변동추이를 어떻게 알려줄 것인가에 대한 구체적 합의 내지 법적 구속력 있는 약정을 하고 있다고 보기 어려운 점.

④ 금융회사는 고객에게 거래에 수반하는 위험성에 관하여 충분한 설명의무를 부담하나, 이러한 고객보호의무는 고객의 수익을 보장하기 위한 것이 아니며, 투자고객으로서 금융회사가 제공하는 정보에 기하여 그 위험을 정확히 이해하고 그 위험이 현실화되었을 때에 이를 감당할 수 있는지를 스스로 판단한 후에 거래를 하여야 하고 그 결과에 대하여 책임을 져야 하는 것이 원칙이고, 증권회사는 고객으로부터 금융상품의 관리나 투자대행 등을 위임받은 등의 특별한 사정이 없는 한 손실발생의 우려가 있다고 해

서 중도상환을 권유해야 할 부수적 의무까지 부담한다고 보기 어려운 점.⁵⁵⁶⁾

⑤ 기초자산의 가격이 특정수준 이상으로 오르는 경우 고객이 이에 대처할 수 있도록 금융회사가 고객들에게 그 가격의 변동추이 등을 개별적으로 미리 알려줄 의무를 부담한다고 보기 어려운 점.⁵⁵⁷⁾

라. 결 론

그렇다면 피신청인은 신청인에 대한 손해배상 책임이 없다 할 것이므로 이를 기각함.

556) 대구지방법원 2007.5.8. 선고 2006가합8478 판결 참조.

557) 대구지방법원 서부지원 2009.4.10. 선고 2007가합2634 판결.

제3절 횡령 및 배임

5-10 직원이 고객에게 타인명의 유상청약을 유도하고 그 자금을 횡령한 경우

[일부 인용] 직원의 횡령이 인정되나 신청인도 자기명의로 아닌 타인명의 유상청약분에 대하여 청약한 과실이 있으므로 신청인의 이러한 과실비율을 30%로 하여 과실상계한 금액을 손해배상 금액으로 지급하도록 함.(1999.9.14. 조정번호 제99-39호)

가. 사실관계

신청인은 1999.4.28. ○○증권사(이하 “피신청인”이라 함) 직원의 권유로 A씨 계좌(직원이 관리하는 계좌이며 신청인과는 아무런 관계가 없음)의 B기업 주식 13,743주에 대한 유상청약대금 68,715,000원을 입금하고, 직원은 같은 달 30일 “B기업 신주의 권리는 신청인에게 있으며 동 주식의 주가가 7천원 이상이 되면 1천주를 제외한 12,743주에 대한 매도대금을 지급하겠다”는 내용을 기재한 확약서를 작성하여 신청인에게 교부함.⁵⁵⁸⁾

신청인이 1999.5.31. 매도자금의 인출을 요구하자 직원은 계좌주의 증권카드 등을 보관하고 있지 아니하다는 이유로 6.7.에 인출해 줄 것을 약속한 후, 해당 일자에 신청인이 매도자금 인출을 요구하자 은행에서 돈을 찾아 오겠다 하면서 도주하여 잠적중임.

나. 당사자의 주장

(1) 신청인의 주장

직원과 협의하여 주식을 매매해 오던 중 직원의 권유로 직원이 관리하고 있는 △△△ 계좌 유상증자분에 대한 청약대금 68,715,000원을 입금하여 청약을 하였으나 직원은 청약한 주식을 매도하고 동 매도대금을 횡령함으로써 금102,483,135원의 손해가 발생함.

558) 직원이 1999.5.26. A씨 계좌에서 B기업 유상증자 주식 13,743주를 102,483,135원에 매도한 후, B씨는 같은 달 28일에 자신의 계좌에서 140,180,000원을 출금하여 105,000,000원을 자신이 가지고 나머지 (35,180,000원)는 직원에게 주었다고 주장하고 있으나 사실확인 되지 않음.

피신청인의 직원에 대한 관리, 감독 소홀로 인하여 이러한 금융사고가 발생하였으므로 피신청인은 직원의 횡령으로 인한 손해금 102,483,135원을 배상하여야 함.

(2) 피신청인의 주장

직원이 신청인에게 A씨 계좌 유상증자분에 대한 청약을 권유하여 신청인이 청약대금 68,715,000원을 입금한 것은 사실이나 신청인은 직원이 개인적으로 작성하여 교부한 청약서를 믿고 타인 계좌에 청약자금을 입금하여 사고가 발생하였으므로 이는 신청인의 중대한 과실로 보여지며, 직원이 잠적한 상태에서 신청인의 주장만을 믿고 손해금을 전부 배상하는 것은 곤란함.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 타인명의로 한 유상증자분의 매도자금 횡령에 따른 손해배상 책임 여부라 할 것임,

(1) 횡령 여부

신청인에 대한 문답조사, 수표조사, 전화녹취, 피신청인의 수시감사결과보고 등에 의하면 직원이 신청인에게 A씨 계좌 유상증자분에 대한 청약을 권유하여 신청인이 청약대금 68,715,000원을 입금한 사실, 직원이 유상증자분을 매도한 사실, 신청인과 아무런 관련이 없는 A씨가 140,180,000원을 출금한 사실(다만, A씨는 직원의 매매로 인한 손해배상금액으로 105,000,000원을 가지고 나머지 35,180,000원은 직원에게 주었다고 주장함)이 확인되며, 신청인이 매도자금인출을 요구하자 직원은 은행에서 돈을 찾아 온다고 하면서 도주하여 잠적한 사실로 미루어 보아 상기 주식매도자금을 피신청인의 직원이 횡령한 것으로 판단됨.

(2) 손해배상금액의 산정기준

신청인은 청약받은 주식의 매도대금 102,483,135원을 전액 배상할 것을 요구하나 신청인은 B기업 주가가 7천원 이상이 되면 1천주를 제외한 12,743주에 대한 매도대금만 받기로 합의한 사실이 있으므로 횡령금액에서 1천주에 상당하는 부분을 제외한 금액

95,026,019원을 손해배상금액의 기준으로 하고, 또한 신청인은 자기명의로 아닌 타인명의 유상청약분에 대하여 청약한 과실이 있으므로 신청인의 이러한 과실을 참작하되 동 과실비율은 30%로 하여 재산정한 66,518,213원을 신청인에게 손해배상금으로 지급하여야 할 것으로 판단됨.

라. 결 론

피신청인의 직원에 의한 주식매도대금 횡령사실이 인정되므로 피신청인은 이로 인하여 신청인이 입은 손해액중 66,518,213원을 지급하여야 할 것으로 판단됨.

5-11 장외매매 명목으로 금원을 편취시 증권회사의 손해배상책임 여부

[기각] 비상장비등록 주식의 경우 영업장소 내에서 제3시장을 통한 장외주식의 거래를 중개한 것이 아닌 한, 순수한 장외거래방식으로 이루어진 주식의 매매의 중개행위는 증권회사의 통상의 업무 내지는 사무라고 할 수 없다 할 것임. 본건 피신청인의 사무와 담당직원의 행위는 그 사무집행관련성이 없거나, 외형상 장외주식의 매매가 피신청인이 사무집행과 관련성이 있다고 할 지라도 담당직원의 행위가 피신청인의 사무집행행위에 해당하지 않음을 신청인 자신이 알았거나 또는 중대한 과실로 알지 못한 경우에 해당한다고 할 것 이어서 신청인의 청구를 기각함.(2003.5.6. 조정번호 제2003-17호)

가. 사실관계

신청인은 1998.1.21. ○○증권사(이하 “피신청인”이라 함) 지점에 수익증권계좌를 개설하여 수익증권에 투자를 하던 중, 동 지점에 근무하던 차장 A씨(이하 “담당직원”이라 함)으로부터 장외주식에 투자해서 수익을 내보자고 여러 차례 권유를 받아, 2002.6.19. 위 수익증권 계좌에서 9백만원을 수표(5백만원권 수표 1매, 1백만원권 수표 4매)로 인출하여 이를 직접 담당직원에게 장외주식 투자금 명목으로 교부함.

2002.6.19. 담당직원은 신청인에게 수기로 작성된 “◇◇ 고객님. 금 9백만원을 장외거래대금으로 수령하였으며 원금과 그 수익금을 45일후에 지급하겠습니다. 2002.6.19 ○○

증권 ∇∇∇(서명)”으로 기재되어 있는 확인서를 교부함.

담당직원은 신청인으로부터 교부받은 9백만원을 당초 신청인의 약속과는 달리 장외주식에 투자하지 않고 다른 증권사의 타인명의로 자신이 운영하고 있던 선물옵션계좌(자기매매 계좌)에 입금하였으며, 옵션거래를 하였으나 전액 손해를 봄.

나. 당사자의 주장

(1) 신청인의 주장

2002.6.19. 신청인이 장외주식 투자명목으로 9백만원을 담당직원에게 교부해 준 것과 관련하여 신청인은 그 전에 수 차례 담당직원으로부터 투자를 권유 받았으며, 최초에는 이를 거절하였으나 40일 정도만 투자하면 된다면 10% 정도의 수익을 낼 수 있다고 강력히 권유함과 동시에 확인서를 작성하여 주어 이에 응하게 된 것임.

(2) 피신청인의 주장

담당직원의 편취행위에 대하여는 다툼이 없음. 그러나 담당직원의 행위는 당사 영업행위에 해당하지 아니하며 담당직원의 본래 직무와 본건 장외주식투자권유 및 투자금 수령행위와 관련성이 있다고 볼 수 없음. 설령, 관련직원 행위가 외형상 사무집행행위로 보여진다고 하더라도 신청인은 수년간 관련직원과 거래하여 관련직원의 직무를 인지하고 있었을 것으로 추정되는 점, 증권회사를 통한 주식의 매매경험을 비추어 볼 때, 비정상적인 거래에 대하여 이를 인지할 수 있었다고 보이는 점, 장외주식 투자목적으로 금원을 교부하면서 그 구체적인 투자방법에 대한 확인을 소홀히 한 점, 과거 유사한 방식으로 장외매매를 통하여 비상장·비등록주식의 거래를 한 경험이 있는 점 등을 종합할 때, 신청인은 담당직원의 행위가 사무집행과 관련이 없음을 알았거나 중대한 과실로 이를 인지하지 못하였던 것으로 보임.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 장외매매와 관련하여 투자금을 편취한 담당직원의 행위가 민법상의 사용자 배상책임에서 요구하는 피신청인의 사무집행의 범위에 속하는지 여부라고 할 것임.

(1) 배상책임 여부

유가증권매매의 위탁매매인인 피신청인은 자기와 사용관계에 있는 피용자가 그 사무집행에 관하여 제3자에게 가해행위를 한 경우, 사용자가 이로 인한 손해배상채무를 직접 피해자에게 부담함이 원칙임. 사무집행 관련성의 판단에 있어서는 사용자의 사무집행 자체 또는 이에 필요한 행위 뿐만 아니라 이와 관련된 것이라고 보여지는 사무를 일반인의 시각에서 객관적이고 외형적인 기준에서 판단하여야 하는 것임. 다만, 피용자의 행위가 사용자의 사무집행행위에 해당하지 않음을 피해자 자신이 알았거나 또는 중대한 과실로 알지 못한 경우에는 사용자책임을 물을 수 없다고 할 것임.⁵⁵⁹⁾

「증권거래법」 제194조, 동법 시행령 제84조의27, 「증권업감독규정」 제5-26조 제1항에 의하면 “장외시장”이라 함은 유가증권시장(증권거래소) 및 협회중개시장(KOSDAQ) 이외의 시장을 말하는 것임.

장외시장에 있어서의 유가증권의 중개행위 중 채권의 장외시장, 증권거래소의 「업무규정」 및 협회의 「협회중개시장운영규정」에서 정한 매매수량단위 미만의 상장주식 및 협회등록주식을 거래하는 단주의 장외시장, 비상장·비등록 주식의 거래 중 호가중개시스템을 통하여 호가를 중개할 수 있는 비상장·비등록 주식을 거래할 수 있는 장외시장(이른바 제3시장-장외주식호가중개시장)등의 거래는 증권회사가 본래 수행하는 업무라고 할 것임.

따라서 비상장·비등록 주식의 경우 영업장소 내에서 제3시장을 통한 장외주식의 거래를 중개한 것이 아닌 한, 순수한 장외거래방식으로 이루어진 주식의 매매의 중개행위는 증권회사의 통상의 업무 내지는 사무라고 할 수 없다 할 것임.

아래의 점을 종합하여 볼 때, 피신청인의 사무와 담당직원의 행위는 그 사무집행관련성이 없거나, 외형상 장외주식의 매매가 피신청인이 사무집행과 관련성이 있다고 할 지라도 담당직원의 행위가 피신청인의 사무집행행위에 해당하지 않음을 신청인 자신이 알았거나 또는 중대한 과실로 알지 못한 경우에 해당한다고 할 것임.

신청인에게 담당직원이 장외매매와 관련한 구체적인 투자대상을 설명하지 않았다고

559) 대법원 2003.1.10. 선고 2000다34426 판결 참조.

하더라도 신청인은 2001.9.22. ‘△△’이라는 비상장·비등록 장외주식에 대하여 호가중개 시스템을 이용하지 아니한 순수한 장외거래를 한 사실이 있는 점과 신청인이 수차례 거래한 상장주식의 단주의 장외거래와 비교하더라도 그 투자규모가 단주의 장외거래 규모에 비하여 상당히 큰 점 및 신청인 자신의 주식위탁계좌가 있음에도 이를 통하여 거래를 하지 아니하고 단순히 수기로 된 확인증만을 교부받고 거래를 한 점 등에 비추어 신청인과 담당직원은 순수한 의미의 장외거래를 하기로 약정한 것으로 볼 수 있으므로 이러한 사무는 증권회사의 통상의 사무가 아니라고 할 것임.

설령, 담당직원의 행위가 외형상으로 증권회사의 사무에 관련된 행위라고 할지라도 본 건 신청인은 상당기간의 현물 주식의 거래와 수익증권 및 환매채권(RP)거래 등을 한 사실이 있어 주식투자의 경험이 있다는 점, 본 건 이전에도 비상장·비등록 주식의 호가중개시스템을 통하지 않은 장외거래 경험이 있을 뿐 아니라 당시에 위와 같은 거래에 대하여 증권회사가 중개수수료를 징수하지 않는 점을 알 수 있었다는 점, 또한 신청인은 담당직원이 교부한 확인서를 근거로 배상을 구하나, 본건 확인서는 수기로 작성되었고 외형적으로 보아도 조작한 것으로 오로지 이를 신뢰하여 증권회사를 믿고 장외거래를 하였다고 보기에는 어려운 점, 담당직원이 ‘△△’이라는 장외투자를 권유하여 300만원을 교부받아 동 주식을 매수, 신청인의 계좌에 입고하였고, 몇 달후 수익이 나지 않아 출고 후 처분하여 투자원금을 반환한 적이 있으므로 본건 투자를 권유함에 있어 10% 정도의 수익을 낼 수 있다고 강력히 권유함과 동시에 확인서를 작성하여 주었기 때문에 투자를 한 것이라는 신청인의 주장은 설득력이 없는 점등에 비추어 신청인은 위 담당직원의 행위가 피신청인의 사무에 속하지 아니함을 알았거나, 조금만 주의를 기울였어도 이를 알 수 있었다고 판단됨.

라. 결 론

그렇다면 피신청인은 피신청인의 직원과 신청인들 사이의 개인적인 거래상 발생한 불법행위에 대하여 이를 사용자로서 배상할 책임이 없음.

5-12 직원의 고객예탁금 횡령에 대한 사용자배상책임 여부

[일부인용] 담당직원이 신청인을 위하여 위탁계좌의 설정을 도운 후 매매의 포괄일임을 받아 증권카드를 임의로 보관하면서 아무런 유가증권 거래 없이 고객예탁금을 횡령한 경우 증권회사의 사용자배상 책임이 인정되고, 신청인으로서 투자자로서 증권카드를 반환받으려고 하거나 잔고확인을 게을리한 과실이 있으므로 그 배상액은 신청인의 과실을 상계한 금액임.(2005.12.6. 조정번호 제2005-82호)

가. 사실관계

신청인은 2003. 12. 8. ○○증권사(이하 “피신청인”이라 함) 지점 영업직원 대리 A씨(이하 “담당직원”이라 함)가 신청인의 사무실로 찾아와 증권투자 권유를 하자 이에 응하여 계좌개설신청서, 투자목적 기재서 등 증권계좌개설에 필요한 서류에 서명한 후 신청인 명의의 통장사본 및 신분증을 동 서류와 함께 담당직원에게 건네 주었음.

담당직원은 증권계좌개설에 필요한 서류를 회사에 제출하여 증권카드를 발급받은 후 증권카드 및 신분증을 신청인에게 돌려주려고 하였으나 신청인이 “꼭 필요하냐”라고 하여 그대로 보관하고 있었음. 신청인은 협의에 의하여 매매거래를 하는 것을 전제로 담당직원에게 매매를 일임하였고, <별표>와 같이 신청인의 위탁계좌로 총 금71백만원을 입금하였음

동 직원은 실제로 매매거래를 하지 않았으면서도 매매를 하고 있는 것처럼 신청인에게 허위보고를 하였고, 보관하던 증권카드로 예탁금을 인출하여 개인용으로 사용하였음.

<별표> 계좌 입출금 현황

입금일자	입금액	출금일자	출금액	비고
2003.12.9.	13,000,000	2003.12.12.~2004.2.4. (이하 “2004.2.4.자 횡령”)	13,003,100	2004.2.10. 회사 퇴직
2004.3.12.	8,000,000	2004.3.16. (이하 “2004.3.16.자 횡령”)	7,999,500	2004.3.8. 투자 상담사로 복직
2004.5.13.	50,000,000	2004.5.13.~5.14. (이하 “2004.5.14.자 횡령”)	50,002,500	2004.5.4. 의원 면직

담당직원은 2004.2.10. 회사를 퇴직하고, 같은 해 3.8. 투자상담사로 재입사하였다가, 2004.5.4.자로 의원면직하였으며, 피신청인은 신청인의 주소지로 2004.2.10. 및 5.4.에 담당 직원의 퇴직 및 잔고내역을 통보하였고, 피신청인 내부감사결과 동 퇴직 및 잔고통보문은 아파트 관리인이 수령하여 신청인의 부모에게 전달한 것으로 파악되었음.

나. 당사자의 주장

(1) 신청인의 주장

담당직원으로부터 투자권유를 받고 위탁계좌를 개설하였고, 동 계좌에 3차례에 걸쳐 총 71백만원을 입금하였으므로 담당직원이 횡령한 금원에 대하여는 피신청인이 사용자배상책임을 져야 함.

(2) 피신청인의 주장

담당직원이 증권계좌개설 이후 증권카드 및 신분증을 교부하려고 하였으나 신청인이 이를 거부하고 카드보유 및 계좌관리 권한 일체를 맡겼기 때문에 본건 횡령이 발생한 것이므로 피신청인은 횡령 금원 일부가 아닌 전부에 대하여 배상책임을 질 수 없음.

2004.5.14.자 횡령은 담당직원이 이미 피신청인 회사를 퇴사한 상태에서 예탁금을 인출한 것이므로 직무관련성이 인정되지 않을 뿐 아니라 피신청인이 동 직원의 퇴직사실 및 잔고통보를 신청인의 주소지로 2회 송부하였음에도 이를 알지 못한 것은 신청인의 과실로서 피신청인은 사용자배상책임을 없음.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 담당직원의 고객 예탁금을 횡령한 행위가 민법상의 사용자배상책임의 요건을 충족하는지 여부라 할 것임.

(1) 사용자배상책임의 사무집행 관련성

유가증권매매의 위탁매매인인 증권회사는 자기와 사용관계에 있는 피용자가 그 사무집행에 관하여 제3자에게 가해행위를 한 경우, 사용자는 민법 제756조(사용자의 배상책

임)에 의하여 손해배상책임이 발생함. 사용자 배상책임의 요건인 '사무집행에 관하여'라는 뜻은 피용자의 불법행위가 외형상 객관적으로 사용자의 사업활동 내지 사무집행 행위 또는 그와 관련된 것이라고 보여질 때에는 주관적 사정을 고려함이 없이 이를 사무집행에 관하여 한 행위로 본다는 것으로, 이는 피용자의 본래 직무와 불법행위와의 관련 정도 및 사용자에게 손해발생에 대한 위험 창출과 방지조치 결여의 책임 정도 등을 고려하여 판단함.⁵⁶⁰⁾

(2) 2004.2.4.자 항령 및 2004.3.16.자 항령 관련

본건 항령사실은 다음과 같은 사유로 사용자배상책임이 인정됨

① 담당직원은 피신청인 회사에 영업직원 대리로 2003.11월경 입사하여 2004.2.10. 퇴직하였고 같은 해 3.8. 다시 투자상담사로 복직하여 같은 해 5.4.까지 재직하였고, 동 재직기간에 담당직원의 투자권유에 의하여 본건 위탁계좌가 개설되어 신청인이 예탁금을 송금하였으며, 2004.2.4.자 항령 및 2004.3.16.자 항령도 동 기간에 발생하는 등 외형상 객관적으로 피신청인 사무집행과 관련성이 인정되는 점.

② 피신청인의 내규인 「증권카드 관리요령」에 의하면 “고객카드는 계좌개설 당일에 발급하여 고객에게 카드를 교부하는 것이 원칙”인데 본건은 영업점이 아닌 장소에서 계좌개설신청서가 작성되었음에도 고객의 카드수령 여부를 확인하는 절차가 없었고, 본건 계좌의 경우 예탁금이 입금된 이후 단 1차례의 매매거래도 이루어지지 않았음에도 관리자에게 맡겨진 채 이를 점검하는 내부통제시스템이 없었다는 사실에 비추어 피신청인에게도 손해발생에 대한 위험 창출과 방지조치 결여의 책임이 인정되는 점.

(3) 2004.5.13.자 항령 관련

본건 항령은 담당직원이 2004.5.4. 퇴직한 이후에 발생한 점에 비추어 담당직원과 피신청인 사이에 선임·감독의 관계나 지휘·감독의 관계에 있었다고 볼 수 없고 달리 피신청인이 업무수행을 묵인하고 이를 수행하는 것처럼 외관을 갖게 하였다고 볼 사정이 없으므로 사용자배상책임이 인정되지 아니함.

560) 대법원 2003.1.10. 선고 2000다34426 판결 참조.

(4) 손해배상액의 산정

본건 2004.2.4.자 횡령 및 2004.3.16.자 횡령으로 인하여 신청인에게 발생한 손실금은 금21,002,600원임. 신청인은 투자금액을 예탁한 자로서 다음과 같은 사실에 비추어 볼 때 예탁금 관리에 조금만 주의를 기울였어도 본건 횡령으로 인한 손실을 줄일 수 있었음에도 이를 소홀히 한 사실이 인정되므로 30%의 과실을 상계함.

① 신청인은 증권카드를 교부받지 않았음에도 계좌개설신청서에 “카드 수령함”이라고 기재하였고, 담당직원이 2004.12.10. 계좌개설 후 신청인에게 증권카드와 신분증을 돌려주려고 전화하자 신청인이 “꼭 필요하냐”라고 하며 반환받으려고 노력하지 않은 점.

② 신청인은 담당직원으로부터 매매가 이루어지고 있다는 허위보고를 받고도 계좌잔고 확인을 한번도 하지 않고 “일일이 보고할 필요 없다”고 말하였던 점.

라. 결 론

그렇다면 피신청인은 담당직원의 사용자로서 본건 횡령사실에 대하여 금14,701,820원의 배상책임이 인정되고 신청인의 나머지 청구는 이를 기각함.

5-13 고객 차명계좌 거래금액을 횡령한 경우 사용자배상책임 인정 여부

[기각] 타인 명의로 개설한 계좌 거래에 대하여 담당직원에게 일체의 권한을 일임하면서 계좌의 운용상황 등에 대하여는 전혀 확인을 하지 않았다면, 담당직원의 권유행위가 외관상 피신청인의 사무집행행위로 보일 여지가 있다고 하더라도 정상적인 업무수행방법으로 볼 수 없어 신청인은 담당직원의 행위가 피신청인의 사무집행 행위에 해당하지 않음을 알았거나 또는 중대한 과실로 인하여 알지 못한 경우에 해당된다고 보아야 할 것임.(2007.4.10. 조정번호 제2007-24호)

가. 사실관계

신청인은 2006.1. 직장동료의 소개로 피신청인 담당직원을 알게 되어, 동 직원으로부터 투자권유를 받고, 피신청인에 개설되어 있던 A씨(담당직원의 처남) 명의의 증권계좌로

2006.1.26. 2천만원을, 같은 해 2.2. 1천만원을 입금하였으며, 같은 해 6.9. 수익금 명목으로 담당직원으로부터 7백만원을 교부받음.

한편, 담당직원은 2006.3.16. 피신청인 회사를 퇴사하고, 같은 달 31일 다른 증권사에 입사하여 근무하였는데, 같은 해 8.4. “직원 및 가족들에 대해 피해를 끼치고 가서 죄송하다”는 내용의 편지를 남기고 잠적하였고, 잠적후 조사결과 담당직원은 투자자들에게 “수수료가 붙지 않는 계좌가 있는데, 이들 계좌를 이용하여 단타매매를 하면 약 월 10%의 이익을 낼 수 있다”며 투자권유를 하여 본인이 만들어 놓은 차명계좌에 입금케 하는 등의 방법으로 자금을 모아 주식거래를 하다가 손실이 증가하자 도주한 것으로 확인됨.

나. 당사자의 주장

(1) 신청인의 주장

담당직원이 자신과 지점장은 매매수수료 없는 계좌가 있어 매월 10%씩 수익금을 지급할 수 있다고 하여 투자를 하였으며, 담당직원이 피신청인 회사를 퇴사할 당시 피신청인은 본인 확인 없이 담당직원에게 고객돈을 인출해 주었는바, 피신청인은 신청인의 투자금 상당액을 배상할 책임이 있음.

(2) 피신청인의 주장

신청인은 월 10%의 수익금을 지급하겠다는 담당직원의 권유를 받고 본인 명의의 계좌를 개설하지 않은 채 차명계좌에 입금을 하였는바, 이는 피신청인의 사무집행행위와는 관련이 없다고 할 것이며, 신청인은 보험설계사로서 수년간의 주식투자 경험이 있어 담당직원의 권유행위가 위법임을 알았거나, 알지 못한 데 중대한 과실이 있다고 할 것임.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 담당직원의 위법한 투자권유행위에 대한 피신청인의 사용자배상책임 성립 여부라 할 것임

(1) 사용자배상책임 성립 여부

판례는 “피용자의 불법행위가 외관상 사무집행의 범위 내에 속하는 것으로 보이는 경우에 있어서도, 피용자의 행위가 사용자나 사용자에게 갈음하여 그 사무를 감독하는 자의 사무집행 행위에 해당하지 않음을 피해자 자신이 알았거나 또는 중대한 과실로 인하여 알지 못한 경우에는 사용자책임을 물을 수 없으며, 사용자책임이 면책되는 피해자의 중대한 과실이라 함은 거래의 상대방이 조금만 주의를 기울였더라면 피용자의 행위가 그 직무권한 내에서 적법하게 행하여진 것이 아니라는 사정을 알 수 있었음에도 만연히 이를 직무권한내 행위라고 믿음으로써 일반인에게 요구되는 주의의무에 현저히 위반하는 것으로 거의 고의에 가까운 정도의 주의를 결여하고, 공평의 관점에서 상대방을 구태여 보호할 필요가 없다고 봄이 상당하다고 인정되는 상태를 말한다”라고 판시하고 있음.⁵⁶¹⁾

주식거래와 관련하여 월 10% 수익금 지급 약정은 「증권거래법」 위반으로 무효임에도 신청인은 담당직원으로부터 이러한 내용의 권유를 받고 투자하였으며, 본인 명의의 계좌 개설 없이 타인 명의의 계좌에 입금을 하고, 동 계좌를 통한 거래에 대하여 담당직원에게 일체의 권한을 일임하면서 계좌의 운용상황등에 대하여는 전혀 확인을 하지 않았는바, 담당직원의 권유행위가 외관상 피신청인의 사무집행행위로 보일 여지가 있다고 하더라도 그 형태가 정상적인 업무수행방법을 현저하게 이탈한 것이어서 5년 넘게 주식투자를 해 온 신청인은 담당직원의 행위가 피신청인의 사무집행 행위에 해당하지 않음을 알았거나 또는 중대한 과실로 인하여 알지 못한 경우에 해당된다고 보아야 할 것임.

라. 결 론

그렇다면 신청인의 청구는 이유없어 기각함.

5-14 원금보장 약속을 통한 투자권유 및 투자금 유용 관련 사용자책임 인정여부

[일부인용] 신청인들로서는 무효인 “원리금보장약정”의 이행을 요구할 법적권리는 없다 하더라도, 담당직원이 별다른 투자경험이 없는 신청인들에게 원리금보장약정을 통해 본건 투자를

561) 대법원 1998.7.24. 선고 97다49978 판결 참조.

권유한 행위는 명백히 부당권유행위에 해당하고, 담당직원이 신청인 계좌에서 투자금을 임의 출금하여 그 일부를 투자목적과 무관하게 사용한 바, 피신청인은 담당직원의 이로 인해 발생한 신청인들의 손해를 배상할 책임을 부담한다 할 것임.(2010.4.13. 조정번호 제2010-34호)

가. 사실관계

신청인들(A씨, B씨, C씨)은 신청의 D씨(신청인 C씨의 동서)의 소개로 ○○증권회사(이하 “피신청인”이라 함) 지점 투자상담사 E씨(이하 “담당직원”이라 함)를 알게 되었는데, 담당직원은 신청인들에게 원리금보장조건⁵⁶²⁾을 제시하며 주식매매를 일임할 것을 권유하였으며, 신청인들은 각 계좌개설시에 자신의 계좌를 담당직원이 관리하도록 하는 “투자상담사 서비스계좌 등록 동의서”를 작성하여 피신청인에 제출함.

이에 신청인들은 피신청인 지점에서 각 위탁계좌를 개설한 후 2006.2.1.~2008.6.2. 기간중 합계 2억 7,510만원을 각 위탁계좌에 입금하였고, 담당직원은 2006.2.2.~2008.12.26. 기간중 HTS로 합계 약 170.9억원 상당의 주식매매거래를 실행하였음.⁵⁶³⁾

한편 담당직원은 2006.2.10.~2008.6.3. 기간중 합계 2억 3,136만원을 신청인들의 위탁계좌에서 임의 출금하여 자신이 고용하고 있던 위 D씨의 은행계좌로 이체하였는데, 그 중 1억 3,437만원은 2006.2.28.~2009.2.16. 기간중 월수익금 명목으로 신청인들에게 지급되었으나, 나머지 잔액 약 1억원은 담당직원이 다른 투자자의 손실금 변제 또는 이자 명목으로 모두 사용하였음. 본건과 관련하여 담당직원은 2009.11.26. ○○지방법원에서 “업무상 배임”으로 징역 1년 6월의 실형을 선고받고 현재 복역 중임.

신청인 A씨(만 78세), B씨(만 74세)는 고령의 농업종사자로서 금융상품에 투자한 경험이 없으며, 신청인 C씨는 자영업자(세탁소 운영)로서 금감원 문답과정에서 “약 7년전에 200만원 정도 주식투자를 한 적이 있다”고 진술하였으나 다른 투자경험은 없는 것으로 나타남.

562) 원금보장, 원금에 대한 월 수익률 1.5~2% 보장, 원금회수 요구시 1개월 이내 환급 약속조건.

563) 신청인들은 계좌개설시 교부받은 거래매체(증권카드, 보안카드 등)를 담당직원이 주식투자를 위해 필요하다고 하여 건네주었고, 담당직원은 이를 이용하여 위 주식거래 및 출금을 실행함.

신청인들의 계좌는 모두 담당직원에 의해 HTS로 거래가 이루어져 피신청인으로부터 신청인들에게 별도의 거래내역 및 잔고가 통보되지는 않았고, 신청인들은 담당직원이 약정으로 일정기간 수익금을 입금하자 잔고 등을 직접 확인하지는 않았음.

나. 당사자의 주장

(1) 신청인의 주장

신청인들은 D씨의 소개로 알게 된 담당직원이 “원리금을 보장하며 매월 1.5~2.0%의 이자를 지급하겠다”고 투자를 권유하여 이를 믿고 피신청인에 위탁계좌를 개설하고 투자금을 입금하여 “매매거래를 일임”하였던 것임. 그러나 담당직원은 위 권유당시의 약속을 지키지 않았을 뿐만 아니라 신청인들의 투자금을 임의로 인출해 유용하였으므로 피신청인이 그 손해를 배상하여야 함.

(2) 피신청인의 주장

신청인들의 계좌에서 출금된 자금은 모두 신청인 C씨의 인척인 D씨의 은행계좌로 이체된 점, 신청인들은 HTS 및 홈페이지 접속을 통하여 투자금 이체사실을 인지할 수 있었음에도 회사를 상대로 별다른 이의제기가 없었던 점 및 이자명목으로 금원을 수령하였다는 점 등을 감안하면, 신청인들과 D씨 또는 담당직원 사이에는 “사적 금전거래”가 있었다고 보아야 함.

그렇다면 신청인들이 주장하는 “원리금보장약정”이 있었던 것이 사실이고 담당직원이 신청인들에 대한 관계에서 업무상 배임죄로 형사처벌을 받았다 하더라도 이는 피신청인의 사무집행과는 무관한 것으로서, 담당직원의 행위에 관하여 피신청인의 손해배상책임이 성립될 수는 없음.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 ① 담당직원의 주식 부당권유 및 투자금 유용 관련 피신청인의 손해배상 책임 여부 및 ② 구체적인 손해배상액의 산정 등이라 할 것임.

(1) 피신청인의 “사적 금전거래” 관련 주장에 대한 판단

피신청인은 본건은 신청인들과 D씨 또는 투자상담사인 담당직원 사이의 “사적 금전거래”에 기반하여 발생한 사안으로서 피신청인과는 무관하므로 본건과 관련한 피신청인의 책임은 없다는 취지로 주장하나, 다음과 같은 점을 감안할 때 신청인들과 피신청인 사이에는 직접 유효한 “위탁계약”이 체결되었다 할 것이므로 피신청인의 위 주장은 받아들이기 어렵다 할 것임.

① 신청인들은 피신청인 지점에 내점하여 직무상 권한이 있는 창구직원을 통해 위탁계좌를 개설하고 위탁계좌에 직접 또는 은행이체 등을 통하여 투자자금을 입금한 점.

② 신청인들은 위 위탁계좌 개설시 담당직원으로 하여금 자신들의 계좌를 관리(상담, 주문수탁 등)하도록 하는 “투자상담사 서비스계좌 등록 동의서”에 기명·날인하여 피신청인에 제출하였으며, 신청인들 계좌에서 실제 매매거래(170.9억원 상당)가 이루어진 점.

③ 대법원 판례에 의하면, “위탁계좌”가 개설된 본건과 달리 투자자가 “증권회사 직원의 개인계좌”로 투자금을 입금한 사안에서도 증권회사의 책임을 인정하고 있는 점.⁵⁶⁴⁾

(2) 피신청인의 손해배상책임

증권회사 또는 그 임·직원의 부당권유행위를 금지하는 「증권거래법」 제52조 제1호⁵⁶⁵⁾는 공정한 증권거래질서의 확보를 위하여 제정된 강행법규로서 이에 위배되는 주식거래에 관한 투자수익보장약정은 무효라 할 것이나, 증권회사의 임·직원이 강행규정에 위반한 투자수익보장으로 투자를 권유하였으나 투자 결과 손실을 본 경우에, 거래행위와 거래방법, 고객의 투자상황, 거래의 위험도 및 이에 관한 설명의 정도 등을 종합적으로 고려한 후 당해 권유행위가 경험이 부족한 일반 투자자에게 거래행위에 필연적으로 수반되는 위험성에 관한 올바른 인식형성을 방해하거나 고객의 투자상황에 비추어 과대한 위험성을 수반하는 거래를 적극적으로 권유한 경우에 해당하여 결국 고객에 대한 보호의무를 저버려 위법성을 띤 행위로 평가될 수 있는 경우 투자자에 대한 불법행위책임이

564) 대법원 2009.5.14. 선고 2007다75921 판결 등 참조.

565) 제52조 제1호. 유가증권의 매매거래에 있어서 고객에 대하여 당해 거래에서 발생하는 손실의 전부 또는 일부를 부담할 것을 약속하고 권유하는 행위.

성립하며,⁵⁶⁶⁾ 법원은 투자자가 증권회사의 증권거래계좌를 이용하지 않은 채 별도로 증권회사 직원과 사이에 개인적인 자금투자거래관계를 맺어 오고 있었다는 사정만으로 곧바로 “피용자의 행위가 사용자의 사무집행행위에 해당하지 않음을 피해자 자신이 알았거나 또는 중대한 과실로 알지 못한 경우”에 해당한다고 할 수 없으므로 증권회사의 사용자책임이 인정된다고 판시함.⁵⁶⁷⁾

위와 같은 규정 및 판례의 취지를 종합할 때, 신청인들로서는 담당직원 또는 피신청인에게 무효인 당초의 “원리금보장약정”의 이행을 요구할 법적 권리는 없다 하더라도, 담당직원이 위와 같이 고령의 농업종사자로서 금융상품에 투자한 경험이 전혀 없는 신청인 A씨(만 78세), B씨(만 74세)와 자영업자(세탁소 운영)로서 별다른 투자경험이 없는 신청인 C씨에게 구 「증권거래법」 제52조 제1호에 위반하는 원리금보장약정을 통해 본건 투자를 권유한 행위는 명백히 부당권유행위에 해당한다 할 것임.

그에 더하여 위에서 본 바와 같이 담당직원은 신청인들의 계좌에서 투자금을 임의 출금하여 그 일부 금원을 투자목적과 무관한 다른 투자자의 손실금 변제 또는 이자 명목으로 사용하기까지 한 바, 결국 피신청인은 담당직원의 위와 같은 행위로 인하여 발생한 신청인들의 손해를 각 배상할 책임을 부담한다 할 것임.

(3) 손해배상액 산정

신청인 A씨의 손해액은 40,498,380원, 신청인 B씨의 손해액은 53,284,822원, 신청인 C씨의 손해액은 46,620,795원 상당이라 할 것임.

다만, 본질적으로 투자자는 자신의 판단과 책임으로 투자하는 것으로서 그 손해 또는 이익은 투자자에게 귀속되는 것이 대원칙이라 할 것이고, 신청인들은 담당직원으로부터 원리금보장 조건의 부당권유를 받고 별다른 의심 없이 매매거래 일체를 일임하면서 담당직원

566) 대법원 1996.8.23. 선고 94다38199 판결 참조.

567) 피고 증권회사 담당직원(투자상담사)은 알고 지내던 원고들에게 특정 종목 등에 투자하면 큰 수익을 얻을 수 있다고 투자를 권유하였고 이에 원고들은 피고 증권회사에 계좌를 개설하지 않은 채 피고 담당직원의 개인 은행계좌로 투자금을 송금하였는데, 담당직원은 투자자금을 편취 후 도주하여 특정 경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률위반(사기)죄 등으로 징역 6년의 실형을 선고 받아 확정된 사안임 (대법원 2009.5.14. 선고 2007다75921 판결).

게 거래매체(증권카드, 보안카드, 공인인증서)를 교부한 후 거래내역 및 잔고 확인을 소홀히 함으로써 손해의 발생·확대에 원인을 제공한 책임이 있으므로, 신청인들의 과실을 참작하여 신청인 A씨, B씨는 각 30%, 신청인 C씨는 40%의 과실상계를 함이 타당함.⁵⁶⁸⁾

라. 결 론

피신청인은 신청인 A씨에게 손해금액 40,498,380원에서 30%의 과실상계를 한 나머지인 금 28,348,866원을, 신청인 B씨에게 손해금액 53,284,822원에서 30%의 과실상계를 한 나머지인 금 37,299,375원을, 신청인 C씨에게 손해금액 46,620,795원에서 40%의 과실상계를 한 나머지인 금 27,972,477원을 각 지급할 책임이 있다 할 것이므로 신청인들의 이 부분 청구를 각 인용하고, 신청인들의 나머지 청구는 이유 없어 이를 각각 기각함.

5-15 고객예탁금 횡령에 따른 손해배상책임

[일부인용] 신청인 子의 친구이자 피신청인의 피용자 정〇〇가 신청인에게 펀드 투자를 권유하고 펀드 예탁금용으로 수표를 수취하였으나 본인 명의로 수표를 배서 및 입금하는 방식으로 자금을 횡령하여 개인적으로 사용한 사안에 대하여 투자권유 및 펀드가입 신청 서류 작성은 펀드판매를 위한 일련의 행위이므로 외형상 객관적으로 피신청인의 사무집행에 해당되고 이는 민법 제756조에서 규정하는 피용자의 ‘사무집행에 관한 행위’라고 할 것이어서 피신청인에게 민법 제756조에 따른 불법행위로 인한 손해배상책임이 인정된다고 판단한 사례 (2015.2.10. 조정번호 제2015-4호).

가. 사실관계

2006.9월경(일자미상) 신청인의 子 A은 H투자증권(이하 ‘피신청인’이라 함) 모지점에서 차장으로 근무중이던 친구 정〇〇으로부터 베트남 펀드에 투자할 것을 권유받음.

2006.12.27. 신청인은 N중양회 금남로 지점에서 수표 3천만원을 발급받아 당일 피신청

568) 신청인 A씨, B씨의 경우 고령의 농업종사자로서 금융상품에 투자한 경험이 전혀 없는 점을 감안하여 신청인 C씨와 과실비율을 달리 적용함.

인 모지점에 내방하여 베트남 펀드 2호 가입서류를 작성하고 동 펀드 예탁금용으로 상기 수표를 정○○에게 전달.

정○○은 펀드가입 처리를 하지 아니한 채 신청인으로부터 받은 가입서류를 폐기하고 수표는 같은 달 29일 N중앙회 금남로지점에 본인명의로 배서 및 입금하는 등 동 자금을 횡령하여 개인적으로 사용함.

2007.6.20. A이 정○○과 통화하면서 “가입한 베트남 펀드가 조회되지 않는다”고 하며 의문을 제기하자, 정○○은 “베트남 펀드는 해외 주식이기 때문에 환매요청을 해야 계좌상에 조회가 가능하다”고 답변.

2014.6.13. 신청인은 펀드를 해지하기 위해 피신청인 서광주지점에 연락하였다가 정○○이 고객자금 횡령으로 퇴사한 사실(2013.12.4. 직권면직) 및 베트남펀드에 가입된 사실이 없음을 알게되었고 이에 A이 정○○에게 항의하자 정○○은 예탁금 3천만원을 횡령하였음을 인정.

한편, 피신청인은 정○○이 본건과 유사한 방법으로 고객에게 투자권유한 뒤 예탁금을 횡령하여 고객으로부터 피소(被訴)되었으며, 1심에서는 피신청인의 배상책임을 인정하였고 현재 항소심 진행 중

나. 당사자 주장

(1) 신청인 주장

피신청인의 직원 정○○으로부터 투자권유를 받아 펀드가입에 필요한 서류를 작성하였고 예탁금을 맡겼으므로 직원이 횡령한 금원 전액을 피신청인이 배상해야 할 것임.

(2) 피신청인 주장

신청인 명의로 계좌가 개설되지 않았을 뿐만 아니라 신청인이 교부하였다고 주장하는 예탁금이 입금되지 않은 이상 펀드거래 여부를 확인할 수 없는 등 신청인과 정○○간 개인적인 금전거래 관계로 보이므로 배상책임을 없음.

다. 위원회 판단

◆ 본건의 쟁점은 ① 피용자의 불법행위에 따른 사용자 배상책임 인정 여부 및 ② 구체적인 손해배상범위라 할 것임.

(1) 피용자의 불법행위에 따른 손해배상책임 여부

타인을 사용하여 어느 사무에 종사하게 한 자는 피용자가 그 사무집행에 관하여 제3자에게 가한 손해를 배상할 책임이 있음(「민법」 제756조 제1항 본문).

사용자책임의 요건인 ‘사무집행에 관하여’는 피용자의 불법행위가 외형상 객관적으로 사용자의 사업활동 내지 사무집행행위 또는 그와 관련된 것이라고 보일 때에는 행위자의 주관적 사정을 고려없이 이를 사무집행에 관하여 한 행위로 본다는 것이고, 외형상 객관적으로 사용자의 사무집행에 관련된 것인지 여부는 피용자의 본래 직무와 불법행위와의 관련 정도 및 사용자에게 손해발생에 대한 위험창출과 방지조치 결여의 책임이 어느 정도 있는지를 고려하여 판단하여야 함.

다만, 피용자의 불법행위가 외관상 사무집행의 범위 내에 속하는 것으로 보이는 경우에도 피용자의 행위가 사용자나 사용자에게 갈음하여 그 사무를 감독하는 자의 사무집행행위에 해당하지 않음을 피해자 자신이 알았거나 중대한 과실로 인하여 알지 못한 경우에는 사용자책임을 물을 수 없음(2010.12.9. 선고 2009다 101824 판결 등).

살피건대, 펀드 판매행위는 증권회사의 업무(舊 간접투자자산 운용업법 제55조, 제57조)에 해당되는 바, 정○○의 투자권유 및 펀드가입 신청서류 작성은 펀드판매를 위한 일련의 행위로 볼 수 있으며 이는 곧 정○○의 본래 직무에 해당되는 바, 신청인이 직접 피신청인 모지점에 내방한 상황에서 정○○이 펀드가입에 필요한 서류 및 펀드투자금 3천만원을 교부받은 것은 외형상 객관적으로 피신청인의 사무집행에 해당된다고 할 것임.

또한, 비록 신청인이 1989.11.30. 피신청인의 광주지점에서 계좌를 개설해본 경험이 있다고 할 지라도 신청인의 자(A)와 정○○은 친구사이인 점을 감안할 때 펀드관련 가입서류만을 작성하고 3천만원을 교부한 채 동 자금이 제대로 입금처리 되었는지 확인하지 않고 펀드가입 확인서류를 교부받지 않았다 하더라도 이를 두고 신청인에게 정○○이 횡령할 것임을 알았거나 알지못한 것에 대한 중과실이 있다고 볼 수는 없다 할 것임.

그렇다면, 정○○이 증권회사에 재직하고 있는 점을 이용하여 신청인으로부터 펀드가 입에 필요한 서류와 예탁금을 교부받은 행위는 민법 제756조에서 규정하는 피용자의 ‘사무집행에 관한 행위’라고 봄이 상당한 바, 피신청인은 민법 제756조에 따른 불법행위로 인한 손해배상책임이 인정된다고 할 것임.

(2) 손해배상범위

불법행위로 인하여 가해자가 배상책임을 지는 손해액의 범위는 그 불법행위와 상당인 과관계에 있는 모든 손해라 할 것이고, 그 중 재산상 손해는 위법한 가해행위로 인하여 발생한 재산상 불이익, 즉 그 위법행위가 없었더라면 존재하였을 재산상태와 그 위법행위가 가해진 현재의 재산상태의 차이를 말하는 것이며 그 손해액은 원칙적으로 불법행위시를 기준으로 산정하여야 함(2011.4.28. 선고 2010다106702 판결 등).

피신청인의 책임제한과 관련하여, 피해자의 부주의를 이용하여 고의로 불법행위를 저지른 자가 그 피해자의 부주의를 이유로 자신의 책임을 감하여 달라고 주장하는 것은 허용될 수 없다고 할 것이며, 불법행위가 사기, 횡령 등의 영득행위인 경우 등 과실상계를 인정하게 되면 가해자로 하여금 불법행위로 인한 이익을 최종적으로 보유하게 하여 공평의 이념이나 신의칙에 반하는 결과를 가져오는 경우에만 예외적으로 과실상계가 허용되지 않음(2013.9.26. 선고 2012다1146 판결 등).

살피건대, 피신청인이 판매보수 등을 취득한 사실이 없으므로 불법행위로 인한 이익을 취득한 사실이 없는 점에서 과실상계가 허용될 수 있다 할 것인 바, 수표입금시 배서를 하지 아니한 점, 입금관련 전표처리를 하지 아니한 점 및 적정하게 펀드가입되었음을 확인할 수 있는 서류를 받지 아니한 점 등 펀드가입 당시 신청인에게 부주의가 있었으며, 본건 사고발생일(2006.12.27.)로부터 현재에 이르기까지 손해확대 방지를 위한 조치를 취하지 않은 점 등을 고려할 때 신청인에게 30%의 과실이 있다고 판단됨⁵⁶⁹⁾.

라. 결론

569) 한편, 신청인은 실제 투자자의사가 있었으므로 현재의 수익률(민원신청일 2014.6.13.기준)도 배상금액 산정시 고려할 필요가 있는 바, 2006년 당시 피신청인이 판매한 베트남펀드 혼합 2호의 수익률은 -34.32%로 30% 과실상계시 배상금액과 환매금액이 유사

그렇다면, 피신청인은 신청인에게 발생한 손해금액 30,000,000원 중 피해액의 70%에 해당하는 금액을 배상할 책임이 있다 할 것이므로 신청인의 청구는 이유 있어 이를 인용함.

5-16 증권회사 직원의 고객예탁금 편취에 따른 손해배상책임

[일부인용] 신청인이 피신청인의 지점이 아닌 신청인 직장에서 신탁상품 가입서류를 작성하고 피신청인 직원에게 신탁상품 청약금을 전달만 하고 실제 동 투자금이 입금되었는지 확인하지 않았으며 신탁상품 가입 확인서류 또한 교부받지 않았다 하더라도 이러한 사정만으로는 신청인에게 피신청인 직원이 편취할 것임을 알았거나 알지 못한 것에 중과실이 있었다고 보기는 어렵다고 판단한 사례(2016.11.9. 조정번호 제2016-30호).

가. 사실관계

2012.4.26. 신청인은 피신청인 모지점 乙 대리(이하 ‘피신청인 직원’이라고 함)를 관리직원⁵⁷⁰⁾으로 하여 박○○, 조○○ 명의로 계좌를 개설하고, 다음 날 만기 1년의 매칭형신탁 12-050호⁵⁷¹⁾에 각각 427,382,921원, 427,382,922원을 투자.

2013.4.17. 피신청인 직원은 신청인의 직장(L카드)을 방문하여 K기업 ABCP에 투자하는 신탁상품에 투자할 것을 권유하였고, 신청인은 동 신탁상품의 청약을 위해 신청인의 부하직원인 이○○, 김○○ 명의로 계좌를 신규 개설하였음.

피신청인 직원은 선물 및 옵션투자로 손실⁵⁷²⁾을 입게 되자 신청인을 속여 신청인의 자금을 자신의 투자금으로 사용하기로 마음먹고⁵⁷³⁾, 2013.4.18. 신청인의 직장을 방문하여 신청인에게 신탁상품 청약서를 작성하도록 한 후, 신청인이 K은행 ***지점에서 발행

570) 신청인은 피신청인 직원이 유진투자증권에서 근무(2007.12.~2009.10.)했던 기간부터 피신청인 직원과 거래해왔음

571) 2013.4.30. 동 신탁계약의 만기가 도래하자 이를 해지하고, 투자금의 일부를 2013.5.23. 매칭형신탁 13-087호에 각각 280,472,160원, 261,774,016원씩 재투자

572) 2010.2. ~ 2015.11. 기간 중 선물옵션으로 18억 66백만여원 손실

573) 피신청인 직원에 대한 1심 판결문에서 인용(서울중앙지법 2016.4.26.선고 2015고합 1250)

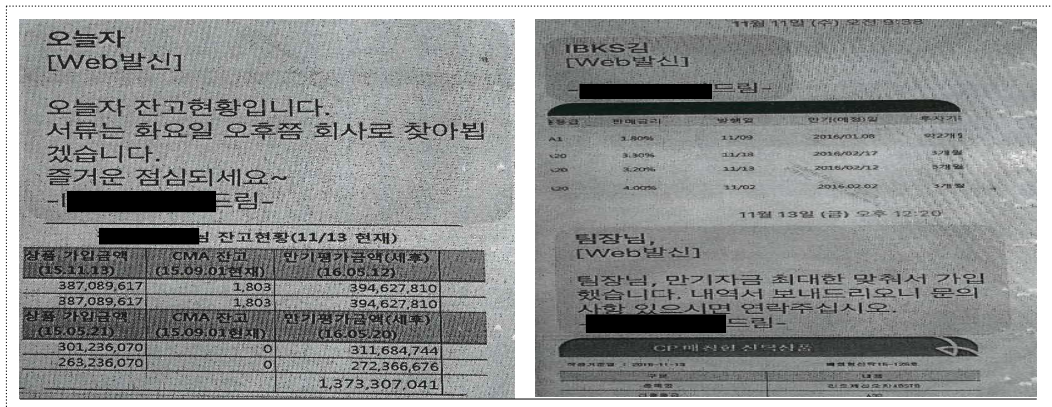
한 자기앞수표 2장(각 347,252,068원)을 신청인으로부터 전달받아 자신의 I은행 계좌로 동 자금(694,504,136원)을 입금하여 편취.

2014. 5. 21. 신청인이 2013.5.23. 가입한 매칭형신탁13-087호의 만기가 도래하자, 피신청인 직원은 이를 편취하기 위하여 신청인의 직장을 방문하여 만기자금을 유사한 상품에 재투자할 것을 권유.

신청인은 신규상품 청약을 위해 계약서를 작성하고 자금출금을 위하여 피신청인 직원에게 박○○, 조○○ 명의 계좌의 증권카드와 자신의 인감을 날인한 출금증을 전달하면서 상기 계좌의 비밀번호를 알려주었으며, 피신청인 직원은 신청인으로부터 전달받은 증권카드 등을 이용하여 박○○ 명의 계좌에서 277,198,957원을, 조○○ 명의계좌에서 296,994,808원을 각각 출금하여 자신의 K은행 계좌로 입금하여 편취.

피신청인 직원은 위와 같은 자금편취 사실을 숨기기 위해 신청인이 박○○ 명의 등의 계좌개설시 신청한 SMS 통보 요청을 삭제하고, 신청인의 금융상품 가입내역 및 잔고현황 등을 허위로 작성하여 SMS를 통해 2~3개월 단위로 신청인에게 전송하였음.

피신청인 직원이 허위로 작성하여 신청인에게 발송한 SMS 사례



2015.12.30. 피신청인 직원은 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(사기) 등 혐의로 기소되어 1심, 2심에서 징역 5년을 선고받고, 상고하였으나 상고기각(2016.9.28.)되어 판결이 확정됨.

법원은 박○○ 명의 계좌(#00670002069) 등을 신청인의 차명계좌로 판단하고 피신청인 직원이 신청인으로부터 1,268,697,901원⁵⁷⁴⁾을 편취하였다고 인정함.

나. 당사자 주장

(1) 신청인 주장

피신청인 직원으로부터 투자권유를 받아 계좌개설과 신탁가입에 필요한 서류를 작성하였고 예탁금을 맡겼으므로 피신청인 직원이 편취한 금원 전액을 사용자인 피신청인이 배상해야 할 것임.

(2) 피신청인 주장

신청인은 금융회사에서 근무하는 자임에도 피신청인 직원에게 자금출금에 필요한 증권카드를 전달하고 비밀번호를 알려주어 피신청인 직원의 편취행위를 용이하게 하였으므로 신청인의 주장을 전부 수용할 수 없음.

다. 위원회의 판단

◆ 본 사건의 쟁점은 피용자의 불법행위에 따른 사용자배상책임이 인정되는지 및 구체적인 손해배상범위라 할 것임.

(1) 피용자의 불법행위에 따른 손해배상책임 여부

타인을 사용하여 어느 사무에 종사하게 한 자는 피용자가 그 사무집행에 관하여 제3자에게 가한 손해를 배상할 책임이 있음(「민법」 제756조 제1항 본문).

사용자책임의 요건인 ‘사무집행에 관하여’는 피용자의 불법행위가 외형상 객관적으로 사용자의 사업활동 내지 사무집행행위 또는 그와 관련된 것이라고 보일 때에는 행위자의 주관적 사정을 고려없이 이를 사무집행에 관하여 한 행위로 본다는 것이고, 외형상

574) 법원은 피신청인 직원이 2013.9.10. 출금한 23,138,800원을 포함한 1,291,836,701원을 편취금액으로 보았으나 신청인이 23,138,800원을 피신청인 직원으로 돌려받았다고 진술하여 동 금액은 제외

객관적으로 사용자의 사무집행에 관련된 것인지 여부는 피용자의 본래 직무와 불법행위와의 관련 정도 및 사용자에게 손해발생에 대한 위험창출과 방지조치 결여의 책임이 어느 정도 있는지를 고려하여 판단하여야 함.

다만, 피용자의 불법행위가 외관상 사무집행의 범위 내에 속하는 것으로 보이는 경우에도 피용자의 행위가 사용자나 사용자에게 같음하여 그 사무를 감독하는 자의 사무집행행위에 해당하지 않음을 피해자 자신이 알았거나 중대한 과실로 인하여 알지 못한 경우에는 사용자책임을 물을 수 없음(2010.12.9. 선고 2009다 101824 판결 등).

신탁상품 판매행위는 증권회사의 업무에 해당(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제6조 등)되는 바, 피신청인 직원의 투자권유 및 신탁가입 신청서류 작성은 신탁상품 판매를 위한 일련의 행위로 볼 수 있으며 이는 곧 피신청인의 본래 직무에 해당하므로 피신청인 직원이 신청인의 직장내에 방문하여 계좌개설서류와 신탁상품 가입에 필요한 서류 및 투자금을 교부받은 것은 외형상 객관적으로 피신청인의 사무집행에 관련되었다고 할 것임.

신청인은 피신청인 직원이 E투자증권에서 근무('07.12.~'09.10.)할 때부터 피신청인 직원과 거래해왔으며, 2012.4.27. 피신청인 직원을 통하여 신탁상품에 가입하여 1년만기 도래 후 2013.5.23. 정상적으로 재투자한 사실이 있는 점을 감안할 때, 비록 신청인이 피신청인의 지점이 아닌 신청인 직장내에서 신탁상품 가입서류를 작성하고 피신청인 직원에게 신탁상품 청약금을 전달만 하고 실제 동 투자금이 입금되었는지 확인하지 않고 신탁상품 가입 확인서류 또한 교부받지 않았다 하더라도 이러한 사정만으로는 신청인에게 피신청인 직원이 편취할 것임을 알았거나 알지 못한 것에 중과실이 있었다고 보기는 어렵다 할 것임.

그렇다면, 피신청인 직원이 증권회사에 재직하고 있는 점을 이용하여 신청인으로부터 신탁상품 가입에 필요한 서류와 청약금을 전달받은 행위는 민법 제756조에서 규정하는 피용자의 '사무집행에 관한 행위'라고 봄이 상당하므로 피신청인은 피신청인 직원의 불법행위로 인한 신청인의 손해를 배상할 책임이 인정된다고 할 것임.

(2) 손해배상범위 및 책임제한

불법행위로 인하여 가해자가 배상책임을 지는 손해액의 범위는 그 불법행위와 상당인

과관계에 있는 모든 손해라 할 것이고, 그 중 재산상 손해는 위법한 가해행위로 인하여 발생한 재산상 불이익, 즉 그 위법행위가 없었더라면 존재하였을 재산상태와 그 위법행위가 가해진 현재의 재산상태의 차이를 말하는 것이며 그 손해액은 원칙적으로 불법행위를 기준으로 산정해야 함(2011.4.28. 선고 2010다106702 판결 등).

따라서, 신청인의 손해액은 피신청인 직원이 두 차례에 걸쳐 편취한 금원의 합계인 1,268,697,901원 이라고 할 것임.

피해자의 부주의를 이용하여 고의로 불법행위를 저지른 자가 그 피해자의 부주의를 이유로 자신의 책임을 감하여 달라고 주장하는 것은 허용될 수 없다고 할 것이며, 불법행위가 사기, 횡령 등의 영득행위인 경우 등 과실상계를 인정하게 되면 가해자로 하여금 불법행위로 인한 이익을 최종적으로 보유하게 하여 공평의 이념이나 신의칙에 반하는 결과를 가져오는 경우에만 예외적으로 과실상계가 허용되지 않음(대법원 2013.9.26. 선고 2012다1146 판결 등).

피신청인은 본건 피신청인 직원의 편취와 관련하여 신탁상품 판매에 따른 판매보수 등을 취득한 사실이 없는 등 불법행위로 인한 이익을 취득한 사실이 없다는 점에서 과실상계가 허용될 수 있다 할 것이며 신청인은 금융회사의 직원임에도 차명계좌를 이용하는 등 정상적이지 않은 방식으로 투자금을 운용하면서 피신청인의 지점이 아닌 외부에서 피신청인 직원에게 고액의 금원(694,504,136원)을 직접 전달하면서 동 투자금이 제대로 입금되었는지와 신탁상품에 정상적으로 가입되었는지를 확인하지 아니하였을 뿐만 아니라 피신청인 직원에게 입출금에 필요한 증권카드를 전달하고 비밀번호를 알려주는 등 신청인에게도 상당한 부주의가 있었던 점을 종합할 때 신청인에게 50%의 과실이 있다고 판단됨.

라. 결 론

그렇다면, 피신청인은 신청인에게 발생한 손해액 1,268,697,901원 중 50%에 해당하는 금원을 배상할 책임이 있다 할 것이므로 신청인의 청구는 이유 있어 이를 일부 인용함.

제4절 기타

5-17 투자자문계약 해지 청구의 건

[일부인용] 「방문판매 등에 관한 법률」 제29조(계약의 해지)는 계속거래업자 등과 계속거래 등의 계약을 체결한 소비자는 언제든지 계약기간 중 계약을 해지할 수 있다고 규정하고 있으며, 판례도 계속적 계약의 기초가 되는 신뢰관계가 파괴되어 계약관계를 그대로 유지하기 어려운 경우 계약 당사자가 계약관계를 막바로 해지할 수 있다고 판시하고 있음. 본건은 피신청인이 계속적 거래관계에 있어 지켜야 할 신뢰관계를 다하지 못하였다는 점에서 신청인의 계약해지 주장은 이유 있음.(2005.7.12. 조정번호 제2005-41호)

가. 사실관계

신청인은 2005.1.9. 모 호텔에서 개최된 피신청인의 투자자문 관련 설명회에 참석하여 피신청인의 전무인 A씨(이하 “담당직원”이라 함)의 강연을 청취한 것을 계기로 같은 달 13일 담당직원과 전화통화를 통하여 구두로 피신청인과 투자자문계약⁵⁷⁵⁾을 체결함(다만, 신청인은 계약체결일에 자문료 중 120만원만 카드로 결제하였음).

신청인은 계약체결 다음날인 2005.1.14. 담당직원의 투자자문⁵⁷⁶⁾을 받고 주식거래를 하였으나 손실이 발생하자 바로 해지를 요청하였는데, 한달간 자문을 계속 받아보되 손실이 발생하면 계약을 해지해주겠다는 담당직원의 말에 해지를 보류하다가, 자문내용에 따른 거래로 손실이 계속 발생하자 같은 달 28일 계약을 해지한다는 통지서를 내용증명 우편으로 피신청인에게 발송함.

나. 당사자의 주장

(1) 신청인의 주장

575) 자문계약 내용 - 계약기간 3월, 자문료 200만원

576) 담당직원과의 전화통화에 의한 투자자문의 통상적인 투자자문정보 제공은 하루 두차례 SMS(휴대폰 문자서비스로 모든 회원에게 동일한 정보를 제공)로 행해짐.

신청인은 피신청인의 과대광고에 속아 투자자문계약을 체결하게 되었으며, 자문내용에 따른 투자로 오히려 손실을 입게 되었는데, 투자자문계약을 해지하고 기납입한 자문료 120만원 및 자문료의 카드결제에 따른 할부수수료 15만원의 반환을 청구함.

(2) 피신청인의 주장

본건 「투자자문계약서」 제12조 제3항은 회사의 중대한 과실이 없는 한 계약자는 계약의 해지를 할 수 없다고 규정하고 있으며, 피신청인은 정상적인 자문서비스를 수행하였음에도 신청인이 성급하게 주식매매를 하여 손실이 발생한 것인바, 피신청인에게는 중대한 과실이 없어 신청인의 계약해지는 부적법함.

다. 위원회의 판단

◆ 본건의 쟁점은 신청인의 계약해지 주장의 적법여부와 관련하여 투자자문계약서의 해지조항 적용 여부와 계속적 용역제공계약에 있어 계약당사자의 임의해지권 인정 여부라 할 것임.

(1) 투자자문계약서의 해지조항 적용 여부

「약관의 규제에 관한 법률」 제3조(약관의 명시·설명의무)에 의하면 사업자는 계약체결에 있어 고객에게 약관의 내용을 일반적으로 예상되는 방법으로 명시·교부하고, 중요한 내용은 고객이 이해할 수 있도록 설명하여야 하며, 이를 위반하여 계약을 체결한 때에는 당해 약관을 계약의 내용으로 주장할 수 없도록 규정하고 있음.

피신청인은 모 호텔 설명회에서 계약해지에 관한 사항을 설명하였으므로 동사의 「투자자문 계약서」 약관상의 계약해지에 관한 조항에 따른 계약해지만이 가능하다고 주장하나, 약관의 중요사항인 해지관련 조항을 설명하였음을 입증할 증거가 없고, 오히려 본건 투자자문계약은 구두로 체결되어 위 계약서가 교부된 사실이 없음을 피신청인의 담당직원도 인정하고 있는 바, 위 약관의 규제에 관한 법률 제3조에 따라 피신청인이 주장하는 투자자문 계약서의 약관은 본건 투자자문계약의 내용으로 주장할 수 없다 할 것임.

(2) 임의해지권 인정 여부

「방문판매 등에 관한 법률」 제29조(계약의 해지)는 계속거래업자등과 계속거래⁵⁷⁷⁾등

의 계약을 체결한 소비자는 언제든지 계약기간중 계약을 해지할 수 있다고 규정하고 있으며, 판례도 계속적 계약은 당사자 상호간의 신뢰관계를 그 기초로 하는 것이므로 계약의 기초가 되는 신뢰관계가 파괴되어 계약관계를 그대로 유지하기 어려운 경우 계약 당사자가 계약관계를 막바로 해지할 수 있다고 판시하고 있음.⁵⁷⁸⁾

1월이상 계속하여 투자자문을 제공하는 본건 투자자문계약에 대한 신청인의 계약해지 주장은 「방문판매등에 관한 법률」 제29조 및 다음과 같이 피신청인이 계속적 거래관계에 있어 지켜야 할 신뢰관계를 다하지 못하였다는 점에서 타당하다 할 것임.

① 피신청인은 「간접투자자산운용업법시행령」⁵⁷⁹⁾이 규정하고 있는 투자자문 계약체결 시 준수사항을 모두 위반하였으며, 과도한 광고로 계약체결을 유인하는 등 계약체결상의 신의성실의무를 다하지 못하였다는 점.

② 「간접투자자산운용업법」 제147조(투자자문회사의 행위제한) 제1항 제7호에 따르면 투자자문회사는 운용전문인력이 아닌 자로 하여금 투자자문업무를 행하게 하여서는 아니됨에도 운용전문인력이 아닌 담당직원으로 하여금 신청인에게 투자자문을 하도록 하였다는 점.

③ 주식투자의 위험성에 비추어 볼 때 자문내용에 따른 거래에서 손실이 발생하였다고 하여 반드시 불성실한 계약이행이라 할 수는 없으나, 여러번의 거래손실로 신청인이 이미 피신청인의 자문내용(주식의 가치나 투자판단에 관한 조언)에 대한 신뢰를 상실하였다는 점.

(3) 피신청인의 환급액 산정

577) 「방문판매등에 관한 법률」은 1월이상 계속하여 재화 또는 용역을 공급하는 계약으로서 중도에 해지할 경우 대금환급의 제한 또는 위약금에 관한 약정이 있는 거래에 대하여 “계속거래”라 규정함과 동시에 부당한 계속거래의 존속으로 인한 소비자 권익 침해를 방지하기 위해 해지권등 일정 사항을 규정하고 있음.

578) 대법원 1995.3.24. 선고 94다17826 판결 참조.

579) 「간접투자자산운용업법시행령」 제139조(투자자문계약등)에 의하면 투자자문회사가 고객과 투자자문계약을 체결하고자 할 때에는 동조에서 규정하는 일정사항이 기재된 서면자료를 사전에 고객에게 교부하여야 하며, 계약을 체결함에 있어서도 계약해지등을 포함한 일정사항이 기재된 서면에 의하도록 하고 있음.

신청인의 계약해지에 따라 피신청인이 환급할 금액은 피신청인이 지급받은 자문료 120만원에서 신청인의 계약해지 의사표시가 피신청인에게 도달한 날(2005.1.28.)까지의 자문제공기간 동안의 일수로 계산한 자문료 355,556원(200만원×16/90)을 제한 844,444원이라 할 것임.

라. 결 론

그렇다면 신청인의 투자자문계약 해지에 따라 피신청인은 금 844,444원을 환급할 책임이 있어 이를 인용하고, 신청인의 나머지 청구는 이유없어 기각함.

5-18 증권저축약관 교부임무 위반 등으로 인한 손해배상책임 유무

[일부인용] 증권저축계약은 약관의 교부를 계약의 성립요건으로 하는 요물계약이라고 볼 수 없고, 신청인이 증권저축 계좌개설신청서 등을 교부받아 직접 서명·날인한 이상 증권저축계약은 유효하게 성립되었다고 할 것임. 다만 유가증권 매매를 일임받은 증권회사 직원은 고객보호의무가 있어 선량한 관리자의 주의의무를 다하여야 하는데, 수수료 수입을 위한 과도한 매매거래행위도 금지되어야 하지만, 반대로 지나치게 과소한 매매거래를 하여 계좌관리를 거의 방치한 것으로 평가되는 경우에도 선량한 관리자의 주의의무를 다하였다고 볼 수 없음. (2005.10.18. 조정번호 제2005-69호)

가. 사실관계

신청인은 ○○증권사(이하 “피신청인”이라 함)의 지점에서 과거 함께 근무하였던 담당 직원 A씨(이하 “담당직원”이라 함)의 권유로 2001.10.31. 및 그 다음 날에 걸쳐 2건의 증권투자상품의 증권저축계좌를 개설하였음.

개설당시 “계좌개설신청서”, “투자목적기재서”, “일중매매거래에 대한 위험고지서”를 교부받아 직접 서명·날인하고, 증권저축통장을 교부받은 후, “2001.10.31.자 증권저축계좌”에는 금3천만원을, 2001.11.1.자 증권저축계좌에는 금2천만원을 입금하는 등 총 금5천만원을 입금하였음.

담당직원은 신청인을 위하여 B기업, C기업, D기업 등 코스닥상장종목을 2001.11.5.~2003.7.7. 기간중 매매하였고, 2003.8월경 피신청인 회사로부터 퇴직함으로써 매매를 중단하였음. 전체 매매기간 동안 2~3차례 휴대폰을 이용하여 신청인 계좌에서 유가증권의 매매가 이루어지고 있다는 사실을 신청인에게 고지하였으나 구체적인 매매내역을 알리지 않았으며, 신청인은 2004.7월경 동 지점의 다른 직원으로부터 매매잔고 내역을 통지받았을 때 비로소 구체적인 매매내역과 손실을 알게 되었음.

나. 당사자의 주장

(1) 신청인의 주장

증권저축약관을 교부받지 못하여 동 저축이 간접투자 형태인 투자신탁상품인 줄 알고 계약을 체결하였으므로, 본건 계약은 「증권저축약관」 제2조(저축계약의 성립 등)⁵⁸⁰⁾에 의하여 불성립한 것이고, 담당직원의 매매거래는 임의매매에 해당하며, 일임매매라고 하더라도 통지의무 등 고객보호의무를 위반한 사실이 있음.

(2) 피신청인의 주장

신청인이 “약관을 승인한다”는 문구가 기재된 증권저축 계좌개설신청서에 직접 서명·날인을 한 이상 계약은 유효하게 성립된 것이며 담당직원과 신청인은 잘 아는 사이로 계좌개설당시 담당직원에게 운용을 잘해보라는 취지로 격려하는 등 임의매매나 통지의무 위반 사실을 인정할 수 없음.

다. 위원회의 판단

◆ 본건에 있어서의 쟁점은 ①증권저축계약의 성립 여부 ②임의매매 해당여부 ③일임매매에 있어 통지의무 등 고객보호의무 위반 여부라고 할 것임

(1) 증권저축계약의 성립 여부

580) 「증권저축약관」 제2조(저축계약의 성립 등) 동 계약은 회사가 저축자에게 약관을 교부하고 약관의 주요내용을 충실히 설명하여 통장을 교부함으로써 성립한다.

신청인은 약관의 미교부를 들어 계약이 불성립하였다고 주장하고 있고 담당직원이 약관을 교부하지 않은 사실은 당사자 사이에 다툼이 없으나, 증권저축계약은 약관의 교부를 계약의 성립요건으로 하는 요물계약이라고 볼 수 없고, 신청인이 증권저축 계좌개설 신청서 등을 교부받아 직접 서명·날인한 이상 증권저축계약은 유효하게 성립되었다고 할 것임.

다만, 「약관의 규제에 관한 법률」 제3조(약관의 명시·설명의무)를 위반한 경우 이를 계약내용으로 편입할 수 없으나, 본건 계약이 투자신탁상품이 아닌 증권투자상품이라는 점은 약관에 기재된 내용이 아닐 뿐 아니라 신청인의 금융 관련업 종사 경력에 비추어 그러한 내용에 대한 설명의무가 강제된다고도 볼 수 없음.

약관의 중요한 내용이라고 하더라도 이미 법령에 규정되어 있는 사항이거나, 고객이나 그 대리인이 그 내용을 충분히 알고 있는 경우에는 당해 약관이 바로 계약 내용으로 되더라도 고객에게 예상하지 못한 불이익을 주지 않으므로 사업자에게 동 내용에 대한 명시·설명의무가 강제되지 아니함.⁵⁸¹⁾

(2) 임의매매 해당 여부

임의매매란 증권회사의 직원이 유가증권을 고객의 동의 없이 매매한 경우에 성립하는 것으로 임의매매인지 일임매매인지 여부에 관한 판단은 구체적인 명백한 증거가 없는 경우가 많으므로 객관적으로 나타난 계약체결당시의 권유방법, 투자목적 내지 동기, 투자자의 거래 경험, 거래원장상에 나타난 거래내역 등의 여러 정황을 종합하여 합리적으로 판단하여야 함. 본건의 경우 신청인은 임의매매라고 주장하고 있으나, 다음 사유에 비추어 묵시적인 포괄적 일임이 있었던 것으로 판단됨.

문답서에 의하면, 신청인은 비록 담당직원의 투자권유에 응하여 계약을 체결하였지만 계약체결당시 담당직원에게 “노후자금이니 투자를 할 때는 꼭 같이 상의하자”고 말하였고 담당직원은 “우량주를 사서 운용을 잘 해 보겠다”고 말하였으며, 이후에도 신청인이 “관리를 누가 하고 있는지” 물었을 때 담당직원으로부터 “제가 하고 있다”라는 말을 들었음에도 별도의 이의를 제기하지 않은 점 등.

581) 대법원 1999.9.7. 선고 98다19240 판결, 1999.3.9. 선고 98다43342 판결 참조.

(3) 일임매매에 있어 통지의무 등 고객 보호의무 위반 여부

포괄적 매매일임이 있었다고 하더라도 일임을 받은 증권회사 직원은 고객에 대하여 보호의무가 있어 선량한 관리자의 주의의무를 다하여야 할 것이어서 수수료 수입을 위한 과도한 매매거래행위도 금지되어야 하지만, 이와 반대로 지나치게 과소한 매매거래를 하여 계좌관리를 거의 방치한 것으로 평가되는 경우에도 선량한 관리자의 주의의무를 다하였다고 볼 수 없고, 증권업감독규정 제4-18조(매매거래등의 통지)⁵⁸²⁾에 규정된 증권회사의 통지의무가 고객의 포괄적 일임이 있는 경우에는 다소 완화된다고 볼 수는 있어도 완전히 면제된다고 보기는 어려움.

본건의 경우 다음의 사유에 비추어 담당직원은 선량한 관리자의 주의의무를 다하지 아니한 것으로 판단됨.

① 「2001.10.31.자 증권저축계좌」에서는 단 한번의 주식을 매수한 후 손실이 났다는 이유로 그대로 방치하였고, 2003.7월경 퇴사시점에도 신청인에게 퇴사하므로 관리가 종료된다는 사실을 알리거나 다른 직원에게 계좌관리를 인계하지도 않는 등 일임된 사무를 충실히 이행하였다고 볼 수 없는 점.

② 문답서에 의하면 담당직원은 신청인에게 “우량주를 사두었으며, 손실이 발생하고 있지만 회복될 것이다”라는 정도의 통지만 2~3차례 했을 뿐, 거래의 형태, 종목, 가격, 수량, 체결일, 수수료, 제세금의 내용등 구체적인 매매내역을 고지하였다고 인정할 증거가 없는 등 최소한의 통지의무도 이행하였다고 볼 수 없는 점.

(4) 손해배상액 산정

신청인의 손해금액은 본건 증권저축계좌의 최초 매매 시점의 잔고와 분쟁조정 신청 시점의 잔고와의 차이인 금47,004,292원이라 할 것임. 다만, 신청인은 금융업 경력에 비추어 조금만 주의를 기울였어도 보유 주식의 종목·주가 등을 확인하여 그 손실을 최소화할 수 있었음에도 담당직원에게 그 내역을 적극적으로 물어보거나 통장 잔고를 확인

582) 「증권업감독규정」 제4-18조 : 증권회사는 고객의 주문에 의한 매매 기타 거래가 성립된 때에는 당해 거래의 형태, 종목, 가격, 수량, 체결일, 수수료, 제세금의 내용등을 지체없이 고객에게 우편, 매매보고서의 교부, 전화, 전신, 모사전송, 컴퓨터 기타 이와 유사한 전자통신등의 방법으로 통지하여야 한다.

하는 등의 주의를 전혀 기울이지 아니한 과실이 인정되고 이를 참작하여 손해금액 중 70%의 과실상계를 함이 타당함.

라. 결 론

그렇다면 피신청인은 위 손해금액 47,004,292원에서 신청인의 과실비율에 상응하는 금 32,903,004원을 차감한 금14,101,288원을 신청인에게 배상할 책임이 있다 할 것이고 신청인의 나머지 청구는 이유 없어 이를 기각함.



부 록 1

금융분쟁조정 관련 법규

1. 금융위원회의 설치 등에 관한 법률(발체)
2. 금융위원회의 설치 등에 관한 법률 시행령(발체)
3. 금융분쟁조정세칙

제정 1997.12.31. 법률 제5490호
일부개정 2017.11.28. 법률 제15144호

제3장 금융감독원

제3절 업무

제38조(검사 대상 기관) 금융감독원의 검사를 받는 기관은 다음 각 호와 같다.

1. 「은행법」에 따른 인가를 받아 설립된 은행
2. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 금융투자업자, 증권금융회사, 종합금융회사 및 명의개서대행회사(名義改書代行會社)
3. 「보험업법」에 따른 보험회사
4. 「상호저축은행법」에 따른 상호저축은행과 그 중앙회
5. 「신용협동조합법」에 따른 신용협동조합 및 그 중앙회
6. 「여신전문금융업법」에 따른 여신전문금융회사 및 겸영여신업자(兼營與信業者)
7. 「농업협동조합법」에 따른 농협은행
8. 「수산업협동조합법」에 따른 수협은행
9. 다른 법령에서 금융감독원이 검사를 하도록 규정한 기관
10. 그 밖에 금융업 및 금융 관련 업무를 하는 자로서 대통령령으로 정하는 자

제5절 금융 분쟁의 조정

제51조(분쟁조정기구) 제38조 각 호의 기관, 예금자 등 금융 수요자와 그 밖의 이해관계인 사이에 발생하는 금융 관련 분쟁의 조정에 관한 사항을 심의·의결하기 위하여 금융감독원에 금융분쟁조정위원회(이하 "조정위원회"라 한다)를 둔다.

제52조(조정위원회의 구성) ① 조정위원회는 위원장 1명을 포함한 30명 이내의 위원으로 구성한다.

② 조정위원회 위원장은 원장이 그 소속 부원장 중에서 지명하는 사람이 되며, 조정위원회 위원은 다음 각 호의 사람으로 한다.

1. 원장이 그 소속 부원장보 중에서 지명하는 사람

2. 판사·검사 또는 변호사의 자격이 있는 사람 중에서 원장이 위촉하는 사람
3. 「소비자기본법」에 따른 한국소비자원 및 소비자단체의 임원 또는 그 직에 있었던 사람으로서 원장이 위촉하는 사람
4. 금융기관 또는 금융 관계 기관·단체에서 15년 이상 근무한 경력이 있는 사람으로서 원장이 위촉하는 사람
5. 금융에 관한 학식과 경험이 있는 사람 중에서 원장이 위촉하는 사람
6. 전문의의 자격이 있는 의사 중에서 원장이 위촉하는 사람
7. 그 밖에 분쟁의 조정과 관련하여 원장이 필요하다고 인정하여 위촉하는 사람
- ③ 제2항제2호부터 제7호까지의 위원의 임기는 2년으로 하되, 연임할 수 있다.
- ④ 조정위원회 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 원장이 지명하는 조정위원회 위원이 조정위원회 위원장의 직무를 대행한다.

제53조(분쟁의 조정) ① 제38조 각 호의 기관, 예금자 등 금융 수요자와 그 밖의 이해관계인은 금융과 관련하여 분쟁이 있을 때에는 원장에게 분쟁의 조정(調停)을 신청할 수 있다.

② 원장은 제1항에 따른 분쟁조정의 신청을 받으면 관계 당사자에게 그 내용을 알리고 합의를 권고할 수 있다. 다만, 분쟁조정의 신청내용이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 합의권고를 하지 아니하거나 제3항에 따른 조정위원회에의 회부를 하지 아니할 수 있다.

1. 이미 법원에 제소된 사건이거나 분쟁조정을 신청한 후 소송을 제기한 경우
2. 신청한 내용이 분쟁조정 대상으로서 적합하지 아니하다고 인정하는 경우
3. 신청한 내용이 관련 법령 또는 객관적인 증빙(證憑) 등으로 비추어 볼 때 합의권고절차 및 조정절차를 진행할 실익이 없는 경우
4. 그 밖에 대통령령으로 정하는 경우

③ 원장은 분쟁조정의 신청을 받은 날부터 30일 이내에 제2항에 따른 합의가 이루어지지 아니하면 지체 없이 이를 조정위원회에 회부하여야 한다.

④ 조정위원회는 제3항에 따른 조정의 회부를 받으면 60일 이내에 이를 심의하여 조정안을 작성하여야 한다.

⑤ 원장은 조정위원회가 조정안을 작성하면 신청인과 관계 당사자에게 이를 제시하고 수락을 권고할 수 있다.

제54조(조정위원회의 회의) ① 조정위원회의 회의는 조정위원회 위원장 1명을 포함하여 조정위원회 위원장이 회의마다 지명하는 7명 이상 11명 이하의 조정위원회 위원으로 구성하며, 조정위원회 위원장이 소집한다.

② 조정위원회는 제1항에 따른 구성원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

③ 원장은 조정위원회의 의결사항이 위법하거나 공익에 비추어 매우 부당하다고 판단하면 재의(再議)를 요구할 수 있다.

④ 제3항에 따른 재의요구가 있으면 제1항에 따른 구성원 3분의 2 이상의 출석과 출석위원 3분의 2 이상의 찬성으로 재의결한다.

제55조(조정의 효력) 당사자가 제53조제5항에 따라 조정안을 수락한 경우 그 조정안은 재판상의 화해와 동일한 효력을 갖는다.

제56조(조정의 중지) 원장은 조정신청사건의 처리절차의 진행 중에 한쪽 당사자가 소송을 제기한 경우에는 그 조정의 처리를 중지하고 그 사실을 양쪽 당사자 모두에게 통보하여야 한다.

제57조(조정위원회의 운영 등) 조정위원회의 운영 및 분쟁조정절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

2 금융위원회의 설치 등에 관한 법률 시행령 [발췌]

제정 1998.4.1. 대통령령 제15751호
일부개정 2016.2.12. 대통령령 제26980호

제13조(분쟁조정 신청) ①법 제53조제1항의 규정에 의하여 분쟁의 조정을 신청하고자 하는 자는 분쟁조정신청서에 다음 각호의 서류를 첨부하여 원장에게 제출하여야 한다.

1. 분쟁조정신청의 원인 및 사실을 증명하는 서류
2. 대리인이 신청하는 경우 그 위임장
3. 기타 분쟁조정에 필요한 증거서류 또는 자료

②제1항의 규정에 의한 분쟁조정신청서에는 다음 각호의 사항을 기재하여야 한다.

1. 신청인과 피신청인(이하 "당사자"라 한다)의 성명 및 주소(당사자가 법인인 경우에는 법인의 명칭 및 주된 사무소의 소재지와 그 대표자의 성명 및 주소를 말한다)
2. 대리인이 있는 경우에는 그 성명 및 주소
3. 신청의 이유

제14조(대표자의 선정) ①다수인이 공동으로 분쟁조정의 신청을 하는 때에는 신청인중 3인이내의 대표자를 선정할 수 있다.

②제1항의 규정에 의하여 신청인이 대표자를 선정하지 아니한 경우에 원장은 필요하다고 인정되는 때에는 신청인에게 대표자를 선정할 것을 권고할 수 있다.

③신청인은 대표자를 변경한 때에는 그 사실을 지체없이 원장에게 통지하여야 한다.

제15조(분쟁조정신청의 보완 등) ①원장은 제13조의 규정에 의한 분쟁조정의 신청에 대하여 보완이 필요하다고 인정될 때에는 상당한 기간을 정하여 그 보완을 요구하여야 한다.

②제1항의 규정에 의한 보완에 소요된 기간은 법 제53조제3항의 규정에 의한 기간에 이를 산입하지 아니한다.

제16조(조정위원회에 회부되지 아니하는 내용 등) ①법 제53조제2항제4호에서 "기타 대통령령이 정하는 경우"라 함은 다음 각호의 1에 해당하는 경우를 말한다.

1. 신청인이 정당한 이유없이 기한내에 보완을 하지 아니하는 경우
2. 신청의 내용과 직접적인 이해관계가 없는 자가 조정신청을 하는 경우
3. 신청인이 부당한 이익을 얻을 목적으로 조정신청을 한 것으로 인정되는 경우
4. 조정을 하는 것이 적당하지 아니하다고 인정되는 경우

②원장은 법 제53조제2항 단서의 규정에 의하여 합의권고를 하지 아니하거나 금융분쟁조정위원회(이하 "조정위원회"라 한다)에 회부하지 아니하는 때에는 이를 당사자에게 서면으로 통지하여야 한다.

제17조(조정위원회의 회의) ①법 제54조제1항의 규정에 의하여 조정위원회의 위원장(이하 이 조에서 "위원장"이라 한다)이 회의를 소집하고자 하는 때에는 당해 회의의 내용에 따라 위원장이 지명한 위원에게 긴급을 요하는 경우가 아닌 한 회의개최 1주일전까지 회의의 일시·장소 및 안건을 서면으로 통지하여야 한다.

②조정위원회의 회의는 공개하지 아니한다. 다만, 위원장이 필요하다고 인정하는 때에는 당사자 기타 이해관계인에게 방청을 하게 할 수 있다.

제18조(위원의 제척·기피 및 회피) ①조정위원회의 위원은 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 그 분쟁조정신청사건(이하 "사건"이라 한다)의 심의·의결에서 제척된다.

1. 위원 또는 위원의 배우자나 배우자이었던 자가 당해 사건의 당사자가 되거나 당해 사건에 관하여 공동권리자 또는 의무자의 관계에 있는 경우
2. 위원이 당해 사건의 당사자와 친족관계에 있거나 있었던 경우
3. 위원이 당해 사건에 관하여 당사자의 대리인으로서 관여하거나 관여하였던 경우
4. 위원이 당해 사건에 관하여 증언·법률자문 또는 손해사정 등을 한 경우

②당사자는 위원에게 심의·의결의 공정성을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에는 기피신청을 할 수 있다. 이 경우 원장은 조정위원회의 의결을 거치지 아니하고 기피여부를 결정한다.

③위원이 제1항 또는 제2항의 사유에 해당하는 때에는 스스로 그 사건의 심의·의결에서 회피할 수 있다.

제19조(사실조사 등) ①원장은 사건의 조사를 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 당사자에 대하여 사실의 확인 또는 자료의 제출 등을 요구할 수 있다.

②조정위원회는 조정사건의 심의를 위하여 필요한 경우에는 원장에게 당해 사건에 대한 조사 또는 관련자료의 수집을 요청할 수 있다.

제20조(당사자의 의견청취) ①조정위원회는 당사자 기타 이해관계인의 의견을 들을 필요가 있다고 인정되는 때에는 이들에게 회의에 출석하여 의견을 진술할 것을 요청할 수 있다.

②조정위원회는 제1항의 규정에 의하여 의견을 듣고자 하는 때에는 시기 및 장소를 정하여 긴급을 요하는 경우가 아닌 한 의견청취 3일전까지 당사자 기타 이해관계인에게 통지하여야 한다.

③당사자 기타 이해관계인은 조정위원회의 허가를 받아 조정위원회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

제21조(조정 의 성립 등) ①원장은 법 제53조제5항의 규정에 의하여 조정안의 수락을 권고하는 때에는 법 제55조의 규정에 의한 조정의 효력과 제2항의 규정에 의한 뜻을 함께 고지하여야 한다.

②당사자가 제1항의 규정에 의한 조정안을 받은 날부터 20일이내에 조정안을 수락하지 아니한 때에는 조정안을 수락하지 아니한 것으로 본다.

③원장은 당사자가 제1항의 규정에 의한 조정안을 수락한 때에는 조정서를 작성하여 교부하여야 한다.

④금융기관은 조정안을 수락하지 아니한 때에는 그 사유를 원장에게 제출하여야 한다.

제22조(소제기의 통지) 당사자는 분쟁조정신청후에 당해 사건에 대하여 소를 제기한 때에는 지체없이 이를 원장에게 통지하여야 한다.

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 세칙은 금융위원회의 설치 등에 관한 법률(이하 “법”이라 한다) 제3장 제5절, 법 시행령(이하 “영”이라 한다) 제13조 내지 제22조 및 금융감독원(이하 “감독원”이라 한다) 정관 제21조의 규정에 의한 금융분쟁조정위원회(이하 “위원회”라 한다)의 운영과 금융분쟁의 조정 절차 등에 관하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 위원회의 운영과 조정절차 등에 관하여는 법·영 및 감독원의 정관에서 정하고 있는 사항을 제외하고는 이 세칙에서 정하는 바에 따른다.

제3조(용어의 정의) 이 세칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “신청인”이라 함은 금융감독원장(이하 “원장”이라 한다)에게 금융관련분쟁의 조정을 신청한 자를 말한다.
2. “피신청인”이라 함은 신청인의 상대방을 말한다.
3. “당사자”라 함은 당사자 일방(신청인 또는 피신청인) 또는 당사자 쌍방(신청인 및 피신청인)을 말한다.
4. “금융관련기관”이라 함은 법 제38조에 의하여 감독원의 검사를 받는 기관을 말한다.
5. “금융분쟁”이라 함은 금융관련기관, 예금자 등 금융수요자 및 기타 이해관계인이 금융관련 기관의 금융업무 등과 관련하여 권리의무 또는 이해관계가 발생함에 따라 금융관련기관을 상대로 제기하는 분쟁을 말한다.

제2장 위원회의 구성 및 운영

제4조(위원회의 구성) ①위원회는 위원장 1인을 포함한 30인 이내의 위원으로 구성한다.

②위원회의 위원장(이하 “위원장”이라 한다)은 원장이 그 소속 부원장 중에서 지명하는 자가 되며, 위원회 위원은 원장이 그 소속 부원장보 중에서 지명하는 자와 다음 각 호의 자 중에서 위촉하는 자로 한다. 이 경우 위촉된 위원은 제7조 제4항의 규정 등을 준수하겠다는 내용의 서약서를 제출하여야 한다.

1. 판사·검사 또는 변호사의 자격이 있는 자
2. 소비자기본법에 의한 한국소비자원 및 소비자단체의 임원 또는 그 직에 있었던 자
3. 금융기관 또는 금융관계기관·단체에서 15년 이상 근무한 경력이 있는 자

4. 법률·경제·경영 또는 소비자 관련 분야 학문을 전공하고 대학이나 공인된 연구기관에서 7년 이상 근무한 자로서 부교수 이상 또는 이에 상당하는 직에 있거나 있었던 자

5. 전문의의 자격이 있는 의사

6. 기타 분쟁의 조정과 관련하여 원장이 필요하다고 인정하는 자

③원장은 위원회 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 위원을 해촉하여야 한다.

1. 금융기관으로부터 부당하게 금품 또는 향응을 제공받은 경우

2. 위촉시 경력, 학력 또는 「부패 방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제2조 제4호에 따른 부패행위 전력을 거짓으로 제출한 경우

3. 제7조 제4항을 위반한 경우

4. 제7조의2 제3항의 회피사유에 해당됨에도 회피신청을 하지 않는 등 위원회의 공정성을 심각하게 훼손한 경우

5. 본인의 귀책사유로 회의소집 요구에 계속적으로 불응하여 절반이상 회의에 불참하는 경우

제5조(위원의 임기) 위원장 및 위원의 임기는 다음 각 호와 같이 한다.

1. 위원장 및 원장이 그 소속 부원장보 중에서 지명하는 위원 : 해당 직에 재직하는 기간

2. 금융관계기관·단체를 대표하는 위원 : 2년으로 하되 해당 직에 재직하는 기간 범위내에서 연임이 가능

3. 제4조 제2항 제1호부터 제6호까지의 위원(이 조 제2호의 위원을 제외한다) : 2년으로 하되 1회에 한하여 연임이 가능

제6조(위원장의 직무) ①위원장은 위원회를 대표하며, 위원회의 회의를 주재하고 사무를 통할한다.

②위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없는 때에는 위원회 위원 중 분쟁조정 담당 부원장보인 위원이 위원장의 직무를 대행한다.

제7조(위원회의 회의) ①위원회의 회의는 위원장 1인을 포함하여 보험 분야 또는 비보험 분야(은행, 증권, 비은행 등)별로 매 회의시 위원장이 지명하는 7인 이상 11인 이하의 위원으로 회의의 1주일 전까지 구성하며, 위원장이 소집한다.

②회의는 매월 첫째주(첫째주 화요일이 없는 경우는 셋째주) 화요일과 셋째주(첫째주 화요일이 없는 경우는 다섯째주) 화요일에 소집함을 원칙으로 하되 위원장이 필요하다고 인정하는 때에는 수시로 소집할 수 있다.

③위원회는 제1항의 규정에 의한 구성원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

④위원회의 회의에 참석한 위원은 회의와 관련하여 알게 된 정보를 타인에게 누설하여서는 아니된다.

제7조의2(위원의 제척, 기피 및 회피) ①위원회의 위원은 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 그 분쟁조정신청사건(이하 “사건”이라 한다)의 심의, 의결에서 제척된다.

1. 위원 또는 위원의 배우자나 배우자이었던 자가 당해 사건의 당사자가 되거나 당해 사건에 관하여 공동 권리자 또는 의무자의 관계에 있는 경우
2. 위원이 당해 사건의 당사자와 친족관계에 있거나 있었던 경우
3. 위원이 당해 사건에 관하여 당사자의 대리인으로서 관여하거나 관여하였던 경우
4. 위원이 당해 사건에 관하여 증언, 법률자문 또는 손해사정 등을 한 경우

②당사자는 위원에게 심의·의결의 공정성을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에는 기피신청을 할 수 있다. 이 경우 원장은 위원회의 의결을 거치지 아니하고 기피여부를 결정한다.

③위원이 제1항 또는 제2항의 사유에 해당하는 때에는 스스로 그 사건의 심의·의결에서 회피할 수 있다.

제8조(간사) ①위원회의 사무를 처리하기 위하여 위원회에 간사 1인을 둔다.

②간사는 감독원직제에서 정한 소관부서장으로 한다.

③간사는 위원회에 참석하며, 위원장은 필요하다고 인정하는 때에는 간사로 하여금 안전에 대하여 설명하게 할 수 있다.

제9조(의사록) ①간사는 회의결과를 기재한 의사록을 작성·보관하여야 한다.

②제1항의 의사록은 위원장(법 제52조 제4항에 따라 대행하는 자를 포함한다), 회의에 참석한 위원 및 간사가 기명하고 날인 또는 서명하여야 한다.

③간사는 제1항 및 제2항의 규정에 의하여 작성한 의사록을 위원회의 차기회의에 보고하여야 한다.

제10조(전문위원) ①원장은 조정업무와 관련하여 원장 또는 위원회의 자문에 응하기 위하여 전문위원을 위촉할 수 있다.

②전문위원은 변호사의 자격이 있는 자, 대학이나 공인된 연구기관에서 조교수 이상 또는 이에 상당한 직에 있는 자, 전문의의 자격이 있는 의사 등 원장이 필요하다고 인정하는 자로 한다.

③감독원에 접수된 사건 및 위원회에 회부된 사건의 처리를 위하여 원장이 필요하다고 인정하는 경우에는 전문위원에게 자문을 의뢰할 수 있다.

④제1항의 규정에 의하여 위촉된 전문위원의 임기는 2년으로 하되 연임할 수 있다.

⑤제7조의2 제1항 및 제3항은 전문위원에게 자문을 의뢰하는 경우에 준용한다. 이 경우 “위원회 위원”은 이를 “전문위원”으로 보고, “심의·의결”은 이를 “자문”으로 본다.

⑥원장은 감독원에 접수된 사건 및 위원회에 회부된 사건의 처리를 위하여 필요하다고 인정할 때에는 전문위원 외의 전문가 등에게 자문을 의뢰할 수 있다.

제10조의2(전문소위원회) ①법률적 또는 의료적 사항 등 전문적 판단이 필요한 사건의 효율적 처리를 위하여 전문소위원회를 둔다.

② 전문위원회의 구성 및 운영에 관하여는 원장이 정하는 바에 의한다.

제3장 조정의 신청 등

제11조(분쟁조정신청) ①금융관련기관, 예금자 등 금융수요자 및 기타 이해관계인은 금융과 관련하여 분쟁이 있는 때에는 원장에게 분쟁의 조정을 신청(이하 “조정신청”이라 한다)할 수 있으며 원장에게 조정신청을 하고자 하는 자는 다음 각 호의 서류를 첨부한 분쟁조정신청서(이하 “조정신청서”라 한다)를 원장에게 제출하여야 한다.

1. 조정신청의 원인 및 사실을 증명하는 서류
2. 대리인이 조정신청서를 제출하는 경우에는 그 위임장
3. 기타 분쟁조정에 필요한 증거서류 또는 자료

②제1항의 규정에 의한 조정신청서에는 다음 각 호의 사항을 기재하여야 한다.

1. 신청인과 상대방의 성명 및 주소(당사자가 법인인 경우에는 법인의 명칭 및 주된 사무소의 소재지와 그 대표자의 성명 및 주소를 말한다)
2. 대리인이 있는 경우에는 그 성명 및 주소
3. 신청의 취지
4. 신청의 이유

③원장은 감독원에 접수된 진정서, 탄원서 기타 민원서류 중 그 내용이 이 세칙에 의한 조정 절차에 의하여 처리함이 타당하다고 인정되는 민원서류는 그 명칭 및 형식의 여하에 불구하고 이를 제1항의 규정에 의한 조정신청이 있는 것으로 처리할 수 있다.

④분쟁처리 담당자는 분쟁조정신청을 접수하는 즉시, 처리부서, 담당자 직성명, 전화번호 등을 유선, 전자우편, 문서 등 연락 가능한 방법으로 접수사실을 통지하여야 한다.

제11조의2(자율조정절차 등) ①원장은 신청인이 분쟁조정을 신청한 경우 그 사건의 처리에 앞서 신청인과 금융관련기관이 자율적인 조정절차를 거치도록 할 수 있다.

②원장은 분쟁조정사건의 내용·성격 등이 금융·보험상품거래와 무관하거나 우리원이 직접 처리하기 어렵다고 판단되는 경우 원장이 별도로 정하는 기관 등에서 자율조정에 대한 검토를

거치도록 할 수 있다.

제12조(대표자의 선정) ①다수인이 공동으로 신청한 분쟁조정에 있어 대표자를 선정한 경우에는 그 선임사실을 서면으로 증명하여야 한다.

②선정된 대표자는 이를 선임한 신청인들을 위하여 사건에 관한 모든 행위를 할 수 있다. 다만, 조정신청의 취하, 피신청인과 합의 또는 조정결정서의 수락은 다른 신청인의 동의를 얻어야 하며, 이 경우 동의를 얻은 사실을 서면으로 증명하여야 한다.

제13조(대리인의 선임) 당사자는 변호사, 기타 제3자를 대리인으로 선임할 수 있다. 이 경우 그 선임사실을 서면으로 증명하여야 한다.

제14조(조정신청의 중간회신) ①감독원에 접수된 조정신청 중 사실조사 또는 위원회의 회부 등의 사유로 처리가 지연되는 경우 원장은 지연사유 등을 신청인에게 통지하여야 한다.

②조정신청이 접수된 때에는 소관부서장은 금융분쟁조정기록부에 조정신청의 접수, 보완, 사실조사 및 처리결과 등에 대한 기록을 유지하여야 한다.

제15조(조정신청의 보완) ①원장은 조정신청에 대하여 관련자료 등 보완이 필요하다고 인정될 때에는 상당한 기간을 정하여 구술·전화·문서·우편·전신·모사전송(FAX) 또는 인터넷 등으로 보완을 요구할 수 있다.

②원장은 신청인이 제1항의 기간 내에 보완을 하지 아니하는 때에는 7일 이내의 기간을 정하여 다시 보완을 요구할 수 있다.

제16조(사실조사 등) ①원장은 사건의 조사를 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 감독원 직원으로 하여금 사건에 대한 사실조사 및 조회 또는 관련자의 출석 등의 방법으로 조사를 하게 하거나 당사자에 대하여 사실의 확인 또는 자료의 제출 등을 요구할 수 있다.

②원장은 사건의 조사를 위하여 관계기관에 감정, 조회 기타 필요한 검사 등을 의뢰할 수 있다.

③금융관련기관에 대한 금융분쟁에 관련된 사실조사는 분쟁조정업무를 담당하는 소관부서장이 관할한다. 다만, 소관부서장은 필요하다고 인정되는 경우 소관 검사국장에게 검사를 의뢰할 수 있다.

④제3항에 의한 검사 및 그 처리 등에 관한 사항은 관련법령 및 감독원의 규정을 준용한다.

⑤원장은 제1항의 규정에 의한 사실조사가 필요한 경우 조사목적, 조사내용, 조사기간 등을 조사출장 3일 전까지 유선, 전자우편, 문서 등 연락 가능한 방법으로 사전통지하여야 한다. 다만 긴급을 요하거나 증거인멸 등이 우려되는 경우 이를 생략할 수 있다.

⑥분쟁조정업무 담당부서는 분쟁조정절차 진행 중 금융기관의 위법·위규사항이 발견되거나 제도개선이 필요한 경우 관련 부서에 이를 통보하여야 한다. 이 경우 통보를 받은 관련 부서에

서는 이에 대한 적절한 조치를 취하여야 한다.

⑦원장은 분쟁조정을 위해 필요한 경우 피신청인에게 조정신청서사본을 송달하거나 상당한 기일을 정하여 조정신청에 대한 의견서 또는 답변서와 관련 자료의 제출을 요구할 수 있다.

제4장 감독원장의 분쟁처리

제17조(조정신청의 위원회 회부 전 처리) ①원장은 조정신청내용이 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 위원회에 회부를 하지 아니하고 직접처리하거나 해당기관에 이첩하여 처리하게 할 수 있다.

1. 이미 법원에 제소된 사건이거나 조정신청이 있는 후 소를 제기한 경우
2. 조정신청의 내용이 관련법령 또는 객관적인 증빙 등에 의하여 합의권고 또는 조정절차 진행의 실익이 없는 경우
3. 신청인이 정당한 사유 없이 제15조의 규정에 의한 보완요구를 받고도 지정된 기한 내에 이를 보완하지 아니하거나 소재불명 등으로 보완요구가 2회에 걸쳐 반송된 경우
4. 조정신청의 내용과 직접적인 이해관계가 없는 자가 조정신청을 하는 경우
5. 신청인이 부당한 이익을 얻을 목적으로 조정신청을 한 것으로 인정되는 경우
6. 신청인이 상당한 이유 없이 취하된 조정신청건 또는 동일한 내용에 대하여 다시 조정신청을 하거나 가명으로 조정신청한 것이 확인된 경우
7. 당사자의 주장이 상이하거나 증거채택이 어려워 사실관계 확정이 곤란하거나 수사사건과 직접적으로 관련된 경우
8. 당사자의 주장내용이 부당하거나 관련법령, 조정선례, 법원판례 등에 비추어 명백하게 받아들일 수 없다고 인정되는 경우
9. 금융·보험상품거래와 직접 관련이 없거나 수사기관의 수사가 필요한 경우 등 조정신청의 내용이 분쟁조정대상으로서 적합하지 아니하다고 인정되는 경우

제17조의2(처리기간의 계산) 사건에 대하여 제 17조의 규정에 의하여 직접처리를 하거나 해당기관에 이첩하여 처리하게 할 때에는 조정신청 접수일로부터 30일 이내에 그 처리결과 및 사유를 명시하여 당사자에게 통지한다.

제17조의3(처리기간에 산입하지 아니하는 기간) 조정신청의 처리기간에 산입하지 아니하는 기간은 다음 각호의 1에 해당하는 기간을 말한다.

1. 조정신청의 보완에 소요되는 기간(보완을 위하여 신청서를 신청인에게 발송한 날과 보완되어 행정청에 도달한 날을 포함한다)
2. 사건에 대하여 사실조사 및 조회 등에 부득이하게 소요되는 기간

3. 공휴일 및 토요일

제17조의4(처리기간의 연장 등) ①원장은 부득이한 사유로 제17조의2가 정한 처리기간 내에 사건을 처리하기 어렵다고 인정되는 경우에 대하여는 30일 이내의 범위에서 처리기간을 연장할 수 있다. 다만, 신청인의 동의를 받은 경우에는 한차례에 한하여 재연장을 할 수 있다.

② 제1항에 따라 처리기간을 연장하였을 때에는 처리기간의 연장 사유와 처리완료 예정일을 지체없이 신청인에게 통지하여야 한다.

제17조의5(처리결과의 통지) 제17조의2 규정에 의한 처리결과의 통지는 문서를 통하여 이루어져야 한다. 다만, 신청인이 원하거나 전자정부법 제9조에 따른 전자민원창구를 통하여 접수된 조정신청은 처리결과를 전자민원시스템에 입력함으로써 통지에 갈음할 수 있다.

제17조의6(반복 및 중복 조정신청의 처리) ①신청인이 동일한 내용의 조정신청을 정당한 사유 없이 3회 이상 반복하여 제출한 경우 2회 이상 그 처리결과를 통지하고, 그 후 접수되는 조정신청에 대하여는 종결처리할 수 있다.

②신청인이 2개 이상의 행정기관에 제출한 동일한 내용의 조정신청을 다른 행정기관으로부터 이송받은 경우에도 제1항의 규정을 준용하여 처리할 수 있다.

③제1항 및 제2항에 따른 동일한 내용의 조정신청인지 여부에 대하여는 해당 조정신청의 성격, 종전 조정신청과의 내용적 유사성·관련성 및 종전 조정신청과 동일한 답변을 할 수 밖에 없는 사정 등을 종합적으로 고려하여 결정하여야 한다.

제18조(조정신청의 취하 등) ①신청인은 사건명, 당사자 및 취하사유가 표시된 취하서를 우편·모사전송(FAX) 등으로 제출하거나 유선(녹취 등)으로 조정신청을 취하할 수 있다.

②신청인이 조정신청을 취하한 경우 등 이 규정에 의한 조정절차진행의 필요가 없는 사유가 발생한 경우에는 조정절차진행을 중지하고 당해 사건을 종결처리할 수 있다.

③제2항의 규정에 따라 사건을 종결처리한 경우 원장은 당사자에게 통지하여야 한다. 다만, 조정신청을 취하한 신청인에게는 그러하지 아니하다.

④당해사건이 위원회에 회부되어 계류 중인 경우에는 위원회에도 이를 통보하여야 한다.

제19조(소 제기 등의 통지) ①분쟁조정 신청 후에 당해 사건에 대하여 소를 제기하였거나 민사조정법에 따라 법원에 조정신청을 한 당사자는 지체없이 다음 각 호의 사항을 원장에게 통지하여야 한다.

1. 당해 사건의 관할법원
2. 소송일자 또는 조정신청일자
3. 소송번호 또는 사건번호

4. 소장 또는 조정신청서의 사본

5. 피신청인이 소를 제기하였거나 법원에 조정신청을 하였을 경우 그 사유

6. 피신청인이 소를 제기하였거나 법원에 조정신청을 하였을 경우 심급별 소송결과

②원장은 사건의 처리절차의 진행 중에 일방당사자가 소를 제기하거나 민사조정신청을 한 경우에는 그 조정의 처리를 중지하고 이를 당사자에게 통보하여야 한다.

제20조(합의권고) ①원장은 감독원에 접수된 사건 중 분쟁의 원만한 해결을 위하여 당사자가 합의하도록 함이 상당하다고 인정되는 사건의 경우에는 구두 또는 서면으로 당사자에게 합의할 것을 권고할 수 있다.

②원장은 제1항의 규정에 의한 합의권고에 있어 필요하다고 인정되는 경우에는 당해 조정신청에 관하여 이해관계를 가지는 자를 출석시켜 합의에 참가하도록 할 수 있다.

제20조의2(제3자 의견 구속력) 의료사항 등에 대한 제3자의 전문적 판단이 필요하다고 인정되는 사건에 대하여 제20조 제1항에 의하여 합의를 권고하는 경우에 당사자가 정한 제3자의 의견을 따르도록 할 수 있으며, 당사자인 금융관련기관은 제3자의 의견에 따라야 한다.

제20조의3(재검토요구) 원장은 법률, 기존의 분쟁조정위원회 조정례 및 판례 등에 비추어 피신청인의 처리가 부당하다고 판단되는 상당한 이유가 있는 때에는 서면으로 피신청인에게 재검토를 요구할 수 있다.

제21조(합의 불성립) 당사자가 원장의 합의권고를 거부하거나 정당한 이유 없이 합의권고절차 진행을 위한 출석기일에 출석하지 아니한 때에는 합의가 성립되지 아니한 것으로 본다.

제5장 위원회의 분쟁조정

제22조(위원회에의 회부 및 통지) ①원장은 다음 각 호의 1에 해당되는 경우에는 위원회 회부 사건 요약표를 작성하고 관련자료를 첨부하여 위원회에 회부하여야 한다.

1. 제17조의 규정에 따라 원장이 직접처리하거나 해당기관에 이첩하여 처리하는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우
2. 제20조의 규정에 의한 합의권고가 적당하지 않다고 인정되는 경우
3. 제20조의 규정에 따라 합의권고절차를 진행하였으나 사건의 접수일로부터 30일 이내에 당사자 간에 합의가 성립되지 아니한 경우

②원장이 제1항의 규정에 의하여 사건을 위원회에 회부한 때에는 당사자에게 당해 사건이 위원회에 회부된 사실을 통지하여야 한다. 이 경우 당사자에게 일정기간 내에 추가자료를 제출할 수 있다는 사실과 위원의 명단 및 이들에 대한 기피의 신청을 할 수 있다는 사실을 통지하

여야 한다.

③제2항의 기피의 신청을 하는 경우에는 기피사유와 증거자료를 서면으로 제출하여야 한다.

④제1항 제3호의 기간을 계산함에 있어 제17조의3과 제17조의4를 준용한다.

제23조(자료제출 등) ①위원회는 사건의 심의를 위하여 필요한 경우에는 원장에게 당해 사건에 대한 조사 또는 관련자료의 수집을 요청할 수 있다.

②원장은 위원회로부터 제1항의 규정에 의한 요청을 받은 때에는 지체없이 조사를 실시하거나 관련자료를 수집하여 위원회에 제출하여야 한다.

제24조(당사자 등의 의견청취) ①위원회는 당사자 기타 이해관계인·감정인·참고인 등의 의견을 들을 필요가 있다고 인정되는 때에는 이들에게 회의에 출석하여 의견을 진술할 것을 요청할 수 있다.

②위원회는 제1항의 규정에 의하여 의견을 듣고자 하는 때에는 시기 및 장소를 정하여 긴급을 요하는 경우가 아닌 한 의견청취 3일전까지 당사자 등에게 통지하여야 한다.

③당사자 기타 이해관계인은 위원회의 허가를 받아 위원회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

제24조의2(사전심의) ①위원회는 다음 각호의 1에 해당되는 사항을 사전심의할 수 있다.

1. 다수인이 신청한 사건으로서 조정기준 마련 등을 위해 필요한 경우
2. 제10조의2의 전문소위원회 심의를 거친 경우
3. 그 밖에 위원회가 사전심의가 필요하다고 인정하는 경우

② 사전심의의 구성 및 운영에 관하여는 제4조부터 제9조까지의 규정을 준용한다.

제25조(결정) ①위원회는 사건이 회부된 날로부터 60일 이내에 이를 심의하여 조정결정하여야 한다. 다만, 신청의 내용이 제17조제1항 각호의 1에 해당되는 등 위원회의 조정의 실익이 없는 경우에는 각하결정을 할 수 있다.

②위원회가 제1항에 의한 결정을 한 때에는 조정결정서 또는 각하결정서를 작성하여야 한다.

③제2항의 조정결정서 또는 각하결정서에는 다음 각 호의 사항을 기재하여야 한다.

1. 당사자의 성명 또는 명칭과 주소
2. 조정 또는 각하결정사항
3. 조정 또는 각하결정이유
4. 조정 또는 각하결정일자

제26조(심의·의결 결과통보) 위원회가 사건에 대한 심의·의결을 종료한 때에는 그 결과를 원장에게 통보하여야 한다.

제27조(원장의 재의 요구) ①원장은 위원회의 의결사항이 다음 각 호의 1에 해당하는 경우 재의요구의 사유 등을 첨부하여 재의를 요구할 수 있다

1. 관련법규를 위반한 경우
2. 공익에 비추어 심히 부당한 경우

②제2항의 규정에 의한 재의 요구가 있는 때에는 제7조 제1항의 규정에 의한 구성원 3분의 2 이상의 출석과 출석위원 3분의 2이상의 찬성으로 재의결한다.

제28조(조정결정 등의 통지) 원장은 재의요구사항을 제외한 사건에 대하여는 위원회의 조정결정서 또는 각하결정서를 첨부하여 위원회의 의결내용을 당사자에게 통지한다. 다만, 신청인의 청구를 인용(부분인용 포함)하는 것으로 조정결정된 사건에 대하여는 다음 각 호의 사항을 함께 통지한다.

1. 조정결정의 수락은 조정결정의 통지를 받은 날로부터 20일 이내에 이루어져야 하며, 그러하지 아니할 경우에는 조정이 성립되지 아니한 것으로 처리된다는 사실
2. 당사자 쌍방이 조정결정내용을 수락할 경우 감독원에 출석하여 조정서를 작성하거나 조정결정 수락서에 기명하고 날인 또는 서명하여 감독원에 제출하여야 한다는 사실
3. 당사자 쌍방이 조정결정 내용을 수락하여 조정이 성립하면 법이 정하는 바에 따라 재판상 화해와 동일한 효력을 가진다는 사실

제29조(조정의 성립 등) ①당사자가 제28조의 규정에 의하여 통지된 조정안을 수락한 경우 당해 조정안은 재판상 화해와 동일한 효력을 갖는다.

②당사자쌍방은 제28조의 규정에 의한 조정결정의 통지를 받은 날로부터 20일 이내에 감독원에 출석하여 조정서 3부에 기명하고 날인 또는 서명하여야 하며 원장이 이를 확인하여 당사자에게 조정서 각 1부를 교부하고 1부는 감독원에서 보관하여야 한다.

③원장은 제1항의 규정에도 불구하고 당사자가 감독원에 출석하여 조정서에 기명날인하기 곤란하다고 판단될 때에는 당사자로 하여금 제28조의 규정에 의한 조정결정의 통지를 받은 날로부터 20일 이내에 조정결정수락서에 기명하고 날인 또는 서명하여 감독원에 제출토록 할 수 있다. 이 경우 원장이 조정결정수락서를 확인하여 조정서 3부를 작성하여 당사자에게 각각 1부를 교부 또는 송달하고 1부는 감독원에서 보관하여야 한다.

④당사자의 일방 또는 쌍방이 제28조의 규정에 의한 조정결정의 통지를 받은 후 소정기일 이내에 조정결정내용을 수락하지 아니한 때에는 조정이 성립되지 아니한 것으로 본다.

⑤원장은 조정이 성립되지 아니한 때에는 당사자에게 조정이 성립되지 아니한 사실 및 사유를 명시하여 통지한다.

⑥금융관련기관은 조정안을 수락하지 아니한 때에는 그 사유를 원장에게 제출하여야 한다.

제30조(처리결과와 통보 및 보고) ①원장은 조정결정한 사건의 처리결과를 위원회에 통보한다.
 ②제29조에 의하여 조정이 성립된 경우 당사자인 금융관련기관은 조정에 따른 처리결과를 조정이 성립한 날로부터 20일 이내에 원장에게 보고하여야 한다.

제31조(재조정신청) ①당사자는 다음 각 호의 1에 해당하는 사유가 있는 때에는 위원회의 결정에 대하여 재조정을 신청할 수 있다. 다만, 당사자가 당초 조정신청을 할 때에 그 사유를 주장하였거나 이를 알면서 주장하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 조정 당시에는 제출되지 아니한 것으로서 조정의 결과에 중대한 영향을 미치는 새로운 사실이 나타난 경우
2. 조정의 증거로 된 문서, 증인의 증언, 참고인의 진술 등의 자료가 위조 또는 변조된 것이거나 허위임이 밝혀진 경우
3. 조정의 기초가 된 법률, 판결 등이 변경된 경우
4. 조정에 영향을 미칠 중요한 사항에 관하여 위원회가 판단하지 아니한 경우
5. 제척되어야 할 위원이 조정에 관여한 경우

②재조정신청은 당사자가 조정결정 또는 각하결정을 통지받은 날로부터 1개월 이내에 하여야 한다.

③제1항의 규정에 따른 재조정 신청사건의 처리에 대해서는 이장의 규정을 준용한다.

④원장은 제2항에서 정하는 기간을 경과한 재조정신청에 대하여는 특별한 사유가 없는 한 이를 각하처리한다.

제6장 보 칙

제32조(분쟁조정공표) 원장은 공익 또는 금융수요자 등의 보호를 위하여 필요하다고 인정하는 때에는 분쟁조정업무와 관련된 내용을 공표할 수 있다.

제32조의2(소송지원) ①원장은 다음 각 호의 1에 해당하는 사건으로서 피신청인의 조치가 현저히 부당하다고 위원회가 인정하여 소송지원을 요청하는 경우 신청인을 위한 소송지원을 할 수 있다. 다만, 소송지원이 실익이 없거나 공익목적상 부적절하다고 인정되는 경우에는 그러하지 아니한다.

1. 위원회에서 신청인의 청구를 인용하는 것으로 조정결정된 사건
2. 위원회에서 조정결정이 있기 전 사건으로서 위원회의 조정선례 또는 법원의 판례 등에 비추어 신청인의 청구를 인용하는 것으로 조정결정될 것이 명백한 사건

② 삭 제

③원장은 소송지원 결정 이후 다음 각 호의 1에 해당하는 사유가 발생하는 경우에는 소송지

원을 중단할 수 있다.

1. 신청인이 특별한 사정없이 소송당사자로서의 의무를 다하지 아니하는 경우
2. 신청인이 소송지원 신청시 제출한 자료나 진술 등이 허위로 판명된 경우
3. 소송지원 과정에서 새로이 발견된 사실로 인해 당해 소송지원이 실익이 없게 되거나 공익 목적상 부적절하게 된 경우
- ④기타 소송지원에 관한 세부사항은 원장이 정하는 바에 의한다.

제32조의3(사건개입 금지 등) ①누구든지 감독원 담당직원에게 분쟁조정 신청사건에 대한 처리를 종용하거나 관련 법령 등에 근거하지 아니하고 정보 등의 제공을 요구하여서는 아니된다.
②감독원 담당직원은 제1항의 요구를 받은 경우 이에 응하여서는 아니된다.

제33조(수당 등) 원장은 다음 각 호의 경우 감독원의 예산범위 내에서 따로 정하는 바에 따라 수당 및 실비, 출장비, 자문료 또는 수임료 등을 지급할 수 있다.

1. 제7조에 의하여 위원이 위원회에 참석하는 경우
2. 위원이 사건의 해결을 위하여 국내외에 출장을 하는 경우
3. 제10조에 의하여 전문위원이 원장의 자문에 응하는 경우
4. 제24조에 의하여 위원회가 요청한 감정인·참고인 등이 위원회에 출석하여 의견을 진술하는 경우
5. 제16조에 의하여 원장이 요청한 감정인·참고인 등이 출석하여 의견을 진술하는 경우

제34조(세부사항 등) 이 세칙의 시행을 위하여 필요한 서식 등 세부사항에 대하여는 감독원 직제에서 정한 소관부서장이 별도로 정하는 바에 의한다.



부 록 2

색

인

1. 법원 판례 목록
2. 수록 안건 색인

대법원

(판결번호)

(조정번호)

대법원 1965.8.31. 선고 65다693	은행·중소서민 99-61
대법원 1969.7.22. 선고 69다548	은행·중소서민 10-25
대법원 1976.7.13. 선고 76다1155	은행·중소서민 00-11
대법원 1976.10.26. 선고 76다517	보험 10-23
대법원 1978.2.14. 선고 76다2119	보험 06-87
대법원 1978.3.14. 선고 76다2168	은행·중소서민 00-23
대법원 1978.3.28. 선고 78다282,283	은행·중소서민 10-25
대법원 1978.6.13. 선고 78다568	은행·중소서민 08-73
대법원 1979.10.30. 선고 79다1234	보험 01-37, 01-46, 08-39
대법원 1980.4.8. 선고 80다188	은행·중소서민 10-87
대법원 1980.11.25. 선고 80다1109	보험 06-34
대법원 1981.6.23. 선고 80다609	은행·중소서민 99-46
대법원 1981.6.23. 선고 81다167	은행·중소서민 08-73
대법원 1984.6.12. 선고 83다카2159	은행·중소서민 11-50
대법원 1984.11.27. 선고 84다310	은행·중소서민 99-46
대법원 1984.11.27. 선고 84다카1283	은행·중소서민 99-46
대법원 1985.12.24. 선고 85다카880	은행·중소서민 05-74, 05-98
대법원 1987.2.10. 선고 86도2338	보험 06-8
대법원 1987.4.28. 선고 82다카789	은행·중소서민 99-25
대법원 1987.5.12. 선고 86다카819	은행·중소서민 16-28
대법원 1987.7.7. 선고 86다카2475	은행·중소서민 10-25
대법원 1988.3.22. 선고 86다카2747	보험 08-14
대법원 1989.4.11. 선고 88다카13219	은행·중소서민 05-66
대법원 1989.11.14. 선고 88다카29962	은행·중소서민 01-4

(판결번호)**(조정번호)**

대법원 1989.11.28. 선고 88다카26758	보험 06-35
대법원 1990.2.13. 선고 89다카10385	은행·중소서민 04-38
대법원 1990.6.26. 선고 89다카7730	보험 99-5
대법원 1991.1.29. 선고 90다11028	금투 03-37
대법원 1991.4.23. 선고 90다15129	은행·중소서민 00-35
대법원 1991.5.14. 선고 90다카25314	보험 01-19
대법원 1991.6.25. 선고 90다12373	보험 13-13, 13-14, 13-14
대법원 1991.12.27. 선고 91다1165	보험 11-17
대법원 1992.2.14. 선고 91다9244	은행·중소서민 00-23, 05-74, 05-98
대법원 1992.6.12. 선고 92다10722	은행·중소서민 99-26, 00-51
대법원 1992.10.23. 선고 92다28259	보험 01-46
대법원 1992.10.27. 선고 92다32852	보험 13-16
대법원 1992.12.22. 선고 91다22346	보험 99-16
대법원 1993.1.19. 선고 92다32111	보험 09-59
대법원 1993.4.27. 선고 92다8101	보험 03-5
대법원 1993.7.13. 선고 93다17980	은행·중소서민 09-48
대법원 1994.5.24. 선고 93다44975	은행·중소서민 99-1
대법원 1994.6.10. 선고 94다3445	은행·중소서민 10-25
대법원 1994.8.23. 선고 93다59595	보험 04-26
대법원 1994.8.26. 선고 93다15267	은행·중소서민 99-1
대법원 1994.9.23. 선고 94다9085	보험 00-33
대법원 1994.9.27. 선고 94다20617	금투 11-25
대법원 1994.9.30. 선고 94다20242	은행·중소서민 09-42
대법원 1994.10.14. 선고 94다14018	보험 99-16
대법원 1994.11.25. 선고 94다8969	은행·중소서민 99-33
대법원 1994.12.27. 선고 93다29396	보험 04-53
대법원 1995.3.14. 선고 94누7935	보험 99-29
대법원 1995.3.24. 선고 94다17826	금투 05-41
대법원 1995.3.24. 선고 94다44620	은행·중소서민 10-86
대법원 1995.5.12. 선고 94다54726	보험 10-13

(판결번호)**(조정번호)**

대법원 1995.7.11. 선고 95다8850	보험 99-16
대법원 1995.7.14. 선고 94다36698	보험 99-64
대법원 1995.9.15. 선고 95다13371	은행·중소서민 04-38
대법원 1995.10.12. 선고 94다16786	금투 03-48
대법원 1995.11.14. 선고 95다30352	금투 09-92
대법원 1996.1.26. 선고 98다48682	보험 12-27
대법원 1996.2.23. 선고 95다49141	은행·중소서민 10-25
대법원 1996.4.23. 선고 95다55986	은행·중소서민 99-18
대법원 1996.8.23. 선고 94다38199	금투 9-12, 9-35, 10-34
대법원 1996.8.23. 선고 95다39472	은행·중소서민 06-19
대법원 1996.9.20. 선고 95다53942	보험 99-16
대법원 1996.9.20. 선고 96다24675	보험 09-45
대법원 1996.10.11. 선고 95다43679	은행·중소서민 09-101
대법원 1996.10.29. 선고 95다2494	은행·중소서민 11-43
대법원 1996.12.23. 선고 96다27971	보험 00-15, 03-59, 8-2, 08-13, 11-17, 11-57
대법원 1997.4.8. 선고 96다54942	은행·중소서민 10-87
대법원 1997.4.11. 선고 97다423	보험 01-51
대법원 1997.7.8. 선고 97다15685	보험 00-33
대법원 1997.8.29. 선고 96다14470	금투 03-37
대법원 1997.9.26. 선고 97다22768	은행·중소서민 00-18, 02-5
대법원 1997.9.30. 선고 97다24276	보험 00-26
대법원 1997.9.30. 선고 97다24412	보험 03-18
대법원 1997.10.24. 선고 97다24603	금투 05-37
대법원 1997.10.28. 선고 97다33089	보험 06-13, 09-75
대법원 1997.11.28. 선고 97다31229	보험 06-7
대법원 1997.12.10. 선고 96나57032	보험 99-7
대법원 1997.12.26. 선고 97다28780	금투 05-37
대법원 1998.2.10. 선고 97다31113	은행·중소서민 16-9
대법원 1998.2.27. 선고 97다16077	은행·중소서민 03-21
대법원 1998.4.14. 선고 97다39308	보험 08-99

(판결번호)

(조정번호)

대법원 1998.4.23. 선고 97다19403	보험 04-61
대법원 1998.5.15. 선고 96다27773	보험 01-19
대법원 1998.6.12. 선고 97다18455	은행·중소서민 99-18
대법원 1998.6.23. 선고 98다10380	보험 08-14
대법원 1998.7.8. 선고 98다1072	보험 01-51
대법원 1998.7.10. 선고 98다15835	은행·중소서민 00-11
대법원 1998.7.10. 선고 98다18988	금투 11-25, 보험 06-7
대법원 1998.7.24. 선고 97다49978	금투 07-24
대법원 1998.8.21. 선고 97다50091	보험 05-38, 11-17
대법원 1998.9.18. 선고 98다25825	보험 99-7
대법원 1998.10.13. 선고 98다28114	보험 08-47
대법원 1998.10.27. 선고 97다47989	은행·중소서민 08-93, 금투 08-4, 08-56, 09-12,
대법원 1998.11.10. 선고 98다20059	은행·중소서민 05-61, 07-4, 11-45, 14-19
대법원 1998.11.13. 선고 97다53359	은행·중소서민 99-18, 04-36
대법원 1998.11.24. 선고 98다33765	은행·중소서민 01-4
대법원 1998.11.27. 선고 98다32564	보험 08-71
대법원 1998.12.8. 선고 98다39923	은행·중소서민 00-11
대법원 1999.2.12. 선고 98다45744	은행·중소서민 01-22
대법원 1999.3.9. 선고 98다43342	금투 05-69, 보험 05-34, 06-52
대법원 1999.3.9. 선고 98다43349	보험 05-34
대법원 1999.3.9. 선고 98다43359	보험 06-52
대법원 1999.3.12. 선고 98다48989	은행·중소서민 99-26, 11-31
대법원 1999.3.12. 선고 98다51626	은행·중소서민 10-25
대법원 1999.6.25. 선고 98도4716	보험 06-34
대법원 1999.7.23. 선고 99다19346	보험 04-27
대법원 1999.8.24. 선고 99다26481	은행·중소서민 01-55
대법원 1999.9.7. 선고 98다19240	은행·중소서민 03-50, 금투 05-69
대법원 1999.11.12. 선고 98다30834	보험 03-18
대법원 1999.11.26. 선고 99다37474	보험 12-13
대법원 2000.1.18. 선고 99다57461	은행·중소서민 10-25

(판결번호)

(조정번호)

대법원 2000.1.28. 선고 99다50712	은행·중소서민 10-25, 보험 09-91
대법원 2000.3.10. 선고 99다67031	은행·중소서민 07-4
대법원 2000.3.28. 선고 99다32332	은행·중소서민 04-78, 10-52
대법원 2000.3.28. 선고 99다56253	은행·중소서민 09-101
대법원 2000.3.28. 선고 99다67147	보험 08-61
대법원 2000.4.25. 선고 99다68027	은행·중소서민 08-17, 보험 07-48
대법원 2000.6.26. 선고 99다65752	보험 03-69
대법원 2000.9.8. 선고 2000다89	보험 08-78
대법원 2000.11.10. 선고 2000다29769	보험 06-87
대법원 2000.12.8. 선고 99다37856	금투 11-25, 보험 02-3
대법원 2000.12.8. 선고 2000다46375	보험 04-26, 05-43, 05-93, 08-78
대법원 2000.12.22. 선고 99다1352	은행·중소서민 02-47, 보험 01-37
대법원 2000다50312, 2006다53344	금투 14-13
대법원 2001.2.13. 선고 99다13737	보험 03-59
대법원 2001.3.23. 선고 2000다40858	은행·중소서민 14-7
대법원 2001.4.24. 선고 99다30718	금투 04-20, 05-25
대법원 2001.5.29. 선고 2001다11765	은행·중소서민 11-31
대법원 2001.7.24. 선고 2000다20878	보험 05-23
대법원 2001.8.21. 선고 2001다27579	보험 09-103
대법원 2001.9.25. 선고 2001다48583	은행·중소서민 07-69
대법원 2001.11.9. 선고 2001다55499	보험 12-19, 13-15
대법원 2001.11.27. 선고 99다33311	보험 12-13
대법원 2001.12.11. 선고 2001다61852	은행·중소서민 02-47, 03-50
대법원 2001.12.24. 선고 2000두598	보험 10-6, 10-7
대법원 2002.2.26. 선고 2000다71494	은행·중소서민 08-73
대법원 2002.3.15. 선고 2000다 9086	은행·중소서민 16-10, 16-28
대법원 2002.3.29. 선고 2001다49128	은행·중소서민 05-37, 16-11
대법원 2002.4.23. 선고 2001다84794	은행·중소서민 10-53
대법원 2002.5.24. 선고 2000다72572	은행·중소서민 16-29
대법원 2002.6.28. 선고 2001다49814	은행·중소서민 10-25, 11-30

(판결번호)

(조정번호)

대법원 2002.7.12. 선고 99다68652	은행·중소서민 09-101
대법원 2003.1.10. 선고 2000다34426	금투 03-17, 05-82
대법원 2003.1.10. 선고 2000다50312 ..	은행·중소서민 06-10, 08-20, 08-83, 10-79, 금투 08-33, 08-55, 09-38, 10-2, 10-45, 10-59, 10-85, 11-38, 14-13, 17-12
대법원 2003.1.10. 선고 2000도5716	보험 09-85
대법원 2003.1.24. 선고 2002다29510	보험 07-79
대법원 2003.4.11. 선고 2001다12430	은행·중소서민 03-67
대법원 2003.4.11. 선고 2001다53059	은행·중소서민 10-107, 16-29
대법원 2004.4.23. 선고 2004다5389	은행·중소서민 15-18, 16-9
대법원 2003.6.27. 선고 2003다12847	보험 03-59
대법원 2003.7.11. 선고 2001다11802	은행·중소서민 08-20, 금투 07-44
대법원 2003.7.25. 선고 2001다10458 ..	은행·중소서민 10-60, 10-79, 금투 10-45, 10-59, 11-38
대법원 2003.8.22. 선고 2003다26211	보험 04-53, 05-25
대법원 2003.8.22. 선고 2003다27054	보험 05-34, 10-111
대법원 2003.10.23. 선고 2001다18285	보험 04-3
대법원 2003.11.28. 선고 2003다35215, 35222	보험 08-18, 08-27, 09-82
대법원 2003.12.16. 선고 2003다49542	금투 10-73, 보험 04-61
대법원 2004.1.15. 선고 2001다70825	은행·중소서민 09-28
대법원 2004.1.15. 선고 2003다53404	보험 08-43
대법원 2004.4.27. 선고 2003다7302	보험 04-61
대법원 2004.7.9. 선고 2004다20304, 20357	보험 10-99
대법원 2004.7.9. 선고 2004다27160	은행·중소서민 10-36
대법원 2004.7.22. 선고 2001다58269	은행·중소서민 06-19
대법원 2004.8.20. 선고 2002다20889	보험 05-23
대법원 2005.4.15. 선고 2004다65138	보험 06-44
대법원 2005.5.27. 선고 2004다60065	은행·중소서민 09-48, 09-86, 11-32
대법원 2005.7.28. 선고 2005다22565	은행·중소서민 11-21, 11-43, 11-50, 13-23
대법원 2005.9.25. 선고 2005다25755	보험 10-56
대법원 2005.10.28. 선고 2005도5975	은행·중소서민 10-76, 13-1
대법원 2005.12.23. 선고 2005다59383	보험 08-3

(판결번호)

(조정번호)

대법원 2005.12.23. 선고 2005다59390	보험 08-3
대법원 2006.1.13. 선고 2003다54599	은행·중소서민 06-17, 14-19
대법원 2006.2.10. 선고 2005다58083	보험 11-28
대법원 2006.3.24. 선고 2005다59673	은행·중소서민 10-76
대법원 2006.5.11. 선고 2003다51057	은행·중소서민 08-93, 금투 08-4, 08-56, 08-67 09-12, 09-34, 09-93, 10-2, 10-74, 17-12
대법원 2006.6.16. 선고 2005다25632	보험 13-21
대법원 2007.4.12. 선고 2004다4980	금투 08-88, 17-12
대법원 2007.4.12. 선고 2004다62641	금투 16-19
대법원 2007.4.26. 선고 2005다24318	보험 07-86
대법원 2007.4.27. 선고 2006다87453	보험 10-42, 10-111, 11-11
대법원 2007.7.12. 선고 2006다53344 ..	은행·중소서민 10-79, 금투 10-2, 10-45, 10-59, 11-38
대법원 2007.7.13. 선고 2005다23599	은행·중소서민 14-19
대법원 2007.9.6. 선고 2006다55005	보험 10-42
대법원 2007.9.6. 선고 2007다30263	보험 09-17
대법원 2007.9.7. 선고 2006도777	보험 11-41
대법원 2007.11.29. 선고 2007다51239	은행·중소서민 13-1
대법원 2007.11.29. 선고 2005다64552	은행·중소서민 14-7
대법원 2008.3.27. 선고 2008다2616	보험 10-56
대법원 2008.4.24. 선고 2006다72734	보험 13-13, 13-14
대법원 2008.6.12. 선고 2008다7772	은행·중소서민 11-31
대법원 2008.8.21. 선고 2008다37674	보험 13-16
대법원 2008.9.8. 선고 2008다17359	보험 08-78
대법원 2008.9.11. 선고 2006다53856	금투 16-11
대법원 2008.10.9. 선고 2007다55491	보험 08-97
대법원 2008.12.16. 선고 2007마1328	금투 16-20
대법원 2008.12.16. 선고 2007마1328	금투 10-74, 16-12, 보험 10-23 10-42, 10-111, 11-11
대법원 2008.12.24. 선고 2006다53672	은행·중소서민 10-53
대법원 2009.2.26. 선고 2007다30331	은행·중소서민 10-25

(판결번호)**(조정번호)**

대법원 2009.3.12. 선고 2008다76020	보험 13-21
대법원 2009.5.14. 선고 2007다75921	금투 10-34
대법원 2009.9.24. 선고 2009다37831	은행·중소서민 10-25
대법원 2009.12.10. 선고 2009다69746	은행·중소서민 10-76
대법원 2010.2.11. 선고 2009다74007	보험 13-16
대법원 2010.3.25. 선고 2009다91316	보험 11-11
대법원 2010.5.13. 선고 2010다6857	보험 12-19
대법원 2010.5.27. 선고 2007다66088	은행·중소서민 10-76, 13-1
대법원 2010.7.22. 선고 2010다28208	보험 10-83, 11-26
대법원 2010.8.19. 선고 2008다78491	보험 12-19, 13-15
대법원 2010.8.24. 선고 2006다72734	보험 13-14
대법원 2010.9.9. 선고 2007다5120	보험 10-92
대법원 2010.9.30. 선고 2010다12241	보험 13-14, 11-28, 13-13, 13-14
대법원 2010.10.28. 선고 2009다59688	보험 12-13
대법원 2010.11.11. 선고 2008다52369	금투 16-20
대법원 2010.11.11. 선고 2010다55699	금투 14-13
대법원 2010.12.9. 선고 2009다60305	보험 12-27, 13-5
대법원 2010.12.9. 선고 2010다66835	보험 11-17
대법원 2010.12.9. 선고 2010다71158	보험 11-35
대법원 2010.12.9. 선고 2009다101824	은행·중소서민 15-4, 16-29
대법원 2011.2.10. 선고 2010다83199	은행·중소서민 11-30, 16-29
대법원 2011.4.28. 선고 2010다106702	은행·중소서민 15-4, 16-28
대법원 2012.5.10. 선고 2011다66610	보험 13-21
대법원 2012.10.11. 선고 2011다12842	은행·중소서민 14-19
대법원 2012.7.12. 선고 2010다108234	보험 13-21
대법원 2013.4.26. 선고 2012다99617	은행·중소서민 16-9
대법원 2013.5.9. 선고 2013다7516	은행·중소서민 14-7
대법원 2013.6.27. 선고 2013다23372	은행·중소서민 13-25
대법원 2013.9.26. 선고 2012다1146	금투 15-4, 16-30
대법원 2014.1.29. 선고 2013다86489	은행·중소서민 14-19

(판결번호)**(조정번호)**

대법원 2015.1.29. 선고 2013다217498	금투 17-12
대법원 2015.4.23. 선고 2013다17674	금투 17-12

하급심**(판결번호)****(조정번호)**

서울고등법원 1993.10.13 선고 93나19452	보험 11-60
서울고등법원 1995.1.26 선고 94나36157	보험 08-29
서울고등법원 1997.8.28 선고 96나5911	금투 99-27
서울고등법원 2001.2.25 선고 99나44412	보험 04-3
서울고등법원 2001.12.20 선고 2001나31129	보험 08-60
서울고등법원 2003.7.10 선고 2002나67972	보험 09-103, 11-4, 11-10
서울고등법원 2004.7.9 선고 2003나37183	보험 12-19, 13-15
서울고등법원 2006.6.8 선고 2005나61623	보험 12-19, 13-15
서울고등법원 2006.6.22 선고 2005다96803	보험 11-26
서울고등법원 2007.4.27 선고 2006나96152, 96169	보험 08-61
서울고등법원 2007.11.7 선고 2007나51255	보험 07-86
서울고등법원 2008.6.11 선고 2007가합113569	보험 12-19
서울고등법원 2012.4.4 선고 2011나76169	보험 12-27
부산고등법원 2003.6.27 선고 2003나1755	은행·중소서민 07-69
광주고등법원 1999.10.15 선고 98나5875	보험 03-69
광주고등법원 2016.3.31. 선고 2014나3004	금투 17-12
서울지방법원 1997.7.11. 선고 97나9085	보험 04-61, 05-34
서울지방법원 1999.2.2. 선고 96가합48614	보험 04-76
서울지방법원 1999.6.23. 선고 99나23368	보험 06-8
서울지방법원 2002.2.8. 선고 2001나27173	금투 02-48
서울지방법원 2002.9.3. 선고 2002가단75597	보험 06-34, 12-19
서울중앙지방법원 2004.6.18. 선고 2003나52790	은행·중소서민 11-23
서울중앙지방법원 2004.10.28. 선고 2004나21069	보험 10-91

(판결번호)

(조정번호)

서울중앙지방법원 2005.4.22. 선고 2004나25771	은행·중소서민 08-48
서울중앙지방법원 2008.5.28. 선고 2007가합107069	금투 09-38, 10-45, 10-59
서울중앙지방법원 2008.6.11. 선고 2007가합113569	보험 12-19, 13-15
서울중앙지방법원 2012.11.15. 선고 2011가단371969	은행·중소서민 13-25
서울중앙지방법원 2013.1.17. 선고 2011가합71808	금투 16-30
서울남부지방법원 2013.7.12. 선고 2012가합8476	금투 17-12
대구지방법원 2007.5.8 선고 2006가합8478	금투 08-56, 09-34, 09-35, 10-96
대구지방법원 2009.4.10 선고 2007가합2634	금투 10-96
대전지방법원 2001.12.20 선고 2001가단1101	보험 05-97
대전지방법원 2004.11.25 선고 2002나4847	보험 04-76
인천지방법원 2004.10.15. 선고 2004나3994	보험 09-76
광주지방법원 2014.11.19. 선고 2014가소501472	은행·중소서민 15-4
전주지방법원 2005.9.1. 선고 2005나1585	은행·중소서민 07-69, 10-76
Mihara v. Dean Witter 619 F.2d 814(9th Cir. 1980)	금투 08-88

제1권 (보험)

조정번호	페이지	조정번호	페이지	조정번호	페이지
1999- 2	587	2000-48	152	2002-50	405
1999- 5	123	2000-54	209	2002-52	785
1999- 7	492	2000-56	571	2003- 5	533
1999-10	807	2001- 2	690	2003-10	577
1999-11	818	2001-13	764	2003-11	724
1999-13	589	2001-19	884	2003-12	850
1999-16	494	2001-26	211	2003-18	852
1999-24	552	2001-27	239	2003-32	55
1999-29	146	2001-34	847	2003-59	10
1999-30	340	2001-37	7	2003-69	265
1999-31	496	2001-39	743	2004- 3	867
1999-36	531	2001-44	574	2004-26	536
1999-42	37	2001-46	40	2004-27	557
1999-43	342	2001-47	241	2004-32	98
1999-44	811	2001-50	52	2004-53	154
1999-52	864	2001-51	502	2004-61	518
1999-58	844	2001-52	355	2004-62	855
1999-60	178	2001-53	260	2004-75	521
1999-64	613	2002- 2	888	2004-76	539
2000-15	3	2002- 3	243	2005- 1	670
2000-26	127	2002- 4	96	2005- 2	745
2000-30	353	2002- 8	43	2005-23	870
2000-33	498	2002-12	554	2005-25	157
2000-39	148	2002-13	262	2005-34	655
2000-46	50	2002-14	180	2005-43	541

조정번호	페이지	조정번호	페이지	조정번호	페이지
2005-50	560	2007-73	788	2009- 7	168
2005-58	563	2007-76	213	2009-14	278
2005-73	182	2007-79	272	2009-16	47
2005-78	748	2007-86	791	2009-17	108
2005-79	766	2007-93	302	2009-29	858
2005-87	673	2007-97	619	2009-30	61
2005-93	544	2008- 2	17	2009-31	307
2005-97	100	2008- 3	165	2009-32	110
2006- 3	129	2008- 7	726	2009-44	513
2006- 7	103	2008- 8	732	2009-45	549
2006- 8	344	2008-13	642	2009-53	695
2006-13	14	2008-14	507	2009-59	582
2006-22	524	2008-27	675	2009-60	361
2006-27	245	2008-29	566	2009-74	364
2006-28	132	2008-31	137	2009-75	20
2006-31	407	2008-35	734	2009-76	750
2006-33	873	2008-39	45	2009-82	736
2006-34	692	2008-41	411	2009-85	793
2006-35	616	2008-43	482	2009-91	773
2006-44	291	2008-45	645	2009-92	496
2006-52	479	2008-47	185	2009-99	248
2006-65	358	2008-49	105	2009-103	193
2006-66	293	2008-53	621	2009-106	310
2006-87	768	2008-60	187	2010- 6	171
2007- 7	560	2008-61	190	2010- 7	174
2007-10	296	2008-70	215	2010- 8	313
2007-22	298	2008-71	304	2010-10	317
2007-25	268	2008-78	546	2010-13	860
2007-29	161	2008-91	591	2010-23	658
2007-34	300	2008-97	625	2010-29	413
2007-55	135	2008-98	510	2010-42	662
2007-70	275	2008-99	485	2010-48	196

조정번호	페이지	조정번호	페이지	조정번호	페이지
2010-50	776	2011-57	69	2016- 8	423
2010-55	218	2011-60	761	2016-12	428
2010-56	515	2012- 3	332	2016-13	225
2010-80	320	2012- 4	701	2016-14	431
2010-83	728	2012-13	651	2016-16	437
2010-90	322	2012-15	628	2016-17	879
2010-91	753	2012-16	719	2016-23	119
2010-92	678	2012-17	29	2016-25	380
2010-99	139	2012-19	681	2016-26	386
2010-101	367	2012-21	739	2016-31	286
2010-103	781	2012-27	802	2017- 1	79
2010-105	647	2012-35	199	2017- 2	203
2010-111	488	2013- 4	43	2017- 3	391
2011- 4	142	2013- 5	876	2017- 4	830
2011- 5	568	2013-13	704	2017- 5	526
2011-10	757	2013-14	708	2017- 6	594
2011-11	665	2013-15	686	2017- 7	633
2011-17	23	2013-16	113	2017- 8	891
2011-18	64	2013-17	814	2017- 9	85
2011-26	251	2013-21	821	2017-10	347
2011-27	323	2015-12	371	2017-11	836
2011-28	698	2015-20	417	2017-14	440
2011-33	326	2015-21	255	2017-15	599
2011-35	712	2015-22	73	2017-16	232
2011-39	222	2016- 3	376	2017-17	454
2011-41	796	2016- 4	826	2017-18	396
2011-46	715	2016- 5	335	2017-19	465
2011-47	800	2016- 6	434		
2011-53	329	2016- 7	281		

제2권 (은행, 중소기업금융, 금융투자)

조정번호	페이지	조정번호	페이지	조정번호	페이지
1999- 1	138	2001- 5	638	2004-38	17
1999- 4	315	2001-16	94	2004-78	110
1999-14	190	2001-17	432	2005- 6	339
1999-18	234	2001-21	96	2005-20	653
1999-23	220	2001-22	48	2005-25	662
1999-25	186	2001-24	641	2005-37	657
1999-26	194	2001-25	434	2005-41	734
1999-27	633	2001-41	615	2005-60	621
1999-28	676	2001-55	54	2005-61	211
1999-33	125	2002- 5	96	2005-66	161
1999-39	709	2002-10	100	2005-68	56
1999-41	596	2002-11	565	2005-69	737
1999-46	236	2002-25	644	2005-71	60
1999-49	548	2002-26	648	2005-74	243
1999-56	550	2002-30	307	2005-82	715
1999-57	695	2002-34	14	2005-95	329
1999-61	277	2002-37	572	2005-98	248
2000- 3	553	2002-47	225	2006- 2	319
2000-11	157	2002-48	475	2006- 4	20
2000-13	555	2003-17	711	2006-17	213
2000-14	562	2003-21	143	2006-19	217
2000-18	107	2003-22	618	2006-69	342
2000-23	240	2003-37	602	2007- 4	252
2000-28	473	2003-48	678	2007-24	718
2000-35	326	2003-49	479	2007-44	405
2000-45	598	2003-50	229	2007-58	575
2000-51	3	2003-67	197	2007-67	667
2000-52	635	2004-20	459	2007-69	283
2000-57	698	2004-33	356	2007-90	578
2001- 4	12	2004-36	280	2007-92	63

조정번호	페이지	조정번호	페이지	조정번호	페이지
2008- 4	437	2009-64	498	2011-25	625
2008- 6	683	2009-86	22	2011-30	9
2008-17	379	2009-92	610	2011-31	6
2008-20	360	2009-93	412	2011-32	154
2008-21	331	2009-100	558	2011-38	468
2008-23	408	2009-101	201	2011-43	128
2008-33	484	2010- 2	453	2011-44	44
2008-37	606	2010- 5	582	2011-45	257
2008-48	345	2010-17	206	2011-49	220
2008-55	463	2010-25	163	2011-50	132
2008-56	445	2010-34	721	2011-51	690
2008-57	147	2010-36	183	2011-56	395
2008-62	36	2010-45	418	2013- 1	291
2008-66	30	2010-52	117	2013-23	121
2008-67	448	2010-53	65	2013-25	173
2008-68	687	2010-59	427	2014- 7	74
2008-73	310	2010-60	373	2014-13	506
2008-81	382	2010-73	701	2014-19	81
2008-82	33	2010-74	503	2015- 4	725
2008-83	364	2010-76	285	2015- 5	351
2008-87	488	2010-77	51	2015-18	264
2008-88	670	2010-78	322	2016- 9	271
2008-93	385	2010-79	369	2016-10	295
2009- 3	335	2010-85	585	2016-11	588
2009- 8	151	2010-86	27	2016-19	526
2009-12	492	2010-87	171	2016-20	535
2009-28	390	2010-88	71	2016-28	300
2009-34	441	2010-96	705	2016-29	89
2009-35	495	2010-107	41	2016-30	729
2009-38	412	2011-21	103	2017-12	541, 628
2009-42	113	2011-22	60		
2009-48	178	2011-23	348		

금융분쟁조정사례집 (제2권)

－ 은행, 중소기업금융, 금융투자 －

-
- 인 쇄 2017년 12월
 - 편 집 인 이 현 열
홍장희, 유형주, 김지정, 이정필,
김택중, 남수빈, 한정원
 - 발 행 처 금융감독원
서울특별시 영등포구 여의대로 38
 - 인 쇄 처 주식회사 한 야 토

< 비매품 >